

مجلة الحقوق

فصلية علمية محكمة - تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت

إصدار خاص لجائحة فيروس كورونا COVID-19

جامعة
الكويت

مجلس
النشر العلمي



ISSN: 1029 - 6069

إصدار خاص - الجزء الثاني

جمادى الآخرة ١٤٤٢ - يناير ٢٠٢١

الجزء الثاني

ثمن العدد

- في الكويت: ٧٥٠ فلساً.
- في دول الخليج: (السعودية ١٠ ريالاً، قطر ١٠ ريالاً، الإمارات ١٠ دراهم، البحرين دينار، عمان ريال).
- في الوطن العربي: ما يعادل دولاراً أمريكياً.
- في الدول الأجنبية: ثلاثة دولارات.

الاشتراكات السنوية

نوع الاشتراك	الكويت	الدول العربية	الدول الأجنبية	سنوات الاشتراك
أفراد	٣ دنانير	٤ دنانير	١٥ دولاراً	سنة
مؤسسات	١٥ ديناراً	١٥ ديناراً	٦٠ دولاراً	
أفراد	٥ دنانير	٧ دنانير	٢٥ دولاراً	مستتان
مؤسسات	٢٥ ديناراً	٢٥ ديناراً	١٠٠ دولار	
أفراد	٧ دنانير	١٠ دنانير	٣٥ دولاراً	٣ سنوات
مؤسسات	٣٥ ديناراً	٣٥ ديناراً	١٤٠ دولاراً	
أفراد	٩ دنانير	١٣ ديناراً	٤٥ دولاراً	٤ سنوات
مؤسسات	٤٥ ديناراً	٤٥ ديناراً	١٨٠ دولاراً	

تدفع الاشتراكات بالطريقة التالية:

- ١ - إما بشيك لأمر جامعة الكويت مسحواً على أحد المصارف الكويتية.
- ٢ - أو بتحويل مصرفي لحساب جامعة الكويت رقم (042/02608) لدى بنك الكويت المركزي وإشعار المجلة بذلك.

رقم الإيبان: KW21CBKU0000000000000004202608

جميع الأوراق التي تضمها هذه المجلة تصدر مع وجهة نظر
كاتبها ولا تصدر مع رأي المجلة والمقال ليس مسئولية هذا

إصدارات مجلس النشر العلمي

مجلة العلوم الاجتماعية ١٩٧٣،	دراسات الخليج والجزيرة	المجلة العربية للعلوم
مجلة الكويت للعلوم والهندسة	العربية ١٩٧٥، لجنة التأليف	الإنسانية ١٩٨١، مجلة الشريعة
١٩٧٤ (انفصلت في ٢٠١٣ إلى	والتعريب والنشر ١٩٧٦، مجلة	والدراسات الإسلامية ١٩٨٣،
مجلة الكويت للعلوم، مجلة	الحقوق ١٩٧٧، حوليات الآداب	المجلة التربوية ١٩٨٣، المجلة
الأبحاث الهندسية)، مجلة	والعلوم الاجتماعية ١٩٨٠،	العربية للعلوم الإدارية ١٩٩١.

مجلة الحقوق



مجلة علمية محكمة ربع سنوية تعنى بنشر الدراسات القانونية والشرعية

إصدار خاص - الجزء الثاني - يناير ٢٠٢١م

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي:

مجلة الحقوق - ص.ب.: ٦٤٩٨٥ الشويخ - ب 70460 الكويت

تلفون: ٢٤٨٣٥٧٨٩ - ٢٤٨٤٧٨١٤ - ٢٤٩٨٤٧٦١ فاكس: ٢٤٨٣١١٤٣

البريد الإلكتروني: jol@ku.edu.kw

jol.ku.kw@gmail.com

تفهرس المجلة وملخصاتها ونصوصها في قواعد البيانات والمعلومات الآتية:

Ebsco Publishing, Legal Source, ISC Databases, Arab World
Research Source, Ulrich's IPD, UNESCO DARE Databank,
Mandumah, PR, Newswire, MECAS Database, copac.

تتوفر نصوص البحوث كاملة لدى:

EBSCO Publishing Products

دار المنظومة www.mandumah.com

تفهرس المجلة في دليل أولرخ الدولي للدوريات تحت رقم 4965711

ISSN 1029 - 6069

مجلة الحقوق



تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت

الهيئة الاستشارية

د. عبد الحميد الأحمد

محامي بالاستئناف - لبنان

أ. د. حسام الدين الأهواني

جامعة عين شمس - مصر

أ. د. ماتيس روه

جامعة إيرلانجن - ألمانيا

أ. د. صادق رضا

كلية نيويورك للقانون - أمريكا

أ. د. ماسيمو بابا

جامعة روما تور فيرغاتا - إيطاليا

د. مارك هويل

أستاذ زائر بجامعة ليدز - المملكة المتحدة

مجلة الحقوق



إصدار خاص - الجزء الثاني - يناير ٢٠٢١م

رئيس التحرير

د. فهد علي الزميع

مدير التحرير

سامي صالح الوهيبي

هيئة التحرير

أ.د. زينب حسين عوض الله

قواعد النشر

مجلة الحقوق : مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت؛ تقبل النشر فيها باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وهي تعنى بنشر كل ما يتصل بميادين اهتمام المجلة، وذلك عن البحوث والدراسات، التعليق على أحكام قضائية، ملخصات الرسائل العلمية، التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات، عرض الكتب الجديدة ومراجعتها . وذلك وفق القواعد التالية:

أولاً - البحوث والدراسات العلمية :

• قواعد عامة :

- ١ - التعهد من الباحث بأن البحث أو الدراسة لم يسبق نشرها - ورقياً أو إلكترونياً - وألا تكون مقدمة للنشر إلى أية جهة أخرى .
- ٢ - أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة الجديدة إلى المعرفة القانونية .
- ٣ - الالتزام بأصول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق لمواد البحث.
- ٤ - ألا يكون البحث أو الدراسة جزءاً من رسالة الدكتوراه أو الماجستير التي تقدم بها الباحث، أو جزءاً من كتاب له سبق نشره.
- ٥ - ألا يزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عن ١٥ ألف كلمة بما في ذلك المراجع والهوامش والجداول والأشكال والملاحق.
- ٦ - لا يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إقرار نشره في مجلة الحقوق.
- ٧ - تقدم البحوث مطبوعة من ثلاث نسخ على ورق (A4) مع قرص مدمج (CD) وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق في جميع النسخ.
- ٨ - أصول البحوث التي تصل إلى المجلة لا ترد سواء نشرت أو لم تنشر.
- ٩ - أن يرفق الباحث نبذة تعريفية عنه.
- ١٠ - أن يرفق الباحث ملخصاً عن بحثه في حدود الصفحة الواحدة باللغة العربية والإنجليزية.
- ١١ - لا تدفع المجلة مكافآت مالية مقابل البحوث المنشورة، أو مراجعات الكتب، أو أي أعمال فكرية، ما لم تكن بتكليف من المجلة.
- ١٢ - المواد التي تتضمنها البحوث المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- ١٣ - ترسل البحوث إلى عنوان رئيس تحرير مجلة الحقوق ص.ب: 64985 الشويخ ب 70460 الكويت، أو إيميل المجلة jol@ku.edu.kw.

• قواعد خاصة :

- ١ - تخصص قائمة بالمراجع في آخر البحث، تتضمن جميع المراجع التي أُشير إليها في المتن، وتوضع في صفحات مستقلة ، على أن ترتب المصادر والمراجع بدءاً بالمراجع العربية ثم المراجع الأجنبية، من دون ترقيم .
- ٢ - يشار إلى الهوامش بأرقام متسلسلة على امتداد صفحات البحث، وتشرح مرقمة بحسب تسلسلها.
- ٣ - يمنح كل باحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه مع عشرين مستخرجاً من بحثه المنشور.
- ٤ - تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر - ورقياً وإلكترونياً - للبحث المجاز .
- ٥ - يخضع ترتيب البحوث المنشورة في المجلة لاعتبارات فنية .
- ٦ - يراعى - ما أمكن - في أولوية النشر :
 - أ - البحوث الواردة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت .
 - ب - البحوث والدراسات التي تعنى بالقوانين الكويتية أو المقارنة بالقوانين الكويتية.
 - ج - تاريخ تسلّم رئيس التحرير للبحث، وأسبقية تقديم البحوث التي يتم تعديلها .
 - د - تنوع البحوث كلما أمكن ذلك .

ثانياً - التعليق على الأحكام القضائية :

تنشر المجلة التعليق على أحكام القضاء، إيماناً منها بأهمية آراء الفقه القانوني في تحليل الحكم وتأصيله ونقده من واقع الربط بين نظرية القانون وعلمه ، وبين التطبيق العملي ، وذلك وفق القواعد الآتية :

- أن يكون معدّ التعليق متخصصاً في القانون.
- أن يتناول التعليق حكماً نهائياً استنفدت طرق الطعن عليه .
- ألا يناقش التعليق إلا المبادئ التي أقام عليها الحكم دعائمه .
- عدم التعرض للهيئة والقضاة الذين أصدروه .

ثالثاً - عرض ملخصات الرسائل الجامعية :

تنشر المجلة ملخصات الرسائل الجامعية (الماجستير - الدكتوراه) التي تم إجازتها ، ويراعى فيها أن تكون حديثة، وأن تعد بمعرفة صاحب الرسالة، وأن تمثل إضافة علمية جديدة في أحد مجالات القانون المعروفة، على ألا يزيد العرض على (١٠) صفحات، مع مراعاة أن يضم ما يلي:

- مقدمة لبيان أهمية موضوع الرسالة .
- ملخصاً لموضوع الرسالة وكيفية تحديده، ويكون ضمن الرسالة .

- ملخصاً لمنهج الرسالة وفروضها وعينتها وأدواتها .
- خاتمة لأهم ما توصل إليه معد الرسالة من نتائج وتوصيات .

رابعاً . تقارير اللقاءات العلمية :

- تنشر المجلة التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات التي تتصل موضوعاتها بواحد أو أكثر من مجالات اهتمام المجلة ، والتي انعقدت حديثاً في داخل الكويت أو خارجها، ويراعى فيها:
- أن يغطي التقرير فعاليات الندوة أو المؤتمر مركزاً على الأبحاث العلمية وأوراق العمل المقدمة ونتائجها، وأهم التوصيات التي توصل إليها .
 - ألا يزيد التقرير عن (٥) صفحات .

خامساً . عرض الكتب ومراجعتها :

- تنشر المجلة المراجعات التقييمية للكتب حديثة النشر، التي تخص أي حقل من حقول القانون والتي تتوافر فيها الشروط التالية :
- أن يكون الكتاب متميزاً ومشتماً على إضافة علمية جديدة .
 - أن يكون معدّ المراجعة متخصصاً في المجال العلمي نفسه للكتاب .
 - ألا يكون قد سبق تقديم العرض للنشر في مطبوعة أخرى .
 - أن يعرض المراجع ملخصاً وافياً لمحتويات الكتاب مع بيان أهم أوجه التميز والقصور، على ألا يزيد العرض على (٥) صفحات .
 - تمنح المجلة مقابلاً مالياً لعرض الكتب، الذي يتم بتكليف من المجلة فقط .

* * * * *

مكتوبات العدد

كلمة العدد:

- ٨ د . فهد علي الزميع
- البهوت والدراسات باللغة العربية:**
- ١٣ د . إبراهيم محمد الحمود
- ٤١ د . عبد الرحمن عبدالواحد الرضوان - د . خالد جاسم الهندياني
- ٨٧ د . دينة ناصر الوقيان
- ١٣١ المستشار الدكتور / عبدالله حباب الرشدي
- ١٦٥ أ . علي عودة الشمري
- ٢١٩ أ . د . عدنان إبراهيم سرحان - أ . إيمان خميس الجبائي
- ٢٦٩ أ . د . محمد ارحيص سالم الطراونة
- ٣٢٩ أ . د . محمد سليمان الأحمد - د . عبدالكريم صالح عبدالكريم
- ٣٧٥ د . محمد عبدالجليل المر
- ٤٤١ د . محمد صلاح عبداللاه محمد
- ٤٩٩ د . بدر الدين براحلية
- ٥٤٩ د . عبداللطيف دحية
- ٥٨٩ د . هيثم السيد أحمد عيسى
- ١١ د . مها البشارة
- ٧٥ د . عبدالرحمن الهاجري - المستشار / محمود خميس
- ١٩ - دراسة تطبيقية على
- مدى التزام الإدارة معونة المتعاقد بالإدارة في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) - دراسة تطبيقية على دولة الكويت.
- نحو استنهاض الفكر الجبائي في معالجة الإشكاليات التشريعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) - دراسة تحليلية نقدية.
- أ . علي عودة الشمري
- فيروس كورونا المستجد / كوفيد-١٩ بين القوة القاهرة والظرف الاستثنائي - دراسة في القانونين الإماراتي والفرنسي.
- أ . د . عدنان إبراهيم سرحان - أ . إيمان خميس الجبائي
- جائحة كورونا ومدى مسؤولية الصين الدولية عنها: قراءة قانونية من منظور القانون الدولي.
- أ . د . محمد ارحيص سالم الطراونة
- التطوع لاختبار فاعلية الملقاح الطبي في مواجهة فيروس كورونا - دراسة تحليلية في القانون المدني.
- أ . د . محمد سليمان الأحمد - د . عبدالكريم صالح عبدالكريم
- أثر جائحة كورونا على الحريات العامة - دراسة تحليلية مقارنة في مصر والكويت.
- د . محمد عبدالجليل المر
- آليات مواجهة خطر إفلاس الشركات في زمن جائحة كورونا وجهود التشريعات الوطنية.
- د . محمد صلاح عبداللاه محمد
- محاولة لتطبيق نظرية العقد الناقص على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا.
- د . بدر الدين براحلية
- أثر جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على عقود التجارة الدولية.
- د . عبداللطيف دحية
- مدى انطباق شروط القوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في إطار العقود المدنية - دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي.
- د . هيثم السيد أحمد عيسى
- الأثار القانونية والاقتصادية لوباء كوفيد-١٩ على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: حالة الكويت (باللغة الإنجليزية).
- د . مها البشارة
- غياب التشريعات الوبائية في النظام القانوني الكويتي وتداعيات تعليق جلسات مجلس الأمة (باللغة الإنجليزية).
- د . عبدالرحمن الهاجري - المستشار / محمود خميس

كلمة العدد

يصدر هذا العدد الخاص من مجلة الحقوق ليتناول الآثار القانونية لجائحة كورونا المستجد، وهذا العدد الخاص جاء نتيجة مبادرة شخصية من رئيس التحرير السابق الدكتورة مشاعل الهاجري؛ حيث إنها وعلى الرغم من الجائحة كانت المتابع الرئيسي للتأكد من أن الفكرة يتم قبولها وترجمتها لواقع حقيقي. لذلك تتقدم المجلة ممثلة بهيئة التحرير ومدير التحرير والفريق العامل ورئيس التحرير بالشكر الجزيل للدكتورة مشاعل الهاجري على كل ما قامت به ليرى هذا العدد النور، وتهدي المجلة هذا العدد الخاص للدكتورة مشاعل الهاجري تقديراً لجهودها الخاصة بهذا العدد. والشكر موصول للأستاذ الدكتور رشيد العنزي - رئيس التحرير السابق - على كل ما بذله من جهد ليمثل استمراراً للجهود التي بذلتها الدكتورة مشاعل الهاجري.

وتأتي أهمية هذا العدد والذي سيصدر على أكثر من جزء ليسلط الضوء على التحديات والتبعات القانونية للجائحة غير المسبوقة على منظومتنا القانونية العربية. وتجدر الإشارة إلى أن الآثار القانونية للجائحة تنقسم إلى أكثر من شق:

الشق الأول: يتعلق بمدى كفاءة وانطباق القواعد القانونية القائمة قبل الجائحة والتي هدف من خلالها المشرعون إلى التعامل مع مثل هذه الأحداث غير المسبوقة، فعلى سبيل المثال فإن نظرية الظروف الطارئة وغيرها من النظريات ذات العلاقة ستكون محوراً رئيسياً للمعارك القانونية في أروقة المحاكم. وسيمثل هذا التفاعل بين النص والواقع والتطبيق فرصة غير مسبوقة لمراجعة هذه النظريات والقواعد القانونية، وإطلاق نقاش فقهي ينطلق من واقع غير مسبوق. ونأمل بمجلة الحقوق أن تمثل هذه الإصدارات انطلاقة لمثل هذه النقاشات التي نادراً ما نراها بعالمنا العربي، فالعمل البحثي الفردي هو النهج المهيمن على واقعنا العربي ولعل من أكثر ما نحتاجه هو إطلاق المبادرات الجماعية البحثية كما هو معمول به في الدول الغربية.

الشق الثاني: يتعلق بالتبعات القانونية لجائحة كورونا ويتمثل بمعرفة الفراغ التشريعي والفقهي الذي ستكشف عنه الجائحة، فهذه الجائحة

ستظهر إشكاليات وتحديات قانونية لن نستطيع التعامل معها في ظل النظريات والتشريعات القائمة؛ لذلك بدأنا نرى التدخل التشريعي على مستوى غالبية دول العالم، كمحاولة للتعامل مع العجز الذي ظهر في المنظومة التشريعية الإنسانية. وهذا العجز ليس نتيجة قصور لما هو قائم ولكن نتيجة واقع غير مسبوق فرضته هذه الجائحة، فعلى الرغم من أن هذه الجائحة لا تعد الأولى على المستوى الإنساني، إلا أنه لأول مرة تضطر البشرية للتعامل مع جائحة في ظل العولمة والانفتاح والاتصال غير المسبوق في التاريخ الإنساني.

وهذا الواقع فرض أسئلة حول مسائل أساسية مثل الحقوق والحريات وحدود السلطات التنفيذية على مستوى العالم، وتقاطع المصلحة العامة مع الحقوق للصيقة بالفرد. وهذه الأسئلة لن تنتهي أو تتوقف مع جلاء الجائحة، ولكنها ستستمر وسيستمر الجدل الفقهي والفلسفي حولها؛ لذلك نرى العديد من المسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان يحذرون من خطورة تراجع نمط الحياة، وتآكل حقوق الإنسان المكتسبة بحجة السيطرة على الجائحة. خاصة مع بروز ظواهر مقلقة على المستوى الإنساني مثل السياسات الشعبوية وإقصاء الآخر. والمحزن هو أن الأثر الأعظم للجائحة كان على فئات المجتمع المهمشة، وهو الأمر الذي أعاد للساحة الفكرية مسائل مثل دور الدولة بتوفير الرعاية اللازمة كحق دستوري لفئات المجتمع المهمشة والأقل دخلاً.

ويحدونا الأمل أن يحظى هذا الإصدار بمباركة القارئ العزيز، وأن يقضي معه وقتاً ممتعاً، ويجد في قراءته علماً زاهياً، داعين المولى - عز وجل - التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس التحرير

د. فهد علي الزميع

البحوث والدراسات

مسك القضاء الإداري المستعجل الفرنسي في حماية الحريات الأساسية في ظل جائحة كوفيد-١٩

الدكتور/ إبراهيم محمد الحمود
رئيس قسم القانون العام
كلية الحقوق - جامعة الكويت

ملخص:

إن تدخل الدولة في ظل مكافحة جائحة كوفيد -١٩ بإصدار القرارات الإدارية والأعمال المادية تمس أحياناً وبشكل جسيم الحريات الأساسية للأفراد والجماعات، وقد يكون هذا المساس خطيراً وبشكل يخل بالمشروعية.

إن القاضي الإداري في فرنسا وبموجب القانون الصادر في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ في شأن مدونة القضاء الإداري نظم القضاء المستعجل في طريقتين: الأولى من خلال الدعوى المستعجلة والوقف، والثاني من خلال الدعوى المستعجلة والحرية.

وإذا كان يشترط في الطريق الأول أن يكون هناك دعوى موضوعية لإلغاء القرار الإداري غير المشروع وإن لم تكن مصاحبة لها في صحيفة الدعوى نفسها وفي المقابل فإن الدعوى المستعجلة والحرية لم يتم اشتراط وجود دعوى موضوعية لإلغائها.

إن القاضي الإداري في الدعوى المستعجلة والحرية يوازن بين المصلحة العامة من أجل مكافحة كوفيد -١٩ وحماية الحريات الأساسية، ويتبع منهجاً ثابتاً وخصاً في إصدار أحكامه.

ولقد تم استخدام مصطلحات مثل: دعوى مستعجلة، وقف، حريات أساسية، أوامر وتوجيهات من القاضي، مجلس الدولة الفرنسي، دستور، معاهدة دولية، قرارات إدارية، أعمال مادية.

تمهيد وتقسيم:

في القضاء الإداري لاسيما بدعوى الإلغاء يكون الأساس هو الدفاع عن المشروعية بمفهومها الواسع، فالقاضي يتصدى للقرارات الإدارية غير المشروعة ويحكم بإلغائها، إلا أن الاعتداء على المشروعية بقرارات إدارية أو حتى بأعمال مادية يتطلب في حالات الاستعجال التدخل السريع للقاضي لوقف هذه الاعتداءات بحسبان الحاجة الملحة لصاحب الشأن في رفع الاعتداء عن حقوقه وحرياته من ناحية، وبسبب بطء إجراءات التقاضي وفترات ومواعيد الفصل في موضوع الدعوى، فإن هذا التأخير

قد يترتب عليه إضرار ونتائج يصعب تداركها إن لم يوقف القرار أو العمل المادي بسرعة وبفاعلية من ناحية ثانية.

لذلك أسند المشرع للقاضي مكنة وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، كما أعطى للقاضي في أحوال معينة التدخل لوقف القرار الإداري أو العمل المادي حتى دون وجود دعوى الإلغاء؛ وذلك لمواجهة المساس بالحريات الأساسية في الأوقات العادية أو في الأوقات الاستثنائية.

وإذا كانت مواجهة جائحة كوفيد-١٩ تطلبت من الدولة التدخل بشكل سريع وقياساً أحياناً لحماية الصحة العامة ووقاية النظام العام، فإن التدخل وإن كان واجباً دستورياً على الدولة، فإنه قد يحمل مساساً خطيراً وجسيماً بالحريات الأساسية التي هي بدورها حقوق أساسية يتعين حمايتها، وهنا يكون دور قاضي الإداري كقاضي للأمور الوقتية المستعجلة لوقف هذه القرارات أو منع تطبيقها بشكل كامل، وكذلك وقف الأعمال المادية أو توجيه أوامر للإدارة كي تتخذ إجراءات معينة وسبلاً وطرقاً أخرى من أجل حماية هذه الحريات من الاعتداء عليها، أو تمكين الأفراد من ممارسة الحرية على شكل ومقتضى معين.

وإذا كان القضاء الإداري الفرنسي قد تطور منذ عام ٢٠٠٠ من خلال توسيع اختصاصاته وسلطاته في مجال القضاء الوقتي المستعجل. وأوجد طريقين للقاضي الإداري في أن يتدخل في حالة الاستعجال، الطريق الأول من خلال القضاء المستعجل والوقف، والطريق الثاني من خلال القضاء المستعجل والحرية، وفي هذا الطريق الأخير يوازن القاضي بين حق الدولة الدستوري في حماية الصحة العامة وتأمين النظام العام، وحق الأفراد والجماعات في حماية حرياتهم الأساسية من التعدي الجسيم غير المشروع عليها.

إننا في هذا البحث نلاحظ الآتي:

أ - إشكالية البحث:

ما هو دور القاضي الإداري لوقف تنفيذ القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية، وكذا وقف القرارات الإدارية أو الأعمال المادية الماسة بالحقوق والحريات الأساسية.

هل أصبح القضاء الإداري الوقتي المستعجل ضرورة لحماية الحريات الأساسية لاسيما في الأوقات الاستثنائية؟ وهل كان للقاضي الإداري المستعجل دور إيجابي في

حماية هذه الحريات في وقت أزمة كوفيد-١٩؟ وما هو دور القاضي في التوفيق بين المصلحة العامة والحريات الأساسية الفردية؟ وما هو المنهج الذي يتبعه في حكمه؟ إن البحث يحاول أن يجيب عن هذه الأسئلة التي تعتبر - بحق - محورية لفهم مساهمة القاضي الإداري المستعجل في حماية المشروعية ومنع الاعتداء على الحريات الأساسية.

ب - أهمية البحث:

يبين البحث أهمية دور القاضي الإداري المستعجل في الموازنة بين مبدأ نافذية القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية وحماية الحريات الأساسية، فالقاضي هو الحامي للمشروعية وهو الملاذ في حماية الحريات الأساسية من التعدي عليها. إن تطور دور القاضي الإداري في القضاء الوقتي المستعجل يحقق مزايا إضافية للمتعاملين مع الإدارة، ويوقف التغول على الحريات الأساسية من خلال وقف تنفيذ القرارات غير المشروعة والأعمال المادية والتصدي للاعتداءات على الحريات الأساسية، فأصبح للقاضي أن يوجه الإدارة فيما عليها اتباعه لعدم المساس الجسيم بالحريات الأساسية.

موضوع البحث:

يتناول البحث الدراسة العملية في دور قاضي الأمور المستعجلة الفرنسي في حماية الحريات الأساسية في ظل جائحة كوفيد-١٩، والتوفيق المتوازن بين هذه الحريات الأساسية من ناحية، وحقوق الدولة وواجبها في حماية الصحة العامة من ناحية أخرى.

إن دور القاضي المستعجل الفرنسي قد تطور منذ عام ٢٠٠٠ بصدر القانون بإنشاء مدونة القضاء الإداري بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٠٠، وقد عني المشرع في هذا القانون في المادة (٢٠١ - ٥٢١) بتمكين القاضي الإداري في المسائل المستعجلة من أن يوقف القرارات الإدارية والأعمال المادية في حالة الاستعجال والاعتداء على مبدأ المشروعية بشكل واضح وجلي، كما أنه أعطى للقاضي الإداري وبصفة مستعجلة أن يتدخل لحماية الحريات الأساسية متى كان هناك مساس جسيم في حالة الاستعجال.

وقد قام القاضي الإداري في ظل جائحة كوفيد-١٩ بالتدخل بشكل ملفت للنظر من أجل حماية الحريات الأساسية والتوفيق بينها وبين واجب الدولة في حماية الصحة العامة، وتأمين النظام العام في هذه الأزمة الصحية الاستثنائية.

منهجية البحث:

اتبع البحث المنهج التحليلي لدور القضاء الإداري الفرنسي في المسائل المستعجلة من أجل حماية الحريات الأساسية في ظل تدخل الدولة بقرارات إدارية وأعمال مادية من أجل حماية الصحة العامة ومكافحة جائحة كوفيد-١٩. وركزت الدراسة على الجانب العملي من خلال عرض الأحكام والقرارات القضائية المستعجلة التي صدرت من مجلس الدولة في موضوع وقف التنفيذ المؤقت وتحليل هذه الأحكام.

لقد اعتمدنا في هذا البحث على تحليل أحكام القضاء الفرنسي دون الدخول في الجانب النظري التقليدي في دراسة نظرية وقف تنفيذ القرارات الإدارية؛ إذ إننا أردنا أن نرى الواقع العملي لتعامل القاضي مع القرارات الإدارية والأفعال المادية في ظل مواجهة جائحة كوفيد-١٩، ودوره في حماية الحريات الأساسية من الاعتداء الجسيم عليها بحسبان تدخل الدولة بشكل مباشر وكبير في إصدار القرارات الإدارية والأفعال المادية ذات الصلة من أجل تحقيق الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطة البحث:

لدراسة مساهمة مسلك القضاء الإداري المستعجل في وقف القرارات الإدارية غير المشروعة والأعمال المادية وحماية الحريات العامة في ظل جائحة كوفيد -١٩، فإننا قسمنا الدراسة على الوجه الآتي:

المبحث الأول: تطور القضاء الإداري المستعجل

المبحث الثاني: موازنة القضاء الإداري المستعجل بين حماية الصحة العامة وتأمين النظام العام والحريات الأساسية

المبحث الأول القضاء الإداري المستعجل في فرنسا

قبل عام ٢٠٠٠ كان القضاء الإداري المستعجل في فرنسا مرتبطاً بالدعوى الأصلية للإلغاء، أي أنه كان لازماً الطلب بإلغاء القرار الإداري، وإن لم يكن يشترط أن يقدم وقف التنفيذ بذات صحيفة الدعوى^(١).

ولكن بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٠٠ صدرت مدونة القضاء الإداري التي أنشأت نوعين من القضاء الإداري الوقتي المستعجل، الأول تحت مسمى القضاء المستعجل والوقف في المادة (L.521.1)، والثاني هو القضاء المستعجل والحرية في المادة (L.521.2).

إن هذا التطور في القضاء الإداري المستعجل كان ملفتاً في التصدي للاعتداءات على مبدأ المشروعية والحقوق والحريات الأساسية بشكل كبير^(٢).

وفي ظل جائحة كوفيد-١٩ كان للقضاء المستعجل والحرية دور بارز في إيقاف الكثير من القرارات الإدارية والأعمال المادية التي صدرت عن الإدارة بحجة المحافظة على الصحة العامة وتأمين النظام العام.

المطلب الأول القضاء المستعجل والوقف

لقد نظم المشرع الفرنسي في مدونة القضاء الإداري موضوع القضاء المستعجل والوقف في المادة (L.521.1) لمواجهة جميع القرارات الإدارية الصريحة بالرفض الإيجابية والضمنية والسلبية. ولقد كان القرار بالرفض الضمني والسلبى يعتبر غير ممكن وقف التنفيذ^(٣)، وهذا الموقف السابق لمجلس الدولة يبنى على مبدأين: الأول يقوم على مفهوم القرار الإداري المنفذ بحسبان أن الصفة التنفيذية هي الأساس للقانون العام، والرفض لا يظهر منه تغيير في المركز القانوني، فلا يغير شيئاً وليس له صفة تنفيذية، فهو لم يتم تنفيذه فكيف يتم وقف تنفيذه بدعوى وقف تنفيذ القرار^(٤).

R.van dermeeren en (Glerton dir) L Harmatton 2002 P. 142. (١)

J.Andriantsm bazoviha versum tontrole de fondamenblifè, RFDA, 2002,p. 133. (٢)

CE,23 Janv,1970 (٣)

D. Labetoulle, le projet de réforme des precedures d'urgence deuant le jue administratif AJDA,1999. (٤)

والمبدأ الثاني يقوم على مفهوم أن القاضي الإداري ليس من سلطته عمل قرارات إدارية أو إصدار توجيهات للإدارة، وأن هذين المبدأين لهما تطبيق عام لأنهما يعينان إلزام الإدارة باتخاذ قرار معاكس للقرار الضمني أو السلبي بالرفض، ومع القانون الجديد فإن مسلك القضاء الإداري قد تغير، وذلك بأن أصبح ينظر من ناحية (إلى القرار بالرفض الضمني والسلبي بأن لهما تأثيراً مباشراً على المتعامل مع الإدارة وقضاء التوجيه للإدارة لاتخاذ إجراءات أصبح ممكناً من أجل تنفيذ القانون وأحكام القضاء الإداري^(٥))، لذلك فقد تم إهمال المبدأ الذي كان يقرر عدم وقف القرارات الضمنية والسلبية بالرفض؛ لأن القاضي في دعوى الوقف والإلغاء سيقوم بفحص الموضوع بشيء من التعمق، وأصبح القاضي يحكم بالوقف استقلالاً قبل الفصل في الموضوع).

(إن طلب وقف التنفيذ في دعوى الوقف والإلغاء لا يقبل إن لم يكن هناك قرار إداري منشئ بما في ذلك القرارات المالية^(٦))، كالقرار بتحصيل أو ربط الضريبة.

وإذا كانت الدعاوى القديمة يشترط فيها أن يكون التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى نتائج من الصعب تداركها، وأن المعطيات في الدعوى يظهر منها تبرير إلغاء القرار، فإنه في الدعوى المستعجلة للوقف فإن الوقف يمكن الحكم به إذا كان الاستعجال يبرره، وتظهر الحالة في الدعوى وجود شكوك حقيقية بالنسبة لمشروعية القرار محل الطعن^(٧).

إن شرط الاستعجال لم يتم تعريفه بشكل محدد في القانون، وإنما ترك الأمر للقضاء الذي لطف وخفف من غلواء معناه، فينظر إلى نتائج القرار إن تم تنفيذه وفقاً للأضرار التي لا يمكن تدارك آثارها، وهذه مسألة واقع، أي أن تؤدي إلى تغييرات مهمة جداً يصعب عند إلغاء القرار تعديلها، وبعبارة أكثر دقة وعمومية تؤدي إلى نتائج من الصعوبة إصلاحها والتعافي منها.

ففي فرنسا فإنه وفقاً للمادة (L.521.1) من مدونة القضاء الإداري تم النص صراحة على شرط الاستعجال ومع ذلك لم يتم تعريفه.

ومن أجل تعريفه يذهب مجلس الدولة في حكم له بأن هناك^(٨) تحليلين، فمن

CE, 12 Janvier 20d.

(٥)

CE, mai 2001.

(٦)

CE, 15 Janvier 2001.

(٧)

CE, 19 Janv, 2001

(٨)

جانب فإن شرط الاستعجال يتعين النظر إليه باعتباره محققاً متى ما كان القرار الإداري قد تسبب بضرر كبير وحال بالنسبة للطاعن أو لمصلحته التي يدافع عنها، ومن ناحية ثانية فإنه يعود للقاضي لتقدير الأسباب والمعطيات التي يقدمها الطاعن إذا كانت بالنسبة للوضع الذي هو فيه، أو الأشخاص المعنيين بالنسبة لهم تعتبر حالة استعجال. وهكذا فإن الاستعجال أصبح مسألة موضوعية ومسألة شخصية في ذات الوقت، وفقاً لكل موضوع على حدة، أي بشكل عام ينظر إلى الاستعجال كحالة واقع.

إن شرط الاستعجال يتحقق بالنسبة لأطباء يريدون تغيير مكان عملهم والانتقال إلى مكان آخر^(٩)، كذلك يتحقق شرط الاستعجال في قرار المحافظ رفض دعوة مجلس المحافظة للاجتماع^(١٠)، كذلك قرار تحصيل الضريبة^(١١)، كذلك قرار رفض ترخيص سيارة^(١٢).

وفي حقيقة الأمر والواقع إن شرط الاستعجال ينظر إليه أحياناً باعتباره مفترضاً بالنسبة لبعض القرارات كقرار حل مجلس إدارة^(١٣) شركة أو مؤسسة، بحسبان مجلس الإدارة هو الحاكم لها الذي من دونه لا يمكن السير بالعمل.

وإذا كان هذا هو مفهوم الاستعجال فإن المادة (L.521.1) من المدونة تشترط أن يكون القرار يحمل شكوكاً حقيقية وخطيرة في مخالفة المشروعية، فعدم مشروعية القرار بحسب الشكوك الحقيقية والخطيرة تكفي بحد ذاتها لوقف تنفيذ القرار، وهذا بطبيعة الحال لا يقيد القاضي عند بحث موضوع الإلغاء.

فإن توفر الشرطان الاستعجال والشكوك الحقيقية الخطيرة لمخالفة المشروعية فإن للقاضي أن يتخذ الموقف المطلوب.

وللقاضي أن يوقف القرار ولكن بصفة مؤقتة، وهذا لا يعني مطلقاً إلغاء القرار. ومن المسلم به أن القاضي لا يستطيع وقف تنفيذ القرار إن كان لا يستطيع إلغاء القرار فإنه لا يستطيع وقفه، فلا يستطيع القاضي وقف قرار الإدارة إن قامت بتوقيع العقد^(١٤).

CE, 28 fèv, 2001 (٩)

CE, 5 mars 2001 (١٠)

CE, sec, 25 Avr, 2001 (١١)

CE, 27 août 2013 (١٢)

CE, 7jin 2019 (١٣)

CE, 27 nov, 2002 (١٤)

ويستطيع القاضي أن يوقف القرار في جزء منه كقرار عدم اعتماد أدوية طبية إلا بعد مرور مدة زمنية، فيستطيع القاضي أن يوقف الجزء الخاص بالمدة الزمنية^(١٥). وبالنسبة للقرارات الضمنية والسلبية بالرفض فإن من سلطة القاضي أن يأمر بالأوضاع التي على الإدارة انتهاجها، أو أن يبين الالتزامات التي على الإدارة أن تقوم بها لتنفيذ الحكم^(١٦).

فللقاضي أن يبين الأوضاع والنهج الذي عليها أن تقوم به لتنفيذ الحكم، أو القانون الذي امتنعت عن إصدار القرار بموجبه، فالقرار السلبي بعدم منح ترخيص يكون إيقافه من خلال الأمر الموجه من القاضي باستخراج ترخيص مؤقت، وللقاضي أن يوجه الإدارة ويلزمها بإصدار القرار السلبي^(١٧)، أي أن يلزمها بإصدار قرار إيجابي بمنح الترخيص، أو إعادة فحص الشروط لمنح الترخيص أو تجديده.

ولا شك في أن القضاء الإداري في دعوى الاستعجال والوقف لا يتصدى للأعمال المادية لعدم وجود قرار إداري فيها، وإنما الذي يتصدى لها الآن وفقاً للقانون الصادر في ٣٠ يونيو ٢٠٠٠ هو القاضي الإداري في دعوى الاستعجال والحرية بعد أن كان القاضي المدني هو الملاذ للحريات في حال انتفاء الصفة عن القرار الإداري وتحوله إلى عمل مادي كما سوف نرى لاحقاً في هذه الدراسة.

المطلب الثاني القضاء المستعجل والحرية

إن المادة (L.521.2) من مدونة القضاء الإداري أعطت للقاضي الإداري التأمين والحماية بواسطة إجراءات القضاء المستعجل للحريات العامة.

(إن الدعوى المستعجلة لحماية الحرية تم تنظيمها متى تم المساس بالحريات الأساسية، إن مفهوم الدعوى المستعجلة والحرية وجدت لحماية الحريات الأساسية التي أشارت إليها المادة (L.521.2) من المدونة، وهذه تعتبر من أهم المفاهيم التي أتى بها القانون الصادر في ٣٠ يونيو ٢٠٠٠، بحسبانه قد وجد لحماية الحريات الأساسية، وهو مدخل جديد لإجراءات القضاء المستعجل الإداري. إن حماية الحريات الأساسية تشمل الحريات الدستورية الفردية والصناعية والاجتماعية والدولية كذلك،

CE, 13 juin 2016

(١٥)

CE, 27 juill 2001

(١٦)

CE, 18 Janvier 2001

(١٧)

بالإضافة للحريات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، وتلك التي يعتبرها القضاء الإداري من المبادئ العامة للقانون.

وقد عمل مجلس الدولة على توسيع مفهوم الحريات الأساسية التي عليه حمايتها، ففي مجال الحريات الفردية تصدى مجلس الدولة للكثير من الطلبات بشأنها ومنها الحق في الحياة^(١٨) والحق في حماية الحياة الخاصة^(١٩) والحق في الزواج^(٢٠) والحق في حياة زوجية هادئة^(٢١) وحرية المراسلات^(٢٢) والأصل البراءة^(٢٣) والحق في عدم الإهانة وعدم الاحترام غير الإنساني^(٢٤) والحق في الانتقال والتنقل^(٢٥) والحرية الشخصية والحق في الاعتقاد^(٢٦) وحرية التعبير للمريض عن علاج يعطى له^(٢٧) وحرية مساعدة الآخرين لأغراض وأهداف إنسانية^(٢٨).

بل إن القاضي الإداري في الاستعجال لحماية الحريات الأساسية توسع وقرر حماية الحريات الأساسية ذات القيمة الأوروبية بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي^(٢٩) كحرية رفع الدعوى القضائية^(٣٠) وحق أصحاب الاحتياجات الخاصة بالتعليم^(٣١).

وفيما يتعلق بالحريات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تم اعتبارها من الحريات الأساسية وفقاً للدستور مثل حرية التملك والانتفاع من العين^(٣٢) والحق في

CE, 16 Nov. 2011	(١٨)
CE, 25 oct, 2007	(١٩)
CE, juill, 2014	(٢٠)
CE, 30 oct, 2001	(٢١)
CE, Avr, 2004	(٢٢)
CE, 4 Mars, 2005	(٢٣)
CE, 22 Dèc, 2012	(٢٤)
CE, 9 Janv, 2001	(٢٥)
CE, 26 Août, 2016	(٢٦)
CE, 16 Août, 2016	(٢٧)
T.A Besançon, 28 Août 2016	(٢٨)
CE, 9dèc, 2014	(٢٩)
CE,30jain,2009	(٣٠)
CE, 15 dèc, 2010	(٣١)
CE, 29 Mars 2002	(٣٢)

الحصول على حكم قضائي^(٣٣) وحرية التجارة والصناعة^(٣٤) والحق في العمل وحرية اختيار نوعه^(٣٥).

كذلك اعتبر قاضي الأمور المستعجلة الحرية الجماعية من الحريات الأساسية واجبة الحماية مثل حرية الانتخابات^(٣٦) وحرية التجمع والاجتماع^(٣٧). إن قاضي الأمور المستعجلة والحرية يعتبر الحق في الصحة العامة من الحقوق الأساسية^(٣٨) كما اعتبر مجلس الدولة أن الحق في طلب اللجوء من الحقوق الأساسية للأجانب^(٣٩)، وكذلك حق الأقاليم في الحماية القضائية^(٤٠)، في مواجهة القرارات والأعمال التي تتخذها الإدارة المركزية.

ومن المهم بيانه هنا أنه يتعين لتدخل القاضي الإداري بصفة مستعجلة لحماية الحريات أن يكون المساس بالحرية تم بواسطة شخص عام أو شخص خاص معهود إليه إدارة مرفق عام أو تنفيذه أو المساعدة بأي شكل فيه أثناء ممارسة سلطاته.

ومما يتعين بيانه أن المساس بالحريات الأساسية قد يكون بفعل مادي يصدر وليس فقط بقرار إداري؛ لذلك - وعلى خلاف دعوى الاستعجال والوقف - فإن دعوى الاستعجال والحرية يمكن إقامتها دون أن تكون هناك دعوى إلغاء قرار إداري؛ لأنها هنا تكون موجهة ضد عمل مادي للإدارة أو لشخص خاص معهود إليه إدارة أو تنفيذ أو المساهمة في نشاط مرفق. ولكن حتى هنا فإنه يتعين أن يكون هناك مساس بالحريات الأساسية، وأن يكون المساس جسيماً، وتكون عدم المشروعية بالاعتداء على الحريات الأساسية فيه واضحة.

أما إن كان المساس بالحرية الأساسية خارجياً عن الإدارة أو من شخص خاص موكل من قبل الإدارة فإنه لا يمكن اللجوء إلى دعوى الاستعجال والحرية، وبالنسبة لقرار فصل الموظف أو تأديبه، وإن كان غير مشروع فإنه لا يشكل بذاته اعتداء أو مساساً بالحرية الأساسية^(٤١)، إلا في أحوال خاصة.

CE, 1er juin 2017	(٣٣)
CE, 12 Nov 2001	(٣٤)
CE, 10 Fèv, 2012	(٣٥)
CE, 7 Fèv, 2001	(٣٦)
CE, 19 Août 2002	(٣٧)
CE, 8 sept 2005	(٣٨)
CE, 12 Jan, 2001	(٣٩)
CE, 18 Jan 2001	(٤٠)
CE, sed, 28 Fèv 2001	(٤١)

فلا شك في أن السبب في القرار هو الذي يبين إن كان هناك مساس خطير بالحريات الأساسية كالقرار بعدم قبول شخص للوظيفة العامة بسبب آرائه السياسية^(٤٢).

إن شرط الاعتداء الخطير والجسيم على الحرية الأساسية وعدم مشروعية الاعتداء على الحريات الأساسية الظاهرة يعتبران شرطين مستقلين، أي لا بد من أن يكون هناك اعتداء خطير وجسيم على الحرية الأساسية من ناحية، ووجود عدم مشروعية الاعتداء الظاهر في القرار أو العمل من ناحية ثانية في الاعتداء على الحرية الأساسية، ويتعين أن يكمل كل شرط الشرط الآخر^(٤٣).

إن جسامة الاعتداء ينظر إليها بالنسبة للموضوع الشخصي لمن تم المساس بحريته الأساسية كالاعتداء على حرية شخص من خلال منعه من العيش في أسرته بسبب قرار إبعاده.

وكذلك تظهر جسامة الاعتداء في الاعتداء على حق الملكية من خلال القرار السلبي برفض طرد غاصب^(٤٤).

(إن شكل وهيئة الاعتداء الخطير والجسيم على المشروعية يمكن أن يكون لإبعاده عن الشخص أو لعدم تطبيقه عليه، أي إبعاد الاعتداء أو القيام بالقرار لحماية الحرية الأساسية لإبعاد العدوان، مثل عدم حماية عاملين في حقول النفط من الانبعاثات الغازية^(٤٥) أو لعدم احترام القوانين واللوائح وتطبيقها عليه)^(٤٦).

وإذا كان القرار الإداري المنعدم يعتبر عملاً مادياً ولم يكن مقبول النظر فيه من اختصاص القاضي الإداري في دعوى الإلغاء فإنه اليوم وبفضل دعوى الاستعجال والحرية أصبح من اختصاص القاضي الإداري المستعجل أن يوقف هذا العمل في هذه الدعوى^(٤٧).

إن الصلاحيات المملوكة للقاضي الإداري في هذه الدعوى للتدخل يتعين تبريرها

CE, 28 mai, 1954 (٤٢)

CE, 30 oct 2001 (٤٣)

CE, 14 Mars, 2011 (٤٤)

CE, 11 Déc, 2015 (٤٥)

CE, 11 Déc, 2015 (٤٦)

CE, 23 Jan 2013 (٤٧)

بعنصر الاستعجال من ناحية، وبوجوب حماية الحريات الأساسية التي يتم الاعتداء عليها بأن يكون هناك اعتداء غير مشروع من ناحية أخرى.

وعنصر الاستعجال في الدعوى المستعجلة والحرية أوسع مدى منه في الدعوى المستعجلة والوقف؛ إذ يقرر القانون وجوب تدخل القاضي والفصل في الدعوى خلال ٤٨ ساعة^(٤٨)، نظراً لأهمية الحريات الأساسية وحجم الاعتداء الجسيم وغير المشروع على هذه الحريات الأساسية.

ويتعين ملاحظة شرط الاستعجال بشكل موضوعي وبشكل خاص شخصي بالنسبة لمن تم الاعتداء على حريته الأساسية، ويتم التنفيذ للأحكام والقرارات القضائية خلال ٨ أيام من تاريخ اتخاذها.

وهكذا فإنه يجب أولاً أن ينظر للظروف الخاصة للمضروور كالقرار السلبي بمنع منح اللجوء إلى شخص عائلته متواجدة في الداخل، أو بأنه مهدد في الخارج، أي أنه يتعين النظر إلى طبيعة الموضوع^(٤٩)، فهو موضوع منع شخص من الالتحاق بأسرته، وهو موضوع حرية أساسية نظمها الدستور بحق اللجوء، وهو موضوع شخص يلم شمل الأسرة.

إن القاضي الإداري يستطيع اتخاذ الوسائل اللازمة والضرورية، فله أن يأمر بوسائل لحماية الحريات الأساسية، والسلطة الممنوحة للقاضي واسعة، إذ إنه يستطيع إلزام الإدارة بأن تتخذ الوسائل اللازمة لحماية الحرية الأساسية، كتخفيف شروط التواجد في مكان عام أو الدخول لدور العبادة، ومن ثم يستطيع أن يؤقلم حكمه للظروف في كل قضية على حدة.

ومن الضروري أن نعلم بأن الوسائل التي يأمر بها القاضي هي وسائل مؤقتة ما لم يكن هناك مجال للتأقيت في الوسائل^(٥٠) فالوسيلة التي يأمر بها القاضي تكون مؤقتة وتتم خلال ٤٨ ساعة من أجل حماية الحريات الأساسية^(٥١).

ويمكن للقاضي إن يأمر بوقف القرار كما هو الشأن في دعوى الاستعجال والوقف، ويمكن للقاضي إصدار توجيهات للإدارة، كتوجيه الإدارة بتمكين المدعي من الدخول لمقر النقابة وأخذ الأوراق، ويستطيع مثلاً أن يوجه الإدارة بإزالة عربة للبيع

CE, 28 Fèv 2003

(٤٨)

CE, 25 Mars, 2002

(٤٩)

CE, 31Mai 2007

(٥٠)

CE, 28 juill 2017

(٥١)

تزعج السكان، أو يوجه الإدارة بمنع وجود بنات الهوى في الحديقة العامة، أو يوجهها لمعالجة حبس الحيوانات^(٥٢) السائبة.

كما يستطيع القاضي أن يأمر الإدارة المختصة بأن تتولى بشكل مؤقت تنظيم خدمة تحت مسؤوليتها إن كان ذلك يمس حرية أساسية، أو أن تطلب وتتفق مع جهة معينة لتنظيم الخدمة^(٥٣)، وهكذا فإن الحكم في دعوى الاستعجال والحرية يمكن أن يوقف القرار الإداري أو العمل المادي غير المشروع الذي يمس الحريات الأساسية. إن ذلك التدخل للقاضي الإداري أدى إلى تقليل دور مكنة التنازع في قضايا الأعمال المادية التي كان يختص فيها حصرياً القضاء المدني.

ومع ذلك فإن القاضي الإداري في هذه الحالة لا يستطيع تقرير تعويض للمتضرر، على خلاف القاضي المدني الذي له ذلك، بالإضافة لإزالة الضرر، فاختصاص القاضي المدني أوسع وأكثر فاعلية، في حين يقتصر دور القاضي الإداري في الدعوى المستعجلة والحرية بإلزام الإدارة برفع الاعتداء عن المساس بالحرية الأساسية لاسيما حرية التملك في الاستعمال والاستغلال والتصرف^(٥٤).

إن دعوى الأعمال المادية التي يختص بها القاضي المدني كانت توجه ضد القرار الإداري المنعدم لسببين: الأول الانعدام بسبب الإجراءات، كأن يتم تنفيذ قرار بمخالفة الإجراءات بشكل جسيم، مثال ذلك أن يصدر قرار من مجلس الأمة بتأديب موظف في وزارة التربية، أو أن يصدر قرار من محافظ البنك المركزي في موضوع يخص وزير التعليم العالي بمنح شهادة علمية.

أما السبب الثاني لانعدام القرار الإداري فهو يتعلق بالمخالفة الصارخة للقانون، كأن يصدر قرار بإزالة مبنى لا يقع ضمن مساحة المشروع أو داخل خط الإزالة، وفي حالتي الأعمال المادية يكون المساس بالحريات الأساسية خطيراً وجسيماً كاعتداء على الحق في الملكية.

CE, 23 Nov, 2015

(٥٢)

CE, 28juill 2017

(٥٣)

T.c 17 juin 2013.

(٥٤)

المبحث الثاني

الموازنة بين الحريات الأساسية وحماية الصحة العامة

القاضي الإداري في تدخله كقاضي أمور مستعجلة يوازن بين حقين دستوريين: حريات الأفراد الأساسية كحقوق دستورية أصيلة من ناحية، وحق حماية الصحة العامة كحق دستوري من ناحية ثانية.

وفي ظل جائحة كوفيد-١٩ كان للدولة أن تتدخل بشكل أكثر تقييداً للحريات الأساسية بحجة التصدي لمخاطر الجائحة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت الضرورة وإعلان حالة الطوارئ الطبية والأحكام العرفية يكون هناك تضيق على الحريات العامة الأساسية لمصلحة توفير الأمن العام والمحافظة على النظام العام الذي منه حماية الصحة العامة.

إن القاضي الإداري بحسبانه قاضياً للأمور المستعجلة يوازن بين توفير الصحة العامة وحماية النظام العام، وبين حماية الحريات الأساسية من التعسف خلال هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-١٩.

ومن خلال استعراض مجموعة من قرارات وأحكام مجلس الدولة الفرنسي بحسبانه قاضي أمور مستعجلة سنتعرف على كيفية تدخل القاضي لتأمين هذا التوازن من خلال وقف تنفيذ القرارات والأعمال المادية التي تمس بالحريات الأساسية بشكل خطير ومتعسف، وأيضاً من خلال توجيه الأوامر للإدارة باتخاذ قرارات لحماية الحريات الأساسية (المطلب الأول)، كما أن القاضي الإداري بحسبانه قاضياً للأمور المستعجلة يتبع منهجية ثابتة في أحكامه لقياس مدى مساس القرارات الإدارية والأعمال المادية المتخذة في ظل مكافحة جائحة كوفيد-١٩ أي في ظل الظروف الاستثنائية بالحريات الأساسية، وكيفية حماية هذه الحريات الأساسية (المطلب الثاني).

المطلب الأول

(أحوال) حالات أو أمثلة لتدخل القاضي الإداري كقاضي أمور مستعجلة لتأمين التوازن بين الحريات الأساسية وتحقيق الصحة العامة

تصدى مجلس الدولة بحسبانه قاضي أمور مستعجلة لعدة طلبات في مواجهة قرارات إدارية أثناء جائحة كوفيد-١٩ بحجة مساس هذه القرارات بالحقوق والحريات العامة الأساسية، ومن أهم هذه الأحكام:

١ - التجمع في دور العبادة: فقد حكم مجلس الدولة في هذا الموضوع حيث^(٥٥) تقدمت عدة جمعيات نفع عام وأفراد بطلب وقف القرار بمنع الاجتماع والتجمعات في دور العبادة خلال فترة رفع الحظر وتقرير تخفيف إجراءاته.

وفي هذا الحكم أمر مجلس الدولة كقاضي أمور مستعجلة رئيس الوزراء خلال مدة ثمانية أيام بعد رفع الحظر الكلي أن يعدل المرسوم الصادر بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠، وبأن يكون بدلاً من حظر التجمعات في دور العبادة بشكل مطلق وتام أن يتم أخذ وسائل متشددة للوقاية المطبقة تبعاً للظروف والزمن، مع بدء رفع الحظر الكلي من أجل إمكانية التجمعات والاجتماع في أماكن دور العبادة.

إن مجلس الدولة انتصر هنا لحرية العقيدة والتعبد معتبراً أنها حرية أساسية تعطي للمؤمنين بها الحق في التجمع والاجتماع لإحياء الشعائر الدينية الخاصة بهم وخاصة في أماكن دور العبادة، ومع ذلك يتعين التوفيق بين هذه الحرية الأساسية والأهداف ذات القيمة الدستورية لحماية الصحة العامة.

ففي هذه الدعوى رفض القاضي الإداري المنع المطلق لحرية ممارسة الشعائر الدينية في أماكن دور العبادة من خلال الاجتماع بين المؤمنين بهذه العقيدة بحسبان ممارسة الشعائر الدينية في هذه الدور تعتبر حرية عامة أساسية، كما أن القاضي الإداري اعتبر المرسوم محل الطعن مخالفاً بمبدأ المساواة؛ إذ إنه في الوقت الذي قرر المنع المطلق للتجمعات في دور العبادة صرح بجواز التجمع لأقل من عشرة أشخاص في الأماكن الأخرى.

٢ - قرار الرقابة بالطائرات دون طيار تنفيذاً لقرار حالة الطوارئ بتاريخ ١٨ مايو^(٥٦): وفي هذه الدعوى تقدمت جمعيات حقوق الإنسان بطعن لإيقاف مرسوم الرقابة بواسطة طائرات الدرون التي أمر بها محافظ باريس من أجل رقابة احترام إجراءات الحظر، وبعد أن رفضت محكمة باريس هذا الطلب تم تقديم استئناف أمام مجلس الدولة كقاضي أمور مستعجلة.

وقد قرر مجلس الدولة إيقاف تحليق طائرات الدرون فوراً عن رقابة الأشخاص خلال فترة الحظر الكلي، ولقد دفع المحافظ في مرافعته بأن طائرات الدرون لم تستخدم للتعرف على الأشخاص ولكن لملاحظة تجمعات الأفراد في منطقة باريس

- ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - ١٣٤ - ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦ - ١٦٧ - ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠ - ١٨١ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - ٤٠٩ - ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ - ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٤ - ٥١٥ - ٥١٦ - ٥١٧ - ٥١٨ - ٥١٩ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - ٥٣٠ - ٥٣١ - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - ٥٣٦ - ٥٣٧ - ٥٣٨ - ٥٣٩ - ٥٤٠ - ٥٤١ - ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - ٥٤٥ - ٥٤٦ - ٥٤٧ - ٥٤٨ - ٥٤٩ - ٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٢ - ٥٥٣ - ٥٥٤ - ٥٥٥ - ٥٥٦ - ٥٥٧ - ٥٥٨ - ٥٥٩ - ٥٦٠ - ٥٦١ - ٥٦٢ - ٥٦٣ - ٥٦٤ - ٥٦٥ - ٥٦٦ - ٥٦٧ - ٥٦٨ - ٥٦٩ - ٥٧٠ - ٥٧١ - ٥٧٢ - ٥٧٣ - ٥٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٦ - ٥٧٧ - ٥٧٨ - ٥٧٩ - ٥٨٠ - ٥٨١ - ٥٨٢ - ٥٨٣ - ٥٨٤ - ٥٨٥ - ٥٨٦ - ٥٨٧ - ٥٨٨ - ٥٨٩ - ٥٩٠ - ٥٩١ - ٥٩٢ - ٥٩٣ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - ٥٩٦ - ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - ٦٠٠ - ٦٠١ - ٦٠٢ - ٦٠٣ - ٦٠٤ - ٦٠٥ - ٦٠٦ - ٦٠٧ - ٦٠٨ - ٦٠٩ - ٦١٠ - ٦١١ - ٦١٢ - ٦١٣ - ٦١٤ - ٦١٥ - ٦١٦ - ٦١٧ - ٦١٨ - ٦١٩ - ٦٢٠ - ٦٢١ - ٦٢٢ - ٦٢٣ - ٦٢٤ - ٦٢٥ - ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٢٩ - ٦٣٠ - ٦٣١ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٣٥ - ٦٣٦ - ٦٣٧ - ٦٣٨ - ٦٣٩ - ٦٤٠ - ٦٤١ - ٦٤٢ - ٦٤٣ - ٦٤٤ - ٦٤٥ - ٦٤٦ - ٦٤٧ - ٦٤٨ - ٦٤٩ - ٦٥٠ - ٦٥١ - ٦٥٢ - ٦٥٣ - ٦٥٤ - ٦٥٥ - ٦٥٦ - ٦٥٧ - ٦٥٨ - ٦٥٩ - ٦٦٠ - ٦٦١ - ٦٦٢ - ٦٦٣ - ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٦٦٦ - ٦٦٧ - ٦٦٨ - ٦٦٩ - ٦٧٠ - ٦٧١ - ٦٧٢ - ٦٧٣ - ٦٧٤ - ٦٧٥ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - ٦٧٨ - ٦٧٩ - ٦٨٠ - ٦٨١ - ٦٨٢ - ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٨٥ - ٦٨٦ - ٦٨٧ - ٦٨٨ - ٦٨٩ - ٦٩٠ - ٦٩١ - ٦٩٢ - ٦٩٣ - ٦٩٤ - ٦٩٥ - ٦٩٦ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - ٧٠٠ - ٧٠١ - ٧٠٢ - ٧٠٣ - ٧٠٤ - ٧٠٥ - ٧٠٦ - ٧٠٧ - ٧٠٨ - ٧٠٩ - ٧١٠ - ٧١١ - ٧١٢ - ٧١٣ - ٧١٤ - ٧١٥ - ٧١٦ - ٧١٧ - ٧١٨ - ٧١٩ - ٧٢٠ - ٧٢١ - ٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - ٧٢٦ - ٧٢٧ - ٧٢٨ - ٧٢٩ - ٧٣٠ - ٧٣١ - ٧٣٢ - ٧٣٣ - ٧٣٤ - ٧٣٥ - ٧٣٦ - ٧٣٧ - ٧٣٨ - ٧٣٩ - ٧٤٠ - ٧٤١ - ٧٤٢ - ٧٤٣ - ٧٤٤ - ٧٤٥ - ٧٤٦ - ٧٤٧ - ٧٤٨ - ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ - ٧٥٢ - ٧٥٣ - ٧٥٤ - ٧٥٥ - ٧٥٦ - ٧٥٧ - ٧٥٨ - ٧٥٩ - ٧٦٠ - ٧٦١ - ٧٦٢ - ٧٦٣ - ٧٦٤ - ٧٦٥ - ٧٦٦ - ٧٦٧ - ٧٦٨ - ٧٦٩ - ٧٧٠ - ٧٧١ - ٧٧٢ - ٧٧٣ - ٧٧٤ - ٧٧٥ - ٧٧٦ - ٧٧٧ - ٧٧٨ - ٧٧٩ - ٧٨٠ - ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٨٤ - ٧٨٥ - ٧٨٦ - ٧٨٧ - ٧٨٨ - ٧٨٩ - ٧٩٠ - ٧٩١ - ٧٩٢ - ٧٩٣ - ٧٩٤ - ٧٩٥ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - ٨٠١ - ٨٠٢ - ٨٠٣ - ٨٠٤ - ٨٠٥ - ٨٠٦ - ٨٠٧ - ٨٠٨ - ٨٠٩ - ٨١٠ - ٨١١ - ٨١٢ - ٨١٣ - ٨١٤ - ٨١٥ - ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨١٩ - ٨٢٠ - ٨٢١ - ٨٢٢ - ٨٢٣ - ٨٢٤ - ٨٢٥ - ٨٢٦ - ٨٢٧ - ٨٢٨ - ٨٢٩ - ٨٣٠ - ٨٣١ - ٨٣٢ - ٨٣٣ - ٨٣٤ - ٨٣٥ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - ٨٣٩ - ٨٤٠ - ٨٤١ - ٨٤٢ - ٨٤٣ - ٨٤٤ - ٨٤٥ - ٨٤٦ - ٨٤٧ - ٨٤٨ - ٨٤٩ - ٨٥٠ - ٨٥١ - ٨٥٢ - ٨٥٣ - ٨٥٤ - ٨٥٥ - ٨٥٦ - ٨٥٧ - ٨٥٨ - ٨٥٩ - ٨٦٠ - ٨٦١ - ٨٦٢ - ٨٦٣ - ٨٦٤ - ٨٦٥ - ٨٦٦ - ٨٦٧ - ٨٦٨ - ٨٦٩ - ٨٧٠ - ٨٧١ - ٨٧٢ - ٨٧٣ - ٨٧٤ - ٨٧٥ - ٨٧٦ - ٨٧٧ - ٨٧٨ - ٨٧٩ - ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨٣ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - ٨٨٦ - ٨٨٧ - ٨٨٨ - ٨٨٩ - ٨٩٠ - ٨٩١ - ٨٩٢ - ٨٩٣ - ٨٩٤ - ٨٩٥ - ٨٩٦ - ٨٩٧ - ٨٩٨ - ٨٩٩ - ٩٠٠ - ٩٠١ - ٩٠٢ - ٩٠٣ - ٩٠٤ - ٩٠٥ - ٩٠٦ - ٩٠٧ - ٩٠٨ - ٩٠٩ - ٩١٠ - ٩١١ - ٩١٢ - ٩١٣ - ٩١٤ - ٩١٥ - ٩١٦ - ٩١٧ - ٩١٨ - ٩١٩ - ٩٢٠ - ٩٢١ - ٩٢٢ - ٩٢٣ - ٩٢٤ - ٩٢٥ - ٩٢٦ - ٩٢٧ - ٩٢٨ - ٩٢٩ - ٩٣٠ - ٩٣١ - ٩٣٢ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٣٥ - ٩٣٦ - ٩٣٧ - ٩٣٨ - ٩٣٩ - ٩٤٠ - ٩٤١ - ٩٤٢ - ٩٤٣ - ٩٤٤ - ٩٤٥ - ٩٤٦ - ٩٤٧ - ٩٤٨ - ٩٤٩ - ٩٥٠ - ٩٥١ - ٩٥٢ - ٩٥٣ - ٩٥٤ - ٩٥٥ - ٩٥٦ - ٩٥٧ - ٩٥٨ - ٩٥٩ - ٩٦٠ - ٩٦١ - ٩٦٢ - ٩٦٣ - ٩٦٤ - ٩٦٥ - ٩٦٦ - ٩٦٧ - ٩٦٨ - ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - ٩٧٢ - ٩٧٣ - ٩٧٤ - ٩٧٥ - ٩٧٦ - ٩٧٧ - ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - ٩٨١ - ٩٨٢ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٥ - ٩٨٦ - ٩٨٧ - ٩٨٨ - ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ٩٩٤ - ٩٩٥ - ٩٩٦ - ٩٩٧ - ٩٩٨ - ٩٩٩ - ١٠٠٠ - ١٠٠١ - ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٤ - ١٠٠٥ - ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - ١٠٠٨ - ١٠٠٩ - ١٠١٠ - ١٠١١ - ١٠١٢ - ١٠١٣ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠١٧ - ١٠١٨ - ١٠١٩ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢٢ - ١٠٢٣ - ١٠٢٤ - ١٠٢٥ - ١٠٢٦ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - ١٠٢٩ - ١٠٣٠ - ١٠٣١ - ١٠٣٢ - ١٠٣٣ - ١٠٣٤ - ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - ١٠٣٧ - ١٠٣٨ - ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - ١٠٤٤ - ١٠٤٥ - ١٠٤٦ - ١٠٤٧ - ١٠٤٨ - ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - ١٠٥١ - ١٠٥٢ - ١٠٥٣ - ١٠٥٤ - ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - ١٠٥٨ - ١٠٥٩ - ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - ١٠٦٥ - ١٠٦٦ - ١٠٦٧ - ١٠٦٨ - ١٠٦٩ - ١٠٧٠ - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - ١٠٧٣ - ١٠٧٤ - ١٠٧٥ - ١٠٧٦ - ١٠٧٧ - ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - ١٠٨٢ - ١٠٨٣ - ١٠٨٤ - ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - ١٠٨٧ - ١٠٨٨ - ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - ١٠٩٤ - ١٠٩٥ - ١٠٩٦ - ١٠٩٧ - ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - ١١٠٠ - ١١٠١ - ١١٠٢ - ١١٠٣ - ١١٠٤ - ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - ١١٠٩ - ١١١٠ - ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - ١١١٤ - ١١١٥ - ١١١٦ - ١١١٧ - ١١١٨ - ١١١٩ - ١١٢٠ - ١١٢١ - ١١٢٢ - ١١٢٣ - ١١٢٤ - ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٢٨ - ١١٢٩ - ١١٣٠ - ١١٣١ - ١١٣٢ - ١١٣٣ - ١١٣٤ - ١١٣٥ - ١١٣٦ - ١١٣٧ - ١١٣٨ - ١١٣٩ - ١١٤٠ - ١١٤١ - ١١٤٢ - ١١٤٣ - ١١٤٤ - ١١٤٥ - ١١٤٦ - ١١٤٧ - ١١٤٨ - ١١٤٩ - ١١٥٠ - ١١٥١ - ١١٥٢ - ١١٥٣ - ١١٥٤ - ١١٥٥ - ١١٥٦ - ١١٥٧ - ١١٥٨ - ١١٥٩ - ١١٦٠ - ١١٦١ - ١١٦٢ - ١١٦٣ - ١١٦٤ - ١١٦٥ - ١١٦٦ - ١١٦٧ - ١١٦٨ - ١١٦٩ - ١١٧٠ - ١١٧١ - ١١٧٢ - ١١٧٣ - ١١٧٤ - ١١٧٥ - ١١٧٦ - ١١٧٧ - ١١٧٨ - ١١٧٩ - ١١٨٠ - ١١٨١ - ١١٨٢ - ١١٨٣ - ١١٨٤ - ١١٨٥ - ١١٨٦ - ١١٨٧ - ١١٨٨ - ١١٨٩ - ١١٩٠ - ١١٩١ - ١١٩٢ - ١١٩٣ - ١١٩٤ - ١١٩٥ - ١١٩٦ - ١١٩٧ - ١١٩٨ - ١١٩٩ - ١٢٠٠ - ١٢٠١ - ١٢٠٢ - ١٢٠٣ - ١٢٠٤ - ١٢٠٥ - ١٢٠٦ - ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - ١٢٠٩ - ١٢١٠ - ١٢١١ - ١٢١٢ - ١٢١٣ - ١٢١٤ - ١٢١٥ - ١٢١٦ - ١٢١٧ - ١٢١٨ - ١٢١٩ - ١٢٢٠ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - ١٢٢٤ - ١٢٢٥ - ١٢٢٦ - ١٢٢٧ - ١٢٢٨ - ١٢٢٩ - ١٢٣٠ - ١٢٣١ - ١٢٣٢ - ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٣٥ - ١٢٣٦ - ١٢٣٧ - ١٢٣٨ - ١٢٣٩ - ١٢٤٠ - ١٢٤١ - ١٢٤٢ - ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - ١٢٤٥ - ١٢٤٦ - ١٢٤٧ - ١٢٤٨ - ١٢٤٩ - ١٢٥٠ - ١٢٥١ - ١٢٥٢ - ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - ١٢٥٥ - ١٢٥٦ - ١٢٥٧ - ١٢٥٨ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٢٦١ - ١٢٦٢ - ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - ١٢٦٥ - ١٢٦٦ - ١٢٦٧ - ١٢٦٨ - ١٢٦٩ - ١٢٧٠ - ١٢٧١ - ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - ١٢٧٤ - ١٢٧٥ - ١٢٧٦ - ١٢٧٧ - ١٢٧٨ - ١٢٧٩ - ١٢٨٠ - ١٢٨١ - ١٢٨٢ - ١٢٨٣ - ١٢٨٤ - ١٢٨٥ - ١٢٨٦ - ١٢٨٧ - ١٢٨٨ - ١٢٨٩ - ١٢٩٠ - ١٢٩١ - ١٢٩٢ - ١٢٩٣ - ١٢٩٤ - ١٢٩٥ - ١٢٩٦ - ١٢٩٧ - ١٢٩٨ - ١٢٩٩ - ١٣٠٠ - ١٣٠١ - ١٣٠٢ - ١٣٠٣ - ١٣٠٤ - ١٣٠٥ - ١٣٠٦ - ١٣٠٧ - ١٣٠٨ - ١٣٠٩ - ١٣١٠ - ١٣١١ - ١٣١٢ - ١٣١٣ - ١٣١٤ - ١٣١٥ - ١٣١٦ - ١٣١٧ - ١٣١٨ - ١٣١٩ - ١٣٢٠ - ١٣٢١ - ١٣٢٢ - ١٣٢٣ - ١٣٢٤ - ١٣٢٥ - ١٣٢٦ - ١٣٢٧ - ١٣٢٨ - ١٣٢٩ - ١٣٣٠ - ١٣٣١ - ١٣٣٢ - ١٣٣٣ - ١٣٣٤ - ١٣٣٥ - ١٣٣٦ - ١٣٣٧ - ١٣٣٨ - ١٣٣٩ - ١٣٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٤٢ - ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - ١٣٤٧ - ١٣٤٨ - ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - ١٣٥١ - ١٣٥٢ - ١٣٥٣ - ١٣٥٤ - ١٣٥٥ - ١٣٥٦ - ١٣٥٧ - ١٣٥٨ - ١٣٥٩ - ١٣٦٠ - ١٣٦١ - ١٣٦٢ - ١٣٦٣ - ١٣٦٤ - ١٣٦٥ - ١٣٦٦ - ١٣٦٧ - ١٣٦٨ - ١٣٦٩ - ١٣٧٠ - ١٣٧١ - ١٣٧٢ - ١٣٧٣ - ١٣٧٤ - ١٣٧٥ - ١٣٧٦ - ١٣٧٧ - ١٣٧٨ - ١٣٧٩ - ١٣٨٠ - ١٣٨١ - ١٣٨٢ - ١٣٨٣ - ١٣٨٤ - ١٣٨٥ - ١٣٨٦ - ١٣٨٧ - ١٣٨٨ - ١٣٨٩ - ١٣٩٠ - ١٣٩١ - ١٣٩٢ - ١٣٩٣ - ١٣٩٤ - ١٣٩٥ - ١٣٩٦ - ١٣٩٧ - ١٣٩٨ - ١٣٩٩ - ١٤٠٠ - ١٤٠١ - ١٤٠٢ - ١٤٠٣ - ١٤٠٤ - ١٤٠٥ - ١٤٠٦ - ١٤٠٧ - ١٤٠٨ - ١٤٠٩ - ١٤١٠ - ١٤١١ - ١٤١٢ - ١٤١٣ - ١٤١٤ - ١٤

بالمخالفة لقرارات الحظر، وتحذيرهم لإخلاء التجمعات حماية للصحة العامة، وأن طائرات الدرون تراقب حماية المدينة من ارتفاع ٨٠ إلى ١٠٠ متر من خلال استخدام زاوية كبيرة دون التقاط صور، ودون أن تكون حاملة لذاكرة تخزينية للصور.

إن القاضي الإداري للأمور المستعجلة استنبط بأن طائرات الدرون تستخدم المعطيات الفنية وتستخدم عدسات وتستطيع أن تحلق على ارتفاع أقل من ٨٠ متراً مما يجعلها قادرة على تحصيل نتائج تعريفية، ورأى القاضي بأن طائرات الدرون لم تزود بأي برنامج يمنعها ويضمن بأنها لا تتعرف على الأشخاص الذين يتم تصويرهم، واستخدام ذلك لغرض آخر غير تحديد التجمعات العامة.

من أجل ذلك قرر القاضي بأن استخدام طائرات الدرون بتجهيزها الفني يعتبر ماساً بمسألة ذات طابع شخصي، ويخالف احترام الحق في المعلومات والحرية الشخصية والحق في الخصوصية، وهذا يخالف القانون ٦ لسنة ١٩٧٨، مما يتعين على الدولة أن توقف دون تأخير استعمال الطائرات الدرون ما دام لم يتخذ مرسوم أو لائحة بذلك، أو مادامت هذه الطائرات لم تزود بمعطيات تقنية تجعلها قادرة على وقف التعرف على الأشخاص الذين يتم تصويرهم.

٣ - قرار أماكن حجز المخالفين للإقامة^(٥٧): هذه دعوى تقدمت بها جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الأجانب، ونقابة المحامين في فرنسا وغيرهما، وبعد أن قررت محكمة باريس رفع وإزالة الحجز من مراكز الحجز للأجانب المخالفين الذين كانت نتائجهم إيجابية بمرض كوفيد-١٩، وتوجيههم إلى مراكز إيواء محلية، ولكن بعد استئناف وزير الداخلية قرر مجلس الدولة كقاضي أمور مستعجلة إلغاء هذا الحكم. ذهب مجلس الدولة إلى أن أحد مراكز الحجر يخصص للمصابين بفيروس كورونا، ويتم تزويدهم بالكمامات والقفازات وبوسائل الوقاية من كوفيد-١٩، ويتم عزلهم لمدة ٧ أيام، ثم تتم إعادة فحصهم، فكان واحد منهم فقط لا يزال مصاباً بالفيروس؛ لذلك تم إبقاؤه بهذا المحجر، وذهب القاضي إلى أن العدد المصاب قليل جداً ولا يشكل بالنسبة لباقي المحتجزين في الأماكن الأخرى ولا للعاملين أي ضرر أو خطر قد يسببه انتقالهم إلى أماكن أخرى.

كما بيّن القاضي بأن الشخص المصاب لا يصبح محلاً للنقل ما دام لم يشف من الجائحة، ومن ثم يرى القاضي وعلى خلاف المدعين بأن بقاء المحتجزين في هذه

الأماكن وهم مصابون بكوفيد-١٩ مبرراً، وأن القائمين على أماكن الإيواء المدنية قرروا بأنهم لن يستقبلوا أي شخص مصاب بفيروس كورونا، كما قرر القائمون على مراكز الإيواء بأنهم ليسوا على استعداد لاستقبال أشخاص يشكلون خطورة على الأمن العام ويتسببون في تعطيل وعرقلة سريان المرفق العام.

لهذا قرر القاضي إلغاء الحكم بنقل الأجانب المخالفين إدارياً من مراكز الحجز إلى مراكز الإيواء.

٤ - طلبات اللجوء السياسي^(٥٨): أصدر وزير الداخلية ووزير الهجرة قراراً بإغلاق مكاتب استقبال طلبات الهجرة واللجوء، وإغلاق الشبكة الإلكترونية للتواصل معهم في طلب الهجرة واللجوء.

وبناء على دعوى تقدم بها عدة محامين وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان لوقف هذا القرار، قرر القاضي بأنه بسبب جائحة كوفيد-١٩ فإن وزير الداخلية ووزير شؤون المهاجرين قررا إغلاق المكاتب والشبكة الإلكترونية بشكل كامل، وأن هذا القرار يحمل اعتداء غير مشروع وجسيم على الحريات الأساسية بحسبان أن الحق في اللجوء من الحقوق الدستورية، ولا تمنع جائحة كوفيد-١٩ من تنظيم استقبال الطلبات ولو من خلال فتح جزئي لمكاتبها بأقل عدد من الموظفين وتفعيل شبكات الاتصال لتقديم الطلبات، وأنه ليس مستحيلاً تنظيم العمل وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وأن حماية الصحة العامة لا تتعارض مع الحق الأساسي للجوء، ومن ثم فإن قرار وزير الداخلية ووزير شؤون الهجرة يخالف المشروعية ويمس بالحريات الأساسية بشكل جسيم.

٥ - دعوى المظاهرات في مكان عام: بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٠ أصدر مجلس الدولة بحسبانه قاضي أمور وقتية في دعوى استعجال وحرية حكماً متميزاً^(٥٩). في الدعوى المرفوعة من الجمعيات والنقابات التي تقدمت بطعن لقاضي الأمور الوقفية بمجلس الدولة لوقف تطبيق المادة (٣) من المرسوم الصادر في ٣١ مايو ٢٠٢٠ الذي يمنع تجمع أكثر من عشرة أشخاص في الأماكن العامة.

ولقد قرر مجلس الدولة وقف تنفيذ القرار بحسبانه يمنع بشكل عام ومطلق التجمعات والمظاهرات في الأماكن العامة.

No440250,440255, 30 Avril 2020.

(٥٨)

CE, No 440846, 440856, 13 juin 2020.

(٥٩)

وقد أسس مجلس الدولة حكمه على أن مجلس الصحة العامة لم يضع في قراره الصادر بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٠ أية عوائق على السير في الطرق والأماكن العامة ما دام أنه قد تم احترام قواعد السير والتباعد الجسماني مسافة متر واحد، وكان هناك تقييد لبس الكمامات، ولم يكن هناك ما يدعو للخشية من انتقال فيروس كوفيد-١٩.

وأضاف القاضي بأن حرية التظاهر والمظاهرات في الأماكن العامة من الحريات الأساسية، وأنه من غير المبرر في حال اتباع التعليمات الصحية الاعتداء على تلك الحرية (أي أن منع التظاهر يكون في حالة عدم احترام هذه التعليمات، أو في حالة عدم إمكانية احترامها والتقييد بها، أو أن الظروف تدعو بأن يحتوي التجمع على أكثر من (٥٠٠٠) شخص في مكان واحد).

وأكد القاضي بأنه استناداً للقانون فإن أية مظاهرة يتعين قبل انطلاقها مخاطبة والطلب الأولي من البلدية أو المحافظة، ويمكن منع هذه المظاهرة إذا قدرت البلدية أو المحافظة أنها ستؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، ومن ذلك الإخلال بقواعد الصحة العامة، أو إذا كانت الظروف المحلية للمدينة المقرر إقامة المظاهرة فيها تستدعي هذا المنع.

واستنتج القاضي بأن ما يتمسك به المدعون مؤسس على انتهاك المادة (٣) من القرار الصادر في ٣١ مايو ٢٠٢٠ لمبدأ حرية التظاهر، وهذا اعتداء على المشروعية وعلى حرية من الحريات الأساسية، وأن هذا التأسيس يقوم على انتهاك حرية التعبير والحق في الاتصال، وهذه حقوق وحريات مثبتة في المادتين ١٠، ١١ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنبثق عنها حرية التعبير الجماعي للأفكار والآراء، وهذه حرية أساسية من الحريات التي أشارت المادة (2-521) من مدونة القضاء الإداري إلى حمايتها والنود عنها، وأن المظاهرة هي تعبير عن هذه الحرية الأساسية التي يترجمها التجمع والتظاهر في مكان عام، وأن هذا مفهوم ديمقراطي، وهو أحد الضمانات الأساسية لاحترام حق التعبير وتكوين النقابات وممارستها لدورها، ومن ثم يتعين احترامها، وهذا في الوقت نفسه يجب أن يتوافق مع احترام موضوع القيم الدستورية لحماية الصحة العامة والمحافظة على النظام العام.

وانتهى القاضي إلى أنه تم الالتزام بتقديم الطلب الأولي للتظاهر والتجمع في مكان عام وفقاً للمادة (L211-1) من مدونة الأمن الداخلي.

وحيث إن شرط الاستعجال متحقق بالنظر إلى كثافة وكثرة عدد الجمعيات والنقابات المتقدمة بطلب التظاهر والتجمع ما يتعين الاستجابة لهم.

وأن القاضي يرى وقف تنفيذ القرار، ومن ثم قيام التجمع والمظاهرات دون توجيه أوامر للإدارة.

في هذه الدعاوى رأينا كيف أن القاضي الإداري بحسبانه قاضياً للأمر المستعجلة وازن بين حقين دستوريين وهما حق الدولة في حماية الصحة العامة والأمن العام والنظام العام وهي حقوق دستورية من ناحية وبين الحقوق الأساسية للأفراد كحق ممارسة الشعائر الدينية والحق في الخصوصية والحق في الحياة والحق في اللجوء من ناحية ثانية.

إن القاضي الإداري يضع حماية المجتمع وصحته وأمنه ونظامه في مركز الحماية المهمة، ولكن دون المساس بحقوق الأفراد والجماعات الأساسية، فكلما كان هناك مجال لممارسة الحقوق الفردية والجماعية دون المساس بالصحة العامة فإنه يتعين إعمال الحقوق ولو بالحد الأدنى وبتنظيم دقيق، فهذه الحقوق الفردية والجماعية تعتبر أساسية في النظام الدستوري شأنها كشأن الحق في حماية الصحة العامة، ففي مجال الحقوق والحريات الأساسية الدستورية يتعين عدم التفريط بحق دستوري لحساب حق آخر له ذات القيمة، بل يتعين إيجاد التوازن بين هذه الحقوق بحيث يمكن إعمالها معاً دون تفريط ولا إفراط لأحدهما على حساب الآخر.

ونلاحظ في هذه الأحكام بأن القاضي الإداري كقاضي أمور مستعجلة وهو يوازن بين الحريات الأساسية وبين المحافظة على الصحة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-١٩ يتبع منهجاً محدداً وخطة تحليلية ثابتة يستند عليها لإصدار أحكامه وقراراته كما سوف نبينه في المطلب التالي.

المطلب الثاني

المنهجية المتبعة من قبل قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة جائحة كوفيد-١٩

إن وقف المحاكم وتعطيلها لم يعطل القاضي الإداري كقاضي أمور مستعجلة عن العمل وإصدار القرارات متى ما كان الأمر يتعلق بالمساس بالحريات العامة، ويمكننا التأكيد على أن مبدأً عاماً جديداً قد ظهر ألا وهو استمرار القاضي الإداري في القضاء المستعجل بالتدخل لحماية للحريات العامة الفردية والجماعية والتوفيق بينها وبين مقتضيات المحافظة على الصحة العامة التي تنص لها الدولة من أجل مكافحة جائحة كوفيد-١٩.

(إن تدخل قاضي الأمور المستعجلة في الأوقات العادية وحتى غير العادية إن كان قد نظمته المادة (2/521) من كود القضاء الإداري الصادر بالقانون في ٣٠ يونيو ٢٠٠٠ التي تعطي القاضي الإداري حق التدخل للحكم في مواجهة أي قرار يحمل تعدياً صارخاً وجسيمياً غير مشروع على الحريات العامة.

وقد رأى القاضي الإداري أن الاعتداء على الحريات العامة في أوقات الأزمات والكوارث من قبل الإدارة لا تمنع قاضي الأمور المستعجلة الإداري من التدخل متى كانت هذه القرارات والأعمال المادية تحمل تعديات غير مشروعة وتحتوي على اعتداء جسيم وظاهر على الحريات العامة واعتبر هذا التدخل القضائي لقاضي الأمور المستعجلة الإداري مبدأً جديداً من المبادئ العامة للقانون^(٦٠).

ويلاحظ في أحكام القضاء المستعجل الإداري كيف أن القاضي يتبع منهجية تحليلية معينة وطريقاً ثابتاً في قضاؤه وقراراته؛ إذ يستعرض من خلالها الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كوفيد-١٩، ثم يعرض القرار محل الطعن ويفحص مدى توافق القرار مع مكافحة الجائحة وكفاية هذا القرار في تحقيق المحافظة على الصحة العامة وبهذا القدر فقط وما يتعداه يعتبر مساساً بالحقوق والحريات الأساسية الفردية أو الجماعية إن حمل اعتداء أو تضييقاً أو تعسفاً، وهكذا يقوم القاضي بتحليل القرار في مدى جدوى وجوده، وهو حق للإدارة وحدوده في محاربة كوفيد-١٩ وتأثير ذلك على الحريات العامة فيما يتعدى تلك المحاربة وانتشار المرض أو الحد منه، ويعتبر ما زاد عن حد مكافحة الجائحة يمثل اعتداء على الحريات العامة، فبالنسبة للقاضي الدفاع عن القرار الإداري هو الأصل ويراه من هذه الزاوية بأنه قد صدر لتحقيق حماية الصحة العامة ومحاربة كوفيد-١٩، لذلك فهو يتفحص القرار بهذه الأبعاد وبهذا السبب ولهذه الغاية، فإن تعدى ذلك ومس الحريات العامة فإنه يقرر وقفه، ويبرر هذا المسلك ضرورة استمرار الإدارة في حماية الصحة العامة.

ففي حكم مستعجل قرر القاضي أنه لا يتضح من خلال الفتح الضيق للمراكز التجارية في ظل الظروف الحالية لمكافحة جائحة كوفيد-١٩ بأن ذلك يمس الحقوق والحريات العامة للأفراد^(٦١).

كما قرر مجلس الدولة في حكم مستعجل بأنه في هذه الظروف اللازمة لمواجهة كوفيد-١٩ فإن عدم توزيع الكمادات والقفازات على العاملين تبعاً للإمكانات وتبعاً للإجراءات التي قامت بها الدولة ووضعتها موضع التطبيق لا يحمل بحد ذاته اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية الفردية^(٦٢).

وفي المقابل اعتبر القاضي أن الإغلاق المطلق لدور العبادة في ظل مكافحة

CE,sec,22 Avril 2020, No440039.

(٦٠)

CE,ord, 27 Mars 2020 N0 439720,2014.

(٦١)

CE, 10 Avril 2020 no 440012.

(٦٢)

جائحة كوفيد-١٩ يمس حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، ورأى القاضي بأن لدور العبادة والقائمين عليها تنظيم ممارسة الشعائر باتباع قواعد التباعد الاجتماعي واستخدام وسائل الوقاية وأحكامها، ومن ثم فإن قرار الغلق المطلق العام غير مشروع ويتعين وقف تنفيذه، ويتعين على الإدارة أن تترك للقائمين على دور العبادة تنظيم الدخول للمعابد مع الأخذ بالحسبان قواعد التباعد الاجتماعي.

وبتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٠ وفي دعوى ملابس الوقاية الصحية وإدارتها للعاملين في القطاع الصحي لمكافحة جائحة كوفيد-١٩ وهي دعوى بطلب إلزام الدولة بشراء وإنتاج ملابس الوقاية الصحية وأدواتها كالكمادات والنظارات والملابس الواقية للقائمين بعلاج مرض كورونا المستجد^(٦٣)، استعرض القاضي في بادئ الأمر ما مفاده بأن الدولة اتخذت إجراءات لتوزيع ١٠٠ مليون كمام في الأسبوع للقائمين بالعمل الصحي لاسيما الذين يواجهون كوفيد-١٩ في المستشفيات والعيادات في المدن والمؤسسات الصحية والاجتماعية بالرغم من وجود بعض الصعوبات المحلية، مما تبين معه بأن هذه الكميات من الأدوات والملابس الوقائية ليست كافية لتلبية احتياجات القائمين بالرعاية الصحية.

ففي خصوص الكمادات لاسيما FFP2 المتخصصة في الحماية فإن هناك ١٢ مليون كمامة يتم توزيعها أسبوعياً، في حين هناك بين ١٦ إلى ١٧ مليون كمامة مطلوب أسبوعياً أخذاً بالاعتبار الحاجة إلى تاريخ الأول من يونيو ٢٠٢٠ وتم توزيع هذه الكمية في المقام الأول للقائمين بالعلاج والمدن التي تعاني من ازدياد انتشار الوباء لتلبية حاجتها الوقائية.

ويلاحظ القاضي في حكمه أن الدولة لم تهمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تؤدي إلى تحسين تلبية الإنتاج في شهر مارس، كما أنها وبسبب المخزون من الكمادات تلتزم بهذه الكمية في التوزيع، وكذلك بسبب صعوبة الاستيراد لن تحصل الدولة بشكل سريع على الكميات التي قامت بطلبها من الخارج وفقاً لما تتوقعه من نتائج في المعالجة والوقاية من كوفيد-١٩، إن تفصيل الوقائع من قبل القاضي وبيان الظروف الخاصة القائمة تعني بأن القاضي يحل حقيقة الوضع القائم والجهود التي قامت بها الدولة، أي يستعرض الظروف الحقيقية والوقائع بشكل كامل من أجل إمكانية الحكم على تصرف الدولة وما يتطلب منه كقاضي للتدخل من أجل حماية المساس بالحريات الأساسية.

وفي خصوص الملابس الواقية يؤكد القاضي بأنه في معرض الرد على طلب الطاعنين بأن الدولة لم تنتج الكمية الكافية منها، يرى القاضي بأن الدولة قد عملت واستقصت أولاً بشكل واضح للتعرف على المنتجين لهذه الملابس الواقية واستطاعت أن تطلب ١٦ مليون منها. كما أنها بحثت وتعاقدت مع مصانع لتصنيع ملابس واقية تستعمل لمرة واحدة وأخرى متعددة الاستعمال، وأن ١١٧ مصنعاً أبدوا قدرتهم على التصنيع بواقع ١١٧ خط إنتاج يصل إلى ٧٠٠٠٠٠ لباس في الأسبوع، وإذا كانت هذه الكمية غير كافية الآن فإنها ستكون كافية مع مطلع شهر يونيو، ومن ثم فإنه في ظل هذه المعطيات فإن القاضي لا يستطيع أن يوجه أمراً للدولة وينعتها بالمقصرة أو أنها تعتدي بشكل جسيم وواضح وبشكل غير مشروع على الحريات الأساسية.

إن قاضي الأمور المستعجلة قام أولاً باستعراض الظروف الاستثنائية وتفحص الوقائع والمعطيات القائمة، وقيّم حقيقة ما قامت به الدولة في سبيل توفير الكمادات والملابس الواقية من واقع ما هو قائم فعلاً، وبأن هذه الإمكانيات وهذا العمل ليس به قصور أو إهمال من قبلها، ومن ثم فإنه لا يستطيع في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهذا العمل الذي قامت به الدولة أن يعتبرها قد اعتدت على الحريات الأساسية ويطلب منها أكثر من ذلك، فهي في نظره وفقاً للظروف والإمكانيات وبجميع ما قامت به لا يمكن اعتبارها قد اعتدت على الحريات الأساسية؛ لذلك في هذه الدعوى رفض القاضي توجيه أوامر لها بإنتاج وتوفير وشراء غزير للكمادات والملابس الواقية كما طالبت بذلك نقابة الأطباء الشباب^(٦٤).

وإذا كانت المبادئ العامة للقانون في ظل الظروف العادية حامية للحريات الأساسية فإنها كذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-١٩ تكون هذه المبادئ قائمة ومنتهجة لأثارها.

ففي مجال حرية اللجوء قرر مجلس الدولة بأن منع تفشي فيروس كورونا المستجد لا يمنع وزير الهجرة من تنظيم العمل في مراكز استقبال طلبات اللجوء من خلال تخفيض عدد العاملين في المراكز وتأكيد التباعد الاجتماعي وتفعيل المنصات الإلكترونية لاستقبال الطلبات، وأنه يتعين التوفيق بين الحق الدستوري في اللجوء وحق الدولة في المحافظة على الصحة العامة^(٦٥).

وفي شأن مبدأ الإخاء كمبدأ أساسي ومبدأ عام للقانون قرر مجلس الدولة بأن

CE, No 440321, 22 Mai 2020.

(٦٤)

CE, No 44250, 30 Avril 2020.

(٦٥)

عدم توفير قانون الحظر الصادر في ٢٥ مارس ٢٠٢٠ لأماكن خاصة لحجر المشردين وعديمي السكن، لا يمس الحريات الأساسية بحسبان المشرع غير ملزم بتوفير أماكن حجر خاصة لهذه الفئة، فالقانون يضع القواعد العامة ومن ثم فهو قانون دستوري، وأن الطاعنين لم يوضحا أو لم يبيّنا مدى الإخلال في هذا التشريع لمبدأ الإخاء كمبدأ عام ذي قيمة دستورية؛ لذلك رفض مجلس الدولة إحالة الطعن للمحكمة الدستورية كإجراء دستوري جديد وفقاً للدستور في المادة ٦١ منه باتباع الطعن غير المباشر على دستورية القوانين من خلال السؤال الأولى لعدم الدستورية^(٦٦).

ويتبع القاضي منهجاً واضحاً وبخطوات واضحة على النحو الآتي:

- ١ - ذكر الطلبات التي يقدمها الطاعنون بشكل تفصيلي، أي يذكر طلب وقف القرار أو اتخاذ تدابير معينة أو تقديم توجيهات للإدارة أو منح ترخيص مؤقت.
- ٢ - ذكر الدفوع التي يقدمها الطاعنون لتأييد طلباتهم بشكل تفصيلي، فيتم ذكر قواعد الشكل الأولية كالصفة والمصلحة في الدعوى.
- ٣ - يبين ما يقدمه الطاعنون من شرط الاستعجال وتحققه لهم، وما يمثله لهم من مصلحة في وجوب الحكم المستعجل.
- ٤ - يبين ما يقدمه الطاعنون من اعتداء جسيم على الحريات الأساسية وكيف أن هذا الاعتداء غير مشروع على هذه الحريات الأساسية، كتحريم التجمع بشكل عام ومطلق ومنع حرية الاتصال الجماعي، وكيف أن هذا الاعتداء على الحريات الأساسية لا تبرره حماية الصحة العامة والمحافظة على النظام.
- ٥ - يبين القاضي بأن الإعلان للإدارة قد تم بصورة قانونية سليمة.
- ٦ - يبين القاضي بأن الإدارة ردت كتابة على الطعن وأسبابه، وتم تقديم المذكرات من الطرفين بشكل كامل.
- ٧ - يبين القاضي تفصيلاً إطلاعه على القوانين الحاكمة للموضوع كالدستور والاتفاقيات الدولية والمدونات القانونية واللوائح والقرارات ذات الصلة، ويذكر كل ذلك بالأرقام والتواريخ تفصيلاً.
- ٨ - يبين القاضي بأنه دعا إلى جلسة عامة، وأن ممثل الطاعنين قد مثل في الجلسة، وأن المحامين حضروا، ويذكر أسماءهم وصفاتهم في التمثيل.
- ٩ - يبين القاضي حضور محامي الدولة والمفوض.
- ١٠ - يبين القاضي ساعة ويوم انعقاد الجلسة.
- ١١ - ثم ينتقل القاضي لبيان الطلبات، وإن كان يمكن ضمها فيقرر الضم للارتباط.

- ١٢- يبين القاضي الظروف العامة والوقائع المحيطة للقرار محل طلب الوقف بشكل تفصيلي شارحاً وجود الجائحة مثلاً وشمولها وأسباب مواضعها، وما اتخذته الحكومة من إجراءات وقرارات لحماية الصحة العامة والنظام العام.
- ١٣- يبين القاضي القوانين والقرارات وأسباب اتخاذها والهدف والغاية منها.
- ١٤- يشرع القاضي بعد ذلك في بيان طلبات الطاعنين الدقيقة في سبب طلب وقف القرار والقوانين التي يستندون عليها.
- ١٥- ينتقل القاضي بعد ذلك إلى فحص الموضوع وينزل شروط قبول الطلب على واقع النزاع من حيث سلطاته كقاضي أمور وقتية.
- ١٦- يبين القاضي بأنه قاضي وقتي يحكم بصفة مؤقتة غير نهائية، فيذكر المواد التي يستند عليها في حكمه كقاضي وقتي، فيذكر المادة (L512-2) ويبين بأنه وفقاً لهذا النص كقاضي وقتي له أن يتخذ كافة السبل لحماية الحريات العامة إذا تم الاعتداء عليها من قبل شخص عام أو شخص خاص منوط به سلطة عامة أثناء تأدية أعماله.
- ١٧- يبين القاضي تحقق حالة الاستعجال في النزاع، وأنه يتدخل لوجود شرط الاستعجال مع ذكر الظروف التي دفعت الدولة لاتخاذ القرار.
- ١٨- يبين القاضي بأنه وفقاً لنص المواد (L.511-106521-2) يتدخل إن كان هناك اعتداء جسيم غير مشروع على الحريات الأساسية من قبل شخص عام أو شخص خاص منوط به سلطة عامة، وأن من سلطته أن يبين الخطوات أو أن يقدم التوجيهات للإدارة لتحسين شروط ممارسة الحرية الأساسية أو الابتعاد عن المساس الخطير والجسيم بها، مع التأكيد بأنه قاضي وقتي يتخذ قرارات وأحكام مؤقتة.
- ١٩- يبين القاضي تفصيلاً الحرية الأساسية التي تم الاعتداء عليها، وأن مصدرها الدستور أو المعاهدات الدولية أو القوانين أو المبادئ العامة للقانون، ويسقط نصوص القانون عليها، وأن هذه القوانين والمبادئ واجبة الحماية وفقاً لمدونة القضاء الإداري التي تمنح القاضي السلطة.
- ٢٠- يبين القاضي مخالفة القرار محل الطعن للقوانين الحامية للحريات الأساسية، وماهية المخالفة التي تمثل الاعتداء على الحرية الأساسية، كما يبين بأن حماية الصحة العامة أو النظام العام لا تقتضي هذا الاعتداء على الحريات الأساسية مادام أنه يمكن ممارسة الحرية بشروط تنظيمية وفقاً للقوانين واللوائح.

- ٢١- يبين القاضي كيف يمكن للطاعنين أن يمارسوا الحرية الأساسية مع وجود الضوابط دون أن يتم منع الحرية أو أن تتم مصادرتها بشكل مطلق وعام.
- ٢٢- يبين القاضي بأنه إن حدث إخلال بالنظام العام أو الصحة العامة فإن من حق الدولة منع هذه الحرية مؤقتاً؛ لأن السلامة الوطنية مقدمة على كل الحريات.
- ٢٣- يبين القاضي بأن ممارسة الحرية الأساسية لها قواعد وأحكام يتعين مراعاتها والالتزام بها، فإن تم انتهاكها فإن للسلطة الإدارية أن تتدخل لمنعها.
- ٢٤- يوازن القاضي بين القرارات محل الطعن وممارسة الحرية الأساسية ووجوب التوفيق بينهما، فما دام أن الحرية الأساسية يمكن ممارستها دون المنع المطلق والعام فإنه يتعين التمكين من ممارستها.
- ٢٥- وبين القاضي بأن السلطة العامة لديها سلطات كبيرة في حالة الإخلال بالنظام العام والصحة العامة، فهي تملك قوات الأمن وحفظ النظام ولا يوجد ما يمنعها من التدخل ولو باستخدام القوة.
- ٢٦- ثم ينتهي القاضي إلى إصدار الحكم بوقف القرار مؤقتاً أو برفع الاعتداء الجسيم بصفة نهائية إن لم يكن هناك مجال لرفعه مؤقتاً، أو أن يوجه الإدارة لاتخاذ إجراءات معينة لممارسة الحرية الأساسية واتباع سلوك معين.
- ٢٧- وللقاضي أن يلزم الإدارة وفقاً لمدونة القضاء الإداري بالتعويض.

الخاتمة:

بينت الدراسة تطور القضاء الإداري المستعجل الفرنسي بمقتضى القانون الصادر في ٣٠ يونيو ٢٠٠٠ بشأن مدونة القضاء الإداري وتنوع طرق الدعاوى الإدارية المستعجلة، وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

أولاً - نتائج الدراسة:

نستنتج من هذه الدراسة أن:

- ١ - القضاء الإداري المستعجل في دعوى الإلغاء له دور أساسي في الحماية لمبدأ المشروعية.
- ٢ - القضاء الإداري من خلال الدعوى المستعجلة والوقف يتدخل لوقف القرارات الإدارية متى كان هناك استعجال واعتداء خطير على مبدأ المشروعية.
- ٣ - لم يعرف المشرع مفهوم الاستعجال وتركه للقاضي رغبة في جعله مسألة واقعية حسب كل دعوى على حدة.

- ٤ - يتدخل القاضي الإداري بصفة مستعجلة لحماية الحريات الأساسية متى كان هناك استعجال واعتداء واضح وجسيم على الحريات الأساسية.
- ٥ - يتدخل القاضي الإداري في دعوى الاستعجال والحرية متى كان هناك اعتداء جسيم وظاهر عدم مشروعيته على الحريات الأساسية.
- ٦ - توسع القاضي الإداري في مفهوم الحريات الأساسية.
- ٧ - يراقب القاضي القرارات الإدارية والأعمال المادية التي تمس الحريات الأساسية.
- ٨ - يصدر القاضي المستعجل أوامر وتوجيهات للإدارة لإجبارها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المساس بالحريات الأساسية.
- ٩ - يوقف القاضي الإداري المستعجل قرارات الرفض الضمنية والسلبية.

ثانياً - التوصيات:

- نرى عدة توصيات يمكن استلهاها من هذه الدراسة كالاتي:
- ١ - التجربة الفرنسية يمكن الاقتداء بها في الكويت لاسيما وأن المنهج اللاتيني هو المعمول به.
 - ٢ - نرى وجوب امتداد القضاء المستعجل والحرية ليشمل قرارات الوظيفة العامة التي تمس الحريات الأساسية للموظف بشكل ظاهر وجسيم، وتلك التي تنزل بالقرار إلى درجة الانعدام.
 - ٣ - أن يستمر فتح أبواب المحاكم في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية حيث تزيد بشكل طردي حالات المساس بالحريات الأساسية بحجة مواجهة هذه الظروف.

The Course of the French Summary Administrative law To protect the basic freedoms under the effects of Covid -19 Pandemic

Dr. Ebrahim Mohammad ALhamoud

The State's intervention in order to fight covid -19 pandemic by issuing the administrative decisions and tangible works sometimes grossly affect the basic freedoms of the individuals and Groups, which may also adversely violates the legal aspects.

The administrative Judge in France , according to law passed on 30 June 2000 concerning the manual of the Administrative law has regulated the summary law in two ways, the First through the summary lawsuit and suspension, and the second through the summary case and freedom.

If in the first way or course places a condition that there should be an objective suit to cancel the non-legislated Administrative Decision even if it is not included with it in the same court summons, on the other hand, in the summary case there is no condition to have an objective case for cancelation.

The Administrative Judge in the summary case and freedom makes a balance between the public interest for Fighting Covid-19 and the protection of basic freedoms, and allows a firm manner in passing his Judgments .

Key Words: summary lawsuit, suspension, basic Freedoms, orders and directions by the Judge, the French State Council, Constitution, International Treaty, Administrative Decisions, tangible works.

أثر فيروس كورونا في عقد العمل في القطاع الأهلي

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان*
الدكتور/ خالد جاسم الهندياني**

ملخص:

لقد شهدت دولة الكويت ودول العالم في الآونة الأخيرة ظهوراً لفيروس كورونا المستجد باعتباره وباء صحياً عالمياً، وانتشار هذه الجائحة قد تسبب بالعديد من المشاكل القانونية، ومن هذه المشاكل أثر هذا الفيروس على عقد العمل وأجر العامل. ويتناول هذا البحث الإجابة عن عدة تساؤلات. فهل يعتبر العامل مخلاً بتنفيذ التزامه بأداء العمل؟ أم يكون معذوراً بسبب قرارات السلطة العامة والتي ستؤدي إلى عدم إمكانية أداء العمل؟ وهل يلتزم رب العمل بدفع أجر العامل الذي لا يقوم بأداء عمله خلال هذه الفترة؟ وهل يستطيع رب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة بسبب عدم أداء العامل للعمل أو بسبب الظروف الاقتصادية الناشئة عن إغلاق المنشأة؟

وجميع هذه التساؤلات تطرح تساؤلاً آخر، هل النصوص القانونية الواردة في قانون العمل أو في القواعد العامة في نظرية العقد كافية لحل هذه الإشكالات القانونية.

المقدمة:

شهدت دولة الكويت ودول العالم في الآونة الأخيرة ظهوراً لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) باعتباره وباء صحياً عالمياً، أثر بشكل مباشر على المعاملات الدولية والتجارية؛ وهو ما نتج عنه ركود اقتصادي عالمي ومشكلات اجتماعية عدة، ومن هذه المشكلات تخفيض أجر العامل أو إنهاء عقد العمل في القطاع الأهلي، وهذه الجائحة الصحية العالمية كان لها أثر في دولة الكويت؛ إذ دعت مجلس الوزراء إلى إصدار العديد من القرارات المتعاقبة للحد من انتشار هذا الوباء ومواجهته، ومنها القرارات الخاصة بإغلاق مؤقت لبعض المنشآت، مثل المجمعات التجارية ودور السينما والمسارح والمراكز التعليمية والنوادي الصحية والصالونات... إلخ، وفرض حظر

(*) الباحث الرئيس: قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت.

(**) الباحث المشارك: قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت.

التجول لعدد من الساعات كحظر جزئي، وما لبث أن استدعى الأمر عزل بعض المناطق. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات كان لها أثر كبير على المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في البلاد، وتعرضت لأضرار مالية جسيمة؛ مما تسبب في توقف أو انخفاض في العائدات والأرباح أو - على الأقل - انخفاض جميع المصاريف التشغيلية أو بعضها من دون مقابل، ومنها المصاريف التي يتحملها رب العمل، كأجر العامل؛ ومن ثم كان لابد من البحث عن مخرج قانوني لوقف الخسائر المالية التي يتكبدها، وفقاً لقواعد المسؤولية القانونية المترتبة عليه.

وتبدو إشكالية البحث من خلال ما يربته انتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة من السلطة العامة على عقد العمل وعلى أجر العامل؛ فقد لا يستطيع العامل تنفيذ التزامه بأداء العمل المطلوب منه؛ وذلك بسبب فرض حظر التجول أو إغلاق المنشأة بقرار من السلطة العامة، أو بسبب خوف العامل على نفسه من الإصابة بالمرض؛ وهو ما يثير العديد من المشكلات القانونية في هذا الخصوص؛ ومن ثم أيعتبر العامل مخرلاً بتنفيذ التزامه بأداء العمل؟ أم يكون معذوراً بسبب قرارات السلطة العامة، التي تؤدي إلى عدم إمكانية أداء العمل؟ وهل يلتزم رب العمل بدفع أجر العامل الذي لا يقوم بأداء عمله خلال هذه الفترة؟ وهل يستطيع رب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة بسبب عدم أداء العامل للعمل أو بسبب الظروف الاقتصادية الناشئة عن إغلاق المنشأة؟ جميع هذه التساؤلات تطرح تساوياً آخر، مفاده: هل النصوص القانونية الواردة في قانون العمل أو في القواعد العامة في نظرية العقد كافية لحل هذه الإشكالات القانونية؟ وهو ما ستتم معالجته من خلال هذا البحث.

وسوف نتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية وإسقاطها على الواقع العملي.

تلك الإشكاليات التي أثارها انتشار وباء كورونا في عقد العمل والعلاقة بين رب العمل والعامل، ولاسيما ما يتعلق بأجر العامل وإنهاء عقد العمل دفعتنا إلى إعداد هذا البحث؛ وبناء على ذلك لعل المناسب أن نقسمه إلى مبحثين:

- المبحث الأول: فيروس كورونا بين القوة القاهرة والظرف الطارئ.
- المبحث الثاني: التكييف القانوني لفيروس كورونا المستجد على عقد العمل.

المبحث الأول

فيروس كورونا بين القوة القاهرة والظرف الطارئ

نقوم في هذا المبحث بتكييف فيروس كورونا (covid- 19) من الناحية القانونية،
أيعتبر قوة القاهرة أم ظرفاً طارئاً؟

لذلك نبني هذا المبحث على ثلاثة مطالب، يتناول الأول مفهوم القوة القاهرة
والحدث الفجائي، في حين يتناول المطلب الثاني نظرية الظروف الطارئة، وعلى ضوء
ذلك يتناول المطلب الثالث التكييف القانوني لفيروس كورونا.

المطلب الأول

القوة القاهرة والحدث الفجائي

الفرع الأول

تعريف القوة القاهرة والحدث الفجائي

يذهب أغلب الفقه إلى أن القوة القاهرة والحدث الفجائي مصطلحان لشيء واحد،
وأتهما مترادفان، فإذا وجدت القوة القاهرة أو الحدث الفجائي انقطعت رابطة السببية،
وتخلفت المسؤولية؛ لعدم توافر أركانها^(١).

غير أن هناك جانباً من الفقه يعتبر القوة القاهرة والحدث الفجائي مصطلحين
مختلفين، وإن لم يتفقوا على الفصيل في التفرقة بينهما.

فمنهم من يقول إن القوة القاهرة هي الحدث الذي يستحيل دفعه، أما الحدث
الفجائي فهو الحدث الذي لا يمكن توقعه، ولكي نفصل بينهما يجب أن ننظر إلى
الخصيصتين اللتين توزعتا بينهما، وهما استحالة الدفع وعدم إمكان التوقع؛ حيث
يكفي للتفريق بينهما في نظر هؤلاء أن يكون الحدث مستحيل الدفع، أو أن يكون غير
ممكن التوقع؛ ومن ثم لا يلزم اجتماع الخصيصتين في أي منهما.

ولكن يعترض بعضهم على هذا الرأي، فيعتبر القوة القاهرة، حادثاً لا مستحيل
الدفع فحسب، بل أيضاً غير ممكن التوقع، كما أن الحدث الفجائي لا يقتصر على أن

(١) للمزيد راجع: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام
بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨١، ص ١٢٢٤
وما بعدها. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الإغفاء من المسؤولية عن حوادث السيارات، القسم
الأول، ص ١٤٥ وما بعدها.

يكون حادثاً غير ممكن التوقع فحسب، بل يكون أيضاً مستحيل الدفع؛ ومن ثم لا يكفي وجود إحدى هاتين الخصيصتين لانعدام رابطة السببية^(٢).

ويرى بعضهم أيضاً كذلك أن القوة القاهرة شيء والحادث المفاجئ شيء آخر. وأعطوا أمثلة بالقول: إن القوة القاهرة تكون مثل الحروب والزلازل والبراكين والعواصف، وهذه لا يمكن للفرد توقعها، كما لا يمكنه تجنبها. أما توقف السيارة فجأة أمام سيارة أخرى، فهذا حادث مفاجئ بحيث يمكن توقعه ويمكن تجنبه، كذلك مثل مرور غزال في شارع وضع فيه علامة تدل على كثرة الغزلان في هذا الشارع، ومرر غزال وصدمته سيارة؛ فهذا يعتبر حادثاً مفاجئاً كان لسائق السيارة الصادمة للغزال أن يتوقعه وكان يمكن تجنبه، بأخذ الحيطة مسبقاً، وهذا مثال واضح للحادث الفجائي عندهم، ولا يمكن نعتة بالقوة القاهرة^(٣).

ومن الفقهاء من يسلم بوجود اجتماع الخصيصتين في كل منهما، وإن كان يميز في خصيصة استحالة الدفع بين استحالة مطلقة؛ ومن ثم نكون أمام قوة القاهرة، واستحالة نسبية؛ ومن ثم نكون أمام حادث فجائي^(٤). وهذا التمييز عند بعضهم لا يقوم على أساس صحيح؛ إذ إن الاستحالة في كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي، يجب أن تكون استحالة مطلقة^(٥).

ومن الفقهاء من يقيم التمييز على أساس آخر، فيجعل كلاً من القوة القاهرة والحادث الفجائي حادثاً مستحيل الدفع، غير ممكن التوقع، ولكن القوة القاهرة تكون حادثاً خارجياً عن الشيء الذي تتحقق به المسؤولية، كعاصفة أو زلزال، أما الحادث

(٢) رادوان (Radvant)، الحادث الفجائي، والقوة القاهرة، باريس، ١٩٢٠، ص ١٧٣ وما بعدها. ولابيه، المجلة الانتقادية، ١٨٧٠، ص ١١٥. يقولان: إن القوة القاهرة والحادث الفجائي تعبيران يكمل أحدهما الآخر، فالتعبير الأول يبرز خصيصة استحالة الدفع، والتعبير الثاني يبرز خصيصة عدم إمكان التوقع، ولكن لابد من اجتماع الخصيصتين معاً في الحادث حتى تنعدم السببية. ولكن هذا الرأي يجعل التمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي معدوم الفائدة من الناحية العملية.

(٣) عبد الرسول عبد الرضا وجمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام والإثبات، الطبعة الرابعة، ٢٠١٤/٢٠١٥، مؤسسة دار الكتب، الكويت، ص ٢٥٢. وراجع كذلك: إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية والإثراء، دون سبب، دراسة للمصادر غير الإدارية للالتزام، وفقاً للقانون المدني الكويتي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت، ١٩٨٥، ص ١١٨ وما بعدها.

(٤) كولان وكابيتان، الطبعة العاشرة، جزء ٢، فقرة ١٢٦.

(٥) السنهوري، المرجع السابق، ص ١٢٢٦.

الفجائي فهو حادث داخلي ينجم عن الشيء ذاته كانهجار آلة أو إنكسار عجلة. ومفاد ذلك أن القوة القاهرة تمنع من تحقق المسؤولية، أما الحادث الفجائي فلا يمنع من تحققها بل يتحمل المدين تبعاتها^(٦). وهذا الرأي عند من يقولون بنظرية تحمل التبعة لا يجوز التسليم به؛ إذ إن الشخص بذلك يكون مسؤولاً عن الحادث الفجائي دون القوة القاهرة.

فالتمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي لا يقوم على أساس صحيح، وأجمع جمهور الفقهاء على عدم التمييز بينهما، وعلى هذا إجماع القضاء أيضاً^(٧).

وقد عرف بعض الفقهاء القوة القاهرة بأنها: "كل فعل لا شأن لإرادة المدين فيه ولا يمكن توقعه ولا منعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة تعفي المدين من المسؤولية العقدية والتقصيرية"^(٨).

الفرع الثاني

الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة والحادث الفجائي

إن نص المادة (٢٣٣) من القانون المدني تصف القوة القاهرة والحادث المفاجئ بأن كلاهما سبب أجنبي لا يد للشخص فيه، وهذا الوصف يحتاج إلى تحديد؛ إذ يجب - كما تقدم ذكره من آراء فقهية - أن يكون كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي حادثاً غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع.

فالأوضح أن عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع، هما الشرطان اللذان يجب توافرها في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولكي تكون القوة القاهرة حادثاً أجنبياً يجب ألا يكون للشخص يد فيه^(٩). والعكس غير صحيح؛ بمعنى قد يكون الحادث أجنبياً عن الشخص لا يد له فيه، ومع ذلك يستطيع توقعه قبل أن يحدث، أو يستطيع أن يدفعه بعد حدوثه. لذلك سوف نتناول هذين الشرطين بشيء من التفصيل:

(٦) Josserand (L), Cours de droit civil positif Français, Paris, 1933, n 451.

(٧) السنهوري، المرجع السابق، ص ٢٢٦.

(٨) حمدي عبد الرحمن أحمد، الوسيط في النظرية العامة إلى الالتزامات، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، ١٩٩٩، ص ٥٤٨.

(٩) طعن رقم (٢٢٩/٢٠٠٣) تجاري، جلسة ٢٧/٣/٢٠٠٤، مجلة القضاء والقانون، السنة ٣١، الجزء الأول، يناير ٢٠٠٧، ص ٢٠٩، رقم ٣٥.

أولاً - شرط عدم إمكان التوقع:

فالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي يجب أن يكون غير ممكن التوقع؛ فلو أمكن التوقع ولو استحالة دفعه، لما كان قوة القاهرة أو حادثاً فجائياً. كما أن الحادث غير مستطاع التوقع لا يكون من جانب المدين فقط، بل من جانب أشد الناس يقظة وحيلة بالأمور أيضاً؛ فالمعيار هنا موضوعي لا شخصي؛ ومن ثم لا يكفي بمعيار الشخص العادي، بل إن عدم الإمكان يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً^(١٠).

ومن الممكن أن يكون الحادث قد وقع سابقاً؛ أي في الماضي، وعلى الرغم من ذلك يبقى غير متوقع في المستقبل، إذا كان حدوثه نادراً؛ ومن ثم لا يقوم سبب خاص لتوقع حدوثه.

وفي المسؤولية العقدية، يكون عدم إمكان التوقع وقت إبرام العقد؛ فمتى كان الحادث غير متوقع عند التعاقد، كان ذلك كافياً حتى ولو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ، وهذا بخلاف المسؤولية التقصيرية التي يكون فيها عدم إمكان التوقع وقت وقوع الحادث.

ثانياً - استحالة الدفع:

يجب أن يكون كل من القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدفع، فلو أمكن دفع الحادث وكان التوقع مستحيلاً فإننا لا نكون أمام قوة القاهرة ولا حدث فجائي، بل يجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، والاستحالة هنا تكون استحالة مطلقة، بمعنى أن الاستحالة ليس بالنسبة للمدين وحده فقط، بل استحالة بالنسبة إلى أي شخص يكون في موقف المدين.

وهذا الأمر هو الذي يميز القوة القاهرة ونظرية الحوادث الطارئة؛ ففي الحوادث الطارئة يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً^(١١).

واستحالة التنفيذ قد تكون استحالة مادية أو استحالة معنوية، فلو أن مغنياً تعهد

(١٠) قضت محكمة النقض أنه لا اعتبار الحادث قوة القاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرر منه، وأن سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي- في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث في الدعوى الماثلة- من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد الطائرة التحرر منها. نقض جنائي في ٧ مارس ١٩٧٩ في الطعن رقم (٤٥٧٨٤) قضائية لم ينشر). مشار إليه عند السنهاوري، المرجع السابق، هامش ص ١٢٢٧.

(١١) راجع المطلب الثاني من هذا المبحث.

بإحياء حفلة غنائية، ومات عزيز عليه يوم الحفلة، مما أثر عليه نفسياً واستحال معه أن يحيي حفلة الغناء، عند ذلك يكون الحادث قوة قاهرة.
والقاضي هو الذي يقدر إذا ما كانت هناك استحالة أو عدم استحالة، وعليه أن يحتاط في تقدير ذلك^(١٢).

الفرع الثالث

تطبيقات عملية للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي

ولعل من المناسب أن نعرض بعض التطبيقات العملية لحوادث تجمع بعض الشرطين المتقدمين كي نتعرف القوة القاهرة من الحادث الفجائي^(١٣). فالحرب - مثلاً - تكون قوة قاهرة لما ينجم عنها من أحداث مادية ومن أزمات اقتصادية، ما دامت مستحيلة الدفع وغير متوقعة. والذي يستحيل دفعه أو توقعه ليس الحرب بحد ذاتها، بل ما نتج عنها من أحداث واضطرابات. فإذا هاجم عدو بلداً ما، ودخلها محتلاً، وطرد سكانها، كان هذا الحادث قوة قاهرة تعفي المستأجر من التزاماته في عقد الإيجار، والمقاول من التزاماته في عقد المقاولة وهكذا. أما إذا كانت الظروف التي تحيط بالمدين تمكنه من اتخاذ الاحتياطات المعقولة ولم يتخذها، كان هذا خطأ من جانبه يتحمل المسؤولية عما سببه من أضرار. والحرب قد تكون سبباً في انقطاع المواصلات وغلاء المواد الأولية؛ ومن ثم تكون قوة قاهرة ترفع المسؤولية عن المدين في هذه الأحوال.

ويعتبر مثل الحرب صدور تشريع أو أمر إداري واجب التنفيذ، أو وقوع زلزال، أو حريق، أو عواصف، أو حدوث مرض طارئ، أو إضراب غير متوقع، أو سرقة، أو تلف، أو غيرها من الحوادث ما دام شرطاً استحالة التوقع واستحالة الدفع متوافرين^(١٤).
وحوادث السيارات قد تكون قوة قاهرة، أو حادثاً فجائياً، كما لو انفجرت آلة، أو انزلقت السيارة في أرض زلقة، أو انفجر إطار من إطاراتها، أو اعترضتها عقبة مفاجئة. المهم أن يتوافر الشرطان: استحالة الدفع واستحالة التوقع^(١٥).

(١٢) مازو، فقرة ١٥٧٠.

(١٣) صدر حكم من محكمة الاستئناف الفرنسية، مدينة كولمار، من الغرفة ٦، بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠، وقد اعتبر وجود جائحة فيروس كورونا، قوة قاهرة لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها، وهي خارجة عن إرادة الأشخاص. (حكم غير منشور).

(١٤) مازو ١٥٧٨ - ١٥٨٩.

(١٥) مازو، ١٥٩٩ - ١٦٠٥.

الفرع الرابع

أثر القوة القاهرة والحادث الفجائي

فإن كانت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هي السبب الوحيد في وقوع الضرر انعدمت علاقة السببية ولا تتحقق المسؤولية؛ بمعنى أنها تجعل الالتزام ينقضي فلا يتحمل المدين تبعه عدم تنفيذه.

ولا تقتصر آثار القوة القاهرة أو الحادث الفجائي على الإعفاء من تنفيذ الالتزام فقط، بل تمتد إلى وقف تنفيذه حتى يزول الحادث إذا كانت القوة القاهرة مؤقتة؛ بمعنى أن الالتزام يبقى موقوفاً، ثم يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث^(١٦).

ويجوز للطرفين أن يتفقا على عدم إعفاء المدين من التزامه عند وقوع حادث معين كالإضراب أو الحرب^(١٧).

المطلب الثاني

نظرية الظروف الطارئة

الفرع الأول

تعريف نظرية الظروف الطارئة

نصت المادة (١٩٨) من القانون المدني على أنه: "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة، لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين؛ بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي - بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين - أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه، أو يزيد في مقابله، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك"^(١٨).

والواضح من نص المادة أنها أوجزت المقصود بنظرية الظروف الطارئة؛ فهي تقع على عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل أو آجال (مثل عقد التوريد)، ويحل أجل

(١٦) تميم، طعن رقم (١٩٨) لسنة ٢٠٠١، تجاري ٣، جلسة ٢٠٠٢/٥/١٨، أنظمة صلاح الجاسم.

(١٧) مازو، ١٦١٥ - ١٦٢١.

(١٨) للمزيد راجع: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨١، ص ٨٥١ وما بعدها.

التنفيذ، فإذا بالظروف الاقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه قد تغيرت تغيراً فجائياً نتيجة حادث لم يكن في الحسبان؛ ومن ثم اختلّ التوازن الاقتصادي للعقد اختلالاً خطيراً^(١٩).

وهكذا أصبحت نظرية الظروف الطارئة من النظريات المستقرة قضاءً وتشريعاً في غالب الأنظمة القانونية، بفضل ما تقوم عليه من اعتبارات العدالة، وما يهمننا في هذا البحث أن نوضح أن نظرية الظروف الطارئة تعد استثناءً على مبدأ القوة الملزمة للعقد، ووجوب التقيد بأحكامه؛ إذ إن هذا المبدأ يفترض بقاء ظروف إبرام العقد على ما هي عليه، فإن تغيرت جاز تغيير أحكام العقد لتنسجم مع ما طرأ من ظروف استثنائية غير متوقعة^(٢٠).

الفرع الثاني

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لابد من توافر ثلاثة شروط: الأول خاص بالعقد حيث يتطلب أن يكون مصدر التزام المدين متراخي التنفيذ، والثاني أن يكون الحادث طارئاً استثنائياً غير ممكن التوقع ولا الدفع، والثالث أن يكون تنفيذ التزام المدين مرهقاً. وفيما يلي نتناول هذه الشروط الثلاثة بشيء من التفصيل:

أولاً - أن يكون العقد متراخياً في التنفيذ:

لا تطبق هذه النظرية إلا على العقود متراخية التنفيذ، وهي العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فاصل زمني، ويحدث خلال هذا الفاصل الزمني حادث طارئ. وأياً كان هذا الفاصل الزمني طويلاً أو قصيراً.

والأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية أن الحادث الطارئ الاستثنائي عام، لم يكن في الوسع توقعه وقت التعاقد، ويقتضي أن تكون هناك فترة من الزمن تفصل بين صدور العقد وتنفيذه^(٢١).

(١٩) إن نظرية الظروف الطارئة بدأت في السنوات الأخيرة تظهر في القانون الخاص نتيجة التقنيات الحديثة؛ فظهرت في قانون الالتزامات المدني الإيطالي، والقانون المدني المصري (المادة ١٤٧/٢)، وفي القانون المدني الكويتي، كما أشرنا، (المادة ١٩٨).

(٢٠) إبراهيم الدسوقي أبو الليل، العقد والإرادة المنفردة، نظرية الالتزام، مؤسسة دار الكتب، الكويت، ١٩٩٨، ص ٢٨٠.

(٢١) السنهوري، المرجع السابق، مصادر الالتزام، المجلد الأول، ص ٨٦٧.

فمجال نظرية الظروف الطارئة هو العقود الزمنية، سواء أكانت مستمرة التنفيذ كعقد الإيجار وعقد العمل، أم كانت دورية التنفيذ كعقد التوريد.

ووفقاً للرأي الراجح، تطبق النظرية أيضاً على العقود فورية التنفيذ، إذا ما تراخى تنفيذ التزاماتها كلياً أو جزئياً، مثل عقد البيع؛ فهو عقد فوري بحسب الأصل، ولكن يجوز لأطرافه الاتفاق على تأجيل التزاماته كلها أو بعضها، حالة تأجيل الثمن أو تقسيطه، أو تأجيل تسليم المبيع^(٢٢).

ويشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الفورية ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام راجعاً إلى خطأ المدين.

ولا تطبق نظرية الظروف الطارئة، إذا وقع الحادث بعد منح القاضي نظرة الميسرة إلى المدين^(٢٣).

وتطبق النظرية أيضاً (بالإضافة إلى العقود فورية التنفيذ التي تم الاتفاق على تأجيل تنفيذها) على العقود فورية التنفيذ، التي يستغرق تنفيذها فترة من الزمن كعقد المقولة.

كما تطبق على العقود الفورية التي أوقف تنفيذها لاستحالة هذا التنفيذ استحالة مؤقتة لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه؛ إذ إن المدين أولى بالرعاية^(٢٤).

ولا يشترط أن يلحق تراخي التنفيذ جميع التزامات المدين، وإنما يكفي أن يلحق بعض التزاماته التي أصبحت مرهقة.

ثانياً – أن يكون الحادث الطارئ استثنائياً غير ممكن التوقع ولا الدفع:

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، أن يقع بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه، حادث استثنائي عام غير ممكن التوقع وغير ممكن الدفع.

(٢٢) انظر: عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، القاهرة، طبعة ١٩٦٢، ص ٥٧٣. وكذلك عبد الحي حجازي، عقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ، رسالة دكتوراه، القاهرة، ١٩٥٠، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ص ١٦٣-١٦٦. فالقانون الإيطالي نص على شرط التراخي باعتباره شرطاً ضرورياً، وعدد أنواع العقود، التي تطبق فيها النظرية، فهي ذات التنفيذ المستمر أو ذات التنفيذ الدوري. بلاينيول ودبير واسمان، فقرة (٣٩٧) ص ٥٥٦. ويجب استبعاد العقود الاحتمالية وعقود المضاربة في البورصة؛ لأنها بطبيعتها تعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو لمكسب كبير.

(٢٣) عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ١٩٨٤، ص ٥٥.

(٢٤) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، العقد والإرادة المنفردة، ص ٢٨١.

ويقصد بالحدث الاستثنائي الحادث الذي يندر وقوعه، أما إذا كان معتاد الوقوع فلا تطبق - عندئذ - نظرية الظروف الطارئة؛ وذلك لعدم تحقق الصفة الطارئة للحدث، وبخاصة أنه غالباً ما يكون متوقعاً حدوثه.

ومن أمثلة الحوادث الاستثنائية الزلازل، الحروب، الانتشار الفجائي للأوبئة، الهزات الأرضية الفجائية، التقلبات الفجائية للأسعار^(٢٥).

وليس بالضرورة أن يكون حدثاً طبيعياً كزلازل، أو اقتصادياً كتقلبات الأسعار، وإنما قد يتمثل في صدور تشريع استثنائي^(٢٦).

ويجب أن يكون الحادث الاستثنائي عاماً وليس خاصاً؛ أي غير مقصور على المدين، مثل إفلاسه أو مرضه أو حريق في ممتلكاته، فهذه الحوادث لا تعتبر عامة، ولا تطبق فيها نظرية الظروف الطارئة^(٢٧)، كما أن صفة العمومية يمكن أن تتعلق بمنطقة أو طائفة معينة، وليس من الضروري أن تصيب جميع المناطق وجميع الأفراد. ويشترط في الحادث الاستثنائي العام أن يكون غير ممكن التوقع وغير ممكن الدفع، وإذا أمكن إرجاع الحادث إلى خطأ المدين نفسه، فلا يمكنه التمسك بنظرية الظروف الطارئة.

ويرى بعضهم أن عدم إمكان التوقع ليس بشرط وإنما هو مجرد عنصر من عناصر عدم إمكان الدفع^(٢٨).

وإذا كانت الحوادث متوقعة أو يمكن توقعها، فلا سبيل لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، باختلاف سعر العملة أو انتشار دودة القطن، أو ما يشبه ذلك، كلها حوادث في الوسع توقعها^(٢٩). وتجدر الإشارة إلى أن الحادث الذي يمكن توقعه يمكن أن

(٢٥) لم يأت النص في القانون المدني الكويتي ولا المذكرة الإيضاحية منه بأمثلة وكذلك القانون المصري والقانون الإيطالي، أما القانون البولوني، فقد مثل الحوادث الاستثنائية بالحرب والوباء وهلاك المحصول هلاكاً كلياً.

(٢٦) محكمة النقض المصرية، صدور تشريع الإصلاح الزراعي بالقانون رقم (١٧٨) لسنة ١٩٥٢، يعد حادثاً استثنائياً يسيغ تطبيق نظرية الظروف الطارئة. نقض مصري ١٩٦٣/٣، مجموعة النقض ١- سنة ١٤ ص ٣٧ رقم (٣).

(٢٧) السنهاوري، المرجع السابق، مصادر الالتزام، المجلد الأول، ص ٨٧٣.

(٢٨) إبراهيم أبو الليل، الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، رسالة دكتوراه، القاهرة، ١٩٧٥، فقرة ٣٨، ص ٣٤٠.

(٢٩) عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص ٥٨٥ - ٥٨٦.

يكون أيضاً مما لا يستطيع دفعه، أما الحادث الذي يستطيع دفعه فيستوي في شأنه أن يكون متوقعاً أو غير متوقع^(٣٠).

ثالثاً - أن يجعل الحادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً:

لكي نطبق نظرية الظروف الطارئة يجب أن يجعل الحادث الطارئ تنفيذ المدين لالتزامه مرهقاً، لدرجة يهدده بخسارة فادحة؛ أي المدين يمكن له أن ينفذ التزامه ويستمر في ذلك، لكن هذا التنفيذ يرهقه، وليس تنفيذ الالتزام بالنسبة له مستحيلاً؛ لأنه إذا كان مستحيلاً انقضى الالتزام وانفسخ العقد؛ ومن ثم انقضى معه الالتزام المقابل في العقود الملزمة للجانبين.

وبالإضافة إلى أن يكون الالتزام مرهقاً للمدين نتيجة للحادث الطارئ، لابد أن يصيبه أيضاً بخسارة فادحة؛ إذ إن الخسارة المعتادة أو المألوفة لا مجال معها لتطبيق نظرية الظروف الطارئة.

والمعيار الذي تقدر به الخسارة الفادحة للمدين، هو المعيار الموضوعي، وقوامه الشخص العادي، ومدى تأثره بتنفيذ الالتزام، دون الالتفات إلى الظروف الخاصة التي تحيط بالمدين، فلا يلتفت - مثلاً - إلى كون المدين ثرياً أو يمكنه تعويض الخسارة من أعمال أخرى مربحة له.

فالإرهاق أو الخسارة الفادحة التي تلحق المدين، نتيجة للحادث الطارئ يترتب عليها اختلال التوازن الاقتصادي للعقد بشكل كبير، وليس اختلال المركز المالي له^(٣١).

فالحادث الطارئ - وفقاً لنظرية الظروف الطارئة - يجعل التزام المدين مرهقاً لا مستحيلاً، وهنا يبدو الفرق واضحاً بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة؛ فهما يشتركان في أن كلاهما لا يمكن توقعه ولا يستطيع دفعه، إلا أنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، أما الحادث الطارئ فيجعل التنفيذ مرهقاً، ويترتب على هذا الفرق في الشروط فرق في الأثر^(٣٢)؛ إذ إن القوة القاهرة - كما سبق ذكره - تجعل الالتزام ينقضي؛ ومن ثم لا يتحمل المدين تبعه عدم تنفيذه^(٣٣). أما الحادث الطارئ، فلا يجعل الالتزام ينقضي بل يرد إلى الحد المعقول؛ فتتوزع

(٣٠) السنهوري، المرجع السابق، مصادر الالتزام، المجلد الأول، ص ٨٧٤.

(٣١) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، العقد والإرادة المنفردة، ص ٢٨٤.

(٣٢) السنهوري، المرجع السابق، مصادر الالتزام، المجلد الأول، ص ٨٧٤.

(٣٣) راجع أثر القوة القاهرة والحادث الفجائي في المطلب الأول من هذا المبحث.

الخسارة بين المدين والدائن، وهذا يعني أن المدين يتحمل شيئاً من تبعه الحادث، وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل.

الفرع الثالث أثر نظرية الظروف الطارئة

عند توافر الشروط التي عرضنا لها سابقاً، وعند طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، يجوز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول؛ فله أن يضيق في مداه أو يزيد في مقابله، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

فتدخل القاضي يستهدف أن يعدل مضمون العقد برداً للالتزام إلى الحد المعقول، وليس له أن يعفي المدين من الالتزام كلياً، بل إن تدخله يكون للحد من الخسارة التي لحقت بالمدين نتيجة الحادث الطارئ وجعلها معقولة.

كما أن القاضي لا يملك تعديل العقد من تلقاء نفسه، وإنما لابد من طلب المدين والتمسك بنظرية الظروف الطارئة، وعندما يطلب المدين ذلك يكون تدخل القاضي وجوبياً لتعديل مضمون العقد ورد الالتزام من الحد المرهق إلى الحد المعقول.

وإذا كان القاضي لا يملك تعديل العقد من تلقاء نفسه إلا بناء على طلب المدين، فإن له السلطة التقديرية المطلقة بطريقة تعديل العقد؛ وذلك لرد الالتزام إلى الحد المعقول، وفي ذلك له أن يلجأ إلى إحدى الطرق الآتية:

أ - أن يضيق من مدى التزام المدين؛ ويكون ذلك برده من الحد المرهق إلى الحد المعقول نتيجة للحادث الطارئ. مثل أن يلتزم المدين بتوريد كمية من سلعة معينة مقابل سعر محدد، كآلف وجبة غذائية، سعر الوجبة خمسة دنانير، ونتيجة للحادث الطارئ أصبح سعر الوجبة ثمانية دنانير؛ فعندئذ يجوز للقاضي أن يخفض كمية الوجبات إلى سبعمائة وجبة.

ب - أن يزيد في مقابل الالتزام الذي أصبح مرهقاً مع الحادث الطارئ؛ ففي المثل السابق نفسه يبقي القاضي على كمية الوجبات التي يلتزم بها المدين وهي ألف وجبة، إلا أنه يزيد بسعر الوجبة لتكون ثمانية دنانير بدلاً من خمسة دنانير. ويجدر التنويه إلى أن القاضي لا يمكنه إجبار الدائن على قبول الزيادة في الالتزام؛ إذ إن للدائن خيار طلب فسخ العقد في هذه الحالة، كما أن القاضي له أن يجمع بين التضيق من مدى الالتزام على المدين وزيادة مقابل الالتزام على الدائن.

وللقاضي أيضاً أن يوقف تنفيذ العقد إذا كان الظرف الطارئ مؤقتاً، ويزول قريباً^(٣٤)، وله أن يمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه؛ أي يمنحه نظرة ميسرة.

ولا يملك القاضي - على العكس مما سبق - سلطة فسخ العقد بناء على طلب المدين وحده؛ لأن معنى ذلك أن يتحمل الدائن وحده كل أثر الظرف الطارئ^(٣٥).

وعندما تمنح السلطة التقديرية للقاضي لتعديل مضمون العقد لكي يعيد إليه توازنه الاقتصادي الذي اختل اختلالاً فادحاً نتيجة للحدث الطارئ، فإن ذلك لا يعني أن له أن يحمل أحد طرفي العقد أثر الظرف الطارئ دون الآخر، بل يجب عليه أن يحمل طرفي العقد (الدائن والمدين) هذا الأثر. وتحمل الدائن ومشاركته أثر الظرف الطارئ يكون بالنسبة إلى العبء الاستثنائي لخسارة المدين وليس العبء العادي المألوف في التعامل. إذ إن العبء العادي المألوف يتحمله المدين دون الدائن، والخسارة العادية المألوفة يتحملها المدين وحده، أما الخسارة الاستثنائية فتكون مناصفة بين الدائن والمدين^(٣٦).

وقد ألزم نص المادة (١٩٨) من القانون المدني أعمال نظرية الظروف الطارئة وسلطة القاضي في تعديل مضمون العقد في النظام العام؛ ومن ثم لا يجوز الاتفاق على استبعاد حكمها وإلا وقع الاتفاق باطلاً. غير أنه بعد تحقق الظرف الطارئ وثبوت حق المدين في التعديل، يجوز الاتفاق على استبعاد سلطة القاضي^(٣٧).

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن على المدين التمسك بإعمال نظرية الظروف الطارئة، أمام قاضي الموضوع، ولا يجوز إثارتها أمام محكمة التمييز مباشرة، لاتصال إعمال النظرية بالمسائل التي تتعلق بالواقع.

(٣٤) السنهوري، المرجع السابق، مصادر الالتزام، المجلد الأول، ص ٨٨١.

(٣٥) إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، العقد والإرادة المنفردة ص ٢٨٥. وقد ورد عند السنهوري، المرجع السابق، مصادر الالتزام، المجلد الأول، ص ٨٨٢، ألا يترتب على فسخ العقد ضرر يلحق الدائن أو ضرر يلحقه من الضرر الذي يصيبه في حالة زيادة التزامه، لذلك منحت بعض التشريعات سلطة فسخ العقد، كالتشريع البولوني، كما أن التشريع الإيطالي في المادة (١٤٦٧) مدني يعالج المسألة بطريقة أخرى، إذ إنه يجعل للمدين أن يطلب فسخ العقد، ما لم يدرأه الدائن بعرضه تعديلاً لشروط العقد بما يتفق والعدالة.

(٣٦) نقض مدني في أول مارس سنة ١٩٧٧، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٨، رقم (١١٠)، ص ٦٠٠.

(٣٧) نقض مدني مصري، ١٩٨٤/١/٩، المجموعة الرسمية، س ٣٥، ص ١٦٨ رقم ٣٦. حكم مشار إليه لدى إبراهيم أبو الليل، المرجع السابق، العقد والإرادة المنفردة، هامش ص ٢٨٦.

المطلب الثالث

التكييف القانوني لفيروس كورونا

بعد أن عرضنا لكل من القوة القاهرة (الحادث الفجائي) ونظرية الظروف الطارئة، نجد من الضرورة أن نعرض للتكييف القانوني الصحيح لفيروس كورونا المستجد (COVID- 19) باعتباره قوة القاهرة أو حادثاً طارئاً، وهو محور هذا المطلب. ويحسن - عند التعرض للتكييف القانوني لهذا الفيروس - أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول متعلق بالوباء أو الجائحة ذاتها، أما الأمر الثاني فمتعلق بالقرارات الاحترازية التي صدرت عن السلطة (الدولة).

الفرع الأول

التكييف القانوني لوباء (جائحة) كورونا المستجد

تشترك القوة القاهرة والحادث الطارئ في أن كلا منهما لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه، وفقاً لما عرضنا له سابقاً، وهذان الشرطان يجب توافرها سواء كنا بصدد قوة القاهرة أو حادث طارئ، ولكن الفرق بينهما هو الأثر المترتب على الحادث، فلو ترتب على الوباء أنه جعل تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلاً كنا بصدد قوة القاهرة، أما إذا كان ما يترتب على الوباء أن أصبح تنفيذ المدين لالتزامه مرهقاً لا مستحيلاً؛ بمعنى أنه يلحق به خسارة فادحة، كنا بصدد حادث طارئ، وتطبق - عندئذ - نظرية الظروف الطارئة. ومفاد ذلك أنه لا يمكن اعتبار جميع الأوبئة قوة القاهرة أو حادثاً طارئاً، بل يجب أن ينظر إلى كل حالة على حدة، وهذا ما تبناه القضاء الفرنسي عام ٢٠٠٩، عندما رفض اعتبار فيروس (H1N1) قوة القاهرة أو حادثاً طارئاً؛ بحجة أنه تم الإعلان عن الفيروس وتوافر الوقت لأجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة مسبقاً والتصدي له، فإذا كان الوباء يمكن توقعه ويمكن دفعه أو التخفيف من حدته بالمسكنات ومقاومته ببعض الأدوية، فلا يعتبر قوة القاهرة، ولا حادثاً طارئاً؛ لتخلف الشرطين أو أحدهما.

إلا أنه - بالنظر إلى وباء (جائحة) كورونا المستجد، نجد أن العالم كله قد فوجئ به؛ أي من الناحية القانونية لم يكن متوقعاً، وهذا الشرط يعتبر شرطاً موضوعياً، بمعنى شرط عدم التوقع بالنسبة للجميع، وليس باستطاعتهم توقع ظهور مثل هذا الوباء، وليس بناء على معيار الشخص العادي، بل بالنسبة إلى جميع الناس؛ بمن فيهم المتخصصون؛ ومن ثم يكون ظهور هذا الوباء مفاجئاً ولم يكن لأحد توقعه بالصورة التي ظهر بها.

وقد شكل هذا الوباء أزمة عالمية لم تمر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية^(٣٨)، وفقاً للدراسة التي صدرت عن منظمة العمل الدولية.

أما الشرط الثاني المتعلق باستحالة رده أو دفعه؛ فإن هذا الوباء جديد وليس له لقاح يحمي الأفراد من الإصابة به، كما أنه ليس له علاج للاعتماد عليه في الشفاء للأفراد المصابين به، وهو ينتشر ويتفاقم بشكل سريع جداً في جميع دول العالم.

فتوافر شرطي عدم التوقع واستحالة الدفع، نجدهما متوافرين بشكل واضح في وباء كورونا. ولكن اعتبار هذا الوباء وتكييفه قوة قاهرة أو حادثاً طارئاً، يتوقف على تنفيذ المدين للالتزامه، فإن كان تنفيذ المدين للالتزامه مستحيلاً اعتبر الوباء قوة قاهرة، وعلى العكس من ذلك؛ إن كان تنفيذ المدين للالتزامه ليس بمستحيل وإنما هو مرهق اعتبرنا الوباء ظرفاً طارئاً.

وعلى سبيل المثال، لو أن العمال علموا بوجود هذا الفيروس وسرعة انتشاره والإصابة به، لأمكن لهم الامتناع عن تنفيذ التزامهم أو جعل هذا التنفيذ مستحيلاً؛ نتيجة سيطرة الخوف عليهم من الذهاب إلى مقر العمل وإمكانية إصابتهم بالوباء عند اختلاطهم مع باقي العمال. وفي هذه الحالة نجد أن الاستحالة ليست باستحالة مادية وإنما هي استحالة نفسية، وهي تصلح - كما عرضنا سابقاً - أن تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً، والناحية القانونية، هي مسألة - بلا شك - من المسائل التي يقدرها قاضي الموضوع، ولذلك يمكن للعامل الامتناع عن الذهاب إلى العمل، ويسقط التزامه نتيجة للاستحالة النفسية التي قامت عنده، وبذلك يفسخ العقد، ويكون الوباء قد أصبح قوة قاهرة.

وعلى العكس من ذلك لو وباء كورونا المستجد لم يخلُ بين المدين وتنفيذ التزامه، بل كان تنفيذ التزامه ممكناً، إلا أنه مرهق ويهدده بخسارة فادحة لكننا - عندئذ - أمام حادث طارئ.

على سبيل المثال لو تعاقد رب عمل (صاحب مصنع) على توريد كمية من إنتاجه لجهة ما، لكنه لم يستطع إنتاج الكمية المتفق عليها أو المتعاقد عليها نتيجة لغياب بعض العمال عنه، ففي هذه الحالة لا يكون تنفيذ المدين (صاحب المصنع) للالتزامه بسبب انتشار الوباء وعدم حضور بعض العمال مستحيلاً بل هو مرهق له في ظل هذه الظروف (الوباء) ووفق المواعيد المتفق عليها؛ ومن ثم لا يمكن أن يعتبر

(٣٨) ما صرحت به منظمة العمل الدولية بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢٠.

الوباء في هذه الحالة بالنسبة إلى رب العمل أو صاحب المصنع قوة القاهرة، بل هو ظرف طارئ.

فالمعول يكون دائماً على الأثر المترتب على الوباء؛ فإن كان من شأنه جعل تنفيذ الالتزام على المدين مستحيلاً، كنا بصدد قوة القاهرة، أما إذا كان من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام على المدين مرهقاً وأن يصيبه بخسارة فادحة كنا بصدد ظرف طارئ.

الفرع الثاني

التكليف القانوني للقرارات الصادرة عن السلطة (الدولة)

كإجراء احترازي

إن انتشار الوباء (الجائحة) وتفاقمه بشكل سريع جداً، جعل الحكومات في العالم تتخذ قرارات حاسمة على الرغم من نتائجها وآثارها السلبية التي ألحقت أضراراً بالعديد من القطاعات الحيوية داخل البلاد، وصعّبت على العديد من الشركات الصناعية والتجارية مواصلة أنشطتها الاقتصادية.

وكان تدخل السلطة (الدولة) وإصدار مثل هذه القرارات إنما بدافع المصلحة العامة والحفاظ على صحة الأفراد في المجتمع، وهو تطبيق للتوصيات التي نادت بها المنظمات الصحية من ضرورة أخذ أقصى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، وكانت هذه القرارات قاسية من قبل الدول المقاومة لهذا الوباء العالمي.

وعليه، فقد أقدمت الدولة على اتخاذ حزمة من القرارات تمثلت في تعطيل المرافق العامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وصولاً إلى حظر التجول ووقف جميع الأنشطة^(٣٩)؛ الأمر الذي كان له تداعيات اقتصادية كبيرة بسبب توقف الأعمال ودخول عدد كبير من المواطنين في بعض الدول إلى حالة الإعسار.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في جلسته الاستثنائية رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١، قراره رقم (٢٠٢٠/٣٩١) المعنون (الإجراءات الوقائية المقترحة للحد من انتشار الفيروس في ضوء المستجدات التي طرأت)، وتبع هذا القرار العديد من

(٣٩) صدر قرار من مجلس الوزراء الكويتي في جلسة ٢٠٢٠/٥/٨، بال حظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد ٢٠٢٠/٥/١٠، من الساعة ٤ عصراً وحتى ٢٠٢٠/٥/٣٠ وذلك بناء على توجيه السلطات الصحية.

القرارات، أهمها قرار حظر التجول الجزئي، الذي عدّل أكثر من مرة بشأن ساعات الحظر، وهذا القرار - بلا شك - يمس أوقات العمل المقررة للعديد من الجهات في القطاع الخاص؛ ومن ثم أثر على إنتاجيتها، بل منع بعضها من ممارسة أعمالها.

وتعددت القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء؛ غير أن ما يهمنا في هذا البحث، تعليق رحلات الطيران من مطار الكويت وإليه، وإغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة، وإغلاق جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي أو عدم الجلوس فيها، وإغلاق الصالونات... إلخ.

وبالنظر إلى هذه القرارات التي صدرت عن السلطة (الدولة) وتصنيفها فهي قوة قاهرة أم حادث طارئ، فإنه لا بد من توافر الشرطين فيهما؛ وهما شرط عدم التوقع وشرط استحالة الدفع، وكلا الشرطين متوافر في القرارات الحكومية التي صدرت عن السلطة.

ولكن المعيار - كما سبقت الإشارة - هو الأثر المترتب عليها، فلو جعلت تنفيذ المدين لالتزامه مستحيلاً لكناً بصدد قوة قاهرة، أما إذا لم يكن أثرها على المدين في تنفيذ التزامه مستحيلاً بل هو مرهق أو يصيبه بخسارة فادحة كنا بصدد ظرف طارئ.

على سبيل المثال، القرارات التي أصدرتها الحكومة بتعليق رحلات الطيران، فإن كل شركات الطيران يجب عليها أن توقف رحلاتها وتقوم بإلغائها؛ أي إن تنفيذ شركات الطيران لالتزاماتها والمتعاقدين معها - سواء نقل ركاب أو نقل بضائع - أصبح مستحيلاً عليها تنفيذ الالتزام الذي تعاقدت عليه؛ ومن ثم يسقط التزام شركات الطيران وينفسخ العقد المبرم بينها وبين من تعاقد معها، وهذا الانفساخ يكون بقوة القانون. والشيء نفسه ينطبق على إغلاق دور السينما والنوادي والفنادق، حيث يؤدي الإغلاق إلى استحالة تنفيذ أصحاب هذه الأماكن لالتزاماتهم. فمن تعاقد مع دور السينما أو مع أحد الأندية أو فندق لإقامة حفل زفاف أو مناسبة معينة أو مؤتمر، فالفندق سوف يعتذر منه عن عدم القدرة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والسبب راجع إلى القرارات الحكومية التي تمنع ذلك؛ ومن ثم يستحيل على أصحاب الفنادق والسينما والنوادي الصحية تنفيذ التزاماتهم السابقة على صدور هذه القرارات، وما دام تنفيذ التزاماتهم أصبح من المستحيل فإن هذه القرارات تكون قوة قاهرة.

وكذلك عندما تصدر الحكومة قراراً بإغلاق المحل التجاري لبعض الأنشطة؛ ومن ثم لا يستطيع العامل الذهاب إلى مقر العمل، وتنفيذ التزامه بأداء العمل المطلوب منه، فإن هذا القرار الحكومي يكون قوة قاهرة دائمة أو مؤقتة.

ولكن إذا كانت طبيعة عمل العامل المتعاقد مع رب العمل، تسمح له القيام بالعمل وهو في منزله، دون حاجة إلى الذهاب إلى مقر العمل، فإن القرارات الحكومية في هذه الحالة لا تعتبر قوة قاهرة ولا تعتبر ظرفاً طارئاً؛ لعدم وجود أي أثر للقرارات التي صدرت على تنفيذ المدين (العامل) لالتزامه.

وقد لا تكون القرارات الحكومية قوة قاهرة بل هي ظرف طارئ، ومن ذلك - على سبيل المثال - شركات المقاولات التي تعهدت ببناء مبان وتسليمها في موعد محدد، ثم نتيجة للقرارات التي صدرت ومنعت توجّه العمال لتأدية أعمالهم أو قيدت ساعات العمل، لم تعد هذه الشركات قادرة على أن تسلم المباني في الموعد المحدد لها؛ ومن ثم فإن التزام شركات المقاولات لم يصبح مستحيلاً، وإنما أصبح مرهقاً في تسليمها في الموعد؛ وهو ما يترتب عليه إلحاق خسائر فادحة بها أو جسيمة، وهنا يمكن اعتبار القرارات الحكومية ظرفاً طارئاً وليس قوة قاهرة.

وخلاصة ما تقدم تتمثل في أن الوباء أو الجائحة في ذاتها وكذلك القرارات الحكومية التي صدرت كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء، كلاهما قد يكيف من الناحية القانونية على أنه قوة قاهرة، أو حادث طارئ، بحسب ما يترتب عليها من أثر على التزام المدين في تنفيذ التزامه، فإن جعلت تنفيذه للالتزام مستحيلاً كنا بصدد قوة قاهرة، أما إذا كان تنفيذه للالتزام مرهقاً فإننا نكون بصدد ظرف طارئ.

ومن ثم؛ لا بد من فحص كل حالة على حدة من قبل قاضي الموضوع لإعطاء التكييف القانوني الصحيح؛ إذ من الممكن أن تعدّ الحالة لأحد طرفي العقد قوة قاهرة، في حين تعدّ للآخر ظرفاً طارئاً.

المبحث الثاني

أثر التكيف القانوني لفيروس كورونا المستجد على عقد العمل

عرضنا في المبحث السابق التكيف القانوني لجائحة كورونا، ثم القرارات التي صدرت عن السلطة كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء أو الجائحة. وتوصلنا إلى أن التكيف القانوني للحالتين: القوة القاهرة والظرف الطارئ، إنه لا يمكن - من وجهة نظرنا - اعتبار جميع الأمراض والأوبئة قوة القاهرة، أو حادثاً طارئاً، بل لا بد من النظر إلى الأثر الناجم (عن الوباء أو القرارات) على التزام المدين عند تنفيذ الالتزام؛ فإن أصبح مستحيلاً كنا بصدد قوة القاهرة، وإن أصبح مرهقاً وليس مستحيلاً كنا بصدد حادث طارئ.

وقبل أن نبين أثر التكيف القانوني لفيروس كورونا على كل من أجر العامل وعقد العمل، لا بد أن نبين مدى إمكانية وقف عقد العمل في القطاع الأهلي من تاريخ وجود الوباء أو الجائحة حين زوالها، أو من تاريخ صدور القرارات الحكومية وحين إلغائها بعد القضاء على الوباء أو الجائحة.

لذا سنتناول في هذا المبحث وقف عقد العمل^(٤٠)، والآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا على كل من أجر العامل وعقد العمل، وذلك في ثلاثة مطالب.

المطلب الأول

وقف عقد العمل

الفرع الأول

تعريف وقف عقد العمل وخصائصه

تعرف محكمة النقض المصرية وقف عقد العمل بأنه تنفيذ الالتزامات الرئيسية المتبادلة التي يفرضها العقد على طرفيه عند حدوث قوة القاهرة تؤدي إلى الاستحالة المؤقتة للتنفيذ.

ويعدّ عقد العمل من العقود الزمنية التي تنفذ خلال فترة زمنية تطول أو تقصر،

(٤٠) انظر في ذلك: خالد جاسم الهندياني، وعبد الرسول عبد الرضا، شرح أحكام قانون العمل الكويتي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠، الطبعة الثالثة، الكويت، ٢٠١٨، ص ٣٩٣ وما بعدها. وكذلك جمال فاخر النكاس، قانون العمل الكويتي المقارن، الطبعة الثانية، الكويت، دار الكتب، ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦، ص ١١١، وما بعدها.

وهذه المسألة قد تعرض عقد العمل في أثناء سريانه إلى موانع تعترض تنفيذه في بعض الفترات، فيتعذر على طرفي العقد تنفيذ التزاماتهما كلها أو بعضها، ومن ذلك - على سبيل المثال - تعرض المنشأة لحريق يؤدي إلى توقف العمل فيها، أو يصاب العامل بمرض يمنعه من أداء العمل.

وقد استحدث القضاء الفرنسي فكرة وقف تنفيذ العقد، وبين أنه إذا كان المانع مؤقتاً، وليس نهائياً، فإن ذلك لا يؤدي إلى فسخ العقد وإنما إلى وقف تنفيذه فترة من الزمن حتى زوال المانع^(٤١).

فقضت محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامها بأن: "القوة القاهرة لا تمنع تنفيذ الالتزام إلا إذا حالت بين المدين وبين إعطاء أو عمل ما هو ملتزم بإعطائه أو عمله، ومن ثم لا يبرأ المدين إذا كان المانع مؤقتاً، بل يكون تنفيذ الالتزام موقوفاً إلى حين زوال القوة القاهرة"^(٤٢).

والمقصود بمصطلح وقف عقد العمل، هو وقف تنفيذ عقد العمل وليس وقف عقد العمل بذاته؛ ومن ثم فالوقف يؤثر في الالتزامات دون أن يؤثر في العقد^(٤٣).

ولم يعرّف المشرع الكويتي في القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ وقف عقد العمل، بل أعطى تطبيقات عدة له.

وقد تعددت التعريفات الفقهية لوقف عقد العمل، فيعرفه البعض بأنه: "وقف مؤقت لحياة العقد، بحيث يستأنف العقد سريانه بعد زوال سبب الوقف"^(٤٤).

ويؤخذ على هذا التعريف أنه تبني الصفة الوقتية للوقف كسمة مميزة، وهو ما يتناقض مع وجود حالات للوقف تنتهي بانتهاء العقد. وعرّف بعضهم وقف العقد بأنه: "ما هو إلا توسع في آثار القوة القاهرة المؤقتة؛ وذلك لتفادي فسخ العقد في حالة الاستحالة المؤقتة للتنفيذ"^(٤٥).

(٤١) انظر: خالد جاسم الهندياني، وقف عقد العمل، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الرابعة والعشرون، ديسمبر ٢٠٠٠، ص ١٧٣.

(٤٢) نقض فرنسي، ١٥ نوفمبر ١٩٢١، دالوز ٥، ص ١٤، مشار إليه لدى وفاء حلمي أبو جميل، وقف عقد العمل، دار النهضة العربية، ١٩٩٠، ص ٥.

(٤٣) خالد الهندياني، المرجع السابق، وقف عقد العمل، ص ١٧٥.

(٤٤) André Brun et Henri Galland, Traité du droit du travail, T.II, Sirey, Paris, 1977, p. 792.

(٤٥) وفاء حلمي، المرجع السابق، ص ١٤، كامر لئك، المرجع السابق، ص ٢٢٢.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه لا يشمل كل حالات وقف عقد العمل؛ إذ إن هناك بعض الحالات تخرج عن فكرة القوة القاهرة، مثل (وقف عقد العمل بسبب الإضراب، الوقف التأديبي عن العمل... وغيرها).

وذهب بعض الفقه محاولاً وضع نظرية عامة للوقف إلى تعريفه بأنه: "وسيلة قانونية لمواجهة اضطراب وقتي بفعل الواقع أو القانون، أو لمواجهة قصور في تنفيذ عقد يترأخى في تنفيذه الزمن؛ لضمان استمرارية العقد وتنفيذه بشكل مباشر وصحيح طالما كان ذلك ممكناً ومفيداً للطرفين في المستقبل" ^(٤٦).

ومع تعدد التعريفات الفقهية لوقف عقد العمل ^(٤٧)، فإننا نتبنى التعريف الذي ذهب إليه (جاستان)، وهو أن الوقف: "انقضاء مؤقت لا رجعة فيه للالتزامات المتولدة عن العلاقة العقدية، خلال فترة تطول أو تقصر، ينشأ من حصول حادث مفاجئ أو عن ممارسة المدين لحق يتناقض مع تنفيذ العقد أو حتى عن عدم التنفيذ الخاطئ، دون أن يؤثر ذلك في بقاء الرابطة العقدية" ^(٤٨).

ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نستخلص الخصائص التي يتميز بها وقف عقد العمل، وهي:

أولاً - وقف عقد العمل هو عدم تنفيذ مؤقت:

يتطلب الوقف - بداية - أن نكون بصدد عدم تنفيذ للالتزامات العقدية؛ فلا يكفي مجرد انقطاع الالتزامات العقدية الناتج من تنفيذ العقد؛ إذ إن العامل لا يقوم بأداء العمل خلال فترات العطل وأيام الراحة الأسبوعية، وهذا يعد انقطاعاً للالتزامات العقدية الناتج من التنفيذ الطبيعي لعقد العمل، لكنه ليس وقفاً للعقد، وإنما الوقف عندما يكون المتعاقد ملزماً بتنفيذ الالتزامات العقدية لكنه يمتنع عن تنفيذها لأي سبب متمسكاً بالوقف.

ولا يعتبر من قبيل وقف العقد أيضاً عدم التنفيذ الخاطئ، إنما يعد هذا عدم تنفيذ للالتزامات العقدية الذي نتج عنه ترتيب المسؤولية العقدية لمن صدر عنه وتوقيع الجزاءات عليه؛ فغياب العامل غير المشروع عن العمل لا يكون مبرراً لوقف عقد العمل ^(٤٩).

(٤٦) Nabil Saad, la suspension dans L. exécution du contrat, essai d'une théorie générale, T. II, Thèse Dijon 1981, p. 286.

(٤٧) للمزيد من التعريفات، انظر: خالد الهندياني، المرجع السابق، وقف عقد العمل، ص ١٨٢ وما بعدها.

(٤٨) Jacques Ghestin, Traité de droit civil, les obligations, L.G.D.J. 1942, p. 374.

(٤٩) خالد الهندياني وعبد الرسول عبد الرضا، المرجع السابق، ص ٣٩٦.

ويجب أن يكون عدم التنفيذ للالتزامات وقتياً؛ فإذا كان نهائياً فإنه لا يمكن إعمال فكرة وقف عقد العمل، بل لابد من اللجوء إلى الفسخ في هذه الحالة. والوقتية المقصودة هي زوال أسباب الوقف، مثل انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، لكن من الممكن أن يستأنف هذا التنفيذ بعد انتهاء فترة الوقف. وتستلزم الصفة الوقتية لوقف العقد، أن تكون مدة الوقف محددة سابقاً، أو قابلة للتحديد على الأقل، ويستمر الوقف ما دام سبب الوقف موجوداً. أما مدة الوقف فيحددها المشرع بنفسه، فعلى سبيل المثال الوقف التأديبي، في قانون العمل في القطاع الأهلي محدد بعشرة أيام. وقد يحدده القضاء مثل وقف عقد العمل بسبب خارجي أو حدوث ظرف طارئ أو إغلاق المشروع مؤقتاً؛ فالقاضي يوقف عقد العمل لفترة تكفي لإعادة تشغيل المشروع من جديد. وقد يكون الوقف من قبل أطراف عقد العمل، مثل أن يتفقوا على بعض الإجازات ومنها المهمات العلمية^(٥٠).

ثانياً - عدم استدراك الالتزامات العقدية الموقوفة:

يكون العقد في حالة سكون أو جمود خلال فترة الوقف، وإذا استؤنف تنفيذه بعد زوال أسباب الوقف، فإن الالتزامات الموقوفة لا تستدرك، وإنما يعفى منها الأطراف خلال فترة الوقف وبعدها؛ ومن ثم فإن الوقف لا يؤدي إلى التأخير في تنفيذ الالتزامات وإنما إلى الإعفاء منها تماماً بشكل نهائي.

ثالثاً - الوقف يؤدي إلى المحافظة على الرابطة العقدية:

الوقف يحافظ على الرابطة العقدية، ويعتبر وسيلة قانونية لتجنب ترتيب المسؤولية أو فسخ العقد في بعض الحالات؛ فهو يضع التزاماً على أطرافه بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدية، كما أنه يمنع المتعاقد الآخر من طلب الفسخ أو التنفيذ العيني خلال فترته، وغاية الوقف هو الاستقرار الوظيفي وتجنب الإنهاء الفجائي لعلاقة العمل، فلا يجوز لرب العمل - مثلاً - من حيث المبدأ أن يفسح العقد خلال مرض العامل أو اعتقاله أو خلال فترة إجازة المرأة العاملة بسبب الحمل والولادة، وبعد زوال سبب الوقف، يقوم الأطراف بتنفيذ العقد دون الأخذ في الاعتبار مدة الوقف.

(٥٠) خالد الهندياني، المرجع السابق، ص ١٨٨. حسام الأهواني، شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وربة حسان، القاهرة، ١٩٩١، ص ٥٦٧. أحمد حسن البرعي، الوجيز في قانون العمل، الكتاب الأول، عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٤٥٦.

الفرع الثاني شروط وقف عقد العمل

يلزم لوقف عقد العمل، أن تتوافر ثلاثة شروط، هي:

أولاً - ألا تكون مدة التنفيذ عنصراً جوهرياً في العقد:

إذا كانت مدة العقد عنصراً جوهرياً واتجهت إرادة الأطراف إليه، فلا يمكن إعمال وقف العقد، كأن يكون المطلوب من العامل أداء عمل معين في فترة محددة، ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى فسخ العقد وليس وقفه. أما إذا كانت المدة عنصراً ثانوياً في العقد، فعندئذ يكون من الممكن وقف عقد العمل واستئناف تنفيذه بعد زوال أسباب الوقف، دون أن يؤدي إلى الإخلال الجوهري في تنفيذه.

ويمكن معرفة مدة التنفيذ إذا كانت عنصراً جوهرياً في العقد أو غير جوهري، من خلال البحث في نية الأطراف ومدى رغبتهم في التنفيذ الكامل للعقد خلال المدة المتفق عليها وعدم ارتضاءهم اللجوء إلى نظام الوقف؛ تفضيلاً منهم لفسخ العلاقة العقدية. أما طبيعة العقد، فإن العقود الموسمية أو المبرمة لفترة وجيزة أو لمواجهة أعباء معينة - على سبيل المثال - لا تسمح بطبيعتها أن يتوقف العقد خلالها^(٥١).

ثانياً - ألا يتضمن العقد شرطاً فاسخاً:

ويكون ذلك إذا اتفق الأطراف على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة إلى أي حكم قضائي؛ بمعنى أن مجرد الإخلال بالالتزامات العقدية الصادرة عن طرفي العقد يؤدي إلى انقضاء العقد بقوة القانون وبغض النظر عما إذا كان لأحد الطرفين مصلحة في عدم فسخ العقد. وتطبق في هذه الحالة أحكام الفسخ تلقائياً؛ احتراماً لإرادة الطرفين^(٥٢).

غير أن من الواجب عدم إعمال هذا الشرط في الحالات التي ينص فيها المشرع على وقف عقد العمل؛ إذ إن المشرع يقرر حالات وقف عقد العمل بنصوص أمرة في قانون العمل، مثل حالات الإجازة المرضية أو الوقف التأديبي أو إجازة الوضع وغيرها؛ فلا يجوز في هذه الحالات أن يشملها الشرط الفاسخ؛ ومن ثم لا يطبق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بين أطراف العقد على هذا الشرط في الحالات

(٥١) خالد الهندياني وعبد الرسول عبد الرضا، المرجع السابق، ص ٣٩٨.

Nabil Saad, op. cit, p. 292.

(٥٢)

المشار إليها يجعل الشرط باطلاً ولا يعمل به؛ لأن الوقف في هذه الحالات يعد من النظام العام.

ثالثاً - أن يكون تنفيذ العقد ممكناً في المستقبل:

أُوجد نظام الوقف لتجنب فسخ العقد، بعد زوال السبب الذي من أجله أوقف العقد؛ لذلك لا يمكن تطبيق نظام الوقف إلا إذا كان العقد ممكن التنفيذ في المستقبل بعد زوال أسباب أو سبب الوقف.

ويمكن أن نستخلص إمكانية تنفيذ العقد في المستقبل من الصفة الوقتية للوقف، ولا بد من ربط هذه الصفة الوقتية بطبيعة العقد؛ انطلاقاً من أن السبب في عقد معين قد يكون وقتياً، في حين يتعذر هذا الوصف للسبب نفسه في عقد آخر؛ فمثلاً لو أن عاملاً مرض لمدة شهر أو اعتقل فإن ذلك يعد سبباً وقتياً لوقف عقد عمل محدد مدته بسنة، ولا يعد كذلك في عقود العمل الموسمية.

وتحتم الصفة الوقتية أن تنتهي أسباب الوقف قبل حلول ميعاد انتهاء العقد؛ لأن الوقف لن يستمر عند حلول أجل انقضاء العقد وإنما ينقضي العقد ولا يمتد بسبب الوقف. وأخيراً، يجب أن يكون تنفيذ العقد في المستقبل مفيداً ومجدياً ويحقق أهدافه؛ فلا يكفي أن يكون ممكناً فقط، واستنتاج ذلك يكون من الصفة الوقتية للوقف؛ فإذا كانت الصفة العرضية منذ نشوئها واضحة فإن الوقف لن يدوم طويلاً، كأن يتعرض عامل لمرض بسيط؛ ومن ثم يتغيب عن العمل فترة وجيزة، فعندئذ يكون من المصلحة اللجوء إلى نظام الوقف.

الفرع الثالث

أسباب وقف عقد العمل

قد ترجع أسباب وقف عقد العمل إلى العامل، كما يمكن أن ترجع إلى رب العمل أو إلى فعل القوة القاهرة^(٥٣)، ونذكر - فيما يلي - بعض الأمثلة لكل حالة على حدة:

أولاً - أسباب الوقف التي ترجع إلى العامل:

إن أسباب الوقف التي ترجع إلى العامل كثيرة، وتشكل معظم حالات الوقف، وتقرير الوقف في هذه الحالات جاء مراعيّاً للظروف الإنسانية والاجتماعية التي تحيط

(٥٣) حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص ٥٧٣ وما بعدها. أحمد حسين البرعي، المرجع السابق، ص ٤٥٧. خالد الهندياني، المرجع السابق، ص ٢٣٩.

بالعامل، وحمايته كطرف ضعيف في عقد العمل، ومراعاة لظروف العامل الشخصية والاجتماعية، جاء وقف عقد العمل وسيلة لتجنب الفسخ، وأهم هذه الحالات:

- أ - الوقف بسبب ولادة العاملة.
- ب - الوقف بسبب الإضراب.
- ج - الوقف بسبب التحاق العامل بالخدمة العسكرية (التجنيد).

ثانياً - أسباب الوقف التي ترجع إلى رب العمل:

ويقصد بهذه الأسباب صدور قرار فردي من صاحب العمل يوقف على أثره تنفيذ عقد العمل، ومن الحالات المرتبطة بهذه الأسباب:

- أ - وقف عقد العمل بسبب التأديبي.
- ب - وقف العقد بسبب حبس العامل سواء أكان لإجراء تحقيق معه أم لتنفيذ حكم قضائي غير نهائي.
- ج - وقف عقد العمل بسبب الإغلاق المؤقت للمشروع.

ثالثاً - أسباب الوقف التي ترجع إلى فعل القوة القاهرة:

إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه مؤقتاً، فإن هذه الاستحالة لا تؤدي إلى إنهاء عقد العمل وإنما يوقف تنفيذه حتى زوال الاستحالة. فقد تطرأ قوة القاهرة تمنع المدين مؤقتاً من تنفيذ التزامه، وعندئذ فإن هذا المدين لا يبرأ نهائياً من تنفيذ التزامه، بل يكون موقوفاً إلى حين زوال القوة القاهرة. والحالات التي تدخل ضمن القوة القاهرة هي:

- أ - وقف عقد العمل بسبب مرض العامل.
- ب - وقف عقد العمل بسبب إصابة العامل أو تعرضه لأحد أمراض المهنة.
- ج - وقف عقد العمل بسبب عطل أصاب المشروع (نشوب حريق، زلزال، فيضان، قرار بسحب المشروع... إلخ)^(٥٤).

(٥٤) انقسم شراح القانون في هذا الشأن إلى فريقين، فمنهم من يتناول الأسباب مجتمعة ويضيف إليها إجازات العامل، وفريق منهم يدرس أنواعاً منها على أساس أنها أسباب عارضة لم ينص عليها عقد العمل بشكل مباشر. جمال النكاس، المرجع السابق، قانون العمل الكويتي، ص ١١٣.

الفرع الرابع آثار وقف عقد العمل

وتنقسم هذه الآثار إلى مرحلتين، مرحلة الآثار خلال فترة الوقف، ومرحلة الآثار عند انتهاء فترة الوقف.

أولاً - الآثار خلال فترة الوقف:

إن الوقف يؤدي إلى إعفاء طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، وهذا الإعفاء يكون لبعض الالتزامات الناشئة عن العقد؛ كأن يعفي المدين الذي يتوافر بحقه سبب من أسباب الوقف من تنفيذ التزامه، دون أن يتعرض للمسؤولية؛ ومن ثم لا يكون مخطئاً خلال فترة الوقف، وفي المقابل يحق للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه.

ولا يشمل هذا الإعفاء - كما سبقت الإشارة - جميع الالتزامات الناشئة عن العقد؛ إذ إن هناك بعض الالتزامات تظل باقية، ويتعين على الطرفين احترامها، فالوقف يرد على الالتزامات الرئيسية دون الثانوية، والالتزامات الرئيسية هي الالتزامات التي أبرم عقد العمل من أجل تحقيقها، وهي التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه والتزام رب العمل بدفع الأجر.

فإذا كان سبب وقف عقد العمل لا يرجع إلى رب العمل - كأن يتعرض المشروع لعطل يوقف العمل فيه، مثل نشوب حريق في المصنع نتيجة ماس كهربائي أو تعرض المشروع لكارثة طبيعية كزلزال أو هطول أمطار غزيرة ترتب عليها فيضانات أو سيول أو غيرها من الأسباب التي ترجع إلى فكرة القوة القاهرة - فعندئذ يعفى رب العمل من التزامه بتمكين العامل من أداء العمل، وعليه لا يلتزم بتقديم الأدوات اللازمة للعمل خلال فترة الوقف، والعامل بدوره يعفى من التزامه بتقديم العمل خلال هذه الفترة.

أما إذا تحقق سبب الوقف من جهة العامل نتيجة لمرضه أو لتمتعه بالإجازة السنوية أو حبسه احتياطياً أو غيرها من الأسباب، فالعامل يعفى من التزامه بأداء العمل المتفق عليه وبالالتزامات المتفرعة عنه، وفي المقابل فإن رب العمل يعفى من ضمان حوادث العمل والتزامه بدفع الأجر وما يشمله من ملحقات.

ولكن هذا الأصل العام قد يرد عليه استثناء بموجب نص قانوني يقرر صرف الأجر كله أو بعضه، مثل حالة الإجازات المرضية أو السنوية.

ومع ذلك، فإن العقد يبقى قائماً بين طرفيه خلال فترة الوقف، وتبقى الالتزامات القانونية؛ فعقد العمل يقوم على الثقة والأمانة، والعامل خلال الوقف يلتزم بالمحافظة

على أسرار المنشأة والإخلاص لرب العمل، وفي المقابل لا يجوز لرب العمل أن يطرد العامل من المسكن الذي خصص له كميزة ملحقة بالأجر.

ثانياً - الآثار عند انتهاء فترة الوقف:

الأصل أن يستأنف تنفيذ العقد ويعاد إلى ترتيب جميع آثاره؛ فتعود الالتزامات الموقوفة إلى السريان؛ فيلتزم العامل بعودته إلى عمله بمجرد زوال سبب الوقف، وفي المقابل يلتزم رب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتسليمه عمله. وإذا أخل أحد طرفي العقد بالتزاماته كان مسؤولاً عن فعله، فلو لم يعد العامل - مثلاً - إلى عمله بعد انتهاء الوقف، يعد مخالاً بالتزامه؛ مما يعطي رب العمل الحق في توقيع الجزاءات عليه.

فالأصل أن يستأنف العقد بالشروط والبنود نفسها التي كانت موجودة قبل الوقف دون أي تعديل، ولا يجوز لرب العمل أن يقوم بتعديل شروط العقد، إلا إذا كان ذلك في صالح العامل^(٥٥).

وتختلف آثار الوقف على مدة العقد؛ إذا ما كانت محددة أو غير محددة.

فإذا كان العقد محدد المدة فإنه ينقضي بحسب الأصل عند حلول أجل انتهائه؛ ومن ثم لا يؤدي الوقف إلى إطالة مدة العقد، فإذا حل أجل الانتهاء خلال فترة الوقف فإن العقد ينتهي عند هذا الأجل، وتعد إطالة العقد لفترة تساوي مدة الوقف تعديلاً جوهرياً لا يتم إلا باتفاق الطرفين.

أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه عند زوال سبب الوقف يعود العقد إلى السريان والتنفيذ إلى أن ينتهي باتفاق طرفيه أو لأي سبب آخر. أما إذا طرأ سبب الوقف خلال فترة الإخطار، فلا يؤثر في هذه المدة ما يتخللها من وقف عقد العمل. فلو قام رب العمل - مثلاً - بإخطار العامل بإنهاء العقد وأصيب العامل بمرض معين أوقف على أساسه، فإن العقد ينتهي بانتهاء مهلة الإخطار ولا يمتد إلى مدة مساوية لمدة الوقف.

المطلب الثاني

أثر فيروس كورونا على أجر العامل

الأصل أن يحدد الأجر باتفاق الطرفين، فإن لم يتفق الطرفان ووقع خلاف على تعيين الأجر يمكن اللجوء إلى القاضي لتحديد الأجر، ويمكن للمشرع أن يتدخل ويضع قيوداً على قيمة الأجر المتمثلة في الحد الأدنى منه.

(٥٥) حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص ٥٧١. خالد الهندياني، المرجع السابق، ص ٢٢٢.

وإذا كان الأصل أن يحدد الأجر وفقاً لاتفاق طرفي العقد، فإن هذا المبدأ قد أدى من الناحية العملية إلى إلحاق الضرر بالعمال؛ انطلاقاً من أن العامل هو الطرف الضعيف في عقد العمل، والطرفان على قدم المساواة في التفاوض على قيمة الأجر، وهذه القيمة أمر مهم بالنسبة للعمال؛ فهي مصدر رزقهم الوحيد، وكان العمال يقبلون بالأجور المتدنية على الرغم من عدم كفايتها لتأمين الحد الأدنى الضروري في المعيشة الإنسانية^(٥٦).

وقد بدأ المشرع في مختلف الدول في التدخل لتحديد أجور العمال عن طريق وضع الحد الأدنى لها؛ حماية لهم من خطر الجوع والعوز، ورفع ذلك الحد كلما ارتفع مستوى الأسعار ارتفاعاً ملموساً^(٥٧).

وقد نص المشرع الكويتي - انسجاماً مع النهج الدولي ومع الاتفاقيات الدولية - في المادة (٦٣) من القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه: "يجب على الوزير أن يصدر قراراً كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقاً لطبيعة المهن والصناعات، مستهدياً في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة". وبالفعل صدر قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يحدد الحد الأدنى للأجور، وحدده للعاملين في القطاع الأهلي بمبلغ (٦٠ د. ك) شهرياً^(٥٨)، وصدر بعد ذلك قرار وزاري آخر يرفع الحد الأدنى للأجر إلى (٧٥ د. ك) شهرياً^(٥٩).

(٥٦) نصت المادة (٢٣/٣) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مُرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية". كما تنص المادة (٢/٥) من الاتفاقية رقم (١١٧) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية على أنه: "عند تحديد الحد الأدنى لمستويات المعيشة، تراعى الاحتياجات الأساسية لأسر العمال كالطعام وقيمته الغذائية، والسكن، والملابس، والرعاية الطبية والتعليم". كما أن المادة (١٠) من هذه الاتفاقية تشجع تحديد الأجور عن طريق الاتفاقيات الجماعية أو من خلال المشرع وتعطي الحق للعامل أن يتقاضى أقل من الحد الأدنى بأن يسترد فرق الأجر وذلك عن طريق القضاء أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون". صدرت هذه الاتفاقية في عام ١٩٦٢ وصدقت عليها دولة الكويت بمرسوم أميري سنة ١٩٦٤.

(٥٧) بدأ التدخل في الدول الأوروبية بين الحربين العالميتين، وفي مصر بعد الحرب العالمية الثانية، وفي لبنان عام ١٩٤١.

(٥٨) قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (١٨٥/ع) لسنة ٢٠١٠، بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي.

(٥٩) قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (١٤) لسنة ٢٠١٧، بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي.

وبناء على ما سبق؛ فإنه لا يجوز الاتفاق على تحديد الأجر بما يقل عن الحد الأدنى المحدد تشريعياً أو المقرر قانوناً.

ويكون تحديد الأجر واحتسابه إما على أساس وحدة زمنية فيتحدد (بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر)، وإما على أساس الإنتاج كأن يتفق على تحديده بالقطعة، ويمكن أن يحدد أيضاً على أساس الطريقتين، وهو ما يسمى (الأجر بالطريقة). وعند الاتفاق على تحديد الأجر وطريقة احتسابه، فإن هذا الاتفاق يكون سارياً بحسب الأصل، ولا يمكن تعديله إلا برضا الطرفين؛ ومن ثم لا يجوز لرب العمل أن ينفرد بتخفيضه تحت ذريعة تنظيم المنشأة^(٦٠).

وقد قضت محكمة التمييز بأنه: "إذ نصت المادة (١٩٦) من القانون المدني على أن - العقد شريعة المتعاقدين - فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون؛ فقد دلت على أنه لا يجوز أن ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد تحت أية ذريعة، ما لم يقض القانون بغير ذلك؛ ومن ثم فليس لصاحب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة أي حق ترتب للعامل بمقتضى عقد العمل"^(٦١).

وقد تعرضنا سابقاً - عند الحديث عن وقف عقد العمل - إلى أن أحد أسباب وقف عقد العمل يرجع إلى قوة قاهرة، وهي تتمثل في الوباء ذاته أو القرار الاحترازي الصادر عن السلطة، الذي قد يكتف في بعض الحالات على أنه قوة قاهرة^(٦٢) وقد يصدق القول إنها قوة قاهرة مؤقتة، تزول عند السيطرة على الوباء ومنع انتشاره أو عند إلغاء القرار الصادر عن السلطة. ووفقاً للقواعد العامة سالفة الذكر فإنه يمكن أن

(٦٠) كان القانون رقم (٣٨ لسنة ١٩٦٤) بشأن العمل في القطاع الأهلي قد أسبغ نوعاً من الحماية على أجر العامل. بما نصت عليه المادتان (٣٢، ٣٣) من عدم جواز الاقتطاع منه أو الحجز عليه أو النزول عنه إلا في الحدود والأموال المبينة فيهما. ونصت المادة (٩٤) على بطلان كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام قانون العمل إلا أنه ليس في نصوص ذلك القانون ما يحظر على طرفي هذا العقد الاتفاق على تعديل شروطه أثناء سريان علاقة العمل أو إبدال به آخر يختلف في هذه الشروط حتى وإن ترتب على ذلك إنقاص أجر العامل أو ميزة له ما دام ذلك بإرادة طرفي العقد. تمييز عمالي، طعن ٨٨/٢٠٠١، جلسة ٣/٦/٢٠٠٢، مجلة القضاء والقانون، نوفمبر ٢٠٠٥، السنة الثلاثون، الجزء الثاني، ص ٢٩٣.

(٦١) تمييز عمالي، طعن ٩٠/٢٢، جلسة ٢٢/٦/١٩٩٢، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية، عقد العمل، قاعدة رقم (٢٦٤)، ص ٢٩٥.

(٦٢) راجع: المطلب الثالث من المبحث الأول في هذا البحث.

يوقف عقد العمل وقفاً مؤقتاً (عقود العمل غير محددة المدة أو عقد العمل محدد المدة الذي لم يحلّ أجل انتهائه خلال فترة الوقف)، ويترتب على الوقف تجنب فسخ العقد، وتكون لدينا - عندئذ - استحالة مؤقتة للتنفيذ. والوقف - كما ذكرنا سابقاً - يرد على الالتزامات الرئيسية دون الثانوية، وهي الالتزامات التي أبرم عقد العمل لتحقيقها؛ أي التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه والتزام رب العمل بدفع الأجر.

وتعرضنا أيضاً - عند الحديث عن نظرية الظروف الطارئة - إلى أن الوفاء ذاته أو القرار الاحترازي الصادر عن السلطة قد يكفي في بعض الحالات على أنه ظرف طارئ، ووفقاً للقواعد العامة لنظرية الظروف الطارئة فإن من آثارها أن للقاضي أن يوقف تنفيذ العقد، إذا كان ظرف الطارئ مؤقتاً، ويزول قريباً^(٦٣).

ولكن وقف العقد في الحالتين - سواء أكانت قوة قاهرة مؤقتة أم ظرفاً طارئاً مؤقتاً - لا مجال - وفق القواعد العامة - أن يطبق على عقد العمل.

ويعدّ قانون العمل من التشريعات التي تسمى أو توصف بالاجتماعية وفيها ينحاز المشرع لطرف دون آخر، بخلاف التشريعات العادية التي يقوم فيها المشرع بمراعاة التوازن بين أطراف العلاقة التي ينظمها التشريع، ويقف المشرع في قانون العمل مع الطرف الضعيف دائماً، ألا وهو العامل الذي لا يملك إلا جهده مقابل الأجر، لذلك نجد أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ قد نص في المادة (٦٢) منه على أنه: "لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب". ونص في مادته (٢/٢٨) على أنه: "سواء أكان عقد العمل محدد المدة أم غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل فترة سريان العقد. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك".

والواضح من النصين المشار إليهما، أنه لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز أيضاً خلال فترة سريان العقد (وحكم النص قاطع الدلالة)، ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي اتفاق خلاف ذلك، سواء أكان الاتفاق سابقاً على سريان العقد أم لاحقاً عليه؛ وهو ما يقطع دابر أي رأي بجواز تخفيض أجر العامل في الظروف الحالية التي يمر بها أرباب العمل بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد.

(٦٣) راجع المطلب الثاني (آثار نظرية الظروف الطارئة)، في المبحث الأول من هذا البحث.

ولو أراد المشرع الكويتي خلاف ذلك لنص عليه صراحة، كما فعل المشرع المصري في قانون العمل رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ في مادته (٤١) والتي نصت على أنه: "إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً.

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره".

وقد نص المشرع البحريني في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢ على الحكم نفسه في مادته رقم (٤٣) التي تقول: "إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعداً لمزاولة عمله في هذه الفترة وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر العامل وحالت بينه وبين أداء عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره" (٦٤).

فالمرعان المصري والبحريني وضعوا استثناء يعطى فيه الحق لصاحب العمل في الحالات التي لا يتمكن فيها العامل من مباشرة عمله لأسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل - أن يقوم بسداد نصف الأجر، ويبنى هذا الحكم قاعدته على مبدأ العدالة وتوزيع المخاطر بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل ورب العمل)؛ ومن ثم لا يتحمل أحد الطرفين العبء كاملاً دون الطرف الآخر، كما أن سداد نصف الأجر في هذه الحالات الاستثنائية يضع حلاً ويقي العامل من حرمانه من كامل أجره خلال تلك الفترة، كما أنه يتجنب قيام أصحاب الأعمال بإنهاء عقود العمل وتسريح العمال؛ بما قد يترتب عليه من أضرار مجتمعية عظيمة يصعب تداركها.

وقد وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته ٢٠٢٠/٥/٤ - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة (٣٩ مكرر) إلى القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي، وكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع (وذلك تمهيداً للموافقة عليه

(٦٤) كما تدخل المشرع السعودي بخصوص تنظيم عقد العمل في ظل ظروف فيروس كورونا، وسمح بتخفيض أجور العمال بنسبة ٤٠٪ لمدة ستة أشهر، منذ بدء الإجراءات الاحترازية. المذكرة التفسيرية للمادة رقم (٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والفقرة (١/٦٣) من المخالفات والعقوبات، وفقاً للقرار الوزاري رقم (١٤٢٩٠٦) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٨/١٣ هـ.

بصيغته النهائية ومن ثم رفعه إلى مجلس الأمة). وصيغة مشروع النص المقترح من قبل الحكومة جاءت على النحو الآتي:

"استثناء من أحكام هذا القانون وفي الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها، إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة توقف النشاط كلياً أو جزئياً، يجوز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطهم بسبب هذه الإجراءات على أي من التالي:

- ١ - منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو من دون أجر، وذلك خلال المدة التي تقدرها الوزارة كفترة تعثر للنشاط، وعلى أن يصرف في هذه الحالة الأخيرة بدل البطالة المقررة للمخاطبين بأحكامه.
 - ٢ - تخفيض أعداد العمال لديهم وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين بالالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال مدة تحددها الوزارة وإلا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل.
- ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام".

فنص المشروع المقدم من الحكومة قد حذا حذو المشرعين المصري والبحريني فيما يتعلق بتخفيض الأجر، واختلفت عنهما في أن التخفيض في الأجرة قد يقل عن النصف ولكنه لا يقل عن الحد الأدنى للأجور^(٦٥)، كما أن المسألة غير متروكة لسلطة صاحب العمل، بل لا بد من أخذ موافقة الوزارة على ذلك، كما أنه ربطها بالكوارث والمحن العامة.

فالمشرع جعل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سلطة الرقابة والموافقة على الإجراء الذي سيتخذه رب العمل أو صاحبه عند الكوارث والمحن العامة.

وقد وزع المشرع المخاطر - بنص المشروع المقدم - بين طرفي العقد (العامل وصاحب العمل)؛ فلا يتحمل أحد الطرفين العبء كاملاً دون الطرف الآخر، وهو بذلك يضع حلاً يجنب العامل قيام صاحب العمل بإنهاء العقد وتسريحه.

ومن وجهة نظرنا، فإننا نرى أن وباء (جائحة) كورونا في ذاته أو القرارات

(٦٥) الحد الأدنى للأجر (٧٥ د. ك) شهرياً، وفقاً للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (١٤) لسنة ٢٠١٧، بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي.

الاحترازية التي صدرت عن السلطة قد تركت أثرها على تنفيذ المدين لالتزاماته، وأياً كان التكيف القانوني لذلك فلا خلاف في أن الوباء - في حد ذاته - أو القرارات المشروعة الاحترازية الصادرة عن السلطة هي السبب في استحالة تنفيذ المدين التزامه أو أن تنفيذ الالتزام بالنسبة له أصبح مرهقاً؛ بمعنى أنه لا يد للعامل أو رب العمل فيه. ومن ثم فالذي يتحمل تبعه ذلك هو الدولة وليس رب العمل أو العامل؛ لأن الوباء أو القرار الصادر عن الدولة يعد سبباً أجنبياً لا يد لأي منهما فيه. والذي يؤيد كلامنا هذا :

- ١ - المادة (٢٥) من الدستور الكويتي التي تنص على أن: "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية".
 - ٢ - إن مسؤولية الدولة لها خصوصيتها في القانون العام، وإذا تجاوز هذا القانون القواعد القانونية العامة، فالأساس هو الخطأ حتى تساءل الدولة، ولكن هناك أسس أخرى (المخاطر، المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة والتضامن الوطني). إن دور القاضي يبقى في جميع الأحوال جوهرياً، لأنه هو من يكيف الخطأ بأنه مرفقي أو شخصي، ويحدد درجة جسامته، وهو من يقبل نظام المسؤولية دون خطأ، ويبدو وأنه بسبب هذه المرونة القضائية تتطور مفاهيم المسؤولية الإدارية^(٦٦).
 - ٣ - إن القضاء الإداري في فرنسا - ممثلاً بمجلس الدولة - قد أقر مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها القوانين، وذلك من خلال حكمه الشهير الصادر في ١٤ يناير ١٩٣٨ في دعوى الشركة المساهمة لإنتاج الحليب (لافلوريت)؛ ففي هذا الحكم، الذي يعد الأول من نوعه، يقرر القاضي الإداري إلزام الدولة تعويض الأشخاص عن الأضرار التي ألحقهم بها القوانين^(٦٧).
- وخلاصة ما تقدم ومن باب التضامن الوطني، وحتى لا تؤثر أزمة وباء كورونا

(٦٦) إبراهيم الحمود، أثر التكيف القانوني لجائحة كوفيد-١٩ على التوازن المالي في عقود الدولة، بحث مقدم للنشر في مجلة الحقوق، جامعة الكويت.

(٦٧) إبراهيم الحمود، الوجيز في القانون الإداري الكويتي، الكتاب الثاني (أعمال السلطة الإدارية ومنازعاتها)، الطبعة الثانية، ٢٠١٩/٢٠٢٠، ص ٤٦٦. حيث وردت قضية (لافلوريت) وتتلخص وقائع القضية في أن شركة لافلوريت تقوم بصناعة منتج أسمته (Gardine) يستعمل بدلاً من الكريمة لبعض المنتجات، ولكنه غير مكون بشكل كامل من الحليب، وقد صدر القانون بتاريخ ٢٩ يونيو ١٩٣٤، وتم بموجبه منع تصنيع وبيع أي منتج للكريمة ما لم يكن مصنوعاً بشكل كامل من الحليب، وعلى أثر ذلك كان لزاماً على شركة لافلوريت =

على الاقتصاد الوطني، نرى تحمل الخزانة العامة لأجر العامل خلال فترة انتشار الوباء ولحين زواله.

وأخيراً ثار خلاف قانوني عن مدى استحقاق العامل الأجر في حالة إغلاق المنشأة من قبل السلطات المعنية بالدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد؛ بسبب انتشار وباء كورونا (وفق توصية منظمة الصحة العالمية)، ونظراً لارتباط الموضوع مع أثر التكييف القانوني لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على عقد العمل، فإننا سنتناوله في المطلب القادم (الثالث) من هذا المبحث.

المطلب الثالث

أثر فيروس كورونا على عقد العمل

إن وباء كورونا - في حد ذاته - أو القرارات التي صدرت عن الحكومة لمواجهة انتشاره مصيرها إلى الزوال، فوباء كورونا المستجد لن يدوم طويلاً وفي وقت ما سوف تتم السيطرة عليه ويتوقف انتشاره ويتحقق التغلب عليه وتنعدم حالات الإصابة (أعلنت الأردن بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٠ ولمدة سبعة أيام عدم وجود حالة إصابة بالفيروس؛ ومن ثم رفعت الإجراءات المتمثلة في الحظر الكلي، وعادت الحياة طبيعية)، كما أنه عند زوال حالة الخطر، فستصدر الدولة تشريعاً يلغي الحظر الجزئي أو الكلي وتعود الحياة لطبيعتها تدريجياً (كما هو الحال في الصين وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول).

وما يهمنا في هذا الأمر من الناحية القانونية هو زوال القوة القاهرة المؤقتة أو الظرف الطارئ، واستعداد العامل للعودة إلى مقر عمله لتنفيذ التزامه الأساسي وهو أداء العمل، وفي المقابل قيام رب العمل بفتح المنشأة (إذا كان هناك إغلاق كامل لها) وإعادة تشغيلها بالكامل، (إن كان هناك غلق جزئي لها)، وأن يعود الحال كما كان عليه قبل أزمة الوباء.

وقد خلصنا في المطلب السابق إلى أنه على الرغم من تكييف أزمة وباء كورونا

= أن تتوقف عن صناعة مادة (Gardine). وكذلك توقفت عن مباشرة جميع أنشطتها؛ مما دفعها للجوء إلى مجلس الدولة بطلب التعويض لتغطية الأضرار التي أصابتها بسبب القانون الصادر في ٢٩ يونيو ١٩٣٤. إن القاضي الإداري قرر بأن من حق الشركة أن تحصل على التعويض مؤسساً ذلك على تعطيل المساواة المقررة للمواطنين أمام التكاليف والأعباء بسبب دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

بقوة القاهرة أو حادث طارئ وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني، فإنه يجب النظر إلى الأثر المترتب على الأزمة وأخذ كل حالة على حدة لتكييفها التكييف القانوني الصحيح من قبل قاضي الموضوع، إلا أنه لا يمكن لرب العمل أن يخفض أجر العامل خلال فترة الوفاء أو القرار الاحترازي بسبب نصوص المواد الموجودة في قانون العمل للقطاع الأهلي، التي تمنع ذلك وتستبعد تطبيق القواعد العامة، وتعد هذه النصوص من النظام العام بوصفها قاعدة آمرة.

ولم يحذ المشرع الكويتي حذو المشرعين المصري والبحريني، اللذين أجازا خفض الأجر لأسباب قهرية لا يد للعامل أو رب العمل فيها.

أما عن استحقاق العامل عن أجره الكامل خلال فترة إغلاق المنشأة من قبل السلطات المعنية بالدولة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد؛ فقد ثار خلاف قانوني بين المهتمين عامة وأهل القانون خاصة، في مدى استحقاق العامل للأجر عن تلك الفترة.

وقد سار المشرع الكويتي في قانون العمل رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع الأهلي، على نهج مجلة الأحكام العدلية فيما نصت عليه المادة (٤٢٥) منها، واستحدث المشرع الكويتي في القانون رقم (٦/٢٠١٠) نصاً لم يكن له نظير في قانون العمل السابق رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ الذي طبقته المحاكم الكويتية بعد الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وقد تمثل ذلك الاستحداث فيما جاء في المادة (٦١) من قانون العمل سالف الذكر التي نصت على أنه: "يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كلياً أو جزئياً لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه".

وقد جاءت هذه المادة بحكم مستحدث ينص على إلزام صاحب العمل بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كلياً أو جزئياً لأي سبب لا دخل للعمال فيه^(٦٨).

والواضح من المادة الذي استحدثها المشرع، أن العامل يستحق أجره كاملاً في حالة إغلاق المنشأة لسبب يرجع لخطأ صاحب العمل أو فعله، كإغلاق المنشأة بحكم قضائي أو قرار إداري ارتكبه صاحب العمل، ما دام العامل مستعداً لأداء عمله.

وأما ما يثار حوله الخلاف فهو الحالة التي يكون فيها إغلاق المنشأة راجعاً لسبب لا يد لرب العمل فيه، مثل الوضع الحالي الذي أصدرت فيه السلطات قرارها بإغلاق

(٦٨) المذكرة الإيضاحية لقانون العمل (التعليق على المادة ٦١).

بعض المنشآت إغلاقاً مؤقتاً، بسبب انتشار الوباء وعدم ذهاب العامل إلى مركز عمله خوفاً من إصابته بالمرض (وهو يرجع في هذه الحالة لسبب أجنبي عن العامل).

وقد اختلف الرأي القانوني في ذلك؛ فذهب بعض الباحثين في القانون^(٦٩) إلى أن ذلك يترتب عليه وقف تنفيذ عقد العمل وعدم استحقاق العمال للأجر في تلك الفترة، ونستطيع إيجاز أسانيد هذا الرأي فيما يأتي:

١ - إن إجراءات الغلق التي اتخذتها سلطات الدولة تعد قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً بحسب الحالة، ومن ثم يكون من شأنها وقف التزام صاحب العمل في أداء الأجر أو التخفيف من حجم ذلك الالتزام بإنقاص الأجر.

٢ - استناداً إلى الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز وقياساً عليها، التي عدت فترة الغزو العراقي حادثاً طارئاً خارجاً عن الإرادة، أدى إلى توقف تنفيذ العقود لفترة مؤقتة.

٣ - لا علاقة لصاحب العمل بغلق المنشأة ولا يستطيع رفع هذا المانع.

٤ - إن العامل لم يحمّل بعمل خلال هذه الفترة.

٥ - إن عبارات المادة (٦١) من قانون العمل غامضة؛ إذ أشارت إلى الغلق بعبارة (أي سبب آخر)، والسبب الآخر يقصد به المشرع - وفقاً لأصحاب الرأي - راجع لفعل رب العمل وليس فعل الغير.

غير أننا نرى استحقاق العامل الأجر كاملاً استناداً إلى نص المادة (٦١) من قانون العمل، بشرط ألا يكون العامل قد امتنع عن أداء العمل، وما دام رب العمل راعياً في استمرار عمله لديه، وذلك وفقاً للأسانيد القانونية الآتية:

١ - إن القواعد القانونية لقانون العمل في القطاع الأهلي قواعد خاصة مقارنة بالقانون المدني، الذي تعد قواعده القانونية عامة إلا فيما لم ينظمه قانون العمل من أحكام، وكما نعلم فإن القانون الخاص لا يلغي القانون العام وإنما يخصصه؛ فهو استثناء وأحكامه واجبة التطبيق في المسائل التي ينظمها، فالتشريعات العام والخاص

(٦٩) من هؤلاء المحامي عمر العمر، بحث مختصر حول الآثار القانونية لوباء فيروس كورونا المستجد على عقود العمل في القطاع الأهلي وعلى التزام رب العمل بأجور العمال، المركز القانوني، الكويت، ٢٧/٣/٢٠٢٠. (بحث أو دراسة قام بها المركز القانوني). وكذلك أنس التورة، أثر جائحة كورونا على قانون العمل، دراسة قانونية، نشرتها جريدة (الجريدة) في ١١/٥/٢٠٢٠.

يعملان معاً كل في نطاقه، والقول بغير ذلك فيه مخالفة صريحة للغرض الذي من أجله صدر القانون الخاص.

٢ - نص المادة (٦١) من قانون العمل في القطاع الأهلي لا يعترىها أي غموض بل جاء واضح الدلالة ولا يحتاج إلى تفسير، المقصود بتعبير (أي سبب آخر) للغلق، أنه السبب الأجنبي الذي لا يد لرب العمل أو العامل فيه.

فلو افترضنا - جديلاً - أن هناك غموضاً والنص يحتاج إلى تفسير، فالمقرر في قواعد التفسير في العقود بشكل عام أن الشك يفسر في مصلحة المدين، فإذا اتصل الشك بالقواعد القانونية المتعلقة بقانون العمل فإنه يؤخذ - عند غموض نصوصه - بما هو أصلح للعامل؛ لأنه هو الطرف الضعيف في العلاقة العمالية، والمشرع عند إصداره لقانون العمل إنما يستهدف حماية العمال.

٣ - الاستناد إلى أحكام محكمة التمييز، التي قضت بشأن وقف نفاذ عقود العمل في أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم، قياساً يفتقر إلى الموضوعية؛ إذ إن هناك فارقاً بين حالة الغزو العراقي وحالة كورونا من حيث المراكز القانونية: أ - إن نص المادة (٦١) من قانون العمل، كما جاء في المذكرة الإيضاحية الخاصة به، هو نص مستحدث لم يكن موجوداً في ظل القانون القديم الساري على علاقات العمل قبل غزو العراق للكويت وبعده^(٧٠).

ب - إن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية كانت معطلة كلياً في فترة الغزو، فلم يكن هناك تشريعات خلال تلك الفترة، وهذا بخلاف الوضع الراهن الذي تمر به دولة الكويت من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ج - إن العامل نفسه في أثناء فترة الغزو العراقي لم يكن مستعداً لأداء العمل؛ ومن ثم لا يمكن القول إنه كان تابعاً خلال تلك الفترة لرب العمل؛ وبناءً على ذلك تكون علاقة العمل قد فقدت أحد أركانها، بعكس الحال في الوضع الراهن المتعلق بانتشار وباء فيروس كورونا.

د - إن تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأثرها، بوقف العقد خلال فترة إغلاق المنشأة، يعتبر من القواعد العامة، التي لا مجال لتطبيقها من قبل القاضي عند وجود نص آخر وهو نص المادة (٦١) من قانون العمل.

(٧٠) انظر: الطعن بالتمييز رقم (١٧ لسنة ١٩٩٩) عمالي جلسة ٢٤/١/٢٠٠٠، الطعن بالتمييز رقم (٢) لسنة ٢٠٠٥، عمالي جلسة ١٢/٦/٢٠٠٦.

وخلاصة رأينا تتمثل في عدم صحة ما ذهب إليه بعضهم من الرأي القائل بعدم استحقاق العامل للأجر؛ إذ إن عدم سداد الأجر للعامل فيه ضرر أعظم من ذلك الضرر الذي سيترتب على صاحب العمل في حال سداد له الأجر للعامل. كما أنه لا يصح القول بإعفاء صاحب العمل من سداد الأجر في حال إغلاق المنشأة في مثل هذه الظروف مع بقاء رغبته في استمرار عمل العامل لديه، إذ إن هذا الإعفاء معناه ترك العامل من دون دخل، وهو ما يخل بحقه في الضمان الاجتماعي الذي كفله له الدستور والقانون.

فبعد انتهاء أزمة الوفاء - إذا رغب رب العمل في استمرار عمل العامل لديه - يجب أن يدفع له أجره عن الفترة التي أغلقت فيها المنشأة، ويدفع الأجر كاملاً دون تخفيض. أما إذا لم يرغب رب العمل في استمرار العمال بالعمل لديه، جاز له إنهاء العقد مع دفع كامل مستحقاتهم من مكافأة نهاية خدمة وبدل إخطار في العقود غير محددة المدة. فإذا كان العقد محدد المدة فإن صاحب العمل ملزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى التعويض عن إنهاء العقد قبل انقضاء مدته على ألا يتجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد.

وأخيراً تحسن الإشارة إلى المقترح المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ في جلسته ٤/٥/٢٠٢٠، وهو مشروع قانون بإضافة مادة جديدة لقانون العمل رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ - أشير إليه سابقاً - ومفاده أنه في الأحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة، إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة توقف النشاط كلياً أو جزئياً، جاز للوزارة الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطهم بسبب هذا الإجراء على واحد من الأمرين الآتيين:

- ١ - خفض الأجر، وهو ما تعرضنا له سابقاً.
- ٢ - تخفيض أعداد العمال لديهم وتسليمهم جميع مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين بالالتحاق بعمل لدى صاحب عمل آخر خلال المدة التي تحددها الوزارة، وإلا كان للوزارة إعادتهم إلى بلادهم على نفقة صاحب العمل^(٧١).

الخاتمة:

إن هذه الدراسة المتعلقة بأثر فيروس كورونا المستجد على أجر العامل وعقد العمل في القطاع الأهلي، تقودنا إلى أن نبين جملة من النتائج التي توصلنا إليها وما خلصنا إليه من توصيات.

(٧١) راجع المطلب الثاني في هذا المبحث، وتعلقنا على مشروع النص المقترح.

أولاً - النتائج :

- ١ - إن الوباء (الجائحة) في ذاته وكذلك القرارات الحكومية التي صدرت كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء، كليهما قد يكتف من الناحية القانونية على أنه قوة قاهرة أو حادث طارئ، بحسب ما يترتب عليه من أثر على التزام المدين في تنفيذ التزامه؛ فإن جعل تنفيذه للالتزام مستحيلاً كنا بصدد قوة قاهرة، أما إذا كان تنفيذه للالتزام مرهقاً ويهدده بخسارة فادحة كنا بصدد ظرف طارئ يطبق عليه نظرية الظروف الطارئة. ويجب على قاضي الموضوع أن يفحص كل حالة على حدة، وذلك لإعطاء التكييف القانوني الصحيح، كما أنه يمكن أن يعد لأحد طرفي العقد قوة قاهرة في حين يعد للآخر ظرفاً طارئاً.
- ٢ - إن الأثر المترتب على التكييف القانوني لفيروس كورونا المستجد بوقف العمل بوصفه سبباً من أسباب الوقف التي يرجع فيها إلى القوة القاهرة، فإن الوباء في حد ذاته أو القرارات الحكومية التي صدرت كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء يكتف في بعض الحالات على أنه قوة قاهرة مؤقتة، تزول عند السيطرة على الوباء ومنع انتشاره أو عند إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة وعودة الحياة إلى طبيعتها؛ ومن ثم يمكن في هذه الحالة أن يوقف (عقد العمل غير محدد المدة أو عقد العمل محدد المدة الذي لم يحل أجل انقضائه خلال فترة الوقف)؛ ويترتب على الوقف تجنب فسخ العقد وتكون لدينا استحالة مؤقتة للتنفيذ، والوقف يرد على الالتزامات الرئيسية دون الثانوية منها، وهي الالتزامات التي أبرم عقد العمل لتحقيقها؛ أي التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه والتزام رب العمل بدفع الأجرة. وقد يرجع كذلك وقف عقد العمل إلى الظرف الطارئ؛ فالوباء في حد ذاته أو القرارات الحكومية التي صدرت كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء يكتف في بعض الحالات على أنه ظرف طارئ ويطبق عليه نظرية الظروف الطارئة، ووفقاً لأثر هذه النظرية فإن للقاضي أن يوقف تنفيذ العقد، إذا كان الظرف طارئاً ويزول قريباً.
- ٣ - إن وقف عقد العمل في الحالتين اللتين تكيّفان على أنهما قوة قاهرة أو حادث طارئ لا مجال لتطبيقه - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - على عقد العمل. والسبب في ذلك أن المشرع الكويتي في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ قد نص صراحة في المادتين (٦١) و (٢٨/٢) منه، على عدم جواز خفض أجر العامل خلال فترة سريانه أو خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق بخلاف ذلك سواء أكان سابقاً على سريان العقد أم لاحقاً عليه.

٤ - إن المشرع الكويتي قد ألزم رب العمل - عند زوال السبب (الوباء أو إلغاء القرارات) - أن يدفع للعامل الأجر كاملاً (وفقاً لنص المادة ٦١) من قانون العمل، بشرط ألا يكون العامل قد امتنع عن أداء عمله، وما دام رب العمل راغباً في استمرار عمله لديه.

فالقواعد القانونية للقانون المدني تعدّ قواعد عامة مقارنة بالقواعد القانونية لقانون العمل في القطاع الأهلي التي تعدّ قواعد خاصة. والقاعدة الخاصة بتقيد القاعدة العامة باتفاق الفقه، ولا يمكن اللجوء إلى القواعد العامة إذا وجد نص خاص ينظم ذلك، فضلاً عن أن النصوص التي نظمت أجر العامل، وعقد العمل (من حيث دفع الأجر كاملاً عند رغبة رب العمل في الاستمرار فيه) نصوص أمرة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفة أحكامها.

٥ - أما إذا رغب رب العمل في الاستمرار في العقد؛ وذلك بعذر زوال الوباء أو إلغاء القرارات الاحترازية، فلا يدفع الأجر عن تلك الفترة (فترة الوقف المؤقت)، وإنما عليه في العقود محددة المدة أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى تعويض العامل عن إنهاء العقد قبل انقضاء مدته على ألا يتجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد. أما في العقود غير محددة المدة فيلزم رب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وبديل الإخطار.

٦ - إن ما ذهب إليه المشرع في بعض قوانين العمل، من أنه في حالة عدم تمكن العامل من أداء عمله لأسباب قهرية لا يد لرب العمل فيها، يجوز لرب العمل أن يدفع نصف أجره خلال فترة الوقف، بحجة أنه يوزع المخاطر بين طرفي العقد (العامل ورب العمل) فلا يتحمل أحد الطرفين العبء كاملاً دون الطرف الآخر، إنما أراد المشرع بذلك أن يضع حلاً يجنب العامل قيام صاحب العمل بإنهاء العقد وتسريحه.

٧ - إننا نرى - من وجهة نظرنا - أن وباء (جائحة) كورونا في ذاته أو القرارات الاحترازية التي صدرت عن الحكومة، هي السبب في استحالة تنفيذ المدين التزامه؛ ومن ثم أصبح بالنسبة إليه مرهقاً؛ بمعنى أنه لا يد للعامل أو رب العمل فيه. ومن ثم فالذي يتحمل تبعه ذلك هو الدولة وليس رب العمل أو العامل؛ لأن الوباء أو القرارات الاحترازية يعد سبباً أجنبياً لا يد لأي منهما فيه.

وسندنا في ذلك نص المادة (٢٥) من الدستور، ومن باب التضامن الوطني، وحتى لا تؤثر أزمة الوباء على الاقتصاد الوطني للدولة، فإن من يتحمل أجر العامل خلال فترة التوقف حتى زوال أسبابه إنما هي الخزنة العامة للدولة.

ثانياً - التوصيات :

- ١ - أن تقوم الحكومة - كما أشارت منظمة العمل الدولية - بتبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على دعم الشركات والمؤسسات الخاصة والمهن الحرة من الناحية المادية وحماية العمال في مكان العمل، واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.
 - ٢ - إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث والمحن العامة؛ وذلك لتعويض العمال وأرباب العمل في مثل هذه الحالات.
 - ٣ - ضرورة تدخل السلطة التشريعية، وسن بعض القوانين الجديدة وتعديل القوانين الحالية، لتواكب المستجدات بناء على ما أظهرته الظروف الحالية من ضرورة القيام بذلك في سبيل معالجة آثار الأزمة وتخفيفها على الدولة وعلى حقوق الأفراد وحمايتهم، وتحمل رب العمل كامل أجور العاملين لديه خلال هذه الأزمة بمفرده، فيه من الضرر ما لا تستسيغه العدالة الاجتماعية. وهذا الضرر لن يصيب رب العمل فقط، بل يمتد أثره إلى العامل، الذي اهتم المشرع بحمايته وحفظ حقوقه، وتحمل رب العمل لسداد أجور العمال خلال فترة إغلاق المنشأة سوف يؤدي حتماً إلى استنزاف موارده وينتهي بعدم قدرته على الاستمرار في دفع أجورهم؛ مما سيضطره إلى إنهاء خدمات بعض العاملين لديه لتخفيف وطأة الاستنزاف أو يؤدي إلى إشهار إفلاسه.
- وهذا خلل اقتصادي جسيم سوف يصيب العاملين في القطاع الخاص وأرباب العمل على حد سواء، وهو بخلاف ما تسعى إليه الدولة من تشجيع العمل في القطاع الخاص وتطويره بوصفه أحد المقومات الرئيسية في نهضة اقتصاد الدولة.

المراجع

أولاً - المراجع باللغة العربية:

- إبراهيم الدسوقي أبو الليل: الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، القسم الأول، رسالة دكتوراه، القاهرة، ١٩٧٥.
- إبراهيم الدسوقي أبو الليل: المسؤولية المدنية والإثراء دون سبب، دراسة للمصادر غير الإرادية للالتزام وفقاً للقانون المدني الكويتي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت ١٩٨٥.
- إبراهيم الدسوقي أبو الليل: العقد والإرادة المنفردة، نظرية الالتزام، مؤسسة دار الكتب، الكويت، ١٩٩٨.
- إبراهيم الحمود: أثر التكييف القانوني لجائحة كوفيد-١٩ على التوازن المالي في عقود الدولة، بحث مقدم للنشر في مجلة الحقوق، جامعة الكويت ٢٠٢٠.
- إبراهيم الحمود: الوجيز في القانون الإداري الكويتي، الكتاب الثاني (أعمال السلطة الإدارية ومنازعاتها)، الطبعة الثانية، ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- أحمد حسن البرعي: الوجيز في قانون العمل، الكتاب الأول، عقد العمل الفردي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٦.
- أنس التورة: أثر جائحة كورونا على قانون العمل، دراسة قانونية، نشرتها جريدة (الجريدة) في ١١/٥/٢٠٢٠.
- جمال فاخر النكاس: قانون العمل الكويتي المقارن، الطبعة الثانية، دار الكتب، الكويت، ٢٠٠٥/٢٠٠٦.
- حسام الدين الأهواني: شرح قانون العمل، طبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، ١٩٩١.
- حمدي عبد الرحمن أحمد: الوسيط في النظرة العامة إلى الالتزامات، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٩.
- خالد جاسم الهندياني: وقف عقد العمل، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الرابعة والعشرون، ديسمبر ٢٠٠٠.
- خالد جاسم الهندياني وعبد الرسول عبد الرضا: شرح أحكام قانون العمل الكويتي المقارن رقم (٦) لسنة ٢٠١٠، الطبعة الثالثة، الكويت، ٢٠١٨.

- عبد الحي حجازي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، القاهرة، طبعة ١٩٦٢.
- عقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ، رسالة دكتوراه، القاهرة، ١٩٥٠، مطبعة جامعة فؤاد الأول.
- عبد الرسول عبد الرضا وجمال فاخر النكاس: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام والإثبات، الطبعة الرابعة، مؤسسة دار الكتب، الكويت، ٢٠١٤/٢٠١٥.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨١.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨١.
- عبد الفتاح عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة، ١٩٨٤.
- وفاء حلمي أبو جميل: وقف عقد العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٠.

ثانياً - المراجع باللغة الفرنسية:

- رادوان (Radovant): الحادث الفجائي والقوة القاهرة، باريس، ١٩٢٠.
- كولان وكابيتان: - الطبعة العاشرة، جزء ٢، ١٩٤٨.
- لابييه: - المجلة الانتقادية، ١٧٨٠.
- مازو: - دروس في القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الأول، النظرية العامة للالتزام، باريس، ١٩٦٦.
- André Brun et Henri Galland: Traité du droit du travail, T.II, Sirey, Paris, 1977.
- Jacques Ghestin: Traité de droit civil, les obligations, L.G.D.J. 1442.
- Josserand(L): Cours de droit civil positif Français, Paris, 1933.
- Nabil Saad: la suspension dans L'exécution du contrat, essai d'une théorie générale, T. II, Thèse Dijon 1981.

COVID 19 and its impact on the work contract in the private sector

Dr. Abdulrahman Alradhwan
Dr. Khalid Jasem Al-hendiany

The State of Kuwait and all countries in the world have recently witnessed the emergence of the new Corona virus as a global health epidemic, and the spread of this pandemic has caused many legal issues. One of these issues is the effect of this virus on the work contract and the worker's wage. This research will explore the answers to several questions such as; Is the worker considered breaching the employment contract when he is absent from work because of the government decisions during the pandemic? Or will he be excused? Is the employer obligated to pay the wage of the worker even if he does not perform his work during this period? and can the employer terminate the work contract by his own decision because the worker failed to perform at work or because of the economics situation that resulted in closing out the company?

All these questions will lead to a major question: Are the legal texts covered under the labor law or the general rules in work contract's article sufficient to solve these legal problems?

مدى قيام المسؤولية الدولية للصين عن تفشي وباء (COVID-19) أمام محكمة العدل الدولية

الدكتورة/ ديمة ناصر الوقيان
قسم القانون الدولي
كلية الحقوق - جامعة الكويت

ملخص:

تسبب انتشار وباء COVID-19 بإعلان حالة الطوارئ في كثير من دول العالم، التي أصدرت العديد من القرارات والإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشاره بين الناس، لكن تبين أن لهذا الوباء سرعة انتشار كبيرة وقد تسبب في انهيار العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، حيث أصدرت الحكومات تعليماتها التي تشمل التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، بما في ذلك الحجر الصحي والعزل وقيود السفر. هذه التدابير، إلى جانب الفيروس نفسه، كان لها تكاليف شخصية وبشرية كبيرة بالفعل، وكان لها أيضاً تأثير أوسع على الاقتصاد العالمي.

نتيجة لكل الخسائر والأضرار التي عانت منها الدول، أصر الكثير منهم على تحميل الصين - منشأ الفيروس - المسؤولية الدولية عن كل ما جرى، مطالبين بالتعويضات عن كل الخسائر الناجمة. وبالنظر إلى مدى قيام مسؤولية الصين عن هذا الوباء، نرى أن الصين تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة كل ما يعيشه العالم بسبب الوباء، فالصين تعاملت مع المجتمع الدولي بعدم وضوح وشفافية، ولم تقم بتزويد منظمة الصحة العالمية بكافة المعلومات والدراسات الضرورية من أجل منع انتشار الوباء منذ بدايته، بل أصرّت على التأكيد بأن الأمور كلها تحت السيطرة، وأن هذا الوباء لا يشكل أي خطورة على العالم، كما أنه يمكن احتواؤه بسهولة. فالصين، بإخفائها للمعلومات وعدم توضيحها للحقائق، قد انتهكت العديد من القواعد الدولية، سواء من ناحية الاتفاقيات الدولية كاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أو دستور منظمة الصحة العالمية الذي يؤكد على ضرورة التزام الدولة بإخطارها بكل المعلومات الدقيقة ذات الصلة بخصوص أي مرض أو عوارض صحية لدى الدولة ممكن أن تؤثر على دول العالم، إضافة إلى انتهاكها لقواعد القانون الدولي العرفي بالتعامل مع الدول والمنظمات الدولية بمبدأ حسن النية.

مقدمة:

تكمن أهمية هذا الموضوع في تحديد المتسبب في الحالة غير المسبوقة التي عاشها العالم الحديث، فقد شهد العالم انتشار وباء COVID-19 والذي أدى إلى كثير من القيود والإجراءات التي تسببت بخسائر فادحة للدول سواء على المستوى

الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، القانوني وحتى في معدل الخسائر البشرية. فلا تزال قصة انتشار هذا الوباء تكتب إلى يومنا الحالي، ولكن من المبكر توقع نتيجة القرارات التي اتخذتها الدولة على اختلافها من أجل القضاء على انتشار هذا الوباء، والتي قد تؤدي إلى تخفيف حدة التفشي الذي نعيشه حالياً.

بحلول تاريخ ٨ مارس ٢٠٢٠، أصيب العالم بما يقارب ١٦٥ ألف حالة مؤكدة من وباء كوفيد-١٩، وأكثر من ٦٥٠٠ وفاة في أكثر من ١٤٦ دولة في أسوأ كارثة صحية وقائية شهدتها العالم الحديث. وقد أعلن الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض يعتبر حالة طارئة ذات أهمية دولية للصحة العامة وذلك في ٣٠ يناير ٢٠٢٠، بناءً على اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام ٢٠٠٥، واعتبرت المنظمة هذا الحدث بأنه "حدث استثنائي" و"خطير" و"غير عادي أو غير متوقع" امتدت آثاره عبر الحدود، وأن هذا الوباء عابر للقارات، وأن المطلوب هو اتخاذ إجراءات دولية فورية شديدة وحاسمة لمواجهته^(١).

وفي ١١ مارس ٢٠٢٠، أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار وباء COVID-19 "جائحة"^(٢). واتخذت عدة دول تدابير قوية في محاولة لاحتواء انتشار المرض والتخفيف من حدته، وأعلنت دول عديدة حالات الطوارئ وفقاً لقوانينها المحلية. في يوم الاثنين ٩ مارس ٢٠٢٠، أعلنت إيطاليا تطبيق حظر كامل لكل الأقاليم الشمالية بداية ثم تدرجت إلى أن شملت كل أقاليم البلاد، وهي تعتبر أول دولة تفرض إغلاقاً على مستوى الدولة لإبطاء أسوأ تفشي لمرض COVID-19 في أوروبا^(٣). أما قبل ذلك، فقد فرضت الصين تدابير أشد شملت كل البلاد، واتخذت إجراءات احترازية

(١) ICC-WHO Joint Statement: An Unprecedented Private Sector Call To Action To Tackle COVID-19, Press Statement (March 16, 2020) available at: <https://www.who.int/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-statement-an-unprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-19>.

(٢) WHO Director-General's Opening Remarks At the Media Briefing on COVID-19-11 March 2020, Secretary-General Statement (March 11, 2020). The Statement Stated: "We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic." Available at: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

(٣) Angelo Amante & Crispian Balmer, Italy in Coronavirus Lockdown as Deaths Soar and Economy Fades, Reuters (March 10, 2020) available at: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/streets-deserted-as-italy-imposes-unprecedented-coronavirus-lockdown-idUSKBN20X11D>.

وتدابير قاسية لمنع انتشار المرض، ومثل ذلك، اتخذت تدابير مماثلة في العديد من الدول الأخرى، حيث يواصل الفيروس انتشاره بشكل سريع.

تشمل التدابير في الغالب التباعد الاجتماعي، بما في ذلك الحجر الصحي والعزل وقيود السفر. هذه التدابير، إلى جانب الفيروس نفسه، كان لها تكاليف شخصية وبشرية كبيرة بالفعل. وكان لها أيضاً تأثير أوسع على الاقتصاد العالمي، وعلى عمليات التوريد والعلاقات التجارية الأخرى، إضافة إلى تأثيرها الكبير على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين الدول. وللتخفيف من تأثير هذه التدابير على الشركات، أصدرت الصين، على سبيل المثال، شهادات قوة قاهرة وفقاً لقانونها الداخلي لعدد قياسي من المصدرين المحليين لإعفائهم من تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية مع المشتريين الأجانب، وتدرس فرنسا والهند تدابير مماثلة لحماية أعمالهما من تأثير الفيروس وتدابير التصدي له^(٤).

فمن المهم الوقوف على قواعد المسؤولية الدولية للقول بتحققها في الموضوع محل الدراسة، فقد ناقشت المسؤولية الدولية عدة نظريات كالقول بوجود الخطأ أو العمل غير المشروع، بالإضافة إلى تحقق المسؤولية المشددة والتي قد تقوم بها، مما يتسبب معه بالأضرار في القانون الدولي، وبالتالي مدى إمكانية الرجوع على الدولة المسببة للضرر بالتعويض. حيث جعلنا كل هذه التأثيرات على المجتمع الدولي نتساءل عن مسؤولية الصين؛ كونها الدولة التي نشأ فيها الفيروس وانتشر منها، في كل هذه الأحداث والأضرار الناتجة من هذا الوباء، خاصة أن تأثيره قد طال كل دول العالم ومن جميع جوانب الحياة كما ذكرنا، فهل تعتبر الصين مسؤولة قانونياً ودولياً عن تفشي هذا الوباء؟ وهل بالإمكان الرجوع على الصين بالمقاضاة للتعويض؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن مطالبتها بالتعويض عن كل الأضرار والخسائر التي لحقت بدول العالم؟ إن الوقوف على هذه الإجابات يتطلب تحليل موضوع المسؤولية في القانون الدولي ومدى انطباقها على الصين في الوقت الحالي، إضافة إلى مدى اختصاص القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولية في محاكمة الصين في حال ثبوت مسؤوليتها، وذلك في المبحثين التاليين، حيث يناقش المبحث الأول قيام المسؤولية الدولية بسبب تفشي وباء COVID-19 في العالم ومدى قيام مسؤولية الصين في هذه الحالة، ويناقش المبحث الثاني إمكانية محاكمة الصين أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتشار الوباء.

(٤) Federica Paddeu & Freya Jephcott, COVID-19 and Defences in the Law of State Responsibility, 1 European J. Int'l L. (March 17, 2020).

المبحث الأول

مدى قيام مسؤولية الصين الدولية بسبب تفشي وباء COVID-19

إن تقييم الكارثة الصحية الدولية المتعلقة بتفشي الوباء يكون على أساس الإجابة عن عدة تساؤلات، فهل انتشار مثل هذا العارض الصحي له أثر وخيم على صحة الناس في العالم؟ وهل يعتبر حدثاً غير مألوف وغير متوقع؟ وهل هناك مخاطر كثيرة سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيره قد تتحقق على الصعيد الدولي؟ وأخيراً، هل من الممكن أن يمتد تأثير هذا العارض الصحي لدرجة فرض قيود على السفر الدولي أو التجارة الدولية؟ فإذا كانت الإجابات عن الأسئلة السابقة بنعم - وهي كذلك في الواقع الحالي- فإن الدولة المسؤولة والتي قد تكون الصين هنا، قد خالفت قواعد الصحة العالمية بشأن الإخطار اللازم في "الوقت المناسب" حتى يتسنى للمنظمة اتخاذ التدابير الدولية اللازمة للحد من انتشار هذا المرض والمتابعة السريعة والدقيقة مع دول العالم للحد من انتشاره وآثاره التي من الممكن أن توصف اليوم بالدمرة للمجتمع الدولي من جميع نواحي الحياة.

المطلب الأول

تحديد قيام المسؤولية لوجود ضرر على المجتمع الدولي

قد تتحقق المسؤولية الدولية للدول نتيجة عدم التزامها بالقواعد الدولية مما يترتب عليها آثاراً وأضراراً قد تمتد لدولة أو دول أخرى، فمسؤولية الدولة قد تتحقق نتيجة الإهمال، التقصير أو الأفعال العمدية والتي قد تؤدي إلى حدوث ووقوع أضرار. والسؤال المطروح هنا هو هل يشترط قيام الدولة بفعل "خطأ" حتى تتحقق المسؤولية الدولية؟ أم هل تقوم المسؤولية الدولية بمجرد مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الدولية حتى وإن لم يترتب عليه ضرر؟ فالسؤال الأهم هو: هل تبني المسؤولية الدولية على فكرة "الخطأ" أو "الضرر"؟

بداية وقبل الإجابة عن الأسئلة السابقة، من المهم الوقوف على معنى المسؤولية الدولية. ويمكن القول بأن المسؤولية تقوم عند "خرق التزام دولي من قبل دولة ما يوجب مساءلتها من الناحية القانونية تجاه الدولة المعتدى عليها أو المتضررة من العدوان". وللمسؤولية الدولية معطيات تتمثل بما يلي:

- تقع هذه المسؤولية على عاتق دولة، وهي وحدها ملزمة بإصلاح الضرر الذي سببه تصرفها غير المشروع، ولا يمنع أن تترتب المسؤولية على منظمة دولية إذا ثبت خطأها أو تسببها بضرر ما.

- المسؤولية الدولية لا تتقرر إلا لمصلحة دولة استناداً إلى مبدأ مراقبتها لحسن تطبيق القانون الدولي ومواجهة كل تقصير قد يوقعه تطبيق القانون حيالها.
- تقوم الدولة المتضررة من فعل مخالف لهذا القانون بإعمال قواعد المسؤولية الدولية^(٥).

أولاً - الخطأ أو الإهمال:

يرى جانب من فقهاء القانون الدولي^(٦) بوجود تحقق "الخطأ أو الإهمال" للقول بقيام المسؤولية الدولية، وقد بنيت نظرية الخطأ من قواعد العرف الدولي، فقد يتحقق الخطأ نتيجة ارتكاب الدولة أو أحد مسؤوليها أو رعاياها فعلاً كانت نتيجته وقوع ضرر ما، ولا يشترط أن يكون ارتكاب الخطأ مقترناً بسوء نية، إنما قد يكون بسبب الإهمال أو عدم مراعاة أمر ما بما يحقق ذات النتيجة. وإن كان ارتكاب الخطأ يتلاءم مع المسؤولية في القانون الداخلي، إلا أنه لا يحمل معايير واضحة في القانون الدولي، فحاجات ومصالح القانون الدولي متجددة بشكل دائم نتيجة الظروف والأحداث المتغيرة، مما قد يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تُعرف بالخطأ دون أن تكون كذلك سابقاً.

وتسعى نظرية الخطأ إلى تحديد قيام المسؤولية الدولية بها فقط، بمعنى آخر، إذا لم ترتكب الدولة خطأً أو إهمالاً يؤدي إلى ضرر، فإن المسؤولية الدولية تنتفي في هذه الحالة، ولا يكون للدولة أي التزام أمام المجتمع الدولي، وهذا الخطأ قد يتم ارتكابه بشكل إيجابي أي القيام بفعل أدى إلى ضرر، أو قد يكون بشكل سلبي، وذلك بالامتناع عن القيام بفعل مما أدى لوقوع ضرر. مثال على ذلك، القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية المعروفة باسم قضية سدود (Gabčíkovo - Nagymaros) لعام ١٩٨٩ بين المجر وتشيكوسلوفاكيا^(٧)، وهو مشروع سدود كبير على نهر الدانوب، قد بدأت

(٥) انظر: د. محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، معهد الدراسات العربية، القاهرة- مصر (١٩٦٢).

(٦) د. محسن الشيشكلي، مذكرات في القانون الدولي العام، جامعة الكويت، (١٩٨٤) ص ٦٠٠-٦٠٢، أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر (٢٠٠٩) ص ٧٣، رشاد عارف السيد، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائيلية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، (١٩٨٤) ص ٤٣-٤٤، سعيد محمد باناجه، دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي وقت السلم وقانون المنظمات الدولية الإقليمية، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان (١٩٨٥) ص ١٠١-١٠٢.

(٧) Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), 1997 I.C.J. 7 (Sept. 25) p. 7, 63.

بموجب معاهدة بودابست في ١٦ سبتمبر ١٩٧٧ بين جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية وجمهورية المجر الشعبية. يهدف المشروع إلى منع الفيضانات الكارثية، وتحسين القدرة على الملاحة النهرية وإنتاج الكهرباء النظيفة. ولكن المجر قامت بتعليق المشروع بقولها إنها ارتكبت خطأً بسبب مخاوف بيئية واقتصادية على الدولة، فما كان من تشيكوسلوفاكيا إلا أن أحالت الموضوع إلى محكمة العدل الدولية بسبب مسؤولية المجر في خطئها بالتعاقد.

كما أكد حكم التحكيم الدولي برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز كويلار، المعروف بقضية تحكيم (Rainbow Warrior) المرفوعة في العام ١٩٨٥ من نيوزيلاندا على فرنسا والتي اتهمتها فيها بإغراق السفينة النيوزلندية Rainbow Warrior في ميناء أوكلاند، في حين دافعت فرنسا بأن فعل إغراق السفينة قد تم بالخطأ دون تعمد الإضرار بها^(٨). وقد أكد حكم التحكيم على اعتبار الخطأ سبباً لقيام مسؤولية الدولة، وأن فرنسا قد أثبتت خطأها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع نيوزلندا، وبالتالي تعتبر فرنسا ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن فعل الخطأ بما يقارب ٢ مليون دولار. وتعتبر هذه القضية سابقة مهمة في تحديد المسؤولية الدولية، وبغض النظر أنه يتألف جزئياً من التحكيم والوساطة، إلا أنه أرسى قواعد هامة في القانون الدولي.

وقد وجهت انتقادات شديدة لنظرية الخطأ لكون الدولة شخصاً اعتبارياً لا يمكن معاقبته جنائياً كما هو الحال في القانون الداخلي، وأن الأشخاص الطبيعيين التابعين للدولة ممن ارتكبوا الخطأ باسمها ولها، يمكن أن يخضعوا للعقاب كما هو الوضع في القانون الجنائي الدولي، ذلك أنه في حال قيام المسؤولية فإن العقاب الوحيد الذي يمكن أن يطبق على الدولة المسؤولة هو إلزامها بالتعويضات عن الأضرار الناتجة، وهو ما قد يعطي نوعاً من عدم الالتزام من الدول نتيجة عدم وجود عقوبات صارمة وراعية^(٩). ولكن لا تزال لهذه النظرية أهمية كبيرة في القانون الدولي خاصة إذا ما كان الالتزام ببذل عناية - كما هو الحال لو ثبت تقصير الصين بنشر المعلومات الخاصة بالوباء لدول العالم - فلا بد هنا من إثبات التقصير في القيام بعمل أدى إلى وقوع الخطأ.

(٨) Rainbow Warrior Case (New Zealand v. France) (1990) 82 I.L.R. 500. In July 1985. Available at: https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/215-284.pdf

(٩) د. رشيد العنزي، القانون الدولي العام ودراسة خاصة عن موقف القانون الدولي من الاحتلال العراقي لدولة الكويت، الطبعة الخامسة، (٢٠١٨) ص ٥٣٩.

ثانياً - العمل غير المشروع:

ويرى جانب آخر من الفقهاء^(١٠) الاستناد إلى "العمل غير المشروع" للقول بقيام المسؤولية الدولية، فلا يشترط لهذا العمل القيام بخطأ، إنما يكفي أن ينسب للدولة عمل مخالف للقواعد والقانون الدولي والأعراف الدولية، إضافة إلى التزامها القانوني مع الدول والمنظمات الدولية، فهذه النظرية تعرف أيضاً بنظرية الضمان والتي تعني وفاء الدولة بمتطلباتها والتزاماتها أمام النظام والمجتمع الدولي، فعندما يستبعد الخطأ فإن الأساس المقبول لقيام المسؤولية الدولية هو مخالفة إحدى قواعد القانون الدولي، بل وقد يعتبر الشرط الأهم لقيامها. بمعنى أن الفعل غير المشروع يراد به كل مخالفة للالتزام دولي ترتبه قاعدة من قواعد القانون الدولي كمخالفة معاهدة أو التزام في اتفاقية ما، سبق للدولة أن تقيدت بها، فإنها تتحمل تبعة هذا الإخلال وتلتزم بتعويض الدولة المتضررة جراء عملها غير المشروع.

وأكد مشروع لجنة القانون الدولي أن منشأ الالتزام الذي انتهكته الدولة لا يؤثر على المسؤولية الدولية إلا إذا تم ارتكاب عمل غير مشروع، كما أنه لا يتأثر بالقانون الداخلي أو بالأشخاص الطبيعيين التابعين للدولة مهما كانت لهم صلاحية إصدار أوامر ارتكاب العمل غير المشروع، فصدور هذا الفعل من الدولة بمخالفة القانون الدولي يكفي معه قيام مسؤوليتها. وفي هذا الصدد، نص مشروع لجنة القانون الدولي على أن: "وصف فعل الدولة على أنه غير مشروع دولياً أمر يحكمه القانون الدولي، ولا يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفاً بأنه مشروع في القانون الداخلي"^(١١).

وهذا الرأي كانت قد أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة، وذلك في قضية مصنع (Chorzow Case) في العام ١٩٢٧، المتعلق بضم إقليم (Chorzow) من ألمانيا إلى بولندا مع ارتفاع قيمة مصنع النيتروجين فيها، مما أدى إلى هجرة الناس بين الإقليمين

(١٠) د. رشيد العنزي، المرجع السابق، ص ٥٤٠، أبو الخير أحمد عمر، القانون الدولي العام، أكاديمية دبي للنشر، دبي - الإمارات العربية المتحدة (١٩٩٤) ص ٥٣٨، شارل روسو، القانون الدولي العام، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت - لبنان (١٩٨٢) ص ٣١، صلاح شلبي، الوجيز الميسر في القانون الدولي، جامعة الأزهر، القاهرة - مصر (٢٠١٥) ص ١١٦.

(١١) مشروع لجنة القانون الدولي، المادة (٣) من مشروع قانون مسؤولية الدول. حيث أقرت لجنة القانون الدولي مشروع المواد القانونية المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة في العام (٢٠٠١)، والتي أقرتها الجمعية العامة في (ديسمبر ٢٠٠١).

Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two). Text reproduced as it appears in the annex to General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001, and corrected by document A/56/49(Vol. I)/Corr.4.

وسببت خسائر فادحة لألمانيا، حيث نصت على أنه: "من مبادئ القانون الدولي، بل ومن المبادئ العامة للقانون أن مخالفة الدولة لالتزام دولي يستتبع الالتزام بالتعويض عن ذلك بطريقة كافية، وأن الالتزام بالتعويض هو النتيجة الحتمية لأي إخلال بتطبيق أي اتفاقية دولية، دون الحاجة للنص على ذلك بطريقة صريحة في الاتفاقية" (١٢).

وفي قضية الفوسفات في المغرب لعام ١٩٣٨، كانت القضية تتعلق ببعض الحقوق المزعومة لمواطنين إيطاليين لاستكشاف بعض رواسب الفوسفات في محمية المغرب الفرنسية آنذاك (المحميات والدول المحمية)، والتي على أساسها طالبت إيطاليا بالتعويض نتيجة نقض فرنسا لبعض الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين للتفتيح عن الفوسفات وإخلالها بالتزامها الدولي مع إيطاليا، فقد نصت محكمة العدل الدولية الدائمة على أنه: "عندما ترتكب دولة ما فعلاً غير مشروع دولياً ضد دولة أخرى، فإن المسؤولية الدولية تنشأ فوراً بين الدولتين" (١٣). وهو ما أخذت به أيضاً محكمة العدل الدولية في قضية كورفو لعام ١٩٤٦، والتي تعرضت فيها سفن الملكية البريطانية لهجوم ناري من الحصون الألبانية ثم ضربها بالألغام البحرية، وعلى إثر ذلك رفعت المملكة المتحدة دعوى ضد ألبانيا مطالبة بالتعويض وهو ما حكمت به المحكمة، حيث دفعت ألبانيا تعويضات تقارب ٩٠٠ ألف جنيه إسترليني، حيث أقرت المحكمة "مسؤولية ألبانيا عن التفجيرات التي وقعت، وأن الامتناع تنطوي على مسؤوليتها الدولية، وثمة واجب يقع على عاتق ألبانيا يقتضي منها دفع تعويض للمملكة المتحدة" (١٤).

ويؤخذ على هذه النظرية، أنه ومع تطور قواعد القانون الدولي، لم تعد بعض الأعمال واضحة الإطار إذا ما كانت تعتبر مشروعة من عدمه، فقيام المسؤولية هنا لم يعد قاصراً على ارتكاب عمل غير مشروع أو امتناع عن ارتكابه، إنما تحقيقها للنتيجة المتعلقة بإحداث ضرر لأحد أشخاص القانون الدولي، وهو ما يمكن القياس عليه اليوم لو ثبت امتناع الصين عن القيام بالتزاماتها الدولية الواردة في ميثاق منظمة الصحة العالمية.

(١٢) Factory at Chorzow (Germany. v. Poland), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 9 (July 26), para 127 stated: "The Tribunal shall decide all disputes on the basis of the provisions of this Convention, and on the general principles of law, and of equity. "It shall be competent to decide the amount, if any, of compensation to be made to the injured Party by the Party found guilty of any infraction of the provisions of this Convention".

(١٣) Phosphates in Morocco (Italy v. France), 1938 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 74 (June 14).

(١٤) Corfu Channel, (U.K. v. Albania), 1948 I.C.J. 15 (Mar. 25).

ثالثاً - المسؤولية المشددة:

ومن جهة أخرى، يرى جانب من فقهاء القانون الدولي^(١٥) تبني نظرية أخرى تعد حديثة نسبياً في القول بقيام مسؤولية الدولة وهي حالة "المسؤولية المشددة"، والتي تبني على تحقق الضرر فقط بغض النظر عن وجود خطأ أو عمل غير مشروع، فالمسؤولية هنا تقوم حتى لو قامت الدولة بفعل مشروع أو غير محظور في القانون الدولي، ولكن أدى فعلها إلى حدوث ضرر لأحد أشخاص القانون الدولي.

إن فكرة المسؤولية المشددة جاءت نتيجة الأعمال الخطرة -التي وإن كانت مشروعة- فإن تأثيرها الضار كبير سواء على الدولة أو الأفراد. فمع وجود التطور الصناعي الحديث، فإن بعض الأعمال قد تشكل خطورة كوجود المصانع التي تنتج الأبخرة أو تؤدي لتلوث البيئة، كذلك ما قد تحدثه هذه المصانع أو الأعمال من أمراض أو أوبئة قد تكون نتائجها كارثية على الناس وصحتهم، فالدولة هنا لا يمكنها التمسك بسيادتها على أراضيها وقيامها بهذه الأعمال على إقليمها إذا كان ضررها قد امتد لدول أخرى وأحدث فيها آثاراً سلبية، فتقوم مسؤولية الدولة هنا بناء على ظرف المسؤولية المشددة^(١٦). فعدد قليل من المعاهدات الدولية تجعل الدول مسؤولة بشكل صارم عن أي ضرر يحدث في إقليم دولة أخرى نتيجة لأنشطة محددة، حتى لو امتثلت الدولة خلاف ذلك لالتزاماتها القانونية، فلا تركز الغالبية العظمى من المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف على الضرر الذي يلحق الدولة المضروعة، إنما على تصرف الدولة القائمة بالعمل، وفرض التزامها بالتعويض والجبر كنتيجة.

ومن أبرز القضايا المتعلقة بهذا الأمر قضية تحكيم (Trail Smelter Case) في عام ١٩٤١ والتي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فهي قضية تلوث عابرة للحدود تشمل الحكومات الفيدرالية لكل من كندا والولايات المتحدة، وقد ساهمت في النهاية بشكل كبير في إرساء مبدأ الضرر في القانون الدولي البيئي للتلوث عبر الحدود حتى ولو كانت الدولة تمارس أنشطتها في إقليمها، فالرصاص المعالج في المصانع في

(١٥) د. رشيد العنزي، مرجع سابق، ص ٥٤٢، محمد الدقاق ومصطفى سلامة، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية- مصر (١٩٩٧) ص ٣٠٢، د. محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية - مصر (١٩٨٢) ص ٤٥٠.

(١٦) John Kelson, State Responsibility and the Abnormally Dangerous Activity, 13 Harv. Int'l. L. J. 197 (1972). Also see; Responsibility and Liability Under International Law for Environmental Damage, JUSTITIA ET PACE- INSTI-TUT DE DROIT INTERNATIONAL, Art. 4, At 3 (1997).

كندا والتي تقع قرب حدود الولايات المتحدة، أدى الدخان الناتج عن المصهر فيها إلى إتلاف الغابات والمحاصيل في المناطق المحيطة للمنطقة وكذلك عبر الحدود الكندية الأمريكية في واشنطن، مما أدى إلى شكاوى السكان وأضرار بالصحة العامة، وبالتالي طلب التعويض^(١٧). وقد قامت كندا بتعويض السكان عن الأضرار استناداً إلى أنه يقع على عاتق الدولة واجب حماية الدول الأخرى من الأفعال الضارة من قبل الأفراد من داخل ولايتها القضائية في جميع الأوقات. فمن خلال النظر في الحقائق الواردة في هذه القضية، اعتبر التحكيم أن كندا مسؤولة وفق قواعد القانون الدولي عن سلوك شركة (Trail Smelter) وبالتالي يقع العبء على عاتق الحكومة الكندية للتأكد من أن سلوك (Trail Smelter) يجب أن يتوافق مع التزامات كندا الدولية كما أكدها القانون الدولي.

وتُنظم المسؤولية المشددة في النصوص المتعلقة بالأنشطة التي تعتبر جديدة أو خطيرة بشكل خاص، مثل استكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله، والتي تقوم بها عادةً الجهات الحكومية في الدولة. وتنص معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، على مسؤولية الدولة مسؤولية مشددة عن تعويض الأضرار التي قد تسببها أجسام المركبات الفضائية على سطح الأرض أو الطائرات الخاصة بها^(١٨).

ويمتد نطاق المسؤولية المشددة ليشمل جميع الأنشطة الحكومية وغير الحكومية المتعلقة بالأمراض والأوبئة والصحة الوقائية والتي تنص عليها المعاهدات والمنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية. ويتعين على كل دولة أن تطلب من موظفيها اتخاذ تدابير وقائية معقولة، ووضع خطط طوارئ للاستجابة للحوادث التي قد تكون لها آثار صحية سلبية محتملة على العالم، واتخاذ إجراءات استجابة سريعة وفعالة عندما تنجم حالة الطوارئ عن وجود كارثة صحية^(١٩). فالملاحظ هنا أن الدولة لا تملك أي سيطرة على ظهور أو تفشي وباء ما، بالتالي قد تفشل في اتخاذ إجراءات استجابة سريعة وفعالة لمنع حدوث كارثة عالمية، فتكون مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن ذلك، خاصة إذا كانت الدولة تمتلك معلومات بخطورة وسرعة انتشار المرض.

(١٧) Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada) Arbitral Trib., 3 U.N. Rep. Int'l Arb. Awards 1905 (1941).

(١٨) معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، (١٩٦٧) المادة ٢.

(١٩) See; Tullio Scovazzi, State Responsibility for Environmental Harm, 12 YB Int'l Env'tl. L. 43 (2001) & J.G. Lammers, International Responsibility and Liability for Damage Caused by Environmental Interferences, 31 Env'tl. Pol'y & L. 42 (2001).

- فالمسؤولية المشددة تتحقق في حالة الطوارئ بسبب:
- فعل أو إغفال ضروري لحماية حياة الإنسان أو سلامته، وذلك يشمل كل ما من شأنه أن يؤدي حياته وصحته ونفسيته، وما من شأنه أن يؤدي إلى موت أو هلاك الإنسان.
 - كارثة طبيعية استثنائية لم يكن من الممكن توقعها بشكل معقول، شريطة اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة من أجل منع انتشار هذه الكارثة عالمياً.
 - عمل إرهابي أو فعل عدائي ضد دول أخرى، فيتم الحفاظ على الحصانة السيادية للسفن الحربية، والطائرات، وكل ما من شأنه أن يهدد سلم وأمن دول أخرى^(٢٠).
- على الرغم من أن الأسباب السابقة تشير إلى المسؤولية المشددة، إلا أنها أيضاً تشير إلى مسؤولية الدولة المتعلقة بفعل أو الامتناع عنه، لأنها تركز على عدم امتثال الدولة لالتزاماتها القانونية في اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الضرر من الجهات الفاعلة من غير الدول داخل ولايتها القضائية، وكثيراً ما يكون هذا الإغفال أساس المطالبات ضد الدول بالتعويض والجبر بموجب قاعدة مسؤولية الدولة.

المطلب الثاني

مدى ثبوت مسؤولية الصين عن تفشي جائحة COVID-19 عالمياً

تحتل الصين حالياً المرتبة السابعة عالمياً، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت ٨٢,٧١٩ حالة إصابة، وتماثل للشفاء ٧٧,٠٢٩، في حين وصل عدد الوفيات فيها إلى ٤,٦٣٢^(٢١) فخلال الأسابيع الماضية ومع تفشي الجائحة في كل أنحاء العالم، انهارت اقتصادات دول صناعية كبرى كألمانيا، بريطانيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم، فقد سجل برميل النفط الأمريكي أسوأ وأدنى سعر في تاريخه، حيث بلغ دولاراً واحداً فقط للبرميل^(٢٢) في أقوى

(٢٠) Dinah Shelton & Alex Kiss, Strict Liability in International Environmental Law, 1137 (2007).

(٢١) Russell Miller & William Starshak, China's Responsibility for the Global Pandemic, Just Security (March 31, 2020).

(٢٢) Ryan Dezember, U.S. Oil Costs Less Than Zero After a Sharp Monday Selloff, Wall St. J. (April 21, 2020). Available at: <https://www.wsj.com/articles/why-oil-is-11-a-barrel-now-but-three-times-that-in-autumn-11587392745>.

ضربة لصناعة النفط في الولايات المتحدة، وهذا جزء من آثار الموجة الاقتصادية السيئة التي ضربت العالم نتيجة تفشي هذا الفيروس.

ولا نرى أنه من المبكر مناقشة مسؤولية الصين عن حدوث كل هذه الخسائر والأضرار سواء البشرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى على مستوى قانون حقوق الإنسان وكل القيود المفروضة على الناس كتدابير احترازية ووقائية لمكافحة انتشار هذا الوباء. ولكن حتى تثير الدول مسؤولية الصين الدولية، هل يمكن لها أن تعتمد على أحد أسس المسؤولية الدولية إذا فشلت الصين في أداء الالتزامات المستحقة عليها بموجب القانون الدولي لأطراف أخرى نتيجة لجهودها للتصدي لوباء COVID-19؟ فمن بين أسس المسؤولية التي سبق مناقشتها والمعترف بها في مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، فهل يمكن تطبيقها على الصين؟ وهل يمكن للصين في حال إثبات مسؤوليتها أن تتمسك بنظرية القوة القاهرة؟ ذلك أن التماسات القوة القاهرة وحالة الضرورة والكوارث يمكن اعتبارها مسؤولية محتملة عن أي أضرار، حيث قد توجد الصعوبة في إثبات وجود "استحالة مادية" لأداء الالتزام، بالتالي هل يمكن للصين أن تعتمد على نظرية القوة القاهرة المتعلقة بظروف انتشار الوباء، وكون هذا الأمر خارجاً عن السيطرة للتخلص من قيام مسؤوليتها الدولية؟

الفرع الأول

ثبوت مسؤولية الصين الدولية عن الأضرار الناتجة عن هذا الوباء

يمكن للدول الاعتماد على الإهمال في القول بقيام مسؤولية الصين عن انتشار هذا المرض عالمياً، فتشير العديد من الأدلة إلى إخفاء الصين المعلومات والصورة الكاملة عن مدى خطورة هذا المرض وسرعة انتشاره، مما لم يؤد إلى تحذير الدول قبلها بوقت كافٍ من أجل أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية من أجل الحيلولة دون انتشاره بالطريقة التي تم بها، فالدول تحمل الصين كافة الأضرار التي لحقت باقتصاداتها وسياساتها الدولية بالإضافة إلى الخسائر المادية والبشرية - الوفيات - التي كان من الممكن تلافيها لو كانت الصين قد تعاملت بشفافية مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي.

وأكد كثير من فقهاء القانون الدولي على تحمل الصين للمسؤولية الدولية الناتجة عن تفشي وباء كورونا أو ما يعرف عالمياً بوباء COVID-19، ذلك أن الصين قد

خالفت صراحة اللوائح الصحية الدولية^(٢٣) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة الإخطار المسبق لمنظمة الصحة العالمية عن أي مرض صحي من شأنه أن يشكل طارئة صحية قد تثير قلقاً دولياً، إضافة إلى موافاة المنظمة "بالوقت المناسب" بكافة المعلومات الدقيقة التي من شأنها أن تمنع حدوث كارثة صحية دولية على مستوى العالم، كما حدث ما نراه اليوم^(٢٤). كما أن الصين لم تلتزم بتقديم تقارير إحصائية ووبائية دورية للمنظمة عن حالة كل مرض وتكوينه وانتشاره وعلاجه، فهي مسؤولة أمام المنظمة عن كل تحديث يخص الحالة الصحية للمرض، إضافة إلى إرسالها للمعلومات بشكل دوري مع البيانات الدراسية العلمية المتعلقة بالحالة موضع النقاش^(٢٥). وبما أن الصين أخفقت في القيام بهذا الدور بشفافية، فإنها تتحمل مسؤولية تأخر المنظمة عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الوقت المناسب، بالتالي تحقق الأضرار الناتجة؛ ذلك أن العديد من حكومات العالم لم تكن مستعدة لحجم الخطر.

ويمكن أن يبنى إخلال الصين بهاتين المادتين بنظريتي الخطأ والفعل غير

(٢٣) اللوائح الصحية الدولية: هي اتفاق ملزم قانوناً بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ودول أخرى وافقت على الالتزام بها (الدول الأطراف). وتحدد اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) "غرضها ونطاقها" على النحو التالي: "الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية ويقتصر عليها، مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية."

(٢٤) اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، (٢٠٠٥). وتنص المادة (٦) على: "١- تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق ٢. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية... بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً وفقاً للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات... ٣- تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة بالوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية، وذلك بالقدر الكافي لها قدر الإمكان... وتبلغ عن الصعوبات التي تواجهها، والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً". كما وتنص المادة (٧) على: "إن وجدت دولة طرف حدثاً غير متوقع أو غير عادي على أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، فعليها أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة...".

(٢٥) انظر المادتين (٦٤) و(٦٥) من دستور منظمة الصحة العالمية.

المشروع، فيمكن الاستناد إلى نظرية الخطأ والإهمال للقول بأن الصين لم تسارع إلى إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن انتشار هذا المرض استناداً إلى إهمالها بالقيام بالتزاماتها الدولية، والتي تبرره الصين بأنها كانت منشغلة داخلياً بمنع انتشار الفيروس مما منعها من إبلاغ المنظمة بشكل دوري وسريع عن كافة التطورات ذات الشأن. ومن جهة أخرى، ممكن أن تبني مسؤولية الصين بنظرية العمل غير المشروع، وعدم إدلائها بالمعلومات المتعلقة بوباء COVID-19 في الوقت المناسب (الامتناع عن عمل)، مما ترتب عليه ضرر جسيم ليس على المنظمة فحسب، وإنما على المجتمع الدولي كله.

فالحالة الأولى للوباء ظهرت بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٩^(٢٦)، في حين أن الصين لم تأخذ الموضوع جدياً إلا بعد انتشاره في مستشفيات في ووهان، حيث ظهر للمرة الأولى^(٢٧)، ثم أرسلت أول تقرير إلى منظمة الصحة العالمية بمواصفات الفيروس الجديد وأنه غير خطير وقابل للسيطرة، مما حدا بالمنظمة إلى إصدار تصريح بعدم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية تجاه هذا المرض^(٢٨). ويلاحظ أنه بناء على التقرير الأول المرسل من الصين، لم تتخذ لا المنظمة ولا الدول أي إجراءات لمنعه، كما يؤكد هذا التقرير عدم مصداقية الصين وعدم شفافيته بالحالات الموجودة وطرق انتشاره، حيث أكدت في أكثر من تقرير أرسلته أن المرض لا ينتقل بالعدوى بين البشر^(٢٩)، وهو ما يعتبر من أكثر الأمور تدليساً للحقيقة، بالتالي عدم التحذير المسبق من سرعة

(٢٦) Chaolin Huang & Yeming Wang, Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, 395 The Lancet 10223, 497 (February 15, 2020).

(٢٧) Qun Li, Xuhua Guan & Peng Wu, Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia, 382 New England J. Med. 1199 (March 26, 2020).

(٢٨) Pneumonia of Unknown Cause - China, WHO Statement, Emergencies Preparedness Response, (January 5, 2020). Available at: <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/en/>

(٢٩) See; The Investigation Has Not Found any Obvious Human-to-Human Transmission, Wuhan Municipal Health Commission (December 25, 2019). Available at: <http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989>

Also; Mandy Zuo, Hong Kong Takes Emergency Measures as Mystery 'Pneumonia' Infects Dozens in China's Wuhan City, South China Morning Post (December 31, 2019). Available at: <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3044050/mystery-illness-hits-chinas-wuhan-city-nearly-30-hospitalised>.

انتشاره بين الناس، مما يؤكد بالتالي على انتهاكها لدستور المنظمة، وقواعد القانون الدولي الأمرة المتعلقة بمبدأ حسن النية بين أشخاص القانون الدولي.

وقد سعت بعض الدول إلى الوقوف على حقيقة تكوين وتفشي هذا الفيروس، فعرضت الولايات المتحدة إرسال فريق طبي متخصص من الخبراء للمساهمة في التحقيق ودراسة تكوينه، إلا أن الصين رفضت تدخل أي دولة بناء على مبدأ عدم التدخل بالشئون الداخلية للدول، وأصررت على عدم خطورته وأنه قابل للسيطرة^(٣٠). ونرى أنه يمكن العودة إلى مثل هذه التقارير والمراسلات للوقوف على مسؤولية الصين^(٣١)، حيث إنها رفضت تدخل المجتمع الدولي من أجل منع انتشار المرض، بل أعطت معلومات خاطئة عن الوضع العام له، وأصررت على التأكيد للمجتمع الدولي مراراً بكون هذا المرض تحت السيطرة، بناء على تصاريح رسمية من المفوضية الوطنية الصحية الصينية^(٣٢).

وقد اتهم وزير الخارجية الأمريكي الصين بأن تأخرها في مشاركة المعلومات حول الفيروس قد خلق حالة خطر بين الناس في جميع أنحاء العالم، وعرضت الآلاف من الأرواح لخطر الموت، وأكد أن الولايات المتحدة تملك معلومات مؤكدة على التستر والتضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني بحجب المعلومات التي يحتاجها العالم حتى يحد من انتشار الوباء باعتباره أزمة عالمية مستمرة، والحاجة إلى التأكد من أن كل دولة يجب أن تتسم بالشفافية ومشاركة المعلومات الحقيقية، حتى يتمكن المجتمع الدولي، والرعاية الصحية العالمية، ومجتمع الأمراض المعدية من بدء العمل على ذلك بطريقة شاملة، في حين أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين كانت شفافة في تقاسمها للمعلومات مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة^(٣٣).

(٣٠) Marisa Tylor, Exclusive: U.S. Axed CDC Expert Job in China Months Before Virus Outbreak, Reuters (March 22, 2020). & Donald McNeil, China Identifies New Virus Causing Pneumonia like Illness, N.Y. Times (January 8, 2020).

(٣١) Jim Geraghty, The Comprehensive Timeline of China's COVID-19 Lies, National Review (March 23, 2020).

(٣٢) New Coronavirus 'Preventable and Controllable', China Says, BBC (January 19, 2020).

(٣٣) David Brunnstrom, Pompeo says China still withholding coronavirus information, Reuters, (March 25, 2020).

ويرى العديد من فقهاء القانون الدولي^(٣٤) أن ثبوت مسؤولية الصين عن انتشار هذا الوباء أدى أيضاً إلى مسؤوليتها عن العديد من الآثار المترتبة عليه والأضرار الكثيرة الناتجة عنه، ومنها التأثير على العلاقات التي ينظمها القانون الدولي. مثال على ذلك، الالتزامات والتعاقدات بموجب قانون الاستثمار الأجنبي، حيث يمكن أن تؤدي إجراءات الحجر الصحي إلى تأخير مشاريع الاستثمار الأجنبي لمدة طويلة، وربما بتكلفة كبيرة جداً على هؤلاء المستثمرين، كما قد يؤثر حظر السفر على الالتزامات الدولية بموجب اتفاقيات الطيران المدني الثنائية، وكذلك الأحكام المتعلقة بعدم التمييز على أساس الجنسية الواردة في اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي^(٣٥). كم أن تدابير العزل والحجر الصحي وإلغاء الأحداث الجماعية أدت إلى التعدي على الحريات الفردية، بما في ذلك الحق في حرية التنقل وحرية التجمع، بما تنص عليه قوانين وقواعد حقوق الإنسان^(٣٦). ولكن يمكن القول أن مسؤولية الدولة عن حماية صحة الناس هي التي تجعل المصلحة الوطنية في الصحة لها الأولوية في التطبيق، مما يمكن معه تقييد بعض الحقوق الأساسية للإنسان والسماح للدولة باتخاذ تدابير تتعامل فيها مع تهديد خطير لصحة السكان، فيجب أن تهدف هذه الإجراءات على وجه التحديد إلى الوقاية من المرض أو الإصابة أو توفير الرعاية للمرضى منهم.

كما أنه من الممكن الاستناد إلى النظرية الثالثة للمسؤولية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المشددة، ذلك أن الصين وإن كانت قد أكدت أكثر من مرة على قيامها بتقاسم المعلومات مع العالم، وأنها لم تضلل الدول فيما يتعلق بانتشار الفيروس، وإن كانت ترى أنها لم ترتكب أي عمل محظور، إلا أن الأخذ بهذه النظرية يُحْمَلُها مسؤولية الأضرار الناتجة عن أفعالها وإن كانت مشروعة. فقد ظهرت العديد من المعلومات والدراسات التي تؤكد أن هذا الفيروس مُصنَّع جينياً، وأنه تكوّن في مختبر صيني

(٣٤) E.g. Sarthak Roy & Niriksha Sanghvi, COVID-19 Lockdown in India - Need for A Tailored Approach as One Size Does Not Fit All Its Regions, 1 European J. Inte'l L. (April 25, 2020), Andrea Maria Pilliconi, Covid-19: Italy is not a "Place of Safety" Anymore. Is the Decision to Close Italian Ports Compliant with Human Rights Obligations? 2 European J. Inte'l L. (April 23, 2020) & Matteo Chinazzi, The Effect of Travel Restrictions on the Spread of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak, 368 Science J. 395 (April 24, 2020).

Convention on International Civil Aviation, Doc. 7300/8 (2006). (٣٥)

Federica Paddeu & Freya Jephcott, supra, note 4. (٣٦)

موجود في ووهان^(٣٧)، وأن الصين هي من أنشأ هذا الفيروس الذي أدى تفشيه إلى انتشاره عبر الحدود ليصل إلى كل دول العالم محدثاً أضراراً كبيرة. وقد أكدت الصين أن الفيروس طبيعي وغير مصنع، وأن ما يتم ذكره عن تجارب في مختبرات الصين إنما تتم لأغراض البحث العلمي وبحسن نية دون رغبة في الإضرار بأحد^(٣٨). ولكننا نرى سواءً قامت الصين بتصنيع الفيروس أم لم تقم به، فإن المسؤولية المشددة تقوم بمجرد حدوث الضرر دون الرجوع إلى الأسباب مما يثير معه مسؤولية الصين عن نتائج تفشي هذا الفيروس.

ولإقرار مسؤولية الصين عن التعويض عن الأضرار الناتجة أمام المحاكم الدولية، يمكن الاستناد بقوة إلى حكم (Trail Smelter Case) الذي سبق ذكره، وذلك بناءً على أساسين قانونيين رائدين أرستهما محكمة التحكيم في القضية بخصوص الضرر العابر للحدود وهما: أولاً، أنه لا يحق لأي دولة استخدام أو السماح باستخدام أراضيها لإلحاق الضرر بأراضي دولة أخرى أو الممتلكات أو الأشخاص فيها. ثانياً، أنه يجب على الدولة الملوثة (المسببة للضرر) أن تدفع ثمن الضرر الناجم عن الأنشطة الملوثة ذات الصلة على أراضيها؛ ففي نهاية المطاف، أمرت المحكمة في كندا بدفع تعويضات للولايات المتحدة، وهو ما يمكن الاستناد عليه بإلزام الصين بدفع تعويضات أضرار انتشار هذا الوباء.

وهكذا، نرى أن أسس المسؤولية الدولية بنظرياتها الثلاث ممكن أن تطبق على مسؤولية الصين في انتشار هذا الوباء، بالتالي حق الدول في مقاضاتها والرجوع عليها بالأضرار. ولكن الصين لازالت تتمسك بعدم مسؤوليتها استناداً إلى نظرية القوة القاهرة التي أدت إلى خروج الأمر عن سيطرتها، واستحالة تنفيذها لالتزاماتها الدولية نتيجة هذا الظرف (الوباء).

(٣٧) Jonathan Marcus, Coronavirus: Trump Stands by China Lab Origin Theory for Virus, BBC News (May 1, 2020). Available at: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52496098>

(٣٨) Nectar Gan, China Pushes Back Against US Claims That Coronavirus Originated from Wuhan Lab, CNN (May 5, 2020). Available at: <https://edition.cnn.com/2020/05/04/asia/china-us-coronavirus-spat-intl-hnk/index.html>

الفرع الثاني

مدى اعتبار تفشي COVID-19 من قبيل القوة القاهرة

تحتوي غالبية النظم القانونية في العالم على قواعد تنظم نتائج الإشراف على الأحداث في الأداء المستمر للالتزامات. وينظم القانون الدولي هذه العواقب من خلال عدد من الأحكام المختلفة، والقوة القاهرة واحدة منها. فيمكن للدول أن تدافع عن نفسها في القضايا التي تثور فيها مسؤوليتها الدولية لأسباب قد تكون خارجة عن إرادتها أو سيطرتها، مما قد يؤدي معه إلى انتهاكات عديدة لقواعد القانون الدولي أولاً، والتزاماتها الدولية مع الدول ثانياً. بالتالي ممكن للدولة أن تسند أساس دفاعها عن نفسها على مبادئ القانون الدولي العرفي للضرورة والقوة القاهرة، على الرغم من أن الدولة قد تواجه عقبات شديدة في تحديد مدى توافرها، كما في حالة انتشار جائحة COVID-19 والتي تستند الصين فيها على موضوع القوة القاهرة خاصة إذا أثبتت سعيها الكامل لمحاولة السيطرة واحتواء انتشار الفيروس عالمياً، وقيامها بكافة الالتزامات الواردة عليها من منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.

وللقول بنجاح الصين في إثبات ادعائها استناداً إلى القوة القاهرة، يجب توافر خمسة شروط أساسية تتمثل بـ:

أولاً - يجب أن يكون هناك حدث غير متوقع أو قوة مفاجئة لا تقاوم:

فيمكن أن يكون مصدر القوة القاهرة أو الحدث قد وقع بشكل طبيعي، أو قد يكون نتاج صنع الإنسان، ذلك بأنه قد صدرت اتهامات عديدة للصين بالتصنيع العمدي والتعديل الجيني لهذا الفيروس في أحد مختبرات مدينة ووهان والتي انتشر منها الفيروس للمرة الأولى^(٣٩)، فصحة هذه الادعاءات قد تضع الصين أمام احتمالين في مواجهة المجتمع الدولي، فإذا كان ما حدث من تصنيع هذا الفيروس من قبيل البحث العلمي بناء على حسن النية، فيمكن القول بحدوث القوة القاهرة، أما إذا ثبت تصنيعها عمداً للضرر بسوء نية أو لأغراض أخرى غير معلنة، فإن إثبات ذلك ينفي نظرية القوة القاهرة، بالتالي ثبوت مسؤولية الصين.

وهناك نوعان من القوة القاهرة، نوع لا يمكن توقعه، وآخر يمكن توقعه بسهولة. مثال على ذلك التفشي الأولي لفيروس (SARS-CoV2) لم يكن متوقعاً، ولكن نتائجه

(٣٩) David Gitter, Sandy Lu & Brock Erdahl, China Will Do Anything to Deflect Coronavirus Blame, Foreign Policy, (March 20, 2020).

لم تكن كارثية، حيث إنه قد تمت السيطرة عليه من قبل الصين وهي بلد المنشأ^(٤٠). فمعظم الدول التي انتشر فيها الفيروس في الأيام الأولى، وإن كان هناك نوع من عدم اليقين بشأن ما يحدث، إلا أنها كانت قادرة على الاعتماد على طبيعة الحدث غير المتوقعة والسير على خطى الصين في مكافحته. أما النوع الثاني فهو ما تم توقعه بسهولة كما حدث مع فيروس (COVID-19) ذلك أنه ظهر قبل شهرين من انتشاره حول العالم ولكن نتيجة لنقص المعلومات الطبية، لم تتعامل معه الدول بجدية مما أدى إلى انتشاره بطريقة مدمرة^(٤١).

ثانياً – يجب أن يكون الحدث أو القوة خارجة عن سيطرة الدولة:

بمعنى أنه يجب أن يكون الحدث قد خرج عن إمكانية وقدرة الدولة للتحكم به والسيطرة عليه، وقد تمت إضافة هذا الشرط من قبل لجنة صياغة مشروع القانون الدولي خلال القراءة الأولى لهذا البند^(٤٢)، وذلك من أجل زيادة التأكيد على عنصر الاستحالة في السيطرة، كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة غير المتوقعة أو التي لا تقاوم للحدث، متى ما أثبتت الدولة عدم توقعها للحدث وعدم قدرتها على السيطرة عليه، تحققت نظرية القوة القاهرة، وهو ما تحاول الصين إثباته من أن الوباء، وإن كانت تتم مكافحته بشتى الطرق، إلا أن قوته وسرعة انتشاره تعتبر خارج حدود سيطرة الدولة.

ثالثاً – استحالة تنفيذ الالتزام مادياً أو معنوياً:

يجب أن تتسبب القوة القاهرة في "استحالة مادية" لأداء أي التزام دولي، ويلاحظ أن تحديد الاستحالة المادية جاءت بناء على ما ذكرته لجنة مشروع القانون الدولي من تحقيق صعوبة كبيرة في تنفيذ الالتزام، وليست الاستحالة التامة بمعناها اللغوي كما ورد تفسيرها بالمادة ٦١ من اتفاقية جنيف لقانون المعاهدات، وكما هو الحال في قضية (Rainbow Warrior) كما سبق ذكرها، فيشير هذا الحكم إلى أن الاستحالة يجب أن تكون مادية ومطلقة. ويقصد بمعنى "مادية": أي عدم القدرة الفعلية على أداء الالتزام، أما مصطلح "مطلق" فيشير إلى درجة هذا الاستحالة، وألا يكون لدى الدولة طريقة للوفاء بالالتزام المعني، ويجب ألا يكون لديها أي خيارات

(٤٠) Stephen Morse, Jonna Mazet, Mark Woolhouse, Colin Parrish, Dennis Carroll, William Karesh, Carlos Zambrana-Torrel, Ian Lipkin, & Peter Daszak, Prediction and Prevention of the Next Pandemic Zoonosis, 380 Zoonoses 1965 (December 1, 2012).

Federica Paddeu & Freya Jephcott, supra, note 4.

ILC Yearbook, Vol.1 234, at 3 (1979).

(٤١)

(٤٢)

مفتوحة أمامها، وهذا ما يؤكد الأساس المنطقي لفكرة القوة القاهرة، والذي يفسر في أن عدم أداء الالتزام يعتبر لا إرادي وليس للدولة حق الاختيار في أدائه من عدمه^(٤٣).

ولا يمكن القول عما إذا كان تفشي الفيروس التاجي سيؤدي إلى هذا النوع من الاستحالة في تنفيذ الالتزامات الدولية، فمن الصعب رؤية كيف سيتم الوفاء بهذا المعيار خاصة أن الدول اتخذت إجراءات شديدة قد تؤدي معها إلى خلل في تنفيذ التزاماتها الدولية، مثل منع الناس من السفر والحركة والتنقل؛ لأنه قد ينطوي على مخاطر جسيمة على الناس، سواء سكانها أو سكان الدول الأخرى.

رابعاً - ألا تكون الدولة قد ساهمت في خلق هذه الظروف:

المساهمة في خلق ظرف ما قد يكون غير مقصود وقد يكون مرتبطاً بمبدأ حسن النية، إلا أن القول بهذا المعيار يعتبر غامضاً إلى حد ما، فإلى أي مدى يمكن العثور على أسباب المساهمة في خلق الظرف؟ بمعنى، كيف يمكن القول بتحقيق الظروف القاهرة إذا ثبت تكوين الصين لهذا الفيروس وتركيبه جينياً، وإن كان لأغراض البحث العلمي وبحسن نية؟ يمكن القول إن كل شيء يتراوح من نقص التمويل لإقامة تجارب سليمة وصحيحة، إلى توفير معدل عالٍ للرعاية الصحية العامة تحسباً لأي طارئ، إلى ردود الفعل البطيئة في منع أو احتواء انتشار المرض، قد يكون ذا صلة بمدى قيام مسؤولية الصين الدولية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تجد الصين صعوبة في إثبات أنها لم تسهم بشكل كبير في الوضع الراهن، وأنها غير مسؤولة عن كل هذه النتائج السلبية المتعلقة بآثار انتشار هذا الوباء. وإن كانت الحكومة قد فشلت في تطبيق تدابير كافية للحد من العدوى والوقاية والسيطرة في الأسواق الرطبة أو ما يسمى بسوق الحيوانات البرية، وأنه على الرغم من حقيقة أن ظروف النظافة السيئة في هذه الأسواق الرطبة كانت متورطة في عدد من الأمراض السابقة كتفشي إنفلونزا الطيور في البشر وكذلك وباء سارس ٢٠٠٢-٢٠٠٣^(٤٤)، إلا أنه من ناحية أخرى، ادعت الصين أن الحكومة سعت بشكل كبير إلى مكافحة هذا الأمر، ومحاولة منع

(٤٣) سالم محمد سليمان، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، الدار الجماهيرية للنشر، (٢٠٠٠) ص ١٧٥.

(٤٤) See; Vittoria Offeddu, Benjamin Cowling & J.S. Peiris, Interventions in Live Poultry Markets for the Control of Avian Influenza: A Systematic Review, 2 One Health, 55 (2016) & Robert Webster, Wet Markets-A Continuing Source of Severe Acute Respiratory Syndrome and Influenza? 363 Rapid Review, 234 (January 17, 2004).

انتشاره في العالم باتخاذها لكافة الإجراءات الصارمة التي تنفي الخطأ أو الإهمال في القيام بالتزاماتها الصحية أمام منظمة الصحة العالمية، وأنها لم تسهم بأي شكل من الأشكال بخلق أي فيروس ونشره، بالتالي انتفاء مسؤوليتها.

خامساً - يجب ألا تكون الدولة على علم بحدوث الوضع وخطورته:

إن تحقق الحدث دون إلمام الدولة بأهميته أو خطورته أو مدى تأثيره عليها أو على دول العالم من شأنه أن يضع هذا الحدث في خانة القوة القاهرة. وعدم علم الدولة شرط أساسي لأنه بوقوع الخطر فإن المصلحة الأساسية العامة للدولة ستعاني من الضرر أو ستظل تعاني منه لفترة قد تكون طويلة، ويمكن أن يكون مصدر الضرر (أي الحدث الذي سيتسبب في ضرر للمصلحة الأساسية) حدثاً سابقاً أو حدثاً مستمراً أو من الممكن حدوثه في المستقبل. ويمكن أن يشير الخطر إلى وقوع الحدث نفسه (بحيث يمكن للدولة أن تعمل لمنع حدوثه) أو إلى تجسيد الضرر الناتج عن الحدث (بحيث يمكن للدولة أن تتخذ تدابير لحماية الناس والمصالح من الحدث). وطالما أنه يمكن إثبات العلم بوضوح على أساس الأدلة المتاحة بشكل معقول في ذلك الوقت، وإثبات أن الدولة كانت قادرة على معرفة هذا الحدث، بالتالي القدرة على تلافي الأضرار، فإن القوة القاهرة تنتفي هنا.

ونرى بأنه يمكن للصين الاعتماد على موضوع القوة القاهرة في حال قدرتها على إثبات عدم تقصيرها وإهمالها في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذا المرض، وأنها قد أدت التزامها المنصوص عليه في دستور منظمة الصحة العالمية استناداً إلى مبدأ حسن النية في القانون الدولي، وهو ما تنص عليه المادة (٢٣) من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بمشروع قانون مسؤولية الدول^(٤٥). ومن جهة أخرى، فإن ذات المادة قد استنتجت انعدام المسؤولية في القوة القاهرة إذا ثبت علم الدولة بالوضع الاستثنائي^(٤٦)، وافترضت بحصول خطر دولي، إضافة إلى إهمالها بمنع آثار هذه

(٤٥) مشروع لجنة القانون الدولي، مرجع سابق، المادة (٢٣) من مشروع قانون مسؤولية الدول تنص على أنه: "يُحظر عدم مشروعية فعل دولة لا يتوافق مع التزام دولي لتلك الدولة إذا كان الفعل بسبب قوة القاهرة، أي حدوث قوة لا تقاوم أو حدث غير متوقع، خارج سيطرة الدولة، مما يجعل من المستحيل مادياً تنفيذ الالتزام في هذه الظروف".

(٤٦) المرجع السابق. تنص ذات المادة في الفقرة ٢ على أن: "لا تنطبق الفقرة ١ في حال: أ) أن القوة القاهرة تعزى، منفردة أو بالاقتران مع عوامل أخرى، إلى تصرف الدولة التي تحتج بها؛ أو

ب) إذا افترضت الدولة الخطر في حدوث ذلك الوضع.

القوة القاهرة وإهمالها التصرف الصحيح، فإنه لا يمكن لها الاستناد إلى هذه المادة للتخلص من المسؤولية. ويقع على عاتق الصين في هذه المرحلة إثبات تحقق القوة القاهرة، بالتالي عدم مسؤوليتها الدولية لتمكن الرجوع عليها بالمقاضاة من قبل دول مختلفة سبق وأن هددت الصين بإلزامها بتعويض الأضرار الناتجة عن تفشي مرض (COVID-19)^(٤٧).

= من الدول التي هددت بمقاضاة الصين نتيجة الأضرار الناتجة من هذا الوباء الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا وأستراليا. انظر: حمزة عتبي، بسبب فيروس كورونا.. معهد أبحاث بريطاني يدعو إلى مقاضاة الصين وإجبارها على تعويض الدول المتضررة، أخبار الآن (٧ أبريل ٢٠٢٠).

(٤٧) <https://www.akhbaralaan.net/news/world/2020/04/07/> بسبب فيروس كورونا مركز أبحاث بريطاني يدعو إلى مقاضاة الصين وإجبارها على تعويض الدول المتضررة.

المبحث الثاني

مقاضاة الصين عن انتشار فيروس COVID-19

بعد ثبوت مسؤولية الصين عن انتشار وباء COVID-19 في العالم، وعدم التزامها بدستور منظمة الصحة العالمية^(٤٨)، خاصة تلك المتعلقة بالإدلاء بالمعلومات عن أي مرض بكل سرعة وشفافية لتلافي كوارث صحية عالمية، فإن السؤال الذي يثور يتعلق بماهية الاختصاص القضائي لمقاضاة الصين عن هذا الوباء؟ هل من الواجب إنشاء تحقيق دولي يقوم به مجلس الأمن للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع؟ أو هل يحال الأمر لمحكمة العدل الدولية المختصة بنظر قضايا الدول؟ وإن كان كذلك، فما هو الاختصاص القضائي لذلك؟ أو هل بالإمكان اللجوء إلى هيئات التحكيم لمقاضاة الصين ومطالبتها بالتعويض؟ وللإجابة عن الأسئلة السابقة لابد من تحديد الانتهاكات التي قامت بها الصين، ومن ثم تحديد الأسس القانونية التي تعطي الاختصاص لمحكمة العدل الدولية في نظر هذه الدعوى.

المطلب الأول

انتهاكات الصين لدستور منظمة الصحة العالمية كأساس لاختصاص محكمة العدل الدولية

لتحديد مدى مسؤولية الصين وإحالتها إلى المحاكمة، لابد من الوقوف على دستور منظمة الصحة العالمية، والذي نص صراحة على أنه في حال مخالفة الدستور أو أي من الالتزامات الدولية المتعلقة به، فإن هذا الأمر يحال إلى محكمة العدل الدولية، في اعتراف صريح من المنظمة باختصاص أصيل للمحكمة لنظر مخالفة الدستور، فقد نصت المادة (٧٥) على أن: "أي مسألة أو نزاع بشأن تفسير هذا الدستور أو تطبيقه لا تتم تسويته بالمفاوضة أو بوساطة جمعية الصحة، يحال إلى محكمة العدل الدولية، طبقاً لنظام المحكمة الأساسي...". وفي الواقع، إن المحكمة نفسها قد اعترفت بوجود هذا الاختصاص لها استناداً إلى دستور منظمة الصحة العالمية، وذلك في قضية الأنشطة المسلحة في الكونغو^(٤٩)، علاوة على ذلك، فقد

(٤٨) هذا الدستور أقره مؤتمر الصحة الدولي المنعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في ٢٢ يوليو ١٩٤٦ بتوقيع وموافقة ٦١ دولة.

(٤٩) Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda) I.C.J. Judgment, (2002) para 99.

فسرت المحكمة المادة (٧٥) سألقة الذكر بالطريقة نفسها التي فسرت بها المادة (٢٢) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في قضية أوكرانيا ضد روسيا^(٥٠)، فهنا لن تحتاج الدولة إلا إلى استيفاء شرط التفاوض من أجل مقاضاة الصين أمام المحكمة، ولن تكون بحاجة إلى الذهاب إليها من خلال منظمة الصحة العالمية^(٥١). ويلاحظ عند النظر إلى المادة (٧٥) أنها حددت اختصاصين للمحكمة: الاختصاص الأول هو اختصاص افتائي بتفسير نصوص الدستور، وهو ما لا يعتبر ملزماً للدول لتطبيقه، والاختصاص الثاني بنظر أي مسألة أو نزاع بـ "تطبيق" الدستور، بمعنى اللجوء إلى المحكمة في حال مخالفة دولة عضو تطبيق أحكام الدستور، وهو محل النقاش هنا.

إن السؤال الذي يمكن إثارته هو: كيف يمكن للدولة أن ترفع دعوى نتيجة تصرف الصين حول انتشار الفيروس على أنها قضية تتعلق بتفسير أو تطبيق دستور منظمة الصحة العالمية؟ فدستور المنظمة لا يبدو أنه يحتوي على التزامات جوهرية متعلقة بقانون الصحة الدولي بشكل مباشر، إنما ركز بدلاً من ذلك، على إنشاء إطار دستوري في المقام الأول، يعالج مسائل مثل العضوية والهيكل التنظيمي، دون التركيز بشكل مباشر على الاختصاصات الصحية والتدابير الاحترازية الوقائية التي على الدول الالتزام باتباعها، مما قد يثير تساؤلاً عن نقل الاختصاص منها إلى محكمة العدل الدولية. فبعد كل هذا، يبدو أن هناك بعض الادعاءات المتعلقة بتفسير أو تطبيق دستور منظمة الصحة العالمية ومدى أحقيته بنقل الاختصاص القضائي إلى المحكمة.

يمكن القول إن الدول التي تنوي مقاضاة الصين، لها أن تستند إلى انتهاك اللوائح الصحية الدولية من خلال المادتين (٢١) و (٢٢) من دستور منظمة الصحة العالمية، فتمنح المادة (٢١) جمعية الصحة العالمية سلطة اعتماد لوائح مثل اللوائح الصحية الدولية، كما تنص المادة (٢٢) على أن هذه الأنظمة تعد نافذة لجميع الدول الأعضاء بعد تلقي إشعار بتصديق جمعية الصحة عليها. ولكن يلاحظ أن القول

(٥٠) Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation) I.C.J. Preliminary Objections, Judgment, (2019) para 113.

(٥١) Swargodeep Sarkar, Liability of China for Covid19 Outbreak, State Responsibility, and Jurisdictional Challenges, Modern Diplomacy (April 13, 2020) available at: <https://modern diplomacy.eu/2020/04/13/liability-of-china-for-covid19-outbreak-state-responsibility-and-jurisdictional-challenges/>

بانتهاك الصين لهاتين المادتين يعد من قبيل الانتهاكات المتعلقة بتفسير أو تطبيق دستور منظمة الصحة العالمية، وليس التزامها القانوني بالامتثال لتلك اللوائح، بمعنى أن المادتين السابقتين تنظيمنتين دون أن تكون على الدولة أي عقوبات في حال مخالفتها.

إلا أن هذا الرأي يتعارض مع ما تسعى الدول إلى إثباته من قيام مسؤولية الصين للسعي لإجبارها على التعويض عن الأضرار الناتجة عن انتشار هذا الوباء، فالدول لا تركز على مخالفة الصين للجانب التنظيمي من دستور المنظمة، إنما تسعى للتركيز على مخالفتها للمادتين (٦٤) و (٦٥) بشأن عدم الشفافية في نقل المعلومات المتعلقة بالمرض والتسبب بكارثة صحية دولية على مستوى العالم مخلفة مئات الآلاف من القتلى، إضافة إلى إثبات مخالفة الصين للمادتين (٦) و (٧) من لوائح التسمية^(٥٢) الصادرة من منظمة الصحة العالمية والتي تعد بناءً على المادة (١٩) من الدستور جزءاً لا يتجزأ من دستور المنظمة. فالمادة (٦) تنص بشكل واضح على تحديد "الطريقة" التي يجب من خلالها إصدار التقارير الإحصائية والوبائية بشكل دوري وسريع وفعال، وأن يتم توفيرها للمنظمة، فالمادة ٦(٢) على سبيل المثال، تلزم الدول الأطراف، بعد إخطار منظمة الصحة العالمية بحدث قد يشكل حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقاً دولياً ويشار إليها بـ (PHEIC) "بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بمعلومات صحية عامة ودقيقة، وفي الوقت المناسب، ومفصلة بما فيه الكفاية... بما في ذلك... عدد الحالات والوفيات". بل أن المادة (تعد أوسع نطاقاً، حيث تطلب من الدول الأطراف إذا كان لديها أدلة على حدث قد يشكل طارئة صحية (PHEIC) "تزويد منظمة الصحة العالمية بجميع المعلومات الصحية العمومية ذات الصلة". وفي ضوء ما سبق، يمكن للدول أن تدعي أن الصين انتهكت المادة (٦٤) من دستور منظمة الصحة العالمية من خلال انتهاك المادتين (٦) و (٧) من اللوائح الصحية الدولية. وكذلك السعي للتركيز على مخالفة الصين لقواعد القانون الدولي العام والعرف

(٥٢) World Health Assembly, 20. (1967)? WHO Nomenclature Regulations) 1967 (Art. 6 states: "Each Member shall, under Article 64 of the Constitution, provide the Organization on request with statistics prepared in accordance with these Regulations and not communicated under Article 63 of the Constitution". Art. 7 states: "3. Any revisions of the International Classification of Diseases adopted by the World Health Assembly pursuant to Article 2 of these Regulations shall enter into force on such date as is prescribed by the World Health Assembly and shall, subject to the exceptions hereinafter provided, replace any earlier classifications".

الدولي بعدم الإضرار بدول أخرى والقيام بأعمالها بحسن نية، وهذا ما تحاول الدول إثباته من أن الصين أخفت المعلومات عن سوء نية، ربما للحفاظ على متانة اقتصادها أو عدم تأثر السياحة أو لأي أسباب أخرى دون أن تتوقع هذا الانفجار الكارثي الذي حدث نتيجة تفشي هذا الوباء.

كما يمكن للدول الاستناد إلى ادعاء آخر ضد الصين وهو بانتهاكها المادة (٦٣) من دستور المنظمة والتي تنص على ما يلي: "تبادر كل دولة عضو إلى إبلاغ المنظمة على الفور بما ينشر فيها من قوانين وأنظمة وتقارير رسمية وإحصاءات هامة تتصل بالصحة والتي تم نشرها في الدولة المعنية". ويلاحظ أن الادعاء هنا لن يكون ضد عدم الإبلاغ عن "القوانين" أو "اللوائح"، بل يتعلق "بالتقارير الرسمية" و"الإحصاءات" التي يجب أن تقدم للمنظمة والتي تتصف بكونها متغيرة ومتجددة وسريعة في رصد الواقع الحالي لظهور أي مرض ومعلوماته وطرق الوقاية منه. وفي الواقع، يُزعم أن الصين حجبت التقارير المبكرة عن إصابة العاملين في المجال الطبي بهذا الفيروس، مما دفع بمنظمة الصحة العالمية إلى الاعتقاد بأن انتقال العدوى من شخص لآخر غير ممكن، كما زُعم أن الصين حجبت "البيانات الحكومية الصينية المصنفة" بشأن عدد الأشخاص المصابين من دون أعراض، وهو عنصر حاسم في التحقق من عدوى المرض وطرق انتشاره من إنسان لآخر^(٥٣).

ولكن هناك مشكلة تتعلق بتطبيق المادة (٦٣)، وهي أنه كان يجب "نشر" هذه "التقارير الرسمية" و"الإحصائيات" ولكن لم يتم تحديد طريقة النشر، هل تكون في الصين أو عن طريق التقارير الرسمية الدورية للمنظمة؟ وإذا كانت الصين قد نشرتها على أراضيها، هل ينفي ذلك عنها قيام المسؤولية؟ نرى بأن دستور المنظمة قد أغفل توضيح معنى كلمة "منشورة" في هذا السياق، فمن ناحية، يمكن القول إنها تشير فقط إلى المنشورات الحكومية الرسمية المتاحة للجمهور، ومن ناحية أخرى، يمكن للمرء أن يقول أن مشاركة الأطباء الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تخضع للرقابة من قبل الصين يجب أيضاً اعتبارها "منشورة" لأغراض المادة (٦٣). ولكننا نرى أن النشر لو كان قد حقق مراده من علم الدول بالمرض لما كنا بصدد نقاش ما تعنيه هذه المادة بالنشر، ذلك أنه وفقاً لعدد من التصريحات والتقارير الدولية، لم يمكن المجتمع الدولي على علم بأي معلومات واضحة بشأن مدى خطورة

Peter Tzeng, Taking China to the International Court of Justice over COVID-19, 2 European J. Inte'l L. (April 2, 2020).

هذا المرض وسرعة انتشاره، وإلا لكان قد اتخذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة قبلها بمدة كافية.

وهناك ادعاء رابع ربما تكون الصين قد انتهكتته هو المادة (٣٧)، والتي تنص في الجزء ذي الصلة على: "يتعهد كل عضو في المنظمة من جانبه باحترام الطابع الدولي الخالص للأمين العام [للمنظمة الصحة العالمية] وللموظفين وبدعم السعي للتأثير عليهم". فقد صرح الأمين العام للمنظمة بأنه سعيد ومرتاح من كافة الإجراءات المتخذة من الصين ويثمن دور تعاون المفوضية الصحية الصينية مع المنظمة وتعاملها الشفاف تجاه كل المعلومات حول الأزمة^(٥٤)، وهو ما يتم اكتشاف عدم صحته اليوم. كما ويمكن تقديم ادعاء بأن الصين من خلال حجب المعلومات أو من خلال تقديم معلومات غير دقيقة، سعت للتأثير على سلوك معين للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية والموظفين التابعين، مثل تعبيرهم القوي عن دعم الصين وللإجراءات - غير الواضحة - التي كانت تقوم بها^(٥٥)، ومن ثم تأجيل إعلان حالة الطوارئ من يناير حتى مارس ٢٠٢٠^(٥٦).

وبالعودة إلى اختصاص محكمة العدل الدولية، نرى بأنه استناداً إلى انتهاك الصين لدستور منظمة الصحة العالمية من خلال انتهاكها عدداً من المواد، فإنه يمكن تفعيل المادة (٧٥) من الدستور بإسناد الاختصاص للمحكمة بناء على عدم التطبيق الصحيح للدستور، وبما أن الصين وافقت مسبقاً على دستور المنظمة عند قبول عضويتها، بالتالي تعتبر قد وافقت مسبقاً على الإحالة إلى المحكمة كما هو منصوص بالدستور، وعلى الرغم من أنه يجب استيفاء طرق حل النزاع السلمية أولاً قبل اللجوء إلى المحكمة، إلا أن خيار اللجوء إليها موجود وواضح بنص المادة، ولا يمنع من تفعيلها القول بضرورة الحصول على موافقة الصين الصريحة، ذلك أن إقرارها وتصديقها على دستور المنظمة وانضمامها إليها كعضو، يعتبر قبولاً صريحاً لكل ما جاء في دستورها،

(٥٤) WHO Director-General's Statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus, WHO Statement (January 22, 2020). Available at: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus>.

(٥٥) Peter Hasson, Top WHO Official Tedros Adhanom Ghebreyesus Won Election with China's Help. Now He's Running Interference for China on Coronavirus, Daily Caller (March 22, 2020).

(٥٦) Karen Teber, WHO's Delayed PHEIC Decision and Wuhan Transportation Shutdown, Georgetown Univ. Medical Center. (2020).

بالتالي يمكن لنا القول بوجود موافقة مسبقة على اختصاص المحكمة في حال وجود نزاع، فالمحكمة لا تحتاج في حال رفع إحدى الدول للدعوى الحصول على موافقة الصين الصريحة عليها لتحقيق القبول المسبق للاختصاص القضائي لنظر الدعوى.

المطلب الثاني

انتهاكات الصين لقواعد القانون الدولي كأساس لاختصاص محكمة العدل الدولية

يمكن الاعتماد على إثبات مسؤولية الصين بانتهاكها للقواعد العامة للقانون الدولي. فبالنظر إلى المادة (١٨) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات^(٥٧)، نرى بأن الصين بالتزامها بالانضمام لهذه المعاهدة قد أقامت على عاتقها التزاماً دولياً لأي معاهدة توقعها وألا تعطل الغرض منها، وتؤكد ذلك المادة (٥) من اتفاقية فيينا بتطبيقها على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية، وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية، وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنظمة، مما يثبت صحة تطبيق المادة (١٨) على الصين حيث إنه بالمقارنة مع الوضع الحالي، يمكن القول بأن الصين انتهكت قواعد وأهداف دستور منظمة الصحة العالمية والذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار أي أمراض، فالمادة الأولى من الدستور تنص على: "أن تبلغ الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن"، في حين أن ما حصل في الواقع هو النقيض تماماً من انتشار المرض وموت الناس وعدم حصولهم على حياة طبيعية من أجل مكافحة انتشاره، فما حدث من انتشار هذا المرض هو النقيض لالتزام الصين الدولي في اتفاقية فيينا بأن تلتزم بدستور منظمة الصحة العالمية.

ولكن يلاحظ أنه بالنظر إلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وغير العسكرية في نيكاراغوا^(٥٨) أنه لا يجوز بناء ادعاء باختصاص المحكمة

(٥٧) انظر: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (١٩٦٩) المادة ١٨ تنص على: "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في ألا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو
ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

(٥٨) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) I.C.J. Merits, Judgment (1984) para 271.

بانتهاك القواعد العامة للقانون فقط، ويمكن الرد على هذا الادعاء أنه وبالرجوع إلى المادة (٧٥) من دستور المنظمة، أنها لم تقصر الإحالة على وجود نزاع، إنما يمكن الإحالة أيضاً من أجل تفسير المادة المتعلقة بانتهاك دستور المنظمة، وبالتالي بناء ادعاء ثبوت المسؤولية عليها. ويمكن القول إن تفسير المحكمة لانتهاك الصين لدستور المنظمة وعدم التزامها بالأهداف المرجوة منه أدى إلى الآثار السيئة التي تسعى معها المنظمة إلى الحيلولة دون وقوعها؛ مما يثبت مسؤولية الصين الدولية عن انتشار هذا الوباء بالعالم، بالتالي اللجوء إلى مقاضاتها من أجل التعويض عن الأضرار الناتجة عنه.

كما أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تعطي اختصاصاً صريحاً ومباشراً لمحكمة العدل الدولية بنظر دعوى تتعلق بمخالفة قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي، حيث نصت المادة (٦٦) على أنه يجوز للدول أن تتقدم بدعوى أمام المحكمة لاستخلاص حكم ضد انتهاك القواعد الأمرة للقانون الدولي^(٥٩). ومن الجدير بالذكر أن موضوع الصحة العامة يعتبر من القواعد الأمرة، ذلك أنه عند الحديث عن الصحة العامة نرى أنه حق رئيسي في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن الدولة لا يمكنها التمسك بسيادتها لمنع التدخل في حال انتهاكها لقواعد حقوق الإنسان كما في مبدأ مسؤولية الحماية الدولية، بالتالي بما أن نظرية السيادة لا يمكن التمسك بها في ظل انتهاك حقوق الإنسان والتي تعتبر الصحة العامة جزءاً منه، فإن فكرة اعتبار الصحة العامة من القواعد الأمرة في القانون الدولي تتحقق، ذلك أن الحق في الصحة العامة من الحقوق المطلقة التي لا تقبل التقييد بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت في حالة الطوارئ، كونها مرتبطة بشكل أساسي ومباشر بحق الإنسان في الحياة، وهذا ما يتحقق بالصحة بشكل عام، أما في حال تخصيصها بما يتعلق بالأمراض والأوبئة التي من الممكن أن تقضي على أعداد كبيرة من البشر فإن هذا الحق للصيق

(٥٩) اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مرجع سابق، المادة (٦٦-أ) تنص على: "يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير المادتين ٥٣ أو ٥٤ أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدولية بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم". وتنص كل من المادة (٥٣) على: "تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة أمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الأمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع." والمادة (٦٤) تنص على: "إذا ظهرت قاعدة أمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي".

بالإنسان قد ارتبط بشكل مطلق بحقه في الحياة، وهو الحق الذي تدور حوله حقوق الإنسان^(٦٠). ومن وجهة نظر أخرى، فإن تحريم الحرب يعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي نتيجة للآثار المهلكة الناتجة عنها، ومنها الخسائر الكبيرة في أرواح البشر، ويرى بعض الفقهاء^(٦١) قياس آثار الحرب بآثار الأوبئة وأن لها ذات النتيجة من خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد وقوة الدول، وتم تصنيف الأوبئة بأنها "أكبر تهديد لأمن الإنسان بعد الحرب العالمية"^(٦٢) ونرى بأن قياس الأمرين محل اعتبار، ذلك بأن القانون الدولي يسعى بوضعه للقواعد الآمرة إلى منع المساس بأهم القواعد التي قد تؤثر على الدول، وتؤدي إلى هلاك الناس، ويؤكد ذلك تصريح الأمين العام السابق لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة Pan American للصحة George Alleyne بربطه المباشر بين السلم والأمن الدوليين وبين انتشار الأوبئة، ويرى أنه يجب التوسع في تفسير القواعد الآمرة لتشمل أكثر من الإبادة والجرائم الدولية والاتجار بالبشر، وأن التركيز على انتشار الأوبئة والصحة العامة في إطار القانون الدولي يؤدي إلى تعزيز أهمية هذا الأمر بين الدول، كما أن المجتمع الدولي أصبح يركز في الوقت الحاضر على الصحة العامة بذات درجة الأمن والسلم^(٦٣).

ومن جانب آخر، نرى أن كثيراً من القواعد التي قننت في اتفاقيات دولية كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كانت في الأصل قواعد عرفية ثابتة في المجتمع الدولي، ارتضتها والتزمتها الدول مما أعطاها القوة الملزمة في اتباعها، وهو أيضاً ما أكدته اتفاقية فيينا بالمادة (٣٨) حيث شددت على عدم مخالفة القواعد العرفية الدولية، وإلا كان الانتهاك مجالاً لنظر المحكمة للنزاع^(٦٤). فنرى هنا اعتبار الصحة بشكل عام

(٦٠) David Fidler, SARS, Governance and the Globalization of Disease, 61 (2004).

(٦١) Paul Farmer, Social Inequalities and Emerging Infectious Diseases, 2 Emerging Infectious Diseases 259, 267 (1996), David Fidler, International Law and Infectious Diseases, (1999), & Hiroshi Nakajima, Global Disease Threats and Foreign Policy, 4 Brown J. World Aff. 319 (1997).

(٦٢) Dennis Pirages, Microsecurity: Disease Organisms and Human Well?Being, 18 Wash. Q. 5, 11 (2010).

(٦٣) George Alleyne, Health and National Security, 30 Bull. P.A.H.O 158, 160 (1996), available at: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/27582/ev30n2p158.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

(٦٤) المرجع السابق، المادة (٣٨) تنص على: "ليس في المواد... ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة."

من القواعد العرفية المرتبطة بحقوق الإنسان والتي قننت بتفاصيلها بمختلف الاتفاقيات، كالاتفاقيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية خاصة تلك المتعلقة بمنع انتشار الأمراض مثل اتفاقية مكافحة التبغ الصادرة عام ٢٠٠٣^(٦٥)، فالمرض بحد ذاته لا يعد من القواعد العرفية بشكل مباشر، إنما يتحقق بارتباطه بحق الإنسان في الصحة والتي تعد في الأساس من القواعد الآمرة.

ومن جهة ثالثة، فقد نصت ديباجة اتفاقية فيينا على تأكيد سريانها على اتفاقيات الأمم المتحدة منها المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تعتبر من القواعد الدولية المقننة، حيث تنص المادة (٢٥) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضمان الصحة والعناية الطبية لكل شخص، وله الحق في العلاج من حالات المرض. وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة ١٢ منه على: "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.. منها الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض". وعليه أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وثيقة متعلقة بتفسير المادة ١٢ من العهد الخاص المتعلق ببلوغ أعلى درجات الصحة مؤكدة في المادة الأولى منه على اعتبار الصحة من الحقوق الأساسية للصيقة بالإنسان، وباعتبار الأوبئة حالة طوارئ دولية تستوجب التدخل الدولي الإنساني للمساعدة^(٦٦). بالتالي كون انتشار الأوبئة وسبب مكافحتها ومنع انتشارها لخطورتها أمراً يستوجب معه مساءلة الدولة التي كانت سبباً في هذا المرض، سواء من خطأ أو إهمال أو عمل متعمد، وبما أن القانون الدولي يولي اهتماماً كبيراً بالصحة العامة والحفاظ عليها، فأى انتهاك لهذا الحق يستوجب المساءلة الدولية كما في أي حالة أخرى من حالات انتهاك القواعد الآمرة.

إن ما يمكن ملاحظته هو أن الحق في الصحة غير وارد في قائمة الحقوق غير القابلة للانتقاص في العهدين الدوليين، فهل علينا إذن أن نؤكد أن الحق في الصحة لا يجب أن يُفسر على أنه من القواعد الآمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ الحقيقة هي أنه مهما كانت التدابير التي تتخذها الدولة من جانب واحد للانتقاص من الحقوق

WHO Framework Convention on Tobacco Control (2003), available at: https://www.who.int/fctc/text_download/en/ (٦٥)

CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) UN. Doc. E/C.12/2000/4 (2000) para 16, available at: <https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf> (٦٦)

المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "يجب أن تكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة" بحيث يتم الحفاظ على الحقوق إلى أقصى حد يتوقعه القانون الدولي، فيكون الحق قابلاً للتطبيق في حالات الطوارئ الوطنية باعتباره قواعد أمر ملزمة كما في حالة انتشار الجائحة وإعلان حالة الطوارئ في العالم، وبالفعل فقد صرحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المكلفة بتوضيح العهد حتى عام ٢٠٠١ "حقيقة أن بعض أحكام العهد قد تم إدراجها في المادة ٤ الفقرة (٢) حيث لا يجوز إخضاع بعض المواد - كالصحة العامة - للانتقاص في حالة وجود تهديد لحياة الأمة". علاوة على ذلك، في غير الأحكام الواردة في المادة السابقة، هناك قواعد ترى اللجنة أنه لا يمكن إخضاعها للتقييد بموجب المادة (٤)^(٦٧)، وهو ما يمكن تأكيده من أن مخالفة الصين للقواعد الأمرة والعرفية وقواعد حقوق الإنسان أدت إلى مخالفة نصوص اتفاقية فيينا، بالتالي أي خرق لقواعد الصحة العامة يعد انتهاكاً غير مباشر لاتفاقية فيينا التي تحيل معها الاختصاص لمحكمة العدل الدولية لنظر النزاع.

وبالعودة إلى السؤال حول ما إذا كان من الواجب فتح تحقيق دولي في مجلس الأمن للوقوف على تفاصيل وأسباب انتشار وباء COVID-19، وما إذا كانت للصين مسؤولية مباشرة عن هذا الأمر، فإن دولة استونيا - باعتبارها عضواً في مجلس الأمن - قد قامت بتقديم مقترح بشأن التحقيق بانتشار هذا الوباء عالمياً وبحصده الأرواح بأعداد مختلفة، وكونه يمثل بالمقام الأول تهديداً للسلم والأمن الدوليين، إلا أن الصين، روسيا، وجنوب أفريقيا أوقفوا النظر بالمقترح لعدم وجود إجماع لنظره، خاصة أن الصين ترأست مجلس الأمن حتى نهاية مارس ٢٠٢٠. وقد كان التبرير الروسي لعدم النظر في فتح تحقيق بانتشار الوباء هو عدم وجود علاقة مباشرة بين انتشار المرض وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وكون مثل هذه الحالات الخاصة غير منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة^(٦٨). ولكن وبالنظر إلى أعمال المجلس السابقة، فإنه سبق وناقش مواضيع انتشار الأوبئة في العالم وأهميتها على الأمن والسلم الدوليين كما في عام

(٦٧) See; L. Caplan, State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory, 97 AM. J. Int'l L. 741-781 (2003), & N. Swazo. The Right to Health, International Law, and Economic Justice, 5 Internet J. L. Healthcare Ethics. 1(2006).

(٦٨) Shishir Gupta, UNSC Won't Discuss Covid-19; China Blocks it With Help from Russia, South Africa, Hindustan Times (March 27, 2020). Available at: <https://www.msn.com/en-in/news/world/unsc-wont-discuss-covid-19-china-blocks-it-with-help-from-russia-south-africa/ar-BB11M6cS?li=AAggbRN>

٢٠١٤ عندما سلط الضوء على انتشار مرض إيبولا في أفريقيا، حيث ربطت الولايات المتحدة بين انتشار المرض وتأثيره على السلم خاصة في سيراليون. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الأمن انتشار الأوبئة، فقد سبق وناقش تفشي الأوبئة في بعض المناطق في العالم عام ٢٠١١، وأن من شأنها أن تسهم في زيادة الجرائم العابرة للقارات؛ مما يوجب معه على المجتمع الدولي مكافحتها لتأمين الأمن والسلم الدوليين، وأكد على أن: "إدماج مكافحة الأوبئة في استراتيجيات بناءً لسلام الدول التي تمر في فترة ما بعد الصراع أحد التدابير الأساسية لتجنب تعريض المكاسب المحققة في توطيد أركان السلام للخطر، ومما يتسم بالأهمية في ذلك الصدد تعزيز الدعم الدولي للبرامج التي تقودها وكالات الأمم المتحدة لمحاربة الأوبئة"^(٦٩).

وعلى الرغم من أن أهمية اقتراح استونيا تكمن في إظهار الشفافية والمعلومات الدقيقة عن هذا المرض، ومن ثم تحديد مسؤولية الدولة المختصة، إلا أن انشغال أغلب أعضاء مجلس الأمن بمكافحة الوباء الذي انتشر بسرعة كبيرة في دولهم حال دون تبني أحدهم الاقتراح مجدداً ورفعته إلى المجلس. إلا أنه ومع استمرار الآثار الكارثية للفيروس، وافق مجلس الأمن على الاجتماع - عن بعد - من أجل الوقوف على تدابير الدول والآثار الناتجة، حيث أصرت الولايات المتحدة على أن تقوم الصين بتزويد أعضاء المجلس بجميع البيانات المستندة إلى الدراسات العلمية وتحليل أصول الفيروس وتكوينه وخصائصه وانتشاره، خاصة أن الولايات المتحدة وحتى كتابة هذه الدراسة، تعد الأولى في عدد الوفيات حيث بلغ أكثر من ٥٠ ألف حالة وفاة، وإصابة ما يقارب ٨٠٠ ألف حالة، وتؤكد الولايات المتحدة على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتقاسم بيانات ومعلومات الصحة العامة في الوقت المناسب داخل المجتمع الدولي حتى يتسنى للدول اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إصرارها على بدء تحقيق دولي شامل للوقوف على مسؤولية المتسبب بالكارثة^(٧٠).

إلا أن الصين أصرت بشكل أكبر، عن طريق تصريح سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة، برفض قاطع لأي تحقيق دولي يتخذه المجلس بهذه المسألة، وأصرت على

UN. Doc. S/PV/6668 (November 23, 2001), available at: <https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/PV.6668> (٦٩)

Michelle Nicholas, U.N. Security Council Meets Over Coronavirus as it Struggles to Act, Reuters (April 10, 2020), available at: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-un/u-n-security-council-meets-over-coronavirus-as-it-struggles-to-act-idUSKCN21R3PB> (٧٠)

أن اتهامات الولايات المتحدة بكونها صنعت أو نشرت الفيروس هو أمر عار عن الصحة وبلا أي أدلة، ذلك إنها (الولايات المتحدة) تريد الضغط من أجل البدء في التحقيق لتحميل الصين المسؤولية. وأن ما تقوم به هو مجرد تلاعب سياسي لوضع الصين في قفص الاتهام ومحاسبتها ومطالبتها بالتعويض، وأن المجلس غير مختص بالتحقيق في الوباء كونه لم ينص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس الأمن، وأنه لا يشكل بشكل صريح ومباشر أي تهديد للسلم والأمن الدوليين^(٧١).

وللتأكيد على اختصاص مجلس الأمن في التحقيق الشامل لتحديد مسؤولية الصين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة Antonio Guterres على أن الوباء يمثل اليوم تهديداً للسلم والأمن الدوليين والذي يتوجب معه على مجلس الأمن القيام باللازم لمحاربته خاصة أنه يؤدي إلى ازدياد الاضطرابات الاجتماعية والعنف، والذي من شأنه أن يقوض إلى حد كبير قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة على مكافحة المرض، ذلك أن تدخل مجلس الأمن سيخفف كثيراً من حدة هذه الأزمة^(٧٢).

ونرى بأنه في حال قيام مجلس الأمن بتحقيق دولي شامل حيال انتشار هذا الوباء، فإنه يمكن للدول المتضررة إحالة المتسبب أو المسؤول عن هذا الأمر إلى محكمة العدل الدولية، بالتالي تعطى المحكمة الاختصاص في نظر الدعوى ضد الدولة المسؤولة سواء أكانت الصين أم غيرها، بناء على الدعوى المرفوعة من دولة على دولة أخرى. كما أن لمجلس الأمن بعد إجراء التحقيق أن يطلب من المحكمة رأياً استشارياً فيما يخص تهديد الفيروس للسلم والأمن الدوليين، وما يتبعه من مسؤولية الدولة المسببة للضرر، وهو ما يمكن للدول الاستناد عليه (الرأي الإفتائي) لاحقاً كأساس قانوني لرفع الدعوى. كما أن لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب رأياً استشارياً من المحكمة فيما يخص هذه المسألة، وعلى الرغم من أن التفسير لا يعد ملزماً، إلا أنه يمكن اعتباره أساساً تعتمد

Statement of Chinese UN Ambassador, Chinese Embassy in the US, (May 6, ٢٠٢٠). Available at: <http://www.china-embassy.org/eng/fyrth/t1776657.htm>. (٧١)

See; Statement by the Secretary-General - on COVID-19, U.N. Press Release (٧٢) (April 8, 2020). Available at: & Secretary-General's remarks to the Security Council on the COVID-19 Pandemic, U.N. Press Release (April 9, 2020). Available at: <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-08/statement-the-secretary-general-covid-19> & Secretary-General's remarks to the Security Council on the COVID-19 Pandemic, U.N. Press Release (April 9, 2020). Available at: <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-covid-19-pandemic-delivered>.

عليه الدول في رفع الدعوى أمام المحكمة والاستناد إلى رأي المحكمة الإفتائي كراي قانوني معتمد لإعطاء الاختصاص القضائي، ففي العام ١٩٤٧ سمحت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنظمة الصحة العالمية بطلب آراء استشارية من المحكمة "بشأن المسائل القانونية الناشئة في نطاق اختصاصها بخلاف الأسئلة المتعلقة بالعلاقات المتبادلة بين المنظمة والأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة الأخرى" (٧٣). وسبق أن طلبت المنظمة رأياً استشارياً من المحكمة يتعلق بالآثار الصحية والبيئية الناتجة من الأسلحة النووية من قبل دولة في حالة حرب أو نزاع مسلح آخر؛ كونه يعد انتهاكاً لدستور منظمة الصحة العالمية، وذلك في العام ١٩٩٣ (٧٤)، وقد أصدرت المحكمة رأيها بقبول الطلب مما يعطي للمنظمة الحق باستخلاص رأي استشاري مستقبلاً فيما يتعلق بالوباء الحالي لتحمل المسؤولية للدولة المسببة للضرر، وهو ما قد يمثل الأساس القانوني لأي دعوى قد ترفع بهذا الخصوص (٧٥).

المطلب الثالث

إثبات اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر مسؤولية الصين عن انتشار الوباء

يمكن لأحكام وقرارات المحكمة أن تقر الحقائق والقانون الواجب التطبيق، وتحدد ما إذا كانت الدولة مسؤولة عن أي فعل ينتهك التزاماتها الدولية، فأى فعل يعتبر غير مشروع دولياً إذا ما أمكن عزوه إلى سلوك الدولة أو عاملها أو أي أفراد يتصرفون بالنيابة عنها أو تحت سيطرتها، فإنه يقتضي مسؤولية دولية للدولة، ويتيح مجالاً للتعويضات. وفي هذه الحالة، تكون الدولة المعنية ملزمة بأن تجبر بشكل كامل الأضرار التي نجمت عن سلوكها غير المشروع دولياً، وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي فيما يتصل بمسؤولية الدولة. ومحكمة العدل الدولية في الأساس لا تحدد بنفسها مبلغ التعويضات في أحكامها، فمسألة التعويضات تحال ثانية إلى التفاوض المباشر بين الدول.

(٧٣) Agreement between the United Nations and the World Health Organization, (٧٣) (August 8, 1947) U.N.- WHO, 19/It U.N.T.S. 193, art. X, para. 2.

(٧٤) Legality of The Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion I.C.J. Report (1996) p. 226.

(٧٥) Nicholas Rostow, The World Health Organization, the International Court of Justice, and Nuclear Weapons, 20 Yale J. Int'l L. 151, 163 (1995).

وبمعنى آخر، يمكن الاستناد إلى المادة (٢٦) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من أجل الرجوع على الصين بالتعويض، وذلك أن المادة تلزم الدول بتنفيذ معاهداتها الدولية بحسن نية. وإثبات إخفاء الصين للمعلومات، كما سبق ذكره، يبين سوء نية الصين في الإدلاء بالمعلومات، وذلك لأسباب عديدة، بالتالي تنفيذها لالتزاماتها بسوء نية هو مخالفة صريحة ليس لاتفاقية فيينا فحسب، إنما للقواعد الآمرة في القانون الدولي والذي يعطي معه الاختصاص لمحكمة العدل الدولية بنظر الدعوى، فللمحكمة اختصاص الحكم في جميع النزاعات المحالة إليها من الدول بشأن طبيعة ومدى التعويض المقرر عن انتهاك التزام دولي، وهو ما نص عليه نظام المحكمة الأساسي في المادة (٣٦ ب-د)^(٧٦). وتذكر الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة أنه من الأمور الراسخة أن الدولة المسؤولة عن فعل ضار معترف به دولياً، تكون ملزمة بتقديم تعويض كامل عن الضرر الذي يحدثه ذلك الفعل كما في قضية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بين البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا السابقة^(٧٧). ومع ذلك لا تقرر المحكمة مباشرة مقدار وطبيعة التعويضات، فهي أولاً تبت بشأن وجود فعل ضار من جانب الدولة، ثم تحيل مسألة التعويضات مرة أخرى إلى الدول في إطار مرحلة ثانية من المفاوضات بعد إصدار أحكامها. ومع ذلك، تشرف المحكمة على هذه المفاوضات بالتأكيد على أنه: "في مرحلة الإجراءات القانونية المكرسة للتعويضات، لا يجوز للطرف أن يشك في استنتاجات حكمها؛ نظراً لأنها أصبحت مقررّة بحكم نهائي.."^(٧٨).

الخاتمة:

تسبب انتشار وباء COVID-19 بإعلان حالة الطوارئ في كثير من دول العالم، التي أصدرت العديد من القرارات والإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشاره بين

(٧٦) النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (١٩٤٥) المادة ٣٦ تنص على: "٢- الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي.. تقرر للمحكمة بولايتها الجبرية بنظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

(ب) أي مسألة من مسائل القانون الدولي؛

(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض".

(٧٧) Application of the Convention to Prevent and Punish the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), Corresponding Allegations, Judgment of 17 December 1997, I.C.J. (1997), p. 243, para 152.

(٧٨) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, supra, at 14, para 284.

الناس، لكن تبين أن لهذا الوباء سرعة انتشار كبيرة تسببت في انهيار العديد من الأنظمة الصحية حول العالم مثل إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا والولايات المتحدة، حيث أصدرت الحكومات تعليماتها للمرضى بالموث في المنازل لمن لا يحتاج إلى رعاية طبية طارئة، وهذا الأمر أدى إلى إطالة إغلاق الدول بالكامل مما ترتب عليه خسائر مادية واقتصادية هائلة.

ونتيجة لكل الخسائر والأضرار التي عانت منها الدول، ثارت فكرة المسؤولية الدولية وتحديد المتسبب في هذه الجائحة للتعويض عن الآثار الناجمة عنه، فأصر الكثير منهم على تحميل الصين - منشأ الفيروس - المسؤولية الدولية عن كل ما جرى، مطالبين بالتعويضات عن كل الخسائر الناجمة.

نتائج الدراسة:

ونستنتج مما سبق، أنه بتحليل فكرة المسؤولية الدولية ومدى قيام مسؤولية الصين عن هذا الوباء، نرى أن الصين تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة كل ما يعيشه العالم بسبب هذا المرض، فالصين تعاملت مع المجتمع الدولي بعدم وضوح وشفافية، ولم تقم بتزويد منظمة الصحة العالمية بكافة المعلومات والدراسات الضرورية من أجل منع انتشار الوباء منذ بدايته، بل كانت تصر على التأكيد بأن الأمور كلها تحت السيطرة، وأن هذا الوباء لا يشكل أي خطورة على العالم، كما أنه يمكن احتوائه بسهولة.

وقد أفرزت هذه الدراسة عدة نتائج نذكر منها:

- ١ - جاءت هذه الدراسة لتبين مدى انطباق قواعد المسؤولية الدولية على الصين، وذلك من عدة نظريات كالقول بوجود الخطأ أو العمل غير المشروع، بالإضافة إلى تحقق المسؤولية المشددة والتي قد تقوم بها، مما يتسبب معه بالأضرار في القانون الدولي، وبالتالي مدى إمكانية الرجوع على الدولة المسببة للضرر بالتعويض.
- ٢ - بيان مدى مخالفة الصين لبعض اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كضرورة الإخطار المسبق لمنظمة الصحة العالمية عن أي مرض صحي من شأنه أن يشكل طارئة صحية قد تثير قلقاً دولياً، والتزام الدول الأعضاء بتقديم تقارير إحصائية وبائية دورية للمنظمة عن حالة كل مرض وتكوينه وانتشاره وعلاجه، وهو ما أخفقت الصين في القيام به.
- ٣ - تضارب المعلومات التي قدمتها الصين لمنظمة الصحة العالمية للتقليل من أهمية هذا الوباء ولعدم نشر الهلع في العالم أدى إلى تعمد إخفاء المعلومات وانعدام الشفافية في التعامل مع الموضوع، ومن ثم رفض التحقيق فيه بأي شكل أمام مجلس الأمن

- من أجل دفع المسؤولية عنها، بالتالي انتهاك الصين لقواعد القانون الدولي العرفي بالتعامل مع الدول والمنظمات الدولية بمبدأ حسن النية، وهو ما وجد خلاف ذلك.
- ٤ - عدم إمكانية الصين التمسك بالقوة القاهرة للتخلص من المسؤولية الدولية خاصة مع انطباق قواعد المسؤولية الدولية عليها ما لم تثبت الصين تحقق القوة القاهرة بالتالي عدم مسؤوليتها الدولية لتمكن الرجوع عليها بالمقاضاة من قبل دول مختلفة لتعويض الأضرار الناتجة عن تفشي مرض COVID-19.
- ٥ - تحقق الاختصاص لمحكمة العدل الدولية في نظر دعوى المسؤولية ضد الصين لمخالفتها دستور منظمة الصحة العالمية كونه يعطي الاختصاص للمحكمة بنظر نزاع يتعلق بأعضائها، ومخالفتها لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والقواعد الآمرة في القانون الدولي.
- ٦ - إثبات المسؤولية الدولية على الصين بانتشار هذا الوباء عالمياً يعطي الحق بفتح باب التعويضات عن الأضرار الناجمة والخسائر الفادحة، كون أهم قواعد المسؤولية الدولية هو جبر الضرر والتعويض عن الفعل الضار.

التوصيات المطروحة:

- ١ - تشكيل فريق دولي بإشراف الأمم المتحدة من أجل التحقيق الكامل في انتشار هذا الوباء، وتأكيد الحاجة إلى الشفافية الكاملة، وتقاسم بيانات ومعلومات الصحة العامة الصحيحة داخل المجتمع الدولي؛ حتى يتسنى للدول اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف عن المتسبب بالكارثة.
- ٢ - دعم الدراسات العلمية والتجارب الطبية من أجل الوصول إلى علاج أو عقار للحد من انتشار هذا المرض عن طريق تعاون المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بدعم الجهود الدولية المشتركة من أجل تحقيق هذه الغاية.
- ٣ - إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية لنظر النزاع وتحديد المسؤولية وإصدار حكم بذلك، حيث نرى أن إنهاء الأمر بإصدار حكم قانوني سيكون أفضل من تأزيم الأوضاع سياسياً بين الصين والدول الأخرى؛ مما قد يؤثر على السلم والأمن الدوليين خاصة في حال تصعيد الأمور كما هو الحال اليوم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
- ٤ - حق الدول في الحصول على التعويضات عن الأضرار الكثيرة، وتحديد مقدار هذه التعويضات يكون عن طريق تحديد مدى تضرر الدولة وعمق الآثار الناجمة عن هذه الأزمة، بالتالي يختلف مقدار التعويض من دولة إلى أخرى.

المراجع

أولاً - المراجع العربية:

- أبو الخير أحمد عمر، القانون الدولي العام، أكاديمية دبي للنشر، دبي - الإمارات العربية المتحدة (١٩٩٤).
- أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر (٢٠٠٩).
- حمزة عتبي، بسبب فيروس كورونا.. معهد أبحاث بريطاني يدعو إلى مقاضاة الصين وإجبارها على تعويض الدول المتضررة، أخبار الآن (٧ أبريل ٢٠٢٠).
- رشاد عارف السيد، المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائيلية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، (٧ أبريل ٢٠٢٠).
- د. رشيد العنزي، القانون الدولي العام ودراسة خاصة عن موقف القانون الدولي من الاحتلال العراقي لدولة الكويت، الطبعة الخامسة (٢٠١٨).
- سالم محمد سليمان، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية، الدار الجماهيرية للنشر، (٢٠٠٠).
- سعيد محمد باناجه، دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي وقت السلم وقانون المنظمات الدولية الإقليمية، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان (١٩٨٥).
- شارل روسو، القانون الدولي العام، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت - لبنان (١٩٨٢).
- صلاح شلبي، الوجيز الميسر في القانون الدولي، جامعة الأزهر، القاهرة - مصر (٢٠١٥).
- د. محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، معهد الدراسات العربية، القاهرة - مصر (١٩٦٢).
- محمد الدقاق ومصطفى سلامة، القانون الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية - مصر (١٩٩٧).
- د. محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية - مصر (١٩٨٢).
- د. محسن الشيشكلي، مذكرات في القانون الدولي العام، جامعة الكويت، (١٩٨٤).

ثانياً – المراجع الأجنبية:

- Angelo Amante & Crispian Balmer, Italy in Coronavirus Lockdown as Deaths Soar and Economy Fades, Reuters (March 10, 2020).
- Andrea Maria Pilliconi, Covid-19: Italy is not a “Place of Safety” Anymore. Is the Decision to Close Italian Ports Compliant with Human Rights Obligations? 2 European J. Inte'l L. (April 23, 2020).
- Chaolin Huang & Yeming Wang, Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, 395 The Lancet 10223, 497 (February 15, 2020).
- David Brunnstrom, Pompeo says China still withholding coronavirus information, Reuters, (March 25, 2020).
- David Fidler, International Law and Infectious Diseases, (1999).
- David Fidler, SARS, Governance and the Globalization of Disease, (2004).
- David Gitter, Sandy Lu & Brock Erdahl, China Will Do Anything to Deflect Coronavirus Blame, Foreign Policy, (March 20, 2020).
- Dinah Shelton & Alex Kiss, Strict Liability in International Environmental Law, 1137 (2007).
- Dennis Pirages, Microsecurity: Disease Organisms and Human WellBeing, 18 Wash. Q. 5, (2010).
- Donald McNeil, China Identifies New Virus Causing Pneumonia like Illness, N.Y. Times (January 8, 2020).
- Federica Paddeu & Freya Jephcott, COVID-19 and Defences in the Law of State Responsibility, 1 European J. Inte'l L. (March 17, 2020).
- George Alleyne, Health and National Security, 30 Bull P.A.H.O 158, 160 (1996).

- Hiroshi Nakajima, Global Disease Threats and Foreign Policy, 4 Brown J. World Aff. 319 (1997).
- Jim Geraghty, The Comprehensive Timeline of China's COVID-19 Lies, National Review (March 23, 2020).
- Jonathan Marcus, Coronavirus: Trump Stands by China Lab Origin Theory for Virus, BBC News (May 1, 2020).
- John Kelson, State Responsibility and the Abnormally Dangerous Activity, 13 Harv. Int'l. L. J. 197 (1972).
- J.G. Lammers, International Responsibility and Liability for Damage Caused by Environmental Interferences, 31 Env'tl. Pol'y & L. 42 (2001).
- Karen Teber, WHO's Delayed PHEIC Decision and Wuhan Transportation Shutdown, Georgetown Univ. Medical Center. (2020).
- L. Caplan, State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory, 97 AM. J. Int'l L. 741-781 (2003).
- Mandy Zuo, Hong Kong Takes Emergency Measures as Mystery 'Pneumonia' Infects Dozens in China's Wuhan City, South China Morning Post (December 31, 2019).
- Marisa Tylor, Exclusive: U.S. Axed CDC Expert Job in China Months Before Virus Outbreak, Reuters (March 22, 2020).
- Matteo Chinazzi, The Effect of Travel Restrictions on the Spread of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak, 368 Science J. 395 (April 24, 2020).
- Michelle Nicholas, U.N. Security Council meets over coronavirus as it struggles to act, Reuters (April 10, 2020).
- Nectar Gan, China Pushes Back Against US Claims That Coronavirus Originated from Wuhan Lab, CNN (May 5, 2020).

- N. Swazo. The Right to Health, International Law, and Economic Justice, 5 Internet J. L. Healthcare Ethics. 1(2006).
- Nicholas Rostow, The World Health Organization, the International Court of Justice, and Nuclear Weapons, 20 Yale J. Int'l L. 151, 163 (1995).
- Peter Hasson, Top WHO Official Tedros Adhanom Ghebreyesus Won Election with China's Help. Now He's Running Interference for China on Coronavirus, Daily Caller (March 22, 2020).
- Peter Tzeng, Taking China to the International Court of Justice over COVID-19, 2 European J. Int'l L. (April 2, 2020).
- Paul Farmer, Social Inequalities and Emerging Infectious Diseases, 2 Emerging Infectious Diseases 259, (1996).
- Qun Li, Xuhua Guan & Peng Wu, Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia, 382 New England J. Med. 1199 (March 26, 2020).
- Responsibility and Liability Under International Law for Environmental Damage, JUSTITIA ET PACE- INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, Art. 4, At 3 (1997).
- Robert Webster, Wet Markets-A Continuing Source of Severe Acute Respiratory Syndrome and Influenza? 363 Rapid Review, 234 (January 17, 2004).
- Russell Miller & William Starshak, China's Responsibility for the Global Pandemic, Just Security (March 31, 2020).
- Ryan Dezember, U.S. Oil Costs Less Than Zero After a Sharp Monday Selloff, Wall St. J. (April 21, 2020).
- Sarthak Roy & Niriksha Sanghvi, COVID-19 Lockdown in India - Need for A Tailored Approach as One Size Does

- Not Fit All Its Regions, 1 European J. Inte'l L. (April 25, 2020).
- Shishir Gupta, UNSC Won't Discuss Covid-19; China Blocks it With Help from Russia, South Africa, Hindustan Times (March 27, 2020).
 - Stephen Morse, Jonna Mazet, Mark Woolhouse, Colin Parrish, Dennis Carroll, William Karesh, Carlos Zambrana-Torrel, Ian Lipkin, & Peter Daszak, Prediction and Prevention of the Next Pandemic Zoonosis, 380 Zoonoses 1965 (December 1, 2012).
 - Swargodeep Sarkar, Liability of China for Covid19 Outbreak, State Responsibility, and Jurisdictional Challenges, Modern Diplomacy (April 13, 2020).
 - Tullio Scovazzi, State Responsibility for Environmental Harm, 12 YB Int'l Envtl. L. 43 (2001).
 - Vittoria Offeddu, Benjamin Cowling & J.S. Peiris, Interventions in Live Poultry Markets for the Control of Avian Influenza: A Systematic Review, 2 One Health, 55 (2016).
 - Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two). Text reproduced as it appears in the annex to General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001, and corrected by document A/56/49(Vol. I)/Corr.4.

China's Responsibility for the spread of COVID-19 pandemic before the international court of justice.

Dr. Deymah Alweqyan

The spread of the epidemic COVID-19 caused the declaration of a State Emergency in many countries of the world, which caused many precautionary decisions and measures in order to limit its spread among people, but it turned out to be having a great speed of spread causing the collapse of many health systems around the world, where it pushed governments to adopt measures that included social distancing, quarantine, isolation, and travel restrictions. These measures, along with the virus itself, did not only had significant personal and human costs, but also it had a wider impact on the global economy.

As a result of all the losses and damages suffered by the countries, many of them insisted on accusing China - where the virus started - with international responsibility for all that happened, demanding compensation for all the resulting losses. Given the extent to which China is responsible for this epidemic, we see that China bears a large part of responsibility as a result of everything the world suffered because of this epidemic.

China dealt with the international community with a lack of clarity and transparency, and did not provide the World Health Organization with all the information and studies necessary to prevent the spread of the epidemic from its inception, but rather insisted on asserting that all things were under control and that this virus does not constitute any danger to the world as it can be easily contained. China, by hiding information and not clarifying the facts, has violated many international rules, whether in terms of international agreements such as the Vienna Convention on the Law of Treaties, or the Constitution of the World Health Organization, which affirms the necessity of a State's obligation to inform it of all relevant accurate information regarding any disease or health symptoms in the country which could affect the international community, in addition to violating the rules of customary international law by dealing with States and international organizations with the principle of good faith.

مدى التزام الإدارة معاونة المتعاقد بالعقد الإداري في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) دراسة تطبيقية على دولة الكويت

المستشار الدكتور / عبد الله حباب الرشدي
الفتوى والتشريع - مجلس الوزراء
دولة الكويت

ملخص:

تأتي هذه الدراسة تلبية لواجب وطني، وآخر أكاديمي استجابة لإعلان مجلة الحقوق بجامعة الكويت - التي أدين لها فضل تعليمي - للباحثين والمفكرين لإصدار عدد مُحكم مُكرس للأبحاث المتعلقة بموضوع جائحة فيروس كورونا COVID-19، وآثارها ونتائجها وما تفرزه من إشكاليات قانونية استشرافاً لوضع الحلول لها. حيث تشير الإحصائيات العالمية الرسمية إلى إصابة أكثر من مليوني شخص ووفاة ما يقارب مائة وخمسين ألف شخص (حتى كتابة هذه السطور)، ومن أجل ذلك تلاحت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومنها دولة الكويت بدءاً من تعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق الحدود وتنظيم وتقييد حركة المرور والتجول على نحو آفئ لنشوء إشكاليات إزاء عدم إعفاء المتعاقد مع الإدارة من التزاماته المنصوص عليها في العقد لمجرد حدوث الظرف الطارئ رغم الإرهاق الذي سببه هذا الظرف، طالما كان التنفيذ ممكناً ولم يصل إلى درجة الاستحالة. رغم أن ذلك الظرف خارج عن إرادة المتعاقد مع الإدارة، ولم يكن في مقدوره توقعه عند التعاقد، وقد يترتب عليها أن يكون تنفيذ العقد مرهقاً بدرجة كبيرة له، على نحو يحتم معاونته بما يسمح له بالاستمرار في تنفيذ العقد. وهو ما تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين، ويطلع تنفيذ العقد بطابع العدالة والرحمة والإنسانية.

مقدمة:

بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً بإمكانية وصف فاشية كوفيد-١٩ بالجائحة، انطلاقاً من قلقها البالغ إزاء المستوى المفزع لتفشي المرض (ووخامته)، والمستوى المفزع أيضاً من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة^(١).

(١) منظمة الصحة العالمية هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة. وقد أنشئت في ٧ أبريل ١٩٤٨. ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا. لطفاً راجع =

ودعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس، معللة ذلك بمخاوف بشأن "المستويات المقلقة للانتشار وشِدَّتِه" (٢).

ومجلس الوزراء في دولة الكويت اطلع في اجتماعه الاستثنائي رقم (٢٠٢٠/١٤) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (٢٠٢٠/٨)

= التسلسل الزمني لإجراءات منظمة الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على موقعها بالإنترنت:

<https://www.who.int/ar/news-room/detail/04-09-1441-who-timeline---covid-19>

(٢) سبق لدولة الكويت أن انضمت إلى منظمة الصحة العالمية ووافقت على دستورها في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٦٠، وقد صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بالموافقة على تعديل المادة السابعة من ميثاق منظمة الصحة العالمية ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ ١٧/٤/١٩٦٦ - العدد ٥٧٢ - السنة الثانية عشرة وبتاريخ ٢٩-٣-١٩٨٧، ثم صدر القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٥ بالموافقة على تعديل المادتين ٣٤ و ٥٥ من دستور منظمة الصحة العالمية ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ ٢٩/٦/١٩٧٥ - العدد ١٠٣٧ - السنة الحادية والعشرون، ثم صدر المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٩ بالموافقة على تعديل المادة ٧٤ من دستور منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ ٢٩/٦/١٩٧٥ - العدد ١٠٣٧ - السنة الحادية والعشرون، ثم صدر القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٤ بالموافقة على تعديل المادتين ٢٤ و ٢٥ من دستور منظمة الصحة العالمية ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ ١٣/٥/١٩٨٤ - العدد ١٥٤٧ - السنة الثلاثون، تلاه وبذات التعديل المرسوم بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٧ ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم - العدد ١٧١٢ - السنة الثالثة والثلاثون. وأخيراً صدر القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ بالموافقة على تعديل المادتين ٢٤ و ٢٥ من دستور منظمة الصحة العالمية ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ملحق العدد ٧٦٢ - السنة الثانية والخمسون الثلاثاء ٦ ربيع الأول ١٤٢٧هـ، ٤/٤/٢٠٠٦، فموجب المادة ٢٤ بعد التعديل أصبح عدد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة أربعة وثلاثين شخصاً بعد أن كان عددهم اثنين وثلاثين شخصاً، وتنتخب جمعية الصحة العالمية الدول الأعضاء المخول لها حق تعيين شخص للعمل في المجلس مع مراعاة التوزيع الجغرافي، على أن تنتخب ثلاثة على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل من المنظمات الإقليمية التي أنشئت طبقاً للمادة ٤٤، وتعين كل من هذه الدول الأعضاء للعمل في المجلس شخصاً من المؤهلين فنياً في ميدان الصحة، ويجوز أن يصحب هذا الشخص بدلاء ومستشارون. كما عالجت المادة ٢٥ من الدستور بعد التعديل مدة عضوية الدول الأعضاء، حيث نصت بأن تنتخب هذه الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن تكون للدولة الإضافية التي تنتخب من بين الأعضاء الأحد عشر الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد سريان هذا التعديل مدة عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولة عضو واحد على الأقل من كل منظمة إقليمية في كل عام.

للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد المنعقد بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠ بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه، حيث استكملت اللجنة مناقشاتها حول التطورات والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية من هذا الوباء واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من آثاره ومخاطره والإجراءات الصحية اللازمة للمواطنين والمقيمين وكذلك القادمين لدولة الكويت، واستمعت لشرح قدمه وزير الصحة بشأن الإجراءات الوقائية المقترحة للحد من انتشار الفيروس والتي تأتي في ضوء المستجدات التي طرأت، ومحاولة الحد من التجمعات وأسباب نشر العدوى لهذا الوباء، وقد أصدر المجلس قراره رقم (٣٩١) التالي:

(أولاً:.....)

- ١ - تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت اعتباراً من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق ١٣/٣/٢٠٢٠ حتى إشعار آخر..
- ٢ - منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق.
- ٣ - إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة.
- ٤ - أ - تعتبر الفترة من يوم الخميس الموافق ١٢/٣/٢٠٢٠ إلى يوم الخميس ٢٦/٣/٢٠٢٠ إجازة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠.
- ب - يكلف الوزراء بإصدار القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم...

ثانياً: تكليف الوزراء - كل فيما يخصه - بإعداد القرارات واللوائح اللازمة في شأن الإجراءات التنفيذية التفصيلية المتعلقة بالقرارات السابقة).

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ١٨/٢٠٢٠ المنعقد بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٠ أصدر قراره رقم (٤٣٣) التالي: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١/٤/أ) المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم (١٤/٢٠٢٠) المنعقد بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠ بشأن العطلة الرسمية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من الفترة من ١٢/٣/٢٠٢٠ وحتى ٢٦/٣/٢٠٢٠، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق ١٢/٤/٢٠٢٠.

كما استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي رقم (٢٣/٢٠٢٠) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦ إلى شرح من وزير الصحة بشأن الإجراءات الوقائية المقترحة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وأكد على تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، وأصدر المجلس قراره رقم (٤٨٩) التالي:

(١- تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٤/١٢ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٠ باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٠...).

كما اعتمد مجلس الوزراء تمديد تعطيل الموظفين إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية^(٣).

(٣) يذكر أن وزير الصحة أصدر القرار الوزاري رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية. ثم صدر القرار الوزاري رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٠ الذي قضى بمادته الأولى "يمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الخامسة بعد العصر وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٢ وحتى إشعار آخر" ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ملحق العدد ١٤٨٨ السنة السادسة والستون - الأربعاء ١ شعبان ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠/٣/٢٥ م. ثم صدر القرار الوزاري رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٠ الذي قضى بمادته الأولى "منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الرابعة بعد العصر وحتى الساعة الثامنة صباحاً من اليوم التالي، وذلك اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري ١٤٤١ هـ وحتى إشعار آخر". ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ملحق العدد ١٤٨٨ السنة السادسة والستون - الأربعاء ٣٠ شعبان ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠/٤/٢٣ م ثم صدر قراران وزاريان منفصلان رقما ٧١ و٧٢ لسنة ٢٠٢٠ يقضيان "بعزل منطقة (جليب الشيوخ) بمحافظة (الفروانية) ومنطقة (المهولة) بمحافظة (الأحمدي)، ولا يسمح بالدخول إليهما أو الخروج منهما بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية القائمة على تنفيذ العزل، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٦ ولحين إشعار آخر. ونُشر على التوالي في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ملحق العدد ١٤٨٨ السنة السادسة والستون - الخميس ١٦ شعبان ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠/٤/٢٣ م ثم أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارين منفصلين رقما ٣٣٥ و٣٣٦ لسنة ٢٠٢٠ يقضيان "تعزل منطقة جليب الشيوخ التابعة لمحافظة الفروانية ومنطقة المهولة التابعة لمحافظة الأحمدية عزلاً تاماً اعتباراً من الساعة (٥ مساءً) من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٦ وحتى إشعار آخر ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لمن يصدر له ترخيص بذلك وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه". =

ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١/٤/أ سالف البيان، والتشريعات ذات الصلة التي صدرت بناء عليه، قد قصت بتعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والدوائر والمؤسسات العامة، وتعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق الحدود وتنظيم وتقييد حركة المرور والتجول، وقد كان لها أثرها في توقف الشركات المتعاقدة مع الإدارة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتقديم خدماتها خلال فترة العطلة.

وهو ما قد يثير تطبيق نظرية الظروف الطارئة لتحقيق التوازن المالي للعقد الإداري لاعتبارات حسن سير المرفق العام بانتظام وإطراد التي تحتم على طرفي العقد أن يستمرا في تنفيذ التزاماتهما رغم الظروف الطارئ.

فلا يعفى المتعاقد من التزاماته المنصوص عليها في العقد لمجرد حدوث جائحة كورونا COVID-19 رغم الإرهاق الذي سببه هذا الظروف، طالما كان التنفيذ ممكناً ولم يصل إلى درجة الاستحالة. يقابله التزام الإدارة تجاهه بتحمل جزء من الخسارة التي تعرض لها بسبب ذلك الظروف الطارئ لمساعدته على تخطيه، ومن ثم استمراره في التنفيذ.

ولا ريب أن التزام جهة الإدارة على النحو المتقدم؛ جزئياً ومؤقتاً حتى زوال الظروف الطارئ؛ وعودة التوازن المالي للعقد؛ إما بزوال الظروف الطبيعية أو الاقتصادية التي كانت سبباً في إرهاب المتعاقد، أو من خلال إعادة النظر في شروط العقد من قبل الإدارة.

= ونُشرا على التوالي في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ملحق ٨ العدد ١٤٨٨ السنة السادسة والستون - الأربعاء ٢٢ شعبان ١٤٤١ هـ - ١٥/٤/٢٠٢٠ م.. ولما كانت الرعاية الصحية حقاً دستورياً تلتزم الحكومة بتوفيره، وحماية المواطنين مما قد يستجد أو يظهر من أوبئة محلية أو إقليمية أو عالمية، تحتم معها اتخاذ تدابير استثنائية للسيطرة أو الحد أو تطويق هذه الأمراض والفيروسات والأوبئة، وانسجاماً مع نص المادة (١٥) من الدستور "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة". فقد صدر تعديل تشريعي للقانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية يحتوي على تدابير استثنائية، استجابة للأوضاع الصحية الراهنة بتضمينه عقوبات رادعة تتناسب مع المستجدات الحالية. ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ملحق ٤ العدد ١٤٨٨ السنة السادسة والستون - الأحد ٥ شعبان ١٤٤١ هـ - ٢٩/٣/٢٠٢٠ م. ثم صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٠ المعدل بالقرار رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول وقضى "بحظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٠ من الساعة (٥ مساءً) إلى الساعة (٦ صباحاً) من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٦ وحتى إشعار آخر وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه". ونُشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ملحق ٦ العدد ١٤٨٨ السنة السادسة والستون - الخميس ١٦ شعبان ١٤٤١ هـ - ٩/٤/٢٠٢٠ م.

منهج البحث:

اقتصرت الدراسة على بيان مدى التزام الإدارة بمعاونة المتعاقد معها في العقد الإداري نتيجة جائحة كورونا COVID-19 باعتبارها من الظروف الطارئة وفقاً للنظام القانوني لدولة الكويت في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١/٤/أ القاضي بتعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والدوائر والمؤسسات العامة، والتشريعات ذات الصلة، وأثرها في توقف الشركات المتعاقدة مع الإدارة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتقديم خدماتها خلال فترة العطلة وتعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق الحدود وتنظيم وتقييد حركة المرور والتجول. وقامت الدراسة على منهج استقرائي وتطبيقي لكافة الحلول القضائية في أحكام محكمة التمييز "الدائرة الإدارية" المتعلقة بنظريات التوازن المالي وكذا فتاوى إدارة الفتوى والتشريع ذات الصلة، من خلال تبني إطار نظري متماسك.

خطة البحث:

تتألف من تقديم، وموضوع البحث، وخاتمة. والتفصيل فيما يلي:

تمهيد: في مفهوم ونشأة نظرية الظروف الطارئة

المبحث الأول: شروط تحقق نظرية الظروف الطارئة بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19

المطلب الأول: طبيعة الظروف الطارئة

المطلب الثاني: موضوع الظرف الطارئ

المطلب الثالث: عدم توقع الظرف الطارئ

المطلب الرابع: استقلال الظرف الطارئ عن إرادة المتعاقد

المطلب الخامس: الوقت الذي يجب أن يحدث فيه الظرف الطارئ.

المطلب السادس: أثر الظرف الطارئ

المبحث الثاني: النتائج القانونية للحوادث الطارئة بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19

المطلب الأول: استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته

المطلب الثاني: التزام الإدارة بتقديم المعاونة إلى المتعاقد

المطلب الثالث: حق المتعاقد في الحصول على التعويض

المطلب الرابع: نهاية الحوادث الطارئة

الخاتمة:

تمهيد

في مفهوم نظرية الظروف الطارئة ونشأتها

سبقت الشريعة الإسلامية غيرها من الشرائع بالأخذ بنظرية الظروف الطارئة، باعتبارها تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، وهي بذلك تختلف عن مبدأ سلطان الإرادة^(٤).

(٤) عرفت الشريعة الإسلامية نظرية الظروف الطارئة من خلال ثلاثة مظاهر، الأول: الضرر الذي يطرأ للمتعاقدين فيجيز له طلب فسخ العقد، والثاني: الجائحة التي تصيب الثمار فتجيز تعديل العقد (والجائحة هي ما أصاب الثمار أو البقول من السماء مثل البرد والقطط والعفن والعطش وفعل الأدمي إذا كان غالباً كالجيش الجرار)، والثالث: تقلب قيمة النقود. أما أساس نظرية الظروف الطارئة في الشريعة الإسلامية، فهو امتناع الضرر أي منع وقوع الضرر. ومن تطبيقاته (المشقة تجلب التيسير - الضرر يزال ويتفرع عنه: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها - امتناع أكل أموال الناس بالباطل - امتناع الحرمة (فالأعذار الشرعية لا مجال فيها للاجتهاد أو الاختيار، حيث تؤدي إلى انفساخ العقد تلقائياً دون أن يتوقف ذلك على تقدير المتعاقد، وذلك لمساسها بالبنیان التكليفي للإسلام). في تفصيل ذلك راجع: د. سعيد السيد علي - نظرية الظروف الطارئة - دون دار نشر - ٢٠٠٥ - ص ٣٩ وما بعدها. د. محمد محي الدين إبراهيم سليم: نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية ٢٠٠٧. يذكر أن الفقيه الفرنسي الأستاذ لامبير في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد بمدينة لاهاي سنة ١٩٣٢ قال: "إن نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي تعبر بصورة أكيدة وشاملة عن فكرة يوجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة، وفي القضاء الإداري الفرنسي في نظرية الظروف المقارنة، وفي القضاء الإنكليزي فيما أدخله من المرونة على نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب، وفي القضاء الدستوري الأمريكي في نظرية الحوادث المفاجئة" وقد نادى الأستاذ السنهوري أيضاً إلى الأخذ بنظرية الظروف الطارئة استناداً إلى نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية. فقد جاء في مقاله الذي نشر عام ١٩٣٦ بعنوان (وجوب تنقيح القانون المدني المصري)، قوله: "على أن هذه النظرية عادلة، ويمكن للمشرع المصري في تقنينه الجديد أن يأخذ بها استناداً إلى نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية، وهي نظرية فسيحة المدى، وخصبة النتائج تتسع لنظرية الظروف الطارئة، ولها تطبيقات كثيرة، منها نظرية العذر في فسخ الإيجار، وقد أصبحت نظرية الضرورة من النظريات الأساسية في الشريعة الإسلامية، وهي تماشي أحدث النظريات القانونية في هذا الموضوع" .. وإذا كان الفقه الإسلامي لم ترد فيه نظرية عامة للحوادث الطارئة على النحو الوارد في القوانين الوضعية، إلا أنه عرف تطبيقات مختلفة لهذه النظرية، أهمها: الأعذار في الإيجار، والمزارعة، والمساقاة، حيث يفسخ عقد الإيجار، والمزارعة، والمساقاة للعذر عند الحنفية، والجوائح في بيع الثمار، حيث ينقص الثمن بقدر معين عند المالكية والحنابلة. انظر: عبد السلام الترماني، نظرية الظروف الطارئة، بيروت، دار الفكر، ص ٣٥-٣٦. د. محمد رشيد قباني، نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الأولى، العدد الثاني، ١٩٨٠، ص ٨٥.

والظروف في اللغة جمع ظرف ومعناة دائر على وعاء الشيء، أما كلمة الطارئة فهي اسم الفاعل من طرأ، ومعناه جاء فجأة ومن بعيد، والطارئ هو الغريب خلاف الأصلي^(٥).

وفي الفقه الإداري لم يثر خلاف حول مضمون هذه النظرية ولا مداها، ولقد اقتبسها المشرع في الكويت ومعظم البلاد العربية من قضاء مجلس الدولة الفرنسي وفقاً لأصولها الموضوعية.

ويقصد بنظرية الظروف الطارئة؛ الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة، والتي تقع أثناء تنفيذ العقد، ولم يكن من الممكن توقعها عند التعاقد، ويترتب عليها أن تجعل تنفيذ العقد مرهقاً بدرجة كبيرة له مما يحتم تعويضه ومساعدته بما يسمح له بالاستمرار في تنفيذ العقد.

وتحقق نظرية الظروف الطارئة التوازن المالي للعقد الإداري في مواجهة ظروف معينة ليست من صنع الإدارة؛ كالأحداث السياسية (حروب) أو كالأحداث الاقتصادية (أزمات اقتصادية) أو كالأحداث الطبيعية (زلازل - سيول - براكين - أوبئة - وغيرها).

والقاعدة أن الحوادث الطارئة في نطاق العقود الإدارية تخضع للقانون الإداري، وتختلف سلطة القاضي حيالها اختلافاً كبيراً. بخلاف عقود الإدارة المدنية، فإنها تخضع للنظرية كما ينظمها القانون المدني، وأحكام الحوادث الطارئة.

ومتى استوفت نظرية الظروف المادية غير المتوقعة شروطها، جاز للمدين التمسك بها دون أدنى تمييز بين المتعاقدين.

ويتعين التقرير بأنه لا يوجد ثمة مانع قانوني يحول دون تمسك الإدارة بنظرية الحوادث الطارئة في مجال العقود الإدارية.

وفي الكويت أصبحت نظرية الظروف الطارئة مقررة بنصوص تشريعية ليس فقط بالنسبة للعقود الإدارية، ولكن أيضاً بالنسبة للعقود المدنية^(٦).

(٥) معجم المقاييس في اللغة، مادة ظرف، ص (٦٤٤)، المنجد في اللغة والأعلام، مادة طرأ، ص(٤٦٢).

(٦) ولقد أخذ المشرع في الكويت بهذه النظرية حيث نصت المادة (١٩٦) من المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بشأن القانون المدني على ما يلي: "العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز لاحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون". والمادة (١٩٨) كما يلي: "إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية =

وجدير بالملاحظة أن الظروف الطارئة تختلف عن القوة القاهرة في أنها لا تصل بتنفيذ الالتزام إلى درجة الاستحالة التي تعفي المتعاقد منه، وتؤدي إلى فسخ العقد. فالتنفيذ مع الظروف الطارئة يظل ممكناً بل واجباً وإن أصبح شاقاً للمتعاقد مع

= عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد من مقابله، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك "كما أخذ بها المشرع المصري في القانون المدني وجعلها من المبادئ المقررة بالنسبة لعقود القانون الخاص على خلاف الأوضاع في فرنسا. فنصت المادة (١٤٧) من القانون المصري المدني على أنه: "١- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله، إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون. ٢- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وإن لم يصبح مستحيلاً، جاء مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسائر فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف، بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك".

وفي هذا الشأن قررت إدارة الفتوى والتشريع بأن " .. مؤدى نظرية الظروف الطارئة حسبما وضع أصولها وقواعدها الفقه والقضاء الإداري إنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف، أو أحداث خارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة، لم تكن متوقعة عند التعاقد، وكان من شأنها وإن لم تجعل الالتزام مستحيلاً، الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد بأن جعلت تنفيذه مرهقاً للمتعاقد ومنزراً بخسارة فادحة، فإن هذا المتعاقد إذ يبقى ملزماً بالاستمرار في تنفيذ العقد يكون له الحق في مطالبة جهة الإدارة بمعاونته على هذه الظروف بأن تتحمل جزءاً من الخسارة، ويجب أن يترتب على الظرف الطارئ أن تنزل بالمتعهد خسارة فادحة تتعدى مجرد تفويت فرصة لتحقيق ربح، وتتجاوز قدر الخسارة العادية في الظروف الطبيعية، ويكون تحديدها عند حساب النتيجة النهائية التي حققها المتعهد من العقد باعتبار أن العقد وحدة واحدة يجب أن يفحص في مجموعة. وحيث إن الثابت من كتابكم رقم ٢٠٠٩ المؤرخ ١٩٨٢/٧/٤ أن متوسط المسافة التي تقطعها السيارة المؤجرة في اليوم ثمانين كيلو متراً، وتستهلك عشرين لتراً من البنزين تقريباً، كما أن من الثابت أن أسعار البنزين قبل الزيادة التي تقررت في شهر أبريل سنة ١٩٨٢ كانت (١٥ فلساً) للتر البنزين العادي و(٢٥) فلساً للتر البنزين الخصوصي، وأصبحت بعد الزيادة (٤٠) فلساً للتر البنزين العادي و(٥٠) فلساً للتر البنزين الخصوصي. وحيث إنه عند حساب النتيجة النهائية التي يحققها المتعهد المذكور من العقد المشار إليه إذا أخذ في الاعتبار قيمة إيجار السيارة وما تستهلكه من بنزين يومياً فإن الزيادة في أسعار البنزين سألقة البيان لا يترتب عليها تحميل المتعهد خسارة فادحة، وبذلك لا تجد نظرية الظروف الطارئة مجالاً لإعمالها على العقد سالف البيان. لذلك نرى أنه لا محل لزيادة الأجرة اليومية للسيارات سألقة البيان تعويضاً عن الارتفاع في أسعار الوقود" حول هذا المعنى: فتوى إدارة الفتوى والتشريع رقم: ٨٢/٢٥٩/٢ بتاريخ: ١٩٨٢/٧/١٦ منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع من أول أكتوبر سنة ١٩٨١ حتى آخر سبتمبر سنة ١٩٨٢ - المجموعة الثامنة - صفحة رقم: ٣٤٠.

الإدارة، إلا أن المشقة توازن بحق المتعاقد في التعويض، وليس بانقضاء الالتزام حتى لا يتوقف سير المرفق العام^(٧).

وعلى ذلك فإذا حدثت ظروف خارجة عن إرادة المتعاقد، غير متوقعة عند إبرام العقد، ومن شأنها قلب اقتصاديات العقد، دون أن تجعل تنفيذه مستحيلاً، فإنه يحق للمتعاقد، رغم التزامه بالاستمرار في التنفيذ، الحصول على مساعدة الإدارة، كي يتخطى هذه الظروف، وذلك بأن تتحمل الإدارة جزءاً من الأعباء التي جدت^(٨).

(٧) راجع: د. محمد فؤاد عبد الباسط: العقد الإداري (المقومات - الإجراءات - الآثار)، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠٠٦، ص ٤٢٤.

(٨) وجدير بالذكر أنه إذا كانت نظرية الظروف الطارئة قد انتكست في عقود الأفراد الخاضعة لأحكام القانون المدني، فإنها ظهرت في نطاق العقود الإدارية الخاضعة لأحكام القانون العام، وكانت الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ هي المناسبة التي أتاحت لمجلس الدولة الفرنسي تطبيق هذه النظرية بشكل واضح. وكان أول حكم أخذ فيه مجلس الدولة الفرنسي بنظرية الظروف الطارئة وطبقها بشكل ظاهر ومفصل استلقت الأنظار، وأثار انتباه الفقه والقضاء هو الحكم المشهور الصادر بتاريخ ٣٠ مارس ١٩١٦ في قضية شركة غاز مدنية بوردو. C.E. 24 Mars 1916. Compagnie du Gaz de Bordeaux S. 1916, 3,17. Concl. Chardenet note Hauriou.

فإذا كانت الأوضاع الناشئة عن الحرب العالمية الأولى بمثابة "الجو الملائم" الذي ولدت فيه النظرية، بحكم مجلس الدولة الفرنسي الشهير في ٣٠ مارس ١٩١٦ والمعروف باسم Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux، فقد حدث أن كانت شركة غاز بوردو ملزمة بتوريد الغاز للمدينة، وفقاً لسعر معين، ثم حدث أن ارتفع سعر الفحم - وهو المادة الأولية اللازمة لإنتاج الغاز - ارتفاعاً فاحشاً من ٢٨ إلى ٧٣ فرنك للطن، وذلك بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى إصابة الشركة بعبء كبير، ففضى مجلس الدولة بأنه يحق للمتعاقد مع الإدارة - في هذه الحالة - أن يطلب من الإدارة أن تساهم في الخسائر التي تلحق به. ثم توالى بعد ذلك أحكام مجلس الدولة في هذا المعنى. يذكر أن مجلس الدولة الفرنسي أعقب هذا الحكم بأحكام عديدة طعن فيها النظرية، ثم طورها ووسع من نطاق تطبيقها، فامتد إلى جميع العقود الإدارية، ولم يقصرها المجلس لمواجهة الظروف الاقتصادية أو الطبيعية التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد وتكون أجنبية تماماً عن الإدارة والمتعاقد معها، بل طبقها على كافة الظروف الطارئة التي تؤدي إلى الإخلال الجسيم باقتصاديات العقد، سواء أكانت هذه الظروف اقتصادية أم طبيعية أم سياسية. كما أضاف لذلك مجلس الدولة الفرنسي الإجراءات الصادرة من السلطات العامة، ورغم ذلك فقد ظل حتى الآن مجال تطبيقها محصوراً في نطاق العقود الإدارية، ولم تتعداه إلى العقود المدنية. راجع مؤلفنا: العقود الإدارية النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن - مع شرح القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية - الطبعة الأولى ٢٠١٧ - ص ٤٣١.

المبحث الأول

شروط تحقق نظرية الظروف الطارئة

بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19)

تمهيد وتقسيم:

لقد أرسى القضاء الإداري الشروط التي يتعين تحققها، حتى يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، كما ساهم الفقه بإضافة بعض الشروط الأخرى. وعلى ذلك يجب أن تجتمع عدة شروط حتى يمكن تطبيق أحكام هذه النظرية نتيجة جائحة فيروس كورونا COVID-19، وهذه الشروط ترجع إلى طبيعة الحادث الطارئ (مطلب أول)، وموضوعه (مطلب ثانٍ)، وعدم توقعه (مطلب ثالث)، واستقلاله عن إرادة المتعاقد (مطلب رابع) والوقت الذي يجب أن يحدث فيه (مطلب خامس) وأخيراً أثر تحقق الحادث الطارئ (مطلب سادس) على النحو الآتي:

المطلب الأول

طبيعة الظروف الطارئة

تتسع نظرية الظروف الطارئة لتشمل الأسباب الراجعة إلى الطبيعة، وتدخل السلطة الإدارية، مما يجعل التمييز بينهما، وبين كل من نظرية الظروف المادية غير المتوقعة، ونظرية عمل الأمير، أمراً صعباً يثق في بعض الأحيان. فالحادث الاستثنائي هو الذي يشذ عن المجرى المعتاد للأمر، فيخرج على الأصل الذي ألفه الناس بما يجعله نادر الوقوع، وإن لم يكن غير مسبوق. ويعتبر من قبيل ذلك، المخاطر الإدارية؛ أي التشريعات واللوائح الصادرة من السلطات العامة (غير الجهة المتعاقدة) سواء أكانت في صورة إجراءات عامة، مثل: فرض ضرائب جديدة، أو تخفيض قيمة العملة، أو وضع قيود على تداولها^(٩)، أو تعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق الحدود وتنظيم وتقييد حركة المرور والتجول كما هو الحال بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19. وبناء على ذلك إذا أعطت الشروط العامة للمناقصة الحق للمتعاقد في المطالبة

(٩) راجع: د. سليمان الطماوي - الأسس العامة للعقود الإدارية - دراسة مقارنة - دار الفكر العربي - الطبعة الخامسة - ١٩٩١ - ص ٦٧٤.

بأية تكلفة يتحملها نتيجة التغييرات في التشريعات، فإنها بهذه المثابة تكون ملزمة للطرفين، ويترتب على ذلك حق المتعاقد في التعويض.

وقد كان مجلس الدولة الفرنسي يحصر المخاطر الإدارية التي تكون سبباً في تحقق شروط نظرية الظروف الطارئة في تلك الإجراءات الصادرة من السلطات العامة الأخرى (غير الجهة المتعاقدة)، إلا أنه مؤخراً عدل عن هذا الاتجاه، وذهب إلى إمكان تطبيق نظرية الظروف الطارئة، سواء أكان الفعل أو الإجراء العام الذي سبب الضرر راجعاً إلى جهة الإدارة أم غيرها^(١٠) في حالة عدم اكتمال تحقق شروط نظرية عمل الأمير في هذه الحالة.

وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الحكمة من إنشاء النظرية هو تمكين المتعاقدين من السير في استغلال المرفق العام، وتحقيق العدالة بالنسبة لشخص قبل التعاون بحسن نية مع الإدارة في تسيير مرفق عام، ولا يعقل أن يتقرر للمتعاقد حق في التعويض طبقاً لنظرية الظروف الطارئة في حالة حدوث ظرف لا دخل لإرادة السلطة الإدارية فيه، وأن يحرم من هذا الحق إذا وقع الحادث بإرادة السلطة الإدارية طالما أنه لا دخل لإرادته في حدوثه، فنظرية عمل الأمير وإن كانت قد تكفلت بالأعمال أو الإجراءات التي تصدر من الجهة المتعاقدة، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا تتوافر فيها جميع شروط هذه النظرية، وبالتالي يحرم المتعاقد من التعويض استناداً إليها، ولذلك فإنه من المتعين طبقاً لمبادئ العدالة وتحقيقاً للأهداف التي أنشئت نظرية الظروف الطارئة لتحقيقها أن يكون للمتعاقد حق المطالبة بالتعويض طبقاً لهذه النظرية^(١١).

وعلى ذلك فإن القضاء الإداري في كل من الكويت^(١٢) ومصر^(١٣) مستقر على ضرورة أن يكون الإجراء صادراً من جهة غير الجهة الإدارية المتعاقدة.

(١٠) راجع: د. إبراهيم محمد علي - آثار العقود الإدارية - دار - ص ٢٦٤.

(١١) راجع: د. محمد فؤاد مهنا - مبادئ وأحكام القانون الإداري ١٩٧٨ - دون ناشر - ص ٧٣٦.

(١٢) على سبيل المثال راجع الطعن رقم ٨٣٤ لسنة ٢٠٠٢ تمييز إداري جلسة ٢٠٠٣/١١/١٠ منشور في مجلة القضاء والقانون السنة ٣١ - الجزء الثالث - ص ٢١٣.

(١٣) على سبيل المثال راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق، جلسة ١٩٨٧/٥/١٦ وحكمها في الطعن رقم ٥٤٩ و ٨٠١ لسنة ٣٥ ق، جلسة ١٩٩٣/٤/٤.

المطلب الثاني موضوع الحادث الطارئ

يجب أن تؤثر الحوادث الطارئة على أحد العناصر المرتبطة بالعقد بدرجة كافية، حتى يمكن أن تحدث النتيجة، وهي قلب اقتصاديات العقد قبل تمام تنفيذه.

فإذا حدثت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) قبل إبرام العقد، ثم واصل المتعاقد عملية الإبرام، فإنه يكون قد قبل التنفيذ رغم هذا الحادث الطارئ وليس له المطالبة فيما بعد بالتعويض استناداً إلى النظرية.

وجدير بالملاحظة أنه إذا حدث ظرف طارئ بعد انتهاء المهلة المبينة بالعقد، والمحددة لإنجاز الأعمال، فإنه إذا كان التأخير بسبب المتعاقد مع الإدارة، فيكون هو المسؤول عن كل تبعات الظرف الطارئ، بالإضافة إلى مسؤوليته العقدية عن تأخره في التنفيذ^(١٤).

أما إذا وافقت الإدارة على امتداد تنفيذ العقد بناء على طلب المتعاقد، فيتعين في هذه الحالة إعمال نظرية الظروف الطارئة^(١٥).

ومتى كان التأخير راجعاً إلى جهة الإدارة، فإنه لا محالة من تحملها نتيجة ذلك، ويتعين إعمال نظرية الأمير في هذه الحالة، وليس نظرية الظروف الطارئة، وبالتالي يحصل المتعاقد على التعويض الكامل نتيجة خطأ الإدارة^(١٦).

المطلب الثالث عدم توقع الحادث الطارئ

الحادث لا يكون طارئاً إلا إذا فاق كل تقدير يمكن أن يتوقعه الطرفان، ويتجاوز الحدود القصوى لأي احتمال، ويصدق هذا الوصف على الآثار المتخذة للتصدى لجائحة فيروس كورونا COVID-19.

(١٤) حول هذا المعنى: راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعين رقمي ٨٤٣ و ٩٢٢ لسنة ٢٦ ق، جلسة ١٩٨٢/١١/٢٠، الموسوعة، الجزء ١٨، ص ٩٠٤، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، جلسة ١٩٨٠/٢/٦، ملف ٧٠٢/٢/٣٢، الموسوعة، الجزء ١٨، ص ٩٠٢.

(١٥) انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣١٥٠ لسنة ٦ ق، جلسة ١٩٦٢/٦/٩، الموسوعة، الجزء ١٨، ص ٩٠٠.

(١٦) راجع: د. جابر جاد نصار - العقود الإدارية - الطبعة الثانية - دار النهضة العربية - ص ٣٣٦.

ذلك أن المخاطر العادية *aleas ordinaires* هي تلك التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان عند إبرام العقد، ويجب أن يتحملها المتعاقد. بخلاف المخاطر غير العادية *alae extraordinaires*، التي لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها، فتكون محلاً للتعويض^(١٧).

ويتفرع من كون الحادث غير متوقع أنه لا يمكن دفعه؛ ذلك أن الحادث الذي يمكن دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقعاً أو غير متوقع.

على أن عنصر المفاجأة أحد الخصائص الأساسية التي تتميز بها فكرة عدم التوقع سواء في مجالات العلاقات التعاقدية أو خارجها، ويستدل القاضي على ذلك من خلال الإحالة إلى ظرف الزمان والمكان؛ فعلى سبيل المثال: فالأمطار كأحدى الظواهر الطبيعية قد تكون أكثر وقوعاً في بعض الفصول عن بعضها الآخر، وفي بعض الأقاليم عنها في بعضها الآخر. ولذلك فإن احتمالات وتواتر وقوع الحدث يجب أن يوضع في اعتبار القاضي عند تقديره لتوقع أو عدم إمكان توقع حادث ما. كما أن للمدة التي يستغرقها الحادث، أو الظرف الذي اعترض تنفيذ العقد دوراً كبيراً فيما يتعلق بالتوقع أو عدم التوقع، فالإرهاق الذي يصيب المتعاقد قد يرجع بصورة مباشرة لطول الفترة غير العادية التي أثر فيها الفعل أو الحادث على تنفيذ العقد. فالحادث أو الظرف قد يوصف بأنه متوقع أو غير متوقع بحسب المدة التي يستغرقها. كما يتم استبعاد عدم التوقع بتكرار وقوع الفعل أو الحادث (مثل فيضان نهر معين، أو بركان في منطقة محددة)، أو كون المتعاقد يقيم في منطقة معروفة بطبقتها الصخرية أو لكثرة منسوب المياه فيها وهي ذاتها محل تنفيذ العقد^(١٨).

(١٧) وفي هذا الشأن قررت إدارة الفتوى والتشريع بأنه " .. من حيث إن الفقه والقضاء الإداري قد استقرا على أن التدخل لتحقيق التوازن المالي تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة رهينة بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة، أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حساب المتعاقد عند إبرام العقد ولا يستطيع دفعها، وأن يكون من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، ومؤدى إعمال هذه النظرية: بعد توافر شروطها أن تشارك الجهة الإدارية في نصيب من الخسائر التي حاقّت بالمتعاقد معها طوال فترة الظروف الطارئة وذلك ضماناً لتنفيذ العقد الإداري واستمراراً لسير المرفق العام الذي يخدمه " راجع فتوى إدارة الفتوى والتشريع رقم: ٩٥/١٠٩/٢ - ٢٤٦٣ بتاريخ: ٢٤/١٠/١٩٩٥ منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع يناير ١٩٩٠ - ديسمبر ٢٠٠٢ الأحرف (م، ن، هـ، و) عدا الموظف - الوظيفة العامة الجزء الرابع، أكتوبر ٢٠٠٧، ص ٤٠٣.

(١٨) لمزيد من التفاصيل، يراجع: د. علي محمد علي عبد المولى - الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري - رسالة دكتوراة - جامعة عين شمس ١٩٩١ - ص ٢٦٨ وما بعدها.

ولا ريب أن تقدير شرط عدم التوقع يتم بتاريخ إبرام العقد، فإذا تم تجديد العقد فيتم تقدير شرط عدم التوقع اعتباراً من هذا الوقت.

وعلى ذلك لو وقع حادث طارئ لكنه كان من الممكن تفاديه، أو درء النتائج المترتبة عليه ببذل الجهد المعقول فلا محل لتطبيق النظرية.

ومعيار تحديد كون الحادث ممكن تفاديه أو دفعه ليس معياراً ذاتياً قوامه المتعاقد نفسه، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه الرجل العادي^(١٩).

(١٩) وفي هذا الشأن قضت محكمة التمييز بأنه: "من المقرر أن مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف وأحداث لم تكن متوقعة عند إبرامه، أو بالإمكان توقعها ولا يملك لها المتعاقد دفعةً وكان من شأنها - وإن لم تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلاً، إلا أنها تجعله مرهقاً، فتتزل بالمتعاقد خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً، فيكون للمتعاقد المضرور أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة بتعويضه عنها تعويضاً جزئياً، فلا يكفي لإعمال هذه النظرية نقصان الربح أو فوات الكسب، وأن معيار الخسارة هو معيار موضوعي يتعلق بالصفقة محل التعاقد وليس ذاتياً بالنسبة إلى شخص المدين وظروفه، وأن تقدير ما إذا كان الظرف الطارئ متوقعاً أو غير متوقع، ومدى تأثيره على الالتزامات الناشئة عن العقد، وما إذا كان تنفيذ الالتزام أصبح مرهقاً للمدين، وألحق به خسارة فادحة، هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية" راجع: حكمها في الطعن رقم ١١١ لسنة ٢٠٠٣ تمييز إداري جلسة ٢٠٠٣/١/٥ طعن غير منشور.

كما قررت إدارة الفتوى والتشريع في بواكير فتاواها بأن التسليم بارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد والمعدات وأسعار الشحن والتأمين المصاحب لحرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ يعتبر ظرفاً طارئاً في مفهوم هذه النظرية. وجاء نص الفتوى يجري على: "إن نظرية الظروف الطارئة قد رسخت في القانون الإداري وأخذ بها المشرع الكويتي في المادة (١٤٦) من قانون التجارة، ومؤدى هذه النظرية أنه إذا طرأت أثناء العقد الإداري ظروف، أو أحداث خارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، وكان من شأنها أنها لم تجعل الالتزام مستحيلاً الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد بأن جعلت تنفيذه مرهقاً للمتعاقد منذراً بخسارة فادحة، فإن هذا المتعاقد إذ يبقى ملزماً بالاستمرار في تنفيذ العقد رغم هذه الظروف يكون له الحق في مطالبة جهة الإدارة بمعاونته على مواجهة هذه الظروف والأحداث بأن تتحمل جزءاً من الخسارة التي تترتب عليها. ومع التسليم بأن ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد والمعدات وأسعار الشحن والتأمين المصاحب لحرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ يعتبر ظرفاً طارئاً في مفهوم هذه النظرية وأنه في خصوص الحالة المعروضة لم يكن أمراً متوقعاً عندما تقدمت شركة.... بعبائها قبيل ١٢/٨/١٩٧٣ فإنه يبقى في الطلب المقدم من هذه الشركة آخر وأهم شروط النظرية، وهو يتعلق بأثر الظرف الطارئ على العقد. إذ يجب لتطبيق النظرية أن يترتب على الظرف الطارئ قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب بأن تنزل بالمتعاقد مع جهة الإدارة خسارة تتعدى مجرد فوات فرصة تحقيق الربح، وتتجاوز حد الخسارة التي تحدث أحياناً في التعامل في الظروف العادية حيث التجارة مكسب وخسارة، وتبدو فداحتها =

المطلب الرابع

استقلال الحادث الطارئ عن إرادة المتعاقد

يترتب على الظرف الطارئ عدم توقعه وعدم إمكانية دفعه، بأن يكون خارجاً عن إرادة المتعاقدين؛ لذا ينبغي أن يكون الحادث الطارئ مستقلاً عن إرادة المتعاقد مع الإدارة. وخلافاً لشرط عدم التوقع الذي يتم تقديره في ضوء الظروف، فإن هذا الشرط يتم تقديره بصفة مطلقة.

ولازم ذلك أنه لا يجوز للمتعاقد التمسك بنظرية الحوادث الطارئة، كلما كان له دخل فيها، سواء أدى إليها، أو ارتكب أي خطأ أدى إلى زيادة أعبائه.

غير أنه قد ينشأ الحادث الطارئ عن عمل الإدارة، ويؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد، وبالتالي يجوز للمتعاقد التمسك بنظرية الحوادث الطارئة، خصوصاً إذا لم تتوافر شروط نظرية عمل الأمير^(٢٠).

= في النتيجة النهائية التي يحققها المتعاقد بعد انتهاء جميع أعمال العقد، فإذا كانت الخسارة طفيفة أو كانت في حدود الخسارة المألوفة في التعامل في الظروف العادية فلا يكون هناك محل لإعمال نظرية الظروف الطارئة. وحتى إذا بلغت الخسارة الحد من الجسامة الذي تتطلبه النظرية، وتوافرت بهذا جميع شروط تطبيقها، فإن التعويض على أساسها لا يقوم على أساس التعويض الكامل عن الخسارة بل على فكرة توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد وجهة الإدارة بأن يتحمل المتعاقد جانباً من الخسارة، وتحمل جهة الإدارة الجانب الآخر، وإن كان من المألوف عملاً أن تتحمل الإدارة الجانب الأكبر" راجع: فتوى رقم ٢٣٩٠/٢ في ١٩٧٦/٤/٧ منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها الفتوى والتشريع خلال سنتين - من أول أكتوبر سنة ١٩٧٥ حتى آخر سبتمبر سنة ١٩٧٧ - المجموعة الثالثة - صفحة رقم: ٥٤.

(٢٠) ويُعد بعض الفقه اعتبار الزلازل والأعاصير والجليد غير العادي أو الحرارة الشديدة جداً والفيضانات، ونقصان المحصول بسبب الجفاف وإعلان الحرب من قبيل الحوادث الاستثنائية أو الطارئة التي لا يمكن توقعها ولا دفعها، بينما لم يعتبر من الحوادث الاستثنائية تقلب الأسعار في زمن الحرب (بالنسبة للعقود التي تبرم أثناء هذه الحرب أو على وشك وقوعها)، أو عدم وجود سفن لسفر المتعاقد لكي ينفذ التزامه، واستمرار الصقيع (في جبل لبنان) لغاية (مايو) أو (يونيه) يعتبر من الطوارئ العادية التي ينتظر المزارع حتماً وقوعها، كما لا تعتبر العواصف والأمواج العالمية التي تغطي السفينة ظرفاً طارئاً، لأنها متوقعة خاصة في فصل الشتاء وفي المحيط الأطلسي، ما لم تكن من الجسامة والشدة بحيث لا يمكن توقعها، وإغلاق الحدود بين سوريا والأردن لا يعتبر حادثاً استثنائياً بالنسبة لملتزم تقديم المواد الغذائية للجيش، ما لم يثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير كمية المواد الغذائية التي التزم بتقديمها، وأنه لم يكن باستطاعته شراؤها من الأسواق الأخرى. راجع: د. عبد السلام الترماني: نظرية الظروف الطارئة، دار الفكر، دون سنة نشر، ص ١٤٠ وما بعدها.

المطلب الخامس

الوقت الذي يجب أن يحدث فيه الظرف الطارئ

القاعدة أنه يتعين أن تطرأ الحوادث الطارئة "جائحة فيروس كورونا (COVID-19)" خلال مدة تنفيذ العقد الإداري؛ أي في الفترة التي تعقب إبرام وحتى نهاية العقد.

غير أن هذه القاعدة ليست طليقة من كل قيد، فالظروف التي تطرأ قبل إبرام العقد وتجعل من المتعاقد ملتزماً بعطائه بمجرد تقديمه، يتعين الاعتداد بها في وقتها وإعمال أثرها الطبيعي كأساس لتعويضه.

فقد تطرأ ظروف بعد انتهاء العقد، وتوافق الإدارة على امتداد المدة المحددة في العقد للتنفيذ، وفي هذه الأثناء يقع الحادث الطارئ، فيحق للمتعاقد التمسك بنظرية الظروف الطارئة بالنظر إلى أن التأخر في التنفيذ راجع إلى خطأ الإدارة وليس خطئه^(٢١).

(٢١) وقد قررت إدارة الفتوى والتشريع بأنه: "وحيث إنه بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة فإن هذه النظرية قد رسخت في القانون الإداري، وأخذ بها المشرع الكويتي في المادة (١٤٦) من قانون التجارة وشروط تطبيق هذه النظرية تكن في: ١- أن تطرأ بعد إبرام العقد حوادث استثنائية عامة، مثل: زلزال أو حرب أو قيام تسعيرة رسمية، أو ارتفاع باهظ في الأسعار. ٢- أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها، فإذا كانت متوقعة أو كان يمكن توقعها فلا سبيل لتطبيق هذه النظرية. ٣- أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة، فالخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي، فإن التعامل مكسب وخسارة، وإرهاق المدين لا ينظر فيه إلا للصفقة التي أبرم في شأنها العقد، فإذا توافرت هذه الشروط فإن المتعاقد يبقئ ملزماً بالاستمرار في تنفيذ العقد رغم هذه الحوادث، ويكون له الحق في مطالبة جهة الإدارة بمعاونته على مواجهة هذه الحوادث بأن تتحمل جزءاً من الخسارة التي تترتب عليها. وعلى هذا فإذا كانت الزيادة في الأسعار - بالنسبة لقيمة العقد - لا تهدد المفاوض بخسارة فادحة، ولا تعدو أن تكون مجرد إنقاص لربحه، فمن ثم فإن شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة لا تعد متوافرة في الحالة المعروضة. ومن حيث إنه عن نظرية فعل الأمير، فإن هذه النظرية قديمة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وهي من خلق هذا المجلس، وهي نظرية غير واضحة الحدود وأحياناً يقع الخلط بينها وبين نظرية الظروف الطارئة، وهي غير معروفة في القانون الكويتي، ولم يسبق تطبيق هذه النظرية، ويضاف إلى ذلك أن هناك نصاً في العقد يمنع زيادة الأسعار، ومن المقرر أن مثل هذا النص يمنع تطبيق هذه النظرية ولا يبقئ إلا نظرية الظروف الطارئة، وقد أوضحنا عدم توافر شروطها "راجع: فتوى رقم ٣٥٧٦/٢ في ٩/٤/١٩٨٠ منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع - من أول أكتوبر سنة ١٩٧٩ حتى آخر سبتمبر سنة ١٩٨٠ - المجموعة السادسة - صفحة رقم: ١١٣.

المطلب السادس أثر الحادث الطارئ

يتعين أن يؤدي الظرف الطارئ "جائحة فيروس كورونا COVID-19" إلى إصابة المتعاقد بخسائر فادحة، تجاوز الخسائر العادية المألوفة في التعامل بحيث يترتب عليها قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب، لدرجة أن يصبح تنفيذ المتعاقد لالتزامه التعاقدية في ظله أمراً مرهقاً للغاية - وإن لم يصبح مستحيلاً - ويستوي في ذلك أن يكون مصدر الظرف الطارئ ظروفاً طبيعية أو اقتصادية أو سياسية أو إدارية.

ومؤدى ذلك أن مناط انطباق نظرية الظروف الطارئة متى كان الحادث الطارئ من شأنه اضطراب الأوضاع المالية للعقد والمتعاقد اضطراباً خطيراً يهدد بانتهياره، ويؤدي إلى خسارة تفوق كل توقع^(٢٢).

ويعتبر شرط الإرهاق الذي يصيب المتعاقد مع الإدارة أهم شرط من شروط النظرية على الإطلاق، وتحقيقه هو الذي يضع النظرية موضع التنفيذ، وينقلها من الحالة النظرية إلى الحالة العملية.

وجدير بالذكر أن الإرهاق هو وصف يلحق بالالتزام أحد المتعاقدين، يجعل تنفيذه لالتزامه مهدداً بإياه بخسارة فادحة نتيجة تأثر هذا الالتزام بظرف طرأ بعد إبرام العقد ونطاقه حدود العقد، لا يتعداها إلى مال المتعاقد الخاص وثرواته، فإذا كانت الخسارة

(٢٢) وفي هذا الشأن قضت محكمة التمييز بأن: " .. تطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود الإدارية رهين بأن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو سياسية لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، ولا يملك المتعاقد لها دفْعاً، ويكون من شأنها - وإن لم تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مستحيلاً - أن تجعله مرهقاً شديداً، فتتزلز بالمتعاقدين خسارة فادحة غير مألوفة في التعامل، تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة كان للمتعاقد المضار أن يطلب من الجهة الإدارية مشاركتة في هذه الخسارة التي تحملها بتعويضه عنها تعويضاً جزئياً دون تعديل للالتزامات العقدية، ولا يستهدف هذا التعويض تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره أو الخسارة العادية المألوفة في التعامل، وإنما أساسه تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة لجزء من الخسارة المحققة الفادحة التي أصابت المتعاقد؛ بغرض إعادة التوازن المالي إلى العقد ولضمان تنفيذه على الوجه الأكمل واستمرار سير المرفق العام الذي يخدمه تحقيقاً للصالح العام " راجع: حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ١٣ لسنة ٢٠١٣ تمييز إداري جلسة ٢٠١٥/٢/٤ حكم غير منشور. وبذات الألفاظ أيضاً راجع: الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٢٠١٢ تمييز إداري جلسة ٢٠١٦/٤/٢٠. حكم غير منشور.

عادية متوقعة، أو إذا انحصر أثر الظرف الطارئ في تفويت فرصة الربح على المتعاقد، فإنه لا يكون هناك إرهاب يستوجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

وأخيراً فإنه يتم تقدير خسارة المتعاقد في ضوء كافة عناصر العقد، بحيث يفحص العقد في مجموعه، إذ قد يكون بعض هذه العناصر مجزياً ومعوّضاً عن العناصر الأخرى التي أدت إلى الخسارة^(٢٣).

(٢٣) وقد قررت إدارة الفتوى والتشريع بأن: " .. مؤدى نظرية الظروف الطارئة - التي رسخت في القانون الإداري، وأخذ بها المشرع الكويتي في المادة (١٤٦) من قانون التجارة - أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث خارجة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة، لم تكن متوقعة عند التعاقد، وكان من شأنها وإن لم تجعل الالتزام مستحيلاً، وإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد، بأن جعلت تنفيذه مرهقاً للمتعاقد، ومنذراً بخسارة فادحة، فإن هذا المتعاقد إذ يبقى ملزماً بالاستمرار في تنفيذ العقد يكون له الحق في مطالبة جهة الإدارة بمعاونته على مواجهة هذه الظروف والأحداث، بأن تتحمل جزءاً من الخسارة التي تترتب عليها، ومن المسلم به أنه من قبيل الظرف الطارئ، الارتفاع الفاحش في الأسعار عما كانت عليه وقت تقديم العطاء، بسبب تقلبات غير متوقعة في أسواق المواد والمعدات الداخلة في تنفيذ العقد، ويجب أن يترتب على الظرف الطارئ، أن تنزل بالمقابل خسارة فادحة تتعدى مجرد تفويت فرصة لتحقيق الربح، وتتجاوز قدر الخسارة العادية في الظروف الطبيعية، ويكون تحديدها عند حساب النتيجة النهائية التي حققها المقابل من العقد، وإذ ثبت وقوعها فإن التعويض يقوم على فكرة توزيع عبء الخسارة بين الإدارة والمقابل " راجع: فتوى رقم ٢/٢٣٣٠ في ١/٦/ ١٩٧٦ منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع خلال سنتين - من أول أكتوبر سنة ١٩٧٥ حتى آخر سبتمبر سنة ١٩٧٧ - المجموعة الثالثة - صفحة رقم: ٣٢.

المبحث الثاني النتائج القانونية للحوادث الطارئة

تقديم وتقسيم:

تعتبر أحكام نظرية الحوادث الطارئة من النظام العام، ويترتب على ذلك اعتبار الشرط الذي يقضي بعدم المسؤولية في حالة حدوث ظروف طارئة باطلاً. وأساس هذا الفرض أن نظرية الحوادث الطارئة مقررة ليست فقط لمصلحة المتعاقد بما تخوله حق التعويض، وإنما هي أيضاً لمصلحة المرفق بما تؤدي إليه من استمرار سيره بانتظام واطراد.

على أن نظرية الظروف الطارئة، ونظريات التوازن المالي عموماً وجدت لكي تساهم مساهمة فعلية في استهداف الصالح العام من خلال معاونة المتعاقد مع الإدارة في تجاوز مختلف الظروف التي يمر بها وما يستتبع ذلك من ضمان استمراريته في مواصلة تنفيذ التزاماته، ومن ثم الحفاظ على حسن سير وانتظام المرفق العام^(٢٤).

(٢٤) وفي هذا الشأن قررت إدارة الفتوى والتشريع بأن: " .. معرفة أثر الظرف الطارئ على العقد، وما إذا كان بالقدر الذي يتطلبه تطبيق النظرية، أمر لا يبدو إلا عند التسوية النهائية لحساب المقاول، ولا يجوز أن يبحث في إطار تسوية جزئية لحساب أسعار المواد والمعدات التي ارتفعت أسعارها. وغني عن الذكر أنه يدخل في هذه التسوية النهائية البت في مطالبات المقاول، التي لم يبت فيها للآن، فإذا ظهر من هذه التسوية النهائية، تحقق الخسارة بالقدر الذي يتطلبه تطبيق النظرية كما سبق إيضاحه، كان من حق المقاول - نظير بقاء التزاماته كما هي - الحصول على معاونة من الإدارة؛ ذلك أن التعويض وفقاً لنظرية الظروف الطارئة لا يقوم على أساس التعويض الكامل عن الخسارة التي تحدث نتيجة الظرف الطارئ، بل على فكرة توزيع عبء الخسارة بين الإدارة والمقاول. وعلى أساس هذا يتعين أن يتحمل المقاول جانباً من الخسارة، وأن تتحمل الإدارة الجانب الآخر، ولو كان ما تتحمله هو الجانب الأكبر، ومن المألوف عند النظر في هذا التوزيع أن تراعى عدة اعتبارات، منها موقف المقاول إزاء الظرف الطارئ وما بذل من جهد في التغلب على العقبات، والاستمرار في تنفيذ أعمال العقد، والرأي فيما تم من ذلك، وكل ما تقدم يقوم على عناصر فنية موضوعية، المرجع فيها إلى الإدارة وإلى تقديرها، فالتعويض وفقاً لنظرية الظروف الطارئة، لا يقوم على فكرة الخطأ، ولا تتحدد عناصره بما أصاب المقاول من خسارة وما فاتته من ربح، وتنطبق عليه القواعد التي أوضحناها " راجع: فتوى رقم: (ف ت/ ٢/ ٢٢٧٩ بتاريخ ١٩ أغسطس ١٩٧٥) منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع خلال خمس سنوات - من ١٥ سبتمبر سنة ١٩٧٠ إلى ١٤ سبتمبر سنة ١٩٧٥ - المجموعة الثانية - صفحة رقم: ٣١٦.

لذلك فإن على المتعاقد الذي قدمت الإدارة له العون، وساعدته على تجاوز المحنة التي مر بها أن يستمر في تنفيذ التزاماته رغم صعوبتها وإرهاقها ما دامت لم تصل لدرجة القوة القاهرة المسببة لفسخ العقد^(٢٥).

ولمزيد من الإيضاح نقسم هذا المبحث ببيان أثر النظرية والذي ينحصر في التزام المتعاقد رغم قيام جائحة فيروس كورونا COVID-19 بالاستمرار في التنفيذ (مطلب أول)، والتزام الإدارة بتقديم المعونة إلى المتعاقد (مطلب ثانٍ)، وحقوق المتعاقد في الحصول على التعويض (مطلب ثالث) ونهاية الحوادث الطارئة (مطلب رابع). على النحو الآتي:

المطلب الأول استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته

إن اعتبارات حسن سير المرفق العام بانتظام وأطراف يحتم على طرفي العقد أن يستمرا في تنفيذ التزاماتهما رغم الظرف الطارئ.

ومن ثم لا يعفى المتعاقد من التزاماته المنصوص عليها في العقد لمجرد حدوث الظرف الطارئ " جائحة فيروس كورونا (COVID-19) " رغم الإرهاق الذي سببه هذا الظرف، طالما كان التنفيذ ممكناً ولم يصل إلى درجة الاستحالة.

وبناء على ذلك، فإن الارتفاع غير المتوقع في الأسعار لا يحول بين الملتزم أو المقل أو المورد، وبين تقديم الخدمة أو القيام بالأشغال أو توريد الأشياء.

غير أن توقف المتعاقد عن مواصلة تنفيذ التزاماته رغم قدرته، يخول جهة الإدارة أن توقع عليه جزاءات، بما في ذلك غرامات التأخير، إضافة إلى حرمانه من التعويض، أو تقديم أية مساعدات^(٢٦).

(٢٥) راجع: د. سليمان الطماوي - الأسس العامة للعقود الإدارية - مرجع سابق، ص ٦٨٩ وما بعدها، انظر كذلك: د. جابر جاد نصار: العقود الإدارية، مرجع سابق، ص ٢٤٠ وما بعدها، وأنظر كذلك: د. محمد سعيد أمين: رسالة دكتوراة - جامعة شمس ١٩٨٣ - الأسس العامة للالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة، ص ٦٢٤ وما بعدها.

(٢٦) وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: " ... من المبادئ المقررة أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص، مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره، وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، ولما كان العقد الإداري يتعلق بمرفق عام فلا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يتمتع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى الإخلال بالوفاء بأحد التزاماتها، بل يتعين عليه إزاء هذه الاعتبارات أن =

المطلب الثاني

التزام الإدارة بمعاونة المتعاقد معها

نتيجة لالتزام المتعاقد مع الإدارة بالاستمرار في تنفيذ العقد، رغم وجود الظرف الطارئ، فإن على الإدارة هي الأخرى أن تلتزم تجاهه بتحمل جزء من الخسارة التي تعرض لها المتعاقد؛ بسبب ذلك "جائحة فيروس كورونا (COVID-19)" وما رتبته من أثر لمساعدته على تخطيه، ومن ثم استمراره في التنفيذ، والذي يشكل هذا في حد ذاته ضماناً لقيام المرفق بتقديم خدماته للجمهور بانتظام وباطراد.

ويكون التعويض الذي تقدمه جهة الإدارة في هذه الحالة جزئياً ومؤقتاً حتى زوال الظرف الطارئ وعودة التوازن المالي للعقد؛ إما بزوال الظروف الطبيعية أو الاقتصادية التي كانت سبباً في إرهاب المتعاقد، أو من خلال إعادة النظر في شروط العقد من قبل الإدارة.

وعادة ما تلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب في عقود التزام المرافق العامة عندما تقبل زيادة الرسوم التي يتقاضاها الملزم من المنتفعين بالمرفق العام الذي يديره وبالصورة التي تعيد التوازن المالي للعقد، وبهذه الطريقة تكون الإدارة قد أفلتت من دفع مبلغ التعويض من الأموال العامة^(٢٧).

وإذا كان التزام الإدارة بمعاونة وتعويض المتعاقد أهم مظهر لتعاونهما في إدارة

= يستمر في التنفيذ ما دام ذلك في استطاعته، ثم يطالب الإدارة بالتعويض عن إخلالها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتضى، وكان له فيه وجه حق، فلا يسوغ له الامتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة، وإلا حقت مساءلته عن تبعة فعله السلبي" راجع: حكمها في الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ١١٠٩، جلسة ١٩٦٩/٧/٥ المجموعة، السنة ١٤، ص ٩٣٢. كما قضت أيضاً بأنه: "ليس مؤدى تطبيق هذه النظرية بعد توافر شروطها أن يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ التزاماته الواردة في العقد" راجع: حكمها في الطعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٢٩٩٠، جلسة ١٩٨٥/١١/٣٠، مجموعة المبادئ في أربعين عام، مرجع سابق، ص ٤٤٩. كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري إلى أن: "... مؤدى تطبيق هذه النظرية - إذا توافرت شروطها - إلزام الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة بحيث ترد إلى الحد المعقول وذلك ضماناً لتنفيذ العقد، فإذا توقف المتعاقد عن تنفيذ العقد المبرم بينه وبين جهة الإدارة بعد أن نفذ جزءاً منه، فإن دواعي تطبيق نظرية الظروف الطارئة تتخلف بالنسبة له إذا كان يتعين عليه أن يستمر في التنفيذ حتى يحتفظ بحقه في المطالبة بتطبيق تلك النظرية إن توافرت شروط أعمالها" راجع: فتاها رقم ٢١١ بتاريخ ١٩٨٠/٢/٢٨ جلسة ١٩٨٠/٢/٦ ملف رقم ١٦٠/٧٥/٣٤ مجموعة المبادئ في أربعين عام، مرجع سابق، ص ٤٥٦.

(٢٧) راجع: د. إبراهيم محمد علي - آثار العقود الإدارية - مرجع سابق، ص ٢٨٧.

المرفق، فإن التساؤل الذي يثور أنه هل يجوز للقاضي أن يعدل من شروط العقد لمواجهة الحوادث الطارئة؟

إن تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين بصورته المعمول بها في نطاق القانون الخاص لا تناسب طبيعة تنفيذ العقود الإدارية، والتي يتصل تنفيذها بالمصلحة العامة حيث يقتضي تمام هذا التنفيذ وسرعته في آن واحد، فضلاً عن عدم قدرة القاضي المدني التعدي على اختصاص الإدارة وحققها، فلا يجوز له أن يعدل من شروط العقد، أو أن يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين. وإنما دوره قاصر على تفسير الاتفاقات المبرمة بقصد العمل على احترامها دون تعديل شروطها. وإن هذا التعديل لا يجوز إلا باتفاق ودي مع الإدارة، فنظرية الظروف الطارئة لا يعرفها القضاء المدني في الكويت، وإنما يعرف فقط فكرة القوة القاهرة، أو الحادث الجبري الذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا استحالة مطلقة^(٢٨).

أما في القضاء الإداري "المتمثل بالدوائر الإدارية" حيث الاختصاص بنظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة (وما في حكمها) من عمليات الشراء العامة، وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية^(٢٩).

(٢٨) أوردت المذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني المنشور في الكويت اليوم العدد ١٣٣٥ - السنة السابعة والعشرون الأحد ٢٩ صفر ١٤٠١ هـ الموافق ٥ يناير (كانون الثاني) ١٩٨١. من أنه تعالج المادة (١٩٨) من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني، حالة إذا حدث، بعد انعقاد العقد، وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، أن وقعت نازلة استثنائية عامة، لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد، وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام - وإن ظل ممكناً - شديد الإرهاق بالمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، فإنه يجوز للقاضي، بناءً على طلب المدين، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. وللقاضي، في هذا المجال، أن يُنقص في مدى التزام المدين، أو أن يزيد في الالتزام المقابل، على النحو الذي تقتضيه العدالة ويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفين كليهما. والحكم الذي تقرره المادة ١٩٨ اعتباراً بأنه يضفي حماية فعالة على التعاقد الذي بات بسبب ظرف طارئ لم يكن في الوسع توقعه، مهدداً بخسارة فادحة، يمس النظام العام، ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق على ما يخالفه. وإذا كان من شأن أعمال حكم المادة ١٩٨ أن تثبت للقاضي، في صدق العقد، السلطة في تعديل آثاره، متجاوزاً في ذلك حدود سلطته الأصلية إزاءه، فإنه يجد مع ذلك مبرره القوي في أنه يتمثل رفقاً بمدين تعسر به الحظ، إذ شاعت ظروف طارئة غير متوقعة أن تهدده بخسارة فادحة بعيدة عن كل حسبان، وهو بهذه المثابة يتضمن تخفيفاً من شدة القانون وصرامة أحكامه، ويطبّع تنفيذ العقد بطابع العدالة والرحمة والإنسانية.

(٢٩) (١) تنص المادة (٧٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة والمنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد ١٢٩٩ السنة الثانية والستون - الأحد ٢٦ شوال ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦/٧/٢١ " تحدد الجمعية العامة للمحكمة الكلية غرفة أو أكثر من غرف =

فإنه إذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة مجتمعة كان للمتعاقد المضار أن يطلب من الجهة الإدارية مشاركته في الخسارة التي تحملها بتعويضه عنها تعويضاً جزئياً دون تعديل للالتزامات العقدية، ولا يستهدف هذا التعويض تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره أو الخسارة العادية المألوفة في التعامل، وإنما أساسه أن تتحمل الجهة الإدارية المتعاقدة لجزء من الخسارة المحققة الفادحة التي أصابت المتعاقد بغرض إعادة التوازن المالي إلى العقد ولضمان تنفيذه على الوجه الأكمل واستمرار سير المرفق العام الذي يخدمه تحقيقاً للصالح العام، ولا تعني الفكرة التوازن الحسابي، ولكن التوازن الشريف بين الالتزامات والحقوق، فإذا كان التوازن المالي أساساً للتعويض في نظرية عمل الأمير، فإن فكرة التوازن المالي بنظرية الظروف الطارئة يكملها مبدأ التعويض دون خطأ من جانب الإدارة على أساس المخاطر أو الغرم بالغنم^(٣٠). وأن تقدير التعويض الذي يحقق التوازن المالي للعقد مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

المطلب الثالث حق المتعاقد في التعويض

يجد حق المتعاقد في التعويض أساسه في الطبيعة الذاتية للعقود الإدارية، وما تتميز به من اتصالها الوثيق بالمرافق العامة، وضرورة سير هذه المرافق بانتظام واطراد. وينشأ للمتعاقد الحق في التعويض منذ اللحظة التي يوجد فيها في مركز لا تعاقد؛ أي منذ اللحظة التي يتجاوز فيها ارتفاع الأسعار الحد الأقصى الذي كان يمكن توقعه عند إبرام العقد.

= الدائرة الإدارية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة (وما في حكمها) من عمليات الشراء العامة، وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية. وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى، ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وتندب المحكمة الكلية قاضياً أو أكثر للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي تخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالقضايا والمنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية، وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها. ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى التي ترفع وفق أحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه".

(٣٠) (١) للمزيد حول موضوع المسؤولية الإدارية دون خطأ: راجع مؤلفنا القضاء الإداري وحدود مسؤولية الدولة عن أعمالها سلطاتها العامة بدولة الكويت (دراسة مقارنة) الطبعة الأولى ٢٠١٩ - ص ٤٠٩ وما بعدها.

ويتم تقدير الخسارة التي تلحق المتعاقد في فترة الظروف الطارئة في ضوء الاعتبارات التالية:

يتعين على القاضي الإداري تقدير الخسارة التي تلحق المتعاقد في فترة الظروف الطارئة في ضوء الاعتبارات التالية:

١ - تحديد بداية ونهاية الظرف الطارئ:

بحيث لا يدخل في حساب الخسائر ما وقع منها قبل بداية الظروف الطارئة، أو الأرباح المحتملة في المستقبل^(٣١).

٢ - تقدير الخسارة التي لحقت بالمتعاقد جراء الظروف الطارئة.

ينبغي ألا يكون من شأن تعويض المتعاقد مع الإدارة تحقيق إثراء له، حيث التعويض وفقاً لنظرية الظروف الطارئة لا يتناول ما فات المتعاقد من كسب، بل

(٣١) وقد طرحت مسألة زيادة في أسعار العطاءات المقدمة في المناقصات العامة، أو في أثمان العقود التي أبرمت مع البعض نتيجة لزيادة أسعار الشحن بسبب غلق قناة السويس، فقررت إدارة الفتوى والتشريع أن: "الأصل هو التزام المناقص بمجرد تقديم عطائه، فلا يسمح له بتعديله أو بسحبه قبل انقضاء المدة المحددة لسريانه، وقد ردد القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات العامة هذه القاعدة، فنص في مادته الرابعة والعشرين على أنه: "لا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه..." أما بالنسبة للمتعاقدين، فإنه وإن كانت العقود المبرمة معهم قد نصت على عدم التزام الحكومة بفروق الأسعار الناجمة عن أي طارئ من الطوارئ، فإن هذا الشرط لا يحول دون تعويض المتعاقد إذا توافرت للطارئ المدعى به شروط معينة، وذلك لما هو مسلم به في الفقه والقضاء من بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية عن الظرف الطارئ، وعلى ذلك ففي خصوص الحالة المعروضة، لا يمنع العقد من النظر في هذه الطلبات، على أن يكون مفهوماً أن إجابتها وتقرير أحقية المتعاقدين في التعويض ألا يتوافر لمجرد حدوث زيادة في أسعار الشحن، بل لابد لنشوء هذا الحق من أن تكون ثمة خسارة فادحة تفوق المألوف قد لحقت بالمتعاقد، على أن ينظر في تقدير هذه الخسارة إلى العقد ككل لا يتجزأ، إذ قد تكون بعض عناصر العقد مجزية بحيث تغطي عناصره التي تستتبع الخسارة، فإذا تحققت هذه الشروط تعين على الحكومة أن تعوض المتعاقد بدفع جزء من خسارته، وفيما عدا ذلك فليس له الحق في المطالبة بما فاتته من ربح، أو بما تحمله من نفقات إضافية، أو خسارة لا تبلغ حد الخسارة الفادحة، وبناء عليها أولاً- فإنه لا يجوز للمناقصين إجراء أي تعديل في أسعار عطاءاتهم. ثانياً- لا يجوز تعويض المتعاقدين عن زيادة أسعار الشحن، إلا إذا كانت هذه الزيادة قد ألحقت بهم خسارة فادحة بالنظر إلى العقد ككل لا يتجزأ" راجع فتاواها رقم: ف ت/٨٥١/٢ (١٠ يوليو ١٩٦٧) منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع خلال عشر سنوات - من ١٥ سبتمبر سنة ١٩٦٠ إلى ١٤ سبتمبر سنة ١٩٧٠ - صفحة رقم: ٢٦٠.

(٣٢) وقد قررت إدارة الفتوى والتشريع في بواكير فتاواها أن: "عقد توريد "صلبوخ" لدائرة

يقتصر على الخسارة التي لحقته جراء الظرف الطارئ، كما أنه لا يشمل الخسارة كلها، بل إن جزءاً منها يتحملة المتعاقد، والجزء الأكبر تتحملة جهة الإدارة، وهذا ما يميز نظرية الظروف الطارئة عن كل من نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ونظرية عمل الأمير اللتين تقرران التعويض الكامل للمتعاقد مع الإدارة أي ما لحقته من خسارة وما فاتته من كسب^(٣٢).

ولتحديد الخسارة التي تعرض لها المتعاقد مع الإدارة في هذه الحالة، يتعين على القاضي إجراء موازنة بين أرباح المتعاقد وخسائره طوال فترة قيام الظرف الطارئ. ويؤخذ في الاعتبار، الفرق بين الأسعار الفعلية وقت التعاقد، والأسعار الجديدة، بحيث يخصم من قيمة الخسائر الناجمة عن الحادث الطارئ، ما يرجع إلى أخطاء المتعاقد في التنفيذ، كما يتعين تقدير الأرباح التي حققها المتعاقد قبل قيام الظرف الطارئ.

٣ - توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد والإدارة:

إن مشاركة المتعاقد في الخسارة هي مشاركة رمزية، بينما الجزء الأكبر منها يقع على عاتق الإدارة، ويؤخذ في الاعتبار في توزيع عبء الخسارة بين الطرفين أي

الأشغال العامة عقد إداري من الوجهة القانونية؛ لاحتوائه على شروط تخالف المألوف في التعامل المدني، وهي من حق الدائرة في توقيع غرامة، قدرها خمس روبيات عن كل متر مكعب، ينقص عن الكميات المتعاقد على توريدها يومياً، وكذلك حق الرئيس في فسخ العقد في حالة مخالفة المتعهد لشروطه، ثم إتمام العمل مع إلزام المتعهد بالفرق في الثمن والمصاريف، وخصمه من أي مبلغ يستحق للمتعهد، وكذلك النص على أن حكم الرئيس أو أي شخص أو أشخاص يندبهم للتحكيم يكون نهائياً وملزماً. وما دام العقد على هذا الوجه إدارياً، وبالتالي يخول للحكومة ميزات لا تتوافر في العقود المدنية، فإن للمتعاقد الآخر أيضاً حقاً لا تتوافر له في العقود المدنية، وذلك طبقاً لنظريات العقود الإدارية، ومنها: نظرية الظروف الطارئة التي يمكن تطبيقها في الحالة المعروضة. وعلى أساس هذه النظرية يكون للمتعهد الحق في تعويض عن جزء من الخسارة الفادحة التي تلحقه نتيجة الظروف الطارئة التي لم تكن متوقعة عند التعاقد، ومن شروط هذه النظرية أن يكمل المتعهد التوريد كاملاً، فإذا تبين بعد ذلك أنه أصيب بخسارة فادحة عوض عن جزء منها، ومعنى ذلك أنه لا يكفي لزيادة الأسعار ألا يحقق المتعهد ما كان يرجو من ربح، كما لا يكفي أن يصاب بخسارة مألوفة إذ التجارة ربح وخسارة، بل يجب أن تكون الخسارة متجاوزة الحدود المألوفة في المعاملات - فإذا ما تحقق ذلك فإن الحكومة لا تلتزم بدفع كامل الخسارة بل هي تعاون المتعهد في تحملها بنسبة معينة، راجع: فتوى رقم: ف ت/٥٦/١٦/٩/١٦٦١ منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع خلال عشر سنوات - من ١٥ سبتمبر سنة ١٩٦٠ إلى ١٤ سبتمبر سنة ١٩٧٠ - صفحة رقم: ٢٠٩.

موقف المتعاقد من الظرف الطارئ "جائحة فيروس كورونا (COVID-19)" وما رتبته من أثر ومحاولته التغلب عليه، وموقف الإدارة من المتعاقد فيما يتعلق بتعديل شروط العقد.

وعلى الرغم من استقرار مجلس الدولة سواء في فرنسا أو في مصر على مبدأ توزيع الخسائر المترتبة على تحقق نظرية الظروف الطارئة، إلا أن قضاءهما لا يجري على قاعدة موحدة وثابتة بشأن تحديد نسبة معينة يتحملها كل من جهة الإدارة والمتعاقد معها.

ويراعى مجلس الدولة الفرنسي عند توزيع عبء الخسارة بين الطرفين اعتبارات كثيرة، منها: موقف المتعاقد في مواجهة الظرف الطارئ، ومدى ما بذله من جهد في التغلب عليه، إضافة إلى مدى الاستقرار الاقتصادي في الدولة عموماً، ومدى تعاون الإدارة أو تعنتها مع المتعاقد معها أو ضده.

المطلب الرابع نهاية الحوادث الطارئة

يترتب على الحادث الطارئ، إما قيام الإدارة بدفع التعويض، أو تعديل العقد بالاتفاق بين الطرفين، وحينئذ ينتهي الحادث الطارئ، ويعود العقد إلى الوضع الطبيعي له.

غير أنه قد يستمر الظرف الطارئ فترة طويلة على نحو يعجز المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ التزاماته في ظل استمرار ذلك الظرف، ولا يمكن للإدارة أن تستمر في دفع التعويض، فحينئذ يجوز لأى من الطرفين أن يلجأ إلى القاضي بطلب فسخ العقد. وعادة ما يستمر الظرف الطارئ فترة معينة ثم يزول، ولكن في بعض الأحوال قد يستمر قيام هذا الظرف فترة طويلة، الأمر الذي يجعل المتعاقد لا يستطيع الاستمرار في تنفيذ التزاماته في ظل استمرار ذلك الظرف، ونتيجة للطابع المؤقت لنظرية الظروف الطارئة، فإن مجلس الدولة الفرنسي - في هذه الحالة - عدل عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأوجد حلاً آخر - حكمه الشهير في قضية ترام شربورج - هو فسخ العقد، والذي قرر فيه:

١ - إذا ثبت فعلاً استحالة زوال الظرف الطارئ، فإن لكل من المتعاقدين الحق في الطلب من القاضي تسجيل الحالة، وإذا ما تم التسجيل تكون الإدارة في حل من دفع التعويض وفقاً لنظرية الظروف الطارئة.

٢ - يتفاوض المتعاقدان فيما بينهما بشأن مدى إمكانية تعديل بنود العقد بما يعيد إليه الحياة وإعادة التوازن المالي له.

٣ - إذا لم يتوصل المتعاقدان إلى حل بشأن عودة التوازن المالي للعقد الإداري، فلا مناص في هذه الحالة من الحكم بفسخ العقد إما بناء على طلب جهة الإدارة أو بطلب من المتعاقد معها، وقد يحكم القاضي أيضاً بالتعويض لمصلحة أي من الطرفين إذا اتضح له أن تعنت أحد المتعاقدين هو السبب في عدم الوصول إلى اتفاق جديد لاستعادة التوازن المالي له^(٣٣).

الخاتمة:

وُجِدَت نظريات التوازن المالي عموماً ومنها نظرية الظروف الطارئة، لكي تساهم مساهمة فعلية في استهداف الصالح العام من خلال معاونة المتعاقد مع الإدارة في تجاوز مختلف الظروف التي يمر بها، وما يستتبع ذلك من ضمان استمراريته في مواصلة تنفيذ التزاماته، ومن ثم الحفاظ على حسن سير المرفق العام وانتظامه.

ولقد أرسى القضاء الإداري الشروط التي يتعين تحققها، حتى يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، كما ساهم الفقه بإضافة بعض الشروط الأخرى.

ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١/٤/أ السالف البيان قد صدر لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع لمواجهة التطورات والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية من هذا الوباء واتخاذ كافة التدابير للحد من التجمعات وأسباب نشر العدوى لهذا الوباء، ضماناً لصحة المواطنين والمقيمين، ولقد ترتب على صدور هذا القرار تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والدوائر والمؤسسات العامة، وقد كان لها

(٣٣) يذهب بعض الفقه إلى أن حكم مجلس الدولة الفرنسي هذا يكشف عن مدى تأثير هذا المجلس بمبادئ العدالة واعتبارات النفع العام، فاعتبارات النفع العام تحتم حماية المال العام وعدم تبيده بإجبار الإدارة على المساهمة المادية في مرفق عام أصبح غير قابل للحياة. أما مبادئ العدالة فتقضي بالمساواة بين حقوق طرفي الرابطة العقدية، وذلك من خلال السماح لكل من المتعاقد والإدارة التقدم بطلب فسخ العقد في حالة قلب التوازن المالي له، فلم يقتصر طلب الفسخ على الإدارة فقط وإنما يشمل المتعاقد معها، وهذا بلا شك مظهر واضح من مظاهر العدالة التي يتسم بها قضاء المجلس في هذا الشأن. كما أن مبادئ العدالة تستلزم أيضاً - إلى جانب فسخ العقد - الحكم بالتعويض لصالح أحد المتعاقدين، إذا تكشف موقف المتعاقد الآخر عن تعنت كان هو السبب في عدم الوصول إلى اتفاق جديد يستعيد وجه العقد توازنه المالي. راجع: د. محمد سعيد أمين: الأسس العامة للالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة، مرجع سابق، ص ٦٤٣.

أثرها في توقف الشركات المتعاقدة مع الإدارة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وتقديم خدماتها خلال فترة العطلة.

لذلك فإن تحديد وبيان حقوق المتعاقدين مع الإدارة خلال فترة العطلة، وتعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق الحدود وتنظيم وتقييد حركة المرور والتجول، يقتضي الرجوع أولاً إلى الشروط التعاقدية لبيان ما إذا كانت هذه الشروط قد تضمنت حكماً ينظم حقوق الطرفين في هذا الخصوص، فإذا وجد نص ينظم ذلك فإنه يتعين الالتزام به بالنظر إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، فيعتبر بالنسبة إلى عاقيه بمثابة قانون خاص بهما وإن كان منشأ الاتفاق وتكون أحكامه تبعاً لذلك هي المرجع في تحديد حقوق والتزامات كل طرف قبل الآخر، بحسب المشرع في دولة الكويت استن أصلاً من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومقتضيات حسن النية. ومن ثم فإن حقوق المتعاقدين مع الإدارة تتحدد وفقاً لنصوص العقد والشروط العامة للتعاقد، ومرد ذلك أن ما اتفق عليه طرفا العقد وما تضمنته الإجراءات السابقة على التعاقد هو الشريعة التي تلاقى عندها إرادتهما ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.

أما إذا لم يوجد نص ينظم تلك الحقوق خلال تلك الفترة وجب تنفيذ العقد مع الظروف الطارئة حتى وإن أصبح شاقاً للمتعاقد مع الإدارة، وهذه المشقة توازن بحق المتعاقد في التعويض، وليس بانقضاء الالتزام حتى لا يتوقف سير المرفق العام.

وجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية سبقت غيرها من الشرائع بالأخذ بنظرية الظروف الطارئة؛ ذلك لأن الشريعة الإسلامية تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، وهي بذلك تختلف عن مبدأ سلطان الإرادة ومن يقول به؛ لأنها تقوم على أساس مفهوم الحق.

ولذلك فإننا نخلص بعد استعراض هذه الدراسة إلى أنه ومتى اكتملت كافة الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية المبرمة في دولة الكويت نتيجة جائحة فيروس كورونا COVID-19 وما رتبته من آثار، تعين فحص كل عقد على حدة، للوقوف على مدى تأثير الجائحة على العناصر المرتبطة بالعقد بدرجة كافية، التي من شأنها إحداث النتيجة، وهي قلب اقتصاديات العقد قبل تمام تنفيذه، مع ضرورة التيقن من ثبوت خسارة المتعاقد مع الإدارة، خسارة تتعدى مجرد تفويت فرصة تحقيق الربح، وتتجاوز قدر الخسارة العادية في الظروف الطبيعية، ويكون

تحديدها عند حساب النتيجة النهائية التي حققها من العقد، فإذا انحصر أثر جائحة فيروس كورونا COVID-19 في تفويت فرصة الربح على المتعاقد، فإنه لا يكون هناك إرهاب يستوجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

وعلى ذلك إذا تم التيقن من ثبوت تأثير جائحة فيروس كورونا COVID-19 على العقد فإنه يتم تقدير خسارة المتعاقد في ضوء كافة عناصر العقد، بحيث يفحص العقد في مجموعه، إذ قد يكون بعض هذه العناصر مجزياً ومعوّضاً عن العناصر الأخرى التي أُلّت إلى الخسارة، فقد يُصار إلى تعديل أو تمديد العقد من دون أي أعباء مالية بالاتفاق بين الطرفين، إذا قدرت السلطة المختصة إمكانية قيام الشركة المتعاقدة إتمام التنفيذ مع أخذ التعهدات اللازمة عليها بعدم أحقيتها في أية مطالبات مالية أو فروق أسعار عن المدة التي تم الموافقة عليها، مع إلزامها بتمديد الكفالة البنكية لمدة مماثلة، وحينئذ ينتهي الحادث الطارئ، ويعود العقد إلى الوضع الطبيعي له.

غير أنه قد يستمر الظرف الطارئ فترة طويلة على نحو يعجز المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ التزاماته في ظل استمرار ذلك الظرف، ولا يمكن للإدارة أن تستمر في دفع التعويض، فحينئذ يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلى القاضي بطلب فسخ العقد.

هذا ما تيسر إيرادها، فما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من نقص أو نسيان فمني ومن الشيطان.

وختاماً نسأل الله أن يرفع البلاء عن وطننا العزيز وعن كافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء، وأن يحرسنا جميعاً بكريم عنايته ولطفه ويحفظنا من كل سوء ومكروه.

المراجع

أولاً - المراجع والمصادر:

- د. إبراهيم محمد علي: آثار العقود الإدارية وفقاً للقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية - دار النهضة العربية ٢٠٠٣.
- د. جابر جاد نصار: العقود الإدارية، الطبعة الثانية، الناشر: دار النهضة العربية.
- د. سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، ١٩٩١.
- د. سعيد السيد علي: نظرية الظروف الطارئة، دون دار نشر، ٢٠٠٥.
- د. عبد السلام الترماني: نظرية الظروف الطارئة، دار الفكر، دون سنة نشر.
- د. عبد الله حباب الرشدي: العقود الإدارية النظرية العامة وتطبيقاتها في القانون الكويتي والمقارن، مع شرح القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، الطبعة الأولى ٢٠١٧.
- د. عبد الله حباب الرشدي: القضاء الإداري وحدود مسؤولية الدولة عن أعمالها سلطاتها العامة بدولة الكويت (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى ٢٠١٩.
- د. محمد فؤاد عبد الباسط: العقد الإداري (المقومات - الإجراءات - الآثار)، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠٠٦.
- د. محمد محي الدين إبراهيم سليم: نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقهاء الإسلامي، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٧.
- د. محمد رشيد قباني: نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الأولى، العدد الثاني، ١٩٨٠.

ثانياً - الرسائل العلمية:

- د. علي محمد علي عبد المولى: الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس ١٩٩١.
- د. محمد سعيد أمين: الأسس العامة للالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس ١٩٨٣.

ثالثاً - المجلات ومجموعات الأحكام:

- مجلة القضاء والقانون، محكمة التمييز، المكتب الفني.
- مجموعة القواعد القانونية، محكمة التمييز، المكتب الفني.

- مجموعة المبادئ التي قررتها إدارة الفتوى والتشريع، مجلس الوزراء.
- موقع مؤسسة العدالة: www.adala.com.kw

The administration's commitment to assist the contractor in the administrative contract Because of the pandemic of the Crohna virus (COVID-19)

An applied study on the State of Kuwait

Dr. Abdullah Habab Al-Rashidi

This study comes in response to a national duty, and another academic in response to the announcement of the Law Journal of Kuwait University - to which I owe an educational preference - for researchers and thinkers to issue a tight number dedicated to research on the subject of the CroVa pandemic (COVID-19), its effects and results and what it produces from legal problems in anticipation of solutions for it . Where official global statistics indicate the infected of more than two million people and the death of nearly one hundred and fifty thousand people (as of this writing) For this reason, the precautionary measures taken by the countries, including the State of Kuwait, have been pursued, starting with the suspension of commercial flights, the closure of borders, the regulation and restriction of traffic and wandering in a manner conducive to the emergence of problems regarding the non-exemption of the contractor from his obligations stipulated in the contract simply because of the occurrence of the emergency circumstance despite the exhaustion that caused this. The emergency circumstances, as long as the implementation was possible and did not reach the degree of impossibility. Although this circumstance is outside the control of the contractor with the administration, and he was not able to expect it at the time of the contract, and it may result in the implementation of the contract being extremely stressful for him, in a manner that necessitates his assistance in a manner that allows him to continue to implement the contract. This is what justice requires and dictates the reconciliation of the interests of both parties. The implementation of the contract is of a nature of justice, compassion and humanity

نحو استنهاض الفكر الجنائي في معالجة الإشكاليات التشريعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (covid-19) دراسة تحليلية نقدية

الأستاذ/ علي عودة الشمري
مدقق قانوني في ديوان المحاسبة
الكويتي - باحث دراسات عليا في
قسم القانون العام - جامعة الكويت

ملخص:

استحدثت المشرع الكويتي مؤخراً نصاً جنائياً في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد في البند الثالث من المادة (١٧) وفقاً للقانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، وهي جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية. فاستعرض هذا البحث البنيان القانوني لهذه الجريمة استعراضاً تحليلياً نقدياً، كما اهتم بإشكاليات عناصر التجريم في تلك الجريمة وكيفية معالجتها، وتطرق إلى سياسة المشرع إزاء الجمود في تناوله الركن المعنوي في تلك الجريمة والمبالغة في السياسة العقابية لهذه الجريمة، مع إبداء الحلول لمعالجة تلك الإشكاليات. كما قام بعرض أهم القرارات الإدارية محل التجريم، وتناول منها جريمة مخالفة القرار رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر حركة المرور والتجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وكان القرار قد استند في العقاب وفقاً لقانون الدفاع المدني رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩، مع التطرق إلى الحكم القضائي الجنائي على المتهم المخالف لذلك القرار، مع بيان الإشكاليات حول ما سبق. وأخيراً تناولنا جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية وفقاً للمادتين (٢، ٣) في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، وأيضاً جريمة مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الصحة وفقاً للمادة (١٥) من القانون السابق. وفي سبيل تحقيق ذلك قُسم هذا البحث إلى مبحثين، في كل منهما مطلبان، وكان المبحث الأول حول بيان عناصر التجريم في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وتباين موقف المشرع الكويتي في العقاب. أما المبحث الثاني، فكان حول جريمة مخالفة قرار حظر التجول وفقاً لقانون الدفاع المدني، ثم بيان إشكاليات جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، وإشكاليات المادة (١٥) من القانون السابق، مع محاولة المعالجة لتلك الإشكاليات في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

مقدمة:

لا يخفى على أحد أن انتشار فيروس كورونا المستجد أصبح يذق ناقوس الخطر على العالم بأسره، ويطلق نيرانه الملتهبة دون توقف حتى وصل إلى دولة الكويت. الأمر الذي يستوجب معه وقفة صارمة للحد من تفشيه، وإيجاد آليات تشريعية لردع كل مَنْ يحاول أن يسهم في تفشي ذلك الفيروس. لذلك ما يهمنا في هذه الدراسة هو تسليط الضوء على الجانب الجنائي؛ إذ تصدى المشرع الجنائي لذلك من خلال إضفاء الحماية الجنائية على أفراد المجتمع مِنْ أن يُنقل إليهم هذا الفيروس، أو مَنْ يسهم في نشره أو نشر غيره من الأوبئة التي تكون محلاً للخطر على أفراد المجتمع ككل. فالتساؤل المهم هنا الذي يطرح نفسه ضمن دراستنا: هل ينتظر المشرع الجنائي الكويتي حتى تقع الحوادث والكوارث والأوبئة كفيروس كورونا المستجد بكل ما تسببه من أضرار على المجتمع من ضحايا لا ذنب لهم فيها ثم يتدخل بنصوصه الجنائية للعقاب، أو يضيفي الحماية الجنائية على أفراد المجتمع قبل حدوث الأوبئة لوقايتهم من تلك الأضرار التي قد تحدث في المستقبل؟ وهذا ما يمكن أن نطلق عليه التجريم الوقائي العام^(١).

وانطلاقاً من ذلك فقد تصدى المشرع الكويتي بشأن مكافحة الأوبئة كالأضرار السارية، تحديداً في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، دون أن نلاحظ وجود مواكبة قانونية جنائية في شأن مكافحة الأوبئة لتطورها في المستقبل. حيث إن مخالفة الأحكام والقرارات المنفذة لهذا القانون تعد جريمة تنطبق عليها قواعد التجريم في الشق الجنائي إن حصلت، وما يُعاب على ذلك التشريع أن المشرع استعمل أسلوب القاعدة الجنائية الموزعة، فقام بتوزيع نصوص متفرقة من حيث شقّ التجريم، وجعل شقّ العقاب في آخر نصوص ذلك التشريع. ثم إنَّ القانون السابق يحتاج إلى مراجعة جنائية من حيث تضيقه في نطاق التبليغ عن الأمراض السارية على المسؤولين حصراً للتبليغ، وعدم عقاب المصاب الذي يعلم بإصابته بالمرض الساري ولم يقيم بتبليغ مركز الصحة عن ذلك. وكان على المشرع أيضاً معالجة المادة (١٥) من القانون السابق التي أعطت وزير الصحة صلاحيات واسعة بإصدار قرارات خاصة لمكافحة الوباء، وجعل في مخالفتها جريمة

(١) د. حاتم عبد الرحمن. الحلقة النقاشية التي عقدتها مجلة الحقوق بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٣ بعنوان: (الحماية القانونية للضحية في القانون الكويتي). وعالجت ثمانية محاور، المحور الثامن منها بحثٌ يتعلق بـ (التجريم الوقائي العام - آمال ومعوقات). المجلد ٢٨ ملحق. (٢٠٠٤). ص ٧٦.

تستوجب العقاب بحيث يصعب على المخاطب بتلك القرارات محل التجريم بيان ماهية النشاط الإجرامي نظراً لمرونة دلالات بنود تلك المادة وتشعبها الزائد.

سُنَّ المشرع الجنائي الكويتي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد نموذجاً إجرامياً جديداً كان من المفترض أن يكون قبل ذلك؛ إذ قام بإصدار القانون رَقْم (٤) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل المادة (١٧) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بأن استحدث نصاً جنائياً جديداً وهي جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، فجاء بقاعدة جنائية متكاملة من حيث شق التجريم والعقاب على نقيض بقية النصوص في ذلك القانون.

ولا يكاد يخلو هذا النص المُستحدث من الإشكاليات، خصوصاً أن المشرع لم يتناول عنصر النتيجة الإجرامية في تلك الجريمة بشكل موفق، فاعتد فقط بإصابة المجني عليه بالعدوى دون أن يستدرك مسألة حدوث نتيجة أخرى وهي وفاته بسبب نقل الجاني العدوى إليه بقصد إصابته بها دون قتله، حتى القواعد العامة لا تسعفنا في هذا المجال.

ثم إن جمود المشرع الكويتي أيضاً في تناوله القصد الجنائي في تلك الجريمة بأن تتطلب القصد الجنائي العمدي، وأغفل وقوع نقل العدوى من قبل الجاني بطريق الخطأ غير العمدي، وأن يفرد لها عقوبة تليق بالفعل إزاء إهمال أو عدم احتياط الجاني بنقل العدوى وغيرها من صور الخطأ غير العمدي، مما أفضى ذلك إلى تباين المنهج العقابي لدى المشرع الكويتي.

أهمية الدراسة وهدفها:

تتبلور أهمية هذه الدراسة نحو استعراض الإشكاليات الجنائية إزاء جمود التشريعات الكويتية في التصدي لفيروس كورونا المستجد وغيرها من الفيروسات التي قد تطرأ في المستقبل؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لتبيّن المثالب التشريعية التي تتولى تنظيم مكافحة الأمراض السارية من حيث الشق الجنائي فيها.

ونظراً لحدثة هذه الصورة التجريبية التي أتى بها المشرع الجنائي الكويتي وهي جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بيّنت هذه الدراسة الإشكاليات التي تنطوي على ذلك النص مما يصعب تطبيقه من الناحية العملية بسبب صعوبة إثبات عناصر التجريم، وعالجت الدراسة تلك الإشكاليات لمعاونة المشرع الكويتي بإعادة النظر في تلك الجريمة.

وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على أهم القرارات محل التجريم وهو القرار

رَقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر حركة المرور والتجول والعقاب على مخالفة ذلك وَفَقاً لقانون الدفاع المدني لا سيما القرار الذي كان محل تداول بين الجمهور، وأيضاً من خلاله أُسندت نيابة الأحداث التهمة بمخالفة الحدث ذلك القرار من خلال الحكم الذي سوف نستعرضه في المبحث الثاني. وقد سعت الدراسة إلى معالجة الإشكاليات حول ذلك القرار، كما اهتمت بمعالجة إشكاليات أهم الجرائم في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد في قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وهي جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية، وجريمة مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الصحة لمكافحة الوباء وَفَقاً لنص المادة (١٥) من القانون السابق.

منهج البحث وخطته:

تقوم هذه الدراسة على المنهج التحليلي النقدي في تحليل أحكام التشريعات والقرارات الإدارية التي تستند إلى تلك التشريعات المتصلة بالشق الجنائي منها، وهو العقاب على مخالفة ما سبق في سبيل مكافحة الأوبئة والتصدي لها كفيروس كورونا المستجد.

واختطت الدراسة مساراً نقدياً في إثارة الإشكاليات الجنائية التي تضمنتها تلك النصوص والقرارات محل التجريم للتصدي لذلك الفيروس. هذا ما يعني البعد عن الدراسة الوصفية للنصوص والقرارات محل التجريم، فليست غاية هذه الدراسة شرح هذه النصوص وترديد ألفاظها للوقوف على معانيها إلا بقدر ما يتصل بغاية الدراسة، هادفين بذلك استنهاض العقلية الجنائية في معالجة تلك التشريعات والقرارات التي تكون محلاً للتجريم فيما يتصل بالعقاب على مخالفتها في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد. وإن كانت هذه الدراسة أشارت بإيجاز إلى بعض التشريعات المقارنة كالتشريعين الفرنسي والإماراتي، فهذا لا يخل بمنهج البحث وقوامه الذي يقوم على التحليل النقدي.

وبناء على ذلك، قُسِّمَت الدراسة على النُّحُو الآتي:

المبحث الأول: البنيان القانوني في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩.

- المطلب الأول: عناصر التجريم للنشاط الإجرامي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية.

- المطلب الثاني: السياسة العقابية لدى المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية.

- المبحث الثاني: الجرائم والقرارات محل التجريم للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
- المطلب الأول: جريمة مخالفة القرار رَقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر التجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
 - المطلب الثاني: مسؤولية المبلغ والقرارات محل التجريم في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩.

المبحث الأول

البنيان القانوني في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩

خطر على ذهن المشرع الكويتي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في دولة الكويت بأن يُجرّم فعل نقل ذلك الفيروس منعاً لانتشاره وردعاً لمن يُقترب ذلك الفعل المحظور جنائياً مما قد يسهم في عدم تفشيهِ؛ لذلك قام المشرع الجنائي في القانون رَقْم (٤) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل المادة (١٧) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩، وأضاف إليها البند الثالث الذي نصّ على الآتي: «٣- كل مَنْ علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويمكن أن نعبر عن هذه الصورة الإجرامية بجريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية^(٢). ثم إن دلالة ألفاظ النص التي عبر عنها المشرع في تلك الجريمة واضحة جداً، غير أن المشكلة تتبلور حول عناصر التجريم التي تناولها المشرع في تلك الجريمة كوسيلة جنائية رادعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ إذ نظر المشرع من زاوية واحدة ضيقة للتجريم وهي محاولة التصدي لذلك الفيروس من الناحية الجنائية في العقاب على نشره، وكأن التجريم قد جاء خاصاً لمواجهة ذلك الفيروس، على الرغم من أن التجريم يطال جميع مَنْ ينقل عمداً الأمراض السارية المدرجة في ذلك القانون بقصد إصابة المجني عليه بها، وهذه النظرة الجنائية الضيقة أفضت إلى وجود إشكاليات كثيرة في ذلك النص من حيث شقّ التجريم وشقّ العقاب.

وانطلاقاً من ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: عناصر التجريم للنشاط الإجرامي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، والسياسة العقابية لدى المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية.

(٢) أُسَسَ المشرع الكويتي - في نظرنا - بأنه لم يدرج جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية كنص إضافي في قانون الجزاء الكويتي رَقْم (١٦) لسنة ١٩٦٠ في باب جرائم الاعتداء على النفس كجريمة الإيذاء العمدي وغيرها من الجرائم؛ إذ إن طبيعة جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية مغايرة عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس؛ لأن نشاط الجاني فيها (وهو فعل نقل العدوى) قد تستوعبه الألفاظ التي جاء بها قانون الجزاء الكويتي في تلك الجريمة.

المطلب الأول

عناصر التجريم للنشاط الإجرامي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية

المقصود بعناصر التجريم ما يستلزمه النص الجزائي من شروط مسبقة وأركان مادية ومعنوية يؤثر توافرها أو تخلفها في الجريمة وجوداً وعدمها؛ إذ لا يتصور الحديث عن الركنين المادي والمعنوي في هذه الجريمة إلا بعد التطرق إلى الشرط المسبق في هذه الجريمة؛ لذلك سنبيّن في هذا المطلب عناصر التجريم (الشرط المسبق والركنين المادي والمعنوي)، مع بيان الإشكاليات الواردة على هذه العناصر في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية.

الفرع الأول

الشرط المسبق في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية

يتطلب أحياناً المشرع الجنائي في تجريم فعل الجاني ركناً مسبقاً يكون أول ركن يجب فحصه قبل أركان التجريم الأخرى (الركنين المادي والمعنوي) وقد أطلقنا عليه الشرط المسبق بدلاً من اصطلاح الشرط المفترض، لا سيما وأن عناصر التجريم لا تقبل الافتراض في هذه الجريمة، فيجب أن يُقام عليها الدليل، ويعتبر الشرط المسبق الأرضية اللازمة لبناء التجريم، فإن تخلف استحالة تحقق الجريمة استحالة قانونية دون الحاجة إلى فحص الأركان الأخرى للتجريم.

وهذا هو شأن المشرع الجنائي الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية وفقاً للبند الثالث في نص المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، التي تطلب لقيامها شرطاً مسبقاً من خلال تحليلنا لتلك الجريمة، وهو أن نكون بصدد مرض من الأمراض السارية حتى يتم تفعيل النص السابق جنائياً؛ إذ يجب أن يكون النقل العمدي عن مرض مدرج في جدول الأمراض السارية بقرار من وزير الصحة، وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة الأولى من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ التي نصت على الآتي: «الأمراض السارية التي تخضع لأحكام هذا القانون هي الأمراض المبينة في الجدول الملحق بقسميه الأول والثاني، ويجوز لوزير الصحة

العامّة بقرار منه إضافة أي مرض سار آخر إلى الجدول المذكور، والحذف أو النقل من قسم إلى آخر من قسمي الجدول»^(٣).

يتضح من النص السابق أن الشرط المسبق للنقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية محل التجريم يقوم على عنصرين أساسيين: العنصر الأول أن يكون عن مرض سار مدرج في الجدول الملحق بهذا القانون، فعلى سبيل المثال لو أن شخصاً قام بنقل فيروس كورونا المستجد إلى شخص آخر عن عمد ولم يكن هذا الفيروس مدرجاً في جدول الأمراض السارية فلن ينطبق عليه التجريم؛ لتخلف الشرط المسبق وهو أن نكون بصدد مرض سار مدرج مسبقاً في جدول الأمراض السارية؛ لأن الجريمة التي استحدثها المشرع وفقاً للبند الثالث من نص المادة (١٧) تندرج تحت أحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. أما العنصر الثاني من عناصر الشرط المسبق لتلك الجريمة، فهو أن يصدر قرار من وزير الصحة بإدراج المرض في جدول الأمراض السارية، وقد صدر قرار من وزير الصحة بإدراج فيروس كورونا المستجد في جدول الأمراض السارية باعتباره من الأمراض السارية وفقاً للقرار رقم (٤٩) لسنة ٢٠٢٠^(٤). وغياب أحد هذين العنصرين من شأنه أن يبعد الفاعل عن نطاق التجريم دون الحاجة إلى الدخول في أركان التجريم الأخرى لاستحالة تحقق الجريمة استحالة قانونية.

(٣) نلاحظ أن موقف قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية فيما يتعلق بالجدول الملحق به وهو جدول الأمراض السارية، بأن المشرع لم يعيد النظر إليه بعد إدراج فيروس كورونا المستجد في هذا الجدول، إذ نلاحظ بأن الأنفلونزا العادية هي أيضاً مدرجة في هذا الجدول وبالتالي يسري عليها التجريم المستحدث فيما يتعلق بنقل الأمراض السارية عمداً، ويُعد هذا توسعاً جنائياً مبالغاً فيه، لا سيما تشابه الأعراض بين فيروس الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد، فكان حرياً بالمشرع الكويتي أن يحذف الأنفلونزا العادية من ضمن جدول الأمراض السارية.

(٤) جاء قرار وزير الصحة بإدراج فيروس كورونا المستجد (covid-19) في مطلع شهر مارس لسنة ٢٠٢٠، وقد جاء القرار متأخراً؛ إذ لو كان ثمة شخص يحمل ذلك الفيروس قبل هذا القرار ونقله عمداً إلى شخص آخر بقصد إصابته بالعدوى، فلن يسأل عن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية؛ لذلك سيكون مرد فعله للقواعد العامة في قانون الجزاء كجريمة الإيذاء العمدي، غير أن دلالة لفظ الإيذاء قد تقبل التأويل بأنها لا تشمل فعل نقل العدوى؛ كون الإيذاء قد يفسر معناه بأنه يجب أن نكون بصدد فعل مادي ملموس، وأفعال نقل العدوى قد لا تستوعب بعض الأحيان لفظ الإيذاء الذي قصده المشرع الكويتي في قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠.

الفرع الثاني

الركن المادي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية

من بديهيات القانون الجنائي أنه لا جريمة دون ركن مادي، والركن المادي هو ماديات الجريمة؛ أي المظهر الذي تبرز فيه إلى الواقع. ويقوم الركن المادي عادةً على عناصر ثلاثة: الفعل والنتيجة والعلاقة السببية^(٥).

وبناءً على ما سبق سنقوم بتحليل الركن المادي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية من الفعل محل التجريم والنتيجة الإجرامية (الإصابة بالعدوى) إلى العلاقة السببية بينهما؛ وفقاً للبند الثالث من نص المادة (١٧) في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ والتي جاءت بما يلي:

«كل مَنْ علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وانطلاقاً من ذلك سنعرض إشكاليات الفعل المادي والنتيجة والعلاقة السببية التي تثار على النص السابق.

أولاً - الفعل المادي محل التجريم في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية:

بالنسبة إلى الفعل المادي محل التجريم في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، فالواضح من النص السابق أنَّ نقل العدوى عن أي مرض سار تكون بأي وسيلة كانت، لا سيما أن فيروس كورونا المستجد يتسم بسهولة نقله على خلاف بقية الفيروسات والأمراض السارية الأخرى المدرجة في جدول القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، فهو ينتقل عن طريق اللمس بمصافحة المصاب بالفيروس أو رذاذ اللعاب أثناء العطس أو غير ذلك من العادات اليومية لأفراد المجتمع.

ومن الممكن أن يقوم الجاني المصاب بذلك الفيروس بوضع لعابه على أدوات يستعملها المجني عليه ومن ثم يُصاب بالعدوى، أو أن يقوم الجاني المصاب بالفيروس بتقبيل المجني عمداً، أو قيامه بالبصق على المجني عليه حتى يصيبه

(٥) د. محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات - القسم العام. القاهرة: دار النهضة العربية. الطبعة السادسة. (١٩٨٩). ص ٤٧.

بالعدوى، لذلك تتسم طريقة نقل هذا الفيروس بالسهولة، وليست على غرار الأمراض السارية الأخرى.

لكن يجب الانتباه في هذا المقام إلى أن هناك مادة يتيمة في قانون الجزاء الكويتي والتي لم يكن لها محل دراسة معمقة وهي مادة جديرة بالاهتمام وقد تغني - بحسب رأينا - عن وجود هذه الجريمة ومشكلاتها في الإثبات وهي المادة (١٧١) من قانون الجزاء حيث جاءت بما يلي:

«كل من ارتكب عمداً فعلاً أنشأ به خطراً يهدد أشخاصاً أو أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق أو بإفساد وسيلة النقل أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة، قاصداً الإضرار بأشخاص أو بالأشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ونلاحظ انطباق عناصر التجريم في تلك الجريمة على من يقوم بفعل نقل فيروس كورونا المستجد كونه فعلاً أنشأ به خطراً على المجني عليه، طالما قصد الإضرار به، لذلك أوجدت هذه المادة نوعين من الحماية الجنائية: الحماية الأولى تختص بتعريض الأشخاص عمداً للخطر، والحماية الأخرى للأشياء وهي التي لا تعيننا في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن السلوك محل التجريم وهو نقل العدوى في النص الذي استحدثه المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ ليس جديداً عليه، فقد جرم المشرع الكويتي فعل نقل العدوى في قانون آخر يسبق النص السابق الذي استحدثه، وهو القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٩٢ في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)؛ إذ نصت المادة (١٥) في فقرتها الثانية من حيث ركنها المادي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الإيدز وفقاً للقانون السابق على الآتي: «كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر».

فقد اتخذ المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الإيدز مسلكاً جنائياً مختلفاً عن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وذلك حينما غاير في النظر إلى كل من الجريمتين، فأوجد نوعين من التعامل الجنائي هما: نظرة خاصة فيما يتعلق بجريمة النقل العمدي عن عدوى الإيدز بأن جعل لها نصاً خاصاً يحكمها على الرغم من أنها أحد الأمراض السارية، وأخرى عامة في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية محل الدراسة، مما يوجب علينا أن نتقيد بقاعدة أن النص

الخاص يقيد النص العام في حال التعارض، لاسيما أن مرض الإيدز على عكس فيروس كورونا المستجد غير المدرج في جدول الأمراض السارية في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩. فقد يسري على مرض الإيدز القانون السابق من حيث التدابير والإجراءات فقط، ولا يسري عليه النص المستحدث في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية فيما يتصل بالعقاب.

وكان حرياً بالمشرع الكويتي أن يفرد نصاً خاصاً بتجريم نقل العدوى عن فيروس كورونا المستجد له طبيعة خاصة مغايرة تماماً عن الأمراض المدرجة في جدول قانون الاحتياطات الصحية، وطبيعته المغايرة نجدها في سهولة انتشاره عن بقية الأمراض السارية؛ لذلك كان من الأحرى عليه ألا يساويه ببقية الأمراض السارية الأخرى.

يتنوع السلوك الإجرامي إلى عدة أشكال، فقد يكون هذا السلوك عن طريق بذل أو تدخل لا يسمح به القانون، وهنا نكون أمام جريمة أو سلوك إجرامي ذي مظهر إيجابي، والآخر سلوك سلبي ويكون بنهي المشرع عن القيام بسلوك معين^(٦). فالتساؤل هنا: هل يمكن أن يتصور وقوع جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية بفعل سلبي من الجاني المصاب بالعدوى؟

نتصور وقوع جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد بسلوك سلبي من جانب الجاني المصاب بالفيروس؛ فمثلاً لو لم يحم الجاني المصاب بالفيروس بأي فعل إيجابي، وقام المجني عليه بمصافحته على نحو يُنقل إليه الفيروس دون أن يُعلمه الجاني بإصابته بالفيروس عمداً بنية أن يُصيبه بالعدوى؛ فهذا يساءل الجاني عن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية وفقاً للبند الثالث من نص المادة (١٧) الذي استحدثه المشرع الجنائي مؤخراً، وما يؤيد رأينا في إمكانية وقوع تلك الجريمة بسلوك سلبي متخذ من قبل الجاني المصاب بالفيروس هو ما نصت عليه المادة المذكورة سلفاً بعبارة: «وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر»؛ إذ لا يهتم المشرع الجنائي كيفية نقل العدوى، سواء في سلوك إيجابي أو في سلوك سلبي محض، وكل ما يهمله هي الإصابة بالعدوى بأي سلوك اتخذته الجاني المصاب في نقلها.

(٦) د. فايز الظفيري و د. محمد عبد الرحمن بوزبر، المبادئ العامة في قانون الجزاء الكويتي، مطبعة المقهوي الأولى، الطبعة الخامسة، (٢٠١٥/٢٠١٤)، ص ١١٠.

ثانياً - النتيجة الإجرامية في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية:

لم يكتف المشرع الجنائي بصدور سلوك من الجاني في نقل العدوى إلى المجني عليه، بل اشترط وفقاً للبند الثالث من المادة (١٧) في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ حدوث نتيجة معينة دون سواها، وهي إصابة المجني عليه بالعدوى دون اشتراط حدوث الوفاة. ومحل الانتقاد هنا أن المشرع جعل جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية من جرائم الضرر؛ أي يجب أن يتحقق ضرر فعلي للمجني عليه، وهي الإصابة بالعدوى، وليست من جرائم الخطر؛ حيث يحدد المشرع الجنائي جرائم الخطر وفقاً لسياسته التجريبية، حيث يشمل نطاق التجريم على حالات الخطر في نصوص تمثل قدراً من الأهمية لدى المشرع الجنائي كتعريض صحة الإنسان للخطر عن طريق تفشي الأمراض^(٧)، وهذا ما لم يرق به المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية.

ويُعاب على المشرع الكويتي في هذه الجريمة أنه لم يأخذ بالنتيجة الإجرامية على صورتين، صورة أخف وصورة أخرى أشد، بل أخذ بالنتيجة الأخف فقط وهي الإصابة بالعدوى. وبناءً على ذلك فالتساؤل المطروح هنا وهو في حال حدوث نتيجة الوفاة جراء الإصابة بالعدوى: هل القواعد العامة في قانون الجزاء الكويتي ستستوعب فرضية حدوث الوفاة فيما لو حصلت. وهذا ما سنطرحه في الإشكالية الآتية.

إشكالية حدوث الوفاة من قبل المجني عليه المصاب بفيروس كورونا المستجد:

يُمثل التكييف الجنائي نقطة تلاق بين الواقع والقانون فيمتزجان سوياً فيما نص عليه المشرع سلفاً، والواقعة هي التي حدثت وثبتت نسبتها إلى المتهم وتحدد عناصرها القانونية، ولذلك يعدُّ التكييف الوسيلة التي يتحقق عن طريقها فعالية مبدأ الشرعية؛ أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص^(٨).

ولم يعالج المشرع الكويتي - وهو بصدد تجريم النقل العمدي عن عدوى

(٧) د. محمد أحمد المنشاوي. دور الخطر في إلهام المشرع قاعدة التجريم، مجلة الحقوق، المجلد ٣٧. العدد ٤. (٢٠١٣). ص ٣١٦.

(٨) د. أحمد عمر إسماعيل، أصول التكييف الجنائي، مجلة بحوث ودراسات العالم الإسلامي، العدد ١٠، (٢٠١٣). ص ٢١٦.

الأمراض السارية - فرضية حدوث الوفاة فيما لو كان قصد الجاني منصرفاً إلى إصابة المجني عليه بالعدوى فقط دون أن يعمد إلى قتله، ثم توفي بناءً على تلك العدوى، فما هو التكليف الجنائي هنا؟

طبيعة قصد الجاني في تلك الفرضية هو القصد المتعدي؛ إذ إن الجاني أراد حدوث نتيجة معينة وهي إصابة المجني عليه بعدوى فيروس كورونا المستجد، ولكن حدثت نتيجة أشد وهي وفاة المجني عليه دون قصد قتله. والشاهد أن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية هي جريمة ذات قصد جنائي عام، والقصد المتعدي حدده المشرع في جرائم معينة على سبيل الحصر كجريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت وفقاً لنص المادة (١٥٢) من قانون الجزاء الكويتي^(٩)، فهل بالإمكان مساءلته عن هذه الجريمة على الرغم من أن الجريمتين هنا عقوبتهما واحدة وهي الحبس مدة لا تتجاوز ١٠ سنوات.

للجواب عن ذلك، نرى أنه لا محل لانطباق نص المادة (١٥٢) من قانون الجزاء الكويتي بشأن جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت، وعلة ذلك أن فعل نقل العدوى لا يشكل ضرباً أو جرحاً وهو الركن المادي لتلك الجريمة، لا سيما أن فعل الضرب أو الجرح يحتاج إلى فعل مادي ملموس يحمل نوعاً من العنف الذي لا يستوعب فعل نقل العدوى، وإلا خرجنا عن قاعدة التفسير الضيق للنصوص الجنائية؛ لذلك فقد أغفل المشرع الكويتي في جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت صورة الإخلال بحرمة الجسم، ولم ينص عليها^(١٠).

لما كانت جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية من الجرائم المادية التي تتطلب حدوث نتيجة كما قلنا فيما سبق، فإن هذه الجريمة تقبل الشروع في ارتكابها حال عدم حدوث النتيجة وهي إصابة المجني عليه بالعدوى كفيروس كورونا المستجد.

فالشروع هو البدء في تنفيذ ارتكاب الجريمة إذا لم يستطع الجاني لأسباب لا دخل لإرادته فيها إتمام الجريمة، ولا يشترط المشرع وجود ضرر مادي للمساءلة على

(٩) نصت المادة (١٥٢) من قانون الجزاء الكويتي على ما يأتي: (كل مَنْ جَرَحَ أو ضَرَبَ غيره عمداً أو أعطاه مواد مخدرة دون أن يقصد قتله ولكن الفعل أفضى إلى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنين، ويجوز أن تضاف إليه غرامة... إلخ).

(١٠) د. سمير الشناوي، شرح قانون الجزاء الكويتي. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. الطبعة الثانية. (١٩٩٢). ص ٢٢٦.

ارتكابه للجريمة في نموذج الشروع^(١١). وقد تناول المشرع الكويتي في قانون الجزاء رُقْم (١٦) لسنة ١٩٦٠ تنظيم الشروع في ارتكاب الجريمة؛ وذلك في المادة ٤٥ التي نصت على ما يأتي: «الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل لأسباب لا دخل لإرادته فيها إتمام الجريمة، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم على ارتكابها، ويعد المتهم شارعا سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها، ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل».

لذلك ثمة ثلاث صور للشروع حسب الفقه الجنائي، وهي الجريمة الموقوفة، والجريمة الخائبة، والجريمة المستحيلة. ويختلف كل تشريع جزائي في الأخذ بأي من الصور السابقة، ومن ثم المعاقبة عليها^(١٢). وسنتطرق بإيجاز إلى كل جزئية لنرى مدى إمكانية تصورهما في نقل عدوى فيروس كورونا من شخص إلى آخر بقصد ارتكاب جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية؛ لأن الشروع لا يتصور إلا في الجرائم العمدية فقط. وأخذ المشرع الجنائي الكويتي ثلاثة أنماط للشروع، وسنقوم باستعراضها ومدى إمكانية إسقاطها على نص المادة (١٧) بشأن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية.

ولا تثار مشكلة فيما يتعلق بالشروع بنوعيه الناقص والتام في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، فلو كان الجاني المصاب بذلك الفيروس قد أتى بفعل يؤدي حتماً إلى وقوع الفعل المادي وهو نقل العدوى كقيامه بالبصق على وجه المجني عليه لينقل إليه العدوى غير أن الأخير تفادها، فهنا يسأل الجاني عن الشروع الناقص في جنائية النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية. أما الشروع التام، فيتصور في حال قيام الجاني المصاب بذلك الفيروس بوضع اللعاب المحمل بالفيروس على جهاز المجني عليه ثم لمسه الأخير، غير أن العدوى لم تصبه نظراً لقوة جهاز المناعة لديه، فهنا أيضاً يسأل الجاني عن الشروع التام في تلك الجريمة. كل ذلك لوجود أسباب خارجة عن إرادته حالت دون إصابة المجني عليه بالعدوى.

أما التساؤل فيثار في الجريمة المستحيلة. وقد أخذ المشرع الكويتي وفقاً لنص

(١١) د. عبد المهيم بكر سالم. الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي القسم الخاص. الكويت:

المطبعة العصرية. الطبعة الأولى. (١٩٧٣). ص ١٠٣.

(١٢) د. فايز الظفيري و د. محمد بوزبر. مرجع سابق. ص ٤١١.

المادة (٤٥) من قانون الجزاء رُقْم (١٦) لسنة ١٩٦٠ بنوعين من الاستحالة، وهما الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية. أما الاستحالة القانونية، فلا تحتاج إلى نص تشريعي يقررها، وهي من مسلمات القانون الجنائي الموضوعي حال تخلف عنصر من عناصر التجريم، فلا جريمة لاستحالة تحققها استحالة قانونية؛ لذلك نرى أنه لا يتصور وقوع الجريمة المستحيلة بجميع أنواعها على جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، فعلى فرض لو أن شخصاً اعتقد فعلاً أنه يحمل مرضاً سارياً كفيروس كورونا المستجد (covid-19) بعد إجراءات فحوصات طبية أكدت إصابته به على الرغم من أنه غير مصاب فعلياً بوجود خطأ في الفحص مثلاً، ثم أراد نقله إلى شخص معين بمصافحته مثلاً بقصد إصابته به، ومع ذلك لم يتعرض المجني عليه بعدوى ذلك الفيروس، فهنا نكون بصدد استحالة قانونية؛ لتخلف الشرط المسبق في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وهو أن يكون الجاني مصاباً بمرض من الأمراض السارية المدرجة في جدول القانون رُقْم (٨) لسنة ١٩٦٩، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد، حتى لو اعتقد فعلاً بإصابته بالعدوى على الرغم من أنه غير مصاب به لاستحالة تحقق الجريمة استحالة قانونية وليست استحالة نسبية أو مطلقة. لذلك نقول: إن الجريمة التي استحدثها المشرع الكويتي مؤخراً وهي جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية لها طبيعة خاصة مغايرة عن الجرائم التقليدية في الاعتداء على النفس التي أوردها المشرع في قانون الجزاء الكويتي.

ثالثاً - العلاقة السببية بين الفعل (نقل العدوى) والنتيجة (الإصابة بالعدوى):

العلاقة السببية عنصر من عناصر الركن المادي في سائر جرائم الاعتداء على النفس، فلا يمكن إلقاء عبء النتيجة الإجرامية على الجاني إلا إذا ثبت ارتباطها السببي بالسلوك الإجرامي^(١٣). فنحن نرى أن إشكالية جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية التي استحدثها المشرع مؤخراً تتبلور حول العلاقة السببية بين الفعل المادي لتلك الجريمة وهو نقل العدوى، والنتيجة الإجرامية وهي الإصابة بتلك العدوى. ونظراً لسهولة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، فإن النيابة العامة والقضاء سيعانيان صعوبة إثبات تلك العلاقة السببية التي من الممكن أن يخرج منها الجاني بسهولة بأن يدفع دفعاً جوهرياً يتعلق بعنصر من عناصر الركن المادي

(١٣) د. سمير الشناوي. مرجع سابق. ص ١٢٧.

للتجريم أي العلاقة السببية، حيث يستطيع أن يتذرّع بأن نقل عدوى ذلك الفيروس إلى المجني عليه لم يكن منه، خصوصاً فيما إذا كان المجني عليه قد خالط غيره، حيث إذا كان ناقل العدوى شخص مبهم فإنه سيستفيد من مبدأ قرينة البراءة.

وتثور الإشكالية الأخرى حول العلاقة السببية إذا كنا بصدد شخصين كليهما نقل فيروس كورونا المستجد إلى الآخر مما أفضى إلى إصابتهما بذلك الفيروس، وبالتالي كيف نستطيع أن نعلم من هو الناقل الفعلي للفيروس، وقد ينتقل الفيروس من شخص ثالث إلى أحدهما أو كليهما، فكيف نحل هذه الإشكالية، لذلك نقول بأن العلاقة السببية هي إحدى المشاكل التي تتصدر مشكلات الإثبات في هذه الجريمة، مما يهدد بعدم تطبيق النص الذي استحدثه المشرع الكويتي وهي جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية.

ونرى عدم انطباق العلاقة السببية في نص المادة (١٥٧) من قانون الجزاء الكويتي على جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية؛ وذلك لأنها تطلبت حدوث نتيجة الوفاة ولم يتناول المشرع هذه النتيجة في تلك الجريمة، إلا أنه تدارك ذلك بأن جاء في صريح العبارة: «وتسبب عمداً في نقل العدوى»، ويعني ذلك أي فعل مباشر أو غير مباشر من شأنه أن يؤدي إلى نقل العدوى للغير، ولكن تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جداً وهي أنه علينا أن نسلط الضوء على البند الرابع من المادة (١٥٧) والتي جاءت بما يلي: «إذا كان المجني عليه مصاباً بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وعجل الفاعل بفعله إلى موت المجني عليه» فلو كان الجاني يعلم بأن المجني عليه مصاب بأمراض مناعية خطيرة من شأن نقل فيروس كورونا المستجد إليه أن يفضي إلى وفاته، وتوفي على إثر ذلك، فنكون هنا أمام جريمة القتل العمد، ولو كان الجاني يقصد أن يريده مصاباً بالعدوى فقط، وذلك لتوافر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد، حيث إنه توقع النتيجة وهي علمه بأن المجني عليه مصاب بمرض مناعي خطير من شأن نقل فيروس كورونا إليه أن يجعل في وفاته، وقبل نتيجة الوفاة لعدم اكترائه بذلك.

الفرع الثالث

ملاحح الركن المعنوي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية

تقضي الأصول العامة في القواعد التجريبية بأن كل جريمة تكون عمدية ما لم ينص المشرع الجنائي على خلاف ذلك، فالقاعدة العامة تقضي بأن القصد الجنائي

العمدي هو الأصل في كل الجرائم^(١٤). والناظر في قانون الجزاء الكويتي يجد أن المشرع الكويتي قد نص في المادة (٤٠) على ما يأتي: «إذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه».

والناظر إلى نص المادة (١٧) في بندها الثالث من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، يستطيع أن يتلمس بوضوح طبيعة القصد الجنائي في هذه الجريمة؛ إذ المشرع الجنائي اختط في منهاجه بتحديد الركن المعنوي وفقاً لنص المادة السابقة صورة القصد الجنائي العمدي، وعرف المشرع الكويتي في نص المادة (٤١) من قانون الجزاء الكويتي رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ القصد الجنائي العام بما يأتي: «يعد القصد الجنائي متوافراً إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة».

ونشير إلى أن سياسة المشرع الكويتي في تناوله الركن المعنوي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية لم تكن موفقة، لا سيما أن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية لها طبيعة مغايرة عن غيرها من الجرائم التقليدية الماسة بالنفس؛ لذلك نرى أن المنهاج الذي اختطه المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية لم يتناول الركن المعنوي مفصلاً؛ إذ أخذ فقط صورة القصد الجنائي العمدي ولم يأخذ صورة الخطأ غير العمدي التي غالباً ما تقع أكثر في حال إهمال الجاني نقل العدوى أو عدم مراعاته للوائح.

ومع ذلك، يجب علينا أن نفرق بين وجود الركن المعنوي وانتفاء القصد الجنائي، فقد ينعدم القصد الجنائي لدى الجاني في ارتكابه للجريمة، لكن ذلك لا يمنع من توافر الركن المعنوي لها، ويكون توافر الركن المعنوي لدى الجاني على الرغم من انعدام القصد الجنائي لديه في حال إذا قضى المشرع اقتران الفعل بالخطأ غير العمدي حال غياب القصد الجنائي، وبالتالي سنكون هنا أمام جريمة غير عمدية، ولكن إذا انتفى الركن المعنوي انتفت معه الجريمة، بحيث ينعدم معه القصد الجنائي العمدي، وأيضاً الخطأ غير العمدي^(١٥).

(١٤) د. مبارك عبد العزيز النوييت. شرح المبادئ العامة في قانون الجزاء الكويتي. الطبعة الثانية.

(٢٠١١/٢٠١٠)

(١٥) د. فايز الظفيري و د. محمد بوزبر. مرجع سابق. ص ٣٦٢ - ٣٦٣.

أولاً - إشكالية نطاق علم الجاني بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد:

يجب أن يكون علم الجاني محاطاً بكل عناصر التجريم في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية؛ لذلك يجب أن يكون الجاني في هذه الجريمة عالماً علماً يقينياً بأنه مصابٌ بمرض من الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد. وهذا ما دل عليه المشرع في تلك المادة بعبارة: «كل من علم بأنه مصاب بأحد الأمراض السارية»؛ إذ يدل على أن المشرع يتطلب علم الجاني بالشرط المسبق في هذه الجريمة وهو ثبوت إصابته بأحد الأمراض السارية كالفيروس السابق. غير أن نطاق علم الجاني في هذا الفيروس نطاق ضيق؛ إذ يجب أن يجري فحوصات معينة أو مسحات طبية حتى تتأكد إصابته بذلك الفيروس، والإشكالية تثار هنا بأنه في حال ثبوت إصابته بهذا الفيروس عن طريق فحوصات يجريها في المستشفى سيتم حجره صحياً إذا ما استدعى الأمر ذلك ولو بالقوة، وبالتالي سيكون بمعزل عن الغير، هذا ما يؤدي إلى تقليل فاعلية تطبيق تجريم النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية وفقاً لنص المادة (١٧) المشار إليه سلفاً، ولم يفترض المشرع علمه بأنه مصاب في حال حدوث أعراض معينة، وذلك وفقاً لمبدأ قرينة البراءة.

يقضي الأصل العام في المواد الجنائية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وينتج عن ذلك أن عبء إثبات عناصر التجريم من الشرط المسبق وأركان التجريم الأخرى يقع على عاتق سلطة الاتهام. والمشرع الجنائي في حالات استثنائية معينة يقلب عبء الإثبات في جرائم معينة من عاتق سلطة الاتهام إلى عاتق المتهم بحيث يمكن له إثبات عكسه^(١٦). لكن القاعدة تقضي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. وإذا كان المتهم صاحب مصلحة في أنه لا يدان وهو بريء، فإن للمجتمع مصلحة ظاهرة لا تقل عن مصلحة المتهم نفسه في أن لا يدين المتهم وهو بريء، فيحصل الظلم^(١٧).

ونرى أن افتراض علم الجاني في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد له ما يبرره في بعض الأحيان؛ إذ لو

(١٦) د. نوفل علي الصفو. ذاتية المصطلح في قانون العقوبات. مجلة الراصد للحقوق. العدد ٦. (٢٠٠٦). ص ١٧٨.

(١٧) د. نسرین عبد الحمید نبیہ. حقوق المتهم أمام النيابة العامة. الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. الطبعة الأولى. (٢٠١٠). ص ١٢٥.

افتترضنا علمه اليقيني بالمرض عن طريق إجراء فحوصات ما يؤدي إلى عزله كإجراء صحي، من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة تحقق الجريمة ويجعل النص التجريمي لغواً لا أكثر. ولو افتترضنا أيضاً أن الجاني يحمل أعراضاً دامغة على أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد كحُمى شديدة جداً وسعال جاف، ثم اعتقد فعلاً بأنه مصاب به، وتعمد مخالطة غيره بنية نقل عدوى الفيروس إليه؛ فهنا نكون أمام احتمالين:

الاحتمال الأول: إذا تبين أنه غير مصاب بذلك الفيروس بعد إجراء الفحوصات الطبية والنتيجة كانت سلبية؛ فهنا لا مجال لتحقيق الجريمة ولو اعتقد فعلاً أنه مصاب بالفيروس وتعمد نقله، فلا يسأل حتى في الشروع، لاستحالة تحقق الجريمة بسبب غياب الشرط المسبق وهو كما قلنا سابقاً أن يكون الجاني مصاباً بمرض من الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد.

الاحتمال الثاني: إذا تبين أنه فعلاً مصاب بالفيروس، فهنا نعتقد أن الجاني يكون بفعله هذا أولى بالتجريم، وإن كان لم يعلم يقيناً أنه مصاب به قبل إجراء الفحص الطبي، فافتراضية علمه نراها هنا مبررة حتى يكون في نطاق تجريم النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية. وتطلب المشرع الكويتي في سياسة تجريمه لنقل العدوى عن الأمراض السارية عن عمد - علم الجاني بإصابته بالعدوى، وهذا العلم يجب أن يكون علماً يقينياً عند المشرع الكويتي، وهذا ما يضيّق نطاق الجريمة في الواقع العملي.

وتلزم الإشارة إلى أن اقتراحنا على المشرع في مسألة افتراض عنصر علم الجاني بأنه مصاب كأحد عناصر القصد الجنائي العمدي في هذه الجريمة، ليس افتراضاً قاطعاً بل كقرينة بسيطة يجوز للجاني دحضها بكل طرق الإثبات. ورأينا في افتراض علم الجاني بأنه مصاب بأحد الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد هو افتراض متصل بالشرط المسبق في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وليس افتراضاً بالفعل المادي محل التجريم وهو نقل العدوى. وأيضاً لا نقترحه في جميع الأحوال، وإنما في الأحوال التي يكون فيها المرض الساري متفشياً كفيروس كورونا المستجد في الوضع الحالي؛ لذلك نرى ما يبرره، وهذا ما يجعل الجريمة لها الفاعلية في التطبيق.

ثانياً - الإرادة كعنصر من عناصر القصد الجنائي العمدي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية:

إنَّ الشرطَ الجوهري في المسؤولية الجنائية ينبنى على ضرورة أن يكون الفعل

المنسوب إلى المتهم قد تم طوعية، فيتعين أن يكون فعل المتهم فعلاً إراديّاً^(١٨)؛ إذ لا يكفي علم الجاني بعناصر التجريم للقول بتوافر القصد الجنائي لديه، بل يجب أن يكون مريداً لارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة؛ لذلك توافر الإرادة أمر ضروري لاكتمال القصد الجنائي في كل سلوك إجرامي.

إشكاليات القصد الجنائي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية:

بعد أن استعرضنا جمود المشرع الكويتي في تناوله القصد الجنائي وفقاً للبند الثالث من نص المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ فيما يتعلق بجريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد، سنبيّن ملاحظتين، الأولى: عدم وجود سياسة واضحة في رسم ملامح القصد الجنائي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، والثانية: مشكلة إثبات القصد الجنائي في الجريمة السابقة.

الملاحظة الأولى: جمود المشرع الكويتي بوضع سياسة جنائية عامة لرسم صور القصد الجنائي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية:

نلاحظ أن المشرع الجنائي الكويتي سلّط الضوء فقط على القصد الجنائي العمدي، لا سيما أن المشرع وهو بصدد تجريم النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، تناول الجريمة بشكل منفصل عن الجرائم الواقعة على النفس كجريمة الإيذاء العمدي في نص المادة (٦٠) من قانون الجزاء الكويتي رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠؛ لذلك كان من المفترض على المشرع رسم سياسة خاصة بالتجريم على ذلك الفعل، وأن يتناولها بشكل مفصل طالما أنه لم يدرجها في باب الجرائم الواقعة على النفس في قانون الجزاء الكويتي، فكان من اللازم عليه ألا يحيط بالقصد الجنائي العمدي فقط، بل أن يتناول مسألة الخطأ غير العمدي؛ وذلك بأن يجرّم الفعل الناتج عن نقل العدوى عن الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ المتمثل بإهمال أو تفريط من المجني عليه أو غيرها من صور الخطأ غير العمدي التي تناولها المشرع الكويتي في نص المادة (٤٤) من قانون الجزاء رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠^(١٩).

(١٨) أ. صفية محمود صفوت. القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة - دراسة مقارنة. بيروت: دار ابن زيدون. الطبعة الأولى. (١٩٨٦). ص ١١٩.

(١٩) نصت المادة (٤٤) من قانون الجزاء الكويتي على الآتي: (يعد الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتبه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح. ويعد الفاعل متصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتائج التي كان =

وقد كان مسلك المشرع الفرنسي موفّقاً في تجريمه للخطأ المؤسس على تعريض الغير عمداً للخطر وفقاً لنص المادة ٢٢٣-١ من قانون العقوبات الفرنسي^(٢٠). وهو نموذج إجرامي قائم على التجريم الجنائي الوقائي؛ أي منع وقوع الضرر، فالخطأ المؤسس على جريمة تعريض الغير عمداً للخطر يفترض حدوث نتيجة تحمل خطراً ولا تحتاج إلى وقوع ضرر فعلي، ومن خلال قراءة النص يتبيّن أن الركن المعنوي في هذه الجريمة يحتل مرتبة وسط ما بين العمد وغير العمد^(٢١). وفي ظل غياب نتيجة ضارة مادياً في تلك الجريمة، سيقع على القاضي الجنائي صعوبة إثبات أن الشخص تعرّض لخطر من هذا النوع، وأن هذا الخطر كان مباشراً وفورياً، وذلك حسب طبيعة كل حالة، ولا يمكن افتراض الخطر فقط على أساس وجود انتهاك لالتزام خاص بالأمن أو الحيلة مفروض من القانون أو اللائحة كما أشارت إليه المادة السابقة، بحيث يجب أن يظهر هذا الانتهاك في صورة معينة^(٢٢)، وهي شبيهة بنص المادة (١٧١) من قانون الجزاء الكويتي والتي سبق وأن تناولناها ولكن ليست على غرارها.

وإزاء عدم تناول المشرع الكويتي للخطأ غير العمدى في نقل عدوى الأمراض السارية، فالمرجعية تكون في قانون الجزاء الكويتي، فلو قام شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد ونقله للغير دون أن يتعمد ذلك، كأن يكون نقل العدوى ناشئاً عن إهمال أو عدم مراعاة اللوائح أو غيرها من صور الخطأ غير العمدى، فلا يكون محل مساءلة جنائية في جريمة الإيذاء غير العمدى وفقاً لنص المادة (١٦٤) في قانون الجزاء الكويتي^(٢٣)؛ لأنه يجب أن يكون الأذى محسوساً، وهذا ما لا ينطبق على فعل نقل فيروس كورونا.

= في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك).

(٢٠) نصت المادة ٢٢٣-١ من قانون العقوبات الفرنسي على الآتي: (الفعل الذي يعرض الغير مباشرة لخطر حال بالموت أو الجروح التي قد تؤدي إلى قطع عضو أو عاهة مستديمة بانتهاك إرادي واضح لالتزام خاص بأمن أو حيلة مفروض بواسطة القانون أو اللائحة، يعاقب بالحبس لمدة عام و١٠٠٠٠٠ فرنك غرامة).

(٢١) د. عادل علي المانع. الخطأ غير العمدى عبر العلاقة السببية غير المباشرة - دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والفرنسي. مجلة الحقوق. المجلد ٣٤. العدد ٣. (٢٠١٠). ص ١٠٣.

(٢٢) Le cabinet d'avocats Glon. Article mise en danger de la personne. Publié le 14 août 2013.

(٢٣) نصت المادة (١٦٤) من قانون الجزاء الكويتي على الآتي: (كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة... إلخ).

الملاحظة الثانية: إشكالية إثبات القصد الجنائي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية:

الشاهد في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية أن المشرع كما قلنا تطلب قصداً جنائياً عاماً، فيجب أن يكون نقل العدوى كفيروس كورونا المستجد نقلاً عمدياً؛ لذلك نرى أنه يصعب جداً على النيابة العامة إثبات نقل الفيروس عمدياً بقصد إصابة المجني عليه به، لا سيما أن الجاني المصاب بالفيروس والذي نقله عمداً إلى المجني عليه، قد يتذرّع بأن المجني عليه لم يتخذ الاحتياطات الكافية للوقاية من الفيروس فيما لو أبلغه الجاني بإصابته به حال مخالطته له، أو أن يتذرّع الجاني بأن نقله للفيروس كان ناتجاً عن إهمال أو عدم مراعاة اللوائح مما أدى إلى إصابة المجني عليه به، على الرغم من أن الجاني كان ينوي عمداً نقله إليه، وهنا أيضاً لا محل لمساءلته عن جريمة الإيذاء غير العمدي المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي.

لذلك يكون القصد الجنائي العمدي في بعض الجرائم قابلاً للتأويل، لا سيما إن كان الفعل المرتكب في ذاته يقبل التأويل، وبالتالي يكون مؤثراً في القصد الجنائي العمدي^(٢٤)، فالوسيلة التي يقتربها الجاني في نقله للفيروس تتسم بالسهولة كاللمس والتقبيل إلى غير ذلك مما يصعب مساءلة الجاني في جنائية النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد (covid-19).

المطلب الثاني

السياسة العقابية لدى المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية

سنستعرض في هذا المطلب الإشكاليات حول السياسة العقابية التي تناولها المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية. وبناءً على ذلك، سنتناول إشكاليات السياسة العقابية لدى المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وسنتحير مدى تناسب العقوبة التي قررها في هذه الجريمة.

(٢٤) د. السر الجيلاني و د. عمر الجيلاني. مفهوم القصد الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون - دراسة مقارنة. مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. العدد ٢١. (٢٠١٠). ص ٢٩٢.

الفرع الأول

إشكاليات السياسة العقابية لدى المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية

يجب أن تمر السياسة العقابية الجنائية من خلال ثلاث نقاط جوهرية، النقطة الأولى: هي أن المفهوم من العقوبة الجنائية ليس القسوة في تشديد العقاب الجنائي بغرض حماية المصلحة من وراء التجريم، والنقطة الثانية: هي أن المشرع وهو بصدد تناوله العقوبة على فعل معين يجب أن يراعي أطرافاً ثلاثة: الجاني والمجني عليه والمجتمع، والنقطة الثالثة: هي أن المشرع حين يوقع العقاب على فعل معين، يجب أن تكون القاعدة العقابية لا تهدف إلى حماية الأمور الثانوية تاركة الأمور الرئيسية في أحوال تعارضهما^(٢٥).

مر المشرع الجنائي الكويتي، وهو بصدد تجريم الفعل العمدي عن نقل عدوى الأمراض السارية وفق ما استحدثه مؤخراً في البند الثالث في المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، بنص مقترح بتعديل تلك المادة قبل النص الحالي، فكانت السياسة العقابية مختلفة جداً ما بين النص المقترح بتغليظ العقوبة من خلال تعديل المادة (١٧) من القانون رقم ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، والنص الحالي.

بناءً على ذلك، سنبيّن السياسة العقابية والإشكاليات التي وقع فيها المشرع الكويتي بشأن العقاب على فعل نقل العدوى عن الأمراض السارية، وسنعرض ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالموافقة على تعديل المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بناءً على مشروع الحكومة والاقتراح بقانون، بهدف تغليظ العقوبة في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، الذي حاز إجماع آراء الحاضرين في تلك اللجنة. وما يهمنا هنا هو البند الثالث من المادة السابقة؛ إذ جاء قبل التعديل الحالي بما يأتي: «كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

(٢٥) د. عادل المانع. الأمن القومي الجنائي مفهومه وأساسه. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المجلد ٢٢. العدد ٢٨٤. (٢٠٠٣). ص ٢٤.

وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى موت شخص أو أكثر».

أما النص الحالي للبند الثالث في المادة (١٧) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، الذي نُشر في جريدة «الكويت اليوم» بعد تعديله الأخير^(٢٦)، وسبق أن تناولناه في المطلبين السابقين، وسنتناوله هنا من حيث العقاب الذي يعدُّ أحد دعائم التجريم والذي جاء بما يلي: «كل مَنْ علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

إذاً فاستعرضنا البند الثالث من المادة (١٧) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ قبل تعديله ونصه الحالي، لبيان كيف تناول المشرع الكويتي مسألة العقاب على هذا النوع من الجرائم، لا سيما أن النصين السابقين (النص قبل التعديل والنص الحالي) قد جاءا بعد ظهور فيروس كورونا المستجد في دولة الكويت.

لذلك سنتساءل: هل كانت العقوبة على جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية ملائمة للفعل محل التجريم، أو أن اندفاع المشرع نحو تغليظ العقوبة كان وليد تسرع تشريعي نحو المغالاة غير المبررة؛ إذ إن العقوبة الجنائية تحكمها قواعد وأصول، وأبرز ما يحكمها هو مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل محل التجريم دون أن يغالي المشرع بالعقوبة بحجة وجود ظروف استثنائية كجائحة فيروس كورونا المستجد؟

سنشير ملاحظتين على البند الثالث من نص المادة (١٧) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية فيما يتصل

(٢٦) وهو التعديل الأخير في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية بشأن البند الثالث من المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، الذي نُشر في جريدة الكويت اليوم ملحق ٤ للعدد ١٤٨٨ بإصدار القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل المادة السابقة. ودلت المذكرة الإيضاحية منه بوضوح على التسرع التشريعي الجنائي بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ إذ نصت المذكرة الإيضاحية على أنه في ضوء الحاجة الملحة لسرعة تفعيل العقوبات المشار إليها؛ أي في المادة (١٧). فعبارة (تفعيل العقوبات) غير دقيقة في التشريعات التي تتضمن شق التجريم والعقاب. وهذا ما يُعاب على ما جاءت به المذكرة الإيضاحية.

بالعقاب قبل تعديل النص الحالي، ثم سنقوم بمقارنته مع النص الحالي لبيان سياسة المشرع في نظرتة لهذه الجريمة.

الملاحظة الأولى: أن السياسة العقابية في البند الثالث من المادة (١٧) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ قبل تعديله الحالي، لم توازن بين عناصر التجريم والعقاب، باعتبار أن العقاب أحد دعائم التجريم المهمة لفعالية النص الجنائي؛ إذ لم يتقيد المشرع الكويتي بالمبادئ التي تحكم العقوبة الجنائية، فجعل عقوبة النقل العمدي للعدوى عن الأمراض السارية لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات؛ أي لم يجعلها عقوبة معينة بذاتها، بل جعلها تتأرجح ما بين الجنحة والجناية، بشكل مغاير تماماً عن العقاب في النصوص الجنائية الأخرى في باب جرائم الاعتداء على النفس في قانون الجزاء الكويتي رَقْم (١٦) لسنة ١٩٦٠ كجريمة الإيذاء العمدي وجريمة الأذى البليغ وغيرهما من الجرائم في قانون الجزاء.

أما النص الحالي وَفْقاً للبند الثالث من المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، فالمشرع جعل هذه الجريمة في مصاف الجنايات بدلاً من أن تتراوح ما بين الجنحة والجنابة كالنص المقترح قبل تعديله، بحيث تكون عقوبة النقل العمدي عن عدوى فيروس كورونا المستجد مثلاً أو غيرها من الأمراض السارية هي الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات؛ أي أن المشرع قام بتغليظ العقوبة وبالغ في تغليظها مبالغة تؤدي إلى إهدار مبادئ العقوبة الجنائية من حيث تناسب العقوبة مع الفعل محل التجريم، لا سيما أن المشرع لم يتطلب حدوث نتيجة الوفاة في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وإنما تطلب فقط حدوث نتيجة الإصابة بالعدوى دون أن يشترط أن تؤدي إلى الوفاة. وأيضاً لم يراع المشرع الفرق بين تلك الأمراض السارية المدرجة في جدول القانون وبين مرض فيروس كورونا المستجد باعتباره مدرجاً أيضاً في ذلك الجدول.

الملاحظة الثانية: يُعاب على ما جاء به المشرع الكويتي في البند الثالث من المادة (١٧) في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ قبل تعديله الحالي من ناحية تغليظ العقوبة في صياغة جنائية غريبة جداً، فجاءت مضاعفة العقوبة على جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية وَفْق الآتي: «وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى موت شخص أو أكثر». ويُعاب على تلك الصياغة أنه غلط العقوبة الجنائية حال نقل العدوى عمداً عن الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد مثلاً إلى أكثر من ثلاثة أشخاص، وهو أمر يخالف المنطق الجنائي في هذا النوع من

الجرائم، فقد يكون المجني عليهم الثلاثة مخالطين لأشخاص آخرين نُقلت إليهم العدوى غير الجاني، خصوصاً بعد أن تطرقنا إلى إشكاليات العلاقة السببية.

غير أن الصياغة الجنائية العقابية السابقة نالت تأييدنا فيما يتصل بحدوث النتيجة وهي الوفاة، وعدم تحديدها عدداً معيناً في عبارة: «وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى موت شخص أو أكثر». وهذا ما كنا نريده من المشرع الكويتي أن يضعه في البند الثالث من النص الحالي، وهو نص المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، فترك حدوث نتيجة الوفاة وفق القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي التي أيضاً لا تسعفنا في هذا المجال. والغريب في الأمر أنه تدارك حدوث نتيجة الوفاة جراء إصابة المجني عليه بعدوى من مرض سار من قبل الجاني في النص السابق المقترح قبل تعديله، بينما لم يتداركها وفقاً للنص الحالي بعد تعديله، بل قام بحذف نتيجة الوفاة في حال الإصابة بالعدوى.

الفرع الثاني

تباين موقف المشرع الكويتي فيما يتصل بالعقاب بين جريمتي النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية وجريمة نقل عدوى الإيدز

لم يأخذ المشرع الجنائي موقفاً موحداً فيما يتصل بالعقاب بين جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية وجريمة نقل عدوى الإيدز على الرغم من أن مرض الإيدز يعتبر مرضاً سارياً، وقام المشرع بتنظيم مرض الإيدز تنظيمياً خاصاً في القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٩٢ بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز). لكن تثار لدينا ملاحظات فيما يتصل بالعقاب في جريمة النقل العمدي عن عدوى الإيدز والجريمة التي استحدثها المشرع الكويتي مؤخراً وهي جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية.

نصت المادة (١٥) من القانون المذكور سلفاً فيما يخص نقل عدوى الإيدز على الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار كل مَنْ علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر».

وبناءً على ذلك، سنبين العقوبة عن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، حتى نستظهر جلياً أوجه المشكلة في السياسة العقابية لدى المشرع الكويتي في الجريمة السابقة، فالعقوبة التي قررها المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي

عن عدوى الأمراض السارية في البند الثالث لنص المادة (١٧) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ما يأتي: «كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ولابد أن يثار التساؤل الآتي وهو: هل تم نسخ المادة (١٥) من القانون رَقْم (٦٢) لسنة ١٩٩٢ بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) بأن استعاض عنها المشرع بالنص الذي استحدثه مؤخراً في البند الثالث من نص المادة (١٧) في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية فيما يتعلق بجريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، باعتبار أن التشريع اللاحق يلغي السابق بطريق تعارض النصوص، حتى تسري عقوبة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية على النقل العمدي عن عدوى الإيدز؟ للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نشير إلى أن الإلغاء الضمني يكون إذا تضمن النص الجنائي الجديد إعادة تنظيم موضوع تولّى تنظيمه نص جنائي سابق عليه^(٢٧). فركنا عناصر التجريم المادي والمعنوي متماثلان في كلتا الجريمتين، جريمة النقل العمدي عن عدوى الإيدز وجريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية المستحدثة مؤخراً. وأيضاً يعدُّ فيروس الإيدز مرضاً من الأمراض السارية، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رَقْم (٦٢) لسنة ١٩٩٢ بشأن مرض الإيدز مع سريان تدابير وإجراءات الوقاية من مرض الإيدز في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩. غير أنه لم يُدرج باعتباره مرضاً من الأمراض السارية في الجدول الملحق في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن مكافحة الأمراض السارية، وطالما أنه لم يُدرج في هذا الجدول، فالإجابة هي أنه لم يتم نسخه بالنص المستحدث في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية وفقاً للقانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩، وبالتالي لا تسري عليه عقوبة جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية؛ لأنه كما قلنا: إن الشرط المسبق في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية أن نكون بصدد مرض سار مدرج مسبقاً في جدول الأمراض السارية.

ومن المعلوم أيضاً أن مرض الإيدز أخطر مرض من الأمراض السارية؛ أي أخطر

(٢٧) د. فايز الظفيري و د. محمد بوزبر. مرجع سابق. ص ١٦٩.

من مرض فيروس كورونا المستجد، فنلاحظ أن المشرع عاقب على نقل الإيدز عمداً بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، بينما عقوبة النقل العمدي لعدوى فيروس كورونا المستجد مثلاً فهي الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وأيضاً نلاحظ التفاوت في عقوبة الغرامة أيضاً بين جريمة النقل العمدي عن عدوى الإيدز وجريمة النقل العمدي عن عدوى فيروس كورونا المستجد مثلاً، فغرامة الأولى لا تجاوز سبعة آلاف دينار، أما غرامة الثانية فلا تجاوز ثلاثين ألف دينار، وهنا يتضح لدينا أن المشرع لم يوفق في سياسته العقابية في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، حيث إن جريمة نقل الإيدز هي أخطر بكثير من نقل فيروس كورونا المستجد وغيرها من الأمراض السارية المدرجة في جدول القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، وكان الأجدر بالمشرع الكويتي أن يوازن في عقوبة جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، كما وازنها في جريمة النقل العمدي عن مرض الإيدز.

الفرع الثالث

الحلول الجنائية فيما يتصل بالعقاب في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية

انطلاقاً من بياننا للسياسة الجنائية لدى المشرع الكويتي في العقاب وإثارة الإشكاليات حولها. من اللازم علينا أن نبدي أهم المعالجات الجنائية في السياسة العقابية لتلك الجريمة، وذلك على النحو الآتي:

١ - نهيب بالمشرع الكويتي أن يقوم بتعديل البند الثالث من المادة (١٧) وفقاً للقانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، بأن تكون مدة عقوبة الحبس لا تزيد على خمس سنوات، كما فعل المشرع الإماراتي في نص المادة (٣٤) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ بشأن مكافحة الأمراض السارية، بأن جعل عقوبة النقل العمدي عن عدوى الأمراض الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات^(٢٨).

(٢٨) جاء القانون الاتحادي الإماراتي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ بشأن مكافحة الأمراض السارية، وأدرج فيها المشرع الإماراتي فيروس كورونا المستجد (covid-19) في الجدول الملحق بذلك القانون، فنصت المادة (٣٤) من ذلك القانون على أنه: "يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (١) المرفق في هذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير". وجاءت المادة (٣٩) بالعقاب على ما سبق؛ إذ نصت على أنه: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٣٤) من هذا القانون بالسجن مدة =

- ٢ - نتمنى من المشرع الكويتي أن يشدد العقاب في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية في حال حدوث نتيجة الوفاة بسبب الإصابة بالعدوى دون أن يقصد الجاني قتله، بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
- ٣ - نهيب بالمشرع الكويتي أن يتناول العقوبة على نمط آخر أيضاً، وذلك بأن يضيف على العقاب فرضية وجود صفة في الفاعل وهو الطبيب المختص الذي يعلم بإصابته بمرض سار ونقله عمداً إلى المجني عليه بقصد إصابته بالعدوى، فيشدد العقاب على هذه الفرضية بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلة اقتراحنا في تشديد العقاب في هذه الفرضية أن الطبيب المختص يستطيع أن يعلم بإصابته بمرض سار كفيروس كورونا المستجد (covid-19) أكثر من الشخص العادي؛ إذ إن الأخير يجري فحوصات معينة حتى تتأكد إصابته، ثم يتم حجره صحياً سواء في المستشفى أو المنزل حسب الأحوال، أما الطبيب المختص فيستطيع أن يكون بمنأى عن الحجر الصحي في حال علمه بإصابته بالعدوى من خلال إجراء فحوصات معينة أو مسحات معينة يجريها مع نفسه دون أن يطلع الغير عليها، ثم يقوم بنقل العدوى عمداً إلى الغير.
- ٤ - نهيب بالمشرع الكويتي أن يعيد نظره فيما يتصل بالعقاب في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية؛ إذ إن جساماً أو نتيجة الأمراض السارية ليست كلها على درجة واحدة. وقد أحسن المشرع الكويتي في وضع تنظيم خاص في سياسته الجنائية بتجريمه السلوك الناشئ عن النقل العمدي لمرض الإيدز، بأن جعل العقوبة مناسبة للفعل محل التجريم كما بيّنا سابقاً.
- ٥ - نقترح على المشرع الكويتي أن يشدد العقاب على الجاني المصاب بمرض سار تعمد نقله إلى أكثر من شخص بقصد إصابتهم به بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. والفلسفة العقابية في التشديد هنا تكمن في قيام الجاني بجعل النطاق الجغرافي الذي هو فيه بؤرةً للوباء من خلال نقله العمدي بفيروس كورونا المستجد (covid-19) مثلاً، دون

= لا تزيد على خمس سنين وبالعقوبة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن"، فنلاحظ أسبقية المشرع الإماراتي في تجريمه وعقابه على جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية على عكس المشرع الكويتي الذي تأخر في تجريمه لذلك الفعل.

تحديد عدد معين كما في النص المقترح قبل التعديل الحالي، وعبارته هي: «تضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص»، فيكفي - في نظرنا - أن يصاب شخصان في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية؛ لذلك نرى الصياغة الجنائية الأدق فيما يتصل بالعقاب هنا هي «إصابة أكثر من شخص».

٦ - إن غياب الدور التشريعي في إقرار مسؤولية الشخص المعنوي وَفَقاً للقواعد العامة يقتضي منا أن نقترح على المشرع الكويتي أن يضيف في البند الثالث من نص المادة (١٧) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، الأخذ بمسؤولية الشخص المعنوي في تسببه لنقل العدوى عن مرض من الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ وذلك بتوقيع العقاب عليه في حال تعريض العمال أو الموظفين في ظل تفشي الوباء لإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد (covid-19). هذا على غرار المشرع الفرنسي الذي أضفى الحماية الجنائية وتوقيع العقاب في جريمة تعريض الغير عمداً للخطر، ويكون الشخص المعنوي تحت العقاب، وذلك وَفَقاً لنص المادة ٢٢٣-١ من قانون العقوبات الفرنسية^(٢٩).

(٢٩) د. حاتم عبد الرحمن. مرجع سابق. ص ٨٣.

المبحث الثاني

الجرائم والقرارات محل التجريم للتصدي لفيروس كورونا المستجد

يسلط هذا المبحث الضوء على الجرائم والقرارات محل التجريم، ونعني بالقرارات محل التجريم القرارات الإدارية التي عاقب المشرع الكويتي على مخالفتها، وتعد مخالفتها جريمة يعاقب عليها الجاني في حال إتيانه السلوك المخالف للقرار، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، والقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني.

ويقتضي أن نطرح أهم القرارات الإدارية محل التجريم، وأهم الجرائم التي عناها المشرع الكويتي للتصدي للأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد في ضوء أحكام القوانين السابقة، وأن نستعرض أهم الإشكاليات التي طرأت على فحوى هذه القرارات، وأهمها قرار حظر التجول من خلال استنباط عناصر التجريم التي جاءت بها، ومدى اتساقها مع أصول التجريم والعقاب. فكان من اللازم أن نعرض ذلك في مطلبين، وهما على النحو الآتي:

- المطلب الأول: جريمة مخالفة القرار رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر التجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
- المطلب الثاني: مسؤولية المبلغ والقرارات محل التجريم في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩.

المطلب الأول

جريمة مخالفة القرار رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر التجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد

يجب أن نبين أولاً أن أي قرار إداري حتى يكون محلاً للتجريم لابد أن يكون صادراً من وزير مختص، وأن يكون القرار منشوراً، وإن كان القرار المعني بحظر التجول - حسب رأينا - هو القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أي القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر من قبل وزير الصحة، إلا أن قرار وزير الداخلية رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ والذي أصبح محل تداول من قبل الجمهور دون أن ينشر في الجريدة الرسمية حيث لا يشترط القانون نشر القرارات المنفذة للقانون في الجريدة

الرسمية فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر تطبيقاً لقانون معين إلا أننا نحبذ أن يكون النشر موحداً في جريدة معينة كجريدة الكويت اليوم، لاسيما وأن نيابة الأحداث قد أسندت الاتهام على الحدث المخالف لذلك القرار أي قرار وزير الداخلية وفقاً لحكم محكمة الأحداث والذي سنبينه لاحقاً. لذلك كان من اللازم بيان عناصر التجريم لجريمة مخالفة قرار حظر حركة المرور والتجول الصادر من قبل وزير الداخلية، وبيان تلك العناصر يقتضي منا أولاً بيان الأساس القانوني الجنائي الذي استند إليه القرار، وعليه سنبدي تساؤلاً أولاً وهو: هل القرار التنظيمي السابق استند إلى صحيح القانون فيما يتصل بالعقاب على مخالفة القرار؟ فإن كانت الإجابة أن القرار التنظيمي السابق قد استند إلى قانون ليس له علاقة بتقييد حركة المرور والتجول، فتبعاً لذلك تُهدم معه بالتبعية جميع عناصر التجريم الأخرى في القرار التنظيمي بشأن تقييد حركة المرور والتجول، وهذا ما سوف نبديه كأول تساؤل قبل التطرق إلى عناصر التجريم في القرار التنظيمي السابق. وسنتناول ثانياً إشكالية الشرط المسبق في جريمة مخالفة ذلك القرار، ثم الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بصدد هذه الجريمة.

الفرع الأول

السند القانوني لجريمة مخالفة القرار الوزاري رَقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقييد حركة المرور والتجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد

إن الأساس القانوني الذي استند إليه القرار السابق بشأن جريمة مخالفة تقييد حركة المرور والتجول التي جاءت وفقاً للمادة الأولى من القرار السابق وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد هو القانون رَقْم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني؛ إذ نصت المادة الثانية من القرار السابق على ما يأتي: «يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني بتنفيذ أحكام المادة السابقة (وهي في شأن تقييد حركة المرور والتجول) واتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رَقْم (٧٩/٢١) في شأن الدفاع المدني المشار إليه».

فالقانون رَقْم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني هو الأساس القانوني والمناط العقابي في جريمة مخالفة القرار الوزاري رَقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقييد حركة المرور والتجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ إذ نصت المادة (١٥) من القانون رَقْم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني على الآتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويلزم الإشارة إلى أن النقطة الحاسمة في هذا الصدد التي تحتاج إلى الوقوف عليها ملياً هي أن القانون رُقْم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني ليس هو السند الصحيح الذي يعتبر محلاً للعقاب على مخالفة القرار رُقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقييد حركة المرور والتجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد وفقاً لنص المادة الثانية من ذلك القرار الذي أشرنا إليه سلفاً، وإنما السند الصحيح لحظر التجول هو أن يكون صادراً من وزير الصحة وفقاً لنص المادة (١٥) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض والتي سنشير إليها لاحقاً، وهو بالفعل قد صدر من قبل وزير الصحة وهو القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٠.

ورؤيتنا السابقة مبنية على غياب الشرط المسبق، وهو وجود حالة من حالات أخطار الحرب كما نصت عليه المادة الثانية من القانون رُقْم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني، بحيث يكون تقييد حركة المرور والتجول حسب البند رُقْم (١٥) من تلك المادة في حال وجود فقط أخطار الحرب، وبالتالي يفقد القرار الوزاري رُقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقييد حركة المرور والتجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد سنده القانوني فيما يتصل بالشق الجنائي في العقاب وهو القانون المشار إليه سلفاً. لذلك سنتناول هذه النقطة - حتى تتضح المسألة - في الشرط المسبق لقيام جريمة مخالفة قرار تقييد حركة المرور والتجول المشار إليه في القانون المذكور سلفاً.

بناءً على ما سبق، سنتناول العناصر التجريبية اللازمة لقيام جريمة مخالفة القرار الوزاري رُقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقييد حركة المرور والتجول، وسنركز على الشرط المسبق للتجريم نظراً لغيابه - حسب رأينا - باعتباره الأرضية التي تُبنى عليها عناصر الركنين المادي والمعنوي للفعل الإجرامي في جريمة مخالفة ذلك القرار، فبغيابه يتعذر التجريم، ويستحيل تحققه استحالة قانونية لتخلف الشرط المسبق في التجريم.

لذلك بعد أن انتهينا من التساؤل الأول في هذه الجريمة وهو السند القانوني الذي استند إليه ذلك القرار محل التجريم، ورأينا أنه استند إلى قانون يخرج عن نطاقه، سنأتي على التساؤل الثاني وهو حول إشكاليات عناصر التجريم في جريمة مخالفة قرار تقييد حركة المرور والتجول، وسنسلط الضوء أكثر على الشرط المسبق

للتجريم نظراً لغيابه كما بيّنا سلفاً، وسنشير إلى الحكم الجنائي القضائي الذي صدر مؤخراً على شخص خالف قرار تقييد حركة المرور والتجول مع تعليقنا عليه.

الفرع الثاني

إشكالية الشرط المسبق في جريمة مخالفة القرار رَقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقييد حركة المرور والتجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد

كان نتاج تحليلنا الجنائي أن وجود أخطار الحرب وَفَقاً للمادة الثانية المشار إليها في قانون الدفاع المدني هو العنصر المسبق في جريمة مخالفة قرار حظر حركة المرور والتجول، لا سيما أن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول مشار إليه في البند (١٥) بأن جعلته المادة الثانية من قانون الدفاع المدني في فقرتها الثالثة وسيلة خاصة من وسائل الوقاية من أخطار الحرب. ونصها الآتي: «تشمل تدابير الدفاع المدني كافة الوسائل التي تحقق الغرض منه، وبصفة خاصة ما يأتي: ... ثالثاً: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحرب، وإعداد متطلباتها ومواجهتها وذلك بتنظيم الوسائل الخاصة بما يأتي: ... ١٥- تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول».

إذاً فالشاهد بعد أن استعرضنا نص المادة الثانية المشار إليه آنفاً من القانون رَقْم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني، أن البند رَقْم (١٥) وهو تنظيم حظر حركة المرور والتجول مقيّد فقط بالشرط المسبق الذي قلناه في جريمة مخالفة القرار الوزاري بشأن حظر حركة المرور والتجول، والشرط المسبق هو وجود خطر من أخطار الحرب حسب ما نراه في البند «ثالثاً» من المادة السابقة. وما يدعم رأينا هو أن المادة السابقة التي عنت بوضع خطط لمواجهة أخطار الحرب قد جاءت بصريح العبارة بأنها من «الوسائل الخاصة» المحصورة حال وجود خطر من أخطار الحرب، ومن ضمنها تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول كوسيلة خاصة بها فقط^(٣٠).

(٣٠) ما يدل على رأينا أن حظر حركة المرور والتجول مقيّد فقط في حالة أخطار الحرب هو ما نصت عليه المادة الثانية - وسنبيّنها هنا بوضوح - من قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني؛ إذ جاء فيها: (تشمل تدابير الدفاع المدني كافة الوسائل التي تحقق الغرض منه، وبصفة خاصة ما يأتي:

أولاً: وضع الخطط الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصلات البرية والمائية والجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية، وضمان سير الإدارة الحكومية في الحالات المشار إليها في المادة السابقة.

ثانياً: وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة وإعداد متطلباتها والتصدي لها. (ولا يصح برأينا =

إذاً نستطيع أن نستنتج بأن حظر حركة المرور والتجول مقيد فقط في حال وجود أخطار الحرب، ولا يعتبر فيروس كورونا المستجد من قبيل أخطار الحرب وإلا توسعنا في ذلك توسعاً يفضي إلى إهدار مبدأ شرعية النصوص الجنائية، لا سيما وأن ذلك القرار تعتبر مخالفته جريمة، فيجب وفقاً لذلك إعمال كافة القواعد والأصول المعمولة في النصوص الجنائية كقاعدة التفسير الضيق للنص الجنائي.

الفرع الثالث

التعليق على حكم المحكمة الكلية (محكمة الأحداث) بشأن جريمة

مخالفة حظر حركة المرور والتجول

أصدرت محكمة الأحداث (وهو حكم أول درجة) مؤخراً في الجلسة المنعقدة بالمحكمة الكلية في تاريخ ٧/٤/٢٠٢٠ الحكم بحبس المتهم (الحدث) ثلاثة أشهر في إحدى المؤسسات العقابية الخاصة بالأحداث.

غير أن المحكمة اتجهت إلى منحي آخر لم يكن متماشياً مع القرار السابق؛ إذ استندت في عقاب الحدث إلى نص المادة (١٥) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية دون أن تشير إلى قرار وزير الصحة بذلك، ولم تلتفت إلى قانون الدفاع المدني الذي يعتبر محلاً للعقاب وفقاً للمادة الثانية من قرار حظر حركة المرور والتجول وفقاً لما أسندته النيابة.

= تأسيس حظر حركة المرور والتجول على هذه الفقرة؛ وذلك لسببين، السبب الأول: أن حظر حركة المرور والتجول مقيد بالفقرة التي تليها؛ إذ تعدّ وسيلة خاصة لها لا يجوز القياس عليها كخطة لمواجهة الكوارث العامة، لا سيما أن القياس محظور في التجريم كقاعدة جنائية أصولية. والسبب الثاني: أن عبارة الكوارث العامة لا تستوعب الأوبئة كفيروس كورونا المستجد (covid-19)؛ إذ يدل معناها على الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والأعاصير وغيرها، ولا سيما أن ثمة قاعدة جنائية وهي أن تفسير النصوص الجنائية على الضيق لا يؤدي إلى خلق تجريم آخر، وإلا خرجنا على مبدأ الشرعية).

ثالثاً: وضع الخطط للوقاية من أخطار الحرب، وإعداد متطلباتها ومواجهتها؛ وذلك بتنظيم الوسائل الخاصة بما يأتي:.... البند ١٥: تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول. ولا يعني ذكر البنود الأخرى؛ إذ ليس لها علاقة بتلك الإشكالية، ونلاحظ هنا أن هذا البند قد جاء كإحدى الوسائل الخاصة للوقاية من أخطار الحرب، ولا يعد فيروس كورونا المستجد (covid-19) خطراً من أخطار الحرب. أما القول بأن ذلك الفيروس هو حرب بيولوجية مثلاً وبالتالي يعد من ضمن أخطار الحرب، فهو قول غير صحيح وغير مثبت أصلاً ويؤدي إلى توسيع في تفسير النص الجنائي، خصوصاً أن مخالفة أحكام المواد والقرارات المنفذة لقانون الدفاع المدني يعاقب عليها وبالتالي تعد جريمة، وطالما أنها جريمة فيجب التقيد وفقاً لأصول التجريم والعقاب.

تبعاً لذلك، فإن مناط التعليق على الحكم القضائي المشار إليه سابقاً، سوف يتبلور حول ثلاث نقاط: بيان وقائع الدعوى الجنائية، والأسانيد والأسباب التي استندت إليها المحكمة في العقوبة، والتعليق على ذلك.

وقائع الدعوى الجنائية في الحكم السابق:

تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في أن نيابة الأحداث قد أسندت إلى المتهم أنه في تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ وجد في الطريق العام في غير الأحوال المصرح بها، وتجول في الطرق العامة بالمخالفة للقرار رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر حركة المرور والتجول. أما بقية الأسانيد فيما يتعلق بمخالفة قانون المرور الكويتي فهي لا تعيننا في هذا المجال، وسوف نسلط الضوء فقط على جريمة مخالفة القرار السابق بشأن حظر حركة المرور والتجول التي أسندتها نيابة الأحداث إليه^(٣١).

غير أن نيابة الأحداث قد استندت إلى نص المادة الأولى من القرار رقم (٢٧٩) بشأن حظر حركة المرور والتجول في عقاب المتهم، وطلبت من محكمة الأحداث عقاب المتهم الذي خالف حظر التجول وفقاً لنص المادتين (٣/١٥) من القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني^(٣٢).

وتبعاً لما سبق بيانه من أسانيد نيابة الأحداث فيما يتعلق بوصف التهمة في عقاب المتهم المخالف للقرار والقانون المشار إليهما سابقاً، سنعرض رأي محكمة الأحداث بشأن ذلك.

رأي محكمة الأحداث في أسانيد نيابة الأحداث بوصف التهمة وهي جريمة مخالفة قرار حظر التجول وفقاً لقانون الدفاع المدني:

لم يكن رأي محكمة الأحداث متماشياً مع أسانيد نيابة الأحداث في وصف التهمة المشار إليها سابقاً، بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذا ما نظرنا في حيثيات الحكم. وانطلاقاً من ذلك سنعرض نقطتين نجل فيهما أسانيد وأسباب محكمة الأحداث في تغيير وصف التهمة في جريمة مخالفة قرار حظر التجول، وذلك على النحو الآتي:

النقطة الأولى: فيما يتعلق بتغيير وصف التهمة؛ إذ قامت محكمة الأحداث بتعديل وصف التهمة التي أسندتها النيابة إلى المتهم، وهي جريمة مخالفة القرار رقم (٢٧٩)

(٣١) حكم المحكمة الكلية في القضية رقم (٢٦٤) لسنة ٢٠٢٠. الدائرة / جنح أحداث د/١. الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٧. فيما يتعلق بأسانيد نيابة الأحداث على المتهم في

البند الأول. ص ١.

(٣٢) الحكم السابق. ص ٢.

لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر التجول، ويعاقب على مخالفتها وفقاً للمادة الثانية من القرار نفسه القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني في نص المادة (١٥)، التي تعاقب كل من يخالف القرارات المنفذة لأحكام قانون الدفاع المدني كحال القرار السابق - بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين^(٣٣). ويلزم الإشارة هنا إلى أن أي تغيير في التكيف الجنائي من خلال وقائع الدعوى الجنائية من حيث التجريم والعقاب من شأنه أن يؤدي إلى الخروج على مبدأ شرعية النصوص الجنائية، فهذا المبدأ ليس موجهاً فقط للمشرع الجنائي، بل أيضاً موجهاً للقاضي الجنائي، فهو المعني أيضاً بتطبيق هذا المبدأ على وقائع الدعوى الجنائية المعروضة عليه، بأن لا يضيف على تلك الوقائع تكييفاً ليس له محل من الأساس^(٣٤).

النقطة الثانية: فيما يتعلق بسند المحكمة، إذ قامت محكمة الأحداث بتعديل التهمة السابقة، وأسندت سلوك المتهم بمخالفة حظر التجول إلى البند الثاني من المادة (١٥) الخاصة بمنع التجول في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية دون أن تشير إلى قرار وزير الصحة بشأن حظر التجول، إذ حتى يتم تفعيل المادة السابقة يجب أن نكون بصدد قرار صادر من وزير الصحة. وقامت بعقابه وفقاً لنص المادة (١٧) في بندها الثاني من القانون السابق، وجاءت بما يأتي: «كل مخالفة للبند المشار إليها في المادة (١٥) يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وجاء منطوق الحكم بحبس الحدث ثلاثة أشهر، ومن خلال اطلاعنا على حيثيات الحكم، كانت المحكمة حريصة على ردع الجاني بعقابه بالحد الأقصى لتلك العقوبة في سبيل التصدي لفيروس كورونا المستجد، بحيث كانت المحكمة تهيب بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بالقوانين ومنها عدم مخالفة حظر التجول^(٣٥).

وبناء على ما سبق، سنعرض ملاحظتنا على أسانيد نيابة الأحداث ومحكمة الأحداث، وذلك على النحو الآتي:

الملاحظة الأولى: أن استناد نيابة الأحداث إلى نص المادتين (٣) و (١٥) من

(٣٣) الحكم السابق. ص ٤.

(٣٤) د. أحمد أسامة حسنية. التكيف في المواد الجنائية ودوره في تحقيق العدالة الجنائية. مجلة الفقه والقانون. العدد ٦٤. (٢٠١٨). ص ١١١.

(٣٥) الحكم السابق. ص ٨.

القانون رَقْم (٢١) في شأن الدفاع المدني في عقاب المتهم لاقترافه السلوك المحظور بتجوله في الطرق العامة دون مسوغ بالمخالفة للقرار رَقْم (٢٧٩) بشأن حظر حركة المرور والتجول - غير صحيح حسب رأينا؛ وذلك لغيباب الشرط المسبق المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون السابق وهو عدم وجود حالة أخطار الحرب؛ لأن تقييد حركة المرور والتجول جاءت فقط في تلك الحالة كوسيلة خاصة للوقاية من أخطار الحرب، مما يستحيل معه تحقق عنصرَي التجريم المادي والمعنوي بشأن حظر حركة المرور والتجول في القرار المشار إليه استحالة قانونية لتخلف الشرط المسبق وهو وجود خطر من أخطار الحرب، فكان حرياً بالنيابة أن تسند إليه في العقاب وفقاً للقرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر من وزير الصحة والمنشور في الجريدة الرسمية، فهو القرار المعني في هذا التجريم وهو منع التجول.

الملاحظة الثانية: إن استناد محكمة الأحداث في عقاب المتهم إلى البند الثاني من نص المادة (١٥) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية في غير محله حسب رأينا، وذلك أن المحكمة لم تشر في حكمها على القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر التجول الصادر من قبل وزير الصحة، ولا يصح الاكتفاء فقط بالمادة السابقة للقول بعقابه، فالقرارات محل التجريم قلنا فيما سبق بأننا يجب أن نكون أولاً بصدد قرار إداري صادر من وزير مختص، وأن يكون القرار منشوراً في الجريدة الرسمية، ونعني بذلك القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٠ والذي لم تشر إليه المحكمة في حكمها^(٣٦).

المطلب الثاني

مسؤولية المبلغ والقرارات محل التجريم في القانون

رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩

سنتطرق في هذا المطلب إلى القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية فيما يتصل بمسؤولية المبلغ حال إصابة شخص أو الاشتباه بإصابته بمرض من الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد، وسنتناول المادتين (١٥، ١٧) من القانون المشار إليه.

ويلزم الإشارة إلى أن القانون السابق بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض ليس قانوناً جنائياً صرفاً، فاستقلال القانون الجنائي بالمفهوم التشريعي

(٣٦) الحكم السابق ص ٤ و ٥.

يُقصد به وضع نصوص جنائية صرفة في مدونة تشريعية واحدة، وثمة فرق بين ذاتية المصطلح في القانون الجنائي وبين استقلاله^(٣٧).

وسنسلط الضوء في هذا المطلب على نوعين من الجرائم بشأن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد وهما: جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية، جريمة مخالفة القرارات الخاصة بالمادة (١٥) من ذلك القانون.

الفرع الأول

الإشكاليات الجنائية في جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية

استخدم المشرع الكويتي في هذه الجريمة القاعدة الجنائية الموزعة التي تعنى بتوزيع شق التجريم في نص وشق العقاب في نص آخر. انطلاقاً من ذلك تجد أساس شق التجريم في هذه الجريمة في المادتين (٢، ٣) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. أما شق العقاب، فتجد أساسه في هذه الجريمة في نص البند الأول من نص المادة (١٧) الذي قام بتعديله المشرع مؤخراً من حيث العقاب فقط بأن قام بتغليظ عقوبة الحبس والغرامة في مخالفة المادتين (٢، ٣) بشأن الجريمة السابقة، من الحبس مدة لا تزيد على شهر إلى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ومن الغرامة بخمسين ديناراً إلى خمسة آلاف دينار.

وجاءت المادتان المشار إليهما من حيث شق التجريم على النحو الآتي:

المادة (٢) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والتي جاءت بما يلي: «إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، وجب الإبلاغ عنه خلال مدة ٢٤ ساعة إلى أقرب مركز للصحة للوقائية، كما يجب التبليغ بالطريقة نفسها عن حاملي جراثيم الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة». أما المادة (٣) من القانون نفسه، فقد حددت المسؤولين عن التبليغ في المادة السابقة، فنصت على أن المسؤولين عن التبليغ المشار إليه في المادة السابقة هم على الترتيب الآتي:

(٣٧) أ. د. نوفل علي الصفو. ذاتية المصطلح في قانون العقوبات. مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت. (٢٠١٨). ص ٢٥٠ - ٢٥١.

- أ - الطبيب الذي قام بالكشف على المريض.
 - ب - أقارب المريض البالغون ذكوراً وإناثاً المقيمون معه في المنزل نفسه أو الذين اتصلوا به أثناء المرض، ويكون ترتيبهم في مسؤولية التبليغ بحسب درجة قرابتهم له.
 - ج - الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بغض النظر عن قرابته له.
 - د - صاحب الفندق أو المطعم أو المصنع أو القائم بإدارته وناظر المدرسة أو المشرف على القسم الداخلي فيها إذا حدثت الإصابة في أحد هذه المحلات أو أي محل آخر من هذا القبيل».
- ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام وفقاً لنص المادة (١٧) المستحدث من القانون نفسه، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وتبعاً لما تقدم، سنجمل القول بعرض عناصر التجريم في جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد:

إشكالية الشرط المسبق في جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية:

يتبلور الشرط المسبق في هذه الجريمة حول عنصرين لازمين لقيام الجريمة وهما: أن نكون بصدد وجود إصابة يقينية بفيروس كورونا المستجد مثلاً أو الاشتباه بهذه الإصابة، وأن نكون بصدد وجود صفة في المبلغ بما وصفه المشرع بعبارة «المسؤولين عن التبليغ». فهذان الشرطان المفترضان يتصدران عناصر التجريم الأخرى كالركنين المادي والمعنوي، وغياب أحدهما يستحيل معه تحقق الجريمة استحالة قانونية.

الإشكالية التي تُثار بالنسبة إلى الشرطين السابقين في التجريم السابق، هي أن المشرع الكويتي قد قيّد مسألة التبليغ عن عدوى الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد بصفة معينة بالمبلغ المشار إليه على سبيل الحصر في نص المادة الثانية المذكورة سلفاً حتى يتحقق التجريم، وبغياب هذه الصفة يستحيل معه تحقق الجريمة دون البحث عن الركنين المادي والمعنوي؛ ولذلك يُثار الإشكال حول عنصر الاشتباه بإصابة شخص مثلاً بفيروس كورونا المستجد، فكيف يحاسب المبلغ في جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية في حال وجود شخص مشتبّه بأنه مصاب بمرض سار ومع ذلك لم يبلغ، كزوج المشتبه به مثلاً، فقد يدفع هنا بانتفاء عنصر

الاشتباه كون أعراض فيروس كورونا المستجد تشابه أعراض الأنفلونزا العادية؛ إذ إن المعني والمختص فقط بتحديد الاشتباه هما الطبيب والمصاب بالفيروس الذي سيقوم بالتحري عن نفسه بوجود الإصابة أكثر من غيره ممن حددهم المشرع.

وئثار إشكالية فيما إذا كان شخص هو نفسه يشتبه بأنه يحمل أعراض فيروس كورونا المستجد مثلاً كقيامه بقياس درجة حرارته واكتشف أنها أعلى من المعدل الطبيعي مع صداع وسعال جاف، حيث لا يسأل عن جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية؛ لأنه ليس له صفة المبلغ المشار إليه في المادة (٢) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. وكان الأجدر بالمشرع أن يطال التجريم المصاب نفسه في حال علمه اليقيني أو علمه الافتراضي وعدم تبليغه للسلطات الصحية بذلك.

ويُثار لدينا تساؤل فيما لو كانت الجريمة السابقة تتعارض مع الحق في الحياة الخاصة كحق المريض بعدم إفشاء سره الطبي، للإجابة عن هذا التساؤل نحن أمام مصلحتين: المصلحة الأولى وهي مصلحة عامة تخص المجتمع وذلك في مكافحة وزارة الصحة هذا النوع من الأمراض وهي الأمراض السارية، والمصلحة الأخرى هي مصلحة خاصة تخص المريض بعدم جواز إفشاء سره الطبي، والقاعدة تقضي بأن المصلحة العامة تغلب المصلحة الخاصة، وتجدر الإشارة بأننا نرى بعدم جواز إفشاء السر الطبي للمريض بأحد الأمراض السارية إلا بالطريقة التي حددتها المادة (٢) من القانون السابق وهي إبلاغ مركز الصحة الوقائية بإصابة المريض بأحد الأمراض السارية، لذلك فالإفشاء بغير ذلك الطريق يعد إفشاء للسر الطبي الخاص بالمريض.

وبعد أن انتهينا من عرض إشكاليات الشرط المسبق في جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية. سنجمل القول في عناصر التجريم الأخرى وهما الركنان المادي والمعنوي في هذه الجريمة.

الركن المادي في تلك الجريمة: يكمن حول إتيان الجاني، وهو مَنْ له صفة التبليغ عن الأمراض السارية كما بيّننا سلفاً، سلوكاً سلبياً في الامتناع عن التبليغ خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه أو اشتباهه بإصابة الشخص بمرض سار، وذلك كما حددها المشرع في نص المادة (٢) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. إذاً فهي جريمة يمكن تصنيفها بأنها جريمة سلبية بحكم النكث، بمعنى أن المشرع في هذا النوع من الجرائم يحدد صراحة فترة تنفيذ الأمر الواجب تنفيذه في

القانون (كالتبليغ خلال ٢٤ ساعة وَفَقاً للجريمة السابقة)، فإن انتهت هذه الفترة دون التبليغ، فإن الممتنع يقع عليه العقاب الجنائي^(٣٨).

الركن المعنوي في هذه الجريمة: الأصل يقتضي أن جميع الجرائم عمدية ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك، إذا فهي جريمة عمدية يكتفى فيها فقط بالعلم والإرادة كعنصرين من عناصر القصد الجنائي العمدية. ونرى أن الإشكالية تُثار فقط في عنصر العلم المتصل بالاشتباه؛ أي أن مسؤولية المبلغين الذين حددهم المشرع على سبيل الحصر تكون فيما إذا أصيب شخص بفيروس كورونا المستجد مثلاً أو ثمة وجود اشتباه في إصابته بهذا الفيروس. وتبعاً لذلك، فإن الجاني يجب أن يكون علمه منصرفاً بعناصر التجريم، ومعيار الاشتباه بإصابة شخص بفيروس كورونا المستجد يختلف من شخص إلى شخص، فقد يراها المتهم (وهو من يحمل صفة المبلغ) بأن الشخص محل الاشتباه بذلك الفيروس لم تكن أعراضه مسوغة للتبليغ، بينما قد يراها شخص آخر أنها مسوغة.

الفرع الثاني

الإشكاليات في جريمة مخالفة القرارات في نص المادة (١٥) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩

سنعرض في هذه الجزئية التي تشوبها مثالب تشريعية جمة، القرارات محل التجريم وَفَقاً لنص المادة السابقة، ثم سنقوم بعرض العقوبة المقررة لها، والتي قام المشرع الكويتي بتغليظها في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، مع بيان الإشكاليات على ذلك، وعلى السياسة العقابية لدى المشرع الكويتي في العقاب على مخالفة القرارات التي تصدر وفقاً للمادة السابقة. وقبل ذلك يجب علينا أن نشير إلى أن المشرع لم يستعمل أسلوب الصياغة الجنائية الدقيقة في تجريم النشاط المخالف لتلك المادة التي سوف نشير إليها؛ إذ قام بتوزيع شق التجريم في نص المادة (١٥) من القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩، وشق العقاب في البند الثاني من نص المادة (١٧) المستحدث أخيراً. وسنبين ذلك على النحو الآتي:

(٣٨) د. فاضل نصر الله. شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي في ضوء الفقه والقضاء. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة. (٢٠١٠). ص ١١٨.

أولاً - فيما يتعلق بشق التجريم في مخالفة قرارات نص المادة (١٥) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩:

نصت المادة السابقة على ما يأتي:

«عند ظهور وباء الجدري أو الكوليرا أو الطاعون أو أي مرض وبائي آخر، يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وبلاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته».

ويخول بصفة خاصة إصدار قرارات التدابير والاحتياطات الآتية:

- ١ - عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلاً تاماً، وعدم السماح بالدخول إليها أو الخروج منها بآية وسيلة كانت إلا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك.
 - ٢ - منع التجول في بعض المناطق المدة اللازمة لإجراء التطعيم الإجباري العام للسكان أو غير ذلك من الإجراءات.
 - ٣ - تخويل أطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعيّنهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في أي وقت للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.
 - ٤ - تكليف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والموظفين الفنيين والإداريين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء.
 - ٥ - إتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها الملوثة أو المشتبه في تلوثها، وإغلاق المحلات العامة التي يحتمل أن تكون مصدراً للعدوى، وإبعاد العاملين في هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل إن اقتضت الضرورة ذلك.
 - ٦ - اتخاذ أية تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء.
- والثابت أن تلك البنود يجب أن يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة حتى تكون محلاً للنشاط الإجرامي في مخالفة المادة السابقة. ويلزم الإشارة إلى أن المشرع بعد تعديله البند الثاني من المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن تغليظ العقاب على النشاط الإجرامي في مخالفة البنود السابقة، والذي استحدثه مؤخراً في سنة ٢٠٢٠ - لم يلتفت إلى مشكلات المادة (١٥) التي أشرنا إليها سلفاً؛ لذلك سنعرض نقطتين فيما يتعلق بعناصر التجريم في المادة السابقة:

النقطة الأولى: فيما يتعلق بالشرط المسبق؛ إذ يجب أن نكون بصدد قرار صادر من وزير الصحة لتفعيل تلك البنود المشار إليها سابقاً في نص المادة (١٥) المشار إليها سابقاً. فسياسة النص جاءت على نوعين وهما: سياسة عامة بأن يخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء كفيروس كورونا المستجد (covid-19) مثلاً، وأخرى خاصة بصدر قرار من وزير الصحة باتخاذ التدابير والاحتياطات فيما يتعلق بالبنود التي أشرنا إليها سلفاً - والتي من ضمنها منع التجول كأبرز تدبير - التي يجب أن يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة حسب النص السابق.

النقطة الثانية: إن البنود السابقة تحمل توسعاً كبيراً - وإن كان له ما يبرره - فإن ذلك يُفضي إلى جعل النشاط الإجرامي مرهوناً بطبيعة وصياغة القرار بتفعيل تلك البنود، مما يصعب على المخاطب بتلك القرارات محل التجريم بيان ماهية النشاط الإجرامي، نظراً لمرونة تلك البنود من حيث دلالاتها وتشعبها الزائد، الأمر الذي يستتبع معه إهدار أصول التجريم.

ونجمل القول بأنه لا بد من تأصيل الموضوع من حيث استقراء الواقع التشريعي الذي رأيناه في بنود المادة (١٥) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ التي أعطت وزير الصحة صلاحيات واسعة تستوعب البعض من أحكام القانون نفسه التي لها نصوص خاصة تحكمها بحيث لا تحتاج إلى قرار لتفعيلها. والأصل في أمور التجريم والعقاب سواء أكانت في نص تجريمي أم في قرار يعاقب القانون على مخالفته بعقوبة جنائية أنها تنطوي على تقييد للحقوق والحريات التي كفلها الدستور من حيث عقوبة الحبس وغيرها^(٣٩).

ثانياً - تباين موقف المشرع الكويتي في العقاب على مخالفة قرارات نص المادة (١٥) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩:

نلاحظ تبايناً في السياسة العقابية لدى المشرع الكويتي فيما يتعلق بالتعديل الذي قام به مؤخراً في القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تغليظ العقاب في البندين (١، ٢) في المادة (١٧) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩. ولبين ذلك سنعرض العقاب حسب البندين السابقين لنستظهر تباين موقف المشرع في العقاب:

العقاب المتصل بالبند الأول من المادة (١٧) من القانون السابق ما يأتي: «كل

(٣٩) د. عوض محمد عوض. مدى دستورية التدخل باللوائح في التجريم والعقاب. مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية. العدد ١. (٢٠١٥). ص ٣٤.

مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين». أما العقاب المتصل بالبند الثاني من المادة (١٧) من القانون السابق، فهو «كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوّه عنها في المادة (١٥) من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

والشاهد هنا تباين واضح في السياسة العقابية لدى المشرع الكويتي؛ إذ إن مخالفة البنود المشار إليها في نص المادة (١٥) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية أشد بنظر المشرع الكويتي من مخالفة أحكام القانون السابق كجريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية، فلو أن الطبيب قد علم بإصابة شخص بفيروس كورونا المستجد ولم يقدم على الإبلاغ خلال ٢٤ ساعة من تاريخ علمه، فذلك أخف لدى نظرة المشرع فيما لو أن شخصاً قد خالف قرار وزير الصحة بمنع التجول في منطقة معينة، فمثال الطبيب إزاء عدم إبلاغه عن عدوى فيروس كورونا المستجد من شأنه أن يسهم كثيراً في تفشي الفيروس بسبب من يخالطهم المصاب، فهو أشد جساماً - بنظرنا - ممن يخالف منع التجول مثلاً وفقاً للبند الثاني في المادة (١٥) من القانون السابق، بحيث يكون عقاب الأخير أشد من عقاب الطبيب، فيجب أن تكون العقوبة الجنائية عادلة من حيث أغراضها بأن تتسم بحسب جسامته الاعتداء على الحقوق والمصالح محل الحماية الجنائية، وما تتضمنه من مساس بالمجتمع ومقومات الحياة^(٤٠).

الخاتمة

بعد أن بيّنا المثالب الجنائية التشريعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، استدعت الدراسة التحليلية النقدية استعراض الإشكاليات الجنائية في الجرائم والقرارات الإدارية محل التجريم من النواحي الفنية والعملية، وذلك في سبيل معاونة الفقه والقضاء الكويتيين، مع بيان الحلول التشريعية للمشرع الكويتي إزاء تلك الإشكاليات. وفي سبيل تحقيق ذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: كان المبحث الأول حول البنين القانوني لجريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وللصورة التجريبية التي استحدثها المشرع الجنائي الكويتي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت العديد من الإشكاليات من عناصر التجريم،

(٤٠) د. فاضل نصر الله. مرجع سابق. ص ٤٦٢.

حيث جاءت خطة المبحث الأول في مطلبين، المطلب الأول: عناصر التجريم في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وأهم ما تطرقنا إليه هو إشكاليات العلاقة السببية وعنصر العلم كأحد عناصر القصد الجنائي العام. أما المطلب الثاني، فتناولنا فيه السياسة الجنائية العقابية لدى المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، وبيّنا من خلاله تباين موقف المشرع الكويتي في تناوله مسألة العقاب في تلك الجريمة، مع مقارنة العقاب في جريمة النقل العمدي عن عدوى الإيدز الذي نظمته المشرع الكويتي في قانون خاص، وأخيراً طرحنا كيفية معالجة العقاب في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد.

وكان المبحث الثاني حول الجرائم والقرارات محل التجريم، وارتكزت خطة دراسة هذا المبحث في بيان أهم القرارات محل التجريم التي صدرت مؤخراً للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مع بيان أهم الجرائم في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٧٩، وهذا ما أوجب التقسيم إلى مطلبين، المطلب الأول: تناولنا فيه جريمة مخالفة القرار الوزاري رَقْم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن حظر التجول للتصدي لفيروس كورونا المستجد، واستعرضنا بيان عناصر تجريم مخالفة ذلك القرار فيما يتعلق بالشرط المسبق، وأهم ما كان في ذلك غياب ذلك الشرط في التجريم حسب القانون رَقْم (٢١) لسنة ١٩٧٩ الذي استند إليه القرار في العقاب، وتطرقنا إلى حكم محكمة الأحداث مع بيان إشكالياتنا عليه. أما المطلب الثاني، فكان حول الجرائم المنصوص عليها في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩، وتناولنا فيه جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية مع تطرقنا للإشكاليات حولها، وأخيراً جريمة مخالفة نص المادة (١٥) من القانون نفسه التي أعطت وزير الصحة بصفة خاصة صلاحيات بإصدار القرارات بشأن مكافحة الوباء، وبيّنا أهم الإشكاليات حول جريمة مخالفة تلك القرارات.

وأوصلتنا هذه دراستنا التحليلية النقدية إلى مجموعة من النتائج التي نأمل في أن تخدم الفقه والقضاء والمشرع الكويتي. وهي على النحو الآتي:

- ١ - إن من ثمرات التحول التشريعي لدى المشرع الكويتي في القانون رَقْم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية استحداث نص خاص في البند الثالث من نص المادة (١٧) من القانون السابق خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بتجريم أي فعل عمدي يصدر من الجاني بقصد إصابة المجني عليه بالعدوى، إلا أن هذه الجريمة صعبة الإثبات من خلال

المروور في العلاقة السببية سنجد صعوبة في تحديد الناقل الفعلي للعدوى لا سيما وأن فيروس كورونا المستجد يتسم بالسهولة في نقله.

٢ - يجب الالتفات إلى نص المادة (١٧١) في باب التعرض للخطر وفقاً لقانون الجزاء والتي قد تغني عن مشكلات الجريمة المستحدثة محل الدراسة من حيث العناصر المادية والمعنوية، ونص المادة (١٧١) التي جرمت أي فعل من شأنه أن يعرض الأشخاص للخطر، وأن يقصد الإضرار بهم والتي تحتوي أفعال نقل العدوى لأنها جاءت بلفظ الخطر.

٣ - لم يكن مسلك المشرع الكويتي موفّقاً في تناوله النتيجة الإجرامية في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية؛ إذ لم يأخذ بالنتيجة كأحد عناصر الركن المادي في تلك الجريمة على صورتين، صورة أخف وأخرى أشد، بل أخذ فقط بالنتيجة الأخف، وهي مجرد الإصابة بالعدوى، بأن جعل عقوبتها الحبس بما لا يزيد على ١٠ سنوات، بينما أغفل العقاب على النتيجة الأشد وهي الوفاة فيما لو حصلت نتيجة أشد جراء تعمد الجاني نقله العدوى كفيروس كورونا المستجد بقصد إصابة المجني عليه وليس بقصد قتله، ولكنه توفي على إثر ذلك، فالقواعد العامة في قانون الجزاء لا تسعفنا في هذه الفرضية، ولا ينطبق عليها جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى موت؛ كون نقل العدوى ليس جرحاً أو ضرباً بمعناه في تلك الجريمة، ولو افترضنا جدلاً انطباقها، فالإشكالية التي ستثار أننا سنكون بصدد العقوبة نفسها في جريمتي النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية والجرح المفضي إلى موت، وكلتا العقوبتين هما الحبس بما لا يزيد على ١٠ سنوات.

٤ - تطلب المشرع الكويتي في جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية أن يكون الجاني عالماً علماً يقينياً بأنه مصاب بمرض سار كفيروس كورونا المستجد، وعلمه بذلك لا يتحقق إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية أو المسحات الطبية، وإن تأكدت إصابته به سيتم حجره صحياً، هذا ما يؤدي إلى تقليل فاعلية تطبيق التجريم فيما لو كان الجاني ينوي فعلاً نقل العدوى لغيره، فكان الأجدر بالمشرع أن يتناول مسألة افتراض علمه في شروط ضيقة.

٥ - بالغ المشرع الكويتي في العقاب على جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية، ولحدّات تلك الصورة التجريبية التي جاءت بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت النظرة العقابية في تلك الجريمة لدى المشرع الكويتي في ظل تفشي ذلك الفيروس الذي لا يعد مرضاً قاتلاً في طبيعته إلا في حالات معينة لدى

- المصابين به - تنطوي على اندفاع وتسرع تشريعي في العقاب الذي من شأنه أن يهدر المبادئ المقررة للعقوبة كمبدأ تناسب الفعل مع العقوبة المقررة له.
- ٦ - إن ما استندت إليه محكمة الأحداث في الحكم بحبس حدث مدة ثلاثة أشهر بسبب تجوله في الطرق العامة دون تصريح بسبب وجود حظر التجول في البلاد - غير صحيح حسب رأينا؛ فقد استندت إلى المادة (١٥) من القانون رقم ١٩٦٩ التي أعطت وزير الصحة صلاحية إصدار قرار منع التجول لمكافحة الوباء، ولم تشر في حكمها إلى القرار رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٠، فلا يصح الاستناد على المادة وحدها دون القرار المطبق لها.
- ٧ - لم يكن مسلك المشرع الكويتي موفّقاً في جريمة عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية وفقاً لنص المادة (٣) من القانون رقم ١٩٦٩؛ إذ حصر المسؤولين عن التبليغ بحيث لا يسعف أشخاصاً آخرين كان من المفترض وضعهم. وتكمن المشكلة التشريعية في تلك الجريمة في أن المشرع الكويتي قد أغفل مسؤولية المصاب نفسه الذي يعلم بإصابته بعدوى من الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد ولم يقوم بتبليغ السلطات الصحية بذلك، فلا يطاله التجريم وفقاً لتلك المادة.
- ٨ - أعطى المشرع الكويتي في نص المادة (١٥) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ وزير الصحة صلاحيات إصدار القرارات محل التجريم في مكافحة الوباء، وأعطاه سلطات استثنائية، وغلّظ العقاب على مخالفة تلك القرارات بعد تعديل البند الثاني من المادة (١٧) من القانون السابق فيما يتصل بالعقاب على مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الصحة في المادة (١٥) من القانون السابق، مما يصعب على المخاطب بتلك القرارات محل التجريم بيان ماهية النشاط الإجرامي، نظراً لمرونة تلك البنود من حيث دلالاتها وتشعبها الزائد، الأمر الذي يفضي معه إهدار أصول التجريم والعقاب؛ لأن النشاط الإجرامي مرهون على حسب القرار الذي يصدره الوزير لتفعيل المادة (١٥) من القانون السابق.

التوصيات:

- ١ - نوصي المشرع الكويتي أن يعيد معالجة جريمة النقل العمدي عن عدوى الأمراض السارية بأن يتناول فرضية حدوث نتيجة أشد جلاء فعل النقل العمدي بقصد الإصابة بالعدوى؛ إذ لا تسعف القواعد العامة في معالجة فرضية قيام الجاني بنقل العدوى عمداً بقصد إصابة المجني عليه لكنه توفي على إثر ذلك؛ لذلك نهيب بالمشرع أن يتناول مسألة حدوث نتيجة أشد وهي الوفاة، وأن يشدد العقاب عليها.

٢ - أمام جمود المشرع الكويتي فيما يتصل بتناول القصد الجنائي العمدى في جريمة النقل العمدى عن عدوى الأمراض السارية باعتبارها من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، نهيب بأن يتناول مسألة العلم كعنصر من عناصر القصد الجنائي العمدى، وذلك بأن يضيف العلم الافتراضي لدى المصاب بأحد الأمراض السارية كفيروس كورونا المستجد حال وجود أعراض دامغة تدل على إصابته به، وفي ظل تفشي الوباء، كقرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، كما فعل المشرع في تجريم عدم الإبلاغ عن عدوى الأمراض السارية في حالة الاشتباه بأن ثمة شخصاً مصاباً بمرض سار وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، فالعلم الافتراضي من شأنه أن يؤدي إلى فعالية تطبيق جريمة النقل العمدى عن عدوى الأمراض السارية، فتطلب المشرع العلم اليقيني لدى المصاب بأحد الأمراض السارية يضيق من تطبيق التجريم السابق، خصوصاً أن العلم اليقيني لا يأتي إلا عن طريق قيام المصاب بإجراء فحوصات طبية أو مسحات طبية، وفي حال التأكد من إصابته بمرض سار سيتم حجره صحياً، هذا ما يضيق من دائرة تطبيق النص فيما لو أراد المصاب فعلاً نقله إلى شخص معين.

٣ - نوصي المشرع بتوسيع دائرة المسؤولين في جريمة عدم التبليغ عن عدوى الأمراض السارية وفقاً للمادتين (٢، ٣) من القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩، وأن يجرم بصفة خاصة المصاب الذي يعلم بإصابته بمرض سار كفيروس كورونا المستجد أو اشتبه في إصابته ولم يقيم بتبليغ السلطات الصحية بذلك، ولا يتعارض ذلك في حق المريض بعدم إفشاء سره الطبي، طالما أن المصلحة العامة تقتضي مكافحة الوباء، وطالما أن التبليغ يكون في أحد المراكز الصحية الوقائية.

المراجع

أولاً - المراجع العربية:

- الكُتُب:

- د. سمير الشناوي. شرح قانون الجزاء الكويتي. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. الطبعة الثانية. (١٩٩٢).
- أ. صفية محمود صفوت. القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة - دراسة مقارنة. بيروت: دار ابن زيدون. الطبعة الأولى. (١٩٨٦).
- د. عبد المهيم بكر سالم. الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي القسم الخاص. الكويت: المطبعة العصرية. الطبعة الأولى. (١٩٧٣).
- د. فاضل نصر الله. شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي في ضوء الفقه والقضاء. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة. (٢٠١٠).
- د. فايز عايد الظفيري و د. محمد عبد الرحمن بوزبر. المبادئ العامة في قانون الجزاء الكويتي. مطبعة المقهوي الأولى. الطبعة الخامسة. (٢٠١٤/٢٠١٥).
- د. مبارك عبد العزيز النوييت. شرح المبادئ العامة في قانون الجزاء الكويتي. الطبعة الثانية. (٢٠١١/٢٠١٠).
- د. محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات - القسم العام. القاهرة: دار النهضة العربية. الطبعة السادسة. (١٩٨٩).
- د. نسرين عبد الحميد نبیه. حقوق المتهم أمام النيابة العامة. الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. الطبعة الأولى. (٢٠١٠).

- الأبحاث العلمية:

- د. أحمد أسامة حسنية. التكييف في المواد الجنائية ودوره في تحقيق العدالة الجنائية. مجلة الفقه والقانون. العدد ٦٤. (٢٠١٨).
- د. أحمد عمر إسماعيل. أصول التكييف الجنائي. مجلة بحوث ودراسات العالم الإسلامي. العدد ١٠. (٢٠١٣).
- د. السر الجيلاني و د. عمر الجيلاني. مفهوم القصد الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون - دراسة مقارنة. مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. العدد ٢١. (٢٠١٠).

- د. عادل علي المانع. الخطأ غير العمدى عبر العلاقة السببية غير المباشرة - دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والفرنسي. مجلة الحقوق. المجلد ٣٤. العدد ٣. (٢٠١٠).
- د. عوض محمد عوض. مدى دستورية التدخل باللوائح في التجريم والعقاب. مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية. العدد ١. (٢٠١٥).
- د. محمد أحمد المنشاوي. دور الخطر في إلهام المشرع قاعدة التجريم. مجلة الحقوق. المجلد ٣٧. العدد ٤. (٢٠١٣).
- د. نوفل علي الصفو. ذاتية المصطلح في قانون العقوبات. مجلة الراصد للحقوق. العدد ٦. (٢٠٠٦).

- المقالات العلمية والحلقات النقاشية:

- د. حاتم عبد الرحمن. الحلقة النقاشية التي عقدتها مجلة الحقوق بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٣ بعنوان: «الحماية القانونية للضحية في القانون الكويتي». وعالجت ثمانية محاور، المحور الثامن منها بحثٌ يتعلق بـ «التجريم الوقائي العام - آمال ومعوقات». المجلد ٢٨ ملحق. (٢٠٠٤).
- د. عادل المانع. الأمن القومي الجنائي مفهومه وأساسه. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المجلد ٢٢. العدد ٢٨٤. (٢٠٠٣).

- الأحكام القضائية:

- حكم المحكمة الكلية في القضية رقم (٢٦٤) لسنة ٢٠٢٠. الدائرة / جنح أحداث د/١. الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/٧/٢٠٢٠.

- القوانين:

- القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ بشأن قانون الجزاء الكويتي.
- القانون رقم (٢١) لسنة ١٩٧٩ بشأن الدفاع المدني.
- القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل المادة (١٧) في القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
- القانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٩٢ بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
- القانون رقم (٨) لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

– القانون الاتحادي الإماراتي رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ بشأن مكافحة الأمراض السارية.

ثانياً – المراجع الأجنبية:

– المقالات العلمية:

- Le cabinet d'avocats Glon. Article mise en danger de la personne. Publié le 14 août 2013.

– القوانين:

– قانون العقوبات الفرنسي الصادر في ١٣ يوليو لسنة ١٩٩٢ في استحداث المادة ٢٢٣-١.

Towards enhancing the criminal concept in addressing legislative issues for combating Novel Coronavirus (Covid-19) Critical Analysis Study

Ali Ouda Alshammari

The Kuwaiti legislator has enacted a criminal provision for combating Novel Coronavirus in the third item of Article (17) pursuant to Law No. 8/1969 concerning the intentional transmission of communicable diseases infection. This research has dealt with this violation on critical and analytical basis and was concerned with the issues of offense elements. It has addressed the legislator's policy regarding the lack of smoothness in dealing with the moral aspect in this violation with giving solutions to address such issues. Furthermore, this research has presented the administrative resolutions regarding the subject matter of conviction including violation of resolution No. 279/2020. This resolution is subject to the Civil Defense Law No. 21/1979 with reference to the criminal judicial ruling against the party violating this resolution. Eventually, we have dealt with the violation of failure to report on the communicable diseases infection under Articles Nos. (2, 3) of Law No. 8/1969 and the violation of resolutions issued by the Minister of Health under Article No. 15. The first section of this research covers the offense elements of violation of intentional transmission of communicable diseases infection. The second section deals with violation of curfew ban violation under the Civil Defense law No.8/1969 and issues stipulated under Article No. 15 of the above law.

فيروس كورونا المستجد / كوفيد-١٩، بين القوة القاهرة والظرف الاستثنائي (دراسة في القانونين الإماراتي والفرنسي)

الأستاذ الدكتور/ عدنان إبراهيم سرحان*
الأستاذة/ إيمان خميس يحيائي**

ملخص:

فيروس كورونا المستجد / كوفيد-١٩، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمواجهة تشكل بما لا خلاف عليه حوادث استثنائية عامة لا يمكن توقعها ولا استطاع دفعها. وبناء على ذلك فهو يصلح لتطبيق أحكام كل من القوة القاهرة والظرف الطارئ، بحسب مدى تأثيره على الالتزامات العقدية. فإن ترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام، سواء بشكل دائم وكامل، أو بشكل جزئي أو مؤقت، خضع لأحكام القوة القاهرة، التي تقرر في الفرض الأول انفساخ العقد كاملاً بقوة القانون، وفي الفرض الثاني انفساخه الجزئي في حدود الشق الذي استحاله تنفيذه، وفي الفرض الثالث تعليق تنفيذ العقد مؤقتاً، مع إعطاء الدائن الحق في الفسخ إذا ترتب على تجزئة العقد أو تعليقه ضرر بالدائن. أما إذا ترتب على الفيروس وما تبعته من إجراءات أن أصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين ويتهدده بخسارة فادحة تخرج عن حدود المألوف في التعامل، فتطبق عليه عندئذ أحكام الظروف الطارئة، حيث يسمح للقاضي في القانون الإماراتي بالتدخل لتعديل العقد بما يعيد له توازنه الاقتصادي وفقاً لمقتضيات العدالة. أما في القانون المدني الفرنسي، فبعد تعديله بمرسوم عام ٢٠١٦، الذي كرس لأول مرة أحكاماً خاصة بالظروف الطارئة غير المتوقعة عند إبرام العقد، يوجه طرفي العقد إلى إعادة التفاوض عليه مع استمرار المدين في التنفيذ أثناء إعادة التفاوض، وهذا أمر حسن، ولا يتعارض مع أحكام القانون الإماراتي التي تتيح تعديل العقد أو إنهائه بإرادة طرفيه المشتركة، وهذا يحل الكثير من الإشكالات المرتبطة بالتقاضي والتنفيذ التي يمكن أن يسببها تأثير فيروس كورونا على العقود. فإن لم تنجح المفاوضات أو رفضت، كان للطرفين باتفاق مشترك بينهما أن يقدم طلباً للقاضي لإعادة النظر في العقد وتعديله، وإن لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق مشترك، كان للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين التدخل لتعديل العقد أو إنهائه في التاريخ والشروط التي يحددها.

(*) الباحث الرئيس: أستاذ القانون المدني، مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع، جامعة الشارقة.
(**) الباحث المشارك: باحثة في برنامج الدكتوراه في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة الشارقة.

مقدمة:

يشهد العالم اليوم جائحة مرضية اجتاحت جميع دوله^(١)، وخلفت ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات حول العالم، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تعلن في الحادي عشر من شهر مارس بأن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مهدداً للصحة العامة.

ولا شك بأن تأثير هذا الفيروس لا يقتصر على القطاع الصحي فحسب، بل بات تأثيره جلياً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، لاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة هذا الفيروس.

وكما هو الشأن في كافة أنحاء العالم فقد تأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الآلاف من الحالات المصابة بالفيروس، مما أدى إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في الدولة^(٢)، كإغلاق

(١) تعرف الجائحة في الفقه الإسلامي بأنها: "الآفة التي تهلك الثَّمار وتجتاح الأموال وتستأصلها، وكل مُصيبة عظيمة وفتنة كبيرة"، انظر: محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ١/٢٥٤، ط ١، ٢٠٠٦. وهذا التعريف يدل على أن أكثر الجوائح التي لها آثار على الالتزامات والحقوق هي جوائح الزروع والثمار، ولكن الفقهاء لم يمنعوا من حدوث غيرها فتوسعوا في مفهومها العام لتطلق على المصائب العظيمة والفتن الكبيرة. وهذا المفهوم العام ينطبق على جائحة الكورونا التي أصابت دول العالم وعطلت الاقتصاد العالمي وأثرت على أعمال الناس وحياتهم المعيشية حتى أصبح الإجماع عليها عرفاً دولياً، انظر: عبد اللطيف آل محمود، عقود العمل في ظل الجوائح ومعالجة آثارها، ندوة البركة الأربعون للاقتصاد الإسلامي (وضع الجوائح والقوة القاهرة)، راجع الموقع الإلكتروني <https://www.albaraka.org/>

(٢) لمواجهة الآثار السلبية المترتبة في حالة الطوارئ الصحية، يجوز للحكومة أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وهو ما يخلق حالة استثنائية توسع من صلاحيات السلطة العامة، ويجعل الدولة في منأى عن التقيد بالتزاماتها الدولية فيما يخص الحريات والحقوق المدنية والسياسية التي يجوز تعطيل بعضها، وذلك من قبيل الحق في التجمع والإقامة، والحق في التنقل والتعبير أو غيرها من الحقوق، وعليه يتعين على المواطنين ألا ينظروا إلى تدخل السلطات وإجبارهم على الانصياع إلى أوامرها على أنه تقييد لحقوقهم وحرياتهم، وإنما هو مجرد تطبيق صارم للتدابير الاحترازية المعتمدة وللتعليمات الصحية لمعالجة وضعية استثنائية ذات أبعاد إقليمية ودولية، والذي يتعين أن ينظر إليه من حيث المآل بأنه انخراط جدي وقوي من جانبها في ضمان الأمن الصحي للمواطن ضد فيروس غير مرئي وعدو خفي ينتقل بشكل سريع. انظر: سمير آيت ارجدال، تدخل السلطات العمومية في ظل حالة الطوارئ المعلنة - مقارنة قانونية حقوقية. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، ع ١٧، أبريل ٢٠٢٠، عدد خاص بكورونا، كوفيد-١٩، ص ٢٨، المجلة تصدر على موقع: www.justicemaroc.com

العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتعليق الرحلات الجوية، وتقييد تجمع وحركة الأشخاص جزئياً، وفي بعض مناطق الدولة بشكل كامل، وغيرها من التدابير والإجراءات الوقائية التي جعلت التبادلات الاقتصادية المتجسدة فعلياً غير ممكنة، وفتحت الباب بشكل أكبر أمام التعاملات الإلكترونية الافتراضية عن بعد. لا بل أن هذه الأخيرة هي الأخرى لم تسلم من التأثيرات السلبية لكورونا، حيث زادت وقائع الاحتيال الإلكتروني بشكل ملفت^(٣).

تلك الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس كان لابد لها أن تنتج آثاراً قانونية على أصعدة مختلفة، كان من أهمها تأثير فيروس كورونا على التعاملات الاقتصادية، وبوجه أخص على العقد، حيث وجدت المؤسسات والشركات والجمعيات والتجار وأصحاب المهن الحرة أنفسهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم العقدية، بسبب هذا الوضع الاستثنائي.

ومع تطور مجريات هذا الظرف كثر الحديث عن القوة القاهرة والحادث الاستثنائي كوسائل للتخلص من العقد أو التقليل من آثاره الضارة دون خسارة، فهذه الجائحة من الأمور التي يمكن تصنيفها وفق إحدى الطوائف أو التكييفات القانونية التي أشار إليها المشرع الإماراتي، وذلك إما باعتبارها قوة القاهرة وهو السبب الأجنبي الذي لا يمكن توقعه أو دفعه ويؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، أو باعتبارها حادثاً استثنائياً تتحقق بموجبه شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي تختلف عن القوة

(٣) الاستخدام الواسع لتقنيات العمل عن بعد أدى إلى توسع كبير في فرص تسرب المعلومات السرية للمنشآت، وهذا ما أكدته إدارة السلامة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الاستخدام الواسع للشبكة الخاصة الافتراضية (virtual private network: vpn) من شأنه أن يزيد من احتمالات الخطأ، خصوصاً إذا كان المشروع قد تخطى عن تحديثها لتجنب أي انقطاع في الخدمة. وفي مقابل ذلك، فإن تعبئة أقسام تقنية المعلومات في الشركات والمؤسسات، لتلبية المقتضيات المستعجلة للعمل عن بعد بقصد استمرار تقديم الخدمة، في الوقت الذي تكون فيه البنية التحتية التقنية محدودة، من شأنه أن يجعل متطلبات الأمن التقني في رتبة متأخرة، وهذا الواقع رغم أنه مؤقت لكنه يمكن أن تدفع تلك المؤسسات والشركات غالباً بسببه. ويعظم من المشكلة أن القطاعات الاقتصادية تمر بسبب كورونا بأزمة صعبة في ظل اقتصاد منهك، وهي بحاجة ماسة لتجنب أي زيادة في الحوادث التي يمكن أن يمثلها الاحتيال الإلكتروني أو الهجمات السيبرانية الواسعة. وللتذكير فقط فإن الهجمات الإلكترونية المسماة (ransomware WannaCry) في العام ٢٠١٩، قد كلفت أضراراً قدرها ٤ مليار دولار على المستوى العالمي. انظر في ذلك:

Myriam Quémener et Clément Wierre, Les cyberattaques à l'heure du coronavirus, Dalloz Actualité, Publié sur (), le 21 mars 2020.

القاهرة بأنها لا يستحيل معها تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وإنما يكون تنفيذها مرهقاً للمدين ويتهدده بخسارة فادحة. لاسيما في ظل أن العديد من الشركات والمؤسسات والتجار وغيرهم ممن تقع على عاتقهم التزامات تعاقدية تأثرت بالأوضاع الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا، يحاولون التمسك بالقوة القاهرة للتخلص من الأعباء الملقاة عليهم نتيجة إخلالهم بتنفيذ العقود ولتفادي التزامهم بالتعويض عن التأخير في التنفيذ أو عدم التنفيذ كلياً.

ووجدنا من المناسب أن نشارك، في تسليط الضوء على الآثار القانونية المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية، عبر هذين النظامين القانونيين. وذلك من خلال بيان مدى توافق التكييف القانوني للفيروس مع كل من القوة القاهرة والظرف الاستثنائي، والآثار المترتبة على كل منهما. سنركز في هذا البحث على أحكام القانون الإماراتي الواردة في قانونه للمعاملات المدنية، ومجمل التنظيمات التي استجبت في دولة الإمارات بعد ظهور الفيروس، ونذكر ذلك بمقارنات مع القانون الفرنسي وقضائه، خصوصاً في مجال الظروف الطارئة حيث كرس القانون المدني الفرنسي لأول مرة منذ صدوره قبل أكثر من قرنين من الزمن نظام الظروف الاستثنائية غير المتوقعة، بموجب مرسوم تعديل قانون الالتزامات والعقود الصادر عام ٢٠١٦. وسنتناول كل ذلك في مطلبين، نخصص الأول لفيروس كورونا والقوة القاهرة، وننتاول في الثاني فيروس كورونا والظرف الاستثنائي.

المطلب الأول فيروس كورونا والقوة القاهرة

قد تحدث ظروف أو حوادث استثنائية قبل البدء بتنفيذ العقد أو أثناء حياته، من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً، وهو ما يعرف بالقوة القاهرة. وفيروس كورونا المعروف عالمياً بكوفيد-١٩، واحد من أهم وأحدث الظروف ذات البعد العالمي التي يطرح التساؤل بشأنها على الصعيد القانوني، عما إذا كان يعد من قبيل القوة القاهرة. هذا ما سنجيب عليه في الفرع الأول من هذا المطلب، لنتبع ذلك بمطلب آخر يبين الآثار المترتبة على اعتباره من القوة القاهرة.

الفرع الأول

فيروس كورونا "كوفيد-١٩" حالة من حالات القوة القاهرة

تنص المادة ٢٧٣ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي^(٤) على أنه: (١- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. ٢- وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين)^(٥). وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، شأنه في ذلك شأن غالبية القوانين الأخرى، لم يضع في هذه المادة تعريفاً للقوة القاهرة، وإنما اكتفى ببيان شروطها وأثرها. وتعرف القوة القاهرة فقهاً بأنها كل فعل لا شأن لإرادة المدين فيه، ولا يمكن توقعه ولا منعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة تعفي المدين من المسؤولية العقدية

(٤) هو القانون الاتحادي رقم (٥) لسنة ١٩٨٥ بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (١) لسنة ١٩٧٨ م.

(٥) جاء في الفقرة الأولى من المادة ٧٩ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع أنه: "لا يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته، وأنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه" وهي نفسها صفات وخصائص القوة القاهرة.

والتقصيرية^(٦). وقد عرفها البعض بأنها أمر غير متوقع حصوله وغير ممكن تلافيه يجبر الشخص على الإخلال بالتزام^(٧).

فالقوة القاهرة في مجال العقد توجد إذن عندما تخرج واقعة معينة عن سيطرة المدين، والتي لا يمكن على نحو معقول توقعها عند إبرام العقد، وليس بالإمكان تجنب آثارها بإجراءات مناسبة، ومن شأنها أن تمنع المدين من تنفيذ التزامه العقدي^(٨).

وقد يرد في بعض الأحيان تسمية القوة القاهرة بالاستحالة، وهو أمر تعوزه الدقة لأن الاستحالة والقوة القاهرة لا يحلمان المعنى ذاته، وإنما الاستحالة أثر من آثار القوة القاهرة، بحيث تربطهما علاقة سببية فتعد القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه المسبب وهو استحالة التنفيذ.

وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد بأن: (القوة القاهرة يشترط فيها لانعدام رابطة السببية أن يكون الحادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع، والذي يجب أن يستحيل توقعه أو دفعه هو ما يخلفه الحادث كالحروب أو وقوع زلزال أو حريق أو غرق أو سرقة أو فيضانات أو جفاف أو عواصف أو جراد ونحو ذلك)^(٩). كما قضت محكمة تمييز دبي بأنه: (من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقيام القوة القاهرة التي يفسخ بها العقد والتي يترتب عليها عدم مسؤولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالتزام أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل

(٦) أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ١٩٨٧، ص ٥٣٦. ويلاحظ أن المشرع في القوانين المتأثرة بالفقه الإسلامي يستخدم مصطلح "الفعل الضار" للتعبير عن ما يطلق عليه في القوانين الأخرى "المسؤولية التقصيرية"، انظر: الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون المعاملات المدنية الإماراتي المواد (٢٨٢-٣١٧)، والفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول من القانون المدني الأردني رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٦، المواد (٢٥٦-٢٩٢). أما القانون المدني الفرنسي فاستخدم مصطلح "المسؤولية غير العقدية" وذلك بموجب تعديله بالمرسوم رقم ٢٠١٦-٣١ الصادر في ١٠ فبراير- شباط ٢٠١٦، المصادق عليه بالقانون رقم ٢٠١٨-٢٨٧ الصادر في ٢٠ أبريل - نيسان ٢٠١٨، انظر: الباب الفرعي الثاني من الباب الرئيس الأول للقانون، المواد (١٢٤٠-١٢٥٢).

(٧) سليمان مرقس، مرجع سابق، ص ١٩٧.

(٨) انظر: المادة (١٢١٨) من القانون المدني الفرنسي المعدل بمرسوم عام ٢٠١٦.

(٩) المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٥، تاريخ الجلسة: ٢٧-١٢-٢٠١٦،

مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

دفعه، أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً وليس في القيام بتنفيذه مجرد مشقة أو عناء على الملتزم به، وإن الحادث غير المتوقع هو ما لا يكون في حسابان المتعاقدين أي ما لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد^(١٠).

القضاء الفرنسي من ناحيته كان قبل تعديل قانونه المدني يشترط لوجود القوة القاهرة أن تحمل الحادثة ثلاث صفات: عدم القابلية للتوقع، وعدم القابلية للدفع، وكونها حادثة أجنبية عن المدين. وجاءت المادة ١٢١٨ الجديدة من القانون المدني الفرنسي لتؤكد ذلك بنصها على أنه: "تتحقق حالة القوة القاهرة في المجال العقدي عندما يقع حدث خارج عن سيطرة المدين، وغير متوقع عند إبرام العقد، ولا يمكن تفادي نتائجه بواسطة إجراءات مناسبة، بحيث يشكل هذا الحدث عائقاً يمنع المدين من تنفيذ التزامه...". ويرى الفقه الفرنسي أن على القضاة التعامل مع شرط عدم التوقع الوارد في هذه المادة الجديدة على نحو مختلف عن ذي قبل، إذ ليس بإمكانهم تقرير صفة عدم التوقع ما لم يؤكدوا في بواعثهم على أن الحادثة المحتج بها "لا يمكن على نحو معقول توقعها عند إبرام العقد". وعليه في حالة الواقعة المتوقعة على نحو معقول لكن من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، لا يمكن للمدين الاحتجاج بالقوة القاهرة، وإن كان له مع ذلك التمسك بعدم انعقاد العقد أصلاً لفوات العناصر الجوهرية للعقد^(١١).

ويشترط في الحادث لكي يوصف بأنه قوة قاهرة أن يكون مستقلاً تماماً عن إرادة أطراف العلاقة التعاقدية، ونعني بأن يكون الحادث مستقلاً عن إرادة المدين بأن لا يكون لهذا الأخير يد أو دور في وقوع الحادث، وقد أكدت المادة ٤٧٢ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على هذا الشرط، حيث نصت على أنه: (ينقضي الحق إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه)^(١٢).

ويطلق البعض على هذا الشرط مصطلح الخارجية أي أن تكون الواقعة خارجة عن إرادة الخصوم أو أطراف الرابطة التعاقدية، فلا يتسبب المدين في حدوثها ولا

(١٠) محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٠٩، تاريخ الجلسة ١٥-١١-٢٠٠٩، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

(١١) Barthélemy MERCADAL, Réforme du droit des contrats, Editions Francis Lefebvre, 2016, n° 693.

(١٢) ولذلك يرى بعض الفقهاء المسلمين أن الجائحة هي المعتبرة آفة سماوية دون صنع الآدمي، جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٣٦٧، والقوانين الفقهية لابن الحاجب، ص ١٧٣، نقلاً عن عبد اللطيف آل محمود، مرجع سابق، ص ٤.

يسبقها أو يقترن بها خطؤه، وأن لا تكون الواقعة ناجمة عن إهمال المدين أو تقصيره^(١٣). وهذا الشرط نادى به الفقهاء، ولم تنص عليه القوانين، لهذا يسمى بالشرط الذي جاء به الفقه أو الشرط الفقهي^(١٤). ويعد هذا الشرط من الشروط المنطقية والمهمة في تطبيق القوة القاهرة؛ ذلك أنه لو كان للخصم دور في وقوع الحادث أو كان له يد في حدوثه نتيجة لتقصيره وإهماله، فليس له أن يدفع به كقوة القاهرة، حتى وإن أدى ذلك إلى اختلال في التوازن العقدي؛ وذلك احتراماً للمبادئ العامة التي تقضي بسلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين. وتطبيقاً لذلك، وفي إحدى الدعاوى التي رفعت أمام القضاء الفرنسي^(١٥)، طلب أحد الصيادلة استرداد الثمن الذي دفعه مقابل طلبية من الكمادات للتأخير في التسليم (وقد رفض تسلم الكمية لعدم مطابقة الكمادات للمواصفات المعتمدة). ذهبت محكمة الاستئناف في القضية إلى أن واقعة حظر البضاعة في الجمارك لعدم المطابقة للمعايير المعتمدة لا تشكل بالنسبة للمدين مستورد الكمادات قوة القاهرة أو سبباً من أسباب الإعفاء، فقد كان عليه اختيار جهاز موثوق به، والتأكد من أن الكمادات ستصنع وفق جميع المتطلبات المعيارية المعلن عنها في مرجع المنتجات المبيعة.

ويجب ملاحظة أنه لا يؤثر على مفهوم الخارجية أن تكون الواقعة مرتبطة بشخص المدين، ولكن حدوثها ونتائجها خارجة عن إرادته. وفي هذا ذهبت الهيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسية^(١٦) إلى أنه لا مجال للقضاء بالتعويض إذا لم يستطع المدين نتيجة قوة القاهرة أو حادث فجائي، إعطاء ما ألزم به، أو فعل ما منع عليه، وهذا ما ينطبق على حالة المدين الذي لم يتمكن من التنفيذ بسبب المرض، متى ما كانت هذه الواقعة غير متوقعة عند إبرام العقد وغير قابلة للدفع عند تنفيذه، ومجسدة لحالة القوة القاهرة. وعلى ذلك تكون محكمة الاستئناف محقة عندما قضت بأن العجز الجزئي

(١٣) سليمان مرقس، مرجع سابق، ص ١٩٩.

(١٤) انظر: أمينة رضوان، مدى مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العلاقة التشغيلية، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، ع ١٧، أبريل ٢٠٢٠، عدد خاص بكورونا، كوفيد-١٩، ص ١٣، المجلة تصدر على موقع: www.justicemaroc.com

(١٥) Poitiers, 24 févr. 2012, n°11/02200. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_POITIERS_2012-02-24_1102200&ctxt=0_YSR0MD0xMS8wM-jIwMMKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo#entete

(١٦) Cass, Assemblée plénière, 14 avril 2006, N° de pourvoi: 02-11168, Bull. civ. 2006, Ass. plén., N° 5 p. 9, et Legifrance.gouv.fr, <https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051847>

المؤقت ومن ثم المرض المفضي إلى الوفاة، يشكل الظروف المجسدة لحالة القوة القاهرة المعفية للمدين من التزامه بتسليم ماكينة صناعية، متى اتسم العجز الجسدي الناتج عن الالتهاب والمرض الخطير الواقع بعد إبرام العقد بعدم التوقع، وكان تسلسل الأحداث والنتائج المؤكدة المترتبة على التراجع الحاد لحالته الصحية تثبت أن المرض لا يقاوم. هذا الحكم الذي استبعد صفة الخارجية كشرط للقوة القاهرة، هو ما كرسه تعديل القانون المدني الفرنسي في المادة ١٢١٨ التي جاءت خلواً من أي إشارة إلى تلك الصفة. وعليه فإن كل حدث " خارج سيطرة المدين"، أيّاً ما كان، داخلياً أو خارجياً، فلا يمكنه السيطرة عليه والتحكم به، يشكل قوة القاهرة. وفي المقابل فإن كل واقعة تخضع لسيطرتة، فيمكن الاحتجاج بها ضده لمنعه من الاستفادة من القوة القاهرة، ومن ذلك الخطأ الذي ارتكبه وكان هو السبب وراء القوة القاهرة.

كما يشترط في الحادث لكي يعد قوة القاهرة أن يكون من غير الممكن توقعه أو دفعه من قبل أطراف العلاقة التعاقدية، وهو ما يتفق مع نظرية الظروف الطارئة التي يشترط كذلك لتطبيقها أن يكون الحادث الطارئ غير ممكن توقعه ولا دفعه. وتعد مسألة التوقع من المسائل المتغيرة فهي ليست ثابتة في كل العقود وإنما تدرك بالواقع، حيث يجب على المحكمة أن تنظر في كافة الظروف والملابسات المحيطة بالعقد قبل أن تحدد ما إذا كان الحادث استثنائياً من عدمه^(١٧). كما يجب استظهار عدم التوقع أو قياسه بالنظر إلى وقت إبرام العقد^(١٨). فالمعيار المتبع في هذا الصدد هو المعيار الموضوعي، حيث لا يعتد بالعناصر الشخصية للصيقة بشخص المدين^(١٩). فلا ينظر إلى مركز المدين الذي يدعي عدم تمكنه من توقع الواقعة أو دفعها، بل ينظر إلى الشخص العادي من أواسط الناس الذي يوجد في ظل ظروف المتعاقد ذاتها، إذا استحال عليه أن يتفادى هذه الواقعة أم لا.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أمكن دفع الواقعة، حتى لو لم تكن متوقعة، فإنها لا توصف بكونها قوة القاهرة^(٢٠).

(١٧) عبد العزيز محمد حمد ساتي، مرجع سابق، ص ١٩٩.

(١٨) عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٨٧٨.

(١٩) المرجع السابق، ص ٩٩٧.

(٢٠) وفي واقعة تخلف المدين عن سداد دين نقدي بسبب الحجر على حيوانته نتيجة إنفلونزا الطيور، ذهبت محكمة فرنسية إلى أن أثر ذلك على النتائج النهائية للاستثمار لا تكفي لتأكيد صفة عدم إمكانية التغلب وعدم إمكانية التفادي بما يسمح بأن يخلع على الواقعة تكييف القوة القاهرة. انظر: حكم محكمة

والعلة من انعدام مسؤولية المدين في حالة ثبوت تحقق شرط عدم إمكانية الدفع، أن هذا الشرط على ارتباط مباشر بالإرادة أي بإرادة المدين، فالقوة القاهرة تمثل قوة ضاغطة لواقعة معينة ذات تأثير سلبي على سلوك المدين، على نحو يفقد معه قدرته على اتخاذ أي مسلك أو إتيان أي تصرف من شأنه تفادي الواقعة^(٢١).

وقد قضت محكمة تمييز دبي بأنه: (يشترط لقيام القوة القاهرة أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه)^(٢٢) كما قضت بأن: (القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم مسؤولية المتعاقد عن تعويض الضرر عند عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام يشترط لقيامها أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يكون الوفاء بالالتزام مستحيلاً)^(٢٣).

ولكي يعد الحادث من القوة القاهرة يجب أن يجعل تنفيذ العقد بذات الشروط المتفق عليها عند التعاقد مستحيلاً، وهو ما يميز القوة القاهرة عن نظرية الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ العقد مرهقاً وليس مستحيلاً. وفي هذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الواقعة غير القابلة للدفع والمتمثلة في التدمير الجزئي للفندق بسبب إحصار لم يكن من شأنها أن تحيل إعادة استثماره مستحيلاً، وهو ما لا يبرر الاستغناء عن جميع الموظفين بفصلهم من أعمالهم^(٢٤). كما ذهبت إحدى المحاكم الفرنسية في حكم قديم بخصوص آثار فيروس سارس، إلى أن المخاطر الصحية ليست كبيرة في تايلند، وعليه لا يمكن قبول أن السفر باتجاه هذا البلد بات مستحيلاً

= Toulouse, 3 oct. 2019, n° 19/01579, https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_TOULOUSE_2019-10-03_1901579&ctxt=0_YSR0MD0-xOS8wMTU3OSBUb3Vsb3VzZcKneCRzZjlzaW1wbGUtc2VhcmNo#entete

(٢١) ياسر باسم، القوة القاهرة وأثرها في أحكام قانون المرافعات المدنية، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، كلية الحقوق، عدد ٣٦، مجلد ١٠، ٢٠٠٨، ص ٦٥.

(٢٢) محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٠، تاريخ الجلسة ٢٠١٠/٦/٦، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

(٢٣) محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٣١٣ لسنة ١٩٩٢، تاريخ الجلسة ١٩٩٣/٤/١٨، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

(٢٤) Cass. Soc. 25 fev.1954, Bull. Civ. IV, n°107, Cass. Civ. 1^{re}, 3 mai 1977, Bull. Civ. 1, n°203.

بسبب سارس^(٢٥). وفي قضية أخرى قرر القضاء أن الهبوط المؤقت في بلد مجاور لمنطقة موبوءة بالطاعون، لا يشكل خطراً مسبباً للقوة القاهرة^(٢٦).

ويجب أن تكون الاستحالة في هذا الصدد استحالة مطلقة وهي التي تقوم بالنسبة للكافة إذا تواجد أحدهم في مثل موقف المدين، أما الاستحالة النسبية التي تتعلق بذات المدين وتكون سمة الاستحالة فيها منسوبة إليه وحده دون غيره فلا يعتد بها كقوة القاهرة^(٢٧).

والاستحالة قد تكون مادية أو قانونية، ويقصد بالاستحالة المادية حدوث أمر مادي قهري يمنع تنفيذ الالتزام، كهلاك المبيع لسبب أجنبي. أما الاستحالة القانونية فتكون باستحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي قانوني وليس لسبب مادي، مثل صدور قانون يمنع تصدير بعض المحاصيل الزراعية، وبالتالي تفسخ كافة عقود تصدير تلك المحاصيل بقوة القانون^(٢٨). أضف إلى ذلك بأن الاستحالة قد لا تكون نتيجة مباشرة للحدث ذاته، وإنما قد تكون نتيجة الإجراءات المتبعة لتفاديه أو لتقليل أخطاره، كما هو الحال فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، فقد يكون تنفيذ الالتزام مستحيلاً ليس بسبب الفيروس ذاته وإنما بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة والحد من انتشاره.

ولكن يلاحظ أن نص المادة ١٢١٨ الجديدة من القانون المدني الفرنسي التي عرفت القوة القاهرة وبينت شروطها، لم تعد تشير إلى الاستحالة المطلقة في التنفيذ، بل إلى الاستحالة بإجراءات مناسبة، بما يعني أن تعريف القوة القاهرة في هذا القانون انعطف بشكل أكبر نحو عدم إمكان تجنب الواقعة لا استحالتها، وهو ما يخفف من شدة وصرامة التقدير^(٢٩).

بعد هذا العرض نكرر السؤال مرة أخرى، هل يدخل كوفيد-١٩ في تكييف القوة القاهرة؟

(٢٥) TI Paris, 4 mai 2004, n° 11-03-000869, cité par E. Llop, Contentieux des agences de voyages: de la sécurité au futile, Tourisme et Droit 2008, n° 102, p. 29.

(٢٦) Paris, 25 juill. 1998, Tour Hebdo n° 944, 2 juin 2000, cité par Pascale Guiomard, La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, Dalloz Actualité, Publié sur (), le 4 mars 2020.

(٢٧) عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٥٨٩.

(٢٨) عدنان إبراهيم سرحان، محمود إبراهيم فياض، محمد محمد سادات، المصادر الإرادية للالتزام، جامعة الشارقة، ط ١، ٢٠١٨، ص ٢١٢.

(٢٩) Stefanie Porchy-Simon, Droit civil 2^e année, Les obligation, Dalloz, 11 édition, 2019, p.530.

في الواقع شهد العالم في أوقات مختلفة انتشار فيروسات وجوائح مختلفة، وكان التوجه القضائي الفرنسي في مجال الأمراض والأوبئة، يذهب إلى اتجاه معاكس، فعصية الطاعون (peste)^(٣٠)، وأوبئة إنفلونزا H1N1 في عام ٢٠٠٩^(٣١)، وفيروس حمى الضنك (dengue)^(٣٢)، وفيروس الشيكونغونيا (Chikungunya)^(٣٣)، لم يتعامل القضاء معها على أنها أزمات صحية مجسدة للقوة القاهرة، ففي هذه الحالات المتقدمة اعتبر القضاء، وبشكل مصطنع، إما أن المرض معروف، وكذلك مخاطر انتشاره وتأثيره على الصحة، أو أنه لم يكن "مميّاً بما فيه الكفاية"، مستبعدين إمكانية الاحتجاج به لرفض تنفيذ العقد^(٣٤).

لكن الملاحظ أن القضاء الفرنسي اعتد في إصدار هذه القرارات على الظروف الخاصة بكل حالة على حدة، بحيث لا يمكن القياس عليها فيما يتعلق بفيروس كورونا. فإذا أخذنا على سبيل المثال حالة فيروس الشيكونغونيا، فقد ذهب القضاء الفرنسي، في شأن حجوزات فندقية، إلى أنه على الرغم من أعراض المرض (آلم المفاصل، والحمى، والصداع، والتعب وما إلى ذلك)، وانتشاره في منطقة البحر الكاريبي، ولاسيما في جزيرة سان بارتليمي خلال ٢٠١٣-٢٠١٤، إلا أن هذا الحدث لا يشتمل على صفات القوة القاهرة، بالمعنى الوارد في المادة ١١٤٨ من القانون المدني الفرنسي، لأنه لا يمكن اعتبار هذا الوباء ذا طابع غير ممكن التنبؤ به، وخاصة مما لا يمكن توقعه، لأنه في جميع الأحوال يمكن تخفيف المرض الذي يسببه عن طريق المسكنات، وهو مما يمكن التغلب عليه بشكل عام، (فلم يذكر المستجيبون للعلاج بأنهم تعرضوا إلى هشاشة صحية معينة)، وعليه فإن بإمكان الفندق تنفيذ التزاماته تجاه زبائنه خلال هذه الفترة^(٣٥). وجرى الأمر ذاته بالنسبة لحمى الضنك في منطقة المارتينيك، فهي لم تعد في نظر المحكمة قوة القاهرة لأنها بنظرها لم تكن غير متوقعة ولا غير ممكنة الدفع^(٣٦).

C.Paris, 25 sept. 1996, n° 1996/08159. (٣٠)

Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229. (٣١)

Nancy, 22 nov. 2010, n° 09/00003. (٣٢)

Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739. (٣٣)

Ludovic Landivaux, Contrats et coronavirus: un cas de force majeure??a (٣٤)
dépend, Dalloz Actualité, Publié sur (<https://www.dalloz-actualite.fr>), le 20 mars 2020.

Basse-Terre, 17 déc. 2018, n°17/00739. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_BASSETERRE_2018-1217_1700739&ctxt=0_YSR0MD0x-Ny8wMDczOSBiYXNzZSB0ZXJyZcKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo#entete. (٣٥)

هذا الحكم المتقدم مفيد لجهة أنه بمفهوم المخالفة، فإن فيروس كورونا يشكل حالة من حالات القوة القاهرة، فهو ليس له إلى الآن علاج فعال، صحيح أن الوباء من حيث العموم لا يشكل بالضرورة وتلقائياً حالة قوة القاهرة، إلا أن لفيروس كوفيد-١٩ شأنًا آخر، فحجم هذه الجائحة وخطورتها يثبتان ذلك، فالإصابات به بالملايين، وغير مستبعد أن يفقد بسببه مئات الآلاف من البشر حياتهم، وغطى مداه المكاني جميع دول المعمورة، إنه فيروس قاتل، لا لقاح له ولا دواء، وكل ما يقدم لمرضاه من الرعاية الصحية لا يتعدى التعامل مع الأعراض^(٣٧). وهو فيروس غير متوقع، حيث يُعدّ، حسب منظمة الصحة العالمية، فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للإنسان والحيوان معاً، وهو يسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها بين نزلات البرد المعروفة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والتي تعرف بـ(سارس)، وهو مرض معد لم يكن هناك أي علم بوجوده، كما أنه يستحيل دفع الضرر عنه في هذه الأيام العvisية التي يمر بها العالم، وليس للمدين دخل في إثارته، كما أنه ذو مصدر أجنبي عن المدين عموماً. والفيروس ما يزال غامضاً إلى حد كبير، الأمر الذي دفع الجهات الصحية الوطنية والعالمية إلى الكثير من الحذر بشأنه. وما الإجراءات التي اتخذت في دولة الإمارات العربية والعالم، على الصعيدين الصحي والقانوني، إلا دليل على حساسية الوضع وخطورته.

تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطة العامة، والتي تشكل ما يطلق عليه قانوناً "فعل الأمير"، وما نتج عنها من تحديد أو منع تجمعات وتنقلات الأشخاص، تشكل بامتياز ظروف قوة القاهرة^(٣٨)، وتخلق مانعاً لا يمكن تخطيه من تنفيذ الالتزامات العقدية^(٣٩). ولذلك يمكننا تأكيد أن جائحة كوفيد-١٩، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطة العامة في دولة الإمارات والعالم، تشكل مجتمعة حالة القوة القاهرة

(٣٦) Nancy, 22 nov. 2010, n° 09/00003. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_NANCY_2010-1122_0900003&ctxt=0_YSR0MD0iMDkvM-DAwMDMiE5hbmN5wqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFiY2g%3D#entete.

(٣٧) Coronavirus covid-19: à quel point le virus est-il dangereux?. https://www.franccetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-covid-19-a-quel-point-le-virus-est-il-dangereux-on-a-pose-la-question-a-des-experts-et-ils-sont-plutot-rassurants_3845231.html.

(٣٨) في فرنسا أعلن وزير الاقتصاد والمالية في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠، بأن فايروس كورونا كوفيد-١٩، يعد حالة قوة القاهرة بالنسبة للمشروعات، خصوصاً في نطاق مؤسسات القطاع العام للدولة، =

التي تسمح بترتيب الآثار القانونية المعتمدة لهذه الحالة^(٤٠)، والتي ستكون محل البحث في الفرع اللاحق.

على أنه يجب الانتباه أخيراً إلى أن اتخاذ السلطة العامة قرارات إدارية أو تشريعية بشأن قطاعات اقتصادية معينة أثرت على قدرتها على تنفيذ التزاماتها العقدية، نظراً لانطباق شروط القوة القاهرة، فذلك لا يمنع من تطبيق آثار القوة القاهرة على أي قطاع تأثر أداؤه بها، وعلى أي عقد توافرت بشأنه تلك الشروط، رغم عدم شموله بالقرارات التشريعية أو الإدارية التي تصدرها الدولة؛ وذلك لعمومية وشمول معيار القوة القاهرة بالنسبة لفيروس كورونا^(٤١).

الفرع الثاني

الآثار المترتبة على اعتبار فيروس كورونا " كوفيد-١٩ " قوة القاهرة

تأكد لنا أن جائحة فيروس كورونا المستجد تعد من الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم بأسره، وقد تحقق فيها وما تبعتها من إجراءات اتخذتها السلطة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة شرط عدم التوقع، فهي من الأمور التي لم يكن لأحد أن يتوقعها، شأنها في ذلك شأن كل الآفات السماوية من الزلازل والأعاصير وغيرها. كما أنها من الأمور التي لا يمكن دفعها أو التحرز منها، فلا يمكن لأي متعاقد أن يوقف انتشار الفيروس أو يمنع الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في مواجهته

= الأمر الذي يبرر عدم تطبيق الغرامات المترتبة على التأخير في تنفيذ الالتزامات العقدية، نقلاً عن، Pascale Guimard, op.cit.

Ludovic Landivaux, op.cit. (٣٩)

(٤٠) وينظر إلى فيروس كورونا شرعاً بنظر الجائحة العامة التي وضع لها الشرع قاعدة وضع الجوائح، فقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح"، صحيح مسلم - كتاب المساقاة باب وضع الجوائح - حديث ٢٩٩٢، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لو بعث من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"، صحيح مسلم - كتاب المساقاة باب وضع الجوائح - حديث ٨ ٢٩، انظر: أحمد عبد العزيز الحداد، أثر جائحة كورونا على حجوزات الطيران والفنادق وخدمات النقل والشحن والتعليم الخاص، ندوة البركة الأربعون للاقتصاد الإسلامي (وضع الجوائح والقوة القاهرة)، راجع الموقع الإلكتروني، <https://www.albaraka.org/>.

(٤١) المحامي عصام التميمي، فيروس كورونا قد ينهي العلاقات التعاقدية، مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة التميمي ومشاركوه، <https://www.tamimi.com>.

بصفتها من فعل الأمير، وذلك لتجنب تأثير الفيروس على الالتزامات التعاقدية التي تقع على عاتقه، فهو أمر خارجي مستقل تماماً عن إرادة الأفراد.

هذا الاستخلاص يتبعه السؤال الأهم عن الآثار التي تترتب على تكييف هذه الجائحة من قبيل القوة القاهرة، والمدى الذي يمكن أن يصله تأثير هذا التكييف على الالتزامات التعاقدية.

لقد سبق بيان أن المادة ٢٧٣ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي تنص على أنه: (١- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. ٢- وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل، وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين).

وهذا يعني أن أثر فيروس كورونا بحسبانه قوة القاهرة على الالتزامات العقدية يختلف بحسب ما إذا كانت استحالة التنفيذ دائمة أو وقتية. ولكن قبل بيان ذلك لابد من الإشارة إلى أنه قد يحصل أن لا يتأثر قطاع أو نشاط أو عقد ما بشكل مباشر بالوضع الناتج عن الفيروس، ويستمر كما كان قبل انتشاره، كأن يستمر المصنع بالإنتاج، وتم التمكن من توفير المواد الأولية والعمالة لتنفيذ الالتزام، أو عمد النشاط إلى تغيير طريقة أداء العمل وأسلوبه، ففي هذا الفرض لن تتأثر الالتزامات العقدية، وعلى أطراف العقد تنفيذه بالشروط المتفق عليها فيه. وفي هذا الصدد نشير إلى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠، في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ألزم كافة المنشآت المسجلة بالوزارة بالعمل وفق أحكامه لتنظيم علاقة العمل بالتوافق بين صاحب العمل والعامل غير المواطن المصرح له بالعمل بالمنشأة، وذلك للمحافظة على مصلحة الطرفين خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد نص في المادة الثانية منه على إمكان استمرار علاقة العمل وفق ما نص عليه العقد بكافة الالتزامات المترتبة على طرفيه عن طريق تطبيق نظام العمل عن بعد إذا كان ذلك ممكناً بحسب طبيعة النشاط والعمل.

١ - الاستحالة الكاملة والدائمة:

إذا ترتب على كوفيد-١٩ أن أصبح تنفيذ المدين كامل التزامه العقدي مستحيلاً وبشكل دائم، كما لو تعاقدت شركة مع وكالة سياحة وسفر لتسيير رحلة لموظفيها لمدة أسبوع، ثم قبل الموعد المحدد وقعت الجائحة واتخذت الدولة إجراءات منع السفر، ففي

هذا الفرض استحالة على الوكالة تنفيذ التزامها، وسقط بالمقابل التزام الشركة بدفع مقابل الرحلة، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه^(٤٢). ولو بادرت الشركة قبل ذلك إلى إلغاء الحجز، فليس من حق الوكالة المطالبة بالغرامة المتفق عليها عند الإلغاء المتأخر للحجز. وقد سبق بيان أن الهيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسية بينت أن العجز المؤقت الناجم عن الالتهاب أو المرض الخطير الواقع بعد إبرام العقد قد اتصف بعدم التوقع، وكان تسلسل الأحداث وكذلك النتائج المؤكدة المترتبة على التراجع الحاد للحالة الصحية تثبت أن المرض لا يقاوم، وبالتالي تنطبق عليه صفات القوة القاهرة. وبتطبيق ذلك على فيروس كورونا يمكننا القول بأن المدين إذا تعرض شخصياً لعدوى الفيروس أمكن عندئذ الاحتجاج بالقوة القاهرة؛ لأنه لن يكون بمقدوره تنفيذ الأداء المتفق عليه، ومن باب أولى عندما يحتاج تنفيذ الأداء إلى الانتقال والتواصل، في الوقت الذي يكون فيه المدين في الحجر الصحي^(٤٣). كما سبق لإحدى المحاكم الفرنسية أن قضت بأن في الإدخال الطارئ وغير المتوقع لأحد المحامين إلى المشفى وانعزاله التام وعدم إتاحة الوصول منه وإليه، ما يحقق صفات عدم التوقع وعدم إمكانية الدفع اللازمة للقوة القاهرة^(٤٤).

ويقصد بانفساخ العقد انحلاله بحكم القانون لتعذر تنفيذه لسبب أجنبي، ودون حاجة إلى صدور حكم قضائي بالفسخ أو وجود شرط تعاقدي يقضي به^(٤٥). وإذا تم اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة لضرورة ما، فإن هذا الحكم يكون حكماً كاشفاً وليس منشئاً، فلا توجد لدى القاضي سلطة تقديرية للحكم بالفسخ من عدمه، فنحن لسنا أمام صورة للفسخ ترجع إلى تقصير من جانب المدين^(٤٦). وقد قضت محكمة نقض (أبو ظبي) في هذا الصدد بأنه: (لما كانت المادة (٢٧٣) من قانون المعاملات

(٤٢) ويعد سبب انحلال العقد في حالة القوة القاهرة سقوط التزام المدين لاستحالة محله، وبسقوطه يسقط الالتزام المقابل، باعتبار أن الأول يعد سبباً للثاني، فلا يقوم الالتزام إذا تخلف سببه، وهو ما أكدته محكمة تمييز دبي بقولها: (محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٠، تاريخ الجلسة ١١/٥/٢٠١٠، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com

(٤٣) Pascale Guiomard, op.cit.

(٤٤) لكن في قضية أخرى لم يتم تقرير صفة عدم التوقع بشأن زكام عادي تعرض له المحامي وادعى بأنه أعجزه عن القيام بالأداء المكلف به، انظر: Nîmes, 6 nov. 2018, n° 18/04133

(٤٥) عدنان إبراهيم سرحان، محمود فياض، محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص ٢١٠.

(٤٦) عادل أبو هشيمة، هشام محمود، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دار الكتب القانونية، جمهورية مصر العربية، ٢٠١٤، ص ٢٠٠.

المدنية تنص على أنه: "١- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه" مما مؤداه أن الانفساخ بقوة القانون لا يكون إلا حيثما يستحيل التنفيذ العيني لسبب أجنبي، ويقصد بالسبب الأجنبي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، والذي يجعل تنفيذ العقد مستحيلًا استحالة مطلقة، ويقع عبء إثباته على عاتق المدين، وتقدير الاستحالة يخضع لتقدير محكمة الموضوع^(٤٧).

وتنص المادة ٢٧٤ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أثر الانفساخ، حيث ورد فيها بأنه: (إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض). وعليه فإنه يترتب على انفساخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وبالتالي زوال أثر كل ما قد تترتب على هذا العقد سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير.

ولكن لا بد في هذا الصدد من الانتباه إلى التسلسل الزمني الذي مرت به الإجراءات الاحترازية المانعة من تنفيذ العقد، لأنه حتى يمكن الاحتجاج بالقوة القاهرة يجب إقامة الدليل على العلاقة بين الحادثة واستحالة التنفيذ^(٤٨).

ففي فرنسا من حجز صالة لمؤتمر يحضره (٢٠٠٠) شخص يمكنه الاحتجاج بالقوة القاهرة لإلغاء الحجز منذ صدور مرسوم ٩ مارس ٢٠٢٠^(٤٩)، الذي نصت المادة الأولى منه على أنه: (لأجل منع انتشار فيروس كوفيد-١٩، يحظر أي تجمع يضم أكثر من ١٠٠٠ شخص في مكان واحد على الأراضي الوطنية حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٠). أما الشركة التي حجزت صالة لتنفيذ ورشة عمل يحضرها (١٥٠) شخصاً لا يمكنها ذلك إلا من تاريخ صدور مرسوم ١٣ مارس ٢٠٢٠^(٥٠)، الذي نصت المادة الأولى منه على أنه: (لأجل منع انتشار فيروس كوفيد-١٩، يحظر أي تجمع أو اجتماع أو نشاط يضم

(٤٧) محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٢٠١١، تاريخ الجلسة ٢٥-١-٢٠١٢، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

(٤٨) Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263.

(٤٩) Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n°0059 du 10 mars 2020 texte n°16, <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-TEXT000041704203&categorieLien=id>.

(٥٠) Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n°0063 du 14 mars 2020\ texte n° 27, <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-TEXT000041721916&categorieLien=id>.

أكثر من ١٠٠ شخص في مكان واحد، مغلق أو مفتوح، على الأراضي الوطنية حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٠) وأي عقد بيع للرحلات والأسفار مقرر قبل ١٦/٣/٢٠٢٠، وهو تاريخ بدء الحجر الصحي، فيمكن التمسك به قانوناً، يستثنى من ذلك الوجهات التي يعد فيها الفرنسيون أشخاصاً غير مرغوب فيهم (Persona non grata)، وإذا بادر العميل إلى إلغاء العقد فعليه تحمل ثمن ذلك، كأن يدفع غرامة الإلغاء المتأخر^(٥١).

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، صدر العديد من المبادرات لحكومتها^(٥٢)، في مختلف القطاعات بقصد تعزيز نمو الاقتصاد وقطاع الأعمال، والتعقيم الوطني وتدابير التباعد، وتعزيز الأمن الغذائي، كما أصدرت إجراءات وقوانين استثنائية، وذلك لمواجهة أزمة كورونا. وتسلسلت القرارات التي اتخذت بها هذه الإجراءات زمانياً، وفي بعض الأحيان مكانياً.

ففي قطاع النقل والسياحة، صدر القرار بمنع سفر المواطنين إلى خارج الدولة ابتداء من ١٨ مارس ٢٠٢٠، وتعليق كافة رحلات خطوط الطيران الوطنية التجارية الخاصة بالركاب، وعليه يجوز لكل من حجز تذكرة سفر أو رحلة سياحية خارجية أن يحتج بالقوة القاهرة، لإلغاء الحجز دون أن يتحمل أي مبلغ مالي مقابل الإلغاء المتأخر. وتطبيقاً لذلك أعلنت شركة طيران الإمارات بتاريخ ٢٧ إبريل ٢٠٢٠ عن تلقيها ٥٠٠ ألف طلب استرداد تذاكر، وخيرت المتعاملين بين استرداد ما قدموه، فإن رغبوا في ذلك فما عليهم إلا تقديم طلب استرداد الأموال إذا لم يتمكنوا من السفر لاحقاً، ولن يفرض عليهم أي غرامات استرداد. أو إصدار قسائم سفر جديدة آجلة كما يرغبون، وأن لهم الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى ٢٤ شهراً، وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، ووسعت هذا الخيار ليشمل أي تذكرة تُشترى قبل أو بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، للسفر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠^(٥٣). ويجوز للأجنبي المقيم في الدولة والموجود خارجها الاحتجاج بالقوة القاهرة لإلغاء حجز عودته للدولة، وذلك من تاريخ صدور القرار بمنع دخول أصحاب الإقامة السارية للإمارات في ١٩ مارس-آذار ٢٠٢٠^(٥٤). وكذا الأمر بالنسبة لمن حجز رحلة سياحية داخلية أو استأجر قارب نزهة، من تاريخ صدور قرار وقف خدمات السفن السياحية وتعليق أنشطة قوارب

(٥١) Ludovic Landivaux, op.cit.

(٥٢) انظر: مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أزمة كورونا، الملف الصادر عن

الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، منشور على الموقع الإلكتروني للهيئة: fcsa.gov.ae

(٥٣) جريدة الإمارات اليوم ٢٧ إبريل ٢٠٢٠.

النزهة. كما يجوز الاحتجاج بانفساخ عقد الاشتراك في جريدة للقوة القاهرة، وذلك من تاريخ صدور قرار وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية ابتداء من ٢٤ مارس - آذار ٢٠٢٠.

كما أطلقت الدولة برنامج التعقيم الوطني ابتداء من مساء يوم الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٠، والذي يصاحبه تقييد الحركة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، وأعطى لكل إمارة صلاحية تطوير خطط التعقيم بما يتناسب مع احتياجاتها، ثم أصدرت حكومة دبي قراراً بتمديد فترة التعقيم والتي تتضمن تقييد الحركة على مدار ٢٤ ساعة اعتباراً من ٣١ مارس - آذار في مناطق النشاط التجاري المكتظة بالأشخاص وخصوصاً منطقتي نايف والراس^(٥٥)، لتقرر لاحقاً تطبيق ذلك ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد اعتباراً من ٤ أبريل - نيسان ٢٠٢٠، على كامل تراب الإمارة^(٥٦)، على أن يستمر السماح بخروج فرد واحد من كل أسرة لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات^(٥٧). وترتب على ذلك أن الاحتجاج بالقوة القاهرة للوصول إلى انفساخ العقد يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار قيود الحركة الزمانية والمكانية، فلا ينفسخ العقد إذ كان تنفيذه ممكناً في الزمان والمكان غير المشمولين بالحظر.

ومن تطبيقات استحالة التنفيذ الكلية الناجمة عن سبب أجنبي، والتي توقعها المشرع الإماراتي منذ صدور قانونه للمعاملات المدنية، ويمكن الاستناد إليها في

(٥٤) وفي المقابل صدر قرار باعتبار إقامة الوافدين، سواء أكانوا داخل الدولة أم خارجها سارية تلقائياً حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، متى صادف تاريخ تجديدها بعد الأول من مارس من هذا العام. كما اعتبرت جميع تأشيرات وأذونات الدخول إلى الدولة للمتواجدين فيها سارية المفعول إلى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس من هذا العام.

(٥٥) وقد تم تخفيفه يوم ٦ أبريل - نيسان ٢٠٢٠ ليستمر تقييد الحركة من الساعة العاشرة مساءً إلى السادسة صباحاً، بعد النجاح الكبير للتعقيم في هذه المنطقة الذي وصلت فيه الإصابات إلى مستوى الصفر بعد إجراء ستة آلاف فحص لفيروس كورونا في محيط المنطقة في أقل من شهر واحد.

(٥٦) مع استثناء بعض القطاعات بتصاريح حركة خاصة، كالصحة، على أن يحمل منتسبوها معهم شهادة من جهة عملهم تبين عملهم ووقت تنفيذه، واستثناء الخارجين لتسوق المواد الغذائية، الذين عليهم الاحتفاظ بفواتير الشراء للإعفاء من غرامات أجهزة ضبط السرعة التي فعلت لرصد السيارات المخالفة للحظر.

(٥٧) عدلت لضرورات شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً.

مواجهة أثر الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا، ما تعلق بالظروف المتغيرة التي قد تطرأ على عقد الإيجار بعد إبرامه والتي لا يمكن توقعها، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٧٨٢ منه على أنه: "إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالشيء المؤجر دون سبب من المستأجر تنفس الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع"^(٥٨). وقاعدة الأثر الرجعي للانفساخ ترد فقط على العقود فورية التنفيذ كعقد البيع، ولا يجري الحكم على العقود مستمرة التنفيذ كعقد الإيجار، حيث يقتصر أثره على المستقبل ولا يتناول الماضي، ويسمى عندئذ إنهاء للعقد.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أنه إذا كان من حق المتعاقد الامتناع عن تنفيذ العقد والاحتجاج بالقوة القاهرة منذ بدء دولة الإمارات في اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في الأول من مارس ٢٠٢٠، فهل يمكنه ذلك قبل هذا التاريخ؟ هذا ما يصعب علينا تأكيده. فلا يمكن مثلاً تأكيد اعتبار الإعلان في الصين عن كوفيد-١٩ في ديسمبر ٢٠١٩، وانتشاره في هذه الدولة، مما يصلح وحده للاحتجاج به بقصد الامتناع عن تنفيذ العقد في دول أخرى، لنرى ما يقرره القضاء الإماراتي في الدعاوى التي تأكد لنا تسجيلها أمام المحاكم بشأن الجائحة، ولكن لم تصدر فيها أحكام بعد.

٢ - الاستحالة الجزئية والاستحالة المؤقتة:

إذا كانت الاستحالة جزئية فإن العقد ينفسخ جزئياً في حدود الجزء الذي استحال تنفيذه، هذا ما تقرره الفقرة الثانية من المادة ٢٧٣ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فلو تعاقد مستشفى مع مذكر أدوية ومستلزمات طبية لشراء كمية من الأدوية والكمادات الطبية لاستخدامها للمرضى والعاملين في المستشفى، وكان لدى المذكر رصيد كافٍ من الأدوية غير أن الكمادات نفدت وكان المذكر معتمداً على قدرته في استيرادها من الخارج، ولكن بسبب وباء كورونا تعطل استيرادها بسبب

(٥٨) انظر في ذلك: محمود علي مصلح السرطاوي، أحكام عقود إجارة المؤسسات المالية الإسلامية في فترة وباء كورونا، ندوة البركة الأربعون للاقتصاد الإسلامي (وضع الجوائح والقوة القاهرة)، راجع: الموقع الإلكتروني <https://www.albaraka.org/>. مع ملاحظة أن العذر الطارئ الذي يمكن معه فسخ عقد الإيجار يمكن أن يكون عاماً كما يمكن أن يكون خاصاً بالمستأجر وحده.

ضغط الطلب على المصنع أو إشكالات النقل، ففي هذه الحالة يُنتقص عقد البيع، فينفسخ في الجزء الذي استحال تنفيذه، أي تسليم الكمات، وينفذ في الجزء الممكن تنفيذه، وهو تسليم الأدوية^(٥٩). ومثل ذلك إذا اشترى المسافر تذكرة طيران ذهاب وإياب، واستخدمها في الذهاب، لكن منعه فيروس كورونا من السفر واستخدام تذكرة العودة، فيكون العقد قد تم تنفيذه فعلاً في جزء منه واستحال تنفيذ الجزء الآخر، فينفسخ في هذا الجزء الذي لم ينفذ وله الحق في الرجوع بثمنه^(٦٠).

أما إذا كانت الاستحالة المترتبة على جائحة كورونا وقتية، فإن القوة القاهرة، من حيث المبدأ، تعلق تنفيذ العقد لكنها لا تلغي نهائياً الالتزام بتنفيذه^(٦١). فإذا كان العقد فوري التنفيذ، كعقد البيع، واستحال تنفيذه بسبب تقييد الحركة في منطقة معينة لمدة أسبوعين، كما حصل في منطقتي نايف والراس في إمارة دبي، فيمكن تأجيل التنفيذ لحين رفع الحظر، وهو ما حصل فعلاً في وقت لاحق، وفي هذا الفرض لا تتأثر التزامات الطرفين من حيث المبدأ. أما إذا كان العقد مستمر التنفيذ، كعقد الإيجار وعقد التوريد، فإن الاستحالة الوقتية وإن كانت تعلق تنفيذ العقد، لكنها في الوقت ذاته تنتقص من التزامات الطرفين؛ لأن مرور الزمن دون تنفيذ العقد يعني فوات الجزء الواجب تنفيذه بفوات الزمن، فلو أبرم مطعم عقد توريد مع شركة لبيع اللحوم لتزويده يومياً بخمسين كيلو غرام من اللحم يومياً، وبسبب فيروس كورونا صدر القرار بمنع عمل المطاعم مؤقتاً، في هذا الفرض سيعلق تنفيذ العقد ويسقط الالتزام بالتوريد طوال أيام المنع، كما يسقط ما يقابله من التزام المطعم بدفع الثمن. خلاصة القول أن جميع الالتزامات التي لا يمكن تنفيذها الآن بسبب الجائحة (أعمال صيانة، إيجار قاعات، تنظيم مناسبات، ورش تأهيل مهني ونحو ذلك)، يجب أن تؤجل ليتم تنفيذها عندما يسمح الوضع بذلك.

ومع ذلك، فإن الفقرة الثانية من المادة ٢٧٣ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، قد أجازت للدائن في حالتي الاستحالة الجزئية والاستحالة المؤقتة فسخ

(٥٩) في شأن خيارات الدائن في حالة استحالة التنفيذ الجزئي بسبب هلاك بعض المبيع بقوة القاهرة، انظر المادة ٥٣١ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وكذلك، عدنان إبراهيم سرحان، محمود إبراهيم فياض، محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص ٢١١.

(٦٠) يتم ذلك في الفقه الإسلامي عملاً بقاعدة تفريق الصفقة عند تعدد المبيع، انظر: أحمد عبد العزيز الحداد، مرجع سابق.

(٦١) في أثر الاستحالة الوقتية، انظر: عبد الحكم فودة، أثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ٢٠١٤، ص ١٩٢.

العقد بشرط علم المدين. وهذا يعني أن العقد يصبح بالنسبة إليه غير لازم^(٦٢)، فيجوز له فسخه بإرادته المنفردة دون أن يعلق خياره في الفسخ على شرط معين، سوى إخطار المدين باختياره الفسخ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة ١٢١٨ الجديدة من القانون المدني الفرنسي أخذت بحكم مماثل عندما نصت على أنه: "فإذا كان العائق مؤقتاً، يُوقف تنفيذ الالتزام، ما لم يبرر التأخير في التنفيذ الذي سيترتب عليه فسخ العقد. وإذا كان العائق نهائياً، انفسخ العقد بقوة القانون، وأعفى الأطراف من التزاماتهم حسب الشروط المنصوص عليها بالمادتين ١٣٥١ و ١٣٥١-١"^(٦٣). كما اشتملت أحكام عقد الإيجار في قانون المعاملات المدنية على ما يدعم ذلك، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة ٧٨٢ من القانون على أنه: "وإذا كان المنع - من الانتفاع - يخل بنفع بعض الشيء المؤجر بصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد وتسقط الأجرة من وقت قيامه بإعلام المؤجر".

ولا يتصور أن يلجأ الدائن إلى الفسخ إذا كان التنفيذ الجزئي أو التنفيذ المتأخر في مصلحته. لكن يتوقع أن يلجأ الدائن إلى فسخ كامل العقد إذا كان في تنفيذ جزء الالتزام الذي لم يتأثر بالقوة القاهرة، دون الجزء الذي استحالة تنفيذه بسببها، ما يفرق عليه الصفقة فلا يستفيد من التنفيذ الجزئي أو يسبب له ضرراً أو إرهاقاً. أو عندما يبرر التأخير الفسخ لأن التنفيذ لن يكون مفيداً لوجوبه في وقت معين فات بسبب القوة القاهرة، كما لو حجز الزوجان صالة مناسبات لإقامة حفل بالذكرى السنوية لزوجهما، وصدر القرار بسبب الفيروس بمنع التجمع وعقد الحفلات والمناسبات، ودخل تاريخ زواجهما في مدة المنع، جاز لهما أن يتمسكا بأن تأجيل الحفل يفقده معناه، ويفسحا العقد. كما يمكن فسخ العقد كاملاً أيضاً إذا لم يعد امتناع التنفيذ مؤقتاً بل أصبح نهائياً، وهي الحالة التي لن تكون، وهو ما نرجوه وندعو الله له، بالنسبة لجائحة

(٦٢) تنص المادة ٢١٨ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه: "١- يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقيه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض. ٢- ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه".

(٦٣) تنص المادة ١٣٥١ الجديدة من القانون المدني الفرنسي على أنه: "استحالة تنفيذ الأداء تبرأ ذمة المدين في حدود الدين، إذا نتجت عن قوة قاهرة وكانت نهائية، ما لم يكن قد اتفق على أن يتحمل تبعه ذلك أو جرى إعذاره سلفاً". أما المادة ١٣٥١-١ منه فتتص على أنه: "إذا نتجت استحالة التنفيذ عن فقد الشيء المستحق الأداء، فإن المدين الذي تم إعذاره تبرأ ذمته كذلك، إذا أقام الدليل على أن الفقد كان سيحدث أيضاً ولو جرى تنفيذ الالتزام. وهو مع ذلك يلتزم بأن يتنازل لدائنه عن الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء المفقود".

كورونا. فالالتزامات العقدية في هذه الفروض ستسقط تماماً وتنفسخ العقود بها، تطبيقاً للمادتين ٢٧٣، ٤٧٢ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي المشار إليهما سلفاً.

وسواء انفسخ العقد بقوة القانون للاستحالة الكاملة والدائمة، أو تمسك الدائن بفسخ العقد في الاستحالة الجزئية أو المؤقتة، فلا يتحمل المدين الأضرار الناتجة عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه إذا كان سببها القوة القاهرة^(٦٤)، ولكن سيفتح الباب أمام الحق في الاسترداد، حيث يجب على المدين الذي سقط التزامه لاستحالة تنفيذه رد ما قبضه من الدائن مقابلاً لهذا الالتزام كاملاً، أو في حدود ما لم يتم تنفيذه منه، وهو ما يضيف بعض التعقيدات للأمر، خصوصاً عندما يكون العقد قد نفذ في جزء منه، وقد يكون المجهز قد دفع بعض التكاليف تحضيراً للتنفيذ، أو يكون العميل قد دفع عربوناً أو دفعات على الحساب.

وفي الختام، لا بد من ملاحظة أنه رغم اعتبار فيروس كورونا و/أو الإجراءات التي اتخذتها السلطة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول حالة من حالات القوة القاهرة، فإن آثارها المتمثلة في عدم التزام المدين بتنفيذ العقد يمكن استبعادها باتفاق مخالف^(٦٥). فتطبيقاً لمبدأ الحرية التعاقدية، يجوز للمتعاقد أن يتفقا على أنه رغم وقوع القوة القاهرة فإن الشروط العقدية تبقى واجبة التطبيق، وخصوصاً ما تعلق منها بالنفقات والشروط الجزائية أو الغرامات المترتبة على

(٦٤) وهو ما قضت به محكمة تمييز دبي بقولها: (من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقيام القوة القاهرة التي يفسخ بها العقد والتي يترتب عليها عدم مسؤولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بالالتزام أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً وليس في القيام بتنفيذه مجرد مشقة أو عناء على الملتزم به، وإن الحادث غير المتوقع هو ما لا يكون في حساب المتعاقدين أي ما لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد)، انظر: محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٠٩، تاريخ الجلسة ١٥/١١/٢٠٠٩، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com. كما ذهبت محكمة نقض أبو ظبي في حكم لها إلى أن: (تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة، أو تعد إخلالاً بتنفيذ التزام تعاقدي يستوجب التعويض، هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها)، انظر: محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠١٦، تاريخ الجلسة ١٧/١٠/٢٠١٦، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

(٦٥) وهذا الاتفاق على تشديد مسؤولية المدين لا يتعارض مع نصوص القانون، لأن ليس فيه مخالفة للنظام العام، عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص ١٩٦.

الانسحاب من العقد. ولا مانع أن يقبل المدين أن يأخذ على عاتقه ومسؤوليته تبعة القوة القاهرة^(٦٦).

(٦٦) تنص المادة ١٣٥١ الجديدة من القانون المدني الفرنسي على أنه: "استحالة تنفيذ الأداء تُبرئ ذمة المدين في حدود الدين، إذا نتجت عن قوة القاهرة وكانت نهائية، ما لم يكن قد اتفق على أن يتحمل تبعة ذلك أو جرى إذاره سلفاً".

المطلب الثاني

فيروس كورونا والظرف الاستثنائي

قد لا تصل جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة لمنع تفشيه والحد من آثاره الضارة، إلى الحد الذي يستحيل معه تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، عندئذ يفقد صفته كقوة قاهرة، لكن ذلك لا يمنع من لجوء المدين إلى نظام آخر يسمح له بالتخفيف من الآثار السلبية للجائحة على التزاماته العقدية، ونقصد هنا أحكام الظروف الاستثنائية. وهذا ما سنراه في فرعين:

الفرع الأول

فيروس كورونا ظرف استثنائي طارئ

نظم المشرع الإماراتي نظرية الظروف الطارئة في المادة ٢٤٩ من قانون المعاملات المدنية، التي جاء فيها: (إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).

والظرف الطارئ كل حادث عام لاحق على تكوين العقد، وغير متوقع الحصول أثناء التعاقد، ينجم عنه اختلاف بين في المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال بحيث يصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقاً شديداً، ويتهدهده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسارة المهنيين^(٦٧).

وقد يكون مفيداً ملاحظة أن القانون المدني الفرنسي بعد تعديله بمرسوم ٢٠١٦، قد كرس بكثير من الحذر لأول مرة، بعد أكثر من قرنين من عمره، أحكام الظروف الاستثنائية بآثار مختلفة عما قرره قانون المعاملات المدنية الإماراتي وجميع القوانين المدنية العربية التي أخذت بنظرية الظروف الطارئة، حيث نصت المادة ١١٩٥ منه على أنه: "إذا طرأ تغير في الظروف لم يكن متوقعاً عند إبرام العقد، مما جعل

(٦٧) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، المجلد الأول، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ٢٠١٥، ص ٧٠٥، مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، ١٩٦٠، ص ٣٣٦.

تنفيذ العقد مرهقاً على نحو مفرط لطرف لم يكن يقبل بتحمل مخاطره، كان له أن يطلب من الطرف الآخر إعادة التفاوض على العقد، ويواصل تنفيذ التزاماته خلال إعادة التفاوض. وفي حالة الرفض أو فشل التفاوض، يجوز للأطراف الاتفاق على فسخ العقد في التاريخ وبالشروط التي يحدونها، أو تقديم طلب مشترك إلى القاضي ليقوم بتعديله. وفي حال عدم اتفاق الأطراف خلال أجل معقول، جاز للقاضي، بناء على طلب أحد الأطراف، تعديل العقد أو إنهائه في التاريخ وبالشروط التي يحددها".

وكان القضاء المدني الفرنسي ومنذ وقت جد مبكر يفرض المساس بالعقد لمجرد تغير الظروف بعد انعقاده، مؤكداً بأنه: "لا اعتبارات الزمن ولا العدالة يمكنها أن تسمح للقاضي بتعديل اتفاق الأطراف"^(٦٨). لكن محكمة النقض الفرنسية، وعلى وجه الخصوص منذ ١٩٩٢، قد زادت من استثناءاتها على قاعدة عدم قابلية العقد للمساس، فارضة تطوراً أساسياً في هذا المجال بالاستناد إلى مبدأ حسن النية. حتى إنها وصلت في حكم صدر عن غرفتها التجارية عام ٢٠١٠ إلى القول بأنه كان على محكمة الاستئناف التي تنظر في قضية متعلقة بتنفيذ عقد صيانة أن تبحث فيما "إذا كان تطور الظروف الاقتصادية، وخصوصاً ارتفاع تكلفة المواد الأولية والمعادن منذ ٢٠٠٦ وانعكاس ذلك على قطع الغيار، لم يكن له أثر، مع الأخذ بنظر الاعتبار المبالغ المدفوعة، في اختلال التوازن الاقتصادي العام للعقد عما أراده الأطراف في ١٩٩٨ وحرّم بالتالي التزام - أحد الطرفين - من أي مقابل حقيقي"^(٦٩).

على أية حال، يتضح مما نص عليه قانون المعاملات المدنية الإماراتي أن نظرية الظروف الطارئة ترتب آثارها في العقود التي يتراخى وقت تنفيذها فيمتد مع الزمن^(٧٠)، أما لأنها عقود فورية وتم تأجيل تنفيذها بحيث لا يكون تنفيذ الالتزامات

(٦٨) Cass. Civ. 6 mars 1876, Canal de Craponne, D. 1876, 1, p.193, note Giboulot, Terré et Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T.2, 12 éd., 2015, Dalloz.

(٦٩) Cass. Com, 29 juin 2010, Soffimat: LPA 24 déc 2010, p. 7, note Choné-Grimaldi, JCP, 2011, 126, note Ghestin.

(٧٠) وبالرغم من وجود جدل فقهي حول مدى تطبيق نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود الفورية المؤجلة التنفيذ، إلا أننا نرى بأن تلك النظريات تنطبق على كافة العقود التي يطرأ بعد إبرامها وقبل تنفيذها حادث طارئ يؤدي إلى استحالة التنفيذ أو يتسبب بخسارة فادحة للمدين، لاسيما وأن المشرع الإماراتي لم يحدد العقود التي تنطبق عليها تلك النظريات، فعموم النصوص القانونية في هذا الصدد يفيد تطبيقها على كافة العقود التي تتوافر فيها شروط تطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، وهو ما أكدته محكمة تمييز دبي فيما =

المرتتبة على العقد بصورة فورية، أو لأنها من العقود مستمرة التنفيذ أو دورية التنفيذ^(٧١)، وذلك في الأحوال التي تتغير فيها الظروف الاقتصادية في وقت التنفيذ عما كانت عليه وقت إبرام العقد، وذلك بسبب حادث أو ظرف استثنائي عام خارج عن إرادة المدين لم يكن من الممكن توقعه أثناء إبرام العقد ولا يمكن دفعه، بما يؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً بالنسبة للمدين بحيث يتسبب له بخسارة فادحة.

وهذا يعني أن تنفيذ الالتزام في حال الظروف الطارئة مازال ممكناً بالنسبة للمدين فلم يغدو مستحيلًا، بحيث إنه قادر على تنفيذ التزاماته العقدية، إلا أن تنفيذه لتلك الالتزامات سيؤدي إلى خسارته خسارة فادحة تفوق الخسارة المتعارف عليها لدى المهنيين وأصحاب الحرفة.

وفي هذا الصدد قد قضت محكمة تمييز دبي بأن: "مفاد النص في المادة (٢٤٩) من قانون المعاملات المدنية يدل على أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلًا، صار مرهقاً للمدين، بحيث يهدد بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، ولا يقتصر إعمال نظرية الحوادث الاستثنائية على عقود المدة فقط بل تطبق أيضاً على أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الحادث الطارئ، ويشترط لإعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال بالتزامات العقد إخلالاً جسيماً، وتقدير جسامتها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاها على أسباب سائغة،

= يتعلق بنظرية الظروف الطارئة، حيث قضت بأنه: (ولا يقتصر إعمال نظرية الحوادث الاستثنائية على عقود المدة فقط بل تطبق - أيضاً - على أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الحادث الطارئ)، الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٠٩، تاريخ الجلسة ٢٠١٠/٢/٧، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

(٧١) وهو ما أكدته محكمة نقض أبو ظبي بقولها: (يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخي التنفيذ باعتبار أنها تسري على عقود المدة، أي العقود المستمرة أو التي يتراخى تنفيذها لفترة من الزمن، كما يشترط ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين؛ إذ لا يجوز له في هذه الحالة أن يستفيد من تقصيره). الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٢٠٠٩، تاريخ الجلسة ١٧/١٢/٢٠٠٩، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

وسلطة القاضي في رد الالتزام المرهق إلى الحد المقبول - وعلى ما يبين من صريح النص - سلطة جوازية يستعملها أو لا يستعملها حسبما يبين له من ظروف الدعوى ووقائعها" (٧٢).

ويمكن القول بأن الأساس الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة هو ضمان العدالة العقدية، لأنه إن كانت القوة الملزمة للعقد تستوجب أن ينفذ المدين ما تم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد، فإن العدالة تقتضي عدم السماح بإجحاف المدين وتحمله خسارة فادحة، نتيجة ظرف استثنائي لم يكن متوقعاً عند إبرام العقد، ما كان ليرتضيه أو يتحمل مخاطره لو علم به عند التعاقد. وعليه فإن العدالة تقتضي تدخل المشرع لحماية المدين وعدم تعرضه للخسارة الفادحة، وذلك من خلال إعطاء القاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول (٧٣).

ومن غير المتصور تحديد الظروف الطارئة على سبيل الحصر، وهي يمكن أن تكون من مصادر مختلفة كأن تكون ظرفاً متعلقة بالتشريع، كصدور تشريع خاص بفرض التسعير الجبري للسلع، أو مرتبطة بالأزمات الاقتصادية، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأجور الأيدي العاملة على نحو فاحش، كما يمكن أن تكون ظرفاً من صنع البشر، كالحروب والثورات والحصار الاقتصادي، تطيح بقيمة العملة الوطنية وتستتبع تضخماً اقتصادياً غير متوقع (٧٤). وهي يمكن أيضاً أن تكون ظرفاً طبيعية كالزلازل والفيضانات، أو الأوبئة والجوائح المرضية، وهو ما عليه حاضرنّا مع انتشار فيروس كورونا الانفجاري، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمنع استمرار زحفه أو التقليل من آثاره.

وبما أن الأصل في العقود هو التزام كلا الطرفين بما ورد في العقد المبرم بينهما وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فإنه لا يحق للمدين التمسك بنظرية الظروف الطارئة والمطالبة بتعديل الالتزامات التعاقدية إلا عند وقوع حوادث أو ظروف بشروط محددة.

فيجب كشرط أول، أن يكون الظرف عاماً واستثنائياً، ويقصد بالظروف والحوادث

(٧٢) محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٠٩، تاريخ الجلسة ٢٠١٠/٢/٧، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

(٧٣) مصطفى أحمد الزرقاء، مرجع سابق، ص ٣٣٦.

(٧٤) محمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، مطبعة زهران، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ١٩٨٧، ص ٢٣.

العامة تلك التي لا تكون خاصة بالمدين الذي يحتج بها، بل يجب أن تشمل عدداً كبيراً من الناس، كاهل بلد أو إقليم معين، أو طائفة معينة منهم كالمزارعين في منطقة معينة، أو منتجي سلعة بذاتها، أو المقاولين، فالعمومية لا تعني أن يكون الطرف شاملاً للجميع، وإنما يكفي أن يكون قد تأثر به مجموعة من الأشخاص بما فيهم المدين^(٧٥). أما إذا اقتصر الحادث الطارئ على المدين وحده كإفلاسه أو موته أو اضطراب تجارته أو حريق محصوله، فلا يمكن للمدين التمسك بها للمطالبة بتعديل العقد وفقاً لنظرية الظروف الطارئة^(٧٦).

ويرى البعض^(٧٧) بأن السبب وراء اشتراط أن يكون الحادث عاماً يكمن في إمكانية التيقن من الطرف وتأثيراته، فالظروف العامة واضحة ومعروفة لدى الجميع ويمكن للمحكمة التأكد من وقوعها بسهولة ويسر، بينما يصعب التأكد من حقيقة الأمر في كثير من الحالات لو أتيح المجال للظروف الفردية. ونضيف إلى ذلك أن نظرية الظروف الطارئة وجدت أساساً لتنظيم الحوادث الاستثنائية العامة، أما الظروف الأخرى فقد تعاملت معها نصوص خاصة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، بما يرفع الإجحاف ويحقق قدراً من العدالة، كالنصوص الخاصة بالغبن في المعاوضات^(٧٨)، أو الإجحاف الذي يصيب المزارع في بيع السلم^(٧٩)، أو البيع في مرض الموت^(٨٠)، أو

(٧٥) أحمد الصويغي شليبيك، نظرية الظروف الطارئة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مجلد ٣، عدد ٢، ٢٠٠٧، ص ١٨١.

(٧٦) فؤاد محمود معوض، دور القاضي في تعديل العقد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ٢٠٠٤، ص ٢٣٢.

(٧٧) عبد العزيز محمد حمد ساتي، التنظيم القانوني لنظرية الظروف الطارئة في العقود التجارية، مجلة العدل، وزارة العدل، المكتب الفني، العدد ٣١، ٢٠١٠، ص ١٩٨.

(٧٨) انظر: المادة ١٨٩ من القانون التي جاء فيها: "إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دين مستغرقاً لماله، كان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل". والمادة ١٩١، التي جاء فيها: "لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغيير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة".

(٧٩) انظر: المادة ٥٧٤ من القانون التي نصت على أنه: (١- إذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشتري منه محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة إجحافاً بيناً كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب من المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف".

(٨٠) انظر: المادة ٥٩٩ من القانون ذاته والتي نصت على أنه: "١- إذا باع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير كان البيع نافذاً دون توقف على إجازة الورثة. ٢- وإذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت كان البيع نافذاً في حق الورثة متى كانت زيادة قيمة =

موت المدين وإفلاسه الخاصة بالوعد الانفرادي المجرد^(٨١).

كما أن نظرية الظروف الطارئة يجب أن تؤخذ على أضيق نطاق؛ بحيث إنها تمثل استثناء للمبادئ العامة في سلطان الإرادة وحرية التعاقد، والقوة الملزمة للعقد، فلا يمكن منح القاضي سلطة التدخل لتعديل العقود إلا في حالات استثنائية ومحددة ومنها الظروف الطارئة العامة التي لا يقتصر تأثيرها على المدين فحسب.

إلا أنه لا يكفي أن تكون الحوادث أو الظروف عامة، بل يشترط أيضاً أن تكون تلك الحوادث استثنائية، وهي الحوادث غير المألوفة والنادرة الوقوع، سواء أكانت آفات سماوية كالزلازل والأوبئة، أو من فعل الآدميين كالحروب أو فرض التسعير الجبري^(٨٢). ففي هذه الأمثلة لا يندرج الظرف المعني في عداد الحوادث التي تتعاقب وفقاً لنظام معلوم^(٨٣)، بل يكون الظرف الطارئ خارجاً عن حدود المألوف ونادر الوقوع بحسب المجرى العادي للأمور، فمن غير الملائم أن تتم التضحية بمبدأ القوة الملزمة للعقد القائم على أن العقد نتاج ما اختاره المتعاقدان بحرية وقبلت به إرادتهما عن بينة وبصيرة، بالسماح بالتدخل القضائي لتعديل العقد، في الظروف المعتادة التي تقع دوماً وفق المجرى العادي.

وقد أكد القضاء الإماراتي على شرطي العمومية والاستثنائية في الحوادث التي تدخل ضمن نظرية الظروف الطارئة، حيث قضت محكمة نقض أبو ظبي بأنه: (من المقرر قضاء أنه وفقاً للمادة ٢٤٩ من ذات القانون يجوز للمحكمة وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، إلا أن شرط ذلك أن تطرأ حوادث استثنائية عامة)^(٨٤).

= المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. ٣- أما إذا جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع".

(٨١) انظر: المادة ٢٨٠ من القانون والتي جاء فيها: (١- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في الحال، وقد يقع على عقد أو عمل ٢ - ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس).

(٨٢) أحمد الصويعي شليبي، مرجع سابق، ص ١٨٠.

(٨٣) عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٧، ص ٢١٩.

(٨٤) محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٣، جلسة ٢٦/١/٢٠١٤ (مدني)، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية، محكمة النقض، المكتب الفني، دائرة القضاء، السنة القضائية الثامنة، ٢٠١٤.

أما الشرط الثاني، لإعمال نظرية الظروف الطارئة، فمفاده أن يكون الحادث الطارئ مما لا يمكن توقعه ولا دفعه، فالمتعاقد يتوقع في العادة عند إبرامه لأي عقد من العقود مخاطر مختلفة ناتجة عن العقد أو مرتبطة به، فعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنبها وعدم التعرض للخسائر، هذه المخاطر العادية المتوقعة لا تعبأ بها نظرية الظروف الطارئة ولا تأخذها بالحسبان، وإنما هي تعنى بالمخاطر التي تفوق توقعات المتعاقدين، فلا يكن بالإمكان توقع حدوثها أثناء إبرام العقد.

ويمكن تعريف عنصر التوقع بأنه الظن السائغ المقبول المؤيد بمعطيات الواقع لاحتمال وقوع أو عدم وقوع حادث معين في المستقبل يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً، أما الظروف غير نادرة الوقوع مثل اختلاف قيمة العملة وانتشار دودة القطن في المحاصيل الزراعية، فتدل على أن الظروف متوقعة أو يمكن توقعها ومن ثم لا سبيل لتطبيق نظرية الظروف الطارئة^(٨٥).

كما تجدر الإشارة إلى أن توقع الحادث أو عدم توقعه من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأشخاص والمهنة والمناطق، وهو ما يثير صعوبة في شأن تحديد المعيار الذي يمكن استخدامه في قياس هذا التوقع. والمعيار المتفق عليه هو المعيار الموضوعي، وهو ما يعني تحديد درجة التوقع لا بحسب الظروف الخاصة بالمتعاقد وإنما بالنظر إلى الظروف والأحوال الموضوعية التي أحاطت بعملية التعاقد، فما كان يمكن للشخص المعتاد توقعه وقت التعاقد كالارتفاع والانخفاض المألوفين في الأسعار فلا يعد ذلك ظرفاً طارئاً، لأنه يعد من الاحتمالات المألوفة التي يتوقعها المتعاقد وعليه تحمل خطرها^(٨٦).

وقد قضت محكمة نقض أبو ظبي في هذا الصدد بأنه: (ومن ثم فإن عقد المقاولة يكون قد أبرم على أساس تصميم متفق عليه لقاء أجر إجمالي، فليس للمقاوّل أن يطلب بأية زيادة في الأجر، فضلاً عن أن زيادة الأسعار لا تعد من الحوادث الطارئة التي ليس من الإمكان توقعها وخاصة من الطاعنة التي تمارس أعمال المقاوولات والتي تتوقع زيادة الأسعار من وقت لآخر، هذا بالإضافة إلى أنه يشترط عن الحوادث الاستثنائية أن تجعل الالتزام مرهقاً للمدين بحيث تهدده بخسارة فادحة، وبذلك فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال نظرية الظروف الطارئة^(٨٧)).

(٨٥) عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٧٢١.

(٨٦) سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، نظرية العقد والإرادة المنفردة، المجلد الأول، الطبعة الرابعة، مطبعة السلام، جمهورية مصر العربية، ١٩٨٧، ص ٣٤١.

(٨٧) محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٢٠١٢، تاريخ الجلسة ٢٠١٣/٢/٦، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

ويعد اشتراط عدم التوقع من الأمور البديهية، حيث إن المدين الذي أبرم العقد، بالرغم من توقعه لحدوث الظرف الطارئ، يعد راضياً بالنتائج التي قد تترتب على حدوثه، ومن ثم فلا يحق له التمسك بنظرية الظروف الطارئة والمطالبة بتعديل الاختلال في التوازن العقدي الناتج عن تلك الظروف المتوقعة. فلا يمكن للمتعاقد الذي قام بإبرام العقد بعد الأول من مارس ٢٠٢٠ وهو تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أو بعد تصنيفه كوباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية في يوم ١١ مارس ٢٠٢٠، التمسك بنظرية الظروف الطارئة في حال أصبح تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد مرهقاً بالنسبة إليه ويهدده بخسارة فادحة؛ ذلك أنه كان من المتوقع أن تسوء الظروف الاقتصادية والتجارية منذ بدء تلك الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

إلا أن عدم توقع حدوث الظرف الاستثنائي العام لا يعد كافياً للتمسك بنظرية الظروف الطارئة، وإنما ينبغي كذلك أن يكون هذا الحادث أو الظرف مما لا يستطيع المتعاقد تحاشيه أو دفعه. فإذا كان في وسع المدين أن يدرأه أو أن يتغلب عليه، فيستوي عندئذ أن يكون متوقعاً أو غير متوقع، ويكون قعود المدين عن دفعه أو تحاشيه مع قدرته على ذلك خطأ يتحمل وزره^(٨٨). كما أن المدين الذي له القدرة على دفع الظرف الطارئ وامتنع عن القيام بذلك يعد سيئ النية، وهو بذلك لا يستحق الاستفادة من نظرية الظروف الطارئة التي تقوم على العدالة وحسن النية في تنفيذ العقود. ويلاحظ هنا أن القانون الإماراتي شأنه في ذلك شأن غالبية التشريعات الأخرى التي نظمت نظرية الظروف الطارئة، لم ينص على شرط عدم القدرة على دفع الظروف الطارئة، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن هذا الشرط يعد من الأمور البديهية التي تقتضيها طبيعة الأساس الذي تقوم عليه نظرية الظروف الطارئة.

ومعيار تحديد كون الحادث ممكناً تفاديه أو دفعه موضوعي، قوامه الشخص المعتاد وليس معياراً ذاتياً قوامه المتعاقد ذاته، فإذا كان الحادث الذي وقع ممكناً دفعه وتفادي النتائج المترتبة عليه طبقاً لمعيار الشخص المعتاد فإنه في هذه الحالة لا يعد ظرفاً طارئاً ولا يصلح كسبب لتطبيق نظرية الظروف الطارئة. وتقدير مدى إمكانية دفع الحادث من عدمه يعتبر من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع قياساً على شرط عدم التوقع^(٨٩).

(٨٨) عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٧٢١.

(٨٩) محمد السناري، الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ١٩٩٨، ص ٦٧.

أما الشرط الثالث، لتطبيق نظرية الظروف الطارئة فهو أن تؤدي هذه الحوادث أو الظروف إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام بالنسبة للمتعاقد مرهقاً، أي أن يتسبب له في خسارة فادحة، وهذا هو الفارق بين الطرف الطارئ والقوة القاهرة، فهما يشتركان في أن كلاً منهما لا يمكن توقعه ولا استطاع دفعه، إلا أنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، بينما تقف الظروف الطارئة عند حدود جعل التنفيذ مرهقاً للمدين.

ويقصد بالإرهاق في هذا الصدد، أن يتسبب تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه في العقد بخسارة فادحة للمدين تجاوز الخسارة المتعارف عليها في التعامل، بحيث يختل التوازن الاقتصادي في العقد المبرم بين الطرفين^(٩٠). وقد أكدت محكمة نقض أبو ظبي على اشتراط الإرهاق في التنفيذ كأحد شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وذلك عندما ذهبت إلى أنه: (لا يكفي لإعمال نظرية الظروف أو الحوادث الطارئة أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً أو مجرد تهديد المدين بخسارة، بل يجب أن تكون خسارة فادحة تجعل الالتزام يتجاوز حدود السعة مما يسوغ معه تعديل الالتزام استناداً إلى هذه النظرية)^(٩١).

ويحدد الإرهاق بصورة موضوعية لا ينظر فيها إلى ظروف المدين الخاصة أو إلى ثروته، فالعبرة بالصفقة محل التعاقد حيث تنسب الخسارة إليها، وبمعنى آخر فإن الإرهاق معياره موضوعي بالنسبة إلى الصفقة المعقودة لا ذاتي بالنسبة إلى شخص المدين، حتى أن الالتزام قد يكون مرهقاً بالنسبة للحكومة في صفقة معينة عقدتها دون النظر إلى ميزانيتها الضخمة^(٩٢). وهو ما أكدته محكمة تمييز دبي بقولها إن: (النص في المادة ٢٤٩ من ذات القانون يدل على أن تدخل القاضي - بناء على طلب المدين - لرد التزام المدين المرهق بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد المعقول رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة، ومناطق هذا الإرهاق الاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها التي أبرم في شأنها العقد لا الظروف المتعلقة بشخص المدين)^(٩٣).

(٩٠) عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٧٢٢.

(٩١) محكمة نقض أبو ظبي، طعن رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ (نقض مدني)، جلسة ٢٨ إبريل ٢٠١٠، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية، السنة القضائية الرابعة، ٢٠١٠، الجزء الأول، ص ٤٥٢.

(٩٢) فؤاد محمود معوض، مرجع سابق، ص ٢٣٣.

(٩٣) محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ١٨ لسنة ٢٠١٠، تاريخ الجلسة ٣٠/٥/٢٠١٠، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

وتجدر الملاحظة هنا أن نص المادة ١١٩٥ الجديدة من القانون المدني الفرنسي، قد أضاف شرطاً آخر لإعمال النظام القانوني المستحدث للظروف الطارئة، يتمثل في عدم شمول العقد على شرط قبول المخاطر المترتبة على الطوارئ غير المتوقعة. هذا الشرط، وعلى خلاف الشروط الأخرى، من طبيعة شخصية ذاتية، وقد تسبب في جعل القاعدة القانونية التي تقرره من طبيعة مكملة، "فالأطراف بإمكانهم استبعادها مقدماً لصالح اختيار تحمل النتائج المترتبة على تحقق مثل تلك الظروف التي من شأنها قلب اقتصاد العقد"^(٩٤). وهو أيضاً قد جعل هذا النظام أقل قيمة مما تم التبشير به على أنه أحد التعديلات الكبرى في قانون العقود الفرنسي، ذلك أن مجمل الآلية التي جاءت بها المادة ١١٩٥ أعلاه يمكن أن تفشل بشرط قبول تحمل مخاطر الظرف الطارئ الوارد في العقد^(٩٥)، وهو الشرط الذي يخشى أن يكون نمطياً في العقود؛ ولهذا فإن توجه قانون المعاملات المدنية الإماراتي كان حليفه الصواب، عندما جعل حكم المادة ٢٤٩ من النظام العام، فأبطل كل اتفاق على خلاف ما تضمنته من إجازة للقاضي في التدخل لإعادة التوازن العقدي المفقود بسبب الظرف الطارئ.

الفرع الثاني

الآثار المترتبة على اعتبار فيروس كورونا "كوفيد-١٩" ظرفاً استثنائياً

إذا تأكد لدينا أن فيروس كورونا و/أو الإجراءات التي اتخذتها الدول لاحتوائه والحد من انتشاره، لم يصل فيها التأثير إلى حد استحالة تنفيذ الالتزام بكافة أشكالها الكاملة والدائمة أو الجزئية والمؤقتة، بل عاد تنفيذ التزام المدين مرهقاً ويهدده بخسارة فادحة تخرج عن المألوف في التعامل، فذلك يقتضي تطبيق أحكام الظروف الطارئة، وفقاً لما قرره المادة ٢٤٩ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وقد اتفقت غالبية التشريعات، ومنها القانون الإماراتي، على منح القاضي سلطة إعادة التوازن

(٩٤) Rapport au Président de la République, Relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (extrait), réforme du droit des obligations, Un supplément Au Code Civil 2016, Dalloz. V. aussi. Jo. 11 février 2016, Texte n°25.

(٩٥) D. Mazeaud, présentation de la réforme du droit des contrats, Gaz.Pal. 23 févr. 2016, p. 15 s.

الاقتصادي للعقد، بما يؤدي إلى رفع الإرهاق الواقع على المدين، وبذلك خول القانون للقاضي سلطة تجاوز حدود مهمته العادية، فأجاز له في هذه الحالة أن يعدل العقد.

وقد يكون الخيار الأول، للتعامل مع الظرف الطارئ الذي أحدثه فيروس كورونا وامتداه على نطاق عالمي، وآثاره السلبية على مختلف القطاعات، ومنها النشاطات الاقتصادية والعلاقات القانونية القائمة عليها، هو الوصول إلى تفاهم يرضي المتعاقدين بشكل ودي بعيداً عن القضاء وإجراءات التقاضي، وبشكل يراعي الظروف الاقتصادية والصحية، وبما يمكنهم من إعادة تنظيم علاقتهم العقدية بأقل ما يمكن من النفقات والأضرار، وتوزيع مخاطر هذه الجائحة بين الطرفين بالقدر الذي يضمن مصلحتهما المشتركة^(٩٦). ولا يوجد في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ما يمنع المتعاقدين من إعادة التفاوض على العقد، وليس في المادة ٢٧٦ من القانون ما ينقض إمكان تعديل العقد بالإرادة المشتركة لطرفيه، فهي تنص على أنه: "إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون".

هذا الخيار الأول، كرسه تشريعاً النظام المستحدث للظرف الطارئ في القانون المدني الفرنسي، فهو رغم الانتقادات التي وجهت إليه، أعطى للمتعاقد المتضرر من الظرف الطارئ، أن يطلب من المتعاقد الآخر إعادة التفاوض على العقد، حيث نصت المادة ١١٩٥ منه على أنه: "إذا طرأ تغير في الظروف لم يكن متوقعاً عند إبرام العقد، مما جعل تنفيذ العقد مرهقاً على نحو مفرط لطرف لم يكن يقبل بتحمل مخاطره، كان له أن يطلب من الطرف الآخر إعادة التفاوض على العقد، ويواصل تنفيذ التزاماته خلال إعادة التفاوض...".

وهذا التوجه يحقق فائدتين، فهو يقرر أولاً أن الطرف الذي يطلب إعادة التفاوض على العقد يستمر في تنفيذ التزاماته خلال عملية إعادة التفاوض. بما يعني أن العقد لن يتم تعليقه، كما كان عليه الحال في الحلول القضائية التي سبقت تعديل القانون، والتي يبدو منها توجه القضاء عند وجود الظرف الطارئ إلى وقف تنفيذ العقد، وربما إلغاؤه^(٩٧)، ما لم يتفاوض عليه الأطراف من جديد، فإذا نجحت المفاوضات، سيتم تنفيذ العقد بشروطه الجديدة^(٩٨). ومن ناحية أخرى، فإن واجب الإخلاص والتعاون

(٩٦) المحامي عصام التميمي، مرجع سابق.

Cass. Com, 29 juin 2010, précité.

(٩٧)

Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p.218.

(٩٨)

الذي يوجد بين أطراف العقد، يجعل من رفض التفاوض أمراً صعباً طالما اجتمعت كل شروط تطبيق النص، بأن: " طرأ تغير في الظروف لم يكن متوقعاً عند إبرام العقد، مما جعل تنفيذ العقد مرهقاً على نحو مفرط لطرف لم يكن يقبل بتحمل مخاطره ". فرفض التفاوض في مثل هذه الحالة يمكن أن يكون تصرفاً مخالفاً لذلك المبدأ، وعلى المتعاقد رافض التفاوض أن يأخذ مخاطر رفضه بالحسبان^(٩٩).

على أية حال إذا تحققت شروط الظرف الطارئ في فيروس كورونا و/أو الإجراءات المتخذة لمنع انتشاره، فإن قانون المعاملات المدنية الإماراتي أذن للقاضي بخرق القوة الملزمة للعقد، والتدخل لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، وبالقدر الذي تقتضيه العدالة.

فلو أن العقد المقصود في هذا الفرض هو عقد مقاوله بناء مائة وحدة سكنية لموظفي مؤسسة معينة، وكان أجر المقاول فيه خمسين مليون درهم إماراتي، وأثناء التنفيذ تفشت جائحة كورونا مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، بسبب صعوبة استيرادها من الخارج، الأمر الذي جعل من تنفيذ المقاول لالتزامه بنفس الشروط العقدية وبذات المقابل كارثة تهدده بخسارة فادحة. في مثل هذا الفرض يجوز للقاضي في سبيل إعادة التوازن الاقتصادي للعقد أن يتنبى عدة حلول، مع ملاحظة أن المقصود من تدخل القاضي هو التخفيف من الخسارة لتكون معقولة لا فادحة، وليس رفعها تماماً، ومن هذه الوسائل:

١ - وقف تنفيذ العقد حتى انتهاء الجائحة وزوال آثارها وعودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي قبل الأزمة، على اعتبار أن هذه الجائحة تبقى وقتية ولا بد لها من زوال. على أن اختيار هذا الحل يجب أن يراعي فيه القاضي أن التأخير لا يصيب الدائن، أي المؤسسة، بضرر جسيم. ولا مانع من أن يكون الوقف في جزء معين من العقد، وذلك في الحالات التي تكون فيها الالتزامات الواردة في العقد في صورة أقساط حالية وأقساط مستقبلية، فإنه في هذه الحالة لا يكون الوقف شاملاً لجميع الأقساط الحالية والمستقبلية، ولكن يتم وقف القسط أو الأقساط التي تأكد لدى القاضي أن التزام المدين بها صار مرهقاً ومهدداً له بخسارة فادحة، ولا يمكن

(٩٩) Christophe Alleaume, La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Travail collectif, Sous la direction de Thibault Douville, avec Christophe Alleaume, Anne-sophie Choné - Grimaldi, Aude-solveig Epstein, Thierry Le Bars, Laurence Mauger- Vielpeau, Gilles Raoul-Cormeil, Odile Salvat, Mathieu Thiberge, 2^e édition Lextenso, 2020, p. 180.

تعديل العقد ووقفه فيما يتعلق بالأقساط المستقبلية التي يحتمل زوال أثر الظروف أو الحوادث عند استحقاقها^(١٠٠).

٢ - زيادة المقابل الذي تدفعه المؤسسة للمقاول، وهنا يلجأ القاضي إلى الإبقاء على الزيادة المألوفة في تكلفة البناء على عاتق المدين ومن ثم يقوم بتوزيع الزيادة غير المألوفة على طرفي العقد، فيزيد المبلغ الذي تدفعه المؤسسة من خمسين مليون درهم إلى سبعين مليوناً مثلاً، مع الإبقاء على عدد الوحدات السكنية كما هو، وبذلك يتحقق نوع من التوازن الاقتصادي بين الالتزامات التي يرتبها العقد على الطرفين^(١٠١). وفي هذا قضت محكمة نقض أبو ظبي بأنه: "يجوز وفقاً للمادة ٢٤٩ من القانون المدني إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدية وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف زيادة الالتزامات المتقابلة لتحقيق الموازنة بين مصلحة الطرفين إذا اقتضت العدالة ذلك"^(١٠٢). إلا أن القاضي في حالة زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق لا يقوم برد الالتزام إلى الحد المعقول إلا بالنسبة للحاضر، ولا شأن له بالمستقبل لأنه غير معروف، فقد يزول أثر الحادث الطارئ، فيرجع العقد إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وتعود له قوته الملزمة كاملة كما كان في الأصل^(١٠٣).

٣ - إنقاص التزام المقاول، بإلزامه مثلاً ببناء ثمانين وحدة سكنية بدلاً عن مائة، مع عدم تعديل المقابل الذي تدفعه المؤسسة^(١٠٤).

ولو كان موضوع العقد توريد مائة كيلو من اللحم يومياً إلى مطعم، وبسبب قرار

(١٠٠) هبة محمد محمود الديب، أثر الظروف الطارئة على العقود المدنية في القانون المدني الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١٢، ص ٦٦.

(١٠١) سليمان مرقس، مرجع سابق، ص ٥٣٢.

(١٠٢) وفي هذا قضت محكمة نقض أبو ظبي بأنه: "يجوز للقاضي إجراء تخفيض على قدر العمولة بعد إبرام العقد الذي توسط فيه، في حالة تطبيق نظرية الظروف الطارئة بشرط أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخي التنفيذ باعتبار أنها تسري على عقود المدة، محكمة نقض أبو ظبي، طعن رقم ١٤٧٧ لسنة ٢٠٠٩، تاريخ الجلسة ١٢/٥/٢٠١٠، مشار إليه في: شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

(١٠٣) عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٧٢٦.

(١٠٤) محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٢٠٠٩، جلسة ١٧/١٢/٢٠٠٩ تجاري، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، السنة القضائية الثالثة ٢٠٠٩، الجزء الثالث، ص ١٥١٤.

الدولة قصر عمل المطاعم على طلبات التوصيل إلى الزبائن منعاً لتجمعهم في مكان واحد، مما يعني عدم حاجة المطعم لهذه الكمية وتعرضه لخسارة فادحة إن ألزم بدفع ثمنها، ففي هذا الفرض يكون الحل الأسلم هو تخفيض الكمية الموردة وإنقاص ما يقابلها من الثمن.

وهذا يعني أن المشرع الإماراتي قد وضع مبدأ عاماً مرناً وهو رد الالتزام للحد المعقول، مما ييسر على القاضي أن يعالج كل حالة بحسب ظروفها الخاصة، والمشرع بذلك جعل معيار الظروف الطارئة معياراً موضوعياً يحد من تحكم القاضي ولم يجعله معياراً ذاتياً^(١٠٥).

وقد أكد القضاء الأعلى في الإمارات حكم قانونه للمعاملات المدنية، فذهبت محكمة نقض أبو ظبي مثلاً إلى أنه: "لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه، ولا يجوز ذلك للقاضي؛ ذلك لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقيدها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين، فلا يجوز نقض العقد إلا وفقاً للمادة ٢٤٩ من قانون المعاملات المدنية رقم ١٩٨٧ التي تجيز تدخل القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ ليقوم ضرباً من ضروب التوازن بين مصلحة الطرفين"^(١٠٦).

والقاضي عند تعديل العقد ورد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول عليه واجب بحث التعديل في إطار الظروف المحيطة بالعقد التي تنفذ فيها الالتزامات التعاقدية، بمعنى أنه لا ينظر إلى الالتزام المرهق بمعزل عن الظروف المحيطة به؛ لأن هذه الظروف هي التي أسهمت في إضفاء صفة الإرهاق على هذا الالتزام، ولذا فإنه يجب على القاضي أن يقوم ببحث هذه الظروف ليتبين مدى أثرها على التزام المتعاقدين، وما إذا كان هذا الظرف الطارئ ذا تأثير مستمر أم مؤقت، وحدود استمرارية هذا

(١٠٥) عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٧٢٦.

(١٠٦) محكمة نقض أبو ظبي، طعن رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ مدني، جلسة ٢٨/٤/٢٠١٠، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية، السنة القضائية الرابعة ٢٠١٠، الجزء الأول، ص ٤٥٢، وانظر أيضاً: حكمها في الطعن رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٣ س ٨ ق. أ، جلسة ٢٦/١/٢٠١٤ مدني، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية، محكمة النقض، المكتب الفني، دائرة القضاء، السنة القضائية الثامنة ٢٠١٤.

التأثير ومدته، كل ذلك من أجل وصول القاضي إلى حل عادل ومناسب للفصل في النزاع القائم أمامه^(١٠٧). وبالعودة إلى مثال الما قول المذكور أعلاه، قد يتضح للقاضي أن لدى الما قول مخزوناً كبيراً من مواد البناء تم شراؤها قبل تفشي كورونا وارتفاع أسعارها، بما يعني عدم تضرره من هذا الارتفاع، أو أن الدولة قد قدمت دعماً مالياً للأنشطة الاقتصادية المتضررة من الجائحة، فحصل الما قول على إعفاء من الضرب والرسوم الواجب عليه دفعها في هذا العقد، والتي كان الما قول قد أخذها بنظر الاعتبار، وهي بمقدار معتبر، عند قبوله بمقابل قيامه بالعمل، مما يخفض من خسارته إلى الحد المعقول، ففي هذه الفروض لن يقدم القاضي إلى تعديل العقد ويلزم الأطراف بما ورد فيه من شروط.

كما يتعين على القاضي كذلك أن يوازن بين مصلحة الطرفين، فتعديل العقد لا يعني رفع الإرهاق كله عن كاهل المدين، ولا يعني إلقائه كله على عاتق الدائن، وإنما يهدف هذا التعديل إلى الموازنة بين الطرفين، ومن هنا تظهر أهمية هذا الضابط المتمثل في إلزام القاضي بإجراء المقارنة بين مصلحة كل من المتعاقدين، وفي ضوء ما يظهر له من هذه المقارنة يكون اختيار الحل المناسب، بمعنى أن هذا الضابط يقوم على إعادة توزيع الأعباء الطارئة مباشرة بين طرفي العقد، وهذه هي الغاية الأساسية من تدخل القاضي والمتمثلة في إعادة تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد^(١٠٨).

وفي هذا الصدد قضت محكمة تمييز دبي بأن: "مفاد المادة (٢٤٩) من قانون المعاملات المدنية أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين، بحيث يهدد بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله"^(١٠٩).

ويجب هنا ملاحظة أنه في القانون الإماراتي، أيّاً كان الحل الذي أخذ به القضاء من الخيارات الثلاثة أعلاه، فهو واجب الاحترام والتطبيق من الطرفين، ولا يمكن لأي منهما مثلاً رفضه وطلب فسخ العقد، لا بل أن القاضي نفسه لم يصرح له القانون

(١٠٧) محمد محيي الدين إبراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ٢٠١٠، ص ٤٣٢.

(١٠٨) محمد عبد الرحيم عنبر، مرجع سابق، ص ١١٩.

(١٠٩) محكمة تمييز دبي، الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٠٩، تاريخ الجلسة ٧-٢-٢٠١٠، مشار إليه في:

شبكة قوانين الشرق، www.eastlaws.com.

بإنهاء العلاقة التعاقدية تماماً، وكل ما يمكنه هو تعديل العقد بما يزيل الإرهاق عن المدين.

لكن الأمر جد مختلف بموجب النظام المستحدث للظرف الطارئ في قانون العقود الفرنسي بعد تعديله بمرسوم ٢٠١٦. فكما قلنا أن المادة ١١٩٥ الجديدة من القانون المدني الفرنسي قد أعطت الأولوية لإعادة التفاوض على العقد بناء على طلب المدين مع مواصلة الأخير لتنفيذ التزاماته خلال المفاوضات. على أن الالتزام بإعادة التفاوض لا يتضمن أي التزام بنجاح المفاوضات، التي إن رفضت أو فشلت فيجب على المتعاقدين، بموجب الفقرة الثانية من المادة ١١٩٥، التوجه إلى أحد خيارين، وكلا الخيارين يصب في التأثير المباشر على العقد كنتيجة للظرف الطارئ، وهو ما سبق للقضاء الفرنسي أن بدأ التوجه إليه تدريجياً:

الخيار الأول، وضع نهاية لعلاقتهم العقدية بالفسخ الاتفاقي للعقد، ولهما أيضاً الاتفاق على التاريخ والشروط التي يحددانها لتلك النهاية.

أما الخيار الثاني، وهو الأهم، أن يقرر الطرفان باتفاقهما المشترك تقديم طلب مشترك إلى القاضي لإعادة النظر في العقد وتعديله. ورغم أن الأمر ما يزال، بقدر ما، في إطار النظرة التقليدية للقوة الملزمة للعقد، لأن القاضي لن يتدخل إلا بناء على طلب الطرفين^(١١٠)، إلا أنهما بتسليم الأمر إلى القاضي يكونان قد فقدوا السيطرة على التغييرات التي سيجريها على محتوى العقد ومضمونه بقصد إزالة الإرهاق المفرط الذي يعانيه أحد المتعاقدين من تنفيذه الالتزامات العقدية بشروطه الأولية. وفي الوقت ذاته، سيفقد القاضي بسبب ذلك حياده الذي يوصف تقليدياً بالقول "إن القاضي خادم العقد". على أن هذا الحل سيكون مقبولاً من الطرفين، ذلك أن القاضي سيقوم بتوفيق العقد بحسب ما استجد من الظروف الطارئة، لا وفقاً لمصالح هذا أو ذاك من المتعاقدين، كما أنه سيكون بالتأكيد مرشحاً لأن يأخذ بما سيشير إليه الطرفان أمامه من اتفاقات. لكن القاضي، سيلجأ بالتأكيد، في حالة الظروف والأوضاع العقدية المعقدة إلى الخبرة، التي يمكن للطرفين أيضاً طلبها بسؤال القاضي إحالة الأمر إلى خبير مع مهمة واضحة بتقديم مقترحاته عن التعديلات التي يمكن إدخالها على العقد^(١١١).

لكن جديد المادة ١١٩٥ من القانون المدني الفرنسي لم ينته بعد. إذ من المتصور أن لا يصل المتعاقدان خلال مهلة معقولة، إلى اتفاق مشترك بالطلب من

Stefanie Porchy-Simon, op.cit, p.218.

(١١٠)

Christophe Alleaume, op.cit, p.180.

(١١١)

القاضي التدخل لتأهيل العقد وتعديله. في هذا الفرض للقاضي، بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، وبناء على طلب انفرادي من أحد الطرفين، إعادة النظر في العقد وتعديله، أو حتى وضع نهاية له، وله في هذه الحالة الأخيرة تحديد تاريخ نهاية العقد والشروط التي سينهى بموجبها. هذا الحل يمثل أهم ما استحدثته المادة أعلاه في شأن الظرف الطارئ، فالوضع السابق على تعديل القانون الفرنسي كان يتلخص في أن الطرف الذي يتعرض لظروف طارئة أثناء تنفيذ العقد لم تكن بالحسبان عند إبرامه، لا يجد أمامه سوى حل واحد وهو وقف تنفيذ العقد (إلا إذا كان العقد غير محدد المدة، حيث يمكنه إنهاءه). والدائن في هذه الحالة يرفع دعواه مطالباً بالتنفيذ الجبري أمام القاضي المختص، الذي وفق التوجه القضائي السائد وقتها سيبحث إذا ما كان الطرف الذي يرفض إعادة التفاوض على العقد قد أدخل بالالتزام بحسن النية. وهذا لم يكن يؤدي إلى أكثر من إعادة التفاوض أو إنهاء العقد. أما بعد التعديل، فإن المادة ١١٩٥ أعلاه تخول القاضي صلاحية وضع حد لنزاع الطرفين بالتدخل على مضمون العقد، عن طريق تعديل المقابل في العقد بالنسبة للمستقبل، أو شروط تنفيذه، كموعده التسليم، أو معدل الفائدة، أو مواعيد الاستحقاق، أو الخصومات ونحو ذلك. هذه الصلاحية ستعمل كأداة للوقاية والردع، ذلك أن خطر إنهاء العقد - وتعديله من قبل القضاء بعيداً عن طرفيه، سيدفعهما إلى تجنب الآثار السلبية للتعرض إلى ظروف طارئة في المستقبل عن طريق تضمين العقد عند إبرامه شروط إعادة التقدير أو إعادة التأهيل، والتي من شأنها أن تبين الخطوات والإجراءات واجبة الاتباع في الحالات التي تعددها أو تعرفها والتي ترتبط بتغيير الظروف غير المتوقعة عند إبرام العقد. فإن لم يكن العقد قد اشتمل على مثل هذه الشروط، فلا أقل من أن يدفع إمكان تحكم القاضي في تعديل العقد أطرافه إلى الاتفاق من جديد على إعادة التفاوض بشأنه بعد حدوث الظرف الطارئ^(١١٢).

ونظراً لطبيعة وخطورة الوضع المترتب على انتشار فيروس كورونا والآثار المترتبة عليه، فلم يترك تنظيم تأثير الظروف الطارئة على تنفيذ الالتزامات العقدية، خصوصاً فيما يتعلق بعقد العمل الذي تأثر بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية المتمثلة بتقييد الحركة ومنع التجمعات، إلى القواعد العامة للظرف الطارئ في قانون المعاملات المدنية، بل صدر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات القرار الوزاري رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٢٠ في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص

خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ٢٦ مارس ٢٠٢٠. هذا القرار ألزم في المادة الثانية منه المنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية والتي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، أن تتدرج فيما تقوم به من إجراءات بالاتفاق مع العامل، فيمكنها تطبيق نظام العمل عن بعد إن كان ذلك ممكناً، وعندئذ لا يتأثر العقد بأي حال من الأحوال، أو أن تلجأ إلى إجراءات أخرى من شأنها إعادة النظر في شروط العقد وتعديله بالتوافق مع العامل^(١١٣)، وتحت رقابة الوزارة، وتتمثل هذه الإجراءات بالآتي:

- ١ - منح العامل إجازة مدفوعة الأجر، وهذا يعني إعفاء العامل من التزامه بالقيام بالعمل مقابل الأجر الذي يبقى يستحقه.
- ٢ - منح العامل إجازة من دون أجر، وهذا يعني وقف تنفيذ العقد في التزاماته الأساسية، القيام بالعمل من جهة العامل، ودفع الأجر من صاحب العمل.
- ٣ - خفض أجر العامل بشكل مؤقت خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وهذا يعني تعديل العقد بشكل مؤقت وذلك بتخفيض التزام صاحب العمل بالأجر. ولضمان الرقابة على تصرف صاحب العمل، فعلى المنشأة في هذه الحالة إبرام " ملحق إضافي مؤقت " لعقد العمل بين طرفيه، وفق النموذج الملحق بالقرار يقدم صاحب العمل منه نسخة إلى الوزارة عند الطلب، ويكون بيد كل طرف نسخة منه، على أن ينتهي الملحق بانتهاء مدته أو فترة سريان القرار الوزاري أيهما أقرب. كما تلتزم المنشأة بتجديد هذا الملحق عند انتهائه باعتماد الطرفين.
- ٤ - خفض أجر العامل بشكل دائم، وهذا يعني تعديل العقد فيما يخص التزام صاحب العمل بدفع الأجر، وذلك بتخفيضه بشكل دائم. وفي هذا الفرض تلتزم المنشأة بالتقديم على خدمة " تعديل بيانات عقد عمل " للحصول على موافقة الوزارة وفق الإجراءات المعمول بها.

(١١٣) وفي الفقه الإسلامي أصول في جواز ترك المتفق عليه في التعاقد وفعل غيره، مما هو مخالفة في الأصل، ولكنه جائز في الاستثناء بسبب ضرورة الجائحة، ويتبغى هنا أن يكتفى بالقدر الذي يندفع به الضرر ويزول به الخطر، فالإجازة بأجر كامل أو مخفض أفضل من التسريح من العمل، وتخفيض الأجور أولى من تسريح العمال، والتخفيض بالأدنى أولى من التخفيض بما فوقه، والتخفيض مع التعجيل أولى من التخفيض مع التأجيل، فالأصل في هذه الصور إعمال هذه القاعدة "الضرورة تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". انظر: نورد الدين الخادمي، عقود العمل في جائحة كورونا ومعالجة آثارها، ندوة البركة الأربعة للاقتصاد الإسلامي (وضع الجوائح والقوة القاهرة)، راجع الموقع الإلكتروني، <https://www.albaraka.org/>.

كل هذه الإجراءات لم تصل إلى حد فسخ العقد، بل إما وقفه أو تعديله، وهذا يتفق مع ما تقضي به نظرية الظروف الطارئة في قانون المعاملات المدنية، كما يتفق أيضاً مع مبدأ نسبية النظام العام في قانون العمل والذي يمكن مخالفته مادام فيه مصلحة العمال، وهو وقف العمل مؤقتاً أو تعديله بدل حل أو إنهاء علاقة العمل بسبب فيروس كورونا القاتل^(١١٤). كما تتحقق المصلحة أيضاً للاحية البت في المشكلة على وجه السرعة، ودون نفقات كبيرة، وتجنب تعقيدات الإجراءات القضائية وطول مدتها وارتفاع النفقات بشأنها، خصوصاً أن القضاء في حالات الظرف الطارئ لا بد أن يسبق فصله في النزاع الإحالة إلى الخبرة، وما يعقب ذلك من تعقيدات وإجراءات التنفيذ.

لكن القرار في المادة الثالثة سمح للمنشآت التي لديها فائض من العمال المصرح لهم بالعمل لديها، ونعتقد أن المقصود هنا ما سيتجد لديها من فائض بسبب تقليص العمل نتيجة للجائحة والإجراءات المتخذة بشأنها، فسخ عقد عمل العمالة الفائضة، مع إلزامها بتسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي، الذي تقرر إنشاؤه بعد ظهور الأزمة، وذلك لإتاحتهم للتدوير بحسب احتياجات المنشآت الأخرى، بما يعني منعها من إلغاء إقامات العمل الحاصلين عليها وطلب مغادرتهم الدولة. ومراعاة للوضع الصحي الاستثنائي السائد، فإن تلك المنشآت إذا كان من حقها الاستغناء عن العمالة الفائضة، لكن يبقى التزامها قائماً تجاه العمال فيما يخص السكن والوفاء بكافة مستحقاتهم، عدا الأجر، وذلك حتى مغادرتهم الدولة أو التصريح لهم بالعمل لدى منشأة أخرى.

الخاتمة:

بعد أن وصلنا في هذا البحث إلى نهايته، نرى من المفيد الإشارة إلى الملاحظات الآتية:

- ١ - لا خلاف على أن جائحة كورونا/ كوفيد-١٩ قد فاجأت العالم بأسره، الذي لم يكن مستعداً لمثلها، في قوتها وسرعة انتشارها، وقد شمل تأثيرها جميع مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكانت لها انعكاساتها القانونية والقضائية، حيث تأثر بها عالم العقود والأعمال، فمنها ما أمكن تنفيذه عن بعد، ومنها ما استعصى على ذلك، فانخفض أو توقف الإنتاج والتوزيع، وعجز المديون عن الوفاء بالتزاماتهم أو أرهقهم ذلك.

(١١٤) أمينة رضوان، مرجع سابق، ص ٢١.

٢ - وإزاء هذا الوضع تعددت الإشكالات، وكثرت التساؤلات عن المخرج القانوني للتخلص من عقود استحالة تنفيذها، أو التخفيف من آثارها السلبية على المدينين. وكان من هذه الأسئلة هل أن فيروس كورونا و/أو الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمنع تفشيه، يمكن أن تكيف على أنها قوة القاهرة أو ظرف طارئ، يمكن معها تطبيق أحكام هذين النظامين على العقود المتأثرة بهما؟.

٣ - للإجابة عن هذا السؤال، نقول إن تكييف الفيروس والإجراءات المصاحبة له على إنها حالة من حالات القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، يتم وفقاً للشروط المطلوبة في كل منهما، وفقاً للظروف المحيطة بكل التزام تعاقدي على حدة، فلا يمكن اعتباره قوة القاهرة أو ظرفاً طارئاً بالنسبة لكافة العقود، وإنما يختلف الأمر باختلاف تأثير الفيروس على الالتزامات التعاقدية. ويكون على المدين واجب إثبات مدى تأثير الفيروس على إمكانية تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لا أن يتخذ من ذلك ذريعة للتملص من الالتزام والتهرب من تنفيذه، فإذا أثبت بأن هذه الجائحة والإجراءات المتبعة لمواجهتها قد جعلت تنفيذ العقد مستحيلاً، يتم حينها اعتبار الجائحة قوة القاهرة تفيد انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ. أما إذا لم يثبت المدين استحالة التنفيذ وإنما تبين بأن تنفيذ الالتزامات التعاقدية أصبح مرهقاً عليه ويتهدهد بخسارة فادحة، فيعد حينها الفيروس من الظروف الطارئة التي تبيح تعديل العقد وإعادة تحقيق التوازن الاقتصادي الذي اختل بسبب هذا الحادث الطارئ.

٤ - قد يتبين كذلك بأن هذه الجائحة لم تؤثر إطلاقاً على تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية، فحينها لن يجد المدين من القضاء تأييداً لتمسكه بانفساخ العقد أو طلب تعديله. ولا شك بأن المسألة ستتطلب اجتهاداً من المحاكم والقضاة لتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة، وذلك فيما يتعلق بتقدير مدى تأثير العقود والالتزامات المترتبة عليها بجائحة كورونا، وتحديد الحالات التي يكون فيها تنفيذ الالتزامات مستحيلاً أو مرهقاً.

٥ - وحتى يمكن تطبيق أحكام القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، لابد من ملاحظة تاريخ إبرام العقد، والتسلسل الزمني لظهور الفيروس وتاريخ إصدار التشريعات والقرارات المتضمنة للإجراءات الاحترازية المقيدة لحرية الحركة والتجمع بقصد منع انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره السلبية، فما أبرم قبلها من العقود جاز تطبيق أحكامهما عليه، وما أبرم بعدها لا يمكن فيه ذلك، لأن أطراف العقد يكونون عندئذ على علم بالفيروس وآثاره ومستحقات الإجراءات التي اتخذت في مواجهته.

- ٦ - ونجد من المهم هنا جداً تحفيز التوافق بين أطراف العقد على تسوية ما بشأن العقد الذي تصدع بسبب الجائحة، تجنباً للإجراءات القضائية الطويلة والنفقات الباهظة للتقاضي.
- ٧ - ويعد حلاً مناسباً أيضاً أن تلجأ الدول إلى عدم الاكتفاء بالقواعد العامة في القانون المدني المنظمة للقوة القاهرة والظرف الطارئ، بل تتبنى حلولاً أخرى استثنائية بتشريعات خاصة أو قرارات وزارية، تتدرج فيها الإجراءات التي يمكن أن تطبق على العقود، خصوصاً عقد العمل، الذي يؤثر في مصدر رزق الملايين من العمال، وذلك لمواءمة الحلول مع مقتضيات العقد، من الأخف إلى الأشد، ويكتفى بالقدر الذي يقل فيه الضرر ويزول به الخطر. ونشيد هنا بما تضمنه قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال مدة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفظاً لحقوق العمالة الوافدة، فوقف العقد أفضل من إعادة النظر فيه وتعديله، وتعديل العقد أفضل من فسخه، فالعقود إنما أبرمت لتنفيذ وتحقيق نتائجها لا لتفسخ ويعاد عاقدوها إلى الصفر.
- ٨ - كما قد يكون من المناسب أن تلجأ المشاريع والشركات والمؤسسات إلى منح عملائها خيارات تسمح باستدامة العلاقة بينهما، كما فعلت شركة طيران الإمارات، حيث خیرت زبائنھا بین استرداد مبلغ تذاكر السفر أو استبدالھا بأي خدمة من الخدمات التي تقدمھا، أو الاحتفاظ بالتذكرة سارية المفعول لمدة سنتين.

المراجع

أولاً - باللغة العربية:

- أحمد عبد العزيز الحداد، أثر جائحة كورونا على حجوزات الطيران والفنادق وخدمات النقل والشحن والتعليم الخاص، ندوة البركة الأربعة للاقتصاد الإسلامي (وضع الجوائح والقوة القاهرة)، الموقع الإلكتروني، <https://www.albaraka.org>.
- أحمد الصويغي شليبيك، نظرية الظروف الطارئة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مجلد ٣، عدد ٢، ٢٠٠٧.
- أمينة رضوان، مدى مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العلاقة التشغيلية، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، ع ١٧، أبريل ٢٠٢٠، عدد خاص بكورونا، كوفيد-١٩، ص ١٣، المجلة تصدر على موقع: www.justicemaroc.com.
- أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ١٩٨٧.
- خميس صالح ناصر المنصوري، نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٧.
- سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، نظرية العقد والإرادة المنفردة، المجلد الأول، الطبعة الرابعة، مطبعة السلام، جمهورية مصر العربية، ١٩٨٧.
- سمير آيت أرجدال، تدخل السلطات العمومية في ظل حالة الطوارئ المعلنة - مقارنة قانونية حقوقية. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، ع ١٧، أبريل ٢٠٢٠، عدد خاص بكورونا، كوفيد-١٩، ص ٢٨، المجلة تصدر على موقع: www.justicemaroc.com.
- عادل أبو هشيمة، هشام محمود، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دار الكتب القانونية، جمهورية مصر العربية، ٢٠١٤.
- عبد الحكم فودة، أثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ٢٠١٤.

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، المجلد الأول، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ٢٠١٥.
- عبد العزيز محمد حمد ساتي، التنظيم القانوني لنظرية الظروف الطارئة في العقود التجارية، مجلة العدل، وزارة العدل، المكتب الفني، العدد ٣١، ٢٠١٠.
- عبد اللطيف آل محمود، عقود العمل في ظل الجوائح ومعالجة آثارها، ندوة البركة الأربعون للاقتصاد الإسلامي (وضع الجوائح والقوة القاهرة)، الموقع الإلكتروني، <https://www.albaraka.org>.
- عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٩٧.
- عدنان إبراهيم سرحان، محمود إبراهيم فياض، محمد محمد سادات، المصادر الإرادية للالتزام، منشورات جامعة الشارقة، ط ١، ٢٠١٨.
- عصام التميمي، فيروس كورونا قد ينهي العلاقات التعاقدية، مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة التميمي ومشاركوه، <https://www.tamimi.com/>.
- فؤاد محمود معوض، دور القاضي في تعديل العقد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ٢٠٠٤.
- محمد السناري، الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ١٩٩٨.
- محمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، مطبعة زهران، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ١٩٨٧.
- محمد محيي الدين إبراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقہ الإسلامي، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ٢٠١٠.
- محمود علي مصلح السرطاوي، أحكام عقود إجارة المؤسسات المالية الإسلامية في فترة وباء كورونا، ندوة البركة الأربعون للاقتصاد الإسلامي (وضع الجوائح والقوة القاهرة)، الموقع الإلكتروني، <https://www.albaraka.org/>.
- مصطفى أحمد الزرقاء، شرح القانون المدني السوري، نظرية الالتزام، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، ١٩٦٠.
- نورد الدين الخادمي، عقود العمل في جائحة كورونا ومعالجة آثارها، ندوة البركة

الأربعون للاقتصاد الإسلامي (وضع الجوائح والقوة القاهرة)، الموقع الإلكتروني
https://www.albaraka.org/

- ياسر باسم، القوة القاهرة وأثرها في أحكام قانون المرافعات المدنية، مجلة
الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، كلية الحقوق، عدد ٣٦، مجلد ١٠، ٢٠٠٨
- هبة محمد محمود الديب، أثر الظروف الطارئة على العقود المدنية في القانون
المدني الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، ٢٠١٢.

ثانياً- باللغة الفرنسية:

- Barthlemy Mercadal Rforme du droit des contrats Editions Francis Lefebvre, 2016.
- Christophe Alleaume, La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Travail collectif, Sous la direction de Thibault Douville, avec Christophe Alleaume, Anne-sophie Choné - Grimaldi, Aude-solveig Epstein, Thierry Le Bars, Laurence Mauger- Vielpeau, Gilles Raoul- Cormeil, Odile Salvat, Mathieu Thiberge, 2édition Lextenso, 2020.
- D. Mazeaud, présentation de la réforme du droit des contrats, Gaz.Pal. 23 févr. 2016.
- E. Llop, Contentieux des agences de voyages: de la sécurité au futile, Tourisme et Droit 2008.
- Giboulot, Terré et Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T.2, 12 éd., 2015, Dalloz.
- Ludovic Landivaux, Contrats et coronavirus: un cas de force majeure? Ça dépend, Dalloz Actualité, Publié sur (https://www.dalloz-actualite.fr), le 20 mars 2020.
- Myriam Quémener et Clément Wierre, Les cyberattaques à l'ldu coronavirus, Dalloz Actualité, Publié sur (https://www.dalloz-actualite.fr), le 21 mars 2020.
- Pascale Guiomard, La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, Dalloz Actualité, Publié sur (< https://www.dalloz-actualite.fr >), le 4 mars 2020.

- Rapport au Président de la République, Relatif à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du regime général et de la preuve des obligations (extrait), réforme du droit des obligations, Un supplément Au Code Civil 2016, Dalloz. V. aussi. Jo. 11 février 2016, Texte n°25.
- Stefanie Porchy-Simon, Droit civil 2année, Les obligation, Dalloz, 11 édition, 2019, p.530.

Corona Virus / Covid 19, between Force Majeure and Exceptional circumstance (Study in UAE and French Laws)

**Prof .Adnan Ibrahim Sarhan
Eman Khamiss ALYahyae**

Corona Virus / Covid 19, and the precautionary measures that countries take to counter it, constitutes indisputably exceptional, general and unpredictable incidents. Accordingly, it is valid for all provisions of force majeure and Unexpected exceptional circumstances, depending on the extent of its impact on contractual obligations. If it results in the impossibility of fulfilling the obligation, whether permanently and completely, partially or temporarily, it is subject to the provisions of force majeure, which in the first imposition is the complete abrogation of the contract by the force of law, and in the second imposition its partial abrogation within the limits of the part that was impossible to implement, and in the third hypothesis a comment Temporarily executing the contract, with the creditor given the right to cancel the contract if the contract splitting or suspension resulted in damage to the creditor. But if the virus and its procedures result in the implementation of the obligation becoming exhausting of the debtor and threatening him with a heavy loss that exceeds the limits of the usual dealings, then the provisions of the exceptional circumstances shall apply to him, whereby a judge in the UAE law is allowed to intervene to amend the contract in order to restore his economic balance in accordance with the requirements of justice. As for the French civil law, after amending it by a 2016 decree, which for the first time enshrined provisions specific to unforeseen exceptional circumstances upon the conclusion of the contract, the parties to the contract are directed to renegotiate it with the debtor continuing to execute during the renegotiation, which is a good thing, and does not contradict the provisions UAE law that allows the contract to be modified or terminated at the will of both parties, and this solves many of the issues related to litigation and implementation that the effect of Corona virus on the contracts can cause. If the negotiations did not succeed or were rejected, the two parties would have a common agreement Between them to submit a request to the judge to reconsider and amend the contract, and if they were not able to reach a joint agreement, the judge had, at the request of one of the parties, intervene to amend the contract or even terminate it on the date and conditions it sets.

جائحة كورونا ومدى مسؤولية الصين الدولية عنها: قراءة قانونية من منظور القانون الدولي

أ. د. مخلص إرخصيص سالم الطراونة
كلية الحقوق - جامعة مؤتة
المملكة الأردنية الهاشمية

ملخص:

يتناول هذا البحث موضوع جائحة كورونا من منظور القانون الدولي، والإشكاليات القانونية المرتبطة بهذا الفيروس، حيث طرحنا وبكل موضوعية جملة من التساؤلات المثارة حول هذه الجائحة التي زلزلت أركان المجتمع الدولي، لاسيما تلك المتعلقة بدور منظمة الصحة العالمية، ومدى فاعلية نظامها القانوني، والإكليات المحددة في لوائحها في مواجهة الأمراض والأوبئة. كما ناقش البحث حدود مسؤولية الصين عن تفشي هذا الوباء من زاوية القانون الدولي، والخيارات أو السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لتقرير هذه المسؤولية، والتحديات والعقبات القائمة بهذا الخصوص.

لقد أدى انتشار، ما بات يعرف بفيروس كورونا المستجد/كوفيد-١٩، في أنحاء العالم إلى ضربة قوية ومؤثرة للغاية. فقد كان لحدة انتشار هذا الوباء الذي ظهرت بدايته الأولى في الصين، في أواخر شهر ديسمبر من العام المنصرم، واشتدت ذروته في شهر فبراير ومارس من العام الحالي، ثم استمرت بعد ذلك، تداعيات وآثار مزلزلة وهائلة من جميع النواحي الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية لجميع الأفراد والدول. كما أن حجم تفشي الوباء، وسرعة انتقال العدوى التي طالت تقريباً حوالي ٢١٥ دولة وإقليم حول العالم، دفعت بمنظمة الصحة العالمية أن تُعلن فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية؛ نظراً لما نتج عنه من إصابات ووفيات. فقد خلف هذا الوباء، وما زال - وفقاً للإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وبعض الجهات الأخرى مثل جامعة جونز هوبكنز - أكثر من ٣٠ مليون مصاب، وقرابة ٩٠٠ ألف وفاة حول العالم، والأرقام مرشحة للزيادة في كل لحظة، فقد انتشر هذا الوباء في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا ودول أمريكا اللاتينية والهند، حيث سجلت هذه الدول أرقاماً قياسية في عدد الإصابات والوفيات، لم تشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وباتت هذه الدول، بعد سيطرة الصين على الوباء بعد مدة شهرين تقريباً، هي بؤرة تفشي هذا الوباء الكبير. كما انتقلت عدوى هذا الفيروس إلى الولايات المتحدة، رغم كل الإمكانيات الهائلة التي تملكها، وانتشر فيها بصورة سريعة وغير متوقعة، ليرفع عدد المصابين فيها لأكثر من ستة ملايين إصابة، وقرابة ٢٠٠ ألف وفاة. هذا الوضع جعل الولايات المتحدة الأمريكية تمر في أزمة

هي الأخرى الأصعب والأقسى منذ الحرب العالمية الثانية وأحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١. ورغم كل ما تبذله الدول من جهود لمواجهة الوباء، غير أنه من الصعب التنبؤ بمآلات الأمور في القريب العاجل، لا سيما أن الدراسات والتقارير الصادرة عن المنظمة تؤكد أن مسألة المعركة مع هذا الوباء للقضاء عليه ستطول نوعاً ما، وإنه ربما يتعين على الدول والشعوب التعايش معه لفترة طويلة قبل أن يتم القضاء عليه.

تناول هذا البحث في ثلاثة مباحث على التوالي العديد من المسائل المرتبطة بهذا الفيروس، ابتداءً من التعريف بفيروس كورونا كوفيد-١٩، وتوضيح أهم خصائصه وأعراضه، وبدايات انتشاره، وأبرز تداعياته، ثم ثانياً، درسنا دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا، وبيّنا الكيفية التي تعاملت بها مع هذه الجائحة، وأبرز الصعاب والتحديات التي واجهتها بهذا الخصوص، وانتقاد بعض الدول لها، خاصة الولايات المتحدة، لطريقة تعاملها مع هذه الجائحة، كما ناقشنا ثالثاً، مدى مسؤولية الصين الدولية من الناحية القانونية إزاء الادعاءات بتحميلها المسؤولية عن تفشي هذا الفيروس، حيث قمنا بمناقشة بعض الخيارات المتاحة والعقبات والتحديات التي تقف حجر عثرة في طريق تطبيقها من الناحية العملية.

الكلمات الدالة: فيروس كورونا المستجد، الجائحة، المسؤولية الدولية، منظمة الصحة العالمية، اللوائح الصحية الدولية، دستور منظمة الصحة العالمية، محكمة العدل الدولية.

مقدمة:

شكل انتشار فيروس كورونا المستجد، أو ما يعرف بكوفيد-١٩ ضربة قوية وموجعة للعالم كله، فحتى نهاية العالم المنصرم، لم يكن أحد يتوقع في الكون بأسره، أن تعصف بالعالم هذه العاصفة القوية، التي زلزلت أركان الدول، ودمرت اقتصادها ومواردها، وكان لها تبعات وتداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية على الدول والشعوب. لقد كانت بداية القصة المريرة مع هذا الفيروس في الصين، وتحديداً في مدينة ووهان/مقاطعة خوبي في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي (٢٠١٩)، حيث بدأت بعض المعلومات والتسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتشر عن وجود فيروس شبيه بفيروس سارس، الذي انتشر بدايةً في الصين، وفي العالم في عام ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وقد نشر أحد الأطباء الصينيين بعض التحذيرات من خطورة هذا الوباء، ودعا الجميع لاتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة؛ لمنع انتشاره. وقد قللت السلطات الصينية آنذاك من شأن هذه المعلومات، وقامت بإلقاء القبض على بعض الأشخاص الذي كانوا يتحدثون عن هذا الفيروس، بمن فيهم الطبيب الصيني لي وينليانغ، بحجة أنهم يقدمون معلومات غير صحيحة ودقيقة، وإن من شأن هذه المعلومات الإضرار بالأمن القومي الصيني، وباقتصاد الدولة الذي يُعد الاقتصاد الأقوى بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في أواخر شهر يناير، بدأت الأمور تزداد سوءاً وتعقيداً مع انتشار المرض بشكل واسع في

مدينة ووهان الصينية، ثم ما لبث أن انتشر هذا الوباء بسرعة غير متوقعة انتشار النار بالهشيم ليصل إلى بعض الدول، فانتقل إلى القارة الأوروبية ليدب فيها الرعب والموت، فانتشر في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والهند وأمريكا اللاتينية، حيث سجلت هذه الدول أرقاماً قياسية في عدد الإصابات والوفيات لم تشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وباتت هذه الدول، بعد سيطرة الصين على الوباء بعد مدة شهرين تقريباً، هي بؤرة تفشي هذا الوباء الكبير. كما انتقل هذا الفيروس إلى الولايات المتحدة، رغم كل الإمكانيات الهائلة التي تملكها، وانتشر فيها كذلك، وبصورة غير متوقعة، ليرفع عدد المصابين فيها لأكثر من ستة ملايين ونصف، ويحصّد أرواح أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن أمريكي. هذا الوضع جعل الولايات المتحدة الأمريكية تمر في أزمة هي الأخرى الأصعب والأقسى منذ الحرب العالمية الثانية وأحداث ١١ سبتمبر. فقد دمر هذا الفيروس الاقتصاد الأمريكي وضربه في مقتل؛ بحيث جعل ولايات أمريكية بأكملها تعيش حالة إغلاق كامل، وبدت بعضها كمدن أشباح، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية التي قدّرت بمليارات الدولارات، وخسارة ملايين المواطنين الأمريكيين لوظائفهم. هذا الوضع، دفع الرئيس الأمريكي والكونجرس لإقرار أكبر حزمة مساعدات في تاريخها بلغت قرابة ٢ ترليون دولار. كما امتد انتشار هذا الوباء الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية - باعتبارها المنظمة الدولية المسؤولة عن المحافظة على الصحة العامة ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض - بتاريخ ١١ مارس/ ٢٠٢٠ فيروس كورونا المستجد/ كوفيد-١٩ كوباء عالمي أو جائحة عالمية إلى بقية دول العالم، فانتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، وقارة أفريقيا وأستراليا، وأمريكا الجنوبية وغيرها. كما انتشر هذا الوباء بصورة سريعة أيضاً في منطقتنا العربية، حيث سجلت بعض الدول العربية العديد من الإصابات والوفيات، وحالات شفاء بصورة متفاوتة. ففي الأردن بلغ عدد المصابين أكثر من ٤٠٠٠ مصاب، في حين وصل العدد لأكثر من ١٢٠ ألفاً في قطر، وأكثر من ٣٠٠ ألف أيضاً في السعودية، وقرابة ٩٥ ألفاً بالكويت. أما الرقم الإجمالي لعدد المصابين على مستوى العالم فوصل لأكثر من ٣٠ مليون، وعدد الوفيات أكثر من ٩٠٠ ألف^(١).

(١) لمزيد من التفصيل حول هذه الأرقام التي تتغير كل لحظة انظر: موقع منظمة الصحة العالمية

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKC>

Ajw7-P1BRA2EiwAXoPWA5in7SHF863mN6Sz1-MoCD4Rybn20aFyy1zCMte

IrKA9p8vv2vrCCR0C8yEQAvD_BwE

أمام هذه الأرقام الكبيرة والخطيرة وغير المسبوقة في هذا الخصوص، دعت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات الوقائية كافة، والإجراءات اللازمة والضرورية الأخرى لمنع انتشار الوباء، وتفاقم الأوضاع بصورة أكبر. كما دعت إلى اتباع سياسة التباعد الاجتماعي، وأن تعمل الدول وتتعاون فيما بينها، ومع المنظمة العالمية، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الجائحة، والحد من أثارها وتداعياتها على العالم والإنسانية جمعاء. كما دعت هذه المنظمة، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة إلى وضع الخلافات والانقسامات جانباً في المرحلة الراهنة، والعمل بصورة مشتركة، وبروح الفريق الواحد لمواجهة هذا الوباء الذي بات يهدد البشرية بالفناء، ودعم الجهود المشتركة أيضاً التي تقوم بها المنظمة، ومساندتها في الأبحاث التي تقوم بها للوصول إلى اللقاحات المناسبة لهذا الفيروس بأسرع وقت ممكن.

بعد هذا العرض البسيط، نشير إلى أنه قد تباينت الآراء، وتعددت الاتجاهات في تحديد طبيعة هذا الفيروس، ومن أين خرج؟ وكيف ظهر؟ وهل هو مُخلَق في مختبرات علمية أو غير مُخلَق؟ وهل هو سلاح بيولوجي أنتجته الصين كما يدعي البعض أو دولة أخرى؟ وهل الادعاءات الأمريكية حول مصدر الفيروس ومنشئه إزاء الصين بهذا الخصوص صحيحة أم لا؟ وهل صحيح أن السلطات الصينية قد ضللت منظمة الصحة العالمية، والرأي العام الدولي بخصوص هذا الوباء أم لا؟ وهل الأرقام التي أعلنتها، وتعلن عنها باستمرار صحيحة، أم ليست هي الأرقام الفعلية؟ وهل صحيح أن سياسة التشدد، والقبضة الحديدية، والتعتيم الإعلامي التي طبقتها الحكومة الصينية داخلياً لمواجهة هذا الوباء هي سياسة انتهجتها لإخفاء الحقيقة حول هذا الوباء؟ والسؤال الأبرز يتمثل في مدى إمكانية مساءلة الصين من الناحية القانونية، وفقاً لقواعد المسؤولية عن هذا الوباء؟ وماذا لو ثبت فعلاً تورط الصين في نشر هذا الوباء، أو تسترهما أو تقصيرها في عدم إخبار أو إخطار منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى عن هذا الفيروس؟ كيف يمكن تأسيس المسؤولية الدولية تجاه الصين بهذا الخصوص؟ وما التحديات أو العقبات التي تحول دون ذلك؟ وماذا عن مسألة إجراء تحقيق مستقل في انتشار هذا الفيروس وتقصير السلطات الصينية في واجب الإبلاغ أو الإخطار، هل هو ممكن أو متاح؟ وما مدى عملية وواقعية هذا الإجراء؟ وفي حال عدم تحقق ذلك، ما البدائل الأخرى المتاحة. كما أن من الأمور التي أثارها ظهور هذا الفيروس وانتشاره، هو موضوع مدى نجاح منظمة الصحة العالمية، وفعاليتها في التعامل مع هذا الوباء الخطير، فرغم نجاحات هذه المنظمة في كثير من المناسبات إلا

أن البعض أخذ عليها عدم قدرتها، لا بل فشلها الذريع في التعاطي مع هذه الأزمة العالمية، فقد تأخرت مثلاً في نشر المعلومات اللازمة حول هذا الموضوع، ولم يُعلن مديرها، ولجنة الطوارئ فيها هذا الفيروس كجائحة عالمية إلا في وقت متأخر نسبياً، وتحديدًا في ١١ مارس ٢٠٢٠ رغم أن بدايات انتشار المرض كانت قبل ذلك بثلاثة أشهر تقريباً، وبعد أن بلغ عدد المصابين ما يزيد عن أربعة ملايين، والوفيات أكثر من ٢٧٠ ألفاً. هذا الأمر دفع البعض - كما سيبين هذا البحث - إلى التشكيك في مصداقية هذه المنظمة، وطريقة تعاملها مع الوباء، لا بل أن بعض الدول كالولايات المتحدة اتهم علانية المنظمة الدولية بالتواطؤ مع السلطات الصينية بخصوص التستر على هذا الوباء، وهو ما تنفيه المنظمة بطبيعة الحال جملةً وتفصيلاً.

إن هذه التساؤلات، وغيرها الكثير يدعونا لدراسة هذا الموضوع المهم في الوقت الراهن، وسنحاول في حدود الصفحات المتاحة الإجابة عن بعض من هذه التساؤلات، وبيان الموقف القانوني من موضوع مساءلة الصين عن هذا الوباء من منظور القانون الدولي. وهذا الأمر على وجه التحديد ذو أهمية بالغة؛ نظراً لما سيطرَب عليه من تداعيات سياسية وقانونية؛ بسبب المكانة المهمة التي تحظى بها الصين كدولة عظمى ومهمة على مستوى العالم كله، فالصين دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرين، وليس من السهولة بمكان - كما هو معلوم - محاسبتها وملاحقتها قانونياً وسياسياً. فقد يكون هذا الأمر، سواء بالنسبة لها، ولكل من الولايات المتحدة وروسيا باعتبارها من الدول العظمى أمراً أقرب للخيال في ظل الواقع الدولي الذي رسمت معالمه الدول العظمى الخمس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكن رغم مرارة هذا الواقع، إلا أن هذه الدراسة ستحاول - كما قلت - التصدي بصورة موضوعية لهذه التساؤلات في محاولة متواضعة منا للإدلاء ببعض الآراء في هذا الجانب، لا سيما أن الأصوات قد بدأت تتعالى فعلاً في الوقت الحاضر مطالبة بضرورة الكشف عن حقيقة ما جرى، وإجراء تحقيق دولي عادل وشفاف بخصوص هذه الجائحة ومآلاتها، ودور الصين فيها. كما أن المشهد بشكل عام ازداد تعقيداً - في حقيقة الأمر - بعد أن بدأت بعض الجهات والأفراد، خاصة في الولايات المتحدة التي تعد من أكبر الخاسرين في هذه الأزمة بالحديث صراحةً عن التوجه الفعلي لتسجيل دعاوى ضد الحكومة الصينية؛ بسبب تسترها على الفيروس، وسماعها لآلاف الأشخاص من المقيمين على أراضيها، وبعضهم كان حاملاً للمرض بالسفر لدول أخرى دون فحصهم، أو اتخاذ أية احتياطات وقائية، وهو ما تسبب في

زيادة تفشي الوباء وانتشاره بالصورة الحالية، والتي جعلت كوكب الأرض كله من أقصاه لأقصاه متأثراً بهذا المرض وتداعياته المختلفة.

من هنا، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإننا سنقوم بدراسته في ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الأول، لمحة موجزة عن فيروس كورونا المستجد/ كوفيد-١٩ وبدايات انتشاره. وندرس في المبحث الثاني، دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا (النجاح والصعاب والتحديات)، أما المبحث الثالث فيعالج مدى مسؤولية الصين الدولية من الناحية القانونية إزاء الادعاءات بتحميلها المسؤولية عن هذا الفيروس.

المبحث الأول

التعريف بفيروس كورونا كوفيد - ١٩ وبدايات انتشاره وأبرز تداعياته

نتناول دراسة هذا الموضوع في مطلبين، نقدم في المطلب الأول لمحة عامة عن فيروس كورونا المستجد/كوفيد-١٩، وأبرز خصائصه وأعراضه، وندرس في المطلب الثاني، كيفية انتشار الوباء وتفشيته، وبداية الأزمة العالمية حوله، ليأخذ الجميع الدروس والعبر من هذه الجائحة العالمية، التي لم يشهد ربما التاريخ الحديث مثيلاً لها، من ناحية الانتشار، والتفشي، وعدد الإصابات، والوفيات. ولعل الغاية من تناول هذين الموضوعين، هي الوقوف على خطورة هذا الوباء، ومعرفة طبيعته، وسماته، وكيفية انتشاره بهذه الصورة غير المعهودة. سنتناول دراسة هذا الموضوع في مطلبين، نقدم في المطلب الأول لمحة عن فيروس كورونا المستجد/ كوفيد - ١٩، وأبرز خصائصه وأعراضه، ونتناول في المطلب الثاني انتشار وباء أو جائحة كورونا، وبداية الأزمة العالمية.

المطلب الأول

لمحة عن فيروس كورونا المستجد / كوفيد - ١٩ وأبرز خصائصه وأعراضه

تُعتبر فيروسات كورونا وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فصيلة كبيرة ومتنوعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان على حد سواء. ومن المعروف، أن عدداً من هذه الفيروسات قد تسبب لدى كثير من البشر خلال السنوات الماضية في حالات عدوى تصيب في العادة الجهاز التنفسي، والتي قد تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد خطورة وفتكاً مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس)^(٢). وقد تم اكتشاف هذا الفيروس الجديد، الذي يسمى بفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا ٢ (سارس كوف ٢)، كمسبب لتفشي أحد الأمراض التي بدأت بالظهور مؤخراً في مدينة ووهان في الصين أواخر سنة ٢٠١٩. وقد سُمي المرض الناتج عنه، بمرض فيروس

(٢) <https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727> , see also <https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/ar/>.

كورونا المستجد / (كوفيد -١٩). ومصطلح كورونا المستجد / أو كوفيد -١٩- هو اختصار للمصطلح باللغة الإنجليزية (COVID-19) Coronavirus Disease 2019 (٣).

ويُعد هذا المرض - الذي ذاع صيته هذه الأيام، وشكل خطراً قاتلاً للعديد من الشعوب في مختلف أصقاع المعمورة - مرضاً معدياً؛ يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً. وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كورونا أو كوفيد-١٩ حسب منظمة الصحة العالمية في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال^(٤). وقد تكون هذا الأعراض في البداية خفيفة ثم تبدأ تدريجياً لتكون أكثر شدة. ويصاب بعض الأشخاص بالعدوى، دون أن تظهر عليهم أحياناً أي أعراض، ودون أن يشعروا بالمرض^(٥). وتشير الدراسات والإحصاءات إلى أن حوالي ٨٠٪ من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس يتعافون منه ودون الحاجة لأية علاجات. في حين تؤكد هذه الدراسات أن حدة المرض تزداد، وتشتد لدى شخص واحد تقريباً من بين كل ٦ أشخاص يصابون بهذا الفيروس، حيث يعانون من صعوبة شديدة في التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو داء السكري، بأمراض وخيمة، وهذا ما شهدته بالفعل كثير من الدول التي تعرضت فيها مثل هذه الفئات كالدول الأوروبية والولايات المتحدة للوفاة؛ بسبب ضعف المناعة الطبيعية لها، وأحياناً نتيجة للإهمال والتقصير الطبي الذي ظهر خلال تفشي هذا الوباء، وعدم قدرة بعض الدول على توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للمصابين؛ وبخاصة أجهزة التنفس. كما وتشير بعض الدراسات إلى أن ما بين ٢ إلى ٤٪ من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس قد تُوفوا، في حين - وكما ذكرت - يتعافى ما يقرب من ٨٠٪ من الأشخاص المصابين بهذا المرض منه، دون الحاجة لأخذ أية علاجات خاصة، وإن ما يقرب من ١٦-١٨٪ من الأشخاص المصابين، قد يكونون عرضة لأعراض أشد مثل صعوبة التنفس، تستدعي

(٣) COVID-19 "an infectious disease caused by a coronavirus (= a type of virus), that usually causes fever, tiredness, and a cough, and can also cause breathing problems. Most often the disease is not serious but it can lead to severe illness in some people." See <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/covid-19>.

(٤) <https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727>.

(٥) <https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>.

حصولهم على الرعاية الطبية، أو الصحية اللازمة، ومنهم من قد يتم إدخاله للعناية الحثيثة عندما تسوء حالتهم كثيراً^(٦).

أما عن كيفية انتشار المرض وانتقاله، فيمكن القول وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أنه يمكن أن يصاب الأشخاص بهذا الفيروس عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، حيث من المحتمل أن تنتقل العدوى بهذا الفيروس من شخص إلى شخص عن طريق القطرات الصغيرة، أو الرذاذ الذي يتناثر من الأنف، أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بهذا المرض، أو يعطس^(٧). وعندما تتساقط هذه القطرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. يمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بهذا المرض عند ملامستهم لهذه الأشياء، أو الأسطح ثم لمس أعينهم، أو أنوفهم، أو أفواههم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كورونا المستجد/كوفيد-١٩ إذا تنفسوا القطرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. من هنا، ترى المنظمة أن من الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض، بمسافة لا تقل على متر واحد تجنباً للإصابة بالعدوى^(٨).

ولم تثبت التقارير والدراسات لغاية الآن مدى إمكانية انتشار هذا المرض عبر الهواء. وبلا شك، تعمل الآن العديد من الدول من خلال مراكز البحوث وشركات الأدوية فيها، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة على البحث عن علاجات ومطاعيم لمكافحة هذا الفيروس المستجد الذي جاء - كما ذكرنا سابقاً - كالصاعقة على البشرية، حيث لم يترك هذا الفيروس بلداً أو إقليماً في العالم إلا وحط فيه مسبباً إصابات ووفيات كبيرة^(٩). ونشير - وكما بينا - في المقدمة أن هذا المرض أو الفيروس المستجد لم يكن معروفاً أو معلوماً قبل منتصف شهر ديسمبر عام ٢٠١٩، فعلى الرغم من أن عائلة فيروسات الكورونا هي - كما ذكرنا - أنواع متعددة ومختلفة، وبعضها ظهر فيما مضى، وتحت مسميات مختلفة مثل السارس وأيبولا

Ibid. (٦)

<https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727>. (٧)

<https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses> (٨)

يبلغ عدد الدول والأقاليم التي انتشر فيها هذا الوباء ٢١٥ دولة وإقليماً على مستوى العالم انظر بهذا الخصوص: موقع منظمة الصحة العالمية https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWA5in7SHF863mN6Sz1-MoCD4Rybn20aFyyIzCMteIrKA9p8vv2vrCCR0c8yEQAvD_BwE (٩)

وغيرها، إلا أن هذا النوع الجديد لم يكن معروفاً، ولم يتوقع أحد أن تصل حدة انتشاره وتفشيه بهذه الصورة الحالية، والتي طالت كل دول العالم وأقاليمه مخلفاً وراءه ملايين الإصابات، وعشرات الآلاف من الوفيات. ونشير إلى أنه - ورغم حالة الشفاء الكبيرة بين الأشخاص المصابين والتي تجاوزت ٨٠٪ تقريباً - الأعداد المتأثرة بهذا الفيروس، سواء بالنسبة للأشخاص المصابين، أو المتوفين في حالة تزايد مستمر في كل لحظة^(١٠).

ونشير ختاماً، إلى أن عدداً كبيراً من المجموعات المختصة بالمحافظة على الصحة العامة، مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بعض الدول مثل الولايات المتحدة (CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، تقوم بجهود كبيرة ومضنية في مراقبة هذه الجائحة الخطيرة، ونشر المعلومات والتحديثات المتعلقة بها كافة على مواقعها على شبكة الإنترنت، كما أصدرت هذه المجموعات عديداً من التوصيات والتوجيهات حول الوقاية من المرض وعلاجه، كما تقوم وسائل الإعلام المختلفة المرئي والمسموع والمقروء بدور كبير وفاعل في هذه الظروف للتحذير من هذا الوباء، وتوعية الناس بمخاطره وأضراره وتداعياته السلبية المختلفة.

المطلب الثاني

انتشار وباء أو جائحة كورونا، وبداية الأزمة العالمية

تشير بعض التقارير إلى أن بداية ظهور أول حالة لفيروس كورونا كانت تقريباً في عام ١٩٣٧، حيث كانت تلك الإصابات قد بدأت بالظهور أولاً في الطيور، الأمر الذي أدى إلى نفوق المئات منها، ثم بدأت تظهر الأعراض لاحقاً على أنواع أخرى من الحيوانات مثل المواشي والأبقار، أما فيما يتعلق بأول حالة من حالات الإصابة البشرية، فقد سُجلت أول إصابة في عام ٢٠١٢م على يد طبيب مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، ثم وصل عدد الحالات التي تم تسجيلها حتى نهاية عام ٢٠١٥ إلى ١٢٥٠ حالة، تماثلت ٦٨٥ حالة منها للشفاء، وتوفي قرابة ٥٣٥ حالة منها^(١١). أما الشكل الجديد من هذا الفيروس والمعروف بكوفيد-١٩، فقد ظهر - كما

(١٠) For more details, see <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

(١١) https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.

قلنا - في البدايات في مدينة ووهان/مقاطعة خوبي في منتصف شهر ديسمبر عام ٢٠١٩. وتشير التقارير إلى أن البدايات كانت من خلال أحد أسواق بيع الحيوانات في هذه المدينة، حيث تُباع هناك جميع أنواع الحيوانات الحية والنافقة في ظروف صحية سيئة ومزرية للغاية، ناهيك عن العادات الغذائية الغربية والسيئة التي تنتشر بشكل واسع في العديد من المقاطعات والمدن الصينية، والتي كانت للأسف وعلى مر العقود الماضية سبباً في تفشي بعض الأمراض والأوبئة التي لم تكن معروفة سابقاً.

لقد بدأت العدوى من هناك، فقد تم نقل عدد من الأشخاص المصابين إلى المستشفيات، حيث كانوا يعانون من بعض الأعراض مثل السعال واحتقان الحلق والإعياء وضيق التنفس، ولكن السلطات الصينية أجبرت الأطباء الذين كانوا يعالجون مرضى الفيروس على الصمت، وعدم الحديث علناً عن هذا المرض خشية إحداث بلبلة وقلق للرأي العام؛ وبالتالي التأثير على الاقتصاد والأوضاع في البلاد^(١٢). وقد كان بإمكان الصين أن تقلل حصة الإصابات والوفيات الناجمة عن هذه الكارثة (فيروس كورونا المستجد / أو كوفيد-١٩)، لو تصرفت هذه السلطات بسرعة، وأخطرت منظمة الصحة العالمية بالوقت المناسب، حسب ما تقررته اللوائح الصحية الدولية بهذا الخصوص، وأيضاً لو لم تجبر الأطباء على الصمت، وعدم الحديث عن هذا الموضوع. وربما هذا الاعتقاد بوجود تقصير أو تقاعس من جانب السلطات الصينية، هو ليس أمراً يروج له الآخرون، بل أن هناك عدداً كبيراً من أفراد الشعب الصيني نفسه الذين تضرروا من هذه الجائحة يلومون سلطات بلادهم حيال ذلك.

ولعل الجميع لا ينسى قصة الطبيب الصيني الشهير لي وينليانغ البالغ من العمر ٣٤ عاماً، الذي كان أول من تحدث عن هذا المرض في البداية، وبدأ يحذر منه ومن خطورة انتشاره ومضاره في مدينة ووهان الصينية مسقط رأس فيروس كورونا المستجد قبل أشهر، فقد حذر لي وينليانغ - الذي كان يعمل في مركز تفشي الفيروس في مدينة ووهان - في نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول زملاءه العاملين في المجال الطبي بضرورة الحذر من هذا الفيروس وأخذ الاحتياطات اللازمة تجاهه، بعد أن لاحظ في شهر ديسمبر إصابة ٧ حالات، ظنّها للوهلة الأولى مصابة بفيروس "سارس"، الذي تفشى كوباء عالمي عام ٢٠٠٣. ويُعتَقَد أن الحالات السبع كانت

(١٢) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwK-CAjwte71BRBCeIwAU_V9h8Apiw9e4klqQxjUjimeis1F7vWln_CQ-pib4XMrSMsJHFafF0NycAxoCUHgQAvD_BwE

قادمة من سوق ووهان للمأكولات البحرية، وكان المصابون قيد الحجر الصحي في المستشفى التي كان يعمل بها الطبيب لي وينليانغ. وفي الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، بعث وينليانغ رسالة إلى زملائه خلال دررشة جماعية على إحدى وسائل التواصل الصينية، محذراً إياهم من تفشي الفيروس، وناصحاً لهم بارتداء ألبسة واقية لتفادي العدوى^(١٣).

غير أن السلطات في الصين لم تعر لكلام هذا الطبيب أي انتباه وبالأ، لا بل أنها، وبدلاً عن البحث في هذا الموضوع والتقصي حول هذا الفيروس، زاره بعد أربعة أيام تقريباً من إطلاق تحذيراته، بعض الأشخاص المسؤولين من مكتب الأمن العام، حيث قاموا بتوبيخه واعتقاله، وفتح تحقيق معه بتهمة "نشر معلومات كاذبة ومضللة". ومن ثم، طالبوه بالتوقيع على مذكرة حكومية أدانتها فيها بنشر معلومات كاذبة، وبالقيام بتصرفات غير قانونية، وبالإدلاء بتعليقات غير صحيحة"، ترتب عليها وفقاً لهذه السلطات "إخلال جسيم بالنظام العام"^(١٤). كما قامت السلطات المحلية بمدينة ووهان على إثر ذلك باعتقال الطبيب لي وينليانغ لعدة أيام في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي^(١٥). لاحقاً نشر الطبيب وينليانغ على موقع "ويبو" قصته مع الفيروس الغامض، ومعاناته من السعال في العاشر من يناير، قبل أن يصاب بالحمى، ويُنقل إلى المستشفى، حيث شُخص بالإصابة بفيروس كورونا في الثلاثين من يناير/كانون الثاني. وفي ٦ فبراير/شباط الفائت، توفي الطبيب لي وين ليانغ جراء إصابته بهذا الفيروس، الذي انتقل إليه بينما كان يعالج المرضى في المستشفى المركزي بمدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها الوباء أول مرة - كما قلنا - في منتصف ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩^(١٦).

وفي الأيام القليلة الأولى من يناير/كانون الثاني، كان المسؤولون في مدينة ووهان يصرون على أن عدوى كورونا؛ لكي تنتقل فإنه لا بد من الاتصال بحيوانات

(١٣) <https://www.bbc.com/arabic/world-51372766>

(١٤) وجاء في الرسالة: "نحذرك بشكل رسمي: وإذا تماديت في عنادك، بهذا القدر من الوقاحة، وتابعت هذا المسلك غير القانوني، فسوف تمثل أمام العدالة - هل هذا مفهوم؟" وفي ذيل الرسالة، وقّع وينليانغ بخط يده: "نعم، مفهوم". وكان وينليانغ أحد ثمانية أشخاص خضعوا للتحقيق من قبل الشرطة بتهمة "نشر شائعات" <https://www.bbc.com/arabic/world-51372766>

(١٥) <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2020/03/21>

(١٦) <https://www.bbc.com/arabic/world-51372766>

مصابة بالفيروس، ولم تكن قد صدرت في ذلك الوقت توجيهات باتخاذ تدابير وقائية للأطباء، ولكن وبعد انتشار الوباء، وزيادة عدد الإصابات بالصين، وثبت ما كان يتحدث عنه الطبيب وينليانغ أعلنت السلطات الصينية في العشرين من يناير/ كانون الثاني - حالة الطوارئ بعد التفشي السريع لفيروس كورونا في مدينة ووهان^(١٧). كما قدمت السلطات الصينية اعتذاراً رسمياً لعائلة الطبيب الراحل، وسحب بيان التوبيخ والاعتقال ضده. كما تم توقيع عقوبات تأديبية على ضابطي الشرطة اللذين كانا يشرفان على عملية التحقيق معه، كما أكد المجلس أن الشرطة أساءت في حقيقة الأمر التعامل مع القضية، وأنها لم تقم باتباع الإجراءات السليمة بهذا الخصوص، وأنها خالفت القانون بشكل عام باستدعائها للطبيب الشاب لي وينليانغ، واتهامه بنشر معلومات كاذبة عن الفيروس على النحو المشار إليه سابقاً. وفي سبيل تحقيق نوع من العدالة نحو قضية هذا الطبيب - الذي وصف من قبل الإعلام بأنه بطل قومي أنقذ أمة - والإقرار بالمسؤولية عن التصرفات الخاطئة تجاهه - قررت هيئة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بمدينة ووهان، منح عائلة الطبيب الذي وُصف بأنه "مكتشف كورونا /كوفيد- ١٩" تعويضاً مالياً قدره ٨٢٠ ألف يوان صيني (ما يعادل ١١٧ ألف دولار أمريكي)^(١٨).

Ibid.

(١٧)

(١٨) الصين تعتذر لعائلته.. مكتشف كورونا يرقد بسلام، تاريخ النشر: السبت ٢٦ رجب ١٤٤١هـ

- ٢١ مارس ٢٠٢٠ - KSA 14:24

<https://ara.tv/5b55b>

المبحث الثاني دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا (النجاح والصعاب والتحديات)

لقد لعبت منظمة الصحة العالمية، منذ نشأتها في منتصف القرن الفائت، دوراً مهماً وأساسياً في الاهتمام بموضوع الصحة والمحافظة عليها، ومكافحة انتشار الأمراض والأوبئة على مر العقود والسنوات الماضية. وقد ظهر الدور البارز والمهم لهذه المنظمة بعد أن اجتاحت العالم في أكثر من مرة بعض الأوبئة والأمراض، كمرض سارس وأنفلونزا الطيور والخنازير والإيبولا، وغير ذلك من هذه الفيروسات، والأمراض. إن خطورة تلك الفيروسات وشدها والإصابات والوفيات التي أوقعتها، لم تكن ربما في نظر الكثيرين بفداحة الكارثة التي ألمت بالمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، والتي تمثلت بانتشار جائحة كورونا أواخر العام المنصرم، واشتدت جذوتها في الشهور الثلاثة الماضية، وما زالت تشتد حتى بات هذا الأمر بمثابة كابوس يؤرق العالم بأسره، فعدد الإصابات والوفيات مازال في وتيرة متزايدة ومطرودة، والدول ومنظمة الصحة العالمية مازالت تحذر منه ومن تداعياته مستقبلاً ومن أخطاره على الإنسانية جمعاء. ورغم كل حالات الشفاء، والجهود الكبيرة من منظمة الصحة في محاربة هذا الوباء، وإعلان المنظمة له باعتباره جائحة عالمية تقتضي التعاون والتنسيق بين الدول لاتخاذ التدابير والاحتياطات الوقائية، والالتزام بسياسة الحجر الصحي والتباعد الاجتماع، مازال البعض يشكك في دور المنظمة في التعاطي مع هذا الوباء، ويرى أنها قصرت كثيراً في التعامل معه، لا سيما في بدايات اكتشافه. إن المنظمة وفقاً لرأي البعض كان بإمكانها أن تقوم بأفضل مما قامت به، لو أنها تعاملت بجدية أكثر مع الموضوع، وسارعت في الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية الدولية، وفقاً للوائحها، وأبلغت الدول بخطورة هذا الوباء.

ولكن وقبل الخوض في ذلك كله، وللوقوف على دور منظمة الصحة العالمية، أردنا في البداية أن نقدم أولاً لمحة عن هذه المنظمة المهمة من ناحية تشكيلها، وأهدافها، وأهم أجهزتها، وهو ما سنتناوله في مطلبين، نعرض في المطلب الأول لنشأة منظمة الصحة العالمية وأهم أهدافها وأجهزتها، ونناقش في المطلب الثاني، دور منظمة الصحة في مواجهة هذه الجائحة، وأهم الصعاب التي واجهتها والدروس المستفادة منها.

المطلب الأول

منظمة الصحة العالمية: النشأة والأهداف والأجهزة

تعتبر منظمة الصحة العالمية من المنظمات أو الوكالات المتخصصة المهمة على الصعيد الدولي، وقد أُنشئت عقب الحرب العالمية الثانية^(١٩). فقد وافق مؤتمر الصحة العالمي على دستور منظمة الصحة العالمية في ٢٢ يوليو عام ١٩٤٦^(٢٠)، ودخل دستورها حيز التنفيذ في ٧ أبريل عام ١٩٤٨^(٢١). وتحققي منظمة الصحة العالمية بتاريخ السابع من نيسان من كل عام، باعتباره يوم الصحة العالمي^(٢٢). لتكون مسؤولة بصورة مباشرة عن حماية الصحة العامة، ومكافحة الأوبئة وانتشار الأمراض في العالم بأسره. ولقد لعبت هذه المنظمة الدولية، خلال فترة مسيرتها التي وصلت لسبعة عقود، دوراً محورياً وأساسياً في مواجهة كثير من الأمراض والأوبئة، التي انتشرت في العالم كالمalaria والكوليرا والتيفوئيد وسارس وإيبولا، وغيرها من الفيروسات والأوبئة الأخرى. تضم منظمة الصحة العالمية حالياً ١٩٦ عضواً، وتصبح الدول أعضاء فيها بعد موافقتها وقبولها بدستورها، وتتخذ المنظمة من مدينة جنيف

(١٩) See for more details, Armin von Bogdandy and Pedro Villarreal "International Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis", file:///C:/Users/Admin/Downloads/SSRN-id3561650%20(1).pdf.

(٢٠) لمزيد من التفاصيل حول هذه المنظمة انظر: د. مخلد الطراونة، المدخل لدراسة المنظمات الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، ط ١، ٢٠١٨، ص ٢٥٢-٢٥٦، انظر أيضاً: د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، ٢٠٠١، ص ٣١١-٣١٢.

(٢١) انظر: د. محمد عزيز شكري ود. ماجد الحموي، الوسيط في المنظمات الدولية، منشورات جامعة دمشق، ٢٠٠٠، ص ١٧٧-١٧٨، د. مفيد شهاب، المنظمات الدولية، ط ٥، ١٩٨٥، دار النهضة العربية، ص ٥٦٢-٥٦٣. <https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions>

(٢٢) لمزيد من التفاصيل انظر: موقع المنظمة <http://www.who.int/ar>

- ١- المكتب الإقليمي لإفريقيا، ومقره برازافيل في الكونغو.
- ٢- المكتب الإقليمي للأمريكتين، ومقره واشنطن.
- ٣- المكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا، ومقره نيودلهي في الهند.
- ٤- المكتب الإقليمي لأوروبا، ومقره كوبنهاغن في الدانمارك.
- ٥- المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ومقره القاهرة في مصر.
- ٦- المكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادي، ومقره مانيتا في الفلبين.

بسويسرا مقرّاً رئيسياً لها، إضافة إلى وجود ستة مكاتب إقليمية حول العالم، كما تضم المنظمة ١٥٠ مكتباً قُطرياً^(٢٣).

وينصّ دستور المنظمة على أنّ هدفها الرئيس "هو بلوغ جميع الناس أعلى مستوى ممكن من الصحة". وتهدف المنظمة إلى معالجة المسائل المتعلقة بالأمور الصحية على المستوى العالمي، وضبط برنامج البحوث الصحية، وتوفير الدعم التقني للدول الأعضاء فيها. كما تسعى إلى دعم التنمية والأمن الصحي، وتعزيز النظم الصحية للبلدان الأعضاء، إضافة إلى إصدار معلومات صحيّة موثوقة بها، وإرساء شراكة فاعلة مع عدّة أطراف لتنفيذ البرامج الصحية التي تعتمدها^(٢٤). كما تحرص المنظمة على تشجيع البحوث والدراسات الطبيّة، وتقدّم عقد الاتفاقيات في مجال الصحة العالمية، كما يقع على عاتقها مراقبة تفشّي الأمراض السارية مثل الجدري والطاعون والأوبئة الخطيرة الأخرى، والعمل على مكافحتها.

مما تقدم نقول، إنّ لمنظمة الصحة العالمية دوراً أساسياً ومحورياً في مجال الصحة، لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، رغم ما قد يقال أحياناً عن وجود بعض القصور والعوار في عملها، وهيكلها، وآليات اتخاذ القرار فيها. من هذا المنطلق، نجد أن هذه المنظمة ما زالت تدافع عن الحق في الصحة العامة، الذي يُعد من أهم الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الإنسان. كما أنّ هذا الحق الذي كفلته الصكوك الدولية المختلفة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي^(٢٥)، أعطى للمنظمة -

(٢٣) أعلنت عام ١٩٧٨ أن هدفها الرئيسي هو توفير الصحة للجميع، وتمكّنت سنة بعد ذلك من استئصال داء الجدري، كأحد أهم الأمراض المعدية، بعد تنسيق استمر ١٢ عاماً في جميع أنحاء العالم. أطلقت عام ١٩٨٨ المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، وتذكر أنها نجحت في تقليص الإصابة بهذا المرض بنسبة ٩٩٪. اعتمدت عام ٢٠٠٣ اتفاقية بشأن مكافحة التبغ، وتبنت سنة ٢٠٠٤ استراتيجية عالمية للنظام الغذائي والنشاط البدني والصحي.

(٢٤) أهم الاتفاقيات والصكوك التي أشارت للحق بالصحة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR, 1966) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW, 1979) واتفاقية حقوق الطفل (CRC, 1989) مصدق عليها ١٩٨٩ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD, 2006) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. لمزيد من التفصيل انظر: https://www.giz.de/en/downloads/SRIP_Right%20to%20Health%20booklet.pdf

(٢٥) انظر: د. مخلد الطراونة، المدخل لدراسة المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٥٤-٢٥٥، د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، ط ٥، ١٩٩٨، ط ٢٠١١، ص ٤٤٤-٤٤٥، لمزيد من التفصيل انظر: موقع المنظمة <http://www.who.int/ar/>

ومن خلال دستورها ولوائحها الصحية الدولية - مهاماً ووظائف أساسية مكنتها طوال تلك السنين السابقة من أداء الدور المنوط بها إلى حد كبير. وبلا شك، يجد المطلع والمدقق لدستور هذه المنظمة أنها تتمتع بجملة من الاختصاصات والوظائف منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي^(٢٦):

- ١ - العمل بمثابة سلطة التوجيه والتنسيق في مجال العمل الصحي الدولي^(٢٧).
- ٢ - الحفاظ على التعاون الفعّال مع الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمؤسسات الصحية الحكومية، والإدارات والجماعات المهنية، وغيرها من المنظّمات عند الاقتضاء.
- ٣ - مساعدة الحكومات ودعمها - بناءً على طلبها - لتعزيز الخدمات الصحية في الدول الأعضاء فيها.
- ٤ - تقديم المساعدة الفنية المناسبة، لا سيما في حالات الطوارئ الصحية الدولية، وأيضاً الإسعافات اللازمة بناءً على طلب أو قبول حكومات الدول الأعضاء.
- ٥ - تقديم أو المساعدة في تقديم - بناءً على طلب من الأمم المتحدة - الخدمات الصحية والتسهيلات لمجموعات خاصة، مثل شعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية.
- ٦ - إنشاء الخدمات الإدارية والفنية وصيانتها، بما في ذلك الخدمات الوبائية والإحصائية.
- ٧ - تحفيز وتشجيع الجهود الرامية للقضاء على الوباء، والأمراض المتوطنة وغيرها من الأمراض^(٢٨).
- ٨ - اقتراح الاتفاقيات والاتفاقات واللوائح والمعايير، وتقديم توصيات فيما يتعلّق بالمسائل الصحية الدولية والمنتجات الغذائية والحياتية والصيدلية وما شابهها،

(٢٦) د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ١٠٠٠-١٠٠٣، د. علي الشكري، المنظمات الدولية، مؤسسة دار الصادق الثقافية، ٢٠١٢، ص ٣٨٢-٣٨٨.

(٢٧) بدأت المنظمة حملة في عام ١٩٩٨ تسمى "الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين". لمزيد من التفصيل انظر: موقع المنظمة <http://www.who.int/ar/>

(٢٨) تشمل الأولويات الحالية لمنظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الملاريا والسل، والتخفيف من آثار الأمراض غير المعدية، والصحة الجنسية والإنجابية، والتنمية، والشيخوخة، والتغذية والأمن الغذائي وتناول الطعام الصحي... إلخ، <https://www.marefa.org/index.php/> منظمة الصحة العالمية. لمزيد من التفصيل انظر: موقع المنظمة <http://www.who.int/ar/>

وتقريرها ونشرها. كما تقدّم منظّمة الصحة العالمية كذلك نوعين من الخدمات^(٢٩) هما: خدمات استشارية تتمثّل في نشر المعلومات وتبادلها والمساعدة في تدريب القائمين بعدة أعمال في مجال الصحة^(٣٠). وخدمات فنية تتمثّل في توحيد دساتير الأدوية والقيام بمشروعات أبحاث دولية عن الأمراض والأمصال، أو اللقاحات والأدوية المختلفة.

أما فيما يتعلق بفروع منظمة الصحة العالمية، فهي تملك وفقاً لميثاقها أجهزة وفروعاً رئيسية وأخرى ثانوية تساعد في عملها، فهناك ثلاثة أجهزة أو فروع تساعد هذه المنظمة في تحقيق أهدافها وغاياتها، وهي جمعية الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي والأمانة العامة، وسندرس هذه الأجهزة تباعاً^(٣١):

أولاً: جمعية الصحة العالمية: يتألف هذا الفرع من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في المنظمة^(٣٢)، وتجتمع الجمعية مرّة واحدة بالعام في جنيف بسويسرا في شهر مايو/أيار من كلّ عام. كما يُعطي دستور المنظمة لكلّ دولة من الدول الأعضاء فيها حقّ إرسال مندوبين بدلاء أو مستشارين^(٣٣). كما يجوز لها عقد اجتماعات أو دورات، خاصة عند الضرورة بناء على طلب مقدم من المجلس التنفيذي أو أغلبية الأعضاء. ويعد هذا الفرع الجهاز الأعلى والأهم في المنظمة، وهو المسؤول الأساسي عن اتخاذ القرارات المهمة في هذه المنظمة. والجمعية هي التي تقوم برسم سياسة المنظمة، وتُشرف على تنفيذ مشروعاتها^(٣٤)، وتملك وضع بعض اللوائح المتعلقة ببعض الأمور مثل الاشتراطات الصحية، والحجر الصحي، وغيرها من الإجراءات التي يراد منها منع انتشار الأمراض والأوبئة في العالم^(٣٥).

ثانياً: المجلس التنفيذي: يضم المجلس في عضويته ٣٤ عضواً يتم انتخابهم

(٢٩) د. عبد الكريم خليفة، قانون المنظمات الدولية، الدار الجامعية الجديدة، ص ١٥٩، د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص ٣١١-٣١٢، د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص ٩٩٨-١٠٠٠.

(٣٠) د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص ٣١١-٣١٢.

(٣١) لمزيد من التفصيل انظر: موقع المنظمة، <http://www.who.int/ar/> لمزيد من التفصيل انظر: د. رجب عبد الحميد المنظمات الدولية بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب الجامعي، ٢٠١٤، ص ١٩١-١٩٣، د. علي الشكري، مرجع سابق، ص ٣٩٣-٤٢١.

(٣٢) راجع: نص المادة ١٠ من دستور المنظمة.

(٣٣) راجع: نص المادة ١٢ من دستور المنظمة.

(٣٤) راجع: نصوص دستور المنظمة. لمزيد من التفصيل انظر: موقع المنظمة.

(٣٥) راجع: نص المادة ٢١.

من قبل جمعية الصحة العالمية، ولمدة ٣ سنوات فقط، وينتخب المجلس رئيساً له من بين أعضائه، يكون مسؤولاً عن إدارة شؤونه، ومتابعة قراراته، وتنسيق أعماله مع بقية الفروع الأخرى، لا سيما جمعية الصحة العالمية. يجتمع المجلس على الأقل مرتين في العام، حيث يُعقد الاجتماع الأول في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام؛ لكي يعتمد القرارات التي تتم إحالتها إلى جمعية الصحة العالمية، في حين يُعقد الاجتماع الثاني - وهو بالعادة يكون اجتماعاً قصيراً مقارنة بالاجتماع الأول - في شهر مايو، وبعد انتهاء الجمعية من أعمالها؛ وذلك للنظر في المزيد من المسائل الإدارية. ويُعقد المجلس الإدارة التنفيذية للجمعية، ويتولى المجلس تنفيذ قرارات جمعية الصحة وسياساتها بشكل عام.

ثالثاً: الأمانة العامة: يعتبر هذا الفرع الجهاز الإداري للمنظمة، ويتشكل من مدير عام، وعدد من الموظفين والفنيين والإداريين^(٣٦)، ويتم تعيين المدير العام من قبل الجمعية، وبناءً على ترشيح من المجلس التنفيذي للمنظمة^(٣٧). ويملك المدير العام عدداً من الصلاحيات والاختصاصات المهمة مثل: إعداد الميزانية لعرضها على المجلس، وتعيين الموظفين وفقاً للنظام الخاص بالموظفين الذي تضعه الجمعية. كما يملك المدير العام، وفي حدود ميزانية المنظمة أن يُنشئ ما يحتاجه من لجان خبراء وجماعات للدراسة والبحث^(٣٨)، ولا شك أن هذه الاختصاصات وغيرها تسمح بأن

(٣٦) يعمل في المنظمة ما يزيد على ٧٠٠٠ شخص من بلدان يتجاوز عددها ١٥٠ بلداً وذلك في ١٥٠ مكتباً قطرياً وستة مكاتب إقليمية وفي المقر الرئيسي في جنيف بسويسرا.. ويشمل موظفو المنظمة، علاوة على الأطباء والأخصائيين في مجال الصحة العمومية والخبراء العلميين وأخصائيي الوبائيات، أناساً مدربين على إدارة النظم الإدارية والمالية والإعلامية، فضلاً عن أخصائيين في ميادين الإحصاءات الصحية وعلوم الاقتصاد والإغاثة في حالات الطوارئ. <https://www.who.int/ar/about/who-we-are/structure>

(٣٧) ترأست المنظمة مديرة عامة تدعى مارغريت تشان منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني - ٢٠٠٦-٢٠١٧. وكانت قبل ذلك تشغل منصب المدير العام المساعد المسؤول عن دائرة الأمراض السارية ومنصب ممثلة المدير العام لمسائل جائحة الأنفلونزا. أما حالياً فالمدير العام هو السيد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. <https://www.who.int/dg/ar/> منظمة الصحة العالمية <http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizations> andstructures/2015/10/30

(٣٨) تصل ميزانية المنظمة لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ التي أقرها وزراء الصحة في مايو الماضي إلى نحو ٤,٨٥ مليار دولار في المجل، بزيادة تسعة في المئة عن الميزانية السابقة. توضع ميزانية المنظمة كل عامين لتغطي هذه الفترة. وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مانح على الإطلاق، حيث بلغت مساهمتها بحلول نهاية ٢٠١٩ أكثر من ٨٠٠ مليون دولار في ميزانية =

يكون له ثقل واضح في تسيير دفة الأمور في المنظمة، ممّا يساعد في تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها بشكل كامل ودقيق^(٣٩). ومن الأمور المنوطة بالمدير العام، والتي تلعب دوراً مهماً في ممارسة وظائفه، مسألة إعلان حالة الطوارئ الدولية التي نص عليها دستور المنظمة ولوائح الصحة الدولية، كما جاء في المادة ١٢. وقد مارس المدير العام هذه الصلاحية غير مرة، كان آخرها إعلان حالة الطوارئ الدولية، بعد التشاور مع لجنة الطوارئ الدولية على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد/كوفيد-١٩ في ١١ مارس من هذا العام^(٤٠).

صفوة القول، أن منظمة الصحة العالمية تعد منظمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة التي تخولها بالتالي التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، وأيضاً تحمل المسؤولية الدولية الناجمة عن أفعالها وتصرفاتها، فإذا ما أخطأت أو قامت بعمل غير مشروع ترتب عليه ضرر لشخص دولي آخر، فعليها من الناحية القانونية أن تتحمل مسؤولية هذا الأمر إعمالاً لقواعد المسؤولية الدولية التي يقرها القانون الدولي بهذا الخصوص. وقد أقرت لجنة القانون الدولي في هذا السياق عام ٢٠١١ مواد مشروع المسؤولية الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية، وقد تضمن هذا المشروع ٦٧ مادة، عملت عليها اللجنة مدة قرابة التسع سنوات، وهذا المشروع شبيه بالمشروع الخاص بمسؤولية الدول الذي اعتمدته اللجنة في عام ٢٠٠١. ومن هذا المنطلق، نقول إنه إذا ما ثبت تقصير أو إهمال المنظمة في التعاطي مع ملف كورونا منذ بداية الأزمة بحيث أدى ذلك التقاعس أو التقصير إلى نشر الوباء، نتيجة عدم قيام المنظمة بما يلزم من إجراءات وفقاً لدستورها، خاصة موضوع الإبلاغ أو الإخطار للدول الأعضاء، فإنه يتعين عليها بلا شك تحمل

= ٢٠١٨-٢٠١٩. ومؤسسة بيل غيتس الخيرية هي ثاني أكبر مانح للمنظمة تليها بريطانيا. يأتي تمويل منظمة الصحة العالمية عبر طريقتين:

- "الاشتراكات المقدرة من الدول الأعضاء وتخصص لاستمرار الوظائف الأساسية للمنظمة.
- والمساهمات الطوعية التي تقدم لبرامج محددة مثل القضاء على شلل الأطفال ومكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والأمراض المعدية الأخرى. <https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/ar/>

(٣٩) د. مخلد الطراونة، المدخل لدراسة المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٢٥٦.

(٤٠) See for more details, Armin von Bogdandy and Pedro Villarreal "International Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis", file:///C:/Users/Admin/Downloads/SSRN-id3561650%20(1).pdf. See also Lauren Tonti, The International Health Regulations: The Past and the Present, But What Future? <https://harvardilj.org/2020/04/the-international-health-regulations-the-past-and-the-present-but-what-future/>.

المسؤولية الدولية عن ذلك، فكل فعل غير مشروع ترتكبه المنظمة الدولية حسب ما جاء في المادة الثالثة من المشروع تتحمل المنظمة الدولية المسؤولية الدولية عنه وفقاً للشروط المقررة، والتي منها إسناد الفعل غير المشروع للمنظمة الدولية، وأن ينتهك التصرف الصادر عن المنظمة الدولية التزاماتها الدولية، حيث تعتبر المنظمة الدولية منتهكة لالتزامها الدولي متى ما كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لمتطلباته، بغض النظر عن مصدر أو طبيعة الالتزام سواء أكان قياماً بفعل أم امتناعاً عن فعل بهذا الصدد^(٤١). وقد عالجت - كما ذكرنا - هذه المواد كافة المسائل المتصلة بموضوع المسؤولية المتعلقة بالمنظمات الدولية، حيث لاقت هذه المواد نجاحاً كبيراً على الصعيد الدولي. وسنحاول في النقطة التالية وفي المبحث الثالث من هذا البحث الغوص أكثر في موضوع مسؤولية منظمة الصحة العالمية في إطار هذا الخصوص، وكيف تعاملت هذه المنظمة مع جائحة كورونا، وهل نجحت المنظمة في التعاطي مع هذا الملف أم أخفقت؟ وما مدى مسؤوليتها القانونية عن ذلك؟

المطلب الثاني

دور المنظمة في التصدي لجائحة كورونا: (التحديات والدروس المستفادة)

لقد ظلت منظمة الصحة العالمية، على الدوام ورغم كل الجهود الكبيرة التي تبذلها في مواجهة الأمراض والتصدي للأوبئة عرضة بين الفينة والأخرى للانتقاد والجدل، فاتجاه يشيد بجهود المنظمة ودورها وقدرتها على القيام بواجباتها خير قيام، وآخر ينتقد عمل المنظمة وطريقة تعاملها مع كثير من المسائل والأمور التي تعترضها، لاسيما سياساتها وتصرفاتها وقراراتها، وردة فعلها تجاه التعاطي مع انتشار بعض الأمراض والأوبئة في العالم. كما طالت تلك الانتقادات هيكلية المنظمة، ودور مديرها - خاصة الحالي - في التعامل مع تلك الأمور. وقد زادت حدة الانتقادات للمنظمة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد/كوفيد-١٩ في الآونة الأخيرة، فرغم إشادة كثير من الدول والمنظمات المعنية بدور هذه المنظمة، وبالكيفية والطريقة التي أدارت بها هذا الملف، إلا أن هناك أيضاً من الدول والأشخاص من صب جام غضبه على هذه المنظمة وطريقة إدارتها للأزمة.

وهنا يبرز دور الولايات المتحدة التي قادت بعض الدول في انتقاد هذه المنظمة بشدة، فالرئيس ترامب أعلن صراحةً بأن المنظمة لم تقم بالدور المطلوب منها، وأنها خضعت للسلطات الصينية في مسألة عدم إعلان حالة الطوارئ الدولية، واعتبار هذا الفيروس وباءً عالمياً وفقاً للوائح الصحية، وأنها تأخرت كذلك في اتخاذ التدابير

والاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الوباء، كما أنها لم تقدم النصائح المطلوبة للدول، وأنها بشكل عام تسترت على الصين في هذا السياق، وضللت الرأي العام بخصوص هذا الفيروس. ويحمل كثير من الدول والأشخاص المسؤولية عن تقصير المنظمة في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمواجهة هذا الوباء الخطير لمدير عام المنظمة الإثيوبي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث يعتقدون أنه شخص غير مناسب لتولي هذا المنصب، وأنه شخصياً يتحمل جزءاً من المسؤولية عن انتشار هذا الفيروس الخطير في العالم، فقد سبق له أن رفض بتاريخ ٢٣ يناير/كانون الثاني إعلان حالة الطوارئ العالمية، وفقاً لما ينص عليه دستور المنظمة ولوائحها الصحية، الأمر الذي زاد من حالات الوفيات والإصابات على مستوى العالم، وسمح بانتشار الوباء؛ بحيث تضاعفت هذه الحالات خمس مرات خلال خمسة أيام فقط، كما أن المنظمة لم تعلن حالة الطوارئ الصحية العامة إلا في يوم ٣٠ يناير/كانون الثاني، كما أنها لم تصف انتشار الفيروس بالجائحة إلا يوم ١١ مارس/ آذار الماضي؛ وذلك بعد أن استشرى الوباء للأسف وانتشر بشكل واسع في معظم دول العالم^(٤٢).

وقبل هذا التاريخ، وتحديداً في ١٤ يناير/كانون الثاني، أشارت المنظمة إلى أن التحقيقات الأولية تبين أن السلطات الصينية لم تعثر على أدلة كافية لتأكيد أن الفيروس ينتقل عبر البشر، لكن الكثير من الخبراء يعيبون على المنظمة تصديقها للمعلومات التي قدمتها الحكومة الصينية، رغم عدم شفافيتها وموثوقيتها بخصوص هذا الموضوع، لاسيما أن السلطات الصينية، قد فرضت - نوعاً ما - تعميماً إعلامياً صارماً على المعلومات المتصلة بانتشار الوباء، والأسباب التي تقف وراءه، كما أنها منعت الأشخاص والصحافة من الكلام ونشر أية معلومات تتصل بهذا الأمر، والدليل على ذلك هو اعتقالها للدكتور لي وينليانغ - كما ذكرنا - الذي كان من أوائل الأطباء الذين كشفوا عن هذا الفيروس، وحذر زملاءه والسلطات المحلية من خطورته^(٤٣).

ويشير في هذا السياق، السيد فرانسوا غودمان، من معهد مونتيني الفرنسي للسياسات، أن المنظمة قد ارتكبت في حقيقة الأمر خطأين رئيسيين أو جوهرين في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد/كوفيد-١٩: الأول هو عندما أخفقت بشكل ذريع في المعرفة المبكرة بأن العدوى تنتقل بين البشر، فالمنظمة وفقاً لبعض التقارير،

(٤٢) https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwte71BRBCEiwAU_V9h-vQaWWDpUaVYEdo3fzA5eoqfg4-S3oljDgvkisXv2_mEmF26TQJqChoCcpsQAvD_BwE

(٤٣) <https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/ar/>

لم تستمع لبعض التحذيرات التي أطلقتها الحكومة التايوانية في أواخر عام ٢٠١٩ من أن عدوى فيروس كورونا المستجد يمكن أن تنتقل بين البشر^(٤٤). فقد نقلت صحيفة "آسيا تايمز" أن الحكومة التايوانية أكدت أنها علمت في تلك الفترة بوجود عدوى تنفسية انتشرت بسرعة في مدينة ووهان الصينية، وأنها وبسبب ذلك حاولت التواصل مع السلطات المختصة في الصين، ومنظمة الصحة العالمية أملاً في الحصول على بعض المعلومات والتوضيحات عن هذا الأمر، لكن الجواب الوحيد الذي استلمته الحكومة التايوانية لم يزد على بريد إلكتروني، جاء فيه أن خبراء المنظمة سيحققون في الموضوع. أما الأمر الثاني فهو عدم إعلانها لفيروس كورونا كجائحة دولية إلا بعد أن تم تسجيل قرابة ١١٨ ألف حالة في ١١٤ دولة تقريباً، وهو ما أثر بشكل سلبي على سياسات الدول التي تتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية بخصوص التصدي للأوبئة والأمراض. كما بين السيد غودمان أن منظمة الصحة العالمية لم ترسل فريقاً إلى الصين للتحقيق إلا في حدود ١٣ فبراير/ شباط، أي تقريباً بعد شهر ونصف من تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو أمر يعد في نظر الكثيرين متأخراً نسبياً في التصدي لهذا الفيروس، وهو ما انعكس سلباً - كما قلنا - في مجهودات الدول في التصدي لهذه الجائحة التي حصدت أرواح الكثير من البشر في كل دول العالم تقريباً^(٤٥). لكن من أكثر الانتقادات التي راجت خلال الفترة السابقة بحق المنظمة ومديرها العام، هو طريقة تعامل المنظمة مع الصين، حيث وصفت بعض التقارير الصحفية هذه المنظمة بـ "منظمة الصحة الصينية"، وليست العالمية، فقد أشادت المنظمة أكثر من مرة في بياناتها الرسمية بالصين، وبما أسمته المنظمة "التزام الحكومة الصينية للشفافية من أعلى درجة، والجهود التي بذلتها للتحقيق في تفشي الفيروس"^(٤٦).

(٤٤) See also Lauren Tonti, The International Health Regulations: The Past and the Present, But What Future? <https://harvardilj.org/2020/04/the-international-health-regulations-the-past-and-the-present-but-what-future/>.

(٤٥) <https://www.dw.com/ar>

(٤٦) في رده على الانتقادات حول مجاملة الصين، قال رئيس المنظمة في مؤتمر صحفي يوم ١٢ فبراير/شباط: "أعرف أن هناك ضغوطاً كبيرة على منظمة الصحة العالمية عندما نشن ما نقوم به الصين، لكن ليس فقط بسبب الضغوط سنتوقف عن قول الحقيقة، فالصين لا تحتاج إلى طلب الثناء"، متابعا: "لم تكن الصين البلد الوحيد الذي اعترفنا بعمله، فقد اعترفنا بجهود حكومات أخرى"، قبل أن يعود للتأكيد: "هذا فيروس خطير جداً، والصين قامت بالكثير من الإجراءات الجيدة التي أبطأتها، وهذا يستوجب الاعتراف". <https://www.dw.com/ar>

كما أن هناك من يفسر هذا التراخي والتعاس في التعامل مع ملف كورونا المستجد من جانب منظمة الصحة العالمية؛ بسبب خصوصية العلاقة التي تربط بين مدير المنظمة والصين، وإن ثمة روابط شخصية ومصالح مشتركة تربط بين الطرفين. وإن طبيعة هذه العلاقة هي التي جعلت مدير المنظمة الإثيوبي السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقف هذا الموقف، الذي وصف من جانب الكثيرين بأنه جاء للتستر على الصين، وطريقة تعاملها مع الوباء، فقد وقفت الصين إلى جانبه وساندته بشكل قوي في الانتخابات التي قادت لتوليها هذا المنصب في شهر مايو عام ٢٠١٧^(٤٧). لا شك أن مثل هذه المعلومات وغيرها جعلت منظمة الصحة العالمية في مرمى سهام الانتقاد الشديد من جانب الكثير من الدول، الأمر الذي أضعف موقفها، وشكك في مصداقيتها في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم.

ومما زاد الطين بلةً هو موقف الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي من هذه المنظمة، فبسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات فيها، والتي وصلت لعشرات الآلاف - والتي جعلت الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية يشير في ٢٤ مارس/آذار إلى إمكانية أن تصبح الولايات المتحدة البؤرة الجديدة للفيروس- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض هجوماً حاداً ولادعاً على المنظمة^(٤٨)، كما كتب عبر حسابه على تويتر، إن "منظمة الصحة العالمية أخفقت حقاً... الغريب أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكن تركيزها منصب على الصين"^(٤٩). كما أعلن أن الولايات المتحدة ستعلق دفع مساهمتها المالية في منظمة الصحة العالمية، وهو ما تم بالفعل في ١٤ نيسان ٢٠٢٠. فقد اعتبر ترامب أن المنظمة أساءت إدارة أزمة فيروس كورونا بشكل كبير، وأنها لم تكن على مستوى الحدث والمسؤولية. وقال ترامب -خلال أحد مؤتمراته الصحفية اليومية في البيت الأبيض - بشأن تطورات وباء كوفيد-١٩ في البلاد "إنني اليوم أمر بتعليق تمويل

(٤٧) تم انتخاب السيد تيدروس مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية من قبل جمعية الصحة العالمية في ٢٣ مايو ٢٠١٧، ليصبح أول مدير عام من غير الأطباء. وقد تولى منصبه في ١ يوليو ٢٠١٧ مدة خمس سنوات. في أوائل عام ٢٠٢٠. <https://www.who.int/dg/election/>. tedros/ar/

(٤٨) See for more details, Armin von Bogdandy and Pedro Villarreal "International Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis", file:///C:/Users/Admin/Downloads/SSRN-id3561650%20(1).pdf.

(٤٩) <https://www.dw.com/ar/%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/a-53056154>

منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يتم فيه إجراء مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية في سوء الإدارة الشديد والتعقيم على تفشي فيروس كورونا^(٥٠). وقد وجه الرئيس الأمريكي لائحة اتهام مطولة إلى المنظمة العالمية، حيث قال بهذا الخصوص إن: "العالم تلقى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات الناجمة عن الوباء"^(٥١).

وتعد الولايات المتحدة في الحقيقة المساهم الأكبر على الإطلاق في تمويل ميزانية منظمة الصحة العالمية التي تقارب الخمسة مليارات دولار. فقد دفعت الولايات في العام الماضي للمنظمة حوالي ٤٠٠ مليون دولار^(٥٢)، ناهيك عن التبرعات الأخرى، التي يقدمها أثرياء أمريكيون للمنظمة مثل مؤسسة بيل جيتس وأماندا، وغيرهما من الأشخاص والمؤسسات، والتي تصنف على أنها موارد غير عادية^(٥٣). ووفقاً للرئيس الأمريكي فإن تأخر الصين في الكشف عن الوباء، ونطاقه، ومدى فتكه بالبشر، كلف سائر دول العالم وقتاً ثميناً كان يمكن خلاله اتخاذ إجراءات لواء الفيروس والقضاء عليه في مهده. وقال ترامب: "لو أن منظمة الصحة العالمية قامت بعملها بإرسال خبراء طبيين إلى الصين لتقييم الوضع على الأرض بشكل موضوعي، وفضحت عدم شفافية الصين، لكان من الممكن احتواء تفشي المرض في مهده مع عدد قليل جداً من الوفيات"^(٥٤). وأضاف "كان من الممكن لهذا الأمر أن يُنقذ آلاف الأرواح، وأن يمنع وقوع الأضرار الاقتصادية العالمية. لكن بدلاً من ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية قررت أن تتق بظاهر التطمينات الصينية، ودافعت عن تصرفات الحكومة الصينية"^(٥٥). وقد قررت الولايات المتحدة في ٢٩ مايو الماضي إخطار المنظمة رسمياً بانسحابها

^(٥٠) <https://www.france24.com/ar/>

^(٥١) <https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/14>

^(٥٢) وقال ترامب "سنناقش الآن ما سنفعل بكل تلك الأموال التي كانت تذهب إلى منظمة الصحة العالمية". وأضاف "في ظل تفشي جائحة كوفيد-١٩، لدينا مخاوف عميقة بشأن ما إذا كان كرم أمريكا قد استخدم على أفضل نحو ممكن". <https://www.france24.com/ar/> 20200415

^(٥٣) تبرعت مؤسسة بيل وميليندا جيتس بمبلغ يصل إلى ١٠٠ مليون دولار للمساعدة في احتواء تفشي المرض. لمزيد من التفصيل حول موارد المنظمة الدولية انظر: د. مخلص الطراونة، المدخل لدراسة المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص ٧٥-٧٦. <https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2020/3/29>

^(٥٤) <https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/15>

^(٥٥) Ibid.

منها كردة فعل على تعاطيها مع الجائحة، متهمة المنظمة بالانحياز إلى الصين، وسوء التعامل مع أزمة الفيروس، حيث ستستكمل الولايات المتحدة عملية الانسحاب بحلول ٦ يوليو ٢٠٢١^(٥٦) ورغم ذلك كله ظل الرئيس الأمريكي ينتقد كلاً من الصين، والمنظمة العالمية؛ بسبب تعاملها مع انتشار الوباء، وعدم الشفافية في إعطاء المعلومات، لدرجة أن الرئيس الأمريكي بات على الدوام، وفي أغلب مؤتمراته الصحفية يردد عبارة "الفيروس الصيني" للتعبير عن فيروس كورونا أو كوفيد-١٩، للتأكيد على أن من يقف وراء ظهوره وانتشاره هي الصين^(٥٧). كما أن الاتهامات الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي لم تتوقف عند وصف كورونا بالفيروس الصيني، بل تم توجيه اتهامات للحكومة الصينية بأنها أخفت كثيراً من المعلومات فيما يخص الفيروس بدايةً من تفشيه وانتشاره، ومروراً بأعداد الإصابات والضحايا، التي يظن الأمريكيون بأنها أكثر بكثير في الواقع من الأرقام التي تفصح عنها بكين في الإعلام الرسمي^(٥٨).

وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق إلى أنه على الصين أن تتحمل العواقب إذا ثبت أنها مسؤولة عن عمد عن وباء فيروس كورونا^(٥٩)، خاصة أنه - وفقاً لتصريحاته - يقول إنه اطلع على أدلة تُرجع نشأة فيروس كورونا إلى مختبر صيني. ومعنى هذا الكلام باختصار أن الفيروس مُخلق في الصين، وتحديداً في مختبرات مدينة ووهان الصينية، رغم وجود تقارير استخباراتية أمريكية تنفي أن يكون هذا الفيروس من صنع الإنسان، أو أنه قد تم تعديله جينياً^(٦٠). وهذا الانتقاد

(٥٦) <https://www.france24.com/ar/20200708-> الولايات المتحدة تنسحب رسمياً من منظمة الصحة العالمية.

(٥٧) <https://www.bbc.com/arabic/world-52342184>

(٥٨) <https://al-ain.com/article/corona-virus-leaked-from-the-wuhan-institute-america-is-investigating-and-china-denies>

(٥٩) وقال ترامب في مؤتمر صحفي يومي: "إذا كان الأمر ناجماً عن خطأ، فالخطأ ليس إلا خطأ. أما إذا كانت مسؤولة عن عمد، إذن بالتأكيد يجب أن تكون هناك عواقب". <https://www.bbc.com/arabic/world-52342184>

(٦٠) بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مناقضاً لخلاصات الوكالات الاستخباراتية التابعة له، عبر إشارته إلى اطلاعه على أدلة تُرجع نشأة فيروس كورونا إلى مختبر صيني. وفي وقت سابق، قال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية إنه لا يزال يحقق في كيفية بدء تفشي الفيروس. لكن المكتب قال: إن كوفيد ١٩ "ليس من صنع الإنسان ولم يعدل وراثياً". <https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-52329699> ليس من صنع الإنسان ولم يعدل جينياً.

والتوصيف للأمور كان في حقيقة الأمر مستغرباً جداً من الرئيس ترامب، الذي غير موقفه فجأةً بعد أن كان يكيل المديح في البداية للصين؛ بسبب طريقة تعاملها مع تفشي الوباء، وإدارة الأزمة الخاصة بها، ونجاحها في ضبط الأمور ومنع تفشي الوباء، ظناً منه أن بلاده لن تتأثر بهذا الوباء، رغم وجود تقارير استخباراتية كانت قد أشارت إلى خطورة هذا الوباء، وإمكانية تفشيه في الولايات المتحدة، وبقيّة دول العالم. لكن الرئيس لم يأخذ هذه التحذيرات والتقارير محمل الجد، معتقداً أن بلاده ستكون لديها القدرة، بما تملكه من إمكانيات على مواجهته، والتصدي له في حالة وصوله إليها.

لكن وقائع الأحداث وسرعة وتيرتها - وكما يقال تجري الرياح بما لا تشتهي السفن - غيرت مجرى الأمور بشكل غير متوقع في الولايات المتحدة، فقد أثبتت سرعة تفشي الوباء، وانتشاره بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة خطأ الرئيس الأمريكي، وأركان إدارته في تقديره للأمور بالنسبة لفيروس كورونا، ومدى انتشاره، وهو ما أدى إلى حدوث عشرات الآلاف من الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي انتشر فيها الوباء بصورة سريعة للغاية فاقت نظيراتها في الدول الأوروبية، التي أصبحت بعد الصين البؤرة الثانية للانتشار، فالولايات المتحدة أضحت اليوم، وحسب منظمة الصحة العالمية، البؤرة الأولى في العالم في انتشار الوباء، وبأرقام عالية جداً لم تشهدها دول أخرى، فالتقديرات الحالية لعدد المصابين تجاوزت - وفقاً لجامعة جونز هوبكنز - حاجز المليون والنصف، وعدد الوفيات زاد عن 200 ألف مواطن أمريكي، معظمهم في مدينة نيويورك التي كانت الولاية الأكثر تأثراً من بين الولايات الخمسين في الولايات المتحدة^(٦١). إضافة إلى ذلك، تعاني الولايات المتحدة من خسائر اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة في التاريخ الأمريكي من جراء انتشار هذا الفيروس، والتي قُدرت بعشرات المليارات من الدولارات، وقد تصل وفقاً لبعض الدراسات والتقارير إلى ١,٧ ترليون دولار أمريكي، وهو ما أثر بشكل سلبي جداً على الاقتصاد الأمريكي وعلى قطاع الوظائف فيها، حيث خسر الملايين من الأمريكيين وظائفهم بسبب هذه الجائحة، ويُندر بحدوث كساد، ونكسات اقتصادية للولايات المتحدة في المدى المنظور^(٦٢).

(٦١) <https://hub.jhu.edu/novel-coronavirus-information/> جامعة جونز هوبكنز

(٦٢) ذهب باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية إلى أبعد من ذلك، وتوقعوا الخطر المحقق بالولايات المتحدة في دراسة صدرت حديثاً تطرقت إلى التكلفة المحتملة من الناحيتين البشرية والمالية. مؤلفو هذه الدراسة أوضحوا أن التكلفة المتوقعة للمال المهترئ يمكن أن تصل إلى ١,٧ ترليون دولار عام ٢٠٢٠، بسبب تفشي فيروس كورونا.

<https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/13/>

وتشير الدراسات إلى أن تفشي فيروس كورونا، ليس هو الأزمة الوحيدة التي ستعاني منها الولايات المتحدة، حيث إن هناك الكثير من التهديدات الرئيسية الأخرى التي تواجهها، من بينها الخسائر التي تكبدها الأسهم الأميركية، إلى جانب الانخفاض الحاد والكبير في أسعار النفط؛ بسبب حرب النفط التي تخوضها السعودية وروسيا، والتي تأثر بها بشكل كبير المنتجون الأمريكيون^(٦٣). إن هذا الوضع الخطير، دفع بالرئيس الأمريكي أن يطلب من الكونجرس حزمة مساعدات مالية، وصلت تقريباً إلى ٢ تريليون دولار؛ لتحفيز الشركات الصغيرة التي تعاني من الإغلاق الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن هذا البرنامج "سيساعد في الحفاظ على توظيف الأمريكيين لتسهيل تعافي سريع وكامل في البلاد"^(٦٤).

وعودة إلى قرار الرئيس الأمريكي الخاص بوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية، وردود الأفعال عليه، فقد لاقى هذه الخطوة الأمريكية كثيراً من الانتقادات والتحفظات، كان من أبرزها ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي اعتبر أن الوقت ليس مناسباً لوقف تمويل المنظمة الدولية، التي تتصدر الجهود العالمية لوقف انتشار الوباء. وقال غوتيريس في بيان صادر عنه اتسم على غير عادته بنبرة حادة: "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظمة الصحة العالمية، أو أي منظمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس، قناعتني هي أنه يجب دعم منظمة الصحة العالمية؛ لأن أهميتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-١٩"^(٦٥). وأضاف الأمين العام أن منظمة الصحة العالمية تتصدى للوباء "في الخطوط الأمامية، وتقديم الدعم للدول الأعضاء ومجتمعاتها، وخصوصاً الأكثر ضعفاً من بينها، بالإرشادات والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للأرواح". وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "عندما سنطوي، في نهاية المطاف، صفحة هذا الوباء، سيكون هناك وقت للعودة بشكل كامل لفهم كيف أمكن لهذا المرض أن ينشأ، وأن ينشر دماره بمثل هذه السرعة في جميع أنحاء العالم". وأضاف "الدروس

Ibid.

(٦٣)

(٦٤) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق، بقيمة ٢ تريليون دولار، لمواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وأكد وزير الخزانة ستيفن منوشين أنه يجري محادثات مع القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس للمطالبة بـ ٢٥٠ مليار دولار إضافية "لضمان حصول الشركات الصغيرة على المال الذي تحتاج إليه". لمزيد من التفاصيل انظر:

<https://www.bbc.com/arabic/world-52072582>

<https://www.france24.com/ar/20200415> .

(٦٥)

المستفادة ستكون ضرورية لإدارة تحديات مماثلة بفعالية، إذا ما ظهرت في المستقبل، لكن هذا ليس الوقت لذلك^(٦٦). وقال الأمين العام إنه سيأتي لاحقاً الوقت الذي يمكن فيه تقييم "أداء كل الذين كانوا معنيين بالأزمة"، مشدداً على أن "الحقائق نفسها يمكن تفسيرها بشكل مختلف من قبل كيانات مختلفة"^(٦٧).

في سياق متصل أيضاً، تنفي الصين باستمرار مسؤوليتها تماماً عن انتشار الوباء، كما أعلنت أن الفيروس غير مخلق في مختبراتها، كما تدعي الولايات المتحدة، وإنها لم تقم بتعديله جينياً إطلاقاً. وقد أكد السيد يوان زيمينغ مدير مختبر معهد علم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، عدم مسؤولية المختبر عن انتشار فيروس كورونا. وقال مدير المعهد لشبكة (سي جي تي إن) التلفزيونية الرسمية، إنه من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادراً عن المختبر^(٦٨)، وقد انتقد السيد زيمينغ وسائل الإعلام المختلفة التي تحاول خداع الناس وإعطاء معلومات خاطئة وغير دقيقة. وهذا النفي أعلنه أيضاً أكثر من مسؤول صيني رفيع المستوى رداً على الاتهامات الأمريكية التي حاولت توجيه التهم للصين في الوقوف وراء انتشار هذا الوباء الذي أودى بحياة آلاف الناس. وفي السياق ذاته، وتأكيداً للموقف الصيني بخصوص مسألة تخليق الفيروس، نفت منظمة الصحة العالمية نظرية أن فيروس كورونا مخلق في مختبرات صينية في أكثر من مرة على لسان المتحدث باسمها، حيث أشارت المنظمة العالمية في ٢٢ نيسان أن جميع الأدلة المتوافرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش داخل الصين أواخر العام الماضي، وأنه لم يتم تخليقه أو إنشاؤه أو التلاعب به في أي من المختبرات أو أي مكان آخر^(٦٩).

خلاصة القول، إن هذا التباين في وجهات النظر، والتبادل في الاتهامات بين كل من الصين والولايات المتحدة، تقف وراءه أهداف سياسية واقتصادية تأتي في إطار الحرب التجارية والاقتصادية الشرسة بين البلدين الكبيرين، والتي انعكست بشكل كبير على عديد من الصعد والملفات المختلفة. وبعد انتشار هذا الوباء، عادت تلك الخلافات مجدداً إلى السطح، وتم استغلال منظمة الصحة العالمية - التي رغم وجود بعض التقصير في

Ibid. (٦٦)

Ibid. (٦٧)

<https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/19> (٦٨)

<https://www.who.int/ar> وقالت المتحدث باسم الصحة العالمية إن الباحثين ينظرون إلى (٦٩)

الخصائص الجينومية المتعلقة به، ووجدوا أن تلك الخصائص لا تدعم نظرية أن يكون الفيروس قد صُنِع في المختبرات بحسب ال سي إن إن.

أدائها في هذه الجائحة العالمية، خاصة كما بيّنا في التأخير في إعلان حالة الطوارئ، وعدم السرعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير والاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الوباء - لتكون وقوداً لهذا الصراع الذي كان العالم في غنى عنه في هذه الفترة الحرجة والصعبة، والتي يحتاج فيها العالم كله أن يوحد جهوده لمواجهة هذا الوباء الداهم، الذي يشكل خطراً محدقاً بالبشرية والإنسانية جمعاء، فعدم التكاتف والتعاقد والتعاون والتنسيق في مثل هذه الظروف بين الدول، والتركيز على الأمور الجانبية أمر سيكون له عواقب وخيمة على البشرية بأسرها، فالوقت هو وقت العمل، والبحث عن الحلول لهذه الأزمة والكارثة، التي لم يمر على العالم مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، فعلى الدول ومنظمة الصحة العالمية أن تركز جهودها على البحث العلمي والتجارب المخبرية، من أجل إيجاد مطاعيم، أو لقاحات وأدوية للتخفيف من حدة هذا الوباء، أو القضاء عليه.

إن هذا الأمر يستدعي - بطبيعة الحال - من الدول، بدلاً من توجيه الاتهامات لمنظمة الصحة العالمية، وبيان إخفاقها وعجزها، أن تدعم هذه المنظمة بكل ما أوتيت من قوة؛ لتمكينها من إيجاد الحلول لهذا الوباء الذي عمّ شره ووباله على جميع دول العالم. كما أن الوقت لا شك، سيكون كافياً لاحقاً عند انتهاء الأزمة لمراجعة ما قامت به منظمة الصحة العالمية من إجراءات وتدابير، وستتم محاسبة مديرها، والمسؤولين فيها عن أي خطأ أو تقصير بهذا الخصوص. وإذا كانت هناك حاجة لمراجعة دستور المنظمة، وتعديل هيكلها، وتركيباتها، وتعديل اختصاصاتها، فهذا الأمر ممكن بالطرق القانونية، وحسب ما ينص عليه ميثاقها. فمن دون أدنى شك، إن هذه الجائحة لن تمر دون أن يكون لها آثار وتداعيات على المنظمة، وهيكلتها وطريقة عملها، وعلى آليات عملها، فالعالم كله بالتأكيد سيتغير بعد هذه الجائحة، وستكون منظمة الصحة العالمية، والأجهزة المرتبطة بها ولوائحها عرضة لهذا التغيير والتعديل، لكي يستفيد كل واحد من هذا الدرس القاسي، ويُعد الخطوات والخطط والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الأخطاء والسلبات التي ظهرت أثناء التعامل مع هذه الجائحة من جانب المنظمة العالمية، والبناء على الإيجابيات والنجاحات التي تحققت لتعميمها، والاستفادة منها عند حدوث أية جائحة لا قدر الله مستقبلاً، فكل أزمة تظهر، وتواجه الناس والدول، لابد أن يكون لها بالتأكيد جوانب إيجابية، وأخرى سلبية، والوقت الآن هو وقت العمل، والتكاتف، ورص الصفوف لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد البشرية جمعاء بالفناء، وليس الوقت للمناكفات، وتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية وكيل التهم. وبلا شك، إن الوقت المناسب سيأتي لاحقاً لفهم حقيقة ما جرى، وبالتالي تقييم أداء والتزام كل الذين كانوا معنيين بإدارة هذه الأزمة الخطيرة، ومحاسبة كل من كان مقصراً في ذلك سواء أكانت دولة أم منظمة أم أشخاصاً، أخلاقياً وسياسياً وقانونياً.

المبحث الثالث

حدود مسؤولية الصين الدولية من الناحية القانونية

قراءة في أبرز السيناريوهات

بعد أن تطرقنا في المبحثين السابقين لبداية انتشار وباء كورونا المستجد/كوفيد-١٩، وبيّنا بداية قصته، وكيفية انتشاره السريع، وطريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع هذا الأمر، وكيفية إدارتها للأزمة، وما رافق ذلك من جدل ومناقشات. نتناول في هذا المبحث مدى مسؤولية الصين عن هذا الوباء وتفشيهِ من الناحية القانونية. وهل يمكن مساءلة الصين دولياً عن تفشي هذا الوباء؟ وما السيناريوهات المطروحة في هذا السياق؟ وهل هناك قضايا أو دعاوى فعلاً حُرِكت أو سُجلت في هذا الصدد أم لا؟ وماذا عن موقف الحكومة الأمريكية وادعاءات الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص؟ هل يمكن أخذها على محمل الجد بخصوص موضوع المحاسبة عن تفشي الوباء أم هي مجرد اختبارات وبالونات سياسية هدفها ابتزاز الصين، ودغدغة مشاعر الناخبين الأمريكيين لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي في الانتخابات التي ستُجرى في نوفمبر هذا العام؟ وكيف سيتم تأسيس المسؤولية الدولية بهذا الخصوص؟ وهل المسؤولية تقع على عاتق الصين وحدها أم على منظمة الصحة العالمية كذلك؟ وما أبرز الحجج التي سيقَت بهذا الخصوص؟ وكيف يمكن الاستفادة من اللوائح الصحية الدولية، وقواعد القانون الدولي ومبادئه، في إثبات أو نفي تلك المسؤولية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها فإننا سندرسها في المطلب التالي:

المطلب الأول

تأطير المشكلة وبيان أبعادها القانونية

لقد سبق القول إن ظهور فيروس كورونا - كوفيد-١٩، قد بدأ في سوق الحيوانات في مدينة ووهان/مقاطعة خوبي، وأن أول حالة حسب ما تشير التقارير قد ظهرت في الأول من ديسمبر عام ٢٠١٩، بل أن بعض التقارير والمصادر تشير إلى ظهور حالات سابقة على هذا التاريخ، وتحديداً في ١٧ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته^(٧٠). ولكن التقارير الطبية تؤكد أن أول حالة تم تصنيفها بـفيروس كورونا المستجد كانت في ٨ من شهر ديسمبر/ ٢٠١٩. وعلى الرغم من ظهور هذا الفيروس،

(٧٠) Has China violated international law on the virus outbreak? <https://theArab-weekly.com/has-china-violated-international-law-virus-outbreak>.

وبداية انتشاره بسرعة، فإن السلطات الصينية لم تبدأ بالاعتراف والإقرار بوجود هذه المشكلة إلا في ٢١ كانون الثاني/ ٢٠٢٠ وهذا يعني أن هناك تأخيراً واضحاً في الإبلاغ عن وجود هذا الوباء، وهذا التأخير الذي قارب على الشهرين هو حسب ما يرى الكثيرون تأخير معتبر (Considerable Delay) في الإبلاغ عن هذا الفيروس للدول، ولمنظمة الصحة العالمية باعتبارها الجهة المختصة بمتابعة مثل هذه الأمور، وهذا كان له تداعياته بطبيعة الحال على التأخر في اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة من جانب المنظمة والدول في مواجهة هذا الفيروس ومنع انتشاره، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية لاحقاً في شهر مارس بالجائحة^(٧١).

لا شك أن مثل هذا التأخير، وما رافقه - بطبيعة الحال - من عدم وضوح وشفافية، فيما يتعلق بالفيروس، ومدى خطورته، والمعلومات المتعلقة به، وكيفية ظهوره وانتشاره بسرعة كبيرة للغاية، وأعداد المصابين به، وعدد الوفيات، إضافة إلى التعتيم الإعلامي، ومحاسبة وملاحقة الأشخاص والأطباء الذين تكلموا عنه، وعن مدى خطورته من جانب السلطات الصينية، طرحت عديد من التساؤلات المتعلقة بمدى مسؤولية الصين من الناحية القانونية عن نشر هذا الوباء والتقصير في إبلاغ منظمة الصحة العالمية والدول حوله، لاسيما في ضوء دستور منظمة الصحة العالمية، ولوائح منظمة الصحة الدولية لعام ٢٠٠٥^(٧٢). وسنحاول قبل الحديث عن مدى مسؤولية الصين، وتوضيح الأبعاد القانونية لهذه المشكلة، أن نبين النظام أو الإطار القانوني الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية للتعامل مع المسائل المرتبطة بموضوع انتشار الأمراض والأوبئة وتفشيها، وفقاً لدستورها ولوائحها الصحية الدولية لعام ٢٠٠٥، وكيف يمكن الاستفادة من هذا الإطار القانوني في فهم المشكلة وتحديد أبعادها القانونية، وتأسيس فكرة المسؤولية القانونية على عاتق الصين.

Ibid.

(٧١)

(٧٢) في ٦ أبريل/نيسان، نشر موقع ناشيونال ريفيو الأمريكي تقريراً بعنوان: "كيف يمكن أن نحاسب الصين؟ منظمة الصحة العالمية تحابي الصين، لكننا لسنا مضطرين لذلك"، ناقش المسألة من منظور أمريكي يعترف باستحالة مقاضاة الصين في ظل القانون الدولي، لكنه وضع سيناريو أمريكياً لجعل بكين تدفع الثمن. التقرير عدّد الطرق المتاحة قانونياً وسياسياً من خلال النظام الدولي الحالي؛ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يمكنه إدانة الصين، فهي تتمتع بحق الفيتو شأنها شأن روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة (الأعضاء الخمسة الدائمين)، وحتى لو نجحت الدول الكبرى في رفع دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية وصدر بالفعل حكمٌ بإدانة الصين، فإنها ببساطة ستتجاهله.

<https://arabicpost.net/>

لقد أدت السرعة الكبيرة في انتشار فيروس كورونا المستجد وانتقاله، وعدم اليقين المستمر فيما يتعلق بخصائصه الوبائية إلى التشكيك في مدى فعالية النظام القانوني الذي حددته اللوائح الصحية الدولية (IHR) لعام ٢٠٠٥، وبالتالي المطالبة بتعديل هذه اللوائح وبآليات عمل المنظمة الدولية، لمواجهة مثل هذه الأزمات والجوائح مستقبلاً بفاعلية أكبر، وبجاهزية أقوى، وبعيداً عن المصالح والأهواء والمحاباة لأي أحد. وعليه فإننا، سنتناول دراسة هذا الموضوع والمسائل المرتبطة به على النحو التالي:

أولاً - نظرة عامة على اللوائح الصحية الدولية (لعام ٢٠٠٥)، ومدى فاعليتها في مواجهة الأوبئة والأمراض:

تعتمد منظمة الصحة العالمية في عملها على دستورها الذي تم إقراره في عام ١٩٤٦، وأيضاً على مجموعة من اللوائح الصحية الدولية التي تم اعتمادها - كما ذكرنا - في عام ٢٠٠٥، بعد انتشار وباء سارس في عام ٢٠٠٢-٢٠٠٣. حيث وفرت هذه الأزمة العالمية زخماً سياسياً من أجل التسريع في اعتماد هذه اللوائح وإقرارها لمواجهة انتشار الأمراض والأوبئة والتعامل معها بفاعلية^(٧٣). لقد كان اعتماد اللوائح الصحية الدولية من قبل جمعية الصحة العالمية، في ٢٣ أيار/ مايو ٢٠٠٥، نهاية جيدة، وموفقة، لعشر سنوات من التحديثات التقنية التي تمت من خلال اجتماعات وحلقات عمل، ومشاورات إقليمية ودون إقليمية، ودورتين عقدهما الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٤ وشباط/ فبراير وأيار/ مايو ٢٠٠٥^(٧٤). وهذه اللوائح، هي عبارة عن صك أو اتفاق قانوني دولي أُعد من أجل المساعدة على حماية جميع الدول من انتشار المرض على الصعيد الدولي. وقد بدأ نفاذها في حزيران/ يونيو، وتُعد هذه اللوائح في الوقت الراهن صكاً ملزماً قانوناً بالنسبة إلى ١٩٦ دولة طرف في جميع أنحاء العالم (الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية)^(٧٥). وركزت هذه اللوائح تقريباً- التي يرجع أصل نشأتها تاريخياً

(٧٣) نطاق تطبيق هذه اللوائح أوسع بكثير مقارنة باللوائح الحالية (١٩٦٩)، التي ينحصر تطبيقها في الإخطار بحالات الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء والاستجابة لمقتضياتها.

(٧٤) For more details about IHR see Talita, de Souza Dias and Antonio Coco Part II: Due Diligence and COVID-19: States' Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak, March 25, 2020 available at <https://www.ejiltalk.org/part-ii-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak/>

إلى القرن التاسع عشر ١٨٣٠-١٨٤٠ على وضع قواعد عامة لمواجهة انتشار وباء الكوليرا، والمخاطر الصحية العمومية الشديدة التي قد تنتشر عبر الحدود الدولية^(٧٦).

ومن خلال اللوائح الصحية الدولية، اتفقت الدول الأطراف على تعزيز قدرتها على الكشف عن أحداث الصحة العمومية، وتقييمها والتبليغ عن أية أحداث أو أخطار قد تحيط بها. وتتولى منظمة الصحة العالمية - كما بيّنا سابقاً - دور التنسيق في اللوائح الصحية الدولية، وتعمل مع شركائها على مساعدة الدول على تعزيز قدراتها في هذا المجال المهم. وتشتمل اللوائح الصحية الدولية أيضاً على التدابير المحددة، التي ينبغي اتخاذها في الموانئ والمطارات والمعابر البرية، من أجل الحد من انتشار المخاطر الصحية في الدول المجاورة، ومنع فرض القيود غير المبررة على السفر والتجارة، من أجل الحد من تعطل حركة المرور والتجارة إلى أدنى قدر ممكن^(٧٧). ووفقاً لما جاء في ديباجتها، فإن هذه اللوائح تهدف إلى أن تكون "الأداة العالمية الرئيسية للحماية من انتشار الأمراض على الصعيد الدولي"^(٧٨). لكن الأحداث التي تسارعت وتيرتها نتيجة لتفشي وباء كورونا المستجد، والتي فتكت بالصين، وكل دول العالم تقريباً طرحت عديداً من التساؤلات حول مدى نجاعة هذه الأداة القانونية وفعاليتها في تحقيق هذا الهدف، وكيف ستسهم في تحقيق ذلك^(٧٩).

ويتمثل الغرض من اللوائح ونطاقها، حسبما ورد في المادة ٢، فيما يلي:

(٧٥) https://www.who.int/ihr/legal_issues/brief_introduction_to_legislative_implementation_far.pdf

(٧٦) See for more details, Armin von Bogdandy and Pedro Villarreal "International Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis", file:///C:/Users/Admin/Downloads/SSRN-id3561650%20(1).pdf. See also Lauren Tonti, The International Health Regulations: The Past and the Present, But What Future? <https://harvardilj.org/2020/04/the-international-health-regulations-the-past-and-the-present-but-what-future/>.

(٧٧) تتولى إدارة القدرات والإنذار والاستجابة على الصعيد العالمي قيادة عمل منظمة الصحة العالمية الخاص بتنسيق تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية " <https://www.who.int/ihr/about/ar/>

(٧٨) لمزيد من التفصيل حول اللوائح الصحية الدولية انظر: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789246580491-ara.-pdf;jsessionid=87BCE0FE8125A7FA3D676D382DDB717E?sequence=8>

(٧٩) See for more details, PEDRO VILLARREAL The 2019-2020 novel coronavirus outbreak and the importance of good faith for international law, 28 January, 2020, <https://voelkerrechtsblog.org/the-2019-2020-novel-coronavirus-outbreak-and-the-importance-of-good-faith-for-international-law/>

"الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه، ومكافحته، ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية، ويقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية". وتتولى كل دولة طرف وفقاً للوائح تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق ٢. وتُخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفا وسيلة اتصال متاحة عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون ٢٤ ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، وفقاً للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأية تدابير صحية يتم تنفيذها استجابة لتلك الأحداث^(٨٠). ومن المواد المهمة التي تضمنتها اللوائح تلك المتعلقة بموضوع الإخطار الذي يتعين على الدولة التي يقع في أراضيها أي ظرف طارئ، يتعلق بالصحة، أن تبلغه للمنظمة، حيث جاء في نص المادة ٧ ما يلي: "إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية تثير قلقاً دولياً فعلياً أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ٦ بالكامل".

كما أنه يجوز للمنظمة وفقاً للمادة ٩ أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات، وتتولى تقييم هذه التقارير وفقاً للمبادئ الوبائية الراسخة، وأن تبلغ بعد ذلك بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. ويتعين على المنظمة، وقبل اتخاذ أي إجراء، بناء على هذه التقارير من هذا القبيل أن تتشاور مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث أو الطارئ الصحي في أراضيها، وأن تعمل - بطبيعة الحال - على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف؛ وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠ من هذه اللوائح.

(٨٠) انظر: نص المادة ١/٦ من اللوائح، وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. كما تواصل الدولة الطرف بعد إرسال أي إخطار موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية؛ وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها تحديد الحالات والنتائج المختبرية ومصدر ونوع الخطر المحتمل وعدد الحالات والوفيات والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة، وتبلغ عند اللزوم عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً"، انظر: المادة ٢/٦ من اللوائح الصحية الدولية.

وتحقيقاً لهذه الغاية يتعين على المنظمة أن تتيح للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها بهذا الخصوص، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل، وستستخدم هذه المعلومات وفقاً للإجراءات المحددة في المادة ١١^(٨١). أما المادة ١٠ فتعطي لمنظمة الصحة العالمية الصلاحية الكاملة في أن تطلب من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات، فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً، ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها^(٨٢).

ومما يجدر الإشارة إليه، أنه عملاً بأحكام الفقرة السابقة والمادة ٩ تقوم كل دولة طرف، وبناءً على طلب من منظمة الصحة العالمية بعمل التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص، وعليها أن تقدم ما يلي: أ - رداً أولياً على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية أو إقراراً بتسلم ذلك الطلب؛ وذلك في غضون ٢٤ ساعة. ب - المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة في غضون ٢٤ ساعة من حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية. عندما تستلم المنظمة معلومات عن حدث ما، وإنه قد يشكل طارئاً من طوارئ الصحة العمومية التي قد تثير قلقاً دولياً فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي، واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي، ومدى كفاية تدابير مكافحة....^(٨٣).

أما المادة ١١ فهي من المواد المهمة، وذات الصلة بأهمية دور المنظمة بالتعاون مع الدول الأطراف في تبادل المعلومات والتصدي لأية أمراض أو أوبئة يمكن أن تواجه الدول الأطراف، فقد جاء في نص المادة ١١ ما يلي: "رهنأً بأحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية عند الاقتضاء إلى الدول الأعضاء كافة، وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وبأكفاً وسيلة متاحة وبسرية المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية، والتي تلقتها بموجب المواد من ٥-١٠،

(٨١) راجع: نص المادة ١١ من اللوائح الصحية الدولية.

(٨٢) لمزيد من التفصيل حول اللوائح الصحية الدولية انظر:

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789246580491-ara.-pdf;jsessionid=87BCE0FE8125A7FA3D676D382DDB717E?sequence=8>

(٨٣) انظر: نص المادة ١٠ من اللوائح.

وهي معلومات لا بد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعد في منع وقوع حوادث مماثلة". ونشير إلى أن المنظمة وفقاً للفقرة ٢ من هذه المادة ستستخدم هذه المعلومات الواردة إليها في أغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات بشكل عام للدول الأطراف الأخرى، ما لم يتفق على غير ذلك، إلا في حالة أن يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً وفقاً للمادة ١٢، أو تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى، أو التلوث على النطاق الدولي وفقاً للمبادئ الوبائية المعمول بها، أو يتبين وجود أدلة على أن تدابير مكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي، لا يحتمل أن تنجح، أو أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض^(٨٤).

من المواد الأخرى ذات الصلة أيضاً بموضوعنا ما ورد في المادة ١٢، حيث تشير هذه المادة لمسألة إعلان حالة الطوارئ الصحية الدولية، والدور الذي يتمتع به مدير عام المنظمة، ولجنة الطوارئ الدولية بهذا الخصوص، فقد جاء في هذه المادة ما يلي: "يتولى المدير العام بالاستناد إلى المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، وفقاً للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. وإذا رأى المدير العام بعد إجراء التقييم المناسب لتلك المعلومات أن هناك طارئاً صحياً يثير قلقاً دولياً، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين مدير المنظمة والدولة الطرف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩ التمس الحصول على موافقة اللجنة المنشأة بموجب المادة ٤٨ والمعروفة بلجنة الطوارئ بشأن اتخاذ التوصيات المناسبة بهذا الخصوص. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بين مدير المنظمة والدولة الطرف حيال وجود طارئ صحي عمومي يثير قلق المجتمع الدولي في غضون ٤٨ ساعة يتخذ القرار وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩".

ولتحديد فيما إذا كان الحدث يشكل، أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، يتعين على مدير منظمة الصحة أن يراعي مجموعة من المعايير الأساسية مثل:

(٨٤) انظر المادتين ١١ و ١٢ من اللوائح الصحية الدولية.

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، والمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق ٢، ومشورة لجنة الطوارئ والمبادئ العلمية، وتقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان، والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي. أما إذا رأى المدير العام، وبعد التشاور مع الدول الطرف التي وقعت فيها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً قد انتهت في أراضيها، فإنه يتخذ قراراً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٩^(٨٥). ويصدر المدير العام إذا تم التأكد من حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً توصيات مؤقتة بهذا الخصوص وفقاً للإجراءات التي حدتها المادة ٤٩ من اللوائح. ويجوز للمدير تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الحاجة، بما في ذلك إمكانية تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن هذه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً قد انتهت. ويجوز أن تتضمن التوصيات المؤقتة اتخاذ بعض التدابير الصحية، التي يمكن للدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً أو دول أطراف أخرى أن تنفذها، فيما يخص الأشخاص أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية؛ للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي، ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي^(٨٦).

من هذا المنطلق، واحتراماً لهذه اللوائح المهمة فقد اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، في ٢٦ أيار/ مايو ٢٠٠٦، القرار رقم (ج ص ع ٥٩-٢) الذي دعا إلى الالتزام، فوراً وطواعيةً، بأحكام هذه اللوائح الوثيقة الصلة بالمخاطر التي تطرحها أنفلونزا الطيور وجائحة الأنفلونزا البشرية المحتملة^(٨٧). كما دعا جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، تحديداً، إلى تحديد مركز اتصال وطني يعني باللوائح. كما أكد القرار على ضرورة أن تقوم منظمة الصحة العالمية بتحديد نقاط اتصال تابعة لها تُعنى باللوائح الصحية الدولية، من أجل ضمان تدفق المعلومات على نحو مطرد بينها، وبين البلدان قبل حدوث الطوارئ الصحية العمومية، بما في ذلك احتمال وقوع جائحة من جوائح الأنفلونزا البشرية، وأثناء وقوعها وبعد انتهائها.

(٨٥) انظر: نص المادة ١٢ من اللوائح.

(٨٦) انظر: نص المادة ١٥ من اللوائح.

(٨٧) تم تحديد الأحكام المتعلقة بالترصد والإبلاغ، وتقاسم المعلومات، ونقل المواد البيولوجية، والتدابير الصحية العمومية المنطبقة على المسافرين، كأحكام ذات أهمية لضمان استجابة المجتمع الدولي بشكل قوي ومنسق لمقتضيات الوضع الراهن ومقتضيات الجائحة المحتملة

على حد سواء <https://www.who.int/ihr/voluntarycompliance06AR.pdf>

ويشير القرار إلى أن الاتصالات الفعالة والشفافة تُعد من الأمور الأساسية للكشف عن حالات الأنفلونزا البشرية، والإخطار بحدوثها في مراحل مبكرة، وتقييم المخاطر على وجه السرعة، والإسراع في تنفيذ التدابير المناسبة في مجالي الاحتواء والاستجابة في حال ظهور سلالة جائحة. كما يتعين على الدول التعاون فيما بينها من أجل تعزيز قدراتها في مجال إنتاج اللقاحات بدعم من منظمة الصحة العالمية، التي سيكون الدور المنوط بها السعي إلى الحد من نقص اللقاح المضاد للأنفلونزا، وزيادة فرص الحصول عليه بأسعار معقولة من أجل التصدي للأوبئة والجوائح العالمية على حد سواء. كما أن من الأمور التي ركز عليها القرار المسؤوليات المشتركة بين الدول الأعضاء والمنظمة، وأهمية حشد الموارد البشرية والمالية والتقنية واللوجستية اللازمة لتحسين تأهب العالم واستعداده لمواجهة جائحة بشرية محتملة، بما في ذلك العمل الدؤوب على توفير مخزون احتياطي معقول من الأدوية الأساسية^(٨٨).

مما تقدم، تظهر لنا أهمية هذه اللوائح في تقدير الأحداث والحالات التي يمكن أن تشكل أو لا تشكل طارئاً دولياً، ودور منظمة الصحة العالمية في تحديد ذلك كله، ففور المنظمة ومدى نجاحها وفعاليتها ومتابعتها للأوبئة والأمراض المختلفة يعتمد إذاً على تعاون الدول الأطراف في توفير المعلومات والبيانات اللازمة عند حدوث أي خطر أو حادث قد يشكل طارئاً صحياً يثير قلقاً دولياً^(٨٩). فثمة شراكة أساسية ضرورية بين المنظمة والدول الأطراف، والنجاح في مواجهة أي طارئ صحي يحتاج توافر المعلومات الموثوقة والدقيقة من جانب الدول الأطراف، وعدم التستر على أي شيء بهذا الخصوص لمعالجة الأوضاع والتعامل معها بكل جدية وصرامة، خاصة أن مثل هذه الأمور والمسائل حساسة ومهمة، ولا يمكن التهاون فيها، فعدم المصادقية أو الشفافية، لاسيما في حالات الطوارئ الصحية الدولية، سيكون له عواقب وخيمة، ليس على الدولة الطرف وحدها، بل على جميع دول العالم، وقد رأينا بأن أعيننا ما آلت إليه الأوضاع والأمور عقب تفشي وباء كورونا، والنتائج المأساوية التي خلفها على الكون بأسره؛ بسبب عدم التعاطي بشفافية مع هذا الفيروس الخطير من جانب السلطات الصينية.

بناءً على ذلك، نقول إن الضبابية والتعتيم الإعلامي والتقاعس في إخطار المنظمة

<http://www9.who.int/ihr/voluntarycompliance06AR.pdf>

(٨٨)

See also Lauren Tonti, The International Health Regulations: The Past and the Present, But What Future? <https://harvardilj.org/2020/04/the-international-health-regulations-the-past-and-the-present-but-what-future/>.

(٨٩)

بجميع المعلومات اللازمة، وعدم الجدية في التعامل مع هذا الفيروس، والتقليل من مخاطره وأضراره، قادت إلى حدوث ما يزيد عن أربعة ونصف مليون إصابة، وما يزيد عن ربع مليون وفاة حول العالم. كما طرحت هذه المسألة بعض التساؤلات التي أثرتنا بعضها سابقاً حول مدى التزام الصين باحترام هذه اللوائح، وتفعيلها في هذه الأزمة، وهل هي فعلاً التزمت بواجباتها ومسؤولياتها القانونية المقررة بهذا الصدد أم لا؟ وهل فعلاً طبقت نص المادة السادسة المتعلقة بتقييم الأحداث التي وقعت على أراضيها، والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا بطريقة صحيحة ودقيقة أم لا؟ وهل أخطرت منظمة الصحة العالمية، وفي غضون ٢٤ ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية المتعلقة بجميع الأحداث، التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، والتي وقعت في أراضيها على إثر انتشار هذا الفيروس وتفشيه أم لا؟ وماذا عن التدابير الصحية التي تم اتخاذها استجابة لتلك الأحداث، هل كانت فعلاً مناسبة وكافية أم لا؟ وماذا عن التزام الصين أيضاً بنص المادة ٧، هل زودت الصين - بعد ظهور الفيروس وبدء انتشاره - منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية، والتي شكلت فعلياً طارئة صحية أثارت قلقاً دولياً عاماً في كل العالم أم لا؟ وماذا عن دور منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص؟ هل تأخر المدير العام للمنظمة في إعلان حالة الطوارئ الصحية الدولية أم لا؟ وهل ثمة تواطؤ أو تستر مع الصين بهذا الخصوص أم لا؟^(٩٠).

إن هذه كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة، حاولنا أن نتصدى لبعضها في هذا البحث، وربما قد يحتاج بعضها إلى مزيد من الوقت قبل أن تصبح الرؤية حولها واضحة وجلية، فالأمر جد خطير، واللاعبان الأساسيان المعنيان بالموضوع وهما الصين والولايات المتحدة اللذان يملكان المعلومات حول هذا الموضوع، قد لا يبوحان بكل شيء في هذه المرحلة؛ لأغراض وغايات خاصة بهما. وقد يحتاج الأمر - كما أشرنا سابقاً - إلى تحقيق دولي شفاف للوقوف على حقيقة ما جرى. وهنا أود الإشارة إلى ما أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي من أن بلده سوف تطرح هذا الموضوع على جمعية الصحة العالمية في اجتماعها القادم في شهر مايو^(٩١). هل ستنتج أستراليا والدول التي ترغب بمثل هذا الإجراء في هذه الخطوة أم لا؟ وهل ستكون هناك عقبات وعراقيل قد تحول دون ذلك؟ إن هذه تساؤلات ليس من السهولة بمكان

(٩٠) انظر: نصوص المواد ٦ و ٧ و ١٢ من اللوائح الصحية الدولية لعام ٢٠٠٥.

(٩١) <https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/27>

معرفة إيجابتها في ظل تعقيدات المشهد العالمي، وتقاطع مصالح بعض الدول مع بعضها بعضاً، أو أحياناً تعارضها، ستكون الأيام والأشهر القادمة مليئة بالأحداث التي قد توفر بعض المعلومات حول كل ما يُثار ويُطرح بهذا الخصوص، وإن غداً لناظره قريب.

ثانياً – الإطار القانوني لمساءلة الصين: الخيارات القانونية المتاحة:

لقد بدأ بعض الخبراء والمختصين يطرحون في ضوء انتشار هذا الوباء – كما ذكرنا سابقاً – موضوع مسؤولية الصين من الناحية القانونية عن تفشي هذا الوباء، والأسس القانونية التي يمكن الاستناد إليها لتقرير هذه المسؤولية القانونية، خاصة أن عدة حكومات ومنظمات غير حكومية أَلقت باللوم على الصين لفشلها في السيطرة على تجارة الحيوانات البرية التي يمكن أن تستضيف الفيروس، وكذلك للتستر على التحذيرات الأولية من المرض في ووهان. فهل الموضوع هنا يتعلق بموضوع المسؤولية الدولية فحسب عن تفشي هذا الوباء، أم أن هناك معايير أو مبادئ أخرى يمكن أن تطرح في هذا الصدد مثل موضوع حسن النية، ومدى التزام الدول باحترامه، وتقدير الصين ومنظمة الصحة العالمية وتقاعسهما، وعدم فاعلية لوائح المنظمة الصحية بهذا الصدد؟^(٩٢). في تقرير كتبه جيمس كراسكا، أستاذ القانون الدولي، ونُشر يوم ٢٣ مارس/آذار/٢٠٢٠ بعنوان: "الصين مسؤولة قانونياً عن كوفيد-١٩، والتعويضات قد تصل لتريليونات"، استشهد بحقيقة تعتمد السلطات الصينية إخفاء المعلومات عن شعبها وإصدار تلميحات زائفة بخصوص الفيروس، كما استشهد بعدد من التقارير الإخبارية المحلية في الصين التي تحدثت عن وجود فيروس غامض يشبه فيروس "سارس" بنسبة ٧٥٪، بدأ بالظهور في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما أعد ماثيو هندرسون – وهو دبلوماسي بريطاني سابق في الصين ويعمل حالياً كمدير لمركز دراسات آسيا – تقريراً يشير إلى ضرورة مقاضاة الصين ومطالبتها بتعويضات مالية تصل لحوالي ٦,٥ تريليون دولار؛ بسبب التستر على تفشي الفيروس، وإخفاء المعلومات المتعلقة به، في وقت كان يمكن فيه – لو كانت الحكومة الصينية شفافة – محاصرته والقضاء عليه قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية؛ بسبب الملايين الذين غادروا مدينة ووهان، في الفترة من منتصف

Antonio Coco and Talita de Souza Dias, Part I: Due Diligence and COVID-19: States' Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak, March 24, 2020, available at <https://www.ejiltalk.org/part-i-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak/>.

ديسمبر/كانون الأول و٢٣ يناير/كانون الثاني، عندما اتخذت الصين قرار إغلاق المدينة. لكن ما الأحكام أو النصوص ذات الصلة التي يمكن الاستناد إليها في القانون الدولي، وفقاً لهندرسون لتقرير هذه المسؤولية؟ يستند هندرسون وغيره من المطالبين بمقاضاة الصين على المادتين ٦ و٧ من لوائح الصحة الدولية التي سبق الإشارة إليهما، وهي - كما قلنا سابقاً - لوائح دولية تنفيذية قبلت بها الصين، وهي بالتالي ملزمة من الناحية القانونية باحترامها وتنفيذ بنودها وأحكامها بكل دقة.

وعند مطالعة نصوص هذه اللوائح، نرى أن هناك بعض المواد التي ينبغي التوقف عندها، والتي قد تؤسس لمسؤولية الصين في حالة ثبوت تعمدتها في إخفاء المعلومات، أو عدم الشفافية حول هذا الفيروس، فالمادة ٦/١ تطلب من الدولة الطرف إبلاغ منظمة الصحة العالمية، في غضون ٢٤ ساعة، بالأحداث التي قد تشكل "حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي". وقد بيّنت اللوائح أن المقصود بعبارة "الطائفة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً" بأنها حدث صحي عمومي يشكل خطراً محتملاً يحق بالصحة العمومية في الدول الأخرى؛ وذلك بسبب انتشار المرض دولياً، وقد يقتضي استجابة دولية منسقة. كما يجب على الدول الأطراف الإبلاغ عن البيانات الدالة على وجود مخاطر محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها، ويحتمل أن تتسبب في انتشار أحد الأمراض على الصعيد الدولي^(٩٣). ويتم توجيه الإخطارات والتقارير - وفقاً لتلك اللوائح - إلى منظمة الصحة العالمية عبر مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية. ويجب على المنظمة، من جهتها، تحديد نقاط اتصال من أجل تيسير الحوار بينها وبين الدول الأطراف. ويجوز للمدير العام، لدى تلقي مشورة من إحدى لجان الطوارئ، وإذا رأى أن أحد البلدان يشهد حدوث طائفة من الطوارئ المذكورة، فله أن يقدم توصيات مؤقتة من أجل الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي، أو الحد منه

(٩٣) تشير الوثائق المؤسسية الأخيرة إلى التحقيق الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في ٤٤٠ "حدثاً" متعلقاً بالصحة خلال عام ٢٠١٩. ويرتبط العدد الأكبر من هذه الأحداث بالأمراض المعدية. في الماضي، أدى تقرير أو اثنان من بين هذه المئات من التقارير إلى استدعاء لجنة طوارئ لتقرير ما إذا كان الإعلان عن PHEIC له ما يبرره. تعكس هذه الأرقام مدى معالجة المنظمة لمعلومات الدول الأعضاء. وبالنظر إلى كيفية اتخاذ هذا القرار بسرعة (في بعض الأحيان، في غضون ساعات)، فإن تفسير محتويات اللوائح الصحية الدولية من قبل مسؤولي منظمة الصحة العالمية - مع السلطة المقيمة في نهاية المطاف لمديرها العام - يحدث تقريباً على أساس يومي.

وتجنب التدخل، على نحو لا داعي له، في حركة النقل الدولي^(٩٤). أما المادة ٧ من اللوائح ذاتها فتتص - كما ذكرنا سابقاً - على أن تلتزم كل دولة بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بشكل فوري عن ظهور أي مرض معدٍ داخل حدودها، وأن تسهل عمل منسوبي المنظمة في جهود استكشاف واحتواء العدوى، وأن تسارع على الفور وفي غضون ٢٤ ساعة إلى "تزويد منظمة الصحة العالمية بجميع المعلومات الصحية العمومية ذات الصلة"^(٩٥). كما أنه يجوز لمنظمة الصحة العالمية وفقاً لنص المادة ٩ (١) من اللوائح الصحية الدولية أن تأخذ في الاعتبار التقارير الواردة من مصادر أخرى غير السلطات، فالدول ليست هي المصادر الحصرية للمعلومات، ومع ذلك فإن منظمة الصحة العالمية ملزمة بموجب المادة ١٠ (١) من اللوائح الصحية الدولية بالتحقق من جميع التقارير المقدمة من خلال القنوات غير الحكومية مع الدول ذاتها. كما يمكن وفقاً لنص المادة ١٠ (٤) من اللوائح الصحية الدولية تهميش الدول الأطراف في حالة عدم التعاون في هذا المجال^(٩٦).

لذلك، وبناءً على ما تقدم، يمكن المجادلة بأن الصين، ربما تكون قد انتهكت قواعد القانون الدولي من خلال تأخرها الواضح في إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأكثر من شهر أو ربما شهرين تقريباً، في حين أن اللوائح الصحية الدولية تفرض الإبلاغ والرصد الوطني لتفشي الأمراض التي يمكن الإبلاغ عنها. فقد اتُهمت الصين، وهي دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، بمراقبة المعلومات وحجبها منذ بداية تفشي المرض، منتهكة بذلك - كما أوضحنا سابقاً - واجباتها وفقاً لما تنص عليه المادتان ٦ و ٧ من اللوائح الصحية الدولية^(٩٧). وقد أدى هذا الأمر إلى تأخر منظمة الصحة العالمية في الاعتراف السريع بوجود حالة "طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي" التي أشارت إليها المادة ٦ في فقرتها الأولى، فالسلطات الصينية كانت لديها في الغالب حالات مصابة بمرض شبيه بمرض السارس في ديسمبر ٢٠١٩، ولكنها للأسف لم تتعامل مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تبدأ السلطات الصينية بالتحرك السريع والعاجل للتعامل معه^(٩٨). كما أن التقارير

(٩٤) <http://www9.who.int/ihr/voluntarycompliance06AR.pdf>

(٩٥) راجع: نص المادة ٧ من اللوائح.

(٩٦) انظر: نصوص المادتين ٩ و ١٠ من اللوائح.

(٩٧) See also Lauren Tonti, The International Health Regulations: The Past and the Present, But What Future? <https://harvardilj.org/2020/04/the-international-health-regulations-the-past-and-the-present-but-what-future/>.

(٩٨) Ibid.

قد أشارت إلى أن تكتيكات إدارة الأزمة في الصين منذ ظهور المرض، مثل التدابير المتعلقة بالرقابة والحجر الجماعي، تنتهك حقوق الإنسان والحريات المدنية، وهو أمر لم تلتزم به الصين خلافاً لأحكام المادة ٣ من اللوائح الصحية الدولية، التي تنص صراحةً على احترام "الكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص" (٩٩).

كما يمكن الادعاء بأن الصين قد انتهكت المادتين ٢١ و ٢٢ من دستور منظمة الصحة العالمية وللتين تمنحان جمعية الصحة العالمية سلطة اعتماد لوائح تنفيذية (مثل اللوائح الصحية الدولية) (١٠٠)، وتتعلق هذه اللوائح ببعض الأمور الأخرى مثل الاشتراطات الصحية، وإجراءات الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات التي يراد منها منع تفشي الأمراض والأوبئة على الصعيد الدولي، والتسميات المتعلقة بالأمراض، والمعايير المتعلقة بالتشخيص، وأسباب الوفاة وممارسات الصحة العامة (١٠١). كما أن المادة ٦٣ تلزم الدول الأعضاء بإبلاغ المنظمة بما ينشر فيها من قوانين وأنظمة وتقارير رسمية وإحصائيات مهمة فيما يتعلق بالصحة، وضرورة أن يقدم كل عضو تقارير إحصائية ووبائية بطريقة تحددها جمعية الصحة (١٠٢). وكذلك يتعين على الدول الأعضاء أن ترسل، وبناءً على طلب المجلس، أية معلومات إضافية تتعلق بالصحة العامة (١٠٣).

بناءً على ما تقدم، نقول إن لدى الصين كثيراً من النقاط، التي لو فُتح تحقيق دولي حولها لزاد الأمر تعقيداً، فهناك جملة من الاتهامات والأقاول حول إدارة الصين للأزمة، وكيفية تعاطيها مع هذا الوباء، لا سيما بعض التقارير التي تقول بأن هناك تقصيراً وتفاعلاً من جانب السلطات الصينية في إدارة هذا الملف الشائك. ونشير في هذا السياق إلى أن اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، التي تتكون من القيادة العليا للحزب الشيوعي الصيني، قدمت في أوائل فبراير اعترافاً نادراً بوجود "أوجه النقص والقصور والثغرات" في استجابة البلاد لهذا الوباء الفتاك، كما دعت اللجنة بشكل

(٩٩) راجع: نص المادة ٣ من اللوائح.

(١٠٠) تنص المادة ٢٢ على أن: "الأنظمة التي تعتمد وفقاً لنص المادة ٢١ تصبح ملزمة لجميع الدول الأعضاء بعد تلقي إشعار بتصديق الجمعية عليها، ويستثنى من ذلك الدول التي تخطر المدير العام برفضها أيها أو بتحفظاتها عليها في خلال المدة المحددة بالإشعار" <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/constitution-ar.pdf> لمزيد من التفصيل انظر د. ياسر الخلايلة، هل يمكن مساءلة الصين قانونياً عن تفشي وباء كوفيد - ١٩، مقال منشور متوافر <https://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=606327> انظر: د. ياسر الخلايلة، المسؤولية القانونية الدولية عن وباء كوفيد-١٩ <https://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=606537>

واضح إلى ضرورة تحسين "نظام إدارة الطوارئ الوطنية في البلاد، وتحسين قدراتها في التعامل مع المهام العاجلة والخطيرة".

كما أن هناك من يطرح مسألة التزام الصين بمبدأ التحوط، أو اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة "العناية الواجبة" "Due diligence"، هو التعبير المستخدم عادة لتعيين معيار للسلوك، والذي يقيس فيما إذا كانت الدولة قد بذلت قصارى جهدها لمعالجة بعض المخاطر أو التهديدات أو الأضرار أم لا. باختصار، هو معيار للحكم الرشيد، وتقييم ما إذا كانت الدولة قد فعلت ما كان متوقعاً منها بشكل معقول عند الاستجابة لضرر أو خطر أم لا، وهذا المعيار مدمج ومدرج في سلسلة من قواعد القانون الدولي التقليدي والعرفي التي تنطبق بشكل عام على العلاقات بين الدول، أو على وجه التحديد في مجالات معينة مثل البيئة، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والفضاء السيبراني، وعلى الأخص، الصحة العامة العالمية. وتفرض هذه القواعد عادة التزامات بسلوك يتطلب من الدول منع و/ أو وقف و/ أو إصلاح مجموعة من الأضرار الداخلية أو العابرة للحدود، أو الخطر الناشئ عن ذلك، ولكن يقتصر بعضها بالتزامات الإجرائية للنتائج، مثل تقييمات المخاطر وتبادل المعلومات. والأهم من ذلك أن أي إجراء تتخذه الدولة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعناية الواجبة "Due diligence" يجب أن يكون متسقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الأخرى، مثل مبدأ عدم التدخل وحظر استخدام القوة^(١٠٤). ونشير إلى أنه من بين أمور أخرى، توجد في الحقيقة خمسة واجبات مختلفة للعناية الواجبة ذات صلة محتملة بانتشار كورونا المستجد أو COVID-19: أ- مبدأ عدم الضرر، ب- واجب حماية الحق في الحياة، ج- واجب حماية الحق في الصحة، د- عدة التزامات بموجب اللوائح الصحية الدولية لعام ٢٠٠٥، هـ- وواجبات حماية الأشخاص في حالات الكوارث^(١٠٥).

(١٠١) انظر: نص المادة ٢١ من دستور منظمة الصحة العالمية.

(١٠٢) انظر: نص المادة ٦٤ من دستور المنظمة.

(١٠٣) انظر: المادة ٦٥ من دستور المنظمة.

(١٠٤) لمزيد من التفصيل حول القانون الدولي لحقوق الإنسان انظر: د. مخلص الطراونة ود. عبد الصمد سكر، الوسيط في حقوق الإنسان، دار وائل للنشر والتوزيع، ط ١، ٢٠١٩.

(١٠٥) For more details about IHR see Talita, de Souza Dias and Antonio Coco Part II: Due Diligence and COVID-19: States' Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak, March 25, 2020 available at <https://www.ejiltalk.org/part-ii-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak/>

كما أن هناك من يرى أن الصين قد انتهكت وخالفت كذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة، المؤرخة في ١٠ أبريل ١٩٧٢، التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٦ مارس ١٩٧٥. والصين كما هو معلوم طرف أساسي في هذه الاتفاقية التي تعالج موضوعاً مهماً، يتعلق بهذا السلاح الخطير. وقد جاء في نص المادة الأولى من الاتفاقية أن تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تعتمد أبداً، في أي ظرف من الظروف إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر: ١ - العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى، أو التكسينات أياً كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من الأنواع، وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى، ٢ - الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل أو التكسينات في الأغراض العدائية أو المنازعات المسلحة.

لا شك أن انتهاك هذه المادة في حالة ثبوته، إضافة لتأخر الصين المعتبر الذي سبق الإشارة إليه في إبلاغ منظمة الصحة العالمية أمانة يمكن الاحتجاج بهما من الناحية القانونية في تأسيس مسؤولية الصين، وفقاً للقانون الدولي باعتبارها خالفت وانتهكت التزاماً تعاقدياً يقع على عاتقها احترامه والالتزام به، وهو خرق أحكام اتفاقية الأسلحة البيولوجية المشار إليها سابقاً^(١٠٦). وهنا يمكن - كما يرى البعض - للدول الأطراف في الاتفاقية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الحكومة الصينية لمخالفاتها لالتزاماتها الدولية، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين؛ باعتبار أن هذه الأسلحة تعد من الأسلحة المحظورة دولياً. وللمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً من تدابير بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى صعوبة مثل هذا الخيار من الناحية العملية، حيث إن اتخاذ أية تدابير، حتى وإن كانت بسيطة، ربما سيصطدم بالفيتو الصيني الروسي الذي قد يبذل أية آمال لأي عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة التي اتهم رئيسها الصين صراحةً بأنها وراء انتشار هذا الفيروس، وأنها لم تتعامل بشفافية ووضوح مع هذا الفيروس، وأنها قد تسترت على كثير من الأشياء المرتبطة به، وهو ما أدى إلى انتشاره، وأودى بحياة آلاف من الأمريكيين، وجعل الولايات المتحدة من أكثر الدول المتضررة إنسانياً واقتصادياً من تداعيات هذا الوباء. كما نشير إلى مسألة في غاية الأهمية هنا، وترتبط بموضوع المسؤولية، وهي الانتكاء

(١٠٦) لمزيد من التفصيل حول تعريف المسؤولية الدولية والأحكام المتصلة بها انظر: د. مخلد الطراونة، القانون الدولي العام، منشورات دار وائل للنشر والتوزيع، ط ٣٢٦-٣٧٦.

على مبدأ عدم الضرر (non-harm-principle)، فقد تم التعبير عن مبدأ عدم الضرر في عدد من القضايا الدولية مثل قضية ألاباما، ومصهر تريل، والأسلحة النووية، وكذلك في عمل لجنة القانون الدولي بشأن مسودة المواد حول المسؤولية الدولية لعام ٢٠٠١ بشأن منع الضرر العابر للحدود. ويقتضي من الدول، وفقاً لهذا المبدأ، أن تمنع وتوقف وتعالج الضرر الجسيم العابر للحدود للدول الأخرى، أو سكانها الناشئين أو العابرين لأراضيها، أو أي منطقة أخرى خاضعة لولايتها أو سيطرتها. وكما هو الحال في مبدأ العناية الواجبة، فإن مبدأ عدم الضرر لا يتطلب من الدول منع حدوث الضرر أو إيقافه بالفعل. وبدلاً من ذلك، فإنه يتطلب من الدول محاولة القيام بذلك، أو تقليل مخاطر ذلك، إلى أقصى حد من قدراتها^(١٠٧). وينشأ هذا الالتزام منذ اللحظة التي تعرف فيها الدول، أو كان يجب أن تعرفها عن الضرر، أو الخطر الناجم عن ذلك^(١٠٨). كما إن تناول البعض لموضوع تفشي هذا الوباء، وانعكاساته على تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية الحق في الحياة، والحق في الصحة العامة التي كفلتها الصكوك الدولية، يزيد المشهد تعقيداً في طرح مسؤولية الصين عن هذا الوباء، ومدى التزامها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون الصحة الدولي (أو اللوائح الدولية الصحية) بهذا الخصوص.

خلاصة القول هنا، نقول إن انتشار وباء كورونا / COVID-19 يمكن أن يطرح كل النقاط التي ذكرناها سابقاً، فقد ثبت الآن علمياً، وبات معروفاً على نطاق واسع أن هذا الفيروس قد سبب عواقب صحية واسعة النطاق وكارثية، أدت إلى عشرات آلاف من الوفيات خارج الحدود الوطنية. وبالتالي، فإن جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان التفشي نشأ في إقليمها، ملزمة ببذل قصارى جهدها، بالقدر الذي تسمح به قدراتها، لوقف انتشار هذا الفيروس الخطير إلى بلدان أخرى، ومنع المزيد من تفشي المرض وانتقاله لغيرها.

لكن هل يمكن في ضوء ما قيل سابقاً محاسبة الصين وفقاً لتلك المبادئ، خاصة التسبب بالضرر، ومخالفة اتفاقية الأسلحة البيولوجية؟ وما البدائل الأخرى

(١٠٧) (انظر: مسودة المواد المتعلقة بالوقاية، في ١٥٣-١٥٤) For more details about IHR see Talita, de Souza Dias and Antonio Coco Part II: Due Diligence and COVID-19: States' Duties to Prevent and Halt the Coronavirus Outbreak, March 25, 2020 available at <https://www.ejiltalk.org/part-ii-due-diligence-and-covid-19-states-duties-to-prevent-and-halt-the-coronavirus-outbreak/>

(١٠٨) (انظر: مشروع المواد المتعلقة بالوقاية، في ١٥٥، التعليق على المادة ٣، الفقرة ١٨).

المتاحة في حالة تعذر ذلك؟ إن صعوبة تحقق هذا الخيار من الناحية العملية، في ظل النظام الدولي الحالي، قد يقود إلى ضرورة البحث عن خيارات وبدائل أخرى، قد تكون أيضاً رغم توفرها من الناحية القانونية، صعبة المنال في ظل القوة التي تتمتع بها الصين. وهذا الخيار يتمثل بالرجوع لمحكمة العدل الدولية، إذا أمكن إثبات التستر وإخفاء المعلومات من جانب الصين وتقصيرها، أو ربما تعمدتها في إبلاغ الدول، ومنظمة الصحة العالمية، وفقاً للوائح الدولية الصحية التي سبق الإشارة إليها. ولكن كيف يمكن تحريك الدعوى؟ ومن سيعلق الجرس، ويبدأ فعلاً بتلك الإجراءات، وعلى أي أساس؟ وهل الدول، بما فيها الدول الغربية، تملك الجرأة للقيام بذلك؟ من الناحية النظرية، نقول إن الولايات المتحدة هي من حمل لواء توجيه الاتهامات ضد الحكومة الصينية في نشر الوباء، والمسؤولية عن تفشيه في العالم، وهذا - كما قلنا - لم يعد سراً، فالرئيس الأمريكي أعلنها مراراً وتكراراً وعلى الملأ كله أن هذا الفيروس، كما يحلو له أن يسميه بالفيروس الصيني، وأنه خرج من مختبراتها في ووهان، وأنها تسترت على كثير من الأمور المتعلقة به^(١٠٩). إذن الولايات المتحدة تستطيع بما لديها من قوة سياسية، وإمكانات اقتصادية مقارعة الصين، لاسيما أن العلاقات بين البلدين ليست في أفضل حالتها منذ اعتلاء الرئيس ترامب دفة السلطة في الولايات المتحدة، فالحرب التجارية والاقتصادية بين البلدين اشتعل أوارها، واشتد لهيبها من خلال حرب الرسوم التي بدأها الرئيس الأمريكي لضرب الاقتصاد الصيني الذي بات يهدد الولايات المتحدة، واقتصادها الكبير، ودورها في قيادة العالم. إن ظهور هذا الفيروس، وانتشاره، وتوجيه الاتهامات للصين بالوقوف ورأه، جعل هذه العلاقة تزداد سوءاً، والحرب الكلامية بين الطرفين لا زالت مستعرة، فالولايات المتحدة تكيل الاتهامات بهذا الخصوص، والصين تنفي مسؤوليتها عن هذا الفيروس إطلاقاً^(١١٠).

(١٠٩) وكانت وثيقة استخباراتية ألمانية، نشرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قد أشارت إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضغط شخصياً على المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وجاء في الوثيقة الأمنية، أنه "في ٢١ يناير، طلب الرئيس الصيني من رئيس منظمة الصحة حجب المعلومات حول انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان وتأخير التحذير من الجائحة". - <https://www.skynewsarabia.com/world/1344015>

(١١٠) أشار تقرير للوكالة إلى أن الصين مارست ضغطاً على منظمة الصحة العالمية، لتأخير التحذيرات العامة بشأن فيروس كورونا في وقت مبكر من تفشي الوباء. وجاء في التقرير: "نعتقد أن الصين ضغطت على منظمة الصحة العالمية للتهوين من خطر الإصابة بفيروس كورونا في يناير، بينما تحفظت بكين على الإمدادات الطبية"، وفقاً لما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأميركية. ويتناغم تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية مع اتهامات إدارة الرئيس =

صفوة القول، أن الولايات المتحدة يمكن لها تحريك الدعوى من الناحية النظرية، ولكن الأمر ليس بالسهولة التي ربما يتصورها البعض، فإجراءات التقاضي أمام المحكمة تحتاج ابتداءً إلى اتفاق الطرفين، أو الأطراف المتنازعة على إحالة الخلاف أو النزاع إلى المحكمة؛ لكي تتمكن الأخيرة من النظر في الموضوع وفقاً لولاياتها القضائية الاختيارية، فالقضاء الدولي هو قضاء اختياري، وليس إلزامياً، ويكون إلزامياً في حالة وجود اتفاق مسبق على القبول باختصاص المحكمة مقرر سواء في اتفاقية، أو من خلال إعلان بقبول الولاية الإلزامية للمحكمة، يُرسل للأمين العام للأمم المتحدة، قبل أو أثناء قيام النزاع، حسب ما يقرره النظام الأساسي للمحكمة^(١١١). وعلى الرغم من أن هناك من يرى بأنه يمكن الاعتماد على المادة ٥٦ من لوائح الصحة الدولية (IHR)، والخاصة بوسائل فض المنازعات من هذه المشكلة^(١١٢)، إلا أن هذا استنتاج يخالف صحيح القانون الدولي، حيث إن قواعد وآليات اللجوء إلى التحكيم الدولي تحتاج - كما هو معلوم - لموافقة الدول الأطراف في النزاع على اللجوء إلى التحكيم ابتداءً كما ذكرنا، وهو أمر ليس باليسير في مثل هذه الحالة، ولا يمكن قبوله أو الموافقة عليه من جانب الصين، التي ترفض جملة وتفصيلاً هذه المزاعم والادعاءات التي تعتبرها باطلة، وأن الغاية منها تحقيق أهداف وأجندات سياسية^(١١٣).

أمام صعوبة الخيارين السابقين، ربما يطرح البعض فكرة رفع قضايا أمام المحاكم الداخلية للدول المتضررة من هذا الوباء مثل المحاكم الأمريكية أو المحاكم الأوروبية على أساس فكرة المسؤولية الدولية المدنية^(١١٤)، وقد سبق القول، أن هناك من بدأ فعلاً بالتحضير لذلك، وهذا يمكن أن يحدث من خلال الحصول على أحكام قضائية من المحاكم الأمريكية التي لديها السلطة في ذلك، وهذا يكون بالعادة بحجز وتجميد الأصول والأموال التي تملكها الحكومة الصينية، والشركات الصينية المملوكة

= دونالد ترامب إلى الصين، بشأن احتمال تسرب الفيروس القاتل من معامل مدينة ووهان، فضلاً عن تستر بكين على الوباء. وذكر التقرير أن الصين هدّدت بوقف التعاون مع تحقيقات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، إذا أعلنت المنظمة الدولية أن التفشي يستلزم "حالة طوارئ صحية عالمية". - <https://www.skynewsarabia.com/world/1344015>

(١١١) د. مخلص الطراونة، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ٤١٦-٤١٩.

(١١٢) انظر: نص المادة ٥٦ من اللوائح الصحية الدولية.

(١١٣) د. ياسر الخلايلة، هل يمكن مساءلة الصين قانونياً عن تفشي وباء كوفيد - ١٩ <https://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=606327>

(١١٤) لمزيد من التفصيل حول المسؤولية الدولية انظر: د. مخلص الطراونة، القانون الدولي، مرجع سابق، وانظر: د. غسان الجندي، المسؤولية الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٠.

لها في حالة ثبوت مسؤوليتها عن الوباء، من أجل إجبارها على دفع تعويضات عادلة عن الأضرار التي تسببت بها. وهذا السيناريو هو خطوة في سلسلة من الإجراءات تشمل اتخاذ إجراءات قانونية أمام محاكم أمريكية، تمكن الإدارة من إسقاط الديون الصينية لحكومات دول في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، في إطار مبادرة الحزام والطريق التي يستغلها الرئيس شي بين جينغ لفرض نفوذ الصين حول العالم^(١١٥). ونشير في هذا السياق إلى الدعوى التي رفعتها ولاية ميزوري ضد الصين، حيث قررت هذه الولاية الأمريكية مقاضاة الحكومة الصينية بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد. وفي الدعوى المقدمة، يقول المدعي العام لولاية ميزوري، إريك شميت، إن الصين لم تفعل الكثير لوقف انتشار الفيروس، كما أشار إلى أن سكان الولاية قد عانوا بسبب أضرار اقتصادية قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. وقد انتقدت الحكومة الصينية هذه الخطوة، واعتبرت أن هذه "الدعوى تافهة، وليس لديها أي سند قانوني، وليست مبنية على حقائق". وقال المتحدث باسم الوزارة: "هذا أمر غريب بالفعل، فحسب مبدأ المساواة في السيادة، ليس للمحاكم الأمريكية أية سلطة على الحكومة الصينية"^(١١٦).

أما في حالة لجأت الصين إلى مقاضاة تلك الدول عن تلك الإجراءات المتخذة ضدها، فإنه قد يتم حينذاك الاحتكام للقانون الدولي، فيما يخص تفشي الوباء، ومسؤولية الصين عنه من الناحية القانونية أمام الجهات القضائية الدولية كمحكمة العدل الدولية مثلاً. ولكن الإشكالية تكمن هنا مرة أخرى في كيفية حصول ذلك، فالدول تملك حصانة قضائية شبه مطلقة، ولا يمكن الحجز على أصولها وممتلكاتها، وحتى لو تم ذلك فرضاً فكيف يمكن تنفيذ مثل هذه الأحكام، فالدول تملك حصانة قضائية - كما ذكرنا - من الأحكام القضائية وعملية تنفيذها. وقصة التجاهل، وعدم الاكتراث من الجانب الصيني قد لا تكون أمراً افتراضياً، فهناك سابقة بالفعل عندما أصدرت محكمة التحكيم الدائمة التابعة للأمم المتحدة قراراً قانونياً بأن قيام الصين ببناء جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي هو انتهاك للقانون الدولي، تجاهلت الصين الحكم ببساطة، بل أعلن مسؤول صيني أن الحكم عبارة عن "قطعة من الورق لا أكثر"، وبالتالي فإن الأمر ذاته متوقع في حالة كورونا / كوفيد-١٩^(١١٧).

<https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD% />, see also about this issue (١١٥)

<https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/4/26/%D8%A7%D9%8>

<https://www.bbc.com/arabic/world-52389432>

(١١٦)

Ibid.

(١١٧)

مما تقدم، نقول إن مسألة قبول اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والمشاركة في أية إجراءات تقوم بها المحكمة بخصوص فيروس كورونا، قد يكون أمراً صعب المنال على الأقل في المنظور القريب، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي التفكير في البحث عن إطار قانوني جديد وواضح للتعامل مع تفشي الفيروس والمسؤوليات التي تتحملها الدول بهذا الخصوص^(١١٨). هناك من يرى أنه ربما يمكن تخطي مشكلة الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية بخصوص أية دعوى ترفع ضد الصين؛ وذلك من خلال الرجوع لنص المادة ٧٥ من دستور منظمة الصحة العالمية، والتي تنص على أن "أي مسألة أو نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الدستور لا تتم تسويته عن طريق التفاوض أو جمعية الصحة يُحال إلى محكمة العدل الدولية...". فنص المادة السابق واضح في دلالاته وعبارته، حيث إنه إذا فشل التفاوض بين الدول، أو عن طريق الجمعية العامة لمنظمة الصحة الدولية لحل أي إشكال يتعلق بتفسير وتطبيق دستور المنظمة، فالمحكمة تملك - في حالة تسجيل شكوى أو دعوى أمامها تتعلق بدستور هذه المنظمة وفشلت الدول في التوصل لتسوية حوله - النظر فيها بغض النظر عن رضا الدولة ذات الصلة، إلا إذا كانت الدولة - بطبيعة الحال - قد سبق لها التحفظ على هذا البند، وهذا أمر بالعادة غير متوقع أو محبذ في المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية. وهذا التفسير الموسع أمر ليس بالجديد في قضاء محكمة العدل الدولية، حيث تبنته في المحكمة في العام الماضي في القضية بين روسيا وأوكرانيا حول نص المادة ٢٢ من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. من هنا يمكن القول أن لأية دولة - ترى أن لها مصلحة أن تحرك دعوى مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها ضد الصين بسبب انتشار جائحة كورونا - أن تلجأ إلى محكمة العدل مباشرة، ودون أن تكون هناك حاجة للرجوع لجمعية الصحة كشرط لرفع تلك الدعوى^(١١٩).

كما أن هناك من يطرح خيار المسؤولية الجنائية الفردية وفقاً لنظام روما الأساسي لعام ١٩٩٨ والذي دخل حيز النفاذ في عام ٢٠٠٢، فانتشار الأوبئة وإطلاق الاتهامات ضد الصين بخصوص هذا الوباء، وأنه قد يكون سلاحاً بيولوجياً تم تصنيعه في مختبرات الصين، جعل موضوع المسؤولية الجنائية يطفو أيضاً على السطح^(١٢٠).

(١١٨) <https://theArabweekly.com/has-china-violated-international-law-virus-outbreak>

(١١٩) لمزيد من التفصيل انظر: د. ياسر الخاليلة، هل يمكن مساءلة الصين قانونياً عن تفشي وباء كوفيد - ١٩، مرجع سابق.

(١٢٠) لمزيد من التفصيل حول المحكمة الجنائية الدولية انظر: د. مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي: دراسة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق، جامعة =

فهل يمكن فعلاً اتهام الصين بأنها ارتكبت جريمة ضد الإنسانية خلافاً لأحكام المادة ٧ التي جاء فيها ما يلي: "يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجيٍّ موجّه ضدّ أيّة مجموعة من السكّان المدنيين، وعن علم بالهجوم. وقد حددت المادة عديداً من الأفعال التي تدخل في هذا السياق مثل القتل العمد والإبادة والاسترقاق وإبعاد السكّان أو النقل القسريّ للسكّان والاختفاء القسريّ للأشخاص وجريمة الفصل العنصريّ والأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبّب عمداً في معاناة شديدة، أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. كما يمكن البحث والمجادلة في موضوع مدى المسؤولية عن القيام بعمل من أعمال العدوان خلافاً لأحكام المادة ٥/د؛ ويقصد بالعدوان بشكل عام "استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة" (١٢١). أما النظام الأساسي، فقد عرفه بأنه التخطيط لعمل عدواني أو الإعداد له، أو الشروع فيه، أو شنّه من قبل شخص يكون في وضع يتيح له التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة أو توجيّهه، بحيث يشكل العمل العدواني بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة (١٢٢).

لا شك، أن نقل المسألة من الإطار الحقوقي أو المدني إلى الشق الجنائي، ومحاولة إقحام المحكمة الجنائية والمدعي العام فيها لتحريك دعاوى بهذا الخصوص ضد الصين، أو أية دولة أخرى يثبت تورطها بنشر هذا الفيروس له تبعات سياسية، وتواجهه في حقيقة الأمر عقبات وتحديات قانونية كثيرة، قد لا يكون هناك مجال للتفصيل فيها في هذه الدراسة، ولكن من أبرزها عدم انضمام الصين لنظام روما؛ وبالتالي صعوبة تحريك دعوى جنائية بهذا الخصوص، كما أن صلاحية المدعي العام، أو مجلس الأمن بتحريك الدعوى، والتي يقررها نص المادة ١٣ قد تكون هي الأخرى متعذرة أو مستحيلة في ضوء حق الفيتو الذي تملكه الصين، والذي قد يعطل أية تحقيقات محتملة بهذا المجال.

= الكويت، ٢٠٠٢، العدد الثالث، السنة ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٣. ١٤. ود. مخلد الطراونة، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ٢، السنة ٢٠٠٥، ٢٩.

(١٢١) الجمعية العامة نجحت في ١٤ ديسمبر/ كانون الأول من عام ١٩٧٤ في تبني قرارها رقم ٣٣١٤ بالإجماع حول العدوان.

(١٢٢) حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان انظر: كلاوس كريس - دراسة قانون الحرب، أيلول / سبتمبر ٦، ٢٠١٨، /<https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/09/06/2016/>

في ظل تعقيدات الخيارات السابقة، وضبابية المشهد الحالي قد يقول قائل إن إجراء تحقيق دولي شفاف وعادل بهذا الخصوص، ربما يكون خياراً مطروحاً ومقبولاً لإزالة اللثام عن حقيقة ما جرى، والوقوف على الحقيقة بكل تفاصيلها وجوانبها، فقد يكون من ضمن الخيارات التي تملكها منظمة الصحة العالمية البدء فوراً بإجراءات تحقيق شفاف، بعيداً عن أية ضغوطات أو محاباة لأي طرف من الأطراف، فالوصول للحقيقة الكاملة وإطلاع الدول والشعوب عليها بات اليوم أمراً ضرورياً، ليس فقط لمحاسبة المتسببين دولاً كانوا أو أفراداً أو كيانات، بل لمنع حدوث مثل هذا الوباء، أو التقليل من فرص حدوثه مستقبلاً. وإذا كانت المنظمة غير قادرة على ذلك، فربما يمكن للجمعية العامة، أو مجلس حقوق الإنسان القيام بهذه المبادرة وبدعم من جميع الدول. فما حدث أمر جلل، وجائحة عظيمة لم تمر على العالم منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، ويحتاج هذا الأمر الذي ذهب ضحيته آلاف البشر بيان كافة جوانبه، ومحاسبة كافة المقصرين والمتسببين به؛ إن ثبت أن هناك تعمداً أو تقصيراً في نشر هذا الوباء وتفشيهِ في العالم.

ولكن مرة أخرى نقول إن هذا الخيار أيضاً ليس سهلاً كما أنه ليس متاحاً في ظل المعطيات الحالية، خاصة أن الصين ترفض مثل هذا الإجراء، لا بل إنها ضغطت على الاتحاد الأوروبي لمنع إصدار قرار أو بيان يدعو لإجراء تحقيق، متهمه في الوقت ذاته الدول التي تسعى لذلك بأنها تخفي وراء ذلك دوافع سياسية، وإن من شأن تلك الدعوات تشتيت جهود الصين في مكافحة الوباء. كما أن الصين قد هددت صراحةً بعض الدول كأستراليا - التي أعلنت أنها ستطرح هذا الموضوع في اجتماع جمعية الصحة في شهر مايو - بقطع علاقاتها التجارية والاقتصادية معها، وإن تلك الخطوة في حالة اتخاذها قد يكون لها تداعياتها السلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى جميع الصُّعد والمستويات. ولا شك أن مثل هكذا تهديدات وتداعيات سيكون لها تأثيرها المباشر على ملف فيروس كورونا وأبعاده المختلفة، بما في ذلك موضوع المسؤولية الدولية، وسيجعل الدول تراجع خطواتها، وتدرس خياراتها عند التفكير باتخاذ أية خطوة تجاه المارد الصيني^(١٢٣). إن المصالح السياسية والاقتصادية،

(١٢٣) رفضت الصين دعوات لتحقيق دولي مستقل في الكيفية التي نشأ بها فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-١٩. وقالت الدبلوماسية الصينية رفيعة المستوى في لندن، تشن ون، لبي بي سي إن الدعوات للتحقيق تخفي دوافع سياسية، ومن شأنها تشتيت جهود الصين في مكافحة الوباء. ويمكن أن يساعد توفر معلومات حول نشأة الفيروس في التعامل مع المرض. <https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/25/>

وحسابات الربح والخسارة التي تهم الدول - للأسف - أحياناً قد تقف عائقاً وسداً منيعاً ضد القيام بأية تحقيقات، أو لجان تقصي دولية حول هذا الموضوع، وريثما يتحقق هذا الأمر؛ إن حدث أصلاً، فإن على العالم أن ينتظر للأسف مزيداً من الضحايا والإصابات حتى يرفع الله البلاء عن الإنسانية جمعاء.

الخاتمة:

لقد تناولنا في هذا البحث موضوع جائحة فيروس كورونا والنتائج والآثار التي ترتبت عليه منذ ظهوره، والذي كانت بداياته في شهر ديسمبر من أواخر العام الماضي، وقد أثّرت حول ظهور هذا الفيروس الخطير، وكيفية انتشاره وتفشيه بهذه الصورة غير المعهودة، ودور الصين فيه، ومدى مسؤوليتها عنه، ودور منظمة الصحة العالمية في مكافحته، وعلاقتها مع الصين بهذا الخصوص الكثير من التساؤلات. وقد ألقت هذه التساؤلات بظلالها على المجتمع الدولي، وعلى منظمة الصحة العالمية، وعلى العلاقات الدولية عموماً وعلى العلاقات الثنائية، لا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فقد أدى ظهور هذا الوباء وسرعة تفشيه بالعالم وإصابة ملايين الأشخاص ووفاة عشرات الآلاف إلى ظهور أزمة عالمية، لم يسبق للعالم أن شهدتها منذ الحرب العالمية الثانية.

لقد تناول هذا البحث بالتحليل مسألة ظهور فيروس كورونا المستجد/كوفيد-19 في الصين، وبداية انتشاره، والطريقة التي تعاملت بها الصين مع الأزمة في البداية، حيث لم تعطِ الموضوع ربما الجدية الكافية، والدليل على ذلك كما بيّن البحث الطريقة التي تم التعامل بها مع بعض الأشخاص الذين حذّروا من هذا الفيروس الخطير كالطبيب لي ويلميانغ، الذي كان من أوائل الأشخاص الذين اكتشفوا هذا الفيروس، كما أن التعتيم الإعلامي، وإخفاء الحقائق والمعلومات، وعدم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بخصوص هذا الوباء في الوقت المناسب، وضعف المنظمة الدولية في مواجهة الصين، وعدم الضغط عليها لكشف الحقيقة الكاملة حول هذا الأمر، وتسترها على الصين وتواطؤها معها، حسب ما يدعي البعض فاقت - بلا شك - من الأزمة، وسارعت في تفشي الوباء وانتشاره؛ بحيث لم يعد أحد قادراً على ضبطه أو الحد منه. فالأرقام الحالية - كما أشار هذا البحث - لعدد المصابين مخيفة ورهيبة، وتزداد حدتها في كل لحظة، رغم انخفاضها في بعض الدول؛ بسبب اتباع سياسة التباعد الاجتماعي، وأخذ الاحتياطات اللازمة كارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم، وغير ذلك من الوسائل المختلفة. كما بيّن هذا البحث الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في مواجهة هذه الجائحة، التي أعلنت عنها في شهر مارس من العالم الحالي، بعد زيادة

أعداد المصابين بهذا الفيروس حول العالم. وقد أشرنا في هذا البحث إلى نشأة هذه المنظمة الدولية المهمة، وبيّنا أهم أهدافها ووظائفها، والتي تتمركز في المحافظة على موضوع الصحة العامة، ومنع تفشي الأمراض والأوبئة في العالم. كما بيّن البحث أن المنظمة لعبت - وعلى مدار السبعين سنة الماضية منذ نشأتها في عام ١٩٤٦ - دوراً مهماً ومحورياً في التصدي للكثير من الأمراض والأوبئة، وإنها كغيرها من المنظمات قد تحققت وتنجح، وقد تخطأ وتصيب، وإذا كانت المنظمة الدولية قد أخفقت إلى حد ما في التعاطي مع أزمة كورونا، خاصة في بدايتها وفقاً لبعض الأصوات، وإنها ربما كما يقول البعض - كالولايات المتحدة - خضعت للضغوط الصينية في عدم إعلان حالة الطوارئ الصحية العمومية؛ الأمر الذي فاقم من الأزمة ومن نتائجها التي طالت جميع الدول، فاليوم انتشر الوباء إلى قرابة ٢١٥ دولة وإقليم حول العالم، وعدد الإصابات وصلت أكثر من ٤ ملايين إصابة، وعدد الوفيات تجاوزت حاجز ٣٠٠ ألف إنسان. وهذه الأرقام مؤشر خطير على هذا الوباء، ومدى تأثيره على العالم بأسره. في المقابل هناك من يرى أن المنظمة قامت بما هو مطلوب منها بهذا الخصوص، وإنها لم تتأخر في إجراءاتها وتدابيرها الاحتياطية، وإن الوقت الآن ليس هو الوقت المناسب لتبادل الاتهامات، وتوجيه الانتقادات للمنظمة، وإنما على الجميع أن يعمل معاً للحد من هذا الوباء، وتشجيع البحوث العلمية للوصول إلى اللقاحات والأمصال التي تؤدي للقضاء عليه نهائياً.

لقد تناول هذا البحث أيضاً، الخلافات التي ظهرت بين منظمة الصحة العالمية، والولايات المتحدة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى إعلان الرئيس الأمريكي وقف التمويل وقطع المساعدات عنها، وهو أمر سيؤثر - بلا شك - على جهود المنظمة في مواجهة هذه الجائحة، وتنفيذ برامجها الأخرى. وقد بيّنا في هذا البحث ربود الأفعال المنتقدة لهذه الخطوة الأمريكية، كما أن الخلاف الأمريكي لم يقتصر على المنظمة، بل إن الولايات المتحدة صبت جام غضبها على الصين؛ بسبب هذه الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ٩٠ ألف أمريكي، والرقم يزداد يومياً وبأرقام كبيرة، ووصلت حالات الإصابة المؤكدة فيها قرابة مليون ونصف المليون حالة.

لقد أشار البحث إلى وجود حرب كلامية، وأخرى سياسية، وثالثة اقتصادية بين الدول عموماً وبين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص، بدأت حداثها وجنوتها بالزيادة عقب ظهور هذا الفيروس، فالولايات المتحدة - كما أظهر هذا البحث - وعلى لسان رئيسها دونالد ترامب اتهمت الصين صراحةً بالوقوف وراء انتشار هذا الفيروس، وإنها أخفت كثيراً من المعلومات والحقائق المتعلقة به. وإن

الصين وبالتواطؤ مع منظمة الصحة العالمية؛ بسبب تسترهما على الوباء، وعدم إبلاغها لمنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب، وضغطها عليها لمنع إعلان حالة الطوارئ الدولية، حسب ما تتضمنه تقارير استخباراتية، قد ألحق ضرراً بالغ الشدة بالولايات المتحدة. وإن التقديرات للخسائر الأمريكية - كما أشار هذا البحث - تصل لمئات المليارات من الدولارات. كما خسر ملايين من الموظفين الأمريكيين وظائفهم، وزادت بالتالي أعداد المتعطلين عن العمل لتصل لأرقام قياسية كبيرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عدة عقود. إن هذه الأمور وغيرها دفعت الولايات المتحدة - كما قلنا - لوقف التعامل مع منظمة الصحة العالمية، وقطع التمويل المالي عنها، وأيضاً وصل الأمر بالرئيس الأمريكي إلى القول إن الولايات المتحدة قد تقطع العلاقات مع الصين، وإنه يرفض الحديث أو التواصل مع الرئيس الصيني حالياً.

لقد تناول البحث كذلك، حدود مسؤولية الصين عن انتشار جائحة كورونا؛ حيث تناولنا الإطار القانوني لهذه المسألة في ظل اللوائح الصحية الدولية، ودستور منظمة الصحة العالمية، فقد تضمنت هاتان الوثيقتان العديد من الأحكام المتصلة بهذا الموضوع، فوفقاً للوائح الصحية الدولية يتعين على الدول أن تتابع موضوع الأمراض والأوبئة، وإنه يقع على عاتق كل دولة أن تبلغ عن أية حالة قد تقع على أراضيها يمكن أن تؤدي إلى طارئة صحية دولية. كما يجب على الدول كما أشار هذا البحث ووفقاً للمادتين ٦ و٧ من اللوائح أن تُخطر وتبلغ المنظمة وفي غضون ٢٤ ساعة حول أية حوادث قد تشكل طارئة صحية تثير قلقاً دولياً، كما يتوجب عليها إضافة لاحترام واجب "الإخطار السريع"، ضرورة مشاركة المنظمة المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية كافة وفي أسرع وقت ممكن، للتقليل من أي تهديد قد يصيب البشرية. وهنا، يمكن القول إن هذا الأمر، وعدم التزام الصين به وانتشار فيروس كورونا المستجد بسرعة كبيرة في أنحاء المعمورة، أثار مسألة مسؤولية الصين من ناحية القانون الدولي، وطرح العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع المهم. لقد حاولنا جاهدين في هذا البحث أن نناقش بعض الجوانب المتصلة بهذا الموضوع الحساس، وطرحنا بهذا الخصوص بعض الخيارات أو السيناريوهات النظرية التي يمكن اللجوء إليها، مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن، وتفعيل مسؤولية الصين وفقاً لاتفاقية الأسلحة الجراثومية والبيولوجية، واللجوء إلى القضاء الدولي وتفعيل مبدأ المحاسبة الفردية في حال ثبتت مسؤولية الصين عن تفشي هذا الوباء. كما طرح البعض فكرة اللجوء إلى القضاء الوطني، والمحاكم الداخلية، خاصة في الولايات المتحدة التي بدأت بعض الولايات فيها كولاية ميزوري بالتحضير لدعوى ضد الصين

بهذا الخصوص، وطرح فكرة تجميد الأصول والممتلكات الصينية، وشطب ديون العالم الثالث المستحقة للصين. كما أن البحث أشار إلى بعض المبادئ الأخرى التي يمكن البناء والتأسيس عليها في هذا المجال كمبدأ العناية الواجبة وعدم الضرر ومخالفة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها. كما أن هناك من نادى أيضاً بتشديد العقوبات على الصين، سواء من جانب الولايات المتحدة، أو الدول الأخرى الفاعلة عقاباً لها على عدم شفافيته وموضوعيتها في ملف كورونا. كما أن اتجاهاً آخر أقل تشدداً طالب بفتح تحقيق دولي شفاف حول هذا الموضوع، يتم في إطار منظمة الصحة العالمية، أو الأمم المتحدة للوصول لحقيقة ما حدث فعلاً، وبيان مدى مسؤولية الصين عن تفشي هذا الوباء الخطير.

لقد ناقشنا بالتفصيل كل هذه الخيارات المتاحة، وأوضحنا أهمية كل واحدٍ منها، وإمكانية تنفيذه من الناحية العملية، كما ناقشنا في المقابل التحديات والعقبات القائمة التي تقف وتحول في الحقيقة دون تطبيقها من الناحية الواقعية. فثمة كثير من الإشكاليات القانونية والسياسية التي تقف سداً منيعاً دون الوصول لمحاسبة الصين عن هذه الجائحة بيّناها في هذه الدراسة.

ختاماً نقول، إن هذه الجائحة أثبتت تقاعس منظمة الصحة العالمية وتقصيرها في إدارة هذا الملف بطريقة جيدة، كما أثبتت أن عدم تعاون الصين وتأخرها في إبلاغ المنظمة وتقاعسها في مشاركة المعلومات مع الدول والمنظمة قاد إلى هذه الكارثة أو الجائحة التي كلفت الإنسانية والبشرية الكثير. كما أن عدم التعاون فيما بين الدول عموماً، والاستهانة باتخاذ الاحتياطات والتدابير الصحية، وعدم الامتثال سواء من جانب بعض الدول أو الأشخاص كان ثمنه باهضاً إنسانياً وصحياً واقتصادياً. كما أمطت الجائحة الحالية اللثام عن الوجه القبيح للحضارة والثقافة الغربية التي تخلت فيها عن قيمها الإنسانية والأخلاقية، فهناك من طالب بوقف تصدير المعدات الطبية، والكمادات والأقنعة، لا بل وصل لدرجة أن يهدد باستخدام القوة للحصول على هذه المعدات، وظهر مصطلح حرب الكمادات بين الدول الغربية والصين. كما أن من المهم، وبعد الانتهاء من هذه الجائحة - وهو أمر غير متوقع في المدى القريب وفقاً لمنظمة الصحة العالمية - إعادة النظر في هيكلة المنظمة ودستورها ولوائحها الصحية لتواكب التطورات الحديثة التي فرضتها هذه الجائحة.

فاللوائح الصحية الدولية السابقة والحالية هي نتاج الخبرة والمداولة والحلول الوسط. ومع ذلك، لا يزال مستقبل هذه الأداة القانونية الحديثة غير مؤكد في ظل هذه الظروف، حيث تحاول الحكم في ظل عالم ووقت يشكك فيه الكثيرون بفعالية منظمة

الصحة العالمية. وإذا دعا المجتمع الدولي مستقبلاً إلى إجراء مراجعات لاحقة للوائح الصحية الدولية، فستكون هناك حاجة إلى إرادة سياسية كبيرة لتحقيق إصلاحات شاملة وفاعلة. وعلى الرغم من أن تحقيق مثل هذا الأمر غير مؤكد، لكن الشيء الوحيد المؤكد، والذي أثبتته هذه الجائحة أن هذه اللوائح والمعايير التي تضمنتها - كما هي عليها الآن - لن تكفي في مواجهة جائحة أخرى.

كما أن من المهم كذلك، أن تضع الدول خلافاتها جانباً في هذا الوقت العصيب، وتعمل معاً، وبروح الفريق الواحد للحد من هذا الوباء والقضاء عليه، ودعم شركات الأدوية، وتشجيع البحوث العلمية التي تقوم بها - كما قلنا - للمساعدة في الوصول لهذه اللقاحات، وتوفيرها لجميع البشر دون تمييز أو تفرقة، فهذا حق أساسي ينبغي أن يتوفر للجميع، وليس كما تحاول بعض الدول قصره على أفرادها أو مواطنيها. إضافة لذلك، يتوجب على الدول الاهتمام بصورة أكبر بموضوع الصحة والرعاية الصحية والتثقيف والتوعية الصحية، وضرورة توفير الموارد والإمكانيات المالية لدعم هذا القطاع الأساسي والمهم في أية دولة، فقد كشفت هذه الجائحة عورة الأنظمة الصحية للأسف الشديد، كما أظهرت نقص الإمكانيات الصحية، وضعفها في العديد من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول. كما بيّنت هذه الجائحة أن على الدول أن تعيد ترتيب أولويتها في مجال الإنفاق، وتخصيص الموارد، فبدلاً من مليارات، لا بل تريليونات الدولارات التي تنفق على إنتاج الأسلحة وإشعال الحروب، وافتعالها لخلق أسواق لبيع تلك الأسلحة، فإن العالم بات بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتخصيص هذه الموارد والمخصصات المالية الضخمة للصحة والتعليم والبحوث العلمية التي تفيد الإنسانية أو البشرية جمعاء. فصحة جميع الشعوب - كما تقول ديباجة منظمة الصحة العالمية - أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، وهي تعتمد في هذا الإطار على التعاون الأكمل بين الأفراد والدول، وإن ما تحققه الدول من تحسن في مجال الصحة وحمايتها، هو أمر له أهميته للجميع، وإن التفاوت بين الدول في مجال تحسين الصحة ومكافحة الأمراض، خاصة الأمراض السارية خطر على الجميع دون استثناء. وإن الحكومات مسؤولة في نهاية المطاف عن صحة شعوبها، وإن عليها أن تقوم بما يلزم في هذا الخصوص من تدابير صحية واجتماعية؛ كون أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، وإن التمتع بهذا الحق ينبغي أن يتم دون أي تمييز.

Corona Pandemic and the Extent of China's International Responsibility For It: legal Reading From An International law Perspective

Prof. Mekhled Tarawneh

This research, deals with the subject of the Corona pandemic from the perspective of international law, and the legal problems associated with this virus, where we discussed with all objectivity a number of questions raised about this pandemic that have shaken the pillars of the international community, especially those related to the role of the World Health Organization (WHO), the effectiveness of its legal system, and the specific mechanisms in its regulations in the face of diseases and epidemics. The research also discussed the limits of China's responsibility for the spread of this epidemic in terms of international law, the options or scenarios that can be used to determine this responsibility, and the challenges and obstacles that exist in this regard.

The spread of what has come to be known as the emerging coronavirus / Covid-19 virus, has caused a powerful and very impressive blow worldwide. The severity of the spread of this epidemic, which first appeared in China, in late December of the previous year, and peaked in February and March of the current year, and then continued, the implications and effects of earthquake and tremendous in all aspects of human, economic, social and life for all Individuals and states. The scale of the epidemic, and the speed of transmission that affected nearly 215 countries and territories around the world, prompted the World Health Organization to declare the new Corona virus as a global pandemic; Due to the resulting injuries and deaths. This epidemic has left, and still - according to statistics issued by the World Health Organization and some other bodies such as Johns Hopkins University - more than 30 million people infected, more than 900 thousand deaths around the world, and the numbers are expected to increase at every moment. It has spread in Italy France, Germany, the Netherlands, Britain, India and Latin America where these countries have recorded records in the number of injuries and deaths, not seen since the end of the Second World War, and these countries, after China's control of the epidemic after nearly two months, are the focus of this great epidemic.

The infection of this virus has also spread to the United States, despite all the huge possibilities it possesses, and it has spread in it quickly and unexpectedly, raising the number of infected people to more than 6 million and four hundred thousand infections, and more than 200 thousand deaths. This situation has caused the United States of America to go through a crisis that is also the most difficult and harsh, since the Second World War and the events of

September 11, 2001. Despite all the efforts made by countries to face the epidemic, it is difficult to predict what matters will happen in the near future, particularly, since studies and reports issued by the organization confirm the question of the battle with this pandemic for its eradication will be somewhat longer, and states and peoples may have to coexist with it for a long time before it is eradicated.

This research, discussed three issues in a row, respectively, starting with the definition of the Corona Covid-19 virus, clarifying its most important characteristics and symptoms, the beginnings of its spread, and the most prominent repercussions, then secondly, we studied the role of the World Health Organization in facing the Corona pandemic, and showed how it dealt with this pandemic, and highlighted the difficulties and challenges that it faced in this regard, and the criticism of some countries, especially the United States, for the way it dealt with this pandemic, as we discussed thirdly, the extent of China's international responsibility from the legal point of view regarding the allegations holding it responsible for the spread of this virus. And we discussed some of the available options, obstacles and challenges that stand in the way of their practical application and implementation.

Key words: emerging coronavirus, pandemic, international responsibility, World Health Organization, International Health Regulations, WHO Constitution, International Court of Justice.

التطوع لاختبار فاعلية اللقاح الطبي في مواجهة فيروس كورونا دراسة تحليلية في القانون المدني

أ.د. محمد سليمان الأحمد*

د. عبد الكريم صالح عبد الكريم**

ملخص:

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وإصابة الآلاف به حول العالم، ظهرت عدة محاولات للبحث عن لقاح بشأنه، وهذا اللقاح يتطلب تجربة سريرية له على البشر، ومن أجل هذا تطوع عدد كبير من الأشخاص لهذا الغرض، ومن هنا برز التساؤل المتعلق بماهية التطوع لاختبار فاعلية اللقاح الطبي، وهل تتوفر فيه دعائم العقود المعروفة في القانون المدني؟ وما هي الآثار القانونية الناجمة عن اختبار اللقاح إذا تكلل بالنجاح أو أصابه الفشل؟ فالتطوع هو متبرع يقدم خدمة مجانية لجهة راعية لاختبار اللقاح، كأن تكون مؤسسة صحية أو شركة من القطاع العام أو الخاص، وذلك لاعتبارات إنسانية واجتماعية، وهذه الجهة قد لا تعطي للمتطوع سوى بعض المكافأة. ولكون هذه التجارب مقرونة بالمخاطر المتعلقة بسلامة المتطوع المشارك في الاختبار، تكون تلك الجهة ملزمة بالتأمين على تلك المخاطر حتى قبل البدء بالاختبار، كما أنها ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمشارك بسبب الأجهزة المستخدمة في الاختبار، أو نظراً لانتهاك الالتزام بالسلامة والإعلام، التي تعد حقاً للمتطوع في الوقت نفسه.

ولقد تم استخدام الأسلوب التحليلي في كتابة البحث مع تقسيمه إلى مبحثين: يتناول أولهما الطبيعة القانونية للتطوع المختبري وأهميته، أما المبحث الثاني فجاء لبحث الآثار القانونية التي تترتب على اختبار اللقاح. وانتهى البحث إلى أن التطوع لاختبار اللقاح هو عقد تبرع يقع ضمن فئة عقود التفضل، وهو عقد ملزم للجانبين، يقدم فيه المتبرع منفعة أو خدمة مجانية، كما توصلت الدراسة إلى أن صفة التبرع، والمكافأة التي قد يتسلمها المشارك في الاختبار لا تنفي مسؤولية الجهة القائمة بالاختبار، خاصة إذا ما تعلق الأمر بسلامة الإنسان ومعصومية جسده. كما وأوصت الدراسة بضرورة سن قانون خاص لإجراء التجارب السريرية لاختبار اللقاح مع الاستعانة بمبادئ إعلان هلسنكي بشأن أخلاقيات إجراء البحوث على البشر، وتنظيم عقود التفضل في القانون المدني لعدم وجود أحكام خاصة به في هذا القانون.

الكلمات الدالة: التطوع، الاختبار السريري، اللقاح، العقد، المسؤولية العقدية.

(*) الباحث الرئيس: جامعة السليمانية، الأستاذ الزائر في جامعة الشارقة.

(**) الباحث المشارك: كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة دهوك - العراق.

مقدمة:

- فكرة البحث ومدخل للموضوع:

ظهرت في الآونة الأخيرة، وتحديدًا خلال العامين المنصرمين من الزمن وبدافع مكافحة الفيروسات المعدية، واكتشاف العلاج المناسب لها، اختبار العديد من اللقاحات والمستحضرات الطبية في المعاهد والمؤسسات والشركات الطبية. واختبار أي لقاح ينبغي أن يمر بمراحل من بينها تجربتها على الحيوان أولاً، فإن نجح يتم تجربته على البشر. ولهذا الغرض تدعو تلك المؤسسات والشركات الناس للتطوع، فيعرض مجموعة من الأشخاص استعدادهم لهذا الغرض ويتطوعون لتجربة اللقاحات على أجسامهم. هذا الاختبار يتم بموجب اتفاق بين المتطوع والمؤسسة القائمة بالبحث والاختبار، وله محل معين وسبب معين، وبذلك قد تتوافر فيه الدعائم اللازمة لأي عقد من عقود القانون المدني، ومن هنا برز التساؤل حول نوع هذا العقد وطبيعته القانونية؟ ولا يخفى على أحد مخاطر اختبار اللقاح على البشر، مما يدعو ذلك إلى ضرورة إحاطته بالتأمين وتعويض الأضرار التي تنجم عنه.

- مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في وجود نقص تشريعي بشأن معالجة وتنظيم موضوع التطوع بصفة عامة، والتطوع لاختبار فاعلية اللقاح الطبي بشكل خاص، سواء في القانون المدني وحتى في القوانين الخاصة كقانون الصحة العامة؛ مما يستدعي ضرورة وضع الأحكام اللازمة له. كما أن عقد تقديم الخدمات المجانية أو عقد التفضل كأحد عقود التبرع يخلو هو الآخر من تنظيم تشريعي ومعالجة فقهية، ومن بين هذه العقود، عقد التطوع لاختبار اللقاح الطبي. ويستمد البحث أهميته من العمل التطوعي ذاته، صحيح أن المغزى من التطوع المختبري هو تقديم الخير للآخرين، غير أنه ينشئ علاقات بين الأفراد يترتب عليها حقوق والتزامات، وهذه العلاقات لا بد وأن تنظم من قبل المشرع، وضرورة الإلزام والتقيد بالقواعد القانونية من جانب أشخاص التطوع، فضلاً عن الأطر الأخلاقية التي تحكم نشاط الجهات المشرفة على الاختبارات الطبية، ومدى التزامها باحترام كرامة الإنسان والأصول الإنسانية للأبحاث الطبية.

- منهجية البحث:

تم الاعتماد على المنهج التحليلي لمعالجة إشكاليات البحث السابقة، وتحليل ومناقشة الأفكار والآراء المتعلقة بموضوع الدراسة، من خلال تطويع القواعد القانونية الواردة في القانون المدني في محاولة لوضع إطار قانوني للتطوع المختبري.

– خطة البحث:

جاءت الدراسة مقسمة وفق الخطة الآتية:

المبحث الأول: ماهية التطوع المختبري وطبيعته القانونية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ماهية التطوع المختبري وأهميته

المطلب الثاني: التطوع المختبري بوصفه عقداً أو مجرد خدمة اجتماعية

المبحث الثاني: الآثار القانونية للتطوع المختبري، ويشتمل على مطلبين كذلك:

المطلب الأول: آثار التطوع المختبري بحسب النتائج

المطلب الثاني: آثار التطوع المختبري بحسب القصد

وسننهي البحث بخاتمة نوضح فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات. والله الموفق.

المبحث الأول

ماهية التطوع المختبري وطبيعته القانونية

لغرض التعرف على حقيقة التطوع المختبري والطبيعة القانونية له، ينبغي بيان ماهية التطوع المختبري وأهميته على الصعيد الإنساني والعلمي، والخوض في طبيعة التطوع المختبري بوصفه عقداً أو مجرد خدمة اجتماعية.

المطلب الأول

ماهية التطوع المختبري وأهميته

في هذا المطلب سنتناول ماهية التطوع المختبري وأهميته، وذلك من خلال فرعين:

الفرع الأول

ماهية التطوع المختبري

في هذا الفرع سنوضح ماهية التطوع المختبري ببيان مفهوم التطوع، وتحديد مفهوم اللقاح والدواء والفرق بينهما.

المقصد الأول: تحديد مفهوم التطوع المختبري

التطوع عموماً تقديم خدمة مجانية لأغراض غير ربحية^(١)، فهو جهد يبذله الإنسان بلا مقابل لمجتمعه للإسهام في تحمل المسؤوليات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية، أو هو خدمة إنسانية تهدف إلى حماية الوطن وأهله من الخطر^(٢). أما التطوع المختبري فيقصد به استجابة شخص ما طوعية لنداء أو عرض - في شكل دراسة بحثية - من شركة أو جهة مختصة حكومية تعمل في مجال

(١) لا تكفي المجانية في توصيف الجهد كي نطلق عليه تطوعاً، فأحياناً يُقدّم التجار بعض السلع والخدمات للجمهور مجاناً، لكن غرضهم ينصب لخدمة أعمالهم، إذ تُقدم لهم هذه الهدايا دعاية مجانية لسلعهم أو خدماتهم، وقد أطلق الفقه التجاري على هذا النوع من المضاربة بالربح الآجل، والذي يُعرّي هذه الأعمال المجانية من الصفة التبرعية (فيما يخص السلع)، ومن الصفة التطوعية (فيما يخص الخدمات). (لاحظ في المعنى نفسه: د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، مطبعة جامعة بغداد، ١٩٨٧، ص ٥٥)

(٢) ويكيبيديا الموسوعة الحرة، <https://www.ar.wikipedia.org/wiki>

(٣) Hoffmann, What is a clinical trial and how does a trial work?, available at: https://www. Roche.com/research_and_development/who_we_are_how_we_work/clinical_trials/what_is_a_clinical_trial.htm?tab_id=tab4 Last accesses, April 11, 2020.

صناعة الأدوية لإنتاج دواء أو تطوير لقاح لأي مرض معدٍ لم يعرف له دواء بعد^(٣). ويلاحظ أن التطوع المختبري يكون من خلال التجربة السريرية والتي يقصد بها اختبار أو دراسة لعقار أو جهاز استقصائي أو علاج طبي آخر في البشر، والتي قد تتم من خلال اختبار بعض الأدوية أو الأجهزة المعتمدة الموجودة بالفعل^(٤). والجهة التي يتم التطوع لها هي إما معاهد وطنية للصحة أو مؤسسات صحية أو منظمات صحية أو مؤسسات البحث أو شركات الأدوية. وعرف التطوع المختبري كذلك بأنه مساهمة الأشخاص في دراسة بحثية تختبر علاجاً طبياً جديداً أو طريقة جديدة لاستخدام العلاج الحالي لمعرفة ما إذا كانت طريقة أفضل للوقاية من مرض ما^(٥). والملاحظ على التعاريف السابقة أنها تتعلق بالجانب الصحي أكثر من الجانب القانوني، ولو أردنا أن نورد معنى التطوع المختبري في الاصطلاح القانوني فإننا نذهب إلى أنه اتفاق بين شخص يسمى بالمتطوع وجهة مختصة في المجال الطبي أو الصحي، بموجب هذا الاتفاق يقدم شخص أو مجموعة من الأشخاص خدمة مجانية عبر التطوع لتلك الجهة في خضوعهم لتجربة سريرية لاختبار لقاح معين لمرض معين. والعلامة الأهم لهذا العقد هي تحرّي الرضا السليم للمتطوع، فهو يغامر بصحته وأحياناً بحياته، ولهذا اتجه الفقه والقضاء إلى تطبيق نظرية قبول المخاطر عليه، وما لهذه النظرية من أثر على المسؤولية المدنية، ولهذا لا يُقبل هذا النوع من التطوع إلا من كاملي الأهلية، وممن تتوافر لديهم حرية اختيار كاملة، فهذا العقد هو من العقود الضارة ضرراً محضاً بالمتطوع، فرضاه مهم جداً ليس فقط في صحة عقده، بل في تحديد المسؤولية المدنية للجهة المتطوعة تجاهه^(٦).

(٤) Office of human subject protection, volunteering for a clinical trial, university of Rochester,. Last access, April 11, 2020.

(٥) S. B. Thorat, S. K. Banarjee, D. D. Gaikwad, S. L. Jadhav, R. M. Thorat, CLINICAL TRIAL: A REVIEW, International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, Volume 1, Issue 2, March - April 2010; Article 019, p.100.

(٦) لاحظ في أثر رضا المريض على المسؤولية المدنية وحقه في التعويض عما قد يصيبه من ضرر ارتضاه لنفسه: د. رضا محمد جعفر، رضا المتضرر بالضرر وأثره على الحق في التعويض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٥، ص ٣٧١ وما بعدها. ود. يوسف أحمد حسين النعمة، دفع المسؤولية المدنية بخطأ المضرور، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ١٩٩١، ص ٢١ وما بعدها.

المقصد الثاني: تحديد مفهوم العلاج الطبي (الدواء واللقاح والفرق بينهما)

عرّف المشرع الأمريكي الدواء من خلال القانون الفيدرالي للغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الصادر في ٢١ نوفمبر ١٩٩٧ في المادة (٢٠١) حيث ذهب إلى أنه: (المواد المعدة خصيصاً للاستعمال في مجالات التشخيص الطبي والعلاج وتخفيف الآلام والشفاء أو الوقاية من الأمراض، وكذلك المواد المخصصة للتأثير على هيكل أو وظائف جسم الإنسان أو الحيوان)^(٧). وتعرف إدارة الغذاء والدواء الأميركية "الدواء" بأنه المادة أو الوصفات الوطنية المستخدمة في التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض البشر والحيوانات عن طريق التأثير على وظائف الجسم. أما اللقاح فهو آلية الوقاية ضد أي بكتيريا أو فيروس، ويعمل كوسيلة لحماية الجسم من الإصابة بالمرض، بعبارة أخرى فإن اللقاح يمنع المرض، أما الدواء فيعالج المرض. ويحتوي اللقاح على نفس الجراثيم المسببة للمرض المراد مكافحته انتشاره، على سبيل المثال يحوي لقاح كورونا على فيروس كورونا نفسه. واللقاح هو على شكل بكتيريا أو فيروس تعرض لعدة عوامل فيزيائية أو كيميائية سريعة الانفعال من أجل إضعاف قدرتها على إنتاج المرض، ولهذا فإن اللقاح يعد من المنتجات الطبية الخطرة^(٨). وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن اللقاح هو منتج يحفز جهاز المناعة لدى الشخص لإنتاج مناعة ضد مرض معين، ويحمي الشخص من هذا المرض، ويعطى اللقاح عادة عن طريق حقن الإبرة في جسم الشخص، ومن الممكن أن يعطى أيضاً من خلال الفم^(٩).

الفرع الثاني

أهمية التطوع المختبري

للتطوع المختبري أهمية على الجانب الإنساني والجانب العلمي والمعرفي، نعالجها في مقصدين:

(٧) لاحظ: د. محمد سامي عبد الصاق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق - جامعة القاهرة، العدد ٨٠، ٢٠٠٨، ص ٥٢.

(٨) لاحظ: د. أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٣، ص ٢٧.

(٩) WHO Collaborating Centre for Advocacy and Training in Pharmacovigilance Accra, Ghana 7th - 18th September 2015 Module 2: Vaccines and drugs: similarities and differences, available at: <https://isoponline.org/wp-content/uploads/2015/10/Differences-on-drugs-and-vaccines.pdf>. last access, April 12, 2020.

المقصد الأول: على الجانب الإنساني

تحتفل كل المنظمات العالمية في اليوم الخامس من شهر تشرين الثاني من كل عام ببيوم التطوع العالمي، وذلك منذ العام ١٩٨٥، بهدف تحفيز الأفراد على روح المبادرة والعمل الإنساني التطوعي في مختلف مجالات الحياة سواء الصحية أو التربوية أو الاجتماعية، ويوصف التطوع بأنه التزام أخلاقي وليس التزاماً وظيفياً، بل هو سلوك حضاري يسهم في بناء المجتمعات^(١٠)، ففي الحقيقة تكمن قيمة الإنسان في مدى مساهمته في تقديم النفع للآخرين، والعمل التطوعي ممارسة إنسانية معروفة لدى المجتمعات الإنسانية منذ القدم؛ لأنه ينطلق من إنسانية الإنسان، وهذا الشعور الإنساني هو الدافع الرئيس في أي عمل تطوعي، فالتطوع هو ما ينبع من ذات الإنسان وباختياره من دون أي إلزام عليه؛ في حين أن الأعمال التي تنجز بعنوان الواجب لا تعد أعمالاً تطوعية؛ لأن الأعمال التطوعية هي التي تكون بدافع إنساني طوعي واختياري، وبحوافز دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية^(١١)

ومن جانب آخر واجهت هذه الأعمال الإنسانية الخيرة، أعمالاً كانت تتصف بالخسة والدناءة في الاعتداء على كرامة الإنسان، بجعله يخضع للتجارب الطبية بالإكراه، أو باستغلال حالة الأسر، كما فعلت النازية بالأسرى، حيث نشأت محاكم عسكرية إبان الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب، الذين كان من بينهم أطباء مارسوا التجارب الطبية على البشر بالإكراه^(١٢).

(١٠) التطوع التزام أخلاقي بالعمل الإنساني، مقال منشور في موقع زهرة الخليج، بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٩، متاح على الرابط: <https://www.zahratakhaleej.ae/Gallery/559555> تاريخ الزيارة للموقع: ٢٠٢٠/٤/١٢.

(١١) د. عبد الله اليوسف، مجالات العمل التطوعي وآفاقه، مقال متاح على الرابط الإلكتروني: www.alyousif.org/?act=artc&id=98&print=1 تاريخ الزيارة ٢٠٢٠/٤/١٢.

(١٢) حيث تشكلت المحكمة الأمريكية لهذا الغرض في ٢٥ تشرين الثاني من عام ١٩٤٦، ونابت عن المحكمة الدولية لتحكم في قضايا متعلقة بـ ٢٣ متهماً من بينهم ٢٠ طبيباً، وكانت أول محاكمة تواجه العلاقة بين الطبيب والمريض الخاضع لتجارب طبية، تنال من كرامة الإنسان والحد من قدره، وقد رسخت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة عشرة مبادئ يجب مراعاتها لتلبية مفاهيم أخلاقية وإنسانية، فكانت أول قاعدة أخلاقية يدونها القضاء لإجراء التجارب السريرية على الإنسان، ومن بين هذه القواعد: ١- التأكيد على أخذ رضا المريض. ٢- يجب أن يكون موضوع التجربة أمراً يهم الإنسانية. ٣- أن تُبَاشَر التجربة في ضوء النتائج السابقة على التجارب التي أُجريت على الحيوانات. ٤- يجب إجراء التجربة بأسلوب يُجنب المجرب عليه جميع الأضرار والمعاناة غير الضرورية. ٥- لا تقود التجربة إلى مخاطر الموت أو العوق، إلا إذا شارك فيها الأطباء أنفسهم. ٦- مستوى الخطر ألا يتجاوز مطلقاً المنفعة =

كما يجب أن تكون هناك موازنة بين ما تقدمه التجارب الطبية والأبحاث العلمية البيولوجية من خدمة لا غنى عنها للبشرية، واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إذ يجب أن تتأطر تلك الأنشطة برسم حدودٍ لها لا تتجاوز القيم الإنسانية المستقرة، فينبغي، في مقابل احترام الأعمال التطوعية لاختبار فاعلية اللقاحات الطبية وحمايتها، أن تُجرّم كل الأفعال التي تستغل حاجة الإنسان للمصل الطبي واللقاح ضد الفيروسات، وألا يتم تأطير هذا الأنشطة بأنماط تجارية غير أخلاقية تجعلها محلاً للمضاربة والمساومة والابتزاز^(١٣).

المقصد الثاني: على الجانب المعرفي والعلمي

أما على الصعيد المعرفي والعلمي، فإن المشاركة في برنامج التطوع الطبي يسهم بلا شك في بلورة المعلومات، بعبارة أخرى سيساعد الباحثين في دراساتهم على معرفة المزيد من المعلومات حول المرض، مما يزيد ذلك من فرصة الحصول على علاج جديد وواعد قد لا يكون متاحاً لعامة الناس، فالتقدم العلمي الكبير في العلوم الطبية والبيولوجية، على سبيل المثال اكتشاف لقاح لفيروس الإنفلونزا والمalaria والسل الرئوي، لم يكن إلا نتيجة للبحوث العلمية التجريبية المتواصلة على الإنسان، فانتشار لقاح جديد أو طريقة مستجدة في العلاج، تسبقه أبحاث علمية وتجارب طبية، وفي ذلك تطوير للعلوم الطبية والبيولوجية وهي ضرورة حتمية لتقدم البشرية، كما أن التجارب الطبية العلاجية تعد مقبولة من قبل الرأي العام باعتبار أنها تهدف إلى تحقيق واكتشاف العلاج المناسب وهو هدف مشروع^(١٤)، ولأجل هذا فإن

= المرجوة. ٧- تجنب جميع التأثيرات الثانوية في المستقبل. ٨- يجب أن تُدار التجربة من قبل أشخاص ذوي كفاءة علمية عالية. ٩- يحق للشخص الذي تُجرى عليه التجربة الانسحاب منها بكل حرية إذا خَمَنَ بأنّ يصبّيه لم يكن في حسبانته. ١٠- يجب أن يتهيأ القائم بالتجربة لقطعها في أية لحظة إذا تملكه الاعتقاد وبحسن نية وبعد استشارة الشخص الأكثر كفاءة، أن الاستمرار يمكن أن يؤدي إلى الجرح أو العوق أو الموت للشخص المجرب عليه. (لاحظ، لمزيد من التفصيل: د. ياسر عبد الحميد محمد الإفتيحات، النظام القانوني لتنفيذ البحث الطبي الحيوي على الكائن البشري والمسؤولية المدنية الناجمة عنه، دار النهضة العربية، الإمارات، ٢٠١٨، ص ٤٤ وما بعدها).

(١٣) في المعنى نفسه لاحظ: د. أحمد فتحي سرور، العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٥، ط ٢، ص ٣٩٢ وما بعدها.

(١٤) د. بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان، ط ١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ٢٠١٢ ص ٣٢.

متطوعين كثر سجلوا أنفسهم في مشاريع اختبار وتجربة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد^(١٥) أو ما يسمى Covid 19.

إن الأبحاث الطبية ساهمت وبشكل كبير في خلاص الإنسان من العديد من الأوبئة والأمراض التي كانت تهدد حياته بل وكيانه، ولهذا أخذت الدول تهتم بها، ليس فقط على الصعيد المدني، بل حتى على الصعيد العسكري^(١٦)، إذ أصبحت هناك مختبرات عديدة تتبع أهم الجيوش في العالم، هدفها الأساس التصدي لأية حرب بيولوجية تشنها الدول المعادية عبر إنتاج فيروسات تنتشر بالعدوى بين فئات مستهدفة من الناس.

المطلب الثاني

التطوع الاختبري بوصفه عقداً أو مجرد خدمة اجتماعية

للعقد منطقة، يتم تحديدها باجتماع جميع العناصر التي يتكون منها العقد، لكن ما هي هذه العناصر؟ أهى فقط أركان العقد المعروفة، (التراضي والمحل والسبب)، أم ثمة عناصر أخرى، يمنع انعدامها إطلاقاً لفظ العقد على ما يربط أي طرفين من رباط؟ هذا التساؤل يُطلق فقط على الروابط التي تتكون من طرفين، إذ لا يمكن إطلاق لفظ الرابطة على حالة يتواجد بها طرف بمفرده؛ إذن يجب أن تكون هناك رابطة، لكن هل كل رابطة بين طرفين عقد؟
انقسم الفقه في ذلك:

– هناك من يشترط نوعاً معيناً من الروابط كي توصف بالعقود، فيشترط في الرابطة أن تكون في نطاق القانون الخاص، وذات طابع مالي^(١٧)، لكن الأخذ بهذا الرأي يحد من منطقة العقد دون منطقٍ مقبول، فهو يُخرج كلاً من العقد الإداري^(١٨)، لكونه

(١٥) في بريطانيا تطوع (٨٠٠) شخص، للاختبارات الأولى لتجربة اللقاح لفيروس كورونا في مدينة أوكسفورد. راجع: مقال منسوب لقناة بي بي سي، بعنوان (فيروس كورونا: بريطانيا تجري أول تجارب سريرية للقاح في أوروبا) متاح على موقع www.bbc.com تاريخ الزيارة ٢٠٢٠/٤/٢٦.

(١٦) لاحظ: د. ياسر عبد الحميد محمد الإفتيحات، مرجع سابق، ص ٣٧.

(١٧) د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج ١، في مصادر الالتزام، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، ١٩٦٣، ط ٢، ص ٣٠.

(١٨) وإن كان البعض، وعلى العكس من هذا الرأي، يذهب إلى أنه لا وجود لعقود إدارية أو تجارية، فالعقود كلها مدنية. (لاحظ: د. محمد سليمان الأحمد، خواطر مدنية، مكتب الفكر والوعي، السليمانية، ٢٠٠٩، ص ٢٧٣).

خارج نطاق القانون الخاص، وعقد الزواج، لكونه ليس بذی طابع مالي^(١٩) - حسب زعمه - من منطقة العقد^(٢٠).

- وهناك من يشترط اتجاه إرادة المتعاقدين إلى ترتيب أثر قانوني. وعليه سوف يشتمل هذا المطلب على فرعين: يخصص الأول منهما للتطوع المختبري بوصفه خدمة اجتماعية، وثانيهما للتطوع المختبري بوصفه عقداً.

الفرع الأول

التطوع المختبري بوصفه خدمة اجتماعية

عندما يذهب أي اتجاه إلى إنكار وصف العقد على أية رابطة، فإن ثمة اعتبارات تدفعه إلى ذلك، تقلل من النظر إليها على أنها عقد، يرجو فيه المتعاقد تحقيق مصلحة معينة هذا من جهة، وتدعم التوجه في عده الروابط مجرد علاقات اجتماعية لا يرتب عليها القانون أثراً، وهذا من جهة أخرى. إذن هناك اعتبارات اجتماعية وأخرى أخلاقية في التطوع المختبري، وسنخصص لكل منها مقصداً مستقلاً.

المقصد الأول: الاعتبارات الاجتماعية للتطوع المختبري

تتعدد في الحياة العملية أنماط الروابط الاجتماعية، مع عدم إمكان وصفها بالعقود، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يتطوعون لإجراء التجارب السريرية، فبالإضافة لمساعدة أنفسهم، فهم يساعدون الآخرين الذين قد يستفيدون من

(١٩) مع أن هذا العقد له طابع مالي، لكن الصبغة الاجتماعية فيه أبرز، كونه ترابطاً أقرب للميثاق منه للعقد، وهذا ما جعله يحتوي على نوعين من الترابط، العقدي والنظامي، والذي يجعل تدخل القانون في ترتيب آثاره أكثر من عقود أخرى، لكنه في النهاية عقد. (لاحظ: د. محمد سليمان الأحمد، المرجع السابق نفسه، ص ٣٦٥).

(٢٠) ذهب الدكتور عبد المجيد الحكيم، المرجع أعلاه، ص ٣٠، إلى أن: "بعض فقهاء القانون العام قد حاول الانتقاص من منطقة العقد، فحصرها في الاتفاق الذي يتفاوض الطرفان في شروطه على قدم المساواة بقصد التوفيق بين مصالح متضاربة، والذي يكون الغرض منه مجرد إنشاء التزامات، بحيث لو تخلف أحد هذه الشروط، لم يصبح الاتفاق عقداً ولو أُتخذ في صورة العقد، فالعبرة بالموضوع لا بالصورة، لذلك فهم لا يطلقون وصف العقد على العقود التي تجمع بين مصالح متوافقة كما في عقد الشركة، ولا على العقود التي تنظم أوضاعاً مستقرة كعقد العمل الجماعي، وتصلح الدائنين مع المدين المفلس، وغاية هؤلاء الفقهاء من وراء ذلك أن تُفسر هذه الاتفاقات لا كما يُفسر العقد، بل كما تُفسر القاعدة القانونية، أي وفقاً لمقتضى الظروف ولما تقتضي به المصلحة العامة". وقد تم هجر هذا التوجه مع تطور مفهوم العقد وحرية الإرادة.

تطوير دواء أو علاج جديد^(٢١). على سبيل المثال ذكرت Jennifer Haller وهي أول متطوعة لاختبار لقاح فيروس Covid 19 بأنها (أرادت أن تفعل شيئاً؛ ذلك لأن هناك الملايين من الأمريكيين الذين لا يتمتعون بنفس الامتيازات التي منحت لها، وأن الناس يفقدون وظائفهم وهم قلقون بشأن دفع الفواتير وإطعام أسرهم، وأتمنى أن أستطيع بهذا التطوع مساعدتهم كواجب اجتماعي)^(٢٢). وعلى هذا يدخل التطوع المختبري في باب التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بغية القضاء على الضرر الذي ينجم من مرض مجهول، تحقيقاً للخير العام الذي هو من غايات المشرع حتى عند وضع القانون.

لكن هذا لا يعني أن تأطير هذا النوع من التطوع في إطار عقدي، قد فقد دعامته الاجتماعية بشكل مطلق، لكن يبقى الأمر متعلقاً بافتراض وجود مصلحة أو عدم وجود مصلحة، وهذا ما يُجلبه طابع الاتفاق القائم بين المتطوع والجهة المشرفة على اختبار اللقاح، كما أن لنية التعاقد أو انعدامها، والتصريح بها أو التصريح بانعدامها، دوراً واضحاً في تجلي طبيعة هذه الاتفاقات. ونية التعاقد، هي نية إنشاء علاقات قانونية، فالاتفاق لا يكون عقداً - بحسب الاتجاه الشائع في الفقه - إلا إذا كان لدى كليهما، حين إبرامه نية التعاقد، أي نية إنشاء علاقات قانونية، هذه النية تكون موجودة في الكثير من الحالات، إلا أن هناك حالات كثيرة أيضاً يكون فيها من الجلي أن الطرفين لا يقصدان من اتفاقهما إنشاء علاقات قانونية. فما أكثر ما يحصل في الحياة العائلية والحياة الاجتماعية أن توجد اتفاقات لا تتوافر عند أطرافها نية الالتجاء إلى المحاكم في حالة عدم تنفيذ الاتفاقات^(٢٣)، وقد يتم التصريح بهذه النية، إذ قد تحتوي الاتفاقات المبرمة مع المقبلين على التطوع لاختبار فاعلية اللقاح، أن الطرفين لا يقصدان من هذا الاتفاق إنشاء علاقات قانونية، وهنا يحترم القانون قصدهما فلا يعتبر أيهما ملزماً، بموجب الاتفاق، في مواجهة الآخر^(٢٤).

(٢١) Office of human subject protection, op.cit. p.2.

(٢٢) Martha Ann Overland, corona virus crises, paper available at: <https://www.npr.org/2020/03/21/818759617/i-wanted-to-do-something-says-mother-of-2-who-is-first-to-test-coronavirus-vacci>. Last access April 11,2020.

(٢٣) لاحظ: د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي، ج ١، المجلد الأول، مطبوعات جامعة الكويت، ١٩٨٢، ص ٢٥٧.

(٢٤) ويضرب الفقه مثلاً: "شركة إنجليزية اتفقت مع شركة أمريكية على أن تتولى الثانية بيع منتجات الأولى، وكان من بين بنود الاتفاق ألا يرفع الخلاف بشأنه إلى القضاء، لا الإنجليزي ولا الأمريكي. ثم نشأ خلاف بين الشركتين أنهت بسببه الشركة الأمريكية الاتفاق دون أن =

لكن يجب عدم الاعتماد على التصريح بما في مكان من أنفس الأطراف المعنية بالاتفاق، فقد لا ينصان صراحة على نيتهما في ترتيب الآثار القانونية أو استبعادها، لذا يبقى على القاضي واجب كشف هذه النية عبر ما يتاح أمامه من قرائن.

المقصد الثاني: الاعتبارات الأخلاقية للتطوع المختبري

لا يقصد بالأخلاق، ما يصدر عن الطبيعة البشرية أو العادات والتقاليد السائدة بين المجتمع، بل الخير وقيمه التي تشكل الضمير الخلقي الفردي والجماعي^(٢٥). فالإنسان الذي يرى أن باستطاعته المساهمة في اختبار لقاح يستفيد منه هو أولاً والمجتمع ثانياً، تفرض عليه القيم الأخلاقية التطوع لذلك، متى ما كان متمتعاً بصحة جيدة تؤهله لذلك، صحيح أنه لا من قانون يجبره بالإلزام على التطوع، لكن الأخير يكون بدافع إيصال الخير لبني جنسه. وجاء في القرآن الكريم ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّرَبِّهِ﴾^(٢٦)، كما جاء في حديث نبوي من أنه: (أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس)^(٢٧).

وقد أخذ القانون الحديث على عاتقه تبني القواعد الكفيلة بدعم السلوكيات الصالحة للإنسان، فما عاد القانون يهتم فحسب بالسلوك السيئ، فيضع الجزاءات المناسبة عليه، بل أخذ يسهم في تربية المجتمع عبر الكثير من القواعد الموجهة لسلوك الأفراد، كالحث على تقديم المساعدة ونبذ العنف والتخلي بالصبر وتحري الصدق والتمييز بين حسن النية وسوئها، ليس في كسب الحقوق فقط، بل في المفاوضات العقدية^(٢٨)؛ ولا شك أن التطوع لاختبار فاعلية اللقاح الطبي يمثل سلوكاً

= تخطر الشركة الإنجليزية، ولما عرض الأمر على القضاء (الإنجليزي) قضى بأن (هذا الاتفاق لم يكن، من الناحية القانونية، عقداً ملزماً للطرفين)". لاحظ: المرجع السابق نفسه، ص ٢٥٨.

(٢٥) لاحظ: العمري حربوش، التقنيات الطبية وقيمتها الأخلاقية في منظور فرانسوا داغوني، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، الجزائر، ٢٠٠٧-٢٠٠٨، ص ٣٧.

(٢٦) الآية (١٨٤) من سورة البقرة.

(٢٧) لاحظ: رواية عبد الله بن عمر، المحدث، الألباني، صحيح الترغيب، ص ٢٦٢٣، تخريج الطبراني، المعجم الأوسط، ٦٠٢٦.

(٢٨) (وفي هذا المعنى يقول أحد القضاة الإنكليز SCRUNTON (في محكمة الاستئناف)، "الآن يجوز للطرفين، عن طريق قبول أحدهما إيجاباً صادراً إليه من الآخر، أن يبرما اتفاقاً يعلنان فيه أنه لا يترتب على هذا الاتفاق أي علاقات قانونية، إنني لا أستطيع أن أرى لماذا يمتنع على الطرفين، حتى في المسائل التجارية، أن يكون قصدهما ألا يعول أحدهما على حسن نية المتعاقد الآخر ونزاهته، وأن يستبعدا كل فكرة لحل منازعاتهما عن طريق أي تدخل خارجي... فإذا نص الطرفان صراحة على قصدهما هذا فليس في النظام العام، فيما أرى، ما يمنع أن يترتب على هذا القصد الأثر المقصود). نقلاً عن: د. عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص ٢٥٨.

أخلاقياً سامياً، يعبر عن روح التضامن وتفاني الفرد من أجل إنقاذ وجود المجتمع، ولهذا، وبعبداً عما إذا كان الاتفاق الذي ينجم منه هذا العمل هو عقد أم مجرد علاقة اجتماعية، فإن القانون أحاطها بالرعاية والعناية عبر إقرار الكثير من القواعد الحمائية التي تحمي الشخص في مواجهة أي ضرر يصيبه^(٢٩)، وإن ارتضى ببعض الأضرار، وكفل لهذا العمل احتراماً وتقديراً من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بأن تكافئ المتطوعين في الأعمال الخيرية بالمكافآت والجوائز، وترصين الوضع الاجتماعي للمتطوع ببعض الإجراءات التي تميزه من أقرانه، وتحث جميع أفراد المجتمع وتحفزهم على الإدلاء بدلوهم في فعل الخير والانصهار في الخدمات الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، وفي مواجهة العالم أجمع للمخاطر المحدقة التي نجمت عن انتشار الفيروسات وفي عدة مراحل من الزمن، وكان آخرها فيروس كورونا، أضى لزاماً أن يتم تدوين وسن قواعد لأخلاقيات المختبرات تحكم أنشطتها العلمية وأبحاثها الطبية، تمثل قواعد موجهة لسلوكها، لا تفتقر إلى الإلزامية، ترسخ للعلاقة القائمة بين الجهات المشرفة على التجارب الطبية والمتطوعين، وتحكم هذه الأنشطة بقواعد سلوكية تعصمها من الانحراف عن مسارها العلمي والأخلاقي والإنساني، وتجعلها تصب أنشطتها في خدمة الإنسانية جمعاء^(٣٠).

الفرع الثاني

التطوع المختبري بوصفه عقداً

ليس الغرض من العقد أن تتحقق لديك مصلحة مالية على الدوام، لكن الغرض منه أن تتحقق لديك مصلحة منه وحسب، بحيث تستطيع أن تمارس حقك القانوني في

(٢٩) لاحظ في المعنى نفسه: د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، القانون والمجتمع دراسة في علم الاجتماع القانوني، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ١٨٣.

(٣٠) يقول الدكتور أحمد فتحي سرور في كتابه "العالم الجديد..."، سبق ذكره، ص ٣٨٧: (إذا كان المبدأ الرئيسي الذي يحكم الأخلاقيات العلمية هو مبدأ الالتزام بالصدق، فإنه لا يصلح وحده في البحوث الطبية، ففي هذا النوع من البحوث ومنه قسم أبقراط أصبح البحث العلمي في البحوث البيولوجية خاضعاً لمعايير أخلاقية أخرى تُضاف إلى معيار الأمانة والالتزام بالصدق. ومع ذلك فإن هذا القسم لا يعتبر الآن كافياً ولا صالحاً لمواجهة المشكلات الجديدة التي تخلق موضوعات ذات طبيعة أخلاقية، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد لوحظ أن معظم الهيئات العلمية لا تلتزم بأي صيغة أخلاقية تحكم سلوك العلماء، فعالم الكمبيوتر، والمهندس، وعالم الطبيعة، والكيميائي، كل هؤلاء رغم الأثر الاجتماعي لأبحاثهم، فإنهم يفتقدون إلى مدونة سلوكية تلزمهم بمراعاة قيم أخلاقية معينة).

الرجوع على المتعاقد الآخر فيما لو لم تتحقق لديك تلك المصلحة؛ لكن ماذا يعني ذلك؟ وهل من ركائز لدعم هذا القول؟

سنبين في هذا الموضوع من البحث أهم الركائز التي يستند إليها العقد ومدى توافرها في التطوع المختبري، ثم إذا انتهينا إلى أن هذا التطوع يعد عقداً وليس مجرد خدمة اجتماعية، سنبحث عن الطبيعة القانونية لعقد التطوع المختبري.

المقصد الأول: الدعائم العقدية للتطوع المختبري

إن السؤال الذي يثار هنا هو كيف لنا أن نتأكد أننا بصدد عقد من العقود المعروفة والمسماة في القانون المدني، أو حتى عقد غير مسمى بمقتضى القانون المدني أو أي فرع آخر من فروع القانون، وذلك حينما يتطوع شخص ما لاختبار لقاح أو تجربة سريرية لدواء ما؟

في الحقيقة إن وصف علاقة قانونية ما بأنها من قبيل العقد يتطلب دعائم أو أسساً، فإذا أعدنا هذه الأسس وتلك الدعائم إلى أركان العقد، فلا بد من وجود طرفين، أحدهما الموجب الذي يدعو إلى التعاقد من خلال الإيجاب، والآخر هو القابل الذي يقبل هذا العرض. وفي التطوع المختبري يوجد فعلاً طرفان، أحدهما يتمثل في مؤسسة صحية أو مركز بحثي قد يدعو المواطنين للتطوع^(٣١)، وهذا يكون من قبيل الدعوة إلى التعاقد، ومن ثم يستجيب المتطوع لهذه الدعوة ويعرض نفسه لاختبار اللقاح، وأخيراً يصدر القبول من المؤسسة إذا رأت بأن كل الشروط المطلوبة متوفرة لدى المتطوع لخضوعه للاختبار السريري أو المختبري. ومن الدعائم الأخرى للعقد ضرورة أن يرد على شيء معين، بمعنى أن يكون له محل معين، وفي التطوع المختبري تعد (الخدمة المجانية) التي يقدمها المتطوع هي المحل الذي يرد عليه عقد التطوع المختبري، وفي هذا نصت الفقرة الثالثة من المادة (٧٤) من القانون المدني العراقي على أنه: (يصح أن يرد العقد على: ٣- عمل معين أو على خدمة معينة). أما التزام المتطوع فهو عمل معين، ويتمثل في تمكين الطرف الآخر من إجراء التجربة على جسمه أو حقنه باللقاح المقترح لمرض معين، وهذه خدمة مجانية. أما السبب في التطوع المختبري فقد يكون نية التبرع لدى المتطوع بأداء خدمة مجانية يستفيد منها المجتمع لاحقاً وهو الحصول على الدواء المناسب لمرض ما. وأما الباعث الدافع على التعاقد من قبل المؤسسة البحثية أو الجهة الصحية فهو خدمة المجتمع، وقد يكون

(٣١) فيما يتعلق بالإعلان والطلبات والعروض الموجهة للجمهور واعتبارها عند الشك دعوة إلى التعاقد، لاحظ، الفقرة الثانية من المادة (٨٠) مدني عراقي.

الحصول على الأرباح من خلال تسويق الدواء بعد تسجيل براءة اختراع بشأنه، فيما لو كانت تلك الجهة شركة من شركات الأدوية. وعليه فإن كل أركان العقد تجتمع في العمل المتمثل بالتطوع المختبري بشكل يؤهله لأن يكون من ضمن عقود التبرع التي نظمها المشرع في القانون المدني.

أما إذا أعدنا تلك الدعائم إلى نية التعاقد، فإن أطراف أي اتفاق يحصل بين اثنين، قد ينصان صراحة على نيتهما في ترتيب الآثار القانونية على تعاقدتهما، وقد ينصان صراحة، وعلى الرغم من وضوح صورة العقد في الاتفاق، على استبعاد الآثار القانونية، إن كل اتفاق بين الطرفين هو واجب الاحترام في حدود الشرعية العقدية، أي عدم مخالفة الاتفاق للثوابت التي حددها القانون، كالقواعد الحماائية الأمرة وما يتصل بالآداب والنظام العام؛ لكن ماذا لو لم يحدد الطرفان نيتهما، أو يفصحان عنها؟

هنا يكون على القاضي البحث عن نية التعاقد لدى الطرفين، بما تتوافر لديه من قرائن، لكن ليس عليه أن يجعل من تلك القرائن شروطاً لاكتساب الاتفاق الطابع العقدي، فوجود المقابل قرينة على وجود العقد، لكن ليس كل العقود معاوضة، فالمقابل ليس شرطاً لوجود العقد. ونية التعاقد - لهذا السبب - تجدها مهمة في عقود التبرع أكثر من عقود المعاوضة، إذ مع عدم وجود المقابل، يكون العقد أقرب إلى الأعمال الخيرية أو التطوعية التي لا تتوجه فيها النية إلى إحداث آثار قانونية، يتم الاعتماد على النية في التأكيد على وجود عقد من جهة، وعلى ترتيبه للآثار المقصودة من جهة أخرى^(٣٢).

المقصد الثاني: التكيف القانوني لعقد التطوع المختبري

المعروف في تقسيم العقود أنها تنقسم من حيث مدى وجود المقابل فيها إلى عقود معاوضة وعقود تبرع، أما عقد المعاوضة فهو العقد الذي ينال فيه كل من المتعاقدين مقابلًا لما يقدمه، كعقد البيع، فهو معاوضة بالنسبة للبائع الذي يأخذ الثمن في مقابل إعطاء المبيع، وكذلك بالنسبة للمشتري الذي يملك المبيع في مقابل دفع الثمن^(٣٣). وأما عقود التبرع، فهي التي لا يأخذ فيها المتعاقد مقابلًا لما يعطي، ومثالها عقد الهبة وعقد القرض وعقد الإعارة وعقد الوكالة دون أجر^(٣٤). وجاء في الفقرة

(٣٢) لاحظ في هذا المعنى: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (دون ذكر سنة نشر)، ص ١٣٩. د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج ١، بغداد، ١٩٦٧، ص ٦٥. د. عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص ٢٥٩.

(٣٣) لاحظ: د. محمود جمال الدين زكي، دروس في نظرية الالتزام، القاهرة، ١٩٦٦، ص ٤٩.

(٣٤) لاحظ: د. أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام، مطبعة مصر، القاهرة، ١٩٥٤، ص ٦٣.

الثانية من المادة (١١٠٧) من التقنين المدني الفرنسي الجديد أن: (عقد التبرع أو المجاني هو عقد يمنح أحد الطرفين للطرف الآخر ميزة دون توقع أو تلقي مقابل). ويميز الفقهاء عادة في عقود التبرع بين الهبات وعقود التفضّل، فالأولى هي ما يخرج به الشخص عن ملكية مال من أمواله، أما الثانية فهي التي يقدم بموجبها أحد الطرفين خدمة للطرف الآخر دون مقابل، أي أن المتبرع يولي المتبرع له فائدة، دون أن يخرج من أموال المتبرع شيئاً^(٣٥)، بل تقتصر على تركه مقابل ما يؤديه للغير من خدمة، كالوكالة دون أجر والوديعة دون أجر^(٣٦). وتسمى عقود التفضّل بعقود الخدمات المجانية^(٣٧)، أو العقود الخيرية^(٣٨)، فالمتبرع يقدم منفعة أو خدمة دون مقابل. وإذا كان كل من الهبة والتفضّل تبرعاً، فلا شك في أن الهبة أشدّ خطراً على المتبرع من عقد التفضّل؛ لأن الواهب فيها يخرج من ذمته المالية مالاً لا يعوضه بمقابل معين، أما عقد التفضّل فإن المتبرع أو المتفضّل فيه لا يخرج مالاً من ذمته، بل يُقدم خدمة ذات قيمة، إذا قدّمها غيره فإنه قد يتقاضى عنها أجراً، لكنه لا يأخذ هذا المقابل؛ هنا من الممكن أن يتنازع اتجاهان في توصيف هذا العقد:

- الأول: أن المتفضّل في عقود التفضّل قد تبرع بالأجر الذي كان من الممكن أن يتقاضاه من المتفضل له، وهذا الرأي تترتب عليه نتائج خطيرة، فهو يلحق هذا العقد بعقود التبرع، وعلى رأسها الهبة، وهو يثير إشكاليات مهمة، فيما يتعلق بالتحقق من ركن العينية في الهبة، أي ركن القبض، فالهبة لا تنعقد إلا بالقبض، فهل القبض مفترض هنا؟ كما أن هذا التصرف سيضر بذمة المتفضّل المالية، مما قد يُسبب إعساره أو زيادة في إعساره، كما يبيح لدائنيه الرجوع عليه بدعوى عدم نفاذ تصرفه في حقهم، دونما أن يُكلفوا بإثبات التواطؤ بينه وبين المتفضّل له.

- الثاني: أن المتفضّل في عقود التفضّل قد تبرع بالعمل أو الخدمة فحسب، دون إمكان افتراض تحقق الأجر، إما لأن الخدمة لا تُقدر بالمال، أو أن اختلاطها

(٣٥) لاحظ: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، الإيجار والعارية، ٢٠٠٧، ص ٨٣٤.

(٣٦) لاحظ: د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ٢، في الالتزامات، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط ٤، ١٩٨٧، ص ١٠١.

(٣٧) د. محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص ٥١.

(٣٨) Par Céline Bondard, Avocat Le contrats a titre gratuit sans contrepartie pecuniaire sont-ils legaux, jeudi 6 avril 2017. <http://www.villag-justice.com/articles/les-contrats-titre-gratuit-sans-contrepartie-pecuniaire-sont-ils-legaux,24683.htm>.

بالتابع الإنساني والشخصي الذي أكسبه إياها العمل التطوعي للمتفضل قد منع توصيفها بالمال، أو حتى تقييمها به، والحقيقة أن هذا ما دعا إلى وجود لبس في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العمل، أهو عقد أم مجرد عمل اجتماعي تطوعي^(٣٩)؟

وإذا عُذنا إلى التكييف، فإن عقود التفضل تبقى نوعاً من التبرعات، لكن محل التبرع مختلف، إذ يتجسد في الخدمة، كما أن المتفضل يُقدم خدمته بنية التطوع أو التبرع، وهذه النية مهمة جداً في تحديد وصف العقد، إذ يؤدي انعدامها إلى خروج التصرف من كونه عقد تفضل إلى الدخول في عقود أخرى توصف بأنها معاوضة، لا سيما تلك التي ترد على الخدمات، كعقد المقاولة وعقد العمل؛ لذا فإنه يجب عند صياغة عقود التفضل تدوين ما يشير إلى النية بأكبر قدر من الوضوح، لكن هل أن عدم الإشارة إلى نية التطوع يجعل الظاهر مع كون العقد معاوضة؟

إن هذا التساؤل مهم جداً في تحديد الوضع القانوني لكل من المدعي والمدعى عليه، فالمدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، أما المدعى عليه فهو من يتمسك بالظاهر^(٤٠)، وقبل هذا فإن تحديد الطبيعة القانونية للعمل التطوعي، لا سيما التطوع المختبري - موضوع بحثنا - دوراً مهماً في تحديد هذا الظاهر.

فإذا رجَّحنا الرأي الذي يذهب إلى عدّ العمل التطوعي، كالتطوع المختبري، مجرد خدمة اجتماعية، فإن الظاهر هو مع كون العمل مجانياً بغير مقابل، لكن وجود المقابل، ومع دلالة على وجود العقد، فإن انعدامه ليس دليلاً على انعدام الصفة العقدية، إذ يبرز هنا دور النية التي يصل إليها القاضي عبر القرائن، وتكون موضوعاً للإثبات من نوي الشأن، فالنية تكون فاصلة في الاتفاقات التي لا يظهر فيها مقابل يُذكر، فعلى من يقع عبء الإثبات، هل يقع على من يدعي أن العقد تفضلاً؟ أم على من يدعي أن العقد بمقابل، كأن يكون مقاوله أو عملاً؟

لربما إذا رجَّحنا الرأي الذي يذهب إلى عدّ العمل التطوعي، كالتطوع المختبري، عقداً، وكان بالإمكان تصور حصول عقد على خدمة بلا مقابل، فإن المسألة قد تدقُّ هنا، فإذا اعتبرنا أن نية التطوع هنا لا تكون مفترضة، بل لابد من إثباتها بالدلائل،

(٣٩) في التمييز بين الطبيعة القانونية والتكييف القانوني، لاحظ: د. محمد سليمان الأحمد، أهمية الفرق بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاق تطبيق القانون المختص، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدرها كلية القانون، جامعة الموصل، العدد ٢٠، ٢٠٠٤، ص ٨٩ وما بعدها.

(٤٠) لاحظ: المادة (٧/ثانياً) من قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩.

فالظاهر أن لكل عقد مصلحة، وبالتالي يكون الظاهر مع وجود المقابل^(٤١)، وعلى مدعي التفضل إثبات نية التطوع لدى المتطوع، لكن لو سلّمنا بافتراض النية في التطوع، سواء أكان افتراضاً قانونياً أم قضائياً، فإن الظاهر هو لصالح مجانية العقد، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. لكن مسألة الإثبات من الصعب ضبط إيقاعها بهذه السهولة، فالظاهر دائماً يقف إلى براءة الذمة، ولهذا يقع عبء الإثبات على مدعي انشغال ذمة المدين، كما أن قاعدة الشك يفسر في مصلحة المدين^(٤٢) لا تسعفنا هنا؛ لأن العقد إذا افترض فيه المقابل ولم يؤدّ، فإن المدين هنا متلقي الخدمة، في حين لو افترضنا المجانية فيه، فإن المدين هنا هو المتطوع (مقدم الخدمة)، لذا لا نفضل التعريف الذي وضعه قانون الإثبات العراقي لكل من المدعي والمدعى عليه، بل نفضل أن تُبحث القضية من حيث صفتي الدائن والمدين بحسب نوع المطالبة، ولهذا ذهب المشرع المصري في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٨، في مادته الأولى إلى أنه: ((على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه))، ولهذا فإنه في حالة التقاضي على الشخص متلقي الخدمة الذي يدّعي بأن العقد هو عقد تفضل إثبات ذلك. ويعود فرض عبء الإثبات على الشخص الذي يدعي أن العقد مجاني إلى العام ١٩٨٩، وذلك من خلال قرار لمحكمة النقض الفرنسية، حيث ادعى زوجان أن مهندساً معمارياً قام بالعمل في منزلهما مجاناً، نفى المهندس المعماري ذلك، واعتبر قضاة المحكمة أن الأمر متروك للمعماري لإثبات العوض والطبيعة المكلفة لخدماته، ثم حكمت المحكمة لصالح هذا المهندس^(٤٣).

ولو رجعنا إلى التطوع المختبري لوجدنا أن الشخص يتطوع لتقديم خدمة مجانية للمجتمع، وهي كما قلنا سابقاً اختبار لقاح على جسم المتطوع لمعرفة نتائجه التي قد تفضي في النهاية إلى اكتشاف علاج أو تطوير لقاح سابق لمرض مستجد بحيث يفيد المرضى المصابين به، دون أن يأخذ المتطوع مقابلاً لهذا العمل أو الخدمة. بعبارة أخرى يتجلى الالتزام الطوعي للمتطوع أو القائم بالخدمة من خلال عدم وجود

(٤١) الأصل في العقود أن تتم على سبيل المعاوضة، وعلى ذلك فإنه يقع عبء الإثبات على من يدعي نية تبرع العاقد. (لاحظ: د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الدراسات البحثية في قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٧، ص ٣٥).

(٤٢) لاحظ المادة (١٦٦) من القانون المدني العراقي.

(٤٣) Bull.1989. may. Cass.3rd Civ.31.civ.111 p.70. and, Cass.civ mars.31, 302, 20.193-14, 2016.

التزام يتحمله المستفيد من الخدمة^(٤٤). وبهذا نستطيع القول إن عقد التطوع المختبري يعد من عقود التبرع، وهو ينتمي إلى فئة عقود التفضل أو ما يسمى بعقود الخدمات المجانية. وفي هذا العقد لا توجد معاملة متبادلة للمزايا، فالتطوع يلتزم بقصد التبرع (العنصر النفسي) لتوفير ميزة للآخرين دون النظر إلى المعيار المادي^(٤٥). وهذا ما يجسد الصفة الخيرية في القانون المدني، ولكن على الرغم من أن عقد التطوع لا ينقل قيمة أو مال من الذمة المالية للمتفضل المتطوع، غير أنه تلزمه بتقديم خدمة غير مدفوعة^(٤٦)، وعلى هذا نستطيع القول إن عقد التطوع المختبري هو عقد تبرع ملزم للجانبين. ودافع الفقيه (سافاتييه) بقوة عن عقود الخدمات المجانية أو عقود التفضل حيث قال: (كثيراً ما يقتضي الأمر تقديم خدمة بناءً على عقد أو بناءً على طلب المستفيد، مثل تقديم خدمة طبية مجانية أو نقل مجاني لا تؤدي إلى افتقار الذمة المالية للمدين، وأن الشيء المهم في العقد ليس هو المقابل المادي أو العوض، وإنما العقد قبل كل شيء هو استعداد الأطراف للدخول في علاقات قانونية، وما يؤكد ذلك هو أن الاجتهاد القضائي ذهب لقبول إمكانية التصنيف التعاقدي للخدمات المجانية^(٤٧)، ومن الجدير بالذكر أن وجود مكافأة مالية (حافز للمتطوعين)^(٤٨) لا يمنع من توافر قصد التبرع لدى المتبرع (المتطوع)، فتعريض المتطوع سلامته للخطر لا يعادله أي مقابل مالي يذكر، فالهبة بعوض تظل تبرعاً على الرغم من وجود العوض^(٤٩).

(٤٤) Bergeman Nicolas. Le contrat de services gratuits un modèle pour penser l'altruisme en droit des contrats. In: Revue juridique de l'Ouest, 2010-4. pp. 445.

Bergeman Nicolas, op.cit, p.445. (٤٥)

Par Céline Bondard, op.cit, p.3. (٤٦)

Ibid, p.452. (٤٧)

(٤٨) عرض مركز الملكة ماري للابتكارات الحيوية في العاصمة البريطانية (لندن) مبلغ (٤٠٠٠) يورو للمتطوعين لاختبار لقاح ضد مرض فيروس كورونا المستجد، وسوافقون على العدوى الطوعية بـ(كورونا) عبر حقنهم بالفيروس بهدف إجراء دراسة لتطوير التطعيم بحسب صحيفة (التايمز) البريطانية. مقال منشور في صحيفة (الإمارات اليوم) بعنوان (مطلوب متطوعين لحقنهم بـ(كورونا) والمكافأة ٤٠٠٠ يورو، متاح على الموقع الإلكتروني emaratallyoum.com تاريخ الزيارة ١١/٤/٢٠٢٠.

(٤٩) كذلك الأمر في كثير من عقود الخدمات المجانية، كالنقل المجاني للأشخاص، فقد يعطي الراكب للنقل هدية رمزية، لم يكن هدف الناقل في تقديم خدمته للراكب بالمجان. (لاحظ في المعنى نفسه: الأستاذ شاكر ناصر حيدر، المسؤولية المدنية الناشئة عن النقل المجاني للأشخاص، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العراقية، العدد (١٦) لسنة ١٩٨٠، ص ١٥). وكذلك الحال في عقد إيواء السيارات بالمجان. (لاحظ: د. جعفر الفضلي و د. محمد =

المبحث الثاني الآثار القانونية للتطوع المختبري

إن البحث في الآثار القانونية للتطوع المختبري يقتضي التطرق لمسائل عدة، فمن البديهي أن اختبار أي لقاح من خلال التطوع له نتيجة معينة، وهذه النتيجة تتمثل إما في نجاح اللقاح، أو فشله، ولكل منهما آثار معينة سواء تلك التي تتعلق بالمسؤولية في حال وجود ضرر يلحق بالمتطوع، ومدى تأثير قصد التطوع في ثبوتها، وكذلك التأمين من مخاطر ذلك الاختبار، أو الحقوق المالية والمعنوية المترتبة على نجاح اللقاح في الاختبار. ووفقاً لما تقدم سنوزع الدراسة في هذا المبحث على مطلبين: يخص أولهما لآثار التطوع المختبري بحسب النتائج، وثانيهما لآثار التطوع المختبري بحسب القصد.

المطلب الأول آثار التطوع المختبري بحسب النتائج

يخضع المتطوعون لاختبار اللقاح، ويكون ذلك على مراحل قد تمتد لغاية سنة، وهذا التطوع والاختبار يفرز آثاراً بحسب نجاح اللقاح أو فشله في الوصول إلى علاج معين أو طريقة جديدة للعلاج ضد مرض معين. ووفقاً لهذا سيتم التطرق لأهم الآثار المترتبة على نجاح اللقاح أو فشله في فرعين:

الفرع الأول الآثار القانونية المترتبة على نجاح اللقاح

إذا أثبت اللقاح فاعليته، فإن ثمة آثاراً مالية وأخرى معنوية تترتب عليه، نتناولهما في مقصدين:

= سليمان الأحمد، عقد موقف السيارات، طبيعته وآثاره، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العراقية، العدد (٣١) لسنة ٢٠٠٢، ص (٧١). وكذا الحال بالنسبة لعقد الهواية الرياضية، وبحسب تعريف قواعد الفيفا للهاوي، فإنه اللاعب الذي لم يتلق أية مستحقات، ما عدا المصاريف الفعلية الحاصلة خلال مشاركته في أي نشاط، أو خلال أي نشاط متصل باللعبة، ولا يتغير هذا الوصف للهاوي، وإن حصل على جوائز أو مكافآت مالية. (لاحظ، لمزيد من التفصيل: د. محمد سليمان الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبين المحترفين، دار الثقافة، عمان، ٢٠٠١، ص ٥٣).

المقصد الأول: الآثار المتعلقة بالحقوق المالية

تطرق إعلان (هلسنكي) الخاص بالمبادئ الأخلاقية للبحوث الطبية البشرية في عام ١٩٦٤ والمعدل في ٢٩/٣/٢٠١٧، إلى حق المتطوع في تلقي الأموال الكافية للعلاج أثناء وبعد اختبار اللقاح وتكمله بالنجاح، وحق الورثة وأقربائهم في التعويض فيما لو توفي المتطوع لسبب جانبي، ليس هذا فحسب، بل يستحق المتطوع المشارك المبالغ المالية التي أعلنت عنها جهة اختبار اللقاح لقاء التطوع له، والدفع للمتطوعين الأصحاء للمشاركة في البحوث الطبية واختبار اللقاح أمر شائع، وما يتم دفعه للمتطوعين يشمل مسائل نفقات الضمان الاجتماعي ورعاية الأطفال والتنقل إلى مكان إجراء الاختبار، والضرائب، وخسارة الأرباح أو ما يسمى بالكسب الفائت على المتطوع بسبب مشاركته في الاختبار، والتعويض عن الإصابات التي لحقت بالمشاركين المتطوعين، وهذه المبالغ تختلف عما يتسلمه المتطوع من مكافآت والتي تعد خاصة بالوقت والإزعاج أو مضايقة المتطوع ببقائه في جهة الاختبار لمدة معينة^(٥٠).

أما بالنسبة للجهة مكتشفة اللقاح فلها الحق في استغلال اللقاح من خلال عقود التراخيص باستيراده واستعماله بمقابل معين، ويستطيع المخترع بيع حقه المالي أو التصرف فيه أو التنازل عنه، ومع هذا تبقى ملكية الاختراع مسجلة باسمه. وفيما يتعلق بالآثار المالية، يثار تساؤلان:

- الأول: هل يجوز للمتطوع التنازل عن المبالغ المذكورة أعلاه؟
- الثاني: هل يجوز للمتطوع اشتراط عدم استغلال الجهة التي تطوع لها، والتي أشرفت على الاختبار لللقاح الذي توصلت إليه بفضل السماح لها بتجربته عليه؟ أو أن يشترط عليها توزيعه بالمجان.

فبالنسبة للتساؤل الأول، فإن المبالغ التي تم تحديدها لا تدخل في نطاق العقد، وإلا جعلته عقداً من عقود المعاوضة، بل هي تدخل في طبيعة العلاقة الناشئة بين المتطوع وجهة التطوع، وعلى الرغم من عدم وجود نص يحكم ذلك، إلا أننا نرى وجوب النص على منع المتطوع من التنازل عن هذه الحقوق، وأن يعد لاغياً كل بند يوقع عليه المتطوع يوحي بتنازله عن تلك الحقوق، وهذا المنع إنما يقتصر على المرحلة التي يتم فيها إبرام العقد (قبل اكتساب الحق في تلك المبالغ) وبخاصة فيما

(٥٠) Matthew j czarny Nancy kass, C Flexnrm Kathryn A carson, Payment to health volunteer in clinical research, 78(3):286-93 . March 2010p.5.

لو تم التنازل للجهة التي تقوم باختبار اللقاح، أما بعد ذلك فلا مانع من التنازل عن تلك المبالغ والحقوق طالما أنها اكتسبت فعلاً ولم تكن لصيقة بشخص صاحبها. كما أنها تنتقل إلى ورثته فيما لو حصلت وفاته، سواء أكان بسبب الاختبار أم لأي سبب كان.

أما بالنسبة للتساؤل الثاني، فإنه يجوز للمتطوع اشتراط ذلك على جهة التطوع، إذ في هذا الشرط منفعة يحميها القانون، وهي منفعة مقدمة لعموم الناس، أو المرضى منهم، كما أن هذا الشرط لا يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة^(٥١).

المقصد الثاني: الآثار المتعلقة بالحقوق المعنوية

نقصد بالحقوق المعنوية تلك التي تتعلق بنتاج الفكر، ويثير أي لقاح مكتشف موضوع إمكانية الحصول على براءة اختراع بشأنه، وهذا ما ذهبت إليه منظمة الصحة العالمية بقولها: (إن هناك تسارعاً من شركات القطاع العام والقطاع الخاص في النشاط الخاص بتسجيل براءات الاختراع، كتلك التي تتعلق بالنمط الفرعي H5N1 من فيروس الأنفلونزا A وخصوصاً في سياق اللقاحات والتشخيص والعلاج)^(٥٢). واستناداً لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية العراقي رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤ فإنه: (تمنح براءات الاختراع استناداً إلى أحكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعياً، حديث ويسهم في خطوة مبتكرة يتعلق إما بمنتج صناعي جديد أو طرق صناعية جديدة أو تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة)^(٥٣). كما أن اتفاقية (تربس) اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الصادرة في عام ١٩٩٤ والتي دخلت حيز التنفيذ عام ١٩٩٥ وضعت الشروط اللازمة لكي يكون الاختراع محلاً للبراءة، وهذه الشروط هي الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي^(٥٤). وبتحليل هذه

(٥١) نصت المادة (١٣١) من القانون المدني العراقي على أنه: "١- يجوز أن يقتزن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو يكون جارياً به العرف والعادة. ٢- كما يجوز أن يقتزن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو للآداب...".

(٥٢) قضايا براءات الاختراع ذات الصلة بفيروسات الأنفلونزا وجيناتها، تقرير ضمن الاجتماع الحكومي الدولي لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات الأنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى، ٧ تشرين الثاني، ٢٠٠٧، ص ٤.

(٥٣) المادة (٢) من القانون.

(٥٤) المادة (١/٢٧) من الاتفاقية.

النصوص نراها تنطبق تماماً على اكتشاف الفيروسات واكتشاف العلاج واللقاح بشأنها. وتمنح المادة (١٢) من القانون العراقي براءة الاختراع مالكها الحق في منع الغير - إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة - من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو استيراده، إذا كان موضوع البراءة منتجاً أو طريقة صنع^(٥٥).

ومن أبرز براءات الاختراع الممنوحة بشأن اللقاح، منح شركة (فايزر) في الهند براءة اختراع للقاحها القوي للالتهاب الرئوي (بريفينار ١٣)، ويمنع قرار مكتب براءات الاختراع في الهند الشركات الأخرى من صنع نسخ أرخص من اللقاح، ويكون بيع اللقاح حصرياً في الهند لتلك الشركة حتى عام ٢٠٢٦، وهذا يشكل حرمان الدول النامية من نسخ أرخص من اللقاح^(٥٦).

وهكذا تتجسد الحقوق المعنوية لمالك براءة اختراع اللقاح في المزايا المالية

(٥٥) يقابلها المادة (٢٨) من اتفاقية تربس.

(٥٦) مقال بعنوان (براءة اختراع للقاح الالتهاب الرئوي يشكل ضربة قوية للفقراء) منسوب لقناة الجزيرة بتاريخ ٢٣/٨/٢٠١٧ متاح على موقع القناة Aljazeera.net تاريخ الزيارة ٢٠٢٠/٤/١٧.

الجدير بالإشارة إلى أن اتفاقية (تربس) في المادة (١/٣) تضمنت مبدأ المعاملة الوطنية، حيث يلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى معاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وهكذا فإن تسجيل براءة اختراع بشأن لقاح فيروس كورونا مثلاً في دولة أجنبية كأمريكا أو دول أوروبا يلزم العراق كعضو في الاتفاقية بمنح الحماية لنفسها لبراءات الاختراع الوطنية، وهذا قد يكون فيه احتكار للسوق، ويحرم الشركات الوطنية من الاستفادة من اللقاح، من منع استيرادها المنتج محل الحماية من أي سوق طيلة المدة القانونية لحماية البراءة. (لاحظ: د. ندى زهير الفيل، دور مبدأ الاستنفاد في تقييد الحق الاستثنائي للمخترع (وضرورة النص على هذا المبدأ في التشريع العراقي)، بحوث ودراسات قانونية لكلية الحقوق، جامعة الموصل، rights.uomosul.edu.iq)، وقد يكون الحل هو الاستناد لما يسمى بمبدأ الاستنفاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية والتي نصت عليها المادة (١٠) من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠٢، حيث يستنفذ حق المؤلف في منع الغير من استيراد المنتجات (اللقاحات) موضوع البراءة إذا قام بتسويقها في داخل أية دولة أو رخص باستغلالها. غير أن هذا الحل كمقتضى يجرّد الملكية الفكرية من كل معنى، وفيه انتهاك لحقوق مالك براءة الاختراع للقاح، بمعنى ينبغي أن تظل عناصر الملكية الفكرية وأعمالها موانع استخدام تتمتع بالحماية المقررة قانوناً (لاحظ: د. أكرم فاضل سعيد، انتقال الحقوق والالتزامات الشخصية في الأشياء غير المادية، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١٦، ص ٦٠٨)، وحيث إذا وجد المانع والمقتضى قدم المانع بحسب المادة (٤) من القانون المدني العراقي.

للبراءة، من مكنة إعطاء الموافقة للغير باستخدام اللقاح محل البراءة، أو الترخيص باستغلاله لقاء مقابل معين وفي جهة معينة لفترة معينة.

ولا يؤثر تمتع الجهة المصدرة للقاح باحتفاظها بحقوقها المعنوية (حقوق الملكية الفكرية)، حتى وإن اشترط عليها المتطوع عدم استغلالها للقاح، وإلزامها بتوزيعه مجاناً، فهذا الشرط يتعلق بالحقوق المالية فقط، أما الحقوق المعنوية فهي تبقى محفوظة بها، وتستطيع أن تقاضي أية جهة تعتدي عليها في هذا الشأن.

الفرع الثاني

الآثار القانونية المترتبة على فشل اللقاح

من الممكن أن يفشل اللقاح في تحقيق الغاية المرجوة منه، وقد يسبب آثاراً جانبية ليس فقط بالنسبة للمتطوع في اختبار اللقاح، بل قد تمتد آثاره الضارة إلى أشخاص آخرين، ولهذا ينبغي جبر تلك الأضرار وتعويضها، ونظراً لكثرة أعداد المتطوعين ولخطورة الاختبارات على جسم الإنسان والمبالغ الطائلة للتعويضات، لابد من التأمين على تلك الأضرار لدى شركة تأمين خاصة.

المقصد الأول: الأضرار الناجمة عن التلقيح وتعويضها

من المحتمل أن يصاب المتطوع بأضرار أثناء أو بعد خضوعه لاختبار اللقاح الطبي، على سبيل المثال أصيب ستة أشخاص شاركوا في تجربة لقاح لدواء جديد يعرف باسم TGN1412 بفشل متعدد في الأعضاء، وكانت هذه تجربة غير علاجية في المرحلة الأولى شملت متطوعين أصحاء^(٥٧)، وفي هذا الشأن يمكن الاستعانة بقوانين حماية المستهلك وقواعد المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة لمؤاخذه الجهة القائمة بتجربة اللقاح، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (١٣٨٦-٤) من التقنين المدني الفرنسي على أنه: (يعتبر المنتج معيباً إذا لم يوفر وسائل السلامة أو الأمان المنتظر منه قانوناً)، فالعيب لم يعد يقتصر على عدم صلاحية الشيء للاستعمال أو نقص منفعة، بل مدى توافر السلامة فيه، وتقدير نقص السلامة في المنتج يتطلب من القاضي الاستعانة ببعض المعايير كعرض المنتج ومدى الإعلام والتحذير من مخاطره. وفي مجال الضرر الناجم من اللقاح، إذا أصيب المشارك بأضرار نتيجة التطوع في

Clinical trial and healthy volunteer, Medical Law Review, Volume 16, Issue 1, (٥٧) Spring 2008, Pages 23-51, <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwm020>, published: 03 January 2008. Last visiting: April 14, 2020.

المراحل المبكرة من التجربة السريرية (مرحلة اختبار اللقاح)، فبإمكانه الاستناد مثلاً لقواعد حماية المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة التي جاء بها التوجيه الأوروبي بشأن مسؤولية المنتج EU/85/374؛ ذلك لأن لفظ (منتج) يشمل الأدوية والأجهزة الطبية وحتى اللقاحات، وعلى المتطوع أن يثبت عيب المنتج (اللقاح) - كأن يكون هناك عيب في تصميم الأنبوب الناقل للقاح والذي قد يتفاعل بشكل ضار مع محتوى الأنبوب، - الضرر الذي أصابه إضافة لرابطة السببية بين العيب والضرر، مع ضرورة مراعاة جميع الظروف كعرض المنتج والاستخدام المعقول للمنتج ووقت استعمال اللقاح أو تداوله، وهنا قد يكون من الصعب على المتطوع أن يثبت أن الدواء أو الجهاز المستخدم في التجربة السريرية به عيب، كما أن (الموافقة المستنيرة)^(٥٨) للمتطوع تضيق من مطالبة المتطوع بالتعويض، فالموافقة المستنيرة تعني بالضرورة إحاطة المتطوع بمخاطر تجربة اللقاح وتحذيره، كذلك يكون لمخاطر التطور العلمي دور أيضاً في تحديد مجال المسؤولية والتعويض^(٥٩). وعرفها البعض^(٦٠) بأنها العملية التي يقرر شخص من خلالها - بعيداً عن أي شكل من أشكال الإكراه أو التأثير غير المبرر - المشاركة في البحث أو الاختبار بعد أن تمت إحاطته بالمعلومات ذات الصلة بذلك القرار، ويلاحظ أن الموافقة المستنيرة تدخل ضمن ما يسمى بالالتزام بالإعلام أو الإدلاء بالبيانات، وهذا الالتزام موجود في كل عقد محله أشياء خطيرة، أو يوجد عدم توازن في المعلومات بين طرفي العقد، وفي هذا نصت المادة (١/١٥٠) من

(٥٨) الموافقة المستنيرة تعد شرطاً أساسياً في تجارب اللقاح السريرية، والهدف منها توفير المعلومات المناسبة بحيث يمكن للمشاركة المحتمل اتخاذ قرار مستنير حول ما إذا كان يجب عليه التسجيل في التجربة أم لا، وهذه المعلومات تتعلق بتوضيح حالة البحث، ووصف الفوائد والمخاطر، والمعالجة البديلة التي قد تكون متاحة، وحقوق ومسؤوليات الشخص. ينظر: Valeria Ferro, Legal Aspects of Informed Consent in Clinical Research: the Case of Vaccinations in the International Legal Framework, BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2019.

وبحسب المادة (٢١/١) من مشروع قانون التجارب السريرية المصري فإن الموافقة المستنيرة هي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطوعية كاملة، والذي يصدر عن الشخص ذي الأهلية، وتتضمن موافقته الصريحة توقيماً وبصمة على المشاركة في البحث. Katie Chandler, Clinical Trial Liability - Navigating the Legal, Regulatory and Insurance Landscape, Journal for Clinical Studies, Volume 10 Issue 6, 2014, p.36.

(٦٠) لاحظ: د. محمد الطاهر جرمون، إعلان هلسنكي بين تأسيس التجارب الطبية واحترام حقوق الإنسان، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، العدد ٣، المجلد ٩، ٢٠١٨، ص ٤٣٨.

القانون المدني العراقي على أنه: (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). ويعد الوفاء بالحصول على الموافقة المستنيرة للمتطوع طريقاً لتنفيذ الجهة القائمة بتجربة اللقاح لالتزامها بالسلامة، وفي شأن هذا الالتزام ذهب المشرع العراقي إلى أنه: (ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام)^(٦١). وهذا يعني التزام الجهة القائمة باختبار اللقاح بالسلامة وإن لم ينص عليه في عقد التطوع المختبري^(٦٢).

وبموجب التوجيهات الأوروبية ذات الصلة وأهمها (EC and 2005/28 Ec/20/2001)، والتنظيم الأوروبي للتجارب السريرية لسنة ٢٠٠٤، فإنه يجب على الجهة التي تقوم بالتجربة السريرية لاختبار اللقاح بالتعهد - من خلال التزام تعاقدية - بمنح التعويض في حالات الإصابة كلما تم إثبات رابطة السببية بين خطأ هذه الجهة والإصابة، وجوهر التعهد يكون كالتالي: (إذا تدهورت صحة وحالة المتطوعين في التجربة السريرية بشكل كبير، سيقوم الراعي (الجهة) بتعويض المتطوع، بغض النظر عن قدرة المتطوع على إثبات الخطأ من جانب الجهة الراعية للاختبار). ولتقدير التعويض ينظر إلى مقدار الأضرار والتعويض الذي كان سيمنح في حالات مماثلة^(٦٣). وجاء في قانون إجراء الدراسات الدوائية للمملكة الأردنية رقم (٢) لسنة ٢٠١١ أنه: (تتحمل الجهة التي تقوم بإجراء الدراسة الدوائية المسؤولية القانونية عن الأضرار

(٦١) الفقرة الثانية من المادة (١٥٠) مدني عراقي.

(٦٢) وهذا عائد إلى أن اللقاح لا شك يعدّ من المنتجات الطبية الخطرة، فالشركة أو المؤسسة أو الجهة التي تشرف على اختبار اللقاح، هي في العادة الجهة الصانعة له، فمسؤوليتها غير مفصولة عن مسؤولية المنتج، إذ يقع على عاتق المنتج عدد من الالتزامات، منها الالتزام بالتبصير والالتزام بالتتبع، والالتزام الأخير يفرض عليه أن يتتبع كل التطورات العلمية الحاصلة والمستجدة على صناعته للدواء أو اللقاح، وبعبارة أخرى يكون مسؤولاً عن أي ضرر ناجم عن اللقاح لم يراع فيه المنتج المعطيات العلمية، ففي حكم قضائي هو "Wright V Dunlop Rubber co" لاحظت محكمة الاستئناف أن واجب الصانع ليس ضرورياً تحديده في مدة زمنية هي السابقة على طرح المنتج للتداول، بل يجب أن يمتد تنفيذ هذا الواجب ليساير التطور العلمي إذا ما أصبح يمثل خطراً على صحة الإنسان. (لاحظ: د. أسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص ٩٧).

(٦٣) Insurance and compensation in the event of injury in Phase I clinical trials, Guidance developed by the Association for the British Pharmaceutical Industry, the BioIndustry Association and the Clinical Contract Research Association in consultation with the Department of Health and the National Research Ethics Service, p.5-6.

التي تلحق بالمتطوع نتيجة مشاركته في الدراسة^(٦٤). ومن هذا النص نستنتج أن التزام الجهة القائمة باختبار اللقاح بالحفاظ على سلامة المتطوع هو التزام بنتيجة، وتكون مخلة بالتزامها بمجرد عدم تحقق هذه النتيجة ما لم تثبت السبب الأجنبي.

لكن هذا لا يكفي، إذ يجب أن تكون هناك فترة، بعد أخذ اللقاح، يمكن أن تسمى فترة مراقبة الحالة الصحية للمتطوع، يتم تحديدها حسب كل حالة وخطورتها، يلتزم فيها الراعي أو الجهة التي أشرفت على الاختبار اللقاحي، بضمان سلامة المتطوع، وليس فحسب الالتزام بسلامته^(٦٥)، فيكون التزام هذه الجهة أكثر تشدداً، فهو التزام بضمان النتيجة^(٦٦)، لطالما أن هذه الفترة لن تقض بعد، إذ يعد المتطوع في عهدة الجهة المشرفة على اختبار اللقاح، فتتحمل مسؤولية أي ضرر حاصل له، ما عدا تلك الأضرار المتوقعة الناجمة عن تلقي اللقاح، والتي تم تبصيره بها وقبل بها وتعاقد على أساسها، لكن ما عدا هذه الأضرار تتحملها الجهة المشرفة على الاختبار اللقاحي، وإن حصلت بحادث فجائي أو بقوة القاهرة^(٦٧)، فالمتطوع في هذه الفترة تحت حراستها وعنايتها ورعايتها، فهو في حالة مرضية تستوجب المراقبة الحثيئة، وهذا الالتزام يُشدد المسؤولية على الجهة المستفيدة من الاختبار، ويجعلها تطابق مفهوم الضمان في صورته التأمينية^(٦٨)، وهو ما يزرع في نفوس المتطوعين الطمأنينة، في أنهم في أمان صحي عالي المستوى، بعد خوضهم لهذه التجربة ذات البعد الإنساني العظيم.

- (٦٤) المادة (٩/ب) من قانون إجراء الدراسات الدوائية في الأردن رقم (٢) لسنة ٢٠١١.
- (٦٥) لاحظ: د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج١، الضرر، بغداد، ١٩٩١، ص ١١٠.
- (٦٦) لاحظ: د. محمد سليمان الأحمد، عقود تنظيم المسابقات الرياضية والمسؤولية المدنية الناجمة عنها، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠٠٢، ص ٢١٧.
- (٦٧) لاحظ: د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الفعل الضار والمسؤولية، المجلد الأول، القاهرة، ١٩٩٢، ط ٥، ص ٤٨٦.
- (٦٨) أقر القضاء الفرنسي بوجود الالتزام بضمان السلامة قديماً، إذ يرجع ذلك إلى عام ١٩١١، عندما تبنت محكمة النقض الفرنسية الرأي القائل بأن: "عقد نقل الأشخاص ينطوي على التزام بضمان سلامة شخص الراكب، فإذا أصيب هذا الشخص بضرر، في أثناء نقله، عُذ ذلك إخلالاً بالتزام ناشئ عن عقد النقل نفسه، تنهض معه المسؤولية العقدية"؛ فكان هذا الالتزام مقتصرًا في البداية على عقود نقل الأشخاص، ثم أخذ القضاء الفرنسي يُوسّع من نطاقه وعلى مدى عقود من الزمن، ليشمل عقوداً أخرى غير مسماة، كعقد التعليم، وعقد النزول في الفندق، وعقود تنظيم المسابقات الرياضية. (لاحظ: د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص ١١٢. وأيضاً: د. عبد الرحمن الطحان، المسؤولية عن الدواء غير الصالح، بحث منشور في وقائع وبحوث المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق في جامعة الموصل، التشريعات الصحية سبل تفعيلها وتطويرها، ٢٠٠٨، ص ٩. وأيضاً: د. محمد سليمان الأحمد، عقود تنظيم المسابقات، مرجع سابق، ص ٢١٨).

المقصد الثاني: أساس الرجوع بالتعويض ونظرية قبول المخاطر

من المعلوم أنه لتعويض الضرر يشترط أن تتوافر أركان المسؤولية المدنية عموماً من خطأ وضرر ورابطة سببية بين الخطأ والضرر، ومن المعلوم أيضاً أن إثبات رابطة السببية قد يعترئها مشكلات، من بينها تعدد الأسباب في إحداث الضرر، كما لو تدخل المتضرر برضائه في إلحاق الأذى بنفسه. وهنا يذهب بعض الفقه^(٦٩) إلى أنه لا تعويض إذا استهدف المتضرر للضرر برضائه في الحالات التي يصح فيها هذا الرضاء، كمن يساهم في الألعاب الخطرة كسباق السيارات والملاكمة وغيرها^(٧٠)، أو من يرتضي مجامعة مريض بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) جنسياً، مع علمه أنه مصاب بهذا المرض^(٧١). وبقياس ما سبق على عمل المتطوع نقول إننا لا نشارك هذا الرأي، فالتطوع لاختبار اللقاح يعد متفانياً في مساهمته بالتطوع، وهو لا يجلب مصلحة مادية مباشرة لنفسه في هذا الفعل، بل كما سبق فهو يقدم خدمة مجانية للمجتمع، وفي هذا اختلاف بين، فالتطوع يتدخل ويغامر في محاولة لمنع الأذى عن الآخرين ومغامرته لا تحسب عليه.

يقول البعض الآخر^(٧٢) - بحق - إن الأصل هو أن رضاء المتضرر بالضرر لا أثر له في مسؤولية المدعى عليه التي تبقى كاملة، كما لو أجرى طبيب - في غير ما ضرورة - عملية خطيرة لمريض ولو كان ذلك برضاء المريض، لكن هذا الرضاء يمكن أن يرقى إلى درجة الخطأ، وبذلك نكون أمام الخطأ المشترك، إذا كان هذا الرضاء لا يمكن أن يصدر من الرجل المعتاد، وعلى هذا يمكن عد رضاء المتطوع من قبيل الخطأ الذي يتمثل في رضاء المتطوع بقبول المخاطر التي تنجم من اختبار اللقاح، والخطأ هنا يكون مشتركاً مع خطأ الجهة القائمة في الاختبار في عدم الحفاظ على سلامة المتطوع أو إهمالها في ذلك، ولا يمكن بعد ذلك أن نتحدث عن استغراق خطأ المتطوع لخطأ الجهة القائمة بالاختبار.

(٦٩) د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني، (أصول الالتزام)، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٧٠، ص ٢٤٥.

(٧٠) لاحظ: د. لطفي البلشي، قبول المخاطر الرياضية ودوره في تحديد المسؤولية المدنية، القاهرة، ١٩٩٤، ص ٥١.

(٧١) لاحظ: د. محمد محمد أبو زيد، بعض المشكلات القانونية الناتجة عن مرض فقد المناعة المكتسبة (الإيدز)، الكويت، ١٩٩٦، ص ٩٨.

(٧٢) د. أحمد حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ٤٤٧. د. أحمد إبراهيم العشماوي، فعل المضرور والإعفاء الجزئي من المسؤولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٥٢ وما بعدها.

لكننا نود أن نضيف هنا أنه، وإن كان من الصواب عدم رضا المتطوع وقبوله للمخاطر، خطأً منه يوجب وصفه من قبيل السبب الأجنبي، بل الاكتفاء بإنقاص مقدار التعويض المستحق له، كونه متضرراً، لكن يجب النظر، ومن زاوية التزام الجهة المشرفة على الاختبار اللقاحي بضمان سلامة المتطوع، أن مسؤوليتها قائمة، فهي تأخذ معنى الضمان^(٧٣)، وهذا الالتزام يجعلها ضامنة حتى مع قيام السبب الأجنبي في صورتها الحادثة الفجائي والقوة القاهرة، لكنها تعفى من المسؤولية إذا تحققت صور أخرى للسبب الأجنبي، ومنها خطأ المتضرر العمدي، فهو يستغرق خطأها المفترض لدرجة يمكن وصفه سبباً أجنبياً مانعاً لقيام مسؤوليتها^(٧٤).

وغالبا ما تؤثر الصفة المجانية للعقد على المسؤولية، فقد خفّض القضاء الفرنسي هذه المسؤولية على الناقل بالمجان كونه متبرعاً، لكن المسألة هنا مختلفة، فالبحث يدور هنا حول مسؤولية المتبرع له وليس المتبرع، وبالتأكيد هي ستكون أشد إذا ما قسنا على درجة الانتفاع من العقد، فالغرم بالغنم، إذ تتشدد المسؤولية بحسب درجة ذلك الانتفاع، فمسؤولية المتبرع له أشد من مسؤولية المعاوز، ومسؤولية الأخير أشد من مسؤولية المتبرع^(٧٥).

نخلص مما سبق، وفي حدود تفسير قبول المتطوع للمخاطر التي يمكن أن تصيبه، وتبصيره بها، تتوزع المسؤولية بين الجهة القائمة باختبار اللقاح والمتطوع، مما يكون ذلك سبباً في إنقاص التعويض المستحق للمتطوع بسبب رضائه بقبول المخاطر المحاطة بعملية اختبار اللقاح حينما وقع جميع استمارات التسجيل للتطوع.

ويكون رجوع المتضرر وهو المتطوع هنا، على الجهة المسؤولة، على أساس المسؤولية العقدية، لوجود عقد التطوع بينهما، وهنا يكون من السهل على المتطوع إثبات الخطأ، فالجهة المشرفة على الاختبار التي تعاقد معها، ملتزمة تجاهه بضمان سلامته^(٧٦).

(٧٣) لاحظ في الفرق بين الالتزام والضمان من جهة والمسؤولية والضمان من جهة أخرى: د. محمد سليمان الأحمد، المدخل لدراسة الضمان، دار الحامد للنشر، عمان، ٢٠٠١، ص ٢٣ وما بعدها.

(٧٤) لاحظ: د. رضا محمد جعفر، مرجع سابق، ص ٢٩٩. و د. يوسف أحمد حسين النعمة، مرجع سابق، ص ١٢٢.

(٧٥) لاحظ: د. علي عبيد الجيلاوي، رضا المتضرر وأثره في المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، ١٩٨٨، ص ٣٨٣.

(٧٦) لكنه سيضطر في الرجوع عليه بدعوى المسؤولية التقصيرية إذا أخذنا بالرأي الذي لا يعتد بوجود عقد الاختبار التطوعي للقاح، بل يصوره على أنه عمل تطوعي ذو طابع اجتماعي خيري وإنساني فحسب، وهنا تكون المسألة أصعب على المتطوع المتضرر من اللقاح، =

المطلب الثاني

آثار التطوع المختبري بحسب القصد

حينما يقصد المتطوع تقديم خدمة مجانية دون مقابل لجهة راعية لتجربة لقاح معين، فما هو مفهوم هذا القصد من الناحية القانونية؟ وهل لتوافر هذا القصد أي أثر فيما يتعلق بمدى إمكانية المطالبة بالحقوق المنبثقة من عقد التطوع؟ هذا ما سنتناوله في فرعين:

الفرع الأول

قصد التطوع

سنقسم هذا الفرع إلى مقصدين: نتعرض في أولهما لمفهوم قصد التطوع، وفي ثانيهما لتجليات الآثار المترتبة على التطوع بتوافر القصد.

المقصد الأول: مفهوم قصد التطوع

إن المشارك في اختبار اللقاح المختبري، إنما يقدم خدمة مجانية للجهة الراعية لاختبار اللقاح وذلك بقصد التطوع، وقصد التطوع إنما نقصد به قصد التبرع أو نية التبرع دون الحصول على مقابل من تلك الجهة. وعموماً قد يقصد بقصد التطوع هو الرضاء الذي ينبغي أن يتجه إلى أمرين، هما عبارة العقد وأثر العقد، بأن يكون المتطوع عالماً بآثار العقد، فبخلاف ذلك قد لا تتجه إرادته لإبرام التصرف القانوني. وقد يقصد بقصد التطوع الباعث الدافع على التعاقد، وهو الغرض غير المباشر للمتعاقد من وراء إبرامه لعقد التطوع^(٧٧)، فقصد المتطوع تقديم خدمة إنسانية إلى المجتمع من خلال اختبار اللقاح على جسمه، وقد يكون باعته متمثلاً في الاعتقاد الراسخ لديه بخدمة الإنسانية، أو الشهرة، أو أنه قد يئس من حياته ويود المغامرة، أو أنه حب المغامرة في ذاتها، أو الحصول على بعض المقابل المادي المتمثل بالمكافأة، وهذا هو سبب العقد، والذي يفترض فيه الوجود والصحة والمشروعية، ما لم يتم

= إذ عليه أن يثبت خطأ الجهة المشرفة، لكن هذه الإشكالية وضع لها القضاء الفرنسي حلاً، إذ ما هي إلا صورة من صور مسؤولية المنتج عن منتجاته الضارة، التي ألحقها هذا القضاء بأحكام المادة (١٣٨٤) من القانون المدني الفرنسي، وهي الخاصة بالمسؤولية عن الأشياء، والتي أقامها على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. (لاحظ في تطبيق أحكام المسؤولية عن الأشياء على مسؤولية المنتج: د. عبد الرحمن الطحان، بحثه سبق ذكره، ص ١٠).

(٧٧) لاحظ: د. محمد سليمان الأحمد، النظرية العامة للقصد المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٩، ص ١٨٣ وما بعدها.

الدليل على خلاف ذلك^(٧٨)؛ وقد يكون قصد التطوع هو نية التبرع في ذاتها، وهذا هو سبب الالتزام بحسب النظرية التقليدية في السبب^(٧٩).

المقصد الثاني: تجليات الآثار بتوفر قصد التطوع

تذهب غالبية الفقهاء في تقسيمهم للعقود الواردة في القانون المدني، إلى أن من بين فوائد التمييز بين عقود المعاوضة وعقود التبرع هي أن مسؤولية المعاول أشد من مسؤولية المتبرع^(٨٠)، كما أن ضمان المتبرع أخف من ضمان المعاول، وبتطبيق هذا القول على عقد التطوع الطبي، نلاحظ أن المتطوع يقدم خدمة مجانية أو دون مقابل، فمن الصعب تصور الرجوع عليه بالمسؤولية، فهو أشبه بالمتفاني والمضحي في اختبار اللقاح، ويعد عمله هذا عملاً مدنياً بعيداً عن أي قصد للمضاربة أو الربح. لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للجهة القائمة بالاختبار التي غالباً ما يكون عملها للأغراض التجارية، من تسويق للقاح وبيعه وما شابه، وبالتالي يمكن اعتبار عملها معاوضة في عقد التطوع المختبري، وبالتالي تكون مسؤوليتها كمسؤولية البائع في عقد البيع مثلاً، والحكم نفسه بالنسبة للضمان. بعبارة أخرى يظل المتطوع متمتعاً بحقوقه المنبثقة من العقد والتي تقابل التزامات الجهة القائمة بالاختبار وتحديداً عند الإخلال بها، ولكن هل يتغير الحكم فيما لو كان المتطوع يقصد التبرع^(٨١)؟

في الحقيقة فإن قصد التطوع لا ينفي مسؤولية الجهة القائمة بالاختبار إذا ما أخلت بالتزاماتها، بل يشدد منها، أما بالنسبة لأخذ موافقة المتطوع المستنيرة عند بدء الاختبار والتوقيع من قبله على مجموعة من الاستمارات، فهي لا تندرج ضمن اتفاقات

(٧٨) وقد استبدل القانون المدني الفرنسي في تعديله في عام ٢٠١٦، فكرة السبب الباعث بفكرة مضمون العقد.

(٧٩) لاحظ: د. محمد علي عبد، نظرية السبب في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٤، ص ٣٨.

(٨٠) لاحظ: د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، مرجع سابق، ص ١٠٢. و د. علي عبيد الجبالوي، مرجع سابق، ص ٣٨٣.

(٨١) وهذا ما يجعل عقود التبرع تتمايز من عقود المعاوضة من حيث المسؤولية، ففي الأخيرة تتساوى مسؤولية الطرفين، فكلاهما معاوض، أما في عقود التبرع، فإن مسؤولية المتبرع له أشد من مسؤولية المتبرع، وهذا يظهر في عقدي الإعارة والوديعة، ففي الإعارة يكون المعير متبرعاً والمستعير متبرعاً له بالخدمة، إذ يُشدد القانون في مسؤولية المستعير في المحافظة على المال المعار، في حين أن في عقد الوديعة، حيث يكون الوديع متبرعاً بالحفظ، والمودع متبرعاً له، تكون مسؤولية الوديع في الحفظ أخف من مسؤولية المستعير. (لاحظ في المعنى نفسه: د. حسن علي الذنون، أصول الالتزام، مرجع سابق، ص ٢٧).

الإعفاء من المسؤولية، والتي تعد مثل هذه الاتفاقات باطلة لمخالفتها للنظام العام، كون أن اختبار اللقاح يمس الصحة والسلامة الجسدية للمتطوع.

الفرع الثاني

تحديد الآثار القانونية المنبثقة عن التطوع المختبري

من الطبيعي أن تترتب آثار قانونية على عقد التطوع عموماً، وعقد التطوع المختبري على وجه الخصوص، سواء اتجهت النية منذ لحظة إبرام العقد إلى إحداث هذه الآثار أم لا، إذ يرتب القانون الكثير منها لحماية الطرف الضعيف^(٨٢)، ومع عد هذا العقد عقداً ملزماً للجانبين، على الرغم من أنه عقد تبرعي، يجعل هناك التزامات على طرفيه.

ففي مقابل التزام الجهة المشرفة على الاختبار بضمان سلامة المتطوع، بكل أبعاد هذا الالتزام، من توفير أجهزة سليمة، وبيئة نظيفة، ومكان ملائم، والقيام بكل الأعمال التي تستلزمها عملية الاختبار، يقع على المتطوع التزام بوضع نفسه وتسليمها إلى الجهة المشرفة على الاختبار والالتزام بتعليماتها وإرشاداتها، كما يجب عليه أن يكون أميناً في تزويد الجهة القائمة على الاختبار بجميع المعلومات اللازمة عن حالته الصحية قبل الشروع في الاختبار^(٨٣).

لكن أهم أثرين يترتبان على هذا العقد هما، كيفية مواجهة المخاطر التي من الممكن أن تواجه صحة المتطوع في أثناء أو بعد عملية الاختبار، وكيف نكافئ شخصاً غامر بحياته لبواعث يفترض فيها، كأصل عام، أنها بواعث إنسانية؟ وهذا ما سنعالجه في مقصدين.

المقصد الأول: التأمين ضد المخاطر

ظهرت الحاجة إلى نظام التأمين من مخاطر التجارب السريرية ضمن المبادئ التوجيهية الأخلاقية للبحوث الطبية الحيوية على البشر والتي نشرها المجلس الهندي للبحوث الطبية في عام ٢٠٠٠، حيث نصت على أن كل اختبار لدواء أو لقاح (بحث

(٨٢) وهذا ما يطلق عليه الآثار الجعلية للعقود. (لاحظ: د. محمد سليمان الأحمد، النظرية العامة للقصد المدني، سبق ذكره، ص ٢٠٠).

(٨٣) كما يقع على عاتق المتطوع التزاماً بعدم إفشاء أية معلومات يتم تداولها أمامه من قبل الأطباء أو المختصين التابعين للجهة المشرفة على الاختبار، لتعلق الأمر بحق معنوي لهذه الجهة في براءة الاختراع، كون هذه المعلومات مما لا يجوز الفصح به. (لاحظ للتفصيل: د. حسام الدين الصغير، حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ٢٠٠٥، ص ٢٣).

سريري) يجب أن يتضمن آلية مدمجة لتعويض المشاركين من البشر من خلال غطاء التأمين أو أية وسيلة أخرى لتغطية جميع المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة، والرعاية اللاحقة بما في ذلك العلاج أثناء وبعد التجربة أو البحث، فيما يتعلق بأي تأثير قد يحدثه إجراء البحث أو التجربة على المشارك البشري، وضمان اتخاذ تدابير تعويض وتأهيل فوري لجميع المتضررين متى كان ضرورياً^(٨٤).

وينبغي على الجهة القائمة بالاختبار السريري لتجربة اللقاح أو الدواء، أن تقدم إلى الجهات المختصة شهادة تأمين بموجب بوليصة تأمين سارية، وبعد النظر في شهادة التأمين، فإن وثيقة التأمين ينبغي فيها أن تكون صالحة لتغطية الأضرار التي تنشأ من أنشطة التجارب السريرية طوال مدتها، وبالتالي يغطي هذا التأمين كل مسؤولية يمكن أن تثار ضد الجهة القائمة بالاختبار أو المشرفة عليه، ولكن يخرج من نطاقه كل ضرر يكون قد ترتب عن طريق حادث دون قصد، أو يعزى إلى الإهمال أو التحايل أو عدم الخبرة أو يكون سببه منتجاً معيباً^(٨٥).

وبالنسبة لتجارب الدول حول التأمين من أضرار التجارب السريرية نشير إلى قانون الصحة العامة الفرنسي، حيث خصص العديد من المواد للتأمين وتعويض المشاركين في اختبار اللقاحات والأدوية، حيث تميز المادة (L1121-7) بين التجربة الطبية لمنفعة فردية والتجربة دون منفعة فردية مباشرة، وتقضي في التجارب ذات المنفعة الفردية المباشرة إلى وجوب قيام الجهة القائمة بالتلقيح بدفع التعويض للمريض المصاب دائماً حتى على أساس عدم وجود الخطأ، وحتى لو انسحب المتطوع من الاختبار مبكراً، ما لم تتمكن الجهة القائمة بالاختبار من إثبات إهمال المريض أو إهمال الجهات الأخرى التي شاركت في الاختبار، ولتغطية مسؤولية الأطراف المعنية، على جهة الاختبار الاتصال بالتأمين الخاص، وحينما تكون الجهة التي أجرت الاختبار هي الدولة، فلا حاجة للتأمين، ولكن على الدولة أن تتحمل الالتزامات التي تتعلق عادة بشركات التأمين^(٨٦).

(٨٤) and, Insurance in clinical research, perspect clin res, v.5 (4) 2014 Oct-Dec, p. 2.

(٨٥) Carlo Tomino Pharm.D., Insurance Policy for Clinical Trials, June 2012, www.unicri.it/special_topics/clinical_research/ethics_human_rights/training_tanzania/Tomino%20%20Insurne.pdf, last access, April 13, 2020.

(٨٦) Sabina Gainotti* and Carlo Petrini2, Insurance Policies for Clinical Trials in the United States and in some European Countries, Journal of Clinical Research & Bioethics, Volume 1 Issue 11000101, 2010, p.4.

ومن الدول التي نصت صراحة على وجوب التأمين من مخاطر اختبار اللقاح، الأردن، حيث صدر فيها قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم (٢) لسنة ٢٠١١، حيث نصت المادة (٥/ب) على أنه: (تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي: ٢- إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين العاملة في المملكة لتغطية الأضرار التي قد تنتج عن الدراسة وخاصة ما يتعلق منها بالإنسان الذي تجري الدراسة عليه...). وهذا التأمين يجب أن يكون تأميناً صحياً شاملاً لأي ضرر يمكن أن يحصل للمتطوع في المستقبل القريب أو حتى البعيد، بحسب نوع اللقاح؛ وعادة ما تحمي الجهات التي تتولى عملية التجارب المختبرية على اللقاحات نفسها عبر منظومة أخرى للتأمين، هي التأمين من مسؤوليتها المدنية^(٨٧)، ومهما كان تكييف هذا النوع من التأمين، فهو تأمين لدين المسؤول أو أنه تأمين لحق المضرور^(٨٨)، فإنه يعطي غطاءً من الأمان لكل متطوع أقبل على اختبارات التلقيح، لكن مع وجود النمطين المختلفين للتأمين، فإن الأمر يحتاج لتدخل تشريعي يضمن بكل صرامة ألا يتعثر أي ضرر يصيب المتطوع نتيجة التطعيم باللقاح من أي تعويض.

ومن الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قد أحاط المتطوع لاختبار مدى فاعلية اللقاح الطبي بمراحل متعددة من الحماية والغطاء التعويضي لما قد يصيبه من ضرر، بدءاً من التعويض من قبل الجهة المشرفة على الاختبار من خلال تأمين خاص، منظماً جواز رجوع شركة التأمين على الجهة المشرفة على الاختبار، بما يجاوز المخاطر التأمينية، بعدما تكفلت بدفع التعويض إلى المتضرر، وصولاً إلى إقرار نظام التعويض على أساس التضامن الوطني عبر المجلس الإقليمي للمصالحة والتعويض عن الحوادث الطبية، الذي له إجراءاته الخاصة في حصول المتضرر من الأبحاث والتجارب الطبية على التعويضات اللازمة^(٨٩)، وهو ما يشكل ضماناً قوية للمتضررين المتطوعين لاختبار فاعلية اللقاح الطبي.

(٨٧) وهو لا يختلف عن التأمين عن المسؤولية المدنية الطبية. (لاحظ: د. أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠١٢، ص ١٧٦).

(٨٨) لاحظ: د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ١٩٩٣، ص ٣١ وما بعدها.

(٨٩) لاحظ لمزيد من التفضيل حول هذه الضمانات وأحكامها وإجراءاتها: د. ياسر عبد الحميد محمد الإفتيحات، مرجع سابق، ص ١١١٣-١١٥٥.

المقصد الثاني: مكافأة العمل التطوعي في مجال الاختبارات الطبية

يتلقى المتطوعون في الاختبارات الطبية مبالغ معينة، تعد بمثابة مكافأة على مشاركتهم في الاختبار، لكن الحصول على هذا المال قد يستغرق الكثير من الوقت، وهذه المبالغ قليلة جداً مقارنة مع حجم خطورة اشتراكهم وخضوعهم للاختبار بما في ذلك المساس بمعصومية الجسد وسلامة الإنسان. ولكن الدراسات أثبتت أن معظم حالات المشاركة في تلك الاختبارات من متطوعين لم يتلقوا العناية الطبية اللازمة، ولا الأجور الإضافية وحالات التأمين من العجز إذا ما أصيبوا بإعاقه حتى أثناء التجربة السريرية. وعلى الجهة القائمة بالتجارب السريرية الداخلية منح المتطوعين كل وسائل الترفيه والمصاريف التي تقتضي ذلك، وتغطية تكاليف السفر، وشهادة مكافأة على الاشتراك والتطوع في برنامج اختبار اللقاح^(٩٠). غير أن تلك المكافأة لا تعني عدم وجود مسؤولية للجهة القائمة بالاختبار، فهذه المكافأة لا توازي أبداً أو لا تقارن بتعريض سلامة المتطوعين للخطر، خاصة إذا ما علمنا أن تلك المكافآت هي مجرد تعويض بسيط لضاياع الوقت وعدم الراحة للمتطوعين، ولا تقابل الإصابات، بل إن معظم المتطوعين يشاركون في الاختبارات ليس من أجل المال، بل لغرض المصلحة العلمية^(٩١) أو هكذا يُفترض. ويشير البعض إلى أن الحوافز والمكافآت تثير القبول الأخلاقي للأجر، وتؤثر على الطبيعة الطوعية للمشاركة، وقد تؤدي هذه الحوافز إلى الكذب والخداع أو إخفاء المعلومات. ومن الجدير بالذكر أن دفع المكافآت ليس سوى أحد الأسباب العديدة التي يختارها المتطوعون الأصحاء للمشاركة في التجارب السريرية، وعلى هذا ينبغي ألا يؤثر هذا الدفع مثلاً سبق القول في مسؤولية الجهة القائمة باختبار اللقاح وإجراء التجربة السريرية، فالتعويض عن أضرار هذه الاختبارات ليس فيها خلاف يذكر^(٩٢).

(٩٠) Tom Scheve, Risks and Rewards of Volunteering for Clinical Trials,. Last visiting: April 17, 2020.

(٩١) J.Bigorram J..E bannos, Weight of financial reward in the decision by medical students and experienced healthy volunteers to participate in clinical trials, volume 38, pages443-446(1990).

Matthew j czarny and others, p.8.

(٩٢)

الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات بشأن الدراسة، وهي كالآتي:

أ - الاستنتاجات:

- ١ - التطوع في اختبار فاعلية اللقاح الطبي هو عقد يبرم بين طرفين أحدهما يسمى بالمتطوع أو المشارك، والآخر هو الجهة الراعية للاختبار من مؤسسة أو معهد أو شركة، بموجب هذا العقد يخضع المتطوع لاختبار اللقاح عبر حقنه في جسمه أو تناوله، دون مقابل يؤخذ من الطرف الآخر، مع التزام الأخير بضمان سلامة المتطوع من أية مخاطر غير متوقعة تخرج عن الأخطار التي قبل بها.
- ٢ - توصلت الدراسة إلى أن عقد التطوع لاختبار اللقاح هو من عقود التبرع، ويقع في التقسيم الفرعي لهذه العقود والتي تسمى بعقود التفضل، ففيه يقدم المتطوع خدمة مجانية للطرف الآخر دون أن يخرج من ماله شيء. ويوصف هذا العقد بأنه عقد ملزم لجانبيين، صحيح أن المتطوع يتبرع بخدمة دون مقابل، ولكنه يلتزم تجاه الجهة القائمة بالاختبار ببعض الالتزامات، من بينها الامتناع عن التطوع لمراكز أو جهات أخرى طيلة فترة اختبار اللقاح، كما أن الجهة القائمة باختبار اللقاح تلتزم من جانبها ببعض الالتزامات من بينها الإعلام والسلامة والرعاية الصحية وغيرها.
- ٣ - يستحق المتطوعون الحقوق المالية المتمثلة بالمبالغ المخصصة للرعاية الطبية والعلاج والسفر والإقامة من جهة الاختبار طيلة فترة الاختبار.
- ٤ - تقوم بعض الشركات والجهات بتخصيص مكافآت لاختبار اللقاح، هذه المكافآت يستحقها أيضاً المتطوع بمجرد بدء الاختبار، ولا تكيف مثل هذه المبالغ بأنها عوض عن الاختبار، بل تعد مجرد وسيلة تحفيزية للمشاركة والتطوع لمثل هذا الغرض.
- ٥ - يترتب على نجاح اللقاح آثار مالية وأخرى معنوية، أما المالية منها فتتعلق بملكية جهة الاختبار للقاح وإمكانية تسويقه والتنازل عنه بمقابل، أو الترخيص باستغلاله. أما الحقوق المعنوية فتتمثل بإمكانية منح براءة اختراع بشأن اللقاح بحد ذاته، متى كان الاختراع يمتاز بالجدة والابتكار والقابلية للتطبيق الصناعي.
- ٦ - من الممكن أن تترتب على اختبار اللقاح أضرار تتمثل بآثار جانبية للمتطوع، ومن الممكن أن تحدث له الوفاة، خاصة إذا ما علمنا أن معظم لقاحات الفيروسات هي نفس عينة الفيروس التي يتم إضعافها وحقنها في جسم المتطوع، وهذه الأضرار

قد تكون نتيجة وجود عيب في الوعاء أو الأنبوب المستخدم لنقل اللقاح، أو نتيجة إهمال وعدم تبصر من الجهة القائمة بالاختبار.

٧ - إن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الجهة القائمة بالاختبار هما الالتزام بالحصول على الموافقة المستنيرة للمتطوع (الإعلام) حول مخاطر وفوائد التجربة، وكذلك الالتزام بضمان سلامة المتطوع خاصة إذا ما كان الأخير من الأصحاء وليس من المرضى المشاركين.

٨ - وإن كان من الصواب عدم عدّ رضا المتطوع وقبوله للمخاطر خطأً منه يوجب وصفه من قبيل السبب الأجنبي، بل الاكتفاء بإنقاص مقدار التعويض المستحق له، كونه متضرراً، لكن يجب النظر، ومن زاوية التزام الجهة المشرفة على الاختبار اللقاحي بضمان سلامة المتطوع، أن مسؤوليتها قائمة، فهي تأخذ معنى الضمان، وهذا الالتزام يجعلها ضامنة حتى مع قيام السبب الأجنبي في صورتي الحادث الفجائي والقوة القاهرة، لكنها تعفى من المسؤولية إذا تحققت صور أخرى للسبب الأجنبي، ومنها خطأ المتضرر العمدي، فهو يستغرق خطأها المفترض لدرجة يمكن وصفه سبباً أجنبياً مانعاً لقيام مسؤوليتها.

٩ - التأمين من مخاطر اختبار اللقاح الطبي التزام يقع على عاتق الجهة القائمة بالاختبار حتى قبل البدء بالتجربة.

١٠ - إن أي اتفاق يرد في عقد التطوع لاختبار فاعلية اللقاح المختبري مفاده إعفاء الجهة القائمة بالاختبار من المسؤولية، يعد باطلاً لمخالفته للنظام العام والصحة العامة.

ب - التوصيات:

١ - ضرورة صياغة قانون إجراء التجارب السريرية في جميع الدول، نظراً للحاجة الماسة لقواعد قانونية تنظم مثل هذه الأعمال في ظل كثرة تفشي الفيروسات والبحث عن لقاحات بشأنها.

٢ - تنظيم عقود التفضل في القانون المدني، أو عقود الخدمات المجانية ومن ضمنها عقد التطوع الطبي، نظراً لعدم وجود أحكام خاصة بمثل هذه العقود في القانون المدني العراقي والكثير من القوانين المدنية.

٣ - وجوب النص على منع المتطوع من التنازل عن الحقوق التي تثبت له بسبب قيامه بالاختبار، وأن يعد لاغياً كل بند يوقع عليه المتطوع يوحي بتنازله عن تلك الحقوق. كما أنها تنتقل إلى ورثته فيما لو حصلت وفاته، سواء أكان بسبب الاختبار أم لأي سبب كان.

- ٤ - يجب أن تكون هناك فترة، بعد أخذ اللقاح، يمكن أن تسمى فترة مراقبة الحالة الصحية للمتطوع، يتم تحديدها حسب كل حالة وخطورتها، يلتزم فيها الراعي أو الجهة التي أشرفت على الاختبار اللقاحي، بضمان سلامة المتطوع، وليس فحسب الالتزام بسلامته، فيكون التزام هذه الجهة أكثر تشدداً، فهو التزام بضمان النتيجة، لطالما أن هذه الفترة لم تنقُض بعد، إذ يعد المتطوع في عهدة الجهة المشرفة على اختبار اللقاح، فتتحمل مسؤولية أي ضرر حاصل له، وإن حصل بحادث فجائي أو بقوة قاهرة، ما عدا تلك الأضرار المتوقعة والتي تم تبصيره بها وقبلها.
- ٥ - وفي مواجهة العالم أجمع للمخاطر المحدقة التي نجمت عن انتشار الفيروسات وفي عدة مراحل من الزمن، وكان آخرها فيروس كورونا، أضحي لزاماً أن يتم تدوين وسن قواعد لأخلاقيات المختبرات، تحكم أنشطتها العلمية وأبحاثها الطبية، تمثل قواعد موجهة لسلوكها، لا تفتقر إلى الإلزامية، ترسخ للعلاقة القائمة بين الجهات المشرفة على التجارب الطبية والمتطوعين، وتحكم هذه الأنشطة بقواعد سلوكية تعصمها من الانحراف عن مسارها العلمي والأخلاقي والإنساني، وتجعلها تصب أنشطتها في خدمة الإنسانية جمعاء.

المراجع

أولاً - المراجع باللغة العربية:

- ما بعد القرآن الكريم

أولاً - الكتب:

- د. أحمد إبراهيم العشماوي، فعل المضرور والإعفاء الجزئي من المسؤولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٩.
- د. أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام، مطبعة مصر، القاهرة، ١٩٥٤.
- د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الدراسات البحثية في قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٧.
- د. أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠١٢.
- د. أحمد فتحي سرور، العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٥، ط ٢.
- د. أسامة أحمد بدر، ضمان مخاطر المنتجات الطبية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٣.
- د. أكرم فاضل سعيد، انتقال الحقوق والالتزامات الشخصية في الأشياء غير المادية، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١٦.
- د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، مطبعة جامعة بغداد، ١٩٨٧.
- د. بلحاج العربي، أحكام التجارب الطبية على الإنسان، ط ١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، ٢٠١٢.
- د. حسام الدين الصغير، حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات الدوائية في الدول النامية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ٢٠٠٥.
- د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني، (أصول الالتزام)، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٧٠.
- د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج ١، الضرر، بغداد، ١٩٩١.

- د. حسين عبد الحميد أحمد رشوان، القانون والمجتمع دراسة في علم الاجتماع القانوني، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ٢٠٠٣.
- د. رضا محمد جعفر، رضا المتضرر بالضرر وأثره على الحق في التعويض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٥.
- د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ٢، في الالتزامات، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط٤، ١٩٨٧.
- د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الفعل الضار والمسؤولية، المجلد الأول، القاهرة، ١٩٩٢، ط٥.
- د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي، ج ١، المجلد الأول، مطبوعات جامعة الكويت، ١٩٨٢.
- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (دون ذكر سنة نشر)، ص ١٣٩.
- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، الإيجار والعارية، ٢٠٠٧.
- د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج ١، في مصادر الالتزام، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، ١٩٦٣، ط٢.
- د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج ١، بغداد، ١٩٦٧.
- د. لطفي البلشي، قبول المخاطر الرياضية ودوره في تحديد المسؤولية المدنية، القاهرة، ١٩٩٤.
- د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ١٩٩٣.
- د. محمد سامي عبد الصادق، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق - جامعة القاهرة، العدد ٨٠، ٢٠٠٨.
- د. محمد سليمان الأحمد، خواطر مدنية، مكتب الفكر والوعي، السليمانية، ٢٠٠٩.
- د. محمد سليمان الأحمد، عقود تنظيم المسابقات الرياضية والمسؤولية المدنية الناجمة عنها، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠٠٢.

- د. محمد سليمان الأحمد، المدخل لدراسة الضمان، دار الحامد للنشر، عمان، ٢٠٠١.
- د. محمد سليمان الأحمد، النظرية العامة للقصد المدني، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٩.
- د. محمد علي عبد، نظرية السبب في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠٤.
- د. محمد محمد أبو زيد، بعض المشكلات القانونية الناتجة عن مرض فقد المناعة المكتسبة (الإيدز)، الكويت، ١٩٩٦.
- د. محمود جمال الدين زكي، دروس في نظرية الالتزام، القاهرة، ١٩٦٦.
- د. ياسر عبد الحميد محمد الإفتيحات، النظام القانوني لتنفيذ البحث الطبي الحيوي على الكائن البشري والمسؤولية المدنية الناجمة عنه، دار النهضة العربية، الإمارات، ٢٠١٨.
- د. يوسف أحمد حسين النعمة، دفع المسؤولية المدنية بخطأ المضرور، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ١٩٩١.

ثانياً - الرسائل والبحوث والمقالات:

- د. جعفر الفضلي و د. محمد سليمان الأحمد، عقد موقف السيارات، طبيعته وآثاره، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العراقية، العدد (٣١) لسنة ٢٠٠٢.
- شاكِر ناصر حيدر، المسؤولية المدنية الناشئة عن النقل المجاني للأشخاص، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العراقية، العدد (١٦) لسنة ١٩٨٠.
- د. عبد الله اليوسف، مجالات العمل التطوعي وآفاقه، مقال متاح على الرابط الإلكتروني: www.alyousif.org/?act=artc&id=98&print=1 تاريخ الزيارة ٢٠٢٠/٤/١٢.
- د. عبد الرحمن الطحان، المسؤولية عن الدواء غير الصالح، بحث منشور في وقائع وبحوث المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق في جامعة الموصل، التشريعات الصحية سبل تفعيلها وتطويرها، ٢٠٠٨.
- د. علي عبید الجيلاوي، رضا المتضرر وأثره في المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، ١٩٨٨.

- العمري حربوش، التقنيات الطبية وقيمتها الأخلاقية في منظور فرانسوا داغوني، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، الجزائر، ٢٠٠٧-٢٠٠٨.
- د. محمد سليمان الأحمد، أهمية الفرق بين التكيف القانوني والطبيعة القانونية في تحديد نطاق تطبيق القانون المختص، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدرها كلية القانون، جامعة الموصل، العدد ٢٠، ٢٠٠٤.
- د. محمد سليمان الأحمد وهالة مقداد الجليلي، استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العراقية، العدد (٢٩) لسنة ٢٠٠١.
- د. محمد الطاهر جرمون، إعلان هلسنكي بين تأسيس التجارب الطبية واحترام حقوق الإنسان، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، العدد ٣، المجلد ٩، ٢٠١٨.
- د. ندى زهير الفيل، دور مبدأ الاستنفاد في تقييد الحق الاستثنائي للمخترع (ضرورة النص على هذا المبدأ في التشريع العراقي)، بحوث ودراسات قانونية لكلية الحقوق، جامعة الموصل، (rights.uomosul.edu.iq).
- التطوع التزام أخلاقي بالعمل الإنساني، مقال منشور في موقع زهرة الخليج، بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٩، متاح على الرابط: <https://www.zahratakhaleej.ae/Gallery/559555> تاريخ الزيارة للموقع: ٢٠٢٠/٤/١٢.
- مقال منشور في صحيفة (الإمارات اليوم) بعنوان (مطلوب متطوعين لحقنهم بـ(كورونا) والمكافأة ٤٠٠٠ يورو، متاح على الموقع الإلكتروني emaratalyoum.com تاريخ الزيارة ٢٠٢٠/٤/١١.
- قضايا براءات الاختراع ذات الصلة بفيروسات الأنفلونزا وجيناتها، تقرير ضمن الاجتماع الحكومي الدولي لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات الأنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى، ٧ تشرين الثاني، ٢٠٠٧.
- مقال بعنوان (براءة اختراع للقاح الالتهاب الرئوي يشكل ضربة قوية للفقراء) منسوب لقناة الجزيرة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٣ متاح على موقع القناة Aljazeera.net تاريخ الزيارة ٢٠٢٠/٤/١٧.

ثالثاً – القوانين والاتفاقيات والمبادئ الدولية:

- القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ المعدل.
- قانون الإثبات العراقي رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩.
- اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) لسنة ١٩٩٤.
- إعلان (هلسنكي) الخاص بالمبادئ الأخلاقية للبحوث الطبية البشرية في عام ١٩٦٤ والمعدل في ٢٩/٣/٢٠١٧.
- قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠٢.
- قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية العراقي رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤.
- قانون إجراء الدراسات الدوائية في الأردن رقم (٢) لسنة ٢٠١١.
- التقنين المدني الفرنسي لسنة ١٨٠٤ المعدل بالمرسوم التشريعي رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٦.

ثانياً – المراجع باللغة الإنجليزية والفرنسية (كتب وبحوث ومقالات)

- Ravindra B. Ghooi and Deepa Divekar, Insurance in clinical research, perspect clin res, v.5 (4) 2014 Oct-Dec.
- Carlo Tomino Pharm.D., Insurance Policy for Clinical Trials, June 2012, www.unicri.it/special_topics/clinical_research/ethics_human_rights/training_tanzania/Tomino%20%20Insurne.pdf, last access, April 13, 2020.
- Sabina Gainotti1* and Carlo Petrini2, Insurance Policies for Clinical Trials in the United States and in some European Countries, Journal of Clinical Research & Bioethics, Volume 1 Issue 11000101, 2010.
- Tom Scheve, Risks and Rewards of Volunteering for Clinical Trials, <https://money.howstuffworks.com/economics/volunteer/opportunities/volunteer-in-clinical-trial3.htm>. Last visiting: April 17, 2020.
- J.Bigorram J..E bannos, Weight of financial reward in the decision by medical students and experienced healthy volun-

- teers to participate in clinical trials, European Journal of Clinical Pharmacology volume 38, pages443-446(1990).
- Katie Chandler, Clinical Trial Liability - Navigating the Legal, Regulatory and Insurance Landscape, Journal for Clinical Studies, Volume 10 Issue 6, 2014.
 - Valeria Ferro, Legal Aspects of Informed Consent in Clinical Research: the Case of Vaccinations in the International Legal Framework, BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2019.
 - Pamela R. Ferguson Clinical trail and healthy volunteer, Medical Law Review, Volume 16, Issue 1, Spring 2008, Pages 23-51, <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwm020>, published: January 2008. Last visiting: April 14, 2020..
 - Matthew j czarny Nancy kass,C Flexnrm Kathryn A carson, Payment to health volunteer in clinical research, Clinical Pharmacology & Therapeutics 87(3):286-93. March 2010.
 - Bergeman Nicolas. Le contrat de services gratuits un modèle pour penser l'altruisme en droit des contrats. In: Revue juridique de l'Ouest, 2010-4.
 - Martha Ann Overland, corona virus crises, paper available at: <https://www.npr.org/2020/03/21/818759617/i-wanted-to-do-something-says-mother-of-2-who-is-first-to-test-corona-virus-vacci>. Last access April 11,2020.
 - Insurance and compensation in the event of injury in Phase I clinical trials, Guidance developed by the Association for the British Pharmaceutical Industry, the BioIndustry Association and the Clinical Contract Research Association in consultation with the Department of Health and the National Research Ethics Service.
 - S. B. Thorat, S. K. Banarjee, D. D. Gaikwad, S. L. Jadhav, R. M. Thorat, CLINICAL TRIAL: A REVIEW, Interna-

- tional Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, Volume 1, Issue 2, March - April 2010; Article 019.
- Hoffmann, What is a clinical trial and how does a trial work?, available at: https://www.roche.com/research_and_development/who_we_are_how_we_work/clinical_trials/what_is_a_clinical_trial.htm?tab_id=tab4. Last accesses, April 11, 2020.
 - WHO Collaborating Centre for Advocacy and Training in Pharmacovigilance Accra, Ghana 7th - 18th September 2015 Module 2: Vaccines and drugs: similarities and differences, available at: <https://isoponline.org/wp-content/uploads/2015/10/Differences-on-drugs-and-vaccines.pdf>.last access, April 12,2020.
 - Office of human subject protection, volunteering for a clinical trail, university of Rochester, <https://www.rochester.edu/ohsp/subject/volunteeringForClinicalTrial.html>. Last access, April 11, 2020.
 - Par Céline Bondard, Avocat Le contrats A titre grautuit sans contrepartie pecuniaire sont-ils legaux, jeudi 6 avril 2017. <http://www.villag-justice.com/articles/les-contrats-titre-gratuit-sans-contrepartie-pecuniaire-sont-ils-legaux,24683.htm>

Volunteering for testing effectiveness of clinical trial against coronavirus

Prof. Mohammed Suleiman Al-Ahmad
Dr. Abdulkarem S. Abdulkarem

After the spread of the new Corona virus and the infecting of thousands of people around the world, several attempts have emerged to search for a vaccine for it, and this vaccine requires a clinical trial in humans, and for this a large number of people volunteered for this purpose. Medical, and do they have the foundations of contracts known in the civil law? What are the legal effects of the vaccine test if it succeeds or fails, the volunteer is a donor who provides a free service to a sponsor to test the vaccine, such as being a health institution or a company from the public or private sector, for humanitarian and social considerations, and this authority may only give the volunteer some of the reward. And because these experiences are associated with the risks related to the safety of the volunteer participating in the test, that body is obligated to insure those risks even before the start of the test, and it is also obligated to compensate for the damage caused to the participant due to the devices used in the test or due to a violation of the commitment to safety and information, which is the right of the volunteer At the same time.

The analytical method has been used to write the research with its division into two researches, the first of which deals with the legal nature of laboratory volunteering and its importance, while the second topic came to discuss the legal implications of vaccine testing. The research concluded that volunteering for the vaccine test is a donation contract that falls within the category of preference contracts, in which the donor provides a benefit or service without leaving anything of his money, and the study also concluded that the characteristic of the donation and the reward that the participant may receive in the test does not negate the responsibility of the examiner, Especially if it comes to human safety and the infallibility of his body.

This study recommended the necessity of enacting act to conduct clinical trial for vaccine testing, and using the principles of the Helsinki Declaration on the Ethics of Conducting Research on Humans, also the study recommended the necessity regulation of free service contracts specially volunteering contracts for clinical trial in the Civil Law, as there are no special provisions in this law.

Keywords: volunteer, clinical trial, vaccine, contract, contractual responsibility.

أثر جائحة كورونا على الحريات العامة دراسة تحليلية مقارنة في مصر والكويت

الدكتور/ محمد عبد الجليل المر
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
جمهورية مصر العربية

ملخص:

منذ أن أطلت جائحة كورونا علي العالم في نهاية عام ٢٠١٩ فإنها غيّرت وجه الحياة فيه، وأثرت على مناحي الحياة كافة، على الدول كبيرها وصغيرها، المتقدمة منها والنامية، ديمقراطية كانت أم ديكتاتورية. بل ولم يقتصر تأثيرها على الدول فقط، وإنما امتد إلى الشعوب والأفراد العاديين، فأثرت على حياتهم، وأرزاقهم وحقوقهم وحرياتهم.

وقد قام العديد من الدول في إطار واجبها الدستوري بالحفاظ على صحة مواطنيها باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار هذه الجائحة، وقد ترتب على هذه الإجراءات تقييد الحقوق والحريات العامة، مثل حرية التنقل وحرية الاجتماع، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والعديد من الحريات الأخرى.

وقد خشي العديد من المهتمين بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، من استغلال الحكومات لتلك الجائحة لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، والعصف بحقوق الإنسان.

لذلك كان هذا البحث في محاولة لبيان الضوابط والمبادئ الدستورية العامة الواجب على السلطات الالتزام بها عند قيامها بواجباتها الدستورية للحفاظ على الصحة العامة لمواطنيها في ظل انتشار هذا الفيروس، لضمان عدم التعسف في استغلال هذا الظرف الاستثنائي في إضافة المزيد من القيود على الحريات العامة، مع عرض تطبيقات حديثة للقضاء الدستوري في بعض الدول المتقدمة (ألمانيا - فرنسا - الولايات المتحدة الأمريكية) لبيان مدى دستورية الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل السلطات لمواجهة الجائحة.

المصطلحات: جائحة - دستور - قيود دستورية - التدابير الاحترازية - السلطات العامة.

مقدمة:

إن لحديث الحرية سحراً يملك على الإنسان له، ويأخذ بمجامع قلبه، فهو حديث الأمس واليوم والغد الذي لا تمل النفس من ترديده، ولا تسأم الروح من تكراره؛ لأنه الحديث عن القوى المحركة للإنسان، والمعنى الجامع لكل آماله ورغباته، والمفهوم

الشامل لمختلف جوانب حياته. وتلك حقيقة عبر عنها جيفرسون (رئيس أمريكي سابق) بقوله: إن الله قد وهبنا الحياة، منحنا معها، في ذات اللحظة ولنفس السبب الحرية. ومن هنا صارت الحرية قيمة خالدة في الضمير الإنساني تزداد في تعمقها حيناً بعد حين، حتى تساوي في طلبها أصحاب التجلة من العلماء، وأهل الصفة من العوام، وتوحد في السعي الحثيث إليها من الناس غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، لذلك فإن كل محاولة تتحدى في الإنسان حريته، وتناوئ تمتعه بها هي ولا شك محاولة لوأد آدميته، ووسيلة لإزهاق إنسانيته^(١).

وفي نهاية عام ٢٠١٩ وبداية عام ٢٠٢٠ اكتسح العالم فيروس كورونا المستجد (covid-19) حيث ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية ثم انتشر في أرجاء العالم كافة. وقد أثر ظهور هذا الفيروس - سريع الانتشار والعدوى - على مناحي الحياة كافة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مخلفاً وراءه مئات الآلاف من المصابين/ وآلاف من حالات الوفاة حول العالم، ولم يمتد أثر هذا الفيروس إلى أرزاق الناس وأحوالهم فقط، وإنما أثر أيضاً في حقوقهم وحرياتهم.

وقد اتخذت العديد من دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية، ودولة الكويت - في إطار السعي للتصدي لخطر هذا الفيروس القاتل - العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية الاستثنائية لمنع انتشاره والسيطره عليه، وقد شملت تلك الإجراءات تقييد العديد من حقوق وحريات المواطنين مثل فرض حظر التجول، وإلزام المواطنين بعدم مغادرة منازلهم، وحظر التجمعات بكافة أشكالها، وغلق المساجد والكنائس، وتعليق العمل بالمحاكم، وغلق المطارات، وتعطيل حركة السفر، وتقييد حرية التنقل بين الدول بعضها بعضاً، أو في نطاق الدولة الواحدة.

ولا شك أن تلك الإجراءات والتدابير التي قامت الدول والحكومات باتخاذها للسيطرة على هذه الجائحة قد أثرت - ضمن تأثيراتها المتعددة - على حقوق وحريات المواطنين، فأدت إلى حرمانهم من ممارسة تلك الحريات، أو تعطيل ممارستها ولو بصفة مؤقتة.

وآثرت المخاوف - في الدول الديمقراطية وغيرها - من استغلال السلطات العامة لتلك الجائحة للتضييق على الحريات العامة، حيث إن السلطة بصفة عامة تجنح

(١) أ. د. محمد باهي أبو يونس: التقييد القانوني لحرية الصحافة "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية ١٩٩٤ ص ١.

إلى التضييق، فالخشية أن تستغل ظروف تلك الجائحة في التضييق على الحقوق والحريات العامة أو زيادة حدته.

فالقرارات والقيود الصارمة التي فرضتها العديد من الدول والحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أثارت قلق ومخاوف الكثير من المنظمات والهيئات المعنية بالحقوق والحريات، والتي تخشى أن تسعى بعض الأنظمة إلى استثمار هذه الأزمة الصحية، في تعزيز قبضتها الأمنية تحت شعارات جديدة قد تكون سبباً في انتهاك الحريات، وفي مقالة بمجلة "فورين بلوسي الأمريكية"، اعتبر فلوريان بيبير أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة غراتس النمساوية وكما نقلت بعض المصادر، أن الوباء وفّر للحكومات الديكتاتورية والديمقراطية على حد سواء فرصة للتعسف وإساءة استخدام القرار وتقليص الحريات المدنية^(٢).

والسؤال الذي يثور هنا هو هل حق السلطة - في ظل هذا الظرف الاستثنائي - في تقييد حريات المواطنين مطلق أم هناك حدود لهذا التقييد؟ وما هي الضوابط الدستورية التي يتعين على السلطة العامة الالتزام بها عند تنظيم الحقوق والحريات العامة في هذا الظرف الاستثنائي؟

أهمية البحث :

تتمثل أهمية البحث في تأكيده على أن الحقوق والحريات العامة لها قدسية خاصة في نفوس الشعوب، بُذلت وسالت من أجلها الكثير من الدماء، ولا يجوز تعطيلها أو تقييدها أو الحرمان من ممارستها - حتى في الظروف الاستثنائية - إلا بضوابط صارمة، وبمراعاة الدستور، والمبادئ الدستورية العامة المستقر عليها في الأمم المتحضرة، وألا تتحول تلك التدابير والقيود إلى أداة للعصف بالحقوق والحريات العامة.

كما تتمثل أهمية البحث في عرضه لبعض الحقوق والحريات العامة التي تأثرت بجائحة كورونا، وتحليل وتقييم الإجراءات التي قامت بها السلطات العامة، وبيان

(٢) عبد الأمير رويح "كورونا فرصة للتعسف: هل تصبح حقوق الإنسان ضحية الجائحة؟ تحقيق صحفي منشور على شبكة النّبأ المعلوماتية في ٢٣/٥/٢٠٢٠. ومما يؤكد ذلك قيام العديد من الدول بإعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة كوفيد-١٩، وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن فيروس كورونا يمكن أن يعطي بعض الدول زريعة لانتهاج خط قمعي لأسباب لا علاقة لها بالجائحة.

الضوابط والمبادئ الدستورية العامة المستقرة عليها في الأمم المتحدة الواجب مراعاتها من قبل السلطات العامة عند تصديها لتلك الجائحة.

أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلى تناول :

- ١ - تعريف الجائحة، وبيان مدى دقة هذا المصطلح للدلالة على انتشار فيروس كورونا
- ٢ - تأثير الجائحة على بعض الحريات العامة.
- ٣ - بيان الإجراءات التي قامت بها السلطات العامة للتصدي لها، والتي أدت إلى تقييد تلك الحريات وحرمان المواطنين من ممارستها.
- ٤ - تحليل وتقييم مدى توافق تلك الإجراءات مع الضوابط الدستورية المقررة، مع عرض بعض التطبيقات الحديثة في القضاء المقارن.

منهج البحث :

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي الذي يركز على عرض المشكلة، وكيفية معالجة المشرع لها، وبيان مدى اتفاق ما قرره من حلول مع المبادئ الدستورية العامة المستقرة في الأمم المتحدة، مع بيان موقف الفقه والقضاء بشأن تلك الإجراءات المقررة.

كما استعان الباحث بالمنهج المقارن في المقارنة بين تأثير جائحة كورونا على الحقوق والحريات العامة في بعض الدول، والإجراءات التي قامت باتخاذها للسيطرة على تلك الجائحة.

خطة البحث :

تحقيقاً لأهداف البحث فقد تم تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين على النحو التالي :

المبحث الأول : تعريف الجائحة، ومدى تأثيرها على الحريات العامة.

المبحث الثاني : الضوابط الدستورية في التصدي للجائحة.

الخاتمة :

قائمة المراجع

المبحث الأول تعريف الجائحة، ومدى تأثيرها على الحريات العامة

تمهيد :

أشيع استخدام كلمة "جائحة" مع بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في دول العالم، وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية رسمياً في ١٤ مارس ٢٠٢٠ على تفشي فيروس كورونا لفظ "الجائحة"، وتداول استخدامه بعد ذلك على نطاق واسع في كافة وسائل الإعلام العربية والعالمية، وفي المؤتمرات العلمية للدلالة على تفشي فيروس كورونا، فما هو معنى كلمة " جائحة " الحديثة الظهور لغة واصطلاحاً؟ وما هي دلالتها اللغوية ؟ وما هو تأثير انتشار هذا الفيروس على الحريات العامة؟

هذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث، وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين :

المطلب الأول: تعريف الجائحة

المطلب الثاني: أثر الجائحة على الحريات العامة

المطلب الأول تعريف الجائحة

أولاً - تعريف الجائحة لغة :

جاء في معجم المعاني الجامع كلمة جائحة بأنها: اسم، والجمع جائحات وجوائح.

وأصابته جائحة : بليّة، تهلكة، داهية.

وسنة جائحة : جدبة، غبراء، قاحلة.

وإن الأصل الثلاثي لكلمة "جائحة" هو (ج و ح) فنجد الخليل بن أحمد الفراهيدي يعرفها في معجم العين في باب الحاء والجيم والواو. وجوح من الاجتياح، اجتاحتهم السنة وجاحتهم جياحة وسنة جائحة : جدبة، فمعنى الجائحة وفقاً لهذا المنظور هو ما يصيب الناس في أموالهم منقولة أو غير منقولة. أما صاحب القاموس المحيط فيقول: "الجائحة هي الشدة المجتاحة للمال". ويعرفها الجوهري في صحاحه بأنها: "الجوح الاستئصال ومنه الجائحة وهي الشدة التي تجتاح المال".

وعليه فقد اتفق جمهور اللغويين القدماء على أن الجائحة هي ما يجتاح المال بمختلف أنواعه وأشكاله فيفنيه سواء أشمل مال فرد أو جماعة من الأفراد^(٣).

وتتبع البعض أول استخدام لكلمة "الجائحة" فذكر أنه ربما كان أول ذكر موثق لمصطلح الجائحة في سنة ٤٠٣ قبل الهجرة أو ٢٣١ ميلادية ببيت شعر لهناء الأزدي يقول فيه :

حلت على مالك الأملاك جائحة هدت بناء العلا والمجد فانفصدا

كما جاء ذكرها بالحديث النبوي في صحيح مسلم "لو بعت من أخيك ثمراً فأصبتة جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً". وبالتالي، فإن كلمة الجائحة المقصود بها النازلة أو المصيبة، أما فقهاء فهي تركز على المال أو الثمار. ولا يوجد في الاستخدام اللغوي باللغة العربية أي علاقة بين الجائحة والوباء؛ مستجداً كان أو غير ذلك^(٤).

ثانياً - تعريف الجائحة اصطلاحاً:

المقصود بالجائحة اصطلاحاً الآفة التي تهلك الثمار أو الزروع أو الخضار المشتره بعد بدو صلاحها، وهي على رؤوس أشجارها، إهلاكاً كاملاً أو جزئياً^(٥).

وعليه يتضح مما سبق ذكره أن المجال المفهومي لمصطلح الجائحة يستخدم لغوياً واصطلاحاً على ما يصيب مال الفرد أو الجماعة من محاصيل أو غيرها، ولا يستخدم فيما يمس الذات أو البدن من أعراض مرضية أو أوبئة.

وكانوا في السابق يصفون الأوبئة بالطاعون، حيث وصفه ابن خلدون "بالطاعون الأسود" وأسماء ابن حجر العسقلاني "بالطاعون الجارف" وله فيه كتاب "بذل الماعون في فضل الطاعون"، وكذلك ابن قتيبة، الذي أقاض بأن بعض السلاطين كانوا

(٣) انظر: في مفهوم الجائحة مقال منشور في جريدة النصر الجزائرية بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٠، تاريخ الدخول على الموقع ٦/٦/٢٠٢٠ الساعة العاشرة صباحاً، وانظر: أيضاً: د. حسين بن سالم الذهب بحث بعنوان "نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي" منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية العدد ٨، أكتوبر ٢٠١١ ص ٩١ وما بعدها. وأيضاً أ. د. عبد الله الصيفي، بحث بعنوان "الجوائح عند المالكية" منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية جامعة آل البيت، المجلد الثالث، العدد الثاني ٢٠٠٧، ولم تخرج تلك التعريفات عن كون الجائحة هي الآفة التي تصيب المال فتهلكه.

(٤) أ. د. غانم النجار: مقال بعنوان "لماذا نستخدم مصطلح الجائحة؟" بجريدة الجريدة الكويتية بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٠.

(٥) د. عبد الله بن حسين الذهب: نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي، المرجع السابق ص ٩٤.

يستغلون الطواغين باستيلائهم على أموال المتوفين الذين لا وارث لهم، وإيداعها في صندوق مالي خاص^(٦).

ثالثاً - شيوع استعمال مصطلح الجائحة :

شاع استعمال لفظ الجائحة في وسائل الإعلام المختلفة، وفي المنظمات الدولية والمننديات العلمية للدلالة على سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم كله، وللدلالة أيضاً على خطورة المرض وقوته.

رابعاً - الفرق بين الجائحة والوباء والمتوطنة :

الجائحة (Pandemic):

هي أعلى درجات الخطورة في انتشار وقوة المرض؛ لأنه يعني أن المرض منتشر في أكثر من دولة، وأكثر من منطقة جغرافية، ولا يقتصر على منطقة جغرافية واحدة مثل قارة أو منطقة، كالشرق الأوسط مثلاً. وانتشار المرض في أكثر من قارة أو منطقة يفرض تعاوناً وتنسيقاً في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وهناك قرارات دولية ملزمة للجميع من حيث الوقاية ومحاربة المرض، ولا يقتصر الأمر على جهود دولة منفردة، ولذلك منظمة الصحة العالمية لها اليد العليا على كل الإجراءات الوقائية.

الوباء Epidemic:

هو انتشار المرض بقوة في منطقة محددة في العالم، سواء أكانت دولة واحدة أم عدة دول، لكن في منطقة جغرافية واحدة، مثل قارة أو منطقة جغرافية واحدة مثل الشرق الأوسط، وهي مشكلة خاصة بهذه الدول المجاورة، وتحتاج إلى تعاون بينها. ودور منظمة الصحة العالمية هو المراقبة والتوجيه والمساعدة حتى لا يتحول الوباء إلى جائحة^(٧).

(٦) أ. د. غانم النجار: المقالة السابقة.

(٧) منظمة الصحة العالمية (يرمز لها اختصاراً WHO) هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، وأنشئت في ٧ أبريل ١٩٤٨، مقرها الحالي في جنيف، سويسرا، وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي. وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث الصحية، ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيانات وتوفير الدعم التقني إلى البلدان ورصد اتجاهاتها الصحية وتقييمها. وقد تعرضت المنظمة للهجوم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم قيامها بما يلزم في مواجهة فيروس كورونا، وقامت الويات المتحدة الأمريكية بقطع التمويل عن المنظمة.

المتوطنة Endemic:

هي مشكلة صحية خاصة بدولة معينة، ومهمة محاربة هذا المرض منوطه بتلك الدولة، مثل انتشار الكوليرا باليمن، أو مشكلة البلهارسيا في مصر في الماضي، ودور منظمة الصحة العالمية هو المساعدة والمشورة فقط^(٨). ولاشك أن كل مصطلح من تلك المصطلحات له دلالة محددة، ويترتب عليه أحكام خاصة.

المطلب الثاني أثر الجائحة على الحريات العامة

لم تؤثر جائحة كورونا على حياة وصحة الشعوب حول العالم فقط، وإنما امتد تأثيرها إلى كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد أعلنت العديد من الدول حالة الطوارئ، واتخذت العديد من التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس المميت^(٩).

فبعد كورونا ضعفت الرقابة على الحكومات، وغاب المشرعون عن البرلمانات، وتأجلت الانتخابات في أكثر من بلد، وتم تعليق العمل في المحاكم ما عدا القضايا المستعجلة، وتم فرض حظر التجول وإلزام الناس بعدم مباحرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مأمورو الضبط القضائي، وتم تعليق حركة الطيران بين الدول، وغلق دور العبادة، وغلق الأندية والمقاهي، وحظر التجمعات بكافة أشكالها وأنواعها. وقد فرضت الدول العقوبات المشددة على من يخالف تلك الإجراءات والتدابير.

ويوجد بعض الحريات العامة التي تأثرت بصورة مباشرة بانتشار فيروس كورونا نتيجة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الحكومات، ومن هذه الحريات حرية التنقل، حرية الاجتماع، حرية ممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحريات العامة الأخرى، ولكن الباحث سيركز على الحريات السالفة الذكر، ولكن قبل الحديث عن تلك

(٨) انظر: الفرق بين الجائحة والوباء والمتوطنة: مقال منشور في جريدة السياسية الكويتية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠.

(٩) تشير أحدث الإحصائيات في العالم إلى أن عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا بلغ ٢٧٥٤٥٠٧٥ حالة إصابة، وعدد الوفيات بلغ ٨٩٧٦٤٦ حالة وفاة حتى تاريخ ٢٠٢٠/٩/٩. المصدر موقع BBC NEWS عربي نقلاً عن جامعة جونز هوبكنز.

الحريات يعرض الباحث في عجالة لتعريف الحريات العامة، وأهميتها بالنسبة للفرد والجماعة، وذلك على النحو الآتي :

أولاً - تعريف الحريات العامة :

تعرف الحريات العامة بأنها إمكانيات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية أو نظراً لعضويته في المجتمع^(١٠).

والحرية هي أغلي ما منحه الخالق للإنسان بعد الحياة، ومن دونها تذل إنسانيته، ويكبل بأغلال الرق - كما كان قديماً - ويقيده سلوكه وحرركته بغير مبرر فطري، فإذا كانت الحرية هبة من الله الخالق لكل شيء، لم يسهم في خلقها أو منحها أحد سواه، لذا كان لها من القداسة ما يفترض أنها هي قانون الله الذي لا يجوز المساس بما خلقه وحصله وأمر باحترامه، فلا يجوز لأحد تحت ستار الادعاء بفضل له في خلق هذه الحرية أو منحها، أن يعترضها بأي عارض تأباه طبيعتها المقدسة، وقوانين الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ لذلك تحظى الحرية في كافة دساتير العالم باهتمام كبير، وتحتل منزلة رفيعة في أفئدة البشر^(١١).

وتظهر أهمية الحريات العامة في أمرين :

الأول : في القيمة القانونية للحريات العامة، ومكانها في النظم الديمقراطية، فالحريات العامة تحتل في النظم الديمقراطية مكانة سامقة، ويكون مكانها دائماً في قمة مدارج التشريع وهو الدستور، فتأخذ منزلة وقيمة الدستور ذاتها. وفي ذلك يقول أحد الباحثين: "تعد الحريات العامة أسمى القيم المرتبطة بشخص الإنسان، وترتقي إلى مرتبة الحريات الأساسية، وتتمتع لهذا السبب بمكانة ممتازة في النظم الديمقراطية؛ ولهذا الإيمان صdah في الفكر القانوني، فإجماع الفقه والنظم السياسية على أن موقع الحريات في البناء القانوني يأتي في قمة القواعد القانونية أو في الدستور، وقد أدى هذا إلى الربط بين الحقوق والحريات وبين الدساتير ربطاً ما يزال قائماً إلى اليوم^(١٢).

(١٠) أ. د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري. الإسكندرية. منشأة المعارف ٢٠٠٠ ص ٨١٥.

(١١) أ. د. محمد صلاح عبد البديع: الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء. القاهرة. دار النهضة العربية الطبعة الثانية ٢٠٠٩، ص ٧.

(١٢) H Hauriou (A.): Les institutions politiques et droit constitutionnel. Paris 1972. p 24. مشار إليه لدى الدكتور حسن أحمد علي: ضمانات الحريات العامة وتطورها في النظم السياسية المعاصرة. رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، دون تاريخ، ص ٦.

وهذا الأمر تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر منذ إنشائها حيث أكدت: "وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة ١٩٢٣ على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً من الشارع الدستوري أن يكون لهذه الحريات والحقوق قوة الدستور وسموه على القوانين العادية، حتى يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام في حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا ما خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، وعن الإطار الذي عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائر دستورياً، وبالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي في حومة مخالفة الدستور" (١٣).

الثاني: في دلالة وجود الحريات العامة واحترامها:

إن أي نظام سياسي لا يمكن وصفه بأنه نظام ديمقراطي إلا إذا كفل للأفراد حقوقهم وحرياتهم العامة، فكفالة الحريات العامة واحترامها هو الذي يميز الأنظمة الديمقراطية عن الأنظمة البوليسية، وبالتالي يصبح احترام الحريات العامة أهم الدلائل على مدى ديمقراطية أنظمة الحكم وعدالتها.

كما أن كفالة الحقوق والحريات العامة تسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وتعد مسألة كفالة الحريات مسألة غير قابلة للتجزئة، وتجسيدا لذلك قررت المحكمة الدستورية العليا الكويتية "أن الحريات العامة إنما ترتبط ببعضها بعضاً برباط وثيق، بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعاً وتتضافر، ولا يجوز فصلها أو تجزئتها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازم، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطي من دونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها دعماً لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها" (١٤).

(١٣) المحكمة الدستورية العليا: ٢٠١٧/٦/٣ القضية رقم ١٣ لسنة ٢٩ قضائية "دستورية" مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا في تسع سنوات من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧ الناشر دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ٢٠١٨ ص ٢١٢ وما بعدها. وانظر أيضاً: حكمها في ٧ مايو ١٩٨٨ القضية رقم ٤٤ لسنة ٧ قضائية "دستورية" الموسوعة الشاملة لأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها وحتى ٢٠٠٩، إعداد الأستاذ عبد الله حسن المحامي، الناشر نقابة المحامين المصرية ٢٠١٠. المجلد الأول ص ١٧١.

وفي بيان أهمية حقوق الإنسان بصفة عامة قررت المحكمة الدستورية الكويتية "أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشروع بإنشائها، بل أنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفاً عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والروح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديمقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيراً للناس بها"^(١٥).

ثانياً - الحريات العامة التي تأثرت تأثيراً مباشراً بجائحة كورونا :

أثرت جائحة كورونا على العديد من الحقوق والحريات العامة للمواطنين في الدول المختلفة، ومن الحريات التي شملها التأثير الحريات الآتية :

أولاً - حرية التنقل :

وهذه الحرية تسمح للإنسان بأن ينتقل من مكان لآخر داخل بلاده، وتسمح له بأن يغادر إقليم بلاده كلية ويعود إليه متى شاء، وهذه الحرية يجب أن تتاح للكافة دون استثناء؛ ولذلك فإنها يجب أن تُنظم حتى لا تتعارض مصالح الأفراد في استعمالها تعارضاً يجعل هذا الاستعمال مستحيلاً. ويمكن أن تقيد هذه الحرية إذا كان ثمة مصلحة عامة تقتضي ذلك، فقد يمنع التجول في أنحاء معينة من المدينة محافظة على الأمن العام، وقد يمنع الدخول إلى مدينة موبوءة محافظة على الصحة العامة، وقد يمنع من الاقتراب من بعض الأماكن ذات الأهمية العسكرية، فالمنع في جميع الأحوال لا يكون مطلقاً، وإنما يكون محدوداً من حيث الزمان والمكان^(١٦).

(١٤) د. غازي عبيد مرضي العياش: الحدود الدستورية لحق الأفراد في الاجتماع - دراسة تحليلية لموقف المحكمة الدستورية العليا في الكويت، بحث منشور في مجلة القانون الكويتية العالمية، العدد ١٣، مارس ٢٠١٦ ص ٢٧٧، ٢٧٨.

(١٥) حكم المحكمة الدستورية الكويتية في أول مايو ٢٠٠٦ أشار إليه في مقال للمستشار شفيق إمام في جريدة الجريدة الكويتية في ٣١/٣/٢٠١٩ بعنوان "ما قل ودل: حق التجمع وحق الاقتراع في مأزق قضائي"، تاريخ الدخول على موقع الجريدة الجمعة الموافق ١٣/٦/٢٠٢٠ الساعة الثانية ظهراً.

(١٦) أ. د. مصطفى أبو زيد فهمي: الدستور المصري، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ٢٠١٢ ص ٢٥٤.

ونصت المادة ٦٢ من الدستور المصري القائم الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل عام ٢٠١٩ على أن:

"حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.

ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".

وتنص المادة ٦٣ منه على أن: "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".

وتنص المادة ٢٨ من الدستور الكويتي على أنه: "لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت، ولا منعه من العودة إليها".

وتنص المادة ٣١ من الدستور الكويتي على أنه: "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون".

ويلاحظ هنا أن الدستور المصري والدستور الكويتي قد حظرا حظراً مطلقاً إبعاد أي مواطن من إقليم الدولة، أو منعه من العودة إليه.

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أهمية حرية التنقل فقالت: "حرية الانتقال اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية - وهي حق عام، وتقييده دون مقتضى مشروع يجرد الحرية الشخصية من خصائصها"^(١٧).

وفي إطار التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا اتخذت العديد من دول العالم قرارات بتقييد وتعليق حرية التنقل سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي.

ففي مصر قررت الحكومة المصرية تعليق حركة الانتقال المؤقت بين المحافظات حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ بتعليق حرية التنقل بين المحافظات المصرية.

(١٧) أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في تاريخ ١٥/١١/١٩٩٧، القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ قضائية "دستورية" مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن ص ٩٢٨.

وأصدر أيضاً القرار رقم ٧١٨ لسنة ٢٠٢٠ الذي نص في مادته الأولى على: "تعلق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٣/١٩ بتوقيت القاهرة، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ بتوقيت القاهرة، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد^(١٨). وقد تم تجديد هذا التعليق عدة مرات أخرى^(١٩).

وفي السعودية؛ أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أنّ الملك سلمان أصدر أمراً بحظر التجول، من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الكويت قررت الحكومة الكويتية تعليق حركة الطيران الدولي، ووقف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات وجعلها مقصورة على البعثات الدبلوماسية فقط بعد اعتمادها من وزارة الصحة. وكذلك الحال في الدول العربية الأخرى اتخذت إجراءات مماثلة، بحظر التجول وتعليق حركة الطيران الدولي وتقييد حرية التنقل على المستوى الداخلي.

ثانياً – حرية الاجتماع :

يراد بحرية الاجتماع أن يتمكن الناس من عقد الاجتماعات السلمية في أي مكان فترة من الزمان، ليعبروا عن آرائهم بأي طريقة من الطرائق؛ كالخطابة، أو المناقشة، أو عقد الندوات، أو تنظيم الحفلات، أو إلقاء المحاضرات^(٢٠).

فمن حق كل إنسان أن يجتمع مع من يشاء من الناس لمناقشة مشكلة معينة أو بحث مسألة من المسائل ذات الأهمية بالنسبة للمجتمعين، واتخاذ اللازم نحو إقناع الآخرين بما قد يسفر عنه الاجتماع، ويستوي أن يكون الاجتماع مديراً محدد الموعد

(١٨) الجريدة الرسمية - العدد ١١ مكرر (هـ) السنة ٦٣ في ٢٠٢٠/٣/١٦.

(١٩) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠ المادة الحادية عشرة والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ١٢ مكرر (ب) في ٢٠٢٠/٣/٢٤. وكذلك القرارات أرقام ١٠٦٩، ١٠٢٤ لسنة ٢٠٢٠.

(٢٠) أ. د. إسماعيل إبراهيم البدوي: الحريات العامة والحقوق الفردية في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة. الإسكندرية. مكتبة الوفاء القانونية ٢٠١٦. ص ٢٥٨. وانظر: في بيان مفهوم حق الاجتماع وأهميته د. غازي عبيد مرضي العياش: الحدود الدستورية لحق الأفراد في الاجتماع. مرجع سابق، ص ٢٧٧ وما بعدها.

من قبل، أو يكون قد بدأ في صورة لقاء من غير تدبير مسبق مهد الفرصة لعقد الاجتماع. وتخضع حرية الاجتماع لتنظيم القانون عادة بما يضع من قيود تستهدف الحفاظ على النظام العام^(٢١).

ولا يمكن لأي نظام حكم أن يعد ديمقراطياً إلا إذا كفل للأفراد حداً أدنى من الحريات، ولعل في مقدمة هذه الحريات حرية الاجتماع التي لا يتسنى للأفراد من دونها تبادل الفكر وتمحيص الرأي فيما يعنى لهم من مسائل تهمهم وحدهم أو تؤثر في صالح الجماعة^(٢٢).

وتعتبر حرية الاجتماع من أهم الحريات الأساسية وأقواها أثراً في تكوين الرأي العام وشخصية المواطن باعتبارها من الحريات الفكرية والسياسية التي لها عظيم الأثر على سائر الحقوق والحريات العامة^(٢٣).

ولأهمية حرية الاجتماع فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على النص عليها وكفالتها، حيث لم تخل وثيقة دستورية من النص على هذه الحرية.

وفي الدساتير اللاحقة على ثورة يناير ٢٠١١ احتلت حرية الاجتماع مكانة سامية، إذ نصت عليها المادة ٥٠ من دستور ٢٠١٢: "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، ويكون ذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون.

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها".

أما دستور ٢٠١٤ فقد نصت المادة ٧٣ منه على أن: "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

فالمشرع الدستوري بعد ثورة يناير ٢٠١١ قد جعل حق تنظيم الاجتماعات العامة بإخطار، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

(٢١) أ. د. ماجد الحلو: القانون الدستوري... مرجع سابق ص ٨٨٩.

(٢٢) أ. د. سعد عصفور: حرية الاجتماع في إنجلترا وفرنسا ومصر. مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة، يناير ١٩٥٢ ص ٢٣٠.

(٢٣) أ. د. عمرو أحمد حسبو: حرية الاجتماع. القاهرة. دار النهضة العربية. ١٩٩٩ ص ٧.

وفي الكويت أكدت المادة ٤٤ من الدستور على قدسية حرية الاجتماع حيث نصت على أنه: "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية و لا تنافي الآداب".

وقد عرفت المحكمة الدستورية في الكويت حق الأفراد في الاجتماع بأنه: "مكنة الأفراد في الاجتماع في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم فيما يعن لهم من مسائل تهمهم، وما يرمي إليه - بالوسائل السلمية - من تكوين إطار يضمهم لتبادل الفكر وتمحيص الرأي بالحوار أو النقاش أو الجدل، توصلاً من خلال تفاعل الآراء إلى أعظمها سداداً ونفعاً" (٢٤).

وقد عبرت المحكمة العليا الأمريكية عن الأهمية الكبيرة لحق الاجتماع باعتباره أحد أهم الحقوق الدستورية اللازمة لأي نظام ديمقراطي حر، فقالت في عام ١٨٧٦: "إن حق الشعب في الاجتماع في هدوء كان قائماً منذ مدة طويلة قبل سن الدستور .. وفي الواقع قد كان دائماً إحدى خصائص المواطنة في ظل حكومة حرة .. ويوجد حيث تكون الحضارة، ولو لم يكن هذا الحق ما وضع الدستور؛ إذ إنه كتبت مجموعة قليلة من الرجال ذوي إرادة لا تنتهي والذين أخذوا على عاتقهم أن يجتمعوا بصورة شبه سرية لصياغته" (٢٥).

وفي مصر، بينت المحكمة الدستورية العليا أهمية حرية الاجتماع باعتبارها من الحريات الدستورية الأصلية التي تحرص النظم الدستورية المتحضرة على كفالتها باعتبارها من أهم دعائم وأسس النظام الديمقراطي. فقد اعتبرت المحكمة أن حق الاجتماع أحد قنوات حرية التعبير، وأنه أحد عناصر الحرية الشخصية. وأن حق الاجتماع حق إرادي سواء في الانضمام إلى الاجتماع أو الانسحاب منه، وأن هدم حرية الاجتماع هو هدم لبنيان أي نظام ديمقراطي، وأنه لا يمكن تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون، وفي الحدود التي تتسامح فيها النظم الديمقراطية. فقالت: ".... كذلك

(٢٤) حكم المحكمة الدستورية الكويتية، مشار إليه لدى الدكتور غازي عبيد مرضي عياش، مرجع سابق ص ٢٨٣، ٢٨٤.

(٢٥) المستشار ياقوت عشاوي: قضايا دستورية. القاهرة، دار المعارف، دون تاريخ ص ١٤٢.

فإن هدم حرية الاجتماع، إنما يقوض الأسس التي لا يقوم من دونها نظام الحكم الذي يكون مستنداً للإرادة الشعبية، ولا تكون الديمقراطية فيه بديلاً مؤقتاً، أو إجماعاً زائفاً، أو تصالحاً مرحلياً لتهدئة الخواطر، بل تكون شكلاً مثالياً لتنظيم العمل الحكومي وإرساء قواعده، ولازم ذلك امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفقاً للقانون، وفي الحدود التي تتسامح فيها النظم الديمقراطية، وترتضيها القيم التي تدعو إليها^(٢٦).

وتعتبر حرية الاجتماع من أكثر الحريات التي تأثرت بجائحة كورونا، حيث إن من أهم وسائل مكافحة انتشار هذا الفيروس هي التباعد الاجتماعي؛ لذلك فقد أصدرت العديد من الحكومات قرارات بحظر التجمعات على اختلاف أنواعها وأشكالها.

ففي مصر كان من أوائل القرارات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا هو القرار رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ٢٠٢٠/٣/٩ والذي نص في مادته الأولى على أنه: "في سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) وحفاظاً على صحة المواطنين؛ تعلق مؤقتاً جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر^(٢٧)."

- وفي سبيل الحد من التجمعات أصدرت الحكومة المصرية القرارات الآتية:
- القرار رقم ٧١٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال.
- القرار رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.
- القرار رقم ٧٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية.
- القرار رقم ٧٤٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية.
- القرار رقم ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات

(٢٦) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في: ١٥ أبريل ١٩٩٥، القضية رقم ٦ لسنة ١٥ قضائية "دستورية" الموسوعة الشاملة. مرجع سابق المجلد الثاني ص ٦٧٧، ٦٧٧.

(٢٧) الجريدة الرسمية - العدد ١٠ مكرر السنة ٦٣ في ٢٠٢٠/٣/٩.

- والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.
- القرار رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢٠ باستمرار غلق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت، وإغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
- كما صدرت عدة قرارات أخرى باستمرار سريان القرارات سالفة الذكر لحين انتهاء الأزمة.

كما صدر القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ، وأضاف عدة بنود جديدة للمادة ٣ من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، ومن أبرز تلك البنود البند ١٣ الذي نص على: " حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة^(٢٨)."

وفي الكويت اتخذ مجلس الوزراء الكويتي مجموعة من القرارات للحد من الاجتماعات والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مثل :

- ١ - عدم السماح باستقبال أكثر من (٥) عملاء داخل المطاعم أو المقاهي بوقت واحد.
 - ٢ - إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق العامة.
 - ٣ - إغلاق صالات الأعراس بهدف منع التجمعات.
 - ٤ - إغلاق مراكز وصالات الترفيه والتسليّة للعب الأطفال.
- وقد فرضت الحكومة الكويتية - في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا - الحظر الكلي في أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

ثالثاً - حرية ممارسة الشعائر الدينية :

تعتبر حرية ممارسة الشعائر الدينية من أهم الحريات الأساسية للإنسان ؛ لأنها تتعلق بأشد ما يحرص عليه وهي عقيدته، ويقصد بحرية ممارسة الشعائر الدينية الممارسات الفعلية أو القولية التي يؤديها أصحاب الملل الدينية بغية التقرب من الذي

(٢٨) الجريدة الرسمية - العدد ١٨ مكرر (١) السنة ٦٣ في ٦/٥/٢٠٢٠.

يؤمنون به ويعتقدون فيه؛ لذا فهي وثيقة الارتباط بالشعور الديني وفق الضوابط والشروط المشروعة^(٢٩).

وتختلف ممارسة هذه الحرية باختلاف الأديان والشرائع، ففي الشريعة الإسلامية تكون في شكل اجتماع ديني مثل صلاة الجمعة أو العيدين أو الوقوف بعرفة.

وفي المسيحية تكون في شكل قداس أو غيره من الاحتفالات الدينية.

وتختلف حرية ممارسة الشعائر الدينية عن حرية المعتقد أو الاعتقاد، فحرية الاعتقاد أمر داخلي بين الإنسان وبين ما يؤمن به من إله يستحق العبادة، فهي متعلقة بواجده ويقينه، وقد لا يؤمن الإنسان بوجود إله، كما هو حال الملاحدة.

ويترتب على ذلك نتيجة هامة هي أن حرية الاعتقاد حرية مطلقة لا يمكن تنظيمها أو تقييدها، لأنها تستعصي على التنظيم أو التقييد بحكم طبيعتها. بعكس حرية ممارسة الشعائر الدينية التي يمكن تنظيمها لأنها تتضمن ممارسات فعلية أو قولية يمكن تنظيمها أو تقييدها بحسب الأحوال.

وقد نصت المادة ٦٤ من الدستور المصري القائم على أن: "حرية الاعتقاد المطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون".

وقد وضّحت المحكمة الدستورية العليا المصرية طبيعة كل من حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية فقالت: "حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة الشعائر الدينية - هاتان الحريتان - طبقاً للدستور - مكفولتان، وهما متكاملتان - أولهما لا قيد عليها، أما ثانيهما فيجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا المرتبطة بها"^(٣٠).

وقد امتد تأثير جائحة كورونا إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية، فقامت العديد من الدول بإغلاق أماكن دور العبادة مثل المساجد والكنائس للحد من التجمعات التي تسهم في زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد.

(٢٩) د. نوال طارق إبراهيم العبيدي: الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ٢٠٠٩. مشار إليها لدى بلحاج مونير: الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة وهران ٢٠١٢ ص ٢٠.

(٣٠) المحكمة الدستورية العليا: ١٨/٥/١٩٩٦: القضية رقم ٨ لسنة ١٧ قضائية "دستورية" الجزء السابع من مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء السابع، ص ٦٥٦.

ففي مصر أصدرت وزارة الأوقاف قرارات وتعليمات مشددة بغلق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة وصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.

وفي المملكة العربية السعودية أصدرت السلطات المختصة قرارات مماثلة بغلق الحرمين الشريفين، المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وغلق المساجد بكافة أنحاء المملكة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، إغلاق جميع المساجد في البلاد حتى إشعار آخر على أن تقام شعيرة الأذان فقط ويؤدي المواطنون والمقيمون الصلاة في منازلهم أو أماكن عملهم^(٣١).

وكذلك الحال في الغالبية العظمى من الدول الإسلامية، وكان النداء مع الأذان، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. وفُرضت عقوبات على مخالفة قرارات غلق المساجد وفتحها.

الأساس الدستوري والقانوني للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات لمواجهة جائحة كورونا:

أولاً - في مصر :

من الناحية الدستورية :

طبقاً لنص المادة ١٨ من الدستور المصري القائم الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل عام ٢٠١٩ فإن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة يعد حقاً دستورياً، فقد نصت تلك المادة على أنه: " لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل"

ومن الناحية التشريعية :

فقد مرت تشريعات مكافحة الأوبئة والأمراض المزمنة في مصر بتطورات عدة، فأول قوانينها صدر قبل ١١٤ عاماً عندما أصدر خديو مصر عباس حلمي الثاني القانون رقم ١ لسنة ١٩٠٦، ثم القانون الأكثر شمولاً رقم ١٣٧ الصادر عام ١٩٥٨ بشأن "الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المزمنة بالإقليم المصري"، والذي عُدل عام ١٩٧٩، وأخيراً التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الطوارئ

(٣١) جريدة الجريدة الكويتية بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٠.

لمواجهة جائحة كورونا. وقد أصدر وزير الصحة المصري القرار رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨^(٣٢).

ثانياً - في الكويت :

يرجع الأساس الدستوري للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية في مواجهة جائحة كورونا إلى نص المادة (١٥) من الدستور الكويتي الصادر عام ١٩٦٢ التي تنص على أنه: "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة".

فالدستور الكويتي قد نص على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة وبتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

وأما عن الأساس القانوني فقد استندت الحكومة الكويتية إلى تشريعين مهمين هما :

التشريع الأول: هو القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، حيث حدد هذا القانون في جدول ملحق بقسميه الأول والثاني الأمراض السارية، وكيفية التبليغ عنها، والمسؤولين عن التبليغ، والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة ظهور أحد هذه الأمراض، وإجراءات العزل الصحي الإجباري، وإجراءات الوقاية والعلاج منها، والاختصاصات الممنوحة لأطباء وزارة الصحة في التعامل مع تلك الأمراض.

ومنحت المادة ١٥ من القانون وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد عند ظهور الأوبئة مثل العزل التام للمناطق المصابة، وعدم السماح بالدخول أو الخروج منها إلا بتصريح سابق، منع التجول في بعض المناطق، إجراء التطعيم الإجباري، عدم جواز نقل الأشخاص المصابين بغير إذن من وزارة الصحة، الحق في أخذ العينات اللازمة من المرضى بأحد الأمراض السارية لتحليلها، الحق في دخول المساكن بعد إخطار أصحابها واتخاذ أية تدابير أو احتياطات أخرى يراها الوزير ضرورية لمكافحة الوباء.

(٣٢) للمزيد من التفصيل حول تشريعات الصحة الوقائية في مصر انظر: الدراسة التي أعدها المستشار الدكتور: محمد عبد الوهاب خفاجي بعنوان "تشريعات الصحة الوقائية ووعي الأمة المصرية عبر تاريخها في مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين صحة المواطنين" بحث منشور على الإنترنت.

وفي إطار جهود دولة الكويت للتصدي لجائحة كورونا^(٣٣)، وافق مجلس الأمة الكويتي في ٢٤/٣/٢٠٢٠ على مشروع قانون بتعديل المادة ١٧ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بتغليظ العقوبات على مخالفة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا - لتحقيق الردع - حيث أشارت المادة الأولى من مشروع القانون إلى "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكانت العقوبة قبل التعديل لا تزيد عن الحبس لمدة شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقب مشروع القانون "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الهدف من تغليظ العقوبات هو احتواء القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، مضيفة "كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له"^(٣٤).

(٣٣) يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قد اتخذ عدة قرارات تتضمن توجيهات وتعليمات للمواطنين والمقيمين يحثهم فيها على التعاون والالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية، وأكد فيها على نهج الشفافية الذي تتبعه الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، ومن أبرز هذه القرارات - القرار رقم (٣٧٦) بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٠ والقاضي بالتأكيد على أن "كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيها أو زائريها، ولا يستهدف أفراداً ولا فئة، ولا جنسية ولا دولا، مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديراً لخطورة الوباء". - القرار رقم (٣٧٦) في ٩/٣/٢٠٢٠ الذي دعا كافة المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الحيطه والحذر، والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصحية التي يتم الإعلان عنها باستمرار حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.. - القرار ٣٩١ في ١١/٣/٢٠٢٠ حيث أكد المجلس على " ضرورة تفعيل العقوبات التي تضمنتها القوانين، وعدم مخالفة الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحد من انتشار العدوى. - القرار رقم (٣٩٤) في ١٤/٣/٢٠٢٠. الذي أكد فيها المجلس على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية للوقاية من الوباء والحد من انتشاره. وكذلك القرار (٤٢٦) في ١٦/٣/٢٠٢٠ بشأن مخالفات ضوابط الحجز المنزلي. وفي هذا الصدد شدد مجلس الوزراء على ضرورة مباشرة وزارة الصحة والجهات المعنية بالإجراءات الكفيلة بتفعيل العقوبات التي تضمنها أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

(٣٤) انظر: جريدة القبس الإلكترونية بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠.

أما التشريع الثاني :

فهو المرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن الدفاع المدني، ويشمل تدابير الدفاع المدني في حالة الحرب أو الأحكام العرفية أو الكوارث العامة، حيث أجازت المادة ١١ من ذلك المرسوم في حالة التعبئة العامة والكوارث العامة لوزير الداخلية - بالتنسيق مع الجهات المعنية - أن يصدر قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام أفراد الفئات الآتية في مقار أعمالهم :

أ - الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو بالمهن المعاونة أو المكملة لها.

ولا شك أن جائحة كورونا تعد كارثة صحية عالمية أصابت غالبية دول العالم، وأدت إلى شلل تام في نواحي الحياة كافة.

الخلاصة :

إن الإجراءات التي قامت بها الحكومات للتصدي لجائحة كورونا قد أثرت تأثيراً مباشراً وواضحاً على الحريات الأساسية للمواطنين، حيث تم تعليق ممارسة تلك الحريات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل السلطات العامة متحررة من الضوابط الدستورية والقانونية عند القيام بمسؤوليتها لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من انتشار هذا الفيروس القاتل ؟

بمعنى آخر هل يحق للسلطات اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة دون ضوابط دستورية أو قيود قانونية تحد من تأثير قراراتها وإجراءاتها على حقوق وحرريات المواطنين ؟

هذا ما سوف نعرض له في المبحث الثاني.

المبحث الثاني الضوابط الدستورية في التصدي للجائحة

تمهيد :

مما لاشك فيه أننا أمام ظرف استثنائي، وجائحة ليس لها من دون الله كاشفة، خلّفت وراءها الكثير من الضحايا على مستوى العالم، لكن ما يُخشى منه أن تستغل السلطات هذا الظرف الاستثنائي في العصف بحقوق وحرّيات المواطنين، لتكون هي الأخرى إحدى ضحايا فيروس كورونا المستجد، وهو ما حذر منه البعض، ففي مقال بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، اعتبر فلوريان بيبر، أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة "غراتس" النمساوية، أن الوباء وفّر للحكومات الديكتاتورية والديمقراطية - على حد سواء - فرصة للتعسف وإساءة استخدام القرار وتقليص الحريات المدنية.

ويرى بيبر، أن الإجراءات الحالية قد تنجح في التخفيف من انتشار الفيروس وتفشي الجائحة، لكن العالم سيواجه خطراً من نوع آخر؛ إذ ستكون العديد من البلدان أقل ديمقراطية بكثير عما كانت عليه، حتى بعد ما يتراجع خطر الفيروس، ويتابع قائلاً إن الضوابط والتوازنات - غالباً - ما يتم تجاهلها من قبل السلطات التنفيذية في أوقات الأزمات، لكن الخطورة تكمن في أن تتحول هذه الإجراءات الاستثنائية المؤقتة إلى دائمة^(٣٥).

ويخشى البعض أن تتحول جائحة كورونا إلى "كارثة" على حقوق الإنسان، حيث دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الدول لاحترام دولة القانون رغم فيروس كورونا عبر الحد زمنياً من التدابير الاستثنائية تفادياً "لكارثة" على حقوق الإنسان^(٣٦).

وعليه، وإزاء هذه المخاوف على الحريات العامة فإن الباحث يرى أنه حتى في ظل هذه الظروف الاستثنائية ينبغي أن تخضع السلطات العامة لبعض الضوابط والقيود التي تحد من إطلاق سلطاتها حتى لا تكون أداة للتعسف، وفي الوقت ذاته، تكون تلك القيود ضمانات لحريات المواطنين وحقوقهم ضد تعسف السلطات.

ومن وجهة نظر الباحث فإن أهم قيدين يردان على السلطات العامة في هذا

(٣٥) تحقيق بعنوان "هل تصبح حقوق الإنسان ضحية "كورونا"؟ منشور في جريدة الجمهورية اللبنانية بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١.

(٣٦) تصريحها المنشور على موقع فرانس ٢٤ والمنشورة في ٢٧/٤/٢٠٢٠.

الظرف الاستثنائي، ويمثلان في الوقت ذاته ضمانات للحريات، مبدآن يعتبران من المبادئ الدستورية العامة وهما مبدأ الضرورة، ومبدأ التناسب.

ولكن قبل أن نعرض لهذين المبدئين، نعرض لتعريف الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها، والتكييف القانوني لجائحة كورونا، هل تنطبق عليها شروط القوة القاهرة أم لا ؟

وهو ما نعرض له في المطالب الآتية :

المطلب الأول: تعريف الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها، والتكييف القانوني لجائحة كورونا

المطلب الثاني: مبدأ الضرورة

المطلب الثالث: مبدأ التناسب

المطلب الأول تعريف الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها، والتكييف القانوني لجائحة كورونا

الأصل أنه يتعين على السلطات العامة الالتزام بأحكام القانون في كل وقت وأياً كانت الظروف، بيد أن هذا المفهوم وإن كان صالحاً في الأوقات والأزمات الطبيعية، إلا أنه يبدو صعب التطبيق في أوقات الأزمات أو الاضطرابات التي لا تخلو من حياة أي دولة، إذ قد يترتب من الإصرار على تطبيقه استنفال الأزمة بما يؤدي إلى انهيار الدولة ذاتها أو على الأقل تعريض سلامتها لمخاطر شديدة تعصف بوجودها، وبكل ما حرص مبدأ المشروعية ذاته على المحافظة عليه، فسلامة الشعب هي القانون الأعلى الذي يجب أن يسمو على القوانين الوضعية وفقاً لقول شائع للفيلسوف "شيشرون" بأن سلامة الشعب فوق القانون^(٣٧).

وعلى أثر انتشار فيروس كورونا المستجد في الغالبية العظمى من دول العالم، قام العديد من الدول باتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية وعاجلة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحيولة دون انتشار هذا الفيروس الخطير، لذلك شكل انتشار هذا الفيروس ظرفاً استثنائياً أتاح للسلطات العامة الفرصة لاتخاذ إجراءات استثنائية بهدف الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة للجميع.

(٣٧) أستاذنا الدكتور سامي جمال الدين: القضاء الإداري، الكتاب الأول، الرقابة على أعمال الإدارة، الطبعة الثالثة ٢٠٠٢، من دون ذكر ناشر، ص ٢٣٢، ٢٣٣.

وعليه سيتناول الباحث في هذا المطلب تعريف الظروف الاستثنائية وشروط تطبيقها، والتكييف القانوني لجائحة كورونا.

أولاً - مفهوم الظروف الاستثنائية :

هي أحداث غير عادية وغير متوقعة، تنذر بوقوع أضرار جسيمة بالدولة أو إخلال جسيم بنظامها العام، ويستتبع مواجهتها اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة للحد من آثارها الخطيرة.

هذه الأحداث قد يكون مصدرها خارجياً مثل قيام حرب خارجية أو إقليمية، أو انتشار وباء في العالم أو في المنطقة المحيطة بالدولة.

وقد يكون مصدرها داخلياً مثل قيام ثورة أو حدوث انقلاب، أو حدوث فتن واضطرابات داخلية، أو حدوث أزمة اقتصادية أو سياسية، أو انتشار وباء أو غيرها من حالات المساس الخطير بالنظام العام^(٣٨).

هذه الظروف أو الأحداث ترتبط بوجود حالة خطر عام ينذر بوجود مخاطر شديدة الوطأة أصيلة في ماهيتها؛ لا متوهمة أو زائفة في مظاهرها؛ غير مستطاع توقعها أو دفعها - بالنظر إلى عنصر المداهمة فيها، وعمق آثارها - بالوسائل القانونية المعتادة التي تقصر فرصها - سواء في طبيعتها أو توقيتها - عن أن توفر للدولة وسائل الدفاع الملائمة عن كيانها أو مؤسساتها^(٣٩).

إذن الظروف الاستثنائية في مجال الضبط الإداري تعني السماح لسلطات الضبط الإداري بإصدار قرارات وأوامر تعتبر في الأوقات العادية خروجاً على مبدأ المشروعية ولكنها تعتبر مشروعة على الرغم من ذلك لصدورها في إطار ظروف استثنائية للمحافظة على النظام العام، وبذلك تعفى هذه السلطات من قيود المشروعية العادية

(٣٨) انظر: في تعريف الظروف الاستثنائية: د. مجدي المتولي السيد يوسف: أثر الظروف الاستثنائية على مبدأ الشرعية: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، ١٩٩٠ ص ٤٧ وما بعدها.

إسماعيل جابوربي: نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري "دراسة مقارنة" مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر / جانفي ٢٠١٦ ص ٣٢ وما بعدها.

شرقي صالح الدين: حماية الحريات العامة للأفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية: مجلة دفاتر السياسة والقانون العدد الرابع عشر / جانفي ٢٠١٦ ص ٩٢ وما بعدها.

(٣٩) المستشار الدكتور عوض المر: الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه - جان دبوي للقانون والتنمية ص ٩٢٩.

سواء تعلقت هذه القيود بالاختصاص أو الشكل أو الموضوع، كما تتمتع هذه السلطات باختصاصات واسعة وشاملة لم ينص القانون على تمتعها بها من ناحية أخرى^(٤٠).

ففي الظروف الاستثنائية تملك سلطات الضبط صلاحيات واسعة تتجاوز السلطات والاختصاصات الممنوحة لها في الظروف العادية بهدف الحفاظ على النظام العام ضد الأخطار الاستثنائية التي لو تركت للإجراءات العادية لأدى ذلك إلى انهيار الدولة والمجتمع ككل.

فعلى سبيل المثال، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً من انتشار فيروس كوفيد-١٩ وما صاحبه من أخطار صحية هددت ملايين البشر، قام العديد من دول العالم باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية استثنائية بهدف الحد من انتشاره، هذه القيود أثرت على الحقوق والحريات العامة للمواطنين في الدول المختلفة، فأدت إلى تعطيل ممارستهم لها، وحرمانهم منها، ولم يكن من الممكن - في ظل الظروف العادية - قبول هذا التقييد أو التعطيل، لكن هذا الظرف الاستثنائي أباح لسلطات الضبط اتخاذها بهدف الحفاظ على هدف أسمى ومصلحة أولى بالرعاية وهي الحفاظ على الحق في الحياة.

ويرجع الفضل في ابتداء نظرية الظروف الاستثنائية لمجلس الدولة الفرنسي^(٤١). ولخطورة الإجراءات المترتبة على تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية فقد استقر القضاء على تحديد شروط تطبيقها، وهو ما نوضحه في البند الآتي:

ثانياً - شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية :

لا يمكن تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية إلا إذا تحققت عدة شروط استخلصها فقهاء القانون الإداري من اجتهادات القضاء الإداري الفرنسي^(٤٢)، وأهم هذه الشروط :

(٤٠) د. محمد علي حسونة: الضبط الإداري وأثره في الحريات العامة، مجلة مصر المعاصرة، المجلد ١٠٤، العدد ٥٠٦، أبريل ٢٠١٢ ص ٢٥٤.

(٤١) انظر في الخلاف حول الأصول التاريخية لنشأة نظرية الظروف الاستثنائية: مديحة الفحلة، نظرية الظروف الاستثنائية بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام والتزام حماية الحقوق والحريات الأساسية. مجلة المفكر، العدد ١٤، ٢٠١٧ ص ٢٢٢ وما بعدها.

(٤٢) للمزيد من التفاصيل حول هذه الشروط انظر: نواف ناصر الرشيد: ضمانات حقوق وحريات الأفراد في ظل إجراءات الضبط الإداري في الكويت، رسالة ماجستير، كلية عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن ٢٠١٧ ص ٤٨.

وانظر أيضاً: شرقي صالح الدين، حماية الحريات العامة للأفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، مرجع سابق ص ٩٧.

١ - وجود ظرف استثنائي يتمثل في وجود خطر جسيم وحال يهدد أمن وسلامة الدولة، أياً كان مصدر هذا الخطر، فالعبرة ليست بمصدر الخطر، وإنما بآثاره على كيان الدولة وسلامتها.

٢ - عجز الطرق العادية أو الوسائل القانونية العادية عن مجابهة هذا الخطر، والحد من آثاره، ولابد من اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهته.

٣ - ينبغي أن يكون الهدف أو الغاية من هذه الإجراءات الاستثنائية هو الحفاظ على المصالح العليا للمجتمع التي من دونها يختل النظام العام.

٤ - ارتباط الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات العامة بالظروف الاستثنائية، فالظروف الاستثنائية هي الحالة أو السبب الذي يبرر للسلطات اتخاذ هذه الإجراءات، فإذا زالت الحالة أو السبب أصبح الاستمرار في الإجراءات باطلاً لزوال موجباته.

وبتطبيق هذه الشروط على الظروف الحالية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩، فقد أطلقت منظمة الصحة العالمية في مارس ٢٠٢٠ على ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد مصطلح "الجائحة" للدلالة على قوة وخطورة وسرعة انتشار المرض في العالم، فالمرض انتشر في ١٧٨ دولة من أصل ١٩٨ دولة أعضاء في الأمم المتحدة، وبالتالي أصبح وباء عالمياً مهدداً بخطر جسيم يهدد البشرية كلها.

وإزاء هذه المخاطر التي سببها انتشار هذا الفيروس سارعت العديد من الدول بإعلان حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية بهدف منع وصول الفيروس إليها، مثل تعليق حركة الطيران الدولي، أو في مكافحته والحد من انتشاره مثل فرض حظر التجوال، ومنع الاجتماعات، وتعليق الدراسة، وتعليق العمل بالمحاكم وغيرها من الإجراءات الوقائية.

فجائحة كورونا هي ظرف استثنائي بامتياز سواء في المخاطر التي يمثلها، أو الإجراءات الاستثنائية التي ترتبت على ظهوره وانتشاره، أو في الآثار التي أحدثها في العالم في مناحي الحياة كافة.

ثالثاً - التكيف القانوني لجائحة كورونا :

جائحة كورونا حدث مفاجئ لم يشهده العالم من قبل :

ظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر ٢٠١٩ بصورة مفاجئة غير متوقعة، وانتقل أيضاً إلى دول العالم بطريقة مفاجئة وسريعة

وغير متوقعة، مخلفاً - ولا يزال - وراءه الملايين من المصابين، ومئات الآلاف من الضحايا، ومؤثراً على مناحي الحياة كافة. وحتى الآن لم يتوصل العلم - على الرغم من الجهود المبذولة - إلى لقاح يعالجه ويقضي عليه.

وقد ثار السؤال حول الطبيعة القانونية لجائحة كورونا، هل تعد قوة القاهرة أم ظرفاً طارئاً، ولا شك أن تحديد الطبيعة القانونية لجائحة كورونا يؤثر - دون شك - على طريقة تنفيذ الالتزامات، وكذلك تحديد المسؤولية ومدى إمكانية الإعفاء منها.

ولتحديد الطبيعة القانونية لجائحة كورونا نعرض لموقف كل من القضاء والفقه والتشريع :

أولاً - القضاء :

اعتبر القضاء في بعض الدول أن جائحة كورونا تعد من قبيل القوة القاهرة، ففي فرنسا وبتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٠ صدر القرار رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٠ عن محكمة استئناف كولمار الفرنسية، الغرفة السادسة، حيث اعتبرت المحكمة أن "فيروس كورونا المنتشر عالمياً (COVID-19) يتصف فعلياً "بالقوة القاهرة"، وأن الأوضاع التي نشهدها بسببه هي استثنائية، ولا يمكن مقاومتها"^(٤٣).

وفي مصر:

اعتبرت محكمة القضاء الإداري في مصر أن فيروس كورونا المستجد يعد جائحة ويشكل "قوة القاهرة"، حيث اجتاحت العالم، وقد أيدت المحكمة قرار نقيب أطباء الأسنان بتأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، التي كان مقرراً لها يوم ٢٦/٣/٢٠٢٠ بعد رفض الدعاوى المقامة من بعض أطباء الأسنان، والتي كانت تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني المقرر لها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة العدوى. وشيدت المحكمة قرارها على أن: "الحياة الإنسانية هي أعلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقاً على حفظ الدين، درءاً لآية تدعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد"^(٤٤).

(٤٣) انظر: في التعليق على هذا الحكم مقال بعنوان "وباء كورونا والقوة القاهرة: تعليق على قرار محكمة استئناف COLMAR" للمحامي جان ثابت والمقال منشور بمجلة " محكمة " بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٠.

(٤٤) حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - في الدعوى رقم ٣٧٢١٤ لسنة ٧٤ ق، جلسة ٢٨/٦/٢٠٢٠.

وفي المغرب :

قضت محكمة القضاء المستعجل بمدينة الرباط بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ برفض سفر المحضون من المغرب للخارج في ظل الظروف الحالية التي قد تهدد صحته وحياته وتنعكس عليه بشكل سلبي، باعتبار أن الحق في حياة آمنة حق من حقوق الطفل، حياة صحية هائلة مستقرة، ولا توجد ضرورة تستدعي السفر للعلاج أو غيره، وبالتالي تم رفض الطلب نظراً للخطر الذي يهدد حياة المحضون وصحته ومستقبله، وأن سفره قد يعرضه للخطر طبقاً لواقع الحال^(٤٥).

وفي لبنان :

أصدر قاضي التحقيق في محافظة لبنان الشمالي بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٥ قراراً قضائياً في قضية ترويج مخدرات، اعتبر بموجبه أن "فيروس كورونا" يشكل "قوة قاهرة" من جراء تعريض المواطنين، بمن فيهم نزلاء السجون، إلى خطر الإصابة بالعدوى المميتة، وأن هذا الأمر يختزن على المستوى الوطني حالة ضرورة تسمح للقاضي بما له من سلطة تقدير أن يتخذ تدابير وقائية لملاءمة الأوضاع الخطرة المشكو منها، عبر تطبيق نص المادة (١٠٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتخليه سبيل الموقوفين على الرغم من عدم اكتمال المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة^(٤٦).

ثانياً – في الفقه :

ذهب بعض الفقهاء الذين تعرضوا لبحث الطبيعة القانونية لفيروس كورونا "كوفيد - ١٩" إلى اعتبار وباء كورونا قوة قاهرة كونه حادثاً خارجياً فجائياً غير متوقع الحدوث وغير ممكن دفعه، فضلاً عن كونه وباءً عالمياً واسع الانتشار عابراً للقارات لا يعرف الحدود ولا المسافات، أصاب الكرة الأرضية بالشلل التام غرباً

(٤٥) أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ مشار إليه لدى الأستاذ عبد المغيث الحاكمي في بحث بعنوان "دور القانون والقضاء في الحد من تأثير فيروس كورونا على العلاقات التعاقدية"، مجلة الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا، كوفيد ١٩ العدد ١٧، أبريل ٢٠٢٠ ص ٤٦.

(٤٦) مشار إليه لدى د. محمود المغربي، د. بلال صنيدي: التكييف القانوني للجائحة "الكرونية" على ضوء الثوابت الدستورية والدولية والمبادئ القانونية المستقرة... بين صلاية المسلمات ومرونة الاعتبارات: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - ملحق خاص - العدد ٦، يونيو ٢٠٢٠ ص ٣٠ هامش ٢٠.

وشرقاً، شمالاً وجنوباً، وأجبر العالم على الحظر المنزلي والتباعد الاجتماعي وأوقف مظاهر الحياة إلا ما تقتضيه الضرورة^(٤٧).

ويرى الأستاذ الدكتور رجائي حسين الشتوي أن "وباء كورونا يعد قوة القاهرة؛ لأنه سيكون السبب الرئيسي وراء القضاء بإعفاء أطراف العقود من أداء التزاماتهم المستحقة أو غير المقدور على تنفيذها"^(٤٨).

ويرى البعض أنه من الواضح أن فيروس كورونا المستجد يصح وصفه بالقوة القاهرة؛ لكونه حادثاً عاماً شمل كافة دول العالم، ولا يمكن توقعه أو درء نتائجه؛ لذلك من الممكن بشكل كبير قانوناً بالنسبة لبعض الأفراد أو الأنشطة التجارية أو الخدمية التي تضررت تضرراً مباشراً أن تتمسك بتوافر معيار القوة القاهرة كمبرر وسند لفسخ العقود من تلقاء نفسها.

أما القطاعات أو الأعمال الأخرى التي لم تؤثر فيها القوة القاهرة بشكل مباشر لكن أعمالها ونشاطاتها تأثرت بسبب تغير الظروف والتكلفة والوقت، فيمكن تعديل شروط العقد أو تغييرها لموازاتها بين الطرفين، لما فيه مصلحتهما. أما بالنسبة للنشاطات الأخرى التي لم تتأثر بالقوة القاهرة ولا بتغير الظروف واستمرت أعمالها ونشاطاتها وفق المعتاد، فلا يمكن أن تتمسك بأي من القوة القاهرة والظروف الطارئة حالياً، ولكن في حال استمر الوضع الناتج عن فيروس كورونا المستجد إلى فترة أطول، فقد يختلف الحال بالطبع مع تغير الظروف الاقتصادية والتجارية والتشريعات التي تتصل بهذا المجال لحماية الأفراد والمجتمع، والتي قد تؤثر بطريقة غير مباشرة سلباً في بعض الأنشطة الاقتصادية أو العقود في ما بين الطرفين^(٤٩).

(٤٧) أ. د. سحر عبد الستار إمام: جائحة كورونا وتداعياتها على المنظومة القضائية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة السادات، المجلد ٦، عدد خاص بجائحة كورونا وتداعياتها القانونية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، صيف ٢٠٢٠، ص ٦٣.

(٤٨) أ. د. رجائي حسين الشتوي: آثار كورونا COVID-19 على الالتزامات التعاقدية. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة السادات، المجلد ٦، عدد خاص بجائحة كورونا وتداعياتها القانونية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية صيف ٢٠٢٠ ص ٥.

(٤٩) عبير أبو شمالة: مقال بعنوان شروط "القوة القاهرة" هل تنطبق على فيروس كورونا، منشور على موقع الخليج الاقتصادي بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٠. ومن الآراء التي تعتبر جائحة كورونا قوة القاهرة أ. د. ج. يوسف عبيدات، حيث يرى أن جميع شروط القوة القاهرة تنطبق على ظرف فيروس كورونا. انظر له بحث بعنوان: "بعض صور الحماية القانونية في زمن جائحة كورونا" - مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - ملحق خاص - العدد ٦، يونيو ٢٠٢٠ ص ٥٧٠.

ثالثاً - التشريع :

ففي فرنسا :

أصدر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بياناً بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ بأن وباء كورونا يعد قوة قاهرة، وبالتالي فإن التأخير في التسليم للالتزامات طبقاً للمواعيد الواردة في العقود التي أبرمتها الدولة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناتج عن اجتياح هذا الوباء لن يترتب عليه توقيع جزاءات لاعتبار هذا الوباء قوة قاهرة لم يكن في الإمكان توقعها ويستحيل دفعها، لأن الفيروس أو المرض لا يعد قوة قاهرة حينما يكون الوباء معروفاً أو متوطناً وليس مميتاً، وهذه الأوصاف لا تنطبق على فيروس كورونا، فمازال تحت الدراسة، وأضراره تجاوزت الحد المألوف، فضلاً عن سرعة انتشاره كالنار في الهشيم^(٥٠).

وفي مصر :

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٢٩٥ لسنة ٢٠٢٠ قراراً بوقف المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعوى والطعون القضائية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه: "تعد الفترة من تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ حتى تاريخ سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٤٦ لسنة ٢٠٢٠ مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية.

ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام"^(٥١).

وبصدور هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء فإنه يكون بذلك قد اعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن مواعيد السقوط تقف بالقوة القاهرة التي لا إرادة للخصم فيها، وتمنعه من القيام بالعمل الإجرائي في الميعاد المحدد له، ويستمر وقف سريان الميعاد ما بقي ذلك الطارئ قائماً ومانعاً من اتخاذ الإجراء^(٥٢).

(٥٠) نقلاً عن الدكتور سحر عبد الستار إمام: مرجع سابق ص ٤٨.

(٥١) الجريدة الرسمية العدد رقم ٢٦ مكرر (ب) بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٠.

(٥٢) الطعن رقم ٤١١٠ لسنة ٨٢ ق جلسة ٢٠١٨/٥/١٤ مشار إليه لدى الدكتور سحر عبد

الستار إمام، مرجع سابق ص ٤١.

وفي الكويت :

إثر تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -١٩ في الكويت؛ أعلن مجلس الوزراء الكويتي الفترة من ١٢ إلى ٢٦ مارس ٢٠٢٠ إجازة رسمية في البلاد، وصدر بعد ذلك قرار آخر بتمديد الإجازة إلى تاريخ ١٢/٤/٢٠٢٠. وبسبب خطر توقف العمل في محاكم الدولة وأثره على انقضاء المواعيد الخاصة بالدعاوى أو الطعون المنظورة أمام المحاكم، أقر مجلس الأمة الكويتي القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل المادة (١٧) من قانون المرافعات الكويتي رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإضافة المادة (١٧ مكرر)، والتي تنص في مادتها الأولى على أنه: "في الأحوال التي يقر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحتسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، على أن تحتسب من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل". ونصت المادة الثانية من التعديل على سريان هذا القانون بأثر رجعي اعتباراً من ١٢ مارس ٢٠٢٠ وهو تاريخ توقف المحاكم عن العمل.

مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة بالنسبة للحقوق والحريات العامة :

لا يعد النظام نظاماً ديمقراطياً إلا إذا كفل لأفراده عدداً من الحريات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطي إلا بها، فوجود الحريات وضمنان تمتع الأفراد بها وممارستهم لها في جو ديمقراطي يسوده القانون هو الدليل على وجود نظام ديمقراطي حقيقي.

وقد جرت سنة الدول الديمقراطية على تقرير الحريات العامة في صلب دساتيرها، حرصاً منها على أن تكون لتلك الحريات قوة الدستور بما له من سمو في النظام القانوني، ولم يكتف الدستور المصري القائم بتضمين الحريات في صلبه والنص على أن لا تنظم إلا بقانون، وإنما أكد على عدم جواز الانتقاص منها حتى ولو بالقانون^(٥٣). حيث أكدت المادة ٢/٩٢ من الدستور المصري القائم على أنه: "ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيد بها بما يمس أصلها أو جوهرها".

(٥٣) د. محمد عبد الجليل المر: حق تكوين الجمعيات الأهلية الضوابط الدستورية (للنشأة - لممارسة النشاط - للانقضاء) دراسة تحليلية مقارنة. رسالة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية ٢٠٢٠ ص ٢.

فالدستور كفل الحريات العامة في مواجهة المشرع العادي نفسه. ودور المشرع في تنظيم الحقوق والحريات هو كفالتها في الحدود الموضوعية على النحو الذي يُمكن الأفراد من ممارستها بطريقة فعالة.

لكن قد تحدث ظروف أو أحداث استثنائية غير متوقعة مثل الحرب أو الأوبئة أو الزلازل تجعل ممارسة الأفراد لبعض الحريات مستحيلاً، وتُحتم على السلطات تعليق ممارسة الأفراد أو المواطنين لحرياتهم أو حرمانهم منها بصفة مؤقتة؛ وذلك بهدف المحافظة على هدف أسمى ومصلحة أولى بالرعاية. فهل تشكل هذه الظروف الاستثنائية قوة القاهرة تعفي الدولة من مسؤوليتها الدستورية بكفالة الحريات العامة؟

تعريف القوة القاهرة :

هي الواقعة التي يترتب عليها عدم قدرة الشخص سواء الطبيعي أو المعنوي على القيام بما كُلف به، فلا تكليف بمستحيل، فالاستطاعة هي مناط التكليف، فالحق سبحانه وتعالى قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٥٤).

وقضت محكمة النقض المصرية بأن القوة القاهرة تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً^(٥٥). واشترطت المحكمة لاعتبار الحادث قوة القاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة^(٥٦).

وقد اعتبرت المحكمة أن أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ تعد من حالات القوة القاهرة حيث قالت: "إذ كانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة يناير ٢٠١١ وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة". وقد اعتبرت المحكمة "أن انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث الموكبة لثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ عذر قهري يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد"^(٥٧).

(٥٤) سورة البقرة آية ٢٨٦.

(٥٥) نقض مدني في ٢٧ نوفمبر ١٩٧٨ مشار إليه لدى الدكتور سحر عبد الستار إمام، مرجع سابق ص ٢٢.

(٥٦) الطعن رقم ٧٧ لسنة ٧٢ قضائية جلسة ٢٨/١١/٢٠٠٢. مشار إليه لدى الدكتور سحر عبد الستار إمام، مرجع سابق ص ٢٦.

(٥٧) الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٧/١٠/٢٠١٢، أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي - السنة ٦٣ ص ٤٣٣.

وفي القضاء الإداري قضت المحكمة الإدارية العليا: "ويجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أمراً غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع، فإن توافر هذان الشرطان كان الحادث أجنياً عن الشخص لا يد له فيه، ويجب أن تكون عدم استطاعة التوقع لا من جانب المدين بل من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمر، فالمعيار موضوعي لا ذاتي، فلا يكتفي فيه بالشخص العادي ولكن يتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلقاً، كما يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدفع، فإن أمكن دفع الحادث حتى ولو استحال توقعه لم يكن ثمة قوة قاهرة أو حادث فجائي، كما يجب أن يكون من شأنه جعل التنفيذ مستحيلاً استحالة مطلقة لا بالنسبة للمدين وحده بل بالنسبة إلى أي شخص يكون في موقف المدين، وهذا هو ما يميز القوة القاهرة والحادث الفجائي عن الحوادث الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً.."^(٥٨).

وبتطبيق شروط القوة القاهرة على فيروس كورونا المستجد نجد أن هذا الفيروس قد ظهر فجأة وبصورة غير متوقعة في مدينة ووهان في دولة الصين في أواخر عام ٢٠١٩، ومنها انتشر بصورة سريعة وغير متوقعة أيضاً في أنحاء العالم مخلفاً وراءه ملايين المصابين ومئات الآلاف من الضحايا، وحتى الآن لم يتوصل العالم - برغم المحاولات المستمرة - إلى علاج لهذا الفيروس، وبالتالي تتوافر في هذه الجائحة صفة القوة القاهرة من عدم إمكان التوقع، فلم يتوقع أحد ظهور هذا الفيروس، ولم يُتوقع انتشاره بهذه الصورة السريعة، وكذلك استحالة الدفع، فحتى الآن لم يستطع العالم دفع هذا المرض بالعلاج المناسب.

وبالتالي فإن عدم استطاعة الدولة كفالة الحريات العامة في هذه الظروف الاستثنائية له ما يبرره، بل أن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت السلطات باتخاذها لمكافحة الجائحة والتي أثرت بلا شك على ممارسة الأفراد لحرياتهم، وأدت إلى تقييدها كانت بهدف مشروع وغاية سامية هي الحفاظ على الحق في الحياة والصحة العامة، لكن ليس معنى ذلك إطلاق يد سلطات الضبط في اتخاذ ما تشاء من تدابير وقيود ضد الحريات العامة بحجة الحفاظ على النظام العام، وإنما يجب أن تكون تلك القيود والتدابير ضرورية ومناسبة.

(٥٨) مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - السنة الخامسة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة ١٩٥٩ إلى آخر يناير سنة ١٩٦٠) - الطعن رقم ٦٨٩ لسنة ٤ القضائية جلسة ١٢/١٢/١٩٥٩.

الخلاصة :

إزاء ذلك كان لابد للدول والحكومات أن تتدخل لحماية مواطنيها من خطر هذه الكارثة الصحية العالمية، ولكن لكي يكون التدخل مشروعاً - في ظل هذه الظروف الاستثنائية - لابد للسلطات في إطار ممارستها لسلطاتها التقديرية في حماية النظام العام مراعاة عدد من المبادئ الدستورية الهامة التي تضبط تصرفاتها^(٥٩)، ذلك ليس معنى أننا نعيش في ظرف استثنائي أن تتحلل السلطات من القيود والضوابط القانونية، أو تتصرف كما تشاء، وإنما يجب أن تخضع لضوابط قانونية تحد من إطلاق سلطاتها، وتكون تخوماً لا يجوز لها أن تتجاوزها. ذلك أنه وفقاً لـ "مبادئ سيراكوزا" التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام ١٩٨٤، والتعليقات العامة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن حالات الطوارئ وحرية التنقل، فإن كل القيود التي تفرض في بعض الحالات - ومنها الصحية - على حقوق وحرية الأفراد يجب أن تكون مُحددة ومُطبقة بما يتماشى مع القانون، موجهة نحو هدف مشروع للمصلحة العامة، ضرورية للغاية في مجتمع ديمقراطي لتحقيق هدف معين، مستندة إلى أسس علمية، وليست تعسفية أو تمييزية عند التطبيق، محددة زمنياً، وتحترم كرامة الإنسان لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية إلا وفقاً لهذه المبادئ، فكل التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومات لمكافحة فيروس كورونا والتي تقيد الحقوق والحرية العامة للمواطنين ينبغي أن تكون ضرورية ولازمة ومتناسبة وغايتها تحقيق المصلحة العامة، وهو ما سنوضحه في المطلبين التاليين.

(٥٩) تعرف المحكمة الدستورية العليا السلطة التقديرية بقولها: "وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة المشرع في تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور بضوابط معينة، وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم" حكمها في القضية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٦/١٢/٣ ق. د جلسة ٢٠١٦/١٢/٣. الجريدة الرسمية العدد ٥٠ (تابع) في ٢٠١٦/١٢/١٥. وانظر أيضاً: حكمها في ٢٠٠٥/٨/٥، القضية رقم ٢ لسنة ٢٠ قضائية "دستورية".

المطلب الثاني مبدأ الضرورة

تمهيد :

من المسلم به أن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تقتضيها، ومن المقرر أن الضرورة دائماً تقدر بقدرها دون إفراط أو تفريط، ويعتبر مبدأ الضرورة من المبادئ الدستورية العامة المستقر عليها في الأمم المتحدة.

ومبدأ أو نظرية الضرورة مبدأ عام أو نظرية عامة لها تطبيقاتها في فروع القانون كافة، وتتقيد بها السلطات العامة في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، وتطبقها في الظروف الاستثنائية أولى.

ولدراسة هذا القيد المتمثل في مبدأ الضرورة يتوجب على الباحث أن يتناول مفهوم مبدأ الضرورة وشروطه وأساسه القانوني وتطبيقاته القضائية.

أولاً - مفهوم الضرورة :

المُتصور في هذه الحالة أن تقوم السلطات العامة باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، هذه التدابير تؤثر حتماً على الأفراد وحرياتهم. ويُفترض في هذه الحالة أن المشرع أو السلطات العامة القائمة على مواجهة هذه الجائحة توازن بين مصلحتين جديرتين بالاعتبار، المصلحة الأولى هي الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، والمصلحة الثانية ضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة، فتقوم السلطات بتقييد المصلحة الثانية وهي الحرية، لضمان الحفاظ على المصلحة الأولى، وهي بلا شك أولى بالرعاية في هذا الظرف الاستثنائي، لكن هذا التقييد لكي تقوم له شرعية ينبغي أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

١ - أن توجد حالة ضرورة قائمة ومتيقنة معلومة أو مظنونة :

ويتحقق ذلك بأن تتيقن السلطات بوقوع الضرر من جراء عدم اتخاذ التدابير الاحترازية، بأن يغلب على الظن وقوعه، فإذا كان وقوعه متوهماً أو غير مرجح الوقوع، انتفت حالة الضرورة؛ لأنه لا يجوز أن تبنى الأحكام على التوهم ولا تبعاً للأهواء والأغراض^(٦٠).

(٦٠) أ. د. محمود عبد الله العكازي: قواعد الفقه الكلية، الإسكندرية، دار الفتح للطباعة والتوزيع ٢٠١٤ ص ١٥٠.

فحالة الضرورة هنا هي الحالة أو الواقعة التي تبرر لسلطات الضبط اتخاذ الإجراءات الاستثنائية لحماية الصحة العامة، وهي التي تضي على هذه الإجراءات صفة الشرعية والقبول.

فمثلاً الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول - ومنها مصر والكويت - وأدت إلى تقييد عدد من الحريات الأساسية مثل تعليق حرية التنقل، منع الاجتماعات العامة والخاصة، غلق دور العبادة، تعليق الدراسة، تعليق العمل بالمحاكم. كل هذه الإجراءات ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد - سريع الانتشار والعدوى - فسبب اتخاذ هذه الإجراءات هو ظهور جائحة كورونا وما مثلته من مخاطر شديدة على الصحة العامة. والغاية أو الهدف من الإجراءات التي اتخذتها السلطات هو منع انتشار هذا الفيروس للحفاظ على مصلحة أولى بالرعاية وهي الحفاظ على الصحة العامة.

فظهور وانتشار هذا الفيروس شكّل الحالة أو السبب في اتخاذ التدابير الاستثنائية، وفي تقييد الحريات العامة، وهو الذي أضفى صفة المشروعية على تلك الإجراءات^(٦١).

٢ - أن لا تكون هناك بدائل أخرى يمكن للسلطات العامة أن تلجأ إليها غير تقييد الحريات العامة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، فإذا توافر بديل أو أكثر يحقق الغاية الأساسية، كان اللجوء إلى تقييد الحريات العامة باطلاً، وغير دستوري، فلا يجوز للمشرع أن يلجأ إلى الحلول السهلة أو الحلول التي يريدها على حساب الحقوق والحريات العامة.

وفي تطبيق حديث وعملي على بطلان وعدم جواز التقييد المطلق للحرية في

(٦١) يعرف السبب بأنه هو حالة واقعية غالباً أو قانونية أحياناً، تعرض للإدارة، فتتدخل على أساسها وتتخذ قرارها. فالسبب إذن هو تلك الحالة الواقعية أو القانونية، التي تنشأ وتتم بعيداً عن رجل الإدارة، فتوحي إليه بأنه يستطيع أن يتدخل، وأن يتخذ قراراً ما، ففكرة السبب تقوم كضمان وقرينة على أن تدخل الإدارة له ما يستوجبه، وهو ركن من أركان العمل الإداري. للمزيد من التفصيل انظر: المرحوم أ. د. سليمان الطماوي: السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة الرابعة، العدد ١-٢، يناير - يونيو ١٩٥٠ ص ١٠٣ وما بعدها. وقضت محكمة التمييز الكويتية بأن: "السبب ركن من أركان القرار الإداري. وجوب أن يقوم على حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل لإحداث قانوني ابتغاء الصالح العام." (الطعن ١٦٩ / ١٩٨٩ جلسة ٢٩ / ١٠ / ١٩٨٩) مشار إليه في المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً في الفترة من (١٠ / ١ / ١٩٧٢ - ٣١ / ١٢ / ٢٠١١) المجلد الإداري ص ٣٩.

حال إمكانية توافر بدائل أخرى غير الحرمان من ممارسة الحرية - حرية ممارسة الشعائر الدينية، قررت المحكمة الدستورية الألمانية: عدم جواز فرض حظر شامل على إقامة الشعائر الدينية شريطة اتباع إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس".

وقد ألغت المحكمة الدستورية في ألمانيا - في ٢٩/٤/٢٠٢٠ - الحظر الشامل المفروض على إقامة الشعائر الدينية أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا والذي فرضته السلطات الألمانية منذ منتصف مارس الماضي في إطار خطتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وقالت المحكمة إن ثمة استثناءات عديدة يمكن تقريرها على مبدأ الحظر إذا اتخذت احتياطات كافية لتجنب العدوى. وقد أصدرت المحكمة قرارها السابق في سياق نظرها لاستئناف رفعته الرابطة الإسلامية - في إحدى الولايات الألمانية الشمالية - والتي كانت ترغب في السماح لها بإقامة صلاة الجمعة في الأسابيع المتبقية من شهر رمضان، واستندت المحكمة في قرارها السابق إلى القول بأنه: "بالنظر إلى الانتهاك الخطير الذي يمثله الحظر الشامل للشعائر الدينية على الحرية الدينية" فإنه لم يعد مستساغاً تقبل فكرة عدم إمكانية إيراد بعض الاستثناءات على هذا الحظر، وشددت المحكمة على ضرورة اتباع إجراءات احترازية معينة: مثل تحديد عد المصلين على نحو يتناسب مع المكان المخصص لإقامة الشعائر، احترام قواعد التباعد الاجتماعي، ارتداء الأقنعة الواقية، وضع علامات تضمن عدم التقارب بين الأشخاص، وغير ذلك من الإجراءات الضرورية لتجنب العدوى.

والمستفاد من هذا الحكم أنه في حالة إمكانية وجود بدائل يمكن تطبيقها - وتكون أقل شدة - وتحافظ على حياة ممارسي الحرية وسلامتهم، فلا يجوز فرض الحظر الشامل والحرمان من ممارسة الحرية بصفة مطلقة^(٦٢).

٣ - أن تقدر الضرورة بقدرها دون إفراط أو تفريط :

ويعني هذا الشرط أن تتقيد السلطات العامة بحالة الضرورة مضموناً ومكاناً وزماناً.

(٦٢) انظر: عكس ذلك، رفض المحكمة العليا الأمريكية طعن أقامته إحدى الكنائس في ولاية كاليفورنيا ضد إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وبصفة خاصة القيود المفروضة على التجمعات العامة. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن القيود المفروضة تبني متسقة مع التعديل "الأول" للدستور الأمريكي الذي يكرس حرية الدين والتجمع السلمي، كما توجد قيود مماثلة، وربما أشد قسوة على التجمعات المدنية المناظرة، بما في ذلك المحاضرات، والحفلات الموسيقية، وعروض الأفلام والعروض الرياضية والمسرحية، حيث تلتقي تجمعات كبيرة من الناس في تقارب لمدد طويلة.

ويعني التقيد بمضمون حالة الضرورة:

أن تتقيد السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لتحقيق المصلحة الأولى بالاعتبار، فإذا قامت السلطات بإجراءات غير لازمة أو غير فعالة في مواجهة تفشي فيروس كورونا أو غير ذات جدوى، كان تلك الإجراءات لغواً وباطلة، ويكون الهدف منها واضحاً وهو العصف بالحريات العامة.

ويرى الباحث أنه يشترط في الإجراءات المتخذة للوقاية من الأضرار الناجمة عن حالة الخطر الذي يهدد النظام العام عدة شروط كي تكون مشروعة :

١ - أن تكون الإجراءات المتخذة ضرورية فعلاً للحفاظ على النظام العام. فمثلاً ثبت عن طريق الدراسات العلمية أنه للحد من انتشار فيروس كورونا يجب تقليل التجمعات وفرض التباعد الاجتماعي في ظل عدم التوصل إلى لقاح، وبالتالي فإن قيام السلطات بتقييد حرية الاجتماعات أو غلق دور العبادة يمثل حالة ضرورة للحفاظ على الصحة العامة. أما إذا كان الإجراء غير ضروري أو يمكن حماية النظام العام بإجراءات أقل تقييداً للحرية فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات تكون غير مشروعة لمخالفتها مبدأ الضرورة^(٦٣).

٢ - أن يكون الهدف من تلك الإجراءات الحفاظ على النظام العام.

٣ - أن لا تتجاوز تلك الإجراءات في تقييدها للحرية ما تقتضيه فعلاً كفاءة النظام العام. فمبدأ الضرورة هنا ليس هو الحالة أو السبب الذي يشكل عنصر الواقعة في اتخاذ الإجراءات الاستثنائية فقط، وإنما يأتي أيضاً كقيود أو ضابط على سلطات الضبط في تحديد مدى لزوم الإجراء الذي تتخذه لحماية النظام العام، فإذا كان الإجراء أو التدبير غير ضروري لحماية النظام العام، أو يمكن حماية النظام العام بإجراءات أقل وطأة على الحريات العامة، فإن هذا الإجراء يكون باطلاً لمخالفته مبدأ الضرورة.

(٦٣) ومن التطبيقات القضائية لذلك ما قضت به محكمة العدل الأوروبية من استبعاد توافر الضرورة في تشريع وطني حاولت السلطات الهولندية تسويغه استناداً إلى اعتبارات الصحة العامة. بيد أن المحكمة خلصت إلى أن هذا الإجراء غير ضروري، لأن السلطات الوطنية الهولندية كان بإمكانها تحقيق ذات الغاية المستهدفة بذات الدرجة من الفعالية، ومن خلال اختيار وسائل أخرى أقل تقييداً. ومن المبادئ المستقرة، في قضاء المحكمة الدستورية الألمانية، أن الإجراء "التشريعي" يكون ضرورياً لبلوغ الغاية المستهدفة "عندما لا يكون ممكناً اختيار إجراء آخر مساوٍ في فعاليته، ولكن أقل تقييداً للحق الأساسي بصورة محسوسة". للمزيد من التفصيل انظر: أ. د. وليد الشناوي: التطورات الحديثة للرقابة على التناسب في القانون الإداري: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد ٥٩، أبريل ٢٠١٦ ص ٣٩٠ وما بعدها.

فمبدأ الضرورة هنا يأتي كضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات العامة من ناحيتين : الضمانة الأولى: تتمثل في أنه يمثل عنصر السبب أو المبرر للتقييد. والضمانة الأخرى: تتمثل في تحديد مدى لزوم أو ضرورة الإجراء الاستثنائي الذي تتخذه سلطة الضبط لحماية النظام العام. ويعني التقييد بحالة الضرورة مكاناً:

أن تكون الإجراءات المتخذة في المكان الصحيح الذي يحقق الهدف من تقييد الحرية، ويحمي المصلحة الأولى بالاعتبار. فمثلاً، لا يجوز للسلطات تقييد حرية المواطنين في التجمع وإقامة الشعائر الدينية في منطقة لا وجود فيها للوباء، بأن كان الوباء غير واصل إليها، أو زال عنها. ويعني التقييد بحالة الضرورة زماناً:

أن تكون إجراءات تقييد الحريات منوطة دائماً بزمان حدوث الجائحة، فإذا انتهت آثارها أو قلت حدتها بما يؤشر على زوالها، فينبغي أن يرتبط ذلك بتخفيف التدابير الاحترازية أو انتهائها طبقاً لمقتضى الحال، فالإجراءات الاستثنائية مؤقتة بطبيعتها. الأساس القانوني لمبدأ الضرورة:

عند الكلام عن القانون في مجمله، فهناك مبادئ عليا حاکمة، لا يمكن التلاعب في وجودها أو معناها؛ لأنها تسمو في مرتبتها على كل قانون ولو كان مكتوباً. تأكيداً وتوطيداً لحقوق الإنسان ولقيمة العدل - الذي تزهو به الأمم - وأطره ومفاهيمه...^(٦٤). ويعتبر مبدأ الضرورة من المبادئ الدستورية العامة^(٦٥)، وهي مبادئ عامة غير مقننة يستنبطها القضاء من المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوني في

(٦٤) حكم محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم ٣٩ لسنة ١٣٠ قضائية، تحكيم الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٦/٢ منشور على شبكة القوانين والأحكام المصرية على الإنترنت.

(٦٥) تجدر الإشارة إلى التفرقة بين ما اصطلح عليه بالمبادئ الحاكمة للدستور أو المبادئ فوق الدستورية، وبين المبادئ الدستورية العامة أو المبادئ العامة للقانون "ذات القيمة الدستورية". فالقول بوجود مبادئ فوق دستورية أو حاكمة للدستور قول يفتقر للدقة؛ لأنه يعني وجود إرادة تعلو إرادة السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور والتي تتمثل في إرادة الشعب، فالشعب هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور، فالشعب هو صانع الدستور، وهو السلطة التي لا تعلوها أي سلطة. ولا توجد إرادة فوق إرادته، وبالتالي لا يمكن تقييد إرادة السلطة التأسيسية الأصلية بأي قيود أو مبادئ، وبالتالي فإن مصطلح المبادئ فوق الدستورية غير دقيق. للمزيد من الإيضاح انظر: أستاذنا الدكتور محمد باهي أبو يونس: أصول القضاء الدستوري: الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٥ ص ٥. =

الدولة، ويقررها في أحكامه باعتبارها قواعد قانونية ملزمة. وعلى هذا الأساس تعتبر هذه المبادئ من عناصر المشروعية، بحيث يتحتم على السلطات العامة الالتزام بها، وتعتبر الأعمال الصادرة عنها بالمخالفة لأحد هذه المبادئ باطلة لخروجها على مبدأ المشروعية^(٦٦).

فالفقه الحديث في مصر بات يسلم بهذه المبادئ ودورها في المجال الدستوري؛ حيث يؤكد أن الواقع العملي يشير إلى أن "القاضي يستعين بهذه المبادئ ليؤول نصوص الدستور إذا تحملت التأويل، أو أنه يعتمد في تطبيقه لهذه المبادئ على

= أما مصطلح المبادئ الدستورية العامة أو المبادئ العامة للقانون "ذات القيمة الدستورية" فهي مبادئ عامة غير مقننة يستنبطها القضاء من المقومات الأساسية للمجتمع، ومن المبادئ المستقر عليها في القانون المقارن، ويضفي عليها صفة العمومية والتجريد، وصفة الإلزام. وتعتبر بذلك أحد مصادر المشروعية ولا يجوز مخالفتها. وقد اختلف الفقه في تحديد القيمة القانونية لهذه المبادئ ما بين منكر لكل قيمة قانونية لها، ويرى أن منح القاضي سلطة استخلاص القاعدة من ضمير "الجماعة" يخرج به عن مهمته، ويكل إليه عملاً تشريعياً لا شك في طبيعته. أ. د. أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، القاهرة، دار النهضة المصرية، ١٩٦٠ ص ٦٠١. ومن هذا الرأي أيضاً د. علي السيد البار في رسالته للدكتوراه: الرقابة على دستورية القوانين في مصر مع المقارنة بالأنظمة الدستورية الأجنبية، كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية ١٩٧٨ ص ٣٩٢ وما بعدها. لكن الرأي الراجح في الفقه والمستقر عليه في القضاء هو الاعتراف بالقيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون مع اختلافهم حول مرتبتها الإلزامية. للمزيد حول الخلاف في المرتبة الإلزامية للمبادئ العامة للقانون: أستاذنا الدكتور، سامي جمال الدين: تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠١٣ ص ١١٣ وما بعدها. والمستقر عليه في القضاء الدستوري المصري والكويتي هو إعطاء عدد من المبادئ العامة للقانون قوة الدستور، بحيث لا يجوز لأي من السلطات العامة الخروج عليها أو مخالفتها، ومن هذه المبادئ مبدأ الضرورة، مبدأ التناسب، مبدأ عدم جواز معاقبة شخص عن فعل واحد مرتين، الحق في اختيار الزوج، الحق في تكوين أسرة، الحق في التنمية، وغيرها من المبادئ ذات القيمة الدستورية. وأخيراً من الفقه المصري الذي يعترف بالقيمة الدستورية للمبادئ العامة للقانون أ. د. عبد الرزاق السنهوري: مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة يناير ١٩٥٢ ص ٥٩ وما بعدها. أ. د. عبد الحميد متولي: مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العامة غير المدونة في الدستور، مجلة الحقوق للبحوث القانونية، السنة ٨ العدد الرابع ١٩٥٩. د. عوض المر: الرقابة على دستورية القوانين.. مرجع سابق ص ٩٢ حيث يقول إن الرقابة على دستورية القوانين لا تنحصر في النصوص التي نص عليها الدستور صراحة، وإنما تندمج فيها كذلك الحقوق التي كفلها ضمناً - لتعلو جميعها على ما سواها - بما يحول دون تدخل المشرع لتحريفها.

صمت الدستور أو عدم وجود نص صريح يعارضها، فيطبق هذه المبادئ باعتبارها أصلاً عاماً أو قاعدة واجبة الاتباع" (٦٧).

فهذه المبادئ مستقرة في الفطرة الإنسانية السليمة، تأبى القيم الإنسانية الخروج على مقتضياتها، أو التجاوز عما تقرره؛ لذلك فهي تعبر عن قيم مستقرة في ضمير الأمم المتحضرة جميعها.

تطبيقات مبدأ الضرورة في القضاء:

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر على مبدأ الضرورة في العديد من أحكامها، واستقر قضاؤها على التزام السلطات العامة بهذا المبدأ، واعتبرته قيداً على المشرع في التشريع، وقيداً على الإدارة في التنفيذ، حيث أعملت المحكمة هذا المبدأ في أخطر مجالات عمل السلطات وهو التشريع وخاصة في مجال الحقوق والحريات العامة، حيث فرضت المحكمة مبدأ الضرورة كأساس لنشأة التجريم أو تقييد الحريات العامة.

فالتجريم، أو التقييد هو انتقاص من حرية الفرد، وتضييق من نطاق ما يتمتع به من حقوق، وهو بطبيعته تلك يفرض على المشرع ألا يجرم سلوكاً، أو يؤثم تصرفاً إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضيه (٦٨).

وأردفت المحكمة وكان لازماً - في مجال دعم هذا الاتجاه وتثبيته - أن تقرر الدساتير المعاصرة القيود التي ارتأتها على سلطان المشرع في مجال التجريم تعبيراً عن إيمانها بأن حقوق الإنسان وحياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تملئها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، واعترافاً منها بأن الحرية في أبعادها الكاملة لا تنفصل عن حرمة الحياة، وأن الحقائق المريرة التي عايشتها البشرية على امتداد مراحل تطورها تفرض نظاماً متكاملاً يكفل للجماعة مصالحها الحيوية، ويصون - في إطار

(٦٦) انظر في تعريف المبادئ العامة للقانون وأساسها القانوني وقوتها القانونية: أ. د. سامي جمال الدين: تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مرجع سابق ص ٩٩. وانظر أيضاً في تعريفها: أ. د. سمير تناغو: النظرية العامة للقانون، الإسكندرية، منشأة المعارف ١٩٩٩ ص ٢٤٦ وما بعدها.

(٦٧) د. محمد ماهر أبو العينين: الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته. ١٩٨٧ ص ٤٣١ وما بعدها.

(٦٨) أ. د. محمد باهي أبو يونس: الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص ٩٤، ٩٥.

أهدافه - حقوق الفرد وحياته الأساسية بما يحول دون إساءة استخدام العقوبة تشويهاً لأغراضها،..^(٦٩).

والعجيب - وفي تطور مذهل لقضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر - أنها لم تقصر العقوبة التي يحددها مبدأ الضرورة على العقوبات الجنائية كالحبس والغرامة، وإنما اعتبرت أن مجرد الحرمان من الحقوق والحريات العامة بصفة مؤقتة عقوبة، فقررت المحكمة أنه: "وإذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة (١٩) من الإعلان الدستوري المشار إليه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. (تقابلها نص المادة ٩٥ من الدستور الحالي) فقد دل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، هادفاً بذلك تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص، مع مراعاة أن نطاق نص المادة (١٩) من الإعلان الدستوري لا يقتصر على العقوبة الجنائية، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التي تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفي أن يكون وقائياً، وهي جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي^(٧٠).

وهكذا فالمحكمة الدستورية قررت هنا - وبحق - أن العقوبة لا تقتصر على العقوبات الجنائية، وإنما يشمل كذلك العقوبات الأخرى التي تأخذ حكمها، وإن لم تكن من جنسها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها، إذ ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفي أن يكون وقائياً؛ وهي جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي.

وهي أيضاً ترتبط بمبدأ مهم وهو مبدأ ضرورة التجريم أو التقيد الذي يعني عدم تقيد الحرية إلا في حالة الضرورة القصوى.

وفي قضاء مجلس الدولة المصري، رسخت هذا المبدأ محكمة القضاء الإداري في بواكير أحكامها حيث قررت "ويتبين من ذلك ومن تقصي الأعمال التحضيرية للدستور أن سلطة الحكومة هي قيد استثنائي وارد على أصل حق يعد أحد الحريات

(٦٩) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٩٢ في القضية رقم ١٠٥ لسنة ١٢ قضائية "دستورية" الموسوعة الدستورية. مرجع سابق. المجلد الثاني. ص ٥٢٢.

(٧٠) حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٧ لسنة ٣٤ قضائية دستورية جلسة ٢٠١٢/٦/١٤، والحكم منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثاني، السنة الثامنة والخمسون، أبريل - يونيو ٢٠١٤، العدد ٢٣٠. ص ١٠٤ وما بعدها.

العامة، فيجب - والحال هذه - أن يفهم القيد المذكور في أضيق حدوده ، فلا تستعمله الحكومة إلا للضرورة القصوى، وذلك عندما تقوم لديها أسباب حقيقية لها سند من الواقع..."^(٧١).

فمبدأ الضرورة لم يعد أساساً للتجريم فقط، وإنما يعد الأساس لأي إجراءات تقيد الحقوق والحريات العامة، فأي إجراءات تقيد الحريات تقوم بها سلطات الضبط في كافة الظروف ينبغي أن تكون ضرورية ولازمة لحماية مصلحة عامة أولى بالرعاية؛ لأن الأصل هو الحرية، والتقييد هو استثناء. فمبدأ الضرورة هو أحد الأدوات التي تؤدي إلى تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وكفالة الحقوق والحريات العامة.

خضوع قيام حالة الضرورة لرقابة وتقدير القضاء:

بصفة عامة، يخضع قيام حالة الضرورة التي تبرر اتخاذ تدابير استثنائية لتقييد الحقوق والحريات العامة، لتقدير القضاء، فتقدير وجود حالة الضرورة، وتوافر شروطها ومبرراتها، وشرعية التدابير المتخذة على أساسها، يخضع حتماً لرقابة القضاء، هذا هو المستقر عليه قضاء في مصر والكويت^(٧٢).

ففي مصر، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ بتعديل بعض أحكام قوانين الأسرة، وذلك لتخلف سند إصداره، وهو عدم قيام حالة الضرورة التي تبرر لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير - في غيبة مجلس الشعب - طبقاً لنص المادة ١٤٧ من دستور ١٩٧١ التي تنص على أنه: "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة

(٧١) حكم محكمة القضاء الإداري في ١٩٥١/٧/٣١ في القضية رقم ١٣٢٠ لسنة ٥ ق، والحكم منشور في كتاب "دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة" الجزء الأول. للمستشار الدكتور: فاروق عبد البر، ص ٣٣٧.

(٧٢) فالقضاء في إطار رقابته على ركن السبب في القرار الإداري يقوم بالتحقق من صحة الوقائع التي تدخلت الإدارة على أساسها، ويقوم أيضاً بالرقابة على التكييف القانوني للوقائع بفرض ثبوتها، ذلك أن أية وقائع لا تبرر تدخل الإدارة، بل يجب أن يتحقق في شأن هذه الوقائع، الصفات القانونية التي يستلزمها المشرع صراحة أو ضمناً، ومن غير المعقول أن يترك هذا التكييف لحرية الإدارة المطلقة. وأخيراً يقوم القضاء بالرقابة على تقدير الخطورة المحتمل تولدها عن الوقائع الثابت حدوثها. للمزيد من التفصيل والتطبيقات القضائية العديدة في كل من مصر وفرنسا انظر: أ. د. سليمان الطماوي، مرجع سابق ص ١٠٥ وما بعدها.

القانون". ورفضت المحكمة ما أثارته الحكومة من أن تقدير الضرورة الداعية لإصدار القرارات بقوانين عملاً بنص المادة ١٤٧ من الدستور متروك لرئيس الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب، باعتبار أن ذلك من عناصر السياسة التشريعية التي لا تمتد إليها يد الرقابة الدستورية^(٧٣).

وفي الكويت، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٢ بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبتعديل بعض أحكام القانون (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات مجلس الأمة لعدم توافر حالة الضرورة. وبعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية لانتفاء حالة الضرورة، وبدستورية المرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٢ في شأن حماية الوحدة الوطنية، وبدستورية المرسوم بقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٨ المعدل للقانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة^(٧٤).

وهكذا، نجد أن القضاء في مصر والكويت يُخضع توافر قيام حالة الضرورة، وشروطها، والإجراءات المتخذة بناء عليها لرقابته، ولاشك أن في ذلك ضمانات كبيرة للحقوق والحريات العامة.

المطلب الثالث

مبدأ التناسب

من المبادئ الدستورية الهامة التي ينبغي على السلطات العامة أن تراعيها وأن تلتزم بها عند اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مبدأ التناسب، وهو مبدأ مكمل ومتمم للمبدأ السابق، حيث يجب عليها أن تكون الإجراءات والتدابير ضرورية ومتناسبة مع حالة الخطر، فأى إجراء أو تدبير يخل بمبدأ التناسب سيكون مخالفاً للدستور والقانون.

وقد أشارت إلى أهمية مراعاة مبدأ التناسب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق

(٧٣) المحكمة الدستورية العليا: جلسة ١٩٨٥/٥/٤ القضية رقم ٢٨ لسنة ٢ قضائية دستورية، الموسوعة الشاملة لأحكام المحكمة الدستورية، المجلد الأول، ص ١١٧.

(٧٤) د. يحيى محمد مرسى النمر: التطبيقات الحديثة لنظرية الخطأ البين في التقدير في القضاء الدستوري ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة. "دراسة مقارنة" بحث منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس ٩-١٠ مايو ٢٠١٨ ص ١٨٦.

الإنسان ميشيل باشليه حيث أكدت على أن "الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون متناسبة وغير تمييزية ومحددة "زمنياً"، وأن تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة". وأكدت "من الواضح أن إطلاق النار على شخص خرق حظر التجول بحثاً عن طعام أو إيداعه السجن وممارسة العنف بحقه غير مقبول وغير مشروع"، دون أن تذكر اسم البلد الذي حصل فيه ذلك^(٧٥).

هذا، وقد قررت السلطات إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وقررت عقوبات على مخالفة تلك الإجراءات، فمثلاً مخالفة قرار حظر التجول، مخالفة حظر التجمعات، فتح النوادي والمقاهي وغيرها، كل هذه الأمور يترتب عليها عقوبات تختلف من بلد لآخر. فمصر مثلاً قررت معاقبة من يخالف قرارات حظر التجول بعقوبة الحبس وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فينبغي أن تتقيد الإجراءات والعقوبات بمبدأ التناسب، كما ينبغي أن تكون القيود المفروضة على الحريات العامة متناسبة مع حالة الخطر.

وعليه سنتناول تعريف مفهوم مبدأ التناسب ، وصوره، وتطبيقاته القضائية.

أولاً - مفهوم التناسب :

١ - مفهوم التناسب لغة :

تَنَاسَبَ : يَتَنَاسَبُ تَنَاسَبًا الشَّيْئَانِ : تَشَابَهَا^(٧٦).

والنسبة تعني الصلة أو الرابطة، وفي علم الرياضيات تعني نتيجة مقارنة إحدى كميتين من نوع واحد بالأخرى، وتناسب الشئان أي تشاكلاً، والتناسب قد يعني التشابه^(٧٧).

ولفظ التناسب في اللغة الفرنسية La proportionnalite يعني في اللغة الفرنسية علاقة أو صلة تامة بين شيء وآخر، أو علاقة بين الأجزاء بعضها بعضاً، وبينها وبين الكل، ومفهوم هذه العلاقة هي أنها علاقة مناسبة^(٧٨).

(٧٥) تصريحها المنشور على موقع فرانس ٢٤ والمنشور في ٢٧/٤/٢٠٢٠.

(٧٦) القاموس المدرسي: تأليف الجيلاني بن الحاج يحيى، بلحسن البليش، علي بن هادية، الشركة التونسية للتوزيع - المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب ١٩٤٨ ص ١٣٤.

(٧٧) قاموس المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم بمصر ١٩٩٩، ص ٦١٢.

(٧٨) أ.د. جورج شفيق زيدان: رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري: دراسة تحليلية مقارنة في بعض الأنظمة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد ٦٦ أغسطس ٢٠١٨ ص ٥.

٢ - والتناسب اصطلاحاً:

التناسب في الاصطلاح القانوني بوجه عام، هو تعبير عن الصلة التوافقية بين حالة معينة وأخرى مناظرة لها، نتيجتها توازن مقبول ومعقول بينهما، فالتناسب يقوم أساساً على وجود علاقة منطقية بين شيئين، ويعبر عنها بالتماثل أو التكافؤ، وهو لن يكون إلا نسبياً حين يتعلق الأمر بإقامة علاقة مقارنة بين قيم مختلفة، وبهذه المثابة فإن التناسب يكتسي مفهوماً حيوياً مزدوجاً، الأول: يعود إلى معادلة رياضية، كعنصر في علم لا يحلل سوى القيم المجردة، والثاني: يقترب من أفكار العقل والمنطق مستندعياً تصوراً أخلاقياً ذا طابع فلسفي^(٧٩).

والتناسب فكرة يسهل فهمها، وإن صعب تعريفها، وهو تعبير عن علاقة تربط بين أمرين أو أكثر، وتتسم هذه العلاقة بالمنطقية أو التوافق أو المعقولية، وغير ذلك من الصفات التي تطلق على العلاقات المعتادة، أو التي يفترض أن تكون عليها، وتحتل فكرة التناسب مكانة هامة في مختلف فروع القانون وفي الشريعة الإسلامية كذلك^(٨٠).

ومقتضى التناسب ألا تغلو السلطة المعنية بتحديد الجزاء في اختياره، ولا تتركب متن الشطط في تقديره، وإنما عليها أن تتخير من العقوبات ما يكون على وجه اللزوم ضرورياً لمواجهة الخرق القانوني أو المخالفة الإدارية، وما يترتب على اقترافها من آثار، وما فيه القدر الذي يكفي لردع المخالف، وزجر غيره من أعضاء المجتمع ممن تسول له نفسه أن يقوم بذات فعله، أو يأتي نفس صنيعه. ومن هنا تكون ضوابط الجزاء أو العقاب موضوعية، ويعتبر بالتالي كل تجاوز لهذه الضوابط تزيدها، واستبداداً ينبغي رفضه^(٨١).

ومبدأ التناسب على هذا له وجهان :

الوجه الأول: هو ألا تكون العقوبة أو الجزاء المقرر على المخالفة مفرطاً إلى حد الشطط الذي تتأذى منه العدالة.

(٧٩) د. خليفة سالم الجهمي: ملامح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة " رقابة التناسب " بحث منشور على موقع المحكمة العليا الليبية ص ٦.

(٨٠) أ. د. سامي جمال الدين: القانون الدستوري والشرعية الدستورية وفقاً لدستور ٢٠١٤ الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٩ ص ٢١٠.

(٨١) أ. د. محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات القسم العام. الإسكندرية. منشأة المعارف ٢٠١٠ ص ٤٥٤.

الوجه الثاني: وهو ألا تكون العقوبة أو الجزاء المقرر واهياً لا يحقق ردعاً للمخالفين، ولا تتحقق به أهداف العقاب.

فالمشرع حين يقوم باختيار الجزاء عليه أن يقيم الموازين القسط بين أمور عدة: قدر خطورة المخالفة على المصالح الاجتماعية أو الفردية، ومدى ما حققه المخالف من منفعة نتيجة اقترافها، ومقدار ما يناله الجزاء في ضوء ذلك من حق أو حرية أساسية. وعلى قدر وصوله لنقطة التوازن بينهم بقدر توفيقه في الوصول إلى التناسب الذي يسيغه العقل أي الذي يكون معه الجزاء قاسياً على نحو يمثل معه عدوياً بغير مقتضى على حرية أو حق أساسي، ولا يعتبر واهياً فيكون مدعاة لإغراء السفهاء على هدر مصالح جديرة بالرعاية^(٨٢).

ويعد مبدأ التناسب تجسيداً حقيقياً لفكرة العدالة، فعندما يسود هذا المبدأ في كافة الأعمال القانونية التي تقوم بها السلطات العامة يتحقق الشعور بالعدالة والرضا من كافة المخاطبين بالقانون.

ويشكل التناسب أحد المبادئ العامة للقانون (ذات القيمة الدستورية) التي تجسد أفكار العدالة والإنصاف والمعقولية - كما يعكس ضرورة توافر الملاءمة في الإجراءات التي تتبناها الدولة - والتي تنطوي في الغالب على تقييد للحقوق والحريات المكفولة دستورياً - بغرض تحقيق هدف مشروع. ويجد هذا المبدأ تكريساً صريحاً له، ليس فقط في الوثائق القانونية للاتحاد الأوروبي، ولكن في العديد من الدساتير الوطنية. ويتسع نطاق تطبيق هذا المبدأ، بحيث لم يعد يقتصر على التطبيق في حالة تقييد ممارسة أو حريات معينة، ولكن في سياق ممارسة الدولة لسلطاتها بصورة عامة^(٨٣).

ثانياً - صور التناسب :

مبدأ التناسب من المبادئ الدستورية العامة الذي له صدى في فروع القانون كافة، لذلك نجد هذا المبدأ في نطاق القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون المدني. كما أن هذا المبدأ من المبادئ المستقر عليها في الأمم المتحدة، حيث "يجد مبدأ التناسب تكريساً له، صريحاً أو ضمناً، سواء في الآليات القانونية الدولية أو في العديد من دساتير الدول الديمقراطية، ففي رومانيا على سبيل المثال، ينص الدستور صراحة على مبدأ التناسب في المادة (٥٣)، كما توجد العديد

(٨٢) أ. د. محمد باهي أبو يونس: الرقابة على شرعية الجزاءات الإدارية، مرجع سابق ص ١١٥.

(٨٣) أ. د. وليد الشناوي: التطورات الحديثة للرقابة على التناسب في القانون الإداري: مرجع سابق ص ٤١٥.

من النصوص الأخرى التي تشير إلى هذا المبدأ ضمناً. ويشير العديد من الكتاب إلى أن مبدأ التناسب أضحى يشكل أحد المبادئ العامة للقانون العام في معظم الدول الأوروبية^(٨٤).

ويترتب على القيمة الدستورية لمبدأ التناسب التزام كافة السلطات العامة به في كافة ما تباشره من اختصاصات، فتلتزم به السلطة التشريعية فيما تصدره من تشريعات، وتلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقرارات فردية، وتلتزم بتطبيقه السلطة القضائية فيما تصدره من أحكام.

ثالثاً - التطبيقات القضائية لمبدأ التناسب :

الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها؛ وكان الدستور يعهد إلى أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين، فإن القواعد القانونية التي تصدر عن أيتهما في هذا النطاق، لا يجوز أن تنال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، وإلا كان عدواناً على مجالاتها الحيوية من خلال إهدارها أو تهميمها^(٨٥).

وإذا كان المشرع يتمتع بسلطة تقديرية في موضوع تنظيم الحقوق والحريات العامة، إلا أن ممارسته لهذه السلطة ليس مطلقاً؛ وإنما مقيد بنصوص الدستور والمبادئ الدستورية العامة التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة الديمقراطية. ومن هذه المبادئ مبدأ التناسب الذي يعد ضماناً حقيقية للحقوق والحريات العامة خاصة في الظروف الاستثنائية. وقد تواتر القضاء في كل من مصر والكويت على تطبيق هذا المبدأ باعتباره قيداً على المشرع والإدارة، وكضمانة ضد تعسف السلطات ضد حقوق المواطن وحرياته، وفيما نعرض لبعض التطبيقات القضائية لمبدأ التناسب :

(٨٤) للمزيد من التفصيل انظر: أ. د. وليد الشناوي: التطورات الحديثة للرقابة على التناسب في القانون الإداري: المرجع السابق ص ٤١٥ وما بعدها.

(٨٥) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ١٩٩٧/٩/١ في القضية رقم ١٤٤ لسنة ١٨ ق. د، الموسوعة الشاملة لأحكام المحكمة... مرجع سابق المجلد الثالث ص ١٢٥٥. وقد وضع الدستور المصري القائم في المادة ٩٢ قيداً عاماً على سلطة المشرع التقديرية عند تنظيمه للحقوق والحريات بنصه "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيد بها يمس أصلها أو جوهرها".

أولاً - في القضاء الدستوري :

في مصر :

تبسط المحكمة الدستورية العليا في مصر رقابتها على عنصر التناسب في التشريع، باعتبار تلك الرقابة من صور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، وربطت المحكمة بين مبدأ التناسب وبعض المبادئ الدستورية الأخرى مثل مبدأ الضرورة، ومبدأ العدالة والإنصاف، ومبدأ شخصية العقوبة، وأحياناً تعبر المحكمة عنه بمبدأ المعقولة، ومن أحكامها :

١ - تقول المحكمة إن: "الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأياً بها عن أن تكون إيلاًماً غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة" (٨٦).

٢ - قررت المحكمة "أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة مرتبطان بمن يكون مسؤولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التي قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقاً لخياراته بشأنها. متى كان ذلك، وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلاً في إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية؛ فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها؛ مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها إلا عملاً مجرداً يعزلها عن بيئتها دالاً على قسوتها أو مجازاتها حد الاعتدال، جامداً، فجاً، منافياً لقيم الحق والعدل" (٨٧).

وواضح من عبارات هذا الحكم أن المحكمة ربطت بين مبدأ التناسب وبين قيم الحق والعدل، بحيث جعلت وجوده محققاً لها، وتخلفه إهداراً لها.

ولأهمية مبدأ التناسب كأداة لتحقيق العدالة فقد جعلته المحكمة الدستورية العليا أساساً لشرعية أي جزاء سواء أكان جزاءً جنائياً أم تأديبياً أم مدنياً، فمبدأ التناسب - وفق تصوير المحكمة - هو الضمانة لشرعية الجزاءات المختلفة بحيث يؤدي تخلفه إلى فقدان أساس وجودها وشرعيتها، فقد قررت المحكمة :

"وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرعية الجزاء، جنائياً كان أو

(٨٦) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ١٢/٢/١٩٩٥ في القضية رقم ٢٨ لسنة ١٧ ق. د، الموسوعة الشاملة لأحكام المحكمة... مرجع سابق المجلد الثاني ص ٨٢٣.

(٨٧) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٨/١١/٢٠١٤ في القضية رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق. د، أحكام المحكمة الدستورية في تسع سنوات مرجع سابق ص ١٠٨ وما بعدها.

مدنياً، أو تأديبياً، مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أئتمها المشرع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها...." (٨٨).

– ففي المجال الجنائي ذكرت المحكمة :

"وفي هذا الإطار لا يجوز أن يكون الجزاء الجنائي بغيضاً أو عاتياً، وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً، أو تعذيبياً، أو قمعياً، أو متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها، وكذلك إذا كان مجافياً – بصورة ظاهرة – للحدود التي يكون معها متناسباً مع الأفعال التي أئتمها المشرع، بما يصادم الوعي أو التقدير الخلفي لأوساط الناس في شأن ما ينبغي أن يكون حقاً أو عدلاً على ضوء مختلف الظروف ذات الصلة، لئتمحض الجزاء عندئذ عن إهدار للمعايير التي التزامتها الأمم المتحدة في معاملتها للإنسان، ولقد كان هذا الاعتبار ملحوظاً في الوثائق القديمة لإعلان الحقوق، فالقاعدة التي تضمنتها "الماجنا كارتا" في هذا الشأن حاصلها أن الرجل الحر لا تفرض عليه من الجرائم التافهة، إلا غرامة تناسبها، فإذا كان ما أتاها يعد من الجرائم الخطيرة، تعين أن تناسبها عقوبتها، ولكن لا يجوز أن تصل قسوتها إلى حد الحرمان من الحياة" (٨٩).

وواضح من هذا الحكم أن المعيار الذي اعتمدته المحكمة لتحديد التناسب هو المعيار الموضوعي، وليس الشخصي.

بل إن المحكمة قررت في صورة أوضح أن الجزاء الجنائي الذي لا يكون متناسباً مع خطورة الأفعال التي أئتمها المشرع يفقد مبررات وجوده، ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافاً، فقد قررت المحكمة :

"وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرعية الجزاء، جنائياً كان أم مدنياً أم تأديبياً، مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أئتمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، وأن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائي بغيضاً أو عاتياً، أو كان متصلاً بأفعال لا يجوز تجريمها، أو مجافياً بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها متناسباً مع خطورة الأفعال التي أئتمها المشرع، فإنه يفقد مبررات وجوده، ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافاً" (٩٠).

(٨٨) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٥ ديسمبر ٢٠١٥ في القضية ١٧٣ لسنة ٢٩ قضائية "دستورية" مجموعة أحكام المحكمة في تسع سنوات... مرجع سابق ص ١٨٩.

(٨٩) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ١٩٩٦/٢/٣ في القضية رقم ٣٣ لسنة ١٦ ق.د، أحكام المحكمة الدستورية الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، المجلد الثاني ص ٨٥٠ وما بعدها.

(٩٠) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢ يونيو ٢٠٠١. القضية رقم ١١٤ لسنة ٢١ قضائية "دستورية" الموسوعة الشاملة، المرجع السابق، المجلد الرابع، ص ١٨٣٠.

إذن، لم يعد المشرع حراً في تقدير العقاب على الجرائم، وإنما مقيد في هذا التقدير بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب، فقد انتهى العهد الذي كانت فيه العقوبة أداة المستبدين في القهر والطغيان، فإذا تجاوزت العقوبة قدر التناسب مع الجريمة فقدت شرعيتها القانونية، هذا ما قرره واستقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بحيث يمكن القول إن هذا المبدأ - وغيره من المبادئ الأخرى - المتعلقة بالتجريم والعقاب أصبحت من المبادئ الدستورية العامة حتى ولو لم يتم النص عليها مباشرة في الدستور^(٩١).

- وفي المجال المدني :

في مجال المسؤولية المدنية قررت المحكمة أنه "فيما خلا الأحوال التي يكون التعويض فيها مقراً بناءً على تدخل من المشرع، فإن الأصل في التعويض أن يكون مقداره متكافئاً مع الضرر، جابراً لمداه دون زيادة أو نقصان، وهو ما يعني تناسباً بينهما لا يجوز أن يختل"^(٩٢).

- وفي المجال التأديبي :

قررت المحكمة أنه "ويتعين دوماً أن يكون تقدير الجهة الإدارية لجزاءاتها

(٩١) انظر في تعريف مبدأ التناسب والمعايير التي يقوم عليها: أ. د. أمين مصطفى محمد: علم الجزاء الجنائي. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. ٢٠٠٨. ص ٧٨ وما بعدها. وانظر في تحديد الأساس التاريخي لمبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة: أستاذنا الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيغي، حق الدولة في العقاب: نشأته وفلسفته - اقتضاؤه وانقضاؤه. دون ذكر ناشر ٢٠١٠. ص ٤٦ وما بعدها. وانظر في بيان مدلول مبدأ التناسب وصوره في قضاء المحكمة الدستورية العليا: الدكتور جابر محمد حجي. السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق، جامعة القاهرة. ٢٠١١ ص ٤٢٤ وما بعدها، حيث عدد الباحث أربع صور لهذا المبدأ في قضاء المحكمة الدستورية العليا وهي: ١- مصادرة الحرية أو الانتقاص منها. ٢- الخطأ الظاهر أو البين في التقدير. ٣- عدم الترابط المنطقي بين أغراض التشريع ووسائله. ٤- الضرورة تقدر بقدرها. وانظر أيضاً: أستاذنا الدكتور سليمان عبد المنعم: النظرية العامة لقانون العقوبات. نظرية المجرم. الإسكندرية. منشأة المعارف ٢٠١٩ ص ١٠٩. حيث يقول سيادته: "مبدأ التناسب هو إرضاء لحاسة العدالة إذ يصير الجزاء الجنائي عادلاً بحق حين يحقق التماثل أو التعادل بين الشر الذي أصاب المجتمع من جراء وقوع الجريمة وبين الشر الذي تقرر إنزاله بالجاني لقاء جرمه. وانظر أيضاً في بيان الأساس القانوني للرقابة القضائية على التناسب في التشريع: أ. د. يسري محمد العصار: رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع. مجلة الدستورية. العدد الثامن عشر. السنة الثامنة أكتوبر ٢٠١٠ ص ١٧.

(٩٢) الحكم السابق.

متوازناً، قائماً على أسبابها بكل أخطارها، مبرراً بما يعد حقاً وعدلاً، فلا يكون شططها حائلاً دون أداء العاملين لواجباتهم، ولا ليناً أو هوناً مؤدياً إلى استهانتهم بها، بل يكون مجرداً عن الميل، دائراً حول الملاءمة الظاهرة بين خطورة الفعل المعتبر ذنباً إدارياً، وبين نوع الجزاء ومقداره، وإلا كان تقديرها انحرافاً بالسلطة التأديبية عن أهدافها. وعلى ضوء هذه المبادئ ذاتها، تتحدد دستورية النصوص القانونية التي يسنها المشرع في المجال التأديبي" (٩٣).

وفي الكويت :

أكدت المحكمة الدستورية الكويتية على أهمية مراعاة المشرع الجنائي لمبدأ التناسب في العقاب باعتباره مرتبطاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فقررت "وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة (٣٠) من الدستور على أن: "الحرية الشخصية مكفولة" وفي المادة (٣٢) منه على أن: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" وفي المادة ٣٣ منه على أن: "العقوبة شخصية" يدل - حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة الذي يخول المشرع بموجب سلطته التقديرية - التي يمارسها وفقاً للدستور - الحق في إنشاء الجرائم وتحديد العقوبات التي تناسبها..." (٩٤).

ويتضح هنا أيضاً أنَّ المحكمة الدستورية الكويتية ربطت بين مبدأ التناسب ومبدأ شرعية الجريمة والعقوبة وشخصيتها.

ثانياً - في القضاء الإداري :

في مصر :

مارس القضاء الإداري في مصر رقابته على التناسب بين المخالفة والجزاء - خاصة في مجال التأديب - تحت مسمى رقابة الغلو في تقدير الجزاء، وبسط رقابته على قرارات الإدارة مبتغياً تحقيق العدالة نحو تحقيق التوازن أو التعادل بين الذنب الإداري وما يتم توقيعه من جزاء، حيث تقول المحكمة الإدارية العليا: "إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان تقدير الجزاء التأديبي متروكاً إلى حد بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب، إلا أن السلطة التقديرية تجد حدها في قيد عدم جواز

(٩٣) الحكم السابق.

(٩٤) حكم المحكمة الدستورية الكويتية في ٢٠٠٩/٦/٧ في القضية رقم ١ لسنة ٢٠٠٩ دستورية.

إساءة استعمال السلطة والتي يعبر عنها بالغلو في تقدير الجزاء، والتناسب بين خطورة الذنب الإداري وما يتم توقيعه من جزاء على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة، وفي ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها، فإذا ما شاب الجزاء غلو معين كان لسلطة الرقابة على ذلك الجزاء أن تلغيه وتنزل الجزاء على النحو المشروع^(٩٥). ومن أحكامها الحديثة في هذا الصدد، حكمها الصادر في شهر في يونيو ٢٠٢٠ حيث قررت المحكمة أن: "الغلو في الجزاء يبطله"^(٩٦).

وفي الكويت:

مارس القضاء الكويتي حقه في الرقابة على ملازمة العقوبة - في مجال التأيب - مع المخالفة المرتكبة، باسطاً رقابته على مبدأ التناسب، ومن الأحكام التي أصدرها القضاء الكويتي في هذا الشأن ما قضت به محكمة الاستئناف العليا من "أن مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة هو أحد مبادئ أربعة يقوم عليها الجزاء التأديبي وهي شرعية الجزاء، أي يجب أن يكون من الجزاءات المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون، وعدم تعدد الجزاء الواحد، وعدم رجعية الجزاء أي لا يترتب أثره إلا من تاريخ توقيعه، ثم مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة، وموداه أن يكون الجزاء متناسباً مع المخالفة المرتكبة على أنه إذا كان للسلطة التأديبية سلطة تقدير خطورة الخطأ الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، فإن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور الغلو عدم الملازمة الظاهرة بين درجة خطورة المخالفة وبين نوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، فيخضع بهذه المناسبة لرقابة المحكمة لما فيه من خطأ في تطبيق القانون..^(٩٧).

وفي حكم آخر قضت محكمة التمييز الكويتية بأنه: "لئن كانت جهة التأيب

(٩٥) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٨٢٠٧ لسنة ٤٩ ق. عليا جلسة ٢٠٠٤/٧/٣.

(٩٦) حيث قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة الإسكندرية بفصل معيدة بقسم الكيمياء بكلية العلوم لعدم تناسبه مع الذنب الإداري الذي ارتكبه الطاعنة، واستبداله بعقوبة أخرى مناسبة وهي الخصم من المرتب مدة ثلاثين يوماً. المصدر: جريدة اليوم السابع في ٢٠٢٠/٧/٤.

(٩٧) محكمة الاستئناف العليا قضية رقم ٢٤٩ / ١٩٧٢ جلسة ١٩٧٤/٦/٢٤ مشار إليه لدى الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي في بحث بعنوان: الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، مجلة الحقوق - جامعة الكويت المجلد ٦، العدد ٣ سبتمبر ١٩٨٢ ص ٩٩، ١٠٠.

سلطة تقدير الذنب الإداري، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى - ألا يشوب استعمالها غلو، والذي من صورته عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، وتقدير الجزاء المشوب بالغلو يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية..^(٩٨).

وهو ما أكدته أحكام الدائرة الإدارية الأولى أيضاً، فقضت بأنه: "ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره"^(٩٩).

ثالثاً - تطبيق مبدأ التناسب في مجال إجراءات الضبط الإداري في ظل جائحة كورونا:

تعريف الضبط الإداري :

الضبط الإداري هو مجموعة الإجراءات والقواعد التي تفرضها السلطة الإدارية المختصة على الأفراد لتنظم بها نشاطهم وتحدد مجالاته ولتقيّد حرياتهم في حدود القانون، بقصد حماية النظام العام ووقاية المجتمع ضد كل ما يهدده. وتتخذ هذه القواعد شكل قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة من جانبها وحدها، أو تتخذ صورة أوامر وإجراءات فردية، مادية أو قانونية، تقوم بها الإدارة بإرادتها المنفردة. وتشترك هذه القواعد والإجراءات جميعاً في كونها تُقيّد الحريات. على أن تقيّد الحريات لا يكون عن طريق الضبط الإداري فقط؛ لأن الحريات جميعاً تخضع لتنظيم المشرع. ولذلك لا يكون التنظيم الضبطي مقصوراً على الضبط الإداري، بل يتعداه إلى الضبط التشريعي الذي يتكون من القوانين التي يصدرها المشرع لتنظيم الحقوق والحريات العامة للأفراد. وهذه القوانين هي الأساس الذي يقرر الأنظمة المختلفة للحريات الفردية، والذي تلتزم بها وتعمل في إطارها سلطات الضبط الإداري^(١٠٠).

وفي مجال مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بظهور فيروس كورونا المستجد الذي أدى ظهوره إلى قيام سلطات الضبط باتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية

(٩٨) محكمة التمييز - الأحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم: ٢٠٧ لسنة ١٩٨٨ قضائية جلسة ١٩٨٩/٢/٥، مشار إليه لدى الدكتور وليد الشناوي: التطورات الحديثة للرقابة على مبدأ التناسب.. مرجع سابق ص ٥٩٧ هامش ١.

(٩٩) حكم محكمة التمييز، الدائرة الإدارية، الطعن رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ قضائية بتاريخ ١٣/١٢/١٩٨٦. (١٠٠) أ.د. ثروت بدوي: القانون الإداري، الجزء الأول، القاهرة، دار النهضة العربية ٢٠٠٦، ص ٣٧٠.

بهدف الحفاظ على الصحة العامة، فإن تطبيق مبدأ التناسب يشكل ضماناً فعالة للحفاظ على النظام العام في أحد أكثر عناصره أهمية وهي الصحة العامة، ويشكل أيضاً ضماناً لحماية الحقوق والحريات.

فمن ناحية الحفاظ على الحق في الصحة :

فإن أعمال مبدأ التناسب يلزم جهات الضبط سواء الضبط التشريعي أو الإداري باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الصحة العامة، فعلى سبيل المثال أدى ظهور جائحة كورونا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره مثل فرض حظر التجول، ارتداء الكمامة، فرض التباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات الوقائية الضرورية للحفاظ على الحق في الحياة والصحة العامة. وقد اقترن وجود هذه الإجراءات بوجود جزء على من يخالفها، فإذا كان هذا الجزء واهياً أو واهناً لا يحقق الردع فإنه يصبح غير متناسب مع أهمية المصالح العليا للمجتمع وعلى رأسها الحق في الحياة والصحة.

وتطبيقاً لهذا الجانب من مبدأ التناسب فقد وافق مجلس الأمة الكويتي في ٢٤/٣/٢٠٢٠ على مشروع قانون بتعديل المادة ١٧ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بتغليظ العقوبات على مخالفة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا - لتحقيق الردع - حيث أشارت المادة الأولى من مشروع القانون إلى "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكانت العقوبة قبل التعديل لا تزيد على الحبس لمدة شهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقب مشروع القانون "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من تغليظ العقوبات هو احتواء القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، مضيفاً: "كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له" (١٠١).

(١٠١) انظر: جريدة القبس الإلكتروني بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠.

وهذا يعني أن تساهل سلطات الضبط في اتخاذ الإجراءات المناسبة على قدر خطورة الظروف الاستثنائية يوصم قرارها بعدم المشروعية لمخالفتها مبدأ التناسب. فإذا كان الإجراء غير كافٍ لمواجهة حالة الضرورة كان باطلاً.

ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد، في عام ٢٠١٠، اعتبرت إحدى المحاكم الإدارية الفرنسية، في قضية *L, Assistance publique Hôpitaux de Paris* أن الجزء الذي فرضته الإدارة غير مشروع، لأنه ليس قاسياً بدرجة كافية. وفي هذه القضية، كان أحد مساعدي الرعاية الطبية للأطفال - والذي ما زال تحت التجربة - قد عُوقب بالوقوف عن العمل لمدة شهرين بسبب الخطأ في الدواء المعطى إلى أحد الأطفال مما أدى إلى وفاة الطفل، وقد اعتبرت المستشفى أن الجزء الذي وقعته اللجنة التأديبية غير كاف. وقد انتهى مجلس الدولة الفرنسي إلى أنه: "بالنظر إلى خطورة الأخطاء التي ارتكبت بواسطة الأنسة (L) والنتائج التي يمكن أن تترتب على هذه الوقائع على نهوض المستشفى بمهام المرفق العام فإن اللجنة التأديبية تكون قد قوضت تقديرها للوقائع نتيجة ارتكابها "لخطأ ظاهر في التقدير"، وذلك لعدم اختيارها الجزء الأكثر قسوة، أي فصل الأنسة (L)^(١٠٢).

ومن ناحية أخرى :

يفرض تطبيق مبدأ التناسب على سلطات الضبط عدة قيود فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتها بحفظ النظام العام، وهذه القيود هي :

- ١ - أن تكون الإجراءات ضرورية لحفظ النظام العام.
 - ٢ - أن تتم مباشرة تلك الإجراءات لتحقيق هدف مشروع.
 - ٣ - أن تكون الإجراءات ملائمة لبلوغ الهدف المشروع.
 - ٤ - ألا توجد وسائل أخرى أخف في تقييد الحق أو الحرية بإمكانها تحقيق الهدف المشروع.
 - ٥ - وفي مواجهة الظروف الاستثنائية لا يجوز للإدارة أن تستخدم سوى الوسائل والإجراءات الضرورية والمناسبة لمجابهة هذه الظروف.
- ويمارس القضاء رقابته على أعمال سلطات الضبط الإداري ليقوم بوزنها بميزان المشروعية، فإذا تجاوزت سلطات الضبط حدودها فيما يتعلق بحفظ النظام العام بأن كانت الإجراءات التي اتخذتها غير ضرورية، أو كانت لتحقيق أهداف غير مشروعة، أو

(١٠٢) مشار إليه لدى د. وليد الشناوي مرجع سابق ص ٥٣٤-٥٣٥.

كانت الإجراءات غير متناسبة مع الظروف الاستثنائية أو متجاوزة حد المعقولة، أو كان بإمكان السلطات اتخاذ إجراءات أخف في تقييد الحريات، وتحقيق الهدف المشروع، ففي هذه الحالات يقضي القضاء بعدم مشروعيتها، لمخالفتها لمبدأ التناسب.

ومن التطبيقات الحديثة لمبدأ التناسب ما قرره مجلس الدولة الفرنسي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية من فرض حظر شامل على حرية العبادة حيث ألغى المجلس تلك القرارات؛ لأن الحظر العام والمطلق غير متناسب مع الهدف المتمثل في الحفاظ على الصحة العامة؛ لذلك أمر مجلس الدولة الحكومة الفرنسية بإعادة فتح دور العبادة، ورفع الحظر الشامل عن التجمعات المفروض على خلفية فيروس كورونا المستجد، مطالباً بالالتزام بالتجمع في مجموعات صغيرة، وجاء في حيثيات قرار المجلس أن: "حظر الحكومة ينتهك بشكل خطير وواضح حرية العبادة ... وقرر أن الحظر العام والمطلق غير متناسب مع الهدف المتمثل في الحفاظ على الصحة العامة .. لذا يجب اتخاذ إجراءات أقل صرامة" (١٠٣).

وفي ذات السياق وفي ٢٠٢٠/٥/٦ قررت المحكمة الدستورية الرومانية عدم دستورية الغرامات المفروضة على مخالفي إجراءات الإغلاق التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بسبب إفراطها (عدم تناسبها) وغموض النص التشريعي الذي تستند إليه.

إذاً، مبدأ التناسب أضحى من المبادئ الدستورية العامة المستقر عليها في الأمم المتحدة، وهو "من الأحكام الأساسية في الفكر الإنساني، الفلسفي والسياسي والقانوني، ومن دون التناسب والتوازن لن تكون هناك إمكانية لاستمرار الحياة المشتركة التي يتقاسمها البشر، ولن تكون هناك إمكانية لاستمرارية الدولة كتنظيم سياسي واجتماعي وقانوني، واستمرار هيئاتها وأجهزتها وسلطاتها" (١٠٤).

واعتبرته المحكمة الدستورية الألمانية بأنه: "مبدأ شامل مرشد لكامل نشاط الدولة" (١٠٥).

الخاتمة :

تناول هذا البحث تعريف الجائحة، والإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول للسيطرة على انتشارها، وتأثير تلك الإجراءات والتدابير على الحريات العامة،

(١٠٣) جريدة الشروق المصرية في ٢٠٢٠/٥/١٩.

(١٠٤) أ. د. جورج شفيق زيدان: رقابة التناسب... مرجع سابق ص ١٧٣-١٧٤.

(١٠٥) أ. د. وليد الشناوي: التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب.. مرجع سابق، ص ٤٦٣.

وخاصة حرية التنقل، وحرية الاجتماع، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وعرض الباحث لأهمية الحريات العامة وقيمتها الدستورية، ثم بيّن الباحث كيف أدت تلك الإجراءات إلى حرمان المواطنين من ممارسة تلك الحريات.

وبيّن الباحث الضوابط الدستورية الواجب على السلطات العامة الالتزام بها عند التصدي لمواجهة الفيروس، وضرورة أن تتقيد السلطات العامة بمبدأ الضرورة، ومبدأ التناسب، ذلك أن حقوق وحريات المواطنين لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة قصوى. وبيّن شروط حالة الضرورة، وأساسها القانوني، وتطبيقاتها القضائية. والتكيف القانوني لجائحة كورونا.

وأوضح أيضاً ضرورة التزام السلطات العامة بمبدأ التناسب الذي يوجب أن تكون العقوبات المقررة متناسبة مع المخالفات والجرائم المرتكبة دون إفراط في العقاب أو تفريط في حق الردع حماية للمجتمع. وينتهي الباحث إلى التوصيات الآتية :

- ١ - يدعو الباحث المشرع والسلطات العامة ألا تتخذ الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد تكأة للعصف بالحقوق والحريات العامة.
- ٢ - على المشرع أن يتقيد بالدستور والقانون، والمبادئ الدستورية العامة، حتى في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ذلك أن أي ظروف استثنائية مهما بلغت شدتها أو قوتها ينبغي ألا تستغلها السلطات في الإفلات من ضوابط الدستور ومبادئه العامة، التي هي صمام الأمان ضد الاستبداد، وتعسف السلطات.
- ٣ - يدعو الباحث السلطات إلى التقيد بمبدأي الضرورة والتناسب عند الشروع في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وألا تتعداهما لكي لا تقع تصرفاتها في حومة مخالفة الدستور.
- ٤ - يدعو الباحث المتخصصين من أهل اللغة إلى البحث وتأصيل المصطلح اللغوي السليم المعبر عن دلالة انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل دعوة البعض إلى أن مصطلح الجائحة لا يعبر بدقة عن الأمراض التي تصيب الإنسان، وأن هذا المصطلح استخدم في غير محله.

المراجع

- أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، القاهرة، دار النهضة المصرية، ١٩٦٠.
- إسماعيل إبراهيم البدوي: الحريات العامة والحقوق الفردية في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة. الإسكندرية. مكتبة الوفاء القانونية ٢٠١٦.
- إسماعيل جابوربي: نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري. مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع عشر، جانفي ٢٠١٦.
- أمين مصطفى محمد: علم الجزاء الجنائي. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٨.
- بلحاج مونير: الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة وهران ٢٠١٢.
- ثروت بدوي: القانون الإداري، الجزء الأول، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢٠٠٦.
- جابر محمد حجي: السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق، جامعة القاهرة. ٢٠١١.
- جان ثابت: "وباء كورونا والقوة القاهرة: تعليق على قرار محكمة استئناف COLMAR" مجلة "محكمة" بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٠.
- جورجى شفيق زيدان: رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري: دراسة تحليلية مقارنة في بعض الأنظمة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد ٦٦ أغسطس ٢٠١٨.
- حسن أحمد علي: ضمانات الحريات العامة وتطورها في النظم السياسية المعاصرة. رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، دون تاريخ.
- حسين بن سالم الذهب، بحث بعنوان "نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي"، منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية العدد ٨، أكتوبر ٢٠١١.
- خليفة سالم الجهمي: ملامح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة "رقابة التناسب" بحث منشور على موقع المحكمة العليا الليبية.
- رجائي حسين الشتيوي: آثار كورونا كوفيد -١٩ على الالتزامات التعاقدية.

- مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، عدد خاص بجائحة كورونا صيف ٢٠٢٠.
- سامي جمال الدين : تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ٢٠١٣.
- : القانون الدستوري والشرعية الدستورية وفقاً لدستور ٢٠١٤، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٩.
- : القضاء الإداري : الكتاب الأول، الرقابة على أعمال الإدارة - مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٢ دون ذكر لناشر.
- سحر عبد الستار إمام: جائحة كورونا وتداعياتها على المنظومة القضائية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، عدد خاص بجائحة كورونا صيف ٢٠٢٠.
- سعد عصفور: حرية الاجتماع في إنجلترا وفرنسا ومصر. مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة، يناير ١٩٥٢.
- سليمان عبد المنعم : النظرية العامة لقانون العقوبات. نظرية المجرم. الإسكندرية. منشأة المعارف ٢٠١٩.
- سليمان الطماوي: السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة الرابعة، العدد ١-٢، يناير - يونيو ١٩٥٠.
- سمير تناغو: النظرية العامة للقانون، الإسكندرية، منشأة المعارف ١٩٩٩.
- شفيق إمام: مقال بعنوان "ما قل ودل : حق الاجتماع وحق الاقتراع العام في مأزق قضائي" مقال منشور في جريدة الجريدة الكويتية بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩.
- شرقي صالح الدين : حماية الحريات العامة للأفراد في ظل تطبيق الظروف الاستثنائية. مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد ١٤، ٢٠١٦.
- عادل الطببائي: الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، مجلة الحقوق، المجلد ٦، العدد ٣، سبتمبر ١٩٨٢.
- عبد الحميد متولي: مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العامة غير المدونة في الدستور، مجلة الحقوق للبحوث القانونية، السنة ٨ العدد الرابع ١٩٥٩.
- عبد الرزاق السنهوري: مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية/ مجلة مجلس الدولة يناير ١٩٥٢.

- عبد المغيث الحاكمي، بحث بعنوان " دور القانون والقضاء في الحد من تأثير فيروس كورونا على العلاقات التعاقدية"، مجلة الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا، كوفيد ١٩ العدد ١٧، أبريل ٢٠٢٠.
- عبد الفتاح مصطفى الصيفي: حق الدولة في العقاب. نشأته وفلسفته - اقتضاؤه وانقضاؤه. دون ذكر ناشر.
- عبد الله الصيفي، بحث بعنوان "الجوائح عند المالكية"، منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية جامعة آل البيت، المجلد الثالث، العدد الثاني ٢٠٠٧.
- د. علي السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر مع المقارنة بالأنظمة الدستورية الأجنبية، رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية ١٩٧٨.
- عمرو أحمد حسبو، حرية الاجتماع، القاهرة، دار النهضة العربية ١٩٩٩.
- غانم النجار: مقال بعنوان "لماذا نستخدم مصطلح الجائحة؟" بجريدة الجريدة الكويتية بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٠.
- غازي عبيد مرضي العياش: الحدود الدستورية لحق الأفراد في الاجتماع. بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية. السنة الرابعة. العدد ١٣ مارس ٢٠١٦.
- فاروق عبد البر: دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، الجزء الأول، ١٩٨٨.
- ماجد الحلو: الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية ٢٠٠٠.
- محمد باهي أبو يونس: التقييد القانوني لحرية الصحافة "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه، كلية الحقوق الإسكندرية ١٩٩٤.
- _____: الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة.
- _____: محمد باهي أبو يونس: أصول القضاء الدستوري: الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ٢٠١٥.
- محمد عبد الجليل المر: حق تكوين الجمعيات الأهلية. الضوابط الدستورية

- (للنشأة - لممارسة النشاط - للانقضاء) دراسة تحليلية مقارنة. رسالة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية ٢٠٢٠.
- محمد عبد الوهاب خفاجي : تشريعات الصحة الوقائية ووعي الأمة المصرية عبر تاريخها في مواجهة الأوبئة تحيين من فيروس كورونا وتأمين صحة المواطنين، بحث منشور على الإنترنت.
- محمد زكي أبو عامر : قانون العقوبات القسم العام، الإسكندرية، منشأة المعارف ٢٠١٠.
- محمد صلاح عبد البديع: الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ٢٠٠٩.
- محمد علي حسونة : الضبط الإداري وأثره في الحريات العامة، مجلة مصر المعاصرة، المجلد ١٠٤، العدد ٥٠٦، أبريل ٢٠١٢.
- محمد ماهر أبو العينين : الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ١٩٨٧.
- محمود عبد الله العكازي : قواعد الفقه الكلية، الإسكندرية، دار الفتح للطباعة والتوزيع ٢٠١٤.
- مجدي المتولي السيد يوسف: أثر الظروف الاستثنائية على مبدأ الشرعية "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس ١٩٩٠.
- محمود المغربي، بلال صنيدي : التكيف القانوني للجائحة "الكرونية" على ضوء الثوابت الدستورية والمبادئ القانونية المستقرة بين صلابة المسلمات ومرونة الاعتبارات : دراسة مقارنة. مجلة القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - ملحق خاص - العدد ٦ يونيو ٢٠٢٠.
- مديحة الفحلة: نظرية الظروف الاستثنائية بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام والتزام حماية الحقوق والحريات الأساسية. مجلة المفكر، العدد ١٤، جانفي ٢٠١٧.
- مصطفى أبو زيد فهمي: الدستور المصري، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر ٢٠١٢.
- نواف ناصر الرشيدى : ضمانات حقوق وحريات الأفراد في ظل إجراءات الضبط الإداري في الكويت، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ٢٠١٧.
- وليد محمد رضا السيد مصطفى الشناوي : التطورات الحديثة للرقابة القضائية

- على التناسب في القانون الإداري : دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد ٥٩، أبريل ٢٠١٦.
- المستشار ياقوت ع شماوي : قضايا دستورية، القاهرة، دار المعارف، دون تاريخ.
 - يسري محمد العصار: رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع، مجلة الدستورية، العدد الثامن عشر، السنة الثامنة، أكتوبر ٢٠١٠.
 - يحيى محمد مرسي النمر : التطبيقات الحديثة لنظرية الخطأ البين في التقدير في القضاء الدستوري، ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة. "دراسة مقارنة" بحث منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس ٩- ١٠ مايو ٢٠١٨.
 - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا في تسع سنوات من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٧، الناشر دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ٢٠١٨.
 - الموسوعة الشاملة لأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها وحتى ٢٠٠٩، إعداد عبد الله حسن، إصدار نقابة المحامين المصرية ٢٠١٠، ٦ مجلدات.
 - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، الجزء الثامن.
 - المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً في الفترة من (١/١٠/١٩٧٢ - ٣١/١٢/٢٠١١) المجلد الإداري.

The Impact of the Corona Pandemic on Public Freedoms. A Comparative Study Between Egypt and Kuwait

Dr. Mohammed Abdul Jalil Al-Murr

Since the Corona pandemic affected the world at the end of 2019, and only changed the face of the world, that pandemic affected all aspects of life, and affected countries large and small, advanced and backward, democratic or dictatorial. Rather, its impact did not extend only to countries, but to peoples and ordinary individuals, and affected their lives, livelihoods, rights and freedoms.

Within the framework of its constitutional duty to preserve the health of its citizens, many countries have taken precautionary measures and measures to counter the spread of this pandemic, and these measures have resulted in restricting public rights and freedoms such as freedom of movement, freedom of assembly, freedom to practice religious rites, and many other freedoms.

Many concerned with human rights and international organizations feared that governments would use this pandemic to impose more restrictions on public freedoms and undermine human rights.

Therefore, this research was an attempt to explain the general constitutional controls and principles that the authorities must adhere to when carrying out their constitutional duties to preserve the public health of their citizens, and to ensure that this exceptional circumstance is not exploited in adding more restrictions on public freedoms, while presenting modern applications of constitutional justice in Some developed countries (Germany - France - USA) to indicate the constitutionality of precautionary measures and measures by the authorities to confront the pandemic.

Keywords: pandemic - constitution - constitutional restrictions - precautionary measures - public authorities.

آليات مواجهة خطر إفلاس الشركات في زمن جائحة كورونا وجهود التشريعات الوطنية

الدكتور/ محمد صلاح عبد اللاه محمد
دكتوراه في القانون التجاري والبحري
كلية الحقوق - جامعة القاهرة

ملخص:

إن العالم قد يتعرض في وقتنا الحالي لجائحة عالمية، لا يقتصر نطاق تأثيرها على البشر فقط، بل يمتد إلى الشركات، ويؤثر عليها تأثير عظيم، لاسيما في الوفاء بالتزاماتها؛ نتيجة وقف حركة التبادل التجاري بين الدول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الشركات نفسها، مما قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تعرض الشركة لخطر الإفلاس، وإغلاقها، وتسريح ما بها من موظفين، مما قد يؤثر على الاقتصاد الوطني بالنسبة للدول التي تتبعها تلك الشركات، مما حفز فينا أن نبحث في آليات مواجهة خطر الإفلاس، وقد استرشدنا في ذلك بتطبيقات عملية لإجراءات اتخذتها دول أوروبية وآسيوية وعربية لتجنب إفلاس الشركات التي تقع داخل قطرها، وقد كان لتلك الإجراءات عظيم الأثر في بقاء كيان تلك الشركات على الوجود.

مقدمة:

تعد جائحة فيروس (COVID-19)^(١)، أكبر تحد يواجهه العالم منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، ونتيجة لذلك فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة (Guterres António) في الأول من أبريل ٢٠٢٠، من أنه بسبب تلك الجائحة قد نخسر الملايين من الأرواح البشرية^(٢)، ونتيجة لذلك قد فرضت العديد من حكومات الدول على مستوى العالم مجموعة من القيود على الحركة البشرية، وممارسة الأنشطة التجارية، وسيكون بالتأكيد

(١) يشير هذا المصطلح إلى مرض (فيروس كورونا ٢٠١٩)، وقد تم تسميته كذلك بالفيروس الذي يسببه وهذا الفيروس هو (SARSCoV-2)، ويطلق عليه أيضاً اسم (الفيروس التاجي).

(٢) Gert-Jan Boon, Markus Konrad Brunnermeier, Horst G. M. Eidenmueller, Luca and Gurrea- Enriques, Aurelio Mart?nez, Kathryn Judge, Jean-Pierre Landau, Marco Pagano, Ricardo A.M.R. Reis, Kristin, The Covid-19 Pandemic and Business Law: A Series of Posts from the Oxford Business Law Blog (April 11, 2020). Oxford Legal Studies Research Paper Forthcoming, p2, Available at (SSRN: <https://ssrn.com/abstract=>), (20/4/2020).

لتلك القيود تأثير مباشر على عدم قدرة الشركات التجارية على ممارسة أنشطتها التجارية كالمعتاد^(٣).

هذا وإنه لم يلاحظ وجود جائحة عالمية مثل جائحة فيروس (COVID-19)، منذ ظهور الإنفلونزا الإسبانية عام ١٩١٨، ومن المؤكد أنه سوف ينتج عن تلك الجائحة أزمة عالمية، وسوف يكون لها تأثير قوي على العقود التجارية، والاقتصاد في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تؤدي إلى الشلل الواسع في الأسواق العالمية، وسيؤدي دون شك، بدفع مجموعة واسعة من الشركات الكبيرة في العالم إلى السقوط من (حافة الهاوية)؛ بسبب الضرر الذي قد يحدث نتيجة، عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التجارية، وعدم سدادها لديونها، وعدم عرضها للخدمات التي كانت تقدمها^(٤)، وانخفاض لمعدل الإنتاج بشكل كبير، وكذلك عدم وجود خطط لاستمرارية الأعمال أو خطط لمواجهة الطوارئ والأزمات لدى معظم الشركات، والضعف الذي قد يحدث في تدفق السيولة النقدية بشكل كبير، لذلك فقد تتفاجأ العديد من الشركات التجارية في جميع أنحاء العالم بنتائج غير مسبوقة عما كانت عليه في الماضي، وفي السياق ذاته، قد لا يظهر الدائنون الذين تأثروا بشكل خطير بالجائحة تساهلاً تجاه المدينين، حيث قد يصبح عليهم التزامات للوفاء بها أيضاً، مما قد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات على مستوى العالم، وهذا يعد بمثابة نهاية ووفاء للشركات التجارية، والذي قد ينتج على إثره إغلاق للشركات، وكذلك فصل لجميع العاملين بالشركة، وكذا بيع أصول الشركات في صورة خردة^(٥).

ونتيجة لما تقدم، فإن القائمين على سن الأنظمة القانونية على مستوى العالم كانوا تحت ضغط شديد للتعامل مع تلك الظروف الحالية، حيث قد تم فسخ العديد من

(٣) Emily Davis, John Alderton, Regulatory requirements for UK Insolvency Practitioners during COVID-19, April 9, 2020, Available at (<https://www.restructuring-globalview.com/2020/04/qa-regulatory-requirements-for-uk-insolvency-practitioners-during-covid-19/>), (15/4/2020).

(٤) Ehud (Udi) Arzi, Ran Feldman, Dorit Hamberg, Noa Lavian, Eden Weiss, The impact on contracts of possible insolvency due to the corona crisis, April 7 2020, Available at (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=992bf6d7-8067-4497-a44c-c5ff6eb82cc3>), (15/4/2020).

(٥) Shameek Jankee, Bhomitrajeet Sandeep Ramlochund, Sivakumaren Robin Mardemootoo, Mauritius: Insolvency Issues with respect to COVID-19, 9 April 2020, Available at (<https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/april/9/mauritius-insolvency-issues-with-respect-to-covid-19>) , (15/4/2020).

العقود التجارية، والمحاكم في حالة شلل تام، والشركات قد أوشكت على الإفلاس، كما أن سن القوانين الطارئة لمواجهة تلك الظروف يعد الأداة الوحيدة القوية لاحتواء آثار جائحة فيروس (COVID-19) على حياتنا، والحد من تداعياته الاقتصادية، ولتحقيق هذا الهدف، قد تحتاج القوانين المصممة للتطبيق في الأوقات العادية إلى إعادة تكييفها مرة أخرى للتكيف مع وضع الأزمات الحالي، على الأقل حتى بصفة مؤقتة، ولذلك فإنه ابتداءً من أوائل فبراير ٢٠٢٠، كان هناك اتجاه لدى أغلبية دول العالم لتعديل القوانين الخاصة بالشركات التجارية؛ وذلك للمساهمة في احتواء تأثيرات تلك الجائحة، ومن الناحية الموضوعية، كان ينصب تركيز التعديل على التمويل المالي للشركات المعرضة للانحيار، وقوانين الإفلاس، وذلك لأن المشكلة الأكثر خطورة والتي تواجهها الشركات في الوقت الحالي تتمثل في نقص التدفق النقدي، والذي من الممكن أن يورث على جميع الشركات^(٦)، ولذلك كانت العديد من الدول، بما في ذلك أستراليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وسنغافورة، قد اقترحت أو نفذت تغييرات مؤقتة في أطر قوانين الإفلاس الخاص بها، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف، وتتمثل تلك التعديلات على النحو التالي^(٧):

- ١ - حماية المستهلكين من عدم توافر المنافسة المشروعة للشركات، وكذلك حماية الموظفين من احتمال فقدان وظائفهم نتيجة لإغلاق الشركات، أو إعادة هيكلة الموظفين التي قد تحدث في الأشهر المقبلة.
- ٢ - الحفاظ على الوضع الاقتصادي للدولة، من خلال حماية الشركات من الخسائر الاقتصادية نتيجة انخفاض السيولة، التي قد يسببها انخفاض المبيعات بسبب الجائحة والتدابير المتخذة لوقفه، لذلك فقد يرغب المشرعون في تجنب انهيار الشركات التي لها دور كبير في جذب العملات الأجنبية من الخارج، فتقوم بتهدئة

(٦) Richard Squire, U.S. Airlines don't need A bailout to stay in Business, March 23, 2020, Available at (<https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/22/us-airlines-dont-need-bailout-stay-business/>), (10/4/2020).

(٧) Aurelio Gurrea-Martínez, Insolvency Law in Times of COVID-19 (March 27, 2020), Ibero-American Institute for Law and Finance, Working Paper 2/2020, p3, Available at (SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3562685>), (10/4/2020), Shreya Prakash, Evaluating Some Strategies for Preventing Insolvency Proceedings in the Wake of the COVID-19 Crisis, 21 Apr 2020, Available at (<https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/04/evaluating-some-strategies-preventing-insolvency-proceedings-wake>), (26/4/2020).

- رجال الأعمال (خاصة أولئك الذين يديرون شركات صغيرة)، والذين تأثرت أعمالهم بسبب عمليات الإغلاق للشركات، وأنهم لن يوضعوا في موضع إفلاس.
- ٣ - قد يكون هناك قلق من أن المحاكم التجارية التي تختص بنظر قضايا الإفلاس قد لا تكون قادرة على الفصل في عدد كبير من قضايا الإفلاس المعروضة عليها والتي يمكن أن تبدأ بكثرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسببها جائحة (COVID-19)؛ بسبب ضخامة كميتها، وكذلك بسبب تعطيل العمل بالمحاكم في تلك الآونة.
- ٤ - عندما تكون إجراءات الإفلاس أكثر ملاءمة لبيع أصول الشركات بدلاً من إعادة هيكلة ديونها، قد يكون هناك قلق من أنه قد لا يوجد هناك ما يكفي من المشتري لأصول الشركات التي تخضع لإجراءات الإفلاس، وهذا يعني أنه في كثير من الحالات، سيتم بيع أصول الشركات بسعر رخيص جداً في حالة الإفلاس. ولكل ما تقدم، فإننا سوف نتناول هذا الفصل في المباحث الآتية:
- المبحث الأول: آليات الوقاية من إفلاس الشركات الناتج عن جائحة (COVID-19).
- المبحث الثاني: الآليات الوطنية للوقاية من إفلاس الشركات في ظل جائحة (COVID-19).

المبحث الأول

آليات الوقاية من إفلاس الشركات الناتج عن جائحة (COVID-19)

مقدمة:

تركت جائحة فيروس (COVID-19) أغلب الشركات على مستوى العالم في المياه الساخنة، حيث قد يتأخر الكثيرون منهم عن سداد الديون المستحقة، وكذلك عدم تنفيذ الالتزامات التجارية؛ ولذلك تدرس الإدارات القانونية بالشركات، وكذلك مجالس إدارتها الحفاظ على أعمال الشركات في مأمن من الإفلاس، وكذلك التخفيف من المشاكل المالية التي قد تسببها الجائحة لشركاتهم، نتيجة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الإلزامي، والعزل الذاتي، والتشتيت الاجتماعي، فتلك كلها استراتيجيات تستخدمها العديد من الدول في جميع أنحاء العالم لقمع انتشار جائحة فيروس (COVID-19)، وكحماية للصحة العامة وإنقاذ للأرواح^(٨).

ويمثل هذا الوضع الطبيعي الجديد تحديات للشركات التجارية، فقد تضطر أغلب الشركات تقريباً إلى مواجهة الضغط الذي تفرضه وزارات القوى العاملة، فقد تفرض على الشركات عمل الموظفين بالكامل من المنزل، وكذلك منح إجازة مرضية لعدد كبير من الموظفين، في حين قد لا يمكن لبعض الأشخاص العمل من المنزل في قطاعات معينة مثل قطاع الأعمال التجارية الزراعية، مما يؤثر على الإنتاج، وبذلك فإن القوة العاملة المنخفضة داخل الشركات تعني انخفاض الإنتاج، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ضعف في السيولة النقدية، ومن الممكن أن يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات^(٩).

ونظراً لما تقدم، سنتناول الآليات الجوهرية للوقاية من الإفلاس على النحو التالي:

أولاً - إعادة هيكلة الالتزامات بالتراضي^(١٠):

لما كانت جميع الشركات (من جميع الأحجام) في جميع القطاعات الاقتصادية قد تشعر بآثار جائحة (COVID-19)، وقبل ذلك كانت تلك الجائحة لا يمكن التنبؤ بها

(٨) Christina McKeon Frutuoso, Avoiding insolvency, and worse, in the covid-19 crisis, 07 April 2020, Available at (<https://latinlawyer.com/article/1225215/avoiding-insolvency-and-worse-in-the-covid-19-crisis>), (15/4/2020)

(٩) Christina McKeon Frutuoso, Avoiding insolvency, and worse, in the covid-19 crisis, 07 April 2020, available at (<https://latinlawyer.com/article/1225215/avoiding-insolvency-and-worse-in-the-covid-19-crisis>), (14/4/2020).

(١٠) Esteban Ortiz-Mena, Noboa Velasco, Pa?l, Propuestas Societarias y Concursales para Mitigar el Impacto Econ?mico del COVID-19 en Ecuador (Corporate

ولا بنتائجها التي قد لا تحصى، لذا فكان من الضروري التفكير في الآليات التي من خلال تطبيقها ستظل الشركات التجارية قابلة للعودة للحياة مرة أخرى دون تعرضها لخطر الإفلاس، وبالتالي يمكن التقليل من تأثير هذا الوباء على الاقتصاد، وعلى رأس تلك الآليات إعادة هيكلة التزاماتها بالتراضي.

هذا وإن إعادة الهيكلة تعني: تعديل هام يتم إجراؤه على ديون أو صفقات أو هيكل الشركة من خلال موافقة أغلب الدائنين.

هذا وتعد إعادة الهيكلة نهجاً غير رسمي للتعامل مع التزامات الشركة، ينطوي على اتصال مفتوح وصريح مع الدائنين، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية التي يمر بها العالم، نعتقد أن العديد من الدائنين سيكونون منفتحين على مثل هذه المناقشات بدلاً من عملية إعادة الهيكلة الرسمية من خلال المحاكم، حيث قد تقل احتمالية حصولهم على أموال على الإطلاق، ولذلك فإنه يعد من المهم جداً إبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع الدائنين، وخاصة الموردين الرئيسيين والدائنين المؤسسين مثل البنوك، والسلطات المحلية لإرجاء بعض المدفوعات، فبعد إعادة الهيكلة يصبح سداد الديون أكثر قابلية للتنفيذ، مما يجعل إجراءات الإفلاس أقل احتمالاً.

ومن خلال تطبيق إعادة الهيكلة تستطيع الشركات مراجعة العقود الرئيسية مع كل من عملائها، ومورديها، فقد تتضمن هذه المراجعة أفضل طريقة لحماية الشركة فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية القائمة، وتلك التي تخضع للتفاوض، ولذا سيكون من المهم أن تكلف الشركة (الإدارة القانونية) لإبداء وجهة نظرها حول ما احتوت عليه تلك العقود الرئيسية من شروط، وما إذا كان يمكن التفاوض عليها مع (الأطراف

- = and Insolvency Proposals to Mitigate the Economic Impact of COVID-19 in Ecuador) (April 4, 2020), p1-2, Available at (SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3568267> or), (10/4/2020), Aiden Murphy, Declan Hanly, COVID-19: Restructuring and insolvency solutions for your business, 07/04/2020, Available at (<https://www.crowe.com/ie/insights/covid-19-restructuring-and-insolvency-solutions-for-your-business>), (20/4/2020), Aurelio Gurrea-Martínez, Insolvency Law in Times of COVID-19 (March 27, 2020). Ibero-American Institute for Law and Finance, Working Paper 2/2020, p 4-5, Available at SSRN: (<https://ssrn.com/abstract=3562685>), (1/4/2020), Christina McKeon Frutuoso, Avoiding insolvency, and worse, in the covid-19 crisis, 07 April 2020, available at (<https://latinlawyer.com/article/1225215/avoiding-insolvency-and-worse-in-the-covid-19-crisis>), (19/4/2020).

المتعاقد) لتخفيف الضغوط على الشركة، وسيكون في تلك الحالة لمهارات التفاوض التي قد لا تقدر بثمن، عامل كبير وجوهري في إعادة الهيكلة، وقد يحاولون إعادة التفاوض على الأخص مع الدائنين والمقرضين لشركاتهم، وسيكون من الحكمة أن تبذل الإدارة القانونية قصارى جهدها - في الوقت الحالي - من أجل التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء، لاسيما وأن الدائنين يصبحون على استعداد تام لقبول ما يمكنهم الحصول عليه من سيولة نقدية، حيث في ظل أزمة (الفيروس التاجي)، من المرجح أن تجد الكثير من الشركات نفسها في ديون عميقة، وقد يكون الدائنون مستعدين لتعديل المبلغ الواجب استحقاقه بالكامل، ومن المحتمل أن يتم التفاوض على مبلغ أقل يدفع للدائنين المستحقين، وبالتالي ستصبح هناك فرصة جيدة للتسوية مع الدائنين، فقد حدث ذلك عقب توقف الاقتصاد في عام ٢٠٠٨، وكانت الأموال قليلة؛ وذلك من أجل الحفاظ على شركاتهم التي تواجه صعوبات في سداد مديوناتها في إطار محاولة إعادة التفاوض على تعديل الشروط التعاقدية، وبالتالي يمكن تجنب خطر إفلاس الشركات.

ويثار التساؤل حول عمّا إذا كان في مرحلة إعادة التفاوض على عقود العملاء والموردين الرئيسية، فهل يمكن في تلك المرحلة الاحتجاج بظرف القوة القاهرة أو شروط انقطاع العمل، فنجد أن جميع الدائنين بمن في ذلك العملاء أو الموردون سيتأثرون بتدابير الإغلاق الإجباري للشركات التجارية، كما هو الحال مع المقرضين منهم، ولذا فيعد من المهم أن تجرى إعادة التفاوض في شكل حوار منتظم بحيث يمكن الاتفاق على الاختلافات المتبادلة للشروط الحالية أثناء فترة الإغلاق، وبالتالي سيكون الحفاظ على العلاقات مع الأطراف المقابلة أمراً بالغ الأهمية في حالة إعادة بدء العمل بنجاح، وكذلك يسهل استعادة نشاط الشركة التجاري بمجرد رفع القيود، هذا وقد تحتوي بعض العقود على شرط (القوة القاهرة) الذي سيسمح للطرف المدين بإنهاء العقد عند وقوع حدث مثل الجائحة العالمية، حتى وإذا كان العقد لا يحتوي على شرط قوة القاهرة، فقد يظل من حق الطرف المدين إنهاء العقد في الظروف التي لا يمكن تنفيذ العقد فيها، هذا وقد يؤدي فسخ العقد إلى نشوب نزاع، وربما اللجوء إلى القضاء، والقضاء بفسخ العقد وإنهاء العلاقة مع الدائنين، لكن الحفاظ على علاقات الشركة يجب أن يكون الشاغل الرئيسي للشركة في ظل تلك الجائحة.

هذا وأنه في حالة تعدد الدائنين، يجب أن تتم الموافقة على إعادة الهيكلة من قبل ٥١٪ من الدائنين فقط، ليصبح الاتفاق بشأن إعادة الهيكلة ملزماً لجميع الدائنين، بمن فيهم المعارضون لإعادة الهيكلة.

هذا ويعد أفضل وقت لإعادة الهيكلة، في الوقت الحالي؛ حيث تكون فيه المحاكم

التجارية معطلة مؤقتاً، وهذا هو الوضع الحالي في معظم الدول في جميع أنحاء العالم، فسيكون لدى الشركات التي تواجه صعوبات في سداد ديونها بعض الوقت لإعادة هيكلة التزاماتها بالتراضي، لاسيما وأن معظم الدائنين ليسوا في وضع يسمح لهم بالحصول بسهولة على أوامر قضائية لبدء إجراءات الإفلاس ضد المدينين لهم.

هذا وقد ينتج عن إعادة التفاوض، تمديد أو تخفيض شروط الائتمان، أو التوصل إلى خطط لسداد الديون، أو حتى التخفيضات المطبقة على الديون التي حل ميعاد سدادها، والسماح بإجراء بعض المدفوعات من التدفقات النقدية المتاحة لدى الشركة، أو قد يتم كذلك تعزيز الشروط الرئيسية طبقاً للوضع الحالي.

وينبغي أن يكون لعمليات إعادة الهيكلة ثلاث مراحل متباعدة، مرحلة البدء في إعادة الهيكلة من خلال دعوة الدائنين للتفاوض على أساس خطة لإعادة الهيكلة، ومرحلة التفاوض، وتنفيذ الاتفاق.

ويثار التساؤل حول مدى حجية ما تم الاتفاق عليه، فنجد أنه يجب صياغة إعادة الهيكلة التي تسمح بصيانة وإنقاذ الشركات من الناحية التشغيلية، من خلال اتفاق مكتوب يتم التوقيع عليه من جميع الأطراف المتفاوضة، بحيث يكون له طابع وقوة التنفيذ في حالة نشوب خلاف فيما بعد بين تلك الأطراف، فيعد حجة عليهم جميعاً. ويظهر الغرض من وجوب كتابة ما يتم التوصل إليه من اتفاق في إعادة التفاوض في الأمور الآتية:

- ١ - إعادة تنظيم العلاقات القائمة بين الشركة والدائنين لها.
 - ٢ - تسهيل إثبات انقضاء الالتزامات التي تم الاتفاق على إلغائها في أثناء إعادة الهيكلة.
 - ٣ - إعادة العلاقات التجارية والائتمانية للشركة من خلال إعادة هيكلة الديون.
 - ٤ - الحفاظ على بقاء الشركة دون تعرضها لخطر الإفلاس.
- وتمتاز عملية إعادة الهيكلة، بأنها في الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب للدائنين لإعادة الهيكلة وأثناء فترة التفاوض، سيتم تلقائياً منح الحماية للشركات المدينة من عدم اتخاذ إجراءات الإفلاس قبل تلك الشركات، وينبغي أن تستمر تلك الحماية حتى نهاية مرحلة التفاوض، وتتمثل الحماية من الإفلاس بشكل أساسي في ما يلي:
- أ - عدم جواز الشروع في أي من الإجراءات الإدارية أو القضائية أو التحكيمية ضد الشركات المدينة، فكل ذلك يتم تعليقه تلقائياً.
 - ب - عدم جواز حل الشركة أو تصفيتها أو إلغائها.
 - ج - يجب تعليق مدفوعات الشركات عن أي ديون قبل تاريخ الطلب لإعادة الهيكلة،

باستثناء المدفوعات التي تعتبر ضرورية للتشغيل العادي للشركة الدائنة، وتعد مبررة حسب التوقعات المقدمة من قبلها أثناء إعادة الهيكلة.

ثانياً - مجالس إدارة الشركات^(١١):

يجب على مجالس إدارة الشركات في زمن جائحة (COVID-19)، توخي الحذر لمواصلة قيامها بواجباتها، والوفاء بها بشكل صحيح، فبمجرد أن يدرك مجلس إدارة الشركة أن الشركة تواجه صعوبات مالية خطيرة، وتتمر بأزمات خطيرة، يجب عليه القيام بجملة من الأمور، وهي علي النحو التالي:

١ - طلب المشورة:

يجب على مجلس إدارة الشركة الاستعانة بأهل الخبرة في شتى المجالات، وطلب المشورة من الخبراء كل منهم حسب اختصاصه في كل ما تتعرض إليه الشركة من أزمات، فالخبير في مجال إعادة الهيكلة يمكن الاستفادة منه في التعليق على خطة مواجهة الجائحة، ومساعدة المجلس في تنفيذ تلك الخطة، وتنقيحها كذلك، وفي السياق ذاته يجب على مجلس الإدارة طلب المشورة من الخبراء في مجال الإفلاس أو من المحامين أو من الخبراء الماليين في أقرب فرصة؛ حيث يمكن لهؤلاء أن يساعدوا في توفير الدفاعات والردود عن أي طلبات محتملة من قبل طالبي الإفلاس إذا دخلت الشركة في وقت لاحق في عملية الإفلاس، كما يمكنهم كذلك أيضاً المساعدة

(١١) Paul Rosen, David Wood, COVID-19 - Temporary Relaxation of UK Insolvency Laws, 7 April 2020, Available at (<https://katten.com/covid-19-temporary-relaxation-of-uk-insolvency-laws>), (11/4/2020), Alison Goldthorp, Sarah Coucher, James Stonebridge, COVID-19: Legal considerations for UK Boards (updated to reflect the position as at April 1, 2020), April 2020, Available at (<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/621d58ef/covid-19-legal-considerations-for-uk-boards>), (10/4/2020), David Murray, David Few, Coronavirus (COVID-19) - Company Directors' Duties and Flexibility in Insolvency Law, 30 March 2020, available at (<https://www.blandy.co.uk/about/news-and-insights/insights/coronavirus-covid-19-company-directors-duties-and-flexibility-in-insolvency-law>), (2/4/2020), Sean F. Collins, James D. Gage, Heather L. Meredith, Walker W. MacLeod, Jocelyn Perreault, Alain N. Tardif, COVID-19 Considerations from Our Bankruptcy & Restructuring Experts, March 17, 2020, Available at (<https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/restructuring-roundup/covid-19-considerations-our-bankruptcy-restructuring-experts>), (1/4/2020), Paul Rosen, David Wood, COVID-19 - Temporary Relaxation of UK Insolvency Laws, April 7, 2020, Available at (<https://katten.com/covid-19-temporary-relaxation-of-uk-insolvency-laws>), (10/4/2020).

في تحديد مجالات الخطر التي يمكن أن ينتهك فيها مجلس الإدارة واجباته دون سابق معرفة، وتقديم التوجيه في التعامل مع الظروف التي ربما لم يواجهها العديد من أعضاء مجلس الإدارة من قبل.

ونتيجة لما تقدم، إذا سمحت الظروف ورأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك فيحق له تعيين خبير استشاري في مجلس الإدارة أو يكون من ضمن فريق الإدارة العليا؛ لتولي مسؤولية الخطوات التي يجب اتخاذها لإدارة المشكلات الناشئة عن انتشار جائحة فيروس (COVID-19).

وكذلك يجب على المجلس طلب المشورة من (مراقب الحسابات) حول الوضع الحالي للشركة في نطاق سلطته، كما يجب على المجلس مناقشة مراقبي الحسابات حول ما إذا كان يجب إجراء تعديلات على الميزانية السنوية للشركة أو الإفصاحات اللاحقة بشأن الميزانية السنوية فيما يتعلق بتأثير الفيروس التاجي (COVID-19)، نظراً للشكوك المحيطة حول طول أو قصر عمر هذا الفيروس التاجي.

كما يجب على مجلس الإدارة عند الحصول على المشورة المهنية المتخصصة أن يعمل على الاستفادة منها قدر المستطاع، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل القانونية والمالية للشركة.

٢ - مراعاة الحيطة والحذر فيما يتخذه من قرارات والتخطيط الجيد لمواجهة خطر الجائحة:

لا تزال الحيطة والحذر الشديد ضروريين عند التفكير في اتخاذ قرارات هامة تتعلق بكيان ومصير الشركة، ومنها صدور قرار بتوزيع أرباح المساهمين في وقت الجائحة من عدمه، وكذلك صدور قرار بإبرام صفقات تجارية تكون بأقل من قيمتها في الأوقات العادية، فلا بد في تلك الحالة من مراجعة تلك الصفقات بعناية خاصة، وكذلك مراعاة الحيطة في القرار بمنح ضمان إضافي للدائنين، وكذلك صدور قرار بالموافقة على شروط التوريد الجديدة، وكذلك دفع بعض الديون لجانب معين من الدائنين فقط دون البقية الآخرين، وكذا القرار الخاص بدفع مكافآت نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين الذين أحيلوا للتقاعد، فتلك القرارات يجب أن يتم تقييمها كلها بعناية وحرص، وكذلك سيظل مجلس الإدارة بحاجة إلى توخي الحذر في تعامله مع الدائنين بشكل عام، ولذا فيعد من الأهمية بمكان أن يتم اتخاذ جميع قرارات المجلس بما يتماشى مع واجباته القانونية وليس في مصالحه الخاصة.

وفي ضوء القرارات التي يصدرها المجلس، يجب أن يكون على علم بأحدث

المعلومات المالية الخاصة بالشركة، والتي يجب على أعضاء المجلس أن يراجعوها بانتظام؛ حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان ينبغي على الشركة الاستمرار في التداول والإنتاج من عدمه، ومن الممكن أن يصبح هذا الأمر صعباً بشكل متزايد، حين يصاب جانب من الموظفين الذين يمدون المجلس بالمعلومات الهامة بالفيروس، أو يعزلون أنفسهم، ففي تلك الحالات يجب على أعضاء المجلس بذل قصارى جهدهم في الحصول على تلك المعلومات من أي مكان لتحديد ما إذا كانت الشركة يجب أن تستمر في التجارة من عدمه.

وبالنظر إلى الاضطراب المستمر بشكل عام، قد يختار مجلس الإدارة دراسة عمليات اتخاذ القرار من خلال إسناد مسؤوليات محددة إلى لجان المجلس أو إلى الخبراء المختصين من أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وكمبدأ عام في اتخاذ القرارات، يجب على مجلس إدارة الشركة ممارسة ولايته مع العناية الواجب مراعاتها، والمعيار المتبع لتقييمه في ذلك هو ما يمكن توقعه من مجلس إدارة دقيق ومثابر في الظروف نفسها، ولذا فيجب دائماً اتخاذ القرارات الخطيرة لما فيه مصلحة الشركة، مع مراعاة مصالح الجميع من (المساهمين، والموظفين، والعملاء، والدائنين، والموردين)، فيجب أن يكون مجلس الإدارة على دراية بمصالح هؤلاء عند اتخاذ قرارات معينة بشأن أفضل طريقة لتوجيه إدارة الشركة، وسيحتاج في ذلك إلى الموازنة بعناية بين الاحتياجات قصيرة المدى للشركة، والتأثير طويل المدى لقراراتهم، فيجب اتخاذ قرارات العمل لما فيه مصلحة الشركة، أي المصلحة طويلة المدى للمساهمين مع مراعاة مصالح جميع أصحاب المصلحة مثل (الموظفين والعملاء والدائنين والموردين).

وضمن هذا السياق، سيصبح من المسؤولية الأساسية لمجلس الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر التجارية والمالية والبشرية الناجمة عن جائحة فيروس (COVID-19).

وكذلك سيحتاج مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات إلى تقييم مدى خطر الأضرار التي تتعرض لها الشركة باستمرار؛ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة على الفور لتجنب أي أضرار أو على الأقل الحد منها، ولذلك فيجب إعادة تقييم هذه القرارات بانتظام لضمان فعاليتها في هذا الوضع المتغير بسرعة، وبالتالي، فإن البقاء على دراية جيدة للمجلس بالتطورات التي تحدث داخل الشركة، وكذلك الإحاطة بالوضع سريع التطور داخل المجتمع بأكمله، والتغيرات في اللوائح المعمول بها، يعد من الأمور الضرورية لمجلس الإدارة في سياق الأزمة الحالية غير المسبوقة.

ومن خلال ما تقدم، نجد أنه يجب أن يكون محط تركيز مجلس الإدارة الأمور الآتية:

- ١ - تقييم المخاطر لشركاتهم بعناية كافية.
- ٢ - التماس المشورة بشأن حقوقهم والتزاماتهم القانونية.
- ٣ - تقديم استجابة استباقية مناسبة لهذه المخاطر مع ضمان استمرارية العمل قدر الإمكان، حيث قد تؤدي سلبيتهم إلى وضعهم في موقف حرج قد يتحملون بسببه المسؤولية.

ويثار التساؤل حول مدى مسؤولية المجلس إذا لم يراع ما تقدم، قد يؤدي عدم التفكير في أي خطر ذي صلة بشكل صحيح إلى عواقب وخيمة على مجلس الإدارة، فإذا لم يقيم مجلس الإدارة بتقييم دقيق للأوضاع الحالية ومعالجة استباقية من خلال الردود المناسبة للتأثير المحتمل لجائحة فيروس (COVID-19)، فيمكن تحميل المجلس المسؤولية كاملة، وتجدر الإشارة إلى أنه عند تقييم مسؤولية المجلس، يجب على المحكمة أن تحترم السلطة التقديرية الممنوحة للمجلس فيما يتعلق بقراراته، ولا يمكنها إلا أن تعاقب على الأخطاء الواضحة التي تقع بشكل واضح خارج ما هو معتاد، وهذا يستلزم أن يستند التقييم إلى المعلومات المتاحة في وقت اتخاذ القرار (وليس لاحقاً فيما بعد).

وبخلاف ما تقدم من واجبات تقع على عاتق مجالس إدارة الشركات، نجد أنه يجب على مجلس الإدارة مراعاة التخطيط الدقيق للطريقة التي يمكن أن تستمر بها الشركة في العمل من خلال جائحة فيروس (COVID-19)، فهذا يعد أمراً ضرورياً، حيث إن الوضع يتطور بسرعة كبيرة، وتجب مراجعة التخطيط في الوقت الحالي على أساس يومي، فقد يصبح التخطيط المقدم حتى قبل أيام قليلة قديماً في اليوم الحالي.

وتطبيقاً لذلك، فإن المجلس يجب أن يتواصل بانتظام مع أصحاب المصلحة (المساهمين والموظفين والمقرضين والموردين)، لإبلاغهم وطمأنتهم بالخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ التخطيط الذي أعده؛ وذلك لضمان أن الشركة يمكن أن تستمر في التجارة، حيث قد توجد صعوبات لدى الشركة في توفير (العمل كالمعتاد)، خاصة عندما يكون هناك خطر تعطل لسلسلة التوريد، فلذا من المتوقع أن يتطلع (المقرضون، والعملاء، والموردون) إلى معرفة تعامل الشركة مع تلك الجائحة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، وكذا مشاركتهم المنتظمة، من خلال إطلاعهم على خطط الشركة.

ويثار التساؤل حول ما يجب أن يضمه التخطيط الجيد، فنجد أنه يجب على

مجلس الإدارة إعداد تخطيط للطريقة التي سيتم من خلالها تنفيذ أعمال الشركات في ضوء هذه الجائحة، وقد يتعامل التخطيط مع احتمالية عمل الموظفين عن بعد، وكيف ستتم إدارة هذا العمل، وكيف يمكن للموظفين تغطية غياب جانب منهم بسبب المرض، وتجب مراجعة مدى مرونة عمل الشركة، ومعرفة المناطق التي قد تكون معرضة للخطر، ووضع خطط لإدارة تلك المناطق، والتعامل معها، وكذا مواصلة النظر في مراجعة سلسلة التوريد، وخطط الطوارئ التي تم إعدادها لأية أزمات محتملة مع سلسلة التوريد.

وفي حالة إذا لم يكن هناك احتمال للتعافي في ضوء القرارات التي تم اتخاذها، فيجب على مجلس الإدارة من حيث المبدأ وفي الظروف العادية اقتراح إنهاء وحل الشركة، ولهذه الغاية، يجب على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة للشركة تقريراً خاصاً يبرر أسباب إنهاء الشركة، بالإضافة إلى بيان يلخص الوضع النشط والسلبى للشركة، بتاريخ لا يزيد على ثلاثة أشهر، ويجب أن يشتمل هذا البيان على تقرير مراقب الحسابات، وفي حالة عدم وجود مراقب للحسابات، فيكون التقرير من قبل مراقب خارجي أو محاسب قانوني، وقبل اقتراح هذا الخيار، يجب على مجلس الإدارة إبقاء الشركة على قيد الحياة إلى أقصى حد ممكن، حتى نهاية الأزمة الصحية على الأقل، للتأكد والتيقن من عدم وجود احتمال للتعافي.

٣ - عقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة متكررة ودورية:

في الأوقات الصعبة أو غير المؤكدة، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تناقش مجالس الإدارة وتتخذ قرارات جماعية تؤثر على أعمال الشركة في تلك الجائحة، كما يحتاج المجلس إلى الرد على المشهد المتغير اليومي، لذلك يجب عقد اجتماعات المجلس بصورة منتظمة للغاية من خلال عقد الاجتماعات بصورة دورية ومتكررة، وعقد اجتماعات كذلك أسبوعية لمجلس الإدارة، أو حتى يومية، بحيث يصبح المجلس في وضع يمكنه من التفكير بعناية فيما إذا كان يجب على الشركة الاستمرار في العمل من عدمه، وما إذا كان لديها احتمال معقول لتجنب التصفية.

وقد يكون ذلك التكرار من الحكمة، لا سيما إذا كانت الشركة تعاني من ضائقة مالية، فعقد الاجتماعات بشكل أكثر من المعتاد، يعد ضرورياً من أجل بقاء الشركة في حالة أكثر مرونة، ويمكنها كذلك الاستجابة للمشهد المتغير.

وكذا يجب على مجلس الإدارة في تلك الاجتماعات توثيق القرارات والخطوات التي يتم اتخاذها بوضوح، فيجب على المجلس الاحتفاظ بسجل مكتوب تسجل فيه

أي قرارات رئيسية، ولا سيما قرارات مواصلة أو وقف التداول، وكذا إجراء اختبارات الملاءة المالية بشكل متكرر، وتقييم الوضع المالي للشركة، فيجب على المجلس إبقاء المركز المالي للشركة قيد المراجعة المنتظمة للغاية، ويجب أن لا يسمحوا للشركة بتحمل التزامات جديدة ما لم يكن من الواضح كيف سيتم الوفاء بهذه الالتزامات عند استحقاقها، وكذلك قد يتم في تلك الاجتماعات مراجعة التخطيط في قيادة الشركة ومناقشته بانتظام، والتأكد من تطبيقه، وكذلك قيام اللجان الفرعية بمراقبة ذلك، وإبلاغ مجلس الإدارة بهذا الشأن بانتظام.

ويثار التساؤل حول طريقة اجتماعات المجلس في الظروف الحالية، فنجد أنه يمكن عقد اجتماعات المجلس عن طريق الهاتف، أو عبر مؤتمر (Video conference)؛ بسبب أن التجمعات قد تؤدي إلى إصابة بعض أعضاء مجلس الإدارة بالفيروس التاجي، كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة إجراء مكالمات هاتفية إدارية يومية؛ نظراً لأن المواقف المتغيرة سريعة الحركة.

ويثار التساؤل حول كيفية التعامل مع الاختلاف فيما بين رئيس المجلس وجانب من أعضاء المجلس في زمن تلك الجائحة، فنجد أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة في المقام الأول حماية مصالح الشركة، ومصالح الدائنين، وفي حالة نشوب اختلاف مع جانب من أعضاء المجلس بشأن أمور ما، فيجب عليه القيام بإقناع بعض أعضاء المجلس بخلاف ما يعتقدون أنه المسار الصحيح في تلك الجائحة، وفي حالة إذا لم يتمكن رئيس المجلس من ذلك، فيجب عليهم جميعاً التعبير عن آرائهم في اجتماع مجلس الإدارة، ويفضل إصدار شرح مفصل مكتوب منهم يحدد وجهات نظرهم المختلفة للنظر فيها من قبل باقي أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، وإذا فشل رئيس المجلس في إقناع باقي الأعضاء الآخرين، فيجب عليه إما الاستقالة أو القيام بمحاولة أخرى لإقناع المجلس من خلال التهديد بالاستقالة، ثم يجب عليه أن يقدم استقالته إذا فشل ذلك الأمر.

ويثار التساؤل حول مدى الاحتفاظ بمحاضر جلسات مجلس الإدارة في زمن الجائحة، فنجد أنه يجب الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات المجلس، فإذا كانت الشركة غير قادرة على تجنب الإفلاس، ستقدم محاضر مجلس الإدارة دليلاً إلى المساهمين على أن أعضاء مجلس الإدارة قد تصرفوا بشكل مناسب ومعقول في زمن الجائحة، مع قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه، وكذا التصرف لصالح دائني الشركة، لذلك فإنه يعد من الضروري ومن الأهمية بمكان الاحتفاظ بمجموعة المحاضر لجميع اجتماعات المجلس.

٤ - استمرار التدفقات النقدية وإدارتها بحكمة:

السيولة النقدية تعد حياة الشركة، وتعد بمثابة تدفق للدم داخل الشركة، فقد يصبح العديد من الشركات معسرة لانخفاض السيولة النقدية بها أو نفادها منها، فمن دون السيولة النقدية يمكن لشركة عظيمة أن تكون في مرمى خطر الإفلاس، وتختلف المحافظة على استمرار السيولة النقدية لكل شركة عن الأخرى، ولكن الهدف يتمثل في الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على التدفق النقدي الجيد، وأحد أهم الأمثلة للحفاظ على السيولة النقدية لمنع خطر الإفلاس، تتمثل في تقديم خصومات للعملاء عن الدفع الفوري، هذا وضع مربح للطرفين؛ لأن العملاء يرغبون في توفير المال، والمدفوعات السريعة تزيد من التدفق النقدي للشركة، وتتجنب مشكلات خدمة المطالبة بالديون.

كما أن مجلس إدارة الشركة قد يحتاج إلى القيام بمراجعة دقيقة للتدفقات النقدية المستقبلية لضمان بقاء القدرة على سداد أي مطالبات قد تنشأ، وكذا فيجب على مجلس الإدارة إدارة التدفق النقدي بحكمة، فيجب عليه على الفور خفض التكاليف المتغيرة، (عن طريق خفض النفقات غير الضرورية للحفاظ على السيولة النقدية، وقد يشمل ذلك تقليل تكاليف المبيعات، والتسويق، ونفقات السفر، والترفيه، والرواتب والأجور، وتكاليف التوريدات المكتبية)، وتأخير أي نفقات اختيارية، وتمديد سداد الديون الحالية، وتسريع قبض المستحقات، واستكشاف خيارات الدفع البديلة داخل سلسلة التوريد الخاصة، فعلى سبيل المثال، يجب بدء محادثة مع مالك العقار في أقرب وقت ممكن، فغالباً ما يستخدم مالكو العقارات التجارية مدفوعات الإيجار لسداد القروض، فإذا قام المجلس بإخطار المالك بالصعوبات المالية، فقد يتمكن من الحصول على تجميد على سداد هذه القروض خلال الأشهر المقبلة، وقد يوافقون عندئذٍ على إيقاف مدفوعات الإيجار الشهرية.

وكذلك من ضمن إدارة السيولة النقدية، يجب على المجلس استخدام الدعم الحكومي المتاح على الوجه الأمثل، فقد تم خلال الأسابيع الماضية سن العديد من التدابير المالية الطارئة لمواجهة جائحة (Covid-19)، فقد تساعد هذه التدابير الشركات على البقاء على قيد الحياة من خلال قيام مجلس الإدارة بإدارة الدعم المالي من تلك الحكومات بعناية فائقة.

كما يجب من أجل المحافظة على السيولة الموجودة التحدث مع البنك، فيجب على مجلس إدارة الشركة الذي يكافح حالياً مع مشكلات التدفق النقدي وغيرها من المشكلات التي تسببها جائحة (Covid-19) الاتصال بالبنوك في أقرب وقت ممكن؛

لمناقشة إمكانية وقف سداد القروض خلال الأشهر القادمة، فقد يكون في تعطيل الدفع هذا الحفاظ على ما لدى الشركة من سيولة نقدية، وكذا المحافظة على العنصر الحيوي الذي يسمح للشركات بالبقاء على قيد الحياة طوال الأشهر القادمة.

كما يجب من أجل المحافظة على السيولة الموجودة مراجعة التغطية التأمينية، فقد تغطي بعض وثائق التأمين انقطاع الأعمال، أو تعويضات الموظفين، ويجب على الشركات مراجعة سياساتها للتأكد مما إذا كان لديهم غطاء تأميني لبعض الخسائر التي قد تنشأ بسبب جائحة (Covid-19)، وقد يتم سداد تلك المطالبات من تلك التغطية التأمينية، فإن ذلك قد يوفر قدراً كبيراً من السيولة النقدية لدى الشركة.

ونظراً لما تقدم، فإنه يجب على أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين بالشركات أن يراجعوا بشكل استباقي سياسات التأمين الخاصة بشركاتهم بالتعاون مع مستشاريهم، مع إيلاء اهتمام خاص لأي استثناءات، وقيود ذات صلة.

٥ - تطبيق مبادئ حوكمة الشركات الجيدة:

طبقاً لمبادئ حوكمة الشركات، يمكن مساءلة ومعاينة مجلس الإدارة إذا دخلت الشركة في حالة تصفية، ولم يطبق ويتبع مجلس الإدارة قواعد الحوكمة الجيدة، ولذا من الواجب تشكيل لجان فرعية لمجلس الإدارة للمضي قدماً بتقديم مبادرات معينة للتعامل مع تأثير جائحة (Covid-19) على الأعمال، وسيصبح التركيز المتزايد لها على جمع السيولة النقدية، وكذا إجراءات خفض التكاليف، فتلك الأمور تعد ذات أهمية متزايدة على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة، وبالنظر إلى حقيقة أن أعضاء اللجان الفرعية قد يكونون مصابين بالفيروس، أو أنهم يقومون بعزل أنفسهم، ولذلك فإننا نوصي المجلس الذي يقوم بتشكيل تلك اللجان الفرعية بتوفير أعضاء احتياطيين لأعضاء تلك اللجان للتكيف مع التعامل مع هذه الاحتمالات.

كما أنه نظراً لحالة عدم اليقين حول جائحة (Covid-19)، سيصبح هناك خطر كبير على الشركات، وإن التركيز على الشفافية والمساءلة اللتين تعدان من أهم مبادئ حوكمة الشركات سيجعل الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسائل معينة مثل الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية أكثر أهمية من أي وقت مضى، فيجب على مجلس الإدارة التأكد من أن شركته تحتفظ بالدفاتر والسجلات المناسبة لتستطيع في أي وقت تحديد الأصول، والخصوم، والمركز المالي، والأرباح، أو الخسائر للشركة بدقة معقولة.

وتشترط حوكمة الشركات على كل شركة أن تسجل وتحتفظ بتفاصيل

المدفوعات المدفوعة لها أو بواسطتها، وتسجيل مركزها المالي، وتعد السجلات المحاسبية الكافية ضرورية لإعداد الشركة للقوائم المالية السنوية التي يجب أن تعطي (رؤية حقيقية، وعادلة) للوضع المالي للشركة، ولذلك فيجب على مجلس إدارة الشركة مراقبة أداء الشركة باستمرار، والاحتفاظ بدفاتر حسابات مناسبة للمساعدة في هذا الصدد؛ لتمكينهم من التحقق من الوضع المالي الدقيق للشركة، وبالتالي تمكينهم من اتخاذ قرارات لمواجهة تحديات جائحة فيروس (Covid-19)، وحماية الأعمال المستقبلية للشركة.

وكذلك سيتعين على مجلس إدارة الشركات المدرجة في البورصة أيضاً مراعاة التزاماته الخاصة بتقديم التقارير، خاصةً في شرح كيفية تزويد الشركة بالموارد للتعامل بفعالية مع الأزمة المستمرة، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، والأثر المحتمل للوباء على الأداء المالي.

٦ - الحفاظ على أعداد العاملين بالشركات:

قد أبدت حكومات العديد من الدول رغبتها القوية في إبقاء العاملين على جدول الرواتب لأطول فترة ممكنة، وسيكون ذلك أفضل للاقتصاد على المدى الطويل، ومن المؤكد أن نظام دعم الأجور المؤقتة قد سهل على الشركات القيام بذلك، ولذلك يجب على مجلس إدارة الشركة بذل كل جهد ممكن لتكييف استراتيجية عمل الشركة لتمكينها من الحفاظ على مستوى معين من النشاط من خلال عدد من العاملين، مع مراعاة القيود التي تفرضها الحكومة من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية صحة ورفاهية الموظفين النشطين والمقاولين من الباطن والجمهور.

وبعد أن تم عرض دور مجلس الإدارة في إدارة الشركة في تلك الجائحة الحالية، يثار التساؤل حول مدى مسؤولية مجلس الإدارة عن القيام بالأعمال التجارية عندما تصبح الشركة معسرة، فنجد أنه في أغلب الدول في جميع أنحاء العالم عندما تكون الشركة أوشكت على الإفلاس، فإن مجلس الإدارة ملتزم بالتصرف لمصلحة الشركة ومساهميها، وعندما تصبح الشركة معسرة، يكون على مجلس الإدارة واجب التصرف في المقام الأول لصالح دائني الشركة، هذا وقد تكون الشركة معسرة على أساس التدفق النقدي (عندما تكون غير قادرة على دفع ديونها عند استحقاقها)، أو على أساس الميزانية العمومية (عندما تكون قيمة أصول الشركة أقل من المبلغ المطلوب سداده، مع مراعاة الحساب المحتمل والالتزامات المحتملة)، وبموجب قوانين التداول المعسرة في أغلب قوانين الشركات، يمكن أن يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً شخصياً عن الديون التي تكبدها الشركة إذا كانت هناك، في وقت تكبد الديون،

(أسباب معقولة) للاشتباه في أن الشركة كانت إما معسرة أو ستصبح معسرة من خلال تكبد الديون.

وفي ظل سياق جائحة فيروس (Covid-19) الحالية، سيحتاج مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرارات عاجلة بشأن تكبد الديون، ولذلك يجب تصميم الملاذ الآمن المؤقت لمنح مجلس الإدارة الثقة لمواصلة الأعمال التجارية، ودفع الديون، والاحتفاظ بالموظفين، من دون ضغط وخوف للخروج بالشركة إلى بر الأمان إذا كانت هناك فرصة حتى لا تصبح في شباك الإفلاس، وسيتمكن أعضاء مجلس الإدارة كذلك من الاعتماد على الإعفاء المؤقت من المسؤولية فيما يتعلق بالديون التي تتحملها الشركة إذا كان الدين طبقاً (للمسار العادي لأعمال الشركة)، وكذلك من ضمن تعليق المسؤولية سيحتاج مجلس الإدارة إلى منحه الإعفاء من المسؤولية نتيجة عدم الكشف عن بعض المعلومات الجوهرية في التقرير السنوي الذي يصدر عنه فيما يتعلق بالمخاطر الرئيسية المرتبطة بآثار الفيروس التاجي وتأثيره، وعلى الرغم من ذلك ينبغي أن يسعى مجلس الإدارة إلى تحديد وتوضيح المخاطر الدقيقة التي تواجهها الشركة وذلك ليس على المستوى العام.

المبحث الثاني الآليات الوطنية للوقاية من إفلاس الشركات في ظل جائحة (COVID-19)

تتطلب أزمة جائحة (COVID-19) من جميع الدول في جميع أنحاء العالم إعادة تكييف قوانين الإفلاس مع تلك الجائحة؛ حيث إنه قد وصلت تلك الجائحة إلى حالة وبائية، فينتشر حالياً الفيروس على مدى واسع في العالم، ومن المتوقع أن يصيب غالبية الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية خلال (الأشهر القادمة) وعلى الأخص الشركات، حيث إن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من الحكومات على مستوى العالم لها آثار مدمرة على الشركات، ورجال الأعمال؛ حيث قد تتباطأ الحركة التجارية، ولذلك فقد يتم إغلاق الشركات بشكل مستمر، ولذلك فقد تم توجيه نداءات قوية على المستوى الدولي لمنع الإفلاس الناجم عن تلك الجائحة، فالصدمة الاقتصادية الخارجية تضرب بعناية جيدة من الناحية المالية الشركات، حيث إنها تعتمد في المقام الأول على التدفق النقدي السلس للسيولة المالية، لاسيما الشركات التي تعتمد على الإنتاج بشكل أساسي، ولذلك فالعديد من تلك الشركات بعد بضعة أسابيع أو أشهر قد تضطر إلى تقديم ملف إفلاسها وربما قد تعاني من التصفية التدريجية، من خلال اتخاذ إجراءات الإفلاس ضدها، الناتجة عن السوق الحالية المتعثرة، ولذلك فنظراً للظروف الحالية سيصبح هناك خطر كبير على مبيعات الشركات بأقل من القيمة، ولذلك فليس من المستغرب أن تبادر العديد من الحكومات على المستوى الدولي باتخاذ التدابير الاقتصادية لمنع اتخاذ إجراءات التصفية حيالها. هذا وقد نشرت المفوضية الأوروبية رسالتين تناولتا العواقب الاقتصادية المحتملة لأزمة جائحة (COVID-19)، وهما على النحو التالي^(١٢):

الرسالة الأولى: قد تناولت فيها المفوضية نهجاً اقتصادياً منسقاً يحتوي على مجموعة من التدابير، والتي تتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القيام بتقديم مساعدات للشركات المتعثرة عن دفع ديونها.

الرسالة الثانية: أعلنت المفوضية إطاراً مؤقتاً لمساعدة الدول الأعضاء، وذلك كما

(١٢) Gert-Jan Boon, Markus Konrad Brunnermeier, Horst G. M. Eidenmueller, Luca and Gurrea- Enriques, Aurelio Mart?nez, Kathryn Judge, Jean-Pierre Landau, Marco Pagano, Ricardo A.M.R. Reis, Kristin, op.cit, p28-29.

أعلن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، عن تدابير مالية لتعزيز الاقتصادات، وذلك لمنع حالات الإفلاس غير الضرورية.

هذا وقد تتطلب الحالة الاقتصادية الحالية غير العادية التي أثارها اندلاع ظهور (COVID-19) من المشرعين للقوانين على المستوى الدولي اتخاذ تدابير استثنائية، ويمتد هذا أيضاً إلى الإفلاس، لإصدار تشريعات لمنع حالات الإفلاس غير الضرورية، حيث إن تشريعات الإفلاس القائمة قد لا توفر ما يكفي من الاستجابات للحالة التي تجد العديد من الشركات نفسها فيها حالياً، فلذلك يجب على المشرعين الوطنيين على مستوى العالم اتخاذ إجراءات فورية لإعادة تكييف تشريع الإفلاس لمنع الشركات المتعثرة تعثراً غير إرادي من تطبيق نظام الإفلاس عليها.

هذا وإعادة تكييف تشريعات الإفلاس يكون من خلال اتخاذ خطوتين أساسيتين على الفور:^(١٣)

الخطوة الأولى: تعليق رفع دعوى الإفلاس بناء على المديونية غير المفرطة للشركات، ومثل هذا التعليق موجود في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فهو على سبيل المثال مطبق في دول النمسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، ولافتيا، وبولندا، وإسبانيا؛ نظراً لأن عدم اليقين الاقتصادي يعيق من فعالية تطبيق نظام الإفلاس، والهدف من هذا التعليق هو منح فرصة العودة للحياة للشركات القابلة لذلك.

هذا وفي الأيام الأخيرة، علقت بعض الدول (ألمانيا) أو مددت (النمسا) تطبيق نظام الإفلاس، وذلك نظراً لإغلاق الشركات لعدة أسابيع أو أشهر، لمنحها فرصة لاتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة عدم توافر السيولة النقدية اللازمة لديها، وكذلك قامت بتعديل تشريعات الإفلاس بشكل عاجل، حيث تضمنت تلك التعديلات تدابير لإتاحة التمويل المؤقت (للأزمات)، وتعليق تقديم طلب الإفلاس على أساس عدم القدرة على الدفع.

الخطوة الثانية: عن طريق الوقف العام أو التأجيل لدفع الديون المستحقة على الشركات، وكذلك تقديم دعم مالي من الحكومة للمساعدة على انتعاش أعمال الشركات وأيضاً مساعدة موظفيها.

(١٣) Gert-Jan Boon, Markus Konrad Brunnermeier, Horst G. M. Eidenmueller, Luca and Gurrea- Enriques, Aurelio Mart?nez, Kathryn Judge, Jean-Pierre Landau, Marco Pagano, Ricardo A.M.R. Reis, Kristin, op.cit, p28-29.

ونظراً لما تقدم، فإنه قد استجابات العديد من الحكومات، والهيئات التنظيمية المالية، والمنظمات الدولية، لجائحة (الفيروس التاجي)، في اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية، والاقتصادية، والمالية، ومن بين التدابير القانونية المدرجة في هذه الحزم الوقائية من الإفلاس بالنسبة للشركات التي قد أصبحت تعاني من ضائقة مالية تمنعها من سداد ديونها الواجبة الدفع على الفور نظراً لحدوث أمور طارئة غير متوقعة، وسوف نلقي الضوء حول أهم الدول التي قامت بفرض العديد من تلك التدابير الوقائية، وذلك على النحو التالي:

أولاً - في دولة إسبانيا^(١٤):

إن الوضع في دولة إسبانيا مقلق بشكل كبير دون باقي الدول حول العالم، وذلك حتى وقتنا الحالي، لأسباب مختلفة منها الآتي:

- ١ - إن دولة إسبانيا تعد إحدى الدول التي انتشر فيها الفيروس بأقصى حد ممكن، ولسوء الحظ، فإنه من غير المتوقع أن يتحسن الوضع في الأشهر القادمة.
- ٢ - كتدبير احترازي لوقف انتشار فيروس (COVID-19)، قيدت الحكومة الإسبانية العديد من الأنشطة الاجتماعية، والاقتصادية، وهذه الإجراءات التي تعد ضرورية لوقف النمو المتسارع للفيروس، والتقليل من انتشاره، وكان يجب أن يتم إصدارها في وقت سابق، وأن تلك التدابير ستلحق بمزيد من الضرر الواضح بالعديد من

(١٤) Dissolution of companies and bankruptcy in times of coronavirus, 15 March 2020, Available at (<https://www.derechoyfinanzas.org/disolucion-de-sociedades-y-concurso-de-acreedores-en-tiempos-del-coronavirus/>) (18/5/2020), Joss Hargrave, Nicolas Morelli, Lyle Abel, Cedric Berckmans, John Shi, ubom?r Bre?ka, Casper Moltke-Leth, Kristiina Lehtil?, Celine Nezet, Dr. Dirk Barcaba, d?m Boross, Nipun Gupta, Matteo Meroni, Adam Kowalczyk, Ken Cheung, Alfonso Carrillo Cano, Mattias Lindberg, René Rieter, Lucas Pitts, Jordan Cooper, COVID-19: International Restructuring & Insolvency Update, 03-2020, Available at (<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/covid-19-international-r-and-i-briefing>), (2/4/2020), Zahra Ali, Spanish measures for restructuring/insolvency in the context of coronavirus (COVID-19)-threats and opportunities, 27 Mar 2020, Available at ([https://www.lexisnexis.co.uk/blog/restructuring-and-insolvency/spanish-measures-for-restructuring-insolvency-in-the-context-of-coronavirus-\(covid-19\)-threats-and-opportunities](https://www.lexisnexis.co.uk/blog/restructuring-and-insolvency/spanish-measures-for-restructuring-insolvency-in-the-context-of-coronavirus-(covid-19)-threats-and-opportunities)), (5/4/2020) Yoko Takagi, Reyes Carvajal, COVID-19: Spanish Government Financial Assistance Measures, 19 APR 2020, Available at (<https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-spanish-government-financial-assistance-measures>), (25/4/2020).

الشركات، والصناعات، التي واجهت مشاكل اقتصادية ومالية خطيرة منذ ظهور هذا (الفيروس التاجي).

٣ - إن الاقتصاد الإسباني يعتمد بشكل كبير على القطاعات والشركات المتأثرة بشكل خاص بالفيروس التاجي، حيث يمكن أن تعد حالة الصناعة والسياحة في أسوأ ظروفها، لذلك يبدو أن كل شيء يشير إلى أنه على الرغم من أن هذا الوباء سيوجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، فإن الأثر الاقتصادي السيئ لفيروس التاجي سيكون الأشد والأكبر في دولة إسبانيا.

وطبقاً لما سبق، فإن حزمة الإصلاحات التي يمكن للحكومة اعتمادها للتخفيف من الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي في إسبانيا، يجب أن تشمل تدابير قانونية، ومالية، وعمالية واقتصادية، وسيكون من المناسب على وجه الخصوص مراجعة مدى تطبيق بعض اللوائح المتعلقة بحل الشركات وإفلاسها؛ حيث إنه على وجه التحديد، أن الانخفاض الحاد على الطلب في العديد من القطاعات الاستراتيجية لإسبانيا سيؤدي إلى آثار اقتصادية ذات أثر سيئ على الشركات الإسبانية وذلك للآتي:

أ - عدم وجود تدفقات نقدية تسمح للشركة بالوفاء بالتزاماتها على أساس منتظم مما سيجعل الشركات غير قادرة على دفع جميع التزاماتها المالية، وأن هذا الأمر سيضع العديد من الشركات الإسبانية في حالة حل أو إفلاس قانوني، لأنه سيجعل لديهم صافي من الأصول أقل من نصف رأس المال، وبالتالي، فإن هذا الوضع سوف ينشط واجب الإدارات القانونية لتجنب الإفلاس بقدر الإمكان إذا كان ذلك مناسباً تحت وطأة الاستجابة الشخصية للدائنين، والتنفيذ للالتزامات الجديدة التي أصبحت الشركة مدينة بها.

ب - كما أن عدم القدرة على الدفع سيضع العديد من الشركات في حالة إفلاس، مع الحاجة الملحة لطلب الإفلاس من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركات كي لا يخضعوا للعديد من العقوبات المدنية، بما في ذلك عدم أهلية أعضاء المجلس لإدارة أصول الشركات الأخرى، بالإضافة إلى مسؤوليات مختلفة أخرى طبقاً للقانون الإسباني. ولتجنب الزيادة الهائلة في قرارات وإجراءات إفلاس الشركات، وتجنب المسؤوليات المحتملة لأعضاء مجلس الإدارة نتيجة انتهاكهم لواجباتهم القانونية، فإن الحكومة الإسبانية، في حزماتها الإصلاحية ينبغي أن تتضمن تدابير مختلفة طبقاً لما نص عليه القانون الإسباني تؤثر على حل الشركات وإفلاسها، ومنها التدابير الآتية:

- فإنه على غرار أحكام القسم الأول من المرسوم الملكي بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨، والذي تم تمديده وتوسيعه لاحقاً ومؤقتاً من حيث النطاق والمحتوى،

فإن بعض الخسائر الناجمة عن انخفاض القيمة (التي تنتج عن الأرصدة غير القابلة للتحصيل)، وكذلك من مصروفات التشغيل العامة (مثل الأجور والإيجارات)، فيجب استبعادها مؤقتاً من مفهوم الخسائر التي ينتج عنها حل الشركات، وذلك على الأقل بالنسبة للشركات في القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، وإلا فإن أزمة (الفيروسات التاجية) ستؤدي إلى حل الشركات، وكذا إفلاسها، وفي حالة إذا لم يطبق ذلك، فستنتقل مخاطر الشلل الاقتصادي إلى مجالس إدارة الشركات؛ لأنها إذا لم تحل الشركات أو تروج للإفلاس في غضون شهرين، ستصبح مسؤولة شخصياً عن الديون الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة.

- وبهدف الحد من الطلب الهائل للإفلاس الذي قد يلوح به في الأشهر القليلة المقبلة بسبب الوضع الانتقالي لعدم توافر السيولة المالية للعديد من الشركات، والتكاليف الباهظة التي يمكن أن يولدها وضع النشاط التجاري، والدائنين، فلذا يتم في مجال القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً تعليق أو تمديد مؤقت حسب الاقتضاء للواجب (المتنازع عليه) لطلب الإفلاس لفترة شهرين من قبل مجلس إدارة الشركة المتعثرة، وتلك القاعدة موجودة في قانون الإفلاس الإسباني. هذا وإن هذا الإجراء قد تم اقتباسه من القانون الألماني (وقد يعد واجب تقديم طلب الإفلاس، في ظل اللائحة الألمانية أكثر صرامة من الوضع في إسبانيا؛ وذلك من خلال تعليق طلب الإفلاس فيه لغضون ثلاثة أسابيع فقط بدلاً من شهرين، ويمكن أن يؤدي خرق هذا الواجب إلى فرض عقوبات مدنية وجنائية على مجلس الإدارة).

- تطبيق الإفلاس العرضي بالنسبة للشركات التي لا تقوم بتنفيذ بعض الالتزامات المحاسبية، كما هو معتاد بين الشركات، وذلك على الرغم من امتثالها لجميع التزاماتها المالية والعمالية والإدارية، ولكن لا تحتفظ بدفتر اليومية، أو دفتر الجرد، وكذلك دفتر الحسابات السنوية، وذلك على عكس ما يطلبه القانون التجاري من جميع أنواع الشركات داخل الدولة من الإمساك بتلك الدفاتر، بغض النظر عن حجم نشاطها أو عملها الرسمي أو نظامها الضريبي.

وتلك ليست مشكلة تتعلق بالفيروس التاجي، بل بالأحرى تتعلق بالتصميم الخاطئ لقانون الإفلاس الإسباني، حيث إن الإفلاس النهائي للشركة التي ستصبح معسرة يجب أن يكون نتيجة للفيروس التاجي بحيث يكون مصادفة لسوء الحظ، ولذلك فوفقاً لتشريعات الإفلاس الإسبانية، يمكن للشركة فقط أن

تثبت أن الجائحة تعد السبب الأول في إفلاسه، وسيتم تصنيف ذلك على أنه إفلاس عرضي، حتى ولو لم يلتزم بمسك الدفاتر.

وخلافاً لما تقدم، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تدابير استثنائية وأصدرت بعض المراسيم الملكية، وأهمها المرسوم الملكي بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر في ١٧ مارس، فقد تضمن تغييرات تشريعية للتخفيف من آثار جائحة (COVID-19) فيما يتعلق بمسائل محددة للشركات والإفلاس، وأدخل عدداً من التعديلات على لوائح الشركات ونظام الإفلاس الحالي لمحاولة تخفيف التحديات التي تواجهها الشركات لتنفيذ التزاماتها القانونية، وكذلك لتسهيل استمرار الأعمال التي أصبحت أو ستصبح معسرة نتيجة لتلك الجائحة أو تواجه صعوبات اقتصادية، هذا وتشمل التغييرات التي تم إدخالها ما يلي:

حوكمة الشركات: خلال حالة الطوارئ، يُسمح لجميع أنواع الشركات بعقد جلسات هيئاتها الحاكمة عن طريق التداول عبر (Video conference)، بغض النظر عما إذا كانت لوائحها الداخلية تنص على تلك الآلية من عدمه.

الحسابات السنوية: يتم تعليق فترة ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لإعداد الحسابات السنوية بعد استئناف حالة الطوارئ.

على الرغم من أنه قبل أو أثناء حالة الطوارئ، تكون الشركة في سبب قانوني للحل، فإن الدعوة للاجتماع السنوي للمساهمين الذي يمكن حل الشركة من خلاله يتم تعليقه حتى نهاية حالة الطوارئ، وإذا حدث السبب القانوني للحل أثناء حالة الطوارئ، فلن يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن الديون خلال تلك الفترة.

وتحتوي هذه الحزمة على عدد من الآليات التي تهدف إلى التخفيف من الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإسبانية الأخرى من التباطؤ في الاقتصاد الناجم عن تلك الجائحة، في صورة خط تمويل بقيمة (٤٠٠ مليون يورو) مقدم من معهد دي كريديتو الرسمي (ICO) لمساعدة تلك الشركات، وكذا خطة ضمان بقيمة (١٠٠ مليار يورو) لمساعدة الشركات والعاملين للحصول على القروض والتمويل اللازم.

ويثار التساؤل حول مدى التزام مجلس الإدارة بتقديم طلب إفلاس الشركة، فنجد أن قانون الإفلاس الإسباني رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٣، يطلب من مجلس إدارة الشركة تقديم طلب الإفلاس دون تأخير لا مبرر له، ووفقاً لحالة الطوارئ في حالة مواجهته صعوبات مالية بسبب الوضع الحالي، فإن الشركات التي تكون في حالة إفلاس خلال حالة الطوارئ لن يكون على مجلس إدارتها التزام بتقديم طلب (الإفلاس المسبق)،

وبالتالي لا يلتزم مجلس إدارة الشركة التي تكون في حالة إفلاس بتقديم طلب لإعلان الإفلاس، فيؤجل المرسوم الجديد الالتزام بتقديم طلب الإفلاس لمدة (شهرين) بعد نهاية حالة الطوارئ، وسيختفي التزام مجلس الإدارة بتقديم ملف في غضون (شهرين) تماماً طالما أن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في ١٤ مارس ٢٠٢٠ سارية، وفي حالة إذا ما قرر أعضاء مجلس الإدارة عدم تقديم طلب الإفلاس خلال فترة شهرين، ولكن قام به طرف آخر، فإنه طبقاً للطريقة التي يتعامل بها المرسوم الملكي بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ فإنه لن تتم معالجة طلب الطرف الآخر هذا إلا بعد شهرين من نهاية حالة الطوارئ.

ثانياً – في دولة الصين^(١٥):

اتخذت الحكومة الصينية مجموعة واسعة من الإجراءات لمكافحة جائحة (COVID-19)؛ وذلك لمساعدة الشركات من جميع الأحجام لتجنب الإفلاس. وتشمل هذه الإجراءات الأمور الآتية:

١ – توفير السيولة النقدية للشركات:

قام (بنك الشعب الصيني) بتدبير (٢,٢٥ تريليون يوان) منذ فبراير الماضي من خلال تخفيضه متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك الوطنية، تقدم كقروض للشركات المتضررة من تفشي جائحة (COVID-19)، وعقب ذلك خصص (٥٠٠ مليار يوان) لذات السبب:

كما خصص (بنك الشعب الصيني) أموال قروض بقيمة (٣٠٠ مليار يوان) صيني مخصصة لمساعدة الشركات التي تلعب دوراً حيوياً في مكافحة جائحة (COVID-19)، تشمل هذه الأعمال المستهدفة عادةً الشركات التي تصنع المعدات، والمواد الطبية، والسلع، والمنتجات الأساسية، والشركات التي تنقل هذه السلع والمواد أثناء تفشي جائحة (COVID-19)، يتم تقديم أسعار فائدة تفضيلية للشركات المستهدفة التي تتراوح بين ٢,٤٪ ، ٣,١٥٪.

(١٥) Joss Hargrave, Nicolas Morelli, Lyle Abel, Cedric Berckmans, John Shi,?u-bom?r Bre?ka, Casper Moltke-Leth, Kristiina Lehtil?, Celine Nezet, Dr. Dirk Barcaba,?d?m Boross, Nipun Gupta, Matteo Meroni, Adam Kowalczyk, Ken Cheung, Alfonso Carrillo Cano, Mattias Lindberg, René Rieter, Lucas Pitts, Jordan Cooper, COVID-19: International Restructuring & Insolvency Update, 03-2020, Available at (<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/covid-19-international-r-and-i-briefing>), (3/4/2020).

وقد قامت بذات الفعل الحكومة المصرية، فقد خصصت (١٠٠ مليار جنيه) لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك قد خصصت الإمارات العربية المتحدة (١٠٠ مليار درهم) لمواجهة كورونا، وكذلك الكويت قد خصصت (١٠ ملايين دينار كويتي) لمواجهة تلك الجائحة.

٢ - خصم من الفائدة:

ستقوم (وزارة المالية الصينية) بخصم ٥٠٪ من تكاليف الفائدة لمدة لا تزيد عن عام واحد، تاركة بذلك معدل الفائدة الفعلي للشركات المستهدفة بما لا يزيد عن ١,٦٪.

هذا وقد تم إعداد قائمة الأعمال المستهدفة من الخصم بشكل مشترك من قبل وزارة المالية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لضمان تأهل الشركات للاستفادة من سياسة الخصم التي تم طرحها. وقد سلكت دولة التشيك مسلك دولة الصين نفسه.

ثالثاً - في أستراليا^(١٦):

نتيجة لتفشي جائحة فيروس (COVID-19) في أستراليا في ٢٣ مارس ٢٠٢٠، أعلنت الحكومة الأسترالية عن إدخال عدد من الإجراءات الجديدة لتوفير المرونة في قانون الشركات؛ بهدف تقديم الإغاثة المؤقتة للأشخاص والشركات المتعثرة مالياً، فقام البرلمان الأسترالي بتمرير قانون الاستجابة الاقتصادية التاجية للفيروس التاجي (القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠)، والذي استقبل الموافقة الملكية في ٢٤ مارس ٢٠٢٠. وبدأت الإصلاحات في ٢٥ مارس ٢٠٢٠، وستكون سارية حتى ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ أو في أي تاريخ لاحق لهذا التاريخ نظراً للظروف.

(١٦) Joss Hargrave, Nicolas Morelli, Lyle Abel, Cedric Berckmans, John Shi,?u-bom?r Bre?ka, Casper Moltke-Leth, Kristiina Lehtil?, Celine Nezet, Dr. Dirk Barcaba,?d?m Boross, Nipun Gupta, Matteo Meroni, Adam Kowalczyk, Ken Cheung, Alfonso Carrillo Cano, Mattias Lindberg, René Rieter, Lucas Pitts, Jordan Cooper, COVID-19: International Restructuring & Insolvency Update, 03-2020, Available at (<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/covid-19-international-r-and-i-briefing>), (4/4/2020), Lisa Calabrese, James Jarvis, Coronavirus (COVID-19): Important Temporary Relief in Insolvency Law, 24/3/2020, Available at (<https://www.finlaysons.com.au/2020/03/coronavirus-covid-19-important-temporary-relief-in-insolvency-law/>), (2/4/2020).

ويثار التساؤل حول الغرض من هذا القانون وأهم التغيرات التي تضمنها، فنجد أن هذا القانون يعد استجابة اقتصادية لتأثير جائحة فيروس (COVID-19) الذي يجتاح جميع أنحاء العالم وكذلك أستراليا، ونجد في هذا القانون تحفيزاً ودعمًا للنشاط الاقتصادي، ويسعى في المقام الأول إلى منع تصفية وإفلاس الشركات التي تعاني من ضائقة مالية قصيرة الأجل، وفيه كذلك حماية لمجلس إدارة الشركات من المسؤولية الشخصية المحتملة؛ من أجل تحفيز استمرار التجارة في ظل تلك الجائحة، وتمتد تدابير الإغاثة المؤقتة كذلك إلى الأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية.

وفيما يتعلق بنظام الإفلاس الأسترالي، أدخل القانون بعض التغييرات الهامة على القوانين ذات الصلة على النحو الآتي:

١ - الإغاثة المؤقتة:

في مسار الحياة العادي، يمكن للدائن بموجب (المادة ٤٥٩هـ) من قانون الشركات الأسترالي أن يقوم بتوجيه إخطار ضد إحدى الشركات المدينة له يطالبها بسداد دين لا يقل عن (ألفي دولار) (الحد الأدنى القانوني) المستحق حالياً والواجب الدفع عقب تلقي الشركة لهذا الإخطار، وستصبح هناك مدة (واحد وعشرين يوماً) لدى الشركة لدفع المبلغ الذي يطلبه الدائن، أو التوصل إلى اتفاق مع الدائن حول الدين بما يرضي الدائن، أو التقدم بطلب إلى المحكمة ذات الاختصاص للمنازعة حول هذا المبلغ.

وفي حالة إذا لم تقم الشركة بالاستجابة والرد على الإخطار في غضون (واحد وعشرين يوماً)، فسيفترض أنها متعثرة، ويمكن للدائن تقديم طلب إلى المحكمة لإغلاق الشركة وتعيين مصفٍ للشركة.

وخلافاً لما سبق، وفي ضوء التعديلات المؤقتة سستتم زيادة الحد الأدنى لمبلغ الدين المستحق على الشركة والمطلوب دفعه للدائن كي يتمكن الدائن من بدء اتخاذ إجراءات الإفلاس غير الطوعي ضد المدين من (ألفي دولار) إلى (عشرين ألف دولار)، وهذا يرفع عتبات طلبات الدائنين التي يمكن أن تدفع الشركات إلى الإفلاس.

كما توفر كذلك التعديلات مؤقتاً مزيداً من الوقت للشركات المدينة للرد على إخطار الدائن بسداد الدين، حيث تم تمديد الفترة من (واحد وعشرين يوماً) إلى (سنة أشهر)، وبذلك يتم تمديد الإطار الزمني الذي تتم فيه حماية الشركة المتعثرة من اتخاذ إجراءات الإفلاس من قبل الدائن مؤقتاً بعد توجيه إخطار من الدائن لتقديم التماس من الشركة بالرد.

ومن خلال ما سبق، نجد أنه تتم الإغاثة المؤقتة للأفراد والشركات المتعثرة مالياً لتجنب حالات الإفلاس غير الضرورية، وبذلك يصبح توفر التعديلات القانونية الجديدة شبكة أمان لمساعدة الشركات على الاستمرار في العمل بدلاً من الدخول في التصفية الطوعية، وذلك من خلال منحها فترة مؤقتة لتدبير أمورها، وكذلك لمساعدتها في إدارة الديون، وتجنب الإفلاس.

٢ - إعفاء مؤقت لمجلس الإدارة من واجب منع التداول المعسر:

في الظروف العادية، بموجب قانون الشركات الأسترالي، على مجلس إدارة الشركة الالتزام بالامتناع عن التداول أثناء الإفلاس، ولذلك فقد يكون المجلس مسؤولاً شخصياً عن الديون التي تتكبدها الشركة في حالة تداولها أثناء الإفلاس، ويمكن أن يؤدي هذا إلى جعل مجلس إدارة الشركة مسؤولاً شخصياً عن ديون الشركة بعد مجرد الشك في تحقق إفلاس الشركة، ولم يحم بتقديم طلب لإفلاس الشركة.

وخلافاً لما تقدم، توفر التعديلات القانونية راحة مؤقتة (ملاذاً آمناً) لمجلس الإدارة من واجباته الشخصية، وذلك لمنع التجارة المعسرة، حتى يتم تحقيق الراحة المؤقتة من خلال تعليق الالتزام على مجلس الإدارة بموجب قانون الشركات بمنع التداول المعسر في حالات الإفلاس، حيث يعد في تلك الحالة تكبد الديون من ضمن السياق العادي لأعمال الشركة خلال الفترة من ٢٤ مارس ٢٠٢٠ إلى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠، وهذا يصل إلى فترة (ستة أشهر).

وينطبق (الملاذ الآمن) على جميع مجالس إدارة الشركات داخل أستراليا، وبالتالي فيجوز للمجلس الاعتماد على الملاذ الآمن المؤقت الجديد فيما يتعلق بالديون التي تتكبدها الشركة، وذلك بالشروط الآتية:

- أ - تكبد الدين في السياق العادي لأعمال الشركة.
 - ب - تكبد الدين خلال فترة (الستة أشهر) التي تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه تطبيق القانون الجديد، أو لفترة أطول على النحو الذي سيتم النص عليه في اللوائح.
 - ج - يتم تكبد الديون قبل تعيين مصفٍّ للشركة.
- وفي حالة توافر تلك الشروط، يعد تحمل المجلس للدين في سياق العمل العادي، إذا كان من الضروري تسهيل استمرار العمل خلال فترة الستة أشهر التي تبدأ عند بدء تطبيق القانون، وبذلك يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، اقتراض مجلس الإدارة القروض لنقل بعض الصفقات التجارية، ويمكن أن يشمل كذلك الديون المتكبدة من خلال الاستمرار في دفع الرواتب للموظفين خلال جائحة (COVID-19).

هذا ويجب أن يدرك مجلس إدارة الشركة أن إجراءات الملاذ الآمن المؤقتة لا توفر إعفاء من واجبات مجلس الإدارة المستحقة للشركة نفسها وللأطراف الأخرى بموجب أحكام أخرى من قانون الشركات، وبموجب القانون العام، وبناءً على ذلك، يجب على المجلس الاستمرار في التخفيف من مخاطر وقوع الشركة في الإفلاس من خلال اتخاذ خطوات معقولة لمواجهة الأزمة المالية الحالية والمستمرة للشركة، وكذلك تقييم مدى أثر تكبد الشركة بأي ديون أخرى.

هذا وإن إجراءات الإغاثة المؤقتة لا تؤثر على مسؤولية الشركة في سداد الديون التي تتكبدتها أثناء فترة (الملاذ الآمن).

ويثار التساؤل حول دور وزير المالية الأسترالي في زمن تلك الجائحة، فمن أجل توفير المزيد من اليقين التنظيمي والمرونة للاستجابة لوضع جائحة فيروس (COVID-19) المستجد، يمنح التعديل التشريعي الجديد لوزير المالية سلطة مؤقتة لتعديل أحكام قانون الشركات، أو للتخفيف من الالتزامات القانونية أو تعديلها، وسيكون لوزير المالية سلطة صنع الأدوات هذه لمدة ستة أشهر، وأي أداة سيقورها وزير المالية بموجب هذه السلطة ستطبق لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ صدور قرار منه بها.

بالإضافة إلى ما سبق، قد أشارت الحكومة الأسترالية إلى أن مكتب الضرائب الأسترالي سوف يصمم الحلول لمجالس إدارة الشركات أو لرجال الأعمال الذين يعانون من ضائقة مالية بسبب جائحة فيروس (COVID-19)، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمدفوعات أو التأجيلات، ووقف إجراءات التنفيذ لإنهاء الشركات.

هذا ومن المأمول، أن تمنح تدابير الإغاثة المقترحة الشركات الثقة لمواصلة التجارة؛ بهدف العودة إلى قابليتها للبقاء بمجرد انتهاء أزمة (COVID-19).

ومن خلال ما تقدم، نجد أنه من المؤكد أن هذه الإصلاحات ستوفر الإغاثة اللازمة بشدة في تخفيف عبء قيود التدفق النقدي على الشركات، وتقليل المخاطر المباشرة المرتبطة بتكبد الديون، أو تأجيل السداد في وقت الأزمة تلك، ومع ذلك فإنه يعرض الدائنين الذين يستمرون في قبول الائتمان رغماً عنهم لمخاطر أعلى؛ نتيجة عدم دفع الديون المستحقة أو تأجيل الدفع لفترة ممتدة، وهذا قد سيزيد من الضغط على هؤلاء الدائنين، وقد يؤدي إلى إنهاء الدائنين لاتفاقيات التوريد مع الشركات المتعثرة، أو تشديد شروط الائتمان بين الشركات، أو مطالبة الدائنين بضمان المديونية في المستقبل، سواء عن طريق ضمانات مجلس الإدارة أو غيرها من أدوات الأمن.

رابعاً - في دولة ألمانيا الاتحادية^(١٧):

بسرعة غير مسبوقة، تم اقتراح تشريعي من قبل الحكومة الفيدرالية الألمانية في ١٦ مارس ٢٠٢٠ بتعليق مؤقت لرفع دعوى الإفلاس ضد الشركات المتضررة من جائحة فيروس (COVID-19)، وذلك حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، وقد مرت جميع المراحل التشريعية من قبل المجلس الاتحادي على وجه السرعة، وصدر قانون بالمقترح، وأصبح ساري المفعول بعد التصديق عليه من قبل (الرئيس الاتحادي)، ونشره في الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي، وذلك للتخفيف من آثار تلك الجائحة، وقد دخل القانون حيز التنفيذ بأثر رجعي، وذلك اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٠، وكان يهدف في المقام الأول إلى حماية الشركات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة تلك الجائحة، هذا ويتضمن القانون تعليقاً مؤقتاً للالتزام بتقديم ملف الإفلاس من قبل الشركات المتعثرة، وكذا تعليقاً لحق الدائن في طلب اتخاذ إجراءات الإفلاس لأسباب الإفلاس التي حدثت بعد ١ مارس ٢٠٢٠.

هذا وقد كان الوضع في الأمور العادية، أنه يقع في الأساس التزام قانوني على الشركة المتعثرة بتقديم ملف الإفلاس، فتكون ملتزمة بتقديم طلب لفتح إجراءات الإفلاس دون تأخير لا مبرر له، بعد انعدام السيولة (يحدث انعدام السيولة إذا كان المدين غير قادر على الوفاء بالتزاماته بالدفع عند استحقاقها، ويفترض انعدام السيولة

(١٧) Joss Hargrave, Nicolas Morelli, Lyle Abel, Cedric Berckmans, John Shi, ubom?r Bre?ka, Casper Moltke-Leth, Kristiina Lehtil?, Celine Nezet, Dr. Dirk Barcaba, d?m Boross, Nipun Gupta, Matteo Meroni, Adam Kowalczyk, Ken Cheung, Alfonso Carrillo Cano, Mattias Lindberg, René Rieter, Lucas Pitts, Jordan Cooper, COVID-19: International Restructuring & Insolvency Update, 03-2020, Available at (<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/covid-19-international-r-and-i-briefing>), (3/4/2020), Peter Hoegen, Dr Franz Bernhard Herding, Dr Sven Prüfer, Dr Walter Uebelhoer, Dr Christopher Kranz, Covid-19 pandemic: Temporary suspension of the obligation to file for insolvency proceedings, 31 March 2020, available at (file:///C:/Users/PC_2018/Desktop/Snapshot-Covid19-Temporary-suspension-of-obligation-to%20file-for-insolvency-proceedings-310320.pdf), (5/4/2020), Frank Grell, Dr. J?rn Kowalewski, Dr. Ulrich Klockenbrink, Legal Update - Remedy for Managing Directors in Times of COVID-19: Suspension of insolvency filing obligations and limitation of liability risks in Germany, March 22, 2020, available at (<https://www.lathamgermany.de/2020/03/legal-update-remedy-for-managing-directors-in-times-of-covid-19-suspension-of-insolvency-filing-obligations-and-limitation-of-liability-risks-in-germany/>) (29/3/2020).

بشكل عام إذا توقف المدين عن تسديد المدفوعات) أو الإفراط في المديونية (ويصبح المدين مديناً للغاية إذا كانت أصول المدين لم تعد تغطي المستحقات الحالية، ما لم تكن الاستثمارية في العمل بالنسبة للمدين محتملة في الغالب " ما يسمى توقعات الاستثمارية الإيجابية ") (القسم ١٥ الفقرة الأولى من قانون الإفلاس الألماني التزام التسجيل)، فيجب على الممثلين القانونيين للشركة التقدم بطلب للإفلاس دون تأخير يمكن أن تترتب عليه الإدانة، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير (القسم ١٥ "أ" من قانون الإفلاس الألماني)، لا يجوز تجاوز فترة الثلاثة أسابيع للالتزام بتقديم ملف الإفلاس إلا إذا كان بإمكان مجلس الإدارة افتراض احتمالية كافية لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى إفلاس الشركة بعد هذه الفترة، عن طريق (القروض الجديدة، أو مساهمات المساهمين، أو تأجيل التزامات السداد المستحقة) ومن المرجح أن تستوفي العديد من الشركات الآن معالجة متطلبات الإفلاس هذه بسرعة كبيرة.

وبالتالي فالالتزام التسجيل للقرارات والمناقشات يعد واجباً شخصياً على جميع الممثلين القانونيين للشركة (وعادة ما يتمثلون في رئيس مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة)، وفي حالة عدم القيام بإجراءات التسجيل، تكون المسؤوليات الشخصية، والعقوبات الجنائية، وشيكة الوقوع على هؤلاء الممثلين القانونيين.

وفي ظل الوضع العادي، يكون من حق الدائنين للشركات التي تواجه حالات تخلف عن سداد المدفوعات التقدم للمحكمة بطلب اتخاذ إجراءات الإفلاس بالنسبة للشركات التي ليس لديها سيولة نقدية، أو مثقلة بالديون، شريطة أن يكون لديهم مصلحة قانونية في فتح إجراءات الإفلاس، وأن يوضح في طلبهم سبب الافتتاح الذي يرضي المحكمة، (القسم ١٤ من قانون الإفلاس الألماني).

وبالنسبة للوضع في ظل القانون الجديد، فإنه يتم تعليق التزام الشركات المتعثرة، وكذلك تعليق حق الدائنين للشركات التي تواجه حالات تخلف عن سداد المدفوعات، في تقديم دعوى الإفلاس، وذلك حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، وبما أنه من غير المتوقع حتى الآن معرفة مدة الوقت الذي سيعتمد فيه الاقتصاد الألماني على تعليق كل من الالتزام بتقديم ملف الإفلاس وحقوق الدائنين في تقديم طلب الإفلاس، سوف يتم تمديد التعليق حتى ٣١ مارس ٢٠٢١، إذا بدا ذلك ضرورياً بسبب استمرار الشركات في الطلب على المساعدة العامة المتاحة، أو استمرت في الوجود صعوبات التمويل، أو ظهرت ظروف أخرى، وبالتالي يمكن تغيير هذا الموعد النهائي إذا استمرت الجائحة بعد هذا التاريخ.

هذا ولا يجوز الاحتجاج بتعليق الالتزام بتقديم طلب الإفلاس إلا من قبل الممثلين القانونيين للشركة الذين ينجحون في إثبات شرطين رئيسيين، وهما على النحو الآتي:

١ - يجب أن يستند سبب الإفلاس إلى آثار جائحة فيروس (COVID-19) (وليس لأسباب أخرى)، ويمكن التحقق من أن الأزمة المالية للشركة كانت نتيجة سبب تلك الجائحة من خلال إثبات أن الشركة كانت في حركة ونشاط، وليست في حالة ركود في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، ويكون ذلك من خلال البيانات المالية للشركة السنوية اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وينص القانون الجديد على افتراض ذلك في الشركات، ما لم يثبت العكس من قبل الدائنين، وبمفهوم المخالفة لا ينطبق تعليق التزام الشركة بتسجيل الإفلاس إذا ثبت إن إفلاس الشركة لم ينجم عن آثار تلك الجائحة.

٢ - يجب أن تكون هناك أسباب حقيقية للقضاء على أي حالة من نقص السيولة المتوفرة، بحيث يجب أن يكون هناك احتمال للقضاء على عدم السيولة، وبالتالي ووفقاً لمفهوم المخالفة لا ينطبق تعليق التزام التسجيل إذا كانت هناك أسباب تؤهل الشركة للقضاء على نقص السيولة.

ويثار التساؤل حول مدى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن تقديم طلب الإفلاس في زمن تلك الجائحة، فنجد أنه في الوضع الطبيعي كانت المسؤولية المدنية تقع على عاتق المجلس طبقاً لقانون الشركات الألماني، وكذا المسؤولية الجنائية طبقاً للقانون الجنائي الألماني، بالإضافة إلى تلك المسؤوليات، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركات في حالة عدم توافر السيولة النقدية أو في حالة المديونية المفرطة يتعرضون لمخاطر مسؤولية كبيرة عن المدفوعات التي تتم، وبالتالي فإنهم يصبحون ملتزمين بتعويض شركاتهم عن المدفوعات التي تم دفعها بعد أن أصبحت الشركة معسرة، أو بعد أن أصبحت المديونية أكثر من اللازم، ما لم تكن المدفوعات متوافقة مع العناية الواجبة لرجل الأعمال الحذر الفطين (قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، قانون شركة الأوراق المالية)، ويبدو في كثير من الأحيان هذا الأمر مشكوكاً فيه.

لكن الوضع في قانون جائحة (COVID-19) الجديد، خلاف ما تقدم، فقد تم النص فيه على تعليق تلك المسؤوليات؛ بحيث يمكن حماية مجلس إدارة الشركة، ولا يكون مجلس الإدارة مسؤولاً، والهدف من ذلك يتمثل في الآتي:

أ - مساعدة مجلس الإدارة على إدارة الآثار المدمرة لتلك الجائحة على حالة عدم توفر السيولة النقدية للعديد من الشركات، وتجنب المزيد من العواقب الاقتصادية

والتجارية السلبية على خلفية نظام الإفلاس، وكذلك للحد من مخاطر مسؤولية مجلس الإدارة.

ب - منع مجلس إدارة الشركات المتضررة من تلك الجائحة من إيقاف المدفوعات، لتجنب المسؤولية الشخصية المحتملة، والتي بدورها سيكون لها تأثير سلبي على حالات سيولة الدائنين، حيث إن تعليق الالتزام بتقديم ملف الإفلاس مصحوب بقيود كبيرة على مخاطر المسؤولية عن المدفوعات في حالة عدم السيولة أو المديونية الزائدة، وبالتالي فإن المدفوعات التي تتم في سياق العمل العادي، ولا سيما المدفوعات التي تعمل على الحفاظ على العمليات التجارية أو استئنافها أو تنفيذ مفهوم إعادة الهيكلة، تعتبر الآن متوافقة مع الرعاية الواجبة (لرجل أعمال عاقل فطن) إلى الحد الذي تم تعليق الالتزام بتقديم ملف الإفلاس.

وكنتيجة منطقية لما تقدم، يتم إعفاء الممثلين القانونيين للشركة (مجلس الإدارة) من المسؤولية المدنية طبقاً لقانون الشركات الألماني والمسؤولية الجنائية طبقاً للقانون الجنائي الألماني، التي تكون نتيجة عدم تقديم الممثل القانوني للشركة لطلب الإفلاس على الرغم من عدم توافر السيولة المالية للشركة، أو في حالة إذا كانت المديونية مفرطة، وذلك (للأشهر الثلاثة المقبلة)، وكذا يُلغى حق الدائنين في طلب فتح إجراءات الإفلاس للشركات التي تستند إلى ظروف الجائحة التي حدثت عقب ١ مارس ٢٠٢٠.

ويثار التساؤل حول الغرض من القانون الجديد، ويرجع الغرض من هذا القانون كما جاء على لسان أحد المسؤولين الألمان بأنه (نريد من خلال هذا القانون منع الشركات من الاضطرار إلى تقديم طلب الإفلاس، لسبب وحيد يتمثل في أن المساعدة التي تقدمها الحكومة الفيدرالية لا تصل إليهم في الوقت المناسب، فمن المحتمل ألا يكون تمويل الدولة الموعود منها أو من غيرها من مؤسسات التمويل الحكومية (الفيدرالية) - متاحاً في غضون ثلاثة أسابيع، حيث عدد الشركات المتأثرة بالجائحة كبير للغاية، وتوفير الأموال معقد للغاية، وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التمويل والبنوك المشاركة عددها محدود بسبب تلك الجائحة، وكذا فترة الثلاثة أسابيع العادية من قانون الإفلاس قصيرة جداً بالنسبة لهذه الحالات، ومن خلال هذه الخطوة، نساعد في تخفيف آثار تفشي جائحة فيروس (COVID-19) على الاقتصاد الوطني)، وبذلك يظهر الغرض من أحكام هذا القانون الجديد في تجنب الإفلاس والتخفيف عن كاهل الشركات من أجل تسهيل مشاركة الشركات المتضررة في المعاملات الاقتصادية العامة.

ويبدو أنه من الواضح، أن تعليق التزام التسجيل للإفلاس لا يعفي الشركة من

أي من التزاماتها (التعاقدية) تجاه شركاء الأعمال والموظفين، وما إلى ذلك بالنسبة لبعض أنواع العقود مثل (اتفاقيات التوريد مع المرافق، واتفاقيات القروض، واتفاقيات التأمين، واتفاقيات الإيجار التجاري)، يسري تعليق الالتزام بتقديم طلب الإفلاس بأثر رجعي اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٠.

خامساً - في المملكة المتحدة^(١٨):

أعلن وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والصناعة الاستراتيجية (Alok Sharma) في ٢٨ مارس ٢٠٢٠، أن الحكومة الإنجليزية ستدخل عدداً من التغييرات على نظام الإفلاس في إنجلترا، الغرض منها تمكين الشركات التي تأثرت سلباً نتيجة تفشي جائحة فيروس (COVID-19) من مواصلة تداولها على الوجه المعتاد، ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن التغييرات حتى وقتنا الحالي، حيث لم تفصح الحكومة بعد، عن موعد إدخال التغييرات للبرلمان، ولكن من الممكن أن يتم البدء في سنّها على وجه السرعة، عندما يعيد البرلمان اجتماعه مرة أخرى، ولذلك فإنه ليس من الواضح متى سيتم سن القانون الجديد بشأن الإفلاس، أو مدى مقدار المراجعة الذي سيتم منحها للتعديلات القانونية، وذلك نظراً لتعليق العمل بالبرلمان حالياً لفترة غير محددة.

ويثار التساؤل حول ما يعتقد إدخاله من تغييرات على القانون، فنجد أن هناك عدة اعتقادات منها الاعتقادات الآتية:

- ١ - يعتقد أن التغييرات ستشمل على نطاق واسع تعليق تطبيق قانون الإفلاس لعام ١٩٨٦ اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٠ لمدة أولية مدتها ثلاثة أشهر (يتم تمديدها إذا لزم الأمر)، وسيتم تطبيق نظام إعادة هيكلة جديد يعرف باسم (الوقف الإجباري لإجراءات الإفلاس)، تم تصميمه لأجل الآتي:
- أ - منع الدائنين من اتخاذ إجراءات الإفلاس، في وقت ما تسعى الشركة إلى إنقاذ نفسها من الخسائر أو إعادة هيكلة ديونها.

(١٨) Andrew Foster, Duncan Lockhart, Andrew Ramsden, Tristan Cox, COVID-19 UK: Prospective changes to insolvency law (England and Wales), 02 April 2020, Available at (<https://www.clydeco.com/insight/article/covid-19-uk-prospective-changes-to-insolvency-law-england-and-wales>), (15/4/2020), Liam Preston, Paul Keddie, Covid-19 proposed changes to UK insolvency laws, 08 April 2020, Available at (<https://www.macfarlanes.com/what-we-think/in-depth/2020/covid-19-proposed-changes-to-uk-insolvency-laws/>), (16/4/2020).

ب - السماح للشركة بمواصلة توريد البضائع والخدمات الضرورية لمواصلة التجارة.

ج - قيام قضاة محكمة الإفلاس والشركات على وجه السرعة بالآتي:

- تأجيل جميع الجلسات المتعلقة بالطلبات غير العاجلة التي تم تقديمها بموجب تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بشأن المديونات التي تكون مستحقة على الشركات.

- تحديد جلسات استماع افتراضية فيما يتعلق بجميع التماسات الأحكام الصادرة بشأن الإفلاس، والتي صدرت عن بعد.

هذا وإن الوقف سيكون لمدة تصل إلى (تسعين يوماً)، والذي سيمنح للشركات التي تواجه عدم توافر السيولة النقدية المرتبطة بجائحة فيروس (COVID-19)، وبالتالي يمنح هذا الوقف الشركات المتعسرة مساحة من التنفس للبحث عن وسائل لإنقاذ نفسها، أو إعادة هيكلة ديونها، وكذا منع الدائنين من فرض الديون خلال تلك الفترة، وإمكانية حصول الشركات على المساعدات، والقدرة على الحصول على قروض جديدة خلال الوقف الاختياري للقدرة على الاستمرارية في التداول.

٢ - يعتقد أن التغييرات القانونية يجب أن يكون من ضمنها تعليق عدم مشروعية التداول غير المشروع، حيث سيتم تعليق مؤقت لأحكام التداول غير المشروعة لمجلس إدارة الشركة، فبموجب المادة ٢١٤ من قانون الإفلاس لعام ١٩٨٦ (القانون)، يجوز للمحكمة أن تعلن أن مجلس إدارة الشركة مسؤول شخصياً عن دفع التعويضات إذا كانت الشركة قد دخلت في تصفية معسرة، وفي وقت ما قبل ذلك، كان المجلس يعرف أو كان يجب أن يعرف أنه لم يكن هناك احتمال معقول أن تتجنب الشركة التصفية المعسرة، ولم يتخذ كل الخطوات الضرورية لتقليل الخسائر المحتملة بدائني الشركات، وينشأ التداول غير المشروع عندما يبدو أثناء التصفية أو الإفلاس، أن مجلس إدارة الشركة كان يعرف أو كان يجب أن يكون قد خلص قبل التصفية إلى أنه لا يوجد احتمال معقول لتجنب هذا التصفية، ولكن مع ذلك استمرت الشركة في التجارة، في ظل هذه الظروف، ويمكن للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر بأن يطلب من مجلس إدارة الشركة المساهمة في مديونية الشركة، وبالتالي يمكن تحسين الوضع العام للدائنين.

في حين أنه في ظل التغييرات لن يكون من الممكن معاقبة مجلس الإدارة

بالمساهمة في حوزة معسرة عن الخسائر الناجمة في (١ مارس ٢٠٢٠)، هذا وقد لا تكون النتائج العملية لهذا التغيير كبيرة، حيث إن السوابق القضائية الحالية بشأن (التجارة غير المشروعة) توفر بالفعل الحماية لمجلس إدارة الشركة في الظروف التي يكون فيها للأحداث الاقتصادية غير المتوقعة تأثير عميق على السوق التي تعمل فيها الشركة المتعثرة، وخلصت المحكمة في إحدى القضايا إلى أنه (لا يمكن انتقاد مجلس الإدارة لعدم توقعه التأثير الكامل لعامل مالي غير مؤكد)، خاصة عندما لا يمكن توقع مدة الانكماش الاقتصادي التي قد تسببها تلك الجائحة.

هذا وقد كانت المسؤولية المحتملة عن التداول غير المشروع مجالاً خصباً للبحث منذ بدء تفشي تلك الجائحة، حيث قد تتسبب في توقف مجلس الإدارة عن التداول، أو كذلك ستجعله يتعجل في تقديم إجراءات الإفلاس، وتجعله يتقدم بها بشكل استباقي كوسيلة لتجنب المسؤولية المحتملة، وبالتالي، فإن تعليق الأحكام سيوفر وضوحاً للمجلس حول هذه النقطة على الأقل، وقد تم الترحيب بذلك من قبل الهيئات الصناعية بما في ذلك اللجنة الفرعية للإفلاس التابعة لجمعية القانون بمدينة لندن (CLLS).

وخلافاً لما تقدم، في حين إنه إذا كان سيتم تعليق التداول غير المشروع، ستظل واجبات مجلس الإدارة المختلفة التي تم تدوينها بموجب قانون الشركات لعام ٢٠٠٦ سارية، وكذلك الأحكام الأخرى التي تخلق أسباباً للمطالبات مثل الأفضليات بالنسبة لبعض الدائنين، والمعاملات بأقل من القيمة، والمعاملات التي يتم فيها التحايل على الدائنين، من المرجح أن نفس السلوك والظروف التي من شأنها (عادة) أن تؤدي إلى المعاقبة على التجارة غير المشروعة ستؤدي أيضاً إلى فرض جزاء عن الإخلال بتلك الواجبات؛ لذلك قد لا يمنح التعليق المقترح لمجلس إدارة الشركة حماية إضافية (إن وجدت) من المسؤولية الشخصية أكثر من تلك الموجودة بالفعل، ويبدو من الضروري أن يستمر المجلس في التفكير بشكل صحيح، في اجتماعات مجلس الإدارة العادية، وتوثيق قراراته أثناء التداول، مستشهدين بها (حيثما كان ذلك مناسباً)، وكذلك بتفاصيل المشورة التي تم تلقيها من الخبراء المحترفين قبل اتخاذ القرارات.

وبناءً على إعلان الحكومة، تم تعليق الأحكام لجميع الشركات بلا استثناء، بدلاً من تلك التي تأثرت بشكل خاص بالجائحة فقط، ولذلك فقد تكون هناك بعض المخاطر من إساءة استخدام الشركات للإجراء من خلال الاستمرار في التداول، على الرغم من الأداء الضعيف غير المرتبط بجائحة فيروس (COVID-19)، والتسبب في خسائر كبيرة للدائنين من خلال القيام بذلك، ولكن مع ذلك سيظل الدائنون يتمتعون بدرجة من الحماية

على أساس أن أعضاء المجلس سيظلون خاضعين لأحكام تجارية احتيالية بموجب قانون الشركات بالإضافة للاضطراب إلى الامتثال لواجباتهم الائتمانية كمديرين (مما يتطلب منهم مراعاة مصالح الدائنين، بدلاً من المساهمين، حينما تكون الشركة معسرة أو تقترب من الإفلاس). وقد تمنع هذه الأحكام سوء المعاملة، ولكنها تعني أيضاً أنه حتى مجلس الإدارة صاحب النية الحسنة يجب ألا يفترض تعليق الأحكام.

٣ - ومن المتوقع أن يعكس النظام المقترح إجراءً تم تحديده في تقرير حكومي بعنوان (الإفلاس وحوكمة الشركات)، والذي تم نشره في أغسطس ٢٠١٨ بعد استشارة حول التغييرات المقترحة لنظام الإفلاس في إنجلترا، والسمة الرئيسية لهذا الإجراء تتمثل في القدرة على وقف سداد الديون باستخدام إعادة الهيكلة خارج المحكمة يشرف عليها ممارس الإفلاس (بمثابة مراقب).

ويجب اعتماد ذلك الإجراء؛ لأنه قد يستغرق إدخال نظام جديد في الظروف الحالية بعض الوقت، وقد تم تصور هذا الإجراء خلال ظروف اقتصادية مختلفة إلى حد كبير، وعادة ما يتطلب تنفيذه تدقيقاً برلمانياً.

وأخيراً، تشير مذكرة إحاطة من مجلس العموم البريطاني تم نشرها في ٣١ مارس ٢٠٢٠ إلى إمكانية إدخال أحكام (التضييق عبر الفئات) بالإضافة إلى التغييرات المشار إليها أعلاه، والتضييق يعني تنفيذ وفرض مقترحات إعادة الهيكلة، على الرغم من أن مجموعة أقلية أو فئة من الدائنين أو المساهمين صوتوا ضد ذلك.

سادساً - في دولة سنغافورة^(١٩):

قام البرلمان السنغافوري في ٧ أبريل ٢٠٢٠، بتمرير قانون (الإجراءات المؤقتة) لمواجهة جائحة فيروس (COVID-19)، وقد دخل القانون حيز التنفيذ على الفور، وقد تم البدء في تطبيقه في اليوم نفسه ٧ أبريل ٢٠٢٠.

وهذا القانون يوفر راحة مؤقتة للشركات المتعثرة والأفراد غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بسبب تلك الجائحة، واشتمل كذلك على تعديلات مؤقتة لقوانين الإفلاس، وذلك نظراً لتلك الظروف الاستثنائية التي تسببها هذه الجائحة.

(١٩) Ian Roberts, Prakash Pillai, Joel Harris, COVID-19 Singapore: Guide to (Temporary Measures) Act 2020, Available At (<https://www.clydeco.com/insight/article/covid-19-singapore-guide-to-temporary-measures-act-2020>), (20/4/2020), Farhana Sharmeen, Marc Jia Renn Tan, Relief in the Time of COVID-19 - Temporary Measures, April 14, 2020, Available at (<https://www.globalfinregblog.com/2020/04/relief-in-the-time-of-covid-19-temporary-measures/>), (22/4/2020).

ويسري هذا القانون بأثر رجعي ويغطي الالتزامات التعاقدية التي يتعين القيام بها في ١ فبراير ٢٠٢٠، أو بعد هذا التاريخ، وكذلك العقود المبرمة أو المجددة قبل ٢٥ مارس ٢٠٢٠، وتطبق تلك التدابير بموجب القانون لمدة (سنة أشهر) ويمكن تمديدتها لمدة ستة أشهر إضافية أخرى بخلاف (الفترة المقررة).

هذا ولم يكن القصد من القانون إبراء أو إلغاء الالتزامات التعاقدية للأطراف الدائنة ولكن تعليقها للفترة المحددة.

وسيكون بالتأكيد لقانون (التدابير المؤقتة) تأثير كبير على تنفيذ بعض العقود والنزاعات التجارية في سنغافورة لمدة قد تصل من (٦ إلى ١٢ شهراً)، والتدابير الرئيسية للقانون تتمثل في الآتي:

١ - تتمثل في إعفاء مؤقت من الإفلاس الذي ينتج من عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، بموجب عقود معينة، إذا كان سبب عدم القدرة مادياً يتمثل في جائحة (COVID-19).

٢ - تغييرات مؤقتة في قوانين الإفلاس لزيادة عتبات الديون المستحقة والموجبة للإفلاس، وإعطاء شبكة أمان للسماح للشركات بمواصلة التجارة بينما من الناحية الفنية تعد في حالة إفلاس.

ويثار التساؤل حول طبيعة تلك التدابير، فنجد أنها تتمثل في تجميد اتخاذ الإجراءات القانونية للإخلال بتنفيذ عقود معينة لمدة الستة أشهر المقبلة، وربما حتى الاثنى عشر شهراً القادمة، وتنص تلك التدابير أيضاً على آلية ملزمة لتسوية المنازعات للتأكد من أن الأطراف المتعاقدة لا تسيء استخدام هذا النظام.

وأن هذه التدابير تهدف فقط إلى أن تكون مؤقتة ولن تؤدي إلا إلى تجميد الحقوق والالتزامات القانونية السارية أثناء سريان القانون، والسماح ببدء الإجراءات إذا لزم الأمر بعد أن يتم التحكم في وضع جائحة (COVID-19).

ويثار التساؤل حول الأثر القانوني لتلك التدابير، فنجد أنه يجب على الشركات المتعسرة المضي قدماً في توجيه إخطار بالتدابير القانونية الجديدة، لجميع الأطراف الدائنة لها، وإذا تم توجيه الإخطار بالإغاثة للطرف الدائن، فإنه يمتنع على الطرف الذي تم توجيه الإخطار إليه القيام بالأمر الآتي:

- أ - اتخاذ إجراءات الإفلاس ضد الشركة المتعثرة أو الضامن لها.
- ب - متابعة أي إجراءات في المحكمة أو إجراءات تحكيم ضد الشركة المتعثرة أو الشخص الضامن لها.

- د - السعي لاستعادة البضائع بموجب عقد إيجار، أو عقد بيع.
- هـ - إنهاء عقد إيجار للممتلكات غير المنقولة لعدم دفع الإيجار.
- و - أي إجراء لتنفيذ حكم قضائي أو قرار تحكيم أو حكم بموجب قانون التنفيذ.
- ومن خلال ما سبق، نجد أن القانون يوفر راحة مؤقتة للشركات والأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية من خلال جائحة (COVID-19)، وذلك بإدخال بعض من التعديلات على قوانين الإفلاس في سنغافورة، كما سيتم تحرير مجلس إدارة الشركة مؤقتاً من التزامه بالامتناع عن التداول أثناء الإفلاس إذا تم تكبد الشركة بالديون في خلال الفترة التي يكون فيها القانون ساري المفعول، ومع ذلك سيظل مجلس الإدارة مسؤولاً جنائياً إذا تم تكبد الديون من خلال استعمال الطرق الاحتياطية.
- وأهم ما يجب ملاحظته، أن تلك الإجراءات مؤقتة فقط، وستتوقف إما عندما ينتهي القانون خلال عام واحد، أو إذا تم إلغاء القانون في وقت سابق، كما أنه بشكل عام لا يؤثر القانون على الالتزامات التعاقدية الأساسية، حيث يتم فقط تجميد الحق في تنفيذ تلك الالتزامات لفترة من الزمن.
- وللوقاية من التعليق لتنفيذ الالتزامات غير العادل، سيتم تعيين المهنيين مثل (المحاسبين والمحامين) من قبل وزارة القانون كمقيمين، لتقرير ما إذا كان عدم القدرة على أداء الالتزامات التعاقدية ناتجاً بشكل جوهري عن جائحة فيروس (COVID-19)، وسيكون لديهم السلطات لمنح الإغاثة التي تعد عادلة ومنصفة في مثل هذه الظروف، هذا ولن تستغرق عملية التقييم أكثر من (خمسة أيام) دون أي تكلفة لأي من الطرفين، ولن يسمح لهؤلاء المحامين بتمثيل الأطراف لدى المحاكم، وستكون قرارات المقيمين نهائية وغير قابلة للاستئناف.
- وكذلك يعدل التشريع الجديد قوانين الإفلاس في سنغافورة من خلال زيادة عتبة الدين النقدي للإفلاس للأفراد من (١٥,٠٠٠ دولار سنغافوري) إلى (٦٠,٠٠٠ دولار سنغافوري)، وكذلك زيادة عتبة الدين النقدي للإفلاس للشركات من (١٠,٠٠٠ دولار سنغافوري) إلى (١٠٠,٠٠٠ دولار سنغافوري) تمديد الفترة القانونية للأفراد والشركات للاستجابة لطلبات الدائنين من (واحد وعشرين يوماً) إلى (سنة أشهر).
- وفي ظل هذا القانون سيحصل مجلس إدارة الشركة كذلك على إعفاء مؤقت من خلال تطبيق الحظر على التداول، بينما تكون الشركة معسرة إذا تم تكبد الديون في سياق العمل العادي، ومع ذلك يظل مجلس إدارة الشركة مسؤولاً جنائياً إذا تم تكبد الديون عن طريق الاحتيال.

وأخيراً، في كلمته أمام البرلمان السنغافوري، أكد (وزير القانون والشؤون الداخلية) أن القانون لا يغير قدسية العقود المبرمة في سنغافورة، وشدد على أن التعديلات القانونية ستكون مؤقتة، وموجهة، وضرورية بالنظر إلى الأثر الضار المحتمل لوجود تنفيذ صارم للحقوق التعاقدية القائمة، كما سيوفر القانون المزيد من الوقت لحكومة سنغافورة لتقييم الوضع الاقتصادي المتطور بشكل أكثر دقة في تقرير ما إذا كان هناك ما يبرر المزيد من التدخلات اللاحقة.

سابعاً - في دولة الدنمارك^(٢٠):

اتفقت الحكومة الدنماركية والبرلمان على برنامج لتغطية بعض التكاليف الثابتة الخاصة بالشركات، وذلك بسبب أن الشركات لم يعد لديها أرباح لتغطية تكاليفها نتيجة لأزمة جائحة (COVID-19).

والبرنامج كان عبارة عن حزمة تعويضات للشركات المتعثرة، ومن خلاله يمكن للشركات الحصول على تعويض عن التكاليف الثابتة الموثقة، مثل الإيجار، والفوائد، وجميع النفقات المرتبطة بالعقد (مثل التأجير)، في الفترة التي تتعرض فيها الشركات لانخفاض كبير في الإيرادات.

هذا ويقوم التعويض على المبادئ الآتية:

- ١ - جميع الشركات التجارية في جميع القطاعات لها الحق في الحصول على التعويض.
- ٢ - يستهدف التعويض في المقام الأول الشركات التي لديها انخفاض كبير في الإيرادات قد يصل إلى (٤٠٪ على الأقل).
- ٣ - يستهدف التعويض التكاليف الثابتة وسيشكل ما بين (٢٥٪ ، ٨٠٪ من التكاليف الثابتة).
- ٤ - سيغطي التعويض ما يصل إلى مدة (ثلاثة أشهر)، ويدفع في أقرب وقت ممكن.
- ٥ - إذا انخفضت الإيرادات بشكل أقل بكثير من المتوقع، فيجب سداد قيمة التعويض.

(٢٠) Joss Hargrave, Nicolas Morelli, Lyle Abel, Cedric Berckmans, John Shi, ?ubom?r Bre?ka, Casper Moltke-Leth, Kristiina Lehtil?, Celine Nezet, Dr. Dirk Barcaba, ?d?m Boross, Nipun Gupta, Matteo Meroni, Adam Kowalczyk, Ken Cheung, Alfonso Carrillo Cano, Mattias Lindberg, Ren? Rieter, Lucas Pitts, Jordan Cooper, COVID -19: International Restructuring & Insolvency Update, 03-2020, Available at (<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/covid-19-international-r-and-i-briefing>), (4/4/2020).

ويثار التساؤل حول قيمة هذا التعويض، فنجد أن قيمة التعويض تحدد طبقاً للأسس الآتية:

أ - تكون قيمة التعويض ٨٠٪ من التكاليف الثابتة إذا كان الانخفاض في الإيرادات ٨٠٪ - ١٠٠٪.

ب - تكون قيمة التعويض ٥٠٪ من التكاليف الثابتة إذا كان الانخفاض في الإيرادات ٦٠٪ - ٨٠٪.

ج - تكون قيمة التعويض ٢٥٪ من التكاليف الثابتة إذا كان الانخفاض في الإيرادات ٤٠٪ - ٦٠٪.

وبخلاف ما سبق، فإنه سيتم تعويض الشركات التي تم منعها من مباشرة نشاطها في زمن تلك الجائحة بنسبة (١٠٠٪ من تكاليفها الثابتة).

وبخلاف التعويض الممنوح من الدولة، فقد وضعت الحكومة خطة بالنسبة للقروض المضمونة من الدولة، للشركات الكبيرة وكذلك الصغيرة والمتوسطة، فبالنسبة للشركات الكبيرة (التي تضم أكثر من ٢٥٠ موظفاً أو تزيد إيراداتها عن ٥٠ مليون يورو)، سيتم رفع حد الضمان إلى ما مجموعه (٢٥ مليار كرونة دانمركية)، وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتم تعيين حد الضمان إلى (١٧,٥ مليار كرونة دانمركية).

هذا ويشترط للحصول على القرض الذي تضمنه الدولة، أن تعاني الشركة من خسارة في الإيرادات بحد أدنى ٣٠٪.

ثامناً - في دولة إيطاليا^(٢١):

قد صدر في دولة إيطاليا المرسوم بقانون رقم ٢٣ الصادر في ٨ أبريل ٢٠٢٠

(٢١) Giovanni Fonte, Covid-19 in Italy: LiquiditÁ Decree dedicates articles to insolvency procedure, 16 April 2020, Available at (<https://www.roedl.com/insights/covid-19/italy-liquidita-decree-insolvency-procedures>), (20/4/2020), Stefano Parlatore, Daniele Geronzi, Daria Pastore, Luca Autuori, Giandomenico Ciamarella, Marialuisa Garavelli, Sara Colombara, New rules on the Italian government's review of investments in Strategic industries at the time of Covid-19 Covid-19 emergency - Italy insolvency and business crisis, APRIL 2020, Available at (https://www.legance.com/wpcontent/uploads/2020/04/Newsletter_COVID-19_emergency_%E2%80%933_Italy_insolvency_and_business_crisis-1.pdf), (22/4/2020), Federico Sutti, Cristian Fischetti, COVID-19: Insolvency measures introduced by Italy's Law Decree no. 23 of April 8, 2020 (the so-called "Liquidity Decree"), published in the Official Gazette and effective as of April 9, 2020, April 10, 2020, Available At (<https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/7/interventions-in-bankruptcy-matters-by-the-liquidity-decree-approved-by-the-council-of-ministers-en>), (23/4/2020).

(ساري المفعول اعتباراً من ٩ أبريل ٢٠٢٠) وهو ما يسمى (بمرسوم السيولة)، وقامت الحكومة الإيطالية من خلاله باعتماد تدابير عاجلة جديدة، من بين تلك التدابير في مجال إفلاس الشركات، الحفاظ على استمرارية أعمال الشركات التي كانت تمارس نشاطها قبل ظهور جائحة (COVID-19)، ثم تأثرت بتلك الجائحة، وكان ذلك من خلال الآتي:

١ - تشمل التدابير المعتمدة تأجيل إصلاح قانون الإفلاس الإيطالي، على النحو المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم ١٤ الصادر في ١٢ يناير ٢٠١٩، والذي كان من المقرر أن يبدأ تنفيذه في ١٥ أغسطس ٢٠٢٠.

وسيتّم بذلك تأجيل دخول قانون الأزمات والإفلاس الجديد حيز التنفيذ إلى ١ سبتمبر ٢٠٢١ (باستثناء بعض القواعد التي أصبحت سارية بالفعل على الفور).

٢ - عدم جواز نظر التماس إفلاس الشركات الكبيرة المودع من قبل الدائنين من ٩ مارس غير قابلة للمقاضاة، وهذا دون اشتراط أن تكون حالة الإفلاس مرتبطة بالطوارئ الوبائية، فستقوم المحاكم برفض طلبات الإفلاس المقدمة فيما بين الفترة ٩ مارس ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وذلك لصدور حكم بإفلاس أو إعسار الشركات الكبيرة بموجب المرسوم التشريعي رقم ٢٧٠ الصادر بتاريخ ٨ يوليو ١٩٩٩، وكان يسمى في تلك الآونة بمرسوم (Prodi-bis).

هذا وتمتد تلك الأحكام إلى جميع طلبات الإفلاس، وبالتالي تشمل الطلبات التي قدمها مجلس إدارة الشركة ذاته؛ وذلك من أجل السماح لأصحاب الشركات الذين يعانون من ضغوط اقتصادية ومالية بتقييم إمكانية وجود أدوات بديلة، وهذا بالتالي سوف يساعدهم على حل أزمة عملهم، مع تجنب التعرض للعواقب المدنية والجنائية المتعلقة بتدهور في حالة الإفلاس الموجودة بالفعل.

الاستثناء الوحيد على القاعدة السابقة، يتمثل في طلبات الإفلاس التي يقدمها النائب العام، مصحوبة بطلب لإصدار تدابير وقائية أو متحفظة لحماية أصول الشركة لا تزال مقبولة، وذلك لتجنب التصرفات المشتتة، بما في ذلك ذات الصلة الجنائية، على حساب الدائنين.

٣ - التسوية مع الدائنين وإعادة التفاوض في اتفاقيات إعادة هيكلة الديون، فقد نص المرسوم بقانون على ما يلي:

أ - فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع الدائنين واتفاقيات إعادة هيكلة الديون، تم تمديد المواعيد النهائية للامتثال لهذه الإجراءات المعتمدة بالفعل، والتي

تبدأ في ٢٣ فبراير ٢٠٢٠، وتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وذلك لمدة (سنة أشهر).

ب - التسوية مع الدائنين أو اتفاقيات إعادة هيكلة الديون التي تكون إجراءات التحقق من صحتها معلقة اعتباراً من ٢٣ فبراير ٢٠٢٠، يحق للشركة صاحبة الطلب، قبل موافقة المحكمة على التسوية القيام بما يلي:

- تقديم طلب جديد للمحكمة يتضمن اتفاقية جديدة لإعادة هيكلة الديون، لتحل محل تلك المقدمة بالفعل.

- تقديم موجز يحدد المواعيد النهائية الجديدة لتحقيق خطة إعادة الهيكلة، بشرط ألا يتجاوز تأجيل هذه المواعيد النهائية ستة أشهر.

٤ - تأجيل إعادة رأسمال الشركة إلى نصابه القانوني:

بسبب الظروف الاستثنائية التي تسببها الأوبئة، والتي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى توليد خسائر تؤثر على رأس المال المسجل حتى بالنسبة الشركات التي كانت في السابق بحالة جيدة في الظروف الاقتصادية والمالية العادية، وطبقاً لأحكام القانون المدني الإيطالي التي تتطلب إعادة رأس المال المسجل إلى ما كان عليه، عندما يتم تخفيضه بأكثر من الثلث كنتيجة للخسائر، فإن تلك القاعدة لن تسري حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٥ - الإجراءات المؤقتة لقروض المساهمين:

تقدم الحكومة الإيطالية إجراء لتزويد الشركات بالدعم المناسب للقروض (وذلك من خلال قروض المساهمين).

فينص (مرسوم السيولة) على تعليق مؤقت من ٨ أبريل ٢٠٢٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، لقواعد تبعية القروض المقدمة لصالح الشركة لقروض المساهمين أو أولئك الذين يقومون بأنشطة الإدارة والتنسيق (المادتان ٢٤٦٧ و ٢٤٩٧ خامساً من القانون المدني الإيطالي)، وذلك من أجل تشجيع مصادر بديلة للاستدامة المالية المحتملة للشركة.

وهذا يعد عاملاً مشجعاً كبيراً للمساهمين، خاصة في الوقت الذي يكون فيه من الضروري تشجيعهم على المشاركة بشكل أكبر في تعزيز مالية الشركة.

وفقاً للتدابير الأخرى، يعد هذا التدبير مؤقتاً ويقتصر على قروض المساهمين الممنوحة منذ تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تاسعاً – في دولة فرنسا^(٢٢):

قد أعلن قانون الطوارئ الفرنسي الصادر في ٢٣ مارس ٢٠٢٠ (حالة الطوارئ الصحية في البلاد) بدءاً من ٢٤ مارس ٢٠٢٠، ومن المقرر أن تنتهي في ٢٤ مايو ٢٠٢٠، وذلك بسبب أزمة جائحة فيروس (COVID-19).

وبموجب قانون الطوارئ هذا، أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً تنفيذياً (له قوة القانون)، وأدخلت من خلاله تعديلات مؤقتة على قانون الإفلاس الفرنسي في ٢٧ مارس ٢٠٢٠ (المرسوم التنفيذي رقم ٣٤١ لسنة ٢٠٢٠)؛ وذلك للمساعدة في حماية الشركات، والموظفين، ومجلس إدارة الشركات من عواقب عدم التدفق النقدي نتيجة للأزمة الصحية الحالية، وسوف نتناول الأحكام الرئيسية للمرسوم التنفيذي، وكذلك بعض آثاره على الشركات المتعثرة، وذلك على النحو الآتي:

١ - تطبيق عدم الإفلاس عن "وقف السداد" حتى ١٢ مارس ٢٠٢٠:

بموجب القانون الفرنسي، يطلب من المدينين عادة تقديم طلب بإفلاسهم في غضون (٤٥ يوماً) من (التوقف عن السداد)، وهو ما يحدث عند تجاوز ديونهم لأصولهم السائلة.

ويتم رفع طلب الإفلاس لاتخاذ إجراءات (الاسترداد القضائي) أو (التصفية القضائية)، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن البدء بأنواع معينة من القيام بإجراءات ما قبل الإفلاس إلا بعد (الوقف عن السداد).

وينص المرسوم التنفيذي الحالي على أنه، حتى انتهاء فترة ثلاثة أشهر عقب انتهاء (حالة الطوارئ الصحية) (أي حتى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ بموجب الجدول الحالي)، يجب تطبيق عدم القضاء بالإفلاس نتيجة (التوقف عن السداد) حتى ١٢ مارس ٢٠٢٠، بغض النظر عن الأحداث أو المواقف اللاحقة.

ونتيجة لذلك، إذا لم تكن الشركة في حالة (توقف عن السداد) في ١٢ مارس ٢٠٢٠، فستكون قادرة على مواصلة العمليات كمنشأة تجارية مستمرة، ولن تكون هناك حاجة للإفلاس طالما استوفى مركز السيولة النقدية لديها سداد الديون.

وبالإضافة إلى ما تقدم، سيتم السماح للشركات التي لم تكن في حالة (توقف

Fabrice Baumgartner, Aude Dupuis, COVID-19: Temporary French Bankruptcy Law Adjustments, March 31, 2020, available at (<https://www.clearygotlieb.com/news-and-insights/publication-listing/covid19-temporary-french-bankruptcy-law-adjustments>).

عن المدفوعات) في ١٢ مارس ٢٠٢٠ ببدء إجراءات ما قبل الإفلاس التي لا تتوفر عادة إلا للشركات التي (تتوقف عن الدفع)، حتى إذا كان وضع السيولة النقدية فيما بعد يستوفي اجتياز (الديون المطلوبة) أي، كما نوقش أعلاه، قد يكون نظام (الحماية) قابلاً للتطبيق، بالإضافة إلى الإجراءات التي تنطوي على وسطاء معينين من قبل المحكمة لإعادة هيكلة الديون، والتي تلعب دوراً مهماً في إعادة الهيكلة، وينظر إليها بشكل عام على أنها أدوات فعالة لإعادة هيكلة الديون في شكل مصالحة.

كما ينص المرسوم التنفيذي كذلك على أنه في حالة إذا ما كانت الشركة في حالة (توقف عن السداد) بعد ١٢ مارس ٢٠٢٠، سيظل يسمح للشركة المتعسرة بتقديم ملف الإفلاس وبدء إجراءات (الاسترداد القضائي) أو (التصفية القضائية)، هذا وقد تختار بعض الشركات تقديم طلب للإفلاس للحصول على أموال عامة لسداد مطالبات معينة للموظفين، ومع ذلك سيكون هذا الخيار في تقدير الشركة المتعسرة وحدها، ولا يجوز لدائنيها ولا مكتب المدعي العام طلب فتح إجراءات "استرداد قضائي" أو "تصفية قضائية" فيما يتعلق بشركة كانت في "توقف عن سداد الديون" "بعد ١٢ مارس ٢٠٢٠، ولأغراض عملية، فإن الشركة المتوقفة عن السداد بعد ١٢ مارس ٢٠٢٠ ستتمكن من استخدام كل إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في القانون الفرنسي، وفقاً لظروفها واحتياجاتها، وعقب نهاية فترة (الثلاثة أشهر) التالية لنهاية (حالة الطوارئ الصحية)، سيتعين على الشركات التي لا تزال في حالة (توقف عن السداد) تقديم طلب للإفلاس في غضون (خمسة وأربعين يوماً).

هذا وقد يكون للقواعد الموضحة أعلاه آثار فيما يتعلق بتطبيق قواعد النقل الاحتياطية، التي تنطبق بموجب القانون الفرنسي خلال "فترة الريبة" فعلى سبيل المثال، تحدد محكمة الإفلاس عادةً تاريخ (التوقف عن السداد)، والتي قد تقرر أنها حدثت قبل (ثمانية عشر شهراً) من تاريخ صدور الحكم في إجراءات الإفلاس، وهذا التاريخ يعد نقطة البداية لـ(فترة الريبة)، والتي يمكن خلالها الطعن في بعض المعاملات وإلغاؤها، وبما أن (التوقف عن السداد) لن يكون قابلاً للتطبيق من ١٢ مارس ٢٠٢٠ حتى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠، فمن المعقول حينئذ أن نتوقع أنه في حالة إجراءات الإفلاس اللاحقة، لا ينبغي لمحاكم الإفلاس أن تحكم في حدوث (التوقف عن السداد) أثناء تلك الفترة على الأقل للشركات التي لم تكن في حالة توقف عن السداد في ١٢ مارس ٢٠٢٠ أو قبل ذلك.

ونتيجة لما تقدم، فإن المعاملات التي أبرمها المدين خلال تلك الفترة لن تكون عرضة لخطر الإلغاء وفقاً لقواعد النقل الاحتياطية، المرسوم التنفيذي يتضمن استثناء،

ولكن في حالة الاحتيال، سيسمح لمحكمة الإفلاس بأن تقرر أن التوقف عن السداد قد حدث في أي وقت حتى (ثمانية عشر شهراً) قبل تاريخ الحكم بالإفلاس.

٢ - تمديد بعض المواعيد النهائية:

يمد المرسوم التنفيذي العديد من المواعيد النهائية المنصوص عليها في قانون الإفلاس الفرنسي، وهي على النحو الآتي:

أ - تمديد المدة القصوى لإجراءات توفيق أوضاع الشركات المتعثرة وهي عادة لفترة زمنية تساوي مدة (حالة الطوارئ الصحية) بالإضافة إلى ثلاثة أشهر أخرى، إذا انتهت (حالة الطوارئ الصحية) التي بدأت في ٢٤ مارس ٢٠٢٠ وتنتهي في ٢٤ مايو ٢٠٢٠، كما هو مقرر حالياً، وبالتالي فستتم زيادة المدة القصوى لإجراءات توفيق أوضاع الشركات المتعسرة لمدة خمسة أشهر إضافية (أي إجمالي عشرة أشهر). يبدو أن هذا لا ينطبق فقط على إجراءات التوفيق المعلقة في ٢٤ مارس ٢٠٢٠، ولكن أيضاً على إجراءات توفيق الأوضاع التي بدأت بعد ٢٤ مارس ٢٠٢٠ وحتى ثلاثة أشهر بعد انتهاء (حالة الطوارئ الصحية).

ب - عندما تكون الشركة خاضعة لـ (خطة حماية) أو (خطة استرداد) أي خطة وافقت عليها المحكمة عند الخروج من إجراءات (التصفية)، يمكن تمديد مدة الخطة، فيجوز لرئيس محكمة الإفلاس، حتى ثلاثة أشهر بعد انتهاء (حالة الطوارئ الصحية)، بناءً على طلب الوصي المشرف على تنفيذ الخطة، تمديد مدة الخطة لمدة مساوية لمدة تصل إلى مدة "حالة الطوارئ الصحية" بالإضافة إلى ثلاثة أشهر (أي ما يصل إلى خمسة أشهر إضافية كحد أقصى إذا ظلت "حالة الطوارئ الصحية" سارية لمدة شهرين، كما هو مقرر حالياً)، ويجوز لمكتب المدعي العام طلب التمديد لمدة تصل إلى عام واحد.

عقب انقضاء فترة الثلاثة أشهر التالية لانتهاء (حالة الطوارئ الصحية)، ولمدة ستة أشهر بعد ذلك، يجوز لمحكمة الإفلاس تمديد فترة الخطة لمدة تصل إلى (سنة واحدة) بناءً على طلب مكتب المدعي العام أو الوصي المشرف على تنفيذ الخطة. ستسمح هذه الأحكام للشركات غير القادرة على الوفاء بالموعد النهائي المنصوص عليه في خطتها بتأجيل هذا الموعد النهائي.

ج - يجوز لرئيس محكمة الإفلاس تمديد المواعيد النهائية المطبقة على أمناء الإفلاس طوال فترة (حالة الطوارئ الصحية) بالإضافة إلى ثلاثة أشهر، بناءً على طلبهم.

د - يتم تمديد المواعيد النهائية التالية تلقائياً لمدة (حالة الطوارئ الصحية) بالإضافة إلى شهر واحد:

- المواعيد النهائية المتعلقة بـ (فترة المراقبة)، أي الفترة المتاحة لوضع خطة خروج من إجراءات (التصفية).
- المواعيد النهائية المتعلقة بتنفيذ (خطط الحماية) (خطط بيع الأصول) المعتمدة بعد الخروج من إجراءات (التصفية).
- المواعيد النهائية المتعلقة بالعمليات المستمرة عندما تكون إجراءات (التصفية القضائية) معلقة.
- مدة إجراءات التصفية المبسطة.

٣ - تنظيم إجراءات الإفلاس:

- يهدف المرسوم التنفيذي إلى تسهيل إجراءات ما قبل الإفلاس والإفلاس في الظروف التي قد يتعذر فيها تنظيم جلسات الاستماع والاجتماعات الجسدية من خلال ما يلي:
- أ - يجوز رفع الدعاوى أمام المحاكم لبدء هذه الإجراءات بأي وسيلة (أي بما في ذلك إلكترونياً).
 - ب - يجوز للمدينين الحصول على تفويضات لتقديم مطالبات وحجج كتابية فقط (دون أي جلسة استماع).
 - ج - يجوز لرؤساء محاكم الإفلاس أن يطلبوا إرسال المراسلات إليهم بأي وسيلة (أي بما في ذلك إلكترونياً).
 - د - يجوز إجراء الاتصالات بين محاكم الإفلاس وأمناء التفليسة بأي وسيلة (أي بما في ذلك إلكترونياً).

عاشراً - في دولة سويسرا^(٢٣):

في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، أصدر المجلس الاتحادي السويسري قانوناً خاصاً فيما يتعلق بنظام الإفلاس وإعادة الهيكلة للديون، وذلك لحماية الشركات التي واجهت صعوبات مالية ناجمة عن جائحة فيروس (COVID-19)، وسمي بقانون (إفلاس

Laurent Gillieron, Bankruptcy laws eased for Covid-affected companies, APR (٢٣) 16, 2020, Available at (https://www.swissinfo.ch/eng/debt-relief_bankruptcy-laws-eased-for-covid-affected-companies/45694796), (25/4/2020) Andrea Trost, Dunja Koch, JÖrme Pidoux, Measures to Assist Swiss Companies During COVID-19: A New Temporary Insolvency and Restructuring Regime, 21 April 2020, Available at (<https://blog.froriep.com/en/insolvency-and-restructuring-regime-for-swiss-companies-covid-19-switzerland>), (25/4/2020).

(COVID-19)، وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في ٢٠ أبريل ٢٠٢٠، وسيظل ساري المفعول لمدة ستة أشهر.

يحتوي قانون (إفلاس COVID-19) على ثلاثة تدابير مؤقتة وهي على النحو التالي:

١ - تعليق واجب مجلس الإدارة بإخطار القاضي في حالة المديونية المفرطة:

بموجب القانون السويسري، يجب على مجلس الإدارة إخطار القاضي دون تأخير إذا كانت الشركة مثقلة بالديون، ما لم يكن بعض الدائنين على استعداد لإخضاع مطالباتهم إلى مطالبات جميع دائني الشركة الآخرين بمبلغ يكفي لتغطية عجز رأس المال وأي خسائر متوقعة سيتم تكبدها في الأشهر (الاثنى عشر) المقبلة، فقد يؤدي عدم إخطار القاضي في الوقت المناسب بمسؤولية مدنية وجنائية. عند تلقي هذا الإخطار، ستبدأ المحكمة في إجراءات الإفلاس ما لم يكن هناك احتمال لإعادة الهيكلة المالية.

وخلافاً لما سبق، يعفي مرسوم (إفلاس COVID-19) مجلس الإدارة مؤقتاً من واجبه بإخطار القاضي، شريطة الآتي:

أ - لم تكن الشركة مثقلة بالديون في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

ب - أن يكون هناك احتمال أن المديونية المفرطة يمكن معالجتها بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وينطبق الشيء نفسه على (مراقبي الحسابات) الذين لديهم واجب قانوني لإخطار القاضي، إذا فشل مجلس الإدارة في القيام بذلك.

ويجب على مجلس الإدارة توثيق وتقديم أسباب قراره كتابة.

٢ - وقف جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الشركات الصغيرة والمتوسطة)، ما يسمى وقف (COVID-19):

قد تتقدم الشركات المتوسطة والصغيرة بطلب للحصول على وقف للديون، ويوفر الوقف الجديد لـ (COVID-19) للشركات الصغيرة والمتوسطة إجراءات بسيطة للحصول على وقف مؤقت لالتزامات الدفع الخاصة بها، على هذا النحو، فهو بديل أبسط لوقف الدين العادي بموجب قانون إنفاذ الديون والإفلاس الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تصفية الشركة بدلاً من إعادة هيكلتها.

شروط وقف (COVID-19) تتمثل في الآتي:

أ - أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تكن مثقلة بالديون في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أو

إذا كانت هناك مديونية زائدة، وقد خضع بعض الدائنين في مطالباتهم لجميع مطالب الدائنين الآخرين في قبول التوقف عن الدفع لحين تجاوز المديونية.

ب - أن تكون أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة غير متداولة علناً.
ج - أن لا تتجاوز الشركات الصغيرة والمتوسطة اثنين من العتبات التالية في عام ٢٠١٩، وهما على النحو التالي:

- إجمالي الميزانية العمومية ٢٠ مليون فرنك سويسري.
- إيرادات مبيعات بقيمة ٤٠ مليون فرنك سويسري أو أكثر.
يجوز منح وقف اختياري لفترة أولية تصل إلى ثلاثة أشهر، كما يجوز للمحكمة تمديد الوقف الاختياري لمدة إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر.

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على وقف (COVID-19) في إجراء بسيط عن طريق تقديم طلب توضّح فيه وضعها المالي بطريقة موثوقة، وتقدم أدلة على ذلك، ليس من الضروري توفير خطة إعادة هيكلة، من خلال تقديم طلب لوقف اختياري لـ (COVID-19)، يعتبر مجلس الإدارة قد أوفى بواجبه بإخطار المحكمة في حالة الإفراط في المديونية، يتم نشر منح الوقف (COVID-19)، ويجب أن تخطر الشركات المتعسرة على الفور جميع الدائنين المعروفين كتابياً أو عبر البريد الإلكتروني.

خلال الوقف الاختياري لـ (COVID-19)، قد تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أنشطتها التجارية، ولا تتأثر المطالبات الناشئة بعد منح الوقف بهذا الوقف.

ومع ذلك، لا يجوز للشركات الصغيرة والمتوسطة القيام بأي أعمال تضر بالمصالح المشروعة للدائنين، أو تفضل الدائنين الأفراد على حساب الآخرين.
بالإضافة إلى ما تقدم، لا يجوز للشركات الصغيرة والمتوسطة التخلص من أصولها الثابتة أو التعهد بها أو رهنها خلال الوقف الاختياري دون موافقة المحكمة.

٣ - التعديلات على نظام إعادة هيكلة الديون الحالي:

قام المجلس الاتحادي السويسري بتنفيذ المزيد من التدابير من أجل تبسيط الوقف العادي الحالي بموجب قانون (DEBA)، والذي بخلاف الوقف في قانون إفلاس (COVID-19) لا يقتصر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، يتم تحرير الشركات من الالتزام بتزويد القاضي بخطة إعادة هيكلة مؤقتة عند التقدم بطلب لوقف اختياري عادي.

علاوة على ذلك، فإن الحد الأقصى لمدة الوقف المؤقت التي قد تمنحها المحكمة في هذا السياق قد تم تمديدتها من (أربعة أشهر) إلى (سنة أشهر)، وقدرة المحكمة على إعلان إفلاس الشركة قبل نهاية الوقف المؤقت محدودة.

هذا ولا يمنع منح الوقف بموجب قانون (COVID-19) الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بطلب للحصول على الوقف الاختياري العادي في أي وقت، ومع ذلك يتم تقليل مدته إلى نصف مدة الوقف بموجب قانون (COVID-19).

بالإضافة إلى هذه التدابير السابقة، اعتمد المجلس الاتحادي السويسري مرسوم (Covid-19) في ٢٥ مارس ٢٠٢٠، وبالتالي وافق على حزمة ضمان بمبلغ يصل إلى (٢٠ مليار فرنك سويسري) قد تمت زيادته لاحقاً إلى (٤٠ مليار فرنك سويسري).

بناءً على هذا القانون تُمنح الشركات التي تحتاج إلى سيولة إمكانية الوصول إلى القروض بطريقة سريعة ومباشرة للغاية.

هذا ويميز هذا القانون بين نوعين من القروض: قرض (Covid-19) بمبلغ القرض يصل فيه إلى (٥٠٠٠٠٠٠ فرنك سويسري)، وقرض (Covid-19 Plus) (مبلغ القرض يصل إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ فرنك سويسري)).

أظهرت التجربة خلال الأيام القليلة الماضية أن قروض (Covid-19) متاحة في غضون بضع ساعات (للعلماء الحاليين) وقرض (Covid-19 Plus) في غضون أيام قليلة (مرة أخرى للعلماء الحاليين).

نتيجة لبرنامج السيولة، تتوفر السيولة بسرعة كبيرة، وقد أظهرت التجربة أن هناك طلباً كبيراً على القروض وأن النظام المصرفي قادر على تلبية الطلبات.

الخاتمة:

إن فترة استمرار بقاء جائحة فيروس كورونا في وقتنا الحالي تعد غير معروفة حالياً لأغلب دول العالم، وأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات قد يمتد إلى أجل غير مسمى، أو قد ينقطع تارة وقد يفرض تارة أخرى، ولذلك يصبح من شبه المستحيل على الشركات إجراء تقييمات دقيقة حول الإيرادات المستقبلية لها، ومدى إمكانية سداد ما عليها من مستحقات مالية لدائنيها، ولذلك يجب على جميع الدول في أنحاء الوطن العربي أن تقوم بسن تشريع أو صدور مرسوم بقانون لحماية الشركات من خطر الإفلاس، ولذلك نوصي أن تتضمن تلك التشريعات الآتي:

١ - يجب إلزام البنوك، والمؤجرين، والموردين، والمدنيين للشركات، والدائنين للشركات والشركات نفسها، بأن يعملوا معاً في تنفيذ عمليات الترحيل التوافقي للديون،

وعادةً ما يفكرون في فترة تتراوح من (أربعة إلى ستة أشهر) من فترات السماح، للتغلب على الأشهر الأكثر صعوبة للوباء، وتلك المدة تترك الوقت للتحضير لإعادة الهيكلة الشاملة للديون خلال الربع الأخير (من عام ٢٠٢٠)، والأمل أن يتم تنفيذ التنبؤات بمزيد من الواقع.

- ٢ - نظراً لوجود ثغرات معينة في التنظيم القانوني للوقف الاختياري في أغلب الدول حول العالم، والتي قد يتم إغلاقها من قبل المشرعين في المستقبل، وبما أن ممارسات المحكمة في مثل هذه الأمور لا تزال قيد التطوير، فسيكون من الضروري إلزام الدائنين والمدينين بإعادة التفاوض على البنود التعاقدية التي من شأنها ضمان الحد الأقصى من الحماية لمصالح كل طرف.
- ٣ - يجب على جميع الدول العربية أن تنتهج نهج أغلب الدول الأوروبية والأجنبية من تعليق حق الدائنين للشركات المتعثرة نتيجة جائحة كورونا من التقدم برفع دعوى إفلاس للشركات المتعسرة، وذلك حتى انتهاء تلك الأزمات.
- ٤ - يجب سن القوانين التي تعمل على إعفاء مجلس الإدارة من المسؤولية أثناء تلك الجائحة إذا قام بالتصرف وإبرام الصفقات وكانت الشركة في حالة تعثر ملحوظ.
- ٥ - يجب تحرير مجلس الإدارة من واجبه بتقديم طلب الإفلاس إذا كانت الشركة متعثرة، وقد رأى إمكانية عودة الشركة لما كانت عليه في السابق، وذلك بإمكان مجلس الإدارة افتراض احتمالية كافية لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى إفلاس الشركة بعد هذه الفترة، عن طريق (القروض الجديدة، أو مساهمات المساهمين، أو تأجيل التزامات السداد المستحقة).
- ٦ - التزام التسجيل للقرارات والمناقشات هو واجب شخصي على جميع الممثلين القانونيين للشركة (وعادة ما يكون رئيس مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة)، وفي حالة عدم القيام بإجراءات التسجيل، تكون المسؤوليات الشخصية، والعقوبات الجنائية وشيكة الوقوع على هؤلاء الممثلين.
- ٧ - منح تعويض من جانب حكومات الدول العربية للشركات التي انخفضت إيراداتها نتيجة تأثرها بتلك الجائحة.

المراجع

- Aiden Murphy, Declan Hanly, COVID-19: Restructuring and insolvency solutions for your business, 07/04/2020, Available at (<https://www.crowe.com/ie/insights/covid-19-restructuring-and-insolvency-solutions-for-your-business>).
- Andrew Foster, Duncan Lockhart, Andrew Ramsden, Tristan Cox, COVID-19 UK: Prospective changes to insolvency law (England and Wales), 02 April 2020, available at (<https://www.clydeco.com/insight/article/covid-19-uk-prospective-changes-to-insolvency-law-england-and-wales>).
- Andrea Trost, Dunja Koch, Jérôme Pidoux, Measures to Assist Swiss Companies During COVID-19: A New Temporary Insolvency and Restructuring Regime, 21 April 2020, Available at (<https://blog.froriep.com/en/insolvency-and-restructuring-regime-for-swiss-companies-covid-19-switzerland>).
- Aurelio Gurrea Martínez, Dissolution of companies and bankruptcy in times of coronavirus, 15 March 2020, Available at (<https://www.derechoyfinanzas.org/disolucion-de-sociedades-y-concurso-de-acreedores-en-tiempos-del-coronavirus/>).
- Aurelio Gurrea-Martínez, Insolvency Law in Times of COVID-19 (March 27, 2020). Ibero-American Institute for Law and Finance, Working Paper 2/2020, p3, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3562685> or < <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3562685> >).
- Alison Goldthorp, Sarah Coucher, James Stonebridge, COVID-19: Legal considerations for UK Boards (updated to reflect the position as at April 1, 2020), April 2020, Available at(<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/621d58ef/covid-19-legal-considerations-for-uk-boards>).
- Christina McKeon Frutuoso, Avoiding insolvency, and

- worse, in the covid-19 crisis, 07 April 2020, available at (< <https://latinlawyer.com/article/1225215/avoiding-insolvency-and-worse-in-the-covid-19-crisis> >).
- Ehud (Udi) Arzi, Ran Feldman, Dorit Hamberg, Noa Lavian, Eden Weiss, The impact on contracts of possible insolvency due to the corona crisis, April 7 2020, Available at (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=992bf6d7-8067-4497-a44c-c5ff6eb82cc3>).
 - Emily Davis, John Alderton, Regulatory requirements for UK Insolvency Practitioners during COVID-19, April 9, 2020, Available at (<https://www.restructuring-globalview.com/2020/04/qa-regulatory-requirements-for-uk-insolvency-practitioners-during-covid-19/>).
 - Esteban Ortiz-Mena, Noboa Velasco, Paúl, Propuestas Societarias y Concursales para Mitigar el Impacto Económico del COVID-19 en Ecuador (Corporate and Insolvency Proposals to Mitigate the Economic Impact of COVID-19 in Ecuador) (April 4, 2020), p1-2, Available at (SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3568267> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3568267>).
 - David Murray, David Few, Coronavirus (COVID-19) - Company Directors' Duties and Flexibility in Insolvency Law, 30 March 2020, available at (<https://www.blandy.co.uk/about/news-and-insights/insights/coronavirus-covid-19-company-directors-duties-and-flexibility-in-insolvency-law>).
 - Fabrice Baumgartner, Aude Dupuis, COVID-19: Temporary French Bankruptcy Law Adjustments, March 31, 2020, available at (<https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/covid19-temporary-french-bankruptcy-law-adjustments>).
 - Frank Grell, Dr. Jörn Kowalewski, Dr. Ulrich Klockenbrink, Legal Update - Remedy for Managing Directors in

- Times of COVID-19: Suspension of insolvency filing obligations and limitation of liability risks in Germany, March 22, 2020, available at (<https://www.lathamgermany.de/2020/03/legal-update-remedy-for-managing-directors-in-times-of-covid-19-suspension-of-insolvency-filing-obligations-and-limitation-of-liability-risks-in-germany/>).
- Federico Sutti, Cristian Fischetti, COVID-19: Insolvency measures introduced by Italy's Law Decree no. 23 of April 8, 2020 (the so-called "Liquidity Decree"), published in the Official Gazette and effective as of April 9, 2020, April 10, 2020, Available At (<https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/7/interventions-in-bankruptcy-matters-by-the-liquidity-decree-approved-by-the-council-of-ministers-en>).
 - Gert-Jan Boon, Markus Konrad Brunnermeier, Horst G. M. Eidenmueller, Luca and Gurrea- Enriques, Aurelio Martínez, Kathryn Judge, Jean-Pierre Landau, Marco Pagano, Ricardo A.M.R. Reis, Kristin, The Covid-19 Pandemic and Business Law: A Series of Posts from the Oxford Business Law Blog (April 11, 2020). Oxford Legal Studies Research Paper Forthcoming, p2, Available at (SSRN: <https://ssrn.com/abstract=>).
 - Giovanni Fonte, Covid-19 in Italy: Liquidità Decree dedicates articles to insolvency procedure, 16 April 2020, Available at (<https://www.roedl.com/insights/covid-19/italy-liquidita-decree-insolvency-procedures>).
 - Joss Hargrave, Nicolas Morelli, Lyle Abel, Cedric Berckmans, John Shi, Ľubomír Brečka, Casper Moltke-Leth, Kristiina Lehtilä, Celine Nezet, Dr. Dirk Barcaba, Ádám Boross, Nipun Gupta, Matteo Meroni, Adam Kowalczyk, Ken Cheung, Alfonso Carrillo Cano, Mattias Lindberg, René Rieter, Lucas Pitts, Jordan Cooper, COVID-19: International Restructuring & Insolvency Update, 03-2020, Avail-

- able at (<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/global/covid-19-international-r-and-i-briefing>).
- Laurent Gillieron, Bankruptcy laws eased for Covid-affected companies, APR 16, 2020, Available at (https://www.swissinfo.ch/eng/debt-relief_bankruptcy-laws-eased-for-covid-affected-companies/45694796).
 - Liam Preston, Paul Keddie, Covid-19 proposed changes to UK insolvency laws, 08 April 2020, Available at (<https://www.macfarlanes.com/what-we-think/in-depth/2020/covid-19-proposed-changes-to-uk-insolvency-laws/>).
 - Lisa Calabrese, James Jarvis, Coronavirus (COVID-19): Important Temporary Relief in Insolvency Law, 24/3/2020, Available at (<https://www.finlaysons.com.au/2020/03/coronavirus-covid-19-important-temporary-relief-in-insolvency-law/>).
 - Paul Rosen, David Wood, COVID-19 - Temporary Relaxation of UK Insolvency Laws, April 7, 2020, Available at (<https://katten.com/covid-19-temporary-relaxation-of-uk-insolvency-laws>).
 - Peter Hoegen, Dr Franz Bernhard Herding, Dr Sven Prüfer, Dr Walter Uebelhoer, Dr Christopher Kranz, Covid-19 pandemic: Temporary suspension of the obligation to file for insolvency proceedings, 31 March 2020, available at (file:///C:/Users/PC_2018/Desktop/Snapshot-Covid19-Temporary-suspension-of-obligation-to%20file-for-insolvency-proceedings-310320.pdf).
 - Richard Squire, U.S. airlines don't need a bailout to stay in business, March 23, 2020, available at (<https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/22/us-airlines-dont-need-bailout-stay-business/>).
 - Stefano Parlatore, Daniele Geronzi, Daria Pastore, Luca Autuori, Giandomenico Ciaramella, Marialuisa Garavelli, Sara Colombero, New rules on the Italian government's re-

- view of investments in Strategic industries at the time of Covid-19 Covid-19 emergency - Italy insolvency and business crisis, APRIL 2020, available at (https://www.legance.com/wp-content/uploads/2020/04/Newsletter_COVID-19_emergency_%E2%80%93_Italy_insolvency_and_business_crisis-1.pdf).
- Shameek Jankee, Bhomitrajeet Sandeep Ramlochund, Sivakumaren Robin Mardemootoo, Mauritius: Insolvency Issues with respect to COVID-19, April 9, 2020, Available at (<https://www.dentons.com/en/insights/articles/2020/april/9/mauritius-insolvency-issues-with-respect-to-covid-19>).
 - Shreya Prakash, Evaluating Some Strategies for Preventing Insolvency Proceedings in the Wake of the COVID-19 Crisis, 21 Apr 2020, available at (<https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/04/evaluating-some-strategies-preventing-insolvency-proceedings-wake>).
 - Sean F. Collins, James D. Gage, Heather L. Meredith, Walker W. MacLeod, Jocelyn Perreault, Alain N. Tardif, COVID-19 Considerations from Our Bankruptcy & Restructuring Experts, March 17, 2020, available at (<https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/restructuring-roundup/covid-19-considerations-our-bankruptcy-restructuring-experts>).
 - Yoko Takagi, Reyes Carvajal, COVID-19: Spanish Government Financial Assistance Measures, 19 APR 2020, Available at(<https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-spanish-government-financial-assistance-measures>).
 - Zahra Ali, Spanish measures for restructuring/insolvency in the context of coronavirus (COVID-19)-threats and opportunities, 27 Mar 2020, Available At ([https://www.lexisnexis.co.uk/blog/restructuring-and-insolvency/spanish-measures-for-restructuring-insolvency-in-the-context-of-coronavirus-\(covid-19\)-threats-and-opportunities](https://www.lexisnexis.co.uk/blog/restructuring-and-insolvency/spanish-measures-for-restructuring-insolvency-in-the-context-of-coronavirus-(covid-19)-threats-and-opportunities)).

Mechanisms for facing the risk of corporate bankruptcy in the time of the Corona pandemic and efforts of national legislation

Dr. Mohamed Salah Abdellah Mohamed

The world may be exposed in our present time to a global pandemic, the scope of which is not limited to humans only, but extends to companies, and has a great influence on them, especially in fulfilling their obligations; As a result of stopping the movement of trade exchange between countries, and applying precautionary measures within the companies themselves, which may lead in many cases to the risk of bankruptcy, closure, and dismissal of its employees, which may affect the national economy of the countries that these companies follow, which It motivated us to study the mechanisms of facing the risk of bankruptcy, and we were guided in that by practical applications of measures taken by European, Asian and Arab countries to avoid bankruptcy of companies located within their country, and these measures had a great impact on the existence of these companies.

محاولة لتطبيق نظرية العقد الناقص على الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا

الدكتور/ بدر الدين براحلية

كلية الحقوق

جامعة باجي مختار عنابة - الجزائر

ملخص:

يكشف المقال مضمون نظرية العقد الناقص، ويوضح ظهورها كنظرية مستحدثة في المنظومة الأنجلو - أمريكية. يعرض المقال الأسس القانونية التي تقوم عليها نظرية العقد الناقص، ويستقرئ الأدوات التي تدعم إدراجها في النظام العام للعقود.

يوضح المقال مدى مساهمة نظرية العقد الناقص في معالجة الالتزامات التعاقدية في ظل جائحة كورونا التي أحدثت ما يمكن تسميته بـ "أزمة العقد". يقدم المقال إعادة التفاوض كمبدأ أصيل لاستمرار العلاقات التعاقدية، وفي الوقت نفسه يبرز محدودية نظرية العقد الناقص أمام العقود المترابطة.

الكلمات المفتاحية: نظرية العقد الناقص، إعادة التفاوض، الالتزامات التعاقدية، جائحة كورونا.

مقدمة:

تقوم نظرية العقد على إعمال مبدأ سلطان الإرادة، أي القوة الملزمة للعقد إلى غاية تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم التعاقدية، وهي بذلك تقوم على أساس أنّ العقد يحقق العدل للأطراف استناداً لمعرفتهم بما يخدم مصلحتهم، في حين تقتضي نظرية العقد الناقص عدم قدرة الأطراف على الإلمام بكل عناصر العقد بناء على التوقعات المستقبلية لتنفيذه، فالعقد الكامل المبني على أساس الإحاطة بكل الظروف والمعلومات في مرحلة إبرام العقد غير ممكن من الناحية العملية.

قد يكون نقصان العقد لسبب داخلي أو خارجي، أي يرجع لإرادة الأطراف في ترك العقد غير محدّد بشكل مطلق لتوجيهه مستقبلاً حسب الظروف والنتائج، أو يرجع لظروف استثنائية تجعل أطراف العقد يتكيفون معها للوصول إلى الغرض المقصود من إنشاء العقد^(١).

(١) Ninel Ulloa Maureira, Introduction du concept Américain des contrats incomplets en droit civil français, Global Jurist Topics, V 4 (3), 2004, (05/05/2020, 23:34).

تختلف نظرية العقد الناقص عن نظرية إنقاص وتحول العقد في حالة البطلان الجزئي (La théorie des contrats incomplets et la conversation du contrats par réduction)، فمجال نظرية العقد الناقص هو العقود الصحيحة وليست العقود المعيبة، أما إنقاص العقد فيتم تطبيقه في الحالة التي يكون فيها العقد باطلاً جزئياً لیتّم تصحيح العيب المشوب به، كما أنّ تكملة العقد في نظرية العقد الناقص يكون من الأطراف، وفي إنقاص العقد يكون من طرف القاضي بعد التثبت من نية الأطراف، ويكون محل العقد الناقص غير محدّد بشكل تام، أما في إنقاص العقد فمحلّه محدّد بشكل كامل وتام، ولا يعاد تكييف العقد الناقص على عكسه في حالة إنقاص العقد.

تعمل نظرية العقد الناقص على إضفاء سلاسة ومرونة على العقد تجعله يتكيف مع الظروف في المستقبل من خلال السماح للأطراف بإعادة التفاوض على بنوده، خاصة ما يتعلّق بكيفية تنفيذه بعد حدوث ظروف معيّنة لم يكن بالإمكان توقّعها، وهي بذلك تبدو كصورة مستحدثة عن نظرية الظروف الطارئة، إلّا أنه بعد التفحص والتمحيص يظهر أنّها تختلف عنها من حيث الأحكام والنتيجة، حيث تستمد نظرية العقد الناقص قوّتها من إرادة الأطراف في التكيّف مع الظروف، في حين تقوم نظرية الظروف الطارئة على عجز يصيب أطراف العلاقة التعاقدية ويفوق قدرتهم على التعامل مع هذه الظروف.

تعتبر نظرية الظروف الطارئة قيداً على سلطة الأطراف في تحديد أحكام العقد، في حين أنّ نظرية العقد الناقص تجعل المبدأ يصل إلى ذروته من حيث الحرية في تحديد صيرورة العقد، فمبدأ سلطان الإرادة وفق هذه النظرية يلعب دوراً غير محدود في مآل ونتيجة العقد دون تدخّل من القاضي أو الغير، بل يتمّ تعديل العقد بإرادة الأطراف في إطار عملية تنافس للوصول إلى غرض كل طرف من العقد^(٢)، وهي بذلك تنبثق عن فلسفة مغايرة لفلسفة التعاون بين أطراف العقد التي ما فتئ يدّعي بها شرّاح القانون المدني الفرنسي والقوانين المتأثرة به.

اعتاد الفقه القانوني على التمييز بين القوة القاهرة والظروف الطارئة من خلال الآثار والنتيجة، في حين أنّ المنطق القانوني يقوم على التمييز من حيث الماهية والشروط، وأما النتيجة والآثار فتحصيل حاصل بالنظر إلى تكييف القاضي للعقد

(٢) يكون التنافس بين المتعاقدين في تغليب مصلحة أحدهما على الآخر واضحاً في بعض العقود كعقد البيع مثلاً، في حين يقلّ هذا التنافس في بعض العقود الأخرى كعقد الشركة دون أن يضمحلّ تماماً خاصة في العلاقة بين أغلبية المساهمين وأقليتهم، وبين الأغلبية أحياناً أخرى.

وتفسير بنوده، كلتا النظريتين تعتمدان على الظروف غير المتوقعة كأساس لتطبيقهما، مع اختلاف في الحكم بحسب إمكانية تنفيذ الالتزامات التعاقدية من استحالتها؛ لذا كان يفضل القانون المدني الفرنسي وصف نظرية الظروف الطارئة بـ "القوة القاهرة المؤقتة".

فكرة التوقع نسبية، تختلف بحسب مركز الأطراف وقدرتهم على امتلاك المعلومة، وهو ما خلق أزمة القانون المدني أمام القوانين الخاصة وأمام قوانين الاستهلاك، فاختلاف المراكز القانونية للأطراف من حيث القوة والمركز الماليين، وقدراتهم على اكتساب المعلومات، والإحاطة بظروف العقد الحالية والمستقبلية، أنتج المحترف في جانب المستهلك، الذي تعمل القوانين الخاصة على توفير الحماية القانونية له في مختلف مراحل العقد، وفي نظرة القاضي للمنازعة، وبالنتيجة منطوق الحكم أو القرار القضائي.

إنَّ اختلاف أسس الأنظمة القانونية المقارنة في تعاملها مع العقود وتغليب النصّ الاتفاقي أو النصّ القانوني على الوقائع المستجدة لم يعد يتّصف بالجمود التقليدي نفسه خاصة في إطار عولمة القواعد القانونية المنظمة للعقد، وفي الوقت نفسه، فالصراع أو التنافس بين الهيئات القضائية لجذب اهتمام واستقطاب المتعاقدين لحلّ نزاعاتهم، ولّد تقارباً بين الأنظمة الكلاسيكية: النظام اللاتيني، النظام الأنجلوساكسوني، والنظام الإسلامي. فمحاولة البحث في هذا التراث الإنساني ومقارنة القواعد قد يسهّل الوصول إلى الحل الذي يسمح بتجاوز "أزمة العقد في زمن كورونا".

لقد ظهرت جائحة كورونا كحدث متوقع نظرياً غير معلوم عملياً^(٣)، تندرج ضمن "عدم توقع المتوقع When you don't expect what is expected"، وهي بذلك برزت كمحصّ لمتانة وصلابة القواعد القانونية المنظمة للقانون العام للعقود، فهي من حيث إمكانية التوقع بها، ومدّتها، وتقدير الأضرار الناجمة عنها، نتيجة نقصان اليقين حول كيفية انتقال العدوى وتاريخ القضاء عليها، أدّت إلى استحالة تنفيذ نوع من العقود، وجهالة مصير نوع آخر، ممّا يجعل تكييفها يتردّد بين القوة القاهرة والظروف الطارئة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية عدم يقينية إن كانت طارئة أم دائمة، وإن كان

(٣) ذلك أنّ النصوص الشرعية تقضي بظهور أوبئة جديدة نتيجة خروج الإنسان عن سلوك الفطرة السليمة، كما أنّ الدراسات الطبية أكّدت قبل سنوات حدوث أوبئة مشابهة لفيروس "سارس" سنة ٢٠١٣ دون إمكانية توقع وتحديد المكان والزمان.

سيتم القضاء على الوباء أم ينبغي التعايش معه، وبالتالي تختلف وجهات النظر والأحكام حسب مآل الالتزامات التعاقدية في كل حالة وفي كل عقد.

بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٠ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنَّ جائحة كورونا تمثل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، وفي ١٠/٠٢/٢٠٢٠ أعلنت الصين أنَّها أمام قوة قاهرة، وشرعت في توزيع شهادات على المؤسسات العاملة فيها تثبت هذه الحالة^(٤)، وهو نفس ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠^(٥)، في حين اتخذت دول أخرى كالجزائر إجراءات وتدابير للوقاية من انتشار الوباء دون الإعلان الرسمي عن حالة القوة القاهرة^(٦)، وإذا كانت الجائحة في حد ذاتها لا تمثل قوة قاهرة، فإنَّ هناك توجُّهاً عالمياً معتبراً على تكييف التدابير المتخذة بسببها بالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ^(٧). هذه التدابير والإجراءات عرفت تفاوتاً زمنياً له آثار قانونية معتبرة

(٤) بلغ عدد هذه الشهادات أكثر من ٦٤٥٤ شهادة بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٠، وغطت ما يقارب ٩٠ مليار دولار أمريكي.

Peter Klaus Berger and Daniel Behn, Force majeure and Hardship in the age of Corona: A historical and comparative study McGill Journal of Dispute Resolution, 2020, p03, Forthcoming; (29/05/2020, 11:38).

(٥) <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-coronavirus-covid-19> (05/05/2020, 10:34).

(٦) المرسوم التنفيذي رقم ٦٩/٢٠ المؤرخ في ٢١/٠٣/٢٠٢٠ المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -١٩) ومكافحته، جريدة رسمية عدد ١٥، مؤرخة في ٢١/٠٣/٢٠٢٠، ص٠٦. المرسوم التنفيذي رقم ٧٠/٢٠ المؤرخ في ٢٤/٠٣/٢٠٢٠، المتعلق بتدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -١٩) ومكافحته، جريدة رسمية عدد ١٦، مؤرخة في ٢٤/٠٣/٢٠٢٠، ص٠٩. المرسوم التنفيذي رقم ٧٢/٢٠ المؤرخ في ٢٨/٠٣/٢٠٢٠ المعدل والمتمم المتعلق بتمديد الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات، جريدة رسمية عدد ١٧، مؤرخة في ٢٨/٠٣/٢٠٢٠، ص٤١.

(٧) Julia Heinich, L'incidence de l'épidémie de coronavirus sur les contrats d'affaires: de la force majeure à l'imprévision. Recueil Dalloz, n=O11/7856, 26/03/2020, p611.

محمود المغربي وبلال صنيدي، التكييف القانوني للجائحة "الكورونا" على ضوء الثوابت الدستورية والدولية والمبادئ القانونية المستقرة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠. ياسر عبد الحميد الإفطحات، جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ الالتزامات العقدية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠. أحمد إشراقية، الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العلاقات التعاقدية: دراسة في القانونين الفرنسي واللبناني، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦،

من جهة، ومن جهة ثانية يبرز دور القاضي في إسقاط الحكم على الواقع، أي اختلاف الأحكام في كيفية تطبيق النظرية على الالتزامات التعاقدية.

يقال "لكل كارثة مستفيدون"، وبالتالي لا يمكن تعميم الحكم نفسه على كل العقود، كما لا يمكن إسقاط الحكم نفسه على كل العقود ذات النوع نفسه، فهناك عقود تمّ تفعيلها وازدهارها بفعل جائحة كورونا، في حين انقضت عقود أخرى بقوة القانون أو الواقع، وبينهما عقود لا تزال عند موقف انتظار أمل العودة للتنفيذ مستقبلاً، وقد ازدادت المسألة تعقيداً نتيجة ما يعرف بـ "العقود المترابطة"، فليس عقد الإيجار لقضاء عطلة صيفية في إحدى الدول الأوروبية، كعقد لاعب كرة قدم محترف في أحد الأندية الأوروبية، كعقد استثمار بناء سدّ في دولة نامية.

إنّ إيجاد حلّ للعقود خلال أزمة كورونا، وإصدار قرارات قضائية أو تحكيمية بعد الأزمة، يحتاج إلى أعمال الجهود الفكرية، وإحياء القواعد المنسية أو المهجورة بما يكفل حقوق الأطراف وعدالة العقد، وبهذا الصدد يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق نظرية العقد الناقص على الالتزامات التعاقدية كأثر لجائحة كورونا؟

تعدّدت الدراسات الاقتصادية التي فصلت في مضمون وأحكام نظرية العقد الناقص^(٨)، في مقابل قلة الدراسات القانونية التي تعرّضت للموضوع^(٩)، وهذا راجع

= جوان ٢٠٢٠. فارس محمد العجمي، الخيارات القانونية المتاحة لأطراف العقد التجاري في مواجهة جائحة فيروس كورونا وسلطة القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠. أسّس فيصل التورة، تأثير جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠. فتحي تيتوس، كوفيد ١٩: هل يشكل قوة قاهرة؟، حوليات جامعة الجزائر، المجلد ٣٤، العدد ٠٣، جامعة الجزائر، جويلية ٢٠٢٠، ص ص ٧٣٨، ٧٤٩. زكرياء مولاي وآخرون، تأثير فيروس كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، حوليات جامعة الجزائر، المجلد ٣٤، العدد ٠٣، جامعة الجزائر، جويلية ٢٠٢٠، ص ص ٣٣٢، ٣٥٢. محمد الأيوبي، المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس "كورونا كوفيد ١٩" في مؤلف جماعي بعنوان "الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا"، سلسلة إحياء علوم القرآن، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، ٢٠٢٠، ص ٢٩٥.

(٨) بلغت خلال الفترة من ١٩٨٦ إلى ٢٠١٦ حوالي ٩٨٤ ورقة بحثية من طرف أكثر من ٦٠٠ مؤسسة في ٣٦ دولة، راجع في إحصاء هذه البحوث:

Wei, Guangyue, The Scientometric Evaluation of the Research on the Incomplete Contract from 1986 to 2016 (August 1, 2017) (22/05/2020, 23:44).

(٩) Wendy Netter Epstein, Facilitating Incomplete Contracts, 65 Case Western Reserve law Review, 297 (2014), (29/05/2020, 16:52). Scott Baker & Kimberley D. Krawiec, Incomplete Contracts in a Complete Contract World, 33 Fla. St. U. L. Rev. (2006). <http://ir.law.fsu.edu/lr/vol33/iss3/8> (30/05/2020, 15:03).

لرفضها من طرف جانب من الفقه القانوني الغربي^(١٠)، وبالتالي تعتبر هذه الدراسة تطبيقاً عملياً لوضع النظرية على المحك من خلال مقارنة تهدف إلى بحث مدى إمكانية تطبيقها لحل المنازعات العقدية التي من شأنها أن تثور بعد الخروج من نفق جائحة كورونا.

نعتمد في هذا المقال على المنهج التحليلي لأساس نظرية العقد الناقص وأدواتها القانونية، كما نستعين بالمنهج المقارن لتتبع تطبيق هذه النظرية في أنظمة قانونية مختلفة، مع محاولة تقديم نظرة استشرافية لحل منازعات ما بعد جائحة كورونا.

لقد ظهرت نظرية العقد الناقص في مرحلة سابقة على جائحة كورونا، وتطوّرت من خلال فكرة العقد الإطار، وإعادة التفاوض حول تنفيذ العقد كآلية مستحدثة في بعض القوانين المدنية للحيلولة دون إنهاء العقد، ولكنها تعرّضت لانتقادات لاذعة على أساس أنها تمسّ بالأمن القانوني للعقود، وتتعارض مع القوة الملزمة للعقد، أي "الصراع بين استقرار ومرونة العقود"، إلا أنه بعد فوز صاحبها "أوليفر هارت" بجائزة نوبل للاقتصاد سنة ٢٠١٦، سطعت شمسها من جديد، وأدّى ذلك إلى إحياء النقاش حول: مضمون نظرية العقد الناقص (المبحث الأول).

أمام صعوبة تعميم تطبيق نظرية العقد الناقص بالموازاة مع النظريات التقليدية للقانون المدني، فسنعرّض لدور جائحة كورونا في تطبيق نظرية العقد الناقص من جهة، وكشفها عن محدودية هذه النظرية من جهة ثانية، تحت مظلة: حدود تطبيق نظرية العقد الناقص في ظل جائحة كورونا (المبحث الثاني).

(١٠) حيث اعتبرها الفقه الفرنسي مثلاً تمسّ بـ "حرمة العقد"، l'intangibilité du contrat، راجع في ذلك:

Colloque «Que reste-t-il de l'intangibilité du contrat?», Droit et patrimoine, 58, mars 1998. de la Faculté de Droit de Chambéry du 28 novembre 1998, Droit et patrimoine, mars 1998, p. 55.

إلا أنه خلال العقدين الأخيرين توجّهت الدراسات القانونية الفرنسية إلى الاهتمام بهذه النظرية وتحليلها في إطار اقتصاد العقود أو الاقتصاد والقانون، راجع في ذلك:

Ejan Mackaay, L'analyse économique du droit, I, Fondement; Les éditions Thémis, 2000. Christophe Jamin, Droit et économie des contrats, LGDJ, 2008. Thierry kirat, L'allocation des risques dans les contrats: de l'économie des contrats «incomplets» à la pratique des contrats administratifs, La Revue International de Droit économique, n° 1, 01/01/2003, pp 11-46.

المبحث الأول مضمون نظرية العقد الناقص

لنّ ندّعي في هذا المقال الإلمام بكل جزئيات نظرية العقد الناقص؛ لأنّها تحتاج لمؤلفات وأبحاث، إنّما سنحاول فتح نافذة للبحوث على جزء من الدراسات الاقتصادية التي لم تأخذ حقّها من الجانب القانوني، باعتبار نظرية العقد الناقص نتاج التحليل الاقتصادي للعقد (المطلب الأول)، وعليه سنقتصر على إيجاز الأسس والأدوات القانونية لهذه النظرية (المطلب الثاني).

المطلب الأول نظرية العقد الناقص نتاج التحليل الاقتصادي للعقد

شهد موضوع التحليل الاقتصادي للعقد تطوراً ملحوظاً في المنظومة الأنجلوساكسونية مقارنة بالمنظومة اللاتينية، حيث يعتبر توزيع المخاطر في أداء الالتزامات التعاقدية - خاصة بالنسبة للعقود طويلة الأجل - ذا أهمية قصوى في الجانب الاقتصادي؛ كونه يحقق كفاءة وفعالية العقد^(١١)، وهو ما يسمح بالنظر للعقد من زاوية الغائية.

إلمام الأطراف بكل العناصر الخارجية عن العقد وتضمينها في شروطه يعتبر أمراً مستحيلاً، وهو ما شكّل مبرراً لظهور نظرية العقد الناقص (الفرع الأول)، لتنتقل الفكرة فيما بعد من المجال الاقتصادي إلى المجال القانوني (الفرع الثاني)

الفرع الأول ظهور نظرية العقد الناقص

تندرج نظرية العقد الناقص (يطلق عليها أيضاً النظرية الجديدة لحقوق الملكية)^(١٢) ضمن النظريات التعاقدية للشركات، فهي تتمثل الركيزة الثالثة بعد نظرية تكلفة المعاملات Transaction Costs Theory TCT التي ركّزت على فكرة عدم

(١١) راجع في ذلك: فهد علي الزميع، نظرية العقد من منظور اقتصادي: دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ٢٠٤، ٢٠١٤.

(١٢) Olivier Soutel, L'évolution de la théorie des contrats incomplets face à la dé-intégration vertical, Revue d'économie Industrielle, V 177, 2007, pp 93 -110 (20/05/2020, 23:01).

التأكد ضمن التيار العقدي^(١٣)، ونظرية الحوافز Incentives Theory IT المتعلقة بالعمل الوظيفي داخل الشركة وفق نظرية الوكالة^(١٤).

كانت نظرية العقد الناقص منبوذة ومهجورة في بدايات ظهورها، ولم تنل اهتماماً إلا من بعض الباحثين في المنظومة الأنجلوأمريكية، وبدرجة أقل في ألمانيا وكندا^(١٥). ليسطع نجمها بعد سنة ٢٠١٦ عندما نال صاحبها "Oliver Hart" جائزة نوبل للاقتصاد.

مرت نظرية العقد الناقص حسب "Soutel" بثلاث مراحل^(١٦): بدءاً بثمانينات القرن الماضي (١٩٨٦)^(١٧) عندما اهتمت بتقييم ملكية الأصول ودورها في الإدارة، ثم بحث مدى تأثير الملكية على الحوافز^(١٨)، ليبرز "Hart" في بحث الدور الضروري والناقص لملكية الأصول والهيكل المالي للشركة.

في سنة ١٩٩٠، وضع "Hart" و "John Moore" نظرية حقوق الملكية Property right theory، التي تقوم على أنّ نقص المعلومات وإرادة الأطراف تسمح بإعادة التفاوض على شروط وكيفية تنفيذ العقد سواء لعدم القدرة على الإلمام بكل العناصر المحيطة بتنفيذ العقد أو كخيار استراتيجي للمتعاقدين^(١٩).

قدّم "Ayres" سنة ١٩٩٨^(٢٠) نظرية النقصان في القانون الأمريكي تحت باب

(١٣) Oliver E. Williamson, Transaction Cost Economics: The Natural Progression, The American Economic Review, Vol. 100, No. 3 (JUNE 2010), pp. 673-690, (22/05/2020, 23:45)

(١٤) Bengt Holmstrom and Paul Milgrom, Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design, Journal of Law, Economic, and Organization, V7, 1991, pp 24-52, (25/05/2020, 00:34).

(١٥) Wei Guangyue, op cit, 03.

(١٦) Olivier Soutel, Ibid.,

(١٧) Grossman S.-J. et Hart O.-D. (1986), «The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration», Journal of Political Economy, vol. 94, n° 4, p. 691-719.

(١٨) Hart O. et Moore J. (1990), «Property Rights and the Nature of the Firm», Journal of Political Economy, vol. 98, n° 6, pp. 1119-1158.

(١٩) Oliver Hart and John Moore, Foundations f incomplete contracts, Review of Economic Studies (1999) 66, 115-138, (20/05/2020, 16:34). Oliver Hart, Incomplete contract and control, American Economic Review 2017, 107(7): 1731-1752, (27/05/2020, 19:56).

(٢٠) Iran Aures, Default rules for incomplete contracts, in P. Newman (éd), The New Palgrave Dictionary of economics and the law, Springer, London, 2002. Ian Ayres and Robert Gertner, Filling gaps in incomplete contracts: An economic theory of default rules, Yale Law Journal, V 99 (87) 1989, (18/05/2020, 22:45).

الالتزامات التي تتطلب عملاً قانونياً لسدّ الثغرات "Filling Gaps"^(٢١)، ممّا طرح مسألة صحة العقد، وهل التزامات العقد غير المحددة تسمح باحتفاظه بخاصية الإلزام؟

انتقلت الفكرة فيما بعد من عدم التأكّد إلى عدم التوقّع حسب "Ménard" سنة ٢٠٠١، حيث اعتبر أنّ عدم التأكّد يندرج ضمن فكرة عدم التوقّع في العقد خاصة بالنسبة للعقود طويلة الأجل، وهو ما أثار مسألة القوة القاهرة وعلاقة الظروف غير المتوقعة باستحالة تنفيذ العقد^(٢٢).

الفرع الثاني

نظرية العقد الناقص من المجال الاقتصادي إلى المجال القانوني

وجدت نظرية العقد الناقص في فقه القانون الاقتصادي الأمريكي حاضناً مثالياً لها، واعتبرت نموذجاً مناسباً لتفعيل نظام اقتصاد السوق، فنقصان العقد ليس مفيداً فقط للأطراف المتعاقدة، بل قد يكون اختياراً استراتيجياً للمتعاقدين.

لقد برزت هذه النظرية كنتاج للتحليل الاقتصادي للعقد باعتبار كفاءته وفعاليته الاقتصادية، والتي تتحقّق بتحقيق مكاسب للأطراف المتعاقدة بغضّ النظر عن صحته من الناحية القانونية، أي أنّه يتمّ تصحيح العقد وتجاوز نقصانه متى كانت للأطراف فائدة يمكن تحقيقها منه، أي أنّها تتجاوز فكرة العقد المحدّد وفق النظرية التقليدية للعقد^(٢٣).

بمفهوم المخالفة يمكن تحديد العقد الكامل أو المكتمل بأنّه العقد الذي لا يمكن تعديله إلا بإرادة الأطراف باعتبارها مصدر التزامات المتعاقدين، أي أنّ العقود المبرمة بين الأطراف تأخذ حكم القانون بينهما من حيث القوة الملزمة^(٢٤)، وفي حالة وقوع ظروف طارئة تكون هذه الإرادة وحدها أساس تعديل العقد، والمرجع الأساس في تحديد الالتزامات المستقبلية للأطراف.

توسّعت النظرية خارج نطاق القانون الخاص لتشمل تفسير الاتفاقيات الدولية بغرض سد الثغرات الموجودة فيها من طرف المحكّمين الدوليين باعتبارها عقوداً

Thierry kirat, op cit, p15.

(٢١)

Ibid.,

(٢٢)

Ibid.,

(٢٣)

Ninel Ulloa Maureira, op cit, p 01.

(٢٤)

ناقصة^(٢٥). ثم تعدّت إلى القانون الدستوري عندما امتدت النظرية لتحليل قرارات المجلس الدستوري، حيث تمّ تكييف القاضي كعون اقتصادي، والدستور كعقد بين السلطة والمواطن، لتمثّل النصوص الدستورية دور بنود العقد الناقص^(٢٦).

كون الفقه القانوني الفرنسي حسّاساً تجاه موجة التحليل الاقتصادي للعقد، لم تجد هذه النظرية صدى كبيراً لها في هذه المنظومة إلّا مؤخراً نتيجة التوجّه العالمي لعولمة قانون العقود والتنافس لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار من جهة، وجعل الهيئات القضائية الفرنسية أكثر جاذبية من جهة ثانية. وعليه تم تقديم العقد الناقص بأنّه: "عقد يتضمّن عدّة شروط مفتوحة أو غير محدّدة تحوّلًا للمستقبل"^(٢٧).

يمكن القول إنّ الفقه الفرنسي يحاول تصوّر نظرية العقد الناقص من خلال عقد البيع البسيط الذي يستلزم تحديد محلّه بدقة، أو كفكرة الشركة الصغيرة عند "ديموج"^{١٩٢٣}، أو مجمّع صغير عند "ماكناييل"^{١٩٧٨}، وهذا باعتبار العقد سنفونية صغيرة متناسقة بين الأطراف^(٢٨).

في حين أنّ القانون الأمريكي اعتمد على نظرة مجتمعه في تقييم العقد المستمدّة من الشركات العابرة للحدود والمجتمع التعاقد الدولي، حيث يأخذ بنظره توسعية تحوّل عقد البيع البسيط إلى عقد التوريد الذي يكون فيه تحديد الكميّة أو السعر متغيّراً بشكل دوري، أي أنّ الفقه الفرنسي انتقل من القانون إلى الواقع، في حين انتقل الفقه الأمريكي من الواقع إلى النصّ التطبيقي محاولاً تجاهل الأسس والأدوات القانونية لنظرية العقد الناقص.

المطلب الثاني

الأسس والأدوات القانونية لنظرية العقد الناقص

يركّز أنصار نظرية العقد الناقص في تقديمها إلى الساحة القانونية على جملة من الأسس (الفرع الأول)، وتعتمد في إثبات وجودها في ميدان الالتزامات على بعض الأدوات القانونية (الفرع الثاني).

(٢٥) Alschner, Wolfgang, Interpreting Investment Treaties as Incomplete Contracts: Lessons from Contract Theory, 30th Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE), July 18, 2013. Available at SSRN: (3005/2020, 10:42).

(٢٦) Sophie Harnay, L'analyse économique du juge constitutionnel», Revue Inter-disciplinaire d'Etudes Juridiques, 78, 2017, pp. 109-124.

(٢٧) Christophe Jamin, Ibid.,

(٢٨) Ibid.,

الفرع الأول

الأسس القانونية لنظرية العقد الناقص

أخذت نظرية العقد طريقها إلى المجال القانوني باتباع سياسة البناء على الأطلال، أي الانطلاق من نقائص نظرية العقد التقليدية القائمة لوضع مقوماتها الخاصة (أولاً)، محاولة في ذلك - ككل نظرية جديدة أو مستحدثة - تجاوز الانتقادات الموجهة إليها (ثانياً).

أولاً: مقومات نظرية العقد الناقص

يمكن حصر المقومات التي اعتمدت عليها نظرية العقد الناقص للولوج إلى العلوم القانونية في: "تعزيز إرادة الأطراف"، "التحفيز العقدي"، "تقليل تكلفة العقود".

تنطلق نظرية العقد الناقص من أنَّ العقد الكامل هو ذلك العقد الذي يبرمه المتعاقدان برضا تام، ويتحقق هذا الأخير متى لم يشبه أي عيب مهما كان مقداره، ومن ذلك: الرضا التام بالوقائع المتنبأ بها، واتفقهما على الحلول في حالة وقوع هذه الظروف، وعليه لا يوجد عقد كامل من الناحية الواقعية مع اختلاف في درجة النقصان من عقد لآخر^(٢٩) لذا يعمل الأطراف على تخصيص جزء من الإرادة لما يمكن أن يحدث مستقبلاً، فتتحرك هذه الإرادة لاستكمال البنود غير المنصوص عليها في العقد بغرض تحقيق توازنه، ولكن يكون سدّ الثغرات من أطرافه وليس من طرف الغير^(٣٠). إنَّ فالغرض من النظرية هو الحفاظ على استمرارية العقد تحت أي ظرف كان، بما معناه إلغاء إمكانية خضوع الأطراف إلا لسلطان الإرادة.

تعمل نظرية العقد الناقص على جعل العقد مفتوحاً، بحيث يكون للأطراف القدرة على اتخاذ القرارات، ولا يكونون مجرد طرف فيها، لأنَّ العدالة ترتبط باتخاذ القرار السليم في الظروف المناسبة، فهي تمنح لأطراف العقد القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذه تحت ظل أي ظرف مستقبلي^(٣١). وهي بذلك تتجاوز المتغيرات الخارجية للعقد (تغيّر سعر المواد الأولية أو العملات، الكوارث الطبيعية، والأوبئة)، وتسمح بتطبيق إرادة الأطراف المتغيرة مع تطورات تنفيذ العقد المتأثر بالظروف الخارجية.

Scott Baker & Kimberley D. Krawiec, op cit, p725.

(٢٩)

Ninel Ulloa Maureira, op cit, p 06, 07.

(٣٠)

Oliver Hart, Incomplete Contracts and Control, Royal economic Society, Past-Presidents Plenary, 02/05/2017 (25/05/2020, 10:03).

(٣١)

ترتكز نظرية العقد الناقص أيضاً على عدم تماثل المعلومات بين أطراف العقد، فاختلاف مركز الأطراف يجعل أحدهم يبرم عقداً يكون المستفيد الأكبر منه في حال وقوع ظروف يتوقعها بحكم خبرته أو إمكانيته، دون أن يكون الطرف الآخر في المركز نفسه^(٣٢). بمعنى آخر، أن النظرية تعمل على أن يكون أطراف العقد في حالة من المساواة دون أن يستمتع أحدهما بحق امتياز في اتخاذ قرار، أو الاستفادة من ظروف لو كان يعلمها الطرف الآخر قبل التعاقد لكانت إرادته قد اتجهت نحو اتخاذ تصرف قانوني آخر. لكن، هل تفسّر النظرية كل بنود العقد أم يجب التمييز بين الشروط الثابتة والشروط القابلة للتغيير؟ إن القواعد الثابتة وجدت لحماية أطراف العقد أو الغير، وعليه تعود بنا النظرية للصراع التقليدي بين الإرادة والقانون في فرض أحكامهما على العقد. تعمل نظرية العقد الناقص على تقوية فكرة التحفيز التعاقدية، فالحقوق المتولدة نتيجة إبرام العقد نوعان: حقوق محدّدة بالعقد تسمى بالحقوق العقدية، وحقوق غير محدّدة بالعقد تسمى بالحقوق المتبقية^(٣٣)، فحسب "أوليفر هارت" إذا كان العقد غير مكتمل (وهو كذلك لا محالة)، فينبغي أن يكون لأحد أطراف العقد حقوق سيطرة متبقية Residual Rights Control، تسمح لأطراف العقد أن يتخذوا قرارات لم يتم التفصيل فيها في العقد^(٣٤).

مثال ذلك: إذا كان لمقاول فكرة دون أن يكون له المال الكافي، في حين يوجد في جانب آخر مستثمر له أموال دون أن تكون لديه الفكرة المناسبة، فيتقدّم المقاول للمستثمر بعرض يمنح بموجبه حقوق مشاركة في الأرباح المستقبلية أو عائد ثابت، لكن هناك بعض المسائل من غير الممكن التحكم فيها حالياً، وحتى يتفادى المقاول منح المستثمر عائداً مرتفعاً، يعوّضه عن ذلك بمنحه صلاحية التحكم والسيطرة على العقد، فيتعهد المقاول أن يمنح المستثمر مبالغ خلال فترات معيّنة، وفي حالة إخفاقه في أية مرحلة يمنح المستثمر حقّ التصرف في العقد والسيطرة عليه، أي أن التصرف في العقد يعدّ بمثابة تهديد على رقبة المقاول، فإذا حدث طارئ ما، يلجأ الأطراف إلى إعادة التفاوض، ويكون المستثمر في مركز قوة مقارنة بالمقاول^(٣٥).

Ibid., (٣٢)

Steve W. Feldman, Laws as implied contract terms: The divergent approaches and a proposed solution, University of Pennsylvania, Journal of Business Law, Vol. 19 Issue No. 4, p 07 (29/05/2020, 00:20). (٣٣)

Oliver Hart, Ibid., (٣٤)

Oliver Hart, Incomplet contract and control, Royal economic Society, Ibid., (٣٥)

تعمل النظرية أيضاً على تقليل تكلفة العقود، فمن المعلوم أنَّ العقود باختلاف أنواعها المدنية، التجارية، الإدارية، والدولية، تتطلب تكلفة أو مصاريف مرتبطة بكتابة العقد، تنفيذه، حل منازعاته، وتكاليف التدابير والإجراءات الخاصة بمعالجة الظروف الاستثنائية^(٣٦). فوفق هذه النظرية: كلما كان العقد ناقصاً نقصت تكاليف العقد، وكلما كان أكثر تفصيلاً زادت هذه التكاليف^(٣٧).

فالعقود الزمنية أو المرحلية في التعاقد تسمح بالاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية^(٣٨)، في حين أنَّه وفق النظرية التقليدية يتم التعاقد حسب النظرة الآنية لقدرات المتعاقدين، وعليه فنظرية العقد الناقص تعتمد على التحفيز التعاقدي -المذكور أعلاه- الذي يؤدي بدوره إلى تقليل تكلفة العقد.

لم تتوقف النظرية عند فكرة العقد، بل اتسعت مجالها لتشمل كل التصرفات القانونية، فمن جهة لم توضع هذه النظرية لظروف استثنائية فقط على غرار بعض النظريات المعروفة في القوانين المدنية (الظروف الطارئة والقوة القاهرة)، إنما كأساس تقوم عليه كل العقود والالتزامات، وتتعدى ذلك إلى بعض التصرفات القانونية، فهي تتعدى النقصان الخارجي الوارد بسبب ظروف لا دخل لإرادة الأطراف فيها كظروف استثنائية غير متوقعة لتشمل أيضاً النقصان الداخلي الذي يكون إرادياً ومقصوداً من المتعاقدين^(٣٩).

من جهة ثانية، يتسع مجال نظرية العقد الناقص ليشمل قانون الشركات وتنظيم العلاقة بين الشركاء (أصحاب الملكية)، والمديرين (إدارة الشركة)، وفكرة الوكالة وتعارض المصالح، بالإضافة إلى عقود التأمينات والخصخصة.

هذا التوسع على مستوى بنود العقد، وعلى مستوى التصرفات التي يمكن أن تشملها النظرية، بالإضافة إلى الفلسفة القائمة عليها، ولّد جملة من الانتقادات والجبهات المعارضة لها.

Wendy Netter Epstein, op cit, p 305. (٣٦)

Susheng Wangm, Definition of incomplete contract, Hong Kong University of Science & Technology (HKUST) - Department of Economics, July 27, 2016, pp 01-11, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2815104 (30/05/2020, 08:10). (٣٧)

فهد علي الزميع، المرجع السابق، ص ص ١٥٢، ١٥٥. (٣٨)

Robert E. Scott, A theory of self-enforcing indefinite agreement, The Columbia Law Review, Nov Vol. 103, N= o 7, Nov 2003, pp. 1641-1699, (15/05/2020, 14:35). (٣٩)

ثانياً: نقد نظرية العقد الناقص

لاقت النظرية في بداية ظهورها انتقادات كبيرة، ولم تلق قبولاً في المجال القانوني، فأصل النظرية - كما ذكرنا - اقتصادي ورياضي، وصّف من طرف الفقه القانوني بـ "المروّع"^(٤٠). كما كان للخوف من فشل التقديم الاقتصادي للعقد دور بارز في نبذ النظرية، لأنّ للعقد آثاراً اجتماعية وبيئية لا يمكن تجاهلها أيضاً، ولا يمكن الإفراط في توزيع البحوث على كل هذه الجوانب في الوقت نفسه^(٤١).

تهدم هذه النظرية أحد مقومات النظرية التقليدية للعقد، وهو الأمن القانوني واستقرار المعاملات، فإذا كانت القوانين الغربية لم تعترف بنظرية الظروف الطارئة على عكس القوانين المدنية العربية التي أخذت بها كأساس لتعديل العقد، وتدخل القاضي لإعادة التوازن إليه، فكيف لها أن تعترف بنظرية تمسّ بجوهر القوة الملزمة للعقد؟

تقوم نظرية العقد الناقص على جعل الباب مفتوحاً أمام إرادة الأطراف لوضع ما يرونه مناسباً في المستقبل، وفي هذا دعم واضح لمبدأ سلطان الإرادة، إلاّ أنّه يقوم على افتراض وصول الأطراف إلى الحلّ المناسب من خلال إعادة التفاوض، وهو ما لا يمكن تقبله في كل الحالات.

فإذا كان المعوّل عليه هو الإرادة، فهي لا تغيب في النظرية التقليدية للعقد حتى في إيجاد حلول للمنازعات تحت مسمّى الوسائل البديلة والوسائل الودية لحلّ المنازعات، وقد أثبتت التجربة العملية فشلها في كثير من المجتمعات، كما أنّ القواعد الأخلاقية المتواجدة في القوانين ونظريات العقود عموماً تقلّل من حالات الاستغلال للمراكز القانونية وتفاوت المعلومات بين المتعاقدين.

فضلاً عن أنّ هذه النظرية تهدم أساسها بنفسها، حيث إنّ جعل العقد صحيحاً رغم نقصانه يتعارض مع فكرة استقلال إرادة الأطراف متى أدّى ذلك إلى إبرامهم عقداً لم يكونوا يرغبون به في الأصل، وإنّما التعبير عن القبول يكون لاحقاً نتيجة تدخّل عامل خارجي عن العقد لتكاملته^(٤٢)، فعدم وجود الكمية مثلاً في أصل العقد قد تحكمه عوامل الإنتاج والاستهلاك، وهي عوامل لا علاقة لها بإرادة الأطراف المتعاقدة، كما قد تتدخّل مصادر أخرى لتكملة العقد كالعرف أو الأعراف التجارية أو الأحكام التنظيمية، وهي مسائل تتعدّى إرادة الأطراف المتعاقدة، وتختلف من حال لآخر. في

Ninel Ulloa Maureira, op cit, p 03.

(٤٠)

Ibid.,

(٤١)

Ibid, p 01.

(٤٢)

حين أن تعديل العقد بشكل يمسّ جوهره يعني أننا أمام عقد أو عقود جديدة وليس أمام العقد الأصلي، ومحلّ النزاع في ظل النظرية التقليدية للعقد هو محاولة إيجاد حلّ مناسب للعقد الأصلي متى طرأت عليه ظروف غير متوقعة.

من جهة ثانية يؤسس أصحاب نظرية العقد الناقص موقفهم تجاه الظروف الطارئة بأنّ العقد الناقص يسمح بإعادة التفاوض حول ظهور هذه الحالات، لكن المتعاقدين في حقيقة الأمر لا يعرفان احتمالات ظهور هذه الحوادث والظروف الطارئة، وبالتالي لا تظهر فائدة من هذه النظرية خاصة أنّ هذه الحوادث والظروف تبقى استثنائية، فليس من المعقول أن نجعل من الاستثناء قاعدة^(٤٣).

يردّ مؤيدو نظرية العقد الناقص على أنّ قلة الرقابة على العقد المفروضة بموجب نصوص محدّدة تزيد من حسن نية الأطراف، وأنّ ازدياد السلوك الانتهازي للأطراف يمكن معالجته من خلال الحثّ على الأعمال (الحوافز) وليس عن طريق التأطير الأخلاقي، لأنّ العقود الناقصة تمنح الوكلاء استقلالاً أكبر، والحوافز تعزّز حسن النية لديهم^(٤٤).

لن ندعي أنّ فوز النظرية بجائزة نوبل كان سبب إدراجها في القانون المدني الفرنسي، حيث إنّ مشروع التعديل قد تمّ تحضيره مسبقاً بغرض جعل القانون المدني أكثر انفتاحاً ومرونة، وتعزيز الأمن القانوني، وتحقيق فعالية القواعد القانونية^(٤٥)، إنّما لهذا التوافق التاريخي دلالة على تأثير - ولو نسبي - لنظرية العقد الناقص على القانون المدني الفرنسي، بعد أنّ تقلّصت حدّة الانتقادات الموجهة للنظرية، وأخذت في التسلّل للمنظومات الغربية، مع التنبيه على وجود أدوات مسبقة لتطبيق نظرية العقد الناقص معترف بها في معظم القوانين.

الفرع الثاني

الأدوات القانونية لتطبيق نظرية العقد الناقص في مجال العقود

تتناثر العديد من الأدوات القانونية التي تسمح بتبني نظرية العقد الناقص في مجال العقود، ومن أهمّها: إعادة التفاوض (أولاً)، العقد الإطار (ثانياً)، الشروط المتغيرة والربط القياسي (ثالثاً)، تفسير العقد (رابعاً)، وبدرجة أقلّ مبدأ حسن النية (خامساً).

(٤٣) Ibid.,

(٤٤) Wendy Netter Epstein, op cit, p311.

(٤٥) (Mustapha Mekki, La bonne foi dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations du 23 octobre 2013, (12/05/2020, 12:34).

أولاً: إعادة التفاوض وتطبيق نظرية العقد الناقص

يشمل إعادة التفاوض ثلاث مراحل أساسية: إعادة التفاوض قبل التعاقد، إعادة التفاوض التعاقد، وإعادة التفاوض بعد التعاقد، مع اختلاف الآثار القانونية للتوقف عن التفاوض باختلاف المنظومات القانونية المعنية بالتعاقد، وفي الوقت نفسه لكل مرحلة من المراحل السابقة إشكالات وحلول مختلفة حتى داخل المنظومة القانونية نفسها^(٤٦).

سواء أكان إعادة التفاوض بموجب شرط في العقد أم اتفاق لاحق^(٤٧)، فهو يسمح للأطراف بالاتفاق على صيرورة العقد وفق إرادتهم الحرة، ويعمل على تكيفهم مع التغيرات الطارئة لإعادة التوازن للعقد، وتجنب التنفيذ المرهق لأطرافه، كما أن الفسخ الفعّال للعقد وفق نظرية العقد الناقص يكون عندما يرغب كلا الطرفين في عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، أي أن خرق الالتزام التعاقدية ينبغي أن يؤدي للفسخ فقط في حالة توجّه إرادة الطرفين إلى هذه النتيجة^(٤٨).

تساعد إعادة التفاوض على تصحيح الخلل المترتب عن تفاوت المعلومات بين الأطراف المتعاقدة، فهو يمثل أداة سابقة ولاحقة على إبرام العقد تسمح للأطراف بسدّ فجوة المعلومات وتوجيه العقد وفق المعطيات الجديدة المحصّل عليها قبل وبعد تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

يضيف إعادة التفاوض مرونة على العلاقة التعاقدية، حيث يجعل التزامات الأطراف أقلّ حدة، ويسمح لهم بتعديل العقد وفق المتغيرات الطارئة، وهو بذلك ينقص من تكلفة المنازعات حول تنفيذ عقود مرهقة، وفي الوقت نفسه تفادي الوصول بالعقد إلى الحل.

تقوم نظرية العقد الناقص على تكريس إرادة الأطراف في التفاوض وإعادة التفاوض حول العقد وكيفية تنفيذه، وهذا دون الحاجة لتدخل الغير^(٤٩)، أي أنها تقوم على ثقة الأطراف في الوصول إلى الحل المناسب للعقد وللمتعاقدين بموجب إرادتهما الحرة المتغيرة مع طريقة تنفيذ العقد والظروف الطارئة عليه.

(٤٦) See; Jeswald W. Salacuse, Renegotiating international business transactions: The continuing struggle of life against form, The international lawyer, V 35m n = o4, 2001, pp 1507-1541, (06/08/2020, 07:27).

(٤٧) علاء الدين الخصاونة، الجوانب القانونية للالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة العقود، مجلة الحقوق الكويتية، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد ٠١، ٢٠١٤، ص ٦١٨.

(٤٨) Christophe Jamin, op cit, p 190.

(٤٩) Ninel Ulloa Maureira, op cit, p 07.

ثانياً: العقد الإطار كأداة لتطبيق نظرية العقد الناقص

العقد الإطار عقد مواضيعه العامة محدّدة بشكل عام، لكن تفاصيل التسليم، والتفاصيل الخاصة بالثمن يمكن تحديدها لاحقاً وفق معيار معين^(٥٠)، ورغم عدم وجود نصوص في معظم القوانين المدنية توضّح أحكامه بالتفصيل، إلّا أنّ الممارسة العملية أثبتت جدواها بالجمع بين عدّة عقود مترابطة لا تنصّ على تفاصيل دقيقة حول الكمية أو الثمن، بل يتمّ تحديدها لاحقاً وفقاً لسعر معقول، أي يترك هامش حرية للتفاوض بين الطرفين^(٥١).

لا يقوم العقد الإطار بتحديد تام ونهائي للعناصر الأساسية للمبادلة الاقتصادية أو التزامات الطرفين، فهو يمثّل "عقداً قاعدياً Contrat de base" يحتاج محله إلى تحديد شامل وتوضيح تام ونهائي^(٥٢)، وفي السياق نفسه يعتبر "الاتفاق المبدئي Accord de principe" التزاماً ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة^(٥٣).

إنّ العقد الإطار يعتبر عقداً ناقصاً بامتياز خاصة في العقود الطويلة كعقود الاستثمار وعقود الأشغال العامة الضخمة^(٥٤)، حيث لا تسمح التغيّرات التجارية والتقنية بتحديد مضمون العقد بدقّة، لذا يتم وضع الإطار العام للعقد، وتترك التفاصيل للاتفاق اللاحق على إبرام العقد.

يمثّل نقصان المعلومات حول مآل العقد والتغيرات المستقبلية أساس قيام نظرية العقد الناقص، لذا يتوجّه المتعاقدان إلى الاحتفاظ بجزء من الإرادة للتعامل مع المعطيات المستقبلية^(٥٥)، وهو نفس سبب ظهور العقد الإطار، بالإضافة إلى عنصر المرونة الذي يساعد الأطراف المتعاقدة على تجاوز العقبات المستقبلية.

يمثّل عدم التحديد اليقيني عنصراً مشتركاً بين العقد الإطار ونظرية العقد الناقص، فكلّا الأمرين يجعلان العقد مفتوحاً، أو يكتفي بوضع ملامح العقد المستقبلي

Ninel Ulloa Maureira, op cit, pp 14-16. (٥٠)

Ibid,. (٥١)

M. Jacques Ghestin, La notion de contrat-cadre et les enjeux théoriques et pratiques qui s'y attachent, in CREDA, Le contrat-cadre de distribution, Colloque organisé à Paris les 11 et 12 décembre 1996, (09/09/2020, 05:09). (٥٢)

Ibid,. (٥٣)

Ninel Ulloa Maureira, Ibid,. (٥٤)

Scott Baker & Kimberley D. Krawiec, op cit, p726. (٥٥)

المراد إبرامه، لذا لاقى العقد الإطار على غرار نظرية العقد الناقص رفضاً في الفقه والقضاء الفرنسي لفترة من الزمن، ليتم قبوله على مضض في السنوات الأخيرة^(٥٦).

ثالثاً: الشروط المتغيرة والربط القياسي ونظرية العقد الناقص^(٥٧)

من المعلوم أنه ليست كل شروط العقد على قدر متساوٍ من حيث الثبات أو القابلية للتغيير، فالشروط المتضمنة حوافز لأحد المتعاقدين متغيرة بحسب نسبة وكيفية تنفيذ التزاماته التعاقدية، تجعل العقد ناقصاً متوقفاً تنفيذه على تحقيق نتائج عملية.

فمحل العقد وفق النظرية التقليدية يكون محدداً أو قابلاً للتحديد، وإذا كانت صفة التحديد لا تثير إشكالاً من حيث الجملة، فإن القابلية للتحديد تتفاوت نسبتها من درجة لأخرى، فقد يكون نقصان العقد مفروضاً على الأطراف في حالة كان الثمن أو محل العقد متغيراً من حيث الأصل، كما يمكن أن يكون التغيير بسبب ظروف خارجية غير متوقعة، فيمكن أن يعطي أحد أطراف العقد للطرف الآخر مجالاً للقياس يكون من حقه الحصول على ثمن لا يتجاوز الحد الأعلى المتفق عليه، كما لا يقل عن الحد الأدنى المتفق عليه أيضاً، ويكون تقدير الثمن واجب الدفع بحسب نسبة التكلفة المرتبطة بدورها بسعر أو أسعار مواد أخرى ذات صلة بمحل العقد المتفق عليه^(٥٨).

وعليه، تكون هذه الطريقة أفضل من اشتراط أحد الأطراف سعراً مرتفعاً يتحوط بموجبه من إمكانية ارتفاع الأسعار عن السعر المتفق عليه والمتوقع من طرفه أو من طرف كلا المتعاقدين. بمعنى آخر تجنب أن يتعرض أحد الأطراف لظلم (غبن) أو خسارة تجعل من العقد مرهقاً وإن لم يكن مستحيلاً.

يلعب الربط القياسي دوراً بارزاً في تفادي تآكل الديون، فالمخاطر المتعلقة

(٥٦) Cass. Civ n=o 70-10752 du 27/04/1971. Cass. Civ n=o 77-10155 du 11/10/ 1978. Cass. Civ n=o 91-15578 du 01/12/1995. See; F. Pollaud-Dulian et A. Ronzano, Le contrat-cadre par déla? les paradoxes: RTD com. 1996, p. 179. J. Gatsi, Le contrat-cadre, Bibl. dr. prive?, n= o 273, LGDJ, 1996.

(٥٧) الربط القياسي هو جعل دين أو التزام مالي آخر يتغير مبلغه بالزيادة أو النقصان عند الاستحقاق بتغير مقياس أو مؤشر معين لا يكون مستواه معروفاً عند التعاقد بل عند الاستحقاق، أو هو: اتفاق أو نظام على ربط دين مؤجل كله أو بعضه بمؤشر (معياري) معين أو جزء منه، يكون الوفاء به عند حلوله بقدر من جنس الدين، يعادل قيمته بحسب المؤشر المعتمد عليه عند العقد. محمد علي القري، دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عدد ٢٠٢، ج ٠٤، ص ١٧.

(٥٨) Oliver Hart, Incomplet contract and control, Royal economic Society, Ibid.,

بمعدل تقلب أسعار سندات الملكية، خطر التسوية بمقابل، وخطر الصرف من قبيل مخاطر تغير الأسعار، وخطر التسوية، وتزداد هذه المخاطر عندما تؤدي إلى تآكل الديون بسبب مشكلة التضخم، الذي يؤدي إلى تدهور القيمة الحقيقية لجميع الحقوق والالتزامات الآجلة^(٥٩)، وبالتالي تغيير في المركز المالي للمتعاقدين، حيث يستفيد منه المدين ويخسر الدائن، ويزداد ضرر الدائن بزيادة طول مدة العقد.

يعتبر تأكل القيمة الوفاءة للدين مقارنة بقيمته العقدية، وبعبارة أخرى الأوراق النقدية نفسها لكن تتفاوت القيمة الشرائية بين زمن العقد وزمن الوفاء بالدين الذي تكون له قيمة اسمية وقيمة فعلية^(٦٠). تتأثر قيمة كثير من العقود والالتزامات الآجلة نتيجة التغيرات في أسعار السلع والخدمات بفعل عوامل العرض التي لا يمكن التنبؤ بها، وعوامل التضخم المتفاقمة التي يصعب القضاء عليها في الوقت العاجل، نتيجة وقوع ظروف استثنائية لم يكن الأطراف على علم بها، وليس لهم القدرة على التنبؤ بوقوعها، لذا يعتمد المتعاقدون على مؤشرات لضبط التوازن العقدي.

تنقسم القوانين من حيث منعها لإمكانية الربط القياسي للحقوق والالتزامات بالذهب مثلاً أو ما يسمى بـ "شرط الذهب" إلى ثلاثة اتجاهات: تذهب بعض القوانين، كالقانون المصري، إلى المنع المطلق من اعتماد غير النقود الورقية كوسيلة للتقدير، خاصة بعد صدور المرسوم رقم ٤٥ لسنة ١٩٣٥ الذي نصّ على بطلان شروط الدفع

(٥٩) يميز الفقهاء بين:

– تغير قيمة النقود من خلال مقارنة قوتها الشرائية بالنسبة للذهب، أي مقدار ما تساويه وحدة نقدية من الذهب، ويطلق عليها القيمة الاسمية للنقود أو التنظيمية أو الشرعية.

– تغير قيمة النقود بمعنى القيمة الخارجية لها أي نسبة مبادلة العملة الوطنية بغيرها من العملات الأجنبية، أو سعر الصرف، ويتم تحديدها في ظل العملات الورقية بواسطة السلطات المالية للدولة، وتتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية عن طريق الطلب الخارجي على العملة الوطنية.

– تغير قيمة النقود بمعنى القوة الشرائية للنقود على سائر العملات والخدمات، وتعرف بالقيمة الحقيقية للنقود، والتي تختلف عن القيمة الاسمية بأن هذه الأخيرة ثابتة لا تتغير، في حين تتبع الأولى التغير الحادث في الأسعار، وهو المقصود بسلطان النقود في المبادلة بسائر السلع والخدمات، أي وجود ارتباط عكسي بين قيمة النقود وأسعار السلع.

عيسى بن مصطفى، أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي – دراسة مقارنة –، مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية، الخروبة، جامعة الجزائر، ٢٠٠٨، ص ٤٠.

(٦٠) رفيق يونس المصري، آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية، دار المكتبي، دمشق، سورية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٩، ص ٠٧.

بالذهب في العقود التي يكون الالتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية^(٦١). في حين تتجّه الاجتهادات الحديثة لمحكمة النقض الفرنسية إلى قبول الربط بالذهب أو بعملة أخرى إذا وجدت علاقة بين محل العقد ونشاط الأطراف^(٦٢). وإذا كان شرط الذهب قد تمّ منعه في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون احتياطي الذهب The Gold Reserve Act 1934، فإنّ الكونغرس قد أعاد إمكانية استخدامه في العقود المبرمة بعد أكتوبر ١٩٧٧، وهو ما أكّده القضاء الأمريكي^(٦٣).

يبدو أنّ الربط القياسي يشكّل أداة لتقييد حرّية الأطراف في توجيه العقد مستقبلاً؛ لأنّه يربط مآل العقد بمؤشرات خارجة عن إرادة الأطراف، لكنّه في حقيقة الأمر يمثّل إحدى الأدوات التي تخرج عن المألوف في النظرية التقليدية للعقد، وتكرّس فكرة التحوّط من التغيرات المستقبلية من خلال أدوات قابلة للقياس، وهو بذلك يشترك مع نظرية العقد الناقص في جانبها المتعلّق بالنقصان الإلزامي أو الخارجي.

رابعاً: تفسير العقد وتطبيق نظرية العقد الناقص:

يرى جانب من الفقه^(٦٤) أنّ نظرية العقد الناقص قد عانت من توجيه مقصود من الفقه القانوني لنظرية العقد، وفشل ذريع في تفسير قدرة العقود الناقصة على تلبية رغبات الأطراف المتعاقدة في جعل العقد مفتوحاً كخيار استراتيجي^(٦٥). فمحاولة نقل نظرية العقد الناقص من الفقه الأمريكي إلى الفقه الفرنسي جعلها مشوّهة، حيث إنّ الفقه الأمريكي يركّز في تقديمه للنظرية على إرادة الأطراف المتطورة مع تنفيذ العقد، في حين يحاول الفقه الفرنسي إيجاد مجال لها في التفسير التقليدي للعقد من طرف القاضي أو المحكّم.

إنّ عملية التفسير ولو تمّت من خلال الرجوع إلى إرادة الأطراف المستنبطة لا يعني أنّ ذلك هو مقصود الأطراف، فقد لا يرمي المتعاقدان إلى ما يذهب إليه القاضي، وقد تكون إرادتهما بعد وقوع النزاع غير تلك التي كانت قبله، بل إنّ التفسير الخاطئ لإرادة الأطراف المتعاقدة يمسّ بجوهر نظرية العقد الناقص التي تحاول

(٦١) محكمة الاستئناف المختلطة، قرار بتاريخ ١٨/٠٢/١٩٣٦، مجلة الأحكام المصرية، عدد ٤٨، ص ١٤٢.

(٦٢) Cass. Civ. 3, du 18 octobre 2005, 04-13.930, www.legifrance.gouv.fr (10/02/2016).

(٦٣) <http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/08a0322p-06.pdf> (05/05/2016).

(٦٤) Wendy Netter Epstein, op cit, p 304.

(٦٥) Ibid.,

"سدّ الثغرات Filing Gaps" بإرادة الأطراف. حيث ترى المحكمة العليا لمقاطعة "الاسكا" أنّ: "الأطراف المتعاقدة لا يمكنهم ملء كل الفراغات بخصوص الحالات الطارئة التي يمكن أن تظهر، فالمحكمة يمكنها سدّ الثغرات في العقد لضمان النزاهة عندما تكون توقعات الأطراف واضحة. عندما يشير سلوك أو تعبير الأطراف في الاتفاقية إلى وجود نية كافية لإبرام العقد، فللمحكمة المجال الواسع لسدّ الثغرات ... لكن لا ينبغي أن تفرض على أيّ طرف أداء ما لم يوافق عليه وربما لم يكن ليوافق عليه^(٦٦). أيّ أن سلطة القاضي وفق نظرية العقد الناقص جدّ محدودة، وتكون في كثير من الأحيان منعقدة أمام إرادة الأطراف المتعاقدة.

يحاول القاضي من تفسير العقد وفق النظرية التقليدية الوصول إلى نية الأطراف عند إبرام العقد وليس لإرادتهم الحالية المتطورة نتيجة اطلاعهم على آثار تنفيذ العقد، فبدلاً من معاقبة النقصان والمرونة حسب مؤيدي نظرية العقد الناقص، ينبغي بحث كيف تجيب المرونة عن الصحة وأيضاً عن تفسير العقد، فلا يتوقّف عند إرادة الأطراف أثناء إبرام العقد، بل كيفية تطوّر هذه الإرادة مع تنفيذ العقد^(٦٧).

إنّ تقييد إرادة العقد بإرادة الأطراف المبرمة للعقد تخنق الإبداع وتقلّل من فرص الابتكار والتطوير، وتقف أمام التحفيز التعاقدية التجاري؛ حيث إنّ في عقود الابتكار مثلاً قد تتفق الشركات على تطوير تكنولوجيا معينة، فيستخدمون كلّ إمكانياتهم لتسليم الشيء غير المحدّد، فكيف يمكن للقاضي تفسير إرادة الأطراف في هذه الحالة؟^(٦٨).

تحاول نظرية العقد الناقص الإجابة عن هذا التساؤل من خلال البحث عن نية الأطراف المعاصرة للتنفيذ وليس الإبرام، هذه النية أساسها التعاون لتخفيف المخاطر، أي أنّ المسألة مرتبطة بعدم التأكّد المتعلّق بطبيعة العقد، لذا تكون إرادة الأطراف الأقرب لتوجيه العقد حسب المستجدات^(٦٩).

(٦٦) Because contracting parties cannot plan for all contingencies that might arise, a court may fill gaps in contracts to ensure fairness where the reasonable expectations of the parties are clear. [Accordingly]when the conduct or expressions of parties to an agreement indicate a sufficient intent to make a contract, a court has latitude to fill in the gaps... [but] the courts should not impose on a party any performance to which he did not and probably would not have agreed". See; Steve W. Feldman, op cit, p21.

Wendy Netter Epstein, op cit, p297.

(٦٧)

Ibid.,

(٦٨)

Ibid.,

(٦٩)

إنَّ هذا التفسير مبني على التعاون المفترض بين الأطراف، في حين أنَّه في حقيقة الأمر يكون التعاون آنياً تنقطع حلقاته بمجرد الوصول أو وضوح معالم النتيجة النهائية للعقد المتفق عليه، فبإدراك اكتشاف تكنولوجيا معينة، تجعل الأطراف ينتقلون من مرحلة التعاون إلى مرحلة السيطرة، لهذه الأسباب وُجد القاضي لإعادة الأطراف إلى الوضعية العادلة والمنصفة، فلا يمكن بأيِّ حال من الأحوال إلغاء دور القضاء في تعديل العقود، كما أنَّ الجهود المشتركة في التعاون إن استمرت في هذه المرحلة يكون سببها خوف الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من استيلاء الطرف القوي على المنتج المبتكر، أي يظهر اختلال في توازن العقد، وبالتالي يحتاج المتعاقدان لطرف ثالث خارج عن العقد يرجع للعقد توازنه.

إذا كان العقد الناقص أكثر كفاءة من العقد المحدد من حيث كثرة المنازعات، فإنَّ هذه النظرة متعلّقة بالموازنة بين العقدين في مرحلة التنفيذ، وإذا ما حدثت نزاعات بين الطرفين، فالرجوع إلى نية الأطراف قبل إبرام العقد وبعد إبرامه تعزّز قدرة القاضي على الفصل في المنازعة.

حاول بعض الباحثين^(٧٠) تطبيق نظرية العقد الناقص على الاتفاقيات الدولية لمساعدة المحكّمين في تفسير بعض المبادئ الدولية كـ " المعاملة العادلة والمنصفة " و"المصادرة غير المباشرة"، حيث ميّز بين الجيل الأول للاتفاقيات الدولية المندرج تحت مظلة المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية OECD لسنة ١٩٦٧ الذي يميّز بدرجة عالية من النقصان (قليلة المحتوى)، عبارات بسيطة وفضفاضة، تركّز على حماية الاستثمار)، والجيل المحاكي لاتفاقية التجارة والصادقة الأمريكية NAFTA لسنة ١٩٩٢ الذي يميّز بدرجة أقل من النقصان (محاولة الموازنة بين حماية الاستثمار وحقوق الدولة المضيفة)^(٧١). وعليه يمكن أن يتم تفسير الجيل الأول من خلال ممارسات وتطبيقات الجيل الثاني، ممّا يسمح بإنشاء منظومة متناسقة^(٧٢).

إلا أن تطبيقات نظرية العقد الناقص في تفسير العقود جدّ محدودة حتّى لا يعتبر القاضي أو المحكّم وصياً على المتعاقدين، فالنظرية تقوم أساساً على توسيع سلطة الأطراف التعاقدية في مواجهة سلطات القاضي التفسيرية؛ لذا يمكن أن تلعب

Wolfgang Alschner, op c it, p 03.

(٧٠)

Ibid.,

(٧١)

Ibid.,

(٧٢)

اللجان المشتركة بين الدول دور المتعاقدين في إعادة التفاوض حول كيفية تنفيذ بعض المبادئ محل النزاع، وتمثل بذلك إحدى أهم ركائز نظرية العقد الناقص.

خامساً: مدى اعتبار حسن النية كأداة لتطبيق نظرية العقد الناقص

أصول مفهوم حسن النية دينية أكثر منها قانونية^(٧٣)، ظهرت في القانون المدني الفرنسي قبل تعديل سنة ٢٠١٦ في المادة ١١٤٣^(٧٤)، وقد وقع خلاف كبير حول تفسيرها، إن كانت من مخلفات القانون الروماني في التمييز بين عقود حسن النية وعقود القانون الضيق^(٧٥)، أو يقصد بها تنفيذ العقد وفق قصد الأطراف والهدف المرجو من العلاقة التعاقدية^(٧٦)، أو هي أداة أو آلة لتحقيق العدالة. وترى المدرسة الحديثة أنّ حسن النية التعاقدية يتمثل في إقامة التوازن العقدي^(٧٧)، الذي يتحقق بمراعاة كل متعاقد لمصالح المتعاقد الآخر خلال كل مراحل العلاقة التعاقدية^(٧٨).

يبدو للوهلة الأولى أنّ مبدأ حسن النية يخدم نظرية العقد الناقص كونهما يشتركان في إعادة التفاوض حول العقد، وتنفيذ العقد وفق مبادئ العدالة والإخلاص والأمانة حسب الاجتهاد القضائي الفرنسي^(٧٩)، كما تمّ فرض واجب الإعلام تطبيقاً لمبدأ حسن النية والتخفيف من السلوك الانتهازي لأحد الأطراف نتيجة تفوّقه في الجانب المعلوماتي مقارنة بالطرف الآخر^(٨٠). أضف إلى ذلك أنّه من الناحية العملية،

(٧٣) Dennis Tallon, Le concept de bonne foi en droit français du contrat, Saggi, conferenze seminari del Centro di studie ricerche di diritto comparato e straniero diretto da M. J. Bonell, site internet: <http://www.cnr.it> (05/03/2007).

(٧٤) Art 1143 du Code civil français (Avant la modification de 2016) déclare: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».

(٧٥) Stéphane Darmaisin, Contrat moral, LDJ, Paris, édition DELTA, Paris, France, 2000, P141.

(٧٦) François Terré, Droit civil - obligation - Dalloz, 8e édition, 2012, p403.

(٧٧) Ibid, p09.

(٧٨) جاك غستان، المطول في القانون المدني، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ٢٠٠٨، ص ٢٦١.

(٧٩) Civ 1, 20/03/1985. B1985,1,n°201, Voir Béatrice J, Op cit, p 44-50. Denis Tallon, op cit, p 02. CC,.. https://www.jurisprudence.dalloz-avocats.fr/search/dz?query=bonne+foi&sort=tri_dt%3Adown&cursor=rows%3A20 (17/05/2020, 23:40).

(٨٠) Thierry kirat, op cit, P19.

جرى العرف على جعل بعض العقود ناقصة اعتماداً على حسن النية بين الأطراف نتيجة وجود مانع أدبي إذا كان العقد المبرم بين أقارب أو أصدقاء، فيكون تحديد الثمن من طرف واحد.

بعد تعديل ٢٠١٦، أصبح مبدأ حسن النية في فرنسا شاملاً لمرحلة إبرام وتكوين العقد، بعد أن كان خاصاً بتنفيذه، كما قُدم مبدأ حسن النية كمبدأ استراتيجي وتنافسي بين المنظومات القانونية^(٨١). ليتحوّل بذلك إلى مبدأ أخلاقي، اقتصادي، واجتماعي، يواجه أيديولوجية السوق^(٨٢). يقلّص مبدأ حسن النية من مجال ودائرة الحرية التعاقدية؛ لذلك لا يزال يلقي اعتراضات وانتقادات فقهية في المنظومة القانونية الفرنسية باعتباره يعمل على إعادة التوازن العقدي، ويمسّ بالقوة الملزمة للعقد^(٨٣).

وإذا كان بعض الفقه الفرنسي يرى أن مبدأ حسن النية ركيزة أساسية لنظرية العقد الناقص؛ كونه يقوم على واجب المساعدة والتعاون والمشاركة بين المتعاقدين في الوصول بالعقد إلى برّ الأمان^(٨٤)، فإننا نرى أنّ الاحتفاظ بجزء من التحكم والسيطرة على العقد بموجب نظرية العقد الناقص سببه عدم الثقة في الطرف الثاني، أو عدم الثقة في الأسباب الخارجية المحيطة بالعقد، وبالتالي فهو بذلك يقع في موقف وسط بين القوة الملزمة للعقد في شكلها الجامد حسب ما كان يأخذ به القانون الفرنسي قبل تعديل ٢٠١٦، وبين مبدأ حسن النية الذي يجعل العقد قابلاً للتغيير من طرف القاضي، فهو يسمح بتغيير وجهة العقد لكن من طرف المتعاقدين وليس الغير.

ما يؤكّد هذه التقييم أنّ نظرية العقد الناقص قد ظهرت وتطوّرت في أحضان المنظومة الأنجلوساكسونية التي تبلغ فيها الحرية المطلقة للمتعاقد في القانون

(٨١) Mustapha Mekki., La bonne foi dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations du 23 octobre 2013, op cit, p 01.

Ibid., (٨٢)

J.-L. Bergel, Theorie générale du droit, Collection: Méthodes du droit; 4e édition; Parution (٨٣)

Dalloz, 2003. Y.-M. Laithier, Les principes directeurs du droit des contrats en droit compare?, RDC 2013, n° 1, p. 410. P. Morvan, Le principe de droit prive?, e.d. Pantheon-Assas, 1999, n° 763. P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Tome II, Videcoq libraire, 1836, p 3. Cité par; Mustapha Mekki., La bonne foi dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations du 23 octobre 2013, op cit, p 03.

Ninel Ulloa Maureira, op cit, p 08. (٨٤)

العقدي ذروتها في مرحلتي التفاوض وإبرام العقد^(٨٥)، فالعقد في هذه المنظومة عبارة عن عدة وعود متعلّقة بالإرادة، وحسن النية فيها شبه معدوم عند الأطراف في مرحلة التفاوض^(٨٦)، لأنها عملياً تعتبر مرحلة عسكرية يتحضّر فيها الأطراف للهجوم، ولا يمكن خلالها الحديث عن الأخوة والتضامن^(٨٧).

إضافة إلى هذه الأدوات، يمكن الاعتماد على التراث الإسلامي في إيجاد مدخل للنظرية من خلال "البيع بسعر السوق" أو "السلم بسعر المثل يوم التسليم"^(٨٨). ناهيك عن وجود بعض الأفكار القانونية كالشرط الواقف والشرط الفاسخ، وتفويت الفرصة، وتعويض ما لحق من ضرر وما فات من كسب، كما أنّ لها تطبيقات متعددة في نظرية العقد الإداري فيما يتعلّق بمراجعة سعر الصفقات العمومية وتغييره في حدود معينة: عقود الأشغال العامة، عقود التوريد، وعقود الصفقات الصناعية، بالإضافة إلى عقود الابتكار وعقود ترخيص الملكية الفكرية (قبل الحصول على الموافقة التنظيمية) التي تعتبر عقوداً ناقصة بطبيعتها، ولو أراد القانون والأطراف عكس ذلك^(٨٩).

من وجهة نظر شخصية ينبغي التمييز بين النقصان الداخلي (الإرادي) والنقصان الخارجي (غير الإرادي) للعقد، فعندما تتجّه إرادة الأطراف إلى ترك العقد مفتوحاً، فإنّ الغلو في هذا التوجّه يجعل أحد أهم أركان العقد (المحل) مهدّداً، أمّا في النوع الثاني من النقصان فيكون للإرادة دور هام، حيث تبرز فكرة العقد الناقص بأكثر قوة متى كان النقصان لقوة قاهرة أو ظروف طارئة، كما هو الحال بالنسبة لجائحة كورونا، موضوع المبحث الحالي.

(٨٥) يشمل القانون العقدي الإنجليزي، بالإضافة للتوجيهات الأوروبية والاجتهاد القضائي، القوانين التالية:

Law reform Trusted Contracts Act 1943, Third Party Liability 1999, Sales of Good Act 1977 and Unfair Contracts Terms 1977.

Scott Baker & Kimberley D. Krawiec, op cit, p 744. (٨٦)

Dema Valente, Enforcing Promises; Consideration and Intention in the law of contract, PP 04 - 14 www.otago.ac.nz (05/09/2020, 12:34). (٨٧)

Rafic Yunus Al-Masri, Market Price of Salam on the Date of Delivery: Is it Permissible? J.KAU: Islamic Econ., Vol. 16, No. 2, pp. 29-32 (29/05/2020, 10:23). (٨٨)

Wendy Netter Epstein, op cit, p313. (٨٩)

المبحث الثاني

حدود تطبيق نظرية العقد الناقص في ظل جائحة كورونا

تأثرت العقود بسبب جائحة كورونا من جوانب عديدة: انخفاض كبير في قيمة العقد أو سعر المنتجات، رفض البنوك أوامر الدفع، منع التجمعات، غلق بعض المؤسسات، غلق الحدود بالنسبة للتجارة الدولية، إلغاء حركة النقل، وفرض قواعد وإجراءات تقييدية على الحقوق والحريات^(٩٠). كما مسّت الجائحة الأجال القانونية بصفة أساسية، خاصة آجال: الرجوع في عقد الاستهلاك، القبول في حقّ الشفعة، الالتزام بالإعلام، الطعن، تسجيل حقّ البطلان، شهر العقود الواردة على المحل التجاري، تسجيل الحقوق العينية، تسجيل حق الأفضلية^(٩١).

لم توضع نظرية العقد الناقص - كما رأينا سابقاً - لمعالجة ظروف استثنائية، بل تطبق كقاعدة عامة في كلّ الظروف والأحوال، إلّا أن الحالة الثانية منها المتمثلة في النقصان الخارجي للعقد أو النقصان بغير إرادة الأطراف تتقارب فيها آراء مؤيدي ومنتقدي النظرية، ومن ذلك حدوث وباء عالمي كما هو الحال بالنسبة لجائحة كورونا، التي أحدثت شخاً في نظرية العقد التقليدية أو ما يمكن تسميته بـ: أزمة نظرية العقد في زمن كورونا (المطلب الأول)، وفتحت المجال لإحياء نظرية العقد الناقص رغم مشكلة المحدودية (المطلب الثاني).

المطلب الأول

أزمة نظرية العقد في زمن كورونا

اختلفت السياسات الحكومية في معالجة جائحة كورونا من الناحية القانونية، فبعض الدول أثرت إصدار تعليمات وأنظمة تقتصر على الحجر أو منع بعض الحريات، في حين فصلت أنظمة أخرى في آثار السياسات المتبعة على الالتزامات التعاقدية، وعليه لم تتأثر نظرية العقد بأزمة كورونا فقط نتيجة الاختلاف حول تكييفها القانوني

(٩٠) Roland Ziadé et Claudia Cavicchioli, L'impact du Covid-19 sur les contrats commerciaux, Dossier de Covid-19 et Contrat, Actualité Juridique Contrat, n=O04, Avril 2020, p176.

(٩١) Mustapha Mekki, De l'urgence à l'imprévu du Covid-19: quelle boîte à outils contractuels? Dossier de Covid-19 et Contrat, Actualité Juridique Contrat, n=O04, Avril 2020, p166.

إن كانت قوة قاهرة أم ظرفاً طارئة (الفرع الأول)، بل بسبب الآثار القانونية المتضمنة في الإجراءات والتدابير التي عالجتها الجائحة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

جائحة كورونا: قوة قاهرة أم ظروف طارئة؟

على عكس معظم الأوبئة السابقة^(٩٢)، تمّ تكييف جائحة كورونا من طرف الحكومات والهيئات الدولية كقوة قاهرة^(٩٣). وهذا في انتظار صدور الأحكام والقرارات القضائية الموضحة لآثارها القانونية على التصرفات والالتزامات التعاقدية.

إذا كان الخلط بين نظرية القوة القاهرة Force Majeure / Superior Force والظروف الطارئة Imprévision / Hardship في مختلف الأحكام النظرية والتطبيقات القضائية ليس وليد جائحة كورونا، فإنّ لهذه الأخيرة دوراً بارزاً في إعادة إحياء الجدل الفقهي والقانوني حول النظريتين.

لقد ميّزت معظم القوانين العربية بين أحكام القوة القاهرة^(٩٤) وأحكام الظروف الطارئة^(٩٥) من خلال فكرة الاستحالة والإرهاق أو المشقة، حيث تعتبر قوة قاهرة الظروف التي تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وظرفاً طارئة الأحداث التي تجعل تنفيذه مرهقاً وليس مستحيلاً، أي أنّ فكرة الاستحالة هي مركز دوران الأحكام القانونية والقرارات القضائية.

بيد أنّ تداخل غرض النظريتين في إيجاد عذر للمدين لعدم تنفيذ التزامه نتيجة سيناريو غير متوقّع، وعدم اعتماد بعض الأنظمة القانونية الغربية لفكرة المشقة أو الظروف الطارئة، ووجود أنظمة هجينة، جعل هذا التمييز غير كاف، حيث يكون الظرف قوة قاهرة أحياناً وظرفاً طارئاً أحياناً أخرى، وهو ما ظهر جلياً حتى في بعض النصوص القانونية الإقليمية على غرار "قواعد اليونيدروا"^(٩٦).

(٩٢) Pascale Guimard, La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, 04/03/2020, (30/05/2020, 14:19).

(٩٣) Roland Ziadé et Claudia Cavicchioli, op cit, p176.

(٩٤) راجع: المادتين ١٦٥، ٢١٧ من القانون المصري، والمواد ٢١٥، ٢٢٣، ٢٩٥ من القانون الكويتي، والمادتين ١٢٧ و ١٧٨ من القانون الجزائري، والمادتين ١٦٥، ٢١٨ من القانون المدني البحريني.

(٩٥) راجع: المادة ١٤٧ من القانون المصري، والمادة ١٩٨ من القانون الكويتي، والمادة ١٠٧ من القانون الجزائري، والمادة ١٢٩ من القانون المدني البحريني.

(٩٦) UNIDROIT Principles 2016, Art 6.2.2. Peter Klaus Berger and Daniel Behn, op cit.,

يتفق القانون الأمريكي والإنجليزي على أحكام القوة القاهرة، بحيث تجعل الاستحالة تنفيذ العقد غير ممكن تحت مسمى "غير العملية أو غير القابلية للتطبيق العملي Impracticability" في القانون الأمريكي، و"الإخفاق Frustration" في القانون الإنجليزي، إلا أن الاستحالة هنا تتعلق بالاستحالة الأولية أي عند إبرام العقد، وليست الاستحالة اللاحقة عند تنفيذه.

حيث لم تطوّر الأنظمة الأنجلوساكسونية فكرة "المشقة Hardship" على المستوى الوطني، وهو ما أكدّه القضاء بعدم العذر بالظروف اللاحقة كارتفاع تكلفة العقد أو حدوث تضخم أو تغيير العملة^(٩٧)، إلا في حالات نادرة عندما تمسّ الظروف بشكل كبير بطبيعة وجوهر العقد^(٩٨). إذاً فكرة المشقة معترف بها في القضاء الإنجليزي بشكل محدود جداً، وليس للقاضي في أي حال من الأحوال تعديل العقد جزئياً أو كلياً، بل تهدم العقد^(٩٩).

تقترب فكرة "عدم القابلية للتطبيق" الأمريكية من فكرة المشقة إذا كان العقد غير قابل للتطبيق إلا بتكلفة غير معقولة، مفرطة، وشريطة وجود نية مشتركة للطرفين لتطبيقها^(١٠٠).

أمّا القانون الفرنسي قبل تعديل ٢٠١٦، فلم يكن يميّز بموجب المادة ١١٤٨ بين القوة القاهرة والظروف الطارئة، بل يعترف فقط بالقوة القاهرة^(١٠١) وبعد التعديل، حدّدت المادة ١٢١٨ عناصر القوة القاهرة بالأحداث الخارجة عن إرادة المدين، والتي يمكن أن تكون غير متوقعة عند إبرام العقد، ولا يمكن تجنبها بوسائل مناسبة، تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. وإذا كانت الاستحالة مؤقتة يؤجّل تنفيذ العقد إلى غاية زوال

(٩٧) Taylor v. Caldwell (1863) 122 Eng. Rep. 309 (K.B. Paradine v. Jane (1647) 82 Eng. Rep. 897 (K.B. Krell v. Henry [1903] 2 KB 740 (CA).

Peter Klaus Berger and Daniel Behn, op cit, p22- 24.

(٩٨) Canary Wharf (BP4) T1 Ltd. v. European Medicines Agency [2019] EWHC 335 (Ch), para. 27. Peter Klaus Berger and Daniel Behn, op cit, p25.

Ibid., (٩٩)

راجع أيضاً: محمود المغربي وبلال صنديد، المرجع السابق، ص ٧٥، ٧٧.

Ibid., (١٠٠)

(١٠١) Article 1148 du CCF (Avant 2016): "Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".

الحادث، أمّا إذا كان الحادث دائماً فينتهي العقد بقوة القانون، ويتحلّل الأطراف من التزاماتهم^(١٠٢).

بإسقاط هذه الأحكام على جائحة كورونا، نجد أنّ مجرد التأخر في التنفيذ بسبب الجائحة لا يعدّ إخلالاً بالتزام، ولا يترتب المسؤولية ولا التعويض مع اختلاف في الحكم بحسب طبيعة العقد، مثلاً: عقد تموين بين مطعم ومؤسسة اقتصادية توقّفت عن النشاط مؤقتاً أو شرع عمّالها في العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا مآله الحلّ أو التأجيل، في حين العقد نفسه تؤدّي الجائحة حتماً إلى حله متى كان هذا التأخير يجعل تنفيذ العقد دون معنى أو فائدة اقتصادية للطرفين كتموين حفلة زواج، فلا يمكن تأجيل تنفيذ العقد إذا اتفق الزوجان على إلغاء الحفلة وإتمام مراسيم الزواج.

من جهة ثانية، يثير الشرط الثالث من شروط القوة القاهرة مشكلة بالنسبة لجائحة كورونا، فلا يمكن التعميم بالنسبة لأثر عنصر التوقّع على استحالة تنفيذ الالتزام في كل العقود، وفي كل الدول، إنّما تتمّ معالجة المسائل حالة بحالة^(١٠٣). فهل يخصّ التوقّع العقود الجديدة أم تجديد العقد؟ كما أنّ العقود المبرمة قبل تاريخ لاحق على انتشار الوباء في دول معينة يجعل من مسألة التوقّع نسبية بالنسبة لأطراف العقد، وبذلك تثار مسألة توقيت التوقّع، فهل العبارة بدخول الوباء للبلد؟ أم بتاريخ إعلان منظمة الصحة العالمية؟ أم بتاريخ انتشاره في الصين؟^(١٠٤).

أخيراً، تتعلّق استحالة التنفيذ أيضاً بطبيعة العقود في حدّ ذاتها، والقدرة على

Article 1218 du CCF: "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles".

Julia Heinich, op cit, p 612. Mustapha Mekki, De l'urgence à l'imprévu du Covid-19: quelle boîte à outils contractuels?, op cit p 170.

راجع في الرأي نفسه: فتحي تيتوس، المرجع السابق، ص ٧٣٨، ٧٤٩. زكرياء مولاي وآخرون، المرجع السابق، ص ٣٤٣. ياسر عبد الحميد الإفتيحات، المرجع السابق، ص ٧٨٢. أحمد إشراقية، المرجع السابق، ص ٧٤٢، ٧٤٧. فارس محمد العجمي، المرجع السابق، ص ٣٣٤. أنس فيصل التورة، المرجع السابق، ص ٣٠١، ٣٠٧. محمد الأيوبي، المرجع السابق، ص ٢٨٨، ٢٩٢.

Ibid., Roland Ziadé et Claudia Cavicchioli, op cit, p179.

(١٠٤)

استبدال أو تأجيل التنفيذ، وهي مسائل تستلزم تدخّل القاضي لا محالة. كما أنّ استحالة التنفيذ لا يمكن أن يحتج بها بسبب الجائحة إذا كان محلّ الالتزام دفع مبلغ من النقود إلا في حالات نادرة (المدين تحت العناية المركّزة)^(١٠٥)، أو كان المدين سبباً في تأخّر الالتزام إلى حلول الجائحة^(١٠٦).

ينتهي العقد بقوة القانون متى كانت الاستحالة مطلقة (حسب المادة ١٢١٨ من القانون المدني الفرنسي الجديد)، أمّا إذا كان تأثير الجائحة على العقد يجعل الالتزام مرهقاً وليس مستحيلاً، ولم يقبل المتعاقد المعني تحمّل المخاطر، فيمكن حسب المادة ١١٩٥ (الجديدة) للأطراف إعادة التفاوض حول تنفيذ العقد، وفي حالة فشل التفاوض أو رفض الطرف الآخر، تتمّ مراجعة العقد من طرف القاضي الذي يمكنه تعديله أو إنهاءه^(١٠٧).

لم تؤثر جائحة كورونا على القواعد الوطنية فقط، بل تعدّتها إلى القواعد عبر الوطنية، حيث عدّلت غرفة التجارة الدولية في مارس ٢٠٢٠ من شروط القوة القاهرة، فلم يعد الطرف المتضرر ملزماً بإثبات عدم إمكانية التنبؤ بالحادث المفاجئ، بل يكفي إثبات عدم قدرته على تجنّبه أو التغلّب عليه^(١٠٨).

من الناحية العملية، أخذ القضاء الإداري الفرنسي بنظرية الظروف الطارئة منذ قضية "شركة بورديو للإضاءة" سنة ١٩١٦^(١٠٩)، في حين أنّ القضاء المدني

Ibid., Erwan Poisson and others, Covid-19 coronavirus - force majeure, (١٠٥) imprévision/hardship and emergency legislation on contracts under French law in light of the Covid-19 pandemic, 30/03/2020 (30/05/2020, 09:35).

Erwan Poisson and others, Ibid., (١٠٦)

Article 1195 du CCF: "Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe". (١٠٧)

<https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf> (26/05.2020, 14:36). (١٠٨)

Conseil d'état, 30/03/1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, (١٠٩) <https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-30-mars-1916-compagnie-generale-d-eclairage-de-bordeaux> (30/05/2020, 10:34).

الفرنسي لا يعترف بهذه النظرية منذ قرار محكمة النقض الفرنسية بخصوص "قناة كاربون" سنة ١٨٧٦ عندما اعتبرت أنه ليس للمحكمة تعديل العقد إلا بموجب نص قانوني بحجة احترام إرادة الأطراف وتحقيق الأمن القانوني^(١١٠). لذا عرفت القضايا التجارية هروباً نحو التحكيم الذي يفضّل الوسائل الودية، ويسمح بوضع شروط إعادة التفاوض^(١١١)، وهو ما انتهى إليه القانون المدني الفرنسي الجديد.

أما بخصوص القرارات الأخيرة الصادرة بمناسبة جائحة كورونا^(١١٢)، فحيثياتها تشير إلى تكيف التدابير المتبعة في ظل جائحة كورونا كقوة قاهرة مؤثرة على الحقوق والحريات وتنفيذ الاستدعاءات القضائية، وستكشف القرارات المستقبلية عن إمكانية توسيعها لتكون قوة قاهرة بمفهوم قانون العقود.

بالمقارنة بين الأنظمة نجد أنّ جائحة كورونا تعتبر قوة قاهرة من حيث المبدأ في جميع الأنظمة القانونية، قد تتحوّل إلى ظروف طارئة في بعض الأنظمة، مع اختلاف في الآثار الواجب تطبيقها في هذه الحالات إن كان يرجع فيها لإرادة الأطراف أم لإرادة وسلطة القاضي.

إلا أنّ التدابير والإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا كان لها الأثر البالغ على تعميق الفجوة بين هذه الأنظمة، فجائحة كورونا قد تكون قوة قاهرة (فسخ العقد) أو ظرفاً طارئاً (تعديل العقد)، بل قد تكون محفزاً على تنفيذ بعض العقود (استمرار التنفيذ)، وهذا بالنظر لطبيعة العقد (محل العقد أو شخصية الأطراف) من جهة، وبالنظر لتأثيرها بالتدابير والإجراءات المتخذة من جهة ثانية.

الفرع الثاني

الآثار القانونية للإجراءات والتدابير المتخذة على نظرية العقد

وصفت التدابير والإجراءات المتخذة بسبب جائحة كورونا بـ "Lex epidemia"^(١١٣) قياساً على قواعد العادات التجارية "Lex Mercatoria" نظراً لتأثيرها على الحياة

(١١٠) CC, Arrêt du 6 mars 1876, Canal de Craponne, (30/05/2020, 10:50)

(١١١) Peter Klaus Berger and Daniel Behn, op cit, p42.

(١١٢) Douai, 4 mars 2020, no 20/00395. Douai, 5 mars 2020, no 20/00400. Douai, 5 mars 2020, no 20/00401. Colmar, 12 mars 2020, no 20/01098. Colmar, 16 mars 2020, no 20/01142; Colmar, 16 mars 2020, no 20/01143. Colmar, 23 mars 2020, no 20/01206; Colmar, 23 mars 2020, no 20/01207. Cité par; Roland Ziadé et Claudia Cavicchioli, op cit, p177.

(١١٣) Mustapha Mekki, De l'urgence à l'imprévu du Covid-19: quelle boîte à outils contractuels?, op cit, p164.

الاقتصادية وآثارها القانونية على العقود والالتزامات، حيث انتقلت بنا من القانون العام إلى القوانين الاستثنائية. وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى إصدار القواعد التي تفسر بنظرية العقد، فهل تمثل إقصاء أو تفعيلاً لقواعد القانون المدني؟ ما محل المدد الواردة في بعض النصوص من الإعراب على ضوء القواعد العامة؟

لقد أصدرت الصين شهادات القوة القاهرة، وإذا كانت هذه الشهادات تعتبر إثباتاً بين المدنيين على المستوى المحلي، فهي ملزمة للمحاكم الصينية (الوطنية) لكنها ليست ملزمة للمحاكم ومراكز التحكيم الدولية^(١١٤). وعليه لا يمكن للأطراف المتعاقدة الاحتجاج بهذه الشهادات للتملص من الالتزامات العابرة للحدود، لكنها ستؤثر عليها بطريقة غير مباشرة، حيث لا يمكن للمتعاقد الصيني الاحتجاج بعدم قدرته على تنفيذ التزاماته بسبب الشهادات في حد ذاتها، لكن قد يحتج بأثر هذه الشهادات على المستوى المحلي، وانعكاس ذلك على الالتزام التعاقدي في مواجهة الغير بالنسبة للعقود التجارية الدولية.

في جانب آخر، اعتبرت المنظومة الفرنسية أن جائحة كورونا تمثل قوة القاهرة، ونصت الأحكام التنظيمية الصادرة (خاصة الأمر الصادر في ٢٥/٠٣/٢٠٢٠)^(١١٥) على تأخير الآجال القانونية Report des délais، وهي بذلك لا تعتبر توقيفاً للعقد Interruption ولا تعليقاً Suspension للآجال القانونية^(١١٦). كما أكدت هذه الأخيرة على توقيف العمل بالشروط الجزائية في مجال الصفقات العمومية والعقود المدنية (باستثناء السندات المالية التي تخضع للقانون النقدي والمالي)^(١١٧) وبشكل أكثر تفصيلاً نظمت الحكومة الفرنسية أحكام فسخ بعض العقود المتأثرة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا كعقود السياحة من خلال محاولة تسوية الوضعية ودياً مع الزبائن بتقديم عروض مستقبلية^(١١٨).

(١١٤) Peter Klaus Berger and Daniel Behn, op cit, p14.

(١١٥) Ordonnance n° 2020/330 du 25/03/2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, (12/09/2020, 10:29)

(١١٦) Mustapha Mekki, De l'urgence à l'imprévu du Covid-19: quelle boîte à outils contractuels?, op cit p166.

(١١٧) Julia Heinich, op cit, p 615.

(١١٨) Ordonnance no 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjour en cas

= de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, JORF?

إذا سلمنا جدلاً بأن جائحة كورونا قوة قاهرة، فهل هي دائمة أم مؤقتة؟ وهل ينقضي العقد بقوة القانون أم بحكم القاضي؟ وهل يمكن للقاضي تعديل بعض بنود العقد وتطبيق نظرية انتقاص العقد (وليس العقد الناقص)؟ وإذا استعاضت الحكومات بالتدابير والنصوص القانونية الخاصة للحفاظ على العقود بعد الحجر، فماذا بقي للنظرية العامة للعقد؟

يبدو أننا سنكون أمام أزمة قانونية كنتيجة لأزمة صحية، فهل ستأتي جائحة كورونا على ما بقي من أحكام النظرية العامة للعقد؟ أم ستحيي هذه الجائحة نظرية العقد الناقص محل البحث.

المطلب الثاني

نظرية العقد الناقص بين الإحياء والمحدودية في ظل جائحة كورونا

يمكن للقاضي وفق النظرية التقليدية للعقد الاعتماد على معايير موضوعية وشخصية لتقدير تطبيق نظرية القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة على العقد، كمدة العقد، نسبة الإنجاز، الالتزامات المنجزة من الطرفين، أهمية العقد بالنسبة لكل طرف، ارتباط العقد بعقود أخرى، معيار شخصية المتعاقد إن كانت محل اعتبار.

أما تطبيق نظرية العقد الناقص في جزئها المتعلق بالظروف الاستثنائية فيغلب الطابع الإرادي للمتعاقد على دور القاضي، حيث يمكن أن تتطور إرادة الأطراف إلى إنشاء التزامات جديدة تلغي الالتزامات السابقة، تجعل من الوضع كأننا أمام عقد أو عقود جديدة على أنقاص العقد السابق؛ لذا قد يكون لجائحة كورونا دور في إحياء نظرية العقد الناقص (الفرع الأول).

ككل نظرية فليس من الممكن تطبيق نظرية العقد الناقص في كل الأحوال بالدرجة نفسها على كل العقود، لذا سنتعرض لمحدودية نظرية العقد الناقص في ظل جائحة كورونا (الفرع الثاني).

= 26/03/2020, (29/05/2020, 13:45). Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, JORF n°0074 du 26 mars 2020, (29/05/2020, 13:59). See; Jean-Denis Pelletier, Coronavirus: une ordonnance pour sauver les professionnels du tourisme, 28/03/2020, (29/05/2020, 14:38).

الفرع الأول

إحياء نظرية العقد الناقص في ظل جائحة كورونا

تمثل إعادة التفاوض أساس نظرية العقد الناقص ولكن بشكل أوسع من المعمول به في نظرية الظروف الطارئة، حيث لا يقتصر إعادة التفاوض على معالجة الحوادث التي تؤثر على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، بل قد يكون متعلقاً بتحسين العقد أو لمواكبة تقدّم تكنولوجي ما وفق مبدأ التحفيز التعاقدى المشار إليه سابقاً.

بالنسبة للجانب الأول من نظرية العقد الناقص الذي تشترك فيه مع نظرية الظروف الطارئة، يمكن الاعتماد على إعادة التفاوض لحل المنازعات الناشئة عن جائحة كورونا، لأنّ غرض إعادة التفاوض بإرادة الأطراف هو الوصول إلى حلّ يرضي الطرفين يتم بموجبه تنفيذ العقد.

إعادة التفاوض قد يكون اتفاقياً (عند إبرام العقد أو تنفيذه)، وقد يكون قضائياً (بطلب من القاضي أو المحكم)، فهو يسمح للأطراف المتعاقدة تعديل العقد والاتفاق على كيفية تنفيذه على ضوء الظروف والحوادث الطارئة عليه^(١١٩)، أيّ أنّه يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة، فهذه الأخيرة أنشأت العقد فكان لزاماً منحها صلاحية تعديله، أي من يملك الكلّ (إنشاء العقد من العدم) يملك الجزء (تعديل العقد المبرم).

الأصل أنّ تكون إعادة التفاوض بموجب شرط يلتزم به أطراف العقد، فهل يمكن إلزام الأطراف بإعادة التفاوض في حالة عدم وجود هذا الشرط؟ وهل يستوي الأمر بالنسبة للعقود الداخلية والدولية؟

أولاً: إعادة التفاوض في العقود المحلية

إذا كان إعادة التفاوض يتمّ بموجب شرط في العقد أو ما يعرف بشرط إعادة التفاوض أو شرط المشقة Hardship، فجائحة كورونا قد جاءت في ظروف استثنائية وبطريقة غير مسبقة، حيث لم تعتد بعض المنظومات على وضع هذا الشرط، كما قد يصاغ هذا الشرط في أنظمة أخرى بشكل لا يشمل حالة وقوع جائحة تؤثر على العقود بالشكل الملاحظ بالنسبة لكورونا.

من جهة ثانية، قد تميل بعض الأنظمة إلى تغليب دور القاضي في تعديل العقد على منح فرصة لأطرافه لإعادة التفاوض، فهل هذا يعني أنّ إعادة التفاوض يفقد مفعوله أمام نظرية الظروف الطارئة؟

(١١٩) علاء الدين الخصاونة، المرجع السابق.

إذا قلنا بأنَّ شرط إعادة التفاوض في ظل القوانين التي تعتمد على نظرية الظروف الطارئة باطل، فهل المادة ١٠٧ من القانون المدني الجزائري (وما يقابلها في القوانين العربية)^(١٢٠) غرضها استمرارية تنفيذ العقد أم منع الاتفاق على إقصاء تدخّل القاضي في تعديل العقد؟ بمعنى آخر هل نظرية الظروف الطارئة في هذه الأنظمة من النظام العام؟ فإذا رغب الأطراف في إعادة التفاوض حول تعديل العقد بعد حدوث ظرف الطارئ (جائحة كورونا مثلاً)، فهل يعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام أم أنَّ المقصود بالبطلان هنا بطلان منع الأطراف من اللجوء إلى القضاء لتعديل العقد؟

لا تعتبر القوانين الغربية كلاً من نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة من النظام العام، أي يمكن الاتفاق على تحمّل أحد الأطراف مخاطر تغيير الظروف، في حين تمنع القوانين العربية الاتفاق على استبعاد سلطة القاضي في تعديل العقد بالنسبة للظروف الطارئة دون القوة القاهرة^(١٢١). لكن في حقيقة الأمر، لم توضع نظرية الظروف الطارئة كقيّد على حرية الأطراف، بل جاءت لتحقيق مقتضيات العدالة في حالة عدم اتفاق الأطراف على تعديل العقد.

إذا قلنا أنَّ نظرية الظروف الطارئة من النظام العام، فكيف يفسّر السماح للأطراف بالاتفاق على تحمّل المدين آثار القوة القاهرة (وهي أشدّ) دون أن نسمح بذلك بالنسبة للظروف الطارئة، لذا فالمقصود هو الرجوع دائماً لإرادة الأطراف كأصل عام، والقاضي كاستثناء وحل أخير.

فالنصوص السابقة لم تلزم القاضي بل جاءت جوازاً لتعديل العقد، فالبطلان المترتب على مخالفة القاعدة يتعلّق بالاتفاق الذي يصبّ على عدم قبول تدخّل القاضي لإزالة الإرهاق اللاحق بالطرف المتضرر من الحادث الطارئ (جائحة كورونا)، أما إن تم الاتفاق على التفاوض بشرط سابق أو اتفاق لاحق، فيكون الشرط أو الاتفاق صحيحين.

حسب مفهوم المواد المتعلقة بنظرية الظروف الطارئة، لو تم الاتفاق على تعديل

(١٢٠) تنصّ المادة ١٠٧ من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "...غير أنّه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفّذ الالتزام التعاقدية، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فاحشة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق بخلاف ذلك".

Roland Ziadé et Claudia Cavicchioli, op cit, p182.

(١٢١)

العقد بشرط أو اتفاق، فالطرفان لم يخرجاً عن دائرة العقد شريعة المتعاقدين، أما إن كان الطلب بإعادة أحدهما فقط، فيمكن للقاضي إن رأى ذلك، إلزام الطرف الآخر بإعادة التفاوض قبل أن يمارس صلاحياته في تعديل العقد وإرجاع الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

يبدو أنَّ نظرية الظروف الطارئة بقواعدها المجسدة في القوانين المعاصرة لا تعطي للأطراف ما تعطيه لهم نظرية العقد الناقص، فهذه الأخيرة يبلغ فيها مبدأ سلطان الإرادة ذروته، حيث يسمح الشروع في تنفيذ العقد للأطراف بأخذ نظرة حقيقية وعملية حول صيرورة تنفيذ ونتائج العقد المتوقعة، ناهيك عن كون الجائحة قد تمسّ جوانب أخرى خارجة عن نطاق العقد لكن ذات علاقة غير مباشرة بتنفيذه، أي أنَّ العقد يبقى مفتوحاً في ظل هذه النظرية خاضعاً لإرادة الطرفين أو الطرف الذي احتفظ بجزء من حقوق السيطرة على العقد عند إنشائه، وهذا طبعاً تكريس للنظام الرأسمالي الذي برزت فيه النظرية، حيث يسمح للسوق بتنظيم نفسها بنفسها، ويقلّ فيها تدخّل الدولة بالتنظيم، وعليه إعادة التفاوض في العقود المحلية لا يمكن أن يحلّ محلّ القاضي بشكل تام، أي أنَّ سلطان الإرادة يبقى ذا أثر محدود في بعض الأنظمة متى كان العقد محلياً.

ثانياً: إعادة التفاوض في العقود الدولية

يتعدّى مبدأ سلطان الإرادة في العقود الدولية شروط العقد إلى تحديد القانون واجب التطبيق، حيث تتميز هذه العقود بطول مدتها: باعتبارها عقوداً مستمرة (تتخلّلها ظروف طارئة أو تغيرات تستوجب إعادة النظر في كيفية تنفيذه)، وخصوصية أطرافها (ذات طرف أجنبي في غالب الأحيان)، وتدخّل الغير (مؤسسات التمويل)، وممارسة الدولة لسلطتها العامة أحياناً، وأهمية موضوعها (تتعلّق بالتنمية عادة).

إنّ المسألة تزداد تعقيداً في العقود الدولية، وإن كان يغلب عليها تضمن شرط إعادة التفاوض، فإنّه يمكن إلزام الأطراف بإعادة التفاوض بموجب شرط في العقد أو حتّى بإلزام من القاضي أو المحكّم. إنّ إلزام الأطراف بإعادة التفاوض لا يعني إلزامهم بالوصول إلى نتيجة مفاها تعديل العقد والاستمرار في تنفيذه، بل هي فرصة تُمنح لهم لتقريب وجهات النظر، فالالتزام بإعادة التفاوض هنا التزام بتحقيق نتيجة، أما الالتزام بالاستمرار في تنفيذ العقد فهو التزام ببذل عناية وفق مبدأ حسن النية والتعاون بين الأطراف وفق مقتضيات العدالة.

إذا كان إعادة التفاوض يمثل أهم مبادئ نظرية العقد الناقص التي يمكن أن تسهم في إبراز نظرية العقد الناقص في حل منازعات الالتزامات التعاقدية المتأثرة

بجائحة كورونا، فإنَّ الإلزام بإعادة التفاوض في العقود التجارية الدولية يمسّ بأساس نظرية العقد الناقص، وهو مبدأ سلطان الإرادة، حيث يمكن أن يلزم الأطراف بالجلوس لإعادة التفاوض دون وجود شرط أو اتفاق مسبق^(١٢٢).

الخلاصة أنَّه يوجد تقارب بين معظم الأنظمة القانونية حول تكييف جائحة كورونا مع اختلاف حول كيفية معالجة آثارها ومدى قابلية تفعيل نظرية العقد الناقص فيها. فالقانون الفرنسي تخلّى عن الجمود السابق وسمح بإعادة التفاوض، أي أنَّه قبل بتطبيق النظرية، ولكن "باحترام". في حين يسمح القانون الأمريكي بإعادة التفاوض دون منح سلطات للقاضي، وهو أساس قيام نظرية العقد الناقص، وتقترب القوانين العربية من القانون الفرنسي فيما يتعلّق بسلطة القاضي مع صمتها فيما يخصّ إعادة التفاوض. هذا الأخير يمكن أن نعتبره ممكناً في القوانين العربية من خلال التفسير الموسّع لعبارة "العقد شريعة المتعاقدين"، لا يمكن تعديله إلا بإرادة الطرفين"، فإذا كان القانون يسمح بتعديل العقد فمن باب أولى السماح بإعادة التفاوض.

أيّ أنّ جزءاً هاماً من تطبيقات نظرية العقد الناقص متأصل في القوانين المعاصرة، ويمكن أن يسهم في حلّ منازعات جائحة كورونا، ولكن يمكن أن يتم ذلك بشكل نسبي، ممّا يعني أنّ هذه النظرية تبقى ذات محدودية أمام جائحة كورونا.

الفرع الثاني

محدودية نظرية العقد الناقص أمام جائحة كورونا

إنّ الغرض من نظرية العقد الناقص جعل العقد انسيابياً ومرناً، يمكن الاستمرار في تنفيذه بإرادة الطرفين أو بتوجيه من أحد أطراف العقد، إلّا أنّ المسألة ليست قابلة للتعميم، فبعض العقود تحتاج فقط للتأخير، وبعضها الآخر لا يمكن أن يستمر أو يؤجل، في حين أنّ نوعاً آخر من العقود يمكن تكييفه وتعديله بما يخدم مصلحة الطرفين أو تحقيق التوازن العقدي، وهو ما يستلزم تدخّل القاضي في تعديل العقد (أولاً)، ومن جهة ثانية ترتبط العقود ببعضها بعضاً في الحياة الاقتصادية المعاصرة، وهو ما يجعل نظرية العقد الناقص محدودة أمام فكرة العقود المترابطة (ثانياً).

(١٢٢) المادة ٥٥ من مسودة الأمم المتحدة لمدونة سلوك الشركات عبر الوطنية، راجع في ذلك: Talal Abdulla Al-Emadi, The renegotiating clause in petroleum international joint venture agreements, Oxford Student Legal Research, Paper Series is at <http://www.ssrn.com/link/oxford?student?LEG.html> (23/05/2020, 14:56).

أولاً: محدودية نظرية العقد الناقص أمام دور القاضي

لا غنى عن الرجوع إلى دور القاضي في تطبيق نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة في تعديل العقد، فمثلاً أثارت جائحة كورونا مشكلة التوقع، فإذا كان انتشار الوباء في بعض الدول كان في نهاية السنة الماضية أي لم يكن متوقعاً بالنسبة للمتعاقدين في هذه الدول، فإنه بالنسبة لدول أخرى لم تشرع في الاحتياط من المرض إلى خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي أنه كان للأطراف المتعاقدة في هذه الدول فرصة توقع وصول الجائحة، وتوقع الآثار الجانبية على التزاماتهم التعاقدية.

إنَّ إلغاء دور القاضي في تعديل العقد يجعل العقد خاضعاً للواقع أكثر من خضوعه للقانون، كما أنَّ التعويل على إرادة الأطراف وحدها في قيادة عربة العقد يجعل القانون خاضعاً للإرادة وليس العكس، ومع اختلاف الإرادات تختلف القوانين، أي حدوث حالة من عدم التناسق في المنظومة القانونية.

إذا حدثت ظروف طارئة قد يكون في تنفيذ العقد إرهاباً لأحد الأطراف، كما يمكن أن يكون في عدم تنفيذه أيضاً تكلفة كبيرة لأحد المتعاقدين، وعليه فالموازنة بين تنفيذ التزام أو التزامات تعاقدية أو عدم تنفيذها نتيجة جائحة كورونا ليست بالأمر الهين، فاحتجاج أحد الأطراف المتعاقدة بتعليمات الحجر الجزئي المفروض من طرف السلطات العامة لا يمكن أن يكون في حد ذاته عذراً لفسخ العقد، أو عدم تنفيذ الالتزامات متى كان ذلك ممكناً ولو بتكلفة زائدة عن التكلفة المتفق عليها في العقد دون أن تصل إلى حد الإرهاب، ومسألة تقدير أن أحد الالتزامات مرهق أم لا نسبية، يمكن أن يتم التفاوض أو إعادة التفاوض حولها، ويبقى تدخّل القاضي أو المحكم لتسوية النزاع معتبراً، وهو ما يعني محدودية نظرية العقد الناقص.

نظرية الظروف الطارئة تتعلّق بحالات استثنائية قد ينجم عنها إنقاص الالتزامات المرهقة للأطراف المتعاقدة، كما أنَّ للقاضي دوراً فعالاً في تعديل العقد، أمّا في العقد الناقص فيتم إعادة التفاوض بين المتعاقدين ولا سلطان للقاضي أمام سلطان الإرادة. أي أنَّ نظرية الظروف الطارئة تشترك في جزء من نظرية العقد الناقص التي تعتبر أشمل وأوسع نطاقاً.

إن نظرية العقد الناقص تجعل من انفساخ العقد حالة مستبعدة، لكن هل انصراف إرادة الأطراف إلى الاستمرار في تنفيذ العقد، ولو بإعادة تحويله وعدم قبول فسخ العقد إلّا بالإرادة المشتركة، كفيلة بتحديد نهايات كلّ العقود، أمَّ أنَّ نظرية العقد

الناقص تقف حائرة أمام انفساخ العقد بحكم القانون أو الواقع؟ وهل وجود علاقة وثيقة بين العقود المبرمة يجعل تطبيق نظرية العقد الناقص محدوداً؟

ثانياً: محدودية نظرية العقد الناقص أمام العقود المترابطة

تقف نظرية العقد الناقص عاجزة أمام ما يمكن تسميته بـ "العقود المترابطة"، أي عند حدوث ظروف استثنائية تمسّ عقد ما، ويكون هذا العقد على صلة وثيقة أو يبني على أساسه تنفيذ عقود أخرى، فإنّ استحالة تنفيذ هذا العقد تجعل من تنفيذ العقود الأخرى مرهقاً أو مستحيلاً، والقاعدة هنا ألا تخضع كلّ العقود للنظام نفسه^(١٢٣)، أي لا يمكن الاحتجاج بالقوة القاهرة نفسها كعذر لتنفيذ كل العقود، بل تعالج حالة بحالة، وعليه سنأخذ ثلاثة نماذج من العقود: عقود التشييد، عقد لاعب كرة القدم المحترف، عقد العمل.

تتأثر عقود التشييد والبناء بجائحة كورونا من جوانب عديدة: صحّة وأمن الأشخاص، كيفية إنجاز الأشغال، التمويل المالي، آجال استلام الرخص الإدارية، تأخر مواعيد الدفع،... إلخ^(١٢٤). بل يمكن أن تتوقّف الأشغال تماماً لارتباط هذه العقود بعقود أخرى لا يستطيع أصحابها تنفيذ التزاماتهم بسبب المرض أو بسبب التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية كمنع النقل مثلاً، أو توقّف عقود المناولة، أو إلغاء تنفيذ التزامات الوعد ببيع العقارات محلّ إنجاز المشاريع، أو تأثر العلاقة بين المقاول ومكاتب الاستشارات الهندسية.

الأكثر من ذلك أنّ القروض البنكية أساسها ودائع العملاء التي تنخفض إلى مستويات دنيا في ظل الجائحة مع التزام هذه المؤسسات بتطبيق القواعد المالية الاحترازية، وهو ما يؤثّر بشكل كبير على سير مشاريع التشييد والبناء، كما تطرح مسألة أسعار العقارات موضوع التشييد^(١٢٥)، وقد تؤدّي الجائحة إلى إفلاس المؤسسات إذا طالت مدّة التدابير والإجراءات المتخذة، وهو ما يطرح قابلية نظام

Julia Heinich, op cit, p 612.

(١٢٣)

Jean-Philippe Tricoire et Cyrille Charbonneau, Covid-19 et VEFA. Dossier de La construction dans la tempête: contrats de construction et VEFA à l'épreuve du Covid-19. Revue de Droit Immobilier, Dalloz, n=o 05, 05/05/2020, pp 209-218. Cyrille Charbonneau et Jean-Philippe Tricoire, Les marchés privés de construction à l'épreuve du Covid-19, Dossier de La construction dans la tempête: contrats de construction et VEFA à l'épreuve du Covid-19. Revue de Droit Immobilier, Dalloz, n=o 05, 05/05/2020, pp 228-230.

Ibid.,

(١٢٥)

الإفلاس المعتمد في الأنظمة القانونية لتجاوز آثار الأزمة، ودور إعادة التفاوض في تعزيز ما يعرف بـ "إعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة".

شهد تكيف عقد لاعب كرة القدم تبايناً حول اعتباره عقد عمل، أو عقد مقالة، أو التزاماً بعمل يخضع للقواعد العامة، ويعتبر قطاع الرياضة (كرة القدم خاصة) من أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا، ليس لأهميته بالنسبة للمواطن، ولكن لنظامه المالي والتعاقدي المعقد والهش^(١٢٦).

فتوقيف المباريات أثر على مصادر التمويل: التذاكر واستغلال المرافق الملحقة بالملاعب، الإشهارات وعوائد البث، الزيارات السياحية ... إلخ^(١٢٧)، وهذا في مقابل رواتب اللاعبين المرتفعة، ورغم أنّ هؤلاء يمكن اعتبارهم قد أحيوا على البطالة الجزئية أو النشاط الجزئي، فإنّه في الوقت نفسه لا يمكن تسوية المسألة من خلال إعادة التفاوض على الرواتب؛ لأنّ قرارات إجراء المباريات في ملاعب مغلقة يجعل اللاعبين يؤدون التزاماتهم كاملة دون الحصول على الأجور المتفق عليها^(١٢٨). بل إنّ استمرار تنفيذ اللاعبين لعقودهم بإجراء المباريات مغلقة وتحمل المزيد من المخاطر (قد تصل للوفاة) يجعل من بعض العقود المرتبطة بها دون جدوى؛ لأنّها لا تقبل التأجيل ما دام العقد الرئيسي محلّ تنفيذ بطريقة مختلفة عن المعتاد^(١٢٩).

عقود العمل غير محدّدة المدّة بطبيعتها، أيّ أنّها تمثّل إحدى أهم تطبيقات نظرية العقد الناقص، حيث تتكفّل الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية بتحديد مضمون العقد ومحلّه بشكل أدقّ، والرضائية فيه نسبية، لذا يوصف وضع العامل بالتنظيمي أكثر من التعاقدي^(١٣٠).

يتأثر تنفيذ عقد العمل بسبب جائحة كورونا نتيجة منع الانتقال من مكان لآخر، وغلق بعض المؤسسات، كما تطرح مسألة التعويضات عن التوقّف عن العمل، وتغيير حجم وتوقيت ساعات العمل، والمخاطر المرتبطة ببيئة العمل في حدّ ذاتها، والأخطار

Frédéric Buy, les organisateurs sportifs et le Coronavirus, dossier de Covid-19 (١٢٦) et Contrat, Actualité Juridique Contrat, n°4, Avril 2020, p199.

Ibid., (١٢٧)

Ibid., (١٢٨)

Ibid., (١٢٩)

Grégoire Duchange, Coronavirus et contrat de travail, dossier de Covid-19 et (١٣٠) Contrat, Actualité Juridique Contrat, n°04, Avril 2020, p191.

المهنية المتعلقة بالمسافة بين المنزل ومكان العمل^(١٣١). كما تطرح أيضاً مسألة بقاء الأولاد في المنزل بسبب غلق المدارس والمؤسسات التعليمية^(١٣٢).

من ناحية أخرى تتأثر عقود العمل بالوضع الاقتصادي العام، فالعامل قد يستمر في نشاطه في بعض المؤسسات جزئياً أو كلياً، غير أنّ عائد المؤسسة الذي يُبنى على أساسه أجر العامل قد ينخفض بسبب جائحة كورونا لارتباطه ببعض العقود الأخرى، وعليه يكون ربّ العمل أمام خيارين: تسريح العمّال أو تخفيض الرواتب، فيطرح التساؤل بالنسبة للحالة الأولى حول مسألة التسريح التعسفي، وفي الثانية بالمساس بجوهر عقد العمل (أجرة العامل)^(١٣٣).

هذه المسائل وأخرى، لا يمكن حلّها إلّا بعد إعادة النظر في كيفية تطبيق روح النصوص القانونية المنظمة للالتزامات التعاقدية، وإعمال القضاة فكرهم واجتهادهم لحل المنازعات بعيداً عن النظريات التقليدية للقانون.

الخاتمة:

يعتبر التحليل الاقتصادي للعقد نتيجة منطقية للدراسات البيئية ومنهجاً مستجداً في بعض الأنظمة، ونتيجة عولمة القواعد القانونية، كانت نظرية العقد الناقص إحدى مخرجات التلاقح والاقتراس بين الأنظمة القانونية.

ترتكز هذه الأخيرة على جعل العقد مفتوحاً أمام إرادة الأطراف للتعامل مع الظروف المستقبلية سواء أكانت طبيعية أم استثنائية، متوقعة أم غير متوقعة، قابلة للتغلب عليها أم لا. وهي فلسفة دخيلة على النظرية التقليدية للعقد، تحتاج لكثير من النظر والتحصيل حول مضمونها ونتائجها القانونية.

إنّ تقييم نظرية العقد الناقص ينبغي أن يكون من خلال التمييز بين حالة النقصان الإرادي (المخاطر الداخلية للعقد)، والنقصان الخارجي (المخاطر الخارجية للعقد): حيث إنّّه بالنسبة للحالة الأولى فإنّ عدم نصّ النظرية على معيار ضابط للحدّ الذي يمكن أن نسمح أو نمنع فيه عدم التحديد يعتبر محلّ جدل كونه يمسّ نظرية العقد في الصميم، وينقل العقود إلى ظاهرة الاحتمالية التي تمسّ بالقوة الملزمة للعقد. أمّا بالنسبة للحالة الثانية فينبغي عدم تركيز المخرج على إرادة الأطراف، بل

Ibid.,

(١٣١)

Ibid.,

(١٣٢)

(١٣٣) أنس فيصل التورة، المرجع السابق، ص ٣٠٩.

تظهر ضرورة التفصيل بين العقود، فلا يمكن وضع نظرية تجمع كل العقود، بالدرجة نفسها، وفي الظروف نفسها. من جهة ثانية لا مناص من تدّخل القاضي أو المحكّم للفصل في النزاعات التي يمكن أن تثار بمناسبة جائحة كورونا، بل إنّ بعض العقود لا تقبل إبقاء الكرة في مرمى الأطراف نتيجة استحالة الاستمرار في تنفيذها أو استحالة وصول الأطراف إلى حلّ ودّي حولها.

لذا يمكن أن نقول أنّ جائحة كورونا تمثّل اختباراً حقيقياً "Test" لنظرية العقد التقليدية ونظرية العقد الناقص. فإذا كانت هذه النظرية ولا شكّ تساهم في إيجاد حلول لآثار جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية، فإنّها تبقى ذات آثار محدودة بالنسبة لبعض الحالات القانونية الشائكة والعقود المترابطة.

بعد الانتهاء من دراسة الموضوع، وجدت عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية ورد فيها جوابه عن الجوائح: "ولا خلاف بين الأئمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ"^(١٣٤). فنلاحظ اختلاف الفتوى وتغيّر الأحكام بتغيّر الظروف والأحوال في العقد نفسه (عقد الإيجار). أي أنّه توجد مجالات أخرى للدراسات المقارنة التي يمكن أن تقدّم الحلول لتأثير جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية، وهذا في انتظار الشروع في حل المنازعات المتوقعة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

(١٣٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة ٢٠٠٥، الجزء ٠٣، ص ٢٩٣.

المراجع

أولاً - المراجع باللغة العربية:

أ - المقالات:

- أحمد إشراقية، الوسائل القانونية الخاصة بمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على العلاقات التعاقدية: دراسة في القانونين الفرنسي واللبناني، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠.
- أنس فيصل التورة، تأثير جائحة فيروس كورونا على عقد العمل بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠.
- رفيق يونس المصري، آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية، دار المكتبي، دمشق، سورية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٩.
- زكرياء مولاي وآخرون، تأثير فيروس كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، حوليات جامعة الجزائر، المجلد ٣٤، العدد ٠٣، جامعة الجزائر ١، جويلية ٢٠٢٠، ص ص ٣٣٢، ٣٥٢.
- علاء الدين الخصاونة، الجوانب القانونية للالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة العقود، مجلة الحقوق الكويتية، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد ٠١، ٢٠١٤.
- فارس محمد العجمي، الخيارات القانونية المتاحة لأطراف العقد التجاري في مواجهة جائحة فيروس كورونا وسلطة القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠.
- فتحي تيتوس، كوفيد-١٩: هل يشكّل قوة القاهرة؟ حوليات جامعة الجزائر، المجلد ٣٤، العدد ٠٣، جامعة الجزائر ١، جويلية ٢٠٢٠.
- فهد علي الزميع، نظرية العقد من منظور اقتصادي: دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والأمريكي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ٠٤، ٢٠١٤.
- محمد الأيوبي، المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس "كورونا كوفيد ١٩"

- في مؤلف جماعي بعنوان " الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا"، سلسلة إحياء علوم القرآن، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، ٢٠٢٠، ص ٢٩٥.
- محمود المغربي وبلال صنديد، التكييف القانوني للجائحة "الكرونية" على ضوء الثوابت الدستورية والدولية والمبادئ القانونية المستقرة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠.
- ياسر عبد الحميد الإفتيحات، جائحة فيروس كورونا وأثرها على تنفيذ الالتزامات العقدية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، عدد ٠٦، جوان ٢٠٢٠.

ثانياً - المراجع باللغات الأجنبية:

A. Books:

- François Terré, Droit civil - obligation - Dalloz, 8^e édition, 2012.
- Stéphane Darmaisin, Contrat moral, LDJ, Paris, édition DELTA, Paris, France, 2000.

B. Articles and papers:

- Alschner, Wolfgang, Interpreting Investment Treaties as Incomplete Contracts: Lessons from Contract Theory, 30th Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE), July 18, 2013 > <https://ssrn.com/abstract=2241652> < .
- Bengt Holmstrom and Paul Milgrom, Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design, Journal of Law, Economic, and Organization, V7, 1991, pp 24-52, > https://econpapers.repec.org/article/oupjleorg/v_3a7_3ay_3a1991_3ai_3a0_3ap_3a24-52.htm .
- Cyrille Charbonneau et Jean-Philippe Tricoire, Les marchés privés de construction à l'épreuve du Covid-19, Dossier de La construction dans la tempête: contrats de construction et VEFA à l'épreuve du Covid-19. Revue de Droit Immobilier, Dalloz, n = o 05, 05/05/2020,.

- Dennis Tallon, Le concept de bonne foi en droit français du contrat, Saggi, conferenze seminari del Centro di studie ricerche di diritto comparato e straniero diretto da M. J. Bonell, site internet: <http://www.cnr.it> .
- Ejan Mackaay, L'analyse économique du droit, I, Fondement; Les éditions themis, 2000. Christophe Jamin, Droit et économique des contrats, LGDJ, 2008.
- Erwan Poisson and others, Covid-19 coronavirus - force majeure, imprévision/hardship and emergency legislation on contracts under French law in light of the Covid-19 pandemic, 30/03/2020 > <https://www.allenoverly.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/covid-19-coronavirus-force-majeure-imprevision-hardship-and-emergency-legislation-on-contracts> < .
- Frédéric Buy, les organisateurs sportifs et le Coronavirus, dossier de Covid-19 et Contrat, Actualité Juridique Contrat, n°4, Avril 2020.
- <https://www.degruyter.com/view/journals/gj/4/3/article-gj.2004.4.3.1141.xml.xml> < .
- Grégoire Duchange, Coronavirus et contrat de travail, dossier de Covid-19 et Contrat, Actualité Juridique Contrat, n°04, Avril 2020.
- Grossman S.-J. et Hart O.-D. (1986), « The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration », Journal of Political Economy, vol. 94, n°4, p. 691-719.
- Hart O. et Moore J. (1990), « Property Rights and the Nature of the Firm », Journal of Political Economy, vol. 98, n°6, pp. 1119-1158.
- Ian Ayres and Robert Gertner, Filling gaps in incomplete contracts: An economic theory of default rules, Yale Law

- Journal, V 99 (87) 1989, > <https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7236&context=ylj> <
- Iran Aures, Default rules for incomplete contracts, in P. Newman (éd), The New Palgrave Dictionary of economics and the law, Springer, London, 2002.
 - Jean-Philippe Tricoire et Cyrille Charbonneau, Covid-19 et VEFA. Dossier de La construction dans la tempête: contrats de construction et VEFA à l'épreuve du Covid-19. Revue de Droit Immobilier, Dalloz, n= o 05, 05/05/2020.
 - Jeswald W. Salacuse, Renegotiating international business transactions: The continuing struggle of life against form, The international lawyer, V 35m n= o 4, 2001, pp 1507-1508, > <http://www.jstor.org/stable/40707631> < .
 - Julia Heinich, L'incidence de l'épidémie de coronavirus sur les contrats d'affaires: de la force majeure à l'imprévision. Recueil Dalloz, n= °11/7856, 26/03/2020.
 - Mustapha Mekki, De l'urgence à l'imprévu du Covid-19: quelle boîte à outils contractuels?, dossier de Covid-19 et Contrat, Actualité Juridique Contrat, n= O04, Avril 2020.
 - Mustapha Mekki, La bonne foi dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations du 23 octobre 2013, > <https://www.mekki.fr/files/sites/37/2015/09/Bonne-foi-Mekki.pdf> < .
 - Ninel Ulloa Maureira, Introduction du concept Américain des contrats incomplets en droit civil français, Global Jurist Topics, V 4 (3), 2004.
 - Oliver E. Williamson, Transaction Cost Economics: The Natural Progression, The American Economic Review, Vol. 100, No. 3 (JUNE 2010), pp. 673-690, > <https://www.jstor.org/stable/27871227> < .
 - Oliver Hart and John Moore, Foundations of incomplete contracts, Review of Economic Studies (1999) 66, 115-138,

- > <http://econ.lse.ac.uk/staff/lfelli/teach/Hart-Moore-1999.pdf> < (20/05/2020, 16:34).
- Oliver Hart Past-Presidents Plenary: Oliver Hart, Incomplete Contracts and Control, Royal economic Society, Past-Presidents Plenary, 02/05/2017 > <https://www.youtube.com/watch?v=T1FhxdFbdqw> < .
 - Oliver Hart, Incomplete contract and control, American Economic Review 2017, 107(7): 1731-1752, > <https://doi.org/10.1257/aer.107.7.1731> < .
 - Olivier Soutel, L'évolution de la théorie des contrats incomplets face à la dé-intégration vertical, Revue d'économie Industrielle, V 177, 2007, pp 93 -110 > <https://journals.openedition.org/rei/1193> < .
 - Pascale Guiomard, La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, 04/03/2020, <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/grippe-epidemies-et-force-majeure-en-dix-arrets#.Xs7W563MyCQ> > <https://www.dalloz-actualite.fr/flash/grippe-epidemies-et-force-majeure-en-dix-arrets> < .
 - Peter Klaus Berger and Daniel Behn, Force majeure and Hardship in the age of Corona: A historical and comparative study McGill Journal of Dispute Resolution, 2020, p03, Forthcoming; > <https://ssrn.com/abstract=3575869> < (29/05/2020, 11:38).
 - Robert E. Scott, A theory of self-enforcing indefinite agreement, The Columbia Law Review, Nov Vol. 103, N= o 7, Nov 2003, pp. 1641-1699, > <https://www.jstor.org/stable/3593401> < .
 - Roland Ziadé et Claudia Cavicchioli, L'impact du Covid-19 sur les contrats commerciaux, dossier de Covid-19 et Contrat, Actualité Juridique Contrat, n= O04, Avril 2020.
 - Scott Baker & Kimberley D. Krawiec, Incomplete Contracts

- in a Complete Contract World, 33 Fla. St. U. L. Rev. (2006). <http://ir.law.fsu.edu/lr/vol33/iss3/8>.
- Sophie Harnay, L'analyse économique du juge constitutionnel », Revue Interdisciplinaire d'études Juridiques, 78, 2017.
 - Steve W. Feldman, Laws as implied contract terms: The divergent approaches and a proposed solution, University of Pennsylvania, Journal of Business Law, Vol. 19 Issue No. 4, p 07 > https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2926643 < .
 - Susheng Wangm, Definition of incomplete contract, Hong Kong University of Science & Technology (HKUST) - Department of Economics, July 27, 2016, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2815104.
 - Thierry kirat, L'allocation des risques dans les contrats: de l'économie des contrats « incomplets » à la pratique des contrats administratifs, La Revue International de Droit Economique, n° 1, 01/01/2003.
 - Wei, Guangyue, The Scientometric Evaluation of the Research on the Incomplete Contract from 1986 to 2016 (August 1, 2017) > <https://ssrn.com/abstract=3291386> < .
 - Wendy Netter Epstein, Facilitating Incomplete Contracts, 65 Case Western Reserve law Review, 297 (2014), > <https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol65/iss2/4> < .

C. Reports:

- Rapport au président de la république relatif à l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, JORF n°0074 du 26 mars 2020, > https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/03/2020-315_rapport.pdf < .

D. Websites:

- www.ca6.uscourts.gov .
- www.dalloz-actualite.fr > <http://www.dalloz-actualite.fr> < .
- www.economie.gouv.fr .
- www.jurisprudence.dalloz-avocats.fr > <http://www.jurisprudence.dalloz-avocats.fr> < .

An attempt to apply the incomplete contract theory to the contractual obligations under pandemic Corona

Dr. Badreddine Berrahlia

The article explores the content of incomplete contract theory. It illustrates the emergence of the incomplete contract theory in the Anglo-American jurisdiction. The paper demonstrates the legal basis of the theory and the tools that support its integration in the general system of contracts.

The article explains the participation of the incomplete contract theory to addressing the contractual obligations issues under pandemic Corona and "the contract crisis".

The paper provides the renegotiation as a genuine principle to the continuity of the contractual relationships. In the same time, it highlights the limitation of the incomplete contract theory in the case of interlinked contracts.

أثر جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على عقود التجارة الدولية

الدكتور/ عبد اللطيف دحية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة المسيلة - الجزائر

ملخص:

لا شك أنّ مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" يبنّي على ثلاثة أسس، أولها قانوني قوامه مبدأ سلطان الإرادة، وثانيها أخلاقي يتمثل في احترام العهود والمواثيق، وثالثها ذو طابع اجتماعي واقتصادي يُترجمه وجوب استقرار المعاملات، ومن هذا المنطلق وبما أنّ تفشي وباء كورونا المستجد (COVID-19) قد كان له بالغ الأثر على مختلف المعاملات التجارية الدولية في كل مناطق العالم، فإنّ عقود التجارة الدولية لم تكن بمنأى عن هذا الوباء، لذلك تناقش هذه الدراسة مسألة التوصيف القانوني لهذا الوباء بين اعتباره قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً، ومآل عقود التجارة الدولية في ظل تفشي هذا الوباء سواء من خلال انفساخ هذه العقود أو توقيفها وما يترتب عليهما من أثر، كما ختمنا دراستنا هذه بخاتمة تضمّنت النتائج والتوصيات.

مقدمة:

شهدت التجارة الدولية^(١) في الفترة الأخيرة تطورات لا حصر لها جعلتها تزدهر وتعيش أزهى عصورها، وما ذلك إلّا بسبب التقدم الهائل في وسائل الإنتاج ووسائل النقل والاتصال، وترابط المصالح والتعاملات بين دول تفصل بينها مسافات كبيرة. يتّخذ النشاط التجاري الدولي غالباً صيغة العقد بين أطرافه، فإذا كان العقد في ميدان التعامل الداخلي عنصراً أساسياً في تبادل الثروات، فإنّ دور هذا العنصر يتعاظم وقيّمته تزداد وأهميته تبرز في ميدان التعامل التجاري الدولي، فلا غرو إذن أنّ العقود الدولية هي أداة مهمة لتسيير عقود التجارة الدولية ووسيلة مثلى لإتمام المبادلات الاقتصادية عبر الحدود.

(١) استُعمل مصطلح "التجارة الدولية" لأول مرة من طرف الاقتصادي الإنجليزي (جون ستوارت ميل ١٨٠٦-١٨٧٣) منتصف القرن التاسع عشر، ثم انتشر استخدامه بعد ذلك في باقي الدول. د. أبو العلا علي أبو العلا النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ٢٠٠٢، ص ١.

تُعتبر قاعدة التنفيذ العيني إحدى أهم المراحل في عقود التجارة الدولية، وذلك بسبب حرص أطراف العقد على تنفيذه، رغم ما قد يعيقهم من ظروف صعبة، ولعلّ مردّ ذلك يعود إما إلى رغبة الأطراف في تحقيق أكبر قدر من الاستقرار في معاملاتهم، أو إلى طبيعة العقد وضخامة الأعمال التي يلتزم الأطراف بتنفيذها، غير أنّ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) قد كان له بالغ الأثر على التنفيذ العيني، فنجمت عنه استحالة تنفيذ هذه العقود بسبب غلق أغلب الدول لحدودها ومنع السفر منها وإليها.

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية موضوع البحث في ارتباطه بعقودٍ تزداد وتتنامي يوماً بعد يوم في حياة الدول جميعها خصوصاً في السنوات الأخيرة مع ظهور ما يسمى بالدول النامية، والتي لا بد لها لكي تلحق بركب الدول المتقدمة من علاقات تربطها بها تظهر بشكل واضح في العقود التجارية، ناهيك عن أنّ هذه العقود تتميز بقيمتها المالية الضخمة التي تتجاوز المليارات من الدولارات في الكثير من الأحيان، وبالتالي فإنّ تنفيذها أو عدم تنفيذها له بالغ الأثر - بلا شك - على الحياة الاقتصادية للدول، خصوصاً النامية منها.

كما أنّ تأثر عقود التجارة الدولية بالقوة القاهرة يؤدي إلى تأثر التجارة الدولية برمتها؛ وذلك نظراً لارتباط هذه العقود ببعضها بعضاً، فعقد البيع الدولي للبضائع يدور حوله عدد كبير من العقود الأخرى كالتأمين والوكالة وغيرهما.

إضافة إلى كل ما سبق فإنّ منظمة التجارة العالمية تتوقع وفق أحدث تقاريرها أن تنكمش التجارة الدولية نهاية العام الجاري (٢٠٢٠) بمعدل بين ١٣٪ و ٣٢٪ بالمقارنة مع العام السابق (٢٠١٩)^(٢)، ومنظمة العمل الدولية تؤكد بأنّ هذه الجائحة أثّرت على نحو ٨٠٪ من القوى العاملة العالمية البالغ عددها ٣ مليارات وثلاثمائة مليون شخص حول العالم، وأنّ ١٩٥ مليون فرصة عمل ستُفقد في هذا العالم بسبب هذا الوباء، منها ١ مليون و ٧٠٠ ألف فرصة عمل في الوطن العربي^(٣)، كما يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA أن تخسر شركات الطيران في المنطقة العربية

(٢) الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

(٣) الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf =

وحدها حوالي ٣١٤ مليار دولار^(٤) من عائدات الركاب مقارنة بالعام ٢٠١٩، يحدث هذا كله في ظل انعدام وجود بوابر تحسُّن الوضع وانحسار الوباء، وعلى اعتبار أنَّ توقف حركة النقل وإغلاق الحدود وتوقيف الرحلات تُعتبر رصاصة الرحمة التي أُطلقت على عقود التجارة الدولية، فإنَّ مصير هذه الأخيرة وما يترتب عنه من ركود اقتصادي يبقى مجهولاً.

أسباب اختيار الدراسة:

تنقسم أسباب اختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية يُترجمها مدى رغبتنا في دراسة هذا النوع من المواضيع القانونية المتخصصة في مجال التجارة الدولية، وكذا مدى حرصنا كأكاديميين على إيجاد التوصيف القانوني للوضع في ظل هذا الوباء، ومن ثَمَّ مصير عقود التجارة الدولية خصوصاً نظراً لحدّثة الوباء، ناهيك عن سعينا لإثراء المكتبات العربية والعالمية بهذا النوع من الدراسات التي تحاول الإجابة عن العديد من التساؤلات التي تُثار بمناسبة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، كذلك بسبب حداثة هذا الموضوع والذي مازال لم يأخذ بعدُ حظّه الوافر من الدراسة والبحث.

إضافة إلى أسباب موضوعية تتعلق بعمق الفجوة الاقتصادية التي تسبّب فيها ظهور هذا الوباء، فلا يخفى على أحد حجم الخسائر الفادحة التي تكبّدها التجارة الدولية منذ تفشي الوباء كما أسلفنا سابقاً.

أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى محاولة توضيح مآل عقود التجارة الدولية في ظل انتشار جائحة وباء كورونا (كوفيد -١٩)، كما يهدف إلى توضيح عدّة مسائل لعلَّ أهمها مدى اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة، وكيفية تعامل الدول مع هذه العقود في ظل الانتشار الرهيب لهذا الوباء وصيرورته واقعاً ملموساً تعيشه دول العالم بِرُمَّتها.

إشكالية الدراسة:

عطفاً على كل ما سبق فإنّه تُطرح العديد من الإشكاليات كالآتي: ما مفهوم القوة القاهرة والظروف الطارئة؟ وما تكييف جائحة فيروس كورونا (COVID-19)؟ هل هي قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ الالتزام التعاقدي ومن ثَمَّ يتحرّر كل طرف من التزاماته، أم هي مجرد ظرف طارئ يُرهق مُنفذ الالتزام ويستوجب إعادة النظر في

(٤) الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: <https://www.iata.org/>

العلاقة التعاقدية؟ ما هو مصير العقود التجارية الدولية في ظل هذه الجائحة؟ وبعبارة أخرى ما هي الحلول المقررة قانوناً في مثل هذه الظروف؟

منهجية الدراسة:

لقد اقتضت الإجابة عن هذه الإشكاليات، وكذا طبيعة الموضوع، أن نعتمد في دراستنا له على التزاوج بين المنهجين الوصفي والتحليلي، اعتماداً على المنطق القانوني، حيث سيتم وصف القواعد القانونية التي تحكم الموضوع، وكذا وصف الكثير من الأوضاع والحالات، ثم تحليل النصوص القانونية والاتفاقيات ذات الصلة.

خطة الدراسة:

- المبحث الأول: مفهوم القوة القاهرة والظروف الطارئة ومدى انطباقهما على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
- المطلب الأول: تعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة.
- المطلب الثاني: فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بين اعتباره قوة القاهرة أو ظرفاً طارئاً.
- المبحث الثاني: مآل عقود التجارة الدولية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
- المطلب الأول: انفساخ العقد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
- المطلب الثاني: وقف تنفيذ العقد وشرط إعادة التفاوض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

المبحث الأول

مفهوم القوة القاهرة والظروف الطارئة ومدى انطباقهما على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

من الثابت أنَّ العقود تخضع لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، أي أنَّ ما اتفق عليه الأطراف في العقد هو الذي يجب أن يلتزموا به، ولا يجوز لأي طرف أن يُخلَّ به، أو يطلب تعديله من تلقاء نفسه، وقد أقرَّت هذه القاعدة غالبية القوانين الوضعية، مثل القانون المدني الفرنسي الذي تناول ذلك في نص المادة ١١٣٤ بقوله: "إنَّ الاتفاقات التي تمَّت على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقيدها"، فبين المتعاقدين يكون مضمون العقد واجب التنفيذ، فهما يحترمانه ويلتزمان به كما هو الشأن بالنسبة إلى أية قاعدة ينص عليها القانون^(٥).

غير أنَّ الظروف المرافقة لتنفيذ العقد غير مضمونة في كثير من الأحيان، خصوصاً إذا ما كان هذا العقد ذا طبيعة دولية^(٦)، وبالتالي فإنَّه يتأثر بتغير الظروف والمعطيات بين الفينة والأخرى تبعاً لتطورات الحياة، فمنذ أن تمَّ الإبلاغ عن فيروس كورونا (COVID-19) لأول مرة في ووهان (الصين)، في ديسمبر من العام الماضي، سعت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر السفر وحجر المواطنين وعزل المصابين في محاولة لوقف انتشار هذا الفيروس الجديد، غير أنَّه ما فتئ أن تطور إلى تهديد عالمي، ففي ٣٠ يناير ٢٠٢٠، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنَّ أعداد

(٥) د. عبد الحكم فودة، أثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ٢٠١٤، ص ٩.

سعید السيد علي، نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية والشرعية الإسلامية "دراسة مقارنة"، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٧، ص ٧٠.

(٦) حتى يمكن اعتبار العقد دولياً هناك عدَّة معايير، ومنها المعيار القانوني الواسع (التقليدي الجامد) والذي يتجسد في اعتبار العقد دولياً متى تضمَّن عنصراً أجنبياً سواء تعلَّق هذا العنصر بأطرافه أو بمحل إبرامه أو بمكان تنفيذه، كما ظهر معيار آخر هو المعيار الاقتصادي والذي يجد أساسه في تصور يركّز على موضوع التعاقد نفسه، حيث يفترض تحليل موضوع العقد ومحتواه المادي والاقتصادي، ومدى حركة رأس المال عبر الحدود وأثر ذلك على اقتصاد الدول المعنية، لذلك يُعد دولياً العقد الذي تُقرض بمقتضاه شركة ما أحد فروعها في الخارج مبلغاً من المال بحيث يُستخدم هذا المال المُقرض لتحقيق أهداف اقتصادية معينة في موطن ذلك الفرع. د. هشام علي صادق، القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ١٩٩٥، ص ٥٠ وما بعدها.

الإصابات شكّلت حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي في جميع أنحاء العالم، وأصبحت الدول في حاجة إلى اتخاذ تدابير الطوارئ التي نتجت عنها اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية، واثرت إشكالية قانونية حول مدى اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة أم ظرفاً طارئاً، وعليه سنحاول بين طيّات هذا المبحث أن نُبيّن تعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة في (المطلب الأول)، وتوضيح مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة أم ظرفاً طارئاً في (المطلب الثاني).

المطلب الأول

تعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة

رغم الأهمية النظرية والعملية التي يحظى بها المفهوم التقليدي للقوة القاهرة والظروف الطارئة، وانطلاقاً من أنّ كلتا النظريتين - في نظر الكثير من الفقهاء - ليستا من النظام العام، فيجوز الاتفاق على ما يخالفهما، فإنّ التعامل التجاري الدولي يأبى - في الواقع - الخضوع لأحكامهما، إذ إنّ طبيعة التعامل التجاري الدولي من حيث السرعة والائتمان والسعي دوماً نحو التنفيذ الكامل للعقود والصفقات التي يُبرمها المتعاملون في هذا المجال، لا سيما وأنّ تلك العقود والصفقات ذات قيمة نقدية ضخمة جداً، كل ذلك جعل الأطراف يسعون نحو استحداث مفهوم جديد للقوة القاهرة والظروف الطارئة يهدف في الحقيقة للتخفيف والتلطيف من شروطهما المتشددة، ويتحقق ذلك في الواقع، من خلال إغفال ذكر أحد الشروط أو استبعاده صراحة في شروطهم التعاقدية، نتناول بين طيات هذا المطلب تعريف كل من القوة القاهرة (الفرع الأول) والظروف الطارئة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

تعريف القوة القاهرة

اتفق الفقهاء على اعتبار القوة القاهرة هي كل حادث عام لاحق على تكوين العقد، غير مُتوقَّع الحصول عند التعاقد، وينجم عنه اختلال بين المنافع المُتولّدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل، ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه - كما أوجبه العقد - مرهقاً إرهاباً شديداً، ويتهدّد بخسارة فادحة تخرج عن حد المألوف، فقد عرّف عميد فقهاء القانون العرب عبد الرزاق السنهوري القوة القاهرة بأنّها: "أمر غير مُتوقَّع الحصول وغير ممكن الدفع يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً دون أن يكون هنالك خطأ

في جانب المدين" ^(٧)، كما عرّفها أولبيان بأنّها ^(٨): "كل قوة لا يمكن مقاومتها، ومن أمثلتها الحريق الناشئ عن الصواعق، والفيضان والعواصف والزلازل والبراكين" ويصعب على أي باحث في القانون الروماني، أن يجد فكرة خالصة عن القوة القاهرة، متميزة عمّن سواها، من كل وجه، ويمكن القول إنّ القانون الروماني، في العصر العلمي، انتصر لفكرة التوحيد بين القوة القاهرة *Vis major* والحادث الفجائي *Casus fortuitus* فلم يفرق بينهما، بل أطلق القول في بيان الأفعال التي تُفضي إلى استحالة تنفيذ الالتزام، ولكنّ الفقه فرّق بين نوعين من الأفعال، فعل يرجع إلى المدين، وفعل يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، هذا الأخير يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، وهو ما خصّه الفقهاء بوصف القوة القاهرة، أو الحادث المفاجئ ^(٩) أو الآفة السماوية *Vis divina*.

فبعض الكتاب يرى اختلافاً كبيراً وجوهرياً بين كلّ من القوة القاهرة والحادث الفجائي، ويُميزون بينهما على أساس أنّه "إذا كانت الاستحالة مُطلقة فتوجد القوة القاهرة، أما إذا كانت الاستحالة نسبية فيوجد الحادث الفجائي" ^(١٠)، في حين يميّز البعض الآخر بين القوة القاهرة والحادث الفجائي على أساس أنّ القوة القاهرة هي حادث يستحيل دفعه، أما الحادث الفجائي فهو الذي لا يمكن توقُّعه ^(١١).

(٧) عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٩٨، ص ٩٦٣.

(٨) د. محمد شتا أبو سعد، مفهوم القوة القاهرة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، المجلد ٧٤، العدد ٣٩٣-٣٩٤، سنة ١٩٨٣، ص ١٧٥.

(٩) يحاول البعض أن يميز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ بالقول إنّ القوة القاهرة تتميز باستحالة دفعها، أما الحادث المفاجئ فيتميز باستحالة توقعه، كما أنّ القوة القاهرة أمر خارجي غير متصل بنشاط المدين كزلازل مثلاً، بينما يكون الحادث المفاجئ أمراً داخلياً متصلاً بنشاط المدين كانهجار آلة مثلاً، ولكنّ الرأي الراجح اليوم هو الذي لا يميز بين المصطلحين. انظر: أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ١٩٩٦، ص ٣٥٦.

د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصية)، دار الثقافة، عمان، الأردن، ٢٠٠٥، ص ٢٩٨.

(١٠) أشار إلى هذا الرأي: يونس إسماعيل حسن، أحكام الفسخ في العقود الإدارية " دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ٢٠١٥، ص ٢١٠.

(١١) المرجع نفسه، ص ٢١٠.

د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، المرجع نفسه، ص ٢٩٨.

وفي هذا الصدد نشير إلى أنَّ القانون المدني المصري يشير في بعض موادّه إلى كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي، مما يفيد تمييزه بينهما، ومن ذلك ما نصّت عليه المادة ٦٧٣/٢ على أنّه: "لملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسؤوليتهم عمّا يصيب المرفق من غطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته، إذا أثبتوا أنّ ذلك يرجع إلى قوة القاهرة خارجة من إدارة المرفق، أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مُقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه..."^(١٢).

وهو السياق نفسه الذي اتّبعه المشرع الجزائري، حيث جمع في العديد من مواد القانون المدني بين عبارتي القوة القاهرة والحادث المفاجئ مما يفيد تمييزه بينهما، ولو أنّه لم يضع معايير واضحة لهذا التمييز، ومن ذلك مثلاً المادة ٨٥١^(١٣).

ونحن نرى في صدد التمييز بين مصطلحي القوة القاهرة والحادث الفجائي، أنّه لا تفرقة بينهما، وأنّ الحادث الفجائي هو فقط تعبير عن إحدى الصفات الغالبة للقوة القاهرة، باعتبار أنّ هذه الأخيرة هي حادث غير مُتوقع ويحدث فجأة، أما عن الأسس التي ضُربت للقول بالتمييز بينهما، فهي لا تقوم على أساس صحيح في نظرنا، كون أنّ كلا من القوة القاهرة والحادث الفجائي يستدعيان أن تكون الاستحالة مُطلقة، وأن يكونا غير متوقّعين ولا يمكن التصدي لهما.

يُطلق علماء القانون على القوة القاهرة أحياناً مصطلح الاستحالة^(١٤)، كما أنّ البعض يُطلق عليها مصطلح استحالة التنفيذ القهري، ولعلّ ذلك راجع للنتائج التي

(١٢) القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني المصري.

د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، المرجع السابق، ص ٢٩٨.

(١٣) تنص المادة ٨٥١ من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة به..... وله نتاج المواشي بعد أن يعرض منها ما هلك من الأصل بسبب حادث مفاجئ أو قوة القاهرة".
عبد الرحمان عباد، أساس الالتزام العقدي، النظرية والتطبيقات، المكتب المصري، الإسكندرية، مصر، ١٩٨٢، ص ١٥٦.

Joseph Emmanued, note, sous, cass, 3 civ 24 avr. 2003, J.C.P, ed. G.2004, p 103.

(١٤) خالد علي سليمان بني أحمد، الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة " دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، الأردن، المجلد ١، العدد ٢، ٢٠٠٦، ص ١٧١.

تُرتَّبها القوة القاهرة تجاه المتعاقدين، ويسمىها البعض الآخر "السبب الأجنبي" وهي العبارة التي استعملها القانون المدني المصري في المادة ٣٧٣ والقانون التجاري الكويتي في المادة ٢٥٦^(١٥)، إلا أننا نرى أنَّ السبب الأجنبي أوسع من القوة القاهرة التي ليست سوى إحدى حالاته، فالسبب الأجنبي قد يتمثل إما في القوة القاهرة أو في خطأ الدائن أو في فعل الغير، كما أنَّ الاستحالة تُعدُّ أثراً للقوة القاهرة، فهما بمثابة السبب والمُسبَّب، تربطهما علاقة سببية، حيث تُعدُّ القوة القاهرة السبب الذي ينتج عنه المُسبَّب وهو استحالة التطبيق^(١٦).

تصنف حوادث القوة القاهرة إلى نوعين:

- ١ - القوة القاهرة بحسب أصل الحادث: تنشأ القوة القاهرة إما عن فعل الطبيعة كالزلازل والصواعق والفيضانات والثلوج والأوبئة، أو عن فعل الإنسان، وفي الحالة الأخيرة لا فرق بين مصدر الفعل الذي يمكن أن يكون العنف الواقعي، كثورة شعبية أو سرقة مسلحة، أو أن يكون العذر القانوني للدولة، كأن تقوم الدولة بنزع ملكية عقار من مالكه عن طريق الاستملاك، أو المصادرة، أو أمر السلطة.
- ٢ - القوة القاهرة بحسب موضوع الالتزام: ينحصر عملياً تطبيق القوة القاهرة في مجال الالتزام بعمل، وفي مجال الالتزام بالامتناع عن عمل، والالتزام بإعطاء شيء معين بالذات، أما في الالتزام بإعطاء شيء معين بالنوع، فيندرج تطبيق القوة القاهرة؛ وذلك لأنَّ الأشياء المعينة بنوعها لا تهلك من حيث المبدأ، فالمدين بتسليم كمية من البضاعة لا تبرأ ذمته إذا هلك كل ما لديه من هذه البضاعة؛ لأنَّ باستطاعته تأمين الكمية التي التزم بتسليمها من السوق الداخلي أو الخارجي. غير أنَّ واقع عقود التجارة الدولية قد ميَّزه هجر بعض المصطلحات المستخدمة في العقود الداخلية، فنجد مثلاً هجراً لمصطلح القوة القاهرة في اتفاقيات التجارة

(١٥) تنص على ما يلي: "ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أنَّ الوفاء به أصبح مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد له فيه".

د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، المرجع نفسه، ص ٢٩٨.

(١٦) عبد الوهاب الرومي، الاستحالة وأثرها في الالتزام العقدي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٩٩، ص ٤٩٦.

عبد الرحمن عباد، المرجع نفسه، ص ١٥٦.

Joseph Emmanued, note, sous, cass, 3 civ 24 avr. 2003, J.C.P, ed. G.2004, p 103.

الدولية، فاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (فيينا ١٩٨٠)^(١٧) على سبيل المثال، تستخدم في المادة ٧٩ منها مصطلح "إعفاء" كعنوان للمادة ٧٩ منها^(١٨).
وأيضاً كان مفهوم القوة القاهرة سواء أكان مفهوماً تقليدياً متشديداً يستمد أساسه من نصوص التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، أم كان مفهوماً مرنًا يستمد أساسه من اتفاق الأطراف، فإنَّ ثمة التزامات تترتب على إعماله، ويتوزع عبء هذه الالتزامات في الواقع على عاتق الطرفين، فنجد أنَّ المدين يلتزم بإخطار الدائن بوقوع حادث القوة القاهرة، وما نجم عنه من آثار تطال قدرته على التنفيذ، ومن جانب آخر فإنَّ الالتزام بالتعاون المتبادل بين أطراف العقد - والذي يفرضه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود - يفرض على الدائن أن يقوم - من جانبه - ببذل الجهود اللازمة للتقليل من حجم الأضرار التي لحقت أو قد تلحق به نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بسبب حادث القوة القاهرة، ونظراً لأهمية الالتزام بالإخطار، فإنَّ المتعاملين في ميدان التجارة الدولية غالباً ما يضمنون عقودهم شروطاً تقضي بسقوط حق المدين في التمسك بالقوة القاهرة إن هو تقاعس عن تنفيذ الالتزام بالإخطار أو أهمل في ذلك^(١٩).

(١٧) اعتُمدت هذه الاتفاقية في ١١ نيسان/ أبريل ١٩٨٠ ودخلت حيِّز النفاذ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٨٨، الغرض من هذه الاتفاقية هو توفير نظام حديث وموحد ومنصف بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع. وهكذا، تسهم الاتفاقية إسهاماً كبيراً في إضفاء طابع اليقين على عمليات التبادل التجاري وخفض تكاليف المعاملات.

(١٨) د. شريف محمد غنام، أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات، الطبعة الأولى، ٢٠١٠، ص ٨.

(١٩) صالح مهدي كحيط العارضي، نور عقيل طاهر عبود الرحيمي، الالتزام بالأخطار في عقود التجارة الدولية، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية القانون تحت شعار "بناء دولة المؤسسات على أسس قانونية أداة فاعلة في محاربة الفساد والإرهاب"، كلية القانون، جامعة آل البيت، العراق، ٢٩/٠٤/٢٠١٧، ص ٤. تاريخ الاطلاع على البحث يوم ١٠/١٠/٢٠٢٠ على الساعة ١٩:١٤ زوالاً، على رابط المداخلة التالي:

<https://abu.edu.iq/sites/default/files/conferences/law/13/170427-120643.pdf>

الفرع الثاني تعريف الظروف الطارئة^(٢٠)

ورد مصطلح (الظروف الطارئة)^(٢١) في استعمالات الفقهاء المعاصرين، ولم يتعرض له الفقهاء القدامى بالشكل الحالي^(٢٢)، فالفقهاء القانونيون هم أول من جاء بهذا المصطلح في شأن البيان للحالات غير المتوقعة التي تطرأ على العقد بعد إبرامه، وهذه بعض التعاريف القانونية لهذا المصطلح:

عرّفها الأستاذ إسماعيل عمر المحامي بأنها: "حالة عامة غير مألوفة أو غير طبيعية، أو واقعة مادية عامة لم تكن في حساب المتعاقدين وقت التعاقد، ولم يكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد، ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام التعاقدية مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة إن لم يصبح مستحيلاً"^(٢٣).

في حين عرّفها الأستاذ حشمت أبو ستيت بقوله: "هي كل حادث عام لاحق على تكوين العقد وغير متوقع الحصول عند التعاقد، ينجم عنه اختلال بين في المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال، ويصبح تنفيذ المدين للالتزام كما

(٢٠) على الرغم من أنّ فكرة الظروف الطارئة عريقة منذ القدم، إلا أنّها لم تستقر على مسمى واحد على مر العصور، حيث حاول الفقهاء وضع إطار متكامل لها مما أدّى لاختلاف الآراء حول مدلولها وأساسها والشروط الواجب توافرها لتطبيقها على العقود. د. محمد محي الدين إبراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإسلامي- دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، مصر، ٢٠١٠، ص ٩.

(٢١) شرّعت نصوص القانون المدني الكويتي العديد من المواد لمعالجة القوة القاهرة، كما تضمّنت المادة ١٩٨ من القانون المدني الكويتي تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة، وذلك لمعالجة الالتزام الذي يصبح مرهقاً ويهدد بخسارة فادحة للمتعاقد.

(٢٢) لقد تردّد صدق نظرية الظروف الطارئة في أقوال بعض الفلاسفة الرومان المتأثرين بالفلسفة اليونانية القائمة على فكرة الحق الطبيعي والعدالة، فقد قال (شيشرون): عندما يتغير الزمن يتغير الواجب، ويُنسب إلى (سينيك) قوله: أنا لا أعتبر حائناً لعهدي ولا يمكن اتهامي بعدم الوفاء، إلا إذا أبقيت الأمور على ما هي وقت التزامي ثم لم أنفذه، والتغير الذي يطرأ على أمر واحد يجعلني خراً في أن أناقش التزامي من جديد، ويخلصني من كلامي الذي أعطيته، ويجب أن يبقى كل شيء على حالته التي كان عليها في الوقت الذي تعهّدت فيه لكي أستطيع المحافظة على كلامي. م. د. عمار محسن كزار، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد، مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد ٣٨، سنة ٢٠١٥، ص ٦.

(٢٣) محمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، دار زهران، الأزهر، مصر، د س ن، ص ١٩.

أوجبته العقد مُرهقاً له إرهاباً شديداً ويتهدهد بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف" (٢٤).

لذلك وبمقتضى نظرية الظروف الطارئة فإنه إذا طرأت على العقد أثناء تنفيذه حوادث استثنائية عامة وغير متوقعة، وكان من نتيجتها أن تنفيذ الالتزام أصبح مرهقاً للمدين ويهدده بخسارة فادحة إذا تمّ تنفيذه بالحال والكيفية التي تمّ الاتفاق عليها عند إبرام العقد، فإنه يجوز للقاضي التدخل من أجل موازنة العقد وإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بحيث يزيل الضرر الذي يلحق بالمدين قدر الإمكان من أجل إعادة التوازن الاقتصادي للعقد (٢٥).

أما في الجزائر (٢٦)، فيرى البعض أن الظرف الطارئ هو حادث استثنائي لم يكن في الوسع توقعه، غير أنه وإن جعل من تنفيذ الالتزام أمراً عسيراً ومرهقاً وهذ المتعامل المتعاقد بخسارة فادحة أو مسّ بالتوازن الاقتصادي للعقد، فإنه يُبقي تنفيذ العقد ممكناً ولا يجعل منه أمراً مستحيلاً (٢٧).

وتتمثل خصائص الظرف الطارئ فيما يلي (٢٨):

(٢٤) بلقاسم زهرة، أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ألكي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، ٢٠١٣-٢٠١٤، ص ٢٥.

(٢٥) محمد السناري، الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د س ن، ص ١٣.

(٢٦) لم يفرق المشرع الجزائري بين القوة القاهرة والحادث أو الظرف الطارئ، وذكرهما مجتمعين في عدة مواد منها: ١٢٧، ١٣٨، ١٧٨/١، ٥٤٤، ٦٤٠، ٨٥١ من القانون المدني، في حين ذكر الحادث الطارئ أو المفاجئ مستقلاً في المواد: ١٦٨، ٥٦٨، ٨٤٣، ٩٥٤ وذكرهما ضمن حالات السبب الأجنبي في المواد ٢١٥، ٣٠٧، ٣٣٦، ٥٦٩، كما استعمل عبارات للتعبير عن القوة القاهرة في مواد أخرى منها (سبب لم يكن يتوقعه)، في المادة ١٣٨/٢، (سبب لا يُنسب إليه) (لا يد له فيه)، المواد ٣٦٩ و ٤٨١/٣، و(ليس من فعله) المادة ٤٩٠. بوغرة الصالح، انتشار فيروس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية بين تطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، حوليات جامعة الجزائر ١، المجلد ٣٤، العدد ٣ (عدد خاص - القانون وجائحة كوفيد-١٩)، جويلية ٢٠٢٠، ص ٣٢٤.

(٢٧) خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة، الجزائر، ٢٠١١، ص ٢٩٧.

(٢٨) محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات، دار الهدى، الجزائر، طبعة ٢٠٠٤، الجزء الأول، ص ٣١٩.

- هو ظرف استثنائي غير عادي، وهو الحادث الذي يندُر وقوعه كالحرب والزلازل والأوبئة.
 - هو ظرف عام لا يختص بالمدين وحده، على عكس القوة القاهرة التي قد تخص المدين وحده أو مدينين معينين بالذات، بل يشمل الناس جميعاً، فالحوادث الخاصة بالمدين وحده كإفلاسه أو موته أو اضطراب أعماله أو حريق محصوله لا تُعد ظروفًا عامة، وتقدير ذلك متروك للقاضي.
 - هو ظرف غير مُتوقع أي لا يستطيع الشخص العادي توقعه وقت إبرام العقد.
 - لا يمكن دفعه، فالمدين ملزم أن يتخطى الحوادث التي تجعله يعجز عن الوفاء بالتزامه أما الحوادث العارضة ولو أوقفت التنفيذ مؤقتاً فلا يُعتد بها.
- تجدر الإشارة إلى أنَّ هناك جانباً من الفقه أقرَّ وحدة القوة القاهرة والظروف الطارئة، أي يرى بأنَّ لهما ذات المفهوم ولا يختلفان من حيث المصدر، الخصائص والآثار، وهو ما أخذ به المشرع المصري الذي نصَّ صراحة على وحدتهما، في حين بقي الغموض يكتنف التشريع الفرنسي الذي ذكرهما على سبيل المثال ضمن السبب الأجنبي، أما التشريع الجزائري فإنه - كما أسلفنا - استعمل العبارتين مجتمعتين في بعض المواد، وفي حالات أخرى نصَّ على إحداها دون الأخرى، وفي مواد أخرى استعمل عبارات أخرى تدلُّ على السبب الأجنبي، مما يجعلنا نميل للتفرقة بين المفهومين خاصة مع وجود حكم خاص بالمادة ١٠٧ من القانون المدني، واختلاف الآثار القانونية في الحالتين.
- إنَّ نتيجة أعمال نظرية الظروف الطارئة موزعة بين الدائن والمدين، إذ لا يُعفى المدين كلياً من تنفيذ التزامه، وفي الوقت ذاته لا يمكن للدائن طلب حقوقه كاملة، أما في حالة القوة القاهرة فإنَّ الدائن وحده من يتحمَّل تبعاتها ويُعفى المدين من التزامه، كذلك تختلف النظريتان - وفقاً للمشرع الجزائري - في مدى تعلقهما بالنظام العام، فأحكام الظروف الطارئة من النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها مثلما جاء في القانون المدني الجزائري المادة ١٠٧: "... ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك"، في حين في نظرية القوة القاهرة أجاز المشرع الاتفاق مسبقاً على تحمل المدين لتبعاتها؛ إذ تنص المادة ١٧٨/٢ على أنه: "يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية".

المطلب الثاني

فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بين اعتباره قوة القاهرة أو ظرفاً طارئاً

كما أسلفنا تُعد القوة القاهرة من أكثر النُظم القانونية اقتراباً من نظرية الظروف الطارئة، وذلك بصورة يصعب معها التمييز أحياناً بينهما، بيد أنه يترتب على القوة القاهرة فسخ العقد^(٢٩) وبالتالي تحل كل طرف من التزاماته تجاه الطرف الآخر، وذلك راجع لاستحالة تنفيذ الالتزام بسبب القوة القاهرة، أما الظرف الطارئ فيجعل تنفيذ العقد من قبل المتعاقدين أشدَّ إرهاباً ويتولد عن هذا أنَّ للمتعاقد المضرور الحق في أن يطلب من القضاء تعديل شروط العقد، أو بعبارة أخرى الموازنة بين مصلحة الطرفين ورد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

لا شك أنَّ طبيعة التدابير الاحترازية المُتخذة من أجل مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، بدءاً بتوقيف الدراسة مؤقتاً، مروراً بمنع وحظر التجمعات العمومية، وإلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والدينية والعروض الفنية، وانتهاءً بإغلاق المجال الجوي والحدود البرية وتخفيض مستوى الخدمات المقدمة بالمرافق العمومية، كلها تؤكد أننا أمام جائحة تتجاوز قدرة الفرد على التوقع^(٣٠)، وسنحاول خلال هذا المطلب الوصول إلى توصيف قانوني لفيروس كورونا المستجد مبيّن مدى اعتباره قوة القاهرة (الفرع الأول)، والأسس التي بناءً عليها يمكن اعتباره ظرفاً طارئاً (الفرع الثاني).

الفرع الأول

فيروس كورونا المستجد كقوة القاهرة

لا يختلف اثنان في أنَّ فيروس كورونا يُعتبر أمراً مُستجداً على الساحة العالمية، حيث ظهرت انعكاساته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي منذ بداية يناير ٢٠٢٠، فمُنظمة الصحة العالمية اعتبرت - على لسان مديرها العام "تيدروس ادهانوم غبريسوس" - فيروس كورونا المستجد وباءً عالمياً وينطبق عليه وصف الجائحة،

(٢٩) خالد علي سليمان بني أحمد، المقال السابق، ص ١٧٤.

(٣٠) د. إبراهيم احطاب، فيروس كورونا كوفيد- ١٩ بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة،

بحث منشور في الإنترنت، تمَّ التصفح يوم ١٩/٠٥/٢٠٢٠ على الساعة ١٣:٠٢ على الموقع

التالي: <https://bit.ly/2RcwJ6M>

وتعني هذه الأخيرة - حسب ذات المنظمة - الانتشار العالمي لمرض جديد^(٣١)، وهو ما اتخذت معه كافة بلدان المعمورة إجراءات شبه موحدة تراوحت بين إغلاق الحدود والحجر الصحي لمواطنيها مخافة انتشار العدوى التي حصدت أرواحاً بشرية عديدة في الكثير من الدول، الأمر الذي وجد معه عالم الأعمال نفسه اليوم أمام تحديات جسيمة أجبرته على اتخاذ قرارات صعبة تجلّت في توقيف الدراسة ومجموعة من الأنشطة وتخفيض سير أخرى، من ذلك خدمات التمويل والتوزيع، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، كما أنّ هذا الوباء جعل من الوفاء بالالتزامات التعاقدية صعبة أو مستحيلة، كما أثر سلباً على الخدمات، وأدّى إلى نقص السيولة المالية، وبالتالي فيمكن اعتبار الفيروس بمثابة قوة القاهرة بوصفه صورة من صور السبب الأجنبي الذي ينفي علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق بالمضروب، وباعتباره حادثاً خارجياً لا يمكن للمدين توقعه، ولا دفعه، من خلال الواقع يمكن استنتاج أسباب اعتبار فيروس كورونا قوة القاهرة كالآتي^(٣٢):

١ - عدم إمكانية توقع الحادث:

ومعيار عدم التوقع معيار موضوعي يتطلب أن يكون عدم التوقع مطلقاً، فلا يكفي فيه أن يكون غير ممكن التوقع من جانب المدين، وإنما أيضاً يجب أن يكون غير ممكن التوقع من جانب أكثر الناس حيطة وحذراً^(٣٣)، ونحن نعلم أنه لم يكن بالإمكان البتة توقع ما ستؤول إليه الأوضاع بعد يناير ٢٠٢٠.

٢ - استحالة دفع الحادث:

لا يكفي لقيام القوة القاهرة عدم إمكانية توقع الحادث، بل يجب إضافة لذلك أن يستحيل دفعه، ومعنى ذلك أنّ الحادث يجب أن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة، فإذا استطاع المدين دفع الحادث ولم يفعل، فلا يعفي هذا الحادث

(٣١) عبد الرحيم بحار، أثر وباء كورونا المستجد كوفيد ١٩ على الالتزامات التجارية، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا (مؤلف جماعي)، سلسلة إحياء علوم القانون، مجلة دولية علمية محكمة، الطبعة الأولى، ماي ٢٠٢٠، ص ٣٨٨. الرابط التالي: <https://www.marocdroit.com/attachment/1935327/>

(٣٢) الدكتور المحامي أيمن العوامل، القوة القاهرة وفيروس كورونا، التزامات الأطراف في ظل انتشار الكورونا واعتبارها (القوة القاهرة)، موقع عين نيوز، تاريخ النشر ٢٣/٠٣/٢٠٢٠، تاريخ التصفح يوم ٠٨/٠٥/٢٠٢٠ على الساعة ٢٢:١٨ مساءً.

<https://ainnews.net>

(٣٣) خالد علي سليمان بني أحمد، المقال السابق، ص ١٧٦.

المدين من المسؤولية حتى لو كان غير ممكن التوقع^(٣٤)، وتكمن العلة في انعدام قيام مسؤولية المدين في حالة ثبوت تحقق شرط عدم إمكانية التوقع، في أن هذا الشرط يمس مباشرة بالإرادة ويؤثر فيها تأثيراً كبيراً على نحو سلبي، بحيث تنعدم معه قدرة الإنسان على التصرف، فإرادة الإنسان تمثل محور شرط عدم القدرة على الدفع، إذ تنعدم القدرة على التصرف في مواجهة القوة القاهرة، ولإسباغ وصف القوة القاهرة على الحادث يُشترط أن يستعصي على المدين، ولا يكون بإمكانه دفع وقوعه والتغلب على نتائجه^(٣٥)، وبإسقاط هذا الشرط على فيروس كورونا المستجد، نرى - وفقاً لتقديرنا - أن الدول العظمى لم تستطع بإمكاناتها الضخمة أن تدفع هذه الجائحة التي استطاعت في ظرف وجيز أن تجمد جميع قطاعات الدول.

٣ - أن يكون الحادث خارجياً:

أي ألا يكون هناك خطأ من المدعى عليه، فإذا تسبّب المدعى عليه بوقوع الحادث أو ساعد على وقوعه، فلا يُعدّ الحادث قوة القاهرة حتى لو توافر فيه الشرطان السابقان، ومن ثم لا يُعفى من المسؤولية، وكذلك إذا كان الحادث داخلياً بالنسبة للشئ، واشتراط خارجية الحادث عن إرادة المدين أمر منطقي ويحقق العدالة، كما أنه يتماشى أيضاً مع مبدأ حسن النية، فمن غير المعقول أن يُسمح للمدين بالاستفادة من عدم تنفيذ العقد إذا كان عدم التنفيذ يُعزى إلى خطئه، وخاصية خارجية الحادث وردت الإشارة إليها في القانون المدني الجزائري بصفة غير مباشرة: "... ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه"^(٣٦)، وعندما نقول أن الحادث لا ينتج الحادث عن فعل المدين فهذا يشمل ألا يكون من فعل من يشملهم برقابه ورعايته، أو من فعل تابعيه، وألا قامت مسؤوليته طبقاً لأحكام المواد ١٣٤-١٣٥ من القانون المدني الجزائري، ويُسلم الفقه عموماً بأهمية هذا الشرط ويرى فيه شرطاً ضرورياً وأساسياً لوصف حادث ما بالقوة القاهرة ولاسيما في العقود الدولية.

وقد اشترط بعض الفقهاء مثل الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري شرطاً آخر تمثل في استحالة التنفيذ، والذي يُقصد به أن يجعل التنفيذ مستحيلاً ولا يكفي أن يجعله صعباً مرهقاً^(٣٧).

(٣٤) خالد علي سليمان بني أحمد، المقال نفسه، ص ١٧٦.

(٣٥) محمد الزين، النظرية العامة للالتزام، الطبعة الثانية، دار قرطبة، تونس، ١٩٩٧، ص ١٥١.

(٣٦) نص المادة ١٧٦ من الأمر ٥٨-٧٥ المؤرخ في ٢٥/٠٩/١٩٧٥، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، ج ٧٨، الصادرة في ٣٠/٠٩/١٩٧٥، ص ٨١٨.

(٣٧) عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، المرجع السابق، ص ٩٦٥.

تجدر الإشارة إلى أنَّ هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية قد أكدت بأنها ستقوم بمنح شهادات (القوة القاهرة) للشركات الدولية التي تأثرت عملياتها وتنفيذ عقودها بظرف جائحة فيروس كورونا، وذلك شريطة تقديمها المستندات التي تُوثق إثبات التأخير وتُعطل وسائل المواصلات وعقود التصدير، وقام فعلاً عدد من الدول بتبني ذات الموقف ودعمه، ومنها ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ بعد اجتماع مع الشركات التي تنفذ مشاريع للحكومة الفرنسية أنَّ فيروس "كورونا" يُعد قوة القاهرة بالنسبة للعقود القائمة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، مؤكداً أنَّهم لن يطبقوا غرامات التأخير في التنفيذ على الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة^(٣٨).

الفرع الثاني

فيروس كورونا المستجد كظرف طارئ

لعلَّ هناك عدة أسباب ومعطيات تجعل من اعتبارنا لفيروس كورونا ظرفاً طارئاً أمراً صحيحاً، وهي كالآتي:

- ١ - تمَّ إعلان غالبية الدول فيروس كورونا المستجد ظرفاً طارئاً وخطيراً، يهدد سلامة البلاد.
- ٢ - تمَّ تناول أحكام الظروف الطارئة في دساتير أغلب الدول.
- ٣ - تمَّ الإعلان في الجزائر أنَّ ما تمرُّ به البلد هي ظروف طارئة.
- ٤ - تمَّ إعلان في الجزائر الإجراءات التي ستتم بها مواجهة هذه الظروف الطارئة. وبإسقاط ما سبق بيانه على العقود نجد أنَّ هناك عقوداً لم تتأثر نهائياً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم لمجابهة فيروس "كورونا كوفيد ١٩" والحد من انتشاره، وهناك نوع آخر من العقود تأثرت لدرجة أنَّ الالتزام أصبح تنفيذه مستحيلاً، وهنا نطبق نظرية القوة القاهرة، وهناك نوع ثالث من العقود لم يصبح تنفيذ الالتزامات فيها مستحيلاً بل أصبح مرهقاً، وهنا نطبق نظرية الظروف الطارئة^(٣٩).

(٣٨) د. محمد رضا منصور بو حسين، معالجة الآثار القانونية لـ "كورونا" على العقود الدولية والمحلية، بحث منشور على شبكة الإنترنت يوم ١٧ مارس ٢٠٢٠، تم الاطلاع عليه يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ على الساعة ٣٠:١٦ على الرابط التالي:
<https://albiladpress.com/posts/633576.html>

(٣٩) د. محمد الأيوبي، المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس كورونا كوفيد ١٩، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا (مؤلف جماعي)، مرجع سابق، ص ٢٩٢.

المبحث الثاني

مآل عقود التجارة الدولية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

لا شك أنَّ حركة التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر تُؤسَّس على مبدئين، أولهما اقتصادي وهو مبدأ حرية التجارة، والذي يقوم على منح الحرية الكاملة أمام التبادل التجاري الحر للسلع والخدمات عبر الحدود الدولية دون قيود، أما الثاني فهو مبدأ قانوني يتمثل في الحرية التعاقدية والذي يُستمد من مبدأ سلطان الإرادة ويُؤسَّس على واجب احترام الإرادة الفردية، فإرادة الإنسان حرة غير مقيدة، ولا يمكن أن تتوجه إلا إلى ما فيه مصلحته.

ومما لا شك فيه أنَّ جائحة كورونا قد أثَّرت على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فالعديد من الالتزامات التعاقدية التي أبرمت قبل حلول هذه الجائحة الوبائية أو بعدها، توقَّفت تنفيذها بسبب الإجراءات التي اتخذتها كافة الدول والتي شلَّت أو قيدت الحركة الاقتصادية في إطار ما أضحى يُعرف بالحجر الصحي أو التباعد الاجتماعي، ولعلَّ الإشكالية التي تثور بشكل كبير هي وقوع فيروس كورونا المُستجد أثناء أو بعد تنفيذ بنود التعاقد الدولي، ففي هذه الحالة يتقرَّر قانوناً إما انفساخ العقد (المطلب الأول) بسبب القوة القاهرة وهي جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وإما وقف تنفيذ العقد وإعادة التفاوض (المطلب الثاني).

المطلب الأول

انفساخ العقد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

من الثابت أنَّ العقود الدولية تتميز عن العقود الداخلية بكونها تتضمن قيمة تعاقدية كبيرة، كما أنَّ أطرافها عادة من جنسيات مختلفة، وبالتالي فإنَّ اللجوء إلى الانفساخ هو أمرٌ غير مُحبَّذ في الغالب الأعم، ولكن على اعتبار أنَّ الانفساخ يُعتبر أحد أهم آثار وقوع القوة القاهرة، فلا بد من التطرق إليه، نتناول بداية مفهوم انفساخ العقد وتمييزه عن الفسخ (الفرع الأول)، ثم الطبيعة القانونية للانفساخ (الفرع الثاني)، خاتمين هذا المطلب بالحديث عن شروط الانفساخ وآثاره في (الفرع الثالث).

الفرع الأول

تعريف انفساخ العقد وتمييزه عن الفسخ

نتناول أولاً تعريف الانفساخ، ثم ثانياً تمييزه عن الفسخ.

أولاً - تعريف الانفساخ:

اختلف الفقهاء في وضع تعريف لانفساخ العقد، غير أنهم أجمعوا على نقطة واحدة وهي انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه بسبب طارئ غير إرادي^(٤٠)، فنجد من الفقهاء من عرفه بأنه: "انحلال العقد بقوة القانون، إذا ما استحال تنفيذ الالتزام العقدي لسبب أجنبي خارج عن إرادة المدين، أي لا يد له فيه"^(٤١)، كما أن جُلَّ التشريعات الداخلية تضمّنَت الانفساخ وإن اختلفت المصطلحات التي تستخدمها للتعبير عن هذا المضمون، فهناك التشريع الجزائري في المادة ١٢١ من القانون المدني والتي عالجَت انفساخ العقد بسبب القوة القاهرة، وهناك أيضاً المشرع الفرنسي القديم الذي نظمَه في المادتين ١١٤٧ و١١٤٨، حيث نصّت المادة ١١٤٧ على: "أنَّ المدين يكون مسؤولاً عن التعويض إذا كان له محل إما بسبب عدم تنفيذ الالتزام، أو بسبب التأخير فيه، وذلك في جميع الأحوال ما لم يثبت أنَّ عدم التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ولم يكن ثمّة سوء نية من جانب المدين"^(٤٢).

وأما المادة ١١٤٨ من القانون نفسه فنصّت على أنه: "لا محل للتعويض إذا حالت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي دون قيام المدين بإعطاء أو عمل ما التزم به، أو إذا قام بأداء ما هو محظور عليه".

والشيء الملاحظ هو أنَّ كل التشريعات الداخلية قد اتفقت على كون سبب انفساخ العقد هو حدوث سبب أجنبي لا يد لأحد طرفي العقد فيه.

ثانياً - تمييز الانفساخ عن الفسخ:

الفسخ^(٤٣) هو زوال العقد بجميع آثاره في الماضي والمستقبل وهو ما يُعبّر عنه

(٤٠) منار عمر حامد الصدر، انفساخ العقد في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، قسم الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا، نابلس- فلسطين، ٢٠٠٣، ص ٢٩.

(٤١) صفاء تقي عبد النور العيساوي، القوة القاهرة وأثرها في عقود التجارة الدولية (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، العراق، ٢٠٠٥، ص ١٤٥.

(٤٢) Code Civile Français, Section 2, <http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf>

(٤٣) الفسخ في اللغة مصدر فَسَخَ يَفْسُخُ وبابه قطع ويحمل معان عدة، منها الفك والإزالة والتفريق والنقض، يقال فُسِخَ البيع فانفسخ أي نُقِضَ فانتقض وفسخ الشيء يفسخه فسحاً فانفسخ، =

بالأثر الرجعي للفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى^(٤٤)، يرجع ظهور نظام الفسخ إلى القانون الكنسي، حيث كانت الغاية منه ترسيخ الوفاء بالوعد، وترتيب المسؤولية على الشخص الذي لا يلتزم بوعده في الالتزامات المتقابلة^(٤٥)، هذا في الجانب الفقهي، أما في الجانب التشريعي فإنه لم يتطرق إلى بيان تعريف الفسخ^(٤٦) وإنما عبّر عنه بنصوص قانونية، مثل المادة ١١٩ من القانون المدني الجزائري^(٤٧)، والتي يتضح من خلالها مدى ارتباط الفسخ بنوع العقد، فالفسخ مقترن بالعقود الملزمة للجانبين^(٤٨)، لوجود التزامات متقابلة، وعدم تنفيذ أيٍّ منها يُعدّ مُبرراً للفسخ، فهو حق ذو طبيعة مزدوجة، فيمثل جزاء إذا نُظر إليه من زاوية المدين الذي أُخلّ بتنفيذ التزامه، وهو ضمان إذا نُظر إليه من زاوية الدائن الذي يسعى لاقتضاء حقه^(٤٩).

ويتّضح الفرق بين الفسخ والانفساخ بصورة جلية في سبب نشوء كلّ منهما،

= ينظر ابن منظور، لسان العرب المحيط، الجزء الثاني، أوفست تكنوبرس، بيروت، لبنان، ١٩٨١، ص ١٠٩٤.

(٤٤) المادة ١١٩ من الأمر ٥٨-٧٥ المؤرخ في ٢٥/٠٩/١٩٧٥، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.

(٤٥) ضحى مثنى داود، فسخ العقد في القانون المدني، بحث منشور، كلية الرافدين الجامعة، قسم القانون، ص ٣. الرابط:

<https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35324>

(٤٦) الترابط والتقابل هو جوهر الفسخ والغاية المبتغاة منه، المتمثلة في حق المتعاقد (الدائن) التمسك تجاه المتعاقد الذي أُخلّ بتنفيذ التزامه، والمستمر بعدم التنفيذ بالفسخ، وبذلك يكون نتيجة لأثر ذلك الترابط المنغمس بمجاله الطبيعي المعمول في العقود الملزمة للجانبين، وعليه ومن غير المتصور والمنطقي إعمال ذلك في العقود التي ترتب التزامات على أحد طرفي العلاقة دون الآخر، لانتهاء التقابل وعدم تحقق الحكمة المرجوة من الفسخ وغياب الأساس القانوني الذي بُني عليه. محمد حسن قاسم، القانون المدني، (المجلد الأول)، الالتزامات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ٢٠١٧، ص ٧٣.

(٤٧) يقابلها نص المادة ١٥٧ من القانون المدني المصري، وكذلك بقية القوانين العربية كالقانون المدني الأردني لسنة ١٩٧٧ في المادة ٢٤٦، وكذلك المادة ٢٧٣ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ المعدل.

(٤٨) Jean- Clauis Auloy, le droit de la consommation, 3^e édition, Paris, 1992, p 159.

(٤٩) طعن ٣٢٢٩ لسنة ٧٧ / قضائية / ٢٠١٥ قرار لمحكمة النقض المصرية، وكذلك ٣٠٢٣ لسنة ٢٠٠٣، والقرار ٣٥٩٨ لسنة ٢٠٠٣ الصادرين من محكمة النقض المغربية، ولمزيد من التفاصيل راجع: المواقع الرسمية للمحكمتين:

- الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: <http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx>
- الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية: <http://www.greffe.courdecassatio>

فالفسخ يكون بسبب إرادة الطرفين أو بحكم القاضي، أما الانفساخ فيكون بسبب غير إرادي وبقوة القانون^(٥٠).

يتفق الفسخ والانفساخ من حيث الأثر على المتعاقدين، أي رجوع المتعاقدين إلى حالة ما قبل العقد، غير أنه في الفسخ هذه الحالة تلزم التعويض، أما في الانفساخ لا يكون هناك تعويض؛ لأنَّ المدين قد انقضى التزامه بقوة قاهرة خارجة عن إرادته^(٥١).

الفرع الثاني الطبيعة القانونية للانفساخ

لقد ظهر اتجاهان في تحديد الطبيعة القانونية للانفساخ، فالاتجاه الأول يرى أنَّ الانفساخ ما هو إلا صورة من صور الفسخ، حيث اعتمد أصحاب هذا الرأي تقسيماً ثلاثياً للفسخ: فسخ قضائي، وفسخ اتفاقي، وفسخ بقوة القانون، ولكل نوع من هذه الأنواع طبيعته الخاصة، والانفساخ يمثل النوع الثالث من هذه الأنواع حيث يقع من تلقاء نفسه وبقوة القانون، لذا أُطلقت عليه تسمية الفسخ القانوني تمييزاً له عن كل من الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي^(٥٢).

أما الاتجاه الثاني فيرى أنَّ الانفساخ يخرج عن كونه مسألة من مسائل الفسخ، وذلك لطبيعته الخاصة التي تُميزه عن مسائل الفسخ الأخرى، فهو لا يقع إلَّا إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة، وعندئذ لا يترتب عليه الحكم بالتعويض، كما أنَّ من شأن طبيعته الخاصة أن قلّصت من سلطة المحكمة، فإذا كان لها أن تتدخل فإنَّ ذلك لا يتعدى مجرد التحقق من مدى توافر شروط الانفساخ من عدمها، وبذلك يكون حكماً كاشفاً لا منشئاً^(٥٣).

ونحن بدورنا نميل للأخذ بالرأي الأول؛ وذلك نظراً لأنَّ الانفساخ يقع من تلقاء نفسه وبالتالي فلا هو يقع عن طريق القضاء ولا بإرادة المتعاقدين، وعليه فهو يمثل العدالة المنشودة منه.

(٥٠) د. عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ١٩٩٧، ص ١٥.

— عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ١٩٩٢، ص ٢١٩.

(٥١) أوليادي موسى وقادري عبد الرزاق، أثر القوة القاهرة في العقود الدولية، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل ماستر أكاديمي تخصص عقود ومسؤولية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة- الجزائر، الموسم الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٨، ص ٤٨.

(٥٢) أوليادي موسى وقادري عبد الرزاق، المذكرة نفسها، ص ٤٩.

(٥٣) المذكرة نفسها، ص ٤٩.

الفرع الثالث شروط الانفساخ وآثاره

أولاً - شروط الانفساخ:

بما أن الانفساخ يُعتبر نتيجة حتمية لاستحالة التنفيذ بفعل انتشار وباء كورونا (كوفيد- ١٩)، فإن وقوع انفساخ العقد يكون بقوة القانون ومن تلقاء نفسه، دون طلب أحد أطراف العقد ذلك، أو دون الحاجة إلى حكم قضائي، ولكي يتم اللجوء إلى هذا الإجراء لابد من توافر الشروط التالية:

١ - الاستحالة المطلقة للتنفيذ:

لا شك أن الاستحالة المقصودة هنا هي الاستحالة الدائمة المطلقة؛ لأن الاستحالة المؤقتة تؤدي إلى وقف العقد، بحيث يُستأنف سريانه بعد زوال المانع^(٥٤)، وبما أن جائحة وباء كورونا ستستمر لمدة لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فإن فرضية الاستحالة المؤقتة هي أمر مُستبعد.

٢ - الاستحالة الكلية:

والمقصود بالاستحالة الكلية هنا عدم القدرة على الالتزام الكلي بتنفيذ بنود العقد؛ لأن الاستحالة الجزئية لا تُعفي المدين من التزاماته إلا في حدود الاستحالة^(٥٥)، وأثر الاستحالة الجزئية يختلف بحسب الأحوال، فقد تؤدي إلى انفساخ العقد كله إذا كان من شأنها التأثير على الهدف المقصود من التعاقد، وقد يبقى العقد مع إنقاصه أي تنفيذه في حدود ما بقي ممكناً إذا كان الجزء المتبقي يحقق المصلحة والفائدة المرجوة للدائن^(٥٦).

(٥٤) عبد الوهاب الرومي، الاستحالة وأثرها في الالتزام العقدي، الرسالة السابقة، ص ٤٨٣.

Jean- Clauis Auloy, op.cit, p 159.

عبد الهادي فهد علي الجفين، أثر القوة القاهرة على العقد في نطاق المسؤولية والرابطة العقدية ودور الإرادة في تعديل الأثر المترتب عليها- دراسة مقارنة- مذكرة الماجستير، جامعة الكويت، ١٩٩٨-١٩٩٩، ص ٢٣٩.

(٥٥) وهذا ما جاءت به المادة ١١٩ من القانون المدني الجزائري سألغة الذكر في حالة الفسخ.

(٥٦) أوليدي موسى وقادري عبد الرزاق، المذكرة السابقة، ص ٤٩.

محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، د س ن، ص ٤٢٥.

٣ - وقوع الاستحالة بعد إبرام العقد:

والمقصود هنا هو أن تكون الاستحالة بعد تنفيذ العقد؛ لأن وقوعها وقت انعقاد العقد تعني ألا ينعقد العقد أصلاً لاستحالة محله^(٥٧).

٤ - أن تكون الاستحالة خارجية:

ونعني بهذا الشرط رجوع الاستحالة لسبب أجنبي، ويتمثل هذا السبب في موضوع الحال وقوع وباء كورونا (كوفيد-١٩) بحيث يمكن إسقاط الشروط السابقة، من حيث عدم التوقع وعدم إمكانية دفعه، وخارجية الحادث عن إرادة أحد أطراف العقد، فقبل يناير ٢٠٢٠ لم يكن أحد يعلم بأن جميع مناحي الحياة سوف تتوقف بما فيها العلاقات التجارية بين الدول بسبب جائحة كورونا (كوفيد-١٩).

ثانياً - آثار الانفساخ:

يترتب على انفساخ العقد الدولي بسبب القوة القاهرة (فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩) عدة آثار تشمل انحلال العقد وزواله وإبراء المتعاقدين مما يترتب عليهما من التزامات، وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، مما يتطلب بالضرورة أن يرد كل منهما ما حصل عليه بموجب العقد، وبما أن الانفساخ قد وقع نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا فإن من آثاره أيضاً انتفاء مسؤولية المدين التعاقدية، الأمر الذي يفرض امتناع الحكم بالتعويض على المدين، وسنتناول هذه الآثار تباعاً:

١ - انتفاء مسؤولية المدين:

لا شك أن أهم أثر يستتبع انفساخ العقد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، هو إبراء ذمة المدين، أو بمعنى آخر انتفاء المسؤولية المدنية للمدين^(٥٨)، فلا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يطالب المدين بما يترتب على عدم التنفيذ من آثار، ذلك أن عدم التنفيذ في هذه الحالة مردّه وقوع جائحة وباء كورونا (COVID-19) التي لا يد للمدين فيها، فليس هنالك خطأ أو تقصير أو إهمال من طرفه حتى ولو تحقق الضرر بالفعل في جانب الدائن، إذ إن القوة القاهرة هي التي

(٥٧) المرجع نفسه، ص ٤٢٥.

(٥٨) يعترف الفقه الإسلامي أيضاً بأثر القوة القاهرة - ويسميتها بالجوائح - على الالتزام وإسقاط الضمان مستنداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "من باع ثمراً فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئاً، على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟" محمد الشحات الجندي، ضمان العقد أو المسؤولية العقدية في الشريعة الإسلامية مقارناً بالقانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ١٩٩٠، ص ١٦٨.

قطعت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وقد نصّت اتفاقية الجات الدولية ١٩٩٤^(٥٩) في المادة ٧ على الأثر المعفي من المسؤولية، ومنها وقوع كوارث طبيعية أو توقف النقل أو قوة قاهرة أخرى تؤثر بصورة كبيرة على المنتجات المتاحة للتصدير.

٢ - انحلال العقد:

يُقصد بانحلال العقد زواله أو بعبارة أدق تحلل المتعاقدين من التزاماتهما التي لم يتم تنفيذها، وقد أشارت لذلك صراحة اتفاقية فيينا للبيع الدولي لسنة ١٩٨٠، فقرّرت أنه بفسخ العقد يصبح الطرفان في حِلٍّ من الالتزامات التي يَرْتَبُّها العقد^(٦٠)، ويتم اللجوء إلى الانحلال سواء أكان سبب الفسخ هو إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته أم قوة قاهرة؛ ذلك أنّ الاتفاقية لم تُفرّق بينهما ولم تجعل للعائق سوى أثر واحد وهو الإغفاء من التعويض، كما أخذت بهذه القاعدة مبادئ اليونيدروا^(٦١)؛ حيث قضت بأنّ إنهاء العقد يترتب عليه تحلل الأطراف مستقبلاً من التزاماتهم المتقابلة.

٣ - حق الاسترداد:

يُقصد بالاسترداد أن يُرجع كل طرف ما تسلمه من الطرف الآخر، فبما أنّ الانفساخ يسري بأثر رجعي-حيث يُعتبر العقد المنفسخ كأن لم يكن- فإنّ ذلك يتطلب عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيُرجع كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد^(٦٢)، إذ يصبح احتفاظ كل طرف بما تسلمه من الطرف الآخر غير

(٥٩) اتفاقية الجات أو GATT تعتبر اختصاراً ل: الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة General Agreement on Tariffs and Trade وهي الاتفاقية الأحدث من بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، عُقِدَت أول مرة عام ١٩٤٧ واستمرت في الانعقاد بعد ذلك في جولات.

(٦٠) المادة ٨١ فقرة ١ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع فيينا ١٩٨٠. بالإمكان زيارتها على الرابط التالي:

<https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf>

(٦١) l'article 3-5-7 des Principes D'UNIDROIT Relatifs aux Contrats du commerce International sur ce lien:

<http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2012/10/principes-unidroit-integral-versionprinciples2010-f.pdf>

(٦٢) مصطفى عبد السيد الجارحي، فسخ العقد، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد ٥٦، ١٩٨٦، ص ١١٥. Serome. Kullmann: note sou, civ, 3, 13 decembre 1989, civ, 3. 28 mars, 1990, Dalloz, 1991, p 237.

مستند إلى أي مُسوّغ^(٦٣)، وهو ما نصّت عليه المادة ٨١ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا" ١٩٨٠ آنفة الذكر في فقرتها الثانية^(٦٤)، كما أخذت به مبادئ اليونيدروا في الفقرة الأولى من المادة ٧-٣-٦، هذه الأخيرة تجيز لطرفي العقد بعد انفساخه المطالبة بالاسترداد العيني لما قاما بتوريده، شريطة أن يقوم كل منهما بصورة متزامنة برد كل ما تأتى له من هذا العقد^(٦٥).

٤ - عدم الأحقية في التعويض:

لابد لكي يُحكم بالتعويض لأحد الطرفين على ما أصابه من خسارة وما فاتته من كسب، أن يصدر إخلال من الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد صدر عمداً أو إهمالاً أو لأي سبب آخر، غير أن الإخلال بالتنفيذ إذا كان بسبب القوة القاهرة فإنّ الأثر الذي يترتب عليه هو الإعفاء من التعويض^(٦٦)، فلا يجوز مطالبة المدين بأي تعويضات عن عدم التنفيذ، وقد نصّت على ذلك المادة ٧٩ من اتفاقية فيينا ١٩٨٠، وينبغي القول بأنّ المدين لا يُعفى إلا من أداء التعويضات

(٦٣) أخذت بهذه القاعدة بعض التشريعات العربية، فالمشرع الجزائري أشار إليها في صلب المادة ١٢٢ من القانون المدني والتي نصت على أنه: "إذا فُسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض"، وتقابلها المادة ٢١٦ من القانون المدني الكويتي التي تنص على أنه: "إذا انفسخ العقد، اعتُبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود بمقتضى المواد ٢١١، ٢١٢، ٢١٣ بشأن الفسخ". وتقابلها المادة ١٦٠ من القانون المدني المصري: "إذا فُسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض".

(٦٤) تنص المادة ٨١ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "فيينا" ١٩٨٠ في فقرتها الثانية على أنه: "يجوز لأي طرف قام بتنفيذ العقد كلاً أو جزءاً أن يطلب استرداد ما كان قد ورّده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد، وإذا كان كل من الطرفين ملزماً بالرد، وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام في وقت واحد".

(٦٥) تنص هذه المادة على ما يلي: "يجوز لأي من الأطراف عند فسخ العقد المطالبة بالاسترداد العيني لما قام بتوريده، على أن يقوم هذا الطرف بصورة متزامنة برد كل ما حصل عليه، وإذا لم يكن الرد العيني ممكناً أو مناسباً فيتم الرد بمقابل نقدي كلما كان ذلك معقولاً، مع ذلك إذا كانت مدة تنفيذ العقد قد امتدت وكان العقد قابلاً، للانقسام، فلا يكون هناك محل للاسترداد إلا عن الفترة التالية للفسخ".

<http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2012/10/principes-unidroit-integral-versionprinciples2010-f.pdf>

(٦٦) CARTIER-MARRAUD M- L. AKYUREK O, Crise économique et révision des contrats, Gazette du palais, 16 Juin 2009, n 167, p 2.

التي قد يُلزم بها في ما إذا كان سبب الفسخ خطأه أو تقصيره في تنفيذ التزامه، أما ما قد يتم الاتفاق عليه من تعويضات كالشرط الجزائي فيرجع في شأنه إلى أحكام العقد والقانون الواجب التطبيق.

٥ - تحمّل تبعة الهلاك:

تحمّل التبعة قانوناً يعني تحمّل الخسارة الناتجة عن قوة القاهرة^(٦٧)، وتختلف التشريعات الوطنية والدولية في تحديد من يتحمل تبعة الهلاك، فمنها من يربط انتقالها بانتقال الملكية ومنها من يأخذ بقاعدة مقتضاها أنّ تبعة الهلاك لا تنتقل إلا بالتسليم^(٦٨)، فبالرجوع إلى اتفاقية فيينا ١٩٨٠ نجد أنّها لم تُنظمها ضمن الجزء الخاص بالإعفاء من المسؤولية، بل تناولتها ضمن الجزء الخاص بالإخلال بالالتزامات لكل من البائع والمشتري، وذلك بموجب المواد من ٦٦ إلى ٧٠، ومن خلال نص المادة ٩٦ من الاتفاقية نفسها نجد أنّها تربط تبعة الهلاك^(٦٩) بالوفاء بالتسليم، بغض النظر عن انتقال الملكية أو عدم انتقاله.

المطلب الثاني

وقف تنفيذ العقد وشرط إعادة التفاوض بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

لا شك أنّ إرادة الأطراف لن تتجه - غالباً - إلى حل الرابطة العقدية في العقود

(٦٧) التبعة في الفقه القانوني نوعان، النوع الأول هو تبعة هلاك الشيء (le risque de la chose) والأصل هنا أنّ التبعة يتحملها المالك، والاستثناء من ذلك إذا كان الشيء محلاً لالتزام بنقل عيني في عقد ملزم للجانبين، فتصبح التبعة على المدين بالتسليم، أما النوع الثاني فهو تبعة هلاك العقد (Le risque du contrat) في العقود الملزمة لجانبين يتحملها المدين الذي استحال تنفيذ التزامه. عبد السلام أحمد بني حمد، تحمل تبعة الهلاك قبل التسليم في عقد المقابلة في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد ٤٥، عدد ٣، ٢٠١٨، ص ١٦.

(٦٨) أوليدي موسى وقادري عبد الرزاق، المذكرة السابقة، ص ٥٥.

(٦٩) ربط المشرع الفرنسي تبعة هلاك المبيع بانتقال الملكية وليس بالتسليم للمبيع، فجعل تبعة الهلاك يتحملها مالك المبيع، وهنا لا يكون الهلاك على المدين بالتسليم، وإنما يقع على عاتق مالك الشيء المبيع، فالملكية وتبعة الهلاك تنتقلان بالعقد، ومتى تم العقد الناقل للملكية انتقلت الملكية إلى المتعاقد الآخر وتحمل تبعة الهلاك بوصفه مالكا. د. أحمد محمد الرفاعي، القانون المدني (العقود المدنية: البيع والإيجار)، بحث منشور على الإنترنت، ص ١٦٤ الرابط التالي:

<http://olc.bu.edu.eg/olc/images/311.pdf>

الدولية؛ وذلك نظراً - كما أسلفنا - لما تحتويه من قيمة اقتصادية ضخمة^(٧٠)، أضف إلى ذلك المدة الكبيرة التي استغرقها إبرام العقد، وهو الشيء المُتوقع، فعقود التجارة الدولية وعقود نقل التكنولوجيا وعقود توريد الأدوية وعقود توريد المُعدات الإلكترونية قد يمتد تنفيذها لفترة طويلة من الزمن، ومن ثم فهي عرضة لتغير الظروف المحيطة بتنفيذها^(٧١)؛ لذا فإنَّ الأطراف لديهم من الحلول ما يُغنيهم عن فسخ العقد، فتكون لديهم فرصة هامة من خلال وقف العقد (الفرع الأول)، كما أنَّ المعاملات سوف تكتسب استقراراً عقدياً أكثر إذا كان الأطراف متفقين على شرط إعادة التفاوض (الفرع الثاني).

الفرع الأول مفهوم وقف تنفيذ العقد

سوف نتناول من خلال مفهوم وقف تنفيذ العقد تعريفه، ثم الطبيعة القانونية له.

أولاً - تعريف وقف تنفيذ العقد:

اختلفت تعريفات الفقهاء لوقف تنفيذ العقد تبعاً لاختلاف توجهاتهم، فمن قائل بأنَّه: "وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية المُتبادلة التي يفرضها العقد على طرفيه عند حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى الاستحالة المؤقتة في التنفيذ، واستئناف تنفيذه عند زوال الاستحالة المؤقتة"^(٧٢)، ومن قائل بأنَّه: "تأجيل أو تأخير مؤقت في تنفيذ الالتزام ناجم عن حادث يخرج عن نطاق رقابة الأفراد، ويهدف إلى الحفاظ على الرابطة العقدية خلال فترة الانقطاع من أجل استئناف تنفيذ العقد مرة أخرى حين تنتهي تلك العقبة"^(٧٣).

ويمكن القول من خلال ما جاد به الفقهاء في التعريفات السابقة أنَّ وقف تنفيذ العقد ما هو إلا علاج قضائي أُخذاً بالمفهوم التقليدي للقوة القاهرة، أو هو اتفاق في حال الأخذ بالمفهوم الحديث للقوة القاهرة، يردُّ على العقد الذي تحوّل دون تنفيذه قوة

(٧٠) د. علاء الدين عبد الله الخصاونة، الجوانب القانونية للالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة العقود (دراسة في القانون الفرنسي والأردني ومبادئ القانون الموحد حول التجارة الدولية ومبادئ القانون الأوروبي للعقود)، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، المجلد ٣٨، العدد ١، سنة ٢٠١٤، ص ٦٣٦.

(٧١) د. علاء الدين عبد الله الخصاونة، المقال السابق، ص ٦١٨.

(٧٢) صفاء تقي عبد النور العيساوي، المرجع السابق، ص ١٨٤.

(٧٣) د. شريف محمد غنام، أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص ٣٠١.

قاهرة تؤدي إلى استحالة مؤقتة في تنفيذ الالتزام، وينقضي إما بزوال الاستحالة وإمكانية التنفيذ أو بانفساخ العقد وزوال الرابطة العقدية.

ثانياً - الطبيعة القانونية لوقف تنفيذ العقد

يذهب جانب كبير من الفقهاء إلى اعتبار وقف تنفيذ العقد فسخاً مؤقتاً للعقد يُوقَف مفعوله بالنسبة إلى الطرفين خلال فترة امتداد القوة القاهرة التي حالت دون إمكانية التنفيذ، في حين تبقى الرابطة العقدية سليمة نافذة قبل مدة الوقف وبعدها^(٧٤)، ولعلّ هناك عدّة مآخذ على هذا الرأي، فمن جانب سيؤدي ذلك حتماً إلى توسيع نطاق الفسخ وإدخال مفهوم جديد إليه، ينتج عنه قطعاً ضياع معالم الفسخ^(٧٥)، كما أنّ من شأن الأخذ بهذا الرأي التسليم بفكرة فسخ العقد مع إمكانية التنفيذ العيني له، في حين أنّ الفسخ لا يتقرّر إلا بعد أن يصبح التنفيذ العيني مستحيلاً^(٧٦).

كما أنّ هناك رأياً آخر اعتبر وقف تنفيذ العقد دفعاً بعدم التنفيذ يُعطى للمدين، يُحوّله عدم تنفيذ التزامه ما دامت الاستحالة قائمة، دون التعرض إلى الحكم عليه بالفسخ، فالهدف من وراء الوقف والدفع بعدم التنفيذ هو إنقاذ الرابطة العقدية من الزوال أملاً في إمكانية معاودة التنفيذ في المستقبل تفادياً لانفساخ العقد^(٧٧)، خصوصاً - كما أسلفنا - أنّ العقود التجارية الدولية تمتاز بضخامة القيمة وطول الإجراءات مما قد ينعكس سلباً على كلا الطرفين في حال فسخ العقد، والواقع يُبين أنّ هناك بوناً شاسعاً بين وقف تنفيذ العقد والدفع بعدم التنفيذ، فهذا الأخير ما هو إلا وسيلة للضغط على إرادة المتعاقد الآخر الممتنع عن تنفيذ التزامه سواء بإرادته أو خطأ صادر عنه بهدف حمله على تنفيذ التزامه^(٧٨).

يمكن في الأخير القول بأنّ وقف تنفيذ العقد هو نظام ذو طبيعة خاصة^(٧٩) تفرضه ضرورة إعادة التوازن والتكافؤ وإيجاد درجة من التناسب بين الاستحالة والأثر المترتب عليها.

(٧٤) صفاء تقي عبد النور العيساوي، المرجع نفسه، ص ١٨٥.

(٧٥) د. شريف محمد غنام، المرجع السابق، ص ٣٠١.

(٧٦) د. الغزالي محمد محمد الحسن، التكييف الفقهي والقانوني لوقف العقود، مجلة النيل الأبيض للدراسات والبحوث، جامعة النيل الأبيض، العدد ١٢، سبتمبر ٢٠١٨، ص ١٩.

(٧٧) صفاء تقي عبد النور العيساوي، المرجع السابق، ص ١٨٤.

(٧٨) د. الغزالي محمد محمد الحسن، المقال نفسه، ص ١٩.

(٧٩) أوليدي موسى وقادري عبد الرزاق، المذكرة السابقة، ص ٥٦.

الفرع الثاني شرط إعادة التفاوض

نتحدث أولاً عن تعريف شرط إعادة التفاوض، ثم ثانياً عن آثار شرط إعادة التفاوض.

أولاً - تعريف شرط إعادة التفاوض:

تُعتبر إعادة التفاوض وسيلة يلجأ إليها المتعاقدان من أجل معالجة ما قد يُستجد من ظروف في أثناء تنفيذ هذا العقد، وقد عرّف بعض شُرّاح القانون شرط إعادة التفاوض بأنه: "الشرط الذي يورده المتعاقدان في العقد والمتضمن إعادة التفاوض فيما بينهما عند وقوع أحداث معينة ومحددة في العقد نفسه أو في اتفاق منفصل، شريطة أن تكون هذه الأحداث مستقلة عن إرادتهما وتوقعاتهما عند إبرام العقد"^(٨٠)، وأن تؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، وإصابة أحدهما بضرر فادح، فقد تكشف الظروف المستجدة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين تؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزامه العقدي أو صعوبة تنفيذه.

وتختلف تسميات شرط إعادة التفاوض تبعاً لاختلاف التشريعات، فقد يُلجأ لاستخدامه في العقود الدولية وفق المصطلح الإنجليزي (HARDSHIP) والذي يعني المَشَقَّة العَقْدِيَّة، ويُعد هذا المصطلح من المصطلحات التي ظهرت في كنف التجارة الدولية^(٨١)، كما أنَّ الفقه الفرنسي يُعبّر عنه بعدة تسميات، كشرط المراجعة clause de rvision، أو شرط العدالة والإنصاف clause d'quit، أو شرط المحافظة Clause de sauvegarde، أو شرط الصعوبة Clause de duret^(٨٢).

وكائناً ما تكون تسميتها فإنّها تسمح للمتعاقدين بإيجاد حلٍّ مُناسبٍ لمعالجة النتائج والآثار الضارة التي يُسببها تغيُّر الظروف، كما تعطي لهذا العقد فرصة الاستمرار والبقاء عن طريق تعديل أحكامه وشروطه^(٨٣).

(٨٠) د. علاء الدين عبد الله الخصاونة، المقال السابق، ص ٦٢٦.

(٨١) Olivier d' Auzon - Contrats commerciaux en français et en anglais: 40 modèles prêts à l'emploi. Cd-Rom offert, Broché - 1 juillet 2010, p 35.

(٨٢) Marcel Fontaine, Droit de contrats internationaux - Analyse et rédaction des clauses FEC, 2ème édition 1989.

(٨٣) Mousseron J-M, technique contractuelle, 2 édition, Francis Lefebvre, 1993, p 74.

ثانياً – آثار شرط إعادة التفاوض:

١ – إعادة النظر في الالتزامات العقدية بعد جائحة كورونا (COVID-19):

لا شك أنَّ فكرة إعادة النَّظر تُمثل النقطة الجوهرية التي يسعى أطراف العقد إلى تحقيقها بإعادة التفاوض بعد اختلال التوازن العقدي بفعل تفشي وباء كورونا؛ وذلك لأنَّ إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية تعمل على التقارب من أجل التوصل إلى حلٍّ مُناسبٍ لمعالجة آثار القوة القاهرة التي أصابت العقد^(٨٤)، وتمنح للأطراف فرصة الاستمرار في تنفيذ العقد، وعليه فإنَّ نظام أو فكرة إعادة التفاوض تمثل آلية من الآليات الهامة لحل الخلافات والنزاعات الناتجة عن القوة القاهرة أثناء مرحلةٍ جدُّ مهمة في حياة العقد وهي مرحلة تنفيذ العقد^(٨٥).

٢ – نجاح التفاوض:

في حال التَّوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات ومن ثَمَّ نجاح عملية إعادة التفاوض، فإنَّه يتم الإبقاء على العملية العقدية وضمن استمرارها، وهو ما قد يميل الأطراف إلى تحقيقه خصوصاً في عقود التجارة الدولية، لِما لهذه العقود من أهمية بالغة وقيمة اقتصادية مرتفعة^(٨٦).

٣ – التحكيم كنتيجة لعدم نجاح التفاوض:

اختلفت تعريفات الفقهاء للتحكيم، فعرَّفه الدكتور أحمد أبو الوفا بأنَّه: "اتفاق على طرح النزاع على شخص أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة"^(٨٧).

وعرَّفه الدكتور أسامة المليجي بأنَّه: "اتجاه إرادة الأطراف إلى طرح نزاعهم على شخص أو أشخاص معينين، ليفصلوا فيه بعيداً عن القضاء، فهو ينشأ نتيجةً لاتفاق الأطراف عليه إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة"^(٨٨).

كما عرَّفه أنطوان كاسس "Antoin Kassis" بأنَّه: "حل النزاع من طرف

(٨٤) د. علاء الدين عبد الله الخصاونة، المقال السابق، ص ٦٦١.

(٨٥) أوليدي موسى وقادري عبد الرزاق، المذكرة السابقة، ص ٧٢.

(٨٦) د. علاء الدين عبد الله الخصاونة، المقال نفسه، ص ٦٦٠.

(٨٧) أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ٢٠٠١، ص ١٥.

(٨٨) أسامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، دار النهضة العربية، مصر ٢٠٠٤، ص ١٢.

شخص أو عدة أشخاص، تم اختيارهم بمحض إرادتهم للرجوع إليهم لحل النزاع الذي قد قام من جرّاء إبرام وتنفيذ عقود تجارة دولية^(٨٩).

وليس هناك من يجادل في أنّ التحكيم قد أضحى القضاء الأصيل لدى المتعاملين في التجارة الدولية^(٩٠)، ففي حالة عدم نجاح عملية إعادة التفاوض أو عدم الالتزام بالاتفاق الجديد، فإنّ اللجوء إلى التحكيم هو الملاذ والحل الأخير، بل أنّ المتعاملين أصبحوا لا يرضون عنه بديلاً؛ لذا فالتحكيم يُعتبر أثراً من آثار إعادة التفاوض في حالة عدم نجاحه^(٩١)، وفي هذه الحالة تتمتع هيئة التحكيم بصلاحيّة إعادة التوازن للعقد المتأثر بتفشي جائحة وباء كورونا (COVID-19).

خاتمة:

لا شك أنّ حدوث ظروف صعبة وقوة القاهرة تُشكل بحق جزءاً قاسياً تتأذى التجارة الدولية منه، وتتأثر العلاقة العقدية به كثيراً، وأنّ ظهور جائحة فيروس كورونا (COVID-19) في نهاية سنة ٢٠١٩ - وبداية سنة ٢٠٢٠ - قد تسبّب في توقف جميع مجالات الحياة في العالم، فتوقّفت المطارات وشلّت حركة النقل داخلياً ودولياً، وتوقّفت المصانع والمدارس والجامعات، وفرضت الدول على مواطنيها حجراً منزلياً وتباعداً اجتماعياً، وبدأت بوادر أزمة مالية عالمية جديدة تلوح في الأفق، فالصين لوحدها بلغت صادراتها نحو العالم (٤ تريليون و٦٠٠ مليون دولار) فمعظم الشركات المحلية أو العالمية إما تستورد من الصين أو لها مصانع فيها.

يُرجّح اعتبار فيروس كورونا قوة القاهرة وبالتالي إحدى صور السبب الأجنبي، فلا يمكن أن يكون لأحد المتعاقدين يدٌ فيه، كما أنّه لم يكن ممكناً توقّعه ولا دفعه، كما أنّ تأثيره على قدرة المدين على الوفاء بالتزامه قد بلغ درجة أصبح معها التنفيذ مستحيلاً، ودرجت العادة على أن يوضع بند القوة القاهرة في بداية إبرام العقود مهما كان نوعها، خصوصاً التجارية الدولية منها.

يصعب تكهن مصير عقود التجارة الدولية في ظل جائحة فيروس كورونا، غير

(٨٩) Antoine Kassis, Problème de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international l'arbitrage Juridictionnel et l'arbitrage contractuel.L.G.D.I Paris 1987, P13.

(٩٠) نرجس البكوري، التحكيم كوسيلة لفض منازعات مفاوضات العقود الدولية، مجلة الحقوق، الناشر محمد أزيان، العدد ١٤، سنة ٢٠١٣، ص ٦٤.

(٩١) أوليادي موسى وقادري عبد الرزاق، المذكرة السابقة، ص ٧٤.

- أنَّ اعتباره قوة قاهرة يجعل تطبيق الحلول القانونية من توقيف العقود وإعادة التفاوض ضماناً للحقوق لكلا طرفي العقد، دون أن يتحمل أي طرف تبعات التعويض.
- وفي الأخير وجب إبداء الاقتراحات والتوصيات التالية:
- ينبغي على المتعاقدين الوصول إلى تفاهم يرضي الطرفين بشكل ودي بعيداً عن القضاء وإجراءات التقاضي بشكل يراعي الظروف الاقتصادية والصحية العالمية.
 - ينبغي على القضاء بمختلف أنواعه، التحرك لتكييف جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على أساس أنها حالة قوة قاهرة.
 - على الرغم من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، والعبرة بما اتفق عليه المتعاقدان، فإنَّه ينبغي على الدول أن تُكيّف تشريعاتها بما يتضمن تفصيلاً دقيقاً وواضحاً لإعمال نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، بما يُسهّل على المتعاقدين أكثر.
 - أزمة فيروس كورونا أثبتت أهمية التحول الرقمي في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة الإلكترونية؛ لذلك وجب تطوير هذا المجال للأفضل.
 - وجب التنسيق الدولي بشأن السياسات الاقتصادية بين الدول في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

المراجع

أ - المعاجم والقواميس:

- ابن منظور، لسان العرب المحيط، الجزء الثاني، أوفست تكنوبرس، بيروت، ١٩٨١.

ب - الكتب:

- أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ٢٠٠١.
- أبو العلا علي أبو العلا النمر، مفاوضات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ٢٠٠٢.
- أسامة أحمد شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، دار النهضة العربية، مصر، ٢٠٠٤.
- أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ١٩٩٦.
- خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة الجزائر، ٢٠١١.
- عبد الحكم فودة، أثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، ٢٠١٤.
- سعيد السيد علي، نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية والشرعية الإسلامية "دراسة مقارنة"، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ٢٠٠٧.
- عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ١٩٩٧.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية ١٩٩٨.
- عبد الرحمان عباد، أساس الالتزام العقدي، النظرية والتطبيقات، المكتب المصري، الإسكندرية، مصر. ١٩٨٢.
- عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٢.
- عدنان السرحان، نوري خاطر، شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصية)، دار الثقافة، عمان، الأردن، ٢٠٠٥.

- شريف محمد غنام، أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات، الطبعة الأولى، ٢٠١٠.
- محمد محي الدين إبراهيم سليم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإسلامي - دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، مصر، ٢٠١٠.
- محمد السناري، الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، د س ن.
- محمد الشحات الجندي، ضمان العقد أو المسؤولية العقدية في الشريعة الإسلامية مقارناً بالقانون المدني دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ١٩٩٠.
- محمد الزين، النظرية العامة للالتزام، الطبعة الثانية، دار قرطبة، تونس، ١٩٩٧.
- محمد حسن قاسم، القانون المدني، (المجلد الأول)، الالتزامات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ٢٠١٧.
- محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، د س ن.
- محمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، دار زهران، الأزهر، مصر، د س ن.
- محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات، دار الهدى، الجزائر طبعة ٢٠٠٤، الجزء الأول.
- هشام علي صادق، القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ١٩٩٥.
- يونس إسماعيل حسن، أحكام الفسخ في العقود الإدارية " دراسة مقارنة "، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ٢٠١٥.

ج - المقالات:

- الغزالي محمد محمد الحسن، التكييف الفقهي والقانوني لوقف العقود، مجلة النيل الأبيض للدراسات والبحوث، جامعة النيل الأبيض، العدد ١٢، سبتمبر ٢٠١٨، ص ١٩.
- بوغرة الصالح، انتشار فيروس كورونا سبب أجنبي لدفع المسؤولية بين تطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، حليات جامعة الجزائر ١،

المجلد ٣٤، العدد ٣ (عدد خاص- القانون وجائحة كوفيد ١٩)، جويلية ٢٠٢٠، ص ٣٢٤.

- خالد علي سليمان بني أحمد، الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة "دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، الأردن، المجلد ١، العدد ٢، ٢٠٠٦، ص ١٧١.
- محمد شتا أبو سعد، مفهوم القوة القاهرة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، المجلد ٧٤، العدد ٣٩٣-٣٩٤، سنة ١٩٨٣، ص ١٧٥.
- عبد السلام أحمد بني حمد، تحمل تبعة الهلاك قبل التسليم في عقد المقاولة في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي - دراسة مقارنة -، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد ٤٥، عدد ٣، ٢٠١٨، ص ١٦.
- علاء الدين عبد الله الخصاونة، الجوانب القانونية للالتزام بإعادة التفاوض ومراجعة العقود (دراسة في القانون الفرنسي والأردني ومبادئ القانون الموحد حول التجارة الدولية ومبادئ القانون الأوروبي للعقود) مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، المجلد ٣٨، العدد ١، سنة ٢٠١٤، ص ٦٣٦.
- عمار محسن كزار، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد، مجلة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد ٣٨، سنة ٢٠١٥، ص ٦.
- مصطفى عبد السيد الجارحي، فسخ العقد، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد ٥٦، ١٩٨٦، ص ١١٥.
- نرجس البكوري، التحكيم كوسيلة لفض منازعات مفاوضات العقود الدولية، مجلة الحقوق، الناشر محمد أزيان، العدد ١٤، سنة ٢٠١٣، ص ٦٤.

د - الرسائل والمذكرات:

- أوليادي موسى وقادري عبد الرزاق، أثر القوة القاهرة في العقود الدولية، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل ماستر أكاديمي تخصص عقود ومسؤولية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، الموسم الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٨.
- بلقاسم زهرة، أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود، مذكرة تخرج لنيل شهادة

- الماستر في القانون تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر ٢٠١٣-٢٠١٤.
- صفاء تقي عبد النور العيساوي، القوة القاهرة وأثرها في عقود التجارة الدولية (دراسة مقارنة) رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، العراق، ٢٠٠٥.
- عبد الهادي فهد علي الجفين، أثر القوة القاهرة على العقد في نطاق المسؤولية والرابطة العقدية ودور الإرادة في تعديل الأثر المترتب عليها - دراسة مقارنة - مذكرة الماجستير، جامعة الكويت، ١٩٩٨-١٩٩٩.
- عبد الوهاب الرومي، الاستحالة وأثرها في الالتزام العقدي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ١٩٩٩.
- منار عمر حامد الصدر، انفساخ العقد في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، قسم الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا، نابلس - فلسطين، ٢٠٠٣.

هـ - المواقع الإلكترونية:

- د. إبراهيم أخطاب، فيروس كورونا كوفيد- ١٩ بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، بحث منشور في الإنترنت، تم التصفح يوم ١٩/٥/٢٠٢٠ على الساعة ١٣:٠٢ على الموقع التالي: <https://bit.ly/2RcwJ6M>
- عبد الرحيم بحار، أثر وباء كورونا المستجد كوفيد ١٩ على الالتزامات التجارية، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا (مؤلف جماعي)، سلسلة إحياء علوم القانون، مجلة دولية علمية محكمة، الطبعة الأولى، ماي ٢٠٢٠، ص ٣٨٨. الرابط التالي: <https://www.marocdroit.com/attachment/1935327>
- الدكتور المحامي أيمن العواملة، القوة القاهرة وفيروس كورونا، التزامات الأطراف في ظل انتشار الكورونا واعتبارها (القوة القاهرة)، موقع عين نيوز، تاريخ النشر ٢٣/٣/٢٠٢٠، تاريخ التصفح يوم ٠٨/٥/٢٠٢٠ على الساعة ١٨:٢٢ مساء. <https://ainnews.net>
- ضحى مثنى داود، فسخ العقد في القانون المدني، بحث منشور، كلية الرافدين الجامعة، قسم القانون، ص ٣. الرابط: <https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35324>
- د. محمد رضا منصور بو حسين، معالجة الآثار القانونية لـ "كورونا" على العقود الدولية والمحلية، بحث منشور على شبكة الإنترنت يوم ١٧ مارس

٢٠٢٠، تم الاطلاع عليه يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ على الساعة ١٦:٣٠ على الرابط

التالي: <https://albiladpress.com/posts/633576.html>

- صالح مهدي كحيط العارضي، نور عقيل طاهر عبود الرحيمي، الالتزام بالأخطار في عقود التجارة الدولية، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية القانون تحت شعار "بناء دولة المؤسسات على أسس قانونية أداة فاعلة في محاربة الفساد والإرهاب"، كلية القانون، جامعة آل البيت، العراق، ٢٩ / ٤ / ٢٠١٧، ص ٤. تاريخ الاطلاع على البحث يوم ٩ / ١٠ / ٢٠٢٠ على الساعة ١٤:١٩ زوالاً، على رابط المداخلة التالي:

<https://abu.edu.iq/sites/default/files/conferences/law/13/170427-120643.pdf>

- الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية:

https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

- الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf

- الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: <https://www.iata.org>

- الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: <http://www.cc.gov.eg/Madany.aspx>

- الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية: <http://www.greffe.courdecassatio>

- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع فيينا ١٩٨٠. بالإمكان زيارتها على الرابط التالي:

<https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf>

- أحمد محمد الرفاعي، القانون المدني (العقود المدنية: البيع والايجار)، بحث منشور على الإنترنت، ص ١٦٤، الرابط التالي: <http://olc.bu.edu.eg/olc/images/311.pdf>

و - القوانين:

- القانون المدني الجزائري.

- القانون المدني الكويتي.

- القانون المدني الأردني لسنة ١٩٧٧.
- قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ المعدل.
- القانون المدني المصري.

ي - المراجع باللغة الأجنبية:

- Antoine Kassis «Problème de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international» Juridictionnel et l'arbitrage contractuel. L.G.D.I Paris 1987, P13.
- CARTIER-MARRAUD M- L. AKYUREK O, Crise économique et révision des contrats, Gazette du palais, 16 Juin 2009, n 167, p 2.
- Jean- Clauis Auloy, le droit de la consommation, 3 édition, Paris, 1992, p 159.
- Joseph Emmanued, note, sous, cass, 3 civ 24 avr. 2003, J.C.P, ed. G.2004, p 103.*/+ 96884516230.
- Marcel Fontaine Droit de contrats internationaux - Analyse et rédaction des clauses FEC 2ème édition 1989.
- Mousseron J-M, technique contractuelle, 2 édition, Francis Lefebvre, 1993, p 74.
- Olivier d' Auzon -Contrats commerciaux en français et en anglais: 40 modèles prêts à l'emploi. Cd-Rom offert, Broché - 1 juillet 2010, p 35.
- Serome. Kullmann: note sou, civ, 3, 13 decembre 1989, civ, 3. 28 mars, 1990, Dalloz, 1991, p 237.
- Les Principes D'UNIDROIT Relatifs aux Contrats du commerce International sur ce lien:
<http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2012/10/principes-unidroit-integralversionprinciples2010-f.pdf>
- Code Civil Français, Section 2, <http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf>

The impact of the Corona virus (COVID-19) pandemic On international trade contracts

Dr. Abdellatif Dahia

The principle of "The contract is the law of the parties" is, with no doubt, based on three foundations. The first foundation is legal based on the principle of "The authority of the will", the second is moral represented in the respect of the covenants and covenants, and the third is of a socio-economic nature translated into the necessity of the stability of transactions.

Since the newcomer (COVID-19) has had a great impact on various international trade transactions in all regions of the world, international trade contracts were not immune to this epidemic.

Therefore, this study discusses the issue of the legal characterization of this epidemic between being considered a force majeure or an emergency, as well as the fate of international trade contracts in light of the spread of this epidemic through the dissolution or suspension of these contracts and their impact, We concluded our study with a conclusion that included the results and recommendations.

مدى انطباق شروط القوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في إطار العقود المدنية دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي

الدكتور/ هيثم السيد أحمد عيسى
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
جمهورية مصر العربية

ملخص:

قد أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 على تنفيذ الالتزامات العقدية، بأن جعلتها مستحيلة التنفيذ في بعض الحالات، بسبب التدابير الحكومية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس أو الآثار الناتجة عن الإصابة به أو مخاطر العدوى أو العواقب الاقتصادية الناشئة عن انتشاره؛ الأمر الذي جعلنا نفكر في بحث موضوع مدى انطباق شروط القوة القاهرة على الآثار الناتجة عن تلك الجائحة، وذلك لكي نوضح الأساس القانوني الذي يمكن للمدين أن يستند عليه في نفي مسؤوليته العقدية التي قد تنشأ عن عدم تنفيذ العقد؛ وهو ما اقتضى منا تقسيم هذا البحث إلى أربعة مطالب؛ وضحنا في الأول مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً خارجياً، وبيننا في الثاني مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً لا يمكن توقعه، وأما الثالث فقد تناولنا فيه مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً لا يمكن مقاومته، وأخيراً قد وضحنا في الرابع مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.

الكلمات المفتاحية: جائحة فيروس كورونا، القوة القاهرة، الالتزامات العقدية، المسؤولية العقدية.

مقدمة:

فيروسات كورونا Coronavirus هي مجموعة من الفيروسات التي تسبب أمراضاً تصيب الجهاز التنفسي، تتراوح شدتها من نزلات البرد العادية إلى الأمراض شديدة الخطورة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" (MERS-CoV) الذي اكتشف عام ٢٠١٢م، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم "سارس" (SARS-CoV) الذي اكتشف عام ٢٠٠٣م؛ وفي ديسمبر عام ٢٠١٩م بدأ تفشي فيروس جديد من عائلة الفيروسات التاجية (كورونا) في مدينة ووهان الصينية، وقد أطلقت عليه اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات (ICTV) اسم فيروس كورونا ٢

المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (SARS-CoV-2)، وتم اختيار هذا الاسم له نظراً لارتباطه الجيني بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم "سارس"، وعُرف أيضاً المرض الذي يسببه هذا الفيروس المستجد باسم كوفيد-19 (Covid-19)، وهو مرض معد ينتقل عن طريق القطرات الصغيرة "الرزاز" المتناثرة من أنف أو فم الشخص المصاب عند العطس أو السعال أو الكلام، والتي يلتقطها شخص آخر بالتنفس، إذا كان على مسافة قريبة، أو بلمس الأسطح أو الأشياء التي تقع عليها تلك القطرات ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين بعد ذلك. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في تاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠م بأن تفشي فيروس كورونا المستجد Covid-19 يشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً *une urgence de sant publique de porte internationale (USPPI)*؛ ووفقاً للوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) يعني ذلك أن الفيروس أصبح حدثاً استثنائياً يشكل خطراً محتملاً يحدق بالصحة العمومية في الدول الأخرى، وذلك بسبب انتشار المرض دولياً مما قد يقتضي استجابة دولية منسقة. وفي تاريخ ١١ مارس ٢٠٢٠م أعلنت المنظمة بأن تفشي فيروس كورونا المستجد أصبح جائحة *Pandémie*، وتعني الأخيرة، وفقاً للمنظمة، تفشي مرض جديد ينتشر بسهولة من شخص لآخر في جميع أنحاء العالم. وهذا غير الوباء *Épidmie* الذي ينتشر بسرعة بين عدد كبير من البشر في منطقة معينة أو مجموعة سكانية معينة، مثال ذلك وباء "سارس" وباء "الإيبولا". ويختلف ذلك أيضاً عن المرض المستوطن *Endémie* الذي يتواجد بصورة دائمة في منطقة جغرافية معينة أو بين مجموعة محددة من السكان، مثال ذلك مرض "جدري الماء".

١ - موضوع البحث:

بعد أن تفشى فيروس كورونا المستجد مُسبباً أزمة صحية عالمية؛ بدأت الدول في إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار الفيروس ومكافحته، واختلقت الإجراءات التي اتخذت لاحتواء تفشي الفيروس ومواجهته، من دولة إلى أخرى، بحسب مدى انتشار الفيروس وخطورته في الدولة وتقدير الموقف من قبل الحكومة إزاء ذلك؛ فهناك دول فرضت حظراً عاماً؛ بحيث ألزمت المواطنين بعدم الخروج من المنازل ومنع التجوال إلا للضرورة أو فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الحيوية في الدولة، فضلاً عن تعطيل العديد من المرافق العامة وإغلاق عدد من المنشآت المختلفة، وهناك دول فرضت حظراً جزئياً؛ بحيث يتقيد المواطنون وأصحاب الأعمال بأوقات محددة، يسمح لهم بالخروج والحركة أو العمل خارج المنزل خلالها فقط، مع تعطيل بعض المرافق وإغلاق بعض المنشآت أو تخفيض عدد العاملين بها،

والمقصود من عرض ذلك بيان أن الأمر لم يكن على وتيرة واحدة في كل دول العالم، وإن كانت هناك تدابير مشتركة بين الدول كتعليق حركة الطيران وإغلاق المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية، إلا للضرورة كإجلاء بعض العالقين ومساعدة الدول الأخرى، وكذلك القيام بعمليات استيراد وتصدير السلع والبضائع المختلفة وما يرتبط بها في حدود ما قدرته الدولة لمواجهة الأزمة، لأن هناك بعض الدول أوقفت تصدير بعض السلع، كما في مصر؛ فقد منعت تصدير بعض البقوليات، ومن الإجراءات المشتركة أيضاً بين الدول حظر التجمعات، كحضور جماهير كرة القدم أو إقامة المؤتمرات والحفلات ودخول الملاهي ودور السينما وخلافه، بالإضافة إلى اتباع إجراءات الحجر الصحي quarantaine بشأن المشتبه في إصابتهم أو الأشياء المشتبه في تلوثها، واتباع إجراءات العزل Isolement بشأن الأشخاص المصابة أو الأشياء الملوثة.

وقد كان لتلك التدابير والإجراءات والقرارات المختلفة أثر كبير على حياة الأفراد بمختلف صورها، وكذلك أنشطة الشركات والأشخاص الاعتبارية بوجه عام، وانعكس ذلك بجلاء في قدرتهم على تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تقع على كاهلهم؛ وأصبح هناك تساؤل يتعلق بالحالات التي يستحيل على المدين فيها تنفيذ التزامه، حول السند القانوني الذي يستطيع الاحتجاج به لنفي مسؤوليته العقدية التي قد تنشأ عن ذلك في ظل مبدأ القوة الملزمة للعقد la force obligatoire du contrat؛ وهو السبب الذي دفعنا إلى البحث عن مساحة لا يتعارض فيها المبدأ الأخير مع قاعدة أنه لا التزام بمستحيل A l'impossible nul n'est tenu، ويتمثل ذلك في نظرية القوة القاهرة Force majeure لأنها جاءت لتواجه الأحداث التي تطرأ بعد إبرام العقد وتجعل تنفيذ الالتزام أمراً مستحيلاً على المدين، بغية تحقيق العدالة التعاقدية بين الطرفين في النهاية؛ ولذا يتحدد موضوع دراستنا في بحث مدى انطباق شروط تلك النظرية على جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19.

والحقيقة أن المشرع المصري لم يضع تعريفاً للقوة القاهرة؛ بيد أن محكمة النقض المصرية (الدوائر المدنية) قضت في الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٤١ قضائية، جلسة ١٩٧٦/١/٢٩م، بأن "القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥ من القانون المدني تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون أمراً إدارياً واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع، وينقضي بها التزام المدين من المسؤولية العقدية، وتنتفي بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسؤولية التقصيرية، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين".

وفي المقابل قد وضع المشرع الفرنسي تعريفاً لها في المادة ١٢١٨ من القانون المدني، والتي أُضيفت بمقتضى القانون رقم ١٣١-٢٠١٦ بشأن إصلاح قانون العقود والنظرية العامة للالتزامات والإثبات، والذي صدر في ١٠ فبراير ٢٠١٦م ودخل حيز النفاذ في ١ أكتوبر من العام نفسه؛ حيث نصت على أنه: "تتحقق القوة القاهرة في المسائل التعاقدية عند وقوع حادثة خارجة عن سيطرة المدين، لم يكن من الممكن توقعها بشكل معقول وقت إبرام العقد، ولا يمكن تجنب آثارها باتخاذ إجراءات مناسبة، وتحول دون قيام المدين بتنفيذ التزامه. وكانت قد قضت أيضاً محكمة النقض الفرنسية (الدائرة الاجتماعية) في تاريخ ١٢ فبراير عام ٢٠٠٣م، (N de pourvoi: 00-46.660) بأن: "القوة القاهرة التي تسمح بإعفاء صاحب العمل من كل أو بعض التزاماته الناشئة عن الإخلال بعقد العمل تعني وقوع حدث خارجي لا يمكن مقاومته يجعل من المستحيل الاستمرار في العقد المذكور".

ونستطيع القول وفقاً للتعريفات السابقة بأن هناك أربعة شروط يجب توافرها في الحادث لكي يوصف بأنه قوة قاهرة، وهي وجوب أن يكون حادثاً خارجياً، ليس في الإمكان توقعه، كما لا يمكن مقاومته، وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.

٢ - إشكالية البحث:

قد اتضح من السطور السابقة أن فيروس كورونا Covid-19 هو فيروس جديد، وهذا يعني، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أن الكثير عنه مازال مجهولاً، بالإضافة إلى أنه مازال ينتشر ولم ينته بعد، وهناك آثار مختلفة تنجم عنه يمكن أن تسبب استحالة تنفيذ الالتزام، ويتطلب الحكم بوصف أي منها بالقوة القاهرة أن يتم تطبيق شروط تحققها عليه أولاً لبيان مدى استجابته لها، وهذا يقتضي الإلمام بخصوصية كل أثر لتقييم المسألة، وفي الوقت نفسه ينبغي أن يتم ذلك من خلال معيار واحد ينطبق على كافة الحالات ويعكس التوقعات المعقولة للمتعاقدين؛ فلا يصح في ظل عدم وضوح هذا الفيروس وبجدة عدم اليقين الذي يرتبط به أن يتم تطبيق نظرية القوة القاهرة عليه كما لو كان حدثاً عادياً نستجلي حقيقته بالقياس على أحداث أخرى لا تتشابه معه، أو نضحي بتطبيق النظرية كلية، أو نخرجها من دائرة توقعات المتعاقدين بحيث ينذر تطبيقها على واقع تلك الجائحة.

٣ - أهمية البحث:

يسهم هذا البحث في بيان كيفية إعمال نظرية القوة القاهرة فيما يتعلق بالآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تجعل من تنفيذ العقد أمراً مستحيلاً؛ وهذا يعني أننا نحاول من خلاله تقديم حلول قانونية للإشكاليات المتعلقة

بخصوصيات تفشي الأوبئة أو الجوائح عند انطباق شروط تحقق القوة القاهرة عليها، وعلى وجه الخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يمثله ذلك من رفع المعاناة عن المدين حيال ظروف تخرج عن إرادته، ويمكن أن تقترب عليها مسؤوليته التعاقدية.

٤ - صعوبات البحث:

تتمثل صعوبات هذا البحث في حداثة الموضوع؛ فالدراسات المتعمقة التي تناولته قليلة بالنظر إلى حجم الأزمة الصحية التي يمر بها العالم الآن، وما ترتب عليها من عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية في بعض الحالات، بالإضافة إلى أن الدراسات التي أُجريت بخصوص أوبئة أو جوائح سابقة والتي يمكن الاهتداء بها عند إجراء دراسة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، قليلة أيضاً، كما أن عدم اختفاء الفيروس حتى كتابة هذه السطور يفضي إلى عدم اليقين حول الآثار التي قد تنتج عنه في المستقبل وانعكاساتها على تنفيذ العقود المدنية، ويسهم في ذلك عدم وجود لقاح أو علاج لمواجهة، وبالتالي فإن الموضوع في كثير من جوانبه مازال يكتنفه الغموض، وهو ما يمثل صعوبة في تناوله والحكم على المسائل المختلفة التي يثيرها.

٥ - المنهج العلمي:

سنقوم في هذا البحث باتباع المنهج التحليلي التأصيلي لكي نستطيع سبر أغوار الآثار الناجمة عن الفيروس وبيان طبيعتها وتطبيق شروط تحقق القوة القاهرة عليها لبيان مدى استجابتها لها، كما أننا سنعتمد أيضاً على المنهج المقارن وذلك عن طريق تطبيق تلك الشروط وفقاً للقانونين المصري والفرنسي، وسنركز على التطبيقات القضائية التي نظرت أمام القضاء الفرنسي فيما يتعلق بموضوع البحث.

٦ - خطة البحث:

سنقوم بمحاولة تقديم الحل القانوني لإشكالية البحث السابق بيانها والتغلب على صعوباته من خلال تطبيق شروط تحقق القوة القاهرة التي ذكرناها أعلاه على جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19؛ ولذا سنقسم هذا البحث إلى أربعة مطالب كالتالي:

المطلب الأول: مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً خارجياً

المطلب الثاني: مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً لا يمكن توقعه

المطلب الثالث: مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً لا يمكن مقاومته

المطلب الرابع: مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً

المطلب الأول

مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً خارجياً

Un événement extérieur

ينبغي أن يكون الحادث المُشكل للقوة القاهرة مستقلاً عن إرادة المدين؛ أي ألا يكون للمدين دخل في وقوعه^(١). وقد أكدت محكمة النقض المصرية على ذلك؛ حيث قضت بأنه: "لما كان إشهار إفلاس شركة الطاعنين والمطعون ضده الأول والتحفظ على أموال الشركاء فيها كان مرجعه تعثرها وامتناعها عن سداد ديونها التجارية وهو أمر راجع إليها ومتوقع الحدوث في مثل هذه الظروف، ومن ثم فلا يمكن اعتبار ذلك من قبيل القوة القاهرة.."^(٢).

وقد ظهر هذا الشرط جلياً أيضاً في أول حكم قضائي في فرنسا يتناول تطبيق القوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعترف بأن مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد تعد قوة قاهرة، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف كولمار في تاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠م، في قضية تتعلق بحقوق الأجانب، لم يتمكن فيها المستأنف من حضور جلسة المحكمة، نظراً للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، في مركز الاحتجاز الإداري (CRA)، والذي يحتجز فيه، وقد قضت المحكمة بأن هذه الظروف الاستثنائية *circonstances exceptionnelles* التي أدت إلى غياب السيد AX في جلسة اليوم، تأخذ طابع القوة القاهرة *force majeure*، كونها خارجية، لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن مقاومتها، بالنظر إلى المهلة الزمنية المحددة للحكم، وحقيقة أنه من غير الممكن في هذه المدة التأكد من عدم وجود خطر العدوى،

(١) انظر هذا المعنى لدى:

Roger Masamba Makela, "L'IMPOSSIBLE ET LE CONTRAT", (2015): 9.

http://www.daldewolf.com/documents/document/2015122111503247_52_roger_masamba__1_x27_impossible_et_le_contrat__fvl__09_02_14.pdf. (15/3/2020);

Jean VAN ZUYLEN, "La force majeure en matière contractuelle: unconcept unifié? Réflexions à partir des droits belge, français et hollandaise", *Revue Générale de Droit Civil Belge - Kluwer, TBBR/RGDC* (2013): 416.

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A124936/datastream/PDF_01/view. (15/3/2020); Sandra DUMOND, *LA DATE ET LE CONTRAT*, (Thèse de doctorat, Université Lyon III, FACULTE DE DROIT, 2003), 112.

<http://www.theses.fr/2003LYO33035>. (15/3/2020).

(٢) نقض تجاري، طعن رقم ٢٠١٣٣ لسنة ٧٧ قضائية، جلسة ٢٧/٤/٢٠١٠.

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111263005&&ja=83999. (16/3/2020).

والحصول على حراسة موكل بها أخذ السيد Ax إلى جلسة الاستماع، بالإضافة إلى أن مركز الاحتجاز الإداري CRA أشار إلى أنه لم يكن لديه المعدات اللازمة لسماع السيد AX عبر الفيديو كونفرانس Visio conference، مما يعني أن مثل هذا الحل غير ممكن أيضاً^(٣). وقد أكدت محكمة استئناف كولمار موقفها السابق في أحكام صدرت في قضايا أخرى، في تاريخ ١٦، ٢٣ مارس ٢٠٢٠، والتي اعتبرت فيها أيضاً الظروف الاستثنائية الناشئة عن فيروس كورونا قوة قاهرة تبرر الغياب عن الجلسات، وتتمثل بصفة أساسية في مخاطر نقل العدوى إلى الغير، وعلى وجه الخصوص الموظفين المطلوبين لضمان عقد الجلسة، والتي تبرهن عليها تدابير الاحتواء التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي الفيروس^(٤).

وقضت أيضاً محكمة استئناف بواتييه في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٢ بأن حجز البضائع، الأقفلة، المستوردة في الجمارك بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وقت انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، لا يشكل قوة قاهرة أو سبباً لإعفاء المدين من التعويض عن عدم التسليم أو التسليم المتأخر، ذلك أنه كان يجب عليه اختيار مورد موثوق به والتحقق من أن الأقفلة سيتم تصنيعها وفقاً للمعايير المعلن عنها^(٥). وهذا يعني أن المحكمة رأت أن حجز الأقفلة المستوردة كان بسبب خطأ المدين ذاته.

(٣) CA Colmar, ch. 6 (étrangers), 12 mars 2020, n° 20/01098..(28/3/2020); <https://www.doctrine.fr/d/CA/Colmar/2020/C8A8F3A305EEEBB31F249> .(28/3/2020);

وانظر أيضاً:

Sophie Latieule, "COVID-19 ET LOCATIONS MEUBLÉES TOURISTIQUES: LES CONDITIONS D'ANNULATION? L'PREUVE DE LA FORCE MAJEURE", Fidal (7/4/ 2020)..(15/4/2020); Séverine Tavenec, "Contrats et covid-19: quid de la force majeure?", Le petit jurist (3/4/ 2020)..(15/4/2020). <https://www.fidal.com/fr/actualites/covid-19-et-locations-meublees-touristiques-les-conditions-dannulation-lepreuve-de-la> .(15/4/2020); SÖverine Tavenec, "Contrats et covid-19 : quid de la force majeure ?", Le petit jurist (3/4/2020). <https://www.lepetitjuriste.fr/contrats-et-covid-19-quid-de-la-force-majeure/> .(15/4/2020).

(٤) CA Colmar, ch. 6, 16 mars 2020, n 20/01142 et 20/01143; CA Colmar, ch. 6, 23 mars 2020, n 20/01206 et 20/01207 ; Olivier Nicolas, "Coronavirus : Peut-on invoquer la Force Majeure ?", echos (6 avril 2020). <https://echos-judiciaires.com/actualite/tribune-coronavirus-force-majeure/> .(27/3/2020).

(٥) CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2012, n 11/02200. <https://www.doctrine.fr/d/CA/Poitiers/2012/BE28434296C65B106A64F> .(1/4/2020).

وقد بينت المواد ١٦٥، ٢١٥، ٣٧٣ مدني مصري ذلك؛ حيث إن المسؤولية المدنية تنتفي وفقاً للمادتين ١٦٥، ٢١٥ إذا نشأ الضرر عن سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وتعد القوة القاهرة، أول مظاهر السبب الأجنبي، كما هو معروف في القواعد العامة ووفقاً لنص المادة ١٦٥^(٦)، وينقضي الالتزام وفقاً للمادة ٣٧٣ إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه^(٧).

وقد اتضح أيضاً من نص المادة ١٢١٨ مدني فرنسي المبينة في السابق أن من بين خصائص الواقعة التي تشكل القوة القاهرة أنها خارجة عن سيطرة المدين^(٨).

والحقيقة أنه إذا كان وجود فيروس كورونا المستجد هو أمر مستقل عن إرادة المدين بالفعل، إلا أن الإصابة به أو نشر العدوى التي قد تتسبب في استحالة تنفيذ العقد، من الممكن أن تنتج عن خطأ المدين المتمثل في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تحول دون انتقال الفيروس، أو عدم الالتزام بتدابير مكافحة الفيروس التي أعلنتها الحكومة، ولا يصح الاحتجاج هنا بأن حالة القوة القاهرة تتمثل في المرض؛ ذلك أن المرض لكي يصل إلى مرتبة القوة القاهرة ينبغي أن يتوافر فيه شروط تحققها المعروفة، وهذا هو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أكثر من مناسبة^(٩).

(٦) محمد شتا أبو سعد، "مفهوم القوة القاهرة"، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ٧٨، عدد ٣٩٣، ٣٩٤ (١٩٨٣)؛ ١٧٨، ١٧٩؛ وتنص المادة ١٦٥ على أنه: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك". كما تنص المادة ٢١٥ على أنه: "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".

(٧) تنص المادة ٣٧٣ مدني مصري على أنه: "ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه".

(٨) Luc Grynbaum, "Force majeure et Épidémie de COVID-19", de gaulle fleurance & Associés (24/03/2020). www.degaulleflurance.com/force-majeure-et-epidemie-de-covid-19/. (28/3/2020);

Alexandre NIVERT, "Entre COVID-19 et droit commun des contrats : la notion de force majeure", DOCTRIN'ACTU (23/3/2020). <https://www.doctrinactu.fr/post/entre-covid-19-et-droit-commun-des-contrats-la-notion-de-force-majeure>. (28/3/2020).

(٩) Cass. 1ère civ. 10 février 1998. N° de pourvoi: 96-13316. Bulletin 1998 I N° 53 p. 34; 1ère civ., 6 novembre 2002. N° de pourvoi: 99-21203. Bulletin 2002 I N° 258 p. 201; Cass. 3ème civ. 22 janvier 2014. N° de pourvoi: 12-28246. Bulletin =

كما أنه إذا سلمنا بأن القرارات أو التدابير الحكومية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، والتي تجعل عملية تنفيذ العقد مستحيلة، هي أمر مستقل عن إرادة المدين؛ وبالتالي تشكل قوة القاهرة تنفي مسؤوليته^(١٠)؛ حيث قضت محكمة استئناف باريس، في هذا الشأن، بأن قرار حظر تصدير الماشية لمنع تفشي وباء اللسان الأزرق يعد قوة القاهرة^(١١)، إلا أنه مع ذلك هناك احتمال أن يستدعي المدين بخطئه التدابير أو القرارات الحكومية التي أعجزته عن تنفيذ التزامه، مثال ذلك ما حدث في القضية التي عرضت على محكمة استئناف بواتييه، والتي تناولناها أعلاه، والتي احتج فيها المدين بالقوة القاهرة الناتجة عن حجز البضائع في الجمارك، وقد تبين أن ذلك يرجع إلى خطئه كما وضحنا من قبل. وهناك أمثلة عديدة على خطأ المدين في هذا السياق، ومن ذلك أن يكون المدين صاحب مصنع لم يلتزم بالاحتياطات الصحية للوقاية من الفيروس مما أدى إلى انتشاره بين العمال، واتخاذ قرار بإغلاق المصنع وعزل المصابين وتعطل عملية الإنتاج. كما أنه ينبغي مراعاة شروط تطبيق هذه القرارات، فقد يكون تطبيق مثل هذه القرارات يمنح مساحة معقولة للمدين تسمح له بتنفيذ العقد لكنه مع ذلك يتقاعس ويمتنع عن ذلك؛ وبالتالي ينبغي أن يكون تطبيق القرار الحكومي يجعل من المستحيل تنفيذ العقد كما ذكرنا.

وتصلح أيضاً العواقب الاقتصادية الناتجة عن الفيروس، والتي تجعل تنفيذ المدين لالتزامه أمراً مستحيلاً، كقوة القاهرة يمكن الاحتجاج بها؛ وهذا هو ما قضت به محكمة استئناف بوج Bourges بشأن فيروس اللسان الأزرق الذي يصيب الماشية؛ فقد اعتبرت العواقب الاقتصادية الناتجة عنه، على نشاط المدين حدثاً لا يمكن مقاومته يبرر تخلفه عن سداد الدين، على أساس أنها قوة القاهرة^(١٢). وعلى

= 2014, III, n° 6; Cass. 3ème civ. 19 septembre 2019. N° de pourvoi: 18-18921. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURI-TEXT000039157072>. (28/3/2020).

Clément Allais, et.al, "Impacts du Covid-19 en droit administratif, droits de l'homme, droit du travail, droit des contrats et droit penal", NAVACELLE (2020): 19. <http://navacellelaw.com/wpcontent/uploads/NavacelleSynthesedes-consequencesduCovid-19.pdf>. (28/3/2020).

CA Paris, ple 5 - ch. 4, 26 sept. 2018, n 15/09123. <https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2018/C00ED894B03741A280996>. (15/4/2020).

CA Bourges, ch. soc., 21 mai 2010, n 09/01290. <https://www.doctrine.fr/d/CA/Bourges/2010/BF16893DA1B54B44C9576>. (15/4/2020).

CA Bourges, ch. soc., 21 mai 2010, n° 09/01290. <https://www.doctrine.fr/d/CA/Bourges/2010/BF16893DA1B54B44C9576>. (15/4/2020).

الرغم من ذلك إذا كان المدين هو من أحدث تلك العواقب أو كان سبباً في تفاقمها فإنه لا يجوز هنا الاحتجاج بها كقوة القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه من الممكن أن يكون المدين قد تأخر عن تنفيذ العقد حتى ظهر الفيروس وانتشر في أنحاء البلاد فأصبح تنفيذ العقد أمراً مستحيلاً، هنا لا يحق له الاحتجاج بالقوة القاهرة؛ ذلك أن ميعاد تنفيذ العقد كان قد حل قبل ظهور الفيروس؛ وقضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بوجه عام بأنه "تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعه عدم تنفيذه، ويشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام، فإذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة، فإنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعه عدم تنفيذ التزامه أو التأخير فيه^(١٣).

ويمكن أيضاً أن يكون خطر الإصابة بالعدوى قوة القاهرة؛ وقد رأينا ذلك في أحكام محكمة استئناف كولمار التي أشرنا إليها من قبل، إلا أنه يجب توافر شروط تحقق القوة القاهرة في هذا الشأن، ومن بينها ألا يكون للمدين يد في ذلك.

وجملة القول أنه ينبغي مراعاة أن هذا الشرط لا يتحقق بصورة تلقائية في كل الحالات التي تتعلق بعدم تنفيذ العقد والتي يزعم فيها المدين بأنها ناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وإنما يجب دراسة كل حالة على حدة بحسب طبيعتها والظروف والملابسات المحيطة بها.

= وانظر أيضاً:

JOAN DRAY, "L'épidémie de coronavirus constitue -il un événement de force majeure?", legavox blog (26/3/2020).

<https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/epidemie-coronavirus-constitue-evenement-force-28444.htm> .(15/4/2020).

(١٣) نقض مدني، طعن رقم ٤٤٤ لسنة ٤٤، جلسة ٢٧/١١/١٩٧٨م، مكتب فني، س٢٩، ص ١٧٦٦.

المطلب الثاني

مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً لا يمكن توقعه

Un évènement imprévisible

يجب أن يكون الحادث الذي يشكل القوة القاهرة غير ممكن التوقع، وتنفي عنه هذه الصفة إذا كان من الممكن توقعه حتى لو كان من المستحيل دفعه^(١٤). وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأن: "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة القاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور، بل يكفي لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله، ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر؛ لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً، فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي"^(١٥). ويتضح من ذلك أن معيار عدم إمكان التوقع هنا هو معيار موضوعي لا ذاتي، كما أنه لا يُكتفى فيه بالرجوع إلى الشخص العادي ولكن الشخص شديد اليقظة والتبصر؛ فعدم إمكان التوقع ينبغي أن يكون مطلقاً وليس نسبياً^(١٦).

(١٤) عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام (بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي، ١٩٧٠)، ٨٧٨؛ مروان يوسف، "مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيروس كورونا -كوفيد ١٩- بين اعتباره قوة القاهرة أم ظرفاً طارئاً"، سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠): ٣١٧؛ محمد الأيوبي، "المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس "كورونا كوفيد ١٩" سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠): ٢٩٠، ٢٩١؛ أمينة رضوان والمصطفى الفوركي، "تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية"، سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠): ٢٧٥؛ محمد الخضراوي، "الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد على الالتزامات التعاقدية"، سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠): ٢٧١؛ عبد الرحيم بحار، "أثر وباء كورونا المستجد كوفيد ١٩ على الالتزامات التجارية"، سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠): ٣٨٧.

(١٥) نقض مدني، طعن رقم ٧٧ لسنة ٧٢، جلسة ٢٨/١١/٢٠٠٢، مكتب فني، س ٥٣، ص ١١٢٩.

(١٦) السنهوري، الوسيط، ٨٧٨؛ سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام (الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، ٢٠٠٩)، ٢٥٢؛ عز الدين الدناصري وعبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء (الإسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٤)، ٢٢٥؛ محمد كامل موسي، شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، الالتزامات (القاهرة: المطبعة العالمية، ١٩٥٥)، ١٢٨؛ رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام (الإسكندرية: دار المطبوعات =

وما سبق ذكره حول معيار عدم القدرة على توقع الحادث، يختلف عما نصت عليه المادة ١٢١٨ من القانون المدني الفرنسي في تعريفها للقوة القاهرة؛ حيث نصت المادة المذكورة على أنه: "تتحقق القوة القاهرة في المسائل التعاقدية عند وقوع حادثة خارجة عن سيطرة المدين، لم يكن من الممكن توقعها بشكل معقول *raisonnablement* وقت إبرام العقد.."; وهذا يعني أن عدم القدرة على توقع الحدث هو أمر نسبي وليس مطلقاً. وقد قنن المشرع الفرنسي ما كان قد توصل إليه الفقه والقضاء في فرنسا فيما يتعلق بهذا الشأن؛ حيث يرى الفقه بأن عدم القدرة على التوقع يقاس بالرجوع إلى معيار المتعاقد المتبصر *un contractant prudent*، وهو شخص عادي *un homme de type moyen* يتسم بالحرص والحذر، مع مراعاة المكان والزمان والظروف والملابسة للحادث^(١٧)، وهناك العديد من الأحكام القضائية تؤيد ذلك^(١٨).

ونميل إلى أنه ليس هناك خطر لا يمكن توقع حدوثه على الإطلاق؛ وإذا اشترطنا

= (الجامعية، ٢٠٠٢)، ٣٧٠؛ نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٤)، ٤٥٧؛ أبو سعد، مفهوم القوة القاهرة، ١٨٠؛ محمد عزمي البكري، دعوى التعويض (القاهرة: دار محمود للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧)، ٨٥؛ انظر أيضاً في هذا الشأن أحكام محكمة النقض المصرية التالية:

نقض مدني، طعن رقم ٦٧٧ لسنة ٦٩ ق، جلسة ٢٠١٢/٤/١٠، مكتب فني، س ٦٣، ص ٥٨٩؛ نقض مدني، طعن رقم ١٩٠ لسنة ٣٤ قضائية، جلسة ١٩٦٨/١٢/١٩، مكتب فني، س ١٩، ص ١٥٥١؛ نقض مدني، طعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية، جلسة ٢٠١٨/٤/١٦، الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية، عبر هذا الرابط:

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111379381&&ja=225800. (30/3/2020).

نقض تجاري، طعن رقم ٧٧ لسنة ٧٢ قضائية، جلسة ٢٠٢٠/١١/٢٨، مكتب فني، س ٥٣، ص ١١٢٩.

(١٧) Marie-France STEINLE-FEUEBACH et, al, INONDATIONS: RESPONSABILITES ET FORCE MAJEURE (Colmar, France: Université de Haute-Alsace, 2002), 25, 26; DUMOND, LA DATE ET LE CONTRAT, 111; Assia TOUAHRI, La responsabilité civile du fait du dommage nucléaire civil (thèse de doctorat, UNIVERSITE DE LIMOGES, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 2018), 52; François Chabas, "La force majeure", Dalloz, n° 13(septembre 2002): 4, 26.

(١٨) Cass. 2ème Civ. 22 novembre 1978. N° de pourvoi: 77-12767. Bulletin. N. 243 P. 187; cass.3ème Civ. 24 mars 1993. N° de pourvoi: 91-13541. Bulletin 1993 III N° 46 p. 30; cass.1ère Civ.18 mai 1989. N° de pourvoi: 87-16051. Bulletin 1989 I N° 205 p. 137; Cass., 2e civ., 6 juillet 1960. Bulletin. N. 439; Cass.2ème Civ. 5 octobre 1961, Bull. n° 636; Cass. 2ème Civ. 23 octobre 1963. Bull. n°659; Cass. 2ème Civ. 30 novembre 1972, Bull. n° 307.

ألا يكون الحادث متوقعاً على الإطلاق، فإن هذا يعني أنه من الصعوبة بمكان تحقق القوة القاهرة في الواقع؛ فكما يقول أندريه تونك Andr TUNC عن حركة المرور على الطرق: "لا يوجد شيء لا يمكن توقعه على الإطلاق. المخاطر موجودة في كل مكان بنسبة معينة. عندما نقول أن تصرف الغير كان غير متوقع، فإننا نعني أننا لم يكن علينا توقع ذلك، أو بشكل أدق، حتى لو كان بإمكاننا توقع ذلك، فإن فرص حدوثه كانت منخفضة جداً لدرجة أننا تجاهلناه"^(١٩).

ولذا فإننا نرى أن عدم القدرة على التوقع هو أمر نسبي في هذه الحالة، وينبغي أن نرجع فيه إلى معيار الشخص المعتاد لتحديد وقياسه، وليس إلى معيار الشخص الأشد يقظة وحرصاً، مع مراعاة المكان والزمان والظروف والملابسة المحيطة بالحادث.

والجدير بالذكر أيضاً أن الوقت المعتبر فيما يتعلق بعدم القدرة على توقع وقوع الحادث، هو وقت التعاقد، وهذا على خلاف الحال إذا كان الادعاء بالقوة القاهرة من أجل نفي المسؤولية التقصيرية، فالوقت المعتبر هنا هو وقت وقوع الحادث^(٢٠).

وإذا حاولنا تطبيق شرط عدم التمكن من توقع الحادث وقت التعاقد، على جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الأمر يثير تساؤلين، الأول: هل وجود أوبئة أو جوائح سابقة يجعل فيروس كورونا المستجد من الأمور التي كان يمكن توقعها من جانب المدين، وماذا لو كان الفيروس السابق مشابهاً لفيروس كورونا المستجد، وهل تكرر انتشار الفيروس نفسه يجعله أمراً متوقعاً أيضاً؟ والثاني: ما هو الوقت المعتبر في اعتبار فيروس كورونا المستجد أمراً متوقعاً؟

وبالنسبة للتساؤل الأول فإن وجود أوبئة أو جوائح سابقة لا يعني أنه كان على المدين توقع ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره^(٢١)؛ ذلك أن الفيروسات تختلف

(١٩) André Tunc, "Force majeure et absence de faute en matière délictuelle", RTD Civ (1946): 187.

(٢٠) STEINLE-FEUERBACH et, al, INONDATIONS: RESPONSABILITES ET FORCE MAJEURE, 45; TOUAHRI, La responsabilité civile, 53;

وراجع أيضاً: السنهوري، الوسيط، ٨٧٨؛ أبو سعد، "مفهوم القوة القاهرة"، ١٨١؛

وراجع أحكام القضاء الفرنسي:

cass.1ère Civ.18 mai 1989. N° de pourvoi: 87-16051. Bulletin 1989 I N° 205. 137;

cass., 1ère Civ. 4 février 1997, N° de pourvoi: 94-22-203.

(٢١) Xavier Azaÿs, CORONAVIRUS (COVID-19) : FAUT-IL PRÉFÉRER L'IMPRÉVISION ? LA FORCE MAJEURE ?, village de la justice (19 MARS 2020). <https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-covid-faut-preferer-imprevision-force-majeure,34184.html>. (30/3/2020).

فيما بينها من حيث مخاطرها وطرق مكافحتها وتأثيرها بوجه عام على حياة الإنسان، كما لا يمكن تحديد وقت ظهورها واختفائها بصورة دقيقة مسبقاً^(٢٢). ولا ينفي ذلك وجود تشابه بين كورونا المستجد (SARS-CoV-2) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم "سارس" (SARS-CoV) الذي انتشر في ٢٠٠٣؛ فعلى الرغم من أن هناك ارتباطاً جينياً بين الفيروسين إلا أن هناك أيضاً اختلافاً بينهما؛ فالأول أقل فتكاً من الثاني لكنه أكثر عدوى منه^(٢٣)، فضلاً عن أن سارس لم يعلن كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية مثلما حدث بشأن كورونا المستجد.

أما مسألة تكرار ظهور الفيروس وهل يعني ظهور فيروس معين في السابق أن يكون على المدين توقع ظهوره في المستقبل؛ بحيث إذا ظهر مجدداً لا يكون من حق المدين الاحتجاج به كقوة القاهرة لنفي مسؤوليته التعاقدية؛ فقد قضت محكمة استئناف نانسي في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠ بأن فيروس حمى الضنك لا يملك خصائص القوة القاهرة؛ لأنه مرض مستوطن Endémie في جزيرة مارتينيك Martinique، أي أنه يتكرر في هذه المنطقة، وبالتالي يمكن توقعه، كما أنه يمكن مقاومته بالوسائل المتاحة^(٢٤).

وقضت أيضاً محكمة استئناف باسي تيري Basse Terre في ١٧ ديسمبر ٢٠١٨، بأن فيروس الشيكونغونيا chikungunya لا يمكن اعتباره غير متوقع أو لا يمكن مقاومته؛ ذلك أنه من الأمراض المعروفة في المنطقة ويمكن علاجه بالأدوية^(٢٥).

(٢٢) راجع هذا المعنى لدى: منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي للشرق الأوسط)، أسئلة وأجوبة حول فيروس كورونا المستجد، من خلال هذا الرابط:

<http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html>. (30/3/2020).

(٢٣) راجع: منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩): أسئلة وأجوبة، من خلال هذا الرابط:

<https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>. (30/3/2020).

CA Nancy, 1re ch., 22 nov. 2010, n° 09/00003..

(٢٤) <https://www.doctrine.fr/d/CA/Nancy/2010/B81811A63DBC13171C555>. (15/4/2020).

وانظر أيضاً:

Pascale Guimard, "La grippe, les ÔpidÔmies et la force majeure en dix arrêts", dalloz (4/3/2020). https://www.dalloz-actualite.fr/flash/grippe-epidemies-et-force-majeure-en-dix-arrets#.Xs_uwzozbIU. (15/4/2020).

(٢٥) CA Basse-Terre, 1re ch., 17 dÔc. 2018, n 17/00739. <https://www.doctrine.fr/d/CA/Basse-Terre/2018/C7C3F833356E1904494E4>. (15/4/2020).

وانظر أيضاً:

ومع ذلك قضت محكمة أستاناف أيكس أون بروفانس Aix en Provence في ٣ مايو ٢٠٠٦، بعدم مسؤولية كل من صاحب فندق ووكالة سفر عن إغلاق نادي الطفل وإصابة اثنين من العملاء بفيروس التهاب المعدة والأمعاء la gastroentrite، تأسيساً على القوة القاهرة؛ لأنه لم يكن في إمكانهما توقع نطاق هذا الفيروس، على الرغم من أنه عدوى شائعة^(٢٦).

والحقيقة أنه كما هو معروف أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-١٩ هو فيروس مستجد لم يكن معروفاً قبل انتشاره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر ٢٠١٩، وفقاً لما بينته منظمة الصحة العالمية^(٢٧)؛ وبالتالي دراسة مسألة تكرار الفيروس ومدى تأثيرها على تحقق شرط عدم التوقع، المتطلب لقيام القوة القاهرة، ليست لها أهمية الآن، لكنها مفيدة من ناحيتين، الأولى: إذا ما تكرر انتشار فيروس كورونا المستجد في المستقبل مرة أخرى. وأما الثانية: فهي لمعرفة مدى تحقق شرط عدم التوقع بخصوص الفيروسات الأخرى التي تكرر انتشارها. وفي كلتا الحالتين فإننا نرى أنه لا يمنع تكرار الفيروس من الاحتجاج به كقوة القاهرة إذا وصل إلى نطاق أو شدة لم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد، وكذلك أيضاً إذا كان نادراً بحيث لا يوجد سبب خاص لتوقع حدوثه وقت التعاقد، كما يذهب بعض الفقهاء^(٢٨).

وفيما يتعلق بالتساؤل الثاني الذي عرضناه أعلاه والخاص بالوقت الذي يعد

= CÉLINE MOILLE, "Force majeure et Covid-19: une notion simple à invoquer en matière contractuelle?", WOLTERS KLUWER FRANCE (25/3/2020).

<https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/contrat/26561/force-majeure-et-covid-19-une-notion-simple-a-invoquer-en-matiere-contractuelle>. (15/4/2020).

CA Aix-en-Provence, 3 mai 2006, JurisData n°2006-306944.

(٢٦)

وانظر أيضاً:

ZAN Daouda, "L'IMPACT DU CORONAVIRUS(COVID-19) SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL", Revue Juridique du Faso (31/3/2020)..(15/4/2020).

<https://revuejuris.net/2020/03/31/limpact-du-coronaviruscovid-19-sur-le-contrat-de-travail/>. (15/4/2020).

(٢٧) راجع: منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩): أسئلة وأجوبة، من خلال هذا الرابط:

<https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>. (30/3/2020).

(٢٨) راجع: السنهوري، الوسيط، ٨٧٨؛ الدناصوري والشواربي، المسؤولية المدنية، ٢٢٥.

الفيروس فيه أمراً متوقعاً؛ فإننا نعني الوقت الذي لا يمكن للمدين في العقود المبرمة بعده الاحتجاج بالفيروس كقوة القاهرة. ويرى البعض في هذا الشأن أنه منذ الإعلان عن وجود الفيروس، لا يصح الاحتجاج به كقوة القاهرة لأنه أصبح أمراً متوقعاً^(٢٩). وقضت محكمة استئناف سانت دينيس بأن وباء الشيكونغونيا الذي بدأ في يناير ٢٠٠٦ لا يبرر إنهاء العقد في أغسطس التالي بعد التعاقد في ٤ يونيو^(٣٠)؛ أي أن العقد قد أبرم بعد وجود الفيروس وبالتالي لا يصح الاحتجاج بالقوة القاهرة. والشيء نفسه أيضاً لم تعتبر محكمة استئناف بيزنسون فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1 قوة القاهرة؛ لأنه كان متوقعاً وقت التعاقد بسبب الإعلانات التي صدرت بهذا الشأن حتى قبل تنفيذ التدابير الصحية^(٣١).

ومن وجهة نظرنا أن الإعلان عن الفيروس لا يصلح ضابطاً في هذا الشأن، وذلك لثلاثة أسباب، الأول: ماذا لو أنه حدث الإعلان بالفعل عن الفيروس ولم يتوقع أحد نطاق انتشاره أو حدته، أو لم يتوقع الشخص المعتاد ذلك، وفقاً لرأينا بخصوص معيار شرط عدم التوقع؟ أما السبب الثاني: ماذا لو تأخر الإعلان رغم وجود تأثير ملموس له في الواقع، وهو افتراض نادر الحدوث، أو ماذا لو لم يعلن عنه نهائياً؟ والسبب الثالث: ما هي الجهة المصدرة للإعلان؛ هل هي منظمة الصحة العالمية أم الدولة؟

وبالنسبة للسبب الأول المذكور أعلاه، فإنه يدور حول عدم توقع نطاق انتشار الفيروس أو حدته حتى لو كان قد أعلن عنه فعلاً؛ فإذا افترضنا أن هناك عقداً أبرم

(٢٩) انظر:

Ludovic Landivaux, "Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? à d'opend", Dalloz (20 mars 2020). <https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend#.XqIOpY9OLIU>. (29/3/2020); MEDEF, "L'impact du Covid-19 dans les relations contractuelles", aacc, (10 mars 2020): 1. <http://www.aacc.fr/uploads/file/file/000/000/770/12601-medef-impact-du-covid-19-dans-les-relations-contractuelles.pdf>. (29/3/2020); Benjamin Balensi et Gisèle-Aimée Milandou, "Coronavirus: quel usage de la force majeure dans les contrats commerciaux ?", taj, (24 mars 2020). <https://taj-strategie.fr/coronavirus-usage-de-force-majeure-contrats-commerciaux>. (29/3/2020); Azaïs, "CORONAVIRUS (COVID-19).

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 déc. 2009, n° 08/02114. (٣٠)
https://www.doctrine.fr/d/CA/SaintDenis_de_la_Reunion/2009/SK70FA78F144-D2A1EBEFD. (15/4/2020).

CA Besançon, 2^{ème} Chambre commerciale, 8 janvier 2014, RG n° 12/02291. (٣١)

بعد ذلك الإعلان، هل يمكن للمدين بالالتزام الناشئ عنه، الاحتجاج بالفيروس كقوة قاهرة لنفي مسؤوليته عن عدم التنفيذ، على أساس أنه لم يتوقع نطاق انتشاره أو حدته؟ والحقيقة أنه يصح ذلك؛ فكما ذكرنا أعلاه أن محكمة استئناف أيكس أون بروفانس Aix en Provence قضت بعدم مسؤولية كل من صاحب الفندق ووكالة السفر؛ لأنه لم يكن بإمكانهما توقع نطاق انتشار فيروس التهاب المعدة والأمعاء على الرغم من أنه مرض شائع؛ وهذا يعني أنهما لم يتوقعا ضراوته وشدته. وقد قضت أيضاً محكمة النقض المصرية بأن: "مخاطر البحر وإن كانت تصلح في ذاتها سبباً اتفاقياً للإعفاء من المسؤولية ولو كانت متوقعة الحدوث أو يمكن دفعها، إلا أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التي تصلح سبباً قانونياً للإعفاء"^(٣٢). ونرى أن ذلك لا يصلح للتطبيق فقط على حالة التعاقد بعد الإعلان عن الفيروس الذي لم يتوقع المدين نطاق انتشاره وحدته، بل يصلح ذلك للتطبيق أيضاً على كل حالات تكرار الفيروس؛ فلو أن هناك فيروساً ظهر لمدة واختفى أو تم القضاء عليه ثم ظهر بعد فترة من جديد، فإنه من الممكن أن يكون قوة قاهرة إذا كان نطاق انتشاره أو شدته غير متوقعة، أو كان نادراً بحيث لم يكن هناك سبب خاص لتوقع وقوعه، وقد وضعنا ذلك أعلاه.

أما بالنسبة للسبب الثاني فإنه يدور حول حكم العقود التي تبرم بعد وجود تأثير للفيروس في الواقع على حياة الإنسان الطبيعية، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات المدنية، في حين لم يتم الإعلان عنه، سواء جاء الإعلان بعد ذلك أم لم يعلن نهائياً عنه، وهو فرض نادر الحدوث كما قلنا. والحقيقة أنه لا يشترط أن يتم الإعلان عن الفيروس لكي يصير أمراً متوقعاً؛ فلو أن هناك ما يشير إلى وجوده أو بمعنى أدق ما يشير إلى ضرورة مواجهته من خلال التدابير الاحترازية والوقائية المعروفة، بصورة لا تخفى على الشخص المعتاد، بحسب رأينا، أو شخص شديد اليقظة والتبصر، بحسب اتجاه محكمة النقض المصرية، فإنه يصبح أمراً متوقعاً.

وبالنسبة للسبب الثالث فإنه يثير مسألة تحديد الجهة التي يعد إعلانها عن وجود الفيروس سبباً في نفي عدم القدرة على توقعه وبالتالي عدم اعتباره قوة قاهرة؛

(٣٢) نقض مدني، طعن رقم ٢٧٢ لسنة ٣١، جلسة ١٧ من مايو سنة ١٩٦٦، المكتب الفني، س ١٧، ص ١١٢٩.

(٣٣) Azaïs, "CORONAVIRUS (COVID-19): FAUT-IL PR?F?RER L'IMPR?VI-SION? LA FORCE MAJEURE?".

فهل هي منظمة الصحة العالمية، كما يذهب البعض^(٣٣)، أم الدولة كما يذهب البعض الآخر^(٣٤)، وإذا كانت الجهة هي منظمة الصحة العالمية فهل نعتد بتاريخ إعلانها عن وجود الفيروس أم إعلانها له كحالة طوارئ صحية عامة أم كجائحة، وإذا كانت الجهة هي الدولة؛ فهل هي الدولة التي يحمل المدين جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها أم هي الدولة التي سينفذ فيها العقد، وماذا لو كان يعتمد على مواد خام من دول أخرى أو عدة دول لتنفيذ الالتزام المطلوب، وهل يمكن التعويل على الإعلان عن الفيروس الصادر من وسائل الإعلام المختلفة وليس الجهات الرسمية. وأمام كل هذه التساؤلات فإننا نرى أنه ينبغي النظر في كل حالة على حدة مع الأخذ في الاعتبار ما كان يتوقعه الشخص المعتاد كما قلنا أعلاه؛ أي بالرجوع إلى المعيار السابق شرحه، وبذلك نكون في غنى عن بحث الإجابة عن التساؤلات السابقة.

وسواء أكان الحدث الذي يحتج به المدين كقوة القاهرة منعه من تنفيذ التزامه، يتمثل في إصابته بالفيروس أو مجرد خطر العدوى به أو التدابير الحكومية التي تتخذها الدولة لمواجهته أو العواقب الاقتصادية الناتجة عنه، فإنه في كل هذه الحالات يجب أن يتوافر شرط عدم القدرة على التوقع لتحقيق القوة القاهرة، وفقاً للنهج الذي اتبعناه بخصوص هذه الحالات عند شرحنا للشرط الأول، وفي ضوء التطبيقات القضائية التي ذكرناها في هذا الشأن.

Valérie Ledoux, “Coronavirus et (in)exécution des contrats d'affaires”, *racine avocats* (2 Avril 2020): 2. <https://www.racine.eu/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus-et-inexecution-du-contrat-daffaires-02042020-2.pdf>. (30/3/2020).

المطلب الثالث

مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً لا يمكن

مقاومته Un événement irrésistible

ينبغي أن يكون الحادث الذي يزعم المدين بأنه قوة قاهرة، غير ممكن دفعه وتجنبه؛ بحيث إذا كان في الإمكان مقاومته وبالتالي يتحقق بذلك تنفيذ الالتزام على الوجه المطلوب، فإنه لا يشكل قوة قاهرة، حتى لو كان من المستحيل توقعه وقت التعاقد^(٣٥). وعدم القدرة على دفع الحدث تعني أن المدين لم يكن لديه القدرة على منع وقوعه أو تلاشيته، أما عدم قدرة المدين على تجنب الحدث فتعني عدم استطاعته معالجة النتائج الضارة الناشئة عنه^(٣٦).

وتقدير توافر عدم القدرة على مقاومة الحدث، وفقاً للعديد من أحكام محكمة النقض المصرية، يكون بمعيّار موضوعي لا ذاتي، أي لا عبرة فيه بشخص المدين وظروفه الخاصة، كما لا يعتد فيه، مثل تقدير عدم القدرة على التوقع، بمعيّار الشخص المعتاد وإنما بمعيّار أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمر؛ فينبغي أن يستحيل على المدين مقاومة الحدث بصورة مطلقة لا نسبية^(٣٧).

(٣٥) STEINLE-FEUEBACH et, al, INONDATIONS: RESPONSABILITES ET FORCE MAJEURE, 29; Jacques Moury, "Force majeure éloge de la sobriété", RTDciv: Revue Trimestrielle de droit civil, N° 3 (2004): 471. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02247568>.(30/3/2020); Patrice Jourdain. Force majeure: l'Assemblée plénière manque l'occasion d'une définition claire. Recueil Dalloz, (2006): 1577. <https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/Juillet/D2006-1577.pdf>.(30/3/2020); Patrice Jourdain, "Le rôle de l'imprévisibilité de la cause étrangère", RTD Civ (1994): 871. https://actu.dallozetudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/04._2017/rtd_civ_1994_871.pdf.(30/3/2020);

وراجع أيضاً: السنهوري، الوسيط، ٨٧٩.

(٣٦) انظر هذا المعنى لدى: شريف محمد غنام، أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية (دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكاديمية شرطة دبي، ٢٠١٠)، ١٠٠؛ يغلى مريم، التزام العون الاقتصادي بالتسليم المطابق (رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ٢٠١٦/٢٠١٧)، ١٦٢؛ بحار، "أثر وباء كورونا المستجد كوفيد ١٩ على الالتزامات التجارية"، ٣٨٧؛ يوسف، مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيروس كورونا"، ٣١٨؛ الأيوبي، المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس "كورونا كوفيد ١٩"، ٢٩١.

(٣٧) نقض مدني، الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية، جلسة ٢٠١٩/٦/١٥. https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392766&&ja=265979. (1/4/2020);

ويتضح من نص المادة ١٢١٨ مدني فرنسي، التي ذكرناها من قبل، أن الحادث الذي تتحقق به القوة القاهرة ينبغي أيضاً ألا يكون في الإمكان تجنب آثاره باتخاذ إجراءات مناسبة، ويفهم من هذه المادة أن عدم إمكان مقاومة الحدث ليس مطلقاً ولكنه نسبي، وهو ما يراه الفقه الفرنسي وتأييده العديد من أحكام محكمة النقض الفرنسية أيضاً؛ حيث إن تقدير هذا الأمر يكون بالرجوع إلى معيار الشخص العادي الذي يوضع في الظروف نفسها^(٣٨).

ونرى أنه يُكتفى في تقدير انعدام القدرة على مقاومة الحدث بالرجوع إلى معيار

- = نقض مدني، الطعن رقم ١٨٤٦٦ لسنة ٨٣ قضائية، جلسة ٢٤/٣/٢٠١٩.
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391071&&ja=260532. (1/4/2020);
 نقض مدني، الطعن رقم ٧٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية، جلسة ١٨/٢/٢٠١٩.
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391429&&ja=261244. (1/4/2019).
 نقض مدني، الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨١ قضائية، جلسة ١٩/١١/٢٠١٨.
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111388866&&ja=255800. (1/4/2019).
 نقض مدني، الطعن رقم ١٣٤٠٤ لسنة ٨١ قضائية، جلسة ١٠/١٠/٢٠١٨.
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389012&&ja=255969. (1/4/2020);
 نقض مدني، الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٨٠ قضائية، ٨/٧/٢٠١٨.
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111388751&&ja=224809. (1/4/2020);
 نقض مدني، الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية، جلسة ٢٤/٦/٢٠١٨.
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111386054&&ja=255225. (1/4/2020);
 وراجع أيضاً معيار عدم إمكان مقاومة الحدث، وكون أن استحالة المقاومة يجب أن تكون مطلقة وليست نسبية: تناغو، مصادر الالتزام، ٢٥٢؛ أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي (عمّان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢)، ٣٢٩؛ رضوان والفوركي، تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية"، ٢٧٥؛ الأيوبي، "المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس "كورونا كوفيد ١٩"، ٢٩١.

(٣٨) Léon Mazeaud et Henri Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle, tome 2 (Paris: Librairie du Recueil Sirey, société anonyme, 1934), n° 1572; Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français tome 7, 2ème edition (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1931), n° 839; DUMOND, LA DATE ET LE CONTRAT, 112; TOUAHRI, La responsabilité civile du fait du dommage nucléaire civil, 54; Pierre Moisan, "Technique contractuelle et gestion des risques dans les contrats internationaux: les cas de force majeure et d'imprévision", Les Cahiers de droit 35, n° 2(1994): 291.
<https://core.ac.uk/download/pdf/59347623.pdf>. (5/5/2020).

وراجع أيضاً أحكام محكمة النقض الفرنسية التالية:

Cass. 2ème Civ.6 juillet 1960, Bull., n° 439.

Cass. 2ème Civ. 6 avril 1965, Bull., n° 355.

الشخص المعتاد؛ ذلك أن الاعتماد على معيار الشخص شديد اليقظة والتبصر، سيعمل على تضيق نطاق تطبيق نظرية القوة القاهرة بصورة كبيرة^(٣٩).

وهناك العديد من الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي تتناول تطبيق شرط عدم إمكانية مقاومة الحدث على فيروسات ظهرت في الماضي؛ فقد قضت محكمة استئناف أجان بأن وباء البروسيلات البقري *épidémie de brucellose bovine* يستجمع خصائص القوة القاهرة؛ فهو ينتشر بسهولة ومعد بشكل كبير لأنه ينتقل عبر أي ناقل، مثل لدغات الحشرات أو جسم الإنسان، ويتسم بفترة خمول *une période de latence* لا يمكن اكتشافها أو التنبؤ بها^(٤٠).

وقد بينت أيضاً محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في تاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨م بأن القيود الحدودية المفروضة من جانب السلطات الصحية لاحتواء تفشي وباء اللسان الأزرق *la langue bleue* الذي يصيب الماشية، والتي ترتب عليها حظر نقلها بين الدول، تعد قوة القاهرة تمنع تنفيذ العقد وقت الأزمة الصحية^(٤١).

وقضت أيضاً محكمة استئناف بوج *Bourges* في تاريخ ٢١ مايو ٢٠١٠م بأن وباء اللسان الأزرق الذي يصيب الماشية كانت له عواقب اقتصادية على نشاط المدين لم يكن في الإمكان مقاومتها، تبرر التخلف عن السداد، كونها قوة القاهرة^(٤٢).

(٣٩) للمزيد من التفاصيل حول الاتجاه الموضوعي في تقدير عدم القدرة على مقاومة الحدث وكذلك عدم إمكان توقعه، والآراء المختلفة بشأن المعيار الذي يجب الرجوع إليه في هذا الشأن، وهل هو معيار الشخص شديد اليقظة والتبصر أم معيار الشخص المعتاد، الذي نميل إلى الأخذ به كما قلنا في المتن، راجع: محمد عبد الصاحب الكعبي، المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية: (دراسة مقارنة) (الإسكندرية: دار التعليم الجامعي، ٢٠١٩)، ١٠٧-١١٣.

(٤٠) CA Agen, 21 janvier 1993, JurisData n°1993-040559.

(٤١) CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 26 sept. 2018, n° 15/09123..(15/4/2020).

<https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2018/C00ED894B03741A280996>. (15/4/2020).

(٤٢) CA Bourges, ch. soc., 21 mai 2010, n° 09/01290..(15/4/2020);

<https://www.doctrine.fr/d/CA/Bourges/2010/BF16893DA1B54B44C9576>. (15/4/2020);

وانظر أيضاً:

Philippe JULIEN, “Coronavirus (Covid-19): faut-il payer les loyers commerciaux du 2e trimestre 2020?”, Editions Francis Lefebvre (19/3/2020)..(15/4/2020); <https://www.efl.fr/actualites/affaires/biens-de-l-entreprise/details.html?-ref=fe6303cfb-7204-49e7-ab1b-98432000f5a5>. (15/4/2020); Romain Rossi-Landi, “Non-paiement des loyers: ce que prévoit le droit pour les baux commerciaux, BFM Immo (25/3/2020). <http://rossi-landiavocat.fr/2020/03/25/non-paiement-des-loyers-ce-que-prevoit-le-droit-pour-les-baux-commerciaux/>. (15/4/2020).

وعلى العكس من ذلك قضت محكمة استئناف باسي تيري، في قضية ذكرناها سابقاً، تتعلق بإلغاء الحجز الفندقي بسبب وباء الشيكونغونيا، بأن الوباء المذكور لا يستجمع خصائص القوة القاهرة؛ فهو لم يكن الحدث الذي لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن مقاومته على وجه الخصوص؛ لأنه في كل الأحوال يمكن التغلب عليه بتناول بعض المسكنات؛ حيث إن المستأنف ضدهم لم يبلغوا عن أي ضعف أو هشاشة طبية معينة تتعلق بهم^(٤٣).

وقضت أيضاً محكمة استئناف تولوز في ٣ أكتوبر ٢٠١٩ بأن تأثير تدابير الاحتواء mesures de confinement المطبقة لمنع تفشي فيروس إنفلونزا الطيور la grippe aviaire (H5N1) وحجز الحيوانات المرتبطة بالفيروس، على تشغيل المزرعة ونتائج الاستغلال، لا يُظهر أن لها طابعاً لا يقاوم أو لا يمكن التغلب عليه un caractere insurmontable et irresistible يمكن أن يجعلها قوة القاهرة تبرر عدم دفع إيجار المزرعة^(٤٤).

وقضت محكمة استئناف نانسي في ٢٢ نوفمبر عام ٢٠١٠ بأن وباء حمى الضنك في جزر المارتينيك لا يعد قوة القاهرة؛ ذلك أنه يمكن توقعه نظراً لتكراره فهو من الأمراض المتوطنة في المنطقة، وقد قلنا ذلك أثناء شرحنا للشرط السابق، كما أنه يمكن مقاومته بالوسائل المتاحة؛ فضلاً عن أن معدل انتشاره منخفض، وعدد الحالات التي حدث لها مضاعفات قليل أيضاً^(٤٥).

CA Basse-Terre, 17 décembre 2018, RG n°17/00739. (٤٣)

CA Toulouse, 3e ch., 3 oct. 2019, n° 19/01579.. (15/4/2020); (٤٤)

<https://www.doctrine.fr/d/CA/Toulouse/2019/C50319E5E954A0498D5C1>. (15/4/2020);

وراجع أيضاً في هذا الشأن:

Me Clément DIAZ, “Le Covid19 constitue-t-il un cas de force majeure pouvant justifier l’inexécution d’une obligation contractuelle?”, Avocat.fr, Blog des avocats, Blog de Me Clément DIAZ (27/5/2020). <https://consultation.avocat.fr/blog/clement-diaz/article-35228-le-covid19-constitue-t-il-un-cas-de-force-majeure-pouvant-justifier-l-inexecution-d-une-obligation-contractuelle.html>. (29/5/2020); Didier DOMAT, Neal LACHMANY et Alexandre DANION, “Les contrats de sponsoring des clubs sportifs à l’épreuve de l’épidémie de covid-19”, doctrine actu (21/4/2020).

<https://www.doctrinactu.fr/post/les-contrats-de-sponsoring-des-clubs-sportifs-a-l-%C3%A9preuve-de-l-%C3%A9pid%C3%A9mie-de-covid-19> . (29/5/2020).

CA Nancy, 1re Chambre civile, 22 novembre 2010, RG n° 09/00003. (٤٥)

أما بالنسبة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، فكما وضحنا أثناء شرحنا للشرط الأول من شروط تطبيق القوة القاهرة، أن محكمة استئناف كولمار اعتبرت أن الظروف الاستثنائية الناتجة عن مخاطر العدوى بالفيروس، تستجمع خصائص القوة القاهرة المعروفة؛ كونها خارجية، لا يمكن التنبؤ بها، ولا يمكن مقاومتها، وتبرر عدم حضور جلسات المحكمة، وظهر ذلك في الأحكام الصادرة عن المحكمة في أكثر من مناسبة، كما وضحنا سابقاً^(٤٦).

ونرى أن النظر إلى فيروس كورونا المستجد من زاوية مدى إمكانية مقاومته، لا ينفصل عن حقيقة هذا الفيروس والخصائص التي يتسم بها؛ فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ليس هناك علاج للمصابين بهذا الفيروس حتى الآن أو لقاح للوقاية منه، كما أنه سريع الانتشار؛ فقد تقشّى في العالم في وقت قصير، للدرجة التي كانت سبباً في إعلانه كجائحة من قبل المنظمة؛ وقد ساعد على ذلك طول فترة حضائته التي قد تصل إلى ١٤ يوماً؛ في حين أنه قد لا تظهر أية أعراض على المصاب خلال هذه المدة أو تظهر عليه مجرد أعراض خفيفة، وبالتالي يمكن أن يكون الشخص سبباً في نقل الفيروس لغيره دون أن يعلم، كما أنه فيروس مستجد مازال الكثير عنه مجهولاً بالنسبة للباحثين^(٤٧).

وعلى الرغم مما سبق فإنه لا يصح القول بأن جائحة فيروس كورونا المستجد تشكل قوة القاهرة في كل الحالات بصورة تلقائية، بل يتعين على القضاء أن ينظر في

(٤٦) راجع أيضاً:

Luc Grynbaum, "Force majeure et épidémie de COVID -19: une première décision vient d'être rendue", le club des jurists (25 mars 2020).

<https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/force-majeure-et-epidemie-de-covid-19-les-premieres-decisions-viennent-detre-rendues/>. (20/5/2020).

(٤٧) راجع: منظمة الصحة العالمية، "مرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩)"، من خلال هذا الرابط: <https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>. (10/5/2020);

وراجع أيضاً: الصفحة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-١٩)، على موقع منظمة الصحة العالمية، من خلال هذا الرابط:

<https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>. (10/5/2020).

وراجع أيضاً: شبكة معلومات منظمة الصحة العالمية عن الأوبئة، من خلال هذا الرابط: <https://www.who.int/epi-win>. (10/5/2020).

كل حالة على حدة لكي يتضح مدى استجابة كل حالة لشروط تحقق القوة القاهرة، ومن بينها شرط عدم القدرة على مقاومة الفيروس أو آثاره^(٤٨).

وكما أشرنا أثناء شرحنا للشرطين السابقين أنه يمكن أن تتمثل القوة القاهرة بشأن جائحة فيروس كورونا في الإصابة بالفيروس أو مجرد خطر العدوى به، أو التدابير الحكومية التي تتخذها الدولة لمواجهة أو العواقب الاقتصادية الناشئة عن انتشاره؛ فكل صورة من الصور الأربع المذكورة يمكن أن تمنع المدين من تنفيذ التزامه على الوجه المطلوب. وبالنسبة للإصابة بالفيروس، فقد وضحنا أثناء شرحنا للشرط الأول أن محكمة النقض الفرنسية في أكثر من مناسبة اشترطت لكي يحتج بالمرض كقوة القاهرة أن يتوافر فيه شروط تحقق القوة القاهرة المعروفة، ومن بينها عدم القدرة على مقاومة المرض^(٤٩)، وقضت أيضاً محكمة استئناف نيم Nmes بأن تعرض المحامي للوهن العضلي الشديد asthnie بصورة مفاجئة وغير متوقعة، مما تحتم معه، بصورة لا تقاوم، دخوله إلى المستشفى، يعد قوة القاهرة يترتب عليها عدم تطبيق الجزاء المنصوص عليه في حالة عدم الالتزام بالموعد الإجرائي^(٥٠).

والشيء نفسه بالنسبة لخطر الإصابة بالفيروس فإنه يجب أن يستجمع هذا الخطر شروط القوة القاهرة ومن بينها شرط عدم إمكان مقاومته، وقد ظهر ذلك في أحكام محكمة استئناف كولمار كما وضحنا في الشرطين السابقين.

(٤٨) انظر هذا المعنى لدى:

Avocats mathias, "Covid-19 : un cas de force majeure ?", avocats-mathias (20 mars 2020).

<https://www.avocats-mathias.com/actualites/force-majeure-impacts-contrat> .(20/5/2020);

Philippe Bensussan, "Le sort des loyers en matière de bail commercial à l'épreuve du COVID-19", LE MONDE DU DROIT (2 AVRIL 2020).. (20/5/2020).

<https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/69198-sort-loyers-bail-commercial-covid19-coronavirus.html> . (20/5/2020).

Philippe Touzet et Maya Dami, "Covid-19: une application pratique de la force majeure", (6 Avril 2020).

https://www.parabellum.pro/Covid-19-une-application-pratique-de-la-force-majeure_a856.html . (20/5/2020); Christine Sévère et Claire Picard, "COVID-19 Force majeure, fait du prince, imprévision et exception d'inexécution", Dentons (19 mars 2020). <https://www.dentons.com/fr/insights/alerts/2020/march/19/covid-19-force-majeure-contingency-and-default-exception> .(20/5/2020).

Nîmes, 6 nov. 2018, n° 18/04133.

(٥٠)

أما بالنسبة للتدابير التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس والتي قد ينشأ عنها حالة القوة القاهرة التي تمنع المدين من تنفيذ التزامه، مثلما رأينا في حكم محكمة استئناف باريس والتي اعتبرت القيود الحدودية التي تنطوي على حظر تصدير الماشية، بسبب وباء اللسان الأزرق، بمثابة القوة القاهرة؛ فإنه ينبغي التدقيق في نطاق تطبيق هذه التدابير بحيث إذا كان في الإمكان تجنب آثارها أو تلاشيها بالوسائل المناسبة المشروعة، فإنه لا تتحقق القوة القاهرة^(٥١)، مثال ذلك المورد الذي يلتزم بتوريد كمية معينة من البضائع كل فترة زمنية محددة، وقد أغلق مصنعه بقرار من الحكومة في إطار مكافحة الفيروس والسيطرة عليه، وكان ذلك دون أن يثبت في جانبه أي خطأ استدعى هذا القرار، وكان لديه مصنع في الخارج يمكنه تلبية الشحنات المطلوبة منه، فإنه لا يحق له الاحتجاج بالقوة القاهرة.

وفيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا؛ فكما رأينا أن محكمة استئناف بروج اعتبرت أن العواقب الاقتصادية الناتجة عن وباء اللسان الأزرق الذي يصيب الماشية، قوة القاهرة لأنه كان له أثر لا يقاوم على نشاط المدين. وعلى خلاف ذلك رأينا أن محكمة استئناف تولوز لم تعتبر أن الآثار الناتجة عن تدابير منع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، على تشغيل المزرعة واستغلالها، لها طابع الحدث الذي لا يمكن التغلب عليه أو مقاومته، وبالتالي لم تعتبرها قوة القاهرة تبرر تخلف المدين عن سداد أجرة المزرعة. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن العواقب الاقتصادية قد تنتج عن انتشار الفيروس ذاته حتى لو لم تتخذ الدولة إجراءات أو قرارات لمواجهة الفيروس من شأنها ترتيب آثار اقتصادية لا تقاوم، مثال ذلك إذا كان هناك مزارع قد التزم بتوريد محصوله الزراعي إلى آخر، ثم بعد ذلك اجتاحت فيروس معين البلاد بشكل كبير؛ مما أدى إلى إحجام الأيدي العاملة عن الخروج إلى العمل؛ بحيث لم يكن في مقدور أي مزارع وقتها العناية بمثل هذا المحصول بمفرده؛ فنتج عن ذلك فسادته وتعذر إتمام عملية التوريد. وفي كل الأحوال ينبغي أن يتوافر في

(٥١) انظر هذا المعنى أيضاً لدى:

Allais et, al, "Impacts du Covid-19 en droit administratif, droits de l'homme, droit du travail, droit des contrats et droit penal", 18-20; David Sabatier, "La résiliation des contrats pour force majeure en raison du covid-19 / coronavirus", 1862 Avocats.

<https://www.1862-legal.com/blog-avocat-droit-immobilier/2020/3/15/doi-on-sat-tendre-une-vague-de-rsiliation-des-contrats-pour-force-majeure-en-raison-du-covid-19-coronavirus-> (20/5/2020).

العواقب الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، الشروط الواجب توافرها لكي تتحقق القوة القاهرة، ومنها ألا يكون في الإمكان مقاومتها^(٥٢).

MEDEF, “L’impact du Covid-19 dans les relations contractuelles”, L’Association Nationale des Industries Alimentaires”, 1-2; Pierre Linas, “La force majeure: un remède contre le COVID-19?”, Stephenson Harwood (avril 2020). <https://www.shlegal.com/news/la-force-majeure-un-rem%C3%A8de-contre-le-covid-19>. (20/5/2020) Elsa Haddad, “Le coronavirus et ses conséquences sur les contrats, cas de force majeure ou cause d’imprévision?”, village de la justice (27 mars 2020).

المطلب الرابع

مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حادثاً من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً

Un événement rend l'exécution de l'obligation impossible

ينبغي بالإضافة إلى الشروط السابقة أن يجعل الحادث تنفيذ التزام المدين مستحيلاً، فلا يكفي أن يؤدي إلى أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً^(٥٣)؛ وهذا هو ما يميز نظرية القوة القاهرة عن الظروف الطارئة "La théorie de l'imprévision"، فيكفي لتطبيق الأخيرة أن يترتب على الحادث أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً كما في الأولى^(٥٤).

كما يجب أن تكون الاستحالة مطلقة وليست نسبية؛ أي أنه لا يكفي أن يستحيل تنفيذ الالتزام على المدين وحده بل على أي شخص في موقفه، ويستوي أن تكون الاستحالة مادية أو معنوية L'impossibilité matérielle ou morale^(٥٥).

وقد قضت محكمة النقض المصرية فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الحادث لكي يصبح قوة القاهرة بأنه "... يجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل

(٥٣) راجع: عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني (بيروت، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، ط ٢، ١٩٩٨)، ٩٦٥؛ وكذلك الوسيط، ٨٧٩؛ حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط٢ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٩)، ٣٩٤؛ تنافو، مصادر الالتزام، ٢٥٣.

وراجع أيضاً: نقض مدني، الطعن رقم ٢٧ لسنة ١ ق، جلسة ١٤/١/١٩٣٢، مجموعة عمر، المجلد الأول، ص ١٦.

(٥٤) راجع: تنافو، مصادر الالتزام، ٢٥٣؛ أحمد الصويغي شليبيك، "نظرية الظروف الطارئة: أركانها وشروطها"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ٣، عدد ٢ (٢٠٠٧): ١٨٥؛ خالد علي سليمان، "الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ١، عدد ٢ (٢٠٠٦): ١٧٧؛ مصطفى عبد الحميد عدوي، الوجيز في قانون العقود الفرنسي الجديد (القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٢٠)، ٤١.

(٥٥) السنهوري، الوسيط، ٨٧٩؛ أبو سعد، "مفهوم القوة القاهرة"، ١٨٢؛ وانظر أيضاً: ZUYLEN, "La force majeure en matière contractuelle: un concept unifié? Réflexions à partir des droits belge, français et hollandaise", 409, 410.

تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة، فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده بل استحالة بالنسبة لأي شخص يكون في موقف المدين^(٥٦).

وجاء النص على هذا الشرط في المادة ١٢١٨ من القانون المدني الفرنسي والتي تناولناها من قبل؛ فقد اشترطت أيضاً في الحادث بالإضافة إلى الشروط السابقة أن يحول دون قيام المدين بتنفيذ التزامه^(٥٧). كما يتضح أيضاً ذلك من أحكام محكمة النقض الفرنسية^(٥٨).

وتطبيق ما سبق على جائحة فيروس كورونا المستجد يقتضي منا استعراض السوابق القضائية التي تعرضت للأوبئة من زاوية استحالة تنفيذ الالتزام نتيجة انتشارها والادعاء بالقوة القاهرة من جانب المدين تبعاً لذلك، لكي يكون من السهل علينا النظر أيضاً إلى تلك الجائحة من الزاوية نفسها.

وفيما يتعلق بهذا الشأن قضت محكمة باريس الابتدائية في تاريخ ٤ مايو ٢٠٠٤ برفض الدفع الذي قدمته إحدى وكالات السفر، بعدم قدرتها على تنفيذ التزامها، وهو القيام بالرحلة السياحية المخطط لها، بسبب القوة القاهرة المتمثلة في وجود فيروس سارس "SARS" في تايلاند، البلد المراد السفر إليه، وقد جاء في الحكم أن: "المخاطر الصحية لم تكن كبيرة في تايلاند ولا يمكن الاعتراف بأن السفر إلى ذلك البلد كان مستحيلاً بسبب فيروس سارس"^(٥٩).

وقضت أيضاً المحكمة نفسها في تاريخ ٢٥ سبتمبر عام ١٩٩٨ بأن التوقف في

(٥٦) نقض مدني، طعن رقم ٦٧٧ لسنة ٦٩ قضائية، جلسة ١٠/٤/٢٠١٢، مكتب فني، س ٦٣، ص ٥٨٩.

(٥٧) راجع أيضاً:

Moury, "Force majeure", 471; Jourdain, "Force majeure", 1477; Alain Sériaux, DROIT DES OBLIGATIONS, 2ème edition (Paris: Presses universitaires de France (PUF), 1998), 244; TOUAHRI, La responsabilité civile, 54.

(٥٨) cass., Soc., 12 février 2003, N° de pourvoi: 00-46660, Bulletin 2003 V N° 50 p. 45; Cass. civ., 4 août 1915, DP 1916, 1, p. 22; cass, Com., 12 novembre 1969, JCP 1971 - II - 16791.

(٥٩) TI Paris, 4 mai 2004, n° 11-03-000869;

وراجع أيضاً:

Catherine Leclercq, "PEUT-ON S'EXONERER DU PAIEMENT DE SON LOYER COMMERCIAL DANS LE CONTEXTE DU COVID-19?", village justice (4/4/2020).

<https://www.village-justice.com/articles/peut-exonerer-paiement-son-loyer-commercial-dans-contexte-covid,34482.html#nh2-1>. (15/4/2020).

بلد مجاور لمنطقة تفشى فيها وباء الطاعون *épidémie de peste* لا يمكن اعتباره قوة قاهرة تبرر إلغاء المسافرين حجز رحلاتهم المخطط لها؛ حيث لم يكن انتشار الوباء في المنطقة المجاورة لمحطة التوقف جسيماً ولم توجه أي تعليمات لشركات الطيران أو وكالات السفر لتفادي تلك المنطقة^(٦٠). وهذا يعني أيضاً أن تنفيذ الالتزام لم يكن مستحيلاً بسبب الوباء المذكور.

كما قضت محكمة استئناف باريس في تاريخ ١٧ مارس ٢٠١٦، فيما يتعلق بشركة استندت في تخلفها عن سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى القوة القاهرة المتمثلة في انتشار وباء إيبولا Ebola؛ بأن الطبيعة المؤكدة للوباء الذي ضرب غرب إفريقيا اعتباراً من ديسمبر ٢٠١٣، لم تكن كافية، حتى لو أُعتبر الوباء قوة قاهرة، لإثبات أن ذلك تسبب في انخفاض أو عدم وجود النقد؛ فلم تقدم الشركة دليلاً على أن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي كان بسبب القوة القاهرة^(٦١).

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد فإنه ينبغي على المدين الذي يستند إلى القوة القاهرة في هذا السياق، تقديم الأدلة للمحكمة التي تثبت أن عدم تنفيذه للالتزام كان نتيجة تلك الجائحة، فإذا كان ما ادعى به من قوة قاهرة يتمثل في الإصابة بالفيروس فإن عليه إثبات أن الإصابة هي السبب في جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً؛ فإذا كان على سبيل المثال تنفيذ الالتزام لا يتطلب وجوده؛ بحيث كان من الممكن القيام به عن طريق أحد من زويه أو العاملين لديه أو كان في استطاعته تكليف غيره بذلك بوجه عام، فإنه لا يصح أن يحتج بأن إصابته بالفيروس شكلت قوة قاهرة منعه من التنفيذ، والشيء نفسه لو كانت الإصابة بالفيروس التي يحتج بها كقوة قاهرة، تتمثل في إصابة عماله، فلا يصح إذا لم يتأثر العمل بذلك بحيث كان في الإمكان تنفيذ الالتزام، أن يستند إلى ذلك لتبرير عدم تنفيذ الالتزام. وبالتالي الإصابة التي يعول عليها هنا هي التي من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، ويجب على المدين تقديم الدليل على ذلك. وأما إذا ادعى بأن القوة القاهرة تتمثل في مخاطر العدوى؛ أي أن خشيته من الإصابة بالفيروس منعه من تنفيذ الالتزام، فإنه ينبغي في هذه الحالة أن يقدم الدليل على أن الفيروس كان من الجسمامة بحيث يخشى على حياة الإنسان من التفاعل الاجتماعي الذي يقتضيه تنفيذ الالتزام. وقريب من ذلك ما استخلصته محكمة استئناف كولمار

Paris, 25e, section B, 25 sept. 1998, n° Juris-Data 1998-024244.

(٦٠)

CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263.

(٦١)

<https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2016/RD450B9F0892CE28A7EF5>. (18/5/2020).

بشأن مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، في أحكامها التي ذكرناها من قبل، فقد استقر في عقيدتها أنه ليس هناك ما يضمن عدم انتقال الفيروس للغير عند إحضار المحتجزين إلى جلسات المحكمة. وإذا كانت تلك الأحكام تتعلق بالمسائل الإجرائية وليس تنفيذ العقود؛ لكننا نستطيع من خلالها أن نتصور معنى الاستحالة التي تنتج عن مخاطر العدوى بفيروس كورونا، عندما يزعم المدين أن هذه المخاطر تمثل قوة القاهرة من شأنها أن تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. وكان هناك تطبيق لذلك على فيروسات سابقة في إطار تنفيذ العقود المدنية؛ فلم تقتنع محكمة باريس الابتدائية في مناسبتين وضحاهما أعلاه بأن المخاطر الصحية للوباء، سواء سارس أو الطاعون، لم تكن كافية للاعتراف بأنها جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً.

والأمر نفسه إذا كانت القوة القاهرة التي يحتج بها المدين تتمثل في التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس؛ فينبغي أيضاً أن يقدم الدليل على أن ذلك تسبب في جعل تنفيذ التزامه مستحيلاً، ويقتضي النظر في هذه المسألة من قبل المحكمة فحص شروط تطبيق تلك التدابير؛ فإذا لم يكن من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً كما يدعي المدين، فإن الأخير لا يكون محقاً في دعواه أو ادعائه، مثال ذلك إذا كان قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة يستثني من نطاق تطبيقه بعض الأنشطة، وكان نشاطه من الأنشطة المستثناة؛ فإنه لا يجوز له الاحتجاج بأن ذلك القرار كان سبباً في إعاقته عن تنفيذ التزامه، لما انطوى عليه من تقييد للحركة.

وينطبق ذلك على العواقب الاقتصادية الناشئة عن الجائحة والتي قد يحتج بها المدين كقوة القاهرة منعه من تنفيذ التزامه؛ بحيث ينبغي أيضاً أن يقدم الدليل على أن تلك العواقب كانت السبب وراء استحالة التنفيذ. وقد رأينا أن محكمة استئناف باريس رفضت التسليم بذلك في قضية ادعى فيها المدين بأنه لم يكن قادراً على سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي بسبب فيروس إيبولا.

والاستحالة الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تكون استحالة جزئية، وفي هذه الحالة لا ينقضي التزام المدين كلية إذا كان في الإمكان القيام بالجزء الآخر ويبقى أيضاً ما يقابله من التزامات تقع على عاتق الدائن^(٦٢)، والأمثلة على ذلك

MEDEF, “L’impact du Covid-19 dans les relations contractuelles”, 2; Ledoux, (٦٢) “Coronavirus et (in)exécution du contrat d’affaires”, Racine Avocats(2 Avril 2020): 2;

Vincent FAUCHOUX, “COVID-19 | Coronavirus et force majeure: quels impacts sur vos contrats?”, Deprez Guignot Associates, “DDG”, (2-3-2020).
<https://ddg.fr/actualite/coronavirus-et-force-majeure/>. (20/5/2020).

عديدة، ومنها إذا كان التزام المدين يتمثل في توريد أصناف معينة من المواد الغذائية خارج البلاد، وكانت الدولة على أثر انتشار الفيروس حظرت تصدير البقوليات، فإنه يظل مع ذلك ملتزماً بتوريد الأصناف الأخرى غير البقوليات. ومع ذلك إذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة indivisible أو أن الجزء المتبقى منه لم يعد مفيداً للدائن، أو أن التنفيذ الجزئي يتناقض مع إرادة المتعاقدين، فإن الالتزام ينقضي في هذه الحالات كلية، والأمر متروك لقاضي الموضوع^(٦٣).

وقد تكون الاستحالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد مؤقتة Temporaire، وفي هذه الحالة يعلق أداء الالتزام حتى يزول العائق الذي منع المدين من التنفيذ^(٦٤)، مثال ذلك إذا حظرت الدولة تصدير المواد اللازمة للوقاية من الفيروس، كالمطهرات والأقنعة وغيرها، وكان محل التزام المدين توريد هذه المواد خارج البلاد، فهنا يبقى التزام المدين قائماً حتى إلغاء قرار الحظر، ومع ذلك فإن الالتزام ينقضي إذا

(٦٣) راجع: عامر وعامر، المسؤولية المدنية، ٣٩٩؛ وانظر أيضاً:

Uggc Avocats, “LE COVID-19 CONSTITUE-T-IL UN CAS DE FORCE MAJEURE? QUELS EN SONT LES EFFETS SUR LES CONTRATS EN COURS?”, Uggc (16/04/2020).

<https://www.uggc.com/le-covid-19-constitue-t-il-un-cas-de-force-majeure-queles-en-sont-les-effets-sur-les-contrats-en-cours/>. (20/5/2020).

وانظر أيضاً حكم محكمة النقض الفرنسية التالي:

Cass Civ, 1er, 13 janvier 1987, N° de pourvoi: 85-12676, Bulletin 1987 I N° 11 p. 8.

Frédéric Danos, “La crise du coronavirus et l’exécution des engagements contractuels”, Editions legislatives (30.03.2020).

<https://www.editions-legislatives.fr/actualite/la-crise-du-coronavirus-et-1%E2%80%99execution-des-engagements-contractuels>. (22/5/2020); JOURNAL CLARD Alexandra, “Le coronavirus n’excuse pas tout”, linkedin (7/4/2020)..(22/5/2020); Philippe Axelrouode, “L’épidémie de Covid-19 peut-elle justifier la rupture d’un contrat de travail sur le fondement de la force majeure?”, Pragma (30/04/2020). <https://pragma.international/article/lepidemie-de-covid-19-peut-elle-justifier-la-rupture-dun-contrat-de-travail-sur-le-fondement>. (22/5/2020);

وراجع أيضاً: السنهوري، الوسيط، ٨٨٠؛ وانظر: حكم محكمة النقض المصرية التالي:

نقض مدني، الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٥٣ قضائية، جلسة ١٩٩١/١/٣٠، مكتب فني، س ٤٢، ص ٣٣٦؛ وكذلك حكم محكمة النقض الفرنسية التالي:

Cass., 1 ère Civ., 24 février 1981, N° de pourvoi: 79-12710, Bulletin N. 65.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURI-TEXT000007007126>. (20/5/2020).

كان تعليقه يجرده من أية منفعة تعود على الدائن، أو كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن أداء الالتزام يتعين أن يكون فوراً في كل الأحوال أو في موعد محدد يعول الدائن عليه لتحقيق مصلحة معينة، أو أن الهدف الذي يسعى إليه المتعاقدان يتناقض مع تعليق تنفيذ العقد. وإذا جرى تعليق أداء الالتزام حتى أصبح تنفيذه بلا جدوى، فإن الالتزام ينقضي أيضاً، وكل ذلك متروك لقاضي الموضوع يحدده بحسب ظروف كل حالة^(٦٥).

وإذا ثبت أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت السبب الوحيد في الاستحالة النهائية لتنفيذ الالتزام ووقوع الضرر بالدائن، فإن الالتزام ينقضي وفقاً لنص المادة ٣٧٣ من القانون المدني المصري، وتنقضي الالتزامات المقابلة، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه وفقاً لنص المادة ١٥٩ من القانون المدني المصري^(٦٦)، كما تنتفي مسؤولية المدين في هذه الحالة بحيث لا يحق للدائن مطالبته بأي تعويض عن ذلك، وذلك لانتفاء علاقة السببية عن طريق القوة القاهرة، تطبيقاً لنص المادة ٢١٥ من القانون المدني المصري^(٦٧)، وقد أشرنا إلى المواد الثلاث أثناء شرحنا للشرط الأول.

وقد نصت المادة ١٢١٨/٢ من القانون المدني الفرنسي في هذا الشأن على أنه: "إذا كان المانع مؤقتاً يتم تعليق تنفيذ الالتزام، ما لم يبرر التأخير الناتج عنه إنهاء العقد. إذا كان المانع نهائياً يتم إنهاء العقد تلقائياً ويتحرر الأطراف من التزاماتهم بموجب الشروط المنصوص عليها في المادتين ١٣٥١، ١٣٥١-١"^(٦٨).

ومع ذلك ينبغي على المدين أن يتصرف وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود le principe de la bonne foi المنصوص عليه في المادة ١/١٤٨ مدني مصري والمادة ١١٠٤ مدني فرنسي^(٦٩)؛ بحيث يتعين عليه إخطار الدائن بأمر

(٦٥) راجع: عامر و عامر، المسؤولية المدنية، ٣٩٩، ٤٠٠.

(٦٦) راجع في هذا الشأن: السنهاوي، الوسيط، ٧٢٢-٧٢٧.

(٦٧) راجع: المرجع السابق، ٨٨٠.

(٦٨) Article 1218-2: Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

(٦٩) تنص المادة ١/١٤٨ مدني مصري على أنه: يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية؛ وتنص المادة ١١٠٤ مدني فرنسي على أنه: يجب التفاوض على العقود وتكوينها وتنفيذها بحسن نية. هذا الحكم من النظام العام؛ وجاء النص =

استحالة تنفيذ الالتزام لكي يتمكن من اتخاذ التدابير واستخدام الوسائل التي تحد من الخسائر التي قد تلحق به جراء ذلك، ويكون ذلك في أقرب وقت يتمكن فيه المدين من القيام بذلك. كما ينبغي عليه أن يقوم بالعناية المتوقعة من الشخص المعتاد لمنع الأضرار التي قد تصيب الدائن بسبب القوة القاهرة أو التخفيف منها، ومن ناحية أخرى ينبغي على الدائن أن يقوم بكل ما تفرضه مقتضيات حسن النية والتعاون في تنفيذ العقد أيضاً؛ ويترتب على ذلك أن يقوم بكل ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المدين، وأن يمتنع عن أي سلوك من شأنه زيادة تلك الأعباء^(٧٠).

والجدير بالذكر أخيراً أنه يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على تعديل أثر القوة القاهرة؛ بمعنى أنه يصح أن يتفق الطرفان على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة^(٧١)؛ وفي هذا الشأن تنص المادة ١/٢١٧ على أنه: "يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة". ويسأل المدين عن تنفيذ الالتزام وفقاً للمادة ١٣٥١ من القانون المدني الفرنسي، على الرغم من تحقق القوة القاهرة، في حالتين: إحداهما إذا كان هناك اتفاق على ذلك، والثانية إذا كان قد أخطر بالتنفيذ ووقعت القوة القاهرة قبل قيامه بذلك^(٧٢)، ومع ذلك فإنه وفقاً للمادة ١-١٣٥١ إذا

= الفرنسي كالتالي:

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

(٧٠) راجع: عامر وعامر، المسؤولية المدنية، ٣٩٦-٣٩٨؛ وانظر أيضاً:

FAUCHOUX, "COVID-19 | Coronavirus et force majeure"; Celine Taieb, "Contrat commerciaux et Coronavirus", Alaris Avocats (21-3-2020).

<https://www.alaris-law.com/fr/contrat-commerciaux-et-coronavirus/> (22/5/2020);

Nicolas Rémy-Néris, "L'exécution des contrats commerciaux à l'épreuve du Covid-19", Grant Thornton (1-4-2020).

<https://www.grantthornton.fr/fr/insights/articles-et-publications/2020/lexecution-des-contrats-commerciaux-a-lepreuve-du-covid-19/> (22/5/2020).

(٧١) راجع: سليمان مرقس، شرح القانون المدني في الالتزامات، الجزء الثاني (القاهرة: المطبعة العالمية، ١٩٦٤)، ٦٤٥؛ حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام (د، ١٩٩٥، ط٢)، ٤٦٥؛ وراجع أيضاً حكم محكمة النقض المصرية التالي: نقض مدني، الطعن رقم ١٢ لسنة ١٥ قضائية، جلسة ٢٩/١٠/١٩٤٥.

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111331605&&ja=126664 (22/5/2020).

(٧٢) انظر: محمد عرفان الخطيب، "المبادئ المؤطرة لنظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي الجديد: دراسة نقدية تأصيلية مقارنة"، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السابعة، =

كانت استحالة التنفيذ بسبب هلاك الشيء المستحق، فإنه تنتفي مسؤولية المدين رغم إخطاره إذا ثبت أن ذلك كان سيحدث حتى لو تم تنفيذ الالتزام^(٧٣). وقد يتخذ الاتفاق على تعديل أثر القوة القاهرة صورة الاتفاق على أن يتحمل المدين القوة القاهرة بوجه عام، ولا تنتفي مسؤوليته إذا تحققت، أو الاتفاق على أن هناك أحداث معينة تعد قوة القاهرة وتنتفي مسؤولية المدين إذا وقع حادث منها دون غيرها، أو الاتفاق على أن مسؤولية المدين تبقى قائمة إذا وقعت حوادث معينة دون غيرها^(٧٤).

خاتمة:

بعد أن انتهينا من دراستنا لموضوع مدى انطباق شروط القوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك من خلال تناول كل شرط على حدة في مطلب مستقل، نستطيع أن نبين هنا أهم النتائج التي توصلنا إليها من البحث، وأهم التوصيات التي تتعلق بذلك، وكذلك الدراسات المستقبلية التي يمكننا اقتراحها فيما يخص هذا الشأن، ونفصل ذلك فيما يلي:

أولاً - النتائج العلمية:

١ - تبين لنا من خلال تطبيق شروط القوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا المستجد أن القوة القاهرة فيما يتعلق بذلك يمكن أن تتمثل في الإصابة بالفيروس أو خطر العدوى به إذا وصل الفيروس حداً من الجسامة يخشى معها على حياة الإنسان من التفاعل الاجتماعي الخارجي، كما يمكن أن تتمثل أيضاً في التدابير الحكومية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، أو العواقب الاقتصادية الناشئة عنه، وفي كل الأحوال يجب أن تتوافر في الصور المذكورة شروط تحقق القوة

= عدد ٢، العدد التسلسلي ٢٦ (يونيو ٢٠١٩): ٢٢٦، ٢٢٧؛ وقد جاء نص المادة ١٣٥١ مدني فرنسي كالتالي:

L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.

Article 1351-1: Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose. (٧٣)

Sévère et Claire Picard, "COVID-19 Force majeure, fait du prince, imprévision et exception d'inexécution", (٧٤)

القاهرة التي عرضناها أعلاه؛ بحيث نستطيع القول أن جائحة فيروس كورونا المستجد ليست بذاتها قوة قاهرة بشكل تلقائي في جميع الحالات، بل ينبغي النظر في آثارها ومدى تحقق تلك الشروط بشأنها بحسب كل حالة على حدة، والأمر متروك لمحكمة الموضوع.

- ٢ - تكرار الفيروس لا يعني افتراض توقع حدوثه، ومن ثم عدم تحقق القوة القاهرة فيما يخص الاحتجاج بالآثار الناتجة عنه؛ بل إذا تكرر ظهور فيروس بحيث لم يكن في الإمكان توقع نطاقه أو شدته أو حدته، أو كان نادراً بحيث لا يوجد سبب خاص لتوقع حدوثه وقت التعاقد، فإن ذلك لا يمنع تحقق القوة القاهرة إذا توافرت شروطها الأخرى، ويظهر ذلك بجلاء في حالة الفيروس المستوطن Endémie.
- ٣ - الإعلان عن الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية أو الدولة لا يصلح ضابطاً لتقدير شرط عدم توقع الفيروس من جانب المدين، وإنما يجب الرجوع إلى معيار الشخص المعتاد مع مراعاة الظروف المحيطة.
- ٤ - الحفاظ على نسبة القوة القاهرة من حيث تقدير شرط عدم توقع الحدث، وكذلك شرط عدم القدرة على مقاومته، بالرجوع إلى معيار الشخص المعتاد في الظروف نفسها؛ يضمن تحققها وفقاً للتوقعات والقدرات المعقولة للمتعاقدين، بما يرفع عن المدين المعاناة وقت الأزمات التي تحدث بعد إبرام العقد وتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
- ٥ - إذا كانت القوة القاهرة المتمثلة في أحد آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، هي السبب الوحيد في الاستحالة النهائية للالتزام، ترتب عليها انقضاء الالتزام وانتفاء مسؤولية المدين؛ بينما إذا ترتب على القوة القاهرة مجرد الاستحالة المؤقتة لتنفيذ الالتزام، فإن الأخير لا ينقضي وإنما يعلق تنفيذه حتى زوال العائق المؤقت الذي يحول دون ذلك، مع مراعاة القواعد العامة في هذا الشأن وفقاً لما وضحه في البحث، كما أنه قد تكون الاستحالة الناتجة عن القوة القاهرة استحالة جزئية وليست كلية، وهنا لا ينقضي التزام المدين كلية وإنما يقتصر ذلك على الجزء الذي استحال تنفيذه فقط، وكذلك الجزء المقابل له من التزام الدائن، مع مراعاة القواعد العامة في هذا الشأن أيضاً.

ثانياً - التوصيات:

- ١ - نوصي المشرع بصياغة أحكام القوة القاهرة على غرار ما قام به المشرع الفرنسي في المادة ١٢١٨ من القانون المدني الفرنسي، والتي أُضيفت بمقتضى القانون رقم ١٣١-٢٠١٦؛ وذلك من خلال وضع تعريف لها يبرز شروط تحققها التي وضحناها في بحثنا، وبيان أثر المانع المؤقت من تنفيذ الالتزام، وهو تعليق

التنفيذ ما لم يبرر ذلك إنهاء العقد، وكذلك أثر المانع النهائي الذي يترتب عليه إنهاء العقد تلقائياً، وإعفاء المدين من الالتزام ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، أو إذا كان قد أخطر المدين بالتنفيذ ووقعت القوة القاهرة قبل قيامه بذلك، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ١٣٥١ مدني فرنسي، إلا إذا كانت استحالة التنفيذ بسبب هلاك الشيء المستحق، فإنه في هذه الحالة تنتفي مسؤولية المدين رغم إخطاره إذا ثبت أن ذلك كان سيحدث حتى لو تم تنفيذ الالتزام، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ١٣٥١-١ مدني فرنسي.

- ٢ - نوصي الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على حركة التجارة الداخلية والدولية وقت الأزمة الصحية بما يضمن الوفاء بالالتزامات التعاقدية قدر المستطاع.
- ٣ - نوصي المحاكم القضائية باتباع النهج النسبي عند تقدير توافر شرطي عدم القدرة على توقع الحدث وعدم إمكان مقاومته، لتحديد مدى تحقق القوة القاهرة بوجه عام، وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد على وجه الخصوص؛ وذلك بالرجوع إلى معيار الشخص المعتاد مع مراعاة الظروف المحيطة.

ثالثاً - الدراسات المستقبلية:

- ١ - الالتزام بمبدأ حسن النية أثناء تنفيذ العقد له دور كبير في الحفاظ عليه من تعرضه للانفساخ بسبب القوة القاهرة، كما أن له دوراً أيضاً في التخفيف من آثار القوة القاهرة عندما لا يكون هناك مفر من تحققها؛ ويقتضي هذا الأمر دراسة المبدأ المذكور لتوضيح ما يجب أن يقوم به الطرفان فيما يتعلق بهذا الشأن.
- ٢ - يمكن أن تسبب الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تطرأ أثناء تنفيذ العقد أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين وليس مستحيلاً عليه؛ ويأتي هنا دور نظرية الظروف الطارئة كوسيلة لرفع المعاناة عن المدين وإعادة التوازن العقدي، ونقترح أيضاً دراسة الأمر من هذه الزاوية.
- ٣ - تأثير أيضاً جائحة فيروس كورونا المستجد موضوع المسؤولية المدنية عن الإصابة بالفيروس ونقل العدوى، ويصلح ذلك أيضاً موضوعاً لدراسة مستقلة في المستقبل.
- ٤ - نقترح أيضاً تناول الضمان الاجتماعي وحماية الفئات المتضررة من آثار انتشار الفيروس، بالبحث والدراسة لما له من أهمية في إبراز الإطار القانوني للمسؤولية الاجتماعية عن ذلك.
- ٥ - تحديد انعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد على عقد العمل يحتاج إلى دراسة مستقلة لبيان التزامات صاحب العمل وحقوق العامل أثناء تلك الجائحة.

المراجع

أولاً - المراجع باللغة العربية:

- أبو سعد، محمد شتا "مفهوم القوة القاهرة"، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ٧٨، عدد ٣٩٤، ٣٩٣ (١٩٨٣). ١٧٥-١٩٥.
- أبو السعود، رمضان. النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٢.
- الأهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام. د. ن، ١٩٩٥، ط ٢.
- الأيوبي، محمد. "المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس كورونا كوفيد ١٩". سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠). ٢٨٧-٢٩٦.
- البكري، محمد عزمي، دعوى التعويض. القاهرة: دار محمود للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧.
- الخضراوي، محمد "الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد على الالتزامات التعاقدية". سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠): ٢٦٨-٢٧٢.
- الخطيب، محمد عرفان، "المبادئ المؤطرة لنظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي الجديد: دراسة نقدية تأصيلية مقارنة". مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السابعة، عدد ٢، العدد التسلسلي ٢٦ (يونيو ٢٠١٩): ١٨٣-٢٣٤.
- السنهوري، عبد الرزاق أحمد. الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام. بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي، ١٩٧٠.
- نظرية العقد، الجزء الثاني. بيروت، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، ط ٢، ١٩٩٨.
- الدناصوري، عز الدين وعبد الحميد الشواربي. المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء. الإسكندرية: منشأة المعارف، ٢٠٠٤.
- الكعبي، محمد عبد الصاحب. المسؤولية المدنية عن أضرار الكوارث الطبيعية: (دراسة مقارنة). الإسكندرية: دار التعليم الجامعي، ٢٠١٩.

- بحار، عبد الرحيم " أثر وباء كورونا المستجد كوفيد ١٩ على الالتزامات التجارية ". سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠) ٣٨٤-٣٩٠.
- تناغو، سمير عبد السيد. مصادر الالتزام. الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، ٢٠٠٩.
- رضوان، أمينة والمصطفى الفوركي. "تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية"، سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠): ٢٧٣-٢٨٦.
- سعد، نبيل إبراهيم. النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ٢٠٠٤.
- سلطان، أنور. مصادر الالتزام في القانون المدني. دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١٢.
- سليمان، خالد علي " الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ". المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ١، عدد ٢ (٢٠٠٦): ١٦٩-١٨٧.
- شليبيك، أحمد الصويغي " نظرية الظروف الطارئة: أركانها وشروطها ". المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ٣، عدد ٢ (٢٠٠٧): ١٦٩-١٩٨.
- عامر، حسين وعبد الرحيم عامر. المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط ٢. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٩.
- عدوي، مصطفى عبد الحميد. الوجيز في قانون العقود الفرنسي الجديد. القاهرة: دار النهضة العربية، ٢٠٢٠.
- غنام، شريف محمد. أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية. دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكاديمية شرطة دبي، ٢٠١٠.
- مرسى، محمد كامل. شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، الالتزامات. القاهرة: المطبعة العالمية، ١٩٥٥.
- مرقس، سليمان. شرح القانون المدني في الالتزامات، الجزء الثاني. القاهرة: المطبعة العالمية، ١٩٦٤.
- مريم، يغلى. التزام العون الاقتصادي بالتسليم المطابق. رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ٢٠١٦/ ٢٠١٧.

- يوسف، مروان. "مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيروس كورونا - كوفيد-١٩ - بين اعتباره قوة قاهرة أم ظرفاً طارئاً". سلسلة إحياء علوم القانون، المغرب (مايو ٢٠٢٠). ٣٣٥-٣١٤.

ثانياً - المراجع باللغة الفرنسية:

- Alexandra, JOUCLARD. "Le coronavirus n'excuse pas tout". linkedin (7/4/2020). <https://www.linkedin.com/pulse/le-coronavirus-nexcuse-pas-tout-jouclard-alexandra/>.(22/5/2020).
- Avocats, Uggc, "LE COVID-19 CONSTITUE-T-IL UN CAS DE FORCE MAJEURE? QUELS EN SONT LES EFFETS SUR LES CONTRATS EN COURS?". Uggc (16/04/2020). <https://www.uggc.com/le-covid-19-constitue-t-il-un-cas-de-force-majeure-quels-en-sont-les-effets-sur-les-contrats-en-cours/>.(20/5/2020).
- Axelrouode,Philippe. "L'épidémie de Covid-19 peut-elle justifier la rupture d'un contrat de travail sur le fondement de la force majeure?". Pragma (30/04/2020).<https://pragma.international/article/lepidemie-de-covid-19-peut-elle-justifier-la-rupture-dun-contrat-de-travail-sur-le-fondement>.(22/5/2020);
- Azaïs Xavier. "CORONAVIRUS (COVID-19): FAUT-IL PRÉFÉRER L'IMPRÉVISION À LA FORCE MAJEURE?". village de la justice (19 MARS 2020). <https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-covid-faut-preferer-imprevision-force-majeure,34184.html>. (30/3/2020).
- Balensi, Benjamin et Gisèle-AiméeMilandou. "Coronavirus : quel usage de la force majeure dans les contrats commerciaux?". taj, (24 mars 2020). <https://taj-strategie.fr/coronavirus-usage-de-force-majeure-contrats-commerciaux>. (29/3/2020).
- Bensussan, Philippe. "Le sort des loyers en matière de bail

- commercial à l'épreuve du COVID-19", LE MONDE DU DROIT (2 AVRIL 2020). <https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/69198-sort-loyers-bail-commercial-covid19-coronavirus.html>. (20/5/2020).
- Chabas, François. "La force majeure". Dalloz, n°13. (septembre 2002).
 - Clément Allais, Amelle Djedi, Soukaina El-Mekkaoui, Christelle Meda et Ekaterina Oleinikova, stagiaires et élèves avocats (EFB École de Formation du Barreau) de Navacelle. "Impacts du Covid-19 en droit administratif, droits de l'homme, droit du travail, droit des contrats et droit pénal". NAVACELLE (2020): 1-29. <http://navacellelaw.com/wp-content/uploads/NavacelleSynthesedesconsequencesduCovid-19.pdf>. (28/3/2020).
 - Danos, Frédéric. "La crise du coronavirus et l'exécution des engagements contractuels". Editions législatives (30.03.2020). <https://www.editions-legislatives.fr/actualite/la-crise-du-coronavirus-et-1%E2%80%99execution-des-engagements-contractuels>. (22/5/2020).
 - Daouda, ZAN. "L'IMPACT DU CORONAVIRUS(COVID-19) SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL". Revue Juridique du Faso (31/3/2020). <https://revuejuris.net/2020/03/31/limpact-du-coronaviruscovid-19-sur-le-contrat-de-travail/>. (15/4/2020).
 - DIAZ, Me Clément. "Le Covid19 constitue-t-il un cas de force majeure pouvant justifier l'inexécution d'une obligation contractuelle?". Avocat.fr, Blog des avocats, Blog de Me Clément DIAZ (27/5/2020). <https://consultation.avocat.fr/blog/clement-diaz/article-35228-le-covid19-constitue-t-il-un-cas-de-force-majeure-pouvant-justifier-l-inexecution-d-une-obligation-contractuelle.html>. (29/5/2020).
 - DOMAT, Didier. Neal LACHMANY et Alexandre DA-

- NION. “Les contrats de sponsoring des clubs sportifs à l’épreuve de l’épidémie de covid-19”, doctrine actu (21/4/2020). <https://www.doctrinactu.fr/post/les-contrats-de-sponsoring-des-clubs-sportifs-a-l-%C3%A9preuve-de-l-%C3%A9pidemie-de-covid-19>. (29/5/2020).
- DUMOND, Sandra. LA DATE ET LE CONTRAT. Thèse de doctorat, Université Lyon III, FACULTE DE DROIT, 2003. <http://www.theses.fr/2003LYO33035>. (15/3/2020).
 - FAUCHOUX, Vincent. “COVID-19 | Coronavirus et force majeure : quels impacts sur vos contrats?”, Deprez Guignot Associates, “DDG”, (2-3-2020). <https://ddg.fr/actualite/coronavirus-et-force-majeure/>. (20/5/2020).
 - FAUCHOUX. “COVID-19 | Coronavirus et force majeure”, ; Celine Taieb, “Contrat commerciaux et Coronavirus”. Alaris Avocats (21-3-2020). <https://www.alaris-law.com/fr/contrat-commerciaux-et-coronavirus/>. (22/5/2020).
 - Grynbaum, Luc Grynbaum. “Force majeure et épidémie de COVID -19”. de gaulle fleurance & Associés (24/03/2020). www.degaullefleurance.com/force-majeure-et-epidemie-de-covid-19/. (28/3/2020).
 - Grynbaum, Luc. “Force majeure et épidémie de COVID -19 : une première décision vient d’être rendue”. le club des jurists (25 mars 2020). <https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/que-dit-le-droit/force-majeure-et-epidemie-de-covid-19-les-premieres-decisions-viennent-detre-rendues/>. (20/5/2020).
 - Guiomard, Pascale. “La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts”. dalloz (4/3/2020). https://www.dalloz-actualite.fr/flash/grippe-epidemies-et-force-majeure-en-dix-arrets#.Xs_uwzozbIU. (15/4/2020).
 - Haddad, Elsa. “Le coronavirus et ses conséquences sur les

- contrats, cas de force majeure ou cause d'imprévision?", village de la justice (27 mars 2020).<https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-ses-consequences-sur-les-contrats-commerciaux-cas-force-majeure,34373.html>.(20/5/2020).
- JOAN DRAY. "L'épidémie de coronavirus constitue -il un événement de force majeure?". legavox blog (26/3/2020). <https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan-dray/epidemie-coronavirus-constitue-evenement-force-28444.htm>.(15/4/2020).
 - Jourdain, Patrice. "Le rôle de l'imprévisibilité de la cause étrangère". RTD Civ (1994): 871. https://actu.dallozetudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/04._2017/rtd_civ_1994_871.pdf. (30/3/2020).
 - ---. Force majeure : l'Assemblée plénière manque l'occasion d'une définition claire. Recueil Dalloz, (2006): 1577. < <https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/Juillet/D2006-1577.pdf> > . (30/3/2020).
 - JULIEN, Philippe. "Coronavirus (Covid-19): faut-il payer les loyers commerciaux du 2e trimestre 2020?". Editions Francis Lefebvre (19/3/2020). <https://www.efl.fr/actualites/affaires/biens-de-l-entreprise/details.html?ref=fe6303cfb-7204-49e7-ab1b-98432000f5a5>.(15/4/2020).
 - Landivaux, Ludovic. "Contrats et coronavirus : un cas de force majeure? Ça dépend...". Dalloz (20 mars 2020). <https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend#.XqIOpY9OLIU> < <https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-depend> > . (29/3/2020).
 - Latieule, Sophie. "COVID-19 ET LOCATIONS MEUBLÉES TOURISTIQUES: LES CONDITIONS D'ANNU-

- LATION À L'ÉPREUVE DE LA FORCE MAJEURE". Fidal (7/4/ 2020).[https://www.fidal.com/fr/actualites/covid-19-et-locations-meublees-touristiques-les-conditions-dannulation-lepreuve-de-la-la.\(15/4/2020\).](https://www.fidal.com/fr/actualites/covid-19-et-locations-meublees-touristiques-les-conditions-dannulation-lepreuve-de-la-la.(15/4/2020).)
- Leclercq, Catherine. "PEUT-ON S'EXONÉRER DU PAIEMENT DE SON LOYER COMMERCIAL DANS LE CONTEXTE DU COVID-19?". village justice (4/4/2020). [https://www.village-justice.com/articles/peut-exonerer-paiement-son-loyer-commercial-dans-contexte-covid,34482.html#nh2-1.\(15/4/2020\).](https://www.village-justice.com/articles/peut-exonerer-paiement-son-loyer-commercial-dans-contexte-covid,34482.html#nh2-1.(15/4/2020).)
 - Ledoux, Valérie. "Coronavirus et (in)exécution des contrats d'affaires". racine avocats (2 Avril 2020): 1-4. [https://www.racine.eu/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus-et-inexecution-du-contrat-daffaires-02042020-2.pdf.\(30/3/2020\).](https://www.racine.eu/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus-et-inexecution-du-contrat-daffaires-02042020-2.pdf.(30/3/2020).)
 - Linais, Pierre. "La force majeure: un remède contre le COVID-19?". Stephenson Harwood (avril 2020). [https://www.shlegal.com/news/la-force-majeure-un-rem%C3%A8de-contre-le-covid-19.\(20/5/2020\).](https://www.shlegal.com/news/la-force-majeure-un-rem%C3%A8de-contre-le-covid-19.(20/5/2020).)
 - Makela, Roger Masamba. "L'IMPOSSIBLE ET LE CONTRAT". (2015): 1-12. [http://www.daldewolf.com/documents/document/2015122111503247_52_roger_masamba__1_-x27_impossible_et_le_contrat__fv1__09_02_14.pdf.\(15/3/2020\).](http://www.daldewolf.com/documents/document/2015122111503247_52_roger_masamba__1_-x27_impossible_et_le_contrat__fv1__09_02_14.pdf.(15/3/2020).)
 - Marie-France STEINLE-FEUEBACH, Hervé ARBOUSSET, Marie-Pierre CAMPROUX- DUFFRENE, Marie DE-ROCHE, Françoise GEISMAR, Valentine HEI NTZ, Caroline LACROIX et Claude LIENHA RD. INONDA-TIONS: RESPONSABILITES ET FORCE MAJEURE Col-mar, France: Université de Haute-Alsace, 2002.
 - Mathias, Avocats. "Covid-19: un cas de force majeure?". avocats-mathias (20 mars 2020). <https://www.avocats->

- mathias.com/actualites/force-majeure-impacts-contrat.(20/5/2020).
- Mazeaud, Léon et Henri Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle, tome 2. Paris: Librairie du Recueil Sirey, société anonyme, 1934.
 - MEDEF. “L’impact du Covid-19 dans les relations contractuelles”, aacc, (10 mars 2020): 1-3 <http://www.aacc.fr/uploads/file/file/000/000/770/12601-medef-impact-du-covid-19-dans-les-relations-contractuelles.pdf>. (29/3/2020).
 - MOILLE, CÉLINE. “Force majeure et Covid-19 : une notion simple à invoquer en matière contractuelle?”. WOLTERS KLUWER FRANCE (25/3/2020). <https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/contrat/26561/force-majeure-et-covid-19-une-notion-simple-a-invoquer-en-matiere-contractuelle>.(15/4/2020).
 - Moisan, Pierre. “Technique contractuelle et gestion des risques dans les contrats internationaux : les cas de force majeure et d’imprévision”. Les Cahiers de droit 35, n°2(1994): 281-334. <https://core.ac.uk/download/pdf/59347623.pdf>. (5/5/2020).
 - Moury, Jacques. “Force majeure éloge de la sobriété”, RTDciv: Revue Trimestrielle de droit civil, N° 3 (2004): 471. < <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02247568> > . (30/3/2020).
 - Nicolas, Olivier. “Coronavirus : Peut-on invoquer la Force Majeure?”. echos (6 avril 2020). <https://echos-judiciaires.com/actualite/tribune-coronavirus-force-majeure/>.(27/3/2020).
 - NIVERT, Alexandre. “Entre COVID-19 et droit commun des contrats : la notion de force majeure”. DOCTRIN’ACTU (23/3/2020). <https://www.doctrinactu.fr/post/entre-covid->

- 19-et-droit-commun-des-contrats-la-notion-de-force-majeure.(28/3/2020).
- Planiol, Marcel et Georges Ripert. Traité pratique de droit civil français tome 7, 2ème édition. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1931.
 - Rémy-Néris, Nicolas. “L’exécution des contrats commerciaux à l’épreuve du Covid-19”, Grant Thornton (1-4-2020). <https://www.grantthornton.fr/fr/insights/articles-et-publications/2020/lexecution-des-contrats-commerciaux-a-lepreuve-du-covid-19/>.(22/5/2020).
 - Rossi-Landi, Romain. “Non-paiement des loyers: ce que prévoit le droit pour les baux commerciaux. BFM Immo (25/3/2020). <http://rossi-landiavocat.fr/2020/03/25/non-paiement-des-loyers-ce-que-prevoit-le-droit-pour-les-baux-commerciaux/>.(15/4/2020).
 - Sabatier, David. “La résiliation des contrats pour force majeure en raison du covid-19 / coronavirus”, 1862 Avocats. <https://www.1862-legal.com/blog-avocat-droit-immobilier/2020/3/15/doit-on-sattendre-une-vague-de-rsiliation-des-contrats-pour-force-majeure-en-raison-du-covid-19-coronavirus->.(20/5/2020).
 - Sériaux, Alain. DROIT DES OBLIGATIONS, 2ème édition. Paris: Presses universitaires de France (PUF), 1998), 244.
 - Sévère, Christine et Claire Picard. “COVID-19 Force majeure, fait du prince, imprévision et exception d’inexécution”, Dentons (19 mars 2020). <https://www.dentons.com/fr/insights/alerts/2020/march/19/covid-19-force-majeure-contingency-and-default-exception>.(20/5/2020).
 - Tavenne, Séverine. “Contrats et covid-19: quid de la force majeure?”. Le petit juriste (3/4/2020). <https://www.lepetitjuriste.fr/contrats-et-covid-19-quid-de-la-force-majeure/>.(15/4/2020).

- TOUAHRI, Assia. La responsabilité civile du fait du dommage nucléaire civil. thèse de doctorat, UNIVERSITE DE LIMOGES, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 2018.
- Touzet, Philippe et Maya Dami. "Covid-19 : une application pratique de la force majeure".(6 Avril 2020). https://www.parabellum.pro/Covid-19-une-application-pratique-de-la-force-majeure_a856.html. (20/5/2020).
- Tunc, André "Force majeure et absence de faute en matière délictuelle", RTD Civ (1946).187.
- VAN ZUYLEN, Jean. "La force majeure en matière contractuelle: unconcept unifié? Réflexions à partir des droits belge, français et hollandaise". Revue Générale de Droit Civil Belge - Kluwer, TBBR/RGDC (2013): 406-421.https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A124936/datastream/PDF_01/view. (15/3/2020).

The Extent to Which Force Majeure Conditions Apply to the Coronavirus Pandemic (Covid-19) within the Framework of Civil Contracts: A Comparative Study in the Egyptian and French Laws

Dr. Haytham Elsayed Ahmed Eissa

The coronavirus pandemic (Covid-19) has impacted the performance of contractual obligations by making them impossible to fulfill in some cases, due to government measures taken by the state to counteract the virus, the infection with it, risks of infection, or the economic consequences of its outbreak; this made us think about studying the topic of the extent to which the conditions of force majeure apply to the effects of that pandemic, in order to clarify the legal basis on which the debtor can rely in proving lack of his contractual liability that may arise from non-performance of the contract; which required us to divide this research into four sections; the first is titled: the extent to which the coronavirus pandemic is considered an external event, the second is titled: the extent to which the coronavirus pandemic is considered an unpredictable event, the third is titled: the extent to which the coronavirus pandemic is considered an irresistible event, and last section is titled: the extent to which the coronavirus pandemic is considered an event that would make the performance of obligation impossible.

Keywords: coronavirus pandemic, force majeure, contractual obligations, contractual liability.

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مجلة علمية محكمة ربع سنوية، تقبل النشر فيها باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وهي تعنى بنشر كل ما يتصل بمبادئ اهتمام المجلة، وذلك عن:

- البحوث والدراسات.
- التعليق على أحكام قضائية.
- ملخصات الرسائل الجامعية.
- التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات.
- عرض الكتب القانونية الجديدة ومراجعتها.



الاشتراكات

في الكويت	في الدول العربية	في الدول الأجنبية
٣ دنانير	٤ دنانير	١٥ دولاراً
١٥ ديناراً	١٥ ديناراً	٦٠ دولاراً
المؤسسات		

ترسل البحوث بعنوان رئيس تحرير مجلة كلية القانون الكويتية العالمية على العنوان التالي:

فاكس: +96522280209

الكويت - مدينة الدوحة - قطعة 4 - قسيمة 800005

www.kilaw.edu.kw

ص.ب: 59062 - الرمز البريدي 93151

هاتف: +96522280222 - مباشر: +96522280181 kilawjournal@kilaw.edu.kw

الكويتية العالمية
كلية القانون
المجلة

إصدار شهري

« تصدر مؤقتاً كل ثلاثة أشهر »

نُعنى بشؤون الأنظمة والمحاماة



أهداف المجلة :

- * طرح ومعالجة شتى قضايا العصر ذات الطابع الشرعي والقانوني مع التركيز على إبراز الفقه الإسلامي وتبيين تميزه وشموليته في معالجة تلك القضايا .
- * أن تكون ساحة إعلامية للنوي الإختصاص الشرعي والقانوني يقدمون من خلالها البحوث والدراسات ، فضلاً عن التحقيقات الصحفية المتميزة ذات العلاقة .
- * نشر الوعي بأهمية المحاماة ، وحاجة الناس إليها والتأكيد على أن المحاماة علم ، وفن ، ورسالة .

دعوة للمشاركة :

- * يسر « المحامي » دعوتكم للمساهمة عبر صفحاتها في كل الشؤون الشرعية والقانونية من بحوث ودراسات ومقالات أو تحقيقات .
- * تقدم المجلة مكافأة عن المقالات والمواضيع التي تقبلها للنشر .

رئيس التحرير :

المحامي / طارق المزني

سكرتير التحرير :

حسين العسكر

مسؤول اشتراكات :

خالد يسر

الهيئة الاستشارية :

فضيلة الشيخ / عبد الله البسام

فضيلة الشيخ / مصطفى الزرقا

فضيلة الشيخ / سعد البريك

سعادة الدكتور / سعود الدرب

سعادة الأستاذ / عبدالله السبهان

سعادة الدكتور / عبدالفتاح خضر

سعادة المستشار / أحمد منير فهمي

الاشتراكات : المملكة العربية السعودية : ١٠٠ ريال في السنة (للأفراد والمؤسسات)

البلد الأخرى : ٢٧ دولار أمريكي (للأفراد والمؤسسات)

تدفع الاشتراكات باسم المجلة ، بشيك مسحوب على أحد المصارف السعودية أو بتحويل مصرفي باسم رئيس التحرير : حساب رقم ٥٦٤٩/١ - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - الرياض - فرع الروضة .

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير : ص . ب ٦٨٧٤ الرياض (١١٤٥٢)

هاتف : ٤٦٥٢٧٢٥ (٩٦٦١) / فاكس : ٤٦١٣١٥٢ (٩٦٦١)

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية



مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت
صدر العدد الأول منها في يناير عام 1975م

رئيس التحرير

أ. د. عثمان حمود الخضر

ترحب المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بشؤون
منطقة الخليج والجزيرة العربية في مختلف المجالات العلمية.

ومن أبوابها

- البحوث العربية
- البحوث الإنجليزية
- البحوث الفرنسية

الاشتراكات

ترسل قيمة الاشتراك مقدماً بشيك لأمر - جامعة الكويت
مسحوب على أحد المصارف الكويتية

داخل دولة الكويت : للأفراد : 3 دنانير - للمؤسسات : 15 ديناراً
الدول العربية : للأفراد : 4 دنانير - للمؤسسات : 15 ديناراً
الدول الغير عربية : للأفراد : 4 دنانير - للمؤسسات : 15 ديناراً

توجه جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

ص.ب: 170073 الخالدية - الرمز البريدي: 72451 الكويت

تلفون: 24984066 - 24833705 (965)

البريد الإلكتروني: jgaps@ku.edu.kw

موقع المجلة: www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps

Facebook: [jgaps.kuniv](https://www.facebook.com/jgaps.kuniv)

Twitter: [jgaps_ku](https://twitter.com/jgaps_ku)

Instagram: [jgaps.ku](https://www.instagram.com/jgaps.ku)

المجلة العربية للعلوم الإدارية



Arab Journal of Administrative Sciences

رئيس التحرير: د. علي راشد المطيري

- صدر العدد الأول في نوفمبر ١٩٩٣ First issue, November 1993.
- علمية محكمة تعنى بنشر البحوث الأصيلة في مجال العلوم الإدارية Refereed journal publishing original research in Administrative Sciences
- تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت ثلاثة إصدارات سنوياً (يناير - مايو - سبتمبر) Published by Academic Publication Council, Kuwait University, 3 issues a year (January, May & September)
- تساهم في تطوير الفكر الإداري واختبار الممارسات الإدارية وإثرائها Contributes to developing and enriching administrative thinking and practices
- مسجلة في قواعد البيانات العالمية Listed in several international databases.
- تخضع للتقييم الأكاديمي الخارجي Reviewed periodically by international referees for high academic standards

الاشتراكات

الكويت: 3 دنانير للأفراد - 15 ديناراً للمؤسسات - الدول العربية: 4 دنانير للأفراد - 15 ديناراً للمؤسسات
الدول الأجنبية: 15 دولاراً للأفراد - 60 دولاراً للمؤسسات

توجه المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان الآتي:

المجلة العربية للعلوم الإدارية - جامعة الكويت ص.ب: 28558 الصفاة 13146 - دولة الكويت

هاتف: (965)24827317 - Tel: أو 4734 / 4416 / 24984415 (965) - فاكس: (965)24817028

E-mail: ajas@ku.edu.kw

Web Site: <http://www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajas>

ajas_ku

ajas_ku

المجلة التربوية



مجلة فصلية، تخصصية، محكمة
تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت

رئيس التحرير: أ. د. فهد عبدالله الخزي

نشر:

- البحوث التربوية المحكمة
- مراجعات الكتب التربوية الحديثة
- محاضر الحوار التربوي
- التقارير عن المؤتمرات التربوية
- وملخصات الرسائل الجامعية

❖ تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية.

❖ تنشر لأساتذة التربية والمختصين بها من مختلف الاقطار العربية والدول الأجنبية.

الاشتراكات:

في الكويت: ثلاثة دنائير للأفراد، وخمسة عشر ديناراً للمؤسسات.
في الدول العربية: أربعة دنائير للأفراد، وخمسة عشر ديناراً للمؤسسات.
في الدول الأجنبية: خمسة عشر دولاراً للأفراد، وستون دولاراً للمؤسسات.

توجه جميع المراسلات إلى:

رئيس تحرير المجلة التربوية - مجلس النشر العلمي ص.ب. ١٣٤١١ كيفان - الرمز البريدي 71955
الكويت هاتف: ٢٤٨٤٦٨٤٣ (داخلي ٤٤٠٣ - ٤٤٠٩) - مباشر: ٢٤٨٤٧٩٦١ - فاكس: ٢٤٨٣٧٧٩٤

E-mail: joe@ku.edu.kw

مَجَلَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالْإِسْلَامِ

فَصْلِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ مَحْكُمَةٌ تَصْدُرُ عَنْ مَجْلِسِ النُّشْرِ الْعِلْمِيِّ بِجَامِعَةِ الْكُوَيْتِ
تُعْنَى بِالْبَحْثِ وَالدراسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ

رئيس التحرير الأستاذ الدكتور: عبد الرزاق خليفة الشايحي

صدر العدد الأول في رجب ١٤٠٤ هـ - أبريل ١٩٨٤ م

- * تهدف إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.
- * تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسير، وحديث، وفقه، واقتصاد وتربية إسلامية، إلى غير ذلك من تقارير عن المؤتمرات، ومراجعة كتب شرعية معاصرة، وفتاوى شرعية، وتعليقات على قضايا علمية.
- * تنوع الباحثون فيها، فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي.
- * تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط التي التزمت بها المجلة، ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة الإسلامية، بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة، ويعمل على رفعة شأنها، نسال المولى عز وجل مزيداً من التقدم والازدهار.

جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير

ص ب ١٧٤٣٣ - الرمز البريدي: 72455 الخالدية - الكويت هاتف: ٢٤٨١٢٥٠٤ - ٢٤٩٨٤٧٢٣ - ٢٤٩٨٨٠٩٥
فاكس: ٢٤٨١٠٤٣٤

العنوان الإلكتروني: E-mail - jsis@ku.edu.kw

issn: 1029 - 8908

عنوان المجلة على شبكة الإنترنت: <http://pubecouncil.kuniv.edu.kw/JSIS>

اعتماد المجلة في قاعدة بيانات اليونسكو Social and Human Sciences Documentation Center

في شبكة الإنترنت تحت الموقع www.unesco.org/general/eng/infoserv/db/dare.html

غياب التشريعات الوبائية في النظام القانوني الكويتي وتداعيات تعليق جلسات مجلس الأمة

الدكتور/ عبدالرحمن الهاجري

المستشار/ محمود محمد خميس

ملخص:

تسببت مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في توجه العديد من الدول لتبني تشريعات متفاوتة من حيث الصرامة على أمل الحد من انتشار هذه الجائحة، ومن بين هذه الدول فرضت دولة الكويت قيوداً يمكن القول بأنها صارمة في شهر مايو، إذ شملت ما يبدو أنه متعارض مع الدستور. يتناول هذه المقالة بالبحث أوجه التشابه والاختلاف بين الإجراءات الكويتية عنها في الدول الأخرى ويقدم تحليلاً للتشريعات واللوائح الخاصة بمكافحة الوباء. يتألف منهج البحث من دراسات مقارنة لحالات متعددة مع المصادر الأولية والأدبيات الأكاديمية والمقالات الإخبارية باعتبارها المصادر الرئيسية للمعلومات. وتشير النتائج التي توصل إليها البحث إلى أن قرار تبني اللوائح أو التشريعات التي تم سنّها على وجه الاستعجال على الرغم من تعارضها المحتمل مع الدساتير لم يكن سلوكاً انفرادياً من قبل دولة الكويت فحسب، ولكن نظراً لمخاطر فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، فقد اعتبرت هذه المخالفات على أنها انتهاكات لها ما يبررها، وتم إضفاء الشرعية عليها من خلال الإجراءات التي تم تنفيذها، وذلك من خلال تمكين الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قاسية لمنع تفشي هذه الجائحة. وعلى الرغم من إقرار منظمة الصحة العالمية للتشريعات الكويتية الخاصة بمكافحة الأوبئة، إلا أنها واجهت بعض المشكلات، منها عدم وجود اعتبارات تتصل بالأوبئة في الدستور الكويتي يضاف إليها تعليق جلسات مجلس الأمة. وقد شملت التداعيات المترتبة على ذلك التوصية بإدخال مواد محددة تركز على مكافحة الأوبئة ضمن الدستور الكويتي، فضلاً عن تضمين أحكام تجيز عقد جلسات مجلس الأمة.

- Nicholas Fandos, With Move to Remote Voting, House Alters What It Means for Congress to Meet (The New York Times 15 May 2020)
- Othman Abdul Malek Al-Saleh, Constitutional Regime and Political Institution in Kuwait (Kuwait University 2003).
- Parmet W and Sinha M 'Covid-19 - The Law and Limits of Quarantine' (2020) 382 The New England Journal of Medicine e28.
- Patro B, Tripathy J and Kashyap R 'Epidemic diseases act 1897, India: Whether sufficient to address the current challenges?' (2013) 18 Journal of Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences 109-111.
- Remuzzi A and Remuzzi G 'COVID-19 and Italy: what next?' (2020) 395 The Lancet 1225-1228.
- The Explanatory Note on the Kuwaiti Constitution at the National Assembly website: <http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=51> accessed 21 May 2020.
- The UK Parliament website:
- U.S. Embassy in Kuwait, 'COVID-19 Information' (U.S. Embassy in Kuwait, 2020) accessed 20 May 2020.
- UK Parliament website: <https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/uk-parliament-coronavirus-update/> accessed 23 May 2020.
- World Health Organisation, 'Joint external evaluation of IHR core capacities of the state of Kuwait' (WHO, 2017) accessed 20 May 2020.

- Gostin L, Sridhar D and Hougendobler D 'The normative authority of the World Health Organization' (2015) 129 The New England Journal of Medicine 854-863.
- Hair J, Celsi M, Money A and Page M, Essentials of Business Research Methods(Routledge 2015).
<https://www.nytimes.com/2020/05/15/us/politics/remote-voting-house-coronavirus.html> accessed 22 May 2020.
<https://www.parliament.uk/business/news/2020/april1/speaker-outlines-virtual-meeting-plan/> accessed 19 May 2020.
<https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-parliament-idUSKCN21W2PL> accessed 23 May 2020.
- https://www.washingtonpost.com/politics/house-poised-to-adopt-historic-changes-allowing-remote-voting-during-pandemic/2020/05/15/b081d9f2-96ab-11ea-91d7-cf4423d47683_story.html accessed 22 May 2020.
- Kandel N, Chungong S, Omaar A and Xing J 'Health security capacities in the context of COVID-19 outbreak: an analysis of International Health Regulations annual report data from 182 countries' (2020) 395 The Lancet 1047-1053.
- Kapur M, 'A 123-year-old law, once used to imprison freedom fighters, is India's primary weapon against coronavirus' (Quartz India, 2020) accessed 3 May 2020.
- KUNA, 'Government desires delaying Wednesday's session' (KUNA, 2020) accessed 12 May 2020.
- KUNA, 'Kuwait in full curfew May 10, public allowed to exercise two hours daily' (KUNA, 2020) accessed 10 May 2020.
- KUNA, 'Kuwait's MoH urges public to abide by home quarantine rules' (KUNA, 2020) accessed 1 May 2020.
- KUNA, 'Photo of the day' (KUNA, 2020) accessed 21 May 2020.
- KUNA, 'Photo of the day' (KUNA, 2020) accessed 3 May 2020.
- May T, Social Research: Issues, Methods and Research (Fourth Edition, Open University Press 2011)
- National Assembly Studies, 'The Explanatory Note on the Kuwaiti Constitution and the extent of its binding'. At National Assembly website: <http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=658> accessed 20 May 2020.

postponing sessions for the safety of the Assembly members. Accordingly, this research recommends, to avoid any constitutional conflict and absence of legislative powers and to guarantee the convening of the National Assembly sessions, adopting new legislations that are of importance such as holding the sessions virtually and this can be done, with the coordination with the ministers, by calling for an urgent session to be held by inviting enough members to meet the quorum in order to minimize any risk. Finally, due to the lack of research on this topic, future research and investigations are highly needed to deal with the current crisis and any future crises that may happen.

Bibliography

Primary Sources

- Constitution of Kuwait, 1962, art. 69, 71, 90, 181, 167-169.
- UK Public Health Act 1875, art. 134-140.
- New Zealand Epidemic Preparedness Act 2006.
- Kuwait, Law No. 8/1969

Secondary Sources

- Arab Times, 'Holding Assembly sessions electronically requires parliamentary proposal or govt draft law: Dr Faili' (Arab Times, 2020) accessed 21 May 2020.
- Arab Times, 'Kuwait has right to impose medical quarantine' (Arab Times, 2020) accessed 21 May 2020.
- Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn S & Napoli R, 'Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)' (StatPearls Publishing, 2020) accessed 1 May 2020.
- Committee on Rules at <https://rules.house.gov/bill/116/h-res-PIH-remote-voting-proxy> accessed 21 May 2020.
- Eriksson P and Kovalainen A, Qualitative Methods in Business Research (SAGE 2015).
- Gilani I, 'India, Pakistan grappling with archaic epidemic law' (Anadolu Agency, 2020) accessed 3 May 2020.
- GorrissenFederspiel, 'COVID-19: The Danish Epidemic Act' (GorrissenFederspiel, 2020) accessed 1 May 2020.

Therefore, a constitutional amendment may not be required in order to adopt the virtual and online sessions for the National Assembly, but a new legislation.

The presented article has some critical limitations. First, due to the restrictions of the article format, it did not introduce many cases for comparison. However, the presented ones did demonstrate certain patterns, which were helpful for the analysis. Furthermore, as is common for qualitative research, it is not reasonable to attempt to view the findings as generalisable⁽⁵⁸⁾. It worth noting that since this topic is fresh and has not been explored before, additional data may change the presented implications rather significantly. As a result, further research is highly needed.

Indeed, regarding the future investigation, it is reasonable to propose a more in-depth inquiry into the individual cases that have been presented in case sufficient literature can be found for them. Since the scope of this article was limited, it could not go into details, but future research can carry out inquiries into individual countries or legislation pieces and apply the lessons learned from them to Kuwait.

Conclusion and Recommendation

COVID-19 has become a global pandemic, which prompted many governments to take direct action that can produce important implications for pandemic- and other healthcare-related legislation. The existing literature shows that historically, epidemic legislation has been implemented with diverse outcomes, and currently, many countries, including Kuwait, introduce regulations that would be against constitutional provisions without the appropriate laws. On the other hand, the specifics of the situation of a pandemic arguably justify such violation provided that it is temporary and reasonable. Kuwait uses a set of legislative acts that empower its medical agencies to handle epidemics, and the measures received the approval of the World Health Organisation. However, the National Assembly sessions must have additional legislation to enable them to meet remotely or any other safe way to ensure the legitimacy of

(58) Eriksson and Kovalainen, *supra* (n 7) at 116.

Assembly⁽⁵²⁾. Accordingly, and although the martial law is not currently applicable, Article 106 prohibits any postponement of the National Assembly for more than two months⁽⁵³⁾, thus the current suspension of the National Assembly without a new legislation in this regard could result in a new constitutional concern and conflict, knowing that no National Assembly sessions were held for a period that exceeds two months to date. Consequently, this could lead the executive to have wider powers in the absence of the National Assembly Members duties.

Given the fact that a highly contagious disease holds severe health risks for National Assembly, these concerns may need to be rectified. Specifically, the legislation meant to enable online Assembly sessions could help in such events by adopting the United States, United Kingdom patterns⁽⁵⁴⁾ or any other appropriate pattern in order to enable the lawmakers in Kuwait to fulfil their constitutional duties, as well as the modification of the Constitution to include epidemics as a form of emergencies that might affect the National Assembly.

It is important to note, despite the fact of the Kuwaiti Constitution in accordance with Article 90, which states. 'Every meeting held by the Assembly at a time or place other than that assigned for its meeting shall be invalid, and resolutions passed thereat shall, by virtue of law, be void'⁽⁵⁵⁾, according to the Explanatory Note on the Kuwaiti Constitution regarding the same Article, it does not preclude the Assembly to hold a meeting at a time or place other than that assigned if necessary, and this is in accordance with the necessity theory and prescribed legal conditions⁽⁵⁶⁾. According to the constitutional experts Othman Abdulmalek and Othman Khalil Othman opinions, the explanatory note shall be binding⁽⁵⁷⁾.

(52) Othman Abdul Malek Al-Saleh, *Constitutional Regime and Political Institution in Kuwait* (Kuwait - Dar Alkutub 2003) at p. 456 (Arabic source).

(53) Constitution of Kuwait, 1962, art. 106.

(54) The UK Parliament regarding the virtual meeting and Committee on Rules, *supra* (n 23) and (n 24).

(55) Constitution of Kuwait, 1962, art 90.

(56) See the Explanatory Note on the Kuwaiti Constitution at the National Assembly website: <http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=51> accessed 21 May 2020.

(57) National Assembly Studies, 'The Explanatory Note on the Kuwaiti Constitution and the extent of its binding'. At National Assembly website: <http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=658> accessed 20 May 2020.

in extreme situations. Given that the Kuwaiti constitution already points out an exception to constitutional rights in the form of Martial law and emergency situations⁽⁴⁷⁾, an introduction of similar exception specifically for urgent situations specified by law appears reasonable. A new-legislation that specifies the importance of epidemic legislation could assist with the National Assembly concern.

Indeed, an interesting issue that has been encountered during the literature review is the problem of postponing the National Assembly sessions, which are especially critical now as quickly enacted decrees are referred to the Assembly⁽⁴⁸⁾. According to the Constitution, under no circumstances, the suspension of the National Assembly shall not occur even as a result of Martial Law, and this is in accordance with 181⁽⁴⁹⁾. Furthermore, as highlighted by Dr Al-Faili, the current legislation does not support the introduction of online-based Assembly sessions⁽⁵⁰⁾. This approach is currently adopted in the United States where the members of the House of Representatives must be present when voting. Nevertheless, the United States have rectified this rule and allowed the lawmakers to vote and hold their hearings virtually due to the current situation with Covid-19⁽⁵¹⁾.

Apart from that, it is imperative to mention that the former head of Faculty of Law at Kuwait University Dr. Othman Abdul Malik, demonstrates that Article 181 of the Kuwaiti constitution has a significant and serious loophole as the executive can apply the martial law by dissolving the National Assembly, thus applying the martial law temporary until the first session of the new National Assembly. Dr. Othman continues to state that in such scenario, the martial law can be valid for a period of two months, whereby the executive can exercise an exceptional and wide powers without any supervision by the National

(47) Constitution of Kuwait, 1962, art. 71, 181.

(48) Constitution of Kuwait, 1962, art. 71.

(49) Constitution of Kuwait, 1962, art 181.

(50) Arab Times, *supra* (n 26).

(51) Committee on Rules at <https://rules.house.gov/bill/116/h-res-PIH-remote-voting-proxy> accessed 21 May 2020. Further details see the Article by Nicholas Fandos, With Move to Remote Voting, House Alters What It Means for Congress to Meet (The New york Times 15 May 2020); see para 1 and 3. <https://www.nytimes.com/2020/05/15/us/politics/remote-voting-house-coronavirus.html> accessed 22 May 2020.

Analysis and Discussion

Given how recent COVID-19 events are, there is a substantial amount of literature on the topic. Naturally, it is still limited, but in addition to that, there is some older literature on epidemic legislation. Finally, there are news articles, which are especially helpful for the most recent events. Thus, the sources for the investigation of Kuwait and its comparison with other cases can be found. That said, the topic of epidemic legislation and regulations is not researched exhaustively, especially when Kuwait is concerned, so more research on it is possible.

The presented literature can be summarised as follows. COVID-19 is a significant issue, which made many governments all over the world introduce rather severe preventative measures. Kuwait, as one of such countries, has the relevant legislation, even as new regulations become enforced. A comparative analysis of several cases can help to understand what general practices are currently employed to deal with such issues.

The worldwide experience of regulations and legislation can be easily compared to that of Kuwait. All the analysed legislation pieces are generally concerned with providing the government with the power to perform the actions that are necessary to stop and manage epidemics. They tend to focus on restrictions, which may be justified since they tend to affect the rights of citizens, but they also often incorporate provisions on medical care and resource management.⁽⁴³⁾ In other words, most laws are comprehensive, and the one that is not (the Epidemic Diseases Act 1897 of India) is an outdated piece of legislation that requires a revision⁽⁴⁴⁾. In summary, the Kuwaiti legal provisions and recent actions are generally in line with the current and prior worldwide practices, and they are approved by the World Health Organisation⁽⁴⁵⁾.

Regarding the concerns about constitutional rights, the Danish Act⁽⁴⁶⁾ demonstrates that aggressive action that may affect them may be justified in extreme situations. Furthermore, it is an example of a legislative act that is specifically designed to override constitutional rights

(43) See the New Zealand Epidemic Preparedness Act 2006; the UK Public Health Act 1875

(44) Patroet al., *supra* (n 28).

(45) World Health Organisation, *supra* (n 35).

(46) GorrisenFederspiel, *supra* (n 3).

which functions more or less the way the above-described regulations of other countries do. According to Dr Al-Faili, the law fully enables medical agencies to introduce restrictions, including quarantine measures, which have been established by the government in May, despite the constitutional right to assembly⁽³⁹⁾.

In the Constitution, the existence of exceptional situations has been recognised by the government. Specifically, in Article 69 of the Constitution, it is stated that Martial Law should be introduced during the times of war, proclaimed by the Amir and referred to the National Assembly every three months⁽⁴⁰⁾. Martial Law is an exception to the Articles of the Constitution, which is stated in Article 181⁽⁴¹⁾. The Article specifies that the provisions of the Constitution, as well as the National Assembly, should not be suspended with the exception of Martial Law enforcement. Additionally, the Article points out that Martial Law should have specified limits that must be taken into account. Furthermore, Article 71 specifies the existence of special events that are classified as emergencies and that can involve quickly enacted decrees, which still need to be referred to the National Assembly and are not supposed to be "contrary to the Constitution."⁽⁴²⁾ Thus, there are some provisions for exceptional situations in the Kuwaiti Constitution and legislation, but they are not explicitly connected to epidemics.

(39) Arab Times, 'Kuwait has right to impose medical quarantine' (Arab Times, 2020) accessed 21 May 2020.

(40) Constitution of Kuwait, 1962, art. 69 which states that "The Amir shall proclaim Martial Law in cases of emergency as determined by Statute and in accordance with the procedure stipulated therein. Martial Law shall be proclaimed by Decree, and that Decree shall be submitted to the National Assembly within the fifteen days to decide the course of Martial Law. Where this takes place during the Assembly's recess the matter shall be submitted to the new Assembly at its first meeting. The continuance of Martial Law shall be subject to promulgation of a Resolution passed by a majority of the members constituting the Assembly. In all circumstances the matter must be referred, under the aforementioned conditions, to the National Assembly every three months.

(41) Constitution of Kuwait, 1962, art. 181. Which states that "No provision of this Constitution may be suspended save in the course of Martial Law and within the limits determined by Law. National Assembly conventions may not, in any circumstance, be suspended during that period, nor may the immunity of its members be violated"

(42) Constitution of Kuwait, 1962, art. 71.

Regarding the more recent epidemic acts, the 2020 amendments to the Danish Epidemic Act were adopted specifically in response to COVID-19. They involved severe restrictions, including the closing of various businesses, prohibition of large gatherings and meetings and public transport regulations with financial coercion methods (fines). However, it also incorporated provisions for ensuring the functioning of the country, including the management of food supplies and medications⁽³³⁾. Gorrisen Federspiel points out that the presented measures were in conflict with different constitutional rights, but the Minister of Health was empowered by the Act to impose such rules and enact them immediately, provided that the restrictions would be temporary and reasonable⁽³⁴⁾. To summarise, epidemic legislation has been practised all over the world, and it has been introduced to empower governments to take rapid, aggressive action, which may not be in line with constitutional rights but which is required for preventing and managing epidemics.

It should also be pointed out that the World Health Organisation has been involved in what can be considered health legislation with both soft recommendations two hard ones, including the International Health Regulations⁽³⁵⁾. The latter is directly connected to epidemicmanagement can be used to assess health issues outbreaks preparedness⁽³⁶⁾. Therefore, there are supra-governmental regulations that are relevant for epidemics as well.

In accordance with the International Health Regulations, the World Health Organisation has been carrying out assessments of Kuwait preparedness to deal with health crises. According to a recent report, Kuwait's capacities are "high," with the relevant legislation being regularly reviewed and updated; the infection-related capacities of the country are predominantly very well-developed⁽³⁷⁾. Regarding the legislation, it includes the Emiri Law on Communicable Diseases⁽³⁸⁾,

(33) GorrisenFederspiel, *supra* (n 3).

(34) *Ibid*.

(35) Lawrence Gostin, Devi Sridhar andDaniel Hougendobler 'The normative authority of the World Health Organization' (2015) 129 *The New England Journal of Medicine* 854, 856-858.

(36) Nirmal Kandel et al.,*supra* (n 5) 1049-1050.

(37) World Health Organisation, 'Joint external evaluation of IHR core capacities of the state of Kuwait' (WHO, 2017) accessed 20 May 2020.

(38) Kuwait, Law No. 8 of 1969.

Health Act 1875, as well as the New Zealand Epidemic Preparedness Act 2006. The first of these documents was introduced in response to a plague epidemic in Bombay, and it specified that the government should be allowed to introduce special measures to prevent epidemics, including the restriction of public assembly, with penalties named⁽²⁸⁾. While an argument can be made that the law can be helpful in the cases of epidemics, it is outdated and does not provide sufficient guidelines on epidemics management. Additionally⁽²⁹⁾, it has been misused to imprison freedom fighters, which is why some changes in this piece of legislation may be required⁽³⁰⁾.

The UK Public Health Act 1875 has been amended since its introduction to fit the modern-day needs of the UK. However, even its original version involved a set of provisions for the prevention of epidemic diseases, which empowered local governments to introduce regulations, including those related to burials, visitation, and medical aid⁽³¹⁾. It also specified violation penalties, vessel regulations, and the order of regulation publications. In other words, it enabled governments to take aggressive actions to stop pandemics.

The New Zealand Epidemic Preparedness Act 2006 provides similar special powers to the Prime Minister of the country, who is instructed to reach an agreement with the Minister of Health. The Prime Minister can then introduce epidemic notices, which signify an exceptional situation that can involve taking aggressive action to prevent and slow down the spread of an epidemic⁽³²⁾. It is a particularly well-detailed epidemic-focused legislation, and it specifies the limits of the actions and modifications to regulations which can be offered to prevent power abuse.

(28) Binod K. Patro, Jaya Prasad Tripathy, and Rashmi Kashyap 'Epidemic diseases act 1897, India: Whether sufficient to address the current challenges?' (2013) 18 *Journal of Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences* 109-110; see also Gilani, 'India, Pakistan grappling with archaic epidemic law' (Anadolu Agency, 2020) accessed 3 May 2020

(29) ManaviKapur, 'A 123-year-old law, once used to imprison freedom fighters, is India's primary weapon against coronavirus' (Quartz India, 2020) accessed 3 May 2020.

(30) Patroet al., supra (n 28).

(31) UK Public Health Act 1875, art. 134-140.

(32) New Zealand Epidemic Preparedness Act 2006.

coronavirus (COVID-19), many steps have been taken to enable the Parliament to continue to fulfil its constitutional duties and to preserve the operation of parliament⁽²²⁾ and this was by adopting virtual means by holding their meetings via online video links⁽²³⁾. Furthermore, in the United States, a huge step was taken by the House of Representatives when they acted to allow the lawmakers to work and vote remotely and do their hearings virtually despite the fact that it is constitutionally required for them to be physically present⁽²⁴⁾.

In Kuwait, such changes could contradict the country's Constitution, including the articles that guarantee the freedom of assembly and prevent the suspension of the National Assembly sessions⁽²⁵⁾. However, as stated by the Kuwaiti constitutional expert Dr Al-Faili, he demonstrated that since the National Assembly presupposes a large gathering of people, it has been assumed that it is reasonable to postpone the session. Online Assembly cannot be held without appropriate legislation enabling such an option⁽²⁶⁾.

It should be highlighted that Kuwait is not the only country to introduce such regulations; they have been employed all over the world for centuries⁽²⁷⁾. The history of pandemic legislation can be illustrated with the help of the Epidemic Diseases Act 1897 of India, the UK Public

(22) See the UK Parliament website: <https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/uk-parliament-coronavirus-update/> accessed 23 May 2020.

(23) The UK Parliament website regarding the virtual meeting: <https://www.parliament.uk/business/news/2020/april1/speaker-outlines-virtual-meeting-plan/> accessed 19 May 2020. Further details are here: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-parliament-idUSKCN21W2PL> accessed 23 May 2020. See also the Guardian: <https://www.theguardian.com/politics/2020/apr/20/mps-expected-approve-plans-virtual-parliament> accessed 24 May 2020.

(24) Committee on Rules at <https://rules.house.gov/bill/116/h-res-PIH-remote-voting-proxy> accessed 21 May 2020. For more details see the New York Times and the Washington Post: https://www.washingtonpost.com/politics/house-poised-to-adopt-historic-changes-allowing-remote-voting-during-pandemic/2020/05/15/b081d9f2-96ab-11ea-91d7-cf4423d47683_story.html accessed 22 May 2020. See also; <https://www.nytimes.com/2020/05/15/us/politics/remote-voting-house-coronavirus.html> accessed 22 May 2020.

(25) Constitution of Kuwait, 1962, art. 44, 181.

(26) Arab Times, 'Holding Assembly sessions electronically requires parliamentary proposal or govt draft law: Dr Faili' (Arab Times, 2020) accessed 21 May 2020.

(27) Wendy Parmet and Michael Sinha 'Covid-19 - The Law and Limits of Quarantine' (2020) 382 The New England Journal of Medicine e28.

(roughly 2% compared to, for example, 10% of people with the severe acute respiratory syndrome coronavirus)⁽¹³⁾, the combination of its features, which include high infectiousness and prolonged incubation period (up to 2 weeks), made it exceptionally dangerous⁽¹⁴⁾.

Currently, no specific treatment for COVID-19 is available, although symptomatic treatment is applied depending on the severity of a condition⁽¹⁵⁾. As a result, the health security capacities of governments become critical; the prevention, detection and response to the new cases is a responsibility of local health organisations, as well as global ones⁽¹⁶⁾.

In Kuwait, at the beginning of May, the total registered cases of COVID-19 were just below 5000 people with 1776 people recovered and 38 deaths (0.7% death rate)⁽¹⁷⁾. By the middle of May, 18609 cases were registered (373% increase), 5205 people were recovered, and the number of deaths rose to 129 (0.7% death rate)⁽¹⁸⁾. Since the beginning of May, Kuwait citizens were urged to stay at home to limit the spread of the disease⁽¹⁹⁾, and from May 10 to May 30 curfew was introduced⁽²⁰⁾. Severe fines and imprisonment were introduced as coercive measures, but exercising in the fresh air was allowed within a specific timeframe for two hours every day with the condition that a mask would be used. Finally, governmental offices were closed for the same period of time with the understanding that online work is possible for some of the operations; but the National Assembly sessions were suspended⁽²¹⁾. However, and from a comparative perspective, the approach in other jurisdictions, such as the United Kingdom and the United States was different. For example, in the UK, with the country's challenging circumstances due to

(13) Nirmal Kandel et al., *supra* (n 5) 1048.

(14) Marco Cascella et al., *supra* (n 4).

(15) *Ibid.*

(16) Nirmal Kandel et al., *supra* (n 5) 1048.

(17) KUNA, 'Photo of the day' (KUNA, 2020) accessed 3 May 2020.

(18) KUNA, 'Photo of the day' (KUNA, 2020) accessed 21 May 2020.

(19) KUNA, 'Kuwait's MoH urges public to abide by home quarantine rules' (KUNA, 2020) accessed 1 May 2020.

(20) U.S. Embassy in Kuwait, *supra* (n 2).

(21) KUNA, 'Government desires delaying Wednesday's session' (KUNA, 2020) accessed 12 May 2020.

Research Methodology

This article presents a comparative case study⁽⁷⁾ that is based on available literature. Specifically, the Kuwaiti case is compared to the information about legislative decisions in other countries. Such an analysis cannot be carried out quantitatively; qualitative analysis, including that of a case study, is capable of developing meaningful insights into the similarities and differences between Kuwait and other countries⁽⁸⁾. The article relies on academic literature, but the most recent developments are based on newspapers and official website information. Additionally, primary sources were used whenever possible. It can be suggested that the article uses a pragmatic approach, in which the case of Kuwait is compared to other cases based on the information that is currently available, with a focus on reputed sources. The results of the comparison form the ground for analysis and recommendations.

Literature Review

In 2020, COVID-19, or coronavirus disease 2019, has reached the status of a global pandemic⁽⁹⁾. First recognised and verified in China in 2019, the disease is caused by 2019 novel coronavirus (COV-19), which is similar to the severe acute respiratory syndrome coronavirus, as well as bat coronaviruses⁽¹⁰⁾. COV-19 causes a range of health outcomes; it can be asymptomatic, have the symptoms of a cold or flu (dry cough, fever), cause mild pneumonia or result in severe conditions that require intensive care, including sepsis and organ dysfunction⁽¹¹⁾. Roughly 81% of the people affected by COVID-19 have mild symptoms; 14% experience severe ones, and 5% have critical COVID-19⁽¹²⁾. While COV-19's fatality rates are less significant than those of the most deadly coronaviruses

(7) Tim May, *Social Research: Issues, Methods and Research* (Open University Press 2011) at 220-227; see also Paivi Eriksson and Anne Kovalainen, *Qualitative Methods in Business Research* (SAGE 2015) at 133; Joseph Hair, Mary Celsi, Arthur Money and Michael Page, *Essentials of Business Research Methods* (Routledge 2015) at 196.

(8) Eriksson and Kovalainen, *supra* (n 7) at 116.

(9) Remuzzi and Remuzzi, *supra* (n 1) 1226.

(10) Nirmal Kandel et al., *supra* (n 5) 1048.

(11) Marco Cascella et al., *supra* (n 4).

(12) *Ibid.*

problems with delaying National Assembly sessions. The implications include the recommendation for the introduction of specific, epidemic-focused comments in the Constitution, as well as a provision for National Assembly sessions.

Introduction

COVID-19 has become a major issue, causing many⁽¹⁾ countries⁽²⁾ all over the world⁽³⁾ to implement quarantine and other measures with the intent of slowing down its extremely quick spread⁽⁴⁾. In connection to these recent events, some⁽⁵⁾ research⁽⁶⁾ has been carried out on how to improve epidemic regulations or legislation to assist in the management of similar events. This literature demonstrates the need for investigating the topic within the context of particular countries, and it will be leveraged in this case study to discuss the implications of the lessons learned in Kuwait. The present article discusses the legislative implications of COVID-19 as illustrated by the regulations from different countries and applied to the case of Kuwait. It aims to compare the issues and current legislation of Kuwait with the concerns and solutions presented by other countries and draw conclusions or propose implications based on the results. The rest of the paper is structured as follows; a note on the methodology is provided, a literature review summarises the key information sources, and a discussion offers the comparisons and implications followed by a conclusion. The paper argues that the study of international epidemic legislation can be helpful for future legislation recommendations in Kuwait and other countries.

-
- (1) Andrea Remuzzi & Giuseppe Remuzzi 'COVID-19 and Italy: what next?' (2020) 395 The Lancet 1225, 1226.
 - (2) U.S. Embassy in Kuwait, 'COVID-19 Information' (U.S. Embassy in Kuwait, 2020) accessed 20 May 2020.
 - (3) GorrisenFederspiel, 'COVID-19: The Danish Epidemic Act' (GorrisenFederspiel, 2020) accessed 1 May 2020.
 - (4) Marco Cascella et al., 'Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)' (StatPearls Publishing, 2020) accessed 1 May 2020.
 - (5) NirmalKandel, Stella Chungong, Abbas Omaarand Jun Xing 'Health security capacities in the context of COVID-19 outbreak: an analysis of International Health Regulations annual report data from 182 countries' (2020) 395 The Lancet 1047, 1049-1050.
 - (6) Remuzziand Remuzzi, supra (n 1) 1226.

The Lack of Epidemic Legislation in the Kuwaiti Legal System and the Implications of the Suspension of the National Assembly Sessions

Dr. Abdulrahman Al-Hajri
(PhD, LL.M, LL.B)
Mahmoud Khamis
(LL.M, LL.B)

Abstract:

The dangers of COVID-19 have caused many countries to introduce regulations of different severity in hopes of curbing the spread of the disease. One of such countries is Kuwait which has introduced arguably severe restrictions, including those that may appear to contradict the Constitution, in May. The present article considers the ways in which Kuwaiti actions are similar to or different from those of other countries and provides an analysis of epidemic legislation and regulations. The methodology consists of a comparative multiple case study with primary sources, academic literature and news articles being the main sources of information. The findings suggest that the decision to promote rapidly enacted regulations or legislation despite their potential conflicts with constitutions was not made by Kuwait alone. Given the dangers of COVID-19, such violations were considered justified, and they were legitimised by corresponding acts, empowering respective bodies to introduce harsh measures to prevent the spread of the disease. Despite the fact that Kuwaiti epidemic legislation is approved by the World Health Organisation, some issues were encountered, including the lack of epidemics considerations in the Constitution and the

(*) Accepted ??/??/????.

الآثار القانونية والاقتصادية لوباء كوفيد-١٩ على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: حالة الكويت "باللغة الإنجليزية"

د. مها البشارة

ملخص:

مرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أثر سلباً على حياة البشر في شتى المجالات. كنتيجة لذلك، أعلنت حكومات من جميع أنحاء العالم إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس. الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تضمنت إغلاق معظم الأعمال التجارية. أثرت الإجراءات الاحترازية بشدة على اقتصاديات الدول، فمعظم الشركات، خصوصاً، المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت على حافة الإفلاس. البحث يناقش آثار كوفيد-١٩ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت. البحث يتناول ما إذا كانت جائحة كوفيد-١٩ تكيف قوة القاهرة أم ظرف طارئ بموجب النظام القانوني في الكويت. يحلل البحث حزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة الكويت أثناء فترة جائحة كوفيد-١٩ تحليلاً نقدياً. البحث يتوصل إلى نتيجة هامة ألا وهي أن حكومة الكويت لم تتخذ مبادرات حقيقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة. السياسات والحلول التي اعتمدتها الحكومة في حقيقة الأمر إما تؤجل التزامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو تزيد من التزاماتها وأعبائها المالية من خلال الحصول على قروض ميسرة. في النهاية، يقترح البحث قوانين واضحة تهدف لتحقيق التوازن بين حماية الموازنة المالية للدولة وتقليل التشوهات الاقتصادية التي قد تنجم عن السياسات المقترحة.

- The National Fund for Small and Medium-Sized Enterprises Development, *Annual Report for the Fiscal Year 2015/2016*, https://nationalfund-new.s3.amazonaws.com/media/160729_annual_report_final_arabic_1.pdf?AWSAccessKeyId=A-KIAQZTLSBVASLOW2JPX&Signature=OX0kXnROLfePL-WhOyF2OzuHTT80%3D&Expires=1588017078 (last visited Apr. 27, 2020).
- The National Fund for Small and Medium-Sized Enterprises Development, *Annual Report for 2016/2017*, <https://nationalfund-new.s3.amazonaws.com/media/Ar-opt.pdf?AWSAccessKeyId=A-KIAQZTLSBVASLOW2JPX&Signature=Q9H3dF8yKwTbQ-DOHWGTUerDO6Uc%3D&Expires=1588021317> (last visited Apr. 27, 2020).
- The United Arab Emirates Government Portal, *The Impact of SMEs on the UAE's Economy* (Dec. 16, 2019), <https://u.ae/en/information-and-services/business/crowdfunding/the-impact-of-smes-on-the-uae-economy> (last visited Sept. 4, 2020).
- The World Bank, *Building Kuwait's Future, One Small Enterprise at a Time* (Mar. 1, 2016), available at <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/01/building-kuwait-future-one-small-enterprise-at-a-time> (last visited Sept. 4, 2020).
- The World Bank, *Small and Medium Enterprises (SMES) Finance: Improving SMEs' Access to Finance and Finding Innovative Solutions to Unlock Sources of Capital*, available at <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance> (last visited Apr. 14, 2020).
- U.S. Energy Information Administration, *Short-Term Energy Outlook*, <https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/prices.php> (last visited Apr. 17, 2020).

- Salem Abdulgafor, *Procedures for Those Affected to Obtain Financing from the Banks*, Alqabas, Apr. 22, 2020.
- Sarmad Khan, *UAE Economy Grew 1.7% in 2018 on Non-oil Sector Growth and Higher Oil Prices*, The Nat'l, (Mar.31, 2019), <https://www.thenational.ae/business/economy/uae-economy-grew-1-7-in-2018-on-non-oil-sector-growth-and-higher-oil-prices-1.843335> (last visited Sept. 3, 2020).
- *Saudi Arabia starts full curfew*, Aawsat (May. 23, 2020), <https://aawsat.com/home/article/2297931/> السعودية تبدأ منع التجول الكلي (last visited Sept. 4, 2020).
- Sultan Al-Qahtani, *A Study on the Effect of Coronavirus (COVID-19) on Employment and Lease Contracts in the State of Kuwait* (2020).
- Sumaya Almajdoub, *Issue Brief: The Structural Constraints of Entrepreneurship in Bahrain*, Baker Institute for Public Policy (2018).
- The Court of Cassation, Civil and Commercial Judicial Decisions, Appeal No. 739 for the Year 2011, the Commercial Secular, December 27, 2011, Audition No. 3.
- The Court of Cassation, Civil and Commercial Judicial Decisions, Appeal No. 121 for the Year 2003, the Labor Secular, March 3, 2005, Audition No. 1.
- The Court of Cassation, Civil and Commercial Judicial Decisions, Appeal No. 103 for the Year 2007, the Commercial Secular, October 9, 2008, Audition No. 3.
- The Explanatory Note for Law No. 98 for 2013.
- The Ministry of Finance, *The State Budget for the Fiscal Year 2019/2020*, at 17, available at <https://www.mof.gov.kw/MofBudget/PDF/Budget20-19.pdf> (Kuwait) (last visited Sept. 2, 2020).
- *The Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum Fund announces that the payment of premiums to the beneficiaries of the fund will be postponed for a period of 3 months*, emaratalyoun (Mar. 20, 2020), <https://www.emaratalyoun.com/business/local/2020-03-20-1.1322649> (last visited Sept. 4, 2020).
- The National Fund for Small and Medium-Sized Enterprises Development, *Annual Report*, <https://www.nationalfund.gov.kw/ar/media-center/publications/> (last visited Apr. 27, 2020).

- New Kuwait, Kuwait Mobilizes Development Efforts to Transform Kuwait into a Financial, Cultural, and Institutional Leader in the Region by 2035, http://www.newkuwait.gov.kw/image/NewKuwait_CampaignLaunchEvent.pdf (last visited Apr. 19, 2020).
- Nitank Rastogi et., *Pestle Technique - A Tool To Identify External Risks in Construction Projects*, 3 Int'l Res. J. Engineering & Tech. 384, 384 (2016) (discussing the types of business risks).
- Norbert Agbeko, *On the Characteristics of the free market in cooperative Society*, Quantitative Fin. Econ. 1, (2015).
- Ole Borre & Elinor Scarbrough, *The Scope of Government* 234 (Oxford University Press, 1995).
- Oxford Business Group, *Range of Measures to Support Growth of Kuwait's SMEs*, <https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/taking-initiative-range-measures-support-growth-smes> (last visited Apr. 18, 2020).
- Prableen Bajpai, *Top Factors That Affect the Price of Oil*, Investopedia (Mar. 16, 2020), <https://www.investopedia.com/articles/investing/072515/top-factors-reports-affect-price-oil.asp> (last visited Sept. 4, 2020).
- PwC, *2019 Oman State Budget: "A Prudent Budgetary Approach"*, <https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2019/2019-oman-state-budget.html> (last visited Apr. 14, 2020).
- Reconnaissance Research, *KUWAIT NEEDS TO SUPPORT ITS SMALL BUSINESSES*, 'Consequences of SMEs going out of business will be felt by everyone' Arab Times (Mar. 24, 2020), <http://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-needs-to-support-its-small-businesses/> (last visited Sept. 4, 2020).
- Restatement (Second) of Contracts § 265 & cmt. a (Am. Law Inst. 1981); Restatement (Second) of Contracts ch. 11, intro. note (Am. Law Inst. 1981).
- Robert J. Samuelson, *Key facts about the great oil crash of 2014*, Wash. Post (Dec. 3, 2014), https://www.washingtonpost.com/opinions/robert-samuelson-key-facts-about-the-great-oil-crash-of-2014/2014/12/03/a1e2fd94-7b0f-11e4-b821-503cc7efed9e_story.html (last visited Sept. 4, 2020).

NcnQAVMaDXJ4sdNL16K0yqkZvHMXOkT6 ARng-s IYrtcK8Fw-ag6X5pqfz0F1psr4KNsg0e_n-pr057wcZpMR8FQJG3ljnjtQFROcKVFcjn6VmnCAA2nvTgvh5r-wlympPCBQsG1oW4-CcTk17rTNu8mfTzb3 MYR2AD8IJblPl-sAz96UVw8CtmiESy OwMqoUdqk49zyOGk2tgw9JTj_e-VoEXHsHdprjfwjnQBFOVhqzZJSVgM9yyCGZN35UclP5ULEx-a9W-jXUKCiVvcjldJl8ksOakw (last visited Sept. 4, 2020).

- *Kuwait sold a barrel with a return of one Kuwaiti Dinar!*, Alqabas, Apr. 9, 2020.
- Lars Oxelheim, *Globalization, Transparency and Economic Growth: The vulnerability of Chinese firms to macroeconomic shocks*, 21 J. Asian Econ. 66 (2008).
- Law No. 14 for 2018 regarding Amending Some Provisions of the Law No. 98 for 2013 (Kuwait).
- Law No. 98 for 2013 concerning the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises (Kuwait).
- Lon Fuller, *The Mortality of Law* 39 (rev. ed. 1969).
- Maha Albesharah, *How to Create an Attractive Legal System for Foreign Direct Investments? The Kuwait Case* (Dec. 2019) (unpublished Ph.D. dissertation, University of Virginia) (on file with author).
- Mahmoud Al-Kafrawy, *The Closure of Commercial Activities in Kuwait Due to Coronavirus and Popular Initiatives to Reduce Losses*, Aljazeera (Mar. 21, 2020), <https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/21/إغلاق الأنشطة التجارية في الكويت بسبب كورونا ومبادرات شعبية> (last visited Sept. 4, 2020).
- Martin Carree & Roy Thurik, *Small Firms and Economic Growth in Europe*, 26 Atl. Econ. J. 137, (1998).
- Nasser Al-Jarah, *The State Audit Bureau of Kuwait: The National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises is Not Doing Well with Its Strategic Plan*, Aljarida (Oct. 21, 2019), <https://www.aljarida.com/articles/1571588419586692700/> (last visited Sept. 4, 2020).
- New Kuwait, <http://www.newkuwait.gov.kw/home.aspx> (last visited Apr. 19, 2020).

- Jim Chappelw, Free Market, Investopedia (June 25, 2019), <https://www.investopedia.com/terms/f/freemarket.asp> (last visited Sept. 4, 2020).
- Julia Anderson, *The fiscal response to the economic fallout from the coronavirus* (May. 25, 2020), <https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/> (last visited Sept. 4, 2020).
- K. Oduntan, *The Role of Small and Medium Enterprises in Economic Development: The Nigerian Experience*, Int'l Conf. of Art. Dubai, UAE, March (2014).
- Khaled Al-Hattab, *A report: 6.4% of Kuwaitis suffer from unemployment*, Alqabas (Jul. 14, 2019), <https://alqabas.com/article/5689854-من-الكويتيين-يعانون-البطالة-64-تقرير> (last visited Sept. 4, 2020).
- Khaled Al-Mutairi, *Oil Prices to Lowest Level Since Year amid Coronavirus Mushrooming*, Kuna, (Mar. 1, 2020), <https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2871480&language=en> (last visited Sept. 4, 2020).
- Khalid Al-Hattab, *40 Thousand Companies Are Subject to Default or Bankruptcy*, Alqabas, Apr. 6, 2020.
- *Kuwait Gov't Imposes Partial Curfew, Extends Holiday for Two Weeks*, Kuna (Mar. 22, 2020), <https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880568&language=en> (last visited Sept. 4, 2020).
- *KUWAIT RAISES PETROL PRICES BY OVER 80% - 'RATIONALIZATION'*, Arabtimes (Aug. 2, 2016), <http://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-raises-petrol-prices-80-rationalization/> (last visited Sept.4, 2020).
- Kuwait Realizes Early the Importance of Small and Medium-sized Enterprises, Saneoualhadath (June 6, 2016), https://saneoualhadath.me/أعمال-المشاريع-الصغيرة-والمتوسطة-الكويت-خصوصا/?cfchljschltk=f1782d1283a6cb2da48ca996f82-b97208a563b41-1587207531-0-AT-mPvNSb91Mx_gifDsWrQPd4-z3OfOpa315YCPQY1Efa0SyG_1E871d4xh8eanyF131eUHLOa-b4E3yKX5VYLu461wv57sxjByXreMfhWML2mdSl8OxUJH-ku654DSeA3K5T286IHSh-7d7EVWeRCDslg6BT-wI3uHL5Z6Pd9ZmSr4bEbMlbmxeAT7NfGxuAGNIHrkxfZZu-Zu4nDjLtyTzp95oSZ0cpX_9bYNfmclUarmuMG0txQIvuhht-JUlcZ9lnZlzMhroc_y6vPiMk2R8QGPvrYC6JRtDriO5C-

- Elisa Braun, *France Injects Billions into Stimulus Plan amid Coronavirus Chaos*, Politico (Mar. 17, 2020), <https://www.politico.eu/article/france-injects-billions-into-stimulus-plan-amid-coronavirus-chaos-bruno-le-maire-economic-catastrophe/> (last visited Sept. 4, 2020).
- European Commission, *2018 SBA Fact Sheet - Romania* (Nov. 19, 2018), <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/24/translations/en/renditions/pdf> (last visited Sept. 4, 2020).
- Fawaz Karami, *The National Fund: About 167 Million Kuwaiti Dinars Credits for Small and Medium-Sized Enterprises*, Kuna (Dec. 10, 2018), <https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2763715> (last visited Sept. 4, 2020).
- Glada Lahn, *Fuel, Food, And Utilities Price Reforms in the GCC: A Wake Up Call For Business* (The Royal Institute of International Affairs, 2016).
- Hidayat Keskin et.al, *The Importance of SMEs in Developing Economies*, 2nd int'l symp. on Sustainable dev. 183 (2010) (discussing the importance of SMEs for developing countries).
- Ibrahim Abduljawad et., *Dismissing the Board of Directors of the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises*, Alqabas (Apr. 18, 2017), <https://alqabas.com/article/384311-إقالة مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة> (last visited Sept. 4, 2020).
- IEA, *Global Oil Demand to Decline in 2020 as Coronavirus Weighs Heavily on Markets*, <https://www.iea.org/news/global-oil-demand-to-decline-in-2020-as-coronavirus-weighs-heavily-on-markets> (last visited Apr. 14, 2020).
- Institute of Banking Studies Research, *Taking Stock of SME Banking in Kuwait*, (2016).
- Inter-American Development Bank, *Action for Growth: Policy Recommendations and 2018-2021 Action Plan for Growth in Americas* 6 (2018).
- Jeddah Chamber of Commerce and Industry, *Small-Medium Enterprises in Saudi Arabia Report for April 2016*.

- Amer Abdulaziz Al-Amr, *Unprecedented Saudi Law Draft of the Commercial Courts and Procedures* (May. 10, 2019), <https://www.dlapiper.com/en/dubai/insights/publications/2019/05/unprecedented-saudi-law-draft-of-the-commercial-courts-law-and-procedures/> (last visited Sept. 4, 2020).
- Anadel Al-Mutar, “Corona” *Between Force Majeure or Emergency Circumstance*, Aljarida (Mar. 22, 2020), <https://www.aljarida.com/articles/1584808158149681200/> (last visited Sept. 4, 2020).
- Antonio Carvalho et., *Post Oil Gulf: SMEs to The Rescue?* 9 (Tri International Consulting Group, 2018).
- Atsu, F & Adams (2005), *S 'Transparency Regulation and Economic Performance in Africa'* Utrecht University, Utrecht.
- *Because of Coronavirus (Covid-19).. The First Decline in Global Demand for Oil Since the Financial Crisis*, Aljazeera (Feb. 13, 2020), <https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/13/بسبب كورونا أول تراجع للطلب العالمي على النفط منذ الأزمة المالية> (last visited Sept. 4, 2020).
- Brian Beers, *How Companies Can Reduce Internal and External Business Risk?*, Investopedia (Feb. 3, 2020), <https://www.investopedia.com/ask/answers/050115/how-can-companies-reduce-internal-and-external-business-risk.asp> (last visited Sept. 4, 2020).
- Cibela Neagu, *The Importance and Role of Small and Medium-sized Businesses*, 23 Theoretical & Applied Econ. 332, (2016) (discussing the importance of SMEs in economic development).
- CSRGULF, *High Waste Risk in the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the State of Kuwait* (Nov. 20, 2019), <https://www.csrgulf.com/2019/11/20/مخاطر هدر عالية في صندوق المشروعات في> (last visited Sept. 4, 2020).
- Decree Law No. 39 for 1980 related to the Issuance of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters art. 1 (Kuwait).
- Donald McNeil, *Coronavirus Has Become a Pandemic*, W.H.O. Says, N.Y. Times (Mar. 11, 2020), <https://www.nytimes.com/2020/03/11/health/coronavirus-pandemic-who.html> (last visited Sept. 4, 2020).
- Ekramy Abdullah, *Record Level of non-Oil Revenues in 2019.. 148% Jump in 5 Years*, Aleqt (Dec. 10, 2019), https://www.aleqt.com/2019/12/10/article_1727151.html (last visited Sept. 3, 2020).

List of References

- 25.5 thousand Kuwaitis are unemployed.. up to 6%, Alanba (Sept. 2, 2018), <https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/853402/02-09-2018>– (last visited Sept. 4, 2020).
- A. Berry, 'The Importance of SMEs in the Economy', ITD Global Conf. on Tax'n of Small and Medium Enterprises, Bueno Aires, Argentina, (October 2017).
- A. Warner, *Small and Medium Sized Enterprises and Economic Creativity*, N.Y.C. & Geneva, Unctad, (2001).
- Abdullah Al-Abduljader, *Labor force statistics and Kuwaiti employment opportunities*, Alanba (Feb. 22, 2019), <https://www.alanba.com.kw/kottab/abdullah-alabdeljader/886638/22-02-2019-إحصائيات القوى العاملة وفرص عمل للكويتيين> (last visited Sept. 4, 2020).
- Abdulsrool Bahbehani et al., *Sources of Commitment and Evidence* 168 (3d ed. 2010).
- Adam Hayes, *Stimulus Package*, Investopedia (Mar. 26, 2020).
- Ahmed Abdel Rahman et., *Kuwait SMEs: Size, Obstacles and Suggested Remedies*, 3 Int'l J. Managerial Stud. & Res. 7, (2015) (examines the current status of small and medium enterprises (SMEs) in the economy of Kuwait).
- AL-MONITOR, *Kuwait announces full curfew as other countries ease restrictions*, <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/kuwait-total-curfew-coronavirus.html> (last visited May. 27, 2020).
- Ali Al-Khaldi, *90% of the Initiators Consider the Role of National Fund to Be "Negative"*, Alqabas, Apr. 6, 2020.
- Ali Al-Khaldi, *Funding Regulations for Affected Companies*, Alqabas, April 21, 2020.
- Ali Al-Khaldi, *Small projects stumbled.. and loans are not repaid*, Alqabas (Apr. 16, 2019), <https://alqabas.com/article/657390-مشاريع صغيرة تتعثّر والقروض لا تُسدّد> (last visited Sep. 2, 2020).
- Ali Qasim, *Small-sized businesses mired in swamp "human trafficking"*, Alraimedia (Aug. 28, 2019), <https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=913118ee-74f6-4a2f-bf5f-b2203c4a2686> (last visited Sept. 4, 2020).

achieve economic growth and increases accountability. In result, it reduces errors conducted by the Fund.

After shedding the light on short and long-term proposals. The following discussion addresses suggestions and recommendations as important lessons grasped from the COVID-19 crisis. It is important to learn from this crisis to prevent repeating the same catastrophic effects in the future.

Suggestion and Recommendation

- 1 - Kuwait needs to take real initiatives to diversify its economy to reduce the emphasis on energy sources.
- 2 - Providing an online service is an important asset, especially for SMEs. SMEs need to create an online platform for their businesses. They need to learn how to market their goods and services online, and they need to adopt techniques that service their old customers and attract new ones. This will help to minimize their losses as much as possible during an economic crisis.
- 3 - Providing training programs on how to create a website and how to market commodities and services through the internet at nominal prices is essential. This will help both SMEs and the State during times of economic crisis to minimize losses as much as possible.
- 4 - Some of the obstacles that SMEs face today are related to issues that were not solved prior to the crisis. The government of the State of Kuwait needs to solve these key issues to help minimize the effects of a future economic crisis.
- 5 - The world after COVID-19 crisis will not return as it was before. There must be drastic changes in the government structure and its size. The government currently follows long, complicated, and repetitive measures, and it needs to be more rapid, flexible, and efficient to sustainably manage the economy after the end of this crisis. One of the crucial changes is merging public bodies and relinquishing unimportant bodies that are a burden to the State.

complicated procedures⁽²⁵⁷⁾. 4) The Fund lacks experienced employees that ensure the prosperity and the success of SMEs after obtaining loans from the Fund⁽²⁵⁸⁾.

As recommendations, 1) the law should clarify and specify the process that the Fund should follow to recover these payments. 2) Kuwait needs to follow the examples of other countries in providing different ways to guarantee loans. For example, Saudi Arabia relies on financial guarantees provided by a public joint stock company to guarantee the loans⁽²⁵⁹⁾. Egypt, Morocco, and Tunisia have funds and companies that specializes in sector of loan guarantees⁽²⁶⁰⁾. 3) Kuwait needs to establish specialized commercial courts to review economic cases. An example of a country that established commercial courts is Saudi Arabia⁽²⁶¹⁾. Commercial courts will eliminate time and the complex procedures. 4) The Fund should cultivate experienced and skilled employees that could offer advice and consult with the SMEs to ensure their efficiency. The Fund should provide educational courses and training for its employees. Moreover, the Fund should motivate its employees to acquire such skills and to develop SMEs. One-way motivational tool is to give workers bonuses if efficiency and improvement for SMEs is achieved. For example, each employee of the Fund may be assigned to be responsible for three businesses to consult with them and offer advice on business management and marketing.

Another problem discussed in Section III is that the Fund lack transparency and mismanagement. Section I showed that the lack of transparency generates bad debts. One uncostly solution that enhances the transparency of the Fund is through making the Fund's spending data available online for the public to access and download. This will

(257) *Id.*

(258) *Id.*

(259) *Id.*

(260) *Id.*

(261) Amer Abdulaziz Al-Amr, Unprecedented Saudi Law Draft of the Commercial Courts and Procedures (May. 10, 2019), <https://www.dlapiper.com/en/dubai/insights/publications/2019/05/unprecedented-saudi-law-draft-of-the-commercial-courts-law-and-procedures/> (last visited Sept. 4, 2020).

Another problem relates to the full curfew that the Government of Kuwait announced on May 8⁽²⁵⁴⁾. Unfortunately, the government shut down all economic activities and prohibits businesses to provide home delivery service. Whether it is a partial curfew or full curfew, the government of Kuwait should allow businesses to continue working through providing home delivery service. To ensure the health of people, the government of Kuwait should impose strict precautionary measures that the businesses and its workers need to follow. In case of violation, the government might impose fines and shut down businesses. This will create incentives for businesses to comply with such measures to prevent the transmission and the spread of the virus. In addition, awareness must also be spread through the media channels about ways of how to protect people from being infected and sterilize goods taken from delivery services. An example of a country that allowed commercial and economic activities to continue working during the full curfew is Saudi Arabia⁽²⁵⁵⁾. This solution will minimize the losses of SMEs as much as possible.

IV.II.II.: Long-Term Solutions

One of the significant problems prior to the COVID-19 crisis is that a number of SMEs failed to continue doing their business. As a result, they were unable to repay their installments to the Fund. A high probability exists that this situation will be repeated by the SMEs during the crisis. Four factors contribute to this problem: 1) Article 28 of the Law for 2013 and Law for 2018 are vague in specifying the process followed by the Fund to recover the debts, and they do not specify the mechanisms to calculate bad debts. 2) A positive relationship exists between the absence of a guarantee for these loans and the failure to pay the loan by SMEs. Additionally, the Fund does not require collateral for loans⁽²⁵⁶⁾. 3) The provisions of the Law for 2013 allow the Fund to recover the payments through legal disputes, which require long and

(254) AL-MONITOR, Kuwait announces full curfew as other countries ease restrictions, <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/kuwait-total-curfew-coronavirus.html> (last visited May. 27, 2020).

(255) Saudi Arabia starts full curfew, AAWSAT (May. 23, 2020), <https://aawsat.com/home/article/2297931/السعودية تبدأ منع التجول الكلي> (last visited Sept. 4, 2020).

(256) CSRGULF, *supra* note 178.

of the value if the guaranteed portfolio: 80% for the government and 20% for the bank^{”(253)}.

The Government of Kuwait should follow more sound plan regarding the distribution of losses to ensure that the public funds are protected and not further wasted. A study needs to be put in place to distinguish between the effects of the precautionary measures on businesses. The study needs to evaluate each business and its losses, in result, the distribution of losses between the bank and the Fund should be in accordance to such results. This solution contributes in achieving economic efficiency.

Subsection IV.I mentioned that another economic decision announced by the government is the deferral of the Fund’s installments for six months. The previous discussion mentioned how this decision generates economic inefficiency. As a proposal for reform, the Fund should study the effect of COVID-19 on SMEs’ contracts on a case by case basis. The study should distinguish between enterprises that were not affected at all by the crisis and those that were affected as well as the extent of their damage. A relationship between the effect of the precautionary measures and the contractual obligations should be determined. Whether the effect of the crisis made the fulfillment of contractual obligations impossible or exhausting needs to be proved by the owners of the enterprises. Then, each contract should be evaluated separately to consider either postponing the payments of installments or reducing the installment amount. For those businesses that were not affected at all, they need to pay their installments in full. This solution will contribute in achieving economic efficiency and safeguarding the state’s funds.

There are SMEs that were forced to shut down and were affected severely. As a solution, the government of Kuwait should consider offering them reasonable non-refundable compensation. The previous argument provided example of some countries that have already adopted such measure. This solution will provide cash flow for affected SMEs and prevent them from bankruptcy.

(253) *Id.*

80% from the Fund, and 20% from the local bank. Subsection IV.I addressed that one of the problems facing the Fund to fulfill the regulation is that both Law for 2013 forbids an additional funding exceeding 80% of the enterprise's cost. As a recommendation, an amendment to the Law for 2013 should be added to achieve a balance between the interests of SMEs and the protection of public money during this critical time. The amendment should state that:

[I]n the event of general crisis, which results to precautionary policies announced by the public authority to combat such crisis, a small or medium-sized enterprise economically affected by these precautionary measures may obtain an additional financing exceeding 80% of the enterprise's costs, after fulfilling the following conditions:

- 1 - Provide evidence that the project was working efficiently prior to the crisis and that it has achieved great results in production and sales.
- 2 - Provide proof that the project paid the monthly installments of the previous loan.
- 3 - Provide proof that the enterprise has been affected due to the lockdown by exhibiting proof of income between a previous period similar to the period of closure announced by the government.
- 4 - The loss needs to be half of what SMEs gain prior to the crisis.
- 5 - The additional financing will only cover the salaries of workers, rent, and payments to suppliers.

Another problem relates to the previous regulation is that the Fund will be responsible for 80% of the loan given to SMEs. Eighty percent is a large percentage for the Fund to bear, especially that Section III expressed that a number of SMEs were unable to repay their installments and their debts became bad debts. As a safe solution, the percentage of the loan which the Fund will be responsible for need to be decreased. For example: in Belgium, C 50 billion was allocated as other liquidity sources and guarantee measures⁽²⁵²⁾. The regulation stipulates that:

[T]he distribution of losses at portfolio level: (a) For losses up to 3% of the value of the guaranteed portfolio: 100% for the bank; (b) Losses between 3% and 5% of the value of the guaranteed portfolio: 50% for the bank and 50% for the government; (c) Losses above 5%

(252) Anderson, *supra* note 219.

considered a sound plan. Depending on the emerging economic conditions, the shorter plan also offers more flexibility to be amended if it needs to be extended.

In conclusion, the government of Kuwait did not adopt real initiatives to assist SMEs during the COVID-19 crisis. The economic measures and regulations lack legal certainty, clarity, and increases inefficiency. Basically, the measures announced by the government of Kuwait either postpone the current liabilities of SMEs or increase their liabilities. The measures do not provide concrete solution to contain the negative effects of the present economic crisis. Subsection IV.II proposes short and long-term economic and legal reforms that contribute to reducing the economic impact of the COVID-19 crisis on SMEs. The proposals aim to achieve economic efficiency from one hand and preserve public funds on the other hand.

IV.II: Short-and Long- term Policy Proposals that Safeguard Fiscal Capacity and Minimize Economic Distortions

Section III illuminated the negative economic effects resulting from the precautionary measures announced by the government to combat the spread of COVID-19. Particularly, the adverse effects of such measures on SMEs. Subsection IV.II introduces both short- and long-term policy proposals as most of the obstacles encountered by SMEs today are similar to the hardships prior to the COVID-19 crisis. The effects of the precautionary measures to combat the spread of the virus made these issues worse. Therefore, addressing long-term solutions is significantly important to eliminate the effects of any economic crisis that might arise in the future and to reduce some of the traditional economic burdens of SMEs. Moreover, long-term solutions help to create an attractive business environment to encourage the prosperity of SMEs. Eventually, such solutions will increase SMEs' contribution in the economy of Kuwait.

In the end, Subsection IV.II highlights some important lessons grasped from COVID-19 crisis.

IV.II.I: Short-Term Solutions

The previous discussion demonstrated that the loans will be given through joint financing from local banks and the Fund, with a weight of

of the virus, A's business was affected, A requests for a concessional loan. However, the Law for 2013 forbids this additional funding. How this issue is resolved? The answer is vague. Second, Section III expresses that a number of SMEs were unable to repay their installments prior to COVID-19 crisis. A high probability exists that this situation will be repeated by SMEs during the crisis. The unclarity of the method to prevent the repetition of a catastrophic scenario of those debts becoming bad debts will jeopardize the public money.

Lastly, the economic decision to postpone the installments of the Fund for six months increases inefficiency. There are three associated issues resulting from this decision. First, the deferral decision applies to all the SMEs projects that were financed by the Fund, and the decision does not distinguish between the projects. As previously mentioned, the policies announced by the government to combat the spread of the virus and the legal effects it imposed on contractual obligations differ from one contract to another. Some businesses were forced to shut down, while others were able to continue working through home delivery service. For the first case, an exemption from paying the premium should be made, and in the second case a reduction of the amount of the installments should be considered. To elaborate, in the first scenario, the fulfillment of the obligation is impossible while in the second situation it becomes exhausting. Most importantly, some enterprises were not affected by the precautionary measures set by the government, and therefore, the payments of installments for such businesses do not need to be postponed. Second, there are some SMEs that recently obtained a loan from the Fund, and already enjoy a grace period. Currently, the policy is unclear if the six months period can be added to the grace period enjoyed by those businesses. Third, the period of six months is a long period compared to strategy adopted by other countries. For example, in Dubai the installments of the beneficiaries from the Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum Fund for SMEs were postponed for a period of three months⁽²⁵¹⁾. Since the end of the COVID-19 crisis is uncertain, setting a shorter period to postpone the installments instead of a longer period is

(251) The Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum Fund announces that the payment of premiums to the beneficiaries of the fund will be postponed for a period of 3 months, EMARATALYOUM (Mar. 20, 2020), <https://www.emaratalyout.com/business/local/2020-03-20-1.1322649> (last visited Sept. 4, 2020).

applicant with a clear vision in advance. Also, the Central Bank of Kuwait mentions that an affected SMEs must submit its financing request to the local bank. While the Council of Ministers states that the regulation applies to SMEs that were affected by COVID-19 crisis, the extent of damage that defines an affected applicant is unspecified. Testing whether the enterprise was affected in accordance to a comparison of income earned by the enterprise in two specific time periods, for example March 2019 and March 2020, might be an option. However, at this time, the criteria concerning this matter is vague.

Furthermore, the Central Bank of Kuwait explains that the affected SMEs must submit a loan request to local banks that maintains SME's primary account. Then, the local bank coordinates with the Fund to assess the request. The adopted assessment criteria are not specified. This is a serious problem because the lack of stated criteria provides the Fund and the local bank greater flexibility to reject some requests.

Another issue is that the Central Bank of Kuwait announced that the value of financing will be equal to the obligations of the affected SMEs, including rent, salaries of workers, and payments due to suppliers. According to Central Bank of Kuwait, the affected SMEs should provide the necessary documents related to rent receipts, payroll, and supplier invoices. However, in the process for obtaining the loan, the Central Bank of Kuwait emphasizes that the local bank will conduct a necessary credit assessment. In accordance with the results of the credit study, the local bank will have the ultimate decision to decide the value of the financing. In this case, the value of the approved financing is not guaranteed to be equal to the loan request.

Another problem is that the loan will be given through joint financing from local bank and the Fund, with a weight of 80% from the Fund, and 20% from the local bank. There are two unresolved issues: First, how the Fund will be able to finance previous SMEs that reached the maximum funding limit is not stipulated. Articles 5 and 25 of the Law No. 98 for 2013 confirm that the Fund will finance enterprises by a maximum of 80% of the enterprise's cost. To illustrate this idea, suppose that A is an owner of a medium business. In 2017, A obtained a loan from the Fund. The Fund was responsible for 80% of the enterprise's cost. Today, because of the precautionary measures to combat the spread

percentage of national employees in SMEs is undetermined; and 2) the actual percentage of non-Kuwaitis employees in SMEs is unknown.

Regarding the first issue, a report notes that less than 7% of Kuwaitis work in the SME sector⁽²⁴⁸⁾. Scholars highlight that this percentage may be inflated due the “phantom employees,” which means that “nationals declared on payroll with the sole purpose of receiving government subsidies for working in the private sector”⁽²⁴⁹⁾.

Regarding the second issue, there are fake SMEs that do not exercise a business activity in practice. A number of individuals issued license for small or medium-sized enterprises. They have brought a large number of foreign workers to be in the name of these projects and work for them⁽²⁵⁰⁾.

Let’s suppose that A owns a commercial license, A has a ‘fake’ small business. A provides documents to the bank related to payroll of his employees working in his enterprise. A claims that his business was severely affected due to precautionary measures to combat the spread of the virus. A asserts that he lacks liquidity and needs the concessional loans to pay the salaries of his workers. The mechanism of how the bank will differentiate between real and fake SMEs is vague. There is no method for discovering this type of manipulation. There should be an auditing instrument to know exactly the actual numbers of employees (Kuwaitis and non-Kuwaitis) actually working in real SMEs to prevent the waste of public funds.

Regarding the procedures to obtain the concessional loan, there is no specification of the time period during which the bank grants the loan approval. The Central Bank of Kuwait stipulates that the approval of concessional loans requests will be faster than before the emergence of the COVID-19. However, “faster” is a flexible term and does not indicate a certain period. Specifying a certain period of time, for example 3-5 days, is a better strategy as this will help to prevent a long time from passing, which will have negative effects on business, and to provide the

(248) ANTONIO CARVALHO ET., POST OIL GULF: SMES TO THE RESCUE? 9 (Tri International Consulting Group, 2018).

(249) *Id.*

(250) Ali Qasim, Small-sized businesses mired in swamp "human trafficking", ALRAIMEDIA (Aug. 28, 2019), <https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=913118ee-74f6-4a2f-bf5f-b2203c4a2686> (last visited Sept. 4, 2020).

only attracted a limited number of Kuwaitis as opposed to a greater number of foreign workers⁽²⁴²⁾.

According to a report, 25,000 Kuwaitis are unemployed⁽²⁴³⁾. Between 2016-2018, 5,000 Kuwaitis left the private sector and either had the chance to work in the public sector or to become unemployed⁽²⁴⁴⁾. In June 2018, the unemployment rate reached 6.1% among Kuwaitis⁽²⁴⁵⁾. In 2019, The Labor Statistics Report for the Gulf Cooperation Council States revealed that 6.4% of Kuwaitis suffer from unemployment-a total of 14,800 citizens-compared to the unemployment rate of 1.7% among non-Kuwaitis⁽²⁴⁶⁾. Another source indicates that Kuwaitis are among the individuals of the Gulf Cooperation Council States to work the least in the private sector. They are in the penultimate rank before the Qataris⁽²⁴⁷⁾. Given these dynamics, it is unclear how the goal of increasing the national workforce can be achieved, especially during this critical time, when businesses are forced to shut down by the government to combat spread of the virus.

Another goal mentioned by the regulations is to support vital sectors and activities that add value to the local economy, which were operating efficiently before the COVID-19 crisis. The measure that will be followed to examine such efficiency and the criteria of measuring whether or not the activity operated efficiently before the crisis is unclear.

Concerning the aspects of spending and use of the financing amounts, the regulations emphasized that the bank pays the loan amounts to beneficiaries and deposits it in their accounts directly. In practice, there is a problem relates to the existence of fake SMEs. There are two associated issues resulting from fake SMEs: 1) the actual

(242) *Id.*

(243) 25.5 thousand Kuwaitis are unemployed .. up to 6%, ALANBA (Sept. 2, 2018), <https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/853402/02-09-2018>– (last visited Sept. 4, 2020).

(244) *Id.*

(245) *Id.*

(246) Khaled Al-Hattab, A report: 6.4% of Kuwaitis suffer from unemployment, ALQABAS (Jul. 14, 2019), <https://alqabas.com/article/5689854-تقرير من الكويتيين يعانون البطالة> (last visited Sept. 4, 2020).

(247) CSRGULF, *supra* note 178.

assurance that the funds will be used effectively, the bank pays the loan to the beneficiaries (i.e., landlords, workers, and suppliers) and deposits it in their accounts directly.

However, there are several negative aspects regarding the economic approach adopted by the government of Kuwait to rescue SMEs during this crisis. The discussion highlights the cons of the regulations approved by the Council of Ministers regarding the concessional loans. The article shows that in practice there are obstacles that deviate the regulations from achieving its purposes, the aspects of spending of the financing amounts, and the boundaries mentioned by the regulations. The debate also focuses on providing critical analysis of the procedures announced by the Central Bank of Kuwait to obtain the concessional loans. Lastly, the argument sheds light on how the deferral of the Fund's installments for six months achieves economic inefficiency.

The regulations stipulate that one of its purposes is to maintain the national workforce and to increase its percentage in the private sector. One of the boundaries and controls that affected SMEs need to follow to obtain concessional loans is maintaining the national workforce and to reach the percentage of the national workforce set for the activity and sector by December 31, 2021. However, in practice, it is difficult to fulfill such goal, because the government employs 95% of the national workforce in its different institutions⁽²³⁸⁾. In 2019, the percentage of national workforce in the public sector was 75.37%, and the percentage of the national workforce in the private sector was 4%⁽²³⁹⁾. Prior to the COVID-19 crisis, a source indicates that SMEs effectively failed to reduce the unemployment rate of Kuwaitis⁽²⁴⁰⁾. The feasibility studies of the SMEs projects financed by the Fund did not comprehensively consider given priority to employ Kuwaitis⁽²⁴¹⁾. Unfortunately, SMEs

(238) The Explanatory Note for Law No. 98 for 2013.

(239) Abdullah Al-Abduljader, Labor force statistics and Kuwaiti employment opportunities, ALANBA (Feb. 22, 2019), <https://www.alanba.com.kw/kottab/abdullah-alabdeljader/886638/22-02-2019-إحصائيات القوى العاملة وفرص عمل للكويتيين> / (last visited Sept. 4, 2020). It is important to note that the total population in Kuwait is 4,714,137. The number of Kuwaitis is 1,407,468, who represent 29.86% of the total population, and the total number of non-Kuwaitis is 3,306,669, who represent 70.14% of the total population. *See id.*

(240) CSRGULF, *supra* note 178.

(241) *Id.*

- 3 - In the event that the conditions apply, the customer applies to obtain the required loan, accompanied by the required amount.
- 4 - Submit the documents confirming the requested amount.
- 5 - A reference number is issued to follow up on the request.
- 6 - The bank then estimates the value of the loan and informs the client of the approval.
- 7 - The bank initiates the procedures for paying the obligations of the client⁽²³⁶⁾.

On April 22, *ALQABAS* published information about the mechanism for granting financing to SMEs clients. Their requests are considered according to the following procedures:

- 1 - The affected client submits the financing request to the bank that maintains their primary account through an online portal designated by the bank. The bank coordinates with the National Fund to assess the request.
- 2 - The bank prepares the necessary credit assessment in an integrated and rapid manner by verifying that the client meets the conditions for financing, reviewing the previous cash flows, and evaluating the applicant through the credit information network company Ci-Net.
- 3 - In accordance with the results of the credit assessment, the bank determines the value of the financing.
- 4 - The Fund shall pay its share of the financing (i.e., 80%) to the granting bank within two days after the bank's decision.
- 5 - In the event that the affected client reaches the maximum amount permitted by the Fund to be provided to each client (500,000 Kuwaiti Dinars), the full amount of financing can be provided by the bank⁽²³⁷⁾.

There is no doubt that the government of Kuwait has evidently strived to find solutions to the economy's survival during the COVID-19 crisis. There are positive aspects regarding the process adopted to finance SMEs. To facilitate the process to obtain concessional loans, there were: 1) the creation of an online platform; and 2) the approval of concessional loans will be made faster electronically. To provide certainty and

(236) *Id.*

(237) *Id.*

- Preserving the national workforce and achieving the percentage of the national workforce designated for the sector/activity by December 31, 2021.
- The irregular paying customer will not benefit from the finance⁽²²⁷⁾.

These concessional loans are jointly financed by local banks and the National Fund⁽²²⁸⁾. The advantages of this method of financing are the following:

- The loans have concessional terms for three years, including a one-year grace period.
- The interest on the loans does not exceed 2.5% annually⁽²²⁹⁾.
- In the first year, the state's general budget bears the interest of financing⁽²³⁰⁾. In the second year, the affected customer shares the interest payments equally with the state⁽²³¹⁾. In the third year, the affected customer incurs the interest in full⁽²³²⁾.

To provide these loans, the Central Bank of Kuwait has directed local banks to create an online platform to communicate with affected clients who wish to obtain financing⁽²³³⁾. The Central Bank sets the necessary criteria for financing amounts to match the obligations of the customer, including laborers' salaries, rent, and payments due to suppliers⁽²³⁴⁾. The borrower will not receive the funding directly; rather, the bank will deposit the money into the beneficiaries' accounts⁽²³⁵⁾. The procedure to apply for a loan through the online platform is as follows:

- 1 - Check the conditions for those who are eligible for the financing.
- 2 - Answer a set of questions to ensure that the conditions apply.

(227) *Id.*

(228) *Id.*

(229) *Id.*

(230) Salem Abdulgafor, Procedures for Those Affected to Obtain Financing from the Banks, ALQABAS, Apr. 22, 2020, at 8. It should be noted that there is a penalty after the end of the grace period. In the event that the client does not commit to pay two consecutive payments, the financing provided is considered to be immediate and the customer must pay it in addition to the full interests. In addition, the state general budget ceases to bear any part of the financing cost. See *id.*

(231) *Id.*

(232) *Id.*

(233) *Id.*

(234) *Id.*

(235) *Id.*

companies with a revenue less than C 1 million, who have lost 50% or more of their revenue in March 2020, compared to March 2019”⁽²²²⁾.

The following discussion presents the stimulus package announced by the Government of Kuwait. Then, the argument proposes long and short-term solutions that are designed to achieve a balance between safeguarding fiscal capacity and minimizing economic distortions that might result from proposed policies.

IV.I: Analyzing the Stimulus Package Announced by the Government of Kuwait

On April 20, 2020 the Council of Ministers approved funding regulations for SMEs affected by the COVID-19 crisis⁽²²³⁾. The purposes of the Council of Ministers’ regulation are the following:

- To support vital sectors and activities with added value to the local economy that were operating efficiently before the crisis.
- To prevent further deterioration of the current economic circumstances and deterring the turn of the short-term liquidity crisis into a solvency crisis.
- To preserve and increase the national workforce in the private sector.
- To involve the participation of all parties in bearing the burdens.
- To not offer compensation for lost profit or realized losses⁽²²⁴⁾.

The regulation addresses the aspects of spending and use of the financing amounts:

- The funding covers the required periodic contractual expenses such as workers’ salaries and rent⁽²²⁵⁾.
- It is prohibited to use the financed amount to pay installments or credit burdens⁽²²⁶⁾.

The regulation sets forth boundaries and controls that must be observed:

(222) *Id.* at 10.

(223) Al-Khalidi, *supra* note 46, at 8.

(224) *Id.* at 8.

(225) It is important to note that the banking sector verifies that the customer’s use of financing in the specified aspects (i.e., salaries of employees and rents). *See Id.*

(226) *Id.*

IV: Stimulus Package, Long and Short-term Proposals

The various lockdown measures in response to COVID-19 have halted economic activity in certain sectors and harshly disrupted others. Governments throughout the world implemented various fiscal measures to contain the economic fallout due to COVID-19. The economic measures are categorized as: 1) immediate fiscal impulse, for example compensation for businesses that were forced to shut down by government policy; 2) Deferrals of payments; 3) other liquidity sources, for example: offering loans.

It is important to note that there is no indication of the value of the stimulus packages announced by the government of Kuwait. The article demonstrates examples of several countries that specified the total value of their economic stimulus packages.

Also, the measures adopted by the government of Kuwait to support SMEs during this crisis are circulated around two categories. These measures include 1) deferrals of the payment of the National Fund's installments for a period of six months. 2) offering concessional loans. To clarify, the government of Kuwait has not taken the approach of some countries concerning providing a non-refundable compensation to businesses that were forced to shut down by government mandate to contain the spread of the virus. Example of such countries: Belgium, in March, the government allocated a C 1.5 billion for active independent workers that were forced to shut down their business to contain the spread of the virus⁽²¹⁹⁾. They were "eligible for 1291,69 euros per month if they do not have a dependent family and 1641,10 euros per month if they do"⁽²²⁰⁾. Another example is Brussels-region, the government allocated C 36 million to support businesses "through a one-time compensation of C 4000 to businesses that have fully shutdown due to government policy"⁽²²¹⁾. In France, on April 16, the government allocated "C 7 billion subsidies through the solidarity Fund, for small

(219) Julia Anderson, The fiscal response to the economic fallout from the coronavirus (May. 25, 2020), <https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/> (last visited Sept. 4, 2020).

(220) *Id.* at 4.

(221) *Id.* at 6.

collect the debt. Both Law for 2013 and Law for 2018 are vague regarding the procedures of which the Fund should follow to recover unpaid debts. Both laws lack a method to guarantee the loans given to SMEs. Finally, the same allegations regarding the payment of monthly installments and the collapse of SMEs when they pay such installments are repeated today in the case of the COVID-19 crisis. These allegations are similar to what is circulating during the COVID-19 crisis. All of this contribute in wasting the public funds.

The Fund's position on this crisis has been called into question, and *ALQABAS* provided an answer. A survey prepared by the newspaper revealed that 90% of the initiators, who obtained loans from the Fund believe that the Fund's behavior since the emergence of COVID-19 has been passive whereas 10% believe that the role of the Fund is positive⁽²¹⁶⁾. The majority of participants affirmed that since the outbreak of the COVID-19 crisis, the Fund officials did not contact them to check on the status of their commercial activities⁽²¹⁷⁾. *ALQABAS* also asked the initiators what problems they face due to the COVID-19 crisis: 34% answered paying their employees' salaries and paying rent, 20% answered cash flow, 16% said the high costs of raw materials in the country of origin and the unavailability of substitutes in local markets, and the remaining 30% face all of the mentioned problems⁽²¹⁸⁾.

Given the extensive needs of SMEs in Kuwait that have been exasperated by the COVID-19 crisis, further stimulus measures have been implemented. Subsection I. of Section IV provides an overview of the stimulus packages and regulations announced by the Council of Ministers concerning the concessional loans to support affected SMEs. The analysis of the stimulus packages and regulations governing concessional loans informs the recommendations that might be more efficient, which are presented in Subsection II. of Section IV.

(216) Ali Al-Khaldi, 90% of the Initiators Consider the Role of National Fund to Be "Negative", *ALQABAS*, Apr. 6, 2020, at 8. The survey included a random sample of 50 initiators from various sectors, but the primary sectors were the industrial and commercial sectors.

(217) *Id.*

(218) *Id.*

Lastly, the State Audit Bureau of Kuwait discovered that 38 SMEs that were financed by the Fund failed to re-pay their monthly installments⁽²⁰⁷⁾. The total value of financing these 38 SMEs amounted more than one million Kuwaiti Dinars⁽²⁰⁸⁾. On April 2019, the *ALQABAS* newspaper also confirmed the finding and published the headline “Small Projects Stumbled... and Loans Are Not Repaid”⁽²⁰⁹⁾. Under the Law for 2013, the financed enterprise enjoys a grace period of 1-3 years⁽²¹⁰⁾. *ALQABAS* noted that for some of the financed SMEs, the grace period had ended, and their projects had not succeeded⁽²¹¹⁾. An unidentified source explained to *ALQABAS* that such financed SMEs will only be able to re-pay the installments for only a short period of time, because they will face a lack in liquidity⁽²¹²⁾. Another study estimates that the Fund financed more than 307 projects⁽²¹³⁾. However, the study estimates that 50% of these projects have failed to continue⁽²¹⁴⁾. The study also specifies that more than 150 projects cannot pay their obligations to the Fund⁽²¹⁵⁾.

In conclusion, the Fund lacks transparency and characterized with internal mismanagement. Particularly, there is no specific rules and conditions regarding financing. Basically, the Fund follows no specific strategy regarding financing or assessing financed projects. The lack of such a strategy contributes to the failure of many financed SMEs. The total amount of financing and the number of projects that were funded since 2013 cannot be accurately determined. Most importantly, the repayment of the loans is ambiguous. A considerable amount of information is unknown, particularly regarding the number of financed SMEs that have repaid their loans, the number of businesses that are still repaying their loans, the number of projects that have failed and cannot repay their loan, and the specific procedures that the Fund is following to

(207) Al-Jarah, *supra* note 194.

(208) *Id.*

(209) Al-Khaldi, *supra* note 46.

(210) Law No. 98 for 2013 art. 26 (Kuwait).

(211) Al-Khaldi, *supra* note 46.

(212) *Id.*

(213) CSRGULF, *supra* note 178.

(214) *Id.*

(215) *Id.*

commits an error and includes A's contract number for B's contract. The same identification number that labels each contract is repeated. This is a threatening situation because the overlap leads to errors when referring to A's or B's contracts. Consequently, A or B will face legal disputes. In addition, A and B both must prove the value of the loan obtained from the Fund. If the loan's value obtained by B is more than the loan obtained by A, this will create a negative incentive for B if they have the same contract numbers. Under this circumstance, B might attempt to uphold this inaccurate contract to avoid repaying the full loan amount.

Another violation conducted by the Fund, according to the State Audit Bureau of Kuwait, is that it has not transferred the funding to some of the approved SMEs⁽²⁰⁰⁾. Therefore, the approved SMEs did not benefit from the loan established for them, yet the Fund's reported loan figures misleadingly include the loan amounts. Another violation mentioned by the State Audit Bureau of Kuwait is that the Fund re-contracted with the same initiators with new contracts, neglecting the fact that there were previous established contracts with them⁽²⁰¹⁾. These new contracts were a result of either issuing new licenses or because the initiators requested additional funding⁽²⁰²⁾. The Fund failed to cancel the previous contracts or to link the new contracts as an amendment to the original ones⁽²⁰³⁾. As a result, the Fund's funding amount exceeded the legally established percentage stipulated in the Law for 2013 (80%)⁽²⁰⁴⁾. The conduct of the Fund violates the provisions of Article 5 and Article 25 of Law No. 98 for 2013. The State Audit Bureau of Kuwait discovered 11 initiators that had obtained two contracts and stated that the total amount of financing for both contracts ranged between 130,000 and 604,000 KWD⁽²⁰⁵⁾. This amount exceeds the amount permitted by the law (i.e., 500,000 KWD)⁽²⁰⁶⁾.

(200) *Id.*

(201) *Id.*

(202) *Id.*

(203) *Id.*

(204) *Id.*

(205) *Id.*

(206) Law No. 14 for 2018 regarding Amending Some Provisions of the Law No. 98 for 2013 art. 5 (Kuwait).

and the initiator for the project should be identified. In accordance with the Law for 2013, the initiator commits 20% of the project's value⁽¹⁹²⁾. This means that the Fund finances the approved project to a maximum of 80% of its cost⁽¹⁹³⁾. There is a general lack of financial information that is made public. Having an access to such information enhances transparency, which in return, increases accountability. As greater transparency is implemented, public money will be preserved from waste.

The National Fund website does not yet include an annual report for 2017/2018. In 2017, the State Audit Bureau of Kuwait provided observations on the Fund's performance and illustrated that the Fund failed to perform its strategic plan⁽¹⁹⁴⁾. According to the State Audit Bureau of Kuwait, a discrepancy was found in the number of projects listed in the strategic plan versus the number of projects listed in the capital budget⁽¹⁹⁵⁾. The number of projects included in the strategic plan was 54.3% lower than the number estimated in the capital budget⁽¹⁹⁶⁾. To elaborate, the capital budget of the Fund provided for 600 projects to be financed for fiscal year 2017/2018, with an average of 200,000 KWD per project⁽¹⁹⁷⁾. However, the actual number of projects that were financed by the Fund was 274 projects⁽¹⁹⁸⁾. The amount of funding that was used for these 274 projects in total is not available.

The State Audit Bureau of Kuwait also mentioned several violations committed by the Fund, including the repetition of contract numbers formed between the Fund and the initiators⁽¹⁹⁹⁾. To illustrate, suppose that A is a small business and B is a medium-sized enterprise. On January 1, 2016, A obtains a loan from the Fund. On January 1, 2017, B obtains a loan from the Fund for the purpose of expanding its business. The Fund

(192) Law No. 98 for 2013 art. 5 & art. 25 (Kuwait).

(193) *Id.*

(194) Nasser Al-Jarah, The State Audit Bureau of Kuwait: The National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises is Not Doing Well with Its Strategic Plan, *ALJARIDA* (Oct. 21, 2019), <https://www.aljarida.com/articles/1571588419586692700/> (last visited Sept. 4, 2020).

(195) *Id.*

(196) *Id.*

(197) *Id.*

(198) *Id.*

(199) *Id.*

proportion of small- and medium-sized enterprises. Lastly, the report does not specify whether the approved projects are startups or existing businesses.

The annual report for fiscal year 2016/2017 is more transparent than the previous reports. The report notes that the total number of applicants was 370, and the Fund approved 245⁽¹⁸⁴⁾. According to the report, the total amount of funding approved was 50,125,458 KWD⁽¹⁸⁵⁾. The report includes a table that provides financing amounts by sector and type and details the number of small- and medium-sized enterprises of the financed projects⁽¹⁸⁶⁾. The table also indicates the number of startups and existing businesses⁽¹⁸⁷⁾. This annual report is significantly different from the previous annual reports. Comparing the annual report for 2015/2016 and the one for 2016/2017, the former only provides a chart that presents the number of approved projects per sector as a percentage⁽¹⁸⁸⁾. The latter provides both the percentage and the actual number of businesses per sector⁽¹⁸⁹⁾. In addition, the report for 2016/2017 indicated similar activities in the related sector, and it mentioned the funding amount for each sector⁽¹⁹⁰⁾.

Despite its strengths, the report for 2016/2017 has some deficiencies. It does not specify the amount of financing provided for each approved project. For example, the report specifies that 107 projects received funding in the commercial sector, and the amount of financing approved for those projects was 22,653,360 KWD⁽¹⁹¹⁾. However, this information does not provide a clear understanding of the amount of financing for each project. The value of the loan given by the Fund to each enterprise should be specified. Moreover, the percentage incurred by both the Fund

(184) The National Fund for Small and Medium-Sized Enterprises Development, Annual Report for 2016/2017, <https://nationalfund-new.s3.amazonaws.com/media/Ar-opt.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAQZTL5BVASLOW2JPX&Signature=Q9H3dF8yKwTbQDOHWGTUer-DO6Uc%3D&Expires=1588021317> (last visited Apr. 27, 2020).

(185) *Id.*

(186) *Id.*

(187) *Id.*

(188) The National Fund for Small and Medium-Sized Enterprises Development, *supra* note 183.

(189) The National Fund for Small and Medium-Sized Enterprises Development, *supra* note 184.

(190) *Id.*

(191) *Id.*

Despite this access to funding, the Fund failed to issue any conditions that detailed a clear vision of how to use this money.

Another uncertainty stemming from Article 4 is the number of projects and the type of activities that the Fund has funded since its establishment as well as the number of both small- and medium-sized businesses that the Fund has supported. Various sources provide uncertain estimates of the number of businesses that the Fund financed⁽¹⁸¹⁾. Since the Fund was established, three annual reports have been issued by the Fund⁽¹⁸²⁾. The annual report for fiscal year 2014/2015 does not include information relating to the total number of SMEs and their activities that were financed by the Fund. The annual report for fiscal year 2015/2016 mentions that the first batch of approvals was given to 59 projects in different sectors, and it includes a chart representing the distribution of approved projects by sector: 41% in the commercial sector, 36% in the services sector, 20% in the light manufacturing sector, and 3% in the agriculture sector⁽¹⁸³⁾. Although some relevant information is presented, other critical information is missing from the report. For example, the total number of initiators (applicants) who applied for the Fund's support is not specified. Furthermore, in the event of a rejection to finance some of the applicants, the total number of rejected applicants is not presented and the reasons for the Fund's refusal are unclear. Most importantly, the report does not provide any information regarding the amount of funding for each approved project. The report also does not identify the size of the approved projects and the

(181) CSRGULF, *supra* note 178. See also Fawaz Karami, The National Fund: About 167 Million Kuwaiti Dinars Credits for Small and Medium-Sized Enterprises, KUNA (Dec. 10, 2018), <https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2763715> (last visited Sept. 4, 2020). According to Munaf Al-Munifi, the General Manager of the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises, the Fund's financing allocations for projects approved in various sectors amounted about 167 million Kuwaiti Dinars (about \$551 million) since its founding in 2013 and until the end of October 2017. *Id.*

(182) The National Fund for Small and Medium-Sized Enterprises Development, Annual Report, <https://www.nationalfund.gov.kw/ar/media-center/publications/> (last visited Apr. 27, 2020).

(183) The National Fund for Small and Medium-Sized Enterprises Development, Annual Report for the Fiscal Year 2015/2016, https://nationalfund-new.s3.amazonaws.com/media/160729_annual_report_final_arabic_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAQZTLBSVASLOW2JPX&Signature=OX0kXnROLfePLWhOyF2OzuHTT80%3D&Expires=1588017078 (last visited Apr. 27, 2020).

elucidates that 2 billion KWD (USD 6.6 billion) is allocated to the Fund and shall be extracted from the State Public Reserve⁽¹⁷⁷⁾. Since the funds are considered to be public money, they must be protected.

However, the provisions of the Law for 2013 are characterized by ambiguities that impose legal issues. Sources indicate that the Fund in practice does not achieve its goals mentioned by Article 4 of the Law for 2013⁽¹⁷⁸⁾. Rather than addressing these problems, this discussion focuses on the Fund and sheds light on one of its critical problems-the legal strategy followed by the Fund to finance SMEs. This argument helps to develop an analysis of whether the economic measure concerning the joint financing between the bank and the Fund to support SMEs during the COVID-19 crisis achieves efficiency.

First, Article 4 of the Law for 2013 needs to be analyzed as certain questions arise. Article 4 states that "The Board, in order to achieve the objectives of this Law, shall set the terms and conditions and the rules to manage the Fund and the rules of financing the enterprises with the instructions set by the Central Bank"⁽¹⁷⁹⁾. However, the terms, conditions, and rules are unclear. In 2016, the State Audit Bureau of Kuwait indicated that the Fund had not issued administrative and financial rules regarding the management and use of the 2 billion KWD, and that the Fund had already received the first payment of its capital, valued at 55.5 million KWD⁽¹⁸⁰⁾.

(177) Law No. 98 for 2013 art. 4 (Kuwait).

(178) See, CSRGULF, High Waste Risk in the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the State of Kuwait (Nov. 20, 2019), <https://www.csrgulf.com/2019/11/20/> – مخاطر هدر عالية في صندوق المشروعات (last visited Sept. 4, 2020). See also Al-Khalidi, *supra* note 46.

(179) Law No. 98 for 2013 art. 4 (Kuwait).

(180) Ibrahim Abduljawad et., Dismissing the Board of Directors of the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises, ALQABAS (Apr. 18, 2017), <https://alqabas.com/article/384311-إقالة مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة> (last visited Sept. 4, 2020). According to the State Audit Bureau of Kuwait, the National Fund committed several violations, including its financing of 59 projects with a uniform amount and without preparing economic feasibility studies for each approved project. This violates Article Fourteen of the Law No. 98 for 2013 regarding the study and evaluation of projects proposed by the owners of the projects. In addition, related sources told ALQABAS that the reason behind the dismissal of the National Fund's Board of Directors was "due to the lack of cooperation with the various oversight bodies, especially the State Audit Bureau of Kuwait, which announced its protest against the management of the Fund because the Fund objected to subject its budget to its control, which led to the withdrawal of the audit team."

sources in order to alleviate the financial burdens off the Government Budget.

- 2 - Raising awareness of the benefits of enterprises, and coordinating and promoting initiatives of small and medium-sized enterprises.
- 3 - Providing information and technical support.
- 4 - Providing and evaluating the economic and environmental feasibility studies for the enterprises, and creating the profitable and innovative opportunities by providing continuous access to information.
- 5 - Developing and training human resources through the Supporting Institutions.
- 6 - Funding enterprises as per this Law.
- 7 - Increasing enterprise competitiveness, while providing maximum support for the enterprise and minimum interference in the business thereof.
- 8 - Supporting the home-made products and encouraging innovation of Kuwaiti Intellectual Property Right⁽¹⁷⁵⁾.

Article 4 of the Law for 2013 states:

[C]apital of (two billion Kuwaiti Dinars) shall be allocated to the Fund in order to achieve the objectives of this Law. The funds necessary for this Fund shall be extracted from the State Public Reserve. The Minister of Finance shall be authorized to pay the same by installments as per the manner to be agreed upon by the Minister of Finance and the Competent Minister, subject to the invested financial surpluses. The Fund capital may be amended by a decree. The Board, in order to achieve the objectives of this Law, shall set the terms and conditions and the rules to manage the Fund and the rules of financing the enterprises in accordance with the instructions set by the Central Bank⁽¹⁷⁶⁾.

The 2013 legislation provided for the creation of a public entity called the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises (Fund). The aim of the Fund is to support SMEs in the State of Kuwait. Based on Article 3, the Fund assumes responsibility for everything related to SMEs' prosperity and improvement. Article 4

(175) Law No. 98 for 2013 art. 3 (Kuwait).

(176) Law No. 98 for 2013 art. 4 (Kuwait).

SMEs through a channel of joint financing between the local banks and the Fund. The Fund will bear 80% of the loan, while, the bank will bear 20% of the loan. Section I briefly discussed how these two economic measures will waste further the public funds. To support such claim, Section III presents a summary of the performance of the Fund prior to the crisis. The debate concludes that the Fund has suffered from the lack of transparency and mismanagement over the years. The discussion clarifies that the Fund, according to sources, has failed to recover previous debts from SMEs. How will the Fund avoid similar crisis occurring in the future? The discussion has an important impact, it assesses that the economic measures adopted by the Fund are not appropriate for the current situation and does not achieve economic efficiency. The discussion paves the way for Section IV to offer a critical analysis of the procedures and legal rules announced by the Council of Ministers regarding the concessional loans.

III: The National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Kuwait

In 2013, the State of Kuwait issued Law No. 98 concerning the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises. In 2018, Law No. 14 was established that amended some provisions of Law No. 98. The Law for 2013 states in Article 2 that: “There shall be established a Fund under the name of (the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises) as a public institution with an independent legal personality, and reports to the Competent Minister,”⁽¹⁷³⁾ who the Minister of Commerce and Industry⁽¹⁷⁴⁾. Article 3 of the Law for 2013 presents the Fund’s goals:

[T]he purposes of the Fund are to support and develop small and medium-sized enterprises, enhance the potentials of their owners in terms of implementations, planning, coordination and promotion, and the following:

- 1 - Developing the national economy by implementation of policies for generation of job opportunities and diversification of income

(173) Law No. 98 for 2013 concerning the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises art. 2 (Kuwait).

(174) Law No. 98 for 2013 art. 1 (Kuwait).

In another ruling, the Court of Cassation confirmed that in order to apply the theory of *force majeure* the conditions specified by Article 215 of the Civil Code should met⁽¹⁷²⁾.

Applying the previous discussion to the current crisis, COVID-19 is an external event that could not be expected at the time of forming the contract. It is a general incident that affects everyone, and it cannot be avoided. However, the difference is in the influence of each theory on the contractual commitment. The main difference between *force majeure* and emergency circumstance is that the former makes performance impossible, while the latter makes performance exhausting. The following discussion will discuss this matter in detail.

B.The Legal Effects of Each Theory on the Parties' Contractual Obligations

According to Article 215, the legal effect of a *force majeure* is the dissolution of the contract. Subsequently, the parties of the contract will return to the state they were in before establishing the contract. According to Article 198, the legal effect arises from the emergency circumstance is returning the exhausted commitment to a reasonable extent by limiting its scope or increasing its counterpart.

This article applies the foregoing analysis to the effects of COVID-19 on contracts. There are three categories of contracts resulting from the crisis. First, some contracts are completely unaffected by the measures announced by the governments to combat the spread of the virus. Second, the performance of some contracts has been rendered impossible by the precautionary measures. In this scenario, the COVID-19 crisis likely constitutes a *force majeure*. Finally, certain contracts were affected to some degree by the precautionary measures, making the fulfillment of the commitment exhausting; here, the theory of emergency circumstance governs.

As mentioned earlier, the government of Kuwait announced stimulus packages to support SMEs during this crisis. The stimulus packages include: 1) postponing the installments of the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises (Fund) for six months; and 2) offering concessional loans for affected

(172) The Court of Cassation, Civil and Commercial Judicial Decisions, Appeal No. 103 for the Year 2007, the Commercial Secular, October 9, 2008, Audition No. 3, at p. 48.

The Kuwaiti Court of Cassation emphasized that in order to apply the emergency circumstance theory that the fulfillment of the debtor's obligation becomes exhausted as a result of the external incident. The court concluded that the decrease in profit or the loss of earnings is not sufficient to apply the rule of this theory. In addition, the court concluded that the criterion for calculating the loss in this event is an objective criterion related to the subject matter of deal agreed in the contract, and is not subjective to the debtor and his personal circumstances⁽¹⁶⁹⁾.

The Kuwaiti Court of Cassation in another ruling concluded that the Iraqi Invasion does not considered a *force of majeure* of which results in the dissolution of the employment contract between the two parties due to the impossibility of its performance, but only to suspend the parties' obligations temporarily until the cessation of the aggression. According to the court, the employee is not obligated to perform the required work during that period nor the employer is obligated to fulfill any rights in respect to the employee⁽¹⁷⁰⁾.

It is worth noting that the previous decision concluded by the Court of Cassation was issued under the Labor Law No. 38 of 1964, and not under the law currently in force, namely Labor Law No. 6 for 2010. Article 61 of the Law No. 6 for 2010 specifies that the employee is entitled to a salary during the period of partial or complete suspension, as long as, the employer desires that the employee continues working for him.

In another ruling, the Court of Cassation concluded that the actions issued by the public authorities and likewise the decisions issued by the administration that result in depriving the tenant of the use or benefit of the leased property are considered a *force majeure*. Hence, the tenant may request the termination of the lease contract or the reduction of the rent, pursuant to Article 581 of the Civil Code⁽¹⁷¹⁾.

(169) The Court of Cassation, Civil and Commercial Judicial Decisions, Appeal No. 739 for the Year 2011, the Commercial Secular, December 27, 2011, Audition No. 3, at p. 212.

(170) The Court of Cassation, Civil and Commercial Judicial Decisions, Appeal No. 121 for the Year 2003, the Labor Secular, March 3, 2005, Audition No. 1, at p. 302.

(171) Al-Qahtani, *supra* note 168, at 32.

unavoidable;⁽¹⁶¹⁾ and (3) not caused by the behavior of one of the parties to the contract⁽¹⁶²⁾. If this incident is caused due to negligence or the fault of one of the parties, then the contract will not be dissolved under a *force majeure* theory⁽¹⁶³⁾. Examples of *force majeure*s include natural disasters and the outbreak of war. The criteria for both *force majeure* and emergency circumstance are essentially the same as they are external and general incidents that cannot be expected at the time of forming the contract. Once they occur, controlling these events or eliminating their associated risks is difficult. However, the difference is in the influence of each theory on the contractual commitment. Therefore, highlighting the conditions of impossibility set forth by Article 215 that dissolve the contract is important. These conditions are the following:

- The impossibility of carrying out the obligation must be due to a foreign cause in which the nonperforming party has no foreknowledge of its occurrence⁽¹⁶⁴⁾.
- The impossibility arises after formation of the contract and before its full performance⁽¹⁶⁵⁾.
- The obligation of fulfilling the contract should become impossible⁽¹⁶⁶⁾.

Accordingly, the Kuwaiti Court of Cassation ruling in the judgement issued in the session of November 1, 1999 in the two appeals No. 343/345 for the year 85 Administrative Commercial, considered that the effects of the contract as a result of the economic crisis resulting from dealing in shares in regard to the *Souq Al-Manakh Stock Market crash* are considered emergency circumstances⁽¹⁶⁷⁾.

The Kuwaiti Court of Cassation in another ruling concluded that the foundation of the emergency circumstance theory depends on the conditions addressed by Article 198 of the Civil Code⁽¹⁶⁸⁾.

(161) *Id.*

(162) *Id.*

(163) *Id.*

(164) Civil Code No. 67 for 1980 art. 215 (Kuwait).

(165) *Id.*

(166) *Id.*

(167) Al-Mutar, *supra* note 160.

(168) Sultan Al-Qahtani, A Study on the Effect of Coronavirus (COVID-19) on Employment and Lease Contracts in the State of Kuwait, 3-4.

- An exceptional circumstance emerges⁽¹⁵⁰⁾. It is important to note that the law does not provide a definition of “exceptional general circumstances”⁽¹⁵¹⁾. Examples of such circumstances include natural disasters and the outbreak of war⁽¹⁵²⁾.
- Exceptional circumstance is common occurrence. Meaning that it should be *general*-i.e., it affects everyone⁽¹⁵³⁾. This means that the event is not specific to the debtor, such as when a debtor faces bankruptcy due to poor operational performance or the loss of a key customer.
- The exceptional circumstance is not expected at the time of contract formation⁽¹⁵⁴⁾.
- The exceptional circumstance cannot be avoided⁽¹⁵⁵⁾.
- The exceptional circumstance occurs after the contract formation and before its full performance⁽¹⁵⁶⁾.
- The emergency incident makes the fulfillment of the debtor’s obligation exhausting, and it threatens him with a heavy loss⁽¹⁵⁷⁾.

Article 215 of the Civil Code No. 67 for 1980 states that “In a binding contract for two parties, if the performance of one of the parties becomes impossible due to a foreign reason, this commitment lapsed, with the corresponding obligations of the other party and the contract has been dissolved by its own”⁽¹⁵⁸⁾. Article 233 of the Civil Code illustrates that a *force majeure* is one of the examples of the “foreign cause”⁽¹⁵⁹⁾. Although the statute does not define *force majeure*, jurists have indicated that the *force majeure* should be (1) an external incident that cannot be expected at the time of forming the contract,⁽¹⁶⁰⁾ (2)

(150) Civil Code No. 67 for 1980 art. 198 (Kuwait). See also ABDULRSOOL BAHBEHANI et al., SOURCES OF COMMITMENT AND EVIDENCE 168 (3d ed. 2010).

(151) Civil Code No. 67 for 1980 art. 198 (Kuwait).

(152) Civil Code No. 67 for 1980 art. 198 (Kuwait).

(153) Civil Code No. 67 for 1980 art. 198 (Kuwait).

(154) Civil Code No. 67 for 1980 art. 198 (Kuwait).

(155) BAHBEHANI, *supra* note 150, at 169.

(156) *Id.*

(157) Civil Code No. 67 for 1980 art. 198 (Kuwait).

(158) Civil Code No. 67 for 1980 art. 215 (Kuwait).

(159) Civil Code No. 67 for 1980 art. 233 (Kuwait).

(160) Anadel Al-Mutar, "Corona" Between Force Majeure or Emergency Circumstance, ALJARIDA (Mar. 22, 2020), <https://www.aljarida.com/articles/1584808158149681200/> (last visited Sept. 4, 2020).

capacity. If the rent is not paid in full, the landlord may sue the tenant. Depending on the tenant's type of enterprise and the precautionary measure applied by the government, the affirmative defense by the tenant varies. For example, if the tenant's enterprise is a fitness center, the fulfillment of the tenant's obligation is impossible, because fitness centers are mandated to be closed. In this circumstance, the tenant will raise the affirmative defense of *force majeure*. If a tenant's enterprise is a café, the fulfillment of the tenant's obligation is exhausting as such businesses are operating at a much lower capacity, and the tenant will raise the affirmative defense of an emergency circumstance. Therefore, in the case of a breach of contract, the status of paying rent as either impossible or exhausting is an important distinction because it impacts the affirmative defenses for the defendant tenant, and in either scenario, the defendant bears the burden of proving the status⁽¹⁴⁷⁾.

A. The Conditions of Each Theory

Under Kuwaiti Civil Code, the contract is *pacta sunt servanda*, which means that is not permissible to revoke or amend the contract except by mutual agreement of the parties or in other circumstances determined by the law⁽¹⁴⁸⁾. However, there is an exception to this rule as stipulated in Article 198 of the Civil Code No. 67 for 1980, which states

[I]f, after the formation of a contract and before its full performance, exceptional general circumstances occur that could not be expected at the time of forming the contract, as a result, the performance of the obligation arising from it-and if it does not become impossible-, became exhausting for the debtor, so that it threatens him with a heavy loss, the judge may after the balance between the interests of the two parties, return the exhausted commitment to a reasonable extent by limiting its scope or increasing its counterpart, and any agreement to the contrary is void⁽¹⁴⁹⁾.

The same section of code discusses the emergency circumstance theory, and the elements are as follows:

(147) Decree Law No. 39 for 1980 related to the Issuance of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters art. 1 (Kuwait).

(148) Civil Code No. 67 for 1980 art. 196 (Kuwait).

(149) Civil Code No. 67 for 1980 art. 198 (Kuwait).

Council of Ministers approved regulations regarding the concessional loans offered to affected SMEs due to COVID-19⁽¹⁴⁶⁾. Section IV scrutinizes these regulations and offers a critical analysis. In the following, Subsubsection II.II.I discusses whether the COVID-19 outbreak constitutes a *force majeure* or an emergency circumstance.

II.II.I COVID-19: *Force Majeure* or an Emergency Circumstance?

The outbreak of COVID-19 and its deadly effects felt around the world have made the governments of countries adopt aggressive precautionary measures to combat its spread. As the introduction of subsection II.II demonstrates, the measures have affected commercial activities, especially after the closure of borders and the suspension of international flights. The effects were directly reflected in the contractual obligations that may impact larger sectors more so than others. For example, in the tourism sector, travel restrictions will make the performance of certain transportation contracts impossible. The situation extends to other sectors as well and the measures have greatly affected other contracts, including supply agreements and commercial exchanges. The effects of COVID-19 have even extended to loan contracts for institutions, companies, and individuals. As a consequence, a legal controversy has arisen as to whether the COVID-19 pandemic is a *force majeure*, or emergency circumstance, which is discussed in this subsubsection. However, before determining a legal answer, analyzing the conditions of each theory is necessary to highlight the main differences between them and to understand their legal effects on contractual obligations. Three questions need to be considered: (1) What type of policy is adopted by the government to combat the virus? (2) Which commercial activities were affected by such policy? (3) Did the policy or measure make the fulfillment of the contractual obligations impossible or exhausting? Rental arrangements offer one example to elaborate on the possible consequences that the pandemic measures have had on commercial activities. While landlords and tenants agree to a rental contract, COVID-19 precautionary measures reduce or eliminate tenants' ability to pay rent since their businesses cannot operate at full

(146) Ali Al-Khaldi, Funding Regulations for Affected Companies, ALQABAS, April 21, 2020, at 8.

that over 105,000 individuals engaged in the SMEs sector are facing bankruptcy⁽¹³⁵⁾. These enterprises are suffering from a lack of liquidity that resulted from the closure of commercial activities to counter the spread of COVID-19⁽¹³⁶⁾. As a consequence, the owners of SMEs are unable to pay for their obligations, including laborers' salaries⁽¹³⁷⁾. AL-QABAS provides the number of the registered employment in SMEs, they represent 85% (a total of 90,000 workers)⁽¹³⁸⁾. ALQABAS also reports that the total number of SMEs in Kuwait is approximately 40,000 companies⁽¹³⁹⁾. Ali Al-Anizi, a financial market expert and economics researcher, emphasizes that the fall of the SME sector will have a severe impact on the macroeconomy of the country⁽¹⁴⁰⁾. Al-Anizi elucidates that the most affected activities in the SME sector are those related to cafes and restaurants, and the losses have already reached 100% in some of them⁽¹⁴¹⁾. As previously mentioned, cafes and restaurants continue to work through providing home delivery service, which has minimized their losses ranging 50-90%, according to Al-Anizi⁽¹⁴²⁾. No definite answer can be determined regarding the loss percentage of such enterprises, and Al-Anizi explains that the loss differs depending on the enterprise's activity⁽¹⁴³⁾. For the restaurants and cafes that do not provide a home delivery service, Al-Anizi notes that they are highly reliant on customers' presence⁽¹⁴⁴⁾. The percentage of their present losses, reported by Al-Anizi, is 40%⁽¹⁴⁵⁾.

The negative economic effects of COVID-19 on SMEs made the Kuwait Government to announce economic stimulus packages to support SMEs. The measures confined on: 1) deferrals of installments; and 2) offering concessional loans for affected SMEs. On April 20, the

(135) *Id.*

(136) *Id.*

(137) *Id.*

(138) *Id.*

(139) *Id.*

(140) *Id.*

(141) *Id.*

(142) *Id.*

(143) *Id.*

(144) *Id.*

(145) *Id.*

and the establishment of regulations that relate to the business environment in the country.

At first glance, the opponents' concerns appear logical. However, Section II demonstrated several academic and empirical studies that emphasize the role of SMEs in economic development as SMEs are vital for economic diversification. The failure to provide support for SMEs during this crisis will result in severe economic and social effects at later stages. One such likely effect is an increase in the unemployment rate. Another consequence of a large-scale collapse of SMEs is that the large firms will gain market power⁽¹³⁰⁾. The combined effects of widespread unemployment and corporate consolidation is likely to disadvantage consumers and accentuate existing inequality. Heightened unemployment will decrease income tax revenues, increase the burden on the State to support its population, and reduce consumption. A deteriorating economic environment of this type could in turn cause heightened social tensions. The State cannot afford these effects, especially in a time of crisis like the current one.

Today, governments from all over the world, including the governments of the GCC States, are adopting the decision to support SMEs. For example, the Saudi Arabian Monetary Authority has assigned a stimulus plan of 50 billion Riyals (USD 13 billion) to save SMEs from the economic impact of COVID-19⁽¹³¹⁾. In the United Arab Emirates, the Governor of the Emirati Central Bank, Mubarak Rashed Al-Mansoori, announced a plan to provide aid in the short and medium term for SMEs and other financial institutions⁽¹³²⁾. The plan includes 100 billion Dirham (USD 34 billion)⁽¹³³⁾. The effect of COVID-19 on SMEs in Kuwait is dire. Unfortunately, the government of Kuwait does not adopt real initiatives to support SMEs during this crisis.

On April 6, 2020, *ALQABAS* newspaper published the headline: "The crisis threatens 40,000 companies"⁽¹³⁴⁾. *ALQABAS* also indicates

(130) Reconnaissance Research, *supra* note 113.

(131) *Id.*

(132) *Id.*

(133) *Id.*

(134) Al-Hattab, *supra* note 25.

The concept of free markets is less valuable than the human costs of the state failing to intervene during a crisis. Markets are almost never wholly “free,” and state infrastructure undergirds some of the most nearly free markets in the world. If some measure of state involvement is an acceptable cost for the existence of markets, then the state’s intervention must also be acceptable for the preservation of markets. The consequences of not doing so are severe both economically and socially. The long-term costs of failing to act outweigh the price of state intervention. Most importantly, the governments of developed economies that support capitalism are announcing stimulus packages to provide support for entrepreneurs, especially SMEs. For example, in France, the Finance Minister, Bruno Le Maire, declared an economic stimulus plan to rescue France’s economy⁽¹²⁸⁾. The plan concludes EUR 45 billion to help entrepreneurs, especially SMEs⁽¹²⁹⁾.

Those in opposition to government support of businesses in times of crisis rationalize their opinion based on the definition of business risks and free market economy. The discussion refutes the claims of the opponents. The business environment is indeed surrounded with business uncertainties and risks. However, certain risks can be forecasted in advance, and other external general events are difficult to be expected at the time of signing a contract. The magnitude of the resulting risks from these external general events is large. External events can affect contractual obligations by making performance either impossible or exhausting for the obligated party. Without a doubt, the COVID-19 pandemic is an external event. However, the question of whether COVID-19 is a *force majeure* or emergency event is discussed in Subsubsection II.II.I.

To respond to opponents’ free-market objections to state support for SMEs, the complexity of Kuwait’s economy must be noted as it combines features of both social welfare economies and capitalism. Kuwait Government already plays an active role in economic planning

(128) Elisa Braun, France Injects Billions into Stimulus Plan amid Coronavirus Chaos, POLITICO (Mar. 17, 2020), <https://www.politico.eu/article/france-injects-billions-into-stimulus-plan-amid-coronavirus-chaos-bruno-le-maire-economic-catastrophe/> (last visited Sept. 4, 2020).

(129) *Id.*

contracts. Once this external event occurs, controlling or minimizing subsequent risks is difficult for the company. This argument paves the way for a later discussion that assesses whether the COVID-19 pandemic is a *force majeure*, or an emergency circumstance that permits excusal of contractual obligations⁽¹¹⁹⁾. The effect of each theory is different on the affected firm's contractual obligations. Does COVID-19 give individuals and businesses engaged in contracts the right to not fulfill their obligations? Subsubsection II.II.I discusses this matter in depth.

Business risk is "an umbrella term for the factors and events that can impact a company's operational performance and income"⁽¹²⁰⁾. During the company's life, it is natural for the company to be exposed to events that carry many risks. Business risks are typically categorized as either internal or external risks⁽¹²¹⁾. For the purpose of the debate in this article, only examples of external risks are highlighted, because these risks resemble the current situation that is dominated by the COVID-19 crisis.

External risks are "economic events that arise from outside the corporate structure"⁽¹²²⁾. They cannot be foreseen at the time of forming the contract and cannot be expected in advance⁽¹²³⁾. Companies are unable to prevent external events from occurring;⁽¹²⁴⁾ such external risks are divided into three types: economic risk,⁽¹²⁵⁾ natural risk,⁽¹²⁶⁾ and political risk⁽¹²⁷⁾.

(119) See generally RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS §§ 265 & cmt. a (AM. LAW INST. 1981); RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS ch. 11, intro. note (AM. LAW INST. 1981).

(120) Brian Beers, How Companies Can Reduce Internal and External Business Risk?, INVESTOPEDIA (Feb. 3, 2020), <https://www.investopedia.com/ask/answers/050115/how-can-companies-reduce-internal-and-external-business-risk.asp> (last visited Sept. 4, 2020).

(121) Nitank Rastogi et., PESTLE TECHNIQUE - A TOOL TO IDENTIFY EXTERNAL RISKS IN CONSTRUCTION PROJECTS, 3 INT'L RES. J. Engineering & TECH. 384, 384 (2016) (discussing the types of business risks).

(122) Beers, *supra* note 120.

(123) Rastogi, *supra* note 121.

(124) *Id.*

(125) Economic risk "includes changes in market conditions."

(126) Natural Risks are "natural disasters that affect normal business operations. An earthquake, for example, may affect the ability of a retail business to remain open for a number of days or weeks, leading to a sharp decline in overall sales for the month. It could also cause damage to the building and merchandise being sold."

(127) Political Risk is "comprised of changes in the political environment or governmental policy that relates to financial affairs. Changes in import and export laws, tariffs, taxes, and other regulations all may affect a business negatively."

The questionnaire has not been made public, and Reconnaissance Research's description of the study does not specify the following information: (1) the percentage of respondents who supported and opposed governmental support for SMEs; (2) the number of participants in the questionnaire; and (3) the participants' educational background, age, and gender. The Reconnaissance Research study only states that "some [participants] were in favor of doing so," while many individuals were opposed to the idea that the government should support SMEs during the COVID-19 crisis⁽¹¹⁴⁾. To justify their opposition, respondents raised two logical concerns. First, they commented that "This is business. Business is about risks and dealing with the effects of those risks. Just as many earn profits and succeed, others lose money and fail"⁽¹¹⁵⁾. They also provided an argument rooted in the concept of free markets. They asserted that SMEs "should be accountable to the free market like everything else"⁽¹¹⁶⁾. In their second claim, they contended that "SMEs profited in years past in the absence of state taxes. Since the government received no revenues from them previously, it has no obligation to help them now"⁽¹¹⁷⁾.

There are two concepts raised in the first concern made by opponents of government support for SMEs: business risk and free markets⁽¹¹⁸⁾. There are two categories of business risk: (1) internal risks and (2) external risks. The principal difference between them is that the company is unable to foresee external risks at the time of entering into

(114) *Id.*

(115) *Id.*

(116) *Id.*

(117) *Id.*

(118) The free market economy concept, it is a synonym for laissez-faire, "an economic theory from the 18th century that opposed any government intervention in business affairs." In English, the word translates to "leave alone"; in other words, non-interference by the government in the economy will have an optimistic effect on business, which will reflect positively on a society. The concept of free market economy is defined as "the process by which people exchange goods and services voluntary under rules of contract, meaning that one must honor any implicit or explicit contracts made." To elaborate further, in the late eighteenth century, some believed that a state must be responsible for regulating the country's economy. Alternatively, liberals believed that government intervention hurts the market. During the twentieth century, socialists discussed that a liberal economy generates social inequality. See Jim Chappelow, Free Market, Investopedia (June 25, 2019), <https://www.investopedia.com/terms/f/freemarket.asp> (last visited Sept. 4, 2020). Norbert Agbeko, On the Characteristics of the free market in cooperative Society, Quantitative Fin. Econ. 1, 10 (2015). Ole Borre & Elinor Scarbrough, The Scope of Government 234 (Oxford University Press, 1995).

SMEs. As a result of the precautionary measures, hundreds of entrepreneurs have complained because their businesses are suffering intensely from these economic disasters. To eliminate the catastrophic economic effects and reduce their losses as much as possible, some of the commercial landlords - without the intervention from the government - have proposed several initiatives⁽¹⁰⁷⁾. For example, some real estate companies that own major commercial complexes (i.e., commercial landlords) enacted two measures in regard to collecting rent from the business tenants. In accordance with these measures, business tenants are divided into two groups. The first category includes restaurants and cafes, and the second group includes all other business tenants. The commercial landlords exempted members of the first group from paying rent for few months⁽¹⁰⁸⁾. Concerning the second category, the commercial landlords reduced the value of their rent by 25%⁽¹⁰⁹⁾. The exemption from paying rent does not include all types of business activities. Aside from the major commercial complexes that have implemented the initiatives of the commercial landlords in response to their tenants, many other business tenants rent spaces in private buildings. However, they have not enjoyed similar privileges⁽¹¹⁰⁾. The business tenants of private buildings must continue to pay their rent in full⁽¹¹¹⁾. The burden of businesses in private buildings is heavier than business tenants who have the option for rent assistance. Besides, the payment of full rent, they are obligated to pay workers' salaries and their suppliers⁽¹¹²⁾. The devastating economic circumstances has caused entrepreneurs, especially SMEs, to urge the government to intervene and become proactive in applying relief measures.

Reconnaissance Research recently reported on the results of a study it conducted to gauge public opinion on the government's support of SMEs⁽¹¹³⁾.

(107) *Id.*

(108) *Id.*

(109) *Id.*

(110) *Id.*

(111) *Id.*

(112) *Id.*

(113) Reconnaissance Research, KUWAIT NEEDS TO SUPPORT ITS SMALL BUSINESSES, 'Consequences of SMEs going out of business will be felt by everyone' ARAB TIMES (Mar. 24, 2020), <http://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-needs-to-support-its-small-businesses/> (last visited Sept. 4, 2020).

more than a thousand cafes located inside shopping malls⁽¹⁰⁰⁾. The number of laborers working in the cafes and restaurants is 200,000 workers⁽¹⁰¹⁾. It should be clarified that the previous source generally demonstrated the effect of precautionary measures on businesses in Kuwait. However, the difference between large companies and SMEs is not mentioned, and a later discussion specifies the effect of the precautionary measures on SMEs in Kuwait.

on March 22, the Deputy Premier and Interior Minister Anas Al-Saleh announced a partial curfew to contain the spread of the virus⁽¹⁰²⁾. The partial curfew hours starts from 5 P.M. to 4 A.M.⁽¹⁰³⁾. The government allowed restaurants, coffee shops, grocery stores, and pharmacies to continue working through providing home delivery service during 5 A.M. to 3 P.M.⁽¹⁰⁴⁾. Even though restaurants are allowed to continue providing meals through home delivery service, estimates indicate that the demand for restaurants has decreased 60-70%⁽¹⁰⁵⁾. The customers' demand for restaurants becomes significantly low compared to the situation prior to the crisis, and the reason is that people are afraid of infection transmission⁽¹⁰⁶⁾.

The government's decisions regarding the lockdown of commercial activities has had many dire economic effects. Presently, the government is facing a challenging fate and must choose between two interests in which a balance is difficult to achieve. On the one hand, the health of people should not be jeopardized, and on the other hand, the negative economic effects of the government's precautionary measures must be minimized. The government's response suggests that the health of individuals outweighs the economic interests. Although assuring safety for citizens and residents in Kuwait is essential, other measures must also be implemented to ensure sustainability for businesses, and particularly

(100) *Id.*

(101) *Id.*

(102) Kuwait Gov't Imposes Partial Curfew, Extends Holiday for Two Weeks, KUNA (Mar. 22, 2020), <https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2880568&language=en> (last visited Sept. 4, 2020).

(103) *Id.*

(104) *Id.*

(105) Al-Kafrawy, *supra* note 98.

(106) *Id.*

SMEs. Subsequently, the discussion will demonstrate two opposing opinions in regard to rescuing SMEs during this crisis.

II.II: Precautionary Measures to Combat the Spread of the Virus in Kuwait

COVID-19 is severely affecting the lives of many individuals. Things will not be the same, particularly for those who own a business. At the beginning of the outbreak of the COVID-19 crisis, SMEs' owners and employees were faced with new obstacles. SMEs faced a difficult choice: either continue to operate their business and risk the health of their staff and consumers or shut down their business without receiving government support. Each choice imposes its own challenges and risks.

On March 11, the World Health Organization (WHO) declared that COVID-19 was a pandemic⁽⁹⁴⁾. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the director-general of WHO, emphasized that COVID-19 is a danger that not one country faces, but it is a common danger that many nations of the world face⁽⁹⁵⁾. Ghebreyesus stressed that countries must unite with each other to defeat this virus⁽⁹⁶⁾. Ghebreyesus also said that "the virus can still be stopped if nations are willing to take aggressive measures"⁽⁹⁷⁾.

As a consequence, on March 14 the government of Kuwait announced a series of precautionary measures to combat the spread of COVID-19. The measures included the complete closure of some commercial activities. For example: the closure of shopping malls, shopping centers, and public markets⁽⁹⁸⁾. In addition, the government mandated the closure of beauty salons, fitness centers, and entertainment centers⁽⁹⁹⁾. The various lockdown measures in response to COVID-19 have halted economic activity in certain sectors and harshly disrupted others. The measures affected approximately 12,000 restaurants and

(94) Donald McNeil, Coronavirus Has Become a Pandemic, W.H.O. Says, N.Y. TIMES (Mar. 11, 2020), <https://www.nytimes.com/2020/03/11/health/coronavirus-pandemic-who.html> (last visited Sept. 4, 2020).

(95) *Id.*

(96) *Id.*

(97) *Id.*

(98) Mahmoud Al-Kafrawy, The Closure of Commercial Activities in Kuwait Due to Coronavirus and Popular Initiatives to Reduce Losses, ALJAZEERA (Mar. 21, 2020), <https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/3/21/بسبب المبادرات الشعبية - الأنشطة - التجارة> (last visited Sept. 4, 2020).

(99) *Id.*

help stimulate economic growth, providing more job opportunities than large enterprises⁽⁸⁵⁾. In addition, SMEs' contributions to innovation are superior to those of large firms,⁽⁸⁶⁾ as SMEs must engage in creating many new products and services, while large firms tend to focus their energies on improving existing products and services⁽⁸⁷⁾. Furthermore, SMEs are more likely than large companies to promote a competitive economy⁽⁸⁸⁾ and are more efficient than large firms. SMEs have a considerable capacity for developing production processes to meet economic and environmental needs more cheaply and quickly than large corporations⁽⁸⁹⁾. Most importantly, SMEs are better able to keep pace with rapidly changing market conditions than the large firms⁽⁹⁰⁾. Given their elasticity, SMEs enjoy the benefit of being less influenced by economic crises than large enterprises⁽⁹¹⁾. The primary reason for this greater flexibility is that SMEs direct their energies toward creating new products and services, which helps them "to adapt their production faster to the changing market requirements"⁽⁹²⁾. However, SMEs often face more difficulties accessing financing than large firms do⁽⁹³⁾.

In conclusion, the academic literature affirms that SMEs are vital for economic growth. Many studies have demonstrated that SMEs are mechanisms for economic diversification. SMEs reduce unemployment and promote innovation. In addition, they increase efficiency because they are leaner and more adaptive to changing economic conditions.

The following discussion evaluates whether COVID-19 pandemic is a *force of majeure* or emergency circumstance. However, first, the argument highlights briefly the precautionary measures adopted by the Government of Kuwait to combat the spread of the virus. Then, the discussion argues the negative economic effects of such measures on businesses, particularly,

(85) Neagu, *supra* note 56, at 334.

(86) *Id.*

(87) *Id.*

(88) *Id.*

(89) SANEUALHADATH, *supra* note 29.

(90) Keskin, *supra* note 34, at 186.

(91) *Id.*

(92) Neagu, *supra* note 56, at 334.

(93) The World Bank, *supra* note 58.

impact investors' incentives⁽⁷⁹⁾. These negative elements are 1) the rise of uncertainty; 2) global competition; and 3) market fragmentation⁽⁸⁰⁾. Therefore, the authors propose adopting SMEs instead of large corporations to minimize negative effects on the business environment⁽⁸¹⁾.

As a summary, scholars favor SMEs over large corporations due to its positive economic effects. The following subsection provides the main difference between SMEs and large firms.

II.I.I: The Difference between SMEs and Large Firms

Many scholars have shed light on the differences between SMEs and large corporations. The following table outlines some of the differences between SMEs and large firms.

Table 1: Differences between SMEs and Large Firms⁽⁸²⁾.

Differences	SMEs	Large Firms
Seizure of business opportunities and acceptance of risks.	Higher.	
Exposure to bureaucracy.		Higher.
Provision of new job opportunities.	Higher.	
Stimulation of competition.	Higher.	
Innovation.	Higher.	
Efficiency levels.	Higher.	
Flexibility.	Higher.	
Access to finance.		Higher.

Having a strong SME sector is important because SMEs provide opportunities for entrepreneurship and promote innovation. As detailed in Table 1, SMEs are more likely to seize new business opportunities and accept risks than large firms,⁽⁸³⁾ in part because SMEs are less exposed to bureaucratic procedures than their larger counterparts⁽⁸⁴⁾. SMEs also

(79) *Id.* See also Martin Carree & Roy Thurik, Small Firms and Economic Growth in Europe, 26 ATL. ECON. J. 137, 138 (1998).

(80) *Id.*

(81) *Id.*

(82) Keskin, *supra* note 34, at 186.

(83) *Id.*

(84) *Id.*

catalyst of economic development”⁽⁶⁹⁾. Drucker stresses that there is a strong correlation between small enterprises and economic growth⁽⁷⁰⁾.

The literature affirms the positive economic effects of SMEs in all economies. However, research also indicates that SMEs are an essential factor particularly for less developed economies⁽⁷¹⁾. For example, Albert Berry posits that SMEs are key players in developing countries⁽⁷²⁾. There are two rationales behind this theory. First, SMEs are associated with a reduction in poverty⁽⁷³⁾. Second, SMEs encourage innovation on the one hand and economic sustainability on the other⁽⁷⁴⁾. Andrew Warner, in his paper *Small and Medium Sized Enterprises and Economic Creativity*, explains that these two effects are connected, because if the first is achieved, the second effect will automatically occur⁽⁷⁵⁾. Thus, if SMEs develop the economy, then the level of poverty will fall⁽⁷⁶⁾.

Given the constructive economic effects of SMEs, many studies advocate for supporting these enterprises. John Adeoti, in his article *Small Enterprise Promotion and Sustainable Development: An Attempt at Integration*, calls for “integrating SMEs promotional measures into the framework of environmentally sustainable development”⁽⁷⁷⁾. Many studies also promote the establishment of policies that aim to lessen restrictions facing SMEs⁽⁷⁸⁾. Martin Carree and Roy Thurik, in their study entitled “*Small Firms and Economic Growth in Europe*,” argue that certain negative factors weaken the business environment and severely

(69) Neagu, *supra* note 56, at 332.

(70) *Id.*

(71) A. Berry, ‘The Importance of SMEs in the Economy’, ITD Global Conf. on Tax’n of Small and Medium Enterprises, Bueno Aires, Argentina, 17-19 (October 2017). *See also* Keskin, *supra* note 34, at 188.

(72) Keskin, *supra* note 34, at 188.

(73) *Id.*

(74) *Id.*

(75) A. Warner, *Small and Medium Sized Enterprises and Economic Creativity*, N.Y.C. & Geneva, UNCTAD, at 61 (2001).

(76) *Id.*

(77) Ahmed Abdel Rahman et., *Kuwait SMEs: Size, Obstacles and Suggested Remedies*, 3 INT’L J. MANAGERIAL STUD. & RES. 7, 7 (2015) (examines the current status of small and medium enterprises (SMEs) in the economy of Kuwait).

(78) *Id.* at 7.

remainder of this section briefly introduces the literature on the role of SMEs in economic growth.

The World Bank asserts the role of SMEs is significant in economic progress. According to a World Bank report, SMEs account for about 90% of enterprises and provide jobs opportunities for more than 50% worldwide⁽⁵⁸⁾. In emerging economies, SMEs provide 7 out of 10 jobs⁽⁵⁹⁾. Moreover, SMEs contribute up to 40% of GDP⁽⁶⁰⁾.

Cibela Neagu, in *The Importance and Role of Small and Medium-Sized Enterprises*, reports that SMEs account for over 99% of the total businesses in most economies⁽⁶¹⁾. She describes the experience of SMEs in her country, Romania⁽⁶²⁾. In Romania, SMEs account for 99.6% of all businesses and 68% of SMEs engage in commercial activity⁽⁶³⁾. Neagu further argues that SMEs create job opportunities at relatively low costs⁽⁶⁴⁾. In Romania, SMEs provide 65.8% of all employment⁽⁶⁵⁾.

Kemi Oduntan, in his paper *The Role of Small and Medium Enterprises in Economic Development: The Nigerian Experience*, similarly emphasizes the strong correlation between SMEs and economic development⁽⁶⁶⁾. Oduntan contends that SMEs promote economic growth through the utilization of locally sourced materials⁽⁶⁷⁾. The leveraging of local resources increases the value-added operations, which in turn boosts the economy⁽⁶⁸⁾. Meanwhile, Peter Drucker, in *Innovation and Entrepreneurship*, said that: “small enterprises represent the main

(58) The World Bank, Small and Medium Enterprises (SMES) Finance: Improving SMEs' Access to Finance and Finding Innovative Solutions to Unlock Sources of Capital, available at <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance> (last visited Apr. 14, 2020).

(59) *Id.*

(60) *Id.*

(61) Neagu, *supra* note 56, at 333.

(62) *Id.*

(63) *Id.*

(64) *Id.*

(65) European Commission, 2018 SBA Fact Sheet - Romania (Nov. 19, 2018), <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/24/translations/en/renditions/pdf> (last visited Sept. 4, 2020).

(66) K. Oduntan, *The Role of Small and Medium Enterprises in Economic Development: The Nigerian Experience*, Int'l Conf. of Art. Dubai, UAE, 22-23 March (2014).

(67) *Id.*

(68) *Id.*

- Section III: The National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Kuwait.
- Section IV: Stimulus Package, Long and Short-term Proposals. This section is divided as following:
 - IV.I: Analyzing the Stimulus Package Announced by the Government of Kuwait.
 - IV.II: Short-and-Long-term Policy Proposals that Safeguard Fiscal Capacity and Minimize Economic Distortions. This subsection is divided into two subsubsections, and they are:
 - IV.II.I: Short-term Solutions.
 - IV.II.II: Long-term Solutions.
 - Suggestions and Recommendations.

II. Logical Justifications for Supporting SMEs

The primary goal of Section II is shedding light on SMEs as the main drivers of economic diversification. It focuses on manifesting the economic importance of SMEs because there is a tendency among some to not provide support for SMEs during the COVID-19 crisis.

II.I: The Theory: The Relationship between SMEs and Economic Growth

Many theoretical and empirical studies have addressed the strong correlation between SMEs and economic progress. Economic studies confirm that robust SMEs promote sustainable development⁽⁵⁴⁾. Scholars generally conclude that SMEs are vital for economic progress, because they contribute to the exploitation of local resources and reduce unemployment⁽⁵⁵⁾. In addition, a healthy SME sector is correlated with higher levels of innovation⁽⁵⁶⁾.

The Arab Planning Institute in Kuwait advocates that SMEs have a role in achieving the principles of human development by expanding alternatives through a variety of work, goods, and services⁽⁵⁷⁾. The

(54) SANEQUALHADATH, *supra* note 29.

(55) *Id.*

(56) Cibela Neagu, The Importance and Role of Small and Medium-sized Businesses, 23 THEORETICAL & APPLIED ECON. 332, 334 (2016) (discussing the importance of SMEs in economic development).

(57) *Id.*

two opposing opinions concerning whether the government should intervene to rescue SMEs during this crisis. Subsubsection II.II.I examines whether COVID-19 is a *force majeure* or an emergency circumstance under the legal system of Kuwait.

Section III then provides a brief discussion of the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Kuwait and the issues that have arisen around the Fund's performance through the years.

Lastly, Section IV is divided into two subsections. Subsection IV.I. scrutinizes the economic decisions and the regulations governing concessional loans to face the current crisis. Basically, the subsection is analyzing the stimulus package announced by the Government of Kuwait. Subsection IV.II proposes clear laws and economic measures designed to achieve a balance between safeguarding Kuwait's fiscal capacity and minimizing economic distortions that might result from the proposed policies⁽⁵³⁾. This subsection fundamentally proposes short- and long-term solutions to guarantee achieving this balance. Hence, the Article is divided as following:

- Section I: Introduction
- Section II: Logical Justifications for Supporting SMEs. This section is divided as following:
 - II.I: The Theory: The Relationship between SMEs and Economic Growth
 - II.I.I: The Differences between SMEs and Large Firms.
 - II.II: Precautionary Measures to Combat the Spread of Virus in Kuwait.
 - II.II.I: COVID-19: *Force of Majeure* or an Emergency Circumstance?
 - A. The Conditions of Each Theory.
 - B. The Legal Effects of Each Theory on the Parties' Contractual Obligations.

(53) Most of the problems facing SMEs today are problems experienced by them prior to COVID-19 crisis. The existence of the crisis contributed to worsening the effect of these problems. Long-term solutions will help to minimize the severe effects of any potential economic crisis in the future.

I.II: The Research Objective

The research aims to achieve economic efficiency during this critical time through proposing short and long-term solutions that protect the interests of SMEs owners without placing a burden on the state's budget.

I.III: The Contribution of the Article to the Academic Literature

I strongly believe that this work is valuable, and it will contribute to the academic literature in a positive way. The subject of the research is significantly important, as it is the topic of the hour. The study revolves around the impact of Covid-19 pandemic on SMEs. The research develops efficient proposals economically, which provide a benefit of a special kind. The benefit is providing the necessary support of SMEs owners in light of the Covid-19 pandemic without burdening the state treasury with any financial burdens.

I.IV: Research Method

I have summarized the theoretical basis in regard to the role of SMEs in economic growth. Due to the economic importance that SMEs give, states must support these enterprises and protect them from collapsing during this crisis. I have supported my arguments by sound and logical analysis justifying the interference of the governments of countries, including Kuwait, in supporting these projects.

Regarding the economic measures announced by the Government of Kuwait, I provided evidences that these measures will increase the state's budget, which contributes in achieving economic inefficiency.

I.V: Organization of the Research

The article is divided into four sections. Section I is the introduction. Section II provides logical justifications for supporting SMEs during this critical time. Subsection II.I offers a theoretical background through a brief discussion of the correlation between SMEs and economic development. Subsubsection II.II.I illustrates the difference between SMEs and large firms. The primary goal of Section II is shedding light on SMEs as the main drivers of economic diversification. It focuses on manifesting the economic importance of SMEs because there is a tendency among some to not provide support for SMEs during the COVID-19 crisis. Subsequently, Subsection II.II begins by highlighting

According to the State Audit Bureau of Kuwait and other official sources, the National Fund for Support and Development for Small and Medium-Sized Enterprises (Fund) committed several violations and errors concerning loans given to most SMEs. The article concludes that the actions of the Fund is lacking both transparency and good management. The situation creates negative legal and economic effects. It considers a significant problem, especially that today one of the economic measures declared by the Council of Minister to support SMEs is: the responsibility of the Fund to finance 80% of the concessional loans given to affected SMEs due to COVID-19. This considers a problem because over the years (according to sources) most of the debts funded by the Fund have become bad debts. High percentage of funded SMEs failed to continue exercising their business activities. As a result, they were not able to repay their installments to the Fund. The Law for 2013 does not clarify the procedures of which the Fund can recover these debts. Given this responsibility to the Fund further wastes the State funds. Also, the Fund's expenses are higher than its returns. Another economic decision made by the Fund is postponing the payment of installments for six months. The article demonstrates how this decision generates economic inefficiency.

I.I: The Problem Examined by the Research

Today, Covid-19 has negatively affected the economies of countries around the world. To avoid the spread of the virus and protect the health of community members, governments, including, the Government of Kuwait have taken harsh precautionary measures. Among these measures was the total lock-down of businesses. Businesses, particularly SMEs, were significantly harmed due to such decisions.

As a consequence, on April, the Government of Kuwait has revealed the stimulus package to deal with the economic effects of Covid-19 on businesses. The main problem highlighted by the research is that the Government of Kuwait did not take real initiatives to support SMEs during this crisis. The policies adopted either postpone SMEs obligations or increase their liabilities through having concessional loans. Most importantly, the economic measures adopted by the government lack certainty and clarity.

provisions of the law, though clear, are not (according to sources) implemented in practice by the Fund⁽⁴⁶⁾.

With respect to transparency, studies emphasized the role of transparency in economic growth. The Americas Business Dialogue in its report *Action for Growth: Policy Recommendations and 2018-2021 Action Plan for Growth in the Americas* states: “Empirical evidence has shown that a lack of transparency and integrity can affect’s country’s productivity and economic growth”⁽⁴⁷⁾. Another study shows that transparency fosters economic growth⁽⁴⁸⁾.

Transparency is defined as: “the clarity and effectiveness of activities with impact on public policy”⁽⁴⁹⁾. Francis Atsu and Samuel Adams in their paper *Transparency, Regulations and Economic Performance in Africa* define transparency as: “the unfettered access to timely and reliable information on decisions and performance of government or organizations”⁽⁵⁰⁾.

Carl Gershman, President of the National Endowment for Democracy argued that: “there can be no accountability without transparency, the lack of which will result in abuse by government, leading to bad loans, bankruptcies, unemployment, stagnant growth and consequently social turmoil”⁽⁵¹⁾. Scholars highlight that transparency enhances the performance of government, accountability, and legitimacy⁽⁵²⁾.

The lack of transparency → reduces accountability → inefficient government performance. The lack of transparency generates errors.

(46) Ali Al-Khaldi, Small projects stumbled .. and loans are not repaid, Alqabas (Apr. 16, 2019), <https://alqabas.com/article/657390-مشاريع صغيرة تتعثر والقروض لا تُسدّد> (last visited Sep. 2, 2020). For example, according to the source, the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises did not provide lands for industrial entrepreneurs to set up their projects, according to Article 10 of the Law for 2013.

(47) INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, ACTION FOR GROWTH: POLICY RECOMMENDATIONS AND 2018-2021 ACTION PLAN FOR GROWTH IN AMERICAS 6 (2018).

(48) Atsu, F & Adams (2005), S 'Transparency Regulation and Economic Performance in Africa' Utrecht University, Utrecht, p. 2.

(49) *Id.* at 1.

(50) *Id.*

(51) *Id.* at 6.

(52) *Id.* at 8. See also Lars Oxelheim, Globalization, Transparency and Economic Growth: The vulnerability of Chinese firms to macroeconomic shocks, 21 J. Asian ECON. 66 (2008).

and employ more than 86% of the private sector's labor force⁽⁴¹⁾. In Dubai, SMEs represent nearly 95% of all businesses in the city, provide jobs for 42% of the labor force, and contribute about 40% of the city's GDP⁽⁴²⁾. In Bahrain, SMEs contribute 30% of GDP⁽⁴³⁾.

There are many legal and practical issues that influence the business environment in Kuwait and suppress SMEs from growing. The present article examines the economic and legal effects of COVID-19 on SMEs in Kuwait. There are two categories of problems facing SMEs during the COVID-19 crisis. The first category includes problems that was existed prior to the crisis, and worsened post crisis. The second category includes problems that arose post crisis. All these problems caused tremendous economic pressure on most SMEs. There are two factors contribute to these problems, and they are: 1) legal uncertainty. 2) the lack of transparency.

Lon Fuller in the *Mortality of Law* concludes that the legal system should have legal certainty⁽⁴⁴⁾. According to Fuller, the guidelines are that laws and/or legal systems: 1) be of general application; 2) be publicized or at least made available to affected parties beforehand; 3) be prospective in application; 4) be understandable; 5) be coherent (i.e., not contradictory); 6) not require conduct beyond the powers of the affected party; 7) not be subject to frequent changes; and 8) reflect congruence between rules as announced and their actual administration⁽⁴⁵⁾.

The Law No. 98 for 2013 concerning the National Fund for Support and Development of Small and Medium-Sized Enterprises suffers from legal uncertainty. The Law for 2013 lacks a number of guidelines that are described by Fuller. The criteria that it lacks are: 1) the inability to understand the language of the provisions of the law itself. 2) there are

(41) *Id.*

(42) *Id.*

(43) Sumaya Almajdoub, Issue Brief: The Structural Constraints of Entrepreneurship in Bahrain, at 1, Baker Institute for Public Policy (2018).

(44) LON FULLER, THE MORTALITY OF LAW 39 (rev. ed. 1969).

(45) *Id.*

The relative weakness of SMEs in Kuwait is problematic, especially because Kuwait is classified as a high-income country. The magnitude of SMEs' contribution to the economy is significantly lower in Kuwait than in both of its peer groups: high-income countries and emerging economies. In emerging economies, according to the World Bank, SMEs generally contribute between 40% and 50% of GDP⁽³³⁾. An empirical study classifies countries by income and examines the economic effects of SMEs in each classification. The classifications were as follows: 1) low-income countries; 2) middle-income countries; and 3) high-income countries. In low-income countries, the study found that SMEs "account for over 60% of GDP and over 70% of total employment."⁽³⁴⁾ In middle-income countries, SMEs "contribute over 95% of total employment and about 70% of GDP."⁽³⁵⁾ Lastly, in high-income countries, SMEs "contribute to over 55% of GDP and over 65% of total employment."⁽³⁶⁾

It is particularly important to examine the contribution of SMEs to the economies of the states of the Gulf Cooperation Council, especially as those countries share similar economic, cultural, and social characteristics to Kuwait. In Saudi Arabia, SMEs contribute 33% of GDP⁽³⁷⁾. According to the Jeddah Chamber of Commerce and Industry's *Small-Medium Enterprises in Saudi Arabia Report* for April 2016, SMEs contribute to 25% of Saudi Arabia's labor force⁽³⁸⁾. The report emphasizes that "Saudi nationals account for not more than 10% of the total employed labor by SMEs."⁽³⁹⁾ Meanwhile, in the UAE, the Ministry of Economy reports that SMEs account for more than 94% of the total businesses in the country⁽⁴⁰⁾

(33) The World Bank, *supra* note 30.

(34) Hidayat Keskin et.al, The Importance of SMEs in Developing Economies, 2nd INT'L SYMP. on Sustainable DEV. 183, 183 (2010) (discussing the importance of SMEs for developing countries).

(35) *Id.* at 183.

(36) *Id.*

(37) Jeddah Chamber of Commerce and Industry, *Small-Medium Enterprises in Saudi Arabia Report* for April 2016, at 3 (2016).

(38) *Id.*

(39) *Id.*

(40) The United Arab Emirates Government Portal, The Impact of SMEs on the UAE 's Economy (Dec. 16, 2019), <https://u.ae/en/information-and-services/business/crowdfunding/the-impact-of-smes-on-the-uae-economy> (last visited Sept. 4, 2020).

floundering economy.”⁽²⁷⁾ According to Adam Hayes, a stimulus package aims to boost the economy against recession⁽²⁸⁾.

This first seeks to quantify the contribution of SMEs to Kuwait’s economy. Unfortunately, this question is difficult to answer. Few sources have reported in detail on the contribution of SMEs to Kuwait’s GDP. In 2016, The World Bank issued a report demonstrating that the number of SMEs is high in Kuwait;⁽²⁹⁾ however, according to the same report, their contribution to the economy is only 3% of the country’s GDP⁽³⁰⁾. In addition, the report highlights that SMEs in Kuwait employ roughly 23% of the total labor force⁽³¹⁾. (Note that this result does not indicate the percentage of Kuwaiti nationals employed by the SMEs). A separate study, entitled “*Taking Stock of SME Banking in Kuwait*,” evaluates the contribution of SMEs to Kuwait’s GDP. The study estimates that SMEs contribute less than 10% of the country’s GDP⁽³²⁾.

(27) Adam Hayes, Stimulus Package, INVESTOPEDIA (Mar. 26, 2020).

(28) *Id.*

(29) According to the data issued by the Central Statistical Bureau, SMEs constitute 90% of the businesses registered in Kuwait. In 2017, the Arab Monetary Fund issued its report on the business environment for SMEs in Arab countries, highlighting the number of these facilities in Kuwait. The report revealed that there are 33,000 SMEs in Kuwait, indicating that the country ranks tenth in the Arab World in the number of SMEs. See Kuwait Realizes Early the Importance of Small and Medium-sized Enterprises, SANEOUALHADATH (June 6, 2016), https://saneoualhadath.me/أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويت - خص /?_cf_chl_jschl_tk__=f1782d1283a6cb2da48ca996f82b97208a563b41-1587207531-0-AT-mPvNSb91Mx_gifDsWrQPd4z3OfOpa315YCPQY1Efa0SyG_Ie871d4xh8eanyF131eUH-LOab4E3yKX5VYLu461wv57sxjByXreMfhWML2mdSl8OxUJHku654DSeA3K5T286IHSh-7d7EVWeRCDslg6BTw13uHL5Z6Pd9ZmSr4bEbMlBmxAT7NfGxuAGNIHrkxfZZu-Zu4nDjLtyTzp95oSZ0cpX_9bYNfmcUarmuMG0txQ1vuhhtJUlcZ9lnZlzMhroc_y6v-PiMk2R8QGPvrYC6JRtDriO5C-NcnQAVMaDXJ4sdNL16K0yqkZvHMXOkT6_ARng-sIYrtcK8Fw-ag6X5pqfz0F1psr4KNsg0e_npr057wcZpMR8FQJG3ljnjtQFROcKVFcjn6Vmn-CAA2nvTgvh5rw1ympPCBQsG1oW4-CcTk17rTnu8mfTzb3_MYR2AD8lJb1PI-sA-z96UVw8CtmiESy_OwMqoUdqk49zyOGk2tgw9JTj_eVoEXHsHdprjfwjnjQB-FOVhqzJJSVgM9yyCGZN35UclP5ULExa9W-jXUKCiVvcj1dJl8ksOakw#/slide-1 (last visited Sept. 4, 2020).

(30) The World Bank, Building Kuwait’s Future, One Small Enterprise at a Time (Mar. 1, 2016), available at <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/01/building-kuwait-future-one-small-enterprise-at-a-time> (last visited Sept. 4, 2020). See also Oxford Business Group, Range of Measures to Support Growth of Kuwait’s SMEs, <https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/taking-initiative-range-measures-support-growth-smes> (last visited Apr. 18, 2020).

(31) *Id.*

(32) Institute of Banking Studies Research, Taking Stock of SME Banking in Kuwait, at 3 (2016).

The International Energy Agency predicted two contrasting scenarios. The first is pessimistic, while the second is optimistic. “In a more pessimistic low case,” the agency wrote, “global measures fail to contain the virus, and global demand falls by 730,000 barrels a day in 2020. In a more optimistic high case, the virus is contained quickly around the world, and global demand grows by 480,000 barrels a day.”⁽²²⁾ Following these statements, Dr. Birol pointed out a critical fact:

[T]he impact of the coronavirus on oil markets may be temporary. But the longer-term challenges facing the world’s suppliers are not going to go away, especially those heavily dependent on oil and gas revenues. As the IEA has repeatedly said, these producer countries need more dynamic and diversified economies in order to navigate the multiple uncertainties that we see today⁽²³⁾.

Today, the economies of the world-particularly economies that rely primarily upon a single source of income-are in danger of collapsing. The spread of COVID-19 has sparked severe economic effects, specifically on the price of oil. The fundamental question is, how is the spread of COVID-19 affecting Kuwait’s economy? On April 9, 2020, the price of oil fell to 16.5 USD per barrel, while the cost of its production was 12.5 USD per barrel. The gross profit from selling a barrel of crude oil was therefore \$4, which is equivalent to 1 KWD⁽²⁴⁾.

Moreover, the impact of COVID-19 in Kuwait has extended far beyond crude oil prices. According to *ALQABAS*, a local newspaper, the initial statistics indicate that 40,000 micro-, small-, and medium-sized enterprises may be affected by the economic closure imposed by the measures to contain the spread of the virus in the country⁽²⁵⁾. The sources confirmed that many companies will enter bankruptcy if they are not covered by the stimulus package⁽²⁶⁾. A stimulus package is “a package of economic measures put together by a government to stimulate a

(22) *Id.*

(23) *Id.*

(24) Kuwait sold a barrel with a return of one Kuwaiti Dinar!, *ALQABAS*, Apr. 9, 2020, at 5.

(25) Khalid Al-Hattab, 40 Thousand Companies Are Subject to Default or Bankruptcy, *ALQABAS*, Apr. 6, 2020, at 8.

(26) *Id.*

crude oil prices⁽¹⁵⁾. A number of causes contributed to this decline. For example, the failure of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) to reach an agreement to reduce oil production exacerbated the existing glut of crude oil in the global economy⁽¹⁶⁾. The principal cause was on the supply side: the deadly spread of COVID-19, and the resulting reduction of economic activity. According to oil expert Ahmad Hassan Karam, “the US self-sufficiency of shale oil is one of the reasons for the oil prices decline, along with the virus spread.”⁽¹⁷⁾ Dr. Ahmad Al-Kouh, a professor of petroleum engineering at Kuwait University, explained that the oil prices have recently hit the worst levels since the Great Recession of 2008, amid to a significant decline in the demand side, largely due to the stoppage of many key production facilities in China, the center of the coronavirus outbreak⁽¹⁸⁾. Dr. Abdulsamee Behbehani similarly emphasized that the main factor behind the sharp drop in oil prices is the effect of COVID-19 in China⁽¹⁹⁾. China has witnessed reduced demand for oil, which has negatively affected the petroleum industry, as China is the world’s largest crude oil consumer. China was responsible for about three-quarters of the global oil demand growth in 2019 (before the COVID-19 outbreak)⁽²⁰⁾.

Dr. Fatih Birol, Executive Director of the International Energy Agency argued, “The coronavirus crisis is affecting a wide range of energy markets - including coal, gas and renewables - but its impact on oil markets is particularly severe because it is stopping people and goods from moving around, dealing a heavy blow to demand for transport fuels.”⁽²¹⁾

(15) WTI Crude Oil declined from \$65.06 per barrel in 2018 to \$29.34 per barrel in 2020. Brent Crude Oil reached from \$71.19 per barrel in 2018 to \$33.04 per barrel in 2020. For more information, see U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, <https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/prices.php> (last visited Apr. 17, 2020).

(16) Bajpai, *supra* note 8.

(17) Khaled Al-Mutairi, Oil Prices to Lowest Level Since Year amid Coronavirus Mushrooming, KUNA, (Mar. 1, 2020), <https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2871480&language=en> (last visited Sept. 4, 2020).

(18) *Id.*

(19) *Id.*

(20) Because of Coronavirus (Covid-19) .. The First Decline in Global Demand for Oil Since the Financial Crisis, ALJAZEERA (Feb. 13, 2020), <https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/2/13/بسبب كورونا أول تراجع للطلب لعالمي على النفط منذ الأزمة المالية> (last visited Sept. 4, 2020).

(21) IEA, Global Oil Demand to Decline in 2020 as Coronavirus Weighs Heavily on Markets, <https://www.iea.org/news/global-oil-demand-to-decline-in-2020-as-coronavirus-weighs-heavily-on-markets> (last visited Apr. 14, 2020).

rate of global GDP growth. For example, in 2014, oil prices experienced a rapid decline, falling from \$115 a barrel in June to \$70 a barrel in December⁽⁹⁾. As a result, the world, including Kuwait, faced economic and financial challenges⁽¹⁰⁾. To confront such challenges, the government of Kuwait announced harsh measures that were previously unthinkable, such as the change in domestic energy pricing. In 2016, the government of Kuwait announced an increase in petrol prices of more than 80%⁽¹¹⁾. This action made it clear to the world, and especially to the states of the Gulf Cooperation Council (GCC), that economic diversification is necessary. The GCC governments consequently initiated strategic economic plans to diversify their income sources away from energy. Among them, the government of Kuwait established “The New Kuwait 2035 Vision.”⁽¹²⁾ The main objective of the plan is to diversify the economy of Kuwait and reduce its reliance on a single commodity (i.e., oil) as its main source of revenues⁽¹³⁾. The goals outlined in the 2035 vision also include transforming “Kuwait into a financial and trade hub, attractive to investors” and energizing the country’s private sector⁽¹⁴⁾.

The contribution of non-oil revenues to the economies of several GCC States demonstrates that these countries are successfully adopting policies to diversify their economies. Unfortunately, Kuwait is falling behind. In February and March of 2020, there was a sharp decline in

(9) Robert J. Samuelson, *Key facts about the great oil crash of 2014*, WASH. POST (Dec. 3, 2014), https://www.washingtonpost.com/opinions/robert-samuelson-key-facts-about-the-great-oil-crash-of-2014/2014/12/03/a1e2fd94-7b0f-11e4-b821-503cc7efed9e_story.html (last visited Sept. 4, 2020).

(10) The reasons behind the decline of oil prices and its effects on Kuwait are mentioned in my Thesis. See, Maha Albesharah, *How to Create an Attractive Legal System for Foreign Direct Investments? The Kuwait Case* (Dec. 2019) (unpublished Ph.D. dissertation, University of Virginia) (on file with author).

(11) See *KUWAIT RAISES PETROL PRICES BY OVER 80% - 'RATIONALIZATION'*, ARABTIMES (Aug. 2, 2016), <http://www.arabtimesonline.com/news/kuwait-raises-petrol-prices-80-rationalization/> (last visited Sept. 4, 2020). See also GLADA LAHN, *FUEL, FOOD, AND UTILITIES PRICE REFORMS IN THE GCC: A WAKE UP CALL FOR BUSINESS* 3-4 (The Royal Institute of International Affairs, 2016).

(12) See New Kuwait, <http://www.newkuwait.gov.kw/home.aspx> (last visited Apr. 19, 2020). See also New Kuwait, *Kuwait Mobilizes Development Efforts to Transform Kuwait into a Financial, Cultural, and Institutional Leader in the Region by 2035*, http://www.newkuwait.gov.kw/image/NewKuwait_CampaignLaunchEvent.pdf (last visited Apr. 19, 2020).

(13) *Id.*

(14) *Id.*

budget⁽¹⁾. This figure constitutes a large percentage even in comparison to neighboring oil-rich countries. For example, in Saudi Arabia, oil revenues accounted for 66%⁽²⁾, while non-oil revenues accounted for 34% of the Kingdom's public revenue in 2019⁽³⁾. In neighboring Oman during the same period, oil revenues accounted for 54%, while non-oil revenues accounted for 46% of the state budget⁽⁴⁾. The United Arab Emirates is a further example. According to the Minister of Economy Sultan Al Mansoori, the country "is on track to deliver the UAE Vision 2021, which aims to develop the country's non-oil sectors and reduce dependency on oil revenues"⁽⁵⁾. Al Mansoori added that "[t]he country's non-oil sector economy, climbed an annual 2.9 per cent last year to 1.13bn at current prices and 1.3 per cent at constant prices compared with 2017"⁽⁶⁾. According to the Federal Competitiveness and Statistics Authority, "the oil and gas sector contributed 25.9 per cent to GDP, while the retail and whole trade sector accounted for 11.2 per cent, the financial sector represented 9.2 per cent, manufacturing came in at 8.9 per cent and building and construction sectors [were] at 8.3 per cent"⁽⁷⁾.

Crude oil prices are unstable, affected by changes in supply and demand⁽⁸⁾. It is difficult to control these variables, as they are surrounded by many uncertainties, ranging from geopolitical machinations to the

- (1) The Ministry of Finance, The State Budget for the Fiscal Year 2019/2020, at 17, available at <https://www.mof.gov.kw/MofBudget/PDF/Budget20-19.pdf> (Kuwait) (last visited Sept. 2, 2020).
- (2) Ekramy Abdullah, Record Level of non-Oil Revenues in 2019 .. 148% Jump in 5 Years, ALEQT (Dec. 10, 2019), https://www.aleqt.com/2019/12/10/article_1727151.html (last visited Sept. 3, 2020).
- (3) *Id.*
- (4) PwC, 2019 Oman State Budget: "A Prudent Budgetary Approach", <https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2019/2019-oman-state-budget.html> (last visited Apr. 14, 2020).
- (5) Sarmad Khan, UAE Economy Grew 1.7% in 2018 on Non-oil Sector Growth and Higher Oil Prices, THE NAT'L, (Mar.31, 2019), <https://www.thenational.ae/business/economy/uae-economy-grew-1-7-in-2018-on-non-oil-sector-growth-and-higher-oil-prices-1.843335> (last visited Sept. 3, 2020).
- (6) *Id.* Note that the statistics are acquired from preliminary macro-economy indexes issued by the Federal Competitiveness and Statistics Authority (FCSA) for 2019.
- (7) *Id.*
- (8) Prableen Bajpai, *Top Factors That Affect the Price of Oil*, INVESTOPEDIA (Mar. 16, 2020), <https://www.investopedia.com/articles/investing/072515/top-factors-reports-affect-price-oil.asp> (last visited Sept. 4, 2020).

COVID-19 Pandemic Effects on SMES in Kuwait

Dr. Maha Albesharah
School of Law
Kuwait University

Abstract:

Coronavirus disease (COVID-19) affected negatively on people lives. The governments from all over the world have announced precautionary measures to combat the spread of the virus. The measures included the lockdown of most businesses. The precautionary policies affected severely on the economies of countries. As a result, businesses, particularly, small and medium-sized enterprises (SMEs) have been on the edge of bankruptcy. The article discusses the effects of COVID-19 on SMEs in Kuwait. The article examines whether COVID-19 pandemic is a *force majeure* or emergency circumstance under the legal system of Kuwait. The discussion scrutinizes the economic stimulus packages addressed by the government of Kuwait and provides critical analysis. The article concludes that the government did not take real initiatives to support SMEs during this crisis. The policies adopted either postpone SMEs obligations or increase their liabilities through having concessional loans. Ultimately, the article proposes clear laws and economic measures that are designed to achieve a balance between safeguarding fiscal capacity and minimizing economic distortions that might result from proposed policies.

I. Introduction

The economy of the State of Kuwait is heavily dependent on crude oil as its primary source of income. The State's general budget for the fiscal year 2019/2020 specifies that oil revenues account for 87.68% of the

English Articles

Table of Contents

Editorial:

DR. FAHAD Ali ALZUMAI	8
-----------------------------	---

Arabic Articles:

The Course of the French Summary Administrative law To protect the basic freedoms under the effects of Covid-19 Pandemic.

DR. EBRAHIM MOHAMMAD ALHAMOUD	13
-------------------------------------	----

COVID 19 and its impact on the work contract in the private sector.

DR. ABDULRAHMAN ALRADHWAN - DR. KHALID JASEM AL-HENDIANY	41
--	----

China's Responsibility for the spread of COVID-19 pandemic before the international court of justice.

DR. DEYMAH ALWEQYAN	87
---------------------------	----

The administration's commitment to assist the contractor in the administrative contract Because of the pandemic of the Crohna virus (COVID-19) - An applied study on the State of Kuwait.

DR. ABDULLAH HABAB AL-RASHIDI	131
-------------------------------------	-----

Towards enhancing the criminal concept in addressing legislative issues for combating Novel Coronavirus (Covid-19) Critical Analysis Study.

Ali Ouda ALSHAMMARI	165
---------------------------	-----

Corona Virus / Covid 19, between Force Majeure and Exceptional circumstance (Study in UAE and French Laws).

PROF. ADNAN IBRAHIM SARHAN - EMAN KHAMISS ALYAHYAE	219
--	-----

Corona Pandemic and the Extent of China's International Responsibility For It: legal Reading From An International law Perspective

DR. MEKHLLED TARAWNEH	269
-----------------------------	-----

Volunteering for testing effectiveness of clinical trial against coronavirus.

PROF. MOHAMMED SULEIMAN AL-AHMAD - DR. ABDULKAREM S. ABDULKAREM	329
---	-----

The Impact of the Corona Pandemic on Public Freedoms. A Comparative Study Between Egypt and Kuwait.

DR. MOHAMMED ABDUL JALIL AL-MURR	375
--	-----

Mechanisms for facing the risk of corporate bankruptcy in the time of the Corona pandemic and efforts of national legislation.

DR. MOHAMED SALAH ABDELLAH MOHAMED	441
--	-----

An attempt to apply the incomplete contract theory to the contractual obligations under pandemic Corona

DR. BADREDDINE BERRAHLIA	499
--------------------------------	-----

The impact of the Corona virus (COVID-19) pandemic On international trade contracts.

DR. ABDELLATIF DAHIA	549
----------------------------	-----

The Extent to Which Force Majeure Connditions Apply to the Coronavirus Pandemic (Covid-19) within the Framework of Civil Contracts: A Comparative Study in the Egyptian and French Laws.

DR. HAYTHAM ELSAYED AHMED EISSA	589
---------------------------------------	-----

English Articles:

COVID-19 Pandemic Effects on SMEs in Kuwait.

DR. MAHA ALBESHARAH	11
---------------------------	----

The Lack of Epidemic Legislation in the Kuwaiti Legal System and the Implications of the Suspension of the National Assembly Sessions.

DR. ABDULRAHMAN AL-HAJRI - MAHMOUD KHAMIS	75
---	----

- 1 - An introduction showing the importance of the subject of thesis .
- 2 - An abstract of thesis and how it was defined . It should be included in the thesis .
- 3 - Abstract of the method of thesis , suppositions , sample and tools .
- 4 - Conclusion of most important results of the thesis .

Fourthly : Reports of Academic meetings :

The Journal publishes Academic reports on seminars and conferences relating to one or more subjects or fields of interest of the Journal which were held recently inside Kuwait or outside . They should be as follows :

- 1 - The report should cover the activities of the seminar or the conference focusing on scientific researches and on work papers offered and their results with the most important recommendations.
- 2 - The report should not exceed 5 pages .

Fifthly : Books expositions and revisions :

The journal publishes assessments of books revisions which were recently published which relates to any field of law with the following provisions :

- 1 - The book should be extinguished and have a new scientific addition .
- 2 - The person undertaking the revision should be specialized in the same scientific field of the book .
- 3 - The book should not be offered to publishing previously in another printed edition .
- 4 - Revision maker should expose a full summery for the book contents showing key points of both excellence and shortcomings . This exposition should not exceed 5 pages .
- 5 - The Journal grants a Remuneration for exposing of books that are only done on demand from the Journal.

● **Special Rules :**

- 1 - A list of references is provided at the end of the research including all references referred to in the text . They are given independent pages provided that sources and references are arranged , starting with Arabic then foreign references without numeration .
- 2 - Footnotes are referred to in serial numbers on all research pages . They are explained according to their serialized numbers .
- 3 - Each researcher is granted three copies of the published issue which contains his research with 20 copies of the published research .
- 4 - The Journal reserves all publishing rights – both paper and electronic of the licensed research .
- 5 - Arrangement of published researches are done according to Technical on Academic considerations .
- 6 - Priority of publishing is done according to the following :
 - a - Researches provided by Kuwait University teaching staff .
 - b - Researches and studies which are concerned with Kuwaiti laws or comparisons with Kuwaiti laws .
 - c - Date of delivery of the research to the editor-in-chief and presidency of research offers which are amended .
 - d - Diversification of researches as possible as that could be .

Secondly: Comment on judicial judgments:

The Journal publishes comments on judicial judgments based on the importance of the views of law fiqh in analyzing judgment and referring it to its origins and criticizing it through the relation between law theory and science and practical application according to the following rules :

- 1 - Commentator should be specialist in law .
- 2 - Comment should deal with final judgment after finishing all kinds of contest.
- 3 - Comment should not discuss anything except principles on which judgment was based on .
- 4 - It should not Criticize Court nor judges who issued the judgment .

Thirdly : Expose abstracts of university thesis :

The journal publishes abstracts of university thesis (masters - PhD's) which were approved provided they are recently approved . They should also be prepared by knowledge of the writer of the thesis . In addition to this it should be a new addition in one of the branches of law . The exposition should not be more than 10 pages putting in mind the following:

Rules of publication

Law Journal is a Academic, refereed, quarterly Journal. It is issued by the Academic publication Council in Kuwait University. The Journal accepts publishing in Arabic, French and English Languages. It publishes everything that relates to topics favored by the Journal that go round researches and studies, comments on judicial rules, abstracts of Academic papers, reports of seminars and conferences, expositions and revisions of new books according to the following rules:

First Academic researches and studies :

● General Rules :

- 1 - Researcher should undertake to contribute researches or studies that have not been previously published - in print on paper nor electronically - nor offered for publication to other places .
- 2 - Research should be Studied with depth , originality , and new addition to Legal knowledge .
- 3 - Commitment to fundamental basics of scientific research and its general rules taking care to accurate scientific documentation of research materials .
- 4 - The research should not be part of thesis of P.H.D or masters offered by the researcher or part of book previously published .
- 5 - The research or study should not be more than 15000 words including references , Footnotes, tables , diagrams and appendices.
- 6 - It is not allowed to publish the research in another Journal after being allowed to be published in law Journal.
- 7 - Research should be offered in three printed versions of A4-size papers and a (CD) . Accurate correction should be attended to in all versions .
- 8 - Origins of researches delivered to the Journal are not returned whether published or kept unpublished .
- 9 - The researcher has to send an Resume (c.v) of himself .
- 10 - The researcher should enclose a summary of his research in about one page in both Arabic and English Languages .
- 11 - The Journal does not pay Remuneration for published researches or book revisions or any intellectual materials unless they came on demand of the Journal.
- 12 - Materials of the published researches express views of their writers and do not necessarily give the point of view of the Journal.
- 13 - Researches are to be sent to the chief editor's address of law Journal P.O.B.64985 shuwaikh-B 70460 – Kuwait or E-mail of the Journal : jol@ku.edu.kw



JOURNAL OF LAW

Published by Academic Publication Council, Kuwait University

Advisory Board

Prof. Husam Al-Deen Al-Ahawany

University of Ain Shams, Egypt

Dr. Abdulhameed alahdab

Lawyer to Appeal, Lebanon

Prof. Sadiq Reza

New York La School - U.S.A.

Prof. Mathias Rohe

Univesity of Erlangen, Germany

Dr. Mark Hoyle

*Visiting Professor, The University
of leeds, United Kingdom*

Prof. Massimo Papa

University of Roma Tor Vergata, Italy



JOURNAL OF LAW

Special Issue - Part Two - January 2021

Editor - in - Chief

Dr. Fahad Ali AlZumai

Managing Editor

Sami Saleh Al-Wuhaibi

Editorial Board

Prof. Zeinab Hussein Awadallah



JOURNAL OF LAW

The Journal of Law is a Periodical, Academic and Refereed Journal
Concerning the Publication of Legal Research and Studies

Special Issue - Part Two - January 2021

All correspondence should be addressed to:

**The Editor, Journal of Law,
P.O.Box 64985 Al-Shuwaikh-B 70460 Kuwait
Tel. 24835789 - 24847814 Fax: 24831143
Email: jol@ku.edu.kw
jol.ku.kw@gmail.com**

**Articles are abstracted and indexed in:
Ebsco Publishing, Legal Source, ISC Databases,
Arab World Research Source, Ulrich's IPD,
UNESCO DARE Databank, Mandumah, PR
Newswire, MECAS Database, copac.**

**Full texts of the research is available in:
EBSCO Publishing Products
www.mandumah.com**

Price List

- Kuwait: 750 Fils
- Gulf States: (Saudi Arabia 10 SR, Qatar 1 QR, Emirates Dh 10, Bahrain BD 1, Oman OR 1).
- Arab Countries: equivalent to \$ 1
- Foreign Countries: \$ 3

Annual Subscription rates

Type of Subscription	Kuwait	Arab Countries	Foreign Countries	Years of Subscription
Individuals	KD 3	KD 4	\$ 15	1 Year
Institutions	KD 15	KD. 15	\$ 60	
Individuals	KD 5	KD 7	\$ 25	2 Years
Institutions	KD 25	KD25	\$ 100	
Individuals	KD 7	KD 10	\$ 35	3 Years
Institutions	KD 35	KD35	\$ 140	
Individuals	KD 9	KD 13	\$ 45	4 Years
Institutions	KD 45	KD 45	\$ 180	

Payment for individual subscription should be paid in advance:

- 1 - By cheque drawn on a Kuwaiti Bank to University of Kuwait.
- 2 - Or By Bank Transfer to the University of Kuwait, Account No: (042/02608) Central Bank of Kuwait, State of Kuwait.

IBAN: KW21CBKU0000000000000004202608

Opinions Expressed in this Journal are Solely Those of their Authors and do not reflect those of the Journal.

The Publications of The Academic Publication Council

Journal of Social Sciences 1973, 1975, Authorship Translation the Humanities 1981, The Kuwait Journal of Science and and Publication Committee Educational Journal 1983, Engineering 1974 (Split in 2013 1976, Journal of Law 1977, Journal of Sharia and Islamic to KJS, JER), Journal of the Gulf Annals of the Arts and Social Studies 1983, Arab Journal of and Arabian Peninsula Studies Sciences 1980, Arab Journal for Administrative Sciences 1991.

JOURNAL OF LAW

A Refereed Academic Quarterly, Published by the Academic Publication Council - University of Kuwait

Special Issue about COVID-19 Panademic

University
of Kuwait

Academic
Publication Council



ISSN: 1029 - 6069

Special Issue - Part Two

Jamada II 1442- January 2021

Part Two